SOMMAIRE

Avant-propos VII
Liste des abréviations IX
Introduction 1
Partie I – Le droit commercial 29
Titre I – Notion de droit commercial **33**
Chapitre I – Caractéristiques du droit commercial 33
Chapitre II – Distinction entre droit civil et droit commercial 49
Titre II – Sources du droit commercial **54**
Chapitre I – Diversité des sources 54
Chapitre II – La hiérarchie des normes en droit commercial 60
Partie II – Droit commun des sociétés 79
Titre I – Notion de société **82**
Chapitre I – Les différentes conceptions de la société 82
Chapitre II – Distinction de la société par rapport à d'autres notions 101
Chapitre III – Les éléments caractéristiques de la société 131
Chapitre IV – Obligations et droits des associés 180
Chapitre V – La constitution de la société 204
Chapitre VI – Preuve du contrat de société 251
Titre II – Le fonctionnement des sociétés **252**
Chapitre I – Règles communes de fonctionnement des sociétés 252
Chapitre II – Sanctions pénales du droit des sociétés 351
Chapitre III – Comptes annuels des sociétés 377
Titre III – Règles communes de fonctionnement des sociétés **424**
Chapitre I – La théorie de l'organe 424
Chapitre II – Les différents organes de la société 432
Partie III – Le droit spécial des sociétés 473
Titre I – Les sociétés par actions **476**
Chapitre I – Les sociétés anonymes 476
Chapitre II – Les sociétés en commandite par actions 677
Chapitre III – La « société par actions simplifiée » (SAS) 684
Chapitre IV – Les SICAV et les SICAF 687

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

Chapitre V – La titrisation 693
Chapitre VI – La SICAR 695
Chapitre VII – La société européenne (SE, *societas europaea*) 706
Titre II – Les sociétés à responsabilité limitée 721
Chapitre I – Nature de la société à responsabilité limitée 722
Chapitre II – Constitution de la société à responsabilité limitée 723
Titre II*bis* – La société à responsabilité limitée simplifiée (S.à r.l.-S) 749
Titre III – Les sociétés de personnes 752
Chapitre I – Les sociétés en nom collectif 753
Chapitre II – Les sociétés en commandite simple 763
Chapitre III – Les sociétés en commandite spéciale 770
Titre IV – Les sociétés coopératives 772
Chapitre I – Les sociétés coopératives en général 772
Chapitre II – Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes 791
Chapitre III – La SEC 793
Titre V – Les sociétés civiles 795
Chapitre I – Des diverses espèces de sociétés 796
Chapitre II – Commentaire des dispositions particulières 800
Titre VI – Les groupements d'intérêt économique 823
Chapitre I – L'objet et le but du G.E.I.E. 824
Chapitre II – Caractéristiques juridiques 826
Chapitre III – Aspects fiscaux 828
Titre VII – Les fonds de pension 830
Chapitre I – La SEPCAV 830
Chapitre II – L'« ASSEP – association d'épargne-pension » 831
Chapitre III – Autres parties concernées par les fonds de pension 832
Titre VIII – Les sociétés d'impact sociétal 833
Chapitre I – Définition de ce type de société 833
Chapitre II – Régime juridique et fiscal 834
Titre IX – Les sociétés étrangères 836
Chapitre I – Administration centrale au Luxembourg 837
Chapitre II – Les succursales de sociétés étrangères 840
Chapitre III – Le droit international privé 843
Partie IV – Les restructurations et les groupes de sociétés 845
Chapitre I – Les transformations de sociétés avant la Loi de Moderinsation 848
Chapitre II – Les transformations de sociétés depuis 2016 853
Chapitre III – Les fusions et scissions de sociétés 857
Chapitre IV – Les transferts d'actifs, de branches d'activités et d'universalité et transfert du patrimoine professionnel 897
Chapitre V – Les groupes de sociétés 901

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

SOMMAIRE V

Partie V – Le droit de la faillite 917
Titre I – La faillite **920**
Chapitre I – Les conditions de la faillite 920
Chapitre II – L'état de faillite 932
Chapitre III – La gestion contrôlée 1004
Chapitre IV – Des sursis de paiement 1015
Chapitre V – Le règlement européen 1019
Titre II – Les procédures particulières de faillite **1022**
Chapitre I – Assainissement et liquidation des entreprises d'assurances 1022
Chapitre II – Assainissement et liquidation d'établissement du secteur financier 1023
Chapitre III – Liquidation des OPC 1024
Chapitre IV – Assainissement et réorganisation du notariat 1027
Titre III – Des banqueroutes **1028**
Chapitre I – La banqueroute simple 1029
Chapitre II – La banqueroute frauduleuse 1032
Chapitre III – De la réhabilitation 1033
Bibliographie 1035
Index 1045

LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

AVANT-PROPOS

Le présent ouvrage entend faire une présentation générale du droit des sociétés luxembourgeois. La doctrine en cette matière, même si elle s'est considérablement développée au cours de ces dernières années, reste clairsemée : ce ne sont guère que les innovations législatives, trouvant souvent leur origine dans le droit européen, ou encore induites par les exigences de la place financière, qui attirent l'intérêt des auteurs et se voient offrir les honneurs d'une publication d'un article dans une revue spécialisée.

Le droit des sociétés, comme d'ailleurs le droit commercial dans son ensemble, constitue un des facteurs de compétitivité de la place financière, ce qui explique d'ailleurs un certain regain d'intérêt. Le droit fiscal a de tous temps été utilisé comme un instrument destiné à offrir un cadre accueillant aux investisseurs étrangers. Encore faut-il que le droit des sociétés complète l'infrastructure juridique. En effet, de façon quasi générale, l'implantation au Luxembourg passe par la constitution d'un véhicule de droit luxembourgeois : il s'agit presque toujours d'une société de capitaux. Il n'est pas sûr que cet aspect soit suffisamment reconnu.

La troisième édition du présent *Manuel de droit des sociétés* tient évidemment compte des multiples changements de la « *Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises* » (ci-après, la **Loi de Modernisation**) ainsi que des nombreux autres changements prévus par les différentes lois spéciales (notamment la Loi **AIFM**[1] du 12 juillet 2013) prises depuis 2011 (année de la deuxième édition).

L'ouvrage est d'abord destiné aux étudiants. Il s'adresse encore aux praticiens qui appliquent le droit des sociétés dans leur activité quotidienne et recherchent des réponses aux problèmes qu'ils rencontrent au gré de leurs activités.

Luxembourg, le 28 février 2019

1 – Abréviation de *Alternative Investment Fund Managers*.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ACE	Ace Magazine (comptabilité, fiscalité, audit et droit au Luxembourg)
aff.	Affaire
AG	Assemblée générale
anc.	Ancien / anciennement
Ann. dr. lux.	Annales de droit luxembourgeois
arr.r.b.	Arrêté royal belge
art.	Article
ASSEP	Association d'épargne-pension
Aufl.	*Auflage* (« Édition »)
b.	Belge
Bd., Bde	*Band, Bände* (« Tome(s) »)
BDB	Bulletin Droit et Banque (Luxembourg)
BDFI	Bulletin de documentation fiscale internationale (Pays-Bas)
BIJ	Bulletin d'Information sur la Jurisprudence (Luxembourg)
Bull. CE	Bulletin des Communautés européennes
Bull. civ.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation de France : Chambres civiles (France)
Bull. Joly	Bulletin mensuel Joly d'information des sociétés (France)
c/	contre
CA	Cour d'appel
c.-à-d.	c'est-à-dire
C. arb.	Conseil arbitral
Cass.	Cour de cassation
Cass. b.	Cour de cassation belge
Cass. fr.	Cour de cassation française
C.c.	Code civil
C.com.	Code de commerce
CDFI	Cahier de droit fiscal international (Pays-Bas)
CE	Conseil d'État
CEDH	Convention européenne des droits de l'homme
CEE	Communauté économique européenne
CES	Conseil économique et social

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CF	Code fiscal
cf.	*confer*
chron.	chronique
circ.	Circulaire
civ.	civil
CJCE / CJUE	Cour de justice des Communautés européennes / Cour de justice de l'Union européenne
com.	de commerce / commercial(e)
comp.	Comparer
Const.	Constitution
contra	solution contraire, d'un avis contraire
Corr.	Tribunal correctionnel
C.pén.	Code pénal
CREDOC / JUDOC	Base de données regroupant les décisions de justice les plus importantes rendues par les tribunaux luxembourgeois
CSJ	Cour supérieure de justice
C. trav.	Cour du travail (Belgique)
CSSF	Commission de Surveillance du Secteur Financier
D.	Dalloz
Deuxième directive	Directive 77/91/CEE du 13 décembre 1976, (puis notamment 2012/30/UE, et en dernier lieu directive 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)
Douzième directive	directive 89/667/CEE (puis directive 2009/102/CE)
Doc. parl.	Documents parlementaires
D.P.	Dalloz Périodique (France)
Dr. sociétés	Droit des sociétés (France)
DPS	Droit préférentiel de souscription
Éd.	Édition
et al.	et autres
etc.	*et cetera*
Euro Tax	European Taxation. Journal officiel de la Confédération fiscale européenne
fasc.	Fascicule
FCP	Fonds commun de placement
FIS	Fonds d'investissement spécialisé
fr.	français (-e)
FS	*Festschrift*
G.-D.	Grand-Duché de Luxembourg
GSN	Groupe spécial de négociation
HGB	*Handelsgesetzbuch* (Code de commerce allemand)
Hrsg	*Herausgeber* (« éditeur »)
Huitième directive	directive 84/253/CEE (puis directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés […])

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ibid	ici même, renvoie à la même référence que précédemment
ID	Référence à plusieurs chiffres permettant au lecteur abonné à la base de données juridiques en ligne Lexnow de retrouver la référence citée très rapidement
infra	plus bas, c.-à-d. renvoi à une page ultérieure
IRE	Institut des Réviseurs d'Entreprises
IAS	*International Accounting Standards*
ICC	Impôt commercial communal
IRC	Impôt sur le revenu des collectivités
IFRS	*International Financial Reporting Standards*
IUIL	Institut Universitaire International Luxembourgeois
J.C.B.	Jurisprudence commerciale de Belgique
J.C.P.	JurisClasseur périodique (France)
JDF	Journal de Droit Fiscal (Belgique)
JDI	Journal du droit international (Clunet)
jgt	Jugement
J.P.	Justice de paix
J.P.A.	Jurisprudence du port d'Anvers (Belgique)
J.T.	Journal des tribunaux
J.T.T.	Journal des tribunaux du travail (Belgique)
Jur. Liège	Jurisprudence de la Cour d'appel de Liège (Belgique)
L	Loi
L.I.R.	Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
LGDJ	Librairie générale de droit et de jurisprudence
LJUS	Jurisprudence luxembourgeoise ; v. CREDOC / JUDOC
Loi AIFM	Loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
Loi de 1915	Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
Loi de 2002	Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés et les comptes annuels des entreprises
Loi de Modernisation	Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
L.C.S.C.	Lois (belges) coordonnées sur les sociétés commerciales (correspondent à la L.S.C. luxembourgeoise)
L.S.C.	Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
Lux.	Luxembourg
Mém.	*Mémorial*
NCPC	Nouveau Code de procédure civile
n.d.l.r.	Note de la rédaction

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

n°	numéro
nouv.	nouveau / nouvellement
OCDE	Organisation de coopération et de développement économique
OECD	*Organization for Economic Cooperation and Development*
OECL	Ordre des Experts Comptables Luxembourgeois
ONU	Organisation des Nations Unies
Onzième directive	directive 89/666/CEE (puis notamment directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)
OPC	Organisme de placement collectif
OPCVM	Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
OR	Organe de représentation des travailleurs
p.	page
P.	Pasicrisie (Recueil des décisions de jurisprudence au Luxembourg)
Pand. pér.	Pandectes périodiques
Pas.	Pasicrisie (Recueil des décisions de jurisprudence belge)
P.C.N.	Plan comptable normalisé
p. ex.	par exemple
Première directive	directive 68/151/CEE (puis notamment 2009/101/CE, et en dernier lieu la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)
Quatrième directive	directive 78/660/CEE (puis en dernier lieu, directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises [...] (*JO* L 182 du 29 juin 2013, pp. 19–76)
R.A.J.B.	Recueil annuel de jurisprudence belge
R.C.J.B.	Revue critique de jurisprudence belge
R.C.S.	Registre de commerce et des sociétés
R.D.C.B.	Revue de droit commercial belge
RE/REA	Réviseur d'entreprises / Réviseur d'entreprises agréé
Rec.	Recueil des arrêts
réf.	référé
Règl.gr.-d.	Règlement grand-ducal
Rép. dr. com.	Répertoire de droit commercial (Dalloz)
RESA	Recueil électronique des sociétés et associations
Rev. Banque	Revue de la banque
Rev. crit. dr. int. pr.	Revue critique de droit international privé (France)
Rev. dr. pén.	Revue de droit pénal et de criminologie (Belgique)
Rev. prat. soc.	Revue pratique des sociétés civiles et commerciales (Belgique ; revue désormais remplacée par la revue R.P.S.)

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Rev. rég. dr.	Revue régionale de droit
Rev. Soc.	Revue des sociétés
R.G.D.C.	Revue générale de droit civil belge
RIW	*Recht der Internationalen Wirtschaft*
R.P.D.B.	Répertoire pratique de droit belge
R.P.S.	Revue pratique des sociétés (Belgique)
RSLF ou RSF	Revue de science et législation financière (avant 1956), puis Revue de science financière (France)
RStBl	*Reichssteuerblatt* (aujourd'hui *BStbl*, Allemagne)
RTD civ.	Revue trimestrielle de droit civil (France)
RTD com.	Revue trimestrielle de droit commercial (France)
RTD eur.	Revue trimestrielle de droit européen (France)
R.W.	*Rechtskundig weekblad* (Belgique)
S.	Recueil Sirey (France)
ss.	et suivant(e)s
S.A.	Société anonyme
SAS	Société par actions simplifiée
S.à r.l.	Société à responsabilité limitée
SE	*Societas Europaea*, Société européenne
SEC	Société coopérative européenne
S.e.c.a.	Société en commandite par actions
S.e.n.c.	Société en nom collectif
S.e.c.s.	Société en commandite simple
S.e.c.-Sp.	Société en commandite spéciale
SEPCAV	société d'épargne-pension à capital variable
SICAV	société d'investissement en capital variable
SICAF	société d'investissement en capital fixe
Septième directive	Directive 83/349/CEE (puis Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises […])
Sixième directive	Directive 82/891/CEE (puis notamment directive 2009/109/CE et en dernier lieu directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)
S.p.r.l.	Société privée à responsabilité limitée (Belgique)
StAnpG	*Steueranpassungsgesetz* (Loi d'adaptation fiscale, L.A.F.)
T.	Tome
T.R.V.	*Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap* (Belgique)
TA	Tribunal d'arrondissement
Tadm	Tribunal administratif
TFUE	Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Trib.com.	Tribunal de commerce

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Troisième directive	Directive 78/855/CEE (puis directive 2011/35/UE, et en dernier lieu directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)
UE	Union européenne
UEBL	Union économique belgo-luxembourgeoise
v.	Voir
Vº	*Verbo*
Vol.	Volume

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

INTRODUCTION

« *C'est parce que les hommes, dans leur isolement, sont faibles et impuissants, qu'ils s'associent : c'est le mobile de toute association ; mais pour que l'association constitue une société, il faut de plus que ceux qui unissent leurs efforts le fassent pour retirer un bénéfice de la chose qu'ils mettent en commun. C'est le caractère qui distingue la société de la simple communauté* »[1].

Le droit des sociétés fait partie du droit commercial et, à ce titre, relève donc du **droit privé**. Le droit commercial est le droit spécial des commerçants, catégorie de personnes plus averties que les simples particuliers, encore appelés « consommateurs » (du moins s'ils interviennent en tant qu'utilisateurs de biens et de services). Le droit des sociétés est donc la partie du droit consacrée aux sociétés et, plus spécifiquement, aux sociétés commerciales.

Cette matière, comme toutes les branches du droit, n'échappe pas à l'**activisme du législateur** et fait ainsi l'objet de modifications législatives continues, sans avoir pourtant fait l'objet d'une réforme globale depuis 1915. « *Les lois doivent être préparées avec une sage lenteur. Les États ne meurent pas, et il n'est pas expédient de faire tous les jours de nouvelles lois* »[2]. Telle n'est plus la devise du législateur moderne.

La devise de notre législation sur les sociétés a pu être résumée ainsi : « *Liberté pour les associés, sécurité pour les tiers* », selon la formule de 1882 du professeur Nyssens, mandaté par le gouvernement luxembourgeois pour établir un avant-projet de loi[3], formule maintes fois reprise par la suite. Cette devise a encore guidé les auteurs de la Loi de Modernisation.

Nous allons dans les paragraphes suivants faire l'historique du droit des sociétés luxembourgeois avant de nous consacrer aux nouvelles tendances de ce droit, tendances qui sont essentiellement celles du droit de l'Union européenne, même s'il est vrai que, récemment, un grand nombre de mesures prises (ou du moins annoncées) trouvent leur source ailleurs.

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 148.

2 – J.-E.-M. Portalis, Exposé des motifs sur le Code civil de 1804.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 4.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – L'historique du droit des sociétés luxembourgeois

Le droit des sociétés est une branche assez **récente** du droit en général et du droit commercial en particulier. Sa première apparition sérieuse en droit positif luxembourgeois date de 1808 avec le Code de commerce napoléonien (applicable à partir de 1808), maintenu en vigueur au Luxembourg après le traité de Vienne de 1815.

A – Le Code de commerce

Les articles 18 à 64 de ce Code étaient consacrés aux sociétés commerciales. Les choix offerts aux commerçants étaient toutefois assez limités, car le Code de commerce ne prévoyait qu'un nombre réduit de sociétés, à savoir, en dehors des sociétés par actions, deux sociétés de personnes : la société en nom collectif, d'une part, qui depuis le Moyen Âge constitue l'archétype de la société commerciale (impliquant que tous les associés sont commerçants et que leur responsabilité est illimitée et solidaire) ; la société en commandite simple, d'autre part, organisme fonctionnellement plus spécialisé associant les associés gérants et les associés « **bailleurs de fonds** », ces derniers n'assumant qu'une responsabilité limitée. Cette dernière forme de société remonte elle aussi, au Moyen Âge et s'est développée dans le secteur maritime, avec le contrat de « **commanda** » connu dans les ports italiens dès le xe siècle, contrat conclu entre un marin et un bailleur de fonds. Le bailleur de fonds fournissait soit un navire soit une cargaison (ou encore les deux) et participait au profit de l'opération. Le risque qu'il encourait était de perdre sa mise, en cas d'échec de l'opération[1].

Cette pratique s'est par la suite étendue au commerce terrestre et a permis à certaines catégories de personnes pour qui le commerce était interdit (ou du moins était déconseillé) de participer à de telles opérations de commerce tout en conservant leur anonymat. La commandite fut ainsi à l'origine de la responsabilité limitée en matière de droit des sociétés[2].

En outre, le Code de commerce distinguait deux sortes de sociétés par actions, à savoir la société anonyme et la société en commandite par actions. La société en commandite par actions pouvait être librement constituée, alors que la constitution d'une société anonyme était subordonnée à l'**autorisation** du gouvernement, car ce type de société était considéré avec une certaine méfiance par le législateur[3]. La jurisprudence considérait que toute société anonyme constituée sans autorisation gouvernementale était entachée de **nullité**[4].

Les déficiences de ce système ne devaient pas tarder à se montrer au grand jour. Lenteurs excessives incompatibles avec les nécessités de la vie des affaires, danger que le public fît une confiance excessive à l'autorisation gouvernementale, etc.[5]. « *Le public, mis en confiance par l'autorisation du gouvernement, s'imaginait que celle-ci était un brevet d'avenir, faisait à une entreprise un accueil que sa situation réelle ne méritait pas* »[6].

---

1 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés*. *Précis*, p. 338.

2 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés*. *Précis*, p. 339.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 18.

4 – Pour une critique globale de ce système d'autorisation, v. C. Resteau, *Traité des sociétés anonymes*, T. 1., p. 7.

5 – C. Resteau, *Traité des sociétés anonymes*, T. 1., p. 16.

6 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 123.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Le système de l'autorisation gouvernementale (qui était très répandu dans tous les pays européens pendant le XIXe siècle) avait partout été aboli avant la fin dudit siècle. Dès 1873, l'autorisation préalable fut abandonnée en Belgique. On considérait, probablement à juste titre, qu'il s'agissait d'une entrave qui n'était compensée par aucun avantage sérieux[1]. « *[...] la loi, quelque attentive et prudente qu'elle soit, ne peut pas et ne doit pas avoir la prétention d'empêcher tous les abus. Le pire des abus, a dit un philosophe, c'est de n'en pouvoir souffrir aucun ! Bien plus, si nous voulons que le public fasse son éducation et qu'il devienne plus perspicace dans les questions qui l'intéressent directement, il serait peu sage de le décharger, par une tutelle excessive, du contrôle qu'il lui incombe d'exercer. Ce qu'il faut, c'est lui fournir les moyens d'exercer par lui-même ce contrôle et de contracter en connaissance de cause* »[2].

Le droit des sociétés est resté inchangé pendant le XIXe siècle et, dans notre pays, il n'a connu de progrès notable qu'au début du siècle dernier.

B – La L.S.C.

La loi belge de 1873 représentait un progrès considérable par rapport aux dispositions que le Code de commerce consacrait au droit des sociétés. Compte tenu de cette évolution connue par notre voisin, l'absence de loi moderne en cette matière était de plus en plus considérée comme une grave lacune susceptible de considérablement **freiner le développement économique** du pays. C'est ainsi que le gouvernement luxembourgeois de l'époque, présidé par Paul Eyschen, demanda en décembre 1882 au professeur de droit de Louvain Albert Nyssen d'élaborer un « avant-projet de loi sur les sociétés commerciales », ceci sans trop s'écarter des grands principes instaurés par la loi belge du 18 mai 1873 et « *tout en évitant les innovations trop hardies et que l'expérience n'aurait pas déjà sanctionnées ou tout au moins commandées* »[3].

Malgré les éloges que ce travail reçut de la part d'Eudore Pirmez[4], ce document ne devait pas être adopté, justement pour avoir été jugé trop téméraire ; un deuxième avant-projet fut donc commandé à Jean Corbiau, autre professeur de droit à Louvain.

Cet « avant-projet Corbiau », calqué sur les lois belges de 1873-1886 fut remis au Conseil d'État luxembourgeois en 1906. En date du 9 juin 1909, le Conseil d'État émit un avis en reprenant quasiment tel quel le projet Corbiau[5]. Ce projet fit encore l'objet d'un avis de la Chambre des députés tenant compte de la nouvelle loi belge adoptée en date du 1er juin 1913, non sans reprendre de la loi française du 22 novembre 1913 les dispositions concernant les modifications statutaires dans les sociétés anonymes[6].

---

1 – A. NYSSENS, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 57, ID 11305.

2 – C. RESTEAU, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, Carton de Wiart, p. 148.

3 – A. NYSSENS, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 7, ID 11305.

4 – E. PIRMEZ, *Observations présentées sur l'avant-projet de loi sur les sociétés commerciales* [rédigé par A. Nyssens], p. 32, jugeait « l'avant-projet [...] comme un travail des plus complets et des plus judicieux qui ait été fait sur la matière ».

5 – L. METZLER, « Le régime légal des sociétés et des associations en droit luxembourgeois », *R.P.S.*, p. 242.

6 – E. PIRMEZ, *Observations présentées sur l'avant-projet de loi sur les sociétés commerciales* [rédigé par A. Nyssens], p. 243.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Consécutivement à la promulgation de la loi belge des sociétés du 25 mai 1913, le législateur luxembourgeois a emboîté le pas à son homologue belge en adoptant finalement la loi dans le courant de l'année 1915 : la loi du 10 août 1915 (loi sur les sociétés commerciales, L.S.C. ci-après)

Cette loi, toujours en vigueur au début du XXIe siècle, tout en ayant subi des changements sur de très nombreux points, reste dans les grandes lignes d'application aujourd'hui.

C'est cette loi qui a introduit les sociétés par actions (société anonyme par actions, S.A., et société en commandite par actions, S.C.A.) dans la forme applicable de nos jours, toutes les deux à responsabilité limitée.

En plus de la société en commandite par actions, la loi a repris du Code de commerce la société en commandite simple. C'est dans les sociétés en commandite que la **spécialisation fonctionnelle** – avec la distinction entre l'organe souverain regroupant tous les associés de la société, l'organe de gestion et l'organe de contrôle – était poussée le plus loin.

Par ailleurs, cette loi a encore introduit une forme de société hybride, à savoir la **société coopérative** qui, elle aussi, avait déjà connu de beaux jours à l'étranger : cette forme de société était basée en quelque sorte sur l'idée du **capitalisme populaire** dans la mesure où le **mouvement coopératif** repose sur l'idée que les associés sont en même temps producteurs et consommateurs, banquiers et utilisateurs de crédit. En éliminant ainsi les intermédiaires, on élimine le « profit capitaliste ».

L'étape suivante du développement du droit des sociétés intervient dans l'entre-deux-guerres : il s'agit de la loi du 18 septembre 1933.

C – La loi du 18 septembre 1933

Cette loi introduisit en droit luxembourgeois la forme de société qui, de nos jours, est la plus utilisée, à savoir la société à responsabilité limitée, la S.à r.l. Située entre la société de capitaux et la société de personnes, la S.à r.l. allie le caractère de la responsabilité limitée, propre aux sociétés de capitaux, au caractère fermé, *intuitu personae*, des sociétés de personnes. En d'autres termes, il s'agit juridiquement d'une **société hybride**, à l'instar de la forme de la société coopérative[1].

Au fil du temps, une nouvelle source du droit des sociétés s'imposa dans la forme du droit de l'Union européenne.

D – La Loi de Modernisation (loi du 10 août 2016)

Cette loi, qui aurait dû être adoptée une année plus tôt pour faire correspondre sa date de promulgation avec la date du 100e anniversaire de la loi originaire de la

1 – Malgré ce caractère hybride, le droit fiscal reprend ce type de sociétés dans la catégorie des sociétés de capitaux en les soumettant donc au traitement fiscal applicable aux sociétés par actions. De cette manière, ce type de société est donc considéré comme sujet fiscal au même titre que les sociétés anonymes ; les associés ne sont soumis à imposition que dans la mesure où la société leur distribue des revenus, que ce soit sous forme de dividendes, d'intérêts, de loyers ou encore de salaires (pour le cas où les associés rendent d'autres prestations de nature spécifique à la société).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

L.S.C., constitue sans le moindre doute possible la **réforme la plus importante** que la L.S.C. ait jamais connue depuis son adoption en pleine Première Guerre mondiale. Le législateur a entendu réformer non seulement le fond de la loi sur les sociétés commerciales, mais également la forme, ce qui a conduit en particulier à une renumérotation complète des dispositions de la L.S.C.

1) Coordination des dispositions de la L.S.C.

Dans sa version initiale, le projet de loi n° 5730 avait prévu l'habilitation du Grand-Duc à regrouper dans un nouveau « Code des sociétés » les dispositions du Code civil relatives aux sociétés et celles de la L.S.C., en tenant compte des modifications de la Loi de Modernisation. Dans ce travail, le Grand-Duc peut :

« *1 harmoniser les dispositions et en accroître la compréhension sans toutefois y apporter de modification de fond ;*

2 modifier la forme, notamment la syntaxe et le vocabulaire, la présentation, l'ordre et la numérotation de ces dispositions, les regrouper en titres, livres, chapitres, sections et paragraphes, le cas échéant, en les dotant d'un intitulé ;

3 adapter la rédaction de ces dispositions en vue d'assurer leur concordance et d'uniformiser leur terminologie [sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes y inscrits] ;

4 modifier les références contenues dans les dispositions en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle ;

5 mettre en concordance les références aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales contenues dans les dispositions d'autres lois avec les adaptations y apportées en vertu de la présente habilitation ».

L'idée formulée par le projet de loi n° 5730 était donc de faire « *une codification à droit constant* », c.-à-d. de ne changer en quoi que ce soit le fond des dispositions (« *sans toutefois y apporter de modification de fond* »). Toutefois, cette exigence est difficilement compatible avec les passages ci-dessus soulignés (par nous).

Par la suite, l'idée de la codification a été entièrement abandonnée, et la Loi de Modernisation a retenu une simple « coordination » de la L.S.C. dans les termes suivants : « *Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la présente loi. La numérotation des parties, titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter les références y contenues. Les coordinations porteront l'intitulé suivant : « Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales* ».

Ce travail de coordination a été réalisé par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

2) Date d'entrée en vigueur de la Loi de Modernisation et dispositions transitoires

Soulignons d'emblée que les développements consacrés ici aux problèmes que ces dispositions peuvent soulever sont limités du fait que, au moment de la présente mise à jour de ce manuel, la période transitoire est bien révolue. Le

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

lecteur à la recherche d'une étude approfondie sur la question des dispositions transitoires est renvoyé à une étude détaillée publiée par Steve Jacoby[1].

Compte tenu de l'envergure des changements apportés à la L.S.C. par la Loi de Modernisation, il n'était pas envisageable de faire application exclusive du droit commun, c.-à-d. de considérer toutes les dispositions comme applicables trois jours francs après leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ce régime de droit commun a effectivement été rendu applicable pour partie, et les dispositions nouvelles (celles de la Loi de Modernisation) étaient d'application immédiate (c.-à-d. qu'elles s'appliquaient donc dès le **23 août 2016**), mais seulement **aux sociétés nouvelles**, celles constituées à partir de cette date.

À l'égard des sociétés existantes, constituées donc avant cette date, des **dispositions transitoires** s'appliquaient, permettant aux sociétés existantes de se mettre de façon retardée en conformité avec les nombreux changements introduits par la Loi de Modernisation. En effet, cette mise en conformité nécessitait dans la majorité des cas des changements de statuts à réaliser quasiment toujours par acte notarié (notamment dans le cas des sociétés de capitaux), de sorte que cette transition ne pouvait matériellement se faire que sur une période de temps étendue.

L'alinéa 4 de l'article V de la Loi de Modernisation prévoit un **délai de 24 mois** à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour l'adaptation des statuts aux dispositions légales nouvelles. En attendant les modifications statutaires, c'étaient donc les dispositions de la loi ancienne qui continuaient de s'appliquer. « *Dans l'intervalle, [les sociétés existantes] demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures. Les décisions d'adaptation sont prises dans les formes et sont sujettes aux publications requises pour la modification des statuts. Toutefois lorsqu'une modification des statuts s'impose en raison du seul fait que ceux-ci font référence à une disposition abrogée ou dont la numérotation a été changée par l'effet de la présente loi, l'organe de gestion est habilité à procéder aux modifications nécessaires. À défaut d'adaptation des statuts, les clauses statutaires contraires aux dispositions de la présente loi seront réputées non écrites et les dispositions impératives de celle-ci seront applicables* »[2]. Cette disposition transitoire était très similaire à celle retenue par la loi belge du 18 juillet 1991, loi qui a réformé fondamentalement la loi belge sur les sociétés commerciales.

Comme soulignée par la doctrine, cette phrase lapidaire n'est pas sans soulever des difficultés d'interprétation. La loi vise-t-elle toutes les dispositions de la loi ancienne (il est donc fait comme si la loi nouvelle n'existait pas) ou convient-il de considérer que ces dispositions ne visent que les seules clauses statutaires qui sont tombées contraires à des dispositions légales impératives nouvellement introduites ? Il y a probablement lieu de considérer que la deuxième solution s'impose[3]. Une des conséquences de cette approche est que les **dispositions impératives (et celles d'ordre public)** de la Loi de Modernisation s'appliquent d'office à tous les cas sur lesquels les statuts sont muets.

En l'absence de modification statutaire dans le délai légal imposé par la loi, les dispositions de la loi ancienne sont réputées non écrites et remplacées par les

1 – St. Jacoby, « Dispositions transitoires et entrée en vigueur de la loi », *La réforme du droit des sociétés luxembourgeois*, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 291 ss.

2 – Art. V de la Loi de Modernisation, ID 24886.

3 – En ce sens également St. Jacoby, *op. cit.*, p. 296.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dispositions impératives (auxquelles il faut ajouter celles qui sont d'ordre public) de la nouvelle loi.

Les rédacteurs des statuts des sociétés ont souvent pour habitude de renvoyer aux dispositions légales impératives, alors que ces renvois sont en principe inutiles, ces dispositions s'appliquant de toute façon. Au lieu de renvoyer à un article précis de la loi, le texte de cet article est souvent copié dans l'acte de société. Dans ce deuxième cas, le doute n'est pas permis, et il faut considérer que les auteurs des statuts ont entendu se soumettre aux dispositions de la loi dans la forme qu'elle avait avant le 23 août 2016. Prenons à titre d'exemple la disposition qui permettait aux actionnaires ayant seuls ou ensemble 20 % des voix au moins d'ajouter un point à l'ordre du jour, faculté contenue à l'article 450-8 [anc. art. 70] L.S.C. La Loi de Modernisation a procédé à un abaissement de ce seuil à 10 %. Si les statuts ne faisaient que renvoyer à l'article 70 L.S.C., alors on peut (malgré certaines prises de position doctrinales contraires) considérer que les auteurs des statuts avaient l'intention d'inclure ce régime légal ancien dans leurs statuts[1]. Cette conclusion vaut à plus forte raison quand le texte de l'article 70 L.S.C. ancienne version est repris dans les statuts. Donc, dans les deux cas de figure, il y avait lieu de continuer à appliquer l'ancien régime (en l'occurrence, il faut donc 20 % des voix pour pouvoir ajouter un point à l'ordre du jour de l'assemblée générale), et ceci, jusqu'à l'expiration du régime transitoire (ou encore jusqu'au moment de la modification des statuts qui reprend le nouvel seuil dans les statuts sociaux).

L'article V de la Loi de Modernisation comprend en plus de la règle transitoire générale **deux règles transitoires spécifiques** :

1) Les **sociétés coopératives** constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient, en l'absence de dispositions statutaires relatives à leur durée, de la disposition contenue à l'article 117, 1°, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

   L'effet de cette disposition est de faire bénéficier les sociétés coopératives de la **durée illimitée** (applicable dans le silence des statuts), alors que, sous le régime antérieur, le silence des statuts sur ce point signifiait que les sociétés avaient une **durée limitée à 10 ans**.

2) Les sociétés au sein desquelles, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est institué un organe de gestion qui porte le nom de « **comité de direction** », doivent, dans le délai fixé en 1), se conformer aux dispositions des articles 60-1, 60-2 et 191*bis*, paragraphe (5), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

   Ce texte assure la transition entre les comités de direction introduits selon l'ancienne loi (qui ne prévoyait pas ce régime de façon spécifique) et ceux fondés sur la Loi de Modernisation. Même si ces deux comités portent le même nom, ils sont fondamentalement différents (comme expliqué en détail ailleurs).

3) Appréciation générale de l'apport de la Loi de Modernisation

Notre évaluation du travail fait par la Loi de Modernisation est basée sur les commentaires de l'époque dans les avis sur le projet de loi n° 5730. « *Le* ***Conseil***

1 – St. Jacoby, *op. cit.*, p. 300.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

d'État *reste sur sa faim quant aux explications de nombreuses modifications proposées et du choix des solutions. […] Les auteurs ont alors pris la décision de modifier ou de maintenir les dispositions correspondantes sans cependant en expliquer la nécessité ou l'utilité. En plus, ils ont opté soit pour la solution belge, soit pour la solution française, soit même pour une combinaison, sans commenter autrement le choix opéré. Cette attitude rend très difficile la compréhension de certains textes et enlève surtout toute ligne directrice à la réforme. Le Conseil d'État aurait hautement apprécié si le commentaire des articles avait fourni les explications nécessaires à la compréhension de l'intention des auteurs, d'autant plus qu'un tel commentaire revêt une nécessité majeure pour l'application des textes, le contrôle des applications pratiques et la solution des litiges en cas de procédure judiciaire* »[1].

« *Les propositions qui s'appliquent tant à la société anonyme qu'à la société à responsabilité limitée, aux deux sortes de sociétés coopératives et à la nouvelle société par actions dite simplifiée auront pour conséquence que non seulement la société anonyme, qui par destination devra gérer des entreprises plus importantes avec des enjeux économiques majeurs, deviendra un véhicule très difficilement gérable, mais aussi les autres sociétés, et notamment la société à responsabilité limitée qui était jusqu'à présent une société du type de société de personnes, deviendra une société où cette caractéristique va se perdre par son assimilation à la société anonyme. Sa gestion devient d'ailleurs plus lourde et plus compliquée. Il est évident que pour cette dernière société aussi la sécurité des tiers et la responsabilité des gérants doit être renforcée, car le passé a montré trop souvent des situations inéquitables entre le sort réservé aux créanciers et celui du ou des gérants. Cependant, imposer des règles de fonctionnement presque aussi lourdes à la société à responsabilité limitée qu'à la société anonyme dépasse la mesure* »[2].

« *Le Conseil d'État a la très nette impression que le projet de loi et les amendements parlementaires sont surtout destinés à faciliter la gestion de sociétés à capital international et ayant un actionnariat qui est très distant du siège de la société. Il est proposé de ce fait un certain nombre de facilités pour le conseil d'administration et les assemblées générales qui sont susceptibles d'empêcher la participation des administrateurs à la gestion de la société et les droits des actionnaires. Le Conseil d'État est conscient qu'une société financière doit être gérée des fois avec des prises de décision beaucoup plus rapides qu'une société à objet commercial ou industriel ou même une PME ; prévoir pour cette raison dans la loi générale une gestion plus utile à un genre de société qu'aux autres lui semble léser l'intérêt général d'une loi organisant toutes les formes de sociétés. Il est d'avis que la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est plus adaptée aux sociétés purement luxembourgeoises, car elle règle les formes de sociétés utilisées surtout par les commerçants et industriels luxembourgeois de façon plus simple et plus adaptée à leurs besoins* »[3].

Les commentaires de la **Chambre de commerce** vont dans le même sens que ceux du Conseil d'État. « *Les auteurs du Projet ont eu le bon réflexe de se baser sur les principes fondamentaux déjà utilisés par le professeur NYSSENS lors de ses travaux préparatoires sur la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Malheureusement,*

1 – Avis du Conseil d'État, *Doc. parl.*, n° 5730/4, p. 1, ID 13321.
2 – Avis du Conseil d'État, *Doc. parl.*, n° 5730/4, p. 2, ID 13321.
3 – Avis du Conseil d'État, *Doc. parl.*, n° 5730/4, p. 3, ID 13321.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

le but des auteurs de modifier substantiellement le droit des sociétés luxembourgeois et de créer un droit facile d'emploi et d'accès n'est pas atteint. La Chambre de commerce déplore que la plupart des changements n'aient pas été clairement expliqués et mis en relation avec la pratique luxembourgeoise. Le but de simplification de la loi n'est pas encore complètement atteint, du moins pas dans son intégralité. En effet, certaines procédures jusqu'à maintenant peu formalistes, se voient octroyer des obligations supplémentaires (par exemple des rapports supplémentaires) sans qu'une réelle cause et plus-value puisse en être détectée. Finalement, certaines des modifications proposées engendreront des coûts non négligeables pour les sociétés concernées, que notamment les plus petites structures auront du mal à assumer »[1].

« *Tout en reconnaissant l'ampleur du travail accompli, la* ***Chambre des Notaires*** *a relevé à la lecture des textes des projets (projet de loi n° 5730 déposé en 2007 ainsi que les amendements apportés par les commissions juridiques en 2009 et 2015) que le nouveau droit qui sera issu de la refonte de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sera particulièrement adapté aux sociétés financières au détriment des sociétés commerciales de type classique. Les commentaires des articles semblent confirmer cette analyse en ce sens qu'il est fréquemment fait référence aux* hedge funds*,* private equity*, … et non aux sociétés ayant une activité commerciale ou industrielle. Toutefois les articles de la loi sont de portée générale et non limités à ces types de sociétés. La Chambre des Notaires a le sentiment que les modifications introduites de manière générale ne seront pas adaptées aux sociétés commerciales de type classique qui existent encore en grand nombre au Grand-Duché de Luxembourg. La Chambre des Notaires regrette que dans de nombreux cas, les auteurs du projet de loi n'aient pas suffisamment exposé les motifs de leurs propositions. Les commentaires des articles ne font souvent qu'une simple référence aux droits belge ou français sans justification supplémentaire. L'éventualité de pouvoir puiser dans la doctrine et la jurisprudence françaises représente certes un avantage non négligeable mais ne justifie pas en soi la qualité de la solution adoptée. Une justification de l'introduction de dispositions de droit des sociétés étrangers dans le droit des sociétés luxembourgeois serait la bienvenue* »[2].

Ces critiques nous paraissent entièrement fondées. La Loi de Modernisation n'a pas procédé à une réforme cohérente. Il y a de nombreuses nouveautés introduites qui, pour la plupart, sont des copies conformes des dispositions légales de nos voisins de l'ouest, essentiellement de la Belgique. Le modèle de société que la réforme avait en vue était celui des acteurs du secteur financier, souvent caractérisés par des capitaux investis pléthoriques. À supposer que les lourdeurs administratives supplémentaires que la Loi de Modernisation leur impose soient justifiées dans leur cas (ce qui reste entièrement à prouver), tel n'est certainement pas le cas de la petite société industrielle ou commerciale qui, elle, n'a comme capitaux propres investis que le capital social minimum imposé par la loi. Cette approche « *one size fits all* » à la base notamment de la Loi de Modernisation mérite d'être revue fondamentalement à l'avenir. On pourrait, par exemple, prévoir des exemptions de nombreuses formalités, largement inutiles, basées sur les critères de taille. À cette fin, on pourrait se servir utilement des critères de définition des « petites sociétés » (art. 35 Loi de 2002) qui seraient alors exonérées de certaines mesures (à condition, encore une fois, que l'on

1 – Avis de la Chambre de commerce, *Doc. parl.*, n° 5730/2, p. 20, ID 10497.

2 – Avis de la Chambre des notaires, *Doc. parl.*, n° 5730/8, p. 2, ID 24209.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conclue que ces rapports sont indispensables pour les autres sociétés). Il paraîtrait également que, dans le but d'accroître la cohérence d'une réforme, il serait indiqué que le pouvoir politique formule quelques lignes directrices qui pourraient guider « les auteurs » dans leur mission de formuler les dispositions nouvelles, dispositions qui seraient alors mesurées à l'aune de ces lignes directrices émises préalablement.

4) Remarque générale sur la prolifération des rapports à rédiger par l'organe de direction

La L.S.C. remonte au 10 août 1915. Si l'on compare cette version d'origine à celle applicable jour pour jour 101 années plus tard (donc en tenant compte des amendements introduits par la Loi de Modernisation), une chose est frappante : on assiste à une prolifération impressionnante des rapports à établir par les dirigeants, rapports obligatoires (en principe) qui, le cas échéant, sont doublés par un autre rapport, celui du réviseur d'entreprises qui commente et évalue le rapport des dirigeants sociaux. Ceci est devenu une sorte de « *default rule* » qui s'applique de plus en plus souvent pour n'importe quelle opération de quelque importance, peut-être pour lui donner un peu de solennité. Sauf erreur de notre part, la Loi de 1915 ne comportait aucun cas de rapport obligatoire à établir par les dirigeants de la société. Entre-temps, les cas de tels rapports obligatoires sont devenus très fréquents, et le nombre augmente à chaque réforme : la Loi de Modernisation ne fait pas exception à cette tendance de fond en soumettant à cette « règle » les cas de transformation de sociétés, de perte grave du capital social, d'émission d'actions au-dessous du pair comptable, etc. etc.

Le début de cette évolution remonte au droit européen, avec les Troisième et Sixième directives en droit des sociétés qui ont prévu que les dirigeants doivent rédiger « un rapport détaillé » qui, à son tour, fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises auquel les actionnaires peuvent toutefois renoncer à l'unanimité. Faute de telle renonciation unanime, l'absence de rapport de réviseur entraîne la nullité de l'opération.

Il convient donc, et en premier lieu, de décider de quelle sorte de nullité il s'agit : nullité absolue ou nullité relative ? La réponse sera différente de cas en cas. Si les associés peuvent, à l'unanimité, renoncer au rapport, il faut en conclure qu'il s'agit d'une nullité relative destinée à protéger les associés (et uniquement ceux-là). La réponse est moins certaine dans les cas où la loi est muette quant aux possibilités de renonciation unanime.

La nullité de l'opération implique que l'opération soit annulée, et ceci, avec effet rétroactif, ce qui peut gravement nuire aux intérêts des tiers. Face au libellé de la loi qui déclare la nullité automatique de l'opération, le juge saisi de l'affaire ne pourra même pas renoncer à la prononciation de la nullité de l'opération.

De façon générale, on a l'impression que le législateur considère qu'en l'absence de rapport les associés, voire les tiers, seraient à la merci de dirigeants peu scrupuleux face auxquels ils seraient dénués de moyens de défense. Or, tel n'est pas le cas : les règles sur la responsabilité des dirigeants sont bien suffisantes, tant à l'égard des associés que des tiers. Le législateur est implicitement d'accord avec ce constat, car, en substance, les dispositions sur la responsabilité des dirigeants n'ont pas été amendées par la Loi de Modernisation (si l'on fait abstraction de « l'action minoritaire »).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Lors de l'élaboration de la Loi de Modernisation de 2016, la devise de la L.S.C. en sa version originale – « liberté pour les associés, sécurité pour les tiers » – a été constamment invoquée. Est-il vraiment conforme à cette devise d'exiger l'établissement d'un rapport et de prévoir comme sanction de l'absence de ce rapport la nullité de l'opération ?

Nous sommes loin de méconnaître que beaucoup de ces rapports sont imposés par les directives européennes, ce qui enlève donc tout choix au législateur national. Mais tel n'est pas toujours le cas. Prenons le cas de la perte grave du capital souscrit visée par l'article 19 de la directive 2012/30/UE. Cette disposition reprise en droit national à l'article 480-2 [anc. art. 100] L.S.C., initialement transposée sans l'exigence d'un rapport, vient d'être modifiée par la Loi de Modernisation pour imposer la rédaction d'un rapport qui « *expose les causes de cette situation et justifie ses propositions dans un rapport spécial […]* ». Ce qui s'est donc passé ici, c'est que, des décennies après avoir transposé la directive *a minima* en droit national, on remet la main à la pâte pour, cette fois-ci, imposer aux sociétés et à leurs actionnaires des formalités non prévues par la directive : la plupart du temps, il ne sert pas à grand-chose de rédiger de savants et volumineux rapports (destinés souvent à décrire l'avenir…), que guère personne ne demande ni ne lit. Ceci n'est non seulement pas conforme à la devise « liberté pour les associés », mais risque encore d'impacter gravement la « sécurité pour les tiers ». En effet, l'absence de rapport (sauf renonciation unanime là où elle est possible) a pour effet de conduire à l'annulation de la décision prise par l'assemblée générale. La société qui a donc décidé la dissolution en l'absence d'un rapport de ses dirigeants sera donc non dissoute. Il serait téméraire d'affirmer que cette solution ne puisse pas avoir de conséquences négatives en termes de sécurité des tiers.

On ne peut s'empêcher de soupçonner qu'à la base de cette multiplication des rapports se trouve une certaine vision bureaucratique, voire dirigiste, du droit des sociétés qui ne nous paraît pas être celle de notre droit. Il n'est pas cohérent que, dans la Loi de Modernisation, on répète inlassablement la devise « liberté pour les associés, sécurité pour les tiers » et que, en même temps, il y ait multiplication des cas de rapports obligatoires, rapports dont l'absence est sanctionnée par la nullité de l'opération. Si la Première directive en droit des sociétés a strictement limité les cas de nullité des sociétés tout en restreignant les effets des quelques cas de nullité subsistants (pas d'effet rétroactif), tout ceci évidemment dans le souci de la sécurité des transactions avec les tiers, alors on peut se demander si l'approche récente du législateur national dans ce domaine, qui ne limite en rien les effets des nullités introduites, ne va pas dans la mauvaise direction. La Chambre de commerce s'exprime également dans ce sens – « *[…] Le but de simplification de la loi n'est pas encore complètement atteint, du moins pas dans son intégralité. En effet, certaines procédures jusqu'à maintenant peu formalistes, se voient octroyer des obligations supplémentaires (par exemple des rapports supplémentaires) sans qu'une réelle cause et plus-value puisse en être détectée. Finalement, certaines des modifications proposées engendreront des coûts non négligeables pour les sociétés concernées, que notamment les plus petites structures auront du mal à assumer* »[1] –, tout comme le Conseil d'État – « *Toujours d'après les auteurs, cette entreprise a veillé à s'inscrire dans l'axe des deux principes directeurs qui a animé les auteurs du projet de loi qui*

1 – Avis de la Chambre de commerce du 12 février 2009, *Doc. parl.*, n° 5730/2, p. 20, ID 10497.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

a abouti à celle du 15 août 1915, à savoir la liberté contractuelle *pour les associés et* la sécurité *pour les tiers. Le Conseil d'État n'est pas convaincu que cette entreprise ait réussi* »[1].

■ § 2 – L'influence du droit de l'Union européenne

En droit européen, on distingue en général le **droit primaire**, créateur de règles nouvelles (traités et conventions) issues directement de l'accord des États membres, et le **droit secondaire** (ou dérivé) fondé sur les traités (directives et règlements) matérialisés par des actes émanant des organes instaurés par les traités[2].

De nos jours, en fait depuis une quarantaine d'années déjà, le principal moteur du droit des sociétés est le droit européen. Ces dernières décennies, les modifications du droit des sociétés qui ne seraient pas directement induites par le droit de l'Union européenne sont assez rares (même si, récemment, elles retrouvent un certain regain de faveur). Celles qui trouvent leur source dans les directives européennes (et dans une moindre mesure dans la jurisprudence de l'Union européenne) sont très nombreuses.

Le traité CE contient peu de dispositions directement applicables aux sociétés. En droit des sociétés, le traité CE vise à « l'*unification des règles juridiques applicables aux entreprises afin d'assurer la liberté d'établissement et la libre prestation de services, l'organisation des conditions égales de concurrence et la protection de l'intérêt des actionnaires et des tiers conçu au sens large* »[3]. Il est à noter qu'en vertu de l'article 48 du traité CE, les sociétés sont assimilées aux personnes physiques pour l'application du droit d'établissement[4]. Pour bénéficier de cette assimilation, « *ces sociétés doivent être constituées en conformité de la législation d'un État membre et [avoir] leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté* »[3]. Même les sociétés qui ne sont pas dotées de la personnalité morale selon leur droit national peuvent bénéficier de la liberté d'établissement, à condition de présenter des « caractéristiques se rapprochant de celles des personnes morales »[3].

Ceci nous conduit à étudier les différentes directives CE prises en matière de droit des sociétés.

A – L'impact des directives européennes

Depuis les années 1960 et sur la base de l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE (devenu art. 44, paragraphe 2, sous g) après la renumérotation selon le traité d'Amsterdam), la Commission s'est engagée dans un **processus d'harmonisation** du droit des sociétés dans les différents États membres : « *en coordonnant, dans la mesure du nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers* ».

---

1 – Avis du Conseil d'État, *Doc. parl.*, n° 5730/4, p. 1, ID 13321.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 152.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 154.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 156.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

1) Harmonisation du droit applicable dans les États membres

D'abord une remarque d'ordre terminologique. Les directives européennes utilisent la notion suivante : « *une société avec un capital social, jouissant de la personnalité juridique, possédant un patrimoine séparé qui répond à lui seul des dettes de la société, et soumise par sa législation nationale à des conditions de garanties telles qu'elles sont prévues par la directive 68/151/CEE, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers* » (selon la formulation de la directive n° 2005/56/CE portant sur les fusions transfrontalières). C'est cette notion que, par concision d'expression, nous visons tout au long de cet ouvrage sous le terme de « **société de capitaux** ». En doctrine, on adopte généralement une conception plus étroite de cette notion en la limitant aux seules sociétés par actions. « *Dans ces sociétés, la personnalité des associés ne joue aucun rôle. Ils n'apparaissent, tant vis-à-vis des associés que vis-à-vis des tiers, que par le chiffre des capitaux qu'ils apportent. Le décès d'un associé est sans influence sur la durée du pacte social* »[1]. Il est évident qu'en suivant cette approche, les sociétés à responsabilité limitée ne devraient pas faire partie de la notion de société de capitaux. Néanmoins, nous les incluons dans cette définition.

Un grand nombre de directives ont été proposées (et, pour la plupart, elles ont été adoptées) en application de cette disposition du traité. Certaines sont restées à l'état de projet. D'autres ont été adoptées au Luxembourg comme dans les autres États membres en exerçant non seulement un profond impact sur le droit des États membres, mais en conduisant également à une **harmonisation** fort bienvenue. Les conséquences de cette harmonisation ne peuvent être surestimées dans la mesure où cette harmonisation permet aux acteurs économiques de considérer que le droit des autres États membres est similaire, voire identique au leur (tel est le cas si la directive prévoit impérativement une certaine solution). Il n'y a donc pas lieu sur un tel point de rechercher à chaque fois le détail du droit des autres États membres, mais on peut tout simplement supposer que le droit de l'autre État membre reprend la solution de la directive[2]. Même si l'autre État n'avait pas transposé la directive (ou l'avait fait de manière incorrecte), il serait souvent possible d'invoquer l'effet direct des directives européennes.

Dans ce contexte, il faut noter que la notion d'effet direct a plusieurs aspects. « *Les textes qui en sont dotés créent immédiatement, dans le chef des particuliers, des droits que ceux-ci peuvent faire valoir devant les juridictions nationales [...] il convient d'opérer une distinction entre l'effet direct vertical (effets juridiques dans les relations entre les particuliers et un État membre à l'encontre duquel est invoquée une directive non transposée) et l'effet direct horizontal (relations entre particuliers, personnes physiques ou morales). La Cour reconnaît généralement aux directives un effet direct vertical à condition que le texte soit, sur le point concerné, suffisamment clair et précis. Elle semble par contre leur refuser tout effet direct horizontal* »[3].

Ce processus d'harmonisation est toutefois limité dans un triple sens :

– Les points qui sont soumis à harmonisation sont limités ; il s'agit d'une limitation *ratione materiae*. Ainsi, il a été procédé à l'harmonisation des fusions et

1 – *R.P.D.B.*, T. 12, V° Sociétés, p. 151.

2 – Même si le droit de cet autre État membre avait mal transposé la directive en droit national, on pourrait compter sur l'effet direct de cette directive.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 169.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

scissions « nationales », mais non aux fusions et scissions transfrontalières. La directive 2005/56 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions et scissions transfrontalières des sociétés de capitaux est destinée à y remédier. Elle a été (partiellement) transposée en droit luxembourgeois par les lois du 10 juin 1999[1]et du 23 mars 2007[2].

– Souvent, le champ d'application des directives est limité *ratione personae*, ce qui signifie en pratique qu'elles s'appliquent aux seules sociétés anonymes. Tel est le cas notamment de la Deuxième directive 77/91/CEE du 13 décembre 1976. Dans d'autres cas, le champ d'application de ces directives s'étend aux sociétés de capitaux (donc à celles qui offrent aux créanciers sociaux le patrimoine social comme seule garantie). Tel est en général le champ d'application maximal de ces directives. En d'autres termes, tout le domaine des sociétés de personnes (et des entreprises individuelles) n'est pour l'instant pas soumis à la moindre harmonisation.
– Finalement, les directives, qui doivent être admises par le Conseil des ministres sont des **documents de compromis** entre États membres. Faute d'unanimité sur une question donnée, elles accordent de nombreuses options aux États destinataires (ou encore aux entreprises). Ces options étant implémentées dans des sens différents, l'harmonisation est très incomplète. Même si, sur un point donné, tous les États membres avaient adopté la même solution, il faudrait encore que le conseiller juridique actif dans ce domaine s'assure d'abord de ce point : en d'autres termes, le conseiller établi dans l'État A ne peut, sur la base de la seule lecture de la directive, être assuré que la solution est identique dans l'État B. Il lui faut à cette fin procéder à une recherche portant sur la manière dont cet État B a transposé la directive dans son droit national. Tel n'aurait pas été le cas si la directive avait rendu obligatoire une certaine solution qui serait donc nécessairement la même dans tous les États membres.

2) Les objectifs des directives

La Première directive en matière de droit des sociétés indique dans son préambule :

« *considérant qu'il est nécessaire, en vue d'assurer la sécurité juridique dans les rapports entre la société et les tiers ainsi qu'entre les associés, de limiter les cas de nullité ainsi que l'effet rétroactif de la déclaration de nullité et de fixer un délai bref pour la tierce opposition à cette déclaration* ».

Cet objectif guide également la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence. Ainsi, a-t-elle décidé[3] que, si l'organe de représentation d'une GmbH peut, en vertu des statuts de la société, être composé d'une ou de plusieurs personnes, il faut publier non seulement le régime de représentation à appliquer lorsque l'organe comprend effectivement plusieurs membres, mais encore les règles à appliquer lorsque l'organe n'en comprend qu'un seul. Il en est ainsi même si ces règles résultent clairement du droit national.

1 – *Mém.* A, 1999, p. 2268.

2 – Loi du 23 mars 2007, ID 9443.

3 – CJUE du 12 novembre 1974, arrêt *Friedrich Haaga GmbH*, n° 32/74, ID 11470.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La cour a déduit cette conclusion non seulement de l'analyse grammaticale de l'article 2, § 1er, alinéa d), deuxième phrase de la Première directive, mais encore de l'objectif de **sécurité juridique** à l'origine de cette directive(1). Les tiers qui traitent avec la société doivent, en consultant les publications, être à même de savoir dans quelles conditions ils peuvent traiter avec les organes de la société sans que l'on puisse requérir d'eux la connaissance des subtilités de chaque droit national. On peut donc en conclure que les extraits des statuts d'une S.à r.l. à publier doivent indiquer quels sont les pouvoirs de représentation du ou des gérants, même si la société applique purement et simplement le régime de l'article 710-15 (anc. art. 191*bis*) L.S.C. Selon ce régime, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, (hormis ceux dont la loi ou les statuts réserve l'accomplissement à l'assemblée générale) et représente la société à l'égard des tiers et en justice(2).

Conformément à cette *ratio legis*, les rédacteurs de la directive ont procédé à des **limitations** très importantes des cas de nullité des sociétés, de sorte que, de nos jours, les **nullités** ont perdu l'importance pratique qu'elles avaient autrefois. Il est vrai que la Première directive n'a pas un champ d'application général, mais qu'elle ne s'applique qu'aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions ainsi qu'aux sociétés à responsabilité limitée (donc aux sociétés de capitaux par opposition aux sociétés de personnes).

Mais le régime de ces nullités a été pour une partie importante étendu aux autres formes de sociétés « *dotées de la personnalité morale* »(3).

Le point commun de ces sociétés est évidemment la responsabilité limitée des associés, ce qui revient donc à dire que les créanciers ont pour seule garantie le patrimoine social.

Concrètement, la **Première directive** avait trait aux points suivants :

- la **publicité des actes de société**, les actes et les indications dont les États membres doivent au moins prévoir la publicité, les modalités et les effets de la publicité ainsi que les mentions que doivent comprendre les documents émanant de la société ;
- la **validité des engagements** de la société, les règles applicables aux actes accomplis au nom des sociétés en formation, les effets à l'égard des tiers des irrégularités dans la nomination des organes et aux pouvoirs des organes de la société ;
- les **nullités** de la société, l'énumération limitative des causes de nullité et les effets de la nullité(4).

La **Deuxième directive** concernait les garanties exigées des sociétés anonymes en vue de la protection des tiers en ce qui concerne la constitution de la société ainsi que le maintien et les modifications du capital social.

---

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978), *R.C.J.B.,* 1981, p. 421.

2 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978), *R.C.J.B.,* 1981, p. 422.

3 – V. les articles 100-19 ss. L.S.C. (anc. art.12*quater* ss. L.S.C.), ID 7520.

4 – M. Van der Haegen et C. Verbraeken, « L'adaptation de la législation belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.,* 1974, p. 125.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

B – Tableau des directives et règlements pris en la matière

Texte européen[1]	Date d'adoption	Désignation	Statut
Première directive 68/151/CEE (puis notamment 2009/101/CE, et en dernier lieu la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)	9 mars 1968	Garanties équivalentes pour protéger les associés et les tiers, pouvoirs des dirigeants, publicité et nullités des sociétés	Reprise par la loi du 23 novembre 1972 concernant le régime des sociétés commerciales […], *Mém*. A72 du 23/11/1972, p. 1586.
Deuxième directive 77/91/CEE (puis notamment 2012/30/UE, et en dernier lieu directive 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)	13 décembre 1976	Constitution de sociétés anonymes, maintien et modification du capital	Reprise par : – la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, *Mém*. A35 du 16/05/1983, p. 864 ; et – la loi du 12 mars 1998 modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier […], *Mém*. A23 du 25/03/1998, p. 338.
Quatrième directive 78/660/CEE (puis en dernier lieu, directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises)	25 juillet 1978	Comptes annuels des « sociétés de capitaux »	Reprise par la loi du 4 mai 1984 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, *Mém*. A40 du 10/05/1984, p. 586.

1 – Liste non exhaustive des textes européens impactant le droit des sociétés.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Texte européen	Date d'adoption	Désignation	Statut
Troisième directive 78/855/CEE (puis directive 2011/35/UE, et en dernier lieu directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)	9 octobre 1978	Fusion des sociétés anonymes	Reprise par la loi du 7 septembre 1987 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, *Mém*. A77 du 15 septembre 1987, p. 1792.
Cinquième directive		Structure des sociétés anonymes et pouvoirs des organes	Bloquée (en raison de problème de participation des travailleurs)
Sixième directive 82/891/CEE (puis notamment directive 2009/109/CE et en dernier lieu directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)	17 décembre 1982	Scission des sociétés anonymes	Reprise par la loi du 7 septembre 1987 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Mém. A77 du 15/09/1987, p. 1792.
Septième directive 83/349/CEE (puis Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises […])	13 juin 1983	Comptes consolidés	Reprise par la loi du 11 juillet 1988 relative à l'établissement des comptes consolidés, *Mém*. A45 du 18 août 1988, p. 872.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Texte européen	Date d'adoption	Désignation	Statut
Huitième directive 84/253/CEE (puis directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés […])	10 avril 1984	Agrément de personnes chargées du contrôle des comptes	Reprise par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises, *Mém*. A81 du 23/08/1984, p. 1346.
Dixième directive 2005/56/CE (puis Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)	26 octobre 2005	Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux	Reprise par la loi du 23 mars 2007 portant modification des articles 271, 273*bis*, et 276 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, *Mém*. A46 du 30/03/2007, p. 826 ; la loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital, *Mém*. A151 du 29/06/2009, p. 2268.
Règlement n°2137/85	25 juillet 1985	Groupement d'intérêt économique européen (GEIE)	Reprise par la loi du 25 mars 1991 (*Mém*. A, 1991, p. 452, *doc. parl*. 3434)

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Texte européen	Date d'adoption	Désignation	Statut
Onzième directive 89/666/CEE (puis notamment directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)	21 décembre 1989	Publicité des succursales créées dans un EM par certaines sociétés établies dans un autre État membre	Reprise par la loi du 27 novembre 1992 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales à la onzième directive […], *Mém*. A95 du 15/12/1992.
Douzième directive 89/667/CEE (puis directive 2009/102/CE)	21 décembre 1989	La société à responsabilité limitée à un seul associé	Reprise par la loi 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à l'effet d'introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle, *Mém*. A106 du 30/12/1992, p. 3141.
Règlement (CE) 1346/2000 (puis règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité)	29 mai 2000	Procédures d'insolvabilité	
Règlement n°2157/2001	8 octobre 2001	Statut de la Société européenne (SE)	

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Texte européen	Date d'adoption	Désignation	Statut
Directive 2001/86/CE	8 octobre 2001	Complétant le statut de la SE en ce qui concerne l'implication des travailleurs	Reprise par la loi du 25 août 2006 complétant le statut de la société européenne (SE) pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (…), *Mém*. A152 du 31/08/2006, p. 2706.
Règlement (CE) n° 1606/2002	19 juillet 2002	Obligation pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne d'établir les comptes consolidés selon les normes IAS à partir du 1er janvier 2005	
Règlement (CE) n°1435/2003	22 juillet 2003	Statut de la société coopérative européenne (SEC)	Repris par la loi du 10 mars 2014 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en vue de mettre en œuvre le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), *Mém*. A39 du 23/03/2014, p. 482.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Texte européen	Date d'adoption	Désignation	Statut
Directive 2003/58/CE	15 juillet 2003	Modifie la Première directive : concerne le dépôt d'informations par voie électronique	Reprise par la loi du 20 avril 2009 sur le dépôt par voie électronique auprès du registre de commerce et des sociétés modifiant – le titre I de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises […], *Mém*. A80 du 27/04/2009, p. 946.
Directive 2003/71/CE	4 novembre 2003	Prospectus	Reprise par la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative au prospectus pour valeurs mobilières, *Mém*. A98 du 12/07/2005, p. 1726.
Directive 2003/72/CE	22 juillet 2003	Complétant le statut de la société coopérative européenne en ce qui concerne l'implication des travailleurs	Reprise par la loi du 18 mars 2009 portant transposition de la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs […], *Mém*. A63 du 27/03/2009, p. 824.
Règlement (CE) n° 1435/2003	22 juillet 2003	Statut de la société coopérative européenne	

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Texte européen	Date d'adoption	Désignation	Statut
Règlement (CE) 1725/2003 (puis règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008)	29 septembre 2003	Adoptant certaines normes comptables internationales	
Treizième directive 2004/25/CE	21 avril 2004	Offres publiques d'acquisition	Reprise par la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE […] concernant les offres publiques d'acquisition, *Mém*. A86 du 22/05/2006, p. 1510.
Règlement (CE) 809/2004	29 avril 2004	Prospectus	
Directive 2004/109/CE	15 décembre 2004	Obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs	Reprise par la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé […], *Mém*. A55 du 15/01/2008, p. 46.
Directive 2005/56/CE (puis directive (UE) 2017/1132 ; v. également règlement d'exécution (UE) 2015/884)	26 octobre 2005	Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux	Reprise par la loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital, *Mém*. A151 du 29/06/2009, p. 2268.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Texte européen	Date d'adoption	Désignation	Statut
Directive 2006/68/CE (puis Directive 2012/30/UE, puis directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)	6 septembre 2006	Constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital	Reprise par la loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital, *Mém*. A151 du 29/06/2009, p. 2268.
Directive 2007/36/CE (modifiée notamment par la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires)	11 juillet 2007	Droit des actionnaires des sociétés cotées	Reprise par loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées*, Mém.* A109 du 27/05/2011, p. 1708.
Directive 2007/63/CE (puis directive 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés)	13 novembre 2007	Exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes	Reprise par loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital, *Mém*. A151 du 29/06/2009, p. 2268.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Texte européen	Date d'adoption	Désignation	Statut
Directive 2011/61/UE	8 juin 2011	Gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs (directive AIFM)	Reprise par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, Mém. A119 du 15/07/2013, p. 1856.
Directive 2014/57/UE (V. également 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché).	16 avril 2014	Abus de marché	Reprise par la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, *Mém*. A83 du 16/05/2006, p. 1470.

■ § 3 – Approche générale du législateur luxembourgeois

L'approche traditionnelle est décrite par le passage suivant extrait de l'avis du Conseil d'État relatif à la L.S.C. de 1915. Le Conseil d'État explique que les difficultés auxquelles le projet de loi donne naissance doivent être résolues : « *[…] dans cet esprit de liberté, sagement pondéré, dont nos institutions politiques portent l'empreinte. Il y a à cela à la fois une raison de droit, une raison économique et une raison d'opportunité. La raison de droit est le principe de liberté des conventions qui est un des fondements de notre législation, et auquel on ne doit donc déroger que pour des motifs graves. La raison économique est que la grande variété des formes sous lesquelles se manifeste de nos jours l'activité économique, s'accommode mal d'une réglementation trop stricte. La raison d'opportunité, qui, en fin de compte, aboutit également à une raison d'ordre économique, est qu'en admettant des restrictions que la législation des pays voisins ne connaît pas, on risque de refouler au-delà de nos frontières bon nombre de sociétés qui n'auraient pas demandé mieux que de s'établir chez nous. Qu'on supprime l'abus ou la fraude partout où l'on peut les atteindre, rien de plus juste ! Mais qu'on évite l'écueil d'édicter des restrictions qui ne gêneront que médiocrement les brasseurs d'affaires mais pourraient devenir, pour les entreprises honnêtes, une entrave intolérable* »[1]. On constate donc que, déjà au début du xx[e] siècle, l'objectif d'attirer des sociétés étrangères était déjà bien présent dans l'esprit du législateur national.

De nos jours, le droit des sociétés doit également tenir compte de la dimension européenne. Comme indiqué ci-dessus, les objectifs des auteurs des directives prises sur la base de l'article 54, 3, g) du traité de Rome étaient assez limités. Il

1 – Projet de loi portant révision de la loi sur les sociétés commerciales, avis Conseil d'État, p. 46, ID 13321.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

s'agissait de coordonner, dans la mesure du nécessaire, en vue de les rendre équivalentes, les garanties des sociétés exigées dans les différents États membres. La marge de manœuvre laissée aux législateurs nationaux était donc assez importante, soit en leur permettant de ne pas prendre certaines mesures, soit en leur permettant de choisir entre plusieurs solutions.

Dans l'exercice de ces options, le législateur luxembourgeois, à juste titre, a systématiquement opté en faveur des **solutions** les plus **libérales**, les moins contraignantes. Le résultat de cette approche est que notre droit des sociétés est effectivement moins contraignant, moins pointilleux, plus flexible que celui de nos États voisins. Ce point est d'une importance primordiale dans la mesure où une place financière digne de ce nom a besoin non seulement d'une infrastructure bancaire et financière (avec tout ce que cela comporte en moyens légaux, matériels et humains), d'un environnement fiscal accueillant, mais encore d'une législation en matière de droit commercial (et donc surtout en droit des sociétés) alliant rigueur et flexibilité sans criminaliser à l'outrance.

Malheureusement, certains signes précurseurs semblent indiquer que cette approche ne fait plus nécessairement l'unanimité et laissent présager un changement de politique assez radical[1].

■ § 4 – Les tendances du droit des sociétés

Le droit des sociétés, comme tant d'autres branches du droit, oscille continuellement entre deux tendances opposées, le **dirigisme autoritaire,** d'une part, et la **liberté,** d'autre part, « deux périls également redoutables, l'insuffisance et l'excès de réglementation »[2]. De même, pour la Belgique : « *Le régime des sociétés commerciales a toujours été traversé par deux grands courants en sens contraire, auxquels la législation française, plus impressionniste que la nôtre, a tour à tour obéi d'une façon exclusive. Ces deux courants sont d'ailleurs les deux forces classiques qui agissent alternativement dans l'histoire de toutes les institutions humaines : le principe de liberté et le principe d'autorité. En matière de sociétés commerciales, quand le premier principe domine de manière absolue, c'est le champ laissé ouvert à toutes les initiatives et aussi à tous les abus. Lorsque le principe d'autorité prévaut, c'est l'activité des négoces et des transactions qui se trouve contrariée par des prescriptions trop rigoureuses. Ce sont alors les affaires qui pâtissent. [...] En 1791, c'est le maximum de libertés. Nous sommes en pleine illusion révolutionnaire. L'homme est considéré comme naturellement bon, et le législateur doit bien se garder d'apporter ou de tolérer des entraves à l'expansion de cette prétendue bonté naturelle. Le résultat ne se fit pas attendre, et les sociétés, considérées comme des libres contrats, devinrent bientôt la proie des agioteurs [...] Aussi, dès 1794, la réaction se produit. Réaction outrancière : les sociétés financières n'apparaissent plus que comme un expédient du banditisme. Aussi la loi interdit purement et simplement de créer des sociétés avec actions au porteur. L'année suivant marque un retour au*

1 – V. le « projet de loi portant des mesures ponctuelles en matière de prévention des faillites et de lutte contre les faillites organisées », n° 5157, ID 9933.

2 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport de la commission spéciale, p. 269, citant Nyssens.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

régime de la liberté. Mais, quelques années plus tard, vient l'Empire. Il nous donne le Code de commerce de 1808 »[1].

Selon l'époque, l'une ou l'autre de ces tendances prend le dessus sur l'autre tout en n'emportant qu'une victoire temporaire. La tendance opposée, profitant des insuffisances de la tendance dominante à ce moment, se refait une santé pour marquer des points lors des modifications législatives suivantes. En droit belge, imité sur ce point par le droit luxembourgeois, la tendance était plutôt à la liberté : « Liberté pour les associés, sécurité pour les tiers », affirmait Nyssens[2], tout en essayant de canaliser cette liberté. « Plus que personne, nous voulons la liberté, mais une liberté sage et réglée. Le libéralisme extrême de l'agioteur consiste à être libéral *[...]* de l'argent des autres ; or, le public, trop souvent ruiné, ne se soucie guère de ce libéralisme-là, ni de telles libéralités »[3].

Les **excès sont à éviter,** comme le montre l'histoire : ainsi, en France, une loi du 2 mars 1791 avait consacré la liberté absolue en abolissant toute réglementation des sociétés commerciales. « *Elles sont régies par ce qu'on peut appeler le droit commun ordinaire des sociétés et des conventions. Résultat : abus considérables, les sociétés livrées à des agioteurs, les petites épargnes en péril et le crédit public ébranlé* »[4]. Par la suite, une loi du spéciale du 15 avril 1795 interdisait toute création de société avec actions au porteur.

Face aux inconvénients de cette situation, cette loi fut à son tour abolie par une loi du 21 novembre 1795. « *La France passait ainsi, en quatre années, par des régimes diamétralement opposés : liberté sans limites en 1791, interdiction complète en 1794 et retour à la liberté en 1795* »[5].

La France a maintes fois connu des excès de dirigisme, peut-être dus à une économie traditionnellement dirigiste, tout en constatant depuis peu un renouveau de la liberté contractuelle qui contraste avec le dirigisme ambiant lors de l'adoption de la loi de 1966.

« *L'ère est à la déréglementation et on aspire aujourd'hui, dans un souci d'efficacité et de concurrence, à libérer les forces créatrices de l'entreprise du carcan étouffant d'une réglementation trop dirigiste* »[6].

Un autre effet des mesures contraignantes est le suivant : « *Toutes ces mesures de précaution, la plupart puériles, seront pour les affaires honnêtes une gêne imméritée et pour celles que l'on veut atteindre un coût d'épée dans l'eau* »[7].

Dans ce débat, qui accompagne toujours le droit dans la mesure où il tend à réglementer l'activité humaine, on peut encore faire intervenir la considération suivante : « *Un abus possible ne saurait empêcher l'exercice d'une liberté nécessaire* »[8]. Face à des dérives potentielles, on peut, en premier lieu, réagir d'une façon

1 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, Carton de Wiart, p. 138.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 19, ID 11305.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 134, ID 11305.

4 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 123.

5 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 123.

6 – M., A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 6.

7 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 264.

8 – Projet de loi français de 1883, exposé des motifs, p. 37, au sujet des avances aux actionnaires, cité par Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 179, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

autoritaire, par des interdictions flanquées de sanctions plus ou moins sévères, dont en dernier lieu des sanctions pénales.

« *Les réparations civiles font déjà grande peur aux administrateurs de sociétés. Ajouter à cela des peines sévères pour des énonciations fausses que l'on peut très facilement attribuer à la mauvaise foi, bien qu'elles soient le résultat d'erreurs involontaires, me semble beaucoup plus nuisible qu'utile. Ce luxe de pénalités suppose que l'on est en face d'une catégorie de gens de sac et de corde qu'il faut à chaque pas maintenir dans la droite voie par des châtiments sévères. Le résultat ne peut être que d'éloigner les personnes honorables des sociétés et d'atteindre un but contraire à celui que l'on cherche* »[1].

Alternativement on peut, comme le fait le législateur français dans le cas visé, prévoir qu'une interdiction n'est pas justifiée par un simple abus potentiel. « *Les deux thèses en présence, celle de la liberté et celle de la réglementation, ont conclu sur le terrain transactionnel de la législation un pacte honorable : celui de la liberté réglementée* »[2].

Comme on l'a vu ci-avant, la tendance des directives européennes est clairement d'assurer la **sécurité des opérations commerciales**, notamment en limitant les cas de nullité des sociétés et en prévoyant que les sociétés sont en principe engagées par les actes posés par les organes auxquels la représentation de la société est confiée, même lorsque ceux-ci se situent en dehors de l'objet social. Une autre tendance consiste à œuvrer en faveur de plus de transparence de la société : la Quatrième directive contribue à cette fin. Tel est encore la devise en matière des tendances nouvelles du gouvernement d'entreprise : « *comply or explain* ».

Le Luxembourg n'échappe pas non plus à la « **pénalisation** » du droit des sociétés ; de plus en plus d'obligations qui s'imposent aux sociétés sont sanctionnées par des dispositions pénales. Les dispositions sur les abus de biens sociaux prévues par l'article 1500-11 (anc. art. 171-1) L.S.C. (introduites par la loi du 21 juillet 1992) sont le reflet de cette tendance. Il en va de même pour la loi du 3 mars 2010 qui a introduit la responsabilité pénale des personnes morales.

Un projet de loi dénommé « *projet de loi portant des mesures ponctuelles en matière de prévention des faillites et de lutte contre les faillites organisées* » (n° 5157), déposé en 2003, a semblé adopter une approche nouvelle que l'on pourrait qualifier de plus dirigiste, et ceci, afin de prévenir les faillites (organisées). Que cet objectif soit louable en soi ne doit évidemment pas faire l'objet de la moindre discussion ; néanmoins, il faudrait éviter que le remède ne soit pire que le mal. En effet, on se demande si le résultat de ce projet de loi n'est pas avant tout d'introduire des obstacles à la création d'entreprises, ce qui indirectement conduit à moins de faillites (moins d'entreprises donnent statistiquement lieu à moins de faillites). Or, ce n'est pas en soi l'objectif recherché. Ceci vaut notamment pour les mesures exigeant un capital social plus élevé que par le passé : 70 000 euros (au lieu de 31 000 euros) et surtout une libération intégrale du capital. Pour la S.à r.l., le montant correspondant est de 25 000 euros, ce qui correspond à un doublement par rapport aux dispositions actuellement applicables[3].

1 – E. Pirmez, *Observations présentées sur l'avant-projet de loi sur les sociétés commerciales* [rédigé par A. Nyssens], p. 31.

2 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport de la commission spéciale, p.266, ID 9792.

3 – Le projet de loi interdit par ailleurs les avances faites par la société à ses actionnaires, art. 1, ID 9933.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

C'est à juste titre que le Conseil d'État a attiré l'attention sur le fait que certaines entreprises multinationales ont commencé dans le garage d'une maison d'habitation, et donc également en l'absence de fonds propres pléthoriques. En outre, le Conseil d'État a fait remarquer que la Constitution luxembourgeoise prévoit la liberté du commerce, ce qui fait obstacle aux possibilités d'imposer des limitations et des seuils à l'entrée.

Heureusement, ledit projet de loi n'a jamais été adopté.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW



PARTIE I – LE DROIT COMMERCIAL

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Le droit civil réglemente les relations ordinaires entre particuliers, les relations de famille, les successions, les donations, la situation juridique des biens qui leur appartiennent. Le droit commercial est un droit d'exception par rapport au droit civil, ce qui signifie concrètement que le droit civil s'applique chaque fois que le droit commercial ou les usages commerciaux ne règlent pas le point en question[1]. Le droit commercial est le **droit spécial** des commerçants, catégorie de personnes plus averties que les simples particuliers et se trouvant ainsi soumises à un droit particulier caractérisé par la célérité, la simplicité des formes, la liberté de l'administration de la preuve.

Cette subdivision s'explique également par le fait que les commerçants étaient traditionnellement soumis à des **juridictions spéciales** : les tribunaux de commerce (appelés juridictions consulaires en France, introduites par l'édit de 1563 promulgué par Charles IX et rédigé par Michel de l'Hospital) régis par des règles particulières et où traditionnellement siégeaient des commerçants, donc des juges non professionnels, supposés mieux connaître les usages et la psychologie des commerçants que les juges professionnels. Ces juridictions connaissaient des affaires ordinaires du commerce.

Il est vrai qu'au Luxembourg la situation a changé depuis lors et que les juges siégeant en matière commerciale sont des juges professionnels ayant un statut identique à celui des autres magistrats. Il n'en reste pas moins que les commerçants relèvent d'une autre chambre et, en principe, d'une autre procédure que celle applicable aux litiges civils.

Il est encore vrai que récemment les frontières entre la procédure commerciale et la procédure civile ont tendance à disparaître. La loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière civile a complété l'article 414 du Code de procédure civile par l'ajout d'un deuxième alinéa ainsi libellé : « *Néanmoins le demandeur peut, en matière commerciale, introduire sa demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix* ». Depuis cette modification, la jurisprudence retient que l'introduction d'une demande revêtue de la forme commerciale n'est plus considérée comme une règle d'ordre public, et donc son inobservation n'est pas sanctionnée par la nullité[2].

1 – L. Frédéricq, *Précis de droit commercial*, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 7.

2 – Cour du 14 juillet 1999, *P.*, n° 31, p. 18, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

À l'intérieur du droit commercial, il existe une branche particulièrement importante et qui fait l'objet de grands efforts d'harmonisation dans le cadre de l'Union européenne : le droit des sociétés, qui est donc la partie du droit commercial consacrée aux sociétés.

Mais il convient de ne pas perdre de vue que le droit des sociétés dépasse le droit commercial, car toutes les sociétés ne sont pas commerciales. Il existe en effet des **sociétés de droit civil** ; c'est d'ailleurs dans le droit civil que se trouvent les fondements sur lesquels le droit des sociétés commerciales est bâti.

Nous étudierons d'abord la notion de droit commercial avant de nous consacrer aux principales différences qui opposent cette branche du droit au droit civil, donc au droit commun.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE I
NOTION DE DROIT COMMERCIAL

Dans une première approche, on peut dire « *qu'il s'agit de la branche du droit consacrée à l'étude des problèmes juridiques que fait naître l'activité commerciale au sens le plus large de l'expression* »[1].

Selon une autre définition, « *le droit commercial régit la "matière du commerce", c'est-à-dire l'ensemble des personnes (commerçants) et des opérations (actes de commerce) qui s'interposent dans la circulation des valeurs économiques* »[2].

En effet, pour un certain nombre de raisons « *[…] est apparue la nécessité de soumettre à une réglementation spéciale, coutumière ou législative, certaines personnes – les commerçants –, certaines opérations – les actes de commerce –, les unes et les autres constituant l'essence de la "matière de commerce"* »[3].

CHAPITRE I
CARACTÉRISTIQUES DU DROIT COMMERCIAL

Le droit commercial connaît certains caractères distinctifs, dont notamment :

1) le commerce a de tout temps été exercé par une catégorie distincte d'individus, par une **classe de personnes** pour laquelle une réglementation particulière a été élaborée ;
2) le droit commercial comporte des **exigences spécifiques** écartant le droit commun (qui ne peut être appliqué compte tenu des exigences particulières applicables en la matière) ;
3) le droit commercial a été **international** avant d'être interne ;
4) enfin, le droit commercial a été **coutumier** avant d'être législatif[4].

Le droit commercial est la partie du droit privé qui représente le droit spécial qui s'applique aux commerçants, notion définie par le Code de commerce.

SECTION I
LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

La Constitution luxembourgeoise (art. 11 (6)) prévoit cette liberté dans les termes suivants :

« *La liberté du commerce et de l'industrie, l'exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi.* ». Il s'agit d'une des

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 7.
2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 56.
3 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 8.
4 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 8.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

matières réservées par la Constitution au pouvoir législatif qui seul est susceptible d'apporter des restrictions à cette liberté. « *Tout ce qui n'est pas interdit est permis, car la société s'inscrit dans un cadre de liberté contractuelle – ou, plus exactement, de liberté de stipulation, si l'on tient compte des sociétés unipersonnelles* »(1).

Il est à noter que, si la Constitution ne garantit cette liberté qu'aux seuls nationaux (les Luxembourgeois), la jurisprudence a étendu cette garantie aux étrangers : « *Les étrangers jouissent au Grand-Duché de tous les droits qui ne leur sont pas spécialement refusés. À défaut de texte contraire, ils sont assimilés aux nationaux. Aucun droit ne peut être refusé à l'étranger, à moins que le législateur n'en ait expressément décidé ainsi* »(2).

Il est pourtant indéniable que les tendances sociales progressivement apparues aux XIXe et XXe siècles ont conduit à restreindre la liberté contractuelle, tant la liberté de contracter(3) proprement dite que la liberté de fixer le contenu des conventions(4).

La théorie des cadres légaux obligatoires illustre ces limitations.

■ § 1 – La théorie des cadres légaux obligatoires

La question qui est soulevée à cet endroit est la suivante : les acteurs économiques qui entendent se regrouper selon les formes prévues par le droit privé sont-ils obligés de recourir obligatoirement aux formes prévues par ce droit ou bien sont-ils libres d'agencer leur activité selon d'autres conventions, ayant recours à la liberté du commerce ou encore à la liberté d'association ? En d'autres termes, les **formes** prévues par le droit commercial **sont-elles obligatoires** ou bien laissent-elles de la place à d'autres formes d'association ?

La théorie des cadres légaux obligatoires entend précisément limiter la marge de manœuvre des opérateurs économiques en les contraignant à recourir **aux seules formes prévues** et plus ou moins strictement réglementées par la loi. Cette théorie, tout en étant dénuée d'un champ d'application général (ce qui permet notamment de constituer des **sociétés d'agrément** en dehors des a.s.b.l.), serait néanmoins applicable en matière de droit des sociétés. Les sociétés d'agrément sont des groupements de personnes qui ont pour but d'assurer à leurs membres leur distraction favorite et qui mettent à cette fin certains biens en commun sans intention de partager les bénéfices éventuels(5).

La raison tient à la **méfiance du législateur** à l'égard de ces entités (en raison du pouvoir considérable que celles-ci peuvent développer)(6).

« *Mais l'on ne peut en déduire que le législateur ait entendu imposer aux sociétés désireuses de constituer une société ou une association le recours à ces cadres, sauf ce que nous dirons des sociétés commerciales* »(7).

À ce dernier égard, on peut noter qu'au Luxembourg comme en Belgique, la loi « *reconnaît* » sept types de sociétés commerciales proprement dites. Pour les

1 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 67.

2 – CE du 4 février 1964, *P.*, no 19, p. 267.

3 – Au Luxembourg, cette liberté est protégée par la disposition constitutionnelle garantissant la liberté du commerce et de l'industrie (Art. 11, (6) de la Constitution).

4 – A. Weill et F. Terré, *Droit civil. Les obligations*, 2e éd., 1975, p. 64.

5 – *R.P.D.B.*, T. 12, Vo Sociétés, p. 166.

6 – P. Van Ommeslaghe, « Les sociétés de fait », *J.T.*, 1957, p. 710.

7 – P. Van Ommeslaghe, « Les sociétés de fait », *J.T.*, 1957, p. 710.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

auteurs de la loi belge de 1873, une société commerciale résultant nécessairement de la poursuite en commun d'un négoce suivi devait nécessairement revêtir la forme d'une société en nom collectif, sauf à présenter les éléments exceptionnels de la commandite ou de la société anonyme.

« *Comme la loi belge, l'Avant-projet "reconnaît" donc cinq espèces de sociétés commerciales proprement dites, c'est dire qu'il ne peut en exister d'autres. L'énumération de l'article 2 est, en d'autres termes, non pas exemplative, mais limitative* »[1]. La raison en est à trouver dans le principe que quiconque s'oblige, s'oblige indéfiniment sur tous ses biens (art. 2092 C.c.). Les dispositions de la loi commerciale seraient ainsi des dérogations par rapport au droit commun, qui en tant que dérogations seraient d'interprétation stricte.

Les acteurs économiques ne sont donc pas autorisés à créer de toutes pièces de nouvelles formes de sociétés, ni à combiner les caractéristiques retenues par la loi de façon inédite afin de donner naissance à une nouvelle forme de sociétés[2].

« *Selon cette théorie, il se forme, par la volonté du législateur, une société en nom collectif dotée d'une personnalité juridique propre entre les personnes qui exploitent ensemble une activité commerciale de manière continue sous une raison sociale dès lors que ces personnes n'ont pas régulièrement fait le choix d'une autre forme sociale* »[3].

Il est vrai que la société en nom collectif ainsi constituée par l'effet de la loi par application de la théorie des cadres légaux obligatoires est entachée d'irrégularité si les associés n'ont pas procédé à la rédaction d'un écrit, étant donné que cet écrit est prévu « *à peine de nullité* ». « *Mais cela ne l'empêche pas d'exister comme une personne morale distincte [...] L'attribution de la personnalité juridique aux sociétés en nom collectif irrégulières implique leur soumission à toutes les règles concernant la dissolution et la liquidation des sociétés commerciales dotées de pareille personnalité* »[4].

C'est donc la **société en nom collectif** qui est la **société de droit commun** pour les personnes poursuivant ensemble une activité commerciale, à moins qu'elles n'adoptent régulièrement un autre type de sociétés[5].

■ § 2 – Limites de cette théorie

Il résulte des développements du paragraphe précédent que la théorie est limitée au domaine des sociétés commerciales. En principe, la liberté contractuelle reste donc entière pour les associés qui entendent créer une association. Il peut donc y avoir création d'une association qui n'est pas une a.s.b.l., constitution d'un syndicat n'ayant pas la forme d'union professionnelle : ces constitutions sont parfaitement valables en tant que contrats. La seule conséquence est que ces associations sont dénuées de la personnalité morale[6].

La théorie visée exige d'abord que plusieurs personnes exercent ensemble une activité commerciale qui soit durable et ostensible. À défaut, l'activité peut relever d'une association momentanée ou encore d'une association en participation.

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 5, ID 11308.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 6, ID 11308.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1992, p. 679.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1992, p. 684.

5 – P. Van Ommeslaghe, *Les sociétés de fait*, *J.T.,*, 1957, p. 709.

6 – P. Van Ommeslaghe, *Les sociétés de fait*, *J.T.,*, 1957, p. 710.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Elle ne s'applique pas non plus à l'exercice d'une activité civile : « *Le caractère peu normatif des règles du titre IX du Code civil [...] explique que, dans la théorie des cadres légaux obligatoires, la société du Code civil ne soit pas considérée comme un cadre* »[1].

Si la théorie des cadres légaux obligatoires s'applique dès lors que toutes les conditions pour la constitution d'une société en nom collectif sont remplies, le droit des sociétés fait également état des **sociétés apparentes**. Cette notion est fondée sur la théorie générale de l'apparence qui infiltre également le droit des sociétés.

Ses conditions d'application sont différentes de celles de la théorie des cadres obligatoires dans la mesure où le tiers n'est pas tenu d'établir toutes les conditions requises pour l'existence d'une société en nom collectif. « *Il suffit que ce tiers ait pu légitimement croire à l'existence d'une société même si, dans la réalité, il n'en existe aucune* »[2].

Dans une affaire soumise à la Cour d'appel de Liège[3], un commerçant s'était fait immatriculer au registre du commerce en déclarant qu'il exploitait l'entreprise « en association de fait » avec son frère. La cour considérait que cette mention suffisait à induire un créancier en erreur et concluait à l'existence d'une société en nom collectif irrégulière. Ladite déclaration créant une apparence trompeuse, l'auteur de celle-ci devait en subir les conséquences[4].

SECTION II
LA NOTION DE COMMERÇANT

La définition de la notion de commerçant n'est pas facile et nécessite le recours à l'histoire.

■ § 1 – Aspects historiques

À l'intérieur de chaque cité, de chaque pays, les commerçants constituaient une classe d'hommes spécialisés, distincte des autres classes, celles des guerriers et des laboureurs. Cette autonomie était visible tant en Égypte qu'à Babylone, tant en Grèce qu'en Perse ou en Chine[5].

Le droit romain ne connaissait pas la séparation entre droit civil et droit commercial, distinction apparue dès le Moyen Âge où les corporations commerciales ont repris certains des pouvoirs qui revenaient traditionnellement à l'État[6]. Dans les statuts des corporations commerciales des villes italiennes (Venise, Gêne, Florence, Pise, Amalfi) à la tête desquelles se trouvaient des consuls, figuraient des règles juridiques applicables aux transactions réalisées par les membres de l'association. Les décisions des organes de la corporation étaient reprises dans des volumes appelés statuts qui regroupaient les règles applicables aux transactions réalisées par les membres[7]. Ces **statuts** donnaient lieu à des compilations telles que les statuts de Florence (1301),

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 514.

2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1992, p. 695.

3 – CA de Liège du 28 octobre 1983, *R.P.S.* 1984, p. 159.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1992, p. 695.

5 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 10.

6 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 12.

7 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 13.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la *Breve consulum mercatorum* de Pise (1305), les statuts de Bergame (1457), de Bologne (1509), de Crémone (1388), de Rome (1317), de Vérone (1318)[1].

Parallèlement, s'est développée la **comptabilité en partie double** donnant lieu à la publication par Luca Paciolo d'un véritable traité de comptabilité en 1494.

§ 2 – Conceptions objective et subjective du droit commercial

En France, le droit commercial s'est construit sur les notions d'actes de commerce et de commerçant[2].

La notion de commerçant est définie par le Code de commerce (article 1) en ces termes : « *Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle* ». Pour donner un contenu à cette définition, il convient donc de définir la notion d'acte de commerce. Au lieu d'en donner une définition synthétique, le Code de commerce procède à une énumération.

On distingue traditionnellement les **actes de commerce objectifs** (qui sont réputés tels par leur nature même), d'une part, des actes de commerce par la qualité de leur auteur (**actes de commerce subjectifs**), d'autre part. Il convient donc de qualifier certaines opérations d'actes de commerce et certaines personnes de commerçants.

La notion de commerçant est définie par rapport à celle d'acte de commerce dans la mesure où c'est la **répétition professionnelle** de tels actes de commerce qui confère la qualité de commerçant à la personne concernée[3].

Pour décrire la **nature hybride de ce système** (à la fois objectif et subjectif), on a pu dire que « *la commercialité part de l'acte, frappe la personne ; puis, en vertu d'un choc en retour, elle retombe sur les actes afin d'en saisir un plus grand nombre* »[4]. L'accumulation d'actes de commerce rend la personne commerçant (conception objective). Une fois cette qualification acquise, celle-ci est de nature à rendre commerciaux les actes qui intrinsèquement ne le sont pas (conception subjective). Est ainsi consacrée la notion d'actes de commerce « accessoires » ou subjectifs qui sont prévus par les dispositions des articles 631 et 2 C.com.[5].

« *Le droit commercial est donc à la fois le droit des actes de commerce, des "affaires", et celui des commerçants. Mais si ce double caractère lui a toujours appartenu, le point de vue personnel et le point de vue réel ont eu tour à tour la prédominance* »[6]. Le droit commercial peut ainsi être soit foncièrement objectif, soit foncièrement subjectif. En France, et par ricochet au Luxembourg, la conception subjective prédominait sans doute.

« *Répétons d'abord qu'en tant que législation indépendante, le droit commercial est, fondamentalement, un droit de caste, comme le prouve son histoire. Il y a des commerçants, qui forment une classe à part dans la cité. Les distinguer des autres citoyens est une tâche qui a préoccupé le législateur bien avant celle d'étiqueter des actes de commerce. Dans les législations anciennes, le commerçant acquiert sa*

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 16.
2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 66
3 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 70
4 – E. Thaller, *Traité théorique et pratique de droit commercial*, p. 54.
5 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 101
6 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 98.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

personnalité et son titre par des formalités extérieures : admission dans une corporation, inscription sur un registre, délivrance d'une attestation, etc. On n'attend pas qu'il y ait des actes de commerce pour qu'il y ait un commerçant. On est commerçant avant même d'avoir accompli le premier acte de commerce »[1].

Le système introduit par le Code de commerce est un **système hybride** reposant sur une transposition du système antérieur, essentiellement fondé sur l'Ordonnance de 1673 (dite **Ordonnance de Colbert** ou encore Code Savary).

L'Ordonnance de 1673 fut édictée par Colbert sous le règne de Louis XIV qui avait décidé de refondre les bases juridiques du royaume en regroupant des lois très disparates en cinq ordonnances : procédure civile en 1667, procédure criminelle en 1670, eaux et forêts en 1669, commerce en 1673 et maritime en 1681[2].

Dans le système antérieur, la définition des actes de commerce n'était faite que pour définir la compétence des juridictions de commerce. Les auteurs du Code de commerce avaient l'intention de reprendre ce système en spécifiant dans l'article 632 C.com. (dans la partie consacrée à la **compétence** des **juridictions** commerciales) les actes réputés être de commerce. Leur intention n'a été réalisée que de façon fort déficiente, l'article 632 étant précédé du bout de phrase : « *La loi répute acte de commerce [...]* ». Cet ajout avait pour effet de s'écarter du système de l'Ordonnance de 1673. En effet, dans cette dernière, l'énumération des actes de commerce n'était pertinente qu'au titre de la compétence juridictionnelle.

L'**Ordonnance de 1673** avait rendu communes à toutes les juridictions du royaume les dispositions de l'édit de Charles IX datant de novembre 1563 relatives aux juridictions consulaires parisiennes, dispositions ainsi libellées : « *Connaîtront lesdits juges et consuls des marchands de tous procès et différends qui seront mus entre marchands, pour fait de marchandises seulement, leurs femmes marchandes publiques, leurs facteurs, serviteurs et commettants, tous marchands [...]* »[3]. Il était ainsi précisé que, même entre marchands, la compétence des juridictions consulaires était limitée aux opérations de commerce « du fait de marchandises seulement ». Ce système fut repris par l'ordonnance de 1673.

Pour des motifs politiques et économiques le **Code de commerce** de 1808 innova par rapport au système de l'ordonnance. En effet, « *L'organisation corporative qu'avait connue celui-ci était en horreur aux hommes de la Révolution, qui se préoccupaient d'en empêcher le retour. Ils ne pouvaient donc plus admettre un droit commercial fondé sur une telle organisation, un droit de caste. [...] Restait alors la conception réelle et objective. On pouvait l'ériger en système général, construire tout un droit positif sur la notion d'acte de commerce substituée à celle de commerçant. Il fallait alors le dire au début du Code. Au lieu que les rédacteurs, impressionnés malgré tout par le précédent de l'Ordonnance, n'ont fait connaître leur conception nouvelle qu'au titre de la compétence et l'ont généralisée bien maladroitement par l'addition des mots : "La loi répute acte de commerce" dans l'article 632. [...] Dès lors s'implantait dans notre droit commercial cette conception hybride, née de ce que les législateurs de 1808 [...] se sont arrêtés entre les deux conceptions extrêmes : subjective et objective* »[4].

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 99.

2 – C. Delplanque, *in Le Code de commerce 1807-2007. Livre du bicentenaire*, p. 2.

3 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 101.

4 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 104.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION III
LES ACTES DE COMMERCE

Traditionnellement, le seul acte de commerce objectif était l'engagement par lettre de change. Les autres actes mentionnés par la loi, s'il s'agit d'actes isolés, ne relèvent de la compétence des juridictions de commerce que s'ils s'accompagnent d'un élément subjectif, à savoir le caractère professionnel de leur auteur[1].

■ § 1 – Les actes de commerce par nature

L'article 2 C.com. illustre la conception positive de l'acte de commerce et a repris plus ou moins littéralement les dispositions de l'article 632 du Code de commerce de 1808.

A – Le catalogue du Code de commerce

Ce catalogue est énoncé par l'article 2 C.com., libellé comme suit :

Texte de loi	Commentaires
« *La loi répute acte de commerce :* *Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage ; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat ; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite ; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises ;*	Faut-il donner une signification spéciale aux termes « denrées et marchandises » utilisés par la loi ? « *Les denrées sont les choses qui se consomment par le premier usage et qui sont destinées à la nourriture des hommes ou des animaux. [...] Par marchandises, il faut donc entendre toutes choses qui peuvent faire l'objet d'un trafic, d'une transaction commerciale* »[2]. Les denrées étant des marchandises, la mention des marchandises aurait été suffisante. Cette dernière expression vise tous les meubles corporels dans la mesure où ils sont dans le commerce tout en incluant les meubles incorporels tels que valeurs mobilières, brevets, dessins, marques de fabrique, droits de propriété littéraire et artistique, fonds de commerce, etc. Cette notion serait à interpréter de façon large afin d'inclure tous les droits faisant l'objet d'une exploitation sous forme d'entreprise[3].

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 107.
2 – C. Resteau, *Traité des sociétés anonymes*, T. 1., p. 41.
3 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 131.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Texte de loi	Commentaires
(suite)	Traditionnellement, on considérait que cette notion n'incluait pas celle d'immeubles, excluant ainsi les opérations de spéculation immobilières du champ d'application des actes de commerce. En dépit de certaines décisions de justice ayant admis le caractère commercial à l'égard de telles opérations immobilières, la jurisprudence française a finalement penché vers leur exclusion du catalogue des actes de commerce, et ceci, sur la base des arguments suivants : 1. aux termes des travaux préparatoires, Portalis avait considéré que « *les immeubles sont particulièrement du ressort de la loi civile* » ; 2. il est impossible d'appliquer aux immeubles les règles de preuve simplifiées prévues par l'article 109 C.c. ; 3. il est impossible d'enlever aux juridictions civiles la compétence pour les litiges relatifs à la propriété et aux droits réels[1].
Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter ;	
Toute entreprise de manufacture [...] de travaux publics ou privés, de transport par terre, air ou par eau, de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires...	La loi répute acte de commerce toute une série non plus d'actes isolés, mais d'entreprises. Dans la conception des auteurs de cette disposition, il ne s'agit pas d'un fait isolé de fabrication, etc., mais de l'exercice d'une profession, ou, du moins, d'une série d'actes d'une certaine importance impliquant d'ordinaire une organisation préétablie[2].
Toute entreprise de manufacture ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles ;	Lorsque le manufacturier effectue un travail à façon (le matériel lui étant livré par le donneur d'ordre), il y a louage d'ouvrage. « *Le manufacturier spécule, soit avec son travail et avec celui de ses auxiliaires, soit avec l'emploi de ses machines ou instruments divers ; on peut dire qu'il a acheté les services de ses ouvriers "pour en louer l'usage"* »[3].

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 134.

2 – C. Lyon-Caen et L. Renault, *Traité de droit commercial*, 1929-1932, T. 1, p. 155.

3 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 150.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Texte de loi	Commentaires
Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transport par terre, par air ou eau ;	Ne sont visées que les entreprises de transport, de sorte que les actes isolés devraient échapper à la qualification d'actes de commerce.
Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, d'établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes ;	L'expression « les agences, bureaux d'affaires, l'agent d'affaires » vise celui qui s'occupe des affaires d'autrui moyennant salaire. « *Il peut se charger de procès, faire des recouvrements, rédiger des contrats, accomplir des démarches et formalités, donner des consultations, etc.* »(1). « *Les agents d'affaires sont donc des commerçants, sauf si la loi leur a assigné un rôle et un statut particuliers qui ne permettent pas de les regarder comme tels (avoués, avocats, notaires, etc. et en général tous les agents d'affaires à monopole ou rentrant dans la classe des officiers ministériels)* »(2). Les établissements de **vente à l'encan** sont des entreprises qui exécutent publiquement, aux enchères ou au rabais des ventes de marchandises pour le compte de particuliers ou de commerçants. Ces exploitants jouent le rôle d'intermédiaires. Cette notion n'inclut pas toutes les personnes qui procèdent aux ventes d'enchères de marchandises. Sont exclus de cette notion les huissiers, greffiers et en général les officiers ministériels(3). En revanche, sont commerciales les activités des établissements qui font profession de recevoir des marchandises en dépôt, en permettant à leurs propriétaires de les vendre ou de les mettre en gage(4).
Toute opération de banque, change, commission et de courtage ;	Les opérations portant sur l'argent et de crédit ont toujours été considérées comme commerciales, à condition d'être faites avec les capitaux d'autrui et à titre commercial(5).

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 157.

2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 157.

3 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 158.

4 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 158.

5 – M. de Juglart et B. Ippolito, *Cours de droit commercial*, Vol. 1, 4e éd., Paris, Montchrestien, 1971, p. 111.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Texte de loi	Commentaires
Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre ;	La qualification de « commerçant » des **entreprises de construction** a également donné lieu à beaucoup d'hésitations. Si, lors de l'élaboration du Code de commerce, il avait été envisagé d'inclure celles-ci dans la définition des entreprises de manufacture, il y a été renoncé par la suite, et seules les entreprises de construction maritime ont été reprises à l'article 633 C.com. Le raisonnement était que ces entreprises « *sont de simples locations ou louages d'ouvrage, et n'ont aucune analogie avec les faits du commerce* »[1]. En droit luxembourgeois, cette discussion est sans objet depuis la loi du 21 juillet 1992 qui, modifiant l'article 2 C.com., inclut dans la notion d'acte de commerce « *toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre* ».
Toutes les opérations de banques publiques ;	Sont visées les banques créées avec l'autorisation du gouvernement et placées sous sans contrôle (Banque de France, Crédit Foncier, etc.)[2]
Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur ;	Ces opérations régies par le droit cambiaire sont entre-temps tombées en désuétude pour ne plus être pratiquées par les commerçants.
Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce ».	Cette disposition prévoit une présomption de commercialité très utile en pratique, permettant de trancher les cas litigieux en faveur de la commercialité.

La première question qui se pose à l'égard de l'**énumération** de cet article est de savoir si elle est **limitative ou non**. Il est admis que cette énumération n'est pas limitative[3]. Par ailleurs, selon certaines décisions, peu nombreuses il est vrai, le terme « répute » instituerait une présomption simple de commercialité, valable uniquement dans les hypothèses où ces actes seraient accomplis dans un but de lucre[4].

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 151.

2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 160.

3 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 163.

4 – Cass. b. du 19 janvier 1973, *R.C.J.B.*, 1974, p. 321, note J. Van Ryn et J. Heenen ; dans cette affaire, il s'agissait d'un curé qui, dans le cadre de ses activités pastorales, assumait l'exploitation d'un bassin de natation. L'installation de filtrage étant défectueuse, le curé assigna l'entrepreneur de travaux. Ce dernier faisait valoir que l'exploitation d'un bassin serait une entreprise de « spectacles publics » au sens de l'article 2, alinéa 5, C.com. (ID 10468), à la suite de l'article 2, alinéa 5, C.com. et que donc l'exploitant serait commerçant.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Pour être considéré comme acte de commerce, il n'est pas suffisant qu'un acte rentre dans l'énumération de l'article 2 C.com. La cour d'appel a confirmé un jugement de première instance retenant que des services de transport rendus à ses membres par une a.s.b.l. ne sont pas constitutifs d'une activité commerciale dès lors qu'ils ne sont pas faits dans un but de lucre par celui qui les accomplit[1].

Rien n'empêche que l'a.s.b.l. poursuive à **titre accessoire** une activité lucrative : celle-ci peut lui fournir les ressources dont elle a besoin pour son activité principale désintéressée. Si les fonds ainsi collectés sont effectivement consacrés à cette activité sans but lucratif, l'activité lucrative accessoire ne va pas lui faire perdre son statut d'organisme désintéressé[2].

Initialement, l'acte de commerce a été défini par l'article 632 C.com. Cette situation devait changer sous l'effet de la loi du 21 juillet 1992 qui non seulement introduisit la définition de la notion d'acte de commerce à l'article 2 du C.com., mais institua encore certains changements de fond. La principale modification à cet égard était celle concernant les opérations immobilières ; traditionnellement les achats, ventes, etc. portant sur des immeubles, étaient considérés comme des opérations civiles, ceci parce que le Code de commerce ne mentionnait que l'achat de denrées et de marchandises pour les revendre, donc de choses corporelles ou incorporelles faisant l'objet d'une circulation[3]. « *La réponse est facile et péremptoire. Ce n'est pas seulement le texte, c'est aussi l'esprit de la loi qui s'oppose à ce qu'on assimile les immeubles aux marchandises […] Pour qu'une chose soit réputée marchandise, il ne suffit pas qu'elle soit susceptible d'achat et de vente ; il faut de plus que la transmission de main en main soit prompte et facile et que, par sa nature, elle se prête, à l'aide d'un prix courant habituellement déterminé, au trafic et aux rapides mouvements de spéculation. Or, de toutes ces conditions, facilité de transmission, valeur vénale habituellement déterminée par un prix courant, simplicité de transmission, rapidité des échanges et de la consommation, il n'en est aucune qui puisse convenir aux immeubles* »[4].

À l'instar de son homologue belge (qui avait sur ce point modifié sa législation nationale en 1956, par la loi du 3 juillet 1956[5]), le législateur luxembourgeois a mis fin à cette anomalie par la loi précitée de 1992.

La loi du 5 août 2005 prévoit également des dispositions concernant la commercialité par la forme, et ceci, en disposant que les contrats de garantie financière et de compensation conclus par un non-commerçant ou par un commerçant sont réputés actes de commerce[6]. Par « *contrat de garantie financière* », on comprend les contrats de gage, de transfert de propriété à titre de garantie, de mise en pension ou de fiducie-sûreté régis par la loi du 5 août 2005 (art. 1er de la loi du 5 août 2005).

1 – CA du 6 mars 2002, n° 26.201.

2 – Cass. com. b. du 5 juillet 1937, *Pas.*, I, p. 212, J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.,* 1967, p. 279.

3 – L. Frédéricq, *Précis de droit commercial*, Bruxelles, Bruylant, 1 970, p. 27.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26., p. 244.

5 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.,* 1967, p. 281.

6 – Art. 2 de la loi du 5 août 2005, ID 1680.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

B – Caractéristiques de l'acte de commerce

L'article 2 C.com. donne une énumération relativement désordonnée qui nécessite un certain travail d'interprétation avant de dégager une définition vraiment opérationnelle. On peut considérer que la définition légale tient dans le premier alinéa de cette disposition ; c'est par rapport au libellé de cet alinéa que nous allons dégager les caractéristiques essentielles de la notion d'acte de commerce.

Le cas type de l'acte de commerce est celui indiqué par le premier point de l'énumération de l'article 2 : il s'agit de **l'achat pour revendre**. Dans toute opération commerciale, il y a un tel achat fait dans le but de revendre. Il faut en premier lieu qu'il y ait achat, donc l'acte de se procurer la marchandise chez quelqu'un d'autre en vue de la revendre. Il ne suffit pas d'un achat et d'une revente, mais *l'intention de revendre est requise*[1]. En outre, cette intention doit être la raison principale de l'achat. « *Si elle n'est que secondaire, elle ne saurait communiquer le caractère commercial à l'opération dans laquelle elle figure. C'est ainsi que le sculpteur qui achète un bloc de marbre et vend la statue ne fait pas un acte de commerce. L'achat du marbre suivi de sa revente n'est ici que la partie accessoire de l'opération civile qu'est, pour un artiste, la vente des produits de son art* »[2]. La même solution est vraie pour le viticulteur qui achète des fûts pour stocker son vin et qui seront vendus avec la récolte.

Pour que l'on soit en présence d'un acte de commerce, il faut donc en principe satisfaire à trois conditions :

– achat ;

– portant sur des marchandises (y compris les immeubles) ;

– dans l'intention de les revendre ou simplement d'en louer l'usage.

C'est cette intention de revendre (ou de louer l'usage) qui dénote l'esprit de spéculation de l'auteur de ces actes. Cette intention lucrative doit avoir existé au moment où l'acte d'achat est réalisé.

La vente ou la location consécutive à l'achat peut avoir lieu soit après transformation soit en l'état.

Il résulte de cette définition que ne sont pas à considérer comme actes de commerce les activités suivantes :

– le jardinier qui vend les produits du sol qu'il cultive[3].

  Cette solution résulte également de l'article 638 C.com. qui retire à la compétence des juridictions de commerce « *les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron pour vente de denrées provenant de son cru [...]* ». Cette disposition est toutefois purement superfétatoire pour la raison que la même solution résulte directement de l'interprétation de l'article 2 (632 C.com. initial). En effet, faute de revente, il n'y a pas d'acte de commerce[4] ;

– l'agriculteur qui vend le lait de ses vaches[5].

---

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 129.

2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 130.

3 – Cour du 28 mars 1874, *P.*, n° 1, p. 295, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 140.

5 – Cour du 13 mai 1881, *P.*, n° 2, p. 39, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

La question s'est posée de savoir si les opérations de transformation des produits du sol en vue de leur revente au public ne donneraient pas lieu à des solutions différentes en faisant rentrer ces opérations dans le cadre de l'article 632 C.com. La jurisprudence répond par la négative à cette question, même si l'exploitation agricole est de temps à autre alimentée accessoirement par des produits achetés sur le marché[1]. La limite est atteinte lorsque l'entreprise de transformation est prépondérante par rapport à l'exploitation agricole elle-même[2] ;

– le photographe qui vend des œuvres d'art[3] ;
– l'enseignant qui dispense contre rémunération des cours portant sur une science ou une technique (P. ex. auto-école[4]).

Le fait, même habituel, d'enseigner contre rémunération une science ou une technique ne constitue pas un acte de commerce et ne saurait attribuer la qualité de commerçant au directeur de l'établissement.

Spécialement, le directeur ou l'exploitant d'une auto-école ne saurait être considéré comme possédant la qualité de commerçant et ne pourrait donc être déclaré en état de faillite[5].

En revanche, les activités suivantes sont considérées comme commerciales :

– l'activité de l'agent d'affaires, qui fait notoirement profession de gérer, comme mandataire, moyennant salaire, les affaires commerciales ou civiles d'autrui, spécialement celui qui s'entremet, moyennant salaire, pour les achats, ventes et locations d'immeubles, notamment de maisons, qui se charge des liquidations de successions, procède à des recouvrements de créances, soigne des placements de fonds, et fait de l'exercice de ces opérations sa profession habituelle[6] ;
– l'activité du charpentier « *qui exécute avec l'aide de deux ou trois compagnons des travaux pour le compte d'administrations publiques et de particuliers après avoir acheté le bois nécessaire à ces travaux, exploite une véritable entreprise commerciale en spéculant sur la main-d'œuvre et sur la valeur des matières premières achetées pour les revendre avec bénéfice après les avoir travaillées. Un tel artisan est alors à considérer comme commerçant* »[7].

L'activité commerciale suppose la **répétition** : l'article 1 C.com. dispose en effet que sont commerçants ceux *« qui exercent des actes de commerce, et en font leur*

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 142.

2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 142.

3 – Cour du 25 mars 1893, *P.*, n° 3, p. 185. En revanche le photographe qui se borne à reproduire servilement par des moyens mécaniques l'image d'objets de toute nature et dont le travail personnel est le plus souvent remplacé par celui de machines et d'employés ; spécialement le photographe qui établit un cliché pour la représentation de sites et de monuments publics est commerçant, Lux. 25 mars 1893, *P.*, n° 3, p. 185. Ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour Lux. du 8 décembre 1965, *P.*, n° 20, p. 44, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Lux. 8 décembre 1965, *P.*, n° 20, p. 44, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Cour Lux. du 15 décembre 1905, *P.*, n° 7, p. 507, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

7 – Cour Lux. du 13 mars 1959, *P.*, n° 17, p. 470, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

profession habituelle ». En d'autres termes, des actes isolés ne confèrent pas la qualité de commerçant.

Selon la jurisprudence, n'est pas commerçant, faute de faire des actes de commerce à titre habituel, « *celui qui se borne à participer à une ou plusieurs opérations commerciales ; spécialement celui qui achète en participation, même avec un entrepreneur commerçant, quelques terrains seulement, pour les revendre après y avoir élevé des constructions ; celui qui se livre à une entreprise isolée d'ouvrages d'art ou de travaux de construction* »[1].

Plus que la réalisation effective d'actes de commerce importe **l'intention de répétition.** Ceci signifie, sans le moindre doute possible, que la personne qui achète un fonds de commerce, qui entreprend les démarches nécessaires pour obtenir une autorisation d'établissement de la part du ministère des Classes moyennes, qui engage du personnel et qui achète du matériel de bureau sera considérée comme commerçant, même si elle décède accidentellement avant de pouvoir effectivement débuter les activités commerciales proprement dites.

C – La notion d'entreprise

En parcourant les différents actes de commerce « objectifs » énumérés par l'article 2 (ancien article 632 C.com.), on constate qu'à certains endroits la loi fait référence à la notion d'entreprise avec, par exemple, la conséquence que, contrairement à l'achat pour revendre, l'opération de transport ne constitue un acte de commerce que si elle est effectuée d'une manière professionnelle, et donc avec une certaine ampleur[2].

La notion d'entreprise n'est définie nulle part. Cette notion supposerait « *qu'il s'agit non d'un fait isolé de fabrication, etc., mais de l'exercice d'une profession ou, tout au moins, d'une série d'actes d'une certaine importance impliquant d'ordinaire une organisation préétablie* »[3]. Il résulte de la loi que les actes de commerce relevant de la notion d'entreprise le sont uniquement s'ils sont accomplis en grand nombre en vertu d'une répétition caractéristique de toute activité professionnelle. Au demeurant, cette répétition est exigée également pour les actes d'achat effectués pour revendre, ainsi que pour les actes d'entremise ; tous se caractérisent donc en fin de compte par l'exercice professionnel de ces activités[4].

On a considéré que c'est cette notion d'entreprise (qui demande qu'une série d'actes impliquant une certaine organisation préétablie soient réalisés) qui constitue alors la véritable synthèse entre les notions d'acte de commerce et de commerçant. « *Le droit commercial n'est plus réel ou personnel d'une manière exclusive et antinomique. Il demeure cependant plus près de la tradition subjective, car qui dit entreprise dit à peu près sûrement profession. Il suffirait donc de faire précéder l'énumération de l'article 632 du terme général d'entreprise pour restituer au droit commercial français son caractère historique* »[5].

---

1 – Cour du 7 avril 1881, *P.*, n° 2, p. 20, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 119.

3 – C. Lyon-Caen et L. Renault, *Droit commercial*, p. 155.

4 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 150.

5 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 120.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

D – Présomption de commercialité à l'égard des commerçants

L'article 2 C.com., dans son dernier alinéa, comprend une disposition simplifiant grandement l'application de ces principes à l'égard des commerçants en réputant encore actes de commerce : « *toutes obligations de commerçants, [...], à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce* ». La présomption est donc simple *(juris tantum)*, mais l'effet est que l'acquisition d'un immeuble par un professionnel de l'immobilier ou d'un objet d'art par un antiquaire sera réputé acte de commerce (sous réserve de la preuve contraire apportée par une personne ayant un intérêt à contester le caractère commercial de ces actes).

La **théorie de l'accessoire** opère dans les deux sens : d'un côté, elle permet de qualifier de commerciaux des actes qui, par leur nature, sont des **actes civils** ; de l'autre côté, des actes qui intrinsèquement sont des actes de commerce perdent cette qualification s'ils ne sont que l'accessoire d'une activité civile qui les absorbe : médecin vendant des médicaments à sa seule clientèle[1]. « *La tendance objective et la tendance subjective se combinent dans la construction de la théorie de l'accessoire et chacune d'elles corrige ce que l'autre a d'insuffisant. C'est la prépondérance de la seconde de ces tendances qui a permis aux tribunaux l'extension de la théorie de l'accessoire aux actes non contractuels, enrichissement sans cause, délits, quasi-délits. Seuls demeurent exclus les actes, de quelque nature qu'ils soient, qui, ayant par eux-mêmes le caractère civil, ne sont accomplis, même par un commerçant, que pour des fins étrangères à son commerce* »[2].

La qualité de commerçant n'embrasse pas nécessairement l'intégralité des activités professionnelles d'une personne. En d'autres termes, une personne donnée peut avoir une activité salariée (qui ne répond donc pas aux critères de l'activité commerciale) et poursuivre en même temps une activité commerciale, ceci en faisant des actes de commerce qui lui confèrent la qualité de commerçant dans le domaine en question. Ainsi a-t-il été jugé que le cabaretier qui est principalement cultivateur et qui n'exploite qu'accessoirement un cabaret est néanmoins commerçant (pour cette activité de cabaretier)[3].

La qualité de commerçant relève de l'état des personnes et partant de **l'ordre public** : il ne suffit pas de se déclarer commerçant pour le devenir. Dans l'affaire soumise au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la personne dénommée B s'était attribué la qualité de commerçant dans l'acte constitutif de la société C. En l'absence de cette qualification de commerçant, la commande de travaux de rénovation de la menuiserie d'un restaurant n'était donc pas à considérer comme acte de commerce[4].

■ § 2 – Les actes de commerce subjectifs

Cette catégorie renferme des actes de nature strictement civile, mais qui deviennent commerciaux lorsqu'ils sont accomplis sous certaines conditions par une personne qui a déjà la qualité de commerçant[5].

---

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 131.

2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 171.

3 – Cour du 2 février 1900, *P.*, n° 5, p. 481, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 20 mars 2009, n° 118.637, ID 12006.

5 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 171.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Tombent dans cette catégorie tous les actes réalisés par des commerçants en vertu d'une présomption légale, qui est toutefois une présomption simple. Au-delà de cette disposition, il faut mentionner que tous les actes des sociétés commerciales sont des actes de commerce. Cette conclusion résulte de l'article 3, alinéa 3, C.com. qui autorise les sociétés dont l'objet est civil à se constituer sous l'une des six formes de sociétés commerciales. « *Mais dans ce cas, les sociétés ainsi que les opérations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce* ». En d'autres termes, des opérations qui en principe sont civiles sont réputées commerciales, et ceci, sans que la preuve contraire ne puisse être rapportée.

On notera que cette formulation est différente de celle retenue en France par la loi du 1er août 1893 ainsi libellée : « *Quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui seront constituées dans les formes du Code de commerce ou de la présente loi seront commerciales et soumises aux lois et usages de commerce* ».

On a pu se demander si cette formulation avait pour conséquence de rendre commerciaux les engagements de ces sociétés ou si elle conférait simplement la qualité de commerçant à la société[1]. Une telle discussion est sans objet au Luxembourg dans la mesure où la formulation retenue par la L.S.C. rend commerciales tant les sociétés que les opérations qu'elles réalisent. Ces dernières sont donc nécessairement des actes de commerce.

■ § 3 – Les actes de commerce mixtes

La notion d'actes de commerce mixtes (ou unilatéraux) est utilisée en pratique et par la doctrine, mais sans trouver de base dans les textes. Par cette notion sont désignés les actes qui sont actes de commerce du côté du commerçant sans avoir cette caractéristique s'ils sont envisagés du point de vue de la contrepartie[2]. À ces actes, on applique distributivement les règles du droit commercial et du droit civil, notamment au regard des règles **de compétence et de preuve**[3].

En doctrine, cette catégorie d'actes n'est pas reconnue unanimement. On a fait valoir qu'il s'agissait d'actes de commerce qui le demeurent même envisagés du côté de la contrepartie qui est non-commerçante, et ceci, nonobstant le fait que cette présence d'un non-commerçant entraîne des dérogations aux règles normales de compétence et de preuve[4].

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 108.
2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 111.
3 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 111.
4 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 111.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
DISTINCTION ENTRE DROIT CIVIL ET DROIT COMMERCIAL

Le domaine du droit commercial est vaste et, historiquement, il a tendance à s'élargir avec l'accroissement de l'activité commerciale. « *Sa délimitation précise est aussi difficile à établir que sa définition exacte. Ses frontières, avec le droit civil, sont indécises, puisqu'il emprunte à celui-ci nombre d'éléments. Il touche également à d'autres branches du droit, par exemple au droit administratif, au droit pénal, au droit fiscal, etc. [...] Comme la définition même du droit commercial, la détermination de son contenu, les raisons de son autonomie, ils trouvent en grande partie leur explication dans l'histoire* »[1].

Le droit commercial est une branche du droit privé, distincte du droit civil, qui représente le droit commun de tous les citoyens[2].

Les règles spéciales applicables en droit commercial se justifient par les besoins de rapidité, de simplicité, d'encouragement du crédit, de rigueur dans le respect des engagements commerciaux et de sécurité des transactions commerciales[3].

La question de savoir si l'on est en présence d'un acte de droit commercial ou d'un acte de droit civil est d'importance à plusieurs égards, que nous aborderons tour à tour ci-après, en commençant par les règles de preuve.

SECTION I
RÈGLES DE PREUVE : LIBERTÉ

En droit civil, toutes les opérations dépassant une certaine valeur doivent en principe faire l'objet d'un écrit (ou d'un commencement d'écrit, article 1347 C.c.). Le Code civil en son article 1341 (complété par un règlement grand-ducal) fixe cette limite à 2 500 euros. En l'absence d'un tel écrit, il n'est pas possible d'établir la preuve de la réalité des opérations effectuées. En droit commercial, la liberté de la preuve est consacrée : celle-ci peut être apportée par tous moyens ; sont donc admises la preuve par témoin, par simples présomptions, etc.

Par ailleurs, l'article 1325 C.c. (selon lequel « *les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct […]* ») n'est pas applicable en matière commerciale[4].

SECTION II
LE TRANSFERT DES CRÉANCES SELON LE DROIT CAMBIAIRE

Le transfert des créances se fait à l'égard de tous par les formalités très simplifiées du droit cambiaire, et donc sans avoir à respecter les dispositions du droit civil (dans la forme de l'article 1690 C.c.).

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 9.

2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 56.

3 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 3.

4 – CA com. du 11 décembre 2003, nos 26.824, *BIJ*, 2004, no 7, p. 121.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

SECTION III
FORCE PROBANTE DES LIVRES DE COMMERCE

Si, en droit civil, la règle est que nul ne peut se faire un titre à soi-même (voir article 1331 C.c. : « *Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits* »), la situation est différente en droit commercial où il est entendu que les livres de commerce, à condition d'être régulièrement tenus, peuvent faire foi entre commerçants pour faits de commerce.

Telle est la solution retenue par le Code de commerce : « *Les livres de commerce régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce* » (art. 17 C.com.). Cet effet de faire foi au profit de ceux qui ont tenu ces livres est toutefois subordonné à la condition que les règles et formalités prévues par la loi soient effectivement respectées (art. 18 C.com.)[1].

Les juridictions apprécient souverainement si les livres de commerce, même régulièrement tenus, constituent une preuve ou non[2]. Selon le texte même de l'article 17 C.com., les livres ne peuvent faire foi contre un non-commerçant[3].

La preuve testimoniale peut être admise même contre et outre le contenu d'un acte. « *Mais les tribunaux doivent se montrer circonspects dans son admission* »[4].

SECTION IV
LA POSSIBILITÉ DE DÉCLARATION DE FAILLITE

Le commerçant qui est en état de cessation de paiements peut être déclaré en état de faillite, l'administration de ses biens lui étant alors retirée. Une procédure comparable n'existe pas à l'égard des particuliers soumis au droit civil. Les particuliers sont en état de **déconfiture**, situation qui en principe ne comporte guère de conséquences juridiques concrètes (en tout cas, pas au même titre que l'état de faillite des commerçants). En effet, le débiteur civil en état de déconfiture conserve la libre administration de ses biens, alors que tous les actes faits par le commerçant failli depuis le jugement déclaratif de faillite sont nuls de plein droit[5].

L'étude de la loi du 8 janvier 2013 sur le **surendettement des particuliers** prévoyant une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation financière du débiteur (qui a abrogé la loi du 8 décembre 2002 sur le surendettement) dépasse le cadre du présent ouvrage.

SECTION V
OBLIGATIONS SOLIDAIRES

En droit commercial, le **droit commun est la solidarité**, ce qui signifie que les obligations assumées dans le cadre d'une activité commerciale ne sont pas simplement divisées par le nombre de participants à cette activité (chacun n'étant tenu

1 – *R.P.D.B.*, T. 12, V° Sociétés, p. 215.
2 – Les Novelles, *Corpus Iuris Belgici*, n° 3852.
3 – *R.P.D.B.*, T. 12, V° Sociétés, p. 215.
4 – *R.P.D.B.*, T. 12, V° Sociétés, p. 215.
5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 231.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

qu'à concurrence de sa part virile), mais que l'un ou l'autre des participants risque de devoir assumer une part plus élevée que sa part arithmétique afin de combler l'insolvabilité de ses codébiteurs.

Cette solidarité applicable en droit commercial constitue une dérogation à l'article 1202 C.c. selon lequel la **solidarité ne se présume pas**. Selon la jurisprudence belge, la solidarité, qui est exceptionnelle, doit s'interpréter restrictivement[1]. Pour la jurisprudence française, l'article 1202 C.c. est inapplicable en droit commercial en raison de l'usage ancien consacrant une présomption de solidarité[2].

L'obligation de solidarité ne joue toutefois que dans les relations avec les tiers. En d'autres termes, les associés solidairement tenus aux dettes sociales sont libres de convenir entre eux d'une autre solution quant à la contribution aux dettes.

Au moins dans les sociétés pour lesquelles les associés ne bénéficient pas de la responsabilité limitée (donc les sociétés de personnes), cette obligation solidaire aux dettes est **d'ordre public** : elle est de l'essence de ce type de sociétés et les statuts ne sauraient y déroger ou la limiter et rendre ainsi plus difficile la situation des créanciers sociaux.

En fait, cette solution risque de ne pas donner entière satisfaction au commerçant qui a dû payer les dettes communes dans la mesure où, en cas d'insolvabilité de ses associés, son droit de recours contre ces derniers est sans la moindre valeur : il a donc dû assumer l'insolvabilité totale ou partielle de ses associés.

■ § 1 – Responsabilité limitée et illimitée

En matière de droit des sociétés, il faut distinguer entre les obligations limitées et les obligations illimitées. Toute personne est tenue aux dettes de façon illimitée, c.-à-d. sur tous ses biens et sans pouvoir limiter ses obligations à une partie de son patrimoine. Dans la conception française du droit civil, une personne a un patrimoine et un seul, toute constitution d'un **patrimoine d'affectation** qui constituerait un sous-ensemble du patrimoine global dont les actifs seraient réservés au paiement des dettes professionnelles est en principe exclue.

Le droit des sociétés commerciales permet de limiter la responsabilité à laquelle sont exposés les associés de la société. En effet, dans presque toutes les formes de sociétés commerciales, la responsabilité est limitée, soit pour tous les associés (S.A. ou S.à r.l. et, le cas échéant, la société coopérative[3]), soit pour au moins une partie d'entre eux (les sociétés en commandite, la S.e.c.a, la S.e.c.s. et la S.e.c.-Sp.). La seule exception est la S.e.n.c. dans laquelle il y a obligatoirement responsabilité illimitée en plus de la solidarité (voir ci-après).

Économiquement, la responsabilité limitée présente l'avantage d'encourager la création d'entreprises et de permettre l'appel à l'épargne publique. De son côté, la responsabilité illimitée comporte aussi des avantages, puisqu'elle constitue une incitation à la bonne gestion et protège les créanciers de la société. D'un point de vue économique, il conviendrait de procéder à une analyse des coûts-avantages : « *la création d'entreprises nouvelles est un bénéfice social et économique ; la mauvaise*

1 – Cass. b. du 5 décembre 1975, *Pas.*, 1976, I, p. 428.

2 – P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations », *R.C.J.B.,* 1988, p. 81.

3 – À condition que les statuts prévoient une telle limitation de responsabilité, v. art. 116, pt 7.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

gestion des sociétés et la faillite qui en découle souvent sont un coût. Le droit des sociétés idéal du point de vue de l'efficience économique est donc celui qui est conçu de telle façon que les bénéfices du système de la responsabilité limitée soient supérieurs aux coûts qu'il entraîne »[1].

■ § 2 – Responsabilité divise ou solidaire

Si la responsabilité est illimitée, elle est en principe **divise**[2], ce qui signifie que les dettes sociales sont divisées par le nombre de débiteurs (donc d'associés), de sorte que chaque associé supporte une certaine part des dettes sociales, proportionnellement à sa participation au capital de la société, à moins qu'une autre clé de répartition ne soit retenue, notamment par les statuts (p. ex., la division par le nombre d'associés, par parts viriles).

Concrètement, ceci signifie que, pour une société civile avec trois associés détenant chacun un tiers du capital et pour laquelle, après liquidation des avoirs, il reste un montant de dettes non honorées de 75 000 euros, chacun des associés sera redevable de 25 000 euros. Le créancier devra effectivement assigner chaque codébiteur pour un tiers du montant de sa créance.

En revanche, en cas d'obligations solidaires, la situation du créancier s'améliore considérablement dans la mesure où il peut assigner n'importe lequel des débiteurs solidaires pour le montant intégral de la créance non encore payée. Ce débiteur ne peut opposer le **bénéfice de division** à son créancier. Dans la mesure où il est solvable, il devra payer l'intégralité des dettes sociales, sans préjudice des recours qu'il peut exercer contre ses co-associés. Ces recours ont trait à la **contribution aux dettes** (voir ci-dessous). La solidarité en matière commerciale est une règle coutumière, affirmée par la Cour de cassation française[3] et la Cour de cassation belge[4].

Dans ce contexte, se pose une question d'une importance pratique considérable : celle de l'**étendue de la solidarité**. Concrètement, il s'agit de décider si les associés solidaires (dont ceux d'une société en nom collectif par exemple) sont tenus de toutes les dettes de la société ou s'ils ne sont tenus que des dettes nées après leur entrée dans la société. Cette question ne connaît pas de réponse simple.

Les auteurs belges classiques[5] ont opiné dans le sens que le nouvel associé n'est pas responsable du passif social qui a déjà existé au moment de son entrée dans la société. Cette solution se fonde sur le raisonnement que les tiers n'ont pas pu compter sur sa solvabilité personnelle au moment où ils ont traité avec la société. Elle est notamment retenue par un arrêt belge[6].

Il existe toutefois des décisions jurisprudentielles françaises[7] allant dans le sens opposé et qui, finalement, semblent emporter la conviction générale. Les associés

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 215.

2 – Tel est notamment le cas des sociétés civiles, et ceci, en application de l'article 1862 C.c.

3 – Cass. du 20 octobre 1920, *D.P.*, 1920, I, p. 161, note Matters.

4 – Cass. b. du 3 avril 1952, P.as. I, p. 498.

5 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. V, p. 323.

6 – CA Mons du 27 mai 1980, *R.P.S.*, 1980, p. 284, note P. Coppens.

7 – Arrêt du 12 mars 1928, *S.*, 1928, p. 226.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

nouveaux sont tenus, parce que la société est tenue et c'est d'elle que dérive l'engagement solidaire[1].

L'argument de texte tiré de l'article 200-1 [anc. art. 14] L.S.C. renforce considérablement cette position défavorable réservée aux nouveaux associés : « *[...] dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société* ». Le mot « tous » ne permet guère de différenciation selon la date de naissance de la dette.

Par conséquent, il paraîtrait essentiel que tout associé d'une telle société soit conscient du fait que sa responsabilité risque de ne pas être cantonnée aux dettes nées après son entrée dans la société.

■ § 3 – Obligation aux dettes et contribution aux dettes

Si la question de l'obligation aux dettes concerne les relations entre, d'une part, la société et les associés de celle-ci et, d'autre part, les créanciers sociaux, la question de la contribution aux dettes a trait aux relations entre associés. Dans ces dernières relations, ce sont les dispositions contractuelles (donc statutaires) qui vont prévaloir.

Si l'on reprend les données de l'exemple précédent en supposant que l'associé A était obligé de désintéresser l'intégralité des créanciers pour l'ensemble de leurs créances, il n'en reste pas moins que A bénéficie d'un droit de recours contre ses co-associés B et C qui, dans leurs relations internes, participent au résultat de la société dans les mêmes proportions que A. Par conséquent, A pourra réclamer à chacun de ses deux associés un tiers du montant des dettes sociales avec donc idéalement le résultat que chacun des associés soit tenu pour un tiers des dettes totales, soit 25 000 euros. Pour le cas où l'un des associés B ou C (p. ex., C) est insolvable, A ne peut obtenir le paiement de la quote-part de la dette de C, avec donc la conséquence que la quote-part de la dette afférente à C reste finalement à sa charge. A ne peut pas, sur la base de la solidarité existant entre les associés, demander le paiement de l'intégralité des créances non payées à B : en effet, cette solidarité concerne exclusivement les relations avec les créanciers de la société, et non les relations des associés entre eux. Concrètement, A ne peut réclamer à B que le montant de 25 000 euros, et non celui de 37 500 euros.

Un cas de figure intéressant est le suivant : le document constatant un emprunt contracté par une S.p.r.l. est signé deux fois par son gérant : une fois ès-qualités et une fois à titre personnel sous la mention « lu et approuvé ». La preuve du cautionnement par le gérant n'ayant pas été établie, pas plus qu'une solidarité conventionnelle, le tribunal a retenu que la société et son gérant étaient tenus conjointement, et donc de manière divise pour l'emprunt[2].

1 – P. Coppens sous CA Mons du 27 mai 1980, *R.P.S.*, 1980, p. 290.

2 – Trib. (civ.) Bruxelles du 8 janvier 1976, *Pas.*, III, p. 31. ; P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations », *R.C.J.B.,* 1988, p. 80.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE II
SOURCES DU DROIT COMMERCIAL

En droit commercial, comme dans les autres branches du droit, il existe une multiplicité de sources entre lesquelles une hiérarchie doit être établie afin de résoudre les inévitables conflits susceptibles de naître entre les dispositions contradictoires.

CHAPITRE I
DIVERSITÉ DES SOURCES

Cette diversité des sources est expressément reconnue par diverses dispositions du droit commercial et du droit civil. Ainsi, l'article 100-1 (anc. art . 1er de la L.S.C.) dispose que les sociétés commerciales « *se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers et par le droit civil* ». L'article 1873 C.c. édicte que le Code civil s'applique aux sociétés à défaut de règles contraires résultant des lois et usages de commerce. Cette disposition reproduit dans un ordre inverse l'article 18 du Code de commerce de 1808 ainsi libellé :

« Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce et par les conventions des parties ».

Il est vrai que cet ordre retenu par la L.S.C. respecte mieux la logique[1] selon laquelle les sociétés commerciales sont régies en premier lieu par les conventions des parties (dans la mesure où elles n'ont rien de contraire aux lois qui intéressent l'ordre public ou aux bonnes mœurs) qui peuvent modifier les règles simplement dispositives (et non prohibitives ou impératives), par les lois et usages particuliers au commerce et, subsidiairement seulement, par le Code civil. En effet, ces dernières dispositions ne sont applicables aux sociétés commerciales « *que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages de commerce* » (art. 1873 C.c.). Sur le fond, on peut noter que les usages de commerce (non repris par le Code de 1808, même si ce n'était que par un oubli[2]) ont repris la place qu'ils ont dans le Code civil qui, dans son article 1873 précité, admet que les usages de commerce puissent **déroger au droit civil**.

Tel était également l'opinion de Corbiau pour qui l'ajout en question ne faisait pas dire autre chose à la loi luxembourgeoise que ce que la doctrine faisait dire au texte belge, à savoir qu'en cas de contestation sur un point donné de la matière, on a d'abord recours aux conventions des parties puis, en cas de silence des parties, à la loi commerciale ou à l'usage (dans la limite où celui-ci ne peut suppléer ou même contredire la loi) et, enfin, au droit commun de la loi civile[3].

De même, le Code civil en ses articles 1107 (« *les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce* »), 1341 (sur les

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 25, ID 11305.
2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 25, ID 11305.
3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 4, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

règles de preuve) et 2084[1] (« *les dispositions ci-dessus ne sont applicables […] ni aux matières de commerce [...]* ») fait allusion à des règles spéciales de commerce et reconnaît que les règles du droit commun sont applicables toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du droit commercial[2].

Une des principales sources du droit commercial a été, au début du XIXe siècle, le Code de commerce de 1807, entré en vigueur en 1808[3].

SECTION I
LE CODE DE COMMERCE

Aux termes de l'article 2 de la loi du 15 septembre 1807 portant promulgation du Code de commerce à partir du 1er janvier 1808, toutes les anciennes lois relatives au commerce sur lesquelles le Code de commerce a statué sont abrogées à compter de cette même date. Par conséquent, les matières non touchées par le Code de commerce lui-même ou encore par une loi postérieure continuent d'être régies par les lois antérieures[4].

Sont donc toujours applicables un certain nombre de textes de loi antérieurs à la promulgation du Code de 1808. En outre, dès le début, le Code de commerce n'a réglementé qu'une partie très limitée du droit commercial. La plupart des dispositions du droit commercial matériel furent introduites seulement après 1808.

L'évolution qui s'est faite au cours des XIXe et XXe siècles, au Luxembourg comme en France, a pu être qualifiée de **décodification** dans la mesure où le Code de commerce fut vidé de l'essentiel de son contenu, notamment de la partie consacrée aux sociétés commerciales[5]. En effet, si dans la forme adoptée par la loi du 15 septembre 1807, le Code de commerce avait 648 articles, ce nombre fut réduit à environ 150 à la fin du XXe siècle.

Mais, telle n'est pas la fin de l'évolution. En France, par une ordonnance du 18 septembre 2000 (no 2000-912), un nouveau Code de commerce a été promulgué : il comporte plus de 1800 articles subdivisés en 9 livres[6]. Le Luxembourg n'a pas connu une évolution similaire.

SECTION II
LE DROIT CIVIL

Le droit commercial est à l'égard du droit civil une **législation d'exception**. Le droit civil s'applique donc à chaque fois que le droit commercial (ou une législation spécialisée) ne prévoit pas une disposition particulière[7]. Dès qu'une telle disposition existe, elle déroge aux dispositions de droit commun du Code civil, *lex specialis derogat legi generali*.

1 – Disposition entre-temps abrogée par la loi du 21 décembre 1994, ID 9594.

2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 38.

3 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 26.

4 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 26.

5 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 5.

6 – C. Delplanque, *in Le Code de commerce 1807-2007. Livre du bicentenaire*, p. 9.

7 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 38.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION III
LES USAGES ET LA COUTUME EN DROIT COMMERCIAL

« *L'une des sources les plus abondantes du droit commercial demeure encore l'usage* »[1].

Il convient d'abord de définir ces deux notions. Les usages sont des pratiques conventionnelles qui naissent de la **répétition généralisée et collective** des mêmes actes ou opérations et qui ont la force de présomption pour les points que les parties n'ont pas précisés dans leurs conventions[2].

Ces usages se forment de la façon suivante : les commerçants poursuivent pendant un certain temps, dans leurs relations d'affaires, soit une certaine pratique matérielle soit une certaine règle juridique. Ces solutions font l'objet de certaines clauses expresses dans les relations contractuelles entre les parties. À force de répétition, les clauses visées entrent dans les habitudes, à tel point que d'expresses elles deviennent tacites ou sous-entendues dans tous les contrats du même genre. Ces clauses expresses représentent des conventions obligatoires uniquement pour ceux qui y sont parties, sans effets à l'égard des tiers. Il n'y a usage qu'à partir « *du jour où les clauses expresses sont sous-entendues et où la pratique générale expresse s'est détachée de la convention pour s'ériger en une disposition objective non exprimée* »[3].

C'est donc à partir du moment où les clauses, jusqu'alors expresses, deviennent sous-entendues qu'il y a usage[4]. « *C'est à ce moment qu'il se détache de la volonté des parties, qui était à son origine, pour s'intégrer en une règle dont le fondement est encore la volonté elle-même, mais une volonté collective qu'on a très heureusement appelée la "conscience générale de la place"* »[5].

Le Code civil, de son côté, fait souvent référence aux usages : il en va ainsi dans les articles 1135 (« *Les conventions obligent, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature* »), 1159 (« *Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé* ») et 1160 (« *On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage quoi qu'elles ne soient pas exprimées* »). L'article 1873 C.c. se situe à un autre niveau en déclarant que les dispositions du titre des sociétés s'appliquent aux sociétés de commerce uniquement sur les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages de commerce. Les usages de commerce **écartent** donc les **dispositions légales contraires**[6].

« *Lorsqu'il est envisagé, non plus par le législateur, mais par le juge, l'usage, en tant que source autonome du droit commercial, se présente toujours en antagonisme avec la loi. Tantôt il se borne à l'interpréter ; mais parfois il ajoute à ses dispositions ; même, il tente de les corriger ou de les abolir. Les usages de ces dernières catégories sont les plus remarquables* »[7]. Un exemple de tels usages de nature à primer les

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 39.
2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 185.
3 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 45.
4 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 46.
5 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 46.
6 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 40.
7 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 41.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dispositions légales est le cas de l'article 1184 C.c. relatif à la condition résolutoire des contrats synallagmatiques.

La **coutume** suppose « *l'existence de pratiques juridiques depuis longtemps observées et la croyance générale que ces pratiques ont un caractère légalement obligatoire, de sorte qu'elles revêtent une valeur normative* »[1]. La coutume est beaucoup plus contraignante que les usages dans le sens où « *[…] la coutume est une règle de droit impérative et d'ordre public qui supplée à l'absence de loi écrite ou qui même contrevient à une disposition de cette loi. [...] L'usage est autre chose. On peut le définir : la clause tacite, sous-entendue dans une convention, par laquelle les parties règlent leurs rapports suivant la pratique établie. Cette pratique est tantôt générale et tantôt limitée à une industrie ou à une place particulière. Dans les deux cas, elle constitue un élément d'interprétation des plus légitimes. Les usages disposent d'une très forte autorité en matière commerciale. C'est en réalité de l'usage que tout ce droit est sorti, c'est par lui qu'il se réforme sans cesse* »[2].

Le premier élément de la coutume « *[…] est représenté par l'usage, c.-à-d. une pratique sociale qui soit à la fois constante et uniforme [...] À l'usage doit s'ajouter la conviction que la pratique suivie est le droit ; négativement, le fait de ne pas suivre l'usage doit être ressenti comme une violation du droit* »[3].

Parmi les différences existant entre ces notions, on peut noter que « *[…] l'application des usages suppose leur connaissance et leur acceptation par les parties, tandis que les coutumes s'appliquent indépendamment de la connaissance et du consentement des parties : la preuve d'un usage doit être rapportée par celui qui l'allègue, mais non celle de la coutume ; enfin l'existence d'un usage relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, tandis que la violation de la coutume peut donner lieu à cassation* »[4].

« *En revanche, malgré les opinions parfois émises en sens contraire, les parties peuvent écarter tant les usages que les coutumes qui revêtent un caractère supplétif* »[5].

Si, aux termes de l'article 1202 C.c., la **solidarité** ne se présume pas, cette règle est écartée en matière commerciale ; les dispositions sur **l'anatocisme** (art. 1154 C.c.) permettent la capitalisation des intérêts uniquement si les intérêts sont dus au moins pour une année entière. La Cour de cassation française a arrêté à plusieurs reprises que l'exception d'anatocisme ne peut être soulevée par le débiteur du solde du compte que s'il s'agit d'une capitalisation mensuelle et s'il n'y a pas eu d'arrêté de compte[6].

La situation du droit commercial diffère de celle du droit civil : en effet, si la loi du 30 ventôse an XII (qui a promulgué le Code civil) a explicitement abrogé toutes les coutumes antérieures, la loi du 15 septembre 1807 (qui a mis en vigueur le Code de commerce) n'a formellement abrogé que les anciennes lois (dans les domaines

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 185.

2 – C. Lyon-Caen et L. Renault, *Droit commercial*, n° 13, cité par L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 9.

3 – P. Pescatore, *Introduction à la science du droit*, Université du Luxembourg, p. 101.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 186.

5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 186.

6 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 43.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

couverts par le Code de commerce). En matière commerciale, il convient donc de conclure que ces anciennes coutumes ne sont abolies que si elles sont tacitement abrogées du fait de leur incompatibilité avec les dispositions du Code de commerce ainsi qu'avec les lois antérieures[1].

Les usages de commerce ont joué un rôle important dans le développement du droit des sociétés. Ainsi, au XVIIIe siècle, la division du capital et les clauses limitatives de responsabilité aux apports étaient des solutions de la pratique[2]. Autre usage de commerce, « *les exigences de célérité, de simplification, de crédit, de stricte exécution, etc. [...] qui, s'imposant aux commerçants, sont inconnues, du moins exceptionnelles, dans les relations ordinaires. La lettre de change est une bonne illustration de ce phénomène* »[3].

Selon Nyssens, toute violation d'un usage de commerce constituerait un moyen de cassation, ce qui fut considéré comme assez problématique dans la mesure où, au Luxembourg, contrairement à la France, il n'existait pas de parères des Chambres de commerce établissant les usages de commerce. Dans son avis sur le projet de loi, la Cour supérieure de justice a néanmoins cru utile de maintenir le texte proposé au double motif qu'au Luxembourg il n'existerait pas d'usages spéciaux propres aux sociétés commerciales et que, s'il en existait, les parties contractantes pourraient les repousser au moyen de leurs conventions[4].

SECTION IV
LA JURISPRUDENCE ET LA DOCTRINE

L'importance de ces deux éléments ne peut être surestimée. Elle peut être soulignée par la citation suivante : « *Toute œuvre législative, en elle-même, et par la force des choses ou plutôt par l'impuissance du langage humain n'est qu'un squelette qui ne prend corps et dont les formes ne se dessinent nettement que par le long travail de la doctrine et de la jurisprudence* »[5].

La jurisprudence joue un rôle des plus importants en droit des sociétés. En premier lieu, les juridictions **interprètent** la loi. Mais, au-delà de cette fonction, les juges ont une **fonction créatrice** à trois points de vue : « *Le juge précise et complète la loi ; il assure la cohérence de l'ordonnancement juridique en éliminant les antinomies ; il adapte le droit à l'évolution des faits* »[6].

SECTION V
LE DROIT INTERNATIONAL

Si le droit international ne se limite certainement pas au droit de l'Union européenne, il est vrai que celui-ci tend à prendre une part prépondérante (au moins du point de vue luxembourgeois) dans l'évolution de notre droit des sociétés.

---

1 – J. VAN RYN et J. HEENEN, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 34.

2 – Th. TILQUIN et V. SIMONART, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 187.

3 – E. ESCARRA et J. RAULT, *Principes de droit commercial*, p. 8.

4 – Projet de loi portant révision de la loi sur les sociétés commerciales, Avis de la Cour supérieure de justice, p. 33.

5 – A. NYSSENS, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 19, ID 11305.

6 – J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, *Droit civil. Introduction générale*, p. 195.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – Le droit européen

Le traité CE ne prévoit que quelques rares dispositions concernant le droit des sociétés proprement dit. Dans les années 1970 et 1980, certaines directives furent prises sur la base de la disposition de l'article 54 (3) (g) du traité de Rome (devenu article 44, 2, sous g après renumérotation) demandant l'harmonisation du droit des sociétés dans les différents États membres. Ce processus est plus ou moins arrêté aujourd'hui. Toutefois, le droit de l'Union européenne exerce une influence très significative sur le droit des sociétés luxembourgeois (comme sur celui des autres États membres), et ceci, par le biais de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, surtout au sujet des quatre libertés fondamentales. Il en sera question à différents endroits dans le présent ouvrage.

§ 2 – La Convention européenne des droits de l'homme

Les personnes morales (et donc les sociétés commerciales) peuvent bénéficier de certains droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme et qui ne sont pas propres aux personnes physiques, comme le respect de ses biens, la garantie d'un procès équitable, certains aspects de la protection de la vie privée. En outre, les relations entre associés peuvent être affectées par les règles dégagées par la CEDH. Les actions et parts de sociétés sont considérées comme biens au sens de l'article 1er du Protocole additionnel, de sorte que la législation nationale en matière de cession forcée doit s'y conformer(1). Certains droits de la personnalité peuvent être défendus en justice par la personne morale : ceci concerne sa réputation, son image de marque, le respect de son domicile(2).

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 171.

2 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 261.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

CHAPITRE II
LA HIÉRARCHIE DES NORMES EN DROIT COMMERCIAL

On a donc pu considérer que la hiérarchie des sources du droit commercial est la suivante :

1) les dispositions d'ordre public[1] de la loi civile ou commerciale ou parfois de certains usages de droit ;
2) les conventions des parties ou leurs usages conventionnels, à condition de ne pas être contraires aux dispositions d'ordre public visées au point précédent ;
3) les usages de droit ;
4) les dispositions interprétatives de la loi commerciale ;
5) les dispositions interprétatives de la loi civile[2].

La question de savoir s'il faut inclure dans ce relevé des sources de droit commercial les principes généraux du droit reste ouverte. Dans une affaire importante soumise au tribunal d'arrondissement dans son jugement du 8 juillet 2003[3], il s'agissait d'apprécier la régularité de l'opération réalisée entre le **groupe GBL** et **Bertelsmann** par laquelle il avait été convenu entre ces deux parties d'échanger la participation de 30 % détenue par GBL dans RTL contre une participation de 25,1 % dans Bertelsmann. De cette façon la participation de Bertelsmann dans RTL serait passée de 37 à 67 %. La question posée était de savoir si cette opération pouvait être sanctionnée par une règle de droit applicable au Luxembourg. Aucune disposition de droit positif n'oblige un actionnaire majoritaire à racheter les actions aux actionnaires minoritaires.

Les actionnaires minoritaires, demandeurs devant le tribunal, revendiquaient le droit de faire racheter leurs titres à des conditions identiques à celles qui avaient été convenues avec le groupe GBL, en faisant valoir qu'une telle obligation du traitement égalitaire aurait la portée d'un **principe général du droit**.

Ils se basaient ainsi sur certaines dispositions spécifiques de la L.S.C., notamment l'article 70, alinéa 2, l'article 67, alinéa 5, l'article 154 et les articles 264, litt. c), 279, litt. c), 292, litt. c) et 306 litt. c), toutes ces dispositions accordant certains droits aux actionnaires minoritaires.

En doctrine, on a défini la notion de principes généraux du droit comme « *un ensemble de principes directeurs (*Grundsätze*,* leading principles*) qui, sans avoir le caractère précis et concret des règles de droit positif, n'en servent pas moins d'orientation dans l'application et dans le développement de l'ordre juridique […]*

Quelques-uns de ces principes sont écrits, p. ex. dans la Constitution, dans la déclaration des droits ou dans les documents politiques (tels le principe de la souveraineté populaire, le principe de la démocratie parlementaire) […]

Mais la plupart des principes généraux ne représentent rien d'autre que des idées, c.-à-d. des convictions juridiques, politiques ou philosophiques qui servent d'orientation à l'activité des juristes tel p. ex le grand principe de l'autonomie de la volonté

1 – Il s'agit de « règles juridiques qui s'imposent pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives dans les rapports sociaux. Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public », v. *Lexique des termes juridiques*, Dalloz.

2 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 54.

3 – TA Lux. du 8 juillet 2003, *Audiolux e.a. c/ Groupe Bertelsmann et RTL Group*, ID 15681.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

privée […] tel encore le principe de légalité, c.-à-d. de l'idée de la soumission de l'État au droit, l'idée du Rechtsstaat »[1].

Si ces principes sont utiles à l'interprète dans la mesure où ils lui permettent d'assurer l'unité systématique du droit, ils trouvent leur limite dans leur caractère général, abstrait et vague, de sorte qu'il « *serait inapproprié d'y chercher des solutions toutes faites* »[2].

Le tribunal rejeta donc les prétentions des actionnaires minoritaires également sur la base d'une réponse ministérielle à une question parlementaire selon laquelle l'absence de mesures légales destinées aux actionnaires minoritaires serait un choix délibéré des milieux politiques et économiques pour donner au droit des sociétés luxembourgeois un caractère libéral et inciter ainsi des sociétés internationales à s'établir à Luxembourg[3].

SECTION I
OBLIGATIONS DE PUBLICATION DES COMMERÇANTS

Certaines obligations (dont le nombre est à vrai dire assez limité) pèsent sur les seuls commerçants. Il s'agit avant tout d'obligations d'information ayant trait au statut de commerçant. Il est satisfait à cette obligation par l'immatriculation au R.C.S. et par la publication du régime matrimonial. Cette obligation est prévue par l'article 13 de la Loi de 2002. Sont également à inscrire au registre de commerce et des sociétés, sous forme d'extraits :

1) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial d'un commerçant personne physique ;
2) la décision judiciaire irrévocable prévue à l'article 223 du Code civil interdisant à un époux le droit d'exercer un commerce ou une profession ou industrie de nature commerciale, ainsi que l'opposition faite par un époux conformément à l'article 223, alinéa 4, du Code civil et la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé.

Il est indispensable que « *les tiers soient renseignés sur la nature exacte de cet être exceptionnel au droit commun, sur ses ressources, sur l'identité de ceux qui se portent personnellement garants de ses engagements, sur la personnalité de ceux qui ont le droit d'agir en son nom et de le représenter légalement* »[4].

La publicité telle qu'elle existe actuellement est le résultat d'une évolution historique et dans laquelle interfèrent tant les aspects traditionnels luxembourgeois que les aspects de droit européen.

Le Code de commerce de 1808 n'organisait qu'une publicité assez rudimentaire : il y avait obligatoirement transcription du pacte social ou de son extrait dans un registre *ad hoc*, tenu au greffe du tribunal de commerce accompagné d'un **affichage pendant trois mois** dans la salle d'audience de ce même tribunal[5].

1 – P. Pescatore, *Introduction à la science du droit*, p. 119.

2 – P. Pescatore, *Introduction à la science du droit*, p. 120.

3 – TA Lux. du 8 juillet 2003, ID 15681.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 13, ID 11308.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 24, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

En Belgique, ce système fut modifié dès 1873 en exigeant la publication des actes (extraits d'acte) dans le journal officiel belge (le *Moniteur*).

Au Luxembourg, la publicité se fait par le biais du **R.C.S.** et du **RESA**[1].

La publication des actes de société est fondée sur une distinction entre la **publication intégrale** et la **publication par extrait**.

■ § 1 – Immatriculation au registre de commerce et des sociétés

L'expression même de registre de commerce et des sociétés (R.C.S.) est relativement récente dans la mesure où elle fut introduite seulement par la loi du 26 avril 1987. Depuis 1909, il existe au Luxembourg un « registre aux firmes » dans lequel tous les commerçants sont tenus de se faire inscrire.

En fait, la dénomination de registre de commerce et des sociétés est inappropriée dans la mesure où celui-ci ne se limite pas à recueillir les publications relatives aux seuls commerçants et aux seules sociétés, mais inclut encore d'autres entités qui n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre de ces catégories. Sont en effet tenus de s'inscrire au registre de commerce et des sociétés, notamment les associations sans but lucratif, les associations agricoles, les fondations, les G.I.E. (G.E.I.E.), les établissements publics de l'État et des communes.

Une association sans but lucratif ne peut avoir pour objet essentiel de procurer à ses membres un avantage patrimonial sous peine d'être considérée comme une **société déguisée**[2].

A – L'organisation du R.C.S.

Le R.C.S. a été fondamentalement réformé par la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que les comptes annuels et la comptabilité des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales. Cette loi a d'abord regroupé les registres de Diekirch et de Luxembourg en un seul registre situé à Luxembourg.

Le registre est public et fonctionne sous le contrôle du ministre de la Justice. La gestion en est confiée à un groupement d'intérêt économique (G.I.E.), regroupant l'État, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers.

B – Informations soumises à publicité

Les obligations de publication qui s'adressent aux **commerçants** (et donc également à toutes les sociétés commerciales) sont en fait et pour l'essentiel basées sur la Première directive 68/151/CEE du 9 mars 1968 : dans son article 2, cette directive demande la publication obligatoire « au moins » des documents suivants :

– l'acte constitutif ;

– les modifications de cet acte ;

1 – V. sous ce terme.

2 – Cass. du 19 janvier 1973, note J. van Ryn et J. Heenen, *R.C.J.B.,* 1974, p. 331.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– après chaque modification, le texte intégral de l'acte modifié dans sa version mise à jour ;
– la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice, ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;
– les comptes annuels ;
– le transfert du siège social ;
– la dissolution de la société ;
– la décision judiciaire prononçant la nullité de la société ;
– la nomination et l'identité des liquidateurs et leurs pouvoirs respectifs ;
– la clôture de la liquidation et la radiation du registre des États membres.

Sont tenus de s'immatriculer les commerçants et les sociétés commerciales. La réquisition du commerçant doit indiquer le nom, les prénoms, l'enseigne commerciale, l'adresse précise de l'établissement principal où s'exerce l'activité commerciale, l'objet du commerce tel qu'il figure sur l'autorisation d'établissement, la date de création du commerce, l'état civil du commerçant, sa nationalité, le cas échéant, le régime matrimonial, etc.

Pour les **sociétés commerciales,** les indications correspondantes sont les suivantes :

- la dénomination sociale (raison sociale), l'abréviation et l'enseigne commerciales ;
- la forme juridique ;
- l'adresse précise du siège social ;
- l'indication de l'objet social ;
- le montant du capital social ;
- les nom et prénoms, date et lieu de naissance des associés, leur adresse et le nombre des parts détenues par chacun (s'il s'agit de S.e.n.c., de S.e.c.s. et de S.à r.l.) ;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, la fonction et l'adresse professionnelle précise des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, la date de nomination et la date d'expiration de leur mandat ;
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse privée ou professionnelle précise du commissaire aux comptes ou du réviseur d'entreprises, la date de nomination et la date d'expiration du mandat ;
- la date de constitution de la société ainsi que sa durée.

Selon la Première directive, la publication des actes dont la publicité est requise se fait exclusivement par le dépôt de l'acte dans les dossiers de la société. Au Luxembourg, lors de la transposition de cette directive il a été considéré utile de maintenir en vigueur le système traditionnel de la publication au ***Mémorial,*** *Recueil des Sociétés et Associations* (aujourd'hui RESA).

Aux termes de la Première directive, le mode de publicité par le dépôt au R.C.S. était donc obligatoire pour le législateur national. Ceci explique également que, en cas de divergence entre les deux modes de publicité, la priorité soit accordée à celle faite au registre de commerce[1].

1 – J. Delvaux, *La société anonyme*, p. 111. ; A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, pp. 206 ss.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Selon l'article 19-3, alinéa 2 de la Loi de 2002, « *[e]n cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié au Recueil électronique des sociétés et associations, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé* ».

La publication des actes notariés incombe au notaire, alors que celle des actes sous seing privé doit être prise en charge par les parties elles-mêmes.

C – Dépôt des actes etc. à publier

Depuis la loi du 27 mai 2016 (et le règlement grand-ducal du même jour) portant introduction du Recueil électronique des sociétés et associations, (RESA) le système de publicité applicable aux actes de société, etc. a fondamentalement changé. Selon le dispositif introduit par lesdits textes, les actes, extraits d'acte ou indications dont la publication est obligatoire sont **dans le mois des actes définitifs** déposés par la voie électronique au R.C.S. Le gestionnaire du R.C.S. est tenu de procéder aux inscriptions imposées par la loi dans un délai de 3 jours ouvrables à compter du dépôt de la demande après avoir fait un contrôle légal sommaire de tous les documents déposés. La publication (au RESA) est faite dans les **15 jours du dépôt**. Un récépissé de dépôt est envoyé au déposant sous format électronique. Cette publication a lieu selon le cas en intégralité, par extrait, ou par mention du dépôt. Les documents déposés sont réunis en un dossier tenu pour chaque personne ou entité immatriculée. Les publications sont consultables au RESA par voie électronique.

D – Réquisition d'inscription

Le dépôt fait au R.C.S. doit être accompagné d'une réquisition d'inscription. Les réquisitions d'inscription prévues par la Loi de 2002 sont faites par le requérant (ou son mandataire) par le biais de **formulaires électroniques** fournis par le gestionnaire du R.C.S. sur son site Internet. Avant le dépôt des actes à faire publier ceux-ci doivent être enregistrés : les frais d'enregistrement sont collectés par le gestionnaire du R.C.S. auprès du requérant.

E – Opposabilité aux tiers

Les actes ou extraits d'actes qui font l'objet de la publicité obligatoire en vertu des dispositions de la loi ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur **publication au RESA**, sauf si la société prouve que les tiers en avaient antérieurement connaissance. Ces tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes non publiés.

En outre, ces tiers pendant un délai de quinze jours (avant le seizième jour qui suit celui de la publication) peuvent tenir ces actes comme leur étant non opposables à condition qu'ils prouvent avoir été « *dans l'impossibilité d'en avoir connaissance* ». Cette possibilité est assez restrictive dans la mesure où la charge de la preuve incombe au tiers et que ce tiers est donc tenu d'établir qu'il était dans « *l'impossibilité* » d'en avoir connaissance. S'il est difficile de savoir quel degré d'impossibilité la loi demande[1], il s'agit assurément d'une disposition rarement appliquée en pratique.

1 – Pour A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 208, il s'agirait d'un fait extérieur au tiers soit « quasiment un cas de force majeure ».

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

F – Accès aux informations

Au vœu de la Loi de 2002, toute personne (et pas seulement tout intéressé) peut gratuitement prendre connaissance des documents déposés et en obtenir copie intégrale ou partielle, étant entendu que, le cas échéant, il peut y avoir demande d'un paiement de frais administratifs fixés par règlement grand-ducal[1]. En fait, la plupart du temps, les personnes désireuses d'obtenir des informations ne vont pas s'adresser au R.C.S., mais vont les chercher dans le RESA.

En cas de divergence entre les informations déposées au R.C.S. et celles du RESA, les informations du R.C.S. priment. En effet, selon l'article 19-3 de la Loi de 2002, les actes (extraits d'acte) ne sont opposables aux tiers qu'à partir de leur publication au RESA, sauf si la société prouve que les tiers en avaient connaissance. À partir de la publication au RESA, les actes sont opposables, mais ceux faits avant le 16e jour ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'avoir connaissance du texte publié.

Avant l'acte	Dépôt acte	15 jours après publication	16 jours après publication
Non opposable aux tiers (sauf preuve par la société de la connaissance)	Opposabilité conditionnelle	Opposable (sauf preuve du tiers de l'impossibilité de la connaissance)	Opposabilité générale

■ § 2 – Sanctions en cas de non-immatriculation

Le Code de commerce de 1808 établissait une sanction unique : la **nullité** de la société constituée en l'absence d'écrit et la nullité de la société pour absence de publicité. Cette nullité pouvait être invoquée non seulement par les tiers, mais encore par les associés, sinon contre les tiers, au moins contre les autres associés[2]. Ce système était excessif en donnant une **prime** aux personnes de **mauvaise foi** en leur permettant de se prévaloir de leur propre faute vis-à-vis de leurs co-associés, pour se soustraire à l'exécution d'obligations librement contractées[3]. Comme on a pu le souligner, les associés ont (en principe) tous figuré à l'acte constitutif et connaissaient donc parfaitement les clauses du contrat : la publication était donc inutile à leur égard. L'utilité de cette publicité n'existe que pour les seuls tiers ; c'est donc à eux seuls qu'il faut accorder le droit de se plaindre[4].

Ce système du Code de commerce était à juste titre jugé trop sévère dans la mesure où il s'est avéré trop peu protecteur des intérêts des associés et, surtout, de ceux des tiers.

Les sanctions actuellement applicables sont de trois ordres : les amendes, l'irrecevabilité des actions en justice et l'inopposabilité aux tiers.

1 – Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003, ID 10216.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 27, ID 11308.

3 – Rapport de E. Pirmez, *Commentaire législatif de la loi de 1873*, II, n° 25.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 27, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

A – Amendes

L'article 21 (5) de la Loi de 2002 prévoit une amende de 251 à 5 000 euros en cas d'omission de l'immatriculation au R.C.S. Cette disposition est encore accompagnée d'une autre contenue à l'article 100-11 L.S.C. : « *Toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis *de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est non recevable* ».

B – Irrecevabilité des actions en justice

La L.S.C. contient une disposition importante relative à la recevabilité des actions en justice intentées par les sociétés commerciales ; en son article 100-11, il est disposé que « *[T]oute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis, *de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est non recevable* » (ci-après la **Loi de 2002**).

Cette disposition est complétée par l'article 22 de la Loi de 2002.

« *(1) Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action.*

De même est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique qui n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action.

Cette irrecevabilité est couverte si elle n'est pas proposée avant toute autre exception ou toute défense.

(2) Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu du paragraphe (1) qui précède interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance ».

En application du principe de la spécialité de la personne morale, la jurisprudence retient qu'il n'est pas satisfait à l'article 22 de la Loi de 2002 si la société est inscrite au R.C.S. (comme l'article 100-11 L.S.C. pourrait le laisser entendre), mais encore faut-il que **l'activité précise** qui donne lieu à litige soit couverte par cette inscription. Ce point a été notamment retenu par le jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans l'affaire *HELLAS*.

« Aux termes de l'article 22, paragraphe (1), de la Loi modifiée de 2002 "Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action. [...] Cette irrecevabilité est couverte si elle n'est pas proposée avant toute autre exception ou toute défense".

Ainsi, a-t-il été jugé que les dispositions relatives au registre de commerce font obligation aux commerçants non seulement de s'inscrire, mais d'inscrire toute activité commerciale qu'ils exercent et d'inscrire toute activité additionnelle qu'ils ajoutent à leur activité après la première inscription (Cour, 15 juillet 2010, n°s 34118 et 34925 du rôle).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'obligation d'inscription au registre de commerce et des sociétés, telle que sanctionnée par l'irrecevabilité de l'article 22 (1), vise partant plus particulièrement les informations et modifications affectant l'objet social de l'entreprise.

En effet, tirant argument du principe de la spécialité de la personnalité morale, la personne morale ne pouvant agir que dans le cadre strictement circonscrit de l'objet social pour lequel elle a été constituée, il a été décidé qu'il ne suffit pas que la personne morale soit inscrite au registre de commerce et des sociétés, mais qu'il faut que l'acte dont elle poursuit la sanction dans le cadre de son action en justice rentre dans son objet social tel que publié à ce registre. À défaut, cette action est déclarée irrecevable (cf. T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, éditions Bauler 2012, pages 488 et 489).

En l'occurrence, il n'est pas établi, ni même allégué que l'action en justice de HELLAS II se rapporte à une activité commerciale dépassant son objet social et pour laquelle elle n'aurait pas été immatriculée au registre de commerce et des sociétés.

HELLAS II fait en premier lieu valoir que les sociétés défenderesses seraient forcloses à soulever ce moyen qui n'aurait pas été soulevé in limine litis*.*

Une forclusion laisse d'être établie, alors que seules les conclusions notifiées en date du 21 novembre 2014 au nom des sociétés HELLAS et HELLAS I peuvent être prises en considération par le tribunal.

Or, dans le cadre de ces conclusions, ce moyen d'irrecevabilité a bien été soulevé après la présentation des faits, mais avant toute défense au fond, partant in limine litis.

Or, il est de jurisprudence constante que l'irrecevabilité prévue par l'article 22 (1) de la Loi modifiée de 2002 constitue une ***fin de non-recevoir générale de l'action*** ; *elle n'est pas conditionnée par l'existence d'un grief dans le chef de la partie qui l'invoque (cf. Cass., 22 décembre 2011, pourvoi n° 72/11, n° 2885 du registre)[…]* »[(1)].

C – Inopposabilité aux tiers

La troisième et principale sanction est celle de l'inopposabilité aux tiers de l'acte de société non publié.

En vertu de l'article 100-13 (4) L.S.C., l'inobservation des formalités de publicité prescrites par la loi a pour conséquence de rendre non opposables aux tiers les clauses de l'acte de société. Par la suite, lorsque la gestion a été confiée par les statuts à un seul associé, elle appartient au regard des tiers à tous les associés, de telle sorte que les actes faits par chacun d'eux peuvent obliger la société. Pour que la société en nom collectif soit obligée envers les tiers, il faut, en règle générale, que l'acte dont doit résulter l'obligation ait été fait par un gérant dans les limites de ses pouvoirs et pour le compte de la société. Les gérants dont le mandat n'a été ni défini ni publié ont le pouvoir général d'administrer, c'est-à-dire de faire en principe tous les actes nécessaires à la réalisation du but de la société. Par suite, lorsqu'un gérant, agissant pour le compte de la société, a posé un acte dommageable qui se rattache par un lien de connexité aux opérations sociales, la responsabilité civile de la société se trouve engagée.

Étant donné que la sanction de l'inobservation des formalités de publicité prescrites par la loi est l'inopposabilité aux tiers, cette non-publication peut avoir pour

1 – TA Lux. du 12 décembre 2013, n° 145724 du rôle.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conséquence que les règles de représentation de la société soient tout autres que celles que les associés avaient l'intention de faire appliquer.

Contrairement à la solution retenue par le Code de commerce de 1808, les associés ne peuvent se prévaloir ni contre les tiers ni entre eux du défaut de publicité légale. Les associés ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions de l'acte ; en outre, ces mêmes associés ne peuvent se prévaloir du défaut de publicité à leur égard.

Les tiers disposent donc d'une **option** consistant pour eux soit à admettre, soit à rejeter à leur gré l'acte de société[1]. S'ils l'admettent, ils se trouvent exactement dans la même situation que s'il y avait eu publication.

La dissolution d'une société anonyme avant terme équivalant à une modification du pacte social, la décision de dissolution doit être constatée, à peine de nullité, par un acte authentique.

Entre associés, la nullité n'opère cependant qu'à dater de la demande tendant à la faire prononcer en justice[2].

« *D'après l'article 9 de la L.S.C. concernant les sociétés commerciales, la publication des actes de société a uniquement pour but de permettre aux tiers, qui traitent ou qui veulent traiter avec une société commerciale, de vérifier les statuts de celle-ci, de se renseigner sur son capital social et sur les pouvoirs donnés aux gérants. On ne saurait conclure de ce texte que tout Luxembourgeois est censé, par la seule publication de l'acte de société au* Mémorial*, connaître l'existence de la société* »[3].

Une SA avait assigné des particuliers en paiement, lesquels soulevèrent *in limine litis* que la société ne saurait agir en justice, étant alors dépourvue de conseil d'administration :

« *Une société commerciale a le droit d'ester en justice. Seulement, pour pouvoir exercer ses droits, elle doit avoir recours à des intermédiaires physiques qui lui servent d'organes. Il faut donc admettre qu'une société ne peut faire aucun acte juridique autrement que par ses représentants légaux. L'article 50 de la L.S.C. concernant les sociétés commerciales prévoit que les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps. Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Aux termes de l'article 11*bis *de la prédite loi, l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des administrateurs, gérants ou commissaires des sociétés anonymes doit être déposé et publié. L'article 9, paragraphe 4, dispose que les actes ou extraits d'actes ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication au* Mémorial*. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir des actes ou extraits d'actes non encore publiés. Il ressort de ces dispositions qu'aussi longtemps que les publications prescrites par la loi n'ont pas été faites, les tiers ont le droit, sans avoir à justifier d'un intérêt légitime, de considérer la nomination de l'administrateur comme non avenue à leur égard et par conséquent de dénier à celui-ci tous pouvoirs pour engager l'être moral (Frédéricq, Droit commercial, Tome IV, n° 159). Il ressort en l'espèce des pièces versées en cause que les administrateurs et commissaires de la partie demanderesse reçurent mandat de*

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 31, ID 11308.

2 – TA Lux. du 14 juillet 1956, *P.*, n° 18, p. 567, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA du 3 février 1970, *P.*, n° 21, p. 280, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

gérer la société [...] jusqu'à la date de l'assemblée générale de l'année 1985 [...] Aucune pièce établissant la nomination de nouveaux administrateurs et aucune publication de cette mesure n'est versée en cause, de sorte qu'il faut admettre que la société [...] n'a plus d'administrateurs à partir d(e) [...] 1986. Elle est donc incapable d'ester en justice. Comme la capacité d'ester en justice s'apprécie au moment de l'introduction de la demande en justice, des mesures postérieures tendant à régulariser une situation irrégulière sont inopérantes et ne sauraient avoir pour effet de combler un vide ayant existé au moment de l'assignation »[1].

La démission d'un administrateur qui n'a pas été portée à la connaissance des tiers conformément aux dispositions de l'article 9 L.S.C. est inopposable aux tiers et partant au ministère public (requérant en l'espèce l'application de la disposition pénale figurant à l'article 1630).

Il ne suffit pas d'être l'administrateur-délégué ou le directeur d'une société pour se voir *ipso facto* déclarer pénalement responsable des manquements commis par la société : le juge doit en outre vérifier si l'agent était, de fait, tenu d'accomplir lui-même l'obligation légale qui fait l'objet de la prévention. Il doit déterminer parmi les personnes concernées le responsable, c'est-à-dire la personne qui, dans la réalité des choses, est cause de l'état infractionnel. Il est constant en cause que A a non seulement démissionné en date du 15 juin 1994 de ses fonctions d'administrateur, mais qu'en plus une autre personne du nom de B a été appelée à sa place aux fonctions d'administrateur par décision de l'assemblée générale du 22 juin 1994. Même si cette décision n'a pas été portée à la connaissance des tiers par sa publication au *Mémorial* et qu'elle leur demeurait dès lors inopposable, il n'en reste pas moins que A n'était plus à partir de cette date tenue au sein de la société de veiller à ce que les comptes annuels de la société soient soumis à l'assemblée générale et déposés au R.C.S. dans le mois[2].

Le défaut de publication de l'acte constitutif d'une société commerciale peut être opposé par les tiers comme fin de non-recevoir à toute action intentée par la société, sans qu'ils aient à justifier d'un intérêt à s'en prévaloir. La non-opposabilité aux tiers de l'acte constitutif non publié exige, au contraire, dans le chef de celui qui l'invoque, l'existence d'un intérêt juridique et légitime[3].

L'exception de non-publication de l'acte constitutif de société ne peut être invoquée par le tiers que dans un intérêt légitime. Dans le cas d'espèce, cette condition était jugée non remplie pour la raison qu'elle était invoquée afin d'échapper à l'obligation de devoir restituer les lieux par l'occupant[4].

Elle doit encore être opposée *in limine litis*[5].

Est irrecevable l'action directe portée devant le tribunal correctionnel par une société commerciale à laquelle le prévenu oppose la fin de non-recevoir tirée du

1 – TA Lux. du 17 janvier 1990, n° 3827, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 6 novembre 2001, n° 375/01, *BIJ*, 2003, p. 45.

3 – TA Lux. du 7 juillet 1933, *P.*, n° 13, p. 61, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 27 février 1948, *P.*, n° 14, p. 386, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – TA Lux. du 27 février 1948, P., n° 14, p. 386, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

défaut de publication de l'acte constitutif de la société. Par conséquent, cette action n'a pu mettre en mouvement l'action publique, qui n'est pas recevable non plus[1].

Dans un cas d'espèce, il y avait assignation à la suite du refus d'une inscription au R.C.S. du transfert du siège social de deux sociétés. Cette inscription a été refusée par le préposé au motif que le transfert desdits sièges sociaux n'aurait pas été acté dans la forme légale prescrite, le transfert du siège constituant selon le préposé une modification statutaire qui ne peut être faite que sous la même forme que celle de l'acte constitutif. D'après les sociétés requérantes, le transfert du siège social ne constituerait pas en l'espèce une modification statutaire, les actes constitutifs des deux sociétés prévoyant que le siège social qui est à Luxembourg pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration. Selon l'article 4 L.S.C. (nouv. art. 100-4), les sociétés anonymes sont formées par des actes notariés spéciaux. L'article 11 (nouv. art. 100-12) de la même loi spécifie que toute modification conventionnelle aux actes de sociétés doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise par l'acte de société. Les requérantes soutiennent que le transfert du siège social ne constituerait pas en l'espèce une modification conventionnelle telle que prévue par l'article 11, alors que les modalités de transfert du siège social seraient prévues par l'acte de constitution même de la société. Tout en étant prévu par les statuts originaires des deux sociétés, le transfert du siège social n'en constitue pas moins une modification conventionnelle des statuts, alors que le siège social des deux sociétés est fixé par les statuts à Luxembourg et que la réquisition tend à son transfert à Esch-sur-Alzette. Cette modification n'ayant pas été actée dans les formes prescrites par l'article 4 précité, il n'y a pas lieu à inscription de la réquisition présentée[2].

Le siège social joue pour les sociétés commerciales le même rôle que le domicile pour les personnes physiques[3]. Pour l'application des diverses dispositions légales qui se réfèrent à la notion, il faut avoir égard au siège réel (au lieu où se concentre effectivement la conduite des affaires sociales). Cette notion correspond en général à l'indication des statuts, mais tel n'est pas toujours le cas[4].

Conformément à cette approche, le Tribunal de Bruxelles refusait de conclure à la nullité d'un exploit de citation que le demandeur avait signifié non pas au siège social statutaire situé à Anvers mais à Bruxelles où se prenaient en fait toutes les décisions essentielles et déterminantes de la vie de la société[5].

§ 3 – Mode de publication

On distingue la publication intégrale de la publication par extrait.

1 – TA Lux. du 7 juillet 1933, P., n° 13, p. 61, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 21 mai 1986, n° 6.295, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – J. VAN RYN, *Principes de droit commercial*, T. 1, 1re éd., n° 374.

4 – P. VAN OMMESLAGHE et X. DIEUX, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 670.

5 – Trib. com. Bruxelles du 9 janvier 1985, *J.T.*, 1985, p. 166.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 100-4 L.S.C.

« Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à responsabilité simplifiées sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés civiles, les sociétés coopératives, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale.

Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux ».

A – Publication intégrale

Aux termes de l'article 100-10 (anc. art. 8 L.S.C.), alinéa 1er, « *[l]es actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés* ».

Concernant ces mandats, la jurisprudence retient qu'il ne suffit pas que la validité d'un acte soit subordonnée à son authenticité pour que le mandat de faire cet acte doive être également authentique. Il est généralement admis que l'authenticité du mandat n'est point exigée dans des cas tels que celui d'une constitution de société anonyme, où l'authenticité de l'acte lui-même n'est exclusivement destinée qu'à donner à cet acte une certaine publicité et à sauvegarder non tant l'intérêt des contractants eux-mêmes que celui des tiers ; aucun texte de loi ne prescrit que les procurations en cette matière soient données dans la forme notariée, et ce serait ajouter à l'article 40 du Code de commerce en subordonnant la validité de la société à l'existence de procurations authentiques[1].

B – Publication par extrait

La publication par extrait suffit à l'égard des sociétés civiles de **type familial** (art. 100-10 L.S.C.). L'extrait doit être signé par les gérants ou, à leur défaut, par tous les associés, et contiendra :

- la désignation précise des associés ;
- la dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ;
- la désignation des gérants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ;
- le montant du capital social et l'indication des valeurs fournies ou à fournir en commandite, avec désignation de la qualité sociale en laquelle elles ont été

1 – TA Lux. du 3 décembre 1902, *P.*, n° 6, p. 223. Trib. Lux. du 10 mai 1913, *P.*, n° 9, p. 221. Ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

fournies ou promises ; la loi demande donc d'indiquer les apports fournis et à fournir, donc la partie acquittée et celle restant à verser.

La même possibilité de la publication par extrait est prévue par l'article 100-7 L.S.C. à l'égard des **sociétés en nom collectif,** des **sociétés en commandite simple** et des **sociétés en commandite spéciale**.

« *Les actes de société en nom collectif et de société en commandite simple sont publiés, par extraits, aux frais de la société* ».

Par la nature des choses, les indications que l'extrait doit détenir sont quelque peu différentes. Il s'agit de :

– la désignation précise des associés solidaires ;
– la dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ;
– la désignation des gérants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ;
– le montant du capital social et l'indication des valeurs fournies ou à fournir en commandite, avec désignation de la qualité sociale en laquelle elles ont été fournies ou promises ; la loi demande donc d'indiquer les apports fournis et à fournir, donc la partie acquittée et celle restant à verser ;
– la désignation précise des commanditaires qui doivent fournir des valeurs, avec l'indication des obligations de chacun ;

La loi demande simplement « l'indication » des valeurs à fournir par les commanditaires, et non le montant de leurs apports. Si donc des apports en nature sont faits, l'extrait ne devra fournir qu'une description sommaire[1]. Il est encore nécessaire d'insister sur le fait que la loi exige l'indication en quelle qualité (commandité ou commanditaire) l'apport est fait. S'il est fait par le commanditaire dont il constitue l'unique participation aux engagements sociaux, alors il augmente d'autant le gage des créanciers sociaux. À l'inverse, s'il est fait par les commandités, déjà responsables sur tous leurs biens, alors l'accroissement du capital n'ajoute rien à la garantie des tiers[1].

– l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir ;
– l'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par le notaire dépositaire des minutes et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires (art. 100-9 L.S.C., anc. art. 7 L.S.C.).

C – Moyen de publication

Au Luxembourg, les dispositions de la Première directive en matière de droit des sociétés ont été transposées par un **système double** obligeant le commerçant ou la société commerciale à procéder au **dépôt des documents à publier** au registre de commerce (R.C.S.) et la **publication** au *Mémorial* C (*Recueil Spécial des Sociétés et Associations*) (aujourd'hui RESA). Ce système a été changé et modernisé par étapes qu'il est inutile de relater en détail. Il suffira ici de décrire ce système tel qu'il fonctionne actuellement (début 2019).

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 17, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Depuis la suppression du R.C.S. de Diekirch par la Loi de 2002, il n'existe plus que le R.C.S de Luxembourg qui concentre donc en un endroit toutes les données concernant les commerçants et les sociétés commerciales luxembourgeois (entre autres). Cette concentration en un endroit constitue une simplification appréciable.

Cette matière est régie par « *la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels de l'entreprise* », loi que, par convention de langage, nous désignons par la « Loi de 2002 ». Le chapitre V*bis* de cette loi intitulé « Des publications au *Recueil électronique des sociétés et associations* », **RESA** sous sa forme abrégée (art. 19-1 à 19-4), ordonne que les actes, extraits d'actes, etc. dont la loi prescrit la publication soient « *dans le mois des actes définitifs déposés par la voie électronique au R.C.S.* ». Le dépôt auprès du R.C.S. a donc été maintenu, mais il se fait par la voie électronique.

La publication au RESA se fait dans les **quinze jours du dépôt**, exception faite des convocations aux assemblées générales pour lesquelles le requérant doit indiquer les dates auxquelles la publication doit être faite (art. 19-2 (2) de la Loi de 2002).

L'article 19-3 de la Loi de 2002 dispose que les actes et extraits d'actes ne sont **opposables aux tiers** qu'à partir de leur publication au RESA, « *sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes ou extraits d'actes non encore publiés. Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ou extraits d'actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance* ».

Le règlement grand-ducal du 23 janvier 2003[1] complète ces indications. Les dépôts auprès du gestionnaire du R.C.S. « sont effectués par la voie électronique par le biais de son site internet ». « *On entend par "voie électronique" : une information envoyée à l'origine et reçue à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques* ».

Un récépissé de dépôt est envoyé au déposant sous la forme électronique.

« Art. 10.
Pour chaque personne ou entité nouvellement immatriculée, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne.
Le dossier de la personne immatriculée peut être tenu partiellement ou intégralement, sous format électronique, par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut décider, de sa propre initiative, d'abandonner de manière définitive le classement des documents déposés sur support papier dans le dossier des personnes immatriculées, en le remplaçant par un classement par ordre chronologique ».

1 – ID 10216.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 11.

Les dossiers individuels sont répartis en sections comme suit :

« – la section A reçoit les dossiers des commerçants individuels

– la section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales et des associations d'assurances mutuelles.

– la section C reçoit les dossiers des groupements d'intérêt économique

– la section D reçoit les dossiers des groupements européens d'intérêt économique

– la section E reçoit les dossiers des sociétés civiles ;

– la section F reçoit les dossiers des associations sans but lucratif

– la section G reçoit les dossiers des fondations ;

– la section H reçoit les dossiers des associations agricoles ;

– la section I reçoit les dossiers des associations d'épargne-pension ;

– la section J reçoit les dossiers des établissements publics.

– la section K reçoit les dossiers des fonds communs de placement.

– la section L reçoit les dossiers des fonds d'investissement alternatifs réservés [...] ».

En application de l'article 6 de la Loi de 2002, toute société commerciale est tenue de requérir son immatriculation. La loi indique ensuite les données que celle-ci doit comprendre, notamment : dénomination sociale, forme juridique, adresse précise du siège social, montant du capital social.

Chaque commerçant personne physique et chaque personne morale se voit attribuer un numéro d'immatriculation unique.

D – Publication par voie électronique

La directive 2003/58/CE modifie la Première directive 68/151/CEE imposant le dépôt d'informations par voie électronique et leur consultation à distance.

Les objectifs de la directive sont résumés comme suit par le projet de loi visé :

– permettre aux usagers de déposer par voie électronique tous les actes et indications soumis à publicité par la directive 68/151/CEE.

– numériser tous les documents et indications déposés au R.C.S. depuis le 1er janvier 2007.

– numériser à la demande des usagers au moins les documents déposés depuis le 1er janvier 1997.

– permettre aux usagers d'obtenir une copie de ce document par voie électronique.

– certifier les copies électroniques au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/903/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.

Dans le cadre de la réalisation du projet eRCS, il est depuis le 1er mars 2007 possible de consulter via internet les documents déposés au RCS de même que d'obtenir par ce biais un extrait de RCS des inscriptions au format électronique(1).

Dans la deuxième phase de ce projet, le dépôt par voie électronique sera rendu possible. Tracer le cadre juridique de ce dépôt était précisément l'objet du projet

1 – Règl. gr.-d. du 25 février 2007, ID 9605.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de loi n° 5716 adopté par la loi du 20 avril 2009[1] qui a transposé les dispositions de cette directive en droit national.

■ § 4 – Inopposabilité aux tiers de l'irrégularité de la nomination des organes

Aux termes de l'article 100-16 L.S.C. initialement introduit en droit luxembourgeois par la loi du 23 novembre 1972 transposant la Deuxième directive CEE : « *Les sociétés agissent par leurs gérants ou administrateurs dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l'acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif.*

L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager les sociétés, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance ».

En disposant que les sociétés agissent par leurs gérants et administrateurs, la loi dit que « *vis-à-vis des tiers les gérants sont plus que des mandataires mais leurs organes directs et légaux, la manifestation physique, l'émanation apparente et concrète, de sorte que lorsqu'ils agissent en cette qualité, ils n'apparaissent pas seulement comme agissant au nom de la société ; c'est la société elle-même qui agit par eux* »[2]. Contrairement à un simple mandataire de la société, ils ne sont donc pas obligés de produire un mandat s'ils veulent signer un acte pour la société, mais il leur suffira d'une simple copie du procès-verbal de l'assemblée qui les a nommés. Il est vrai qu'à divers endroits la loi se réfère aux administrateurs/gérants comme mandataires de la société. L'explication de cette contradiction apparente est la suivante : « *Mais si, vis-à-vis des tiers les gérants et administrateurs de la société s'identifient ainsi avec l'être moral à qui ils servent d'organes, ils reprennent, dans leurs rapports avec la société qui les nomme, la qualité de mandataires, ainsi que le prouvent les termes dont se servent dans cet ordre d'idées divers articles ultérieurs, et c'est par conséquent d'après les principes du mandat que se règle, à ce second point de vue, leur qualité juridique* »[3].

Avant l'introduction de cette disposition en 1972, une société pouvait en principe opposer aux tiers la nullité de la nomination pour cause de nomination irrégulière de ses organes et elle pouvait faire valoir qu'elle n'était pas engagée par les actes accomplis en son nom par ses organes. Il est vrai que cette règle était fortement atténuée par la **théorie de l'apparence**, selon laquelle la société était liée par rapport aux tiers de bonne foi lorsque la nomination avait une apparence de régularité et si la **légitime confiance** des tiers avait été trompée[4].

La question s'est posée de savoir si l'on peut appliquer la théorie du mandat apparent en matière de représentation de la société. La réponse est en principe négative pour la raison que, si la société a rempli toutes les exigences relatives à la publicité lui imposées, le tiers doit vérifier si la personne qui agit est l'organe légal et est légalement habilitée à représenter la société[5].

---

1 – ID 10553.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 42, ID 11308.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 42, ID 11308.

4 – M. van der Haegen et C. Verbraeken, « L'adaptation de la législation belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.*, 1974, p. 130.

5 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 219.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Néanmoins, la nouvelle disposition légale modifie la charge de la preuve. Autrefois, le tiers, tout en étant présumé de bonne foi, devait prouver l'apparence de régularité de la nomination et la légitimité de son erreur. Maintenant, il appartient à la société de prouver que le **tiers avait connaissance** de l'irrégularité[1]. Il reste encore à noter que, selon le libellé de la loi, cette réglementation ne s'applique **qu'aux organes de la société,** et non aux préposés, fondés de pouvoir et autres mandataires.

En cas de non-publication des nominations des organes de la société, la nomination n'est pas opposable aux tiers et ceux-ci peuvent la considérer comme non avenue[2].

La question laissée en suspens par ce texte est la suivante : les tiers ayant traité avec la société par le biais d'un organe irrégulièrement nommé peuvent-ils opposer cette irrégularité à la société ? La problématique est identique à celle relative aux conséquences du dépassement de l'objet social de la société et la jurisprudence y répond de la même façon[3]. De même que les tiers ne peuvent se prévaloir du dépassement de l'objet social à l'égard de la société, ils ne peuvent opposer la nomination irrégulière de l'organe à la société. Cette solution doit être approuvée[4].

La différence entre la situation de dépassement de l'objet social et celle de la nomination irrégulière des organes réside (du moins au Luxembourg) dans leur champ d'application. Les règles sur la nomination des organes s'appliquent à toutes les sociétés commerciales, alors que celles concernant l'objet social ne concernent que les sociétés visées par la Première directive, donc les « sociétés de capitaux » (dans notre terminologie).

SECTION II
OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERÇANTS

Le Code de commerce de 1808 ne consacrait que quelques **dispositions très lapidaires** à la tenue de la comptabilité (art. 8 et suivants). Ces règles ne s'adressaient d'ailleurs pas seulement aux sociétés, mais à tous les commerçants. Elles ne faisaient pas de distinction non plus selon que la société était à responsabilité limitée ou non. En outre, ces règles très rudimentaires n'étaient même pas respectées en pratique[5]. La L.S.C. consacrait à ce sujet l'article 461-1 L.S.C. qui retenait que, chaque année, l'administration doit dresser un inventaire. La seule et unique règle d'évaluation était que « *[…] les amortissements nécessaires doivent être faits* ».

Pendant un siècle et demi, cette matière n'a guère connu de progrès (au Luxembourg du moins). Ce n'est qu'avec le processus d'harmonisation du droit des sociétés sur un plan communautaire, puis de l'Union européenne, que cette réglementation a finalement connu un développement proprement phénoménal. En effet, depuis les années 1985, tous les commerçants sont tenus d'établir leurs comptes annuels (bilan et comptes de

1 – M. VAN DER HAEGEN et C. VERBRAEKEN, « L'adaptation de la législation belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.*, 1974, p. 130.

2 – Lux. du 17 janvier 1990, n° 38.274, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA Mons du 18 mars 1981, *Pas.*, 1981, II, p. 82.

4 – En ce sens, v. aussi P. VAN OMMESLAGHE et X. DIEUX, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 646.

5 – J. VAN RYN et J. HEENEN, *Principes de droit commercial*, 2e éd., T. 1, p. 83.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

profits et pertes) selon des schémas déterminés, d'adopter un plan comptable déterminé, d'appliquer des règles d'évaluation précises et de faire contrôler ces comptes par un réviseur d'entreprises externe, à condition de dépasser certains seuils d'importance.

Pour plus de détails, le lecteur est renvoyé au chapitre consacré à ce sujet, voir p. 377.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

2

PARTIE II – DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Dans cette partie sera abordé le droit commun des sociétés, à savoir les caractéristiques communes à tous les types de sociétés. Seront donc traités les éléments communs de l'acte de société, soit, selon l'enseignement traditionnel, les associés, les apports, l'*affectio societatis*, etc.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE I
NOTION DE SOCIÉTÉ

La notion de société a de tout temps donné lieu à des difficultés de qualification, difficultés qui sont loin d'être totalement éliminées de nos jours. Nous allons donc, dans une première étape, essayer de clarifier cette notion. Le Code de commerce de 1808 ne contenait pas de définition des sociétés commerciales. Cette lacune fut comblée par la doctrine et la jurisprudence.

CHAPITRE I
LES DIFFÉRENTES CONCEPTIONS DE LA SOCIÉTÉ

La notion de société a évolué au cours des deux siècles passés. Dans le Code civil (art. 1832), dans sa version de 1804, la partie consacrée aux sociétés figurait dans la partie III entre le contrat de louage et le contrat de prêt : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter *ou, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d'une personne qui affecte des biens à l'exercice d'une activité déterminée* »[1].

Dans la définition du Code civil, la société supposait un partage de bénéfices. Dans nos pays voisins, cette définition a évolué dans le sens de l'élargissement : le partage des bénéfices n'est plus la caractéristique indispensable du contrat de société. En France, dès 1978, a été ajoutée « ***la recherche d'économies*** »[2].

Les associations d'assurances mutuelles ne sont pas des sociétés pour la raison qu'elles n'ont pas pour objet le partage des bénéfices. Chaque membre est en même temps assureur et assuré : le but est de répartir entre les assureurs les pertes que les assurés éprouvent par un accident quelconque, l'incendie, la grêle, les épizooties ; l'assuré étant aussi assureur supporte une part dans la perte, part diminuée par le concours des autres membres. Le but et l'effet de la convention est de diminuer la perte éventuelle que peuvent faire les associés. « *Donc il n'y a jamais de bénéfices à partager entre les membres de ces associations, partant il n'y a pas de société* »[3].

Ce qu'il faut entendre par ce terme de partage de bénéfices a encore été sujet à controverse (voir section suivante).

En plus du partage des bénéfices, le contrat de société devrait prévoir un partage des **pertes**. L'article 1855 C.c. prévoit la nullité de la société qui exclut un associé du partage des pertes. Pour Pothier, une telle exclusion pouvait être stipulée. En effet,

1 – Le bout de phrase souligné a été ajouté par la loi du 28 décembre 1992 qui a transposé la directive 89/667/CEE en droit luxembourgeois.

2 – Amendement effectué par la loi du 4 janvier 1978.

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 148.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

même s'il est vrai que les associés ne s'associent pas pour faire des pertes, il n'en reste pas moins que de telles pertes sont toujours possibles et que le contrat de société doit donc prévoir des dispositions également sur le partage des pertes tout autant qu'il en contient à l'égard du partage des bénéfices. La définition donnée par le Code civil est donc incomplète[1].

SECTION I
CONCEPTION DE LA NOTION DE BÉNÉFICE

Dans le sens étroit, il s'agit d'un profit pécuniaire qui **accroît la fortune** des associés. Cette conception correspond à la notion de bénéfice patrimonial direct[2]. Elle s'oppose à celle proposée par J. Van Ryn qui définit le bénéfice comme « *tous avantages matériels de nature patrimoniale* »[3]. Cette dernière approche (qui se fonde sur le droit comptable dans la mesure où, en comptabilité, il n'importe pas qu'un résultat positif soit dégagé par une augmentation des recettes ou encore par une diminution des charges) inclut donc le bénéfice patrimonial indirect et peut notamment consister en une économie de frais. En dépensant moins, on accroît le patrimoine tout autant que si on augmente les revenus : ceci constitue une autre manière de s'enrichir[2].

Cette évolution consistant à élargir la notion de bénéfice n'a pas été suivie au Luxembourg. Ceci est d'ailleurs regrettable pour la raison que l'extension effectuée en France par le législateur de 1978 est fort justifiée : dans le monde des affaires, faire des économies contribue autant à la maximisation des résultats que la recherche d'un bénéfice prévue par la définition de 1804. Les licenciements massifs auxquels procèdent régulièrement les grands groupes internationaux n'ont pas d'autre fin que celle d'augmenter les bénéfices ; en tant que tels, ils sont d'ailleurs fort appréciés par les opérateurs boursiers.

En 1914, la Cour de cassation française, dans l'affaire ***Caisse rurale de Manigod***[4], avait encore arrêté qu'une coopérative de crédit prêtant à des taux de faveur à ses membres serait à considérer comme une association, et non comme une société. La Cour de cassation avait retenu que le bénéfice est « *un gain pécuniaire ou un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés* » ; en obtenant des prêts à des conditions avantageuses, les membres de la coopérative n'augmenteraient pas leurs revenus, mais diminueraient simplement leurs charges. La situation aurait été différente si la Caisse avait distribué les excédents sous forme de dividendes[5].

En France, cette conception étroite fut définitivement abandonnée en 1978 du fait que la loi a retenu qu'une société, en dehors du but de réaliser des bénéfices au sens étroit, pouvait également avoir comme seul objectif de profiter de l'économie résultant de leur activité.

---

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 156

2 – M. Coipel, « La société dans tous ses états », *Le droit des sociétés. Aspects pratiques et conseils des notaires*, p. 64.

3 – J. van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. I, 1954, n° 327.

4 – D.P., 1914, I, p. 257, note L.S.

5 – M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 7.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION II
CONCEPTION CONTRACTUELLE OU INSTITUTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ

La définition de la société connut une seconde extension qui, cette fois-ci, fut également suivie au Luxembourg : il s'agit de celle qui consiste à admettre la société unipersonnelle, donc la société n'ayant qu'un seul associé.

Ce changement est tout simplement la consécration de la pratique telle qu'elle s'est développée pendant les années suivant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, on s'est rendu compte du fait que beaucoup de sociétés fonctionnent en réalité comme s'il n'y avait qu'un associé unique, « associé » qui détient tous les titres de la société à l'exception du minimum qui doit être détenu par les autres associés pour satisfaire aux exigences légales (p. ex., une action détenue pour un deuxième associé ou encore six actions en possession de six associés différents).

Dans une première étape, le législateur luxembourgeois a tenu compte de cette évolution en diminuant le nombre minimum des associés d'une société anonyme de sept à deux. Mais l'évolution ne s'est pas arrêtée à cet endroit : en effet, le législateur a d'abord reconnu qu'une société anonyme n'est pas nécessairement dissoute du fait que le nombre d'actionnaires est réduit à un seul (voir article 101, alinéa 1, L.S.C., selon la version introduite par la loi du 24 avril 1983).

D'autre part, et de façon plus significative encore, le législateur a permis la création d'une société à responsabilité limitée n'ayant dès le départ qu'un seul associé. Cette possibilité d'avoir une société unipersonnelle a d'ailleurs été étendue aux sociétés anonymes, et ceci, par la loi du 25 août 2006. Ces innovations législatives ont nécessairement conduit à **l'abandon de la théorie du contrat,** en tout cas comme base unique de la société, dans la mesure où, depuis l'introduction de la société unipersonnelle, elle peut être simplement une technique d'affectation du patrimoine (d'une partie du patrimoine) à une personne morale. « *C'est l'idée du patrimoine d'affectation enfin traduite dans notre droit* »[1].

Lorsqu'on fait abstraction de ce cas de la société unipersonnelle, la question est la suivante : la société est-elle un **contrat** ou une **institution** ?

On sait que le Code civil a dès 1804 qualifié la société de contrat. Cette conception a dominé au XIXe siècle et au début du XXe siècle[2]. La situation actuelle est bien reflétée par la constatation suivante de la Cour de justice de l'Union européenne : « *dans certains ordres juridiques les rapports entre une société anonyme et ses membres sont qualifiés de contractuels et, dans d'autres, ils reçoivent la qualification d'institutionnels, de normatifs ou de* sui generis »[3].

■ § 1 – Conception contractuelle de la société

La théorie contractuelle a prévalu au XIXe siècle. Selon cette conception, le droit civil domine le droit des sociétés, y compris celui de la société anonyme. Toutefois, la société n'est pas un contrat comme les autres, de façon donc que les associés ne se trouvent pas dans la même situation que les contractants ordinaires.

1 – M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 5.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 95.

3 – CJUE du 22 mars 1992,, n° 214/89, ID 15897.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

A – Limites de la conception contractuelle

« *La règle de l'autonomie de la volonté n'est point complètement abolie, mais elle va subir des restrictions de plus en plus sévères [...] La notion du contrat est demeurée très vivace dans cette catégorie de sociétés qu'on dénomme sociétés de personnes et qui comprend la société en nom collectif et la société en commandite simple [...] il en est tout autrement dans les sociétés de capitaux. Sans doute, elles aussi tirent leur origine d'un contrat. Mais, dès sa formation même, ce contrat obéit à des règles particulières. L'importance des capitaux engagés dans l'entreprise, l'existence d'un grand nombre de contractants ont conduit le législateur soucieux de protéger l'épargne, à restreindre singulièrement le domaine de l'autonomie de la volonté. Telle est la raison d'être des nombreuses dispositions impératives qui régissent la constitution des sociétés par actions [...]*

La société devient, avant tout, une entité économique à tel point que certains ne veulent y voir, à tort d'ailleurs, qu'un patrimoine d'affectation. La vie du groupement est soumise à la loi de la majorité et, dans la société anonyme, qui est la forme type des sociétés de capitaux, cette majorité est quasi omnipotente. En présence de cette décadence de la notion de contrat, certains auteurs n'ont pas hésité à conclure que la société de capitaux constituait une institution véritable. La personne morale s'est hypertrophiée au point d'effacer jusqu'au souvenir du contrat »[(1)].

La conception contractuelle de la société s'est toujours heurtée à des problèmes pour expliquer certains aspects de son fonctionnement. En effet, comment pouvait-on expliquer qu'un contrat conclu par tous les associés puisse être modifié à la majorité de ceux-ci contre la volonté des associés minoritaires ? « *Dire que ces associés ont accepté par avance de s'incliner (sans dire sur quoi), en signant les statuts, paraît quelque peu artificiel, comme un contrat qui renoncerait à sa propre identité. En effet, les associés s'engagent à subir des modifications dont ils ne peuvent à l'avance connaître la teneur. Et l'individualisme, si marquant dans le droit des contrats, doit s'incliner devant l'impératif collectif, caractéristique du droit des sociétés. Toutefois le droit positif semble s'accommoder de ces difficultés en distinguant le contrat de base, nécessairement unanime, et ses évolutions, dont seules celles qui augmentent les engagements des associés restent inopposables à ceux qui ne les ont pas acceptées* »[(2)].

Comment expliquer la personnalité morale ou encore la limitation de la responsabilité des associés à l'égard des tiers ? Comment expliquer la notion d'**intérêt de la société** distinct de l'intérêt des associés ? Comment peut-on expliquer la volonté d'assurer la **pérennité de l'entreprise** au-delà de la mort des associés[(3)-(4)]? En matière de droit des sociétés, la théorie contractuelle doit accepter que le contrat qui est à la base d'une personne morale est fortement influencé par la loi qui prévoit une organisation rendue largement obligatoire, ce qui réduit d'autant la liberté contractuelle[(2)].

Par ailleurs, d'un point de vue purement juridique, on a fait valoir que le contrat de société, lorsqu'il est à l'origine d'une société ayant personnalité morale, n'est ni

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 4.

2 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 66.

3 – M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 5.

4 – V. Simonart, « La contractualisation des sociétés ou les aménagements contractuels des mécanismes sociétaires », *R.P.S.,* 1995, p. 96.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

synallagmatique (pas de réciprocité des obligations) ni unilatéral (tous les associés s'engagent)[1].

Depuis l'introduction de la société unipersonnelle, il est clair que cette conception n'a qu'une valeur explicative partielle. En effet, la société unipersonnelle est étrangère à toute idée de contrat. Mais, déjà avant cette modification législative, cette conception était contestée dans la mesure où l'on considérait que la notion d'acte unilatéral individuel ou collectif ne correspondait pas davantage à la réalité : en effet, « *l'acte unilatéral se distingue du contrat en ce qu'il poursuit un intérêt unique là où le contrat se caractérise par une opposition d'intérêts. L'acte unilatéral collectif se définit comme l'acte émanant de deux ou plusieurs participants dont les volontés conjointes poursuivent un même but : tel est bien le cas en matière de société, puisque les associés poursuivent tous un même but, à savoir partager les bénéfices ou profiter des économies qui peuvent en résulter* »[2].

Malgré ces limites, la théorie contractuelle ne doit pas être écartée, même si cette théorie, pas plus que les autres d'ailleurs, ne prétend pas tout expliquer et reconnaît l'existence de mécanismes originaux créés par le législateur en marge du droit des obligations, tels que la personnalité morale, la théorie de l'organe ou encore la limitation de la responsabilité des associés[3]. La Loi de Modernisation (notamment dans des documents parlementaires) a d'ailleurs expressément insisté sur le poids de la conception contractuelle de la société en droit luxembourgeois.

B – Conséquences de la théorie contractuelle

En principe, un contrat de société ne peut être modifié qu'à l'unanimité. Face aux difficultés consistant à expliquer pourquoi le contrat de société pouvait en fait être modifié par décision majoritaire, il avait été invoqué que « *les associés minoritaires ont consenti lors de la fondation de la société, à abdiquer devant la majorité et elle limite cette présomption aux clauses non essentielles du contrat* »[4].

La dissolution anticipée du contrat de société requiert le consentement de tous les associés.

Les membres des organes de la société sont des mandataires.

L'exclusion d'un associé coïncide avec la résolution du contrat synallagmatique de société à son égard.

Même habilitée à changer le contrat de société, la majorité ne peut changer ses **éléments essentiels.** Une telle modification ne peut être effectuée qu'à l'unanimité et entraîne une novation qui se traduit par une discontinuité entre la société initiale et la nouvelle société[5]-[6].

---

1 – R. Libchaber, « La société, contrat spécial », *Dialogues avec Michel Jeantin. Prospectives du droit économique*, Paris, Dalloz, 1999, pp. 281 ss., cité par P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 66.

2 – M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 4, qui se réfèrent à G. Wicker, *Rép. dr. civ.* (Dalloz), V° Personne morale.

3 – V. Simonart, « La contractualisation des sociétés ou les aménagements contractuels des mécanismes sociétaires », *R.P.S.,* 1995, p. 97.

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. IV, p. 61 ; pour la critique de cette présomption, v. G. Ripert, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, Paris, LGDJ, 1946, p. 91.

5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 100.

6 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 45.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La théorie contractuelle se trouvait mise à mal par le fait qu'elle n'était pas à même d'expliquer les éléments suivants :

– la personnalité morale de la société ;
– la responsabilité limitée des associés dans leurs relations avec des tiers, l'artifice consistant à recourir à la volonté présumée des parties pour expliquer la possibilité de modifier les statuts à la majorité a été considéré comme peu convaincant ;
– la distinction de plus en plus nette entre l'intérêt de la société et l'intérêt de la majorité des associés ;
– l'apparition de la société unipersonnelle(1).

On a donc assisté à un glissement de plus en plus net vers la conception institutionnelle de la société.

§ 2 – Conception institutionnelle de la société

Cette conception s'est donc développée en réaction contre la conception contractuelle de la société. Elle s'est développée en France, surtout à la fin du XIXe siècle, essentiellement sous l'influence de Thaller(2). Sous cette conception on a pu définir l'institution comme « *un groupement humain organisé de façon durable pour la réalisation d'une idée* ».

Cette définition montre que le facteur **organisation** est essentiel. Ce caractère justifie la loi de la majorité et la structuration du pouvoir sur différents organes dans la société (gestion, représentation, contrôle) et son caractère durable : l'institution doit échapper à l'arbitraire de ses maîtres(3).

« *Elle définit la société comme un organisme permanent, réuni autour d'une idée-mère, qui tend à la personnalité morale et qui repose sur le principe d'autorité, essentiel pour le maintenir dans la ligne de l'idée-mère.*

Elle postule l'existence de règles d'organisation non écrites, par essence impératives ou d'ordre public, comme la hiérarchie des divers organes sociaux, la séparation des pouvoirs, la cessibilité des actions, le droit de rester actionnaire, le droit de vote [...]

Elle analyse l'acte constitutif de la société, non plus comme un contrat, mais comme un faisceau de déclarations unilatérales de volontés tendant vers un but unique, parfois qualifié comme un acte collectif, ou un acte-règle, soit un acte qui établit une situation juridique générale, abstraite et permanente.

Elle invite à interpréter les règles relatives au fonctionnement de la société, leur portée et leurs effets en fonction du contenu et du but de l'institution, et non sur la base d'une recherche de l'intention subjective des parties.

Cette théorie repose en réalité sur un postulat : la prévalence de l'idée-mère et l'assujettissement au principe d'autorité, et revêt ainsi un caractère essentiellement tautologique dans son rôle explicatif et descriptif »(4).

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 102.

2 – E. Thaller, *Traité théorique et pratique de droit commercial*, n° 248.

3 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 68.

4 – V. Simonart, « La contractualisation des sociétés ou les aménagements contractuels des mécanismes sociétaires », R.P.S., 1995, p. 98.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le droit des sociétés commerciales oscille entre le pôle contractuel et le pôle institutionnel[1]. Si, à son origine, au moment de sa constitution, la société est un contrat, ceci ne doit pas faire perdre de vue que la société est une institution permanente, « *dont la fonction est de réaliser l'activité collective en vue de laquelle les associés se sont groupés avec l'intention d'en partager les bénéfices* »[1].

En définitive on peut retenir qu'à la naissance de la société il y a sans aucun doute possible une déclaration de volonté des associés (ou de l'associé), qu'on la qualifie de contrat ou d'acte unilatéral collectif (ou individuel). De ce contrat naît une organisation dotée de la personnalité morale.

Cette théorie trouve son origine dans les atteintes irrémédiables portées à la conception contractuelle par le législateur à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle[2]. La théorie institutionnelle découle de la « *dissociation de la condition d'associés [entre les épargnants et les gestionnaires], l'émergence de l'être collectif et la découverte de l'entreprise* »[3]. La notion d'institution désigne « *un ensemble de règles légales ou extra- légales, auxquelles se soumettent les personnes dont l'activité se déroule dans un secteur déterminé ou dans une société* » ou encore « *une organisation permanente qui s'oriente vers l'individualité vivante et tend à la personnalité morale ou un organisme social dans lequel ceux qui détiennent le pouvoir se soumettent à l'idée qui anime l'entreprise* »[4]. Quelle que soit la définition retenue, « *pour interpréter la portée et les effets, il faut recourir, non pas à la recherche d'une intention subjective comme dans les contrats, mais à l'analyse du donné social, économique ou historique, de l'origine et du but de l'institution, ce qui explique le développement des règles non écrites fondées sur ce "donné"* »[5].

Cette conception a quelques conséquences qui sont de grande importance. « *Dans la conception institutionnelle, la répartition des pouvoirs au sein de la société et la hiérarchie des organes sociaux revêtent un caractère impératif, voire d'ordre public, et il n'est pas permis à l'assemblée ou à des tiers de donner des directives au conseil d'administration, car le conflit entre l'administration et l'assemblée doit se résoudre [...] par le jeu normal du mécanisme institutionnel de la société* »[6].

La jurisprudence française a retenu que l'exclusion d'un associé dans le but d'assurer la pérennité de la société est conforme à « l*a notion institutionnelle de la société qui veut qu'une société ne soit pas qu'un contrat abandonné en tant que tel à la volonté de ceux qui lui ont donné naissance, mais plutôt une institution, c'est-à-dire un corps social dépassant les volontés individuelles* »[7].

Un des aspects de la théorie institutionnelle est que la fictivité de la société et, en particulier, de la société de capitaux est écartée. « *L'institution qu'est la société dure. Elle est appelée à fonctionner. Ses structures subsistent même si les hommes changent. Le consentement permanent des associés n'est pas indispensable à son existence. Elle conserve son identité et échappe à la volonté de*

1 – J. Van Ryn, Principes de droit commercial, T. 1, p. 205.
2 – Th. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, T. 1, p. 103.
3 – Th. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, T. 1, p. 104.
4 – Th. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, T. 1, p. 105.
5 – Th. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, T. 1, p. 141.
6 – Th. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, T. 1, p. 18.
7 – CA Reims du 24 avril 1989, Gaz. Pal., II, somm. 431, note P. de Fontbressin.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ses fondateurs malgré les vices qui peuvent affecter sa constitution. La société poursuit une finalité propre et se détache du concours des volontés individuelles dont elle procède »[1].

■ § 3 – Conception mixte en droit positif luxembourgeois

Le **législateur** luxembourgeois, pas plus que son homologue français, n'a jamais clairement pris position en faveur de l'une ou l'autre de ces deux conceptions[2]. La définition française de la société donnée par l'article 1832 C.c. (français) reflète bien cette neutralité dans la mesure où celle-ci se réfère aux deux théories à la fois : « la société est *instituée par un contrat* ». Cette approche lui assure effectivement la flexibilité optimale sans être emprisonnée par une certaine théorie.

De son côté, la jurisprudence fait tour à tour référence à l'une ou l'autre théorie. « *Bien que, dans la conception ancienne qui reste celle du code civil, la société soit un contrat, il ne saurait être contesté qu'elle constitue bien plus qu'un contrat, une institution dont la constitution, le fonctionnement sont réglés dans tous les systèmes juridiques par des dispositions légales non seulement dans le domaine propre du système législatif de droit interne auquel la société appartient, mais encore dans celui du droit international privé*[3] ».

L'enjeu de cette discussion n'est pas seulement de nature théorique, pour ne pas dire académique. En effet, selon qu'on privilégie l'une ou l'autre théorie, on accorde une place plus ou moins grande à **l'autonomie de la volonté,** à la liberté contractuelle. Il s'agit donc d'un choix fondamental en quelque sorte de nature philosophique conduisant soit à accorder une place importante à la liberté contractuelle (conception contractuelle), soit en revanche à ne lui accorder qu'une place fort réduite (conception institutionnelle)[4].

On a pu dire que « [*L]a société anonyme est un contrat qui donne naissance à une institution permanente, puisque la société constituera, pendant toute sa durée, un être juridique distinct. Les statuts de cette société présentent donc un caractère hybride : convention de société entre les fondateurs et, en même temps, charte fondamentale de l'institution qu'ils ont créée* »[5].

Dans les sociétés de personnes (parfois qualifiées comme n'ayant qu'une personnalité morale incomplète), la société n'est que partiellement une entité juridique distincte des associés. Le contrat l'emporte sur l'institution[6]. En revanche, dans les sociétés à personnalité complète, en particulier dans les sociétés anonymes, c'est la notion d'institution qui domine.

On peut encore retenir que schématiquement les mécanismes contractuels sont d'application dans la sphère interne de la société, alors que les mécanismes institutionnels sont principalement d'application dans les relations externes[7].

---

1 – Cass. b. du 1er juin 1979, note F. t'Kint, *R.C.J.B.,* 1981, p. 63.

2 – La même remarque a pu être faite pour la France où l'on se réfère à la neutralité du législateur (P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 70).

3 – CA Paris du 26 mars 1966, *Gaz. Pal.,* 1966, I, p. 400.

4 – A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 18.

5 – Cass. b. du 5 juin 1947, *R.C.J.B.,* 5 juin 1947, note J. van Ryn, p. 15.

6 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 257.

7 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 246.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Quelle que soit l'approche adoptée, dans tous les cas de figure la limite à la liberté de la volonté privée est constituée par l'ordre public. Les conventions privées devront en tout état de cause s'effacer devant les dispositions d'ordre public. C'est précisément à cet endroit que se montre la véritable différence entre les deux conceptions. Selon que l'on adopte l'une ou l'autre, le domaine de l'ordre public sera plus ou moins étendu.

SECTION III
LA THÉORIE FONCTIONNELLE

Cette théorie repose sur une analyse de la fonction de la société au regard du droit de l'entreprise. « *La personnalité morale n'a plus pour substrat le groupement, mais l'entreprise, et la société n'est qu'une technique juridique d'organisation de l'entreprise, résumant l'ensemble des règles juridiques, des techniques et des mécanismes destinés à permettre l'organisation juridique et la vie d'une forme de production ou de distribution, d'un organisme économique : l'entreprise* »[1]. La théorie fonctionnelle « *déplace ainsi le débat des partisans du contrat et des partisans de l'institution sur un autre terrain (puisqu') elle admet la validité de l'analyse institutionnelle pour l'explication de certains mécanismes sociétaires tels que la fonction de direction sociale, sans pour autant rejeter totalement les explications fondées sur les mécanismes contractuels qui trouvent leur place dans une structure juridique complexe* »[1].

La théorie fonctionnelle définit la société comme une **technique d'organisation** des structures du capital et du pouvoir de l'entreprise[2].

La théorie visée se contente pour l'essentiel de constater la substitution progressive de l'entreprise au groupement des personnes associées comme objet de l'organisation réalisée par le droit des sociétés et la **substitution progressive du législateur aux associés** pour organiser la société. Une organisation d'origine légale a été peu à peu substituée à une organisation d'origine contractuelle[1].

SECTION IV
LA THÉORIE STRUCTURELLE

La société est analysée à la fois comme relevant d'un contrat et d'une institution. La doctrine a constaté qu'en opposant l'institution au contrat, il arrive « *un moment où les rapports entre les hommes deviennent trop nombreux, trop complexes et trop variés pour qu'ils puissent être créés ou transmis par le simple jeu de l'échange contractuel des volontés individuelles. Le législateur met alors à la disposition des hommes les mécanismes juridiques utiles à leurs transactions* »[3].

La société peut être définie comme une structure *sui generis*. Elle constitue ainsi « *un tout formé de phénomènes solidaires, tels que chacun dépend des autres* »[4].

« *L'analyse de la société en une structure n'est pas liée à une abstraction à partir du patrimoine ou à la réification des relations entre associés ou actionnaires,*

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 114.

2 – V. Simonart, « La contractualisation des sociétés ou les aménagements contractuels des mécanismes sociétaires », *R.P.S.,* 1995, p. 100.

3 – G. Ripert, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, p. 106.

4 – Dictionnaire *Le Robert*.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

sur laquelle reposait l'analyse institutionnelle. Elle vise toutes les formes de sociétés, même unipersonnelles ou sans personnalité : leur structure conserve sa fonction d'équilibre statique et dynamique, en particulier entre les intérêts internes et externes »[1].

La théorie structurelle « *considère la société comme une structure sui generis ayant recours aux techniques contractuelles et institutionnelles, ces dernières étant considérées comme des mécanismes originaux créés par le législateur en marge du droit des obligations, et un lieu d'équilibre des intérêts homogènes et hétérogènes gravitant autour du concept d'intérêt social.*

Elle rejette le présupposé de l'existence de règles non écrites d'ordre public découlant de la théorie institutionnelle et n'admet plus à ce degré que les règles édictées comme telles par le législateur, essentiellement dans un souci de sécurité juridique et de protection des tiers »[2].

Pour certains auteurs, seule cette théorie structurelle, dans la mesure où elle reconnaît tant le rôle des mécanismes du droit des obligations que l'existence de mécanismes originaux créés par le législateur, paraît satisfaisante[3].

SECTION V
AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ

Quelle que soit la position que l'on adopte dans ces querelles théoriques, il est indéniable que la société est en principe un contrat (du moins, un tel contrat en fait-il toujours partie, si l'on fait abstraction du cas de la société unipersonnelle). Il reste à préciser les caractéristiques de ce contrat.

■ § 1 – Contrat consensuel

Un contrat de ce type se forme par le seul consentement des parties, alors que les **contrats solennels** ne sont parfaits qu'une fois accomplies les formalités généralement protectrices de la volonté des parties[4]. Si l'article 1834 C.c. exige un acte écrit lorsque l'objet de la société est de plus de 3,75 euros, cette exigence concerne uniquement le régime de preuve[2].

La L.S.C., dans son article 4 (nouv. art. 100-4), connaît une disposition plus exigeante dans le sens que le contrat de société écrit (selon le cas sous forme authentique ou sous seing privé) est exigé « *à peine de nullité* ». « *D'après le droit commun, la méconnaissance de cette règle essentielle entraînerait l'inexistence du contrat. Celui-ci ne serait pas susceptible de ratification ou de confirmation. La nullité pourrait être invoquée par quiconque y a intérêt. Ses effets se produiraient* ex nunc*. Elle opérerait de plein droit. L'acte ne pourrait être validé par aucune prescription. […] La nullité de l'article 4 déroge, du moins sur la plupart des points, à la rigueur de ces principes. Elle doit être demandée. Elle n'est pas opposable aux tiers. Entre associés, elle n'opère qu'à dater de la demande tendant à la*

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 136.

2 – V. Simonart, « La contractualisation des sociétés ou les aménagements contractuels des mécanismes sociétaires », *R.P.S.,* 1995, p. 101.

3 – V. Simonart, « La contractualisation des sociétés ou les aménagements contractuels des mécanismes sociétaires », *R.P.S.,* 1995, p. 102.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés,* T. 1, p. 335.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

faire prononcer. C'est ce qui détermine la doctrine à lui reconnaître une nature complexe sui generis *et à la qualifier parfois de nullité relative* »[1].

Le caractère tout à fait spécifique de cette **nullité** explique que la société de fait est reconnue, donc l'existence d'une société en dehors de tout contrat écrit[2].

Pour la doctrine, le contrat de société occupe une place intermédiaire entre le contrat consensuel et le contrat solennel[2].

Cette question rejoint celle de la valeur juridique de la **promesse de société** par laquelle les parties s'engagent réciproquement à constituer une société. En principe, le mode de preuve d'une promesse de contrat est identique à celui applicable au contrat lui-même. En toute logique, il faudrait en conclure que la promesse de contrat portant sur une société commerciale devrait être donnée par écrit, alors que celle portant sur une société civile pourrait être apportée par les autres moyens de preuve admis en droit civil[2].

Le contrat de **promesse de constituer une société anonyme** est valable à condition que les éléments essentiels de la société à constituer y soient déterminés avec suffisamment de précision[3]. En revanche, si les parties ne s'expriment pas avec suffisamment de précision sur la société à constituer, la convention de promesse de société est nulle faute d'objet[4].

Lors de la formulation d'une promesse de société à l'occasion de la constitution d'une société anonyme par acte authentique suivant le mode prévu à l'article 28 de la L.S.C.,

« *[...] étant donné l'objet spécial d'une pareille promesse, qui n'équivaut nullement à la constitution même de la société, le promettant qui ne remplit pas ses engagements, ne saurait y être contraint, et, comme la loi sur le régime des sociétés ne reconnaît pas ces promesses, mais réserve plutôt aux intéressés leur liberté d'action jusqu'à la constitution définitive, la renonciation doit entrer dans les prévisions des contractants et la faculté de donner suite au projet de société est implicitement réservée dans ces promesses* »[5].

Cette position de la jurisprudence n'est pas à l'abri de la critique, dans la mesure où l'on peut valablement soutenir que, sur la base des règles générales applicables en matière de conventions, il est difficile de dénier toute validité à une telle promesse de société : en effet, une telle promesse contient tous les éléments nécessaires à la validité des conventions[6]. Une telle promesse est valable et obligatoire pour autant qu'elle contienne tous les éléments essentiels du contrat de société, notamment donc l'objet social, apports, répartition des résultats. Son inexécution se résout en dommage-intérêts[7].

---

1 – *R.P.D.B.,* T. 12, V° Sociétés, p. 190.

2 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 159.

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. IV, n° 315. ; J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », R.C.J.B., 1967, p. 296.

4 – Cour Bruxelles du 24 décembre 1962, *R.P.S.,* 1964, p. 156.

5 – CA du 11 décembre 1928, P., n° 11, p. 375, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC) ; L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 159.

6 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 161 qui se réfère à Resteau, 2e éd., n° 447.

7 – R.P.D.B., T. 12, V° Sociétés, p. 155.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Sur ce point, le droit belge a connu une évolution différente du droit luxembourgeois. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995, l'acquisition de la personnalité morale est subordonnée au dépôt de l'acte constitutif : depuis lors, la société est sans aucun doute un **contrat solennel**. Le législateur luxembourgeois n'a pas suivi cette voie, de sorte qu'une société constitue toujours un contrat consensuel. « *Si les parties se sont exprimées par référence expresse à la loi sur le type de société qu'elles entendaient créer, il n'y aura guère de difficultés sauf la nécessité éventuellement de redresser les qualifications inexactes. Le contrat peut avoir été conclu par écrit aussi bien qu'oralement. Le contrat de société n'est en effet pas solennel* »[1].

Signalons toutefois que, même avant 1995, une partie de la doctrine belge avait considéré que la société est un acte solennel[2].

■ § 2 – Contrat commutatif

Un contrat commutatif est un contrat comportant une certaine équivalence entre les prestations réciproques des parties. Par opposition, le contrat aléatoire se caractérise par le fait que les parties ont les unes contre les autres des chances de gain ou de perte qui dépendent de la réalisation d'un événement incertain[3]. « *Le contrat de société revêt en principe un caractère commutatif car l'engagement de chaque associé vis-à-vis des autres est considéré comme l'équivalent de ce qui est donné ou fait en sa faveur et ne dépend d'aucun aléa* »[5].

Mais les frontières sont mouvantes : un contrat de société peut être aléatoire si tout l'actif est attribué au survivant des associés[5]. Tel est le cas du **contrat de tontine**. Par contrat de tontine, on entend la convention par laquelle tous les avoirs des prémourants profitent aux survivants. Le caractère de société de ce genre de convention a été mis en doute. « *Les tontines ne produisent ni mouvement, ni capital, ni industrie ; la somme des capitaux reste toujours la même ; les produits considérés en bloc restent invariables ; la répartition seule est soumise à des variations qu'amène la chance du décès ; il ne se fait aucun bénéfice par le travail, il ne peut donc y avoir aucun partage de bénéfices. C'est un contrat aléatoire* »[4].

La société est un contrat (ou, le cas échéant, un acte unilatéral) que certains qualifient à caractère aléatoire[5], et ceci, pour la raison que, si l'associé au moment de son entrée dans la société sait quelle somme il investit dans la société, il n'est en rien assuré quant aux revenus qu'il touchera en retour. Ces revenus consisteront en distributions courantes de bénéfices ainsi que, au terme de la vie de la société, en une distribution du produit de liquidation : ce produit peut être largement supérieur aux sommes investies. Souvent, hélas, la liquidation est une liquidation forcée qui survient dans le cadre de la faillite de la société. Dans un tel cas de figure, il est à peu près certain que les associés ne toucheront rien dans le cadre de cette liquidation. Dans les sociétés de personnes, les associés indéfiniment responsables seront au contraire encore appelés à désintéresser les créanciers de la société qui sont restés impayés.

---

1 – P. Van Ommeslaghe, « Les sociétés de fait », *J.T.,* 1957, p. 710.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 336 et les multiples renvois à la doctrine y faits, notamment à Resteau,T. 1, p. 182.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 337.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 149.

5 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 131.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 3 – Contrat synallagmatique

Le contrat de société est un contrat synallagmatique dans le sens que ce contrat suppose des prestations réciproques. La conséquence de cette caractéristique est que la non-exécution de son obligation par l'une des parties permet à l'autre partie de suspendre l'exécution de sa propre obligation (*exceptio non adimpleti contractus*)[1]. Alternativement, elle peut poursuivre la résolution judiciaire du contrat en application de l'article 1184 C.c.

La théorie des risques s'applique à ce contrat dans le sens que, si un associé n'est pas en mesure, pour cas de force majeure, d'exécuter son obligation, l'autre partie sera libérée de son obligation (*res perit debitori*). En revanche, si l'obligation porte sur **une chose déterminée**, le créancier de cette obligation sera considéré comme propriétaire du bien dès la conclusion du contrat, même si le bien n'a pas encore été matériellement livré (*res perit domino*, art. 1302 C.c.)[2].

Le contrat de société est particulier du fait que l'obligation de chaque associé est identique à celle des autres. Dans les autres contrats synallagmatiques, les parties sont mises en opposition de sorte que l'obligation de l'une est fortement différente de l'autre.

« *Le contrat de société diffère du contrat de vente. Dans la vente, chacune des parties stipule dans son intérêt, et il est permis à l'une de s'avantager au détriment de l'autre. Il n'en est pas ainsi dans la société, ce contrat a pour but l'égalité entre associés, l'attribution des bénéfices est proportionnelle à l'importance de la mise ; si donc un associé fait une mise moindre que celle qu'il a promise, le principe de l'égalité serait violé si le bénéfice était calculé à raison de l'apport nominal. C'est en ce sens que l'article 1845 dit que chaque associé est débiteur de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Il doit donc tout son apport, sinon il y a indemnité. Et s'il y a excédent, le principe de l'égalité demande que les associés lui en tiennent compte* »[3].

§ 4 – Contrat pluripartite

Un contrat pluripartite est un contrat par lequel plus de deux parties poursuivent ensemble la réalisation d'un but commun. Une des caractéristiques essentielles de cette catégorie de contrats est l'intérêt commun particulièrement fort qui les anime. Sans être mentionnée par le Code civil, cette catégorie de contrats est autorisée par celui-ci même si la plupart des dispositions consacrées « *aux "contrats et obligations conventionnelles en général" sont manifestement conçues pour deux parties* »[4].

La question essentielle qui se pose à l'égard de cette catégorie de contrats est de savoir si le contrat peut ou non se former en cas de défaut ou de vice de l'un des consentements exprimés. Est-ce que chaque partie qui exprime son consentement ne le donne que sous la condition de l'acceptation par toutes les autres personnes ou est-ce que chaque partie a entendu donner un consentement séparé et individuel ?[5]. Avec la doctrine, il faut admettre que la deuxième alternative doit s'imposer : une fois le minimum d'adhérents atteint, il est sans importance que certains se rétractent ou disparaissent par la suite ; le contrat est valablement formé[2]. Il peut en

1 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés. Précis*, p. 297.

2 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés. Précis*, p. 298.

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 261.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 307.

5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 314.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

aller différemment dans le cas où la prestation d'une partie est essentielle pour la réalisation de l'objet du contrat pluripartite (p. ex., détention d'un brevet nécessaire à la réalisation du projet), la défaillance de cette partie entraîne la dissolution du contrat dans son ensemble[1].

■ § 5 – Contrat à objet civil ou commercial ?

Les sociétés ont nécessairement un caractère lucratif, et ceci, contrairement aux associations qui, elles, sont limitées aux activités bénévoles. Cette contrainte est imposée par la loi.

A – Le principe de spécialité des sociétés

En outre, il existe des limitations qui sont prévues simplement par les statuts de la société : il s'agit de **l'objet social** de la société, expression par laquelle on entend la désignation de l'activité précise de la société telle que définie par les statuts. En général, ces statuts définissent de façon très large l'objet de la société. Cette approche n'est pourtant pas sans risques.

La définition d'un **objet étroit** comporte un intérêt certain dans la mesure où les associés disposent ici d'un moyen efficace pour limiter les pouvoirs des organes sociaux : traditionnellement, la société n'était en effet pas engagée par les actes posés en dehors de l'objet social (même si, de nos jours, ce point est moins évident, et ceci, sous l'impulsion du droit de l'Union européenne).

Les activités commerciales ne peuvent valablement être exercées que par les sociétés commerciales. Telle est la raison d'être de cette catégorie de sociétés. Les activités de nature civile sont en principe exercées par les sociétés civiles (même si, de nos jours, tel est loin d'être toujours le cas), celles visées par les articles 1832 et suivants C.c.

Cette séparation, qui, en principe, est assez stricte, n'empêche pas que les sociétés à objet civil puissent exercer leur activité sous la forme d'une société commerciale : « *Mais, dans ce cas, ces sociétés, ainsi que les opérations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et aux usages de commerce* »[2].

À cet égard, la situation en droit belge est traditionnellement très différente de celle prévalant en droit luxembourgeois. « *[…] ce serait vouloir l'impossible que de convenir qu'une société qui, par sa nature, est civile sera une société commerciale. En effet, la loi définit les sociétés de commerce ; et la loi définit aussi quels actes sont des actes de commerce. Dire que les parties peuvent déclarer commerciale une société qui a pour objet des actes civils, ce serait dire qu'il dépend d'elles de changer la nature légale des actes, de sorte qu'un acte civil deviendrait un acte de commerce ; ce serait faire la loi puisqu'il en résulterait qu'il y a d'autres actes de commerce que ceux auxquels la loi donne cette qualification* »[3].

Dans la pratique luxembourgeoise, cette hypothèse est fréquemment réalisée : de nombreuses activités de profession libérale, souvent pour des raisons de

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 325.

2 – Art. 100-3, 3e alinéa, 2e phrase (anc. art. 3, 3e alinéa, 2e phrase), L.S.C., ID 7520.

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 233.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

responsabilité professionnelle, sont exercées dans le cadre de sociétés de capitaux : tel est notamment le cas des fiduciaires, des experts-comptables et fiscaux, des bureaux de réviseurs d'entreprises, des architectes, des ingénieurs et des consultants de tout ordre.

La loi est muette sur l'hypothèse inverse, celle où une activité dont l'objet est commercial serait exercée sous une société civile. Cette possibilité doit donc être considérée comme exclue.

La question de savoir si une société à objet civil pouvait prendre les formes d'une société commerciale était très controversée lors de l'élaboration de la Loi de 1915. La question était rendue compliquée par le fait que la position de la jurisprudence au regard de la personnalité morale était diamétralement opposée dans nos deux pays voisins que sont la Belgique et la France. En Belgique, la personnalité morale était traditionnellement refusée aux sociétés civiles : la crainte était donc que certaines activités civiles seraient exercées dans le cadre de sociétés commerciales justement pour pouvoir bénéficier de la personnalité morale dont le bénéfice était refusé en cas de constitution d'une société civile. Telle n'était pourtant pas la position des juridictions françaises, ni celle des juridictions luxembourgeoises (qui suivaient la jurisprudence française)[1].

Par conséquent, lorsqu'une société civile demandait à pouvoir emprunter la forme de la société anonyme (du temps où la constitution de telle société était encore subordonnée à une autorisation gouvernementale), celle-ci était régulièrement accordée, et ceci, tant en France qu'au Luxembourg[2].

En Belgique, cette question était traitée de façon très différente, et certains projets économiques de grande envergure échouèrent précisément à cause de cette impossibilité pour une société à objet civil d'adopter cette forme anonyme. Tel a notamment été le cas d'un projet visant à produire dans la région de Bruxelles des légumes pour le marché de Londres[3].

Sur ce point, notre droit des sociétés a toujours été en décalage par rapport au droit belge. En droit belge, la personnalité civile a été constamment refusée aux sociétés civiles, alors qu'au Luxembourg, dans la ligne de la jurisprudence française, celle-ci était reconnue aux sociétés civiles de droit luxembourgeois. Si une certaine activité de nature civile (p. ex. agricole) voulait donc bénéficier de la personnalité morale, elle cherchait à se placer sous le droit commercial en créant ainsi une société commerciale. Ceci était toutefois refusé jusqu'à ce qu'une loi du 14 juin 1927 permette aux activités civiles d'emprunter la forme des sociétés commerciales[4].

Toutefois, et à la différence du Luxembourg, ces sociétés gardent leur caractère civil : il s'agit de **sociétés commerciales à objet civil.** Au Luxembourg, la forme de la société commerciale l'emporte sur la nature civile de l'activité, de sorte qu'une telle société est considérée commerciale (nonobstant son objet civil)[5].

En droit luxembourgeois, la forme de la société commerciale l'emporte sur le fond (la nature de l'objet social, en l'occurrence l'objet civil).

1 – CSJ du 11 mars 1875, P., n° 1, p. 63.

2 – Projet de loi sur les sociétés commerciales, Avis du Conseil d'État, p. 54.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 36, ID 11305.

4 – L. Metzler, « Le régime légal des sociétés et des associations en droit luxembourgeois », R.P.S. p. 244.

5 – TA com. du 7 mai 2004, n° 86.468, BIJ, 2004, n° 10, p. 204.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

La loi luxembourgeoise suit en fait la solution adoptée en France par la loi du 1er au 3 août 1893 qui dispose dans son article 68 : « *Quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui se seront constituées dans les formes du code de commerce ou de la présente loi, seront commerciales et soumises aux lois et usages de commerce* ». La même solution prévaut encore en Allemagne aux termes de la loi du 18 juillet 1884 (§§ 174 et 208)[1].

Cette question de la commercialité par la forme a été débattue lors de la procédure d'adoption du projet de loi n° 4992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La **chambre de commerce** a émis un avis sur ce projet en exprimant « *son opposition la plus stricte* » au projet tendant à introduire la possibilité d'exercer des activités civiles dans le cadre d'une société commerciale[2]. Il n'est sans doute pas faux de prétendre que cette chambre professionnelle a pris cette position pour des raisons qui ne sont pas totalement désintéressées. En effet, si les sociétés à objet civil peuvent adopter des formes commerciales, et ceci, sans perdre leur caractère civil, alors leur revenu n'est plus à considérer comme bénéfice commercial, avec donc la conséquence peu souhaitable (du point de vue de la Chambre de commerce) de ne plus être soumis à la cotisation de la Chambre de commerce (calculée sur le bénéfice commercial)[3].

Une société d'experts-comptables (Fiduciaire X) est constituée sous la forme de société anonyme. Indépendamment de l'objet civil de ladite société, celle-ci a la forme d'une société commerciale proprement dite conformément à l'article 100-2 (anc. art. 2) L.S.C. L'article 100-3, 3e alinéa, 2e phrase de ladite loi précise : « *Pourront toutefois les sociétés, dont l'objet est civil, se constituer dans les formes de l'une des sociétés commerciales énumérées à l'article 100-2, alinéa 1er. Mais, dans ce cas, ces sociétés, ainsi que les opérations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce* ».

À l'époque de la genèse de la loi, cette question avait été abordée différemment dans le sens que l'article 4 de l'avant-projet de loi préparé par Nyssens avait prévu la possibilité pour les sociétés civiles de rester régies par les lois civiles (« *sans perdre leur caractère civil [...] ce qui attribue à une société le caractère commercial, c'est son objet ; la forme adoptée ne saurait rendre commerciale une société qui par son essence est civile. C'est en effet un principe capital, que les parties ne peuvent par des conventions déroger aux lois d'ordre public ; or telles sont les lois relatives à la compétence et à la faillite. Les sociétés commerciales sont justiciables des tribunaux de commerce, elles sont exposées à la faillite ; il ne saurait dépendre des parties de changer l'ordre des juridictions, ni de soumettre à la faillite une société civile, en lui donnant une forme commerciale* »[4]).

Cette proposition avait toutefois était rejetée.

La situation de notre pays est dès lors différente de celle de la Belgique où des sociétés dont l'objet est civil restent civiles, même si elles adoptent la forme commerciale. Depuis une loi du 14 juin 1926 (reprise à l'article 212 des lois coordonnées), les sociétés civiles peuvent emprunter les formes des sociétés commerciales sans

1 – Projet de loi sur les sociétés commerciales, Avis du Conseil d'État, p. 64.

2 – Avis de la chambre de commerce, Doc. parl., n° 4992/2, 22 avril 2004, p. 1, ID 9912.

3 – V. la loi du 10 avril 1924 sur les chambres professionnelles.

4 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 37, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

perdre leur caractère civil. Aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel de Gand[1], un tel emprunt n'implique pas seulement la soumission de la société civile à toutes les dispositions des lois coordonnées concernant les conditions de constitution et de fonctionnement de la société commerciale dont elle a revêtu la forme, mais il entraîne encore l'application des lois spéciales dont l'objet est d'assurer la protection du public en relation avec le fonctionnement des sociétés commerciales[2]. En revanche, les sociétés civiles à forme commerciale relèvent des juridictions civiles et, notamment, du régime de la preuve applicable en cette matière.

Ce régime suppose que la société civile à forme commerciale ait véritablement un objet civil : si celui-ci est commercial, la société en question constitue une véritable société commerciale et elle sera intégralement soumise au droit commercial[3].

Il découle de ce qui précède qu'au Luxembourg, la **commercialité par la forme** l'emporte sur l'absence de commercialité de l'objet. Il s'ensuit que les factures émises par ces sociétés ne constituent pas des « états » ou « notes d'honoraires », mais des factures proprement dites, et que l'article 109 du Code de commerce est d'application[4].

Il existe donc une dissymétrie entre ces dispositions. Si, pour les sociétés commerciales, la forme de la société l'emporte toujours sur l'objet (de sorte que cette forme prime la nature civile de l'objet), la forme n'a pas ce même effet à l'égard des sociétés à objet civil. Pour ces dernières, l'objet effectif sera déterminant : si un objet civil est autorisé, l'objet commercial est interdit. Si une telle activité était poursuivie, il faudrait conclure au caractère commercial de cette société (qui, conformément à ce qui vient d'être dit ailleurs, aurait donc la forme de société en nom collectif)[5].

La réalisation et la répartition de bénéfices étant l'objectif indispensable de toute société civile ou commerciale, ne remplit pas cette condition essentielle une société coopérative qui a pour but exclusif la sauvegarde et la défense des intérêts professionnels et matériels de ses membres ; ne possédant pas une individualité distincte de celle des associés, pareille société est irrecevable à se porter partie civile[6].

Selon la jurisprudence, la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés à participation financière (*holding companies*) a une portée purement fiscale ; en vertu de cette loi, l'objet de la société *holding* est essentiellement civil ; du point de vue du droit commercial, la « *holding company* » n'est cependant pas un type de société à part ; son statut est déterminé par la L.S.C. concernant les sociétés commerciales ; en application de l'article 3, 3e alinéa (ancien) de ladite loi, la société *holding* sous la forme d'une société anonyme est une société de commerce ; ses opérations sont à considérer comme des actes de commerce, et les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu sont de la compétence de la juridiction commerciale ; les articles 16 et suivants de la loi du 27 novembre 1986 concernant la concurrence déloyale lui sont dès lors applicables[7].

1 – CA Gand du 4 mars 1982, *R.W.,* 1982-1983, col. 2.143.

2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1992, p. 590.

3 – Trib. com. Liège du 30 janvier 1989, *T.R.V.,* 1989, p. 215.

4 – TA Lux. du 6 mai 1994, n° 41.866, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – V. sous principe des cadres légaux obligatoires.

6 – CA du 12 janvier 1928, *P.,* n° 11, p. 267, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

7 – CA du 24 mai 1989, n° 11.162, ID 11862.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il est vrai que cette règle a également entre-temps changé au Luxembourg dans la mesure où la loi 16 décembre 2011 sur les sociétés d'avocats dispose que, par dérogation à la loi concernant les sociétés commerciales, les activités des sociétés d'avocats ont une nature civile malgré l'adoption de la forme d'une société commerciale.

Dans une société civile (dotée de la personnalité civile en vertu de la loi du 18 septembre 1933[1]) dont les statuts prévoyaient la cessibilité des parts entre associés, la validité d'une convention de rachat des parts d'un associé par la société était contestée[2].

B – Incidence du caractère civil ou commercial

Dans les sociétés sans personnalité morale, le caractère civil ou commercial détermine en particulier :

– l'étendue de la responsabilité des associés envers les tiers ; en application de l'article 1863 C.c., les associés sont tenus envers les tiers par **parts viriles,** alors que la responsabilité est solidaire en matière commerciale ;
– la compétence *ratione materiae* des tribunaux ;
– le régime de la **preuve** (strictement réglementé en matière civile, libre en matière commerciale) ;
– la nature civile ou commerciale des actes[3].

■ § 6 – Contrat ouvert

Le contrat de société est un contrat ouvert, donc un contrat auquel il est possible **d'adhérer** après sa conclusion. Chaque fois qu'un associé vend ses titres de participation à un tiers, cette acquisition comporte pour l'acquéreur adhésion au contrat de société conclu antérieurement. Il accepte donc d'assumer les obligations qui découlent de la conclusion de ce contrat, telles que prévues par les statuts et par la loi[4].

■ § 7 – Contrat causé

Il convient d'abord de distinguer la notion de « cause » de notions voisines telles que l'objet du contrat ou encore les mobiles des contractants. Nous nous plaçons ici dans le cadre des seules conventions synallagmatiques telles que le contrat de

1 – Cour du 11 mars 1999, *BIL-Viloti S.C.I.,* n° 21.955, *P,* 31, p. 126, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Réf. n° 905/2000 du 27 novembre 2000, *Ann. dr. lux*., 2001, p. 587: « *en droit luxembourgeois la cession de parts par un associé d'une société civile n'est réglementée par aucun texte. Force est cependant de relever d'une part qu'aux termes de l'article 1865, 5°, du Code civil la société finit [...] par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de ne plus être en société. Le principe même du retrait d'un associé de la société est partant acquis [...] La société civile a [...] une personnalité juridique propre distincte de celle de ses associés et ne permettre qu'aux associés de se porter acquéreurs des parts sociales d'un associé qui désire quitter la société et non à la société elle- même serait méconnaître la réalité de la personnalité morale propre de la société civile* ».

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 26.

4 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 258.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

société. La cause est prévue par les articles 1131, 1132 et 1133 C.c. Il s'agit du quatrième élément nécessaire à la validité d'une convention.

Les controverses doctrinales sur cette notion n'intéressent pas à cet endroit : la raison pour celles-ci est à trouver essentiellement dans la confusion existant entre la cause de la convention, d'une part, et la cause de l'obligation, d'autre part. Dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation d'une des parties est l'obligation de l'autre. Par conséquent, pour ces contrats, la cause de chacun des contractants sera l'obligation assumée par les autres contractants.

Est jugé nul « *le contrat d'association en participation selon lequel un des contractants devait servir de prête-nom à l'autre, et ceci, afin d'éluder une clause de non-concurrence par laquelle ce dernier est lié à l'égard d'un tiers* »[1]. Ce contrat étant contraire aux bonnes mœurs, la cause en étant illicite, il ne saurait, en application de l'article 1131 C.c., produire le moindre effet.

Il ne peut être question de cause illicite au sens de l'article 1131 C.c. entraînant la nullité de la convention que si la cause illicite est connue de toutes les parties ayant contracté et que correspondant au but collectif de l'opération, le mobile psychologique a pénétré dans le contrat dont il est devenu un élément constitutif. « *Le mobile psychologique immoral personnel à l'une des parties au contrat qui est resté dissimulé à son cocontractant n'entre pas à titre d'élément déterminant dans la conclusion du contrat qui est le produit de l'accord de deux ou plusieurs volontés […]* »[2].

1 – Cour du 5 janvier 1927, *P.,* n° 11, p. 316, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA (civ.) du 13 juillet 1959, *P.,* n° 18, p. 7, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
DISTINCTION DE LA SOCIÉTÉ PAR RAPPORT À D'AUTRES NOTIONS

La loi connaît d'autres formes d'association que les sociétés. En outre, la pratique a recours à d'autres notions qui sont également à distinguer du concept de société.

SECTION I
LES ENTITÉS AVEC PERSONNALITÉ MORALE

Comme les personnes physiques, les sociétés sont des sujets de droit et ont un patrimoine propre. Faisant preuve d'un « anthropomorphisme instinctif » (selon la formule de J. Carbonnier[1]), on considère alors que ces entités sont des personnes auxquelles on attribue l'épithète « morales » par opposition aux personnes physiques.

Par le passé, la question de savoir dans quelle mesure les sociétés avaient la personnalité morale était souvent controversée, et ceci, tant en doctrine qu'en jurisprudence. Pour une partie de la doctrine, la personnalité morale était fondée sur l'article 529 C.c. selon lequel les actions dans les sociétés anonymes sont de nature mobilière, et ceci, même si la société détient des actifs immobiliers. La doctrine en déduisait que ces sociétés devaient être dotées de la personnalité morale[2].

En vertu du principe du **légalisme**, c'est le législateur qui détermine si une entité bénéficie ou non de la personnalité morale[3]. En Belgique, ce principe a entretemps été consacré par la loi du 13 avril 1995 qui a amendé l'article 1832 C.c. pour préciser « *qu'une société n'est dotée de la personnalité morale que lorsque la loi le prévoit* »[3]. Cette évolution n'a pas été suivie au Luxembourg. Pour autant, la situation n'en est pas vraiment différente dans la mesure où la loi attribue directement la personnalité morale. Tel est le cas de l'article 100-2 (anc. art. 2), alinéa 2 de la L.S.C. qui précise que : « *Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés […]* », complété par l'article 100-3 (anc. art. 3), alinéa 1er, L.S.C. : « *Les sociétés dont l'objet est civil et qui se placent sous le régime des art. 1832 et suivants du Code civil, constituent pareillement une individualité juridique distincte de celle des associés […]*». Même s'il peut paraître étonnant que la personnalité morale des sociétés civiles soit attribuée par la loi sur les sociétés commerciales, telle est bien la situation de droit (sauf à considérer qu'il ne s'agit que d'une simple disposition déclarative destinée à éliminer toute contestation sur la question).

« *Comme les sociétés personnalisées constituent des sujets de droit distincts, leur création intéresse les tiers ; elles doivent faire l'objet d'un acte écrit (les statuts) et de formalités de publicité ; en outre, les sociétés à forme commerciale personnalisées doivent s'immatriculer à un registre et tenir une comptabilité. Ces règles ne s'appliquent pas aux sociétés sans personnalité* »[4].

1 – J. Carbonnier, *Droit civil*, T. 1, p. 263.

2 – Dans un sens contraire toutefois, Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 185.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 201.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 202.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La personnalité morale confère une **autonomie** à la société par rapport aux associés, et ceci, surtout sur le **plan patrimonial** : la société a un patrimoine propre entièrement distinct de celui des associés.

Étant dépourvues de la personnalité morale, il n'existe aucune raison pour imposer à ces associations des conditions de forme analogues à celles exigées par les sociétés commerciales proprement dites. « *Absence complète de conditions de forme, ni acte écrit ni publicité, soit pour la constitution, soit pour les modifications au pacte social, en d'autres termes, application du droit commun quant aux obligations comme en ce qui concerne les droits, tel est le régime légal des simples associations commerciales* »[1].

À leur égard, un écrit n'est donc nullement nécessaire. Il s'agit d'un simple moyen de preuve, étant entendu que cette preuve est entièrement libre.

La situation en Belgique et au Luxembourg n'est pas nécessairement identique à celle d'autres pays : « *L'examen des droits occidentaux révèle que la personnalité morale est généralement refusée aux sociétés à responsabilité illimitée :* "partnership" *anglaise,* "Offene Handelsgesellschaft" *allemande, société en nom collectif italienne,* "vennootschap onder firma" *hollandaise, société simple, en commandite, en nom collectif suisses [...] Pourtant les effets reconnus en droit français et belge à ces sociétés se retrouvent généralement dans ces droits étrangers. C'est dire que ces caractéristiques ne sont pas liées d'une manière indissoluble et nécessaire à la notion de personnalité morale* »[2].

■ § 1 – Société et association

Le contrat d'association n'est, en tant que tel, pas défini et, à plus forte raison, pas réglementé par le législateur. Il s'agit donc d'un contrat innommé, créé de toute pièce par la pratique, sur la base du principe d'autonomie de la volonté privée qui, en l'occurrence, repose sur le principe constitutionnel de la liberté d'association (article 26 de la Constitution)[3].

« *Les lois portées pendant la révolution française ont supprimé les corporations religieuses d'hommes et de femmes, par le motif, dit l'assemblée législative, qu'un État vraiment libre ne peut souffrir dans son sein aucune corporation. Ces lois n'abolissent pas seulement les ordres religieux considérés comme corporations, c'est-à-dire comme formant un corps moral ou une personne civile* »[4].

Associations et sociétés ont en commun non seulement qu'il s'agit de groupements de personnes (contrairement aux fondations), mais encore que des associés mettent quelque chose en commun (leur travail ou leur argent sous la forme de cotisations) en vue de réaliser une ou plusieurs activités. Le critère distinctif de l'association est l'absence de but de lucre[5].

L'association poursuit un but désintéressé. L'association ne peut rechercher ni son propre enrichissement ni celui de ses membres. C'est l'objet social, tel que

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 44, ID 11308.

2 – Cass. b. du 31 mai 1957, note P. Van Ommeslaghe, p. 287.

3 – M. Coipel, « La société dans tous ses états », *Le droit des sociétés. Aspects pratiques et conseils des notaires*, p. 56.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 199.

5 – M. Coipel, « La société dans tous ses états », *Le droit des sociétés. Aspects pratiques et conseils des notaires*, p. 57.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

décrit dans les statuts, qui permet de distinguer une association d'une société[1]. Néanmoins, le statut d'association n'est pas incompatible avec une activité lucrative : une telle activité lucrative est autorisée dans la mesure où la poursuite de cette activité permet de réaliser les buts non lucratifs de l'association. Par exemple, un club de sport exploite une buvette dont les recettes sont utilisées afin de subvenir aux besoins financiers de la pratique du sport. Le but poursuivi par l'association est d'entraide et de mutualité : il ne comporte jamais la distribution de bénéfices[2].

En dehors de ces associations, qui souvent ne sont pas formalisées (et pour cette raison sont nommées « associations de fait »), il y a les associations soumises à la loi de 1928 sur les associations sans but lucratif.

Par a.s.b.l., il faut, aux termes de la loi du 21 avril 1928 (fortement amendée par la loi du 4 mars 1994[3]) comprendre « *celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.*

Elle jouit de la personnalité civile si elle réunit les conditions déterminées ci-après »[4].

Dans cette définition, la conjonction « ou » soulève des difficultés d'interprétation : à strictement parler, cette conjonction signifierait qu'est une a.s.b.l. une association qui, à la fois, ne poursuit pas des activités industrielles et commerciales et qui ne procure pas un gain matériel à ses membres. Une telle interprétation serait difficile à défendre et l'on convient, en général, que les deux conditions sont cumulatives et que la conjonction « ou » signifie en fait « et ». Telle est la position en Belgique où, en substance, le même texte d'une loi datant du 27 juin 1921[5] est applicable.

Si l'activité principale ne peut pas consister en une **activité commerciale**, il est possible qu'une telle activité soit exercée à titre **accessoire**. Dans ce cas, les recettes de l'activité accessoire doivent être utilisées aux fins de l'activité désintéressée. Il faut toutefois qu'un lien existe entre cette activité commerciale et l'objet de l'association[6].

Il est encore à noter que certaines des associations sans but lucratif sont reconnues d'utilité publique (en application de l'article 26-2 de la Loi de 1928). Les associations de cette catégorie (soumises au même régime juridique que toutes les autres) peuvent collecter plus facilement des dons dans la mesure où ces derniers sont fiscalement déductibles dans le chef d'associés résidents luxembourgeois (à titre de « dépenses spéciales »).

Les associations, comme les sociétés, sont régies par le **principe de la spécialité** avec la conséquence que les actes qui leur sont interdits ne sont pas opposables aux tiers : si, aux termes de l'article 15 de la Loi de 1928, l'association « *ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l'objet*

1 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés. Précis*, p. 177.

2 – L. Metzler, « La personnalité morale et ses limites dans la législation luxembourgeoise », P., n° 15, p. 16.

3 – Loi du 4 mars 1994, ID 1812, *Doc. parl.,* n° 2978, ID 9816.

4 – Art. 1 de la loi.

5 – M. Coipel, « La société dans tous ses états », *Le droit des sociétés. Aspects pratiques et conseils des notaires*, p. 59.

6 – Sur ce point, V. A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 129.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

social ou les objets en vue desquels elle est formée », l'association qui contreviendrait à cette interdiction ne pourrait pas devant les tribunaux obtenir la protection de ses droits sur de tels immeubles[1].

A – Constitution de l'association

La constitution de l'association requiert trois membres au moins, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Elle doit avoir un siège social sur le territoire national. Les statuts doivent mentionner les points suivants :

– la dénomination ;
– le siège ;
– l'objet (qui doit être désintéressé) ;
– le mode de fonctionnement ;
– les conditions d'entrée et de sortie des membres ;
– etc.

La personnalité morale n'est acquise qu'au moment de la **publication** des statuts. La situation est donc différente de celle que l'on connaît pour les sociétés qui, elles, acquièrent la personnalité morale dès la signature de l'acte de constitution. En revanche, la situation sera similaire à celle que l'on connaît dans les pays voisins, et ceci, tant pour les associations que pour les sociétés.

Les administrateurs encourent une responsabilité contractuelle fondée sur le contrat de mandat.

B – Fonctionnement de l'association

La direction de l'association appartient à un conseil d'administration qui représente celle-ci dans toutes ses activités. Il ne semble pas exclu que le conseil d'administration délègue une partie de ses pouvoirs à des personnes non membres (un peu à l'instar de ce qui est acceptable dans les sociétés anonymes : possibilité de déléguer la gestion journalière).

Aux termes de l'article 11 de la loi du 21 avril 1928, « t*ous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des associations sans but lucratif, doivent contenir :*

a) *la dénomination de l'association ;*
b) *la mention « association sans but lucratif » reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé « a.s.b.l. » placée immédiatement avant ou après la dénomination ;*
c) *l'indication précise du siège de l'association ;*
d) *les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d'immatriculation ».*

Ces exigences de publication, qui ont été introduites par la loi du 19 décembre 2002, ont évidemment beaucoup de ressemblances avec celles introduites par la L.S.C. à l'égard des sociétés de capitaux.

---

1 – L. METZLER, « La personnalité morale et ses limites dans la législation luxembourgeoise », P., n° 15, p. 25.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La sanction prévue par la loi (article 26 de la Loi de 1928) est qu'en cas d'omission des publications et formalités, l'association ne peut se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers. Selon la jurisprudence, cette sanction est applicable uniquement « *en cas d'abus ou de fraude* »[1]-[2]-[3].

C – Association de fait

Tout comme il existe des sociétés de fait, il existe des associations de fait.

Dans une affaire soumise aux juridictions, le tribunal de paix avait retenu que la demande en justice tendant à la condamnation d'une a.s.b.l. serait irrecevable du fait que cette a.s.b.l. était dépourvue de personnalité juridique faute d'avoir dûment publié ses statuts au *Mémorial*. En effet, d'après l'article 3 alinéa 1er de la loi du 21 avril 1928, « *La personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts sont publiés [au RESA].* ». Le tribunal d'arrondissement, siégeant en appel contre ce jugement devait retenir que, malgré la non-publication des statuts, « *les tiers ont la possibilité de faire état de la personnalité morale à l'encontre de l'association de fait, si cette solution leur paraît la plus avantageuse* »[4].

Une autre décision confirme la solution de bon sens retenue par l'article 26 de la loi du 21 avril 1928 selon laquelle une association, bien qu'elle n'ait pas respecté les règles de l'article 26 (avec donc la conséquence que toute action introduite par l'association serait irrecevable, faute de personnalité morale) ne peut se soustraire à ses engagements et peut donc être citée comme défendeur devant une juridiction et être condamnée[5].

Si une telle association de fait est assignée devant la juridiction, elle peut faire état de tous les moyens de défense accordés par la loi nonobstant l'absence de personnalité juridique ; le groupement dispose ainsi de la capacité passive d'ester en justice. Cette capacité passive inclut la possibilité d'exercer les voies de recours prévues par la loi, en particulier donc la possibilité de faire appel contre un jugement de première instance[6].

■ § 2 – Société et fondation

Traditionnellement, la fondation consiste dans un acte juridique unilatéral par lequel une personne, le fondateur, affecte tout ou partie de son patrimoine à la

1 – CE du 8 juillet 1982, *Kollektiv Spackelter c/ Ministre de la Santé, P.,* n° 25, p. 329.

2 – CE du 26 février 1987, *Biergerinitiativ Eist Duerf soll liewen a.s.b.l. ... c/ Ministre du Travail, Amer-Sil, P.,* n° 27, p. 4.

3 – CE du 27 février 1987, *Association des Patrons Mécaniciens-Dentistes a.s.b.l. c/ Secrétaire d'État aux Classes moyennes, P.,* n° 27, p. 7.

4 – TA du 19 octobre 1977, P., n° 24, p. 58, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – CA (trav.) du 23 novembre 1995, P., n° 30, p. 7, ID 6862.

6 – CA (réf.) du 21 mai 1996, P., n° 30, p. 86, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

réalisation d'un objectif déterminé[1]. Cette définition rejoint encore celle de la loi luxembourgeoise du 21 avril 1928 telle que substantiellement amendée par les lois postérieures[2]. La fondation, contrairement à la société et à l'association, n'est pas un contrat par lequel plusieurs personnes se regroupent pour exercer une activité déterminée, mais une **affectation permanente** de biens à une œuvre désintéressée, charitable ou d'intérêt général. Ce patrimoine d'affectation est géré dans le but de réaliser l'objet défini par un acte unilatéral de volonté du fondateur qui s'est exprimée soit dans un acte notarié, soit dans un testament. La fondation jouit de la personnalité civile dès la publication de l'arrêté grand-ducal portant approbation des statuts de la fondation ; l'approbation par arrêté grand-ducal est en effet requise.

Comme l'a.s.b.l., la fondation est gérée par un ou plusieurs administrateurs. La société n'ayant pas de membres, le rôle de l'assemblée des associés est (dans une certaine mesure) assumé par le ministère de la Justice. Il en va de même pour le contrôle de ces fondations : ces pouvoirs sont également dévolus au ministère de la Justice. Aux termes de l'article 40 de la Loi de 1928, les comptes de la fondation ainsi que le budget concernant l'exercice suivant doivent être communiqués annuellement au **ministère de la Justice** ; c'est le même ministère qui contrôle que les biens de la fondation soient utilisés aux fins prévues.

La **liquidation** de la fondation est prononcée par le tribunal sur demande d'un administrateur, d'un tiers ou du ministère public (art. 41 de la loi de 1928).

Les liquidateurs, après avoir procédé aux opérations de liquidation proprement dites, vont donner aux avoirs restants après désintéressement de tous les créanciers de la fondation l'affectation prévue par les statuts de la fondation.

■ § 3 – Société et groupement d'intérêt économique

La notion de groupement d'intérêt économique (G.I.E. ci-après) est récente en droit luxembourgeois. Il convient d'abord de décrire la nature de cette entité assez particulière.

A – Nature du groupement

Le concept de groupement du groupement d'intérêt économique a pris son origine **en France** où il avait été lancé pour permettre la collaboration entre entreprises destinée à générer de simples économies : la Cour de cassation avait en effet adopté la conception stricte du bénéfice (voir p. 78). Sous cette jurisprudence, il restait aux entreprises désireuses de se regrouper uniquement l'association de la loi de 1901 (si elles entendaient bénéficier de la personnalité morale)[3].

Malgré la modification ultérieure de l'article 1832 C.c., on a continué à considérer qu'il existerait une différence fondamentale entre société et G.I.E.[4]. Tel n'est pas le

1 – M. Coipel, « La société dans tous ses états », *Le droit des sociétés. Aspects pratiques et conseils des notaires*, p. 60.

2 – Loi du 22 février 1984, ID 9558, et loi du 4 mars 1994, ID 1812.

3 – M. Coipel, « La société en tous ses états », *Le droit des sociétés. Aspects pratiques et conseils des notaires*, p. 68.

4 – Une différence effective est que les membres du groupement n'ont pas à effectuer un apport (ce qui est en contradiction avec l'article 1833 C.c.), ID 11337.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

cas en réalité : en effet, le règlement (CEE) n° 2137/85 abandonne aux droits nationaux les questions relatives au contrat du groupement. Par conséquent, un certain nombre de lois nationales renvoient simplement au droit des sociétés en considérant donc que le G.E.I.E. est une société. Tel est le cas en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Angleterre[1].

Par le règlement (CEE) n° 2137/85[2] a donc été institué le G.E.I.E., une nouvelle forme de « *coopération transnationale pour exercer en commun certaines […] activités, telles que p. ex., la recherche et le développement, l'achat, la production et la vente […] le traitement de données par ordinateur, la formation de consortiums multidisciplinaires dans le domaine de la construction en vue de la soumission de marchés publics ou privés* »[3]. Le G.E.I.E. doit être composé au moins de :

– deux sociétés ayant leur administration centrale dans deux États membres différents (article 4 du règlement) ; ou

– deux personnes physiques exerçant leur activité à titre principal dans des États membres différents.

Afin d'offrir aux personnes physiques et morales luxembourgeoises les mêmes possibilités de coopération que celles qui sont données par le G.E.I.E. sur le plan transnational, le législateur national a également introduit le groupement d'intérêt économique (G.I.E.)[4]-[5].

B – Caractéristiques de ces groupements

Juridiquement, les points suivants, en principe communs aux deux catégories de groupements, sont à relever :

1. la constitution a lieu par acte notarié ou sous seing privé ;
2. le groupement a la **personnalité juridique** (dès la conclusion du contrat pour le G.I.E. ; dès l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés pour les G.E.I.E.) ;
3. les membres répondent indéfiniment et solidairement de toutes les obligations du groupement ;
4. le but exclusif est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. L'activité doit se rattacher à celle des membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

   Il ne peut :

   – exercer le pouvoir de direction ou de contrôle des activités propres de ses membres,

   – détenir des participations dans les entreprises membres,

1 – M. Coipel, « La société en tous ses états », *Le droit des sociétés, Aspects pratiques et conseils des notaires*, p. 68.

2 – Règlement n° 2137/85 adopté le 25 juillet 1985 par le Conseil des ministres, *J.O.C.E.,* n° 2199/1, 31 juillet 1985.

3 – *Bull. CE*, Suppl. 3, 1987.

4 – Loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, ID 9566.

5 – Loi du 25 mars 1991 sur les groupements européens d'intérêt économique, ID 9569.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– rechercher des bénéfices pour son propre compte ;

5. les contrats de groupement sont publiés par extrait au RESA ;
6. Le groupement est immatriculé au R.C.S. sans que cette immatriculation n'emporte présomption de commercialité ;
7. le groupement est géré par une ou plusieurs personnes membres ou non du groupement.

SECTION II
LES SOCIÉTÉS SANS PERSONNALITÉ MORALE

À l'égard de l'attribution de la personnalité morale, le droit des sociétés luxembourgeois s'avère être beaucoup plus **généreux** que celui de nos pays voisins. En effet, en droit luxembourgeois, l'attribution de la personnalité est la règle (tel est le cas pour les formes de sociétés commerciales de l'article 100-2, alinéa 1er, ainsi que pour la société civile, voire pour les groupements d'intérêt économique). En outre, l'attribution de la personnalité morale n'est en général pas soumise à l'accomplissement de la moindre formalité ; il n'y a pas besoin d'une autorisation, ni d'une immatriculation au R.C.S. Dans nos États voisins, certaines des formes de sociétés visées (souvent les sociétés de personnes ou les sociétés civiles) ne sont pas dotées de la personnalité morale ; en outre, même s'il y a attribution de la personnalité, celle-ci a lieu seulement à partir du moment où il y a publication de l'acte des sociétés (au R.C.S. notamment).

Quant à la question de savoir si la société civile est ou n'est pas dotée de la personnalité morale, elle a, par le passé, donné lieu à des controverses « *généralement résolues en faveur de l'absence de personnalité morale des sociétés civiles en Belgique et en faveur de la reconnaissance de la personnalité morale en France* »[1]. Entre-temps, cette solution fut également consacrée en Belgique par l'effet de la loi du 13 avril 1995.

Néanmoins, le droit des sociétés luxembourgeois connaît également la société sans personnalité morale, et ceci, sous la forme de la société en participation et de la société momentanée.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires des fonds d'investissement alternatifs (souvent désignée par le terme de « Loi AIFM[2] »,) la L.S.C. **distinguait les sociétés commerciales** (énumérées à l'article 2 (anc.) L.S.C.) des **associations commerciales** (associations momentanées et associations en participation) des articles 138 à 140 (anc.) L.S.C. Si les premières étaient dotées de la personnalité juridique, les deuxièmes ne l'étaient pas. La Loi AIFM a changé de terminologie à l'égard des associations commerciales en faisant valoir que, depuis la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, le terme association est réservé aux **groupements sans but lucratif** tout comme celui de société caractérise les entités à but lucratif. Du fait que le caractère lucratif desdites « associations commerciales » n'est pas douteux, le changement de terminologie en sociétés commerciales s'imposait[3].

1 - Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 5.

2 - Loi qui a porté transposition de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 encore appelée « directive AIFM », publiée au *Mémorial* A 255 en date du 15 décembre 2016 et entrée en vigueur le 19 décembre 2016.

3 - *Doc. parl.*, nº 5730, point 7*bis*), ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette modification, qui peut paraître anodine, pose toutefois un problème de terminologie du fait qu'il n'y a plus de terme générique pour désigner les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation. En effet, on ne peut pas les appeler « sociétés commerciales dénuées de la personnalité juridique », car cette caractéristique n'est plus distinctive de ces deux catégories de sociétés commerciales depuis que la même Loi AIFM a introduit la notion de « société en commandite spéciale », autre société commerciale dénuée de la personnalité juridique.

■ § 1 – Caractéristiques des sociétés sans personnalité morale

Elles n'ont pas de patrimoine, pas de capacité de contracter, pas de nationalité, pas de siège et ne peuvent être déclarées en faillite[1]. Les sociétés visées n'ayant pas de personnalité morale reposant sur un contrat, seules les personnes peuvent en faire partie, à l'exclusion des entités ne bénéficiant pas de la personnalité morale[2].

Les associés de telles sociétés ne sont pas détenteurs de « titres » ou de « parts » représentant une quote-part du capital social, et ceci, faute de capital social. Les associés ont en fait un lien contractuel envers les autres associés de la société. Néanmoins, les associés ont des droits sur le fonds social et sur les biens qui en font partie. De même, ces associés ont des obligations envers les tiers[3].

Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales, étant entendu que, dans le second cas, l'intervention de l'organe compétent est requise. Dans la société anonyme, il s'agit du conseil d'administration, car la constitution d'une société (ou association) excède les pouvoirs du délégué à la gestion journalière[4].

A – Absence de patrimoine

Dans les sociétés sans personnalité morale, les biens mis en commun ne deviennent pas la propriété de la société. Les droits des associés ne sont pas régis par l'article 529 C.c.[5]. Le **droit comparé** montre que cette solution n'est pas la seule concevable. Ainsi, en droit allemand, les sociétés dénuées de personnalité morale ont une propriété commune qui se compose des apports des associés ainsi que des actifs acquis au cours de la vie de la société et qui constituent un patrimoine distinct « *sur lequel seuls les créanciers sociaux peuvent exercer leurs droits* »[6].

Traditionnellement, la doctrine envisage la société comme entièrement transparente et les associés sont individuellement copropriétaires des objets dans la proportion de leurs mises[7]. Il s'agit par conséquent d'une **indivision** entre associés.

Certaines conséquences importantes résultent de cette situation :

– les créanciers personnels des associés devraient pouvoir saisir la part de leur débiteur dans ses biens ;

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 11.
2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 67.
3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 113.
4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 65.
5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 12.
6 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 189.
7 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 550.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– les créanciers personnels se trouvent sur un pied d'égalité avec les créanciers de la société. Les créanciers personnels des associés peuvent compenser leur créance avec une dette de la société[1].

Malgré cette absence de patrimoine, il a de tout temps été reconnu que les associés ne peuvent, par des actes de disposition, arrêter ou entraver la marche de la société et qu'ils restent toujours tenus de leur obligation initiale de laisser dans le fonds commun les choses qu'ils y ont mises, pour être utilisées suivant leur destination fixée par l'usage ou par la convention[2]. Puisqu'un associé ne confère pas à ses créanciers personnels plus de droits ni des droits plus actuels sur l'actif commun, ces créanciers n'ont pas le droit de poursuivre immédiatement sur cet actif le recouvrement de leurs créances. En particulier, ceci signifie que le créancier d'un associé ne peut pratiquer de saisie-arrêt sur les créances sociales[3]. Dans un tel concours de créanciers, la solution est la suivante : « *Dès qu'il y a plusieurs créanciers en présence, il en est qui ont tous les associés pour obligés et pour gage tous les biens de la société, et d'autres qui, sans rapport avec la société, n'ont pas d'action sur l'actif social, il est clair que ceux-ci doivent s'effacer devant les premiers et leur céder le pas* »[4].

Les créanciers de la société sont d'abord créanciers des associés : ceux-ci ont un patrimoine qui leur appartient en propre et une part indivise dans la société. Sur les biens personnels des associés, les créanciers sociaux ont absolument les mêmes droits que les créanciers personnels des associés[5]. Les créanciers sociaux ont encore pour gage les droits indivis que leurs débiteurs ont dans la société. Alors que les créanciers sociaux ont pour gage tous les biens de la société, les créanciers personnels des associés n'ont comme débiteur que l'associé avec lequel ils ont traité personnellement.

Les créanciers d'un associé ne peuvent rien faire qui puisse porter préjudice aux associés autres que celui avec lequel ils ont traité. Par conséquent, ils ne peuvent pas pratiquer de saisie-arrêt sur une créance sociale, car, en le faisant, ils saisiraient également sur la part indivise qui appartient aux associés avec lesquels ils n'ont pas traité[2].

Les créanciers sociaux, en revanche, peuvent agir sur les biens de la société qui sont dans le patrimoine de leurs débiteurs (les associés) : même si ces biens sont indivis, les créanciers peuvent les saisir et les faire réaliser. « *Aucun d'eux ne peut objecter aux créanciers qu'ils poursuivent des biens qui ne lui appartiennent pas, et qu'ils doivent attendre le partage ; les créanciers leur répondraient que les biens appartiennent en tout cas à tous les associés, donc à tous leurs débiteurs ; ils sont donc leur gage et ils peuvent le réaliser* »[2].

Si les créanciers sociaux et les créanciers des associés ont pour gage les patrimoines des associés et les biens sociaux, la différence entre les deux est que les créanciers sociaux peuvent saisir les biens sociaux, les créanciers des associés n'ayant pas ce droit[6].

L'associé est **copropriétaire indivis** des choses qui appartiennent à la société. Les créanciers n'ont sur ces biens pas d'autres droits que leurs débiteurs. « *L'associé*

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 192.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 196 et les références y données.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 196.

4 – P. Pont, *Commentaire-traité des sociétés civiles et commerciales*, T. 1, Paris, Delamotte Fils et Cie, 1880, p. 466.

5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 366.

6 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 368.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

a un droit indivis restreint par le droit égal des autres associés, droit qu'il ne peut pas réaliser tant que dure la société, et il ne lui appartient pas d'en provoquer la dissolution. Le droit des créanciers est soumis aux mêmes restrictions. Peuvent-ils saisir les biens indivis et les faire vendre tant que la société dure ? Non, car ce serait provoquer la dissolution de la société ; et ils ne peuvent pas, au nom de leur débiteur, exercer un droit que celui-ci n'a point »[1].

Il est vrai que cette approche peut entrer en conflit avec la règle « pas de privilège sans texte », règle qui signifie que les parties ne peuvent, en l'absence de disposition légale spécifique, affecter le produit de la réalisation d'un bien faisant partie du patrimoine du débiteur au paiement privilégié de l'un ou de l'autre d'entre eux[2].

B – Absence de capacité

Les sociétés sans personnalité morale n'ont pas la capacité pour contracter avec des tiers ou pour agir en justice. Les actes juridiques doivent être faits par les associés qui sont représentés par un gérant ou autre mandataire, et ils produisent leurs effets dans le chef de ces associés[3]. Ce sont les associés, dûment représentés par un mandataire, qui agissent en justice, et les actions sont dirigées contre les associés.

C – Absence de nationalité

Les sociétés sans personnalité morale n'ont pas de nationalité dans le sens d'un lien d'allégeance entre une personne et un État[4]. Les associés définissent librement la *lex contractus*.

D – Absence de mise en faillite

Seuls les associés sont susceptibles d'être déclarés en faillite, et ceci, même si la société a un objet commercial.

E – Absence de siège social

Il n'y a donc pas de siège attributif de compétence. Il est loisible aux associés de prévoir une élection de domicile à un endroit déterminé pour l'exécution des contrats avec les tiers[5].

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 362.
2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 198.
3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 11.
4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 12.
5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 13.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

F – Caractère *intuitu personae*

Si les sociétés sans personnalité morale sont en général considérées comme présentant un caractère *intuitu personae*, ce caractère ne relève ni de l'ordre public ni de leur essence, de sorte que, souvent, les parties y dérogent, que ce soit dans le contrat constitutif ou ultérieurement lors d'une modification de ce contrat[1]. Le caractère *intuitu personae* est donc souvent aménagé, et ceci, dans deux directions.

En premier lieu, il peut y avoir modification des effets consécutifs à l'atteinte à l'*intuitu personae*. Les événements visés par l'article 1865, 3 et 4 du Code civil entraînent la dissolution de la société et donc la perte, par tous les associés, de leur qualité d'associé[2]. Le contrat de société peut prévoir la continuation de la société avec l'associé affecté par un des événements visés, avec ses héritiers ou encore entre les autres associés. Il peut encore être prévu que la société sera dissoute en cas de décision expresse des autres associés[1].

En sens inverse, il se peut que les associés étendent le caractère *intuitu personae* en prévoyant la dissolution dans d'autres hypothèses que celles visées par l'article 1865 C.c. ou encore en visant la perte de certaines qualités professionnelles[1].

■ § 2 – Les associations visées par la L.S.C.

Il peut paraître étrange de mentionner des associations dans la section consacrée aux sociétés sans personnalité morale. L'explication de ce choix est simplement la suivante : le terme d'association en participation ou d'association momentanée est erroné. « *[…] dans la* summa divisio *traditionnelle entre les sociétés qui poursuivent un but de lucre et les associations qui ont un but idéal, les associations momentanées et en participation appartiennent à la catégorie des sociétés* »[3]. En effet, ces associations remplissent en fait toutes les conditions de la société. Cette position est encore confirmée par Corbiau qui, dans son avant-projet préparé pour le gouvernement luxembourgeois, avait dans son article 2 écrit : « *La loi reconnaît cinq espèces de sociétés commerciales proprement dites [...]* ». Les termes soulignés qui n'ont finalement pas été repris dans la loi étaient destinés à clarifier que « *les simples associations citées sous l'article 3 sont, elles aussi, des sociétés dans le sens juridique du mot* »[4].

En fait, il s'agit d'une société en participation. Le législateur belge, depuis fort longtemps, lui attribue la désignation correcte de société en participation (par la loi du 18 mai 1873). Le terme d'association a été choisi pour désigner l'absence de personnalité morale. En réalité, et en général, le terme d'association vise l'absence de but lucratif[5] ; il est donc inapproprié à cet endroit.

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 74.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 74.

3 – V. Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 7, pour une description historique de cette terminologie ; Dans le même sens, P. Van Ommeslaghe, « Les sociétés de fait », J.T., 1957, p. 710.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 5, ID 11308.

5 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés. Précis*, p. 283.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 900-3 L.S.C.

« *Les sociétés momentanées et les sociétés en participation ont lieu entre les associés pour les objets, dans les formes avec les proportions d'intérêts et aux conditions convenues entre eux* ».

L'article 100-23 L.S.C. précise que : « *Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique.*

Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale ».

Ces dispositions tout à fait lapidaires de la L.S.C., quasiment les seules applicables à cette matière, montrent l'importance de la liberté contractuelle en cette matière. On se trouve vraiment aux antipodes de la société anonyme, strictement réglementée par la loi, et où le rôle de la liberté contractuelle est autrement réduit.

Le Code de commerce de 1808 ne connaissait que l'association en participation. Le texte de l'article 47 du Code de commerce prévoyait que le critère distinctif de cette association était son caractère éphémère, car réservée à « *une ou plusieurs opérations de commerce* ». La loi du 10 août 1915 y a ajouté l'association momentanée (qui, depuis la loi du 12 juillet 2013 est dénommée société momentanée).

A – L'association momentanée

En tant que telle, elle n'était pas connue en ancien droit et constituait une variété de la société en participation. Elle ne constitue un type particulier de « société » que depuis la loi du 18 mai 1873[1]. L'association momentanée se caractérise donc par son objet qui doit se limiter à un **nombre restreint d'opérations**. C'est dans le secteur de la construction que ce genre d'entités est très fréquent dans la pratique luxembourgeoise (tout comme dans la pratique belge[2]).

On les rencontre encore en matière d'achat et de vente de produits, en matière d'études et de recherches, de production de films, d'exécution d'un contrat d'achat grâce à un crédit documentaire, de représentation d'un spectacle[3].

Ces caractéristiques essentielles sont dégagées par l'article 900-1 L.S.C. selon lequel la société momentanée a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.

Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.

En revanche, ont été considérés incompatibles avec une société momentanée l'exécution en commun de tous travaux, un commerce de fruits, l'exploitation d'une brasserie, l'exploitation d'un garage, des opérations d'import-export[3].

Dans une affaire soumise aux juridictions, les défendeurs avaient constitué entre eux un groupement, ayant pour objet l'érection en commun de maisons, qu'ils avaient

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 25.

2 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés. Précis*, p. 282.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés,* T. 2, p. 33.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

qualifié « d'association momentanée ». Le juge refusa de retenir cette qualification, estimant que les défendeurs avaient en réalité constitué entre eux une société en nom collectif irrégulière constituant une individualité juridique distincte de celle de ses associés. Le tribunal estima en effet que l'objet du groupement envisagé, la convention ayant été conclue sans indication de durée, ne correspondait pas à celui de traiter sans raison sociale une ou plusieurs opérations commerciales déterminées, tel que décrit à l'art. 900-1 L.S.C. pour les associations momentanées[1]. Cette décision est en opposition flagrante avec celle de la Cour de cassation belge précitée.

Dans un autre cas d'espèce, il s'agissait de déterminer la répartition du bénéfice dans une association momentanée conclue entre deux architectes. La cour appliqua les règles du Code civil qui permettent en fait toutes les répartitions imaginables, sauf à respecter les dispositions de l'article 1855 C.c. concernant la société léonine. En l'absence de conventions contraires, et lorsque les seuls apports faits sont des apports en industrie, la répartition des bénéfices se fait par parts égales[2].

B – La société en participation

En un autre endroit, nous avons déjà mentionné qu'on devrait parler non pas d'association en participation, mais de société en participation. Toutefois, le législateur en a décidé autrement, et nous nous rallions à cette convention de langage.

1) Notion

La définition en est donnée par l'article 900-2 L.S.C. :

« *La société en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans des opérations qu'une ou plusieurs autres personnes gèrent en leur propre nom.*

Les gérants sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité ».

Encore appelée « contrat de compte à demi » ou « société à 50-50 », son organisation est **librement déterminée** par les parties[3].

Dans l'ancien droit, elle constituait l'une des formes de sociétés connues, ensemble avec la société en nom collectif (la « société générale ») et la société en commandite. Le tiers ne pouvait agir qu'à l'encontre de l'associé avec qui il avait traité, à l'exclusion de l'associé occulte, et ceci, même s'il connaissait son identité[4].

Le Code de commerce (art. 47-50) reconnaissait l'association en participation. Dans sa conception, ce type d'association concernait une ou plusieurs opérations de commerce, ce qui avait comme conséquence de les soustraire aux formalités prescrites pour les autres sociétés[4]. La conception que les sociétés en participation ne devraient avoir qu'une existence limitée n'était pas partagée par la Cour de cassation belge qui, dès 1861, devait retenir : « *en disant que l'association en participation*

1 – TA Lux. du 31 janvier 1992, n° 40.303, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA (civ.) du 23 janvier 2001, n° 23.581, Fr. Fayot, « Chronique – Droit des sociétés (1997-2002) », *Ann. dr. lux.,* 2001, p. 587, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 21.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 13.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

autorisée par l'article 47 est relative à une ou plusieurs opérations commerciales, la loi ne détermine ni le caractère, ni le nombre et la durée de ces opérations ; rien, dans le texte, n'empêche de l'appliquer à des opérations successives ou continues qui constituent l'exploitation d'un commerce »[1].

Elle se caractérise par son caractère occulte : elle n'est pas révélée aux tiers.

a) La caractéristique distinctive : le caractère occulte

« *Rien n'est plus controversé dans la doctrine et dans la jurisprudence que la nature constitutive des associations en participation. La divergence d'opinions en est arrivée à ce point que les agissements contractuels que les uns désignent par ces mots n'ont rien de commun avec ceux que d'autres qualifient de ce nom* »[2]. Ce commentaire continue alors par expliquer que, pour certains, l'essence de la société en participation serait en fait son **caractère éphémère**, conception qui se base essentiellement sur le Code de commerce qui réservait la notion d'associations commerciales à celles qui n'effectuent qu'un nombre limité d'opérations. À leur égard, les lourdes formalités imposées aux sociétés commerciales ne se justifieraient point.

Selon une autre approche, c'est moins ce caractère temporaire qui caractérise cette association que son **caractère occulte** selon lequel une personne s'intéresse dans une ou plusieurs opérations ou encore dans le négoce continu d'une autre, étant entendu que celui qui exploite ces opérations traite avec les tiers comme s'il agissait pour son propre compte. Rien ne révèle que cet exploitant partage avec un tiers les résultats de son exploitation.

Le critère distinctif serait donc le **secret** de l'intervention du participant. Mais ce n'est pas parce que les tiers, d'une façon ou d'une autre, ont connaissance de l'existence d'un participant occulte que la société (ou l'association en participation) cesse d'exister. Plus que le secret, ce qui importe, c'est que le gérant agit non pas au nom commun des associés, mais en son propre nom. « *C'est juridiquement seulement que les participants doivent être ignorés des tiers. Mais rien ne s'oppose à ce que ceux-ci les connaissent en fait* »[3].

Si cette intervention vis-à-vis des tiers existe, elle n'a aucune vie externe. Seul le gérant traite les affaires de l'association, et ceci, en son nom personnel. Les associés occultes ne révèlent pas leur existence aux tiers.

Les tiers ne connaissent que le **gérant** (les gérants) avec qui ils traitent, tout en ignorant que celui-ci agit pour le compte d'une société. Les droits et obligations qu'il contracte naissent directement dans son chef, même si, en vertu du contrat de société, ces opérations ont ensuite des effets sur les associés de la société.

Ces derniers peuvent intervenir dans la gestion externe et même agir en tant que mandataires du gérant[4]. Par le passé, la question de savoir à quel point ce caractère occulte de la société était existentiel à la société était contestée. Si, dans l'ancien droit, le fait que les tiers connaissaient l'existence de la société en participation était considéré comme non dommageable à l'existence de la société, certains auteurs devaient

1 – Cass. b. du 29 novembre 1861, *P.,* I, nº 1862, p. 85.

2 – E. Pirmez, Commentaire législatif de la loi de 1873, II, 73.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 309, ID 11308.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 17.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

par la suite considérer que, dès que la société perdait son caractère occulte, elle cessait d'exister. En définitive, tant que les participants ne font pas d'immixtion dans la gestion *à l'égard des tiers* et tant que leurs noms n'apparaissent pas dans une raison sociale, etc., tant que les tiers ne sont pas induits en erreur sur la nature de la société (dans le sens qu'ils pourraient penser traiter avec une société en nom collectif), le caractère de la société en participation ne devrait pas être remis en question[1].

b) Les créanciers de la société en participation

À proprement parler, il n'existe pas de créanciers de l'association : aucun être moral juridique distinct n'est créé et aucun fonds social n'existe. « *Il s'ensuit que les tiers qui ont traité avec un des coparticipants n'ont d'action que contre lui, personnellement, comme ses créanciers personnels, non comme créanciers sociaux, et doivent donc l'assigner en son nom personnel, et non comme représentant ou coobligé d'une société qui, à leur égard, n'existe pas* »[2].

Ce point est depuis longtemps confirmé par la jurisprudence : « *Attendu qu'il est universellement admis en doctrine et en jurisprudence que le propre de l'association en participation est de n'avoir pas d'existence au regard des tiers et qu'à moins que les associés n'aient donné à ceux-ci de justes raisons de croire qu'ils garantissaient les actes du gérant, les tiers qui n'ont traité qu'avec l'un des membres, n'ont pas d'actions contre les autres membres de l'association* »[3].

Mais il en va différemment dans le cas où les noms des associés sont portés à la connaissance des tiers contractants de manière à leur faire croire « *qu'ils se trouvent en présence d'une collectivité solidaire* ». Dans ce cas de figure, les associés sont tenus solidairement envers les tiers des obligations contractées par eux. « *Tel est notamment le cas, lorsque tous les associés se sont immiscés directement et personnellement dans l'opération* »[2].

c) Notion de bailleur de fonds

La notion de bailleur de fonds a fait son entrée en droit luxembourgeois par le biais du **droit fiscal** luxembourgeois en raison de sa filiation avec le droit fiscal allemand. Dans ce dernier pays, la notion existe dans le Code de commerce (HGB, §§ 230-237)[4]. Il s'agit dans ce cas d'une **société de droit civil occulte** (un peu à l'instar de la société en participation à laquelle se réfère l'article 2 L.S.C.) et dépourvue de personnalité morale. Elle est constituée par une personne morale ou une personne physique (l'associé principal ou associé « ostensible ») et une autre personne (l'associé silencieux ou « bailleur de fonds ») à la poursuite d'une finalité

1 – V. en ce sens, T Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 19.

2 – CSJ du 26 février 1901, P. , n° 5, p. 517, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA du 23 octobre 1901, P., n° 6, p. 53, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – M. R. Theisen et M. Wenz, « Germany », *The Tax Treatment of Financial Instruments. A Survey to France, Germany, The Netherlands and the United Kingdom*, p. 171.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

commune qui est en général le soutien de l'activité de l'associé principal. L'activité est conduite par l'associé principal.

L'associé silencieux ne fait qu'apporter du capital (ou d'autres actifs en nature) qui entre dans le patrimoine de l'associé principal. Dans les comptes de ce dernier, l'apport du bailleur de fonds figure en tant que dette envers lui.

Les droits de contrôle du bailleur de fonds sont fortement limités : il a le droit de vérifier les comptes annuels. « *Lorsqu'un bailleur de fonds est rémunéré par une participation aux bénéfices réalisés par l'emprunteur, mais qu'il n'existe aucune participation à l'activité de ce dernier ni aucune intervention dans les pertes qu'il pourrait encourir, la jurisprudence exclut l'existence d'une société commerciale, lors même que le prêteur exercerait une certaine surveillance sur l'emprunteur* »[1].

Le bailleur de fonds n'est pas tenu des dettes de l'entreprise. Il est rémunéré par une quote-part du bénéfice de celle-ci. En principe, il *participe* aux dettes de l'entreprise jusqu'à hauteur de son apport en capital. Cette participation aux pertes peut être exclue, mais elle peut également être étendue par l'accord des associés. En l'absence de participation aux pertes, la société peut ressembler à un **prêt partiaire**[2].

Selon les auteurs du commentaire des articles de la L.I.R. (loi de l'impôt sur le revenu du 4 décembre 1967), la différence entre la société occulte et l'association en participation serait que, dans la société occulte, les apports de l'associé occulte entrent dans le patrimoine de l'associé principal alors que tel ne serait pas le cas des associations en participation. En effet, l'associé apporteur reste propriétaire des biens apportés. Il serait néanmoins possible de faire fonctionner une association en participation comme une société occulte.

d) Distinction avec la société occulte « atypique »

La société occulte décrite précédemment (encore souvent appelée société occulte « typique ») doit être distinguée de la société occulte dite « atypique » dans le sens que cette dernière société se caractérise par le fait que l'associé occulte bénéficie de droits excédant ceux qui sont légalement prévus par le Code de commerce (allemand), notamment du fait qu'il participe aux réserves occultes et au ***goodwill*** de l'entreprise à laquelle il est lié, ou encore qu'il a des droits de contrôle plus importants, voire le droit de participer dans les décisions de gestion[3]. Le bailleur de fonds atypique est lui considéré comme un coexploitant ; en tant que tel, il est soumis à l'impôt commercial communal et le droit d'imposition est réparti en fonction de l'article sur les bénéfices des entreprises. En d'autres termes, un bailleur de fonds atypique étranger participant dans une entreprise luxembourgeoise est imposable au Luxembourg.

1 – Bruxelles du 30 novembre 1962, *R.P.S.,* 1964, p. 117, J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.,* 1967, p. 284.

2 – M. R. Theisen et M. Wenz, « Germany », *The Tax Treatment of Financial Instruments. A Survey to France, Germany, The Netherlands and the United Kingdom*, p. 171.

3 – M. R. Theisen et M. Wenz, « Germany », *The Tax Treatment of Financial Instruments. A Survey to France, Germany, The Netherlands and the United Kingdom*, p. 172.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2) La convention de croupier

Aux termes de l'article 1861 C.c., chaque associé a le droit « *sans le consentement de ses associés,* [de] *s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société [...]* ». Une telle convention par laquelle un associé s'associe à un tiers est appelée convention de croupier, et il s'agit en général d'une des variantes des associations en participation qui, pas plus que la société en participation ordinaire, ne doit être confondue avec la notion de prête-nom, cette dernière faisant partie de la notion de simulation. Il s'agit de « *la convention par laquelle une personne qui est associée convient avec une ou plusieurs autres personnes dites croupiers, de partager le bénéfice résultant de ses parts dans cette société, le ou les croupiers restant tiers à l'égard de celle-ci et des autres associés* »[1]. L'association ainsi formée est appelée convention de croupier, parce que le tiers est « *pris en croupe* » par l'associé[2].

Une telle convention peut s'avérer utile dans plusieurs hypothèses : un associé d'une société existante entend associer un tiers à cette société, encore que ce tiers ne soit pas acceptable pour les autres associés, même si ce croupier veut rester inconnu pour des raisons de discrétion.

La convention de croupier s'analyse en un contrat de société par lequel l'associé et le croupier réalisent des apports en vue d'en partager les bénéfices qui peuvent en résulter. Le croupier participe aux décisions relatives à la société principale, encore que l'associé principal reste le seul à mettre ces décisions matériellement en œuvre[3].

Cette société pourrait avoir la forme d'une société civile, ou encore de la société en nom collectif.

Le croupier est un tiers par rapport à la société et n'a aucun droit ni aucune obligation à son égard[4]. Par conséquent, il ne peut prendre part aux délibérations ou exercer le moindre droit de contrôle.

Il pourrait exercer l'action oblique par application de l'article 1166 C.c. En même temps, les autres associés pourraient le contraindre à contribuer aux pertes ou à engager sa responsabilité extracontractuelle pour le cas où il aurait commis une faute leur portant préjudice[4].

Le croupier reste étranger à la société, il ne lui est pas permis de s'immiscer dans les affaires sociales pas plus qu'il ne peut provoquer la dissolution de la société ou le partage du patrimoine social ; « *[…] il peut seulement exercer les droits de l'associé dont il est croupier quant à la part d'intérêt pour laquelle il est associé, ou réclamer comme cessionnaire les droits qui appartiennent au cédant* »[5].

---

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, n° 337.

2 – C. Houpin et H. Bosvieux, *Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales et des associations*, T. 1, n° 180.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 39.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 126.

5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 361.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

3) Points communs et caractères distinctifs des deux types d'association

Les relations entre associés sont régies par les conventions des parties, par leurs conventions particulières. Aucune condition de forme n'est requise pour la validité ou la preuve des associations commerciales. Le contenu du pacte social qui les régit peut être établi par tous les modes de **preuve** admissibles en droit commercial. Il s'agit en quelque sorte de la compensation pour l'absence de personnalité morale dont bénéficient les sociétés commerciales proprement dites[1].

C'est dans les relations avec les tiers que se montre la différence fondamentale entre ces associations. « *Dans l'association momentanée, tous les associés traitent personnellement et directement avec les tiers. Ils acquièrent donc des droits et prennent des obligations pour lesquels ils peuvent actionner et être actionnés* »[2]. *À la question de savoir s'il y a ou non solidarité (question dont la réponse ne va pas de soi), la loi répond clairement par l'affirmative. Tout autre est la situation de l'association en participation : les « participants » (c.-à-d. les associés occultes) ne traitent ni par eux-mêmes ni par mandataires : tous les droits et toutes les obligations naissent dans le chef de celui qui a traité. C'est lui seul qui peut agir contre les tiers ou encore être actionné par les tiers. En revanche, l'action oblique de l'article 1166 C.c. reste possible dans le sens que les créanciers de l'associé qui a traité peuvent exercer les droits que cet associé a contre les participants. De même, le participant, créancier de l'associé qui a traité peut exercer les droits que cet associé a contre les tiers* »[3].

■ § 3 – La société de fait

En premier lieu, il convient de noter certaines difficultés de terminologie.

A – Notion de société de fait

Certains auteurs ont souligné la **multiplicité des sens** que la pratique donne à cette expression de « société de fait » : « *des sociétés momentanées ou en participation, des sociétés commerciales créées en dehors des cadres prévus par la loi commerciale, des sociétés simplement apparentes, des sociétés dont le juge déduit l'existence du comportement des associés, des sociétés n'ayant pas respecté les conditions de forme prévues par la loi commerciale, des sociétés annulées pour vice de fond ou pour vice de forme, des sociétés ayant continué leur activité après l'intervention d'une cause de dissolution et malgré celle-ci, des sociétés en cours de formation mais manifestant déjà leur activité, des sociétés étrangères dissoutes par l'effet d'un décret de nationalisation dans leur pays d'origine, mais dont la succursale en Belgique a une certaine activité et doit être liquidée, des sociétés entre époux ou entre concubins, des sociétés d'un type déterminé affectées d'un vice*

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 311, ID 11308.

2 – E. Pirmez, Commentaire législatif de la loi de 1873, II, 75.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 305, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

les rendant irrégulières comme sociétés de ce type, des sociétés ou associations qualifiées "de fait" parce que dénuées de la personnalité civile »[1].

On ne peut parler de société de fait que si elle présente une **certaine irrégularité**[2]. En droit français, on retient que la société de fait est « *une société qui a fonctionné en dépit d'une cause de nullité* ». Celle-ci serait à distinguer de la société créée de fait, notion qui désigne la situation où « *deux ou plusieurs personnes, sans avoir fondé entre elles une société, se comportent en fait comme des associés* »[2] ou encore, la société créée de fait « *[...] est une société résultant indépendamment de tout acte constitutif, du simple fait que plusieurs personnes se sont comportées comme des associés menant ensemble une activité commune et partageant les bénéfices et les pertes* »[3].

Il a été à juste titre souligné tant en doctrine qu'en jurisprudence luxembourgeoise (où l'on ne procède pas à la distinction entre « société de fait » et « société créée de fait ») que les cas soumis sont en réalité plutôt des « sociétés créées de fait » : il s'agit donc de sociétés ayant fonctionné un certain temps à l'égard desquelles les juges sont appelés à déduire certaines conséquences, notamment quant au partage des bénéfices de la société[4].

Le droit des sociétés était depuis fort longtemps obligé de tenir compte de la réalité des sociétés qui sont irrégulières, par exemple pour la raison qu'elles n'ont pas procédé aux formalités de constitution ou de publication requises par les lois afférentes. Cette solution se doit de tenir compte de la réalité de cette société qui peut pendant de longues années avoir fonctionné de façon apparemment tout à fait normale. « *La société, malgré le vice l'infectant, a un passé. La nullité frappe de mort la société rebelle ; mais puisqu'elle meurt, elle a vécu* »[5].

Il est incontesté que, de façon générale, dans les contrats à exécution successive (contrat de louage, contrat de travail), il n'est pas possible de faire abstraction des faits accomplis et de revenir à l'état antérieur à l'exécution de ce contrat. La nullité de ce contrat ne produit pas d'effet rétroactif. « *Il en sera de même pour le contrat de société, contrat successif, à exécution échelonnée, qui crée une sorte d'état à l'égard des associés. Une société entraîne toute une série d'actes que la loi, pas plus que la volonté des parties, ne saurait annihiler : elle présente un caractère de permanence qui s'y oppose* »[2].

La société de fait est celle qui est constituée involontairement par des personnes qui exercent ensemble une activité commerciale, mais sans avoir adopté une des formes de sociétés prévues par la loi tout en remplissant les conditions de la société[6].

Pour la jurisprudence luxembourgeoise, la société de fait désigne la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés sans avoir exprimé la volonté de former une société (ce qui correspond donc à la conception française de la société créée de fait).

1 – P. Van Ommeslaghe, « Les sociétés de fait », J.T., 1957, p. 709.

2 – *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, V° Société de fait, Société créée de fait.

3 – P. Guiho, *Dictionnaire juridique*, V° Société créée de fait.

4 – En ce sens, v. Fr. Fayot, « Chronique – Droit des sociétés (1997-2002) », *Ann. dr. lux.,* 2001, p. 585.

5 – J. Hémard, *Théorie et pratique des nullités de sociétés et des sociétés de fait*, 2e éd., p. 3.

6 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés. Précis*, p. 175.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Selon la théorie classique, la société de fait est « *un groupement qui :*

1) *présente tous les éléments spécifiques de la société ;*
2) *ne remplit pas les conditions de validité de contrat ;*
3) *a fonctionné pendant un certain temps*[1] ».

Dans une affaire récente, la Cour d'appel devait rappeler que l'*affectio societatis* reste pour la jurisprudence luxembourgeoise un élément essentiel du contrat de société. Le tribunal d'arrondissement avait retenu que deux personnes (A et B) étaient liées par les liens d'association dans une société de fait. Compte tenu de la mésentente entre elles, A avait demandé et obtenu la dissolution et la liquidation de la société de fait sur la base de l'article 1855-5 C.c. Le tribunal avait fait droit à cette demande. La Cour d'appel, pour sa part, devait retenir que la simple collaboration pendant une période prolongée entre A et B n'établit pas qu'il y avait véritable *affectio societatis* entre associés, et donc que l'existence de la société de fait n'était pas établie (ceci d'autant plus que les apports en société et la participation aux résultats n'étaient pas établis à suffisance non plus)[2].

Selon une autre décision : « *On se trouve en présence d'une société de fait si la preuve est faite que les parties avaient entendu se comporter comme tel ou, du moins, avaient inconsciemment cette attitude, à savoir : mise en commun de biens ou d'activités en vue de partager gains et pertes dans l'esprit de collaboration égalitaire appelé* affectio societatis »[3].

La question qui se pose est de savoir quels sont les effets d'une telle société de fait.

B – Régime juridique de la société de fait

La Cour de cassation belge, depuis des décennies, reprend constamment la position de principe adoptée dans deux arrêts de 1968[4] relatifs aux « *sociétés de fait* »[5]. Selon cette jurisprudence constante, il suffit que soient remplies les conditions de l'article 15 L.C.S.C.

1) Effets de la société de fait

Selon cette jurisprudence, une telle société possède nécessairement une personnalité morale distincte de celle de ses associés. Aux termes de ces décisions, plusieurs personnes exerçant ensemble une activité commerciale pour en partager les bénéfices ou les pertes et se présentant comme telles envers les tiers, en particulier en utilisant une raison sociale, constituent entre elles une « *société en nom collectif irrégulière* »[6].

Les conséquences en sont donc les suivantes :

– la société peut être déclarée en état de faillite en tant que telle ;

1 – TA du 22 novembre 1990, n°s 13805 et 13809, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 28 mai 2008, n° 33.368, ID 15894.

3 – CA du 15 février 1984, n° 7547, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cass. b. du 17 mai 1968, *Pas*., I, p. 1074 et du 28 juin 1968, *Pas*., I, p. 1076.

5 – Notamment Cass. b. du 17 mars 1972, *Pas*., I, p. 1074 et du 17 juin 1976, *Pas*., I, p. 1174 et note.

6 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978), *R.C.J.B.*, 1981, p. 285.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– les créanciers de cette société irrégulière peuvent demander sa condamnation et ensuite celle des associés solidairement avec elle. Il est vrai que devra en premier lieu être demandée la condamnation de la société, et ensuite seulement celle des associés. Rien n'empêche que les différentes condamnations soient demandées dans un même exploit et prononcées dans le même jugement.
– Les associés en nom, exploitants du fonds de commerce, ne peuvent solliciter à leur profit une condamnation des débiteurs de la société. « Ceux-ci continuent à faire valoir avec succès qu'ils n'ont pas traité avec les exploitants personnellement, mais bien avec la société comme telle. Il n'y a pas de lien de droit avec les associés et suivant la jurisprudence la plus récente, il s'agit d'une exception au fond et non d'une fin de non-recevoir [...] »[1]. En revanche, si la société entend mettre en œuvre ses droits, elle se voit opposer une fin de non-recevoir tirée de l'article 4 L.S.C. qui dispose que les sociétés commerciales et les sociétés civiles sont à peine de nullité constituées par un acte écrit.

L'irrégularité de la société peut être invoquée même en phase de liquidation de celle-ci. La dissolution maintient la société, sa personnalité morale et les irrégularités qui l'affectent. Ces irrégularités peuvent donc être invoquées même si la société est représentée par son liquidateur[2].

Si un commerce est exploité conjointement et au même titre par deux époux, « *[…] il existe entre eux une association de fait, bien que la firme soit inscrite au registre aux firmes au seul nom de la femme. En conséquence, les deux époux sont tenus solidairement des dettes résultant de l'exploitation du commerce* »[3]. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a rejeté la théorie de l'absence de personnalité juridique (défendue par les demandeurs) ou encore de la personnalité juridique réduite (soutenue en doctrine par Ronse)[4].

« *Que la personnalité morale est la conséquence qu'attache la loi à l'existence d'une société commerciale qui répond à la définition légale et, partant, que son attribution est soustraite à la volonté des associés* ». S'il est vrai que la société en nom collectif doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, il est vrai encore que « *le législateur a attribué un caractère relatif à ladite nullité ; que celle-ci ne peut être opposée aux tiers par les associés et qu'entre associés elle n'opère qu'à dater de la demande tendant à la faire prononcer ; qu'il s'ensuit que l'option entre le rejet et l'acceptation de la société en nom collectif appartient aux tiers sans que la loi ne fasse de distinction entre ceux-ci et non aux associés ; qu'entre ces derniers la société existe aussi longtemps qu'ils n'en demandent pas la nullité* »[5]-[6].

---

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978), *R.C.J.B.*, 1981, p. 289.

2 – Trib. com. Anvers du 24 mai 1972, J.C.B., 1972, I, p. 530, cité par J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978), *R.C.J.B.*, 1981, p. 290.

3 – CA com. du 19 juin 1934, *P.,* n° 13, p. 572, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cass. du 17 mai 1968, *P.,* 1968, p. 1082, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cass. du 17 mai 1968, *P.,* 1968, p. 1083, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – *R.P.D.B.*, T. 12, V° Sociétés, p. 192.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Dans une affaire tranchée par le Tribunal de commerce d'Ostende[1], le débiteur avait d'abord opposé à une action introduite par les associés en nom propre une exception déduite de ce qu'il n'avait pas traité avec eux, mais avec la société. Les associés firent alors constater l'existence entre eux d'une société en nom collectif, et cette société fut alors assignée pour faire valoir ses droits. « *Autrefois, les demandeurs auraient pu opposer une exception déduite de la nullité de la société à l'époque de la naissance de la créance et faire constater celle-ci avec effet rétroactif. Aujourd'hui, selon l'article 13quater nouveau des lois coordonnées, la nullité n'est plus prononcée avec effet rétroactif ; en conséquence les tiers ne peuvent plus opposer à une action intentée par une société régularisée que celle-ci était nulle au moment de la naissance de la créance et que, partant, ils demeurent en droit d'opposer cette exception. À tort aussi, les défendeurs dans l'action soumise au tribunal, faisaient valoir que la société n'aurait acquis son existence qu'à dater de l'acte de régularisation : en réalité, la personnalité morale de la société en nom collectif existe dès sa formation, même irrégulière. De plus, la nullité ne peut être prononcée qu'avec un effet constitutif de droit et l'on en déduit que les conditions requises pour qu'elle soit accueillie doivent exister au moment où le juge statue, suivant le droit commun des jugements constitutifs de droits nouveaux* »[2].

Une société de fait peut exister entre **concubins**. Mais, pour établir l'existence d'une société de fait, il ne suffit pas de constater le fait du ménage commun. Il est nécessaire que soient établies la réalité des apports et la « *volonté de collaborer à un but économique* »[3].

« *Tel est le cas d'un compte bancaire commun alimenté par les deux concubins, les intérêts produits par l'argent étant partagés* »[4].

Pour qu'il y ait société de fait, il faut que les conditions de fond du contrat de société soient remplies, soit donc des apports et la volonté de s'associer en vue d'une activité économique. Pour établir ces conditions, il est insuffisant de prouver le concubinage. Celui qui invoque le contrat de société entre concubins est donc tenu d'en rapporter la preuve, et ceci, indépendamment du concubinage[5].

Selon la jurisprudence, une telle société de fait peut encore exister **entre époux**. Cette possibilité d'une société de fait entre époux mariés sous un régime exclusif de communauté a longtemps été rejetée par la jurisprudence. La raison en était que le contrat de société créerait une indivision que le régime matrimonial ne comporte pas. Dans ce cas, « *il y a incompatibilité entre le droit des sociétés créées de fait et le régime matrimonial lorsqu'un des époux cherche à obtenir sa part ou la plus-value d'une entreprise dont le régime matrimonial réserve la propriété exclusive à l'autre époux* »[6].

1 – Trib. com. Ostende du 12 mai 1977, *R.W.*, 1978-1979, col. 500.

2 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978), *R.C.J.B.*, 1981, p. 293.

3 – CA du 13 mars 1989, *B c/ G., P.*, n° 27, p. 315, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA du 13 mars 1989, *B c/ G., P.*, n° 27, p. 314, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – CA (civ.) du 22 avril 1997, n° 15.816 ; CA (civ.) du 22 octobre 1997, n° 18.905 ; CA (civ.) du 14 novembre 2001, n° 24.466, ID 13860.

6 – CA (civ.) du 31 janvier 2001, *R. c/ N., P.,* n° 32, p. 202, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Dans un cas d'espèce soumis aux juridictions, la jurisprudence a retenu l'absence de société de fait dans le cas où le futur époux devait construire une maison destinée à servir de domicile conjugal sur le terrain de sa fiancée. La cour d'appel a argumenté comme suit : « *L'existence d'une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports quelle que soit leur forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et* l'affectio societatis.

Or, en l'espèce la mise en commun de moyens pour la construction d'une maison s'explique par le projet de mariage des parties, la maison à construire devant servir de domicile conjugal, et non par la volonté de réaliser et de partager un quelconque bénéfice au sens de l'article 1382 C.c. L'esprit de lucre qui caractérise la société fait défaut en l'occurrence »[1].

2) Effets d'une telle société à l'égard des tiers

Lorsqu'une telle société de fait a fonctionné pendant un certain laps de temps, la question se pose de savoir quelles sont les conséquences de l'absence de caractère régulier de celle-ci à l'égard des tiers, et parmi ces derniers, en premier lieu les créanciers. La jurisprudence retient une solution très protectrice des intérêts de ces tiers dans le sens suivant : « *Un tiers créancier d'une société de fait a en effet le choix d'opter ou non pour la validité de la société qu'il peut considérer comme existante bien qu'elle soit irrégulière [...]* »[2].

La situation ressemble donc à celle que l'on connaît en matière de simulation. Les tiers se voient attribuer la **possibilité d'opter**, en fonction de leurs intérêts, soit pour la réalité soit pour l'apparence. Cette solution se fonde sur l'article 1321 C.c. selon lequel les contre-lettres ne peuvent avoir d'effet *contre* les tiers ; la jurisprudence en déduit que ces contre-lettres peuvent avoir des effets *en faveur* de ces tiers, ce qui revient donc à accorder aux tiers le choix entre la réalité et l'apparence. L'apparence est une société en bonne et due forme ; la réalité est une société irrégulière, une société de simple fait.

Dans quelle mesure cet article est-il applicable en matière de constitution de société ? Pour certains, la réponse à cette question dépend de la théorie à la base de la conception de la société. La Cour d'appel de Bruxelles[3] a ainsi, semble-t-il, retenu la conception contractuelle pour décider que l'acte constitutif de la société serait un contrat auquel les règles de la simulation seraient applicables. Cette interprétation n'est pas partagée par une partie de la doctrine qui écarte l'article 1321 C.c. sur la base de l'analyse que l'acte constitutif ne serait pas un contrat, car résultant d'engagements unilatéraux des fondateurs adhérant à l'institution que constitue la société[4].

1 – CA du 27 octobre 2004, *S. c/ R., P.,* n° 32, p. 619, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA du 22 novembre 1990, n°s 13.805 et 13.809, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA Bruxelles du 16 mars 1965, *R.P.S.,* 1966, p. 196.

4 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978), *R.C.J.B.*, 1981, p. 233.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La question qui se pose dans ce contexte est la suivante : cette société de fait (qui en tant que telle s'oppose à la « société de droit ») bénéficie-t-elle de la personnalité morale ou non ? La jurisprudence semble répondre par l'affirmative : « *La société en nom collectif irrégulière constitue comme la société en nom collectif régulièrement constituée, une individualité juridique distincte de celle de ces associés. Il en résulte que des créanciers de la société irrégulière peuvent demander sa condamnation et ensuite celle de ses associés solidairement avec elle, et cela, dans le même exploit* »[1].

En matière commerciale, la **preuve** est libre. En matière civile, les actes juridiques doivent, au-delà d'un montant de 2 500 euros, être établis par écrit, du moins à titre de preuve. Ceci vaut pour les parties à l'acte. Pour les tiers, les actes juridiques sont des faits juridiques à leur égard qui peuvent donc être prouvés par toutes voies de droit[2].

S'il existe une société irrégulière, c'est celle-ci qui doit agir en justice en défense de ses intérêts. Une action qui serait introduite par des associés qui agiraient ut singuli ne saurait être accueillie[3].

« *Lorsque, dans les conditions ci-dessus, une association de fait est dans le cas de produire à l'égard des tiers tous les effets d'une société en nom collectif, elle ne possède cependant pas, en réalité, la personnalité civile et ne peut conséquemment pas, comme telle, ester en justice* »[4].

Un arrêt de la Cour d'appel du 20 mai 2009[5] a infirmé un jugement de première instance qui avait retenu une société de fait dans le cas de l'acquisition d'un terrain en vue de la réalisation d'un projet immobilier. La Cour a retenu que les éléments caractéristiques de la société de fait doivent être établis séparément et qu'ils ne peuvent se déduire les uns des autres. En particulier, l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier sans rechercher si les parties avaient l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune. La Cour arrêta que le fait de vivre en commun pendant cinq ans et d'avoir acquis en commun un terrain en vue de la construction d'un immeuble n'établit pas l'existence de cette société. En l'occurrence, le terrain avait été acheté en commun et en indivision à concurrence de la moitié pour chacun.

Ceci suppose que chaque indivisaire finance la moitié du terrain, ce qui en l'occurrence n'était pas le cas, étant donné que A a fait cadeau à son concubin B de la moitié du prix d'achat de 3 500 000 Flux en supportant la charge de l'intégralité du prix d'achat.

---

1 – TA Lux. du 22 novembre 1990, n°s 13805 et 13806, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 128.

3 – Cour de Bruxelles du 23 janvier 1958, *Jur. comm. Brux.,* 1958, p. 311 ; J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.,* 1967, p. 321.

4 – CSJ du 26 février 1901, *P.,* n° 5, p. 517, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – CA (civ.) du 20 mai 2009, n° 34.091, ID 15892.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 4 – Les conséquences de l'absence de personnalité morale

En raison de leur caractère purement contractuel, les associations commerciales (au sens de la L.S.C.) n'ont pas de patrimoine propre. « *[…] les biens sont communs à tous ou propres à certains associés, d'après leurs droits originaires ou les effets des conventions avenues entre associés, dans l'association en participation, les biens sont en principe la propriété du gérant* »[1].

Du fait de l'absence de personnalité morale, les associés n'ont de droits et d'obligations qu'envers les co-associés, et non envers la société[2].

En même temps, ces sociétés n'ont ni créancier, ni débiteur : ce sont seulement les associés qui sont débiteurs (créanciers). Ces associés subissent donc le concours de leurs créanciers personnels avec ceux de la société. Les créanciers sociaux sont ceux qui ont contracté avec un associé ou un gérant ayant pouvoir d'engager les autres associés. Ils peuvent exercer leur recours sur l'ensemble des biens faisant partie de la propriété collective.

A – L'absence de personnalité morale en droit comparé

En droit des sociétés luxembourgeois, l'absence de personnalité morale est exceptionnelle. Des sociétés sans personnalité morale sont beaucoup plus fréquentes dans d'autres États, notamment en Belgique, en Allemagne ou en Suisse, voire dans les pays anglo-saxons où les « *partnerships* » sont souvent dénués de personnalité morale.

Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que la notion de personnalité morale n'a pas le même contenu dans tous les pays. Ainsi, en droit allemand, la société civile (appelée *BGB-Gesellschaft*) est dotée d'une quasi-personnalité. La même chose vaut pour la société simple du droit suisse[3].

B – La reconnaissance internationale de la personnalité morale

La **convention de La Haye** du 1er juin 1956 sur la reconnaissance des personnes morales prévoit la reconnaissance de la personnalité juridique acquise à l'étranger par une société, une association ou une fondation. En plus de définir les conditions auxquelles est subordonnée la personnalité juridique, elle énumère encore les circonstances qui justifient le refus de la reconnaissance et réglemente les effets du transfert de siège[4]. Cette convention n'est jamais entrée en vigueur et, avec l'extension de l'Union européenne, son adoption est devenue tout à fait illusoire.

Sur le plan du droit européen, on peut encore citer la convention de Bruxelles du 29 février 1968.

Cette convention n'est jamais entrée en vigueur pour ne pas avoir été signée par les Pays-Bas[5], seul pays parmi les six États membres fondateurs attribuant la

1 – *R.P.D.B.,* T. 12, Vº Sociétés, p. 213.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés,* T. 2, p. 77.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 30.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 172.

5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 159. V. encore J. Renauld, « La reconnaissance mutuelle des sociétés dans le Marché commun », R.P.S., 1968, pp. 207 ss.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

nationalité des sociétés sur la base du lieu de constitution. Un certain nombre de **conventions bilatérales** ont été conclues à l'effet de reconnaître mutuellement la personnalité juridique des entités des deux États en présence.

■ § 5 – Les modifications des associés dans la société

Les changements dans la composition des associés de la société peuvent conduire à la dissolution du contrat de société. La jurisprudence admet qu'en cas de changement majeur selon les faits du cas d'espèce il y a **novation**[1]. En principe, la cession par un associé de sa position contractuelle n'entraîne pas la dissolution du contrat de société ou la conclusion d'un nouveau contrat de société[2].

■ § 6 – Gestion et prise de décision

Ce genre de sociétés n'a pas d'organe au sens juridique du terme[2]. Il peut néanmoins y avoir dissociation entre la gestion et les décisions dépassant le cadre de cette gestion. Un gérant auquel la gestion de la société est confiée peut être appointé.

Les décisions qui excèdent la gestion quotidienne relèvent de la compétence des associés et sont prises en principe à l'unanimité, sauf possibilité pour le contrat de société de prévoir des majorités allégées[3]. En application de l'article 1859 C.c. : « *les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit conclue* ».

Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire l'un sans l'autre tous les actes de cette administration (art. 1857 C.c.). Par conséquent, chaque gérant dispose du pouvoir de gérer seul la société comme s'il n'y avait pas d'autre gérant[4].

Traditionnellement, on analyse le **contrat de gestion** comme un contrat de mandat ou un contrat de louage d'industrie. La qualification de la fonction de gérant en un mandat s'imposerait notamment en présence d'une convention distincte relative aux actes matériels. « *Toutefois, si le gérant a pour mission de représenter les associés mais également d'accomplir toutes les tâches de gestion interne, administrative, comptable ou commerciale, il s'agit d'un contrat mixte comportant à la fois un louage d'industrie et un mandat. Tel est notamment le cas lorsque les associés confient à un tiers la gestion et l'ensemble des tâches qu'ils ne peuvent accomplir eux-mêmes aisément* »[5].

L'opposition qui peut être exercée par un des associés ne signifie pas qu'il puisse définitivement faire obstacle à un acte que la majorité jugerait utile. En décider autrement reviendrait à faire prévaloir la volonté de la minorité sur celle de la majorité[6].

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 75.
2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 78.
3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 79.
4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 152.
5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 146.
6 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 143.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La disposition de l'article 1859, alinéa 1, C.c. est de nature supplétive, de sorte que les associés peuvent soit écarter ce droit de veto, soit l'accorder uniquement à certains associés, soit encore le limiter à certaines catégories d'actes[1].

Les associés ont encore un pouvoir de contrôle sur la gestion de la société et, en tout cas, lors de la reddition des comptes annuels. En outre, chaque associé a un droit individuel de contrôle, droit qui s'exerce notamment par la possibilité de pouvoir prendre connaissance des livres et des documents sociaux[2].

Le gérant associé statutaire est dans une situation spéciale dans la mesure où, en application de l'article 1856, alinéa 1er C.c., « *l'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude* ».

Les associés non gérants ne peuvent donc pas s'opposer au gérant statutaire, car une telle opposition porterait atteinte à un élément essentiel du contrat de société. Il est vrai que, dans la mesure où ces autres associés seraient en droit de révoquer cet associé statutaire, ils peuvent également prendre la mesure moins lourde qui consisterait à s'opposer à l'opération en question avant qu'elle ne soit conclue[3].

Le champ d'application de l'article 1856, alinéa 1er, est en tout état de cause limité dans le sens que le gérant ne peut pas excéder ses pouvoirs ni agir frauduleusement. Si l'une de ces hypothèses est remplie, les associés retrouvent leur droit d'opposition.

En principe et sauf disposition contraire des statuts, le gérant statutaire associé ne peut être **révoqué** sans cause légitime (art. 1856, alinéa 2, C.c.). Cette solution s'écarte du principe de la révocation *ad nutum* du mandataire. La signification en est que la décision de révocation peut être prise sans préavis, sans justification et sans indemnité[4]. « *La référence à un simple signe* ("ad nutum") *évoque le geste par lequel le spectateur des jeux du cirque pouvait d'un signe décider de laisser ou non la vie au gladiateur vaincu. Un droit de vie ou de mort, en quelque sorte [...] L'image est évocatrice et restitue bien le caractère discrétionnaire de la décision de mettre fin aux fonctions de direction* »[5].

Le fait qu'une indemnité substantielle correspondant à six mois de préavis (51 048,60 euros) est allouée à un administrateur en cas de révocation par la société est-il de nature à restreindre ou àentraver la faculté de révoquer librement l'administrateur ? Le tribunal d'arrondissement avait jugé par l'affirmative en annulant la clause d'indemnité. La Cour d'appel devait juger différemment en retenant qu'il n'est pas établi que l'indemnité en question ait pu influencer la décision de la société anonyme[6].

Quelle est la situation quand le gérant est un **gérant statutaire** ? En général, on entend par là « *le gérant nommé par les associés dans l'acte de société* ». En pratique, il est très fréquent que les fondateurs d'une S.à r.l., après avoir adopté l'acte de société dans une première étape, désignent un gérant par une assemblée des associés tout

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 144.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 79.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 154.

4 – Cass. com. fr. du 21 juin 1988, Bull. Joly, 1988, p. 687.

5 – D. Ferrier, « La liberté du commerce et de l'industrie », *Libertés et droits fondamentaux*, Paris, Dalloz, 2005, p. 698.

6 – CA du 28 mai 2008, n° 33.550, *BIJ,* 2008, n° 8.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de suite après la formation de la société. « *S'agit-il d'un gérant statutaire par le fait que la désignation fait matériellement corps avec l'acte constitutif ?* »[1]. Selon la jurisprudence belge, un gérant serait statutaire, spécialement protégé contre les révocations *ad nutum*, si la désignation du gérant apparaît comme une condition de la constitution de la société, par analogie avec les règles appliquées en matière de sociétés de personnes[2]. « *Il s'agit donc là du fil conducteur qui permettra de rechercher la volonté réelle des parties sans s'attacher uniquement à la forme dans laquelle cette volonté serait exprimée* ».

Ce principe est **d'ordre public** (tel que rappelé par la Cour d'appel de Mons[3]) ou encore impératif, mais non d'ordre public selon des décisions isolées[4]. Par conséquent, s'il est exclu de convenir d'une indemnité avec les administrateurs pour le cas où ils seraient révoqués « *rien n'interdit, une fois la révocation prononcée, de convenir librement avec eux d'une indemnité ou de confirmer une convention antérieure à ce sujet, dont la nullité se trouve ainsi couverte. La nullité est en effet relative* »[5].

Ce principe s'oppose également à ce que les fonctions d'administrateurs puissent faire l'objet d'un contrat de travail. « *Le cumul dans le chef d'une même personne de ces fonctions avec la qualité d'employé n'est admissible que si le contrat de travail a pour objet d'autres activités, de nature technique, commerciale ou administrative, et que le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, existe entre l'administrateur et la société pour l'exercice de ces fonctions distinctes* »[6]. La jurisprudence belge a retenu que les fonctions de gestion journalière assumées par l'administrateur délégué ne sont pas indivisibles des fonctions d'administrateur en constatant que « *l'administrateur peut être chargé de la gestion journalière sous l'autorité d'un organe de la société* »[7].

Dans l'esprit des auteurs du Code civil, cette solution était justifiée de la manière suivante : si, par le contrat de société, la gestion est confiée à un des associés « *cette marque de confiance a été ou a pu être pour celui-ci le motif de son association* »[8]. En outre, les autres associés se sont peut-être associés en raison de la personnalité du gérant choisi.

La Cour de cassation belge a confirmé qu'il n'existe aucune impossibilité légale pour un administrateur d'être en même temps employé pour la société[9]. « *L'autorité caractéristique du contrat d'emploi peut être exercée soit par le conseil lui-même, soit par une personne déléguée par lui à cet effet* »[10].

---

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978), *R.C.J.B.*, 1981, p. 419.

2 – J. van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. II, 1re éd., n° 930.

3 – CA Mons du 16 octobre 1984, *R.P.S.,* 1985, p. 48.

4 – CA Bruxelles du 24 mars 1960, *R.P.S.*, 1961, p. 167, qui retient que cette règle étant destinée seulement à protéger des intérêts privés était impérative, mais non d'ordre public. La Cour de cassation belge, par décision du 13 avril 1989, vient de confirmer sans hésitation que la règle est d'ordre public, en mettant ainsi fin à cette controverse.

5 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1967, p. 335.

6 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 749.

7 – Cass. b. du 28 mai 1984, *Pas*., 1984, I, p. 1172.

8 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 158.

9 – Cass. b. des 24 mars 1964 (*Pas*., I, p. 418) et 4 mars 1965.

10 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le droit de révocation des dirigeants, pour autant qu'il ait jamais été un droit discrétionnaire, ne l'est plus, en tout cas plus tout à fait. La révocation ne doit pas être utilisée pour porter atteinte à l'honneur et à la réputation des dirigeants. Tel est le cas notamment si la révocation est brutale ou encore si elle s'accompagne d'injures ou de comportements grossiers.

La révocation du gérant statutaire associé donne lieu à des difficultés : sa révocation exige la **modification des statuts** ; celle-ci demandant l'unanimité, une révocation ne peut en pratique s'opérer que par décision du tribunal[1].

La révocation est « *ad nutum* », même si les administrateurs ont été nommés par les statuts (« *ils sont toujours révocables par l'assemblée générale* » (art. 441-2, alinéa 5, anc. art. 51 alinéa 5 L.S.C.)). C'est pour ces cas-là qu'elle est la plus importante: « *[...] lorsque la nomination est faite par les fondateurs, que presque toujours ils se désignent eux-mêmes pour remplir les fonctions d'administrateurs et que c'est précisément contre les manœuvres coupables qui auraient été commises dans la constitution de la société et qu'ils auraient intérêt à celer, que les actionnaires ne doivent pas être désarmés* »[2].

■ § 7 – Participation aux bénéfices et aux pertes

Le contrat de société définit dans quelle mesure chaque associé a droit aux résultats sociaux. En cas de silence du contrat de société, la répartition se fait en application des règles du Code civil, donc proportionnellement aux apports[3]. L'exclusion d'un associé de toute participation aux bénéfices sociaux entraîne la nullité de la société[1]. Une telle clause léonine n'est donc pas seulement réputée non écrite, même s'il est vrai qu'il en va différemment pour les sociétés de capitaux couvertes par la Première directive en matière de droit des sociétés.

Le contrat de société peut prévoir la limitation de la responsabilité d'un associé à son apport, possibilité dont il est fréquemment fait usage dans les associations en participation. À défaut de telle clause, les participants sont tenus au-delà de leur mise[4]. Dans une telle hypothèse, les engagements des autres associés sont augmentés d'autant en répartissant le surplus de pertes sur les associés restants[5].

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 159.
2 – Commentaire législatif de la loi belge de 1873, II, 48. Nyssens, p. 183.
3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 80.
4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 87.
5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 88.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE III
LES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ

Le droit des sociétés ne connaît pas de définition propre de la notion de société, pas plus que le droit européen d'ailleurs. La définition de la société provient du droit civil (art. 1832 C.c.) et, selon la définition originale de 1804, la société suppose que plusieurs personnes mettent quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices qui peuvent en résulter. Cette définition nous permet de dégager les éléments caractéristiques du contrat de société : des personnes, les associés (Section I), des apports mis en commun (Section II), dans un but déterminé, le but lucratif (Section III).

SECTION I
LES ASSOCIÉS

La société est un groupement de personnes.

■ § 1 – Identité des associés de la société

Qui peut être associé d'une société ? La réponse dépend dans une certaine mesure de la nature de la société. Les associés des sociétés de personnes, du moins ceux qui sont indéfiniment responsables, sont commerçants, condition qui est de nature à limiter le cercle des personnes éligibles. Il faut donc être majeur capable pour devenir associé de cette catégorie de sociétés. Les associés peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Les personnes morales sont donc éligibles pour devenir associés des sociétés. Ceci vaut même pour les sociétés dites « de personnes », telles que les sociétés en nom collectif. Rien n'empêche donc que deux S.à r.l. unipersonnelles, le cas échéant avec le même associé, forment entre elles une société en nom collectif (ou encore une société en commandite simple).

Les conjoints peuvent être associés de la même société, le cas échéant, ils peuvent être les seuls associés.

A – La société formée entre époux

La seule disposition du droit des sociétés consacrée à ce sujet était celle de l'article 181 L.S.C. qui prévoyait que : « *Les époux peuvent valablement intervenir comme associés dans les sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, à condition que le contrat de société ne modifie pas les effets du régime matrimonial des époux. – Dans ce cas la société pourra même être formée par le mari et la femme, comme seuls associés* ». Cette disposition a été supprimée par la Loi de Modernisation.

B – Incompatibilités pour certaines personnes

Le statut de certaines professions (essentiellement les professions libérales classiques, telles que médecins, notaires, avocats, etc.) interdit à leurs

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

membres d'exercer leur activité sous forme de sociétés commerciales. Il est vrai que ces professions ont tendance à se départir de cette approche traditionnelle en permettant à leurs membres de suivre la tendance générale de la société qui consiste à exercer les activités économiques exclusivement sous forme de société et, en particulier, de société comportant la responsabilité limitée pour leurs membres.

La question se pose de savoir si les sociétés peuvent exercer les **activités de profession libérale**. En premier lieu, il convient de distinguer les sociétés professionnelles proprement dites de celles qui sont des sociétés de moyens. Ces dernières se limitent à fournir à un ou plusieurs titulaires de profession libérale les **moyens** d'exercer leur activité : les locaux, le personnel, etc.

Quant aux sociétés professionnelles proprement dites, la situation est qu'une société dotée de la personnalité morale peut exercer l'activité d'une profession libérale. Ce n'est pas en effet la société qui exerce elle-même la profession, mais elle se limite à coordonner l'activité qui est personnellement exercée par les titulaires de la profession qui en assument personnellement l'activité[1]. Cet objet est compatible avec la nature de la personne morale[2].

Au sujet de la définition de la notion de profession libérale : « *La cour [de Liège du 31 mars 1976] considère que l'objet défini ci-dessus rentre dans les limites de l'entreprise d'agence ou de bureau d'affaires défini par l'article 2 C.com. Les ingénieurs-conseils offrent leurs services à autrui, sans lien de subordination et contre rémunération ; ils sont donc commerçants. Les ingénieurs-conseils ne peuvent être rangés, notamment à défaut de traditions et d'organisation professionnelles comparables à celles des médecins, des avocats ou des architectes, parmi les titulaires de professions libérales* »[3].

■ § 2 – Pluralité des associés de la société

Sous l'influence du droit européen, la définition de la société, telle que comprise à l'article 1832 C.c., a connu une extension dans le sens que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1992, une société peut encore être constituée « *dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d'une personne qui affecte des biens à l'exercice d'une activité déterminée* ». L'article 1832 du Code civil belge a connu en substance la même modification « *par un acte juridique d'affectation de biens émanant de la volonté d'une seule personne* ».

L'extension de la notion de société (traditionnellement toujours un contrat) à la **société unipersonnelle** conduit à une difficulté terminologique, à savoir l'utilisation des notions de « sociétés » et d'« associés ». Ces notions sont en fait incompatibles avec la société unipersonnelle. Néanmoins, la pratique parle de « société unipersonnelle » tout comme elle fait référence à « l'associé unique ». Nous nous rallions à ces conventions de langage.

La société unipersonnelle a été introduite dans la loi nationale par le biais d'une directive européenne ; en effet, la **Douzième directive** (applicable depuis 1989) en

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 179.

2 – J. van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, n° 390.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 227.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

matière de droit des sociétés, prise afin de favoriser le développement des petites et moyennes entreprises, a imposé aux États membres l'organisation d'un véhicule à responsabilité limitée qui, dès sa constitution et au cours de toute son existence, peut n'avoir qu'un seul associé.

Au Luxembourg, cette faculté n'existait qu'à l'égard de la seule société à responsabilité limitée, mais elle a été étendue à la société anonyme[1].

Par application *a contrario* de ces dispositions de droit européen, on peut conclure que, si une société anonyme passe à un seul associé par réunion de toutes les actions en une seule main, la Douzième directive ne s'applique pas[2]. Toutefois, conformément à cette Douzième directive, la réunion de toutes les actions (de société anonyme et de société en commandite par actions) ne peut plus entraîner la dissolution automatique de ce genre de société(s). Autrefois donc, avant l'entrée en vigueur de cette directive, la réunion de toutes les actions en une seule main constituait un moyen bien commode pour procéder à la dissolution des sociétés par actions. Une telle réunion de toutes les actions en une seule main comportait nécessairement l'annulation du contrat de société par confusion.

Cette réunion n'avait en fait pour effet que d'entraîner la dissolution, mais non la clôture de la liquidation par le transfert du patrimoine, activement et passivement, à l'associé unique. Un arrêt de la Cour de cassation belge devait rappeler que la réunion de toutes les actions entre les mains d'un associé unique n'entraînait **pas la clôture de la liquidation** à l'égard des créanciers sociaux[3]. Dans une telle situation d'associé unique, ce dernier exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il peut donc à tout moment décider de clôturer la liquidation de la société et de transférer le patrimoine dans le sien « *par l'effet d'une transmission universelle analogue à celle qui se produit en cas de fusion* »[4].

Cette position semble rejoindre la pratique luxembourgeoise qui procède fréquemment à ce qu'on appelle la « **dissolution simplifiée** » de la société. Elle consiste dans le fait qu'une personne déclare devant notaire qu'elle a acquis toutes les actions de la société à dissoudre, qu'elle décide la dissolution de la société sans passer par une liquidation formelle et que le passif de la société est soit réglé, soit dûment provisionné et que, finalement, elle reprend à sa charge tout passif de la société qui éventuellement serait inconnu à ce moment-là. La liquidation de la société peut donc être considérée comme faite et clôturée[5]. Dans l'affaire citée, la Cour considéra qu'il y avait transfert de la créance de la société liquidée à son actionnaire, du fait de la liquidation : « *Par l'effet de l'acte notarié, l'entreprise des Postes et Télécommunications s'est vu céder – à un moment où la société Sat-Com S.A. a encore existé – l'actif, et partant la créance de celle-ci vis-à-vis de la société United Continent Lines. Il n'y a pas de disposition légale prescrivant que cette cession de créance au profit d'un établissement public se fasse conformément aux articles 157 et suivants de la loi sur les sociétés, articles régissant la fusion entre sociétés anonymes* ». Cet arrêt fait suite à un autre arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 28 mars 1996 où celle-ci a arrêté : « *Si, selon l'article 141 de la susdite loi [...] les sociétés commerciales sont,*

1 – Loi du 25 août 2006, ID 9590.

2 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés. Précis*, p. 34.

3 – Cass. b. du 22 mars 1962, *Pas*., 1962, I, p. 808.

4 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B*., 1965, p. 384.

5 – CSJ com. du 20 février 2002, n° 137/02, *BIJ*, 2003, n° 1, p. 9.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation, en l'espèce l'être moral n'avait même pas à survivre pour les besoins d'une liquidation et d'un partage entre les associés qui n'existaient plus. C'est en effet la propriété même des biens composant le fonds social qui selon les stipulations de l'acte de dissolution s'est trouvée directement acquise par "l'associé unique" qui est ainsi devenu le débiteur du passif social en tant qu'acquéreur des biens composant le fonds social [...] le patrimoine tout entier de la personne morale comportant l'ensemble du passif et de l'actif [...] s'est trouvé transféré »[1]. En l'occurrence, le patrimoine de la société comportait bien des dettes, la cession de dettes requérant en principe l'accord du créancier. La Cour ajoute expressément que cet accord du créancier n'est pas requis : « *sans même que soit nécessaire l'accord du créancier* ».

Tel n'est plus le cas actuellement : en effet, conformément à ladite directive, même en cas de réunion de toutes les actions de la société en une seule main, la dissolution de la société **doit être prononcée** par le juge tout en accordant à l'associé la possibilité de régularisation.

En application de l'article 5 de la Deuxième directive, la dissolution entraîne la liquidation de la société. Hors du champ d'application de la Douzième directive (donc en dehors de la société à responsabilité limitée et des sociétés par actions), la conception contractuelle de la société est fermement maintenue. En d'autres termes, la constitution d'une société requiert deux associés au moins (sauf évidemment si la loi requiert un nombre plus élevé) et la réunion de toutes les parts en une seule main comporte la dissolution de plein droit de la société. Telle est donc la situation applicable aux sociétés de personnes, aux sociétés coopératives[2], etc.

Les biens des associés constituent une indivision volontaire, mais non soumise aux règles de droit commun de l'indivision[3].

La question qui s'est posée est celle de savoir si les titres qui sont en **indivision** doivent ou non être pris en considération pour la détermination du nombre minimum d'associés dans la société. Les droits des titres en indivision sont suspendus, de sorte qu'aucun des indivisaires n'a le droit d'exercer les prérogatives d'actionnaires. Selon la jurisprudence, seuls doivent être comptés les associés qui peuvent être considérés comme associés effectifs. Si donc il ne reste que six actionnaires en dehors des titres indivis, alors la dissolution devra être prononcée sans qu'il faille avoir égard à la possibilité d'un partage de ces titres indivis et à l'effet rétroactif du partage[4]. Cette solution n'a pourtant pas été étendue au cas de transmission de titres à cause de mort[5].

Il en allait de même pour les sociétés anonymes avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 avril 1983 : la société était dissoute tant à l'égard des associés qu'à l'égard des tiers. La question qui restait ouverte était de savoir si, à la suite de la dissolution, la liquidation était automatique ou bien s'il fallait encore procéder à des opérations de liquidation proprement dites. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la société même dissoute garde la personnalité morale avec donc un patrimoine séparé de

1 – CA du 28 mars 1996, n° 15.351, ID 10136.

2 – Il est à noter que ce genre de sociétés requiert sept associés au moins.

3 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés. Précis*, p. 285.

4 – Cass. b. du 22 novembre 1951, *Pas*., 1952, I, p. 153 ; J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1966-1971) », *R.C.J.B.*, 1973, p. 517.

5 – Cass. b. du 15 mai 1970, *Pas*., I, p. 810.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

celui du ou des associés. On a fait valoir que le maintien de la personnalité morale serait destiné à **éviter l'état d'indivision** entre les associés, ce qui serait de nature à porter préjudice à la situation des créanciers dans le sens que ceux-ci devraient assigner plusieurs associés plutôt que d'assigner uniquement la société[1].

Il est encore à noter que la jurisprudence considère que cet article doit être interprété de façon littérale dans le sens qu'il ne s'applique pas aux sociétés civiles. Ces dernières, une fois la liquidation prononcée, ne sont donc plus dotées de la personnalité morale. À partir du jour de la dissolution, les anciens associés se trouvent donc en indivision. Les relations existant entre les anciens associés doivent donc s'organiser sur la base des règles du mandat, et non plus sur la base des règles concernant la dissolution et la liquidation des sociétés[2].

SECTION II
LES APPORTS

Du point de vue terminologique, on peut noter que la notion d'apport désigne soit l'opération consistant à transférer des biens à l'entreprise, soit l'objet de l'apport. Les apports, utilisés dans le deuxième sens de ce terme, entrent dans le patrimoine de la société au moins lorsque celle-ci a la personnalité morale, ce qui est le cas général au Luxembourg, mais pas nécessairement dans d'autres États. En l'absence de personnalité morale, les biens sont seulement mis à disposition de l'ensemble des associés[3] ou encore des gérants de la société[4].

L'opération doit être envisagée de façon tout à fait différente selon que la société a ou n'a pas la personnalité morale. Le premier cas fera l'objet des développements étendus qui suivent. Il suffit de dire à cet endroit que ce cas se traduit par un transfert de propriété entre l'associé et une autre personne, la société.

Le deuxième cas de figure est celui où l'entité bénéficiaire n'est pas dotée de la personnalité morale ; tel est le cas de la société en participation, de la société momentanée ou encore de la S.e.c.-Sp. Faute de personnalité morale de l'entité bénéficiaire des apports, il n'y a pas de transfert de propriété, mais transformation d'une propriété exclusive sur le bien de l'apporteur en une **copropriété indivise**. L'apporteur ne se défait pas de l'entièreté de sa propriété, à l'instar du vendeur, mais il conserve la part indivise dans la chose. Il abdique la propriété exclusive en retenant un droit de copropriété[5]. L'acquisition de cette copropriété doit se faire selon les règles concernant les obligations, la copropriété étant une propriété (art. 711 C.c.).

Chaque société suppose des apports (voir article 1832 C.c.) ; à cet égard, il est d'ailleurs indifférent que la société soit d'origine contractuelle ou qu'elle soit unipersonnelle. L'apport consiste donc à mettre à disposition soit de la société, soit de l'ensemble des associés (si la société n'a pas de personnalité morale) certains éléments de patrimoine qui se trouvent ainsi soumis aux aléas sociaux.

1 – J. Delvaux, A. Wildgen et R. Breininger, « La réunion de tous les titres d'une société anonyme en une seule main »,. Ann. dr. lux., Vol. 2, 1993, p. 103.

2 – CA (civ.) du 20 avril 2005, n°s 28.560, ID 10331.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 363.

4 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 107.

5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 258.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Est exclu comme apport le crédit politique, ce qui était déjà conforme à la position de Pothier qui considérait une telle convention comme nulle, car contraire à l'honnêteté politique[1]. Telle ne fut pas la position en droit romain : « *Les Romains reconnaissaient, outre les biens ou l'industrie, une troisième sorte de mise, le crédit et la faveur,* gratiam. *On ne peut écrire ces mots sans honte que dans les États corrompus, où l'on trafique de tout, même de la puissance publique* »[2].

On distingue la souscription d'un apport qui est la **promesse d'apporter** un bien à la société, de la libération de l'apport qui est l'exécution de la promesse et qui comporte la dépossession effective au profit de la société bénéficiaire de l'apport[3].

En contrepartie de l'apport fait à la société, l'apporteur reçoit des droits sociaux, matérialisés par des parts sociales qui, parfois, sont désignées par le terme d'actions (S.A. et S.e.c.a.). Dans ce contexte se pose la question de l'évaluation des apports : « *[...] le contrat d'apport n'étant en réalité qu'un contrat de vente, dans lequel le prix des choses apportées est payé en titres, au lieu d'être payé en espèces, c'est aux intéressés qu'il appartient de déterminer librement, comme dans toute convention, les conditions de leur engagement. L'apporteur, comme tout vendeur, s'efforce de retirer des choses qu'il met en société le prix le plus élevé qu'il peut en obtenir, et l'évaluation qu'il en fait est d'autant plus considérable qu'il n'est rémunéré qu'en papier et que pour faire argent de sa mise il faut qu'il trouve à placer lui-même les titres qui lui ont été donnés en paiement. [...] Cette liberté des évaluations, la loi nouvelle ne la modifie en rien. Elle se borne à prohiber pendant deux exercices sociaux la négociation des titres par les voies commerciales et encourage ainsi le bénéficiaire des titres d'apport à conserver pendant un certain temps un intérêt dans la société qu'il a contribué à créer et à ne pas mettre immédiatement à la charge du public les risques de l'entreprise* »[4].

Par le passé, il a été soutenu que l'apport est un contrat à part au sens de l'article 1101 C.c., même s'il s'agit d'un contrat accessoire au contrat de société[5]. Cette thèse est de nos jours écartée au motif qu'il est inexact et contraire à la volonté des parties de décomposer la constitution d'une société en une série de contrats[6]. L'étude des apports exige l'introduction de plusieurs distinctions qui ont trait aux catégories d'apports que l'on rencontre en pratique.

Il s'agit de la distinction entre :

- apports en propriété, apports en jouissance et en usufruit ;
- apports en numéraire et apports en nature ;
- apports purs et simples ou apports à titre onéreux ;
- apports représentatifs du capital et apports non représentés par le capital social.

§ 1 – Apports en propriété, apports en jouissance et en usufruit

Plusieurs questions se posent à cet égard. En premier lieu, les associés ont-ils droit à la récupération de leur apport ? La réponse est négative dans le sens que

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 146.

2 – Gillet, Discours n° 6, Exposé des motifs, cité par Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 146.

3 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés. Précis*, p. 227.

4 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, Carton de Wiart, p. 302.

5 – L'article 1844-3 du Code civil français parle ainsi du contrat d'apport.

6 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 366.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

le bien apporté entre dans l'actif social et, à la dissolution, le fonds commun sera partagé. « *L'associé est débiteur envers la société de la propriété de la chose et, étant débiteur, il ne saurait être créancier. La société n'a donc aucune obligation de ce chef envers l'associé* »[1].

La question qui se pose dans ce contexte est de savoir quelle est la nature des droits qui sont apportés : il peut d'abord s'agir de la **propriété** (la pleine propriété) sur les biens qui font l'objet de l'apport. À l'instar d'une vente, l'apport transfère la propriété à la société bénéficiaire[2]. Pour que ce transfert de propriété soit valablement fait, notamment à l'égard des tiers, les formalités de transfert doivent être accomplies en fonction de la nature des biens. Pour les immeubles, il s'agit des transcriptions aux registres de l'administration de l'enregistrement et au cadastre ; pour les marques et brevets, de l'inscription sur les registres des brevets ; pour les titres nominatifs de sociétés, de l'inscription au registre des titres de société (registres des actions ou parts) et pour les titres au porteur, de l'inscription auprès du dépositaire désigné, etc.

Pour être en présence d'apports, susceptibles de donner lieu à une société entre les auteurs des apports, il est nécessaire que ces apports soient soumis aux aléas sociaux. Cette condition s'applique tant aux apports en propriété qu'à ceux faits en jouissance. Selon un arrêt de la Cour de cassation belge, lorsque les apports sont faits en jouissance, le risque porte sur la rémunération de la jouissance transférée à la société[3]. Selon cet arrêt, il n'y avait en l'occurrence pas d'apport en jouissance, dans la mesure où la redevance pour la mise à disposition du terrain (faite par un actionnaire) était calculée en fonction des terrains mis à disposition des campeurs : la redevance était due même s'il n'y avait aucun terrain qui ait pu être loué à des campeurs[4].

En principe, l'apporteur doit à la société les mêmes garanties qu'un vendeur, notamment la garantie contre les **vices cachés**.

En échange des apports faits à la société, les apporteurs obtiennent en principe la pleine propriété sur des titres émis par la société. La plupart du temps, ces titres sont d'une nature différente des biens apportés. Par exception, ces titres peuvent avoir la même nature, lorsque les biens apportés sont également des titres représentant le capital d'une société.

Dès l'apport des biens à la société, ceux-ci sont à ses risques et deviennent sa pleine propriété. L'apporteur ne peut en principe jamais récupérer ces biens : même en cas de **clause de reprise des biens,** il n'est pas sûr que les biens en question feront encore partie du patrimoine de l'entreprise au moment de la liquidation de cette dernière[5].

En cas **d'apport en jouissance**, l'associé continue à avoir la propriété du bien et la société use et jouit de ce bien. C'est au moment de la dissolution que cesse le

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 280.

2 – TA du 14 juillet 1989, n° 296/89, « Lorsque l'apport en société est un bien corporel, droit réel, l'apporteur est dans la situation d'un vendeur et les principes de la vente sont applicables dans les rapports de l'apporteur avec la société », cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cass. b. du 5 septembre 1961, *Pas*., 1962, I, p. 29.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 598.

5 – R. J. Pothier et R.J. Bugnet, *Œuvres de Pothier*, Vol. IV, *De la Société*, p. 280 ss. ; P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 117.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

droit de la société sur la chose et que l'associé reprend tous ses droits. L'associé peut demander la restitution de l'objet apporté par lui. La société est débitrice d'un corps certain avec la conséquence qu'on lui applique les règles régissant les dettes de choses déterminées[1].

Si la loi parle de **l'apport en jouissance,** elle entend que la société n'aura qu'un simple droit de jouissance sur les fruits, et non un usufruit. En effet, l'usufruit, en tant que droit réel, est soumis aux mêmes règles que le droit de propriété, avec donc la conséquence que la mise de l'usufruit se fait immédiatement.

Il convient encore de distinguer selon que les biens apportés sont des corps certains ou des choses fongibles. Dans le premier cas de figure, l'apporteur qui a reçu des titres de société, représentatifs du capital social, a droit à la restitution des biens apportés. Étant resté propriétaire de la chose apportée, l'apporteur est certain de récupérer les biens, même si les créanciers de la société n'ont pas été payés. L'apport en jouissance peut être limité dans le temps : dans ce cas, la restitution se traduira par une réduction du capital[2].

Dans le cas d'apport en jouissance, la participation aux pertes peut consister dans l'absence de toute rémunération de la jouissance[3].

Dans la pratique luxembourgeoise, les apports en jouissance sont peu utilisés. La question se pose de savoir quelles sont les formalités qui devraient être accomplies dans l'hypothèse où un actif donné est apporté en jouissance et si, au moment où les créanciers entendent se saisir du bien, il leur sera expliqué que le bien est la propriété de l'associé. Le problème est identique à celui que l'on rencontre à l'égard de la saisie des biens donnés en leasing.

L'apport en jouissance peut encore porter sur des **biens fongibles** : dans ce cas de figure, la société bénéficiaire de l'apport devient propriétaire des biens apportés et est simplement tenue de restituer l'équivalent en fin de contrat[4]. La différence par rapport au cas d'apport en jouissance est donc que l'apporteur subit le risque d'insolvabilité de la société.

L'apport en **usufruit** est celui par lequel l'apporteur transfère à la société l'usufruit d'un bien tout en en conservant la nue-propriété. La question est de savoir si cette façon d'agir est une modalité de l'apport en jouissance. Cette question est controversée en doctrine[5]. En théorie juridique pure, on devrait retenir que le droit d'usufruit confère un droit réel. L'apport en nue-propriété est en quelque sorte l'opération inverse : l'usufruit est détenu par une autre personne, en général, mais pas nécessairement, l'apporteur. Économiquement, ces deux droits réels ont une consistance tout à fait différente. Si la nue-propriété du bien s'apprécie avec le temps (du moins, s'il porte sur un bien non amortissable), la valeur de l'usufruit, du fait de son caractère limité dans le temps, se déprécie en principe. Le capital qui correspond à un apport en usufruit est l'exemple type d'un apport destiné à disparaître avec le temps[2].

En application de l'article 619 C.c., la durée de l'usufruit ne peut excéder trente ans s'il n'est pas accordé à des particuliers.

---

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 284.

2 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 117.

3 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 289.

4 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., pp. 116 et 117.

5 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés. Précis*, p. 230.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 2 – Apports en numéraire, apports en nature et apports en industrie

Cette distinction en trois catégories provient de l'article 1833, alinéa 2, C.c. qui énumère les apports en argent, en nature (« d'autres biens ») et en industrie. Cette terminologie était aménagée pour les sociétés de capitaux, pour lesquelles, sous l'influence du droit européen, on parlait d'« apports en numéraire » et d'« apports autres qu'en numéraire »[1].

La Loi de Modernisation a procédé à une modification de terminologie en remplaçant la notion « d'apport ne consistant pas en numéraire » par celle « d'apport en nature », et ceci, pour des raisons de précision terminologique. La subdivision ancienne en « apport en numéraire » et « apport autre qu'en numéraire » masque le fait qu'il y a en cette matière une division non pas en deux catégories d'apports différentes, mais en trois : « apports en numéraire », « apports en industrie » et « apport en nature ». En utilisant la terminologie « apport en numéraire » et « apport autre qu'en numéraire », l'apport en industrie glisse dans cette deuxième catégorie, alors qu'il connait un régime juridique bien différent : si les apports en nature peuvent servir à libérer le capital social souscrit (le cas échéant, en faisant l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises indépendant), il en va autrement des apports en industrie qui ne peuvent servir à cette fin.

A – Les apports en numéraire

En général, et du moins dans la pratique luxembourgeoise, l'apport est en numéraire, donc en espèces. Dans ce cas, l'apport est fait en un instrument de paiement ayant cours légal au Luxembourg, donc en euros. En doctrine belge, on ajoute « *ou dans une unité monétaire d'un État membre de l'OCDE* »[2]. Ceci soulève la question de savoir si un apport en une devise autre que l'euro est à qualifier d'apport en nature[3]. La position au Luxembourg semble être que tel est le cas ; en pratique, ceci signifie donc que, le cas échéant, un rapport de révision est à établir. Tel est le cas pour les sociétés par actions.

En pratique, les fonds apportés en numéraire ne seront pas remis sur la table devant le notaire au moment de la constitution de la société, mais la somme correspondante sera transférée sur un compte bancaire bloqué jusqu'au moment de la signature de l'acte de société. La banque auprès de laquelle le compte bancaire est ouvert émet un ***certificat de blocage***, certificat qui est remis au notaire. Ce dernier est ainsi à même de vérifier que l'argent déposé en compte bancaire est toujours disponible en compte au moment de la constitution de la société. Ce compte ne sera débloqué qu'au moment où l'acte de formation de la société est signé par les associés (ou l'associé unique). Cet acte sert à débloquer le compte bancaire et permet aux organes de gestion de la société de disposer librement de l'argent déposé en compte.

En pratique, le notaire, dès la signature de l'acte, émet un **certificat** dit **de déblocage** qui est remis à la banque et qui sert donc à « débloquer » le compte bancaire dont l'argent se trouve à la disposition des dirigeants de la société.

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 373.

2 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés. Précis*, p. 227.

3 – Louis, J.-V., « Le franc belge n'est plus requis dans les actes publics et administratifs », J.T., 1991, p. 669.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'acte de société précise la composition de l'apport fait à la société. Lorsqu'il y a constitution par acte notarié, ce qui correspond au cas général, le notaire sera responsable de vérifier la composition et la valeur des apports, et en particulier devra-t-il s'assurer que la valeur des apports faits est au moins égale à la valeur nominale (pair comptable) des titres émis en contrepartie de ces apports.

B – Les apports en industrie

Par apport en industrie (donc l'apport de la force de travail), on entend « *l'engagement d'exercer une activité personnelle ou de prester certains services au profit des associés ou de la société* »[1]. Cet engagement doit comporter d'autres activités que celles qui résultent de l'exécution par chaque associé de ses droits d'associés, notamment sous la forme de participation aux assemblées d'associés[2]. Si la plupart des autres catégories d'apport comportent une obligation de donner, l'apport en industrie consiste en une obligation de faire (ou de ne pas faire) et, à ce titre, il se réalise de manière successive. L'apport en industrie comporte un caractère d'*intuitu personae* très marqué, avec comme conséquence qu'il ne peut être effectué par une autre personne et également que les parts émises en contrepartie d'un apport en industrie sont **considérées comme incessibles**[3]. La notion d'*intuitu personae* a toutefois évolué au fil du temps, et ceci, en faveur de la notion d'*intuitu firmae*[4] qui fait prévaloir les caractéristiques de l'entreprise de l'associé.

C – Les apports en nature

Il est évident que les apports en nature donnent lieu à des problèmes d'évaluation qui sont inconnus en matière d'apports en espèces. De tels apports ont toujours été la source de maints scandales financiers, de sorte que le législateur s'est préoccupé de trouver des systèmes destinés à éviter des surévaluations parfois fantaisistes de ces apports qui ont permis à certains de s'enrichir de façon scandaleuse tout en causant la ruine d'autres personnes souvent modestes et crédules. « *Les fraudes les plus colossales, les plus scandaleuses, se sont produites dans les estimations des apports. La pratique a révélé des majorations incroyables : des usines en ruine, des forêts inexploitables, des mines épuisées, sises en France ou à l'étranger, des brevets d'invention périmés ou sans valeur, des concessions précaires, révocables, etc., etc., ont été apportés pour des sommes énormes et payées en actions [...] Le prix exagéré des apports et la non-vérification de leur valeur sont des manquements autrement graves que le versement incomplet du quart. Dans ce dernier cas, le vice est réparable, et a pu ne pas causer de dommages, si on suppose que la société a reçu les fonds quelques jours après, qu'il y a eu simple retard. Au contraire, dans l'autre cas, c'est une tromperie sur la chose vendue, c'est un vice irréparable, dès que l'estimation une fois faite ne peut plus être contestée, ou lorsqu'elle a été éludée : c'est un préjudice certain qui pèse sur tout l'avenir de la société* »[5].

---

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 376.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 377.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 377. ; A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 57.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés* tés, T. 2, p. 65.

5 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 130, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'évaluation des apports en nature est en premier lieu une question **d'arrangement contractuel** entre associés. À cet égard, c'est en principe la liberté contractuelle qui s'applique. Les associés évaluent librement la valeur des apports et, par conséquent, la part de chacun dans la société[1]. Cette évaluation lie en principe définitivement les associés[2], étant entendu qu'en cas de vice du consentement, cette estimation peut être remise en question conformément au droit commun des contrats. La notion de **lésion** de plus de sept douzièmes (art. 1674 C.c.), qui permet d'annuler un contrat de vente, n'est pas applicable en cas d'apport[3].

Toutefois, cette évaluation comporte également un autre aspect qui met en jeu les relations avec les créanciers, donc des tiers par rapport à la société. À leur égard, toute surévaluation des apports conduit à rendre le capital au moins partiellement fictif en réduisant ainsi le gage des créanciers de la société et en le portant à un montant inférieur à celui que les statuts et les comptes annuels le laissent croire aux tiers. Pour cette raison, une procédure de contrôle des apports en nature est mise en place dans les sociétés de capitaux afin justement d'éviter ce genre d'effets négatifs.

Dans ce contexte, on peut noter qu'à ce jour aucun système entièrement satisfaisant n'a pu être trouvé. Ainsi a-t-on pensé à confier aux tribunaux une mission de vérification de l'évaluation des parties. En France, cette idée a été repoussée : « *Ce seraient les experts ou le tribunal homologuant qui deviendraient les arbitres de la formation ou de l'avortement de la société ; or nous voulons les sociétés anonymes libres sous le respect de la loi* »[4]. On redoutait que, de cette manière, on réintroduise une **autorisation gouvernementale** pour la création de la société anonyme, autorisation qui existait sous le Code de commerce, mais entre-temps abolie partout.

1) Consistance des apports en nature

L'apport en nature (en pleine propriété) rend la société propriétaire du « bien » au sens de l'article 1832 du Code civil. Ce bien peut être un bien corporel ou incorporel. Il peut s'agir donc de biens d'équipement, d'immeubles, de brevets, de marques de fabrique, de titres de sociétés, de créances, etc. Dans tous ces cas, les biens doivent faire l'objet d'une évaluation qui soulève des problèmes inconnus en cas d'apports en numéraire. En principe, l'apporteur doit également apporter à la société la garantie des vices cachés (voir cependant ci-dessus au sujet de la garantie des vices cachés sur les créances et les titres).

Les apports en nature peuvent porter sur toutes choses possibles et imaginables à condition qu'elles ne soient pas hors du commerce, qu'elles soient susceptibles d'évaluation en argent ainsi que d'une réalisation forcée[5].

Selon la forme de la société, l'évaluation par un réviseur d'entreprises indépendant peut être requise. Tel est le cas des sociétés par actions, mais non des sociétés à responsabilité limitée, solution peu logique au demeurant (mais maintenue par

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 375.

2 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial,* T. 1, 1re édit., p. 234.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 376.

4 – Exposé des motifs cité par A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 124, ID 11305.

5 – A. Schwachtgen, « Le contrôle des apports en capital au Luxembourg », *Vennootschapsrecht in EG-perspectief*, Berlin, Springer, 2001, p. 201.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la Loi de Modernisation) dans la mesure où, dans les deux types de sociétés, la garantie de la réalité du capital social revêt une importance fondamentale pour les créanciers.

Si, au moment de la reprise en droit national des dispositions de la directive concernée, il a été considéré que les S.à r.l. devraient être soumises aux mêmes règles que la société anonyme, on a par la suite changé d'avis dans le sens qu'on a estimé que pour les S.à r.l., souvent constituées avec le capital minimum (de 500 000 francs à l'époque), la charge consistant à payer un réviseur d'entreprises pour évaluer les apports en numéraire serait excessive et entamerait de manière substantielle les fonds propres de celle-ci[1]. D'où la solution consistant à ne pas exiger l'établissement d'un tel rapport de révision.

Pour les S.à r.l., l'obligation de l'intervention d'un réviseur d'entreprises a existé de mai 1983 à mai 1988 dans la mesure où l'article 184 L.S.C. rendait applicables aux S.à r.l. les dispositions de l'article 27 L.S.C. : « *Malheureusement, sous la pression des milieux artisanaux ainsi que des petites et moyennes entreprises qui invoquaient le coût trop élevé à leurs yeux de tels rapports, le Gouvernement luxembourgeois a fait voter par la loi du 28 avril 1988 un amendement de l'article 184 précité qui prévoit désormais que les dispositions de l'article 27 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve de celles se rapportant au capital social et à l'intervention d'un réviseur d'entreprises dans la spécification des apports autres qu'en numéraire* »[2]-[3].

Si l'on ne peut dénier tout mérite à ce raisonnement, cette solution est loin d'être logique. En premier lieu, il faut retenir que les S.à r.l. ne sont pas nécessairement de petites sociétés, pas plus que les S.A. ne sont toujours des sociétés importantes. En effet, il existe de petites S.A. et de grandes S.à r.l. Il eût donc été préférable de décider qu'une société de capitaux dépassant une certaine taille a besoin d'une procédure de rapport de révision (p. ex., critères requis pour avoir besoin d'un réviseur d'entreprises). En outre, il faut reconnaître que, dans la perspective de la protection des tiers (des créanciers), la nécessité de contrôler les apports en nature est aussi importante pour les S.à r.l. que pour les S.A.

2) Cas particulier des « apports de créance »

La notion d'apport de créance n'est pas dénuée d'ambiguïté. Elle peut concerner une créance sur un tiers. Le cas visé est celui où une personne possède une créance sur la société X et qu'elle décide d'apporter cette créance à une autre société, la société Y, contre émission de titres de la société bénéficiaire. Dans le chef de la société Y, il y a évidemment apport, et il va sans dire que les formalités de vérification des apports en nature doivent être suivies. Si la situation financière de la société débitrice est difficile, la créance ne pourra pas être apportée à sa valeur nominale.

Le deuxième cas de figure est celui où la créance que possède A est détenue sur la société débitrice Y. En d'autres termes, A apporte sa créance sur Y au patrimoine

1 – *Doc. parl.*, n° 2960, Exposé des motifs, p. 3, ID 9810.

2 – A. SCHWACHTGEN, « Le contrôle des apports en capital au Luxembourg », *Vennootschapsrecht in EG-perspectief*, p. 202.

3 – *Mém.* A 24 du 27 mai 1988, p. 516.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de Y. Une des façons de présenter cette opération consiste à dire qu'après l'opération d'apport, Y sera détenteur d'une créance sur lui-même. On aura donc :

Actif	Passif
Créance 1000	Dette 1000

On peut considérer que, dans ce cas, il y a simple confusion des qualités de créancier et de débiteur, de sorte que, par confusion, la dette et la créance disparaissent.

La doctrine belge semble considérer que la libération d'un apport en espèces par la voie d'une compensation légale avec une créance de l'actionnaire contre la société est licite, puisqu'elle équivaut à un double paiement sans que l'objet de la souscription ne se trouve modifié[1]. Pour plus de détails, voir p. 147 ci-après.

3) Apport d'un fonds de commerce

Un fonds de commerce comporte des dettes. L'apport d'un tel fonds de commerce (comportant donc tant des éléments actifs que passifs) à une société commerciale (donc dotée d'une personnalité morale distincte de celle des associés) implique ainsi « *une stipulation pour autrui acceptée par la société en faveur des créanciers de l'apporteur* »[2].

En application de ce concept, la société s'engage à payer les dettes à décharge de l'apporteur. De leur côté, les créanciers bénéficiaires de la stipulation pour autrui peuvent agir contre la société, mais tout en conservant le droit d'agir contre l'apporteur[3]. Les conséquences sont identiques en cas de fusion de sociétés, par exemple, sauf mesures spécifiques déchargeant l'apporteur de son obligation.

Dans une affaire tranchée par la Cour d'appel d'Anvers[4], un créancier avait assigné les fondateurs d'une société au motif qu'ils avaient fait l'apport à la société d'un fonds de commerce dont le passif excédait l'actif (au lieu d'une valeur positive de 2,5 millions résultant de l'acte constitutif, il présentait une valeur négative de 6 millions de francs). Cet apport étant fictif, la responsabilité solidaire des fondateurs fut retenue. Cet apport avait été réalisé en 1956 par transformation d'une S.p.r.l., étant entendu qu'à cette époque cette transformation était inconnue en droit belge et qu'elle impliquait donc la dissolution de la société transformée et l'apport de son actif et de son passif à une société nouvelle constituée pour les besoins de l'opération. La Cour de Bruxelles rejeta l'action du créancier en argumentant que la constitution était antérieure à la loi du 30 juin 1961 et que la loi belge ne sanctionnait pas la surévaluation des apports en nature par une responsabilité particulière des fondateurs. « *La Cour*

1 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 645 – J. Van Ryn. Principes de droit commercial, T 1,1re éd., p. 338.

2 – Il en est ainsi en raison de l'interdiction de céder des dettes sans l'accord du créancier, voir J. van Ryn/P. van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence (1961-1965), *R.C.J.B.*, 1965, p. 295.

3 – J. van Ryn/P. van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence (1961-1965), *R.C.J.B.*, 1965, p. 295.

4 – Cour d'Anvers du 13 septembre 1976, *R.P.S.* 1976, p. 131.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de Bruxelles confondait ainsi l'apport manifestement surévalué avec l'apport fictif, c'est-à-dire complètement inexistant, pour lesquels les lois coordonnées prévoyaient dès avant 1961 la responsabilité des fondateurs envers tout tiers intéressé ».[1]

4) Dispositions nouvelles quant au contrôle des apports en nature

La loi du 10 juin 2009 sur les fusions transfrontalières, en faisant fruit d'une option accordée par les articles 10*bis* et 10*ter*, paragraphes 1 et 2, de la directive 77/91/CEE, a introduit (par un nouvel alinéa 3*bis* de l'article 26-1 nouv. art. 420-10 (4) L.S.C.) deux entorses à la règle générale qu'il faut un rapport de réviseur pour tous les apports en nature qui sont faits à des sociétés par actions.

– En premier lieu, il s'agit du cas d'apport de valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) de la directive 2004/39/CE ou d'instruments financiers ou d'instruments du marché monétaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19) de cette directive « *lorsque ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) de ladite directive au cours d'une période de 6 mois précédant la date effective de l'apport autre qu'en numéraire* ». La loi précise que, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire (art. 26-1, 3*bis*, L.S.C. nouv. art 420-10 (4) L.S.C.).
– En deuxième lieu, les apports d'actifs autres qu'en numéraire et autres qu'en valeurs mobilières ou instruments monétaires visés à l'alinéa 3*bis* (nouv. art. 420-10 (4) L.S.C.) qui ont fait l'objet d'une **évaluation à la juste valeur** par un réviseur d'entreprises, à condition que :

a) la juste valeur soit déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport ;
b) l'évaluation ait été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus au Luxembourg pour le type d'élément d'actif constituant l'apport.

Dans ce cas également, si des circonstances nouvelles ont sensiblement modifié la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation peut être effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire (art. 26-1, 3ter, L.S.C.). En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son rapport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire. Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises (ce qui rend applicables les dispositions normales d'évaluation des apports en nature).

1 - CA Anvers du 13 septembre 1976, *R.P.S.*, 1976, p. 131.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– Lorsque, sur décision du conseil d'administration (directoire), l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments autres qu'en valeurs mobilières et autres qu'en instruments du marché monétaire dont la **juste valeur est tirée des comptes légaux de l'exercice financier précédent**, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE (art. 26-1, 3*quater* L.S.C.). En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son rapport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire. Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises (ce qui rend applicables les dispositions normales d'évaluation des apports en nature).

Au cas où la société entend utiliser ces simplifications légales, certaines formalités sont requises, qui sont destinées à suppléer à l'absence d'un rapport de révision en bonne et due forme. Celles-ci sont prévues par l'article 26-1, 3*quinquies*, L.S.C. Il s'agit d'une publication au RESA, etc., portant sur les éléments suivants : description de l'apport, sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation, une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale, etc. des actions à émettre en contrepartie de cet apport, une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l'évaluation initiale n'est intervenue (article 420-10 (7), anc. article 26-1, alinéa 3*quinquies*).

Ces mesures de simplification, tout en témoignant de bonnes intentions, ne sont pas sans soulever d'importantes difficultés pratiques soulignées par la doctrine à laquelle nous renvoyons ici[1]. Ainsi le « prix moyen pondéré » de valeurs traitées en bourse peut être très difficile à établir. En outre, il apparaît que, si l'on veut bénéficier de ces dispositions de simplification, il n'est pas possible de faire le transfert à une valeur inférieure au prix moyen pondéré (alors qu'une telle évaluation ne peut qu'être bénéfique aux tiers, notamment aux créanciers).

■ § 3 – Apports purs et simples et apports à titre onéreux

Traditionnellement, la théorie des droits d'enregistrement distingue entre les notions d'apport pur et simple et d'apport à titre onéreux. Finalement, il peut y avoir apport mixte, et ceci, dans le cas où les apports d'un associé sont pour partie purs et simples et pour partie à titre onéreux.

A – Définition de la notion

Comme indiqué ci-dessus, il y a apport pur et simple lorsque celui-ci est rémunéré par des droits sociaux, c.-à-d. des droits dont la valeur est soumise aux aléas sociaux. Ainsi, l'associé qui apporte une somme de 100 000 euros à une société de capitaux et qui, en contrepartie, reçoit des actions d'une valeur nominale équivalente procède à un apport pur et simple.

1 - I. Corbisier et D. Burbi, *Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009*, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 36 ss.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Par apport à titre onéreux, on entend un apport en rémunération duquel l'apporteur reçoit, en dehors des droits sociaux, des valeurs qui ne sont pas soumises aux risques de l'entreprise. Cette notion est en fait assez ambiguë. À strictement parler, un apport à titre onéreux, donc une opération qui à la fois comporte un apport proprement dit (encore dénommé apport pur et simple), et une opération qui est rémunérée par des valeurs certaines, est pour partie un apport et pour partie une opération étrangère à tout apport (par exemple, une vente), puisque rémunérée autrement que par des droits sociaux. Ainsi, si un apport est rémunéré en partie par des liquidités (l'associé reçoit donc en dehors de titres, émis par la société bénéficiaire, de l'argent liquide, par exemple dans le cas où il s'agit d'un apport en nature), alors il y a apport à titre onéreux.

En réalité, un apport à titre onéreux n'est en fait pas un apport, mais une opération **d'aliénation ordinaire** qui reçoit le qualificatif d'apport pour la simple raison qu'elle est accompagnée par une seconde opération qui elle est un apport pur et simple de biens à une société. À la limite, c.-à-d. si l'opération d'apport à titre onéreux n'est plus rémunérée par des titres, il n'y a plus d'apport du tout, mais une simple opération d'aliénation (une vente en général).

L'opération d'**apport mixte** reflète la même notion, à savoir un transfert de biens à la société qui est pour partie rémunéré par des titres de société (apport pur et simple) et pour partie rémunéré par des valeurs certaines (opération d'aliénation). Les notions d'apport à titre onéreux et d'apport mixte sont donc en fait équivalentes.

Après avoir défini la notion, nous allons préciser très brièvement le régime d'imposition qui en résulte.

B – Imposition des apports à titre onéreux

Dans la mesure où il y a apport à titre onéreux, il y a assujettissement aux droits fixés par le tarif des droits proportionnels d'enregistrement (loi du 7 août 1920) pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature que ceux apportés. Cette règle est entièrement justifiée : le fondement en est à trouver dans le fait qu'il convient d'appliquer le régime fiscal qui correspond à la nature de l'opération effectuée.

L'apport à titre onéreux comporte par définition que les biens apportés à la société connaissent deux sortes de contreparties à savoir, d'une part, des droits sociaux et, d'autre part, des valeurs certaines soustraites aux aléas sociaux. Dans une telle situation, il se pose un problème d'imputation dans tous les cas où les biens apportés sont soumis à des régimes d'imposition différents au regard des droits d'enregistrement.

En effet, dans l'hypothèse où des apports de 1000 sont faits (dont la moitié à titre onéreux) et que des droits d'enregistrement de x % sont dus sur cette partie des apports, alors que tel n'est pas le cas sur l'autre moitié, il se pose un problème d'imputation des deux catégories d'actifs au regard des titres représentatifs de ces apports[(1)].

Depuis l'abolition du droit d'apport sur le plan de l'Union européenne, par la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 transposée en droit national par la loi du 19 décembre 2008, cette matière est régie par les articles 5 et suivants de ladite loi. Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2009.

1 – Pour plus de détails, v. J.-P. Winandy, *Fiscalité et comptes annuels des entreprises*, Luxembourg, Portalis, 2005, p. 959.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 4 – Réalisation des apports

Il y a lieu de distinguer entre l'engagement d'effectuer un apport à la société et l'exécution de cet engagement. S'il est vrai que ces deux opérations sont souvent réalisées simultanément, tel n'est pourtant pas nécessairement le cas.

A – Engagement d'apporter et exécution de l'engagement

Pour les sociétés de capitaux, cette matière est strictement réglementée par la loi : on parle de **souscription du capital** (contrepartie de l'engagement de faire un apport) et de la **libération du capital** (qui en est l'exécution). Selon le cas, l'exécution de l'engagement doit être immédiatement réalisée pour la totalité ou, alternativement, il suffit de l'exécution partielle de cet engagement suivie d'une exécution retardée pour le solde.

Pour les sociétés de personnes et les sociétés civiles, aucune disposition n'est prévue à cet égard. En général, l'exécution est faite au moment de la prise de l'engagement, en dehors du cas de l'apport en industrie pour lequel l'exécution est successive[1].

Le Code civil (art. 1846) prévoit en revanche les conséquences pécuniaires en cas de versement tardif par l'associé promettant : les sommes non versées portent intérêt, et ceci, sans nécessité de mise en demeure. Cette disposition constitue donc une entorse au droit commun en matière civile, dans la mesure où, dans cette matière, la règle est que les intérêts ne courent qu'à partir d'une mise en demeure (art. 1153 C.c.). Il est à noter que les associés ne peuvent être assignés par les créanciers sociaux en application de l'article 1400-1 (anc. art. 152) L.S.C. qu'après avoir obtenu une condamnation de la société.

B – Libération du capital social par compensation de créance

En droit luxembourgeois, il existe une controverse doctrinale (et notariale) ancienne sur le sujet de la possibilité de libérer les actions par compensation avec une créance sur la société ayant émis ces actions. Pour éviter d'emblée tout malentendu, précisons que le cas qui pose problème est celui où l'actionnaire (qui a souscrit des actions) détient une créance sur la société émettrice (et non pas sur un tiers) : si l'actionnaire de la société A possède une créance sur la société B et apporte cette créance à la société A pour libérer les actions souscrites de la société A, alors il y a apport en nature (avec obligation de produire un rapport d'un réviseur d'entreprises certifiant que la valeur de cet apport est au moins équivalent à la valeur nominale des titres émis en contrepartie). Cette conclusion n'est en fait contestée par personne, et la situation est identique dans nos deux pays voisins ayant des affinités certaines avec notre droit des sociétés, à savoir la Belgique et la France.

Le cas qui pose problème est celui où C possède une créance sur la société A et qu'il entend libérer les actions souscrites au moyen de cette créance qui disparaît ainsi.

Certains praticiens (des notaires, p.ex.) ont considéré que, du fait que la valeur réelle de cette créance ne serait pas nécessairement identique à sa valeur nominale

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 365.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

(pour raison d'une mauvaise situation financière de la société débitrice) et afin d'éviter la fictivité du capital social, il y aurait lieu d'avoir recours à l'évaluation de cette créance par un réviseur d'entreprises.

Cette approche n'a pas fait l'unanimité et a notamment été contredite par Henri Hellinckx[1] qui explique d'abord que la libération de l'augmentation de capital par un créancier de la société A détenant une créance sur cette même société A peut se faire de deux façons différentes, à savoir soit par **confusion**[2] soit par **compensation**[3]. Lorsque la créance de C sur A est apportée à A, celle-ci devient part de son actif, et elle devient créancier envers elle-même : il y a donc confusion. « *L'obligation de vérification de la valeur de cet apport, conformément aux dispositions de l'article 26-1, semble ici inévitable* »[4].

En revanche, si la créance est liquide et exigible, il y a compensation : la créance de C sur A disparaît de plein droit par compensation. Pour l'auteur cité, la différence entre ces deux cas de figure est que, dans le premier cas, il y a apport en nature (rendant donc nécessaire l'intervention d'un réviseur d'entreprises) alors que, dans le deuxième cas, il n'y a pas à proprement parler d'apport[5]. L'auteur continue à analyser la situation en droit français et en droit belge pour conclure que, si en France la compensation est certainement admise comme mode de libération des actions souscrites et qu'elle ne constitue pas un apport en nature, la situation est différente en Belgique où toute constitution de société ou augmentation de son capital suppose que l'apport destiné à libérer les actions souscrites soit déposé en compte spécial, ce qui signifie que tout ce qui est apporté sans pouvoir être déposé en compte spécial est à considérer comme apport en nature et doit faire l'objet d'un rapport de réviseur.

En outre, H. Hellinckx fait valoir que la **conversion d'obligations convertibles** en actions n'était pas considérée comme un apport en nature et, au vœu de l'article 32-4 L.S.C. de l'époque, échappait à l'évaluation par un réviseur d'entreprises. Il est vrai que l'intervention du réviseur d'entreprises était requise au moment de l'émission des obligations convertibles. La Loi de Modernisation a d'ailleurs expressément confirmé ce point en retenant dans son alinéa 3 (nouv. article 420-27 alinéa 3) que : « *La conversion d'obligations convertibles est à considérer comme un apport en numéraire libérable par compensation avec une créance sur la société et sera soumise aux mêmes conditions qu'un tel apport* ». Le commentaire des articles justifie cette solution par le fait que, tant en droit français qu'en droit belge, la conversion d'obligation est considérée comme un apport en numéraire[6].

Dans le contexte de la discussion à propos de la nécessité d'un contrôle par un réviseur d'entreprises, il convient de ne pas perdre de vue que l'élément de la protection des tiers (qui est la justification essentielle du contrôle des apports en nature)

1 – H. Hellinckx, « Les difficultés de qualification de la libération du capital par incorporation de créances réciproques en droit des sociétés luxembourgeois », *BDB*, n° 9, 1986, pp. 25 ss.

2 – Art. 1300 C.c. « *(1) Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint la créance […]* ».

3 – Art. 1289 C.c. « *Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés* ».

4 – H. Hellinckx, *op. cit.*, p. 26.

5 – H. Hellinckx, *op. cit.*, p. 27.

6 – *Doc. parl.*, n° 5730/00, Commentaire des articles, Ad 21) Article 32-4, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

n'entre guère en ligne de compte. En effet, si C détient une créance sur la société A et que cette créance est convertie en capital, alors la situation des créanciers restants s'améliore du fait de ce « *downgrade* » subi par un des créanciers qui vient d'endosser la qualité d'actionnaire et qui cesse ainsi de faire partie des actionnaires de la société. L'obligation du contrôle par un réviseur peut donc paraître une formalité inutile qui ne répond à aucun besoin réel.

C – Apports faits en fraude aux droits de tiers

Parfois, des débiteurs aux abois réalisent des apports en société pour soustraire les biens apportés aux poursuites de leurs créanciers. Ceci suppose en premier lieu qu'il y ait eu appauvrissement du débiteur du fait de l'apport. Tel n'est le cas que si le patrimoine du débiteur a été diminué en raison de cette opération d'apport. En principe, cette condition n'est pas réalisée pour la raison que les titres qui sont entrés dans le patrimoine du débiteur apporteur ont *a priori* la même valeur que les biens apportés à la société, en tout cas s'il n'y a pas de sous-évaluation caractérisée des biens apportés. « *Toutefois, il faut tenir compte non du "bilan théorique du patrimoine", mais des possibilités concrètes des créanciers d'obtenir le paiement : elles dépendent notamment de la négociabilité des titres reçus en contrepartie* »[(1)].

Les créanciers disposent de plusieurs moyens pour se défendre contre de telles opérations frauduleuses : lorsque l'apport a été réalisé pendant la période suspecte, le curateur peut agir en inopposabilité de ces opérations (en application des articles 435 et suivants du Code de commerce). Les créanciers individuellement ou collectivement peuvent introduire une action en **déclaration de simulation** qui, si les conditions de la simulation sont réalisées, peut conduire à l'annulation de l'opération simulée au profit de l'opération réellement voulue par les personnes en présence.

Ils peuvent écarter l'apparence trompeuse créée par l'acte ostensible pour faire prévaloir la réalité sous la forme de la contre-lettre. L'action en déclaration de simulation basée sur l'article 1321 C.c.[(2)] se prescrit par 30 ans à compter du jour de l'acte attaqué pour cause de simulation[(3)]. L'objet de cette action est de démontrer qu'un acte a créé une fausse apparence. Elle n'est pas destinée à réprimer une fraude : lorsque la simulation est invoquée par des tiers, elle peut être établie par témoins et par présomptions, indépendamment de la question de savoir si elle est frauduleuse ou non[(4)]. Il est suffisant que les intérêts du demandeur aient été lésés, de sorte que celui-ci ait donc intérêt à rétablir la vérité[(5)].

Cette action doit être distinguée de **l'action paulienne** qui ne remet pas en cause le contenu de l'acte, mais qui lui reproche d'avoir été conclu dans le dessein de frauder les créanciers[(6)]. L'action en déclaration de simulation tend simplement à faire

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 398.

2 – Fl. Deboissy, *La simulation en droit fiscal*, p. 271. ; M. Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 270 ; J. Carbonnier, *Droit civil*, T. 1, p. 148.

3 – Fr. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, *Droit civil. Les obligations*, p. 396.

4 – *Pandectes belges*, V° Simulation, n° 1.

5 – Boulanger, *Rép. dr. civ*. (Dalloz), V° Simulation, n° 26.

6 – Boulanger, *Rép. dr. civ*. (Dalloz), V° Simulation, n° 24.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

reconnaître la fictivité d'un acte ; le demandeur n'a donc pas à apporter la preuve d'une fraude[1]. Ceci vaut quelle que soit la forme de la simulation visée[2].

« *L'action paulienne tend à entendre déclarer inopposable un acte anormal, déterminant ou aggravant l'insolvabilité de son débiteur, afin de pouvoir exercer ses droits sur les biens aliénés ou grevés comme si l'acte attaqué n'existait pas* »[3]. Cette action ne sera couronnée de succès que si trois conditions sont remplies : le dommage éprouvé par le créancier du fait de l'appauvrissement du débiteur, la fraude de ce dernier et la « complicité d'un tiers »[3].

■ § 5 – Apports représentatifs du capital et apports non représentés par le capital social

En principe, les biens qui entrent dans la propriété de la société donnent lieu à l'émission de titres de capital d'une valeur correspondante. Ceci ne vaut toutefois que pour les biens qui peuvent faire l'objet de saisies, de gages, etc. au profit de tiers. En d'autres termes, les apports qui ne peuvent être saisis ne sont pas susceptibles d'être représentés par du capital social.

Il s'agit en particulier de ce qu'on appelle les apports en industrie, par lesquels les associés s'engagent à effectuer des travaux au profit de la société. Ce genre d'apports peut consister en prestations manuelles ou intellectuelles ; il peut s'agir d'apports « *de connaissances techniques, de relations commerciales, de recherches* »[4]. Depuis l'abolition de l'esclavage, ces apports ne peuvent plus faire l'objet de saisies, etc.

La loi consacre peu de dispositions à ce genre d'apports. En revanche, dans les sociétés à responsabilité illimitée, cette catégorie d'apport peut donner lieu à l'attribution de titres représentatifs du capital social.

Il suffit de mentionner à cet endroit que, dans les sociétés civiles, l'apporteur en industrie est obligé de mettre à disposition sa force de travail entière au profit de la société à laquelle il s'est engagé à faire cet apport en industrie (art. 1847 C.c.).

■ § 6 – Principes d'évaluation des apports

La détermination de la valeur des apports (en fait, cette question ne se pose que pour les apports autres qu'en numéraire) est avant tout une question qui concerne les relations entre associés. Si l'associé A apporte une somme d'argent de 300 000 euros et l'associé B un immeuble, et que chacun des associés reçoit 50 % des actions, il est clair qu'implicitement l'immeuble a été évalué à 300 000 euros. Toute sous-évaluation est préjudiciable aux intérêts de l'associé apporteur, alors que, logiquement, toute surévaluation lui est favorable.

Écoutons Nyssens à ce sujet : « *Les associés eux-mêmes, c'est-à-dire les souscripteurs et les acheteurs d'actions sont les premiers et les principaux intéressés à ce que les exagérations frauduleuses des apports en nature et des avantages soient évitées.*

---

1 – J. Vidal, *Essai d'une théorie générale de la fraude en droit français*, p. 184 ; il est entendu que l'auteur, en ne visant que la fictivité d'un acte, est en fait trop restrictif : en effet, sont visées non seulement les simulations « absolues », mais encore celles par acte déguisé et par interposition de personne.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 376.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 397.

4 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés*. *Précis*, p. 227.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Examinons d'abord la situation des associés actuels, c'est-à-dire de ceux qui prennent part à la souscription initiale du capital. Ne sont-ils pas exposés à se laisser entraîner par les manœuvres dolosives de spéculateurs intrigants ? Ne céderont-ils pas à des promesses mirobolantes, à des prospectus habilement rédigés, aux mille trucs et artifices qui, malgré tant de funestes exemples, continuent à capter la confiance publique et à répandre dans les foules, pour une affaire, un fol engouement ?

Ah certes, et c'est l'argument qu'on ne manque pas d'invoquer en faveur de la liberté absolue, chacun doit apprendre à veiller à ses intérêts, chaque désastre nouveau est pour le public une leçon, […] Il fallait être plus prudent, plus perspicace, examiner de plus près l'affaire, l'étudier, en mesurer les chances et en découvrir les écueils.

Malheureusement l'expérience dément l'efficacité de cette théorie. Malgré tout, le public des petits capitalistes est resté un mineur vis-à-vis des puissants de la Finance et de la Bourse ; il est un prodigue que la loi doit protéger. Car, voici ce qui arrive après la fondation de la société. Ce ne sont plus seulement les premiers souscripteurs qui sont exposés dont l'avoir est compromis, eux auxquels la prudence commandait de vérifier les conditions et les chances de la société naissante, c'est tout le monde. Ceux qui ne sont entrés dans la société les mains vides que pour en sortir les poches pleines font, grâce à des trucs connus et trop souvent efficaces, "mousser" les actions, ils se débarrassent de leurs titres d'apport en les vendant à la Bourse ou en formant un syndicat quelconque pour la vente publique. Et les voilà bientôt désintéressés d'une affaire qu'ils ont fondée et qui, dès le premier jour, est condamnée à la ruine et à la mort, par suite de la création d'un capital fictif et d'innombrables actions représentées dans l'avoir social par des apports sans valeur […] Et ce sont surtout les actionnaires futurs qui en souffrent ; tiers au moment de la constitution de la société, ils n'ont pas été appelés à approuver les statuts, et se sont laissé entraîner par les manœuvres à la hausse, à la faveur menteuse de la Bourse et parfois même par des distributions de dividendes fictifs »[1].

L'évaluation de ces apports est susceptible d'avoir également une incidence sur les relations avec **les créanciers**. En effet, une surévaluation rend le capital (ou de façon générale les fonds propres) fictif (au moins pour partie). Un tel résultat est évidemment à proscrire, surtout dans les sociétés de capitaux dans lesquelles les fonds propres représentent la marge de sécurité offerte aux créanciers pour les protéger contre tous risques de mauvaise évaluation des biens (soit donc une surévaluation des actifs et/ou une sous-évaluation des passifs).

Il a donc fallu organiser une procédure de vérification des apports en nature, charge qui, au vœu du droit de l'Union européenne, est attribuée aux réviseurs d'entreprises. La mission du réviseur d'entreprises est définie par l'article 420-10 (anc. art. 26-1) L.S.C. qui l'oblige de constater en conclusion de son rapport que les modes d'évaluation conduisent à une valeur qui est **au moins égale à la valeur nominale** (pair comptable) des **titres émis** en contrepartie (le cas échéant, augmentée du montant de la prime d'émission). Il résulte de cette disposition que la charge du réviseur est d'éviter toute surévaluation, mais il ne certifie pas que la valeur est correcte (donc ni surévaluation ni sous-évaluation). On voit donc que la mission du réviseur semble s'exercer essentiellement dans l'intérêt des créanciers. On peut penser que les associés seront bien placés pour défendre leurs intérêts lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la valeur de leurs apports et que l'intervention du réviseur n'est donc pas nécessaire à cet endroit.

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 135, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il est donc possible de prendre la position que les sous-évaluations des apports ne sont en rien interdites[1]. Il nous semble utile de faire trois remarques à cet endroit :

1) Faire un apport à une S.A. (ou une S.à r.l.) n'est pas un acte de commerce. Il n'est donc pas certain que les apporteurs (qui peuvent être mineurs, p. ex.) n'aient jamais besoin de protection.
2) La sous-évaluation des apports (même si elle semble être dans l'intérêt des créanciers dans la mesure où elle procure à cette société des réserves qui ne peuvent être distribués) conduit à des réserves comptables latentes qui risquent fort de contribuer à la non-transparence des résultats et de nuire à la comparabilité des résultats, d'un exercice à l'autre[2]. Ces inconvénients sont de plus en plus nettement combattus au moyen de nouvelles normes comptables internationales (voir normes IFRS dont les règles d'évaluation évitent largement la formation de réserves cachées).
3) Certains auteurs soulignent le fait que les directives européennes et, en particulier, la Deuxième directive (qui a introduit l'obligation du contrôle des apports autres qu'en numéraire) ont pour objet de protéger non seulement les tiers, mais encore les actionnaires[3].

§ 7 – Nullité des apports

Les apports représentent une des conditions de la définition de la société de l'article 1832 C.c. : « *quelque chose* » doit être mis en commun. L'article 1833 C.c. confirme ce point en précisant que : « *Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie* ». L'absence de tout apport est une cause de nullité de la société.

En pratique, on ne rencontre guère de cas d'absence d'apport proprement dit. En revanche, il est tout à fait possible d'observer des cas où il n'y a pas absence d'apports, mais (ce qui à toutes fins utiles revient à la même chose) des apports sans valeur : un brevet périmé, une créance sur un débiteur insolvable, un fonds de commerce pour lequel les dettes dépassent les actifs, un terrain pollué pour lequel les frais de dépollution dépassent la valeur, etc. sont des hypothèses où il y absence d'apport, voire apport négatif[4].

A – Apports et simulation

La question des sociétés fictives est à distinguer de celle des apports fictifs. Un apport peut être fictif sans que la société ne soit fictive. En revanche, si tous les apports sont fictifs, la société le sera également[5].

---

1 – V. en ce sens A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 53.

2 – Sur les dangers et inconvénients des réserves occultes de façon générale, v. J.-P. Winandy, *Fiscalité et comptes annuels des entreprises*, p. 250.

3 – I. Corbisier, *Droit des sociétés. Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 198, qui cite J. Delvaux, *La société anonyme*, p. 13.

4 – M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 59.

5 – Fl. Deboissy, *La simulation en droit fiscal*, p. 116.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

On distingue en général les **souscriptions fictives** qui concernent les apports en numéraire (que ce soit à la constitution ou ultérieurement) et les apports fictifs proprement dits qui ne concernent que les apports en nature[1]. La situation juridique des biens apportés peut entraîner la fictivité de l'apport dont ils font l'objet[2]. En France, de telles souscriptions fictives semblent fréquentes pour assurer que le gérant majoritaire (ce « mal-aimé de la fiscalité »[3] devienne gérant minoritaire du fait de la dilution de ses titres entraînée par l'augmentation du capital de la société. À cette fin, une personne souscrit à une augmentation de capital qu'elle prétend avoir souscrite par des prêts accordés par les autres associés. Un contrôle de l'administration révèle alors que ni les remboursements du prêt ni les paiements d'intérêts n'ont été effectués[4].

Les souscriptions sont fictives si les conditions posées par le Code civil ne sont pas remplies. Il faut donc qu'il y ait transfert de la propriété ou de la jouissance d'un bien à la société et qu'en contrepartie des titres représentatifs du capital soient accordés[5]. Il est à souligner qu'une souscription n'est pas fictive pour la raison que les versements ont été financés par un emprunt, même si cet emprunt a été accordé par un autre associé[6].

Au moment de la **constitution,** la simulation peut porter sur la qualité des parties ou de certaines d'entre elles ou sur leur intention de constituer une société. Il est à noter que, dans le cas de la constitution des sociétés anonymes par souscription, les règles de la simulation des contrats ne sont pas applicables pour la raison que la souscription est un simple engagement unilatéral[7].

La simulation des apports peut être constitutive d'un **faux pénal**. L'élément matériel de la simulation existe du fait de l'inexactitude de la déclaration des hommes de paille quant à leur intention de s'associer et quant au paiement par eux de leur souscription, alors qu'ils n'ont aucune intention d'être associés et qu'ils paient leur souscription à l'aide de fonds provenant de celui pour le compte de qui ils interviennent[8]. Pour que le faux soit réalisé, encore faut-il que les déclarations fausses des fondateurs soient de nature à causer préjudice à autrui, et cette condition doit être appréciée concrètement à partir des données du cas d'espèce[9].

La seule intervention **d'hommes de paille** ne suffit pas à caractériser l'infraction du faux. L'intervention d'hommes de paille sans *affectio societatis* n'est pas suffisante pour constituer l'intention frauduleuse en dehors du fait qu'elle ne cause pas nécessairement un préjudice au détriment de tiers.

Cette possibilité de préjudice était retenue dans une affaire[10] où des actionnaires belges avaient participé à une augmentation de capital d'une société et s'étaient présentés comme actionnaires, alors qu'ils agissaient en réalité comme prête-noms d'une société britannique. Le résultat de cette opération était que, de cette façon, la société

1 – F. Deboissy, *La simulation en droit fiscal*, p. 116. ; M. Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 81.

2 – M.Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 81.

3 – V. Fl. Deboissy, *La simulation en droit fiscal*, p. 116. ; M. Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 113.

4 – CE, 11 mars 1985, req. 42.310 ; *Dr. fisc.*, 1986, n° 14, com. 720, *RJF*, 1985, n° 5, p. 375.

5 – Fl. Deboissy, *La simulation en droit fiscal*, p. 117.

6 – Cass. com., 23 janvier 1963, *Bull. civ.,* III, n° 46. ; M. Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 79.

7 – Bruxelles du 18 juin 1933, *B.J.*, 1934, col. 280, confirmé par Bruxelles du 5 avril 1939, *R.P.S.*, 1948, p. 22.

8 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965), *R.C.J.B.,* 1965, p. 292.

9 – Cour Bruxelles du 3 mars 1965, *J. T.*, 1965, p. 387.

10 – CA Bruxelles du 10 novembre 1971, *R.P.S.*, 1973, p. 141.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dont le capital était augmenté apparaissait comme belge sur la base de la législation relative aux agréations des entreprises de travaux publics et pouvait donc participer à des soumissions. L'intention frauduleuse étant ainsi retenue ensemble avec le préjudice potentiel dans le chef des concurrents potentiels, la cour concluait au faux en écriture[1].

Il y a apport fictif lorsque « *la société n'est susceptible d'en retirer aucun avantage direct ou indirect, soit que le bien apporté soit dénué de toute valeur effective et certaine, soit qu'il n'ait qu'une valeur insignifiante non susceptible d'accroître le fonds social ou d'être prise en considération pour la détermination du capital social, soit encore que la société ne puisse juridiquement bénéficier du bien apporté* »[2].

La fictivité de l'apport n'entraîne pas nécessairement la **nullité de la société** : il en est ainsi seulement si cet apport est nécessaire à la réalisation de l'objet de la société ou s'il est effectué par une personne dont la présence est indispensable[3].

Une souscription n'est pas non plus fictive en raison de la rétrocession immédiate des actions, alors qu'on ne peut inférer de la courte période de détention l'absence de consentement réel et l'absence d'*affectio societatis*[4].

Il est entendu que l'intervention d'un prête-nom lors de la constitution ne rend ni fictive ni frauduleuse une société ainsi créée[5]. En effet, dans l'interposition de personne (une des trois formes de simulation), c'est le maître de l'affaire qui est engagé. Il y a bien souscription simulée, mais la simulation ne porte pas sur la souscription, mais sur l'identité du souscripteur. Ceci n'est vrai toutefois que si, derrière le prête-nom, il existe un **mandant véritable** qui souscrit les titres et libère effectivement les apports qu'il s'est engagé à faire à la société[6]. S'il y a plusieurs prête-noms, la société ne sera fictive (dans le cadre de la conception contractuelle) que s'ils interviennent tous pour le compte de la même personne. Dans la négative, la société aurait deux associés au moins et ne pourrait être déclarée fictive sur cette base de l'interposition de personne[7]. La pratique prend souvent recours au **prête-nom,** et on peut supposer qu'il en est en général ainsi dans le cas d'une société par actions ayant deux actionnaires dont l'un ne détient qu'une seule action. La présence du deuxième associé s'explique uniquement par les dispositions du droit des sociétés qui exigent la présence de deux associés au moins (conception contractuelle de la société)[8]. Si les souscriptions par prête-nom sont des souscriptions simulées, elles ne sont pas pour autant des souscriptions fictives, mais la simulation porte simplement sur l'identité du souscripteur. En effet, dans le cas d'une souscription par prête-nom, il y a véritable souscription, à savoir par le mandant dissimulé derrière le

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978), *R.C.J.B.,* 1981, p. 236.

2 – A. Bougnoux, « Théorie des apports. Notion d'apport en société », *Jur. Cl.*, *Traité Sociétés*, fasc. 10, n° 103 vérif.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 368.

4 – M. Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 79.

5 – Cass. com. du 3 janvier 1961, *D.*, 1961, p. 292, *RTD com.*, 1961, p. 384, note Houin.

6 – M. Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 78.

7 – M. Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 67.

8 – Art. 26 (nouv. art. 420-1) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite. À l'égard des sociétés par actions, le caractère contractuel de la société est donc maintenu (alors que tel n'est plus le cas à l'égard des sociétés à responsabilité limitée qui peuvent n'avoir qu'un seul associé, v. art. 179 (nouv. art. 710-1) L.S.C., ID 7520).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

prête-nom. Pour qu'il y ait souscription fictive, il faut qu'il n'y ait pas de souscripteur réel, donc que le souscripteur soit purement imaginaire ou encore qu'une personne existant réellement soit faussement désignée comme souscripteur[1].

L'infraction du faux pénal suppose que l'altération de la vérité s'accompagne d'une intention frauduleuse ou de l'intention de nuire et doit être susceptible de porter préjudice à un tiers[2]. Ces conditions sont réunies lorsque la souscription de complaisance a pour but de soustraire à l'imposition les deniers au moyen desquels la société est constituée[3].

B – Action paulienne

Les créanciers lésés par les actes frauduleux de leur débiteur peuvent recourir à l'action paulienne à condition que leur créance soit antérieure à l'acte critiqué[4].

La constitution d'une société peut être attaquée au moyen de l'action paulienne. Mais les décisions de jurisprudence sur cette question sont très rares en pratique. Un de ces cas fut celui soumis au Tribunal de Dinant[5]. Dans le cas d'espèce, la société avait été constituée essentiellement dans le but de permettre à son fondateur principal d'échapper aux poursuites de l'O.N.S.S[6]. À cette fin, l'entièreté du fonds de commerce fut apportée avec la seule exception de la dette envers ledit organisme de sécurité sociale. Les cofondateurs étaient tous des proches parents de l'exploitant du fonds de commerce. En l'occurrence, le demandeur échoua à rapporter la preuve de la troisième condition requise, à savoir donc celle du préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et l'acte attaqué. En réalité, les apports n'étaient pas sous-évalués, et le fondateur avait reçu dans son patrimoine privé des titres d'une valeur équivalente et qui étaient devenus le gage du créancier.

Cette jurisprudence fut critiquée pour être trop stricte : « *pour apprécier le préjudice subi par le créancier, il faut avoir égard à la valeur économique des biens reçus par le débiteur en échange de biens aisément saisissables qu'il s'est efforcé de mettre à l'abri des poursuites de ses créanciers ; ce sont les possibilités pratiques du créancier d'obtenir satisfaction qui sont déterminantes. Dès lors, si les actions ou leurs parts reçues en échange de l'apport sont incessibles à des tiers et si les associés n'acceptent de les acquérir qu'à des conditions peu favorables pour le créancier ou même, plus généralement, s'il s'agit de parts difficilement réalisables sur saisie, en sorte que le prix de la réalisation serait inférieur à la valeur des biens apportés, l'action paulienne doit, à notre avis, être accueillie* »[7].

Si la fraude paulienne est établie, la conséquence en est que l'apport est inopposable au créancier, de sorte que ce dernier peut exercer ses droits sur les biens apportés comme si ces derniers faisaient toujours partie du patrimoine du débiteur.

---

1 – M. Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 78.

2 – Cass. b. du 27 septembre 1988, *Pas.*, 1989, I, p. 93.

3 – Trib. corr. Bruxelles du 25 juin 1980, *R.P.S.*, 1981, p. 53.

4 – P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1974-1982).Les obligations », *R.C.J.B.,* 1988, p. 128.

5 – Trib. Dinant du 9 mai 1963, *Jur. Liège*, 1963, p. 21 et Trib. com. du 9 janvier 1964, *R.P.S.*, 1964, p. 169, obs. Coppens.

6 – N.d.l.r. : Office national de sécurité sociale belge.

7 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.,* 1965, p. 295.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 8 – Notion de capital social

« *Le capital social représente la valeur monétaire constatant la somme des apports en numéraire ou en nature transmis à une société personne morale à sa constitution ou en cours de vie sociale. Un tel capital existe dans toute les sociétés personnalisées* »[1].

Parfois, il est prétendu que, dans les sociétés de capitaux, le capital serait « *le seul gage des créanciers* ». Il convient de soumettre cette formule à une analyse critique. Nous nous expliquons au moyen d'un exemple. Supposons une société avec un capital de 50 000 euros, avec des actifs de 500 000 euros et des dettes de 450 000 euros. Ce sont les actifs de la société (tous les actifs) qui représentent le gage de ses créanciers, fort heureusement de loin supérieurs au capital de cette dernière. En effet, si le gage des créanciers (représentant des créances de 450 000 euros) était le capital social de 50 000 euros, alors ils auraient des soucis à se faire. Le capital social est en fait simplement la réserve ultime des créanciers, la **marge de sécurité** destinée à amortir les chocs en cas de perte d'exploitation ou tout simplement à estomper les surévaluations d'actifs (sous-évaluations de passifs). S'il est vrai que, dans le souci de distinguer les sociétés de capitaux des sociétés de personnes, on peut retenir que les créanciers des sociétés de capitaux n'ont comme gage que les avoirs de la société, il est pour les raisons données erroné de parler du capital comme seul gage des créanciers : le seul gage est en effet le *patrimoine* social.

La fonction du capital (et par extension celle des fonds propres en général) est donc de constituer une marge de sécurité pour les créanciers sociaux. Plus les fonds propres sont élevés, mieux les créanciers sont protégés contre une perte de valeur des actifs. Mais il est important de noter que même l'absence totale de fonds propres ne signifie pas que les créances sociales ne puissent nécessairement pas être intégralement remboursées. Il est vrai que, dans ce cas extrême de l'absence totale de fonds propres, la moindre perte de valeur des actifs va directement au détriment des créanciers qui, dans leur globalité, sont certains de n'être remboursés que partiellement.

La notion de capital social connaît des acceptions fort diverses : tantôt elle désigne les apports, tantôt l'ensemble des biens affectés à l'activité sociale, tantôt le patrimoine commun et tantôt l'actif net commun[2].

A – Capital social et fonds social

Le capital social est encore à distinguer du **fonds social**, notion beaucoup moins utilisée en pratique et qui correspond à la somme de l'actif et du passif (ou plutôt du solde de l'actif sur le passif tiers, c.-à-d. les dettes) de la société à un moment donné.

Le fonds social, ainsi compris, correspond aux fonds propres de la société, et ceux-ci fluctuent continuellement. « *Le capital social ne coïncide avec le fonds social que durant un instant de raison, lors de la constitution de la société, et même le fonds social se trouve immédiatement amputé des frais de constitution* »[3].

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 202.
2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 190.
3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 366.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le capital social, notion qui par la loi n'est prévue que pour les sociétés de capitaux (pour lesquelles un capital minimum est prévu par les dispositions légales afférentes), est le montant net des avoirs (des actifs) de la société qui ne peuvent être distribués aux associés en cours d'exploitation. Il s'agit d'une grandeur purement comptable à laquelle ne correspondent pas des actifs déterminés. Il est purement futile de chercher à trouver dans quels actifs le montant du capital est investi ; la même chose vaut à l'égard des autres fonds propres, qu'il s'agisse des réserves comptables, de la prime d'émission, du report à nouveau, etc.

En **droit fiscal**, la situation est quelque peu différente : il n'est pas indifférent que certains actifs soient financés par fonds propres ou par fonds de tiers. Ainsi, lorsqu'un actif produit des revenus exonérés, les charges y correspondant ne sont pas déductibles. Si le bien est financé par des fonds propres, alors tous les frais de financement restent déductibles, alors que tel n'est pas le cas si le bien est financé par des dettes. Afin de résoudre les questions qui se posent à cet égard, la loi fiscale prévoit des présomptions selon lesquelles les fonds propres sont censés être investis[1].

Le capital social peut encore être considéré comme une **dette envers les associés**. Cette présentation est défendable pour autant qu'on n'oublie pas quelques particularités de cette « dette » qui est pour le moins *sui generis* : en premier lieu, le montant de cette dette n'est pas fixé une fois pour toutes.

« *Tandis que l'action, née d'un apport, n'est qu'un titre de créance fictive, basée sur la notion abstraite de la personnalité juridique mais en réalité représentative d'une part du capital social, l'obligation, née d'un prêt fait à la société, est un titre de créance véritable, représentative d'une charge sociale* »[2].

Le montant qui en fin de compte revient aux associés est le reliquat qui reste après paiement de toutes les dettes sociales : ce montant peut être de beaucoup supérieur, mais également nettement inférieur à celui qui figure au bilan. Ni juridiquement ni fiscalement, il ne s'agit d'une **créance** dans le chef des associés (en tout cas pas d'une créance dans le sens normal de ce terme). Pour eux, il s'agit d'un investissement dans des valeurs mobilières qui représentent le capital de la société.

Dans le chef de la société, il s'agit de fonds propres sur lesquels **aucun paiement d'intérêt** ne doit être fait et qui représentent donc une source de financement bon marché constitutive d'une réserve financière destinée à éponger des pertes dans des périodes de conjoncture difficile.

B – Principe de fixité du capital social

Le montant et la devise du capital social sont **fixés au moment de la constitution** de la société et, en principe, ces grandeurs restent inchangées par la suite. Il va sans dire que cette fixité du capital social n'est pas nécessairement accompagnée de la fixité des fonds propres de la société. En d'autres termes, l'actif net de la société pour sa part est exposé à des modifications permanentes au gré des résultats annuels successifs dégagés par celle-ci.

Le principe de la fixité du capital doit être nuancé, et ceci, à plusieurs égards.

1 – V. règl. gr.-d. du 23 juillet 1983 pris en exécution de l'article 54 L.I.R., ID 1845.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 186, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En premier lieu, ce principe connaît certaines **exceptions notables** : la société coopérative en fait partie, tout comme les SICAV et les SEPCAV.

Même pour les types de sociétés qui connaissent le principe de la fixité du capital, le capital n'est pas une donnée immuable, mais est susceptible d'être changé à la hausse comme à la baisse. Le seul point remarquable est que ces modifications supposent une modification des statuts à prendre par décision des associés en assemblée générale à tenir devant notaire, en principe.

Si l'augmentation de capital est une opération non problématique à l'égard des créanciers dans la mesure où il s'agit (en principe) d'augmenter le gage de ces créanciers, il n'en va pas de même lorsqu'il y a diminution du capital social. En effet, ce cas de figure correspond directement à une diminution du gage des créanciers, ce qui demande en principe que des garanties soient demandées avant qu'il ne soit possible de procéder au remboursement du capital aux associés.

En outre, il existe des cas où la diminution du capital a uniquement pour effet de faire correspondre la présentation comptable à la réalité des faits. En cas de pertes sociales qui ont pour conséquence de diminuer les fonds propres au-dessous du montant du capital social, la constatation comptable de cette diminution n'est évidemment pas sujette à des contraintes particulières : cette réduction du capital social ne reflète pas une diminution du gage des créanciers, mais elle ne fait qu'acter la réalité économique et financière de la société.

SECTION III
PARTAGE DES BÉNÉFICES ET DES PERTES

En application de l'article 1832 C.c. dans sa forme initiale et qui (sur ce point) est toujours inchangé au Luxembourg, un des éléments caractéristiques du contrat de société est l'intention « *de partager le bénéfice qui peut […] résulter* » de la mise en commun des apports.

Chaque associé doit donc en principe avoir vocation aux bénéfices (et aux pertes), faute de quoi la société risque de s'exposer au reproche d'être une société léonine.

Sous cette dernière réserve, les associés disposent de toute liberté pour fixer la participation de chacun. « *La participation aux bénéfices et la contribution aux pertes ne doivent être ni égales pour tous les associés, ni proportionnelles aux apports, ni équilibrées entre elles, les parties pouvant, par exemple, valablement convenir que l'une aura deux parts dans les bénéfices mais n'en supportera qu'une seule dans les pertes* »[1]. Il est encore envisageable, et d'ailleurs tel est souvent le cas en pratique, que l'attribution d'un bénéfice à un des associés soit subordonnée à la réalisation d'une condition déterminée telle que la société réalise un certain minimum de bénéfices[1].

L'article 1853 C.c. contient une règle supplétive selon laquelle, en l'absence de spécifications statutaires, le partage des bénéfices se fait proportionnellement aux apports : cette règle s'oppose donc à la répartition par tête, donc par parts viriles[2].

L'application de cette règle donne lieu à des difficultés dans le cas où les associés n'ont pas évalué leurs apports dans l'acte constitutif. Pour le cas où des apports

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 413.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 414.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

en industrie ont été faits et que les statuts n'ont pas prévu la répartition des bénéfices, l'article 1853, alinéa 2, C.c. prévoit une autre règle supplétive selon laquelle l'apporteur en industrie est assimilé à celui des apporteurs qui a le moins apporté.

« *Il est contre la nature qu'une société de plusieurs […] se forme pour l'intérêt particulier, pour le seul intérêt d'une des parties. On n'a pas pu marquer plus fortement les vices d'une pareille société qu'en la qualifiant de léonine* »[1]. La nullité de la clause léonine telle que prévue par l'article 1855 C.c. entraîne en général la nullité de la société, du moins dans la mesure où cette clause est un élément essentiel du contrat de société (ce qui en général est le cas).

Le Tribunal de commerce d'Ostende déclara nulle une S.p.r.l. dont un associé garantissait l'autre contre toute participation dans les pertes par une convention sous seing privé signée le jour même de la constitution de la société. La nullité affectait la société en son entier, et non seulement la clause léonine[2].

SECTION IV
L'OBJET ET LE BUT DE LA SOCIÉTÉ

Plus d'un étudiant débutant en droit se sera déjà étonné du fait que le droit des sociétés se réfère régulièrement au droit civil au point d'y puiser la définition de ce qu'il faut entendre par le terme de société.

Le titre IX du Code civil est en effet intitulé : « Des sociétés ». La cause profonde de cet étonnement éventuel réside dans le fait qu'inconsciemment, on assimile la notion de société à celle de commerce en supposant donc de manière implicite que droit civil et sociétés sont des notions antinomiques.

Il est vrai que cette situation peut être considérée comme relativement nouvelle : dans l'ancien droit, certains auteurs considéraient que les sociétés étaient nécessairement commerciales[3].

■ § 1 – Code civil et droit des sociétés

La notion de société ne se limite donc pas au domaine commercial. Il existe bel et bien des sociétés civiles. Il est vrai que, du moins selon la conception luxembourgeoise, celles-ci ont impérativement pour objet de réaliser des bénéfices. Néanmoins, il est vrai aussi que l'activité en est fort similaire à celle de n'importe quel bon père de famille gérant sa fortune personnelle : la location d'immeubles, le placement en banque de dépôts à terme sont des activités qui satisfont parfaitement à la définition de la société au sens du droit civil (pour autant que les autres éléments de la définition soient également remplis).

Au sujet des relations pouvant exister entre le droit civil (Code civil) et le droit des sociétés, on peut citer deux dispositions, à savoir, en premier lieu, l'article 1873 C.c. : « *Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages de commerce* ».

1 – Travaux préparatoires du Code civil, Locré, T. VII, 242, cité par Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 424.

2 – Trib. com. Ostende du 28 avril 1960, *R.P.S.*, 1963, p. 64.

3 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 2.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En deuxième lieu, l'article 100-1 [anc. article 1er] L.S.C. est ainsi libellé :

« *Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.*

Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et par le droit civil.

Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés commerciales momentanées et sociétés commerciales en participation».

Cette disposition définit donc trois sources de droit des sociétés et, il faut le supposer, en même temps une certaine hiérarchie :

– les **conventions** (reflet de la conception contractuelle traditionnelle, le contrat est donc la source première du droit des sociétés) ;

– les **lois et usages particuliers** au commerce.

L'utilité d'ajouter les usages de commerce dans cette énumération de l'article 1er (nouv. art. 100-1 L.S.C.) a été mise en doute par Pirmez[1] au motif que, s'il peut y avoir des usages en matière de marchés commerciaux (dont il faudrait tenir compte lors de l'interprétation des conventions, art. 1159 C.c.), ces usages ne pourraient pas directement former le droit des sociétés ;

– le **droit civil** (en dernier lieu), ce qui confirme donc bien le caractère complémentaire du droit civil (tel que déjà mentionné par l'article 1873 C.c.).

« *Ce texte établit la hiérarchie des règles qui conditionnent le fonctionnement de toute société commerciale. Il commence par constater la liberté contractuelle, l'autonomie des volontés. Cette liberté n'a pour limite que les principes d'ordre public (règles de droit impératives […]).*

À défaut d'accord contractuel sur le point spécial d'un contrat de société commerciale, la loi commerciale […] règle ce point, en tant que loi supplétive, c'est-à-dire déclarative, interprétative des volontés des parties. Il y a plus. La loi commerciale se double des "usages particuliers de commerce". Enfin, si la loi commerciale et l'usage commercial ne fournissent pas la règle d'interprétation d'une société commerciale valablement constituée, le droit civil reprend son empire »[2].

L'explication de cet état de choses qui, il est vrai, peut à première vue surprendre, tient dans le fait que le droit civil est le droit commun en matière de droit privé. Les autres branches de ce pan du droit, qu'il s'agisse du droit commercial dont fait partie le droit des sociétés, du droit du travail, etc., tout en développant leurs propres solutions, puisent leur source dans le droit civil. Celles-ci sont *lex specialis* par rapport au droit civil : elles y dérogent donc pour autant que de besoin.

Le caractère supplétif de ces dispositions du droit civil en matière de droit des sociétés est bien souligné par l'article 1873 C.c. qui précise que : « *Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce* ».

On peut noter qu'en droit belge la situation est exactement identique à celle décrite ci-dessus, sauf que l'article 1 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales ne comporte pas la référence aux usages de commerce (contrairement à l'article 100-1 L.S.C.)

1 – E. Pirmez, *Observations présentées sur l'avant-projet de loi sur les sociétés commerciales* [rédigé par A. Nyssens], p. 77, ID 11305.

2 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 8.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'**objet du contrat de société** est défini par l'article 1832 C.c. : il consiste dans la mise en commun d'apports en vue de partager les bénéfices en résultant. Il doit être distingué de l'**objet social** : il s'agit de la fin spécifique que la société donnée définit dans ses statuts, d'où encore la désignation d'objet statutaire.

L'activité sociale est l'activité qui est effectivement poursuivie par la société : elle sera la plupart du temps plus limitée que l'objet statutaire. Ainsi, l'**objet social** peut consister en « *toutes activités immobilières consistant notamment en l'achat, la vente, la promotion immobiliers* », alors que l'activité effective se réduira, le cas échéant, aux seules activités de syndic. Si cette limitation des activités à une partie seulement de l'objet social ne pose pas de problème, il n'en va pas de même du cas inverse, c.-à-d. donc du cas où l'activité sociale effective excède l'activité de la société. Ce cas de figure soulève non seulement la question de savoir si la société est engagée par les actes qui dépassent l'objet social, mais encore celle de la responsabilité des organes qui posent des actes au-delà du mandat leur confié par les associés.

La cause du contrat de société est le but direct et immédiat en vue duquel l'associé (donc le débiteur de l'obligation) s'est engagé.

Cette cause, qui est objective, est la même pour chaque catégorie de contrat (pour le vendeur la cause du contrat de vente est le paiement du prix, etc.). Elle se distingue des **mobiles personnels** qui, eux, sont éminemment variables d'une personne à l'autre. La licéité de ces mobiles peut être sujette à caution : tel est le cas, par exemple, du débiteur aux abois qui apporte tous ses avoirs à une société afin de se soustraire aux créanciers, etc.[1].

■ § 2 – La notion d'intérêt social

On peut concevoir l'intérêt social comme l'intérêt commun des associés ; telle est la conception étroite traditionnellement adoptée. En général, on considère toutefois que cet intérêt est plus que la somme des intérêts particuliers des associés : « *C'est l'intérêt de la société vue comme une institution et pas seulement comme un contrat* »[2].

Est-ce que la notion de l'intérêt social débouche sur celle de l'entreprise comme tel est le cas en jurisprudence française[3] ? Selon celle-ci, l'entreprise constitue une communauté de personnes qui, loin de se limiter aux associés, comprend en même temps les salariés et dont la santé concerne la collectivité dans son ensemble[3].

« *Le droit des sociétés a toujours connu des "concepts mous", sans contenu préétabli mais adaptés par les cours et tribunaux au gré des circonstances pour corriger le fonctionnement de la société, tels que les "justes motifs", la "cause légitime", "l'intérêt commun" ou "l'intérêt social"* »[4].

« *Dans la conception contractuelle, l'intérêt de la société se confond en principe avec celui des associés. Il revêt un sens plus large dans la conception institutionnelle moderne. […] Il est préférable d'appréhender l'intérêt social comme un concept de gestion de l'intérêt collectif, c'est-à-dire comme une représentation idéale de la gestion de l'intérêt commun* »[5].

1 – M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 53.

2 – J. van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 713.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 205.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 140.

5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 141.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La notion « *d'intérêt social* » ne trouve pas directement son origine dans la L.S.C., mais elle est mentionnée à divers endroits du Code civil. Ainsi, l'article 1833 C.c. retient que : « *Toute société doit avoir un objet licite et être contractée pour l'intérêt commun des parties […]* ». De même, l'article 1859, 2, C.c. interdit aux associés d'utiliser les choses appartenant à la société « *contre l'intérêt de la société* ». Mais le concept d'intérêt social joue un rôle bien plus important dans la mesure où la doctrine traditionnelle considère que « *l'assemblée générale et le conseil d'administration doivent exercer leurs pouvoirs dans l'intérêt de la société elle-même : la méconnaissance délibérée de l'intérêt de la société peut entraîner la nullité de la décision de l'organe* »(1).

Cette disposition a été considérée comme bafouée notamment au XIXe siècle : après l'abolition des associations religieuses, des sociétés se sont créées afin de permettre aux ecclésiastiques la possession des **biens des couvents**, qui ne pouvaient être détenus par les ecclésiastiques eux-mêmes qui avaient fait des vœux de pauvreté. Il a été considéré qu'il manquait à ces sociétés la poursuite de l'intérêt commun des associés. En effet, celles-ci étaient constituées par quelques moines du couvent, sans qu'il n'y ait jamais la moindre distribution de revenus pas plus qu'un partage de l'actif social dans un avenir plus ou moins rapproché, au moment du décès d'un des associés, il était simplement remplacé par un autre, sans que jamais la possibilité d'un partage de l'avoir social ne puisse être envisagée, le vœu de pauvreté fait par les moines leur interdisant tout simplement la possession des avoirs résultant d'un partage éventuel(2).

La Cour de Bruxelles considéra que « *cette convention qualifiée de société est entachée d'une nullité radicale, comme contrevenant à la loi d'ordre public qui subordonne l'existence d'une personne civile à l'autorisation du législateur* »(3).

Dans une autre conception, l'intérêt social représente un impératif qui s'impose aux organes de la société : ils ne doivent rien faire qui soit contraire à l'intérêt de la société(4).

La société a un **intérêt propre** ; cette notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence est parfois assimilée à la notion « d'intérêt social »(5). « L'intérêt social » sert à apprécier la validité d'une décision d'un organe ou d'une clause statutaire ou extrastatutaire. Les décisions non conformes à l'intérêt social pourraient être contestées devant les juridictions. La L.S.C. dans son article 441-7 [anc. article 57] fait référence à la notion « d'intérêt opposé » que peut avoir un administrateur par rapport à la société. Dans un tel cas, il ne peut pas participer à la délibération du conseil d'administration portant sur la question visée.

La notion d'intérêt social est une **notion contingente**, susceptible de varier en fonction du contexte dans lequel elle est invoquée. Elle rejoint souvent la possibilité pour la société de réaliser un gain matériel sur une opération déterminée(5). Une opération contractée par l'entreprise est inattaquable à cet égard lorsque l'entreprise réalise (ou du moins peut être raisonnablement certaine de réaliser) un gain matériel en raison d'une telle opération.

Il se pose encore la question de savoir si la notion d'intérêt social comprend également d'autres intérêts que ceux de la société et de ses actionnaires. Cette question

1 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.,* 1991, p. 231.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, pp. 199 ss.

3 – Cour Bruxelles, Arrêt du 13 mai 1861, *Pas.*, 1861, II, p. 191.

4 – M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 53.

5 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés*. *Précis*, p. 231.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

s'est notamment posée dans le cas de fermetures d'entreprises dans la mesure où l'on peut considérer que l'intérêt des actionnaires était opposé à celui des salariés. Dans ce contexte, on a fait valoir que l'intérêt social serait la résultante d'intérêts fort divers tels que ceux des apporteurs de capitaux, des dirigeants de l'entreprise, des salariés, de la région dans laquelle la société est implantée jusqu'à la communauté nationale tout entière[1].

Cette approche est toutefois rejetée : l'intérêt social ne peut comprendre que l'intérêt de la société et de ses actionnaires[1]. Dans l'appréciation des juridictions consistant à vérifier si l'intérêt social est ou non respecté on applique la conception dite du « **contrôle marginal** »[1]. Il en serait ainsi pour la double raison que le juge n'est pas juge de l'opportunité mais seulement de la légalité des décisions soumises. Le juge ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle des organes de la société. En outre, les organes de la société disposent dans leurs décisions d'une certaine marge d'appréciation. C'est uniquement si les limites de cette marge d'appréciation sont clairement dépassées que la décision soumise au juge peut être sanctionnée[2].

Un **cautionnement gratuit** souscrit par la société au profit d'un de ses associés manquerait certainement au critère de l'intérêt social pour la raison que, en l'occurrence, c'est l'intérêt de l'associé, par opposition à celui de la société, qui est poursuivi. Souvent, l'intérêt social rejoint celui de l'ensemble des acteurs dont le sort est lié à la société. Dans ce sens, l'intérêt social est surtout invoqué lorsque la pérennité de l'entreprise est en cause : l'intérêt social garantit la survivance de la personne morale (et surtout celle de l'entreprise, indépendamment de la forme juridique qu'elle revêt).

La jurisprudence belge maintient ce principe avec fermeté : « *les pouvoirs ne peuvent être exercés que dans l'intérêt social : qu'une majorité ne peut imposer à la minorité des décisions prises au détriment de la société et au préjudice des intérêts collectifs : que ces décisions constituent un détournement ou un abus de pouvoir* »[3]. Ce principe vaut tant au niveau de l'assemblée des associés qu'à celui du conseil d'administration[4].

À défaut de définition légale de la notion d'intérêt social, on est ramené à l'étude de la doctrine qui, pour sa part, a identifié plusieurs conceptions différentes de l'intérêt social dans le sens que l'on peut distinguer entre une conception qui s'oriente par rapport aux intérêts des associés et uniquement par rapport à ceux-là et, en deuxième lieu, une conception nettement plus large qui, elle, identifie l'intérêt de la société par rapport à un cercle plus large de personnes, y compris les créanciers, les salariés, les clients, les pouvoirs publics, etc. Toutes ces différentes catégories de personnes ont un intérêt plus ou moins évident à la pérennité de l'entreprise. « *Une fraction importante de la jurisprudence et de la doctrine se réfère à la notion d'entreprise, conçue comme un* going concern *autour duquel de multiples intérêts s'agglomèrent. Suivant cette conception, l'intérêt de la société ne peut être ramené à l'intérêt patrimonial de ses actionnaires, même envisagés dans leur généralité. Il englobe l'intérêt des travailleurs, des fournisseurs, des bailleurs de fonds, des clients, de la région ou de*

1 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.,* 1991, p. 236.

2 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.,* 1991, p. 237.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence, (1966-1971) », *R.C.J.B.,* 1973, p. 533.

4 – CA Bruxelles du 13 janvier 1971, *Rev. prat. soc.*, 1971, p. 116.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la communauté dans laquelle l'entreprise exploite son activité, voire l'intérêt général »[1]. Ou encore : « *la société faisant publiquement appel à l'épargne et ayant notamment à veiller, dans l'intérêt d'autres acteurs de la vie économique, tels les travailleurs, dispensateurs de crédit, petits porteurs d'actions, fournisseurs, clients […] à son fonctionnement harmonieux, son développement et son avenir industriel, économique, financier et commercial* »[2].

Cette conception de l'intérêt social s'oppose à celle, traditionnelle, qui l'assimile à l'intérêt des actionnaires[3]. La notion d'intérêt social a en premier lieu une fonction limitée à certaines situations extrêmes dans le sens qu'elle permet de faire annuler certaines opérations en tant qu'opérations dites **d'abus de biens sociaux**. En deuxième lieu, cette notion permet encore de sanctionner les **abus de majorité** (abus de minorité) dans le sens que certaines décisions prises dans l'intérêt de certains groupes d'associés au lieu d'être prises dans celui de la société dans son ensemble sont attaquables justement pour cette raison qu'elles ne sont pas conformes à l'intérêt social.

Cet intérêt social est à distinguer de la notion d'**intérêt du groupe**. Concrètement, la question est la suivante : une convention d'actionnaires par exemple contraire à l'intérêt de la société peut-elle être considérée conforme à l'intérêt du groupe, et donc être considérée comme valable ? La doctrine (belge) semble aller dans le sens de la distinction suivante : si les intérêts de la société en question sont sacrifiés au profit de ceux de la société mère (ou encore d'une autre société du groupe), la convention de vote peut être annulée par application des règles sur l'abus de majorité[4]. En revanche, à partir du moment où « *la société tire profit de son appartenance au groupe, on peut raisonnablement considérer que des sacrifices peuvent lui être imposés en vue d'assurer la meilleure coordination possible des activités de l'ensemble du groupe et la recherche du meilleur résultat pour tout le groupe. Encore faut-il qu'il y ait un véritable groupe structuré et organisé de sociétés qui concourent à la réalisation d'une politique commune, dont chacun des membres est susceptible de tirer profit. De surcroît, il est nécessaire d'assurer un équilibre raisonnable entre les inconvénients imposés à la société membre du groupe et les avantages qu'elle est susceptible de retirer, éventuellement à plus long terme et sous une forme différente, de son appartenance au groupe. Cela implique notamment que l'on ne peut sacrifier les intérêts d'un membre du groupe dans l'intérêt commun, et que le groupe ne peut imposer une rupture durable de l'équilibre entre les engagements respectifs des sociétés qui le composent* »[5].

Par conséquent, il s'agit de définir l'intérêt de la société du groupe de façon à ce qu'y soit inclus l'intérêt de son appartenance au groupe en prenant en considération l'existence des relations du groupe et les avantages que la société peut en retirer, fût-ce à terme. Seraient ainsi critiquables les conventions selon lesquelles les **bénéfices** d'une société seraient **systématiquement distribués** à la société mère.

Dans l'**affaire *Fruehauf*** (Cour de Paris du 22 mai 1965), la conception de l'intérêt social fut dégagée : il s'agissait de la décision des actionnaires majoritaires

1 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1993, p. 772.

2 – Trib. com. Bruxelles du 17 mai 1988, *R.P.S.*, 1988, p. 288.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1993, p. 777.

4 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.,* 1991, p. 234.

5 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.,* 1991, p. 235.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

américains d'empêcher leur filiale française d'exécuter une importante commande à destination de la Chine communiste. La décision n'était pas dirigée contre les associés minoritaires, mais elle était préjudiciable à tous les associés. En même temps, la décision était clairement contraire à l'intérêt de l'entreprise, en particulier l'intérêt des salariés et de la collectivité en général. À la demande des actionnaires minoritaires, il a donc été procédé à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de prendre la décision d'autoriser l'exécution de la commande[1].

§ 3 – Le principe de spécialité des sociétés

La portée de ce principe dépasse le domaine de la société. Il s'applique à tous les groupements de personnes, aux syndicats, aux fondations, etc.

Il s'agit de la **spécialité légale,** d'une part, et de la nature d'être moral, d'autre part. En ce sens, la société est d'abord à distinguer de l'association. Si la société ne peut se livrer qu'à des activités lucratives, celles-ci sont interdites aux associations (sauf à titre accessoire de leur activité non lucrative, voir ci-dessus). En tant que personne morale, la société ne peut, par la force des choses, être titulaire de certains droits qui, par leur nature, ne peuvent appartenir qu'à une personne physique (droits de la famille notamment)[2].

Le droit des sociétés est dominé par le principe de spécialité des personnes morales, c.-à-d. que les sociétés sont constituées pour un objet déterminé ; cet objet doit être distingué de l'objectif général de la société qui est un but « lucratif », par opposition au but désintéressé qui caractérise les associations et les fondations. Les personnes morales n'existent qu'en vue de la fonction qu'elles se sont assignée ou qui résulte de leur nature.

Elles sont soumises à la règle de la spécialité dont la violation entraîne la nullité des actes accomplis[3].

A – Contenu de ce principe

Par spécialité légale, on entend une règle limitative de l'activité des personnes morales. En effet, si les institutions juridiques mises à disposition de groupements d'individus varient suivant la nature des activités poursuivies, il est normal de conclure qu'un tel groupement ne peut poursuivre une activité différente de celle qui est organisée pour ce groupement[4].

Les personnes morales sont des créations de la loi, et celle-ci leur assigne, ou encore leur interdit, certains domaines de l'activité économique et sociale. Les personnes morales sont donc régies par le principe de spécialité légale dans le sens que la loi les organise en vue d'un certain nombre de fins[5].

Le rôle du principe de spécialité des personnes morales est de protéger les associés ou les membres contre les dépassements de pouvoirs des gérants, mais aussi les tiers

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 207.

2 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.,* 1989, p. 388.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 117.

4 – Art. 9, 1, de la Première directive (68/151/CEE).

5 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.,* 1989, p. 396.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

en leur permettant de contrôler plus aisément les pouvoirs de ceux qui prétendent agir au nom d'une société ou d'un groupement[1]. « *Cette dernière justification n'emporte plus guère la conviction. C'est précisément pour protéger les tiers éventuellement au détriment des associés que la première directive communautaire a imposé, pour les S.A. et les S.P.R.L., l'abandon du principe de la spécialité conformément au droit allemand* »[2].

Le principe visé définit le champ d'action des sociétés et autres entités et de leurs représentants : de façon générale, la personne morale et ses représentants ont tous les pouvoirs dans le cadre de cet objet et, en même temps, ils ne peuvent aller au-delà[3]. Le principe visé signifie simplement que les personnes qui se sont ainsi regroupées entendent limiter leurs activités au cadre qu'elles ont ainsi défini.

La portée exacte de ce principe est pourtant fortement estompée dans les sociétés de capitaux. En effet, dans un souci de **sécurité juridique**, la Première directive CEE a édicté que les sociétés sont engagées même quand elles agissent en dehors de leur objet social (« *à moins que lesdits actes n'excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes* »)[4]. En vertu notamment de cette règle, la portée pratique de ce principe de spécialité est fortement réduite. Si l'article 54, 3, g), du traité de Rome visait à la fois la protection des associés et des tiers, les auteurs de la Première directive ont en fait mis l'accent sur la sécurité des tiers, et donc sur la sécurité du commerce[5]. Il résulte de cette approche que toutes les irrégularités dans la nomination des organes sont déclarées inopposables aux tiers.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que ce principe a un champ d'application très limité et qu'il ne s'applique notamment ni aux sociétés civiles ni aux sociétés autres que celles tombant sous la directive précitée (notamment les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple).

Traditionnellement, on enseignait que la capacité de jouissance d'une personne morale était limitée à la réalisation de son objet social. « *La société n'avait une existence juridique propre qu'à cette fin. En dehors de ce cadre, les actes accomplis tombaient en quelque sorte dans le néant* »[6].

Au fil du temps, la portée de ce principe a d'ailleurs connu des modifications : depuis l'arrêt de la Cour de cassation belge du 31 mai 1957, l'objet social n'était plus considéré comme une restriction à la **capacité des personnes morales,** mais uniquement comme une limitation des pouvoirs des organes de celles-ci[7]. « *L'être moral ne peut agir qu'à l'intervention de personnes physiques, ses organes ; ceux-ci n'agissent en cette qualité, et dès lors ne s'identifient avec l'être moral, que s'ils restent dans les limites de leurs attributions ; […] l'opération litigieuse étant étrangère à l'objet de la société demanderesse et les personnes physiques qui l'ont accomplie en son nom étant, partant, sorties de leurs attributions, ladite opération n'est pas un acte de la société* »[7].

---

1 – V. Trib.com. Liège du 21 septembre 1976, *R.P.S.*, 1976, p. 225, cité par J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978), *R.C.J.B.,* 1981, p. 248.

2 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978), *R.C.J.B.,* 1981, p. 248.

3 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 126.

4 – Art. 9, 1, de la Première directive (68/151/CEE).

5 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.,* 1989, p. 396.

6 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.,* 1989, p. 393.

7 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.,* 1989, p. 394.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La Cour de cassation belge[1], dans une jurisprudence constante, affirme le principe que « *pour tous les actes juridiques que n'exclut pas sa nature d'être moral, la capacité d'une société dotée de la personnalité juridique est en principe la même que celle d'une personne physique si la loi ne l'a pas restreinte* ». Il est vrai qu'une restriction importante de la capacité des personnes morales ou, si l'on préfère, des pouvoirs de leurs organes, réside dans le principe de la **spécialité légale** des personnes morales[2].

« *La capacité des personnes morales se mesure et se limite à leur objet, c'est-à-dire à l'activité ou aux activités en vue desquelles elle a été créée. Elles se distinguent par là des personnes physiques. La Cour de cassation, il est vrai, paraît avoir consacré une conception différente : suivant divers arrêts […] ce seraient seulement les pouvoirs des organes de la personne morale qui seraient limités par l'objet de celle-ci, tandis que sa capacité serait, en principe la même que celle des personnes physiques, à moins que la loi ne l'ait restreinte. Cette vue des choses nous paraît moins heureuse. […] Il nous paraît plus rationnel, dès lors, d'admettre que c'est la capacité de la personne morale, et non celle de ses organes, qui se trouve nécessairement limitée en vertu du principe indiscutable de la spécialité* »[3].

Les sanctions de la violation de ce principe peuvent notamment consister dans la nullité, à l'égard de la personne morale, des actes accomplis par la personne morale[4]. Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation de France a annulé les actes de commerce accomplis par un syndicat qui était sorti du cadre tracé par la loi[5]. « *S'expliquant par l'organisation même du régime des personnes morales, elle intéresse l'ordre public et il faut admettre que les actes accomplis en dehors du champ d'activité légalement autorisé au groupement sont annulables à l'égard de la personne morale, à la requête de tout tiers intéressé, sans préjudice aux autres sanctions […]* »[4].

Autrefois, on considérait que, si la société anonyme agissait en dehors de son objet social, il se constituait une **société irrégulière distincte** ; celle-ci ne pouvant pas avoir la forme d'une société anonyme, elle était traitée comme une société en nom collectif[6].

Une seconde limitation de leur activité réside dans le principe de la **spécialité statutaire**. Ce principe signifie qu'une personne morale ne peut procéder à la formation d'actes juridiques que dans la mesure où ceux-ci sont destinés à permettre la réalisation de son objet social. « *En dehors de la poursuite de cet objet, la personne morale cesse d'exister, c'est le néant. Ainsi exprimée, la règle s'explique par une limitation apportée à l'existence même de la personne morale comme sujet de droit et non point par une restriction aux pouvoirs de ses organes. Elle conduit à la conséquence que toute personne intéressée, et notamment les tiers cocontractants, peuvent se prévaloir du fait qu'un acte est étranger à l'objet social et ne saurait faire naître aucun droit ni engendrer aucune obligation pour l'être moral* »[7].

1 – V. notamment Cass. b. du 13 avril 1989, *Pas*., 1989, I, p. 825.

2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1992, p. 636.

3 – Cass. b. du 12 novembre 1965, *R.C.J.B.,* 1966, note J. van Ryn, p. 407.

4 – Cass. b. du 31 mai 1957, note P. Van Ommeslaghe, p. 291.

5 – Cass. fr. du 3 avril 1912, *S.*, 1913, I, p. 489.

6 – V. Trib. com. Bruxelles du 12 janvier 1938, *R.P.S.*, n°s 40-46, p. 95 ; V. P. Van Ommeslaghe, « Les sociétés de fait », *J.T.*, 1957, p. 713.

7 – Cass. b. du 31 mai 1957, note P. Van Ommeslaghe, p. 290.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Ce principe trouve son fondement dans un double **objectif de protection** : la protection des associés en délimitant le champ d'application de la société ; la protection des tiers qui n'ont accordé crédit que pour la réalisation d'opérations dans un domaine déterminé. Les tiers sont assurés que les fonds prêtés ne seront pas utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été avancés. En Belgique, la conséquence de ce principe était que tous les actes de la société posés au-delà de l'objet social pouvaient être déclarés inexistants, cette demande pouvant émaner tant des tiers que de la société ; cette position fut nuancée par l'arrêt précité de la Cour de cassation belge du 31 mai 1957[1].

Évoquant l'éventualité de la transformation d'une société agricole en société anonyme :

« *Les sociétés et les associations sont, comme toutes les personnes morales, des fictions de la loi. Elles ne peuvent exercer leur activité que dans le cadre qui leur est tracé par la loi. Elles ne peuvent être créées, transformées ou liquidées que dans la mesure où la loi le leur permet et dans les formes prévues par la loi. L'article 3 de la L.S.C. dispose que les sociétés civiles peuvent être transformées en sociétés commerciales et que les sociétés commerciales d'un type peuvent être transformées en sociétés commerciales d'un des autres types prévus par la loi. Cet article énumère les conditions d'une telle transformation et précise qu'elle ne donne pas lieu à une personnalité juridique nouvelle. Ces dispositions, loin de traduire le droit commun – elles seraient alors inutiles et incomplètes – constituent au contraire une dérogation au droit commun en vertu duquel une société ne peut changer de forme sans perdre son ancienne personnalité juridique, sauf dérogation de la loi. Ainsi une société commerciale ne peut se transformer en société civile sans passer par une dissolution de la première et une nouvelle constitution de la seconde. Il en est de même des associations agricoles, aucune disposition légale réglementaire et spécialement l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur les associations agricoles n'autorisant une telle association de se transformer en société commerciale sans observer les formalités de la dissolution et de la liquidation des associations agricoles et celle de la constitution des sociétés commerciales* »[2].

B – Utilité de l'objet social statutaire

Le principe de spécialité des personnes comporte un deuxième volet en dehors de celui de la spécialité légale ; il s'agit de la « spécialité statutaire ». En application de ce principe, les sociétés doivent fixer un objectif statutaire qui définit le champ d'activité en vue duquel la société est constituée.

L'objet de la société doit être un objet déterminé, précis et mentionné dans les statuts sociaux. Cet objet doit être licite (art. 1833 C.c.) ; un objet illicite constitue une des rares causes de nullité de la société. Pour être licite l'objet :

– doit exister ;

– être réalisable (et non pas impossible) ;

1 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.,* 1989, p. 394.

2 – TA Lux. du 14 novembre 1984, n° 29.500, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– être non contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs[1].

La question de l'objet statutaire doit être distinguée d'une autre question, distincte mais néanmoins liée, celle de l'autorisation administrative permettant à la société d'exercer l'activité qu'elle entend exercer. Selon le cas, il s'agit soit d'une autorisation dite d'établissement délivrée par le ministère des Classes moyennes, soit d'une autorisation spéciale requise notamment dans le secteur bancaire et financier et dans le secteur des assurances. En l'absence d'une telle autorisation d'établissement, la société ne peut exercer l'activité qu'elle envisage de réaliser conformément à son objet social sous peine des sanctions prévues par le droit d'établissement. Il s'agit donc d'une limitation de la capacité d'exercice de la société.

A été déclarée illicite une société en nom collectif formée entre un pharmacien et deux médecins pour l'exploitation en commun d'un établissement pharmaceutique comme violant les règles régissant l'exercice de la pharmacie. La doctrine considérait qu'une telle société devrait encore être déclarée comme illégale pour la raison qu'elle serait contraire aux bonnes mœurs. « *Donner à des médecins un intérêt dans un établissement pharmaceutique, n'est-ce pas les placer entre leur intérêt et leur devoir ? Supposons qu'ils soient convaincus que la médecine homéopathique soit préférable à la vieille médecine, suivront-ils leur conviction aux dépens de leur intérêt ? Et s'ils ne consultent que leur intérêt, ne prescriront-ils pas des drogues pour augmenter leur dividende, au lieu de ne consulter que l'intérêt du malade ?* »[2].

En application du droit commun des sociétés commerciales, le principe de la spécialité statutaire implique que la société n'est pas engagée par les actes accomplis par ses organes en violation de l'objet social pour la réalisation duquel la société a été constituée.

En même temps, « *la société ne peut puiser de droits dans une convention étrangère à son objet social et les tiers peuvent donc se refuser à exécuter des engagements résultant d'une convention étrangère à l'objet statutaire de leur contractant* »[3].

Aux termes de l'article 1131 C.c. une telle convention illicite ne peut produire aucun effet. Telle est la conséquence des contrats inexistants qui n'existent pas aux yeux de la loi[4].

L'on sait que la Première directive a entendu harmoniser, tout en les allégeant, sur le plan de l'Union européenne, les conditions par lesquelles une société se trouverait engagée envers des cocontractants.

L'objet social doit être **licite** (art. 1833 C.c.), ce qui signifie qu'il ne peut contrevenir à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Il reste à voir quelles sont les sanctions en cas de violation de cette condition. À l'égard de certaines sociétés (en fait il s'agit des sociétés de capitaux), l'illicéité de l'objet social[5] est une cause de nullité (art. 100-18, anc. art. 12*ter* L.S.C.). Tel est le cas si l'objet social est « *illicite ou contraire à l'ordre public* »).

1 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 125.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 162.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1992, p. 639.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 162.

5 – « Illicite » : défendu par la morale ou par la loi.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La question peut se poser de savoir si cette condition se rapporte à l'objet social tel que prévu par les statuts ou bien à l'objet social effectif : il va de soi qu'il peut y avoir un gouffre entre ces deux notions.

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne[1] a eu l'occasion de préciser que l'objet visé était l'objet statutaire, et non l'objet social effectif de la société[2].

Dans l'affaire soumise à la Cour de justice de l'Union européenne, cette conclusion n'était pas évidente pour la raison notamment que les différentes versions linguistiques de la directive n'allaient pas toutes dans le même sens : « objet social » en français, « *tatsächlicher Gegenstand* » en allemand. Cette deuxième formulation laisse ouverte l'interprétation selon laquelle c'est l'activité effective qui est déterminante.

Cette solution, qui peut paraître illogique dans la mesure où elle semble récompenser la malhonnêteté, s'explique par le souci de faire prévaloir la sécurité juridique à l'égard des tiers. Si l'on peut exiger de ces tiers de s'enquérir sur la nature de l'objet statutaire, on peut difficilement leur demander d'être au courant de l'objet social effectif. Si donc les tiers cocontractants ont pu vérifier que l'objet statutaire est licite, la société (du moins s'il s'agit d'une société de capitaux) n'encourt pas de nullité.

La question de la sanction d'un objet social illicite est beaucoup plus incertaine en ce qui concerne les autres sociétés.

C – Prise de décision et représentation de la société

Il convient d'insister sur la distinction existant entre prise de décision et représentation de la société en raison de cette prise de décision.

1) Les règles prévues par le droit de l'Union européenne

Les règles de procédure interne concernant la prise de décision et d'autorisation qui doivent être respectées par les organes de représentation de la société sont **inopposables aux tiers**. En d'autres termes, si un représentant de la société agit en dehors des pouvoirs qui lui sont attribués par la société, alors la société est néanmoins engagée, à moins qu'elle prouve que le tiers était au courant de cette limitation.

Il est encore précisé que la simple publication de la limitation des pouvoirs de ce représentant n'est pas suffisante pour établir cette preuve de la connaissance par les tiers du dépassement de ses pouvoirs.

Pour le dépassement de l'**objet social**, la solution est différente, et celle retenue par la directive est le fruit d'un compromis. Si le texte primitif restait attaché au principe de la spécialité en maintenant l'opposabilité des limitations légales et les limitations de l'objet social, la directive a finalement laissé le choix au législateur national. À condition que la loi nationale le prévoie, la société peut invoquer les dépassements de l'objet social, à charge pour elle de prouver que le tiers « *savait*

1 – V. CJCE du 13 novembre 1990, arrêt *Marleasing*, C-106/89, *Rec.*, 1990, p. I-4139, ID 11663.

2 – Dans le cas visé, le but argué a été la spoliation des créanciers des fondateurs ; J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés*. *Précis*, p. 39.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve »[1].

Tout comme son homologue belge, le législateur luxembourgeois a textuellement repris en droit national ce libellé de la directive. Par ailleurs, certaines législations nationales continuent de se référer à la notion de bonne foi[2], bien que cette notion ait été délibérément abandonnée par les auteurs de la directive pour être trop imprécise[3].

Le résultat de cette transposition était finalement un renversement de la charge de la preuve. La théorie du mandat apparent a souvent été invoquée en matière de représentation de la société, mais beaucoup plus rarement en matière de dépassement de l'objet social[4].

2) Preuve exigée par la société pour renier ses engagements

Quelle est la vigilance que l'on peut attendre du tiers ? Peut-on exiger de lui de procéder à des recherches approfondies ? La disposition légale requiert une appréciation *in concreto* du juge. « *La société devra en fait prouver deux éléments. Le premier, objectif, porte sur la connaissance que le tiers avait de la définition statutaire de l'objet social, le second, subjectif, amène la démonstration que ce même tiers a su mesurer l'incidence de l'acte accompli* »[5]. Dans cette appréciation, il ne faut pas perdre de vue que, dans beaucoup de pays (y compris au Luxembourg), la pratique est de prévoir un libellé extrêmement large à l'égard des clauses relatives à l'objet social de sorte que, à la lecture du pacte social, il est souvent impossible de se faire une idée précise de l'activité réelle de la société.

La question se pose de savoir si des personnes qui ont traité avec les organes d'une société peuvent se prévaloir des restrictions à leurs pouvoirs. Dès 1987, la Cour de cassation belge, en tranchant pour la première fois sur la base des dispositions des directives européennes, a répondu négativement à cette question en reconnaissant à ces limitations un aspect purement interne.

« *Les limitations afférentes à l'objet social doivent être assimilées, comme le fait l'arrêt, aux autres restrictions statutaires. Sans doute, la loi autorise-t-elle une réserve dans l'application rigoureuse de l'inopposabilité mais cette dérogation a été retenue au bénéfice de la société et elle seule peut l'invoquer* »[6].

Le tiers (contrairement à la société) n'est donc pas admis à se prévaloir d'un tel dépassement des pouvoirs de l'organe de la société avec laquelle il a traité.

SECTION V
L'ACTE CONSTITUTIF

Pour être valablement formée la société doit satisfaire certaines formalités. La nature exacte de celles-ci dépend de la catégorie de société concernée. En tout état

1 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.,* 1989, p. 397.
2 – Tel est le cas de l'Italie, du Royaume-Uni, de l'Irlande.
3 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.,* 1989, p. 397.
4 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.,* 1989, p. 398.
5 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.,* 1989, p. 401.
6 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.,* 1989, p. 419.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de cause, il faut un acte écrit dont la forme (notariée ou non) et la nature juridique (contrat ou **acte unilatéral**) varient selon la forme de la société et selon qu'on est en face d'une société à plusieurs personnes ou d'une société unipersonnelle.

Lors de la préparation de la Loi de 1915, l'avant-projet Nyssens avait proposé, afin d'éviter les nullités de sociétés, de faire subir à toute société une **procédure** dite **d'entérinement** qui serait exercée par les juridictions et qui, une fois passée avec succès, rendrait la société inattaquable. Ce système a été critiqué essentiellement parce que l'intervention du tribunal pourrait porter non seulement sur la viabilité juridique, mais comporter en même temps une appréciation sur la valeur de l'affaire et sur sa rentabilité future. On risquerait de faire ainsi renaître les inconvénients de l'autorisation gouvernementale requise pour les sociétés anonymes sous l'empire du Code de commerce de 1808[1].

§ 1 – Nature de l'acte

La nature juridique de l'acte et ses caractéristiques sont très loin de faire l'unanimité.

A – Acte unilatéral ou contrat

La forme du contrat est largement dominante dans la mesure où elle concerne toutes les formes de sociétés, à l'exception de celles de la S.à r.l. et de la S.A. unipersonnelle. Pour ces dernières, l'acte constitutif est un acte unilatéral, alors que pour toutes les autres formes de sociétés, il s'agit d'un contrat. Cette conséquence est due à l'effet de la Douzième directive. En dehors de ces deux exceptions, les sociétés sont toujours fondées sur un contrat.

B – Acte notarié ou acte sous seing privé

Si pour le Code civil la société est un contrat, il n'en reste pas moins que toutes les sociétés ne sont pas soumises au même régime : pour certaines formes de sociétés, il s'agit d'un **contrat consensuel**, alors que pour d'autres formes, il s'agit d'un **contrat solennel**.

L'exigence d'un acte authentique ne date pas d'hier. En effet, déjà le Code de commerce (art. 40) exigeait la formation des sociétés par acte authentique. Comment peut-on justifier ces formalités plus lourdes à l'égard de certaines sociétés ? « *C'est que des intérêts trop nombreux, trop généraux et qui touchent de près à l'ordre public, sont ici engagés. En effet, les sociétés par actions font à tout moment appel au public, chacun est sollicité d'entrer dans une telle société, ce qui se fait par la simple acquisition d'une action ; d'autre part, ces sociétés, par leur importance et l'étendue de leurs affaires, sont habituellement en rapport avec un grand nombre de tiers qui n'ont d'autre garantie que la bonne organisation de la société, administrée conformément à des statuts sérieusement et prudemment rédigés. Il importe donc*

1 – E. Pirmez, *Observations présentées sur l'avant-projet de loi sur les sociétés commerciales* [rédigé par A. Nyssens], p. 12, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

que la constitution sociale soit écrite et qu'elle soit constatée par un acte à l'abri des fraudes, des altérations et de la destruction, c'est-à-dire par un acte authentique »[1].

Aux termes des dispositions de la Première directive européenne, il est indispensable que la constitution des sociétés, et en particulier des sociétés de capitaux, soit soumise à un **contrôle de régularité** lors de la constitution ; en d'autres termes, il faut que quelqu'un s'assure que les conditions de fond et de forme requises pour la constitution de la société soient remplies. En l'absence d'un tel contrôle, les cas de constitution de sociétés irrégulières risqueraient d'être nombreux et les sanctions ultérieures de ces irrégularités ne pourraient que contrarier la volonté déclarée des auteurs de la Première directive, à savoir donc celle de garantir avant tout la sécurité juridique des opérations faites avec les sociétés de capitaux. La directive accorde en fait une option aux États membres, à savoir le choix entre un système de **contrôle administratif ou judiciaire** (soit donc en général par une juridiction commerciale) et un contrôle basé sur un **système d'acte notarié**. Cette solution est retenue par l'article 10 de la Première directive : « *Dans tous les États dont la législation ne prévoit pas un contrôle préventif administratif ou judiciaire lors de la constitution, l'acte constitutif et les statuts de la société ainsi que les modifications à ces statuts doivent être passés par acte authentique* ».

Le Luxembourg a opté pour le deuxième système, donc celui de l'acte notarié obligatoire pour ces trois types de sociétés, conférant la responsabilité limitée aux apporteurs à la société. Par conséquent, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, sous peine de nullité, constituées par acte notarié.

Au Luxembourg, la quasi-totalité des sociétés sont donc formées sous la forme d'un acte notarié, ce qui signifie que les associés, tous présents ou représentés devant notaire, demandent à ce dernier d'acter la constitution d'une société d'une certaine forme et lui précisent les clauses que doivent contenir les statuts de la société.

Néanmoins, au vœu de l'article 100-4 L.S.C. (anc. 4 L.S.C.), les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives et les sociétés à responsabilité limitée simplifiées peuvent être formées par acte sous seing privé, tout en étant dans ce cas en principe soumises à l'obligation de l'article 1325 C.c., qui demande la confection du contrat en autant d'exemplaires que de parties. Il est fait exception à cette règle pour certaines de ces sociétés pour lesquelles deux originaux sont suffisants. En l'absence de règle générale édictée par la loi, les dispositions portant modification statutaire d'une société de personnes sont prises à l'unanimité, sauf si les associés se sont antérieurement départis de ce principe[2].

Une question qui peut se poser en pratique est celle de savoir quelles sont les conséquences du fait qu'une société a été constituée entièrement ou partiellement par des porteurs de mandat, et qu'il s'avère par la suite que les personnes qui se sont présentées à l'assemblée de constitution n'avaient pas de mandat valable. La L.S.C., dans son souci constant d'éviter les cas de nullité de société, retient d'abord le principe que celui qui participe à la société sans avoir reçu de mandat valable ou comme porte-fort sans obtenir par la suite la ratification des engagements a pris la place du mandant ou du tiers défaillant en assumant personnellement les engagements qu'il a déclaré prendre pour le mandant (tiers défaillant). Cette solution est dérogatoire au droit commun pour la raison que le Code civil, en cas d'absence de mandat, ne

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 55, ID 11305.

2 – CA du 2 juin 1999, n° 21265, ID 10241.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

connaît que la responsabilité délictuelle du mandataire et, en cas d'engagement en tant que porte-fort, l'obligation de celui-ci à des dommages-intérêts (art. 1120 C.c.).

Mais la loi ne s'arrête pas à ce point-là : afin d'éviter que des mandats soient donnés à des personnes peu solvables, agissant prétendument pour le compte de personnes honorablement connues ou encore en prenant des engagement au titre de porte-fort dont la ratification est totalement utopique et que la garantie tirée de l'engagement personnel de ces mandataires est sans valeur en raison de leur insolvabilité, la loi prévoit encore la responsabilité des fondateurs qui en demeurent solidairement tenus[1].

La responsabilité des fondateurs se fonde sur des raisons d'ordre public. Celle-ci existe envers tout intéressé et elle est encourue malgré toute stipulation contraire. Dans tous les cas, la responsabilité est aggravée de la solidarité[1]. Cette solidarité ne joue qu'à l'égard des tiers, et non entre les fondateurs : entre ceux-ci, la responsabilité est divise.

■ § 2 – Procédure de constitution en pratique

En pratique, la première démarche consiste à choisir une **dénomination** pour la société à constituer et à vérifier au R.C.S. que ce nom est toujours disponible (c.-à-d. qu'il n'est pas déjà pris par une société existante) au risque d'engager la responsabilité de la société créée au cas où elle adopterait une dénomination identique ou très proche de celle d'une société existante au moment de sa constitution.

Ensuite, il est procédé à l'ouverture d'un **compte** auprès d'une **banque** luxembourgeoise au nom de la société à constituer. À cet effet, la banque doit connaître le nom de la société, le montant du capital social et l'objet de la société (activité commerciale proprement dite, société de participation, détention immobilière, etc.).

Dès que le numéro de compte est attribué, il est communiqué au(x) fondateur(s) afin que les fonds représentant le montant du capital social puissent y être transférés.

Le projet de statuts est préparé par un bureau d'avocat en général et discuté avec les promoteurs de la société. Le cas échéant, des procurations sont envoyées au(x) fondateur(s) avant la constitution de la société.

■ § 3 – Publicité accordée à l'acte constitutif

L'acte de société doit être soumis à des mesures de publicité afin de permettre aux tiers de s'informer sur un certain nombre d'informations qui sont d'un intérêt direct pour eux. Ces informations sont notamment celles qui concernent la forme de la société, les organes habilités à représenter la société à l'égard des tiers, le cas échéant, l'identité des associés (dans les sociétés de personnes), l'adresse statutaire, etc. Cette dernière information est notamment utile pour déterminer le lieu où la société peut être assignée en justice.

Il y a lieu de noter que l'effet de **l'immatriculation de la société au R.C.S.** est assez limité dans la mesure où, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, cette formalité n'attribue pas la personnalité morale. En effet, la personnalité morale est accordée sur la base de la simple signature de l'acte de société, voire du fait de la simple formation de la société de fait.

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 89, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il est vrai qu'il existe au moins une décision de jurisprudence qui affirme le contraire[1] :

« *C'est la procédure d'immatriculation de la société qui confère à celle-ci la personnalité juridique. Cette procédure comprend l'immatriculation au registre de commerce, qui donne la personnalité morale à la société et la publication au* Mémorial *qui rend opposable aux tiers les actes ou extraits d'actes des sociétés* ». Cette décision est clairement erronée. Le seul effet de la publication de l'acte constitutif est que la société peut dorénavant **agir activement en justice**. Avant cette publication, elle peut seulement être assignée en justice (capacité passive) en dehors de toute capacité active.

SECTION VI
LE SIÈGE DES SOCIÉTÉS

Comme les personnes physiques, les personnes morales doivent avoir une adresse, un domicile auquel elles peuvent être atteintes, par exemple pour être assignées en justice. Mais la désignation du siège de la société a d'autres effets qui sont plus importants que ceux attachés à la détermination du domicile à l'égard des personnes morales.

■ § 1 – Siège statutaire et siège réel

Parmi les données que doit contenir tout contrat de société figure le siège social, encore appelé « siège statutaire ». Pour les sociétés anonymes, la disposition en question est comprise à l'article 420-15 (anc. article 27, 3) L.S.C. Des dispositions correspondantes existent, en général pour les autres formes de sociétés également.

Ce siège comporte une série de fonctions, à savoir donc celle d'être l'endroit où la société peut être assignée, où les notifications peuvent lui être faites. Finalement, le siège a encore une autre fonction : celle de déterminer la **nationalité** et donc la loi applicable (en dehors d'incidences fiscales).

Le siège statutaire (qui est unique) résulte des statuts et la détermination de ce siège ne pose pas le moindre problème, étant donné que la consultation des statuts suffit pour en prendre connaissance.

Cette notion diffère de celle de **l'administration centrale** (autrefois appelé principal établissement) ou de siège réel. « *Par principal établissement d'une société, il faut entendre le siège de son administration, le lieu où elle a établi sa comptabilité centrale, où elle a ses archives, où se réunissent ses assemblées générales, où se concentre en un mot l'activité directrice des affaires sociales* »[2].

Cette définition a été reprise par le droit fiscal, et ceci, avec l'objectif déclaré d'harmoniser les notions de droit fiscal et du droit des sociétés. Selon le commentaire relatif au projet de loi 571 (qui a donné lieu à la loi de l'impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, L.I.R.), le Conseil d'État avait proposé de remplacer les termes « leur siège de direction » par ceux de « leur principal établissement » pour assurer la

1 – TA Lux. du 15 juillet 1988, n° 356/88, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – C. Resteau, *Traité des sociétés anonymes*, T. I, p. 27.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

concordance de la notion de droit fiscal avec celle consacrée à l'article 159 L.S.C. (nouv. art. 1300-2 L.S.C.). Par conséquent, le législateur a, en adoptant le concept du principal établissement, changé par rapport à l'ancienne loi qui avait retenu le lieu de la direction d'affaires, notion définie au paragraphe 15, alinéa 1, StAnpG qui reste applicable en vertu de l'article 186, alinéa 2, L.I.R. La détermination de l'endroit du principal établissement est une question de fait à trancher au cas par cas. Compte tenu du changement engagé par le Conseil d'État en 1967, il reste la question de savoir si ce changement correspond à un changement fondamental par rapport à la loi antérieure. En général, on pourra probablement conclure que les fonctions qui normalement relèvent du conseil d'administration dans une société de capitaux et qui même dans des grandes sociétés ne sont pas déléguées à d'autres personnes, font partie de la « *Oberleitung* » de la société[1]. On peut penser que la notion allemande est plus ciblée sur la prise de décision, moins sur l'exécution de ces décisions[2]. Les critères du paragraphe 15 StAnpG se focalisent sur les fonctions du conseil d'administration telles qu'exercées dans les sociétés anonymes.

Il doit s'agir d'un siège réel, et non d'un siège fictif[3]. Mais ce siège ne se confond pas avec le lieu d'exploitation, pas plus qu'avec le domicile de l'administrateur délégué[4].

On s'accorde généralement à considérer que la notion luxembourgeoise ne diffère pas essentiellement de la notion allemande[5]. Au Luxembourg, le siège effectif (administration centrale) a pour fonction supplémentaire de déterminer la loi applicable ou encore la nationalité de la société. Ceci résulte de l'article 1300-2, alinéa 1er (anc. art. 159 alinéa 1er) L.S.C. libellé comme suit : « *Toute société dont l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger* ».

Par le concept de nationalité il s'agit « *de définir l'ordre juridique étatique dont la société tient sa personnalité morale et sous l'empire duquel elle est organisée et fonctionne* »[6]

Lorsqu'une société a donc son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement applicable.

■ § 2 – Domiciliation de sociétés

En 1999, le législateur luxembourgeois est intervenu afin de réglementer une matière qui jusqu'alors était essentiellement abandonnée à la liberté contractuelle : l'essence de cette activité de domiciliation était que certains prestataires de services mettaient un siège social à disposition des sociétés qui souvent n'avaient pas la moindre activité ou présence réelle au Luxembourg.

1 – A. Riewald, *Reichsabgabenordnung*, Berlin, C. Heymann, 1941, cité par Kunsch.

2 – L'endroit où le mot décisif en matière d'affaires de la société est prononcé (RFH du 3 juillet 1936, RStBl 1936, p. 804), où la volonté décisive est formée (RFH du 23 juin 1938, RStBl 1938, p. 949), R. Kühn, *Reichsabgabenordnung*, p. 647.

3 – *R.P.D.B.*, T. 12, V° Sociétés, p. 276 et les nombreuses références de jurisprudence y citées.

4 – *R.P.D.B.*, T. 12, V° Sociétés, p. 277 et les décisions de jurisprudence y citées.

5 – L. Kunsch, « La réforme de l'impôt sur le revenu des collectivités », p. 10.

6 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1992, p. 674.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La loi visée est celle du 31 mai 1999[1] régissant la domiciliation des sociétés et elle définit comme suit cette activité : « *Lorsqu'une société établit auprès d'un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit un contrat de domiciliation* ».

L'objet de cette loi était de réglementer cette activité de domiciliataire en en accordant le monopole d'exercice à certaines **professions réglementées**, à savoir les établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier et du secteur des assurances, avocats, réviseurs d'entreprises, experts-comptables. L'objectif déclaré était d'en moraliser les pratiques. Les obligations des domiciliataires consistent notamment à devoir vérifier le domicile de la société qui se situe à l'endroit du principal établissement de la société : ce dernier est supposé être le lieu du siège statutaire (présomption simple).

La *mission* du domiciliataire consiste à mettre à disposition de la société le « siège statutaire » ou un « siège quelconque » dans le cas où la société a son siège statutaire ailleurs. Le domiciliataire est obligé de faire signer une **convention de domiciliation** avec la société domiciliée et de la faire publier par extraits. Le domiciliataire est encore tenu de vérifier que la société respecte les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales s'il entend éviter que sa responsabilité ne soit mise en jeu. En cas de faute grave (notamment de la part du client), le domiciliataire est en droit de procéder à la dénonciation de la convention, et ceci, sans préavis.

Conformément à l'article 1, alinéa 4, de la loi du 31 mai 1999, les dispositions de la loi ne s'appliquent pas à « *la domiciliation d'une société auprès d'une personne qui est elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société* », condition censée remplie quand la société domiciliataire détient directement ou indirectement plus de 10 % du capital social.

Il résulte de ces dispositions qu'une société peut domicilier dans ses locaux des **sociétés du groupe** pour autant qu'elle soit à même d'exercer sur celles-ci une certaine influence[2]-[3].

Une société à responsabilité limitée, *Caldwell S.à r.l.*, constituée en novembre 2005, connaît un changement d'associé en date du 9 décembre 2005 par lequel tous les titres sont transmis à un ressortissant et résident néerlandais qui, le même jour, prend la qualité de gérant unique de la société. Concomitamment, le siège de direction effective est transféré aux Pays-Bas. Suivant un contrat de prestation de service daté du 28 décembre 2005 conclu avec la société Equity Trust, une adresse pour son siège de direction effective est fournie à cette société aux Pays-Bas.

Le même jour, par un acte effectué par un notaire néerlandais, l'associé unique transfère 99 % des parts à une « *stichting administratiekantoor* » dénommée CW S.à r.l.

En date du 3 janvier 2006, les associés de Caldwell augmentent le capital de ladite société par l'apport de 320 000 actions d'une société néerlandaise Jill Holdings B.V. pour un montant de 123 millions d'euros.

1 – Loi du 31 mai 1999, ID 1694, *Doc. parl.*, n° 4328, ID 9879.

2 – A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 87.

3 – Sur la question des problèmes soulevés par ces versions législatives successives auxquelles la loi sur la domiciliation a été soumise, v. A. Elvinger, « Évolution législative de la décennie 1993-2003 », *ALJB Dr. banc. fin.*, p. 32.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans l'acte notarié portant sur cette augmentation du capital, une exemption est demandée sur base de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1971 sur le droit d'apport (en fait, cet article ne prévoit pas d'exonération du droit d'apport, mais il dispose uniquement que le droit d'apport n'est pas dû lorsque la société bénéficiaire de l'apport maintient son siège de direction effective dans un autre État de la CE).

Du fait du transfert de son siège de direction effective vers les Pays-Bas, Caldwell était d'avis que l'augmentation de capital du 3 janvier 2006 n'était plus soumise au droit d'apport. Étant donné que le droit d'apport avait été aboli aux Pays-Bas avec effet au 1er janvier 2006, cette opération n'aurait été soumise au droit d'apport nulle part. Sauf que l'administration mettait en doute qu'il y avait effectivement transfert du siège de direction effective vers les Pays-Bas. Par conséquent, elle soumit l'opération au droit d'apport de 1 %.

La question fut finalement soumise aux juridictions. Le tribunal d'arrondissement, dans sa décision du 18 avril 2008[1], devait donner raison à l'administration en retenant que le transfert de siège de direction effective vers les Pays-Bas n'était pas établi. Ce jugement retenait que : « *Au contraire, il ressort des éléments de la cause qu'au courant du mois de décembre 2005, la direction et la gestion de Caldwell étaient encore opérées, sinon exclusivement, du moins en majeure partie au Luxembourg, lieu où s'est tenue également l'assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2006.*

Il résulte des éléments qui précèdent qu'au moment de l'augmentation du capital de CALDWELL, son siège de direction effective se trouvait au Luxembourg de sorte que le Receveur a fait une exacte application de la loi ».

Cette argumentation ne parvient pas vraiment à convaincre. En effet, si le tribunal dit que la gestion de Caldwell était encore essentiellement au Luxembourg en décembre 2005, ceci est sans doute vrai, mais dénué de la moindre pertinence dans la mesure où la seule date qui compte était celle du 3 janvier 2006. En définitive, l'élément décisif retenu par le tribunal était l'assemblée générale du 3 janvier 2006. Or cette assemblée n'a pas pu avoir lieu ailleurs qu'au Luxembourg du fait qu'il s'agissait bien d'une société luxembourgeoise avant comme après cette augmentation de capital.

La décision du tribunal fut confirmée en appel en date du 21 octobre 2009[2]. La motivation de l'arrêt est encore moins convaincante que celle du jugement de première instance. « *La charge de la preuve du transfert incombe à l'appelante. En effet, jusqu'au 28 décembre 2005, les sièges statutaire et de direction effective se trouvaient au Luxembourg. Caldwell se prévaut d'un transfert du siège de direction effective à l'étranger ; à elle de prouver ce fait nouveau, contesté par l'intimé. Or, l'appelante n'apporte pas cette preuve ; elle ne fait état d'aucun acte d'administration concret qui aurait été posé aux Pays-Bas. La tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2006 s'est faite au Luxembourg. Il en résulte qu'au jour de l'augmentation de capital, le siège de direction effective de la société Caldwell se trouvait toujours au Grand-Duché* ». Deux remarques : la Cour se contredit lorsqu'elle dit que la Caldwell n'aurait fait état d'aucun acte de gestion posé aux Pays-Bas. En effet, à la page 2 de l'arrêt, la Cour cite la société invoquant les différents actes posés par elle. La Cour donne l'impression que le critère décisif de détermination du siège serait le lieu de la tenue des assemblées générales.

1 – TA Lux. du 18 avril 2008, n° 105744, ID 10311.

2 – CA du 21 octobre 2009, n° 33908, ID 26841.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Cette contradiction fut à la base du pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d'appel. En son arrêt du 9 décembre 2010[1], la Cour de cassation n'a pas accepté cette argumentation en statuant comme suit : « *Mais attendu que la Cour d'appel fonde sa décision sur le motif que "La tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2006 s'est faite au Luxembourg. Il en résulte qu'au jour de l'augmentation de capital, le siège de direction effective de la société Caldwell se trouve toujours au Grand-Duché" ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif décisoire, abstraction faite du motif surabondant, que la société Caldwell n'aurait fait état d'aucun acte d'administration concret posé aux Pays-Bas* ».

La Cour de cassation enfonce donc le clou : en fait, selon elle, la question de savoir si des actes de gestion sont posés aux Pays-Bas n'est pas pertinente, la tenue de l'assemblée générale au Luxembourg à elle seule établit à suffisance que le principal établissement se trouve au Luxembourg. Le résultat est d'autant plus cocasse que l'assemblée générale du 3 janvier 2006 était tenue sur la base de trois procurations données à des personnes résidentes du Luxembourg par les associés néerlandais. Ces procurations ont été établies aux Pays-Bas, de sorte qu'indéniablement la décision d'augmenter le capital était prise aux Pays-Bas, et nullement au Luxembourg.

En tout état de cause, même si elles paraissent critiquables, ces décisions peuvent être considérées comme favorables au secteur de la domiciliation qui n'ont qu'à s'assurer que les assemblées générales soient tenues au Luxembourg (!), la gestion effective peut être considérée comme étant de moindre importance, en fait sans aucune importance (si l'on suit la Cour de cassation). Il est bien vrai que les administrations étrangères risquent d'avoir des vues très différentes sur cette question.

1 – Cass. du 9 décembre 2010, n° 2795, ID 28317.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE IV
OBLIGATIONS ET DROITS DES ASSOCIÉS

Comme toujours, les obligations des associés ont pour contrepartie leurs droits, et vice versa. Nous analyserons en premier lieu les obligations, car celles-ci se matérialisent principalement au début de la vie de la société et sont en fait beaucoup moins nombreuses que les droits des associés.

SECTION I
LES OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS

Les obligations des associés sont en fait peu nombreuses.

§ 1 – Obligation de libérer les actions (parts) souscrites

Il s'agit de la première obligation de l'associé qui, justement, lui confère la qualité d'associé. En effet, au moins dans les sociétés de capitaux, il est indispensable de libérer les titres souscrits, soit en totalité, soit en partie.

A – Libération intégrale ou partielle

Dans les sociétés à responsabilité limitée, il y a obligation de libérer la totalité des parts souscrites (art. 710-6, anc. art. 183 L.S.C.).

Dans les sociétés par actions (S.A. et S.e.c.a.), il suffit que les actions souscrites soient immédiatement libérées **d'un quart**. Pour la partie non libérée, il n'existe pas de délai dans lequel celle-ci devrait être libérée intégralement, sauf pour les apports en nature dont la libération doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq ans.

En cas d'appel de fonds supplémentaires, appel par hypothèse non suivi par l'actionnaire, la L.S.C. prévoit la sanction suivante édictée par l'article 450-1 (8) (anc. art. 67 (7)) L.S.C. : l'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

La question s'est posée de savoir à quel organe revient la compétence de décréter un appel de fonds dans le cadre d'une société anonyme. À cette question, la jurisprudence a répondu comme suit : « *L'article 53, alinéa 1er nouveau* [actuel art. 441-5 L.S.C.] *attribue au conseil d'administration tous les pouvoirs, en ce qui concerne les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale ;*

Attendu que, d'autre part, la loi précitée du 10 août 1915 ne contient pas d'article qui détermine quel organe social d'une société anonyme est compétent pour décider de la libération par un appel de fonds des actions souscrites mais non entièrement libérée ;

Attendu que finalement il ne saurait être sérieusement contesté que les appels de fonds doivent être rangés parmi les actes qu'il peut être nécessaire ou utile de poser pour assurer la réalisation de l'objet social d'une société anonyme. Attendu qu'eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent il est manifeste qu'en vertu de

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

l'article 53, alinéa 1er, de la L.S.C. tel qu'il a été modifié par la loi du 23 novembre 1972, le conseil d'administration de X avait le pouvoir pour décréter l'appel de fonds dont il s'agit en l'espèce »[1].

B – Fixation du prix d'émission des titres

À quel niveau doit être fixé le prix de l'action ? Au vœu de la loi, les titres ne doivent pas être émis au-dessous du pair. Une telle émission reviendrait à une violation du principe de la **souscription intégrale** du capital social. Ce principe a été partiellement abandonné par la Loi de Modernisation (v. sous Partie III). En revanche, il peut y avoir de bonnes raisons pour émettre des titres au-dessus du pair, c.-à-d. « *avec une prime variable, représentative des réserves ostensibles ou occultes destinées à rétablir l'égalité entre les anciens et les nouveaux souscripteurs* »[2].

■ § 2 – Obligation de se comporter en associé de bonne foi

Il s'agit en fait de la notion fortement critiquée et ambiguë d'*affectio societatis*. En somme, celle-ci se réduit à exiger que l'associé évite tout ce qui peut nuire à la société, mais sans exiger des actes positifs de sa part.

Parfois, les juridictions adoptent une conception plus large de cette notion : « *La cour d'appel, condamnant le demandeur sur la base de ces éléments, a considéré de manière implicite mais certaine que toutes les conditions précitées étaient remplies et, plus spécialement, qu'existait en l'espèce, l'*affectio societatis*, impliquant la volonté d'une part, de mettre une chose en commun et, d'autre part, de partager les bénéfices produits par cette mise en commun* »[3].

Selon la jurisprudence luxembourgeoise[4], il s'agirait d'un des éléments spécifiques à la société, lui-même décomposé en trois éléments : collaboration active à la formation et/ ou à la vie de la société, existence d'une égalité de droits et d'obligations et intention de partager les risques et les profits de l'entreprise commune[5].

Dans le cadre du *jus fraternitatis* qui caractérise les relations entre associés, les associés ont le droit et le devoir de collaborer aux activités essentielles de la vie sociale[6].

SECTION II
LES DROITS DES ASSOCIÉS

On distingue traditionnellement les droits politiques des droits financiers et patrimoniaux. De manière plus détaillée, on peut faire état des droits suivants.

---

1 – CA du 22 juin 1993, *P.*, n° 29, p. 108, n° 199, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 125.

3 – Cass. b. du 26 octobre 1989, *Pas.*, n° 10, p. 248, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 22 novembre 1990, nos 13.805 et 13.806, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – I. Corbisier, *Droit des sociétés. Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, p. 18.

6 – L. Maeyens et P. Roose, « Syndicats d'actionnaires de société anonyme », *R.P.S.*, 1964, p. 62.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – Le droit au traitement égalitaire

Le **principe d'égalité** est un principe à portée générale (ayant rang constitutionnel), donc également applicable en droit des sociétés. Il convient toutefois de le préciser dans le sens qu'il exige seulement qu'il y ait égalité entre associés se situant exactement dans la **même situation,** et non égalité entre tous les associés. En d'autres termes, il n'est pas requis qu'il y ait égalité entre associés commandités et commanditaires, pas plus qu'il ne doit y avoir égalité entre associés détenant des titres de différentes catégories (actions A et actions B, actions ordinaires et actions privilégiées, etc.).

De façon générale, la répartition des bénéfices de la société se fait de façon proportionnelle aux apports des associés. Telle est la solution de l'article 1853 C.c. pour le cas où les statuts sont muets sur ce point. En d'autres termes, la règle proportionnelle n'est pas d'ordre public.

Dans une affaire judiciaire retentissante relative à la cession par le *Groupe Bruxelles Lambert (GBL)* d'une participation importante conférant le contrôle de *RTL Group* à *Bertelsmann*, certains actionnaires minoritaires avaient revendiqué le droit d'obtenir la cession de leurs participations aux mêmes conditions financières avantageuses que celles accordées par le Bertelsmann à GBL, et ceci, sur la base du principe d'égalité des actionnaires, principe qui, selon eux, aurait le rang d'un principe général de droit. Cette question avait fait l'objet d'un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation luxembourgeoise à la Cour de justice de l'Union européenne qui, dans son arrêt du 15 octobre 2009, devait retenir que « *le droit communautaire ne contient pas de principe général de droit selon lequel les actionnaires minoritaires sont protégés par l'obligation de l'actionnaire dominant acquérant ou exerçant le contrôle d'une société, d'offrir à ceux-ci de racheter leurs actions aux mêmes conditions que celles convenues lors de l'acquisition d'une participation conférant ou renforçant le contrôle de l'actionnaire dominant* ». Les trois questions préjudicielles soumises à la Cour de justice de l'Union européenne avaient pour objet de savoir si l'existence de certaines dispositions concrètes du droit des sociétés telles que prévues par le droit européen secondaire permettait de conclure à l'existence d'un **principe général de droit** sous la forme de principe d'égalité des actionnaires. Compte tenu de cette réponse, la Cour de cassation dans sa décision du 23 septembre 2010 (n° 54/10, n° 2456 du registre[1]) devait rejeter le pourvoi comme non fondé.

La pratique dite des « *golden shares* » donnant des droits disproportionnés à certaines personnes de droit public est susceptible d'être en conflit avec le droit de l'Union européenne. Tel était en particulier la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire *Portugal Telecom*[2] où l'État portugais, après la privatisation de cette entreprise autrefois publique, conservait uniquement 500 actions privilégiées dont l'accord était requis pour un grand nombre de décisions stratégiques, en particulier pour la modification des statuts. Par ce biais, l'État portugais maintenait sur cette société une influence sans rapport avec l'importance de sa participation, ce qui, selon la Cour de justice de l'Union européenne, est de nature à décourager les investissements directs de la part des investisseurs d'autres États membres, du fait que ceux-ci ne pourraient pas participer à la gestion et au contrôle de cette société

1 – ID 17326.

2 – CJUE du 8 juillet 2010, arrêt C-171/08, *Portugal Telecom*, ID 15861.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

à la hauteur de leurs participations[1]. En l'occurrence, la Cour de justice de l'Union européenne retint qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux ne serait pas justifiée par les raisons invoquées par le Portugal.

§ 2 – Le droit de rester associé et de sortir de la société

En droit luxembourgeois, il n'était traditionnellement pas possible d'exclure un associé de la société faute de disposition expresse consacrant cette solution[2]. Ce point distinguait notre droit du droit allemand notamment (où il est possible d'exclure un associé qui est considéré comme encombrant, « *lästig* »).

La Deuxième directive CEE (77/91) avait dans son article 36 laissé aux États membres la possibilité de pouvoir procéder au **retrait forcé** des actions (en imposant alors un certain nombre de conditions auxquelles une telle possibilité d'exclusion devait être subordonnée). Le législateur luxembourgeois n'a pas repris cette faculté en droit national à l'égard des sociétés de capitaux.

Sur cette notion du retrait forcé d'un actionnaire en droit luxembourgeois, il y a lieu de noter que l'article 450-7 (anc. art. 69-2 L.S.C.), malgré son libellé, ne prévoit pas une clause de retrait forcé (comme la loi aurait pu le faire en application de l'article 36 de la Deuxième directive). La disposition visée concerne les cas d'annulation d'actions propres acquises en application de l'article 430-15 (anc. art. 49-2) L.S.C., ou encore les cas d'acquisition d'un certain nombre d'actions d'un commun accord entre les actionnaires et la société[3].

La question de savoir si un tel droit de rester associé existe ou non est plus difficile à aborder qu'il n'y paraît à première vue. Ainsi, la Cour d'appel de Reims[4] a décidé que les actionnaires n'ont pas un droit intangible de faire partie de la société, surtout pas dans les sociétés anonymes où un tel droit individuel n'aurait guère de sens[5].

Toutefois, une telle possibilité d'exclusion existe, et ceci, en matière de coopératives, selon l'article 812-5 L.S.C. (anc. art. 123) et suivants L.S.C.

Notons que la loi belge[6] (depuis la loi du 13 avril 1995) a organisé une telle procédure d'exclusion et de retrait en utilisant le terme de **justes motifs** plutôt que celui de « comportement » qui évoquait davantage l'idée de faute[7]. L'article 190*quinquies* des lois coordonnées prévoit la faculté pour un actionnaire disposant de plus de 95 % des actions, d'acquérir les actions des actionnaires minoritaires[8].

Conformément au droit romain, les anciens auteurs admettaient que chaque associé est libre de sortir de la société quand bon lui semble. « *Soit que l'union*

1 – P.-E. Partsch, « Chronique de jurisprudence de droit bancaire et financier européen », *BDB*, n° 46, p. 61.

2 – Certains droits étrangers consacrent expressément cette solution. Ainsi, le Code fédéral suisse des obligations (1937) dispose en son article 646 que « les actionnaires ne peuvent être privés sans leur assentiment des droits attachés à leur qualité d'associé ».

3 – I. Corbisier, *Droit des sociétés. Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, p. 449.

4 – CA de Reims du 24 avril 1989.

5 – T. Tilquin, « Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé », *R.P.S.*, 1991, p. 31.

6 – Articles 190*ter* et 190*quater* des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

7 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 141.

8 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 73.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

manque entre les associés ; ou que quelque absence nécessaire ou d'autres affaires rendent la société onéreuse à celui qui veut en sortir ; ou qu'il n'agrée pas un commerce que veut faire la société ; ou qu'il n'y trouve pas son compte ; ou pour d'autres causes. Et il peut y renoncer sans le consentement des autres, même avant le terme où elle doit finir, et quand il aurait été convenu qu'on ne pourrait interrompre la société. Pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi qu'il y renonce […] »[1].

Il existe également une jurisprudence belge selon laquelle il est permis à l'assemblée des associés d'une société ayant émis, en dehors des actions, des parts de fondateurs de supprimer les actions ordinaires et de les remplacer par des actions privilégiées. Les juges du fond avaient considéré la décision de l'assemblée ayant décidé la suppression de cette catégorie comme étant nulle pour le motif que l'assemblée ne pourrait, sans le consentement de l'unanimité des intéressés, porter atteinte aux droits acquis en vertu des statuts[2]. Pour la cour, il résulte de l'article 71 des lois coordonnées que, lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actionnaires, l'assemblée générale peut porter atteinte aux droits attribués par les statuts à certaines catégories d'actionnaires pourvu que dans chaque catégorie soient réunies les conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts. Ceci ne serait pas porter atteinte aux **droits acquis** des associés pour la raison que cette notion se limiterait « *aux avantages attribués par le pacte social à certains associés personnellement et créant dans le chef de ceux-ci des intérêts propres et spéciaux, à l'exclusion des droits conférés par les statuts à des catégories d'actionnaires […] Partant, tous les droits statutaires communs à tous les actionnaires peuvent être modifiés dans le cadre d'une procédure normale de modification statutaire. Bien entendu, le principe de l'égalité devra être respecté à l'occasion du déroulement de cette procédure* »[3].

Il ne faut pas perdre de vue que cette solution consacrée par la Cour de cassation belge est susceptible de donner lieu à des **graves abus**, en particulier en raison du fait que, très souvent, les mêmes personnes possèdent des titres de diverses catégories. Elles peuvent donc facilement concéder des sacrifices sur une catégorie des titres, car ce qu'elles perdent d'un côté, elles le récupèrent de l'autre au détriment, bien entendu, de ceux qui, eux, n'ont que des titres de la catégorie sacrifiée. La décision de la cour a été assez sévèrement critiquée par la doctrine pour violer le principe d'égalité des actionnaires[4].

La théorie des droits acquis n'a de sens qu'en tant qu'elle s'applique aux droits qui trouvent leur source dans les statuts. « *Les droits trouvant leur source dans la loi sont quant à eux soumis aux procédures légales d'abrogation et de modification éventuelle […] Aujourd'hui seuls les droits spéciaux à certains actionnaires – et non les droits propres à une catégorie d'actions – conservent leur caractère de droits acquis. La situation de l'actionnaire individuel est donc similaire à celle d'un tiers – créancier ayant contracté avec la société – laquelle ne pourra modifier la teneur de ses obligations qu'avec son consentement (art. 1134, al. 2 C.c.). Bien que la thèse ait été défendue par les meilleurs auteurs […], on voit mal comment le droit de la libre négociabilité pourrait être un tel droit individuel qui ne serait pas commun à tous les actionnaires* ».

1 – J. Domat, *Lois civiles*, Liv. I, tit. VIII, sect. 5, p. 357.

2 – Cass. b. du 5 juin 1947, *R.C.J.B.,* 5 juin 1947, p. 9.

3 – Cass. b. du 5 juin 1947, *R.C.J.B.,* 5 juin 1947, p. 12.

4 – Cass. b. du 5 juin 1947, *R.C.J.B.,* 5 juin 1947, p. 18.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

A – Causes de dissolution communes à toutes les sociétés

Parmi ces causes, on peut citer l'extinction de la chose, la consommation de la négociation, le *mutuus dissensus* et la dissolution judiciaire (art. 1871 C.c.), notamment pour raison de **mésintelligence grave** entre associés[1].

Art. 1871 C.c.
« La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges ».

La question de savoir si l'article 1871 C.c. est applicable aux sociétés anonymes a longtemps été discutée[2]. La jurisprudence belge a autrefois considéré que, dans les sociétés anonymes, un pouvoir majoritaire est seul habilité à décider de la dissolution de la société. Une minorité n'aurait le droit de demander la liquidation que dans le cas exceptionnel où les pertes sociales ont absorbé les trois quarts du capital de la société[3]. Certains auteurs belges ont encore insisté sur le fait que les situations de blocage total, du fait de l'opposition de deux groupes égaux et hostiles, sont loin de relever du cas d'école, tout en ne trouvant pas de solution dans la loi ou encore dans les statuts. En effet, si, dans les conseils d'administration, il est souvent spécifié qu'en cas de partage des voix la voix du président l'emporte, une telle disposition fait défaut en matière d'assemblée des actionnaires[4].

La jurisprudence belge s'est finalement ralliée à l'opinion défendue en doctrine en décidant l'applicabilité de cet article aux sociétés anonymes[5]. Elle a ainsi rejoint la solution qui était depuis toujours celle de la jurisprudence française[6].

On considère par ailleurs que cette disposition consacre une règle **sinon d'ordre public, du moins impérative** (étant donné qu'elle protège des intérêts privés), en vertu de laquelle les associés ne peuvent pas d'avance renoncer à se prévaloir de cette possibilité de faire dissoudre la société par le juge[7].

En premier lieu se pose la question de savoir si la dissolution peut être prononcée sur la base du droit commun des obligations, donc sur la base de l'article 1184 C.c. qui permet **d'exclure celui qui manque à ses obligations**, et ceci, tant dans les sociétés que dans les associations[8]. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution que

1 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 135.

2 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 296.

3 – P. Coppens, « Le cas des sociétés anonymes paralysées par deux groupes hostiles et le "juste motif" de dissolution de l'article 1871 du Code civil », *R.P.S.*, 1954, p. 209.

4 – P. Coppens, « Le cas des sociétés anonymes paralysées par deux groupes hostiles et le "juste motif" de dissolution de l'article 1871 du Code civil », *R.P.S.*, 1954, p. 210.

5 – Trib. com. Bruxelles du 12 juin 1973, *R.P.S.*, 1974, p. 270.

6 – P. Coppens, « Le cas des sociétés anonymes paralysées par deux groupes hostiles et le "juste motif" de dissolution de l'article 1871 du Code civil », *R.P.S.*, 1954, p. 213.

7 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 296.

8 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 218.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dans les sociétés (associations) multipartites[1]. La résolution ne produit « *que des effets relatifs et restreints à celui qui n'exécute pas ses obligations ou qui se plaint qu'à son égard on n'ait pas exécuté les obligations résultant du contrat* »[2].

Cette situation telle qu'elle résulte de l'application du droit commun des obligations peut, le cas échéant, être infléchie par les dispositions du droit des sociétés et, en particulier, par l'article 1871 C.c. qui autorise chaque associé d'une société à terme à demander la dissolution, avant le terme, pour **justes motifs**, notamment lorsqu'un autre associé manque à ses engagements. Sont assimilés à ce cas celui d'une **infirmité habituelle** le rendant inhabile aux affaires de la société ainsi que d'autres « **cas semblables** ». Il existe d'importantes différences entre les articles 1184 et 1871 C.c. étant donné que l'article 1184 C.c. est supplétif alors que l'article 1871 C.c. est impératif[3].

En outre, l'article 1184 C.c. n'opère la résolution d'un contrat pluripartite qu'à l'égard de celui qui a manqué à ses engagements ; l'article 1871 C.c. opère la dissolution de la société à l'égard de tous.

Si les articles 1869 et 1870 C.c. concernent la renonciation des associés, l'article 1871 C.c. est abandonné à l'appréciation des juges. C'est au juge qu'il appartient de prononcer la dissolution de la société pour cause grave[4]. La loi mentionne deux cas précis dans lesquels le juge sera dénué de tout pouvoir d'appréciation : celui où l'un des associés manque à ses engagements et celui où une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société.

Le premier cas n'est pas autre chose que la **clause résolutoire tacite** qui est donnée dans tous les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à ses engagements. Dans ce cas de figure, le juge doit d'abord constater s'il y a effectivement inexécution des engagements avant de constater les motifs pour lesquels une des parties n'a pas rempli ses engagements. Selon le cas, il peut accorder un délai au débiteur. Si, à l'expiration de ce délai, il n'y a pas exécution de la part du débiteur, la dissolution doit être prononcée[5].

Pour tous les autres cas non expressément prévus par la loi, c'est au juge qu'il appartient « *d'apprécier la légitimité et la gravité* ».

« *La société en nom collectif emporte pour tous les associés l'obligation de prendre part à la gestion des affaires sociales. Cet engagement est une obligation de faire ; or, personne ne peut être contraint à faire ; donc, du moment que l'un des associés refuse de faire ce à quoi il était tenu, la société doit être dissoute* »[6].

La **mésintelligence** entre associés constitue un juste motif au sens de l'article 1871 C.c. permettant de prononcer la résiliation du contrat de société. Les parties reconnaissent l'impossibilité de réaliser la société par suite des incidents survenus[7].

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en dissolution d'une société commerciale pour l'une des causes prévues expressément ou

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 218.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 219.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 219.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 408.

5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 409.

6 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 411.

7 – Cour 20 février 1920, *P.*, n° 11, p. 79, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

implicitement par l'article 1871 du Code civil. La mésentente grave entre associés constitue un motif autorisant la dissolution anticipée d'une société, dès lors qu'elle empêche toute action commune et met en jeu l'existence de la société. De mauvais rapports entre associés qui n'entravent pas le fonctionnement normal de la société sont par contre insuffisants pour conduire à la dissolution de la société.

Nonobstant ces différences, il n'y a pas d'indications selon lesquelles les auteurs du Code civil aient entendu écarter la disposition de l'article 1184 C.c. à l'égard du contrat de société. Par ailleurs, l'article 1871 C.c. est de nature impérative, de sorte que chaque associé susceptible de l'invoquer peut y renoncer[1]. Les associés autres que celui qui est à l'origine de la faute critiquée peuvent renoncer à l'application de l'article 1871 C.c. et opter en faveur d'une résolution partielle sur le fondement de l'article 1184 C.c.

À noter que le tribunal saisi en application de l'article 1871 C.c. d'une action en dissolution de la société ne pourrait pas prononcer l'exclusion d'un associé sur la base de l'article 1184 C.c. au lieu de la dissolution de la société[2].

B – Causes de dissolution spéciales aux sociétés à durée limitée

Les sociétés de ce genre sont dissoutes en cas d'expiration du terme fixé par les statuts, sans préjudice de la nécessité de procéder à une modification des statuts en bonne et due forme *avant* l'arrivée du terme de la société.

La décision de prorogation de la société doit obligatoirement intervenir avant l'échéance de ce terme. Sinon, la société est dissoute et « *aucune décision de l'assemblée générale des associés ne peut la remettre en vie* »[3].

Lorsque la « prorogation » intervient après l'échéance du terme, cette décision sera considérée comme un acte constitutif d'une société nouvelle. Toutes les conditions requises à cet effet doivent donc être remplies, et la décision doit être prise à l'unanimité. Mais encore faut-il que les associés présents aient effectivement l'intention de ce faire[4].

C – Cas particulier des sociétés à durée illimitée

L'article 1869 C.c. prévoit une solution spécifique applicable aux seules sociétés à durée illimitée.

Art. 1869 : « ***La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contretemps*** ».

À l'égard des sociétés à durée illimitée, la loi prévoit donc qu'il peut y avoir dissolution par **volonté unilatérale** d'un des associés, et donc sans l'intervention du

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 220.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 220 ; J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1966-1971), *R.C.J.B.,* 1973, p. 538.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1966-1971), *R.C.J.B.,* 1973, p. 546.

4 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1966-1971), *R.C.J.B.,* 1973, p. 541.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

juge. Il est vrai que, par le passé, il a été soutenu que le mode de dissolution de l'article 1871 C.c. serait commun aux sociétés à durée limitée et illimitée. L'associé pourrait avoir intérêt à ne pas se prévaloir de sa faculté de résiliation unilatérale et à demander donc la dissolution judiciaire pour justes motifs sur la base de l'article 1871 C.c. afin d'éviter toute discussion quant à la bonne foi et quant à l'opportunité de sa décision[1].

Cette opinion ne fait pas l'unanimité : « *À notre avis, l'article 1871 ne peut, comme le veut son texte et la* ratio legis*, s'appliquer qu'aux sociétés à terme. Dans les sociétés à durée illimitée, l'associé dispose soit de l'article 1869 qui se rattache au principe général de la liberté individuelle, c'est-à-dire à l'interdiction d'ordre public de l'engagement à vie dans tous les contrats à prestations successives sans limitation de durée (cf. article 1780 du Code civil […]), soit de la condition résolutoire tacite […]* »[2].

Dans ce contexte, il faut noter qu'une société (en l'occurrence une S.à r.l. constituée pour une durée de 99 ans) est constituée pour une durée illimitée, car constituée pour une durée supérieure à la vie humaine[3].

Les solutions prévues par cet article 1869 C.c. et l'article 1870 C.c. constituent des applications du droit commun ; les contrats à durée indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement par chacune des parties, étant entendu que cette faculté ne peut être exercée de manière abusive. C'est donc dans la théorie générale de l'abus de droit qu'il faut rechercher s'il y a usage abusif de la faculté de mettre fin à la société formée pour une durée illimitée[4].

Il y a toutefois lieu de noter que le droit des sociétés connaît une entorse d'importance à ce principe dans le sens qu'il est précisé que cette règle de l'article 1865-5 C.c. ne s'applique pas aux sociétés anonymes, S.e.c.a., S.à r.l. et aux sociétés coopératives à durée illimitée.

« *Mais cela ne doit pas conduire à rejeter toute prise en considération de l'intérêt des autres associés. La théorie de l'abus de droit impose de vérifier si l'avantage recherché ou obtenu par l'associé qui se retire n'est pas hors de toute proportion avec l'atteinte que cette décision porte à l'ensemble des autres intérêts liés à la continuité des activités sociales, en ce compris l'intérêt des autres associés* »[4].

La jurisprudence belge[5] retient qu'il faut apprécier le comportement de l'associé qui souhaite provoquer la dissolution de la société au regard de l'intérêt de la société elle-même, et non au regard de l'intérêt des associés qui sont opposés à la dissolution.

La loi permet à tout associé de demander la dissolution de la société à tout moment. La raison d'être de cette disposition est d'éviter les **engagements perpétuels** des associés dans les sociétés à durée illimitée. Cette règle perd par conséquent toute justification à l'égard d'un associé qui est sur le point d'être exclu, ceci d'autant plus que la demande doit être faite de bonne foi, et non à contretemps[6]-[7].

---

1 – V. en ce sens L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. IV, n° 260.

2 – J. Lehrer, « La dissolution des sociétés pour justes motifs », *R.P.S.*, 1962, p. 177.

3 – Douai du 26 mars 1959, *Journ. Soc*., 1961, p. 142.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1992, p. 700.

5 – Trib. com. Audenarde du 29 octobre 1987, *T.R.V.*, 1988, p. 68 et note J.R.

6 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 221.

7 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.,* 1992, p. 699.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette cause de dissolution existe uniquement dans les sociétés de personnes. La question est de savoir si elle s'applique dans les S.à r.l.[1].

Selon la jurisprudence française, l'article 1871 C.c. est considéré comme étant d'ordre public[2].

Si l'article 1871 est d'ordre public, alors la clause par laquelle les associés renonceraient par avance à invoquer les justes motifs serait nulle. Serait encore inopposable au demandeur toute clause des statuts qui subordonnerait l'action à une délibération de l'assemblée générale[3].

La jurisprudence luxembourgeoise a eu l'occasion de préciser ces notions. Ainsi, la cour d'appel retient « *[…] qu'une renonciation est faite de mauvaise foi lorsque l'associé s'est retiré pour profiter seul de la jouissance de biens d'une succession qui est sur le point de s'ouvrir et qui serait tombée dans la société ou pour faire à son compte un marché que la société allait faire. Une renonciation est faite à contretemps si la société a de grands stocks en magasin et où une vente imminente serait désastreuse ou si la société a l'espoir légitime de réaliser sous peu d'importants bénéfices. Ce qu'il faut donc prendre en considération, c'est l'intérêt commun de la société et non pas l'intérêt particulier de celui qui s'oppose à la renonciation* »[4].

D – Les clauses d'exclusion

L'exclusion d'un associé est à distinguer de la dissolution de la société, sur la base de justes motifs tels que prévus par l'article 1870 C.c. Le juge invité à appliquer l'article 1871 C.c. ne peut que prononcer la dissolution de la société ou bien la rejeter si la demande ne lui paraît pas motivée à suffisance. En revanche, il ne peut pas prononcer l'exclusion d'un associé[5]. Par contre, la clause de sortie d'un associé a pour objet de permettre l'exclusion d'un associé et la continuation de la société entre les autres[6].

Selon les juridictions belges[7], l'exclusion n'est possible qu'en cas de faute et sauf recours aux tribunaux de l'associé exclu. Cette approche est basée sur la notion d'*affectio societatis*[8] et, par conséquent, certains auteurs considèrent que ce principe ne peut faire obstacle à l'autonomie de la volonté[6] ; selon cette approche, l'exclusion d'un associé serait possible sans lui ouvrir le recours aux tribunaux, à condition qu'il soit remboursé pour le montant de sa part[9].

---

1 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 135.

2 – V. Cass. com. fr. du 23 janvier 1950, C.Cl. P, n° 5355 ; Cass. com. du 5 décembre 1956, *Bull. Cass*., 3, p. 289 ; Cass. com. fr. du 12 juin 1961, *D.*, p. 661.

3 – J. Lehrer, « La dissolution des sociétés pour justes motifs », *R.P.S.*, 1962, p. 178, qui se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation française.

4 – CA (civ.) du 21 novembre 2001, n° 24.504 ; TA (civ.) du 22 avril 2001, n° 72.251 ; Fr. Fayot, *Ann. dr lux.*, 2001, n° 11, p. 585, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Ce point est parfois négligé par les juridictions : v. CA Bruxelles du 22 mars 1988, *J.T.*, 1988, p. 585.

6 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 700.

7 – CA Bruxelles du 22 mars 1988, *J.T.*, 1988, p. 585.

8 – Expression empruntée à Ulpien.

9 – J. Kirkpatrick et B. Glansdorff, « Les statuts d'une société de personnes peuvent-ils conférer à la majorité des associés le pouvoir de dissoudre la société avant le terme convenu ou d'exclure un associé ? », *R.C.J.B.*, 1967, p. 208.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Souvent, le caractère *intuitu personae* du contrat de société est invoqué pour justifier que les cas de mésintelligence entre associés soient résolus non pas par l'exclusion de l'associé, mais par la dissolution de la société. Ces caractères ne relèvent pourtant ni de l'ordre public ni de l'essence de ces sociétés[1]. Il est par conséquent généralement reconnu que les clauses d'exclusion d'un associé sont en principe valables[2]. Ces clauses d'exclusion précisent souvent les motifs pour lesquels l'exclusion est possible. La plupart du temps, il s'agit de manquements au contrat de société. Alternativement, il peut s'agir de justes motifs au sens de l'article 1871 C.c.[3].

Pour les **sociétés coopératives**, la sortie de la société résulte de dispositions particulières, dans le sens que la démission ne peut intervenir que dans les six premiers mois de l'exercice social (art. 812-5, anc. art. 123 L.S.C.), en dehors du fait que l'exclusion d'un associé est possible également[4]. En outre, contrairement aux autres sociétés commerciales, la société coopérative n'est en principe pas fermée, au contraire. Tout tiers qui remplit les conditions prévues par les statuts peut en principe devenir membre de la société[4].

■ § 3 – Le droit de ne pas voir les engagements augmentés

Dans les sociétés, les décisions sont de façon générale prises à la majorité (soit simple, soit qualifiée). Cet aspect est un des principaux arguments contre la théorie contractuelle en tant que fondement du droit des sociétés dans la mesure où il est difficile d'expliquer qu'un contrat qui a été conclu à l'unanimité au moment de la constitution de la société puisse être changé par simple majorité, fût-elle qualifiée.

Mais, au moins sur un point, la théorie contractuelle prend le dessus, à savoir donc que les engagements des associés ne pourront pas être augmentés contre leur gré. Néanmoins, de telles augmentations des engagements pourront se révéler nécessaires dans certains passages difficiles pour la société.

Exemple

La société TACO S.A. connaît de sérieuses difficultés financières. La banque « maison » est prête à accorder des prêts supplémentaires, mais à condition que les associés fassent eux-mêmes un effort, et ceci, sous la forme d'une augmentation de capital de 400 000 euros à 800 000 euros. Les associés représentant ensemble 80 % des actions sont d'accord pour augmenter le capital social, mais non plusieurs associés minoritaires qui détiennent les titres restants. L'augmentation de capital ne peut se faire, car les associés minoritaires y sont opposés.

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 220.

2 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1966-1971) », *R.C.J.B.*, 1973, p. 538.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 228.4 – J.-P. Spang, « Les changements apportés au droit des sociétés et des associations par les lois introduisant en droit luxembourgeois les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et créant des fonds de pension (SEPCAV et ASSEP), *BDB*, n° 29, p. 19.

4 – J.-P. SPANG, « Les changements apportés au droit des sociétés et des associations par les lois introduisant en droit luxembourgeois les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et créant des fonds de pension (SEPCAV et ASSEP), BDB, n° 29, p. 19.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans le cas particulier où la société a subi d'importantes pertes, le moyen pour néanmoins réaliser cette opération est la technique ancienne du **coup d'accordéon** qui consiste à réduire le capital social à zéro (opération qui ne fait que faire correspondre le capital social avec la situation effective de la société), dans une première phase, pour recapitaliser la société ensuite, au moyen de nouveaux apports, dans une deuxième phase. Il y aura augmentation de capital, mais celle-là se fera sans droits préférentiels de souscription au profit des anciens actionnaires, ceux-là ayant cessé d'être associés au moment de la réduction (à zéro) du capital social[1].

D'autres cas d'augmentation des engagements des associés sont les suivants :

– l'allongement de la durée de vie de la société ;
– la transformation d'une société de capitaux en société de personnes (ce qui fait passer au moins certains des associés d'une responsabilité limitée à une responsabilité illimitée).

Un autre cas où l'unanimité des associés était traditionnellement requise était celui du changement de nationalité de la société. Ce changement de nationalité comporte souvent une modification tellement fondamentale du cadre légal auquel la société est soumise qu'il ne peut être exclu que, sur l'un ou l'autre point, il y ait une augmentation des engagements sociaux des associés.

L'unanimité est donc en fait justifiée par cette même raison de l'interdiction d'augmenter les engagements des associés. Le document parlementaire relatif à la Loi de 1915, en se référant au législateur français mentionne : « *Il serait inique qu'une assemblée pût imposer à des actionnaires d'une société française les dispositions d'une loi étrangère* »[2]. Néanmoins, la Loi de Modernisation a aboli l'exigence de l'unanimité pour la remplacer par celle de la majorité requise pour les changements de statuts.

■ § 4 – Les droits politiques

Par droits politiques, on entend les droits que l'associé, un peu comme le citoyen dans la cité ou dans l'État, peut faire valoir dans le cadre de sa communauté (urbaine ou nationale). Il s'agit en premier lieu des droits d'information et, surtout, du droit de vote.

A – Le droit d'information

Le droit d'information comporte d'abord le droit d'obtenir des **informations périodiques** sur la marche de la société. En général et au minimum, cette information doit être annuelle. Il s'agit de l'information que l'associé reçoit dans les sociétés de capitaux avant l'assemblée annuelle des associés et qui doit lui permettre d'exercer ses droits de vote en bonne connaissance de cause. Les informations visées ne sont pas davantage commentées à cet endroit. Le lecteur intéressé sera prié de se rapporter au chapitre consacré aux comptes annuels. Telle est donc la situation pour les sociétés de capitaux.

1 – À ce sujet, v. A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 294.

2 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport de la commission spéciale, p. 285.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

De nos jours (en fait, depuis 2005), ces exigences sont largement généralisées dans la mesure où les obligations de présentation et de publication des comptes annuels sont étendues à toutes les entreprises et donc à toutes les sociétés.

Le registre des actions nominatives est accessible aux associés (mais non aux tiers dont on craint la curiosité indiscrète)[1]. Le registre des actions au porteur tenu par un dépositaire choisi par la société n'est pas accessible par les actionnaires (sauf en ce qui concerne les informations le concernant directement).

Pour les sociétés de personnes, la loi est muette sur les droits des associés. Toutefois, leur droit à l'information est certainement plus important encore que dans les sociétés de capitaux, et ceci, pour deux raisons. En premier lieu, la responsabilité illimitée (et solidaire) des associés fait que ceux-ci ont un intérêt beaucoup plus direct à la marche des affaires que les associés des sociétés de capitaux. En deuxième lieu, les associés de ce genre de sociétés sont en principe tous gérants en même temps qu'associés et, à ce titre, ils sont donc souvent actifs à plein temps dans la société : leur droit d'information est donc sans limite.

Même en l'absence de texte spécifique, les associés devaient avoir la possibilité de poser des questions aux dirigeants de la société, du moins dans les sociétés de personnes.

« *Le droit de l'assemblée de demander au conseil d'administration et au commissaire aux comptes tous renseignements susceptibles de l'éclairer avant d'approuver les comptes n'a pas à être transféré aux actionnaires à titre individuel : un actionnaire n'a droit qu'aux informations que la société doit donner aux actionnaires conformément à la loi (en vertu de l'art. 73 L.S.C.). Admettre à un actionnaire, fût-il détenteur de 76 % du capital, un droit de communication plus étendu entraînerait une gêne considérable dans le fonctionnement des sociétés* »[2].

Dans les sociétés cotées en bourse, les exigences portant sur l'information des associés ont évidemment une tout autre envergure en ce qui concerne le volume de l'information et aussi en ce qui concerne les destinataires de cette information. Ces informations sont en effet diffusées par les médias de communication et ne sont donc nullement limitées aux associés actuels ; elles s'adressent au grand public en général. En deuxième lieu, les marchés financiers de nos jours exigent une information quasi générale et extrêmement rapide qui dépasse de très loin les obligations d'information qui peuvent être prévues par les textes légaux et réglementaires. Les sociétés qui ne se plient pas à ces exigences (notamment de publier un « *profit warning* » aussi tôt que possible) voient leurs titres boudés par les investisseurs professionnels, avec donc la conséquence que la chute des cours est inévitable dès qu'une société a la réputation d'avoir une politique de communication insuffisamment transparente. En d'autres termes, les marchés financiers globalisés imposent des standards d'information qui vont bien au-delà de ceux que prévoient les dispositions légales.

La loi accorde une place de plus en plus grande à **l'information** tant des associés que des tiers. Les actionnaires individuels ont, pendant un délai de quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle, le droit de prendre connaissance des comptes annuels au siège de la société. Leur droit individuel ne va pas plus loin. Il est impossible d'accorder des **droits d'investigations individuels** aux actionnaires.

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 95, ID 11308.

2 – TA Lux. du 28 juillet 1986, n° 832/86, ID 11777.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Ceux-ci sont donc tenus de s'en remettre aux commissaires (réviseur d'entreprises). Mais ces organes sont nommés par la majorité qui peut être aveugle ou encore oppressive. Il fallait donc prévoir une solution pour ces cas dans le sens qu'il fallait accorder aux minoritaires, représentant tout de même une proportion appréciable du capital, un droit spécial de vérification par des commissaires spéciaux[1].

La L.S.C. prévoit ainsi une mesure qui, en réalité, débouche sur un véritable droit d'investigation : il s'agit de l'article 1400-3 [anc. art. 154] L.S.C.

« *Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social ou 10 pour cent des voix attachées à l'ensemble des titres existants, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit à l'organe de gestion des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés contrôlées au sens de l'article 1711-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt des sociétés comprises dans l'obligation de consolidation. Une copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du contrôle légal des comptes.*

À défaut de réponse dans un délai d'un mois, ces associés peuvent demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société.

Le juge détermine si le rapport doit faire l'objet d'une publicité.

L'usufruitier d'actions ou de parts sociales bénéficie également des droits énoncés au présent article ».

L'art. 430-2 [anc. art. 38] L.S.C. a connu une modification bien justifiée par la Loi de Modernisation. Si les droits attachés aux actions ayant plusieurs propriétaires peuvent être suspendus par la société jusqu'à la désignation d'une seule personne, la nouvelle version de cet article précise désormais que ceci ne concerne pas les droits à l'information visés à l'article 461-6 [anc. art. 73] L.S.C. dont continuent donc à bénéficier tous les propriétaires indivis. Cette solution (entièrement justifiée) a également été introduite pour la S.à r.l., art. 710-9 L.S.C.

B – Le droit de vote

Le droit de vote est le droit de pouvoir **participer aux décisions** dans toutes les assemblées des associés (qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires) et, de façon plus générale, de pouvoir participer aux décisions qui sont de la compétence des associés. En effet, la tenue d'assemblées générales des associés n'est pas obligatoire dans toutes les formes de sociétés. Dans plusieurs types de sociétés commerciales, la tenue d'une assemblée annuelle n'est pas requise. Tel est, par exemple, le cas des S. à r. l., dans la mesure où celles-ci n'ont pas plus de 60 associés (25 avant la Loi de Modernisation). Les décisions portant sur les comptes annuels se prennent alors par **vote circulaire**.

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 364, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le droit de vote constitue une prérogative très essentielle de l'actionnaire, dans le sens qu'il lui permet de veiller à la protection de son patrimoine investi dans la société. En principe, l'actionnaire n'a pas de prise sur la gestion de la société. Son droit de vote lui permet pourtant d'influencer le vote de l'assemblée, au moins dans la mesure où il fait partie de la majorité des associés[1].

Le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives est **d'ordre public**, ce qui exclut donc que les statuts puissent y déroger en le lui enlevant[2]-[3]. En particulier, avant la Loi de Modernisation, les statuts ne pouvaient, en dehors des situations prévues par la loi, procéder à la suppression du droit de vote pour certains des associés[4]. Cette situation a changé depuis la Loi de Modernisation. La L.S.C., dans sa partie consacrée aux sociétés anonymes, prévoit également la possibilité d'émettre des actions sans droit de vote.

Par le passé, la L.S.C. interdisait encore le **vote plural,** et ceci, en réaction à la situation ayant prévalu autrefois. Par actions à vote plural, on entend des actions auxquelles sont attachées deux ou plusieurs voix, alors que d'autres actions de même valeur théorique ne disposent que d'un seul vote[5].

En Belgique, le vote plural a été aboli par l'arrêté royal n° 26 du 31 octobre 1934. Par le passé, le vote plural était censé défendre certaines affaires contre les reprises par des spéculateurs belges ou étrangers. Toutefois, certaines utilisations abusives en avaient été faites permettant la mainmise de quelques actionnaires qui étaient loin d'avoir la majorité du capital de la société[6].

Dans le droit des sociétés belge et luxembourgeois, « *le droit de vote est considéré comme une prérogative essentielle de l'actionnaire, ou, plus exactement comme un attribut essentiel de l'action, car il permet à l'actionnaire de veiller à la protection de ses intérêts au sein de la société. Le droit de vote est d'ordre public : il ne peut être enlevé à l'actionnaire. Hormis les cas où la loi le permet explicitement, il n'est pas possible de créer des actions sans droit de vote* »[7].

Traditionnellement, il était admis que les actions de la S.A. doivent obligatoirement être à valeur égale ; pour écarter tout doute, l'article 47 L.S.C. disposait : « *Le capital des sociétés anonymes se divise en actions d'égale valeur, avec ou sans mention de valeur* ». La Loi de Modernisation a supprimé le passage souligné de la phrase précédente en permettant ainsi l'émission d'actions de valeur inégale. Ce changement induit une autre modification, à savoir celle de l'article 450-1 [anc. art. 67] L.S.C. relatif à la tenue des assemblées générales ; une fois le principe des parts d'égale valeur abandonné, il fallait déterminer les droits de vote attachés à ces actions désormais (le cas échéant) de valeur inégale. Comme souvent, les auteurs de la Loi de Modernisation se sont inspirés du droit belge (concrètement de l'article 451 du Code belge des sociétés en adoptant la nouvelle version du paragraphe (5) de cet article ainsi libellé :

1 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 242.
2 – M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 169.
3 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 243.
4 – V. Cass. Com. fr., *Rev. soc*., 1999, p. 80, note P. Le Cannu.
5 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 259.
6 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 32.
7 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.*, 1991, p. 225.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« *Lorsque les actions sont de valeur inégale ou que leur valeur n'est pas mentionnée, sauf disposition contraire des statuts, chacune d'elle confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible ; il n'est pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à l'article 450-4* ».

En clair, ceci signifie que, sauf si les statuts prévoient autre chose, les actions de valeur inégale confèrent un droit de vote proportionnel à leur participation dans le capital social, la quotité la plus faible comptant pour une voix. Cette règle n'est que supplétive (dans le silence des statuts). Lesdits statuts peuvent donc parfaitement maintenir la règle traditionnelle « une action une voix ». Avec des actions à valeur inégale, cette règle qui paraît comme l'incarnation du principe d'égalité entre associés s'avère être le contraire de cette égalité. Supposons que A souscrit 10 actions à un euro chacune alors que B souscrit 1 action à 10 euros. Si les statuts prévoient le principe une action une voix, alors A aura en définitive un droit de vote multiple (10 pour 1) par rapport à B[1].

Quelle est la nature du droit de vote ? S'agit-il d'un **droit-fonction** ou non ? Par droits-fonctions, on entend des droits qui sont accordés à leur titulaire non pas dans leur intérêt propre, mais dans celui d'autrui. « *Le droit-fonction doit être exercé dans le but pour lequel il a été créé et ne peut être détourné de sa finalité par opposition au droit subjectif égoïste, qui peut être exercé dans le seul intérêt du titulaire, sous réserve de l'abus de droit* »[2]. Si la doctrine traditionnelle considérait que le droit de vote des administrateurs devait être exercé dans l'intérêt de la société, il en irait différemment pour les actionnaires : en effet, l'actionnaire n'est ni obligé de voter aux assemblées, ni même de participer à celles-ci[2].

En général, on s'accorde à dire que le droit de vote serait à la fois une prérogative et une fonction. Il s'agit d'un « *moyen de défense du patrimoine de l'actionnaire et d'un procédé de gestion de la société […] On admet donc que, si l'actionnaire est en droit d'assurer la défense de ses propres intérêts par l'exercice du droit de vote, il doit consentir certains sacrifices au nom de la société* »[2].

Une question directement liée à la précédente est celle de savoir si les associés sont obligés de participer aux assemblées des associés. La réponse est clairement non. On pourrait toutefois aboutir à des situations où aucun des associés ne participerait aux assemblées annuelles des associés. La conséquence de cet état de choses serait alors que la société ne pourrait plus normalement fonctionner. L'absence d'*affectio societatis* étant ainsi établie, ceci pourrait, le cas échéant, conduire à une dissolution judiciaire de la société, mais sans qu'il ne soit possible d'enjoindre aux associés de participer aux réunions des associés.

La cession du droit de vote contre paiement (« trafic de vote ») a depuis toujours été considérée comme prohibée. Expressément interdit par le projet de Cinquième directive (article 35, c), le trafic de vote fait l'objet de sanctions pénales en droit français (article 440, 3 de la loi du 24 juillet 1966).

1 – Selon l'exemple donné par L. Schummer et S. Weydert, « Le nouveau régime des titres », *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, p. 180.

2 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.*, 1991, p. 239.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

C – Droit de vérification des comptes

Comme indiqué sous « A – Le droit d'information », les associés de sociétés anonymes ou encore de sociétés coopératives bénéficient d'un droit spécial consistant à pouvoir demander la vérification des comptes. Cette faculté est prévue par l'article 1400-3 L.S.C. qui permet aux associés représentant **10 % au moins** du capital de demander par la voie judiciaire la désignation d'un ou de plusieurs commissaires chargé(s) de procéder à la vérification des comptes de la société avec toutefois une **mission bien précise**. Le « *tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale* » **nomme un ou plusieurs commissaires** ayant pour mission de vérifier les livres et comptes de la société. Le jugement du tribunal précise les points sur lesquels portera l'investigation et fixe la consignation préalable à effectuer pour le paiement des frais ; ces frais pourront être compris dans ceux de l'instance auxquels donneraient lieu les frais constatés. Le rapport est déposé au greffe.

■ § 5 – Les droits financiers

Ceux-ci sont de plusieurs ordres. En premier lieu, l'associé a le droit de bénéficier d'une participation aux bénéfices courants de la société.

A – Droit au bénéfice annuel

Tous les ans, l'organe de direction de la société doit établir des **états financiers** selon des règles plus ou moins précises et détaillées en fonction de la nature de la société concernée. Sur la base de cet état de la situation économique et financière, le résultat est affecté d'une certaine façon par les associés. La liberté des associés quant à la répartition du résultat annuel est en principe entière, avec cependant certaines restrictions. Signalons d'abord que, si le résultat annuel est négatif (et si, en même temps, la société est déficitaire globalement, donc y compris les années antérieures), il n'y a pas lieu de décider de l'affectation de celui-ci[1] : la perte réalisée vient tout simplement en diminution des fonds propres de la société.

Quelle est la nature de ce droit au dividende ? Une décision isolée[2] y voit un droit à terme auquel s'appliquerait l'article 1186 C.c. En réalité, il s'agit d'un droit éventuel dont la naissance dépend à la fois de l'existence de bénéfices et d'une décision à prendre par l'assemblée générale. « *Ce n'est pas davantage un droit conditionnel, puisque les deux aléas auxquels est subordonné le droit au dividende ne résultent pas de circonstances extérieures à ce droit, mais en sont au contraire un élément constitutif* »[3].

Si le résultat est positif, les associés peuvent donc décider soit de le distribuer en totalité ou en partie, soit de le mettre en réserve (totalement ou partiellement). Les seules limites à cette liberté (en l'absence de limitations statutaires telles que

1 – La seule décision à prendre est de nature comptable, et elle consiste à décider si la perte vient en déduction des postes de fonds propres.

2 – Trib. Anvers du 5 mai 1972.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 413.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dans les SICAV de capitalisation) sont les suivantes. En premier lieu, la disposition sur la **réserve légale** applicable dans les sociétés de capitaux (en application de l'article 461-1 de la L.S.C.) oblige les sociétés anonymes de doter au moins 5 % de leur bénéfice annuel net en une réserve légale et obligatoire jusqu'à ce que celle-ci atteigne le montant de 10 % au moins du capital social.

La question s'est posée de savoir si la réserve légale pourrait être alimentée par prélèvement sur la **prime d'émission**. En Belgique, la Commission bancaire a répondu négativement à cette question pour la raison que la réserve légale devrait être dotée par prélèvement sur les bénéfices nets sociaux, alors que la prime d'émission, pour sa part, est constituée par les apports des associés[1]. « *Il existait autrefois une conception large des réserves, qui justifiait que les primes d'émission fussent portées à un compte de réserves. […] Cette pratique n'est plus conforme aujourd'hui au droit comptable […]* »[2].

La deuxième limitation à la liberté de décision au sujet de l'affectation des résultats est celle des **réserves statutaires**. Il se peut en effet que les statuts stipulent obligatoirement qu'une partie des résultats annuels soit dotée en une réserve statutaire. La dotation est obligatoire tant que les statuts ne sont pas modifiés. Un tel changement est évidemment toujours possible, mais il est bien entendu subordonné aux conditions de majorité et de quorum requises dans le type de société visé.

Les dispositions statutaires peuvent aller jusqu'à interdire la moindre distribution de bénéfices. Le domaine des fonds d'investissement nous fournit la principale application pratique de cette possibilité. En effet, les **OPC de capitalisation** sont précisément fondés sur le principe qu'il ne peut y avoir de distribution courante de bénéfices aux associés. Cette solution est motivée par des raisons fiscales : les associés ne peuvent pas se plaindre de cette absence de distribution courante des résultats, car (en dehors du fait que la non-distribution entraîne que la valeur nette d'inventaire de ces entités augmente plus rapidement que tel ne serait le cas s'il y avait distribution courante de revenus) cette caractéristique de la non-distribution des bénéfices a été connue dès le départ. De surcroît, les investisseurs visés ont généralement la possibilité de **changer de compartiment** en échangeant leurs titres contre les titres de distribution, dont la caractéristique est que les bénéfices annuels leur sont obligatoirement distribués dans leur intégralité.

Dans la plupart des sociétés, la situation est entièrement différente dans le sens qu'aucune limitation ne s'applique. En pratique, les clauses statutaires imposant des limitations aux associés au sujet de la distribution des résultats sont relativement rares. Abstraction faite de la dotation éventuelle à la réserve légale, les associés sont entièrement libres de décider chaque année de l'affectation des résultats.

Dans un souci de protection des créanciers, les auteurs de la Quatrième directive ont introduit d'autres limitations légales qui ont les mêmes effets que la réserve légale ou encore que les réserves statutaires, à savoir qu'elles limitent la distribution des résultats annuels. Il s'agit de l'interdiction de toute distribution de bénéfices tant que les frais d'établissement ne sont pas entièrement amortis, à moins que le montant des réserves disponibles et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant

1 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 674.
2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence, (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 675.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

des frais non amortis[1]. La même solution prévaut à l'égard des **frais de recherche et de développement**[2].

En principe[3], l'assemblée des associés est appelée à décider sur l'affectation du bénéfice distribuable. On peut définir cette grandeur comme suit[4] :

Bénéfice distribuable = Bénéfice de l'exercice – montant mis en réserves obligatoires – reports déficitaires + reports bénéficiaires

Cette liberté de décision sur les résultats annuels peut conduire à des situations abusives du fait que les associés majoritaires peuvent profiter de la position de force qui est la leur dans l'assemblée générale de la société en refusant systématiquement toute répartition de résultats. Même si cette rétention de résultats empêche également les associés majoritaires de bénéficier d'un revenu courant, une telle approche peut surtout pénaliser les associés minoritaires qui, eux, contrairement à ceux qui sont majoritaires, n'ont pas le choix de changer d'avis en procédant à des distributions quand bon leur semble. En outre, les associés majoritaires assument souvent des fonctions de gestion dans la société, fonctions qui leur assurent alors une rémunération stable indépendamment de l'évolution des résultats de la société.

La répartition bénéficiaire est dans une très large mesure librement déterminée par les associés dans les statuts de la société. La seule limitation légalement prévue est celle de l'interdiction de la **société léonine** prévue par l'article 1855 C.c., alinéas 1 et 2 : « *La convention qui donnerait à un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il en est de même de la convention qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs associés* ».

Lorsque les statuts sont muets sur la répartition des résultats, la loi, relayée par la jurisprudence, prévoit la solution suivante : « *Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chacun des associés dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans les fonds de la société, conformément à l'article 1853 du Code civil* »[5].

À l'égard de celui qui n'a **apporté** que **son industrie**, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. À noter que le tribunal de commerce de Namur a écarté l'application de l'article 1855 C.c. à une société commerciale en « *se fondant sur les usages du droit commercial, qui "ont multiplié le recours à des conventions qui, distinctes du contrat initial, ont pour effet d'affranchir une partie de la communication des pertes" et qui ont été "rendus nécessaires par l'évolution propre aux sociétés de capitaux et par les exigences de leur restructuration ou de leur financement"* »[6].

---

1 – Art. 53 (1) b de la Loi de 2002.

2 – Art. 59 (3) de la Loi de 2002.

3 – Pour être tout à fait complet, il faudrait ajouter les limitations qui résultent de la Quatrième directive (2013/34/UE) et qui limitent les distributions de bénéfices en présence de frais d'établissement ou de frais de recherche et de développement.

4 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 156.

5 – TA Lux. du 6 décembre 1982, n° 26.868, ID 10483.

6 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 188.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette décision paraît critiquable dans la mesure où l'article 1873 C.c. ne rend applicable les dispositions du droit civil que pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux lois et usages de commerce, ce qui confirme la hiérarchie de l'article 100-1 (anc. art. 1er) L.S.C.

B – Droit au produit de liquidation

Parmi les droits financiers de l'associé, il y a encore celui de participer au produit de liquidation. En général, la liquidation est d'abord le moyen par lequel les associés obtiennent le remboursement des apports qu'ils ont faits dans la société par le passé. Il va sans dire que le montant de cette distribution est **sans lien obligatoire** avec le montant de l'apport fait initialement par l'associé. Il n'est en rien garanti que le montant payé en tant que produit de liquidation soit du tout supérieur à celui initialement versé en tant qu'apport à la société. Souvent d'ailleurs, le montant remboursé sera tout simplement nul en donnant ainsi lieu à une perte totale du montant investi : il en est en réalité quasiment toujours ainsi en cas de faillite de la société : les associés ne récupèrent rien dans le cadre de celle-ci.

SECTION III
NOTION D'ABUS DE MAJORITÉ OU DE MINORITÉ

Comme indiqué en un autre endroit, il se peut que certaines décisions des associés soient attaquées en justice pour être abusives. Une jurisprudence relativement abondante est consacrée à cette matière.

Il est à noter que des situations d'abus de majorité peuvent se présenter non seulement dans le cadre des assemblées générales des associés, mais encore dans le cadre des décisions prises dans le conseil d'administration (voire dans tout organe social[1]).

Les critères de l'abus sont les mêmes dans tous les cas.

■ § 1 – Les critères de l'abus de majorité

Pour être constitutive d'un abus de majorité, une décision doit satisfaire à deux conditions, à savoir :

– être prise contrairement à l'**intérêt général** de la société[2] ;
– être prise dans l'unique **dessein de favoriser** les membres de **la majorité** au détriment des membres de la minorité[3] ou encore avoir un effet spoliateur pour les minoritaires et avoir été prise dans l'intention de spolier les minoritaires[4].

Selon la jurisprudence luxembourgeoise : « *En effet, si la majorité dans une assemblée d'actionnaires peut imposer sa volonté à la minorité, c'est uniquement parce qu'elle est présumée agir dans l'intérêt social (V. CA Paris, 2 nov. 1954 : D. 1954, p. 758). Il convient*

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 378.

2 – « *[…] l'abus de majorité suppose que la décision soit prise non dans l'intérêt de la société, mais en considération d'un intérêt étranger à celle-ci* », Trib. com. Verviers du 28 avril 1986, *R.D.C.*, 1987, p. 540.

3 – V. Cass. com. du 18 avril 1961, *D.*, 1961, p. 661.

4 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 204.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

donc de reconnaître aux tribunaux le pouvoir de prononcer la nullité des décisions d'une assemblée lorsqu'elles ont été prises sans aucun égard pour l'intérêt de la société, mais uniquement en vue de favoriser l'intérêt d'un associé ou d'un groupe d'associés majoritaires, étant observé que l'intervention des tribunaux doit conserver un caractère exceptionnel afin d'éviter toute substitution du pouvoir judiciaire au pouvoir majoritaire.

La rupture de l'égalité entre les actionnaires qui conditionne l'abus de majorité doit favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. En outre, cette rupture d'égalité doit être intentionnelle, c'est-à-dire que les majoritaires doivent avoir la conscience de s'avantager personnellement, directement ou indirectement (M. Rives-Lange, L'abus de majorité : RJ com. 1991, n° spécial, p. 65. – D. Tricot, Abus de droit dans les sociétés, abus de majorité et abus de minorité : RTD com. 1994, p. 617. – Y. Reinhard, l'abus de droit dans le contrat de société : JCP E 1999, Cah. dr. entr. n° 6, p. 8. – A. Couret, L'abus et le droit des sociétés : Dr. et patrimoine, juin 2000, p. 66).

La jurisprudence exige donc la réunion de deux éléments pour que l'abus de majorité soit constitué : la décision adoptée en assemblée doit être contraire à l'intérêt social et doit aboutir intentionnellement à une rupture de l'égalité entre actionnaires au profit des majoritaires (Ph. Merle, op. cit., n° 580. – V. Cass. com., 18 juin 1997 : RJDA 1997, n° 1360. – Cass. com., 4 mai 1993 : RJDA 1993, n° 702) »[(1)].

Le cas où l'abus de majorité est le plus fréquemment avancé est celui de la mise en réserve systématique des bénéfices de la société, ce qui peut avoir pour effet de priver les associés minoritaires de tous les bénéfices courants qu'ils peuvent espérer retirer de leur investissement dans la société[(2)]. S'il est vrai que la mise en réserve des bénéfices sociaux touche au même titre les associés dominants, ceux qui ont le pouvoir de décision à l'assemblée des associés, il n'en reste pas moins que les majoritaires, de manière tout à fait automatique, se partagent la direction de l'entreprise (ils disposent par définition des majorités suffisantes pour se faire nommer dirigeants), en profitant donc de contrats de travail au profit de la société, de rémunérations pour prestations de services, etc. Il se peut donc fort bien que les majoritaires préfèrent se faire rémunérer au moyen de tels contrats plutôt que de compter sur des distributions de dividendes. En fin de compte, toute rétention systématique des bénéfices sera essentiellement préjudiciable aux associés minoritaires : ce point étant connu aux majoritaires, ceux-ci peuvent utiliser ce moyen afin de forcer à la sortie les associés minoritaires.

Les sanctions de l'abus de majorité peuvent être diverses. Elles peuvent consister d'abord dans l'annulation de la décision retenue comme abusive bien qu'aucun texte du droit des sociétés ne compte un tel abus parmi les cas d'ouverture des cas d'annulation des décisions. Le fondement de cette annulation est l'article 1382 C.c. La nullité est ici considérée comme une **réparation civile**. L'action peut être intentée par les associés victimes de l'abus et uniquement par ceux-là.

Il a ainsi été jugé que, si la dissolution d'une société se justifie par d'impérieuses raisons économiques et notamment par le mauvais état des affaires sociales (auquel cas elle est nécessaire à la sauvegarde des intérêts communs), elle est à considérer comme frauduleuse lorsqu'elle est imposée par une majorité d'actionnaires dans leur

1 – TA Lux. du 26 février 2015, n° 142277 du rôle, ID 24652.

2 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 143.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

intérêt en vue de leur permettre la constitution immédiate à leur profit exclusif d'une société[1]-[2].

■ § 2 – Les critères de l'abus de minorité

Il est vrai que la notion de minorité ne peut être définie de manière mathématique : dans les sociétés dont le capital est largement réparti dans le public, la minorité qui subit les décisions de la majorité peut représenter la majorité du capital de la société. « *La raison de ce paradoxe apparent se trouve évidemment dans l'absentéisme et le manque de cohésion de ces actionnaires minoritaires. S'ils s'organisaient, ils transformeraient leur majorité "numérique" en une majorité "politique", la seule qui compte, celle qui impose ses décisions à l'assemblée générale* »[3]. Mais, évidemment, ceci supposerait encore qu'ils trouvent un accord entre eux sur la position à prendre face aux actionnaires « majoritaires ».

Il n'y a **pas de symétrie** entre abus de majorité et abus de minorité. Cette dernière notion vise une situation où les minoritaires refusent de prendre des décisions qui sont pourtant dans l'intérêt de la société. De ce fait, la sanction de l'abus de majorité ne peut pas s'appliquer à cet endroit : en général, il n'existe en effet **pas de décision à annuler**. Il s'agit à leur égard de s'interroger sur la manière dont ils exercent leur droit de vote à l'assemblée et, en général, sur la manière dont ils font usage des prérogatives que la loi ou les statuts leur accordent[4].

« *[…] La lutte contre ce genre d'abus est faite pour passer outre au refus des minoritaires, inertes ou opposés à tout lorsque l'existence de la société est en péril et qu'ils poursuivent un intérêt égoïste* »[5]. Un des cas fréquents d'abus de minorité est celui du refus de voter une augmentation de capital. Il est vrai que, de façon générale, l'associé minoritaire peut avoir de bonnes raisons pour s'opposer à une telle augmentation à laquelle il n'est soit pas disposé, soit pas à même de participer. L'augmentation de capital conduirait à la dilution de sa propre participation, ce qui en principe est une justification largement suffisante pour son refus. Néanmoins, le refus peut être qualifiée d'abusif si l'augmentation de capital est nécessaire à la survie de la société[6].

Les décisions retenant ou rejetant l'abus de minorité le font sur la base des mêmes critères que ceux qui ont été retenus pour l'abus de majorité, à savoir la **mauvaise foi** ou encore l'absence d'exécution de bonne foi du pacte social, parfois par **l'intention de nuire** ou encore par l'absence d'une quelconque raison de nature à justifier l'acte critiqué[7].

Dans certains cas, les actionnaires minoritaires refusent leur concours indispensable à une mesure proposée par la majorité qui requiert une majorité qualifiée.

---

1 – Bruxelles du 28 février 1952, R.P.S. 1955, p. 316.

2 – M. Coipel, Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés, p. 205.

3 – L. Simont, « Réflexion sur l'abus de minorité », *Liber amicorum Jan Ronse*, p. 307.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 811.

5 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 146.

6 – Cass. com. du 18 juin 2002, *Bull. Joly*, 2002, p. 1197.

7 – L. Simont, « Réflexion sur l'abus de minorité », *Liber amicorum Jan Ronse,* p. 319.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les sanctions retenues par les juridictions sont de divers ordres : tantôt allocation de dommages-intérêts, tantôt réparation en nature (sous forme d'annulation de la décision critiquée obtenue par suite d'un vote surprise obtenu par la minorité). En revanche, la dissolution de la société pour mésintelligence grave entre les associés envisagée comme ultime remède ne semble pas encore avoir été prononcée tant en jurisprudence belge que française[1]. Une autre solution adoptée a consisté à nommer un administrateur provisoire qui, lui, est appelé à voter en lieu et place des associés minoritaires susceptibles d'avoir abusé de leur droit de vote en l'utilisant dans un sens contraire à l'intérêt de la société[2]. Dans cette affaire, les actionnaires minoritaires avaient systématiquement proposé des administrateurs qu'ils savaient inacceptables pour les actionnaires majoritaires.

L'utilisation d'une **minorité de blocage** par les actionnaires à l'effet d'empêcher l'adoption par l'assemblée d'une décision estimée contraire à leurs intérêts représente le cas le plus fréquent d'abus de minorité. Dans ce sens, on a un abus de minorité lorsque le vote est exercé sans considération pour l'intérêt social et pour le préjudice important qui est ainsi causé à la société, préjudice qui est hors de proportion avec l'avantage recherché par les minoritaires[3]. Plusieurs décisions, tout en rejetant l'abus dans le cas précis, se sont prononcées dans ce sens, notamment à l'occasion du refus de voter la prorogation de la durée de la société[4], d'une opération de recapitalisation comportant un « coup d'accordéon »[5], du refus des minoritaires de procéder à la vente d'un portefeuille de titres[6].

Un jugement du Tribunal de Bruxelles[7] retient à l'occasion d'une affaire portant sur une clause de représentation proportionnelle des actionnaires minoritaires au conseil d'administration, que l'exercice du droit de représentation de candidats administrateurs « *ne peut porter atteinte à l'intérêt social ni servir les intérêts exclusifs d'une catégorie d'actionnaires* ».

A – Fondement juridique de l'abus de minorité

Il est difficile de trouver le **fondement juridique** de l'abus de minorité : l'abus de minorité consiste à ce que des actionnaires minoritaires exercent leur droit de vote de façon « critiquable », de façon « abusive ». Cette qualification nécessite que soit déterminée la nature exacte du droit de vote des actionnaires : quel est donc exactement le droit dont ces actionnaires abusent ? Le droit de vote dont jouit tout actionnaire et, en particulier donc l'actionnaire minoritaire, constitue-t-il un droit subjectif égoïste (le cas échéant, un droit discrétionnaire) ou bien s'agit-il d'un droit-fonction ?

On convient généralement que le droit de vote de *l'administrateur* est effectivement un droit-fonction (qui n'existe donc qu'en vue de la gestion de la société, avec donc

1 – L. Simont, « Réflexion sur l'abus de minorité », *Liber amicorum Jan Ronse*, p. 320.

2 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 147.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 813.

4 – CA Liège du 9 novembre 1981, *R.P.S.*, 1982, p. 145.

5 – CA Mons du 23 mars 1989, *R.P.S.*, 1989, p. 196.

6 – CA Bruxelles du 20 mai 1981, *R.P.S.*, 1981, p. 133.

7 – Trib. com. Bruxelles du 13 décembre 1984, P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 813.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la conséquence que l'administrateur qui l'exerce doit avoir en vue uniquement l'intérêt de la société). En revanche, le droit de vote de l'actionnaire peut être considéré tant comme un droit égoïste que comme l'exercice d'une fonction, la gestion de la société.

Dans l'appréciation du caractère abusif ou non du comportement des actionnaires minoritaires, le juge fera état de la méthode dite de **l'appréciation marginale**. Il s'agit d'un contrôle assez sommaire et ne considérant comme abusif que le comportement qui n'aurait pas pu être raisonnablement adopté par un homme normalement prudent et diligent se trouvant dans la même situation[1].

Au terme de cette brève discussion assez théorique sur ce sujet relativement difficile, il nous reste à donner quelques exemples concrets à l'occasion desquels la question de l'usage abusif des droits de la minorité est susceptible de se poser.

B – Quelques applications jurisprudentielles

Le premier cas mentionné est celui de la **prorogation de la société**, prorogation refusée par les actionnaires minoritaires. En général, tout reproche d'abus de minorité est exclu pour la raison que les actionnaires minoritaires peuvent faire état d'un intérêt légitime les poussant à ne pas davantage subir les risques de l'activité sociale. « *Si cependant, les actionnaires majoritaires leur ont préalablement offert le rachat de leur part pour un prix égal ou supérieur au montant qu'ils peuvent espérer dans la meilleure hypothèse possible de liquidation, le refus des actionnaires de vendre leurs actions et leur vote négatif provoquant la dissolution pourront être constitutifs d'un abus. Sans doute le souci des actionnaires minoritaires de vendre leur participation au meilleur prix est-il en principe légitime, ainsi que le relève la Cour d'appel de Liège dans son arrêt du 9 novembre 1981, mais il reste à vérifier quel avantage la minorité retire de l'exercice de son droit et si cet avantage est ou non raisonnablement proportionné à la charge […] que la liquidation imposera à la société et, par voie de conséquence, aux actionnaires majoritaires* »[1].

Le deuxième cas de figure visé ici est celui de **l'augmentation de capital** refusée par les actionnaires minoritaires. « *Si une discussion est raisonnablement possible quant à l'opportunité de cette mesure, le vote négatif des actionnaires minoritaires ne pourra évidemment pas constituer un abus. Si l'augmentation s'impose de toute évidence dans l'intérêt de la société, le vote négatif des actionnaires pourra être difficile à justifier. Le vote de l'augmentation de capital n'oblige pas les actionnaires minoritaires à souscrire à cette augmentation et ils pourront négocier leur droit de souscription dans la mesure prévue par l'article 34*bis *des lois coordonnées.*

Dans certains cas, les minoritaires pourront justifier leur vote négatif par leur souci de ne pas perdre leur minorité de blocage en raison de la dilution de leur participation à la suite de la réalisation d'une augmentation de capital qu'ils n'auraient pas suivie »[1].

1 – D. VAN GERVEN, « Le Groupement européen d'intérêt économique – G.E.I.E. », *R.P.S.*, 1986, p. 326.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE V
LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

La constitution de la société a lieu soit par formation d'une société nouvelle, soit par transformation d'une société existante dans la forme visée (il est vrai que dans ce deuxième cas la personne morale préexiste à la transformation de la société). Par ailleurs, la constitution d'une société nouvelle peut encore avoir lieu par des opérations de restructuration telles que des fusions ou des scissions de sociétés. Dans le présent chapitre, nous ne nous occupons que de la constitution d'une société nouvelle.

SECTION I
CONDITIONS DE FORMATION DE LA SOCIÉTÉ

La constitution de la société exige la réalisation de conditions de fond et de conditions de forme. Aucune autorisation n'est en principe à obtenir pour pouvoir constituer une société. Cette liberté est le reflet du principe de « la liberté du commerce et de l'industrie », principe par ailleurs garanti par la Constitution luxembourgeoise dont l'article 11 (6) est libellé comme suit : « *La liberté du commerce et de l'industrie, l'exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi* » (voir p. 33).

Il s'agit donc d'une « matière réservée », ce qui signifie que seul le législateur, à l'exclusion du pouvoir réglementaire notamment, peut apporter des restrictions à cette liberté.

Cette liberté est aussi reconnue par le droit européen qui admet d'ailleurs expressément le droit des citoyens de choisir la législation nationale la moins contraignante afin d'y constituer une société et d'agir par le biais de succursales dans les autres États membres[1].

Il est vrai que, pour exercer certaines activités, une autorisation administrative (la plupart du temps, il s'agit d'une autorisation d'établissement au sens de la Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales[2]) est requise, mais cette question est en principe étrangère à la constitution de la société, personne morale distincte de ses associés. En effet, l'absence d'une telle autorisation n'empêche en rien la formation de la société, elle empêche uniquement qu'elle exerce (en tout cas légalement) l'activité qu'elle se propose de poursuivre.

■ § 1 – Les conditions de forme

La première question qui se pose dans ce contexte est de savoir si le contrat de société doit ou non être obligatoirement établi **par écrit**. L'article 4 L.S.C. dans la version résultant de la loi du 23 novembre 1972 (pris sur base de la Première directive CE) retient que les six sociétés commerciales et les sociétés civiles doivent « à peine de nullité » être constituées soit sous forme d'acte notarié spécial[3], soit sous

1 – CJCE, arrêt *Centros*, 9 mars 1999, C-212/97, ID 11674.

2 – ID 16333.

3 – Tel est obligatoirement le cas pour les sociétés de capitaux (les S.A., S.C.A. et S.à r.l.).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

forme d'acte sous seing privé[1]. Par acte spécial, on entend un acte « *ayant directement pour but de fonder une société et d'en régler les clauses, à l'exclusion par conséquent de tout acte qui, visant un autre objet, ne s'occuperait de la constitution d'une société qu'à titre secondaire et dans des énonciations accessoires* »[2].

Le contrat de société qui, en pratique, est appelé « *les statuts* » de la société, régit tout le fonctionnement interne de la société en dehors du fait qu'il relate les faits qui se sont produits au moment de la constitution de la personne morale. Dans les pays anglo-saxons, il existe une distinction entre « *le "*memorandum of association*", "*charter*" ou "*statute*" (droit anglais) ou "*articles of association*" (droit américain) qui comportent les mentions essentielles de la société, et les "*articles of association*" ou "*by-laws*" (droit américain), qui leur sont hiérarchiquement subordonnés et règlent le fonctionnement interne de la société (Gower, Principles of Modern Company Law, 5e ed. Sweet and Maxwell, 1992, p. 14)* »[3].

Dans les sociétés plus importantes, il existe souvent encore un « **règlement intérieur** » qui ne fait que réglementer le fonctionnement interne de la société. Ce règlement est non publié et n'a finalement que l'autorité des décisions de l'organe qui l'a émis[4]. Les lois luxembourgeoises et belges sur les sociétés n'envisagent pas l'existence d'un règlement intérieur : ceci n'empêche pas la doctrine d'en admettre la validité[3]. La loi du 25 août 2006 avait introduit dans la L.S.C. un nouvel article 64*bis* [art. 444-4 L.S.C.] qui, en faisant référence au règlement intérieur, en reconnaît donc ainsi la parfaite légalité.

La jurisprudence pour sa part retient que l'écrit (pour l'acte de société) n'est exigé qu'à titre de **preuve**[5].

Le résultat de cette situation est le suivant : en premier lieu, pour être valable en tant que contrat de société, la forme écrite est bel et bien requise (et ceci, aux termes de l'article 4 (nouv. art. 100-4) L.S.C., disposition qui est tout à fait claire et non ambiguë à cet égard, et qui ne peut donc pas être écartée par l'interprète). En revanche, une société créée sans écrit serait une « société créée de fait » (ou une société de fait, pour la terminologie, voir p. 119), non valable en tant que telle. Elle est donc traitée comme société de fait et, par conséquent, sera regardée comme société en nom collectif.

Aux termes de l'article 4 (nouv. art. 100-4) L.S.C., les sociétés par actions et les S.à r.l. sont constituées par acte notarié. Pour les sociétés civiles et les autres formes de sociétés commerciales, la constitution a lieu soit par acte sous seing privé, soit par acte notarié. La sanction du non-respect de ces conditions est la nullité (qui n'est toutefois pas une nullité absolue).

Afin de préparer l'acte de société, les renseignements suivants sont nécessaires :

- la langue dans laquelle les statuts doivent être rédigés. Il est permis d'utiliser l'anglais (avec une traduction en français ou en allemand), le français ou l'allemand ;
- l'objet de la société (société commerciale proprement dite, « Soparfi » ou tout autre objet) ;

1 – Les sociétés autres que les sociétés de capitaux peuvent être constituées par actes sous seing privé (en plus de la constitution par acte notarié).

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 10, ID 11308.

3 – V. Simonart, « La contractualisation des sociétés ou les aménagements contractuels des mécanismes sociétaires », *R.P.S.*, 1995, p. 90.

4 – A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 201.

5 – TA Lux. du 6 décembre 1982, n° 26.868, ID 10483.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

- le nom, les qualités et le domicile des personnes physiques ou morales constituant la société et leur représentant ;
- le nom de la société (il conviendra d'indiquer plusieurs noms, par ordre de préférence), afin de vérifier auprès du R.C.S. que le nom est disponible ;
- le capital souscrit de la société (le cas échéant, la proportion libérée) ;
- la devise du capital social ;
- le nombre de parts émises et leur valeur nominale (depuis 2007, il n'existe plus de minimum légal) ;
- l'année sociale (couramment, mais non obligatoirement, l'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre) ;
- le nombre de parts souscrites par chaque associé ;
- le nom, les qualités, le domicile et la durée du mandat du ou des gérants, qui peuvent être des personnes physiques ou morales ;
- l'adresse du siège social de la société.

A – La langue de l'acte constitutif

De façon générale, l'application des langues est au Luxembourg précisée par la loi du 24 février 1984[1] sur le **régime des langues**. Au vœu de cette loi, le principe est qu'il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise en matière contentieuse ou non contentieuse et en matière judiciaire, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières.

L'acte constitutif de la société est en principe rédigé en français ou en allemand au choix des parties (donc des associés). Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 1991[2], il est permis d'utiliser **l'anglais** (avec obligatoirement une traduction en français ou en allemand), et ceci, sous la condition que les comparants le demandent et qu'ils comprennent et parlent cette langue, ajoutée à la condition supplémentaire que le notaire instrumentant comprend l'anglais (dont mentions expresses doivent être faites dans l'acte constitutif). Ces précisions ne résultent pas de la L.S.C., mais de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat[3]. En cas de divergence entre les versions française ou allemande, d'une part, et la version anglaise, d'autre part, la version française ou allemande fera seule foi, à moins que les parties ne stipulent que la version anglaise fait seule foi entre parties. De façon générale, il est fait fruit de cette possibilité, et donc les statuts comprennent la précision que la version anglaise fait seule foi. Il est bien entendu que cette primauté reconnue vaut entre parties, et pas nécessairement envers des tiers.

B – La devise du capital social

Les sociétés de capitaux ont un capital social minimum qui est donc exprimé en la monnaie officielle du Luxembourg, soit donc, depuis 2002, l'euro. La devise dans laquelle le capital est exprimé définit également la devise des états financiers annuels.

---

1 – *Mém.* A 16 du 27 février 1984, *P.*, 196, *Doc. parl.*, n° 2535.

2 – Loi du 25 mars 1991, ID 9566, *Doc. parl.*, n° 3434, ID 9834.

3 – ID 14911.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le choix de la devise du bilan commercial d'une société de capitaux est au Luxembourg caractérisé par une grande flexibilité et se fait en fonction des considérations suivantes : une des données que les statuts de la société doivent obligatoirement contenir est le montant du capital social (article 420-15, anc. article 27 L.S.C.). Cette exigence se justifie pleinement à l'égard des sociétés de capitaux, étant donné que le patrimoine social est l'unique gage des créanciers à l'égard de ce type de sociétés. Il est évident que cette exigence comporte en même temps l'indication de la devise du capital : faute de l'indication de la devise, l'indication du montant du capital social serait sans objet.

Cette indication dans les statuts du capital et de la devise du capital détermine la **devise des comptes annuels**. Le montant de ce capital social reste en principe inchangé (sauf modification des statuts) : la raison en est le principe de la **fixité du capital social**. Ce principe est général si l'on fait abstraction des SICAV, des SEPCAV et, le cas échéant, des sociétés coopératives.

Or, une divergence entre la devise du bilan et celle du capital social des statuts rencontrerait certains problèmes.

Exemple

Supposons que le capital social fixé par les statuts soit de 100 000 euros et que les comptes sociaux soient établis en US $, alors, en cas de variation des cours de change (variations qui sont inévitables), le montant du capital social de cette société variera fatalement d'une année sur l'autre. Il ne sera pas possible de maintenir au bilan le montant du capital social à un certain niveau.

Supposons encore que la somme de 100 000 euros soit déposée dans un coffre-fort et ne génère donc pas de revenus. La société n'a ni des dettes ni d'autres actifs. La société comptabilise en US $. Si, au jour de la constitution, le cours EUR-US $ était de 1 contre 1, il est supposé qu'à la prochaine clôture, il passe à 1 US $ contre 1,05 euro. Le capital social passe donc à 95.238 US $ pour varier continuellement par la suite. Par conséquent, le capital social exprimé au bilan devrait être ajusté tout le temps pour correspondre (en valeur) au montant retenu par les statuts. Le problème est que l'on ne sait pas comment comptabiliser cette différence (la différence existant entre 100 000 US $ et 95 238 US $ pour la première année, p. ex.).

■ § 2 – Les conditions de fond

A – Conditions générales de validité des contrats

Aux termes de l'article 1108 C.c. relatif aux conditions essentielles des contrats en général, tout contrat doit avoir un « objet certain » et une « cause licite ». Dans le domaine des sociétés, il faut encore se référer à l'article 1833 C.c. qui fait état de l'objet (au lieu de la cause de l'article 1108 C.c.).

Dans les contrats synallagmatiques, il y a **confusion de la cause et de l'objet** dans le sens que la cause de l'obligation contractée par l'une des parties est l'objet de l'engagement de l'autre[1]. Ceci explique que l'article 1833 C.c. ne mentionne pas une cause licite, mais uniquement un objet licite (l'objet et la cause se confondant donc l'un avec l'autre).

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 156.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il convient donc d'appliquer à l'objet ce que l'article 1133 C.c. dispose à l'égard de la cause. L'objet est donc illicite quand il est prohibé par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public[1].

Un contrat suppose un consentement non vicié, donc non affecté des caractères suivants.

1) L'absence de volonté

Il y a absence de volonté en cas d'aliénation mentale ou d'ébriété. Il y a absence partielle de volonté si les parties ne se sont pas mises d'accord sur un élément essentiel de la société[2].

2) L'erreur

L'erreur doit être commune et excusable.

Aux termes de l'article 1110 C.c., l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet[3]. « *L'erreur sur les qualités substantielles est traditionnellement définie comme la croyance erronée en une qualité de l'objet du contrat, qualité en fait inexistante et la jurisprudence comme la doctrine ont fini par admettre que l'erreur sur les qualités substantielles résidait dans l'absence d'une qualité attendue ou promise* »[4].

Pour mettre en péril la validité du consentement, il faut qu'elle porte sur la nature ou l'objet du contrat. « *Lorsque l'erreur ne porte ni sur la nature de la convention, ni sur l'objet même de celle-ci, ni enfin sur la substance de l'objet, il ne saurait y avoir ni contrat nul, ni contrat annulable* »[5]. Si l'appelant s'est trompé dans ses calculs notamment sur les prix de revient escomptés, ce fait ne peut avoir pour conséquence de vicier son consentement.

« *L'erreur sur une qualité substantielle de la chose dans laquelle a versé un contractant, soit spontanément, soit même à la suite de manœuvres dolosives du cocontractant, n'est une cause de nullité du contrat que si cette erreur n'était pas facilement décelable. Si le contractant a, au contraire, disposé des moyens et du temps nécessaire pour déceler l'erreur, mais que par légèreté ou négligence il n'a pas procédé à certaines vérifications élémentaires, l'erreur dans laquelle il a versé est inexcusable, alors qu'un homme normalement raisonnable et avisé ne se serait pas exposé à la commettre* »[6]. Erreur sur la substance à l'occasion d'une cession d'actions (non)[7].

---

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 157.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 338.

3 – CA (civ.) du 30 juin 1993, *P.*, n° 29, p. 253, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA (civ.) du 30 juin 1993, *P.*, n° 29, p. 256, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – CA du 17 juin 1904, *P.* , n° 6, p. 469, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – CA com. du 16 juin 1970, *P.* , n° 21, p. 362, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

7 – Cass. b. 5 juillet 1887, *Pas.*, II, p. 625, Cass. b., 11 juillet 1890, *Pas.*, II, p. 632, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

3) Le dol

Il y a dol en cas de manœuvres frauduleuses commises à l'occasion de la conclusion d'une convention[1]. Le dol n'est une cause de nullité du contrat que si les mensonges employés par un contractant étaient tels que son cocontractant **ne pouvait pas vérifier facilement** les allégations mensongères, lesquelles ont ainsi provoqué chez lui une erreur invincible et partant excusable[2].

4) La violence

Il s'agit d'un fait de nature à inspirer une crainte telle que la victime donne son consentement à un acte que, sans cela, elle n'aurait pas accepté[3]. Aux termes de l'article 1112 C.c., il n'y a violence que lorsque celle-ci atteint un **degré de gravité suffisant** et qu'il existe un danger raisonnable pour la personne ou les biens du contractant[4].

B – Capacité de contracter

Comme pour tout contrat, la capacité de contracter est requise. Cette capacité n'est pas donnée dans le chef des mineurs ou encore des majeurs placés sous tutelle.

Les mineurs ne peuvent être associés dans les sociétés dans lesquelles la qualité d'associé confère la qualité de commerçant, un mineur ne pouvant être commerçant.

C – *Affectio societatis*

Par cette notion on entend l'élément intentionnel du contrat de société[5].

1) Notion d'*affectio societatis*

L'*affectio societatis* peut être définie comme « *la volonté qu'ont les cocontractants de coopérer sur un pied d'égalité, par leur collaboration, à la réalisation du but commun, en acceptant le partage qu'elle comporte* »[6].

Certains indices conduiront le juge à conclure à l'absence d'*affectio societatis*. Il en est ainsi notamment en cas de disproportion des apports[7], de lien de parenté de l'associé dominant avec les associés fortement minoritaires[1], de défaut d'activité de la société[8].

---

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 341.

2 – CA com. du 16 juin 1970, *P.* , n° 21, p. 362, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Th. Debard et S. Guinchard, *Lexique des termes juridiques*, V° Violence, Dalloz.

4 – TA Lux. du 7 avril 1948, *P.* , n° 14, p. 399, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – P. Soumrami, *Le portage d'actions*, p. 407. Cet auteur souligne le caractère hétéroclite et le déclin de cette notion du fait de la pratique des affaires (notamment pour les sociétés cotées où les actionnaires sont des bailleurs de fonds) et des modifications législatives (en particulier, les actions sans droit de vote). Conformément aux thèses développées par M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 71, la notion d'*affectio societatis* se réduirait à un apport ainsi qu'au droit d'intervenir dans les affaires sociales, pour conclure que le porteur des actions serait doté de tous les attributs de l'associé.

6 – J.P. Bours et P. Hermant, « Les principes généraux du droit des sociétés », *Traité pratique de droit commercial*, T. IV, *Les sociétés*, p. 30.

7 – M. Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 68 ; C. Cutajar-Rivière, *La société écran*, p. 310.

8 – C. Cutajar-Rivière, *La société écran*, p. 311.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En droit positif, on peut rattacher cette exigence à l'article 1833 C.c. selon lequel toute société « *doit être contractée pour l'intérêt commun des parties* ».

Pour une partie importante de la doctrine, la question de l'*affectio societatis* ne constitue pas un élément particulier et nouveau du contrat de société. Cet élément serait inclus dans le consentement donné par les parties[1]. La volonté des parties n'aurait pas le pouvoir de former une convention autre qu'un contrat de société dès lors que se trouvent remplies les conditions de l'article 1832 C.c.

« *En réalité, si l'on range traditionnellement la nécessité de l'*affectio societatis *au nombre des conditions essentielles à l'existence de la société, c'est parce que l'article 1832 du Code civil n'épuise pas complètement le contenu de société.*

Pour que celle-ci existe, il faut encore que les contractants aient eu l'intention de collaborer pour faire produire à leurs apports des bénéfices, tout en acceptant le partage des risques »[3]. Cette approche a le mérite de souligner le point que la définition retenue par l'article 1832 C.c. envisage la société au moment de sa formation en spécifiant les conditions requises pour la validité de sa formation. Mais le contrat de société est un contrat qui s'inscrit dans la durée, et la société ne peut fonctionner sans un minimum d'esprit de collaboration.

Ce dernier critère est à prendre avec beaucoup de précaution pour la raison que les sociétés de **gestion de patrimoine** (dont l'objet est, par exemple, la détention d'un portefeuille titres, d'un immeuble locatif) qui se sont fortement développées au cours des dernières années[2], tout en n'étant pas sans activité, n'ont qu'une activité très réduite. Dans de tels cas, force est de constater que l'on est assez loin des hypothèses qu'avaient en vue les rédacteurs du Code civil. Il a été souligné, à juste titre, que dans l'appréciation du caractère fictif général[3] : « *La perception de la fictivité est largement contingente : elle est dépendante d'un contexte, d'une époque et d'un état d'esprit : ce qui aurait été jugé fictif hier ne l'est plus forcément aujourd'hui* »[4]. Même si l'activité d'une société est donc des plus limitées, ceci ne suffit pas pour la déclarer fictive. Toutefois, l'absence d'activité sera certainement considérée comme indice de fictivité.

La notion même d'*affectio societatis* est non seulement vague, mais encore, de manière évidente, inadéquate pour caractériser la société unipersonnelle. Dans les catégories traditionnelles de sociétés (pluripersonnelles), l'*affectio societatis* signifie la vocation de chaque associé à participer au fonctionnement de la société dans le cadre des modalités prévues par la loi et les statuts sociaux. L'utilité de la notion réside dans le fait qu'elle permet de distinguer la société d'autres contrats qui n'impliquent pas une telle vocation tout en comportant une

1 – *R.P.D.B.*, T. 12, V° Sociétés, p. 151.

2 – Le critère de l'activité est important dans le sens que la poursuite d'une activité régulière et effective est de nature à protéger la société contre les reproches de fictivité ; CA Bordeaux du 20 novembre 1978, *J.C.P.,* 1980, II, 19.381, observ. Prévault.

3 – Cette nécessité de l'évolution du droit est, nous semble-t-il, insuffisamment reconnue par un auteur français : « *Présenter l'EURL comme moyen de diminuer le nombre des sociétés fictives relève d'une dialectique alarmante. Accorder le droit au fait, telle est la nouvelle philosophie législative. Rien de plus simple, pour supprimer la déviance au regard d'une norme en vigueur, il suffit d'ériger la déviance en nouvelle règle de droit. L'EURL ne supprime pas les sociétés fictives, elle les consacre* », P. Diener, « Les sociétés en nom collectif dont tous les associés sont des EURL », *J.C.P.* E, 1992, I, p. 153.

4 – F. Deboissy, *La simulation en droit fiscal*, p. 88.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

participation aux bénéfices[1]. Dans cet ordre d'idées, la jurisprudence[2] a refusé le caractère de société (en participation) à un contrat existant entre une société anonyme acquéreuse de terrains à lotir et le vendeur de ces terrains, en retenant que le prix du terrain était fixé en deux fois : une première partie exigible de suite était calculée en fonction du prix par m^2, tandis que le solde devait être ultérieurement payé en fonction du prix de revente des terrains. L'existence de société était exclue entre autres pour la raison que, dans les circonstances en cause, les parties n'étaient animées en rien par une *affectio societatis* du fait que le vendeur du terrain n'intervenait aucunement dans la gestion ou dans le contrôle de l'activité de la société[3].

Dans une affaire soumise à la Cour d'appel de Bruxelles, la cour[4], contrairement aux premiers juges, a considéré qu'en l'espèce l'*affectio societatis* serait « *la volonté de s'unir en se reconnaissant réciproquement le droit de contrôler et de critiquer, d'égal à égal, la gestion d'une chose* »[5].

La notion même d'*affectio societatis* est fortement **critiquée en droit belge** pour être tout simplement inutile[6]. En effet, la formation de la société requérant le consentement, l'intention de constituer une société serait comprise dans cette notion de consentement qui doit être non vicié pour avoir été valablement donné.

L'absence d'*affectio societatis* ne constitue plus une cause de nullité pour les sociétés par actions et les S.à r.l. À leur égard, la loi énumère de façon limitative les causes de nullité de la société. De même, elle ne fait pas partie des notions requises par le Code civil pour donner lieu à un contrat de société valable.

Néanmoins, selon la jurisprudence, l'absence de ce caractère d'*affectio societatis* peut conduire à la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs[7].

La notion d'*affectio societatis* n'est pas directement prévue dans les textes (ni en France, ni en Belgique, ni au Luxembourg). Il s'agit d'une notion propre au contrat de société : d'autres formes d'association comportent néanmoins des notions similaires. Ainsi, les G.I.E. connaissent l'intention de se grouper et de se comporter comme des membres du groupement, et encore les associations qui font référence à l'intention de collaborer à égalité sans partager les bénéfices[8].

Cette notion remplit une double fonction dans le sens qu'elle est :

a) une condition de **validité** du contrat de société ;

b) un **élément distinctif** du contrat de société[9].

Ad a : L'absence de cet élément peut conduire le juge à conclure à l'existence d'une société fictive et donc à la nullité de la société. Sur la base de la jurisprudence

1 – En ce sens, *R.P.D.B.*, T. 12, V° Sociétés, p. 153.

2 – CA Anvers du 12 avril 1984, *R.P.S.*, 1985, p. 41.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 599.

4 – CA Bruxelles du 17 septembre 1975, *R.P.S.*, 1977, p. 125.

5 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 231.

6 – J. Malherbe, P.h. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 232.

7 – J. Malherbe, P.h. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 233.

8 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 88.

9 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 86.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

en question, on peut conclure de l'absence de cet élément intentionnel qu'il y a en fait une société unipersonnelle prohibée. Un défaut d'*affectio societatis* peut conduire à l'inexistence de la société[1].

Ad b : L'absence de la volonté d'intervenir dans les affaires sociales peut permettre de distinguer certains contrats qui comportent une participation au bénéfice du contrat de société. En effet, prenons les contrats de vente, de location, de prêt assortis d'une participation aux bénéfices et la situation des parties qui se rapprochent de celle des associés. Étant donné que le vendeur, le prêteur, etc. n'ont pas la volonté d'intervenir dans la gestion des fonds concernés, l'absence d'*affectio societatis* permet donc de distinguer ces contrats du contrat de société. La même différence est donnée dans le cas où des salariés bénéficient d'une participation aux résultats de l'entreprise[2].

Pour certains auteurs, l'intérêt de la notion serait encore de permettre la compréhension de certaines règles de fonctionnement de la société[3].

2) Sanction du défaut d'*affectio societatis*

Conformément aux principes traditionnels applicables en la matière, les juges du fond, dès qu'ils constatent souverainement l'absence d'*affectio societatis,* devraient conclure à la nullité de la société entre parties. La situation est toutefois différente à l'égard des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés à responsabilité limitée : l'article 100-18 [anc. art. 12*ter*] L.S.C. sur la base des dispositions de la Première directive CEE énumère limitativement les causes de nullité de ces trois types de sociétés.

D – But lucratif

Par rapport aux autres formes d'association, la société commerciale se distingue essentiellement par le but lucratif, qui exclut donc en principe toute activité désintéressée.

Il est fort important d'insister sur le fait que, depuis une dizaine d'années, notre droit des sociétés s'éloigne très fortement de celui de notre voisin belge dans le sens que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 qui a modifié l'article 1832 du Code civil belge en définissant dorénavant le but de la société comme suit : « *de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect, à moins que, dans les cas prévus par la loi, l'acte de société n'en dispose autrement* », il en a résulté une triple modification du but de la société :

– en premier lieu, le bénéfice peut consister en un bénéfice patrimonial direct ou indirect (incluant ainsi les économies) ;
– en deuxième lieu, au lieu de partager les bénéfices, il s'agit de procurer un bénéfice aux associés ;
– en troisième lieu, le but lucratif n'est plus l'apanage obligatoire de la société : dans la mesure où la loi le permet, la société peut avoir un but

1 – Cass. com. du 22 juin 1976, *D.*, 1977, p. 619, note P. Diener.

2 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 89.

3 – En ce sens, A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 71.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

non lucratif. Tel est le cas de la société à finalité sociale (prévu par l'article 164*bis* L.C.S.C.).

En droit français, l'évolution est également allée dans le sens de l'élargissement de la définition du but de la société, dans le sens que, depuis la réforme du 4 janvier 1978, l'article 1832 C.c. dispose que la société est « *instituée en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter* ». Cette définition conduit donc à mettre sur un même pied les bénéfices et les économies et à admettre les simples avantages patrimoniaux[1].

La notion du but de lucre comme critère distinctif de l'activité commerciale par rapport aux activités non commerciales est de plus en plus contestée et, pour l'essentiel, cette critique est justifiée. En effet, toutes les activités économiques répondent à ce critère. « *Si l'on avance que le commerce comporte un esprit de risque qui répugnerait aux autres professions, cela n'est guère confirmé par l'expérience : ne voit-on pas bien des commerçants aspirer à un monopole assorti de marges bénéficiaires garanties ? Et les agriculteurs qui sèment sans savoir ce qu'ils récolteront ni s'ils pourront vendre ne courent-ils pas plus de risques que bien des commerçants ? En caractérisant le commerce par la spéculation, on suggère que le gain du commerçant résulte moins de son travail que d'un pari sur les différences de cours. En réalité, le commerçant ne vit pas de la spéculation, mais de son travail. Sa rémunération se justifie par les services qu'il rend au public* »[2].

La jurisprudence belge va dans le même sens : « *Inutile et inconsistante, la notion d' "esprit de lucre" risque d'obscurcir la distinction nécessaire entre l'entreprise économique et son propriétaire. Elle présente aussi l'inconvénient d'exclure du droit commercial les entreprises exploitées par une personne morale de droit public* »[3].

■ § 3 – La constitution d'une société sous condition suspensive

Il n'est pas vraiment contesté que les parties puissent prévoir dans l'acte constitutif de la société que la société commence non au moment de la constitution, mais à une date ultérieure, par exemple à une date déterminée postérieure à la date de l'acte constitutif. Il y a en l'occurrence « terme suspensif ». En attendant l'arrivée de ce terme, la société n'est pas effectivement constituée : elle est une société en formation et l'article 100-17 (anc. article 12*bis*) L.S.C. est applicable[4].

Il est encore possible d'affecter la constitution de la société d'une condition suspensive, avec donc la conséquence que la constitution de la société ne sortira ses effets que si un événement futur se réalise : la naissance de la société est suspendue jusqu'au moment de la réalisation de cette condition.

La question qui se pose à cet égard est celle de l'effet de la réalisation de la condition : fait-elle remonter la naissance de l'être moral à la date de l'acte constitutif selon le principe de l'article 1179 C.c. ? Il est vrai que le principe posé par cet article n'a rien d'absolu dans la mesure où il connaît de nombreuses

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 405 ; V. encore M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 12.

2 – J. Savatier, « Contribution à une étude juridique de la profession », *Dix ans de conférences d'agrégation. Études de droit commercial offertes à Joseph Hamel*, p. 8.

3 – Cass. b. du 19 janvier 1973, note J. van Ryn et J. Heenen, *R.C.J.B.*, 1974, p. 333.

4 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 154.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

exceptions. « *Invoquant la sécurité des tiers et le bon sens, la majorité de la doctrine se prononce pour la naissance de la personnalité morale au jour de l'accomplissement de la condition, donc sans rétroactivité […] Cette position doit, à notre avis, être nuancée de la manière suivante.* Pendente conditione*, la société constituée sous condition suspensive est une société en formation […] La rétroactivité selon le Code civil doit dès lors être écartée, car elle aurait pour conséquence de valider automatiquement les opérations accomplies,* pendente conditione*, au nom de la société, à ce moment en formation : or ce caractère automatique est contraire au régime prévu par l'article 13*bis *des lois coordonnées sur les sociétés commerciales qui laisse la société libre de reprendre à son compte les opérations conclues en son nom avant sa formation effective. […] L'application de l'article 1179 du Code civil doit donc être écartée : l'être moral naît en principe à l'arrivée de la condition ; toutefois une rétroactivité limitée peut résulter de la mise en œuvre du régime de l'article 13*bis *des lois coordonnées sur les sociétés commerciales […]* »[1].

La question de la validité d'un tel mode de constitution a été soumise à l'appréciation des juridictions dans une affaire où un groupe d'hommes d'affaires se proposait de soumissionner à la mise en adjudication de la concession relative à l'exploitation de taxis sur le territoire de la ville de Bruxelles. Afin d'économiser les frais de la constitution et de la liquidation d'une société pour le cas où la concession ne serait pas obtenue, la société fut constituée sous la condition suspensive de l'obtention de la concession. « *Rien n'empêche que les parties subordonnent à un événement futur – certain ou incertain – la naissance même de la société. Avant cet événement, la société n'aura pas de personnalité morale, ni de patrimoine, et elle ne pourra contracter envers les tiers […] Tous les effets de l'acte sont alors suspendus […]* »[2].

En même temps, la doctrine refuse de reconnaître l'effet rétroactif de la condition suspensive : l'article 1179 C.c. ne peut être appliqué chaque fois qu'il est de nature à heurter la sécurité des relations juridiques[3].

Il est en revanche indiscutable que la **naissance de la personnalité morale ne peut rétroagir**. « *[…] il est par contre impossible de décider que la constitution a eu des effets avant d'avoir été réalisée. On ne peut permettre aux associés d'imposer aux tiers les conséquences d'une personnalité morale à laquelle ils n'ont pu s'attendre* »[4]. À cette interdiction de la rétroactivité, il existe cependant une exception, à savoir le régime de la « société en formation ». Si les engagements sont repris par la société, ceux-ci sont réputés avoir été les siens dès l'origine. Ceci a pu être le cas uniquement si elle était une entité juridique autonome. Il y a donc attribution rétroactive de la personnalité morale[5].

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 155.

2 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 298.

3 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 299.

4 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 155.

5 – L. Simont, « La loi du 6 mars 1973 », R.P.S., 1974, p. 72.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION II
LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

Il est souvent économiquement indispensable, pour la société en formation, de réaliser certains actes juridiques pour le compte de la future société : conclusion d'un bail, engagements de personnel, acquisition d'une participation, d'un brevet, etc.

Avant l'entrée en vigueur des dispositions afférentes des directives européennes, les personnes qui prenaient des engagements pour le compte de sociétés en formation étaient considérées comme **gérants d'affaires,** avec la conséquence que les tiers ne pouvaient agir contre eux après la constitution de la société[1].

■ § 1 – Notion de la société en formation

Par le terme de « société en formation », on entend une société qui est en train de se mettre en place et qui n'a pas encore acquis la personnalité morale[2]. Le fait que, dans nos pays voisins, cette attribution de la personnalité morale est retardée (jusqu'au moment de l'accomplissement des mesures de publicité requises par les directives européennes) explique que les dispositions légales spécifiques aux sociétés en formation ont dans ces pays une importance qu'elles ne connaissent pas au Luxembourg.

En effet, contrairement à ce qui se passe au Luxembourg, ces dispositions relatives à la société en formation couvrent également cette période qui s'écoule entre la constitution de la société et son immatriculation au R.C.S. Ainsi, l'article 1842, alinéa 2 C.c. français : « *Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations* »[3].

Cette définition diverge par rapport à celle qui a été donnée par un jugement luxembourgeois : « *La société en formation se définit par deux éléments complémentaires, à savoir qu'il doit s'agir d'une société valablement constituée mais non encore immatriculée, le début de la période de formation étant cependant antérieur à la constitution* »[4]. Cette définition est manifestement erronée dans le sens qu'au Luxembourg la personnalité morale s'acquiert au moment de la signature de l'acte de société, et non au moment de l'immatriculation au R.C.S.

On peut retenir que la notion de société en formation correspond à **trois hypothèses** différentes : ou bien l'acte constitutif n'a pas encore été conclu ; ou bien la naissance de la personnalité morale a été retardée (terme ou condition suspensifs) ; ou bien il y constitution par souscription publique avec la conséquence que, tant que l'assemblée générale n'a pas eu lieu, la société n'est pas encore définitivement constituée[5].

---

1 – J. VAN RYN et P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 296.

2 – « *Une société en formation est dépourvue de personnalité morale* », P. LE CANNU, *Droit des sociétés*, p. 197.

3 – P. LE CANNU, *Droit des sociétés*, p. 207.

4 – TA du 15 juillet 1988, n° 34097, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – M. COIPEL, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 156.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La question se pose donc de savoir quelle est la valeur des engagements pris avant la formation de la société.

§ 2 – La situation avant et après la Première directive

Avant l'entrée en vigueur de la Première directive, la société était engagée par les actes accomplis avant sa formation, conformément aux règles de la gestion d'affaires ou du porte-fort[1]. Ce système avait de graves inconvénients pour la personne qui prenait de tels engagements au profit de la société. Si son intervention était utile, la société était engagée, même en l'absence de ratification de sa part. Si son intervention était injustifiée, la société n'était engagée que par sa **ratification**. Le tiers n'avait jamais d'action contre le promoteur et était donc dépourvu de tout recours lorsque la société ne se constituait pas.

Le délai dans lequel la ratification de cet engagement doit intervenir a fait l'objet de longues discussions lors de l'élaboration de la loi belge de 1913. Les risques inhérents à cette disposition tiennent au fait que l'on peut se porter fort pour des personnes non désignées. Un arrêt de la Cour de cassation belge du 25 mars 1909 a en effet reconnu la légalité de la clause du **porte-fort** pour des tiers non désignés. Cette possibilité permettait donc aux fondateurs en fonction de la marche de l'opération, selon qu'elle réussit ou non, soit de désigner un insolvable, soit quelqu'un qui puisse valablement souscrire[2].

La période de formation doit être déterminée en fonction de circonstances propres à chaque espèce. « *La société est en formation dès que les fondateurs ont manifesté leur volonté concrète de constituer une société et qu'ils ont commencé une exploitation anticipée* »[3]. Dans le cas d'espèce soumis à la cour, les appelants avaient fait valoir que la société ne serait pas en formation du fait du délai (jugé excessif) de un an et demi entre la signature du compromis d'achat immobilier et la constitution de la société. La cour a retenu que ce délai ne serait pas excessif pour la raison que la loi elle-même envisageait un délai pouvant atteindre deux ans entre la naissance de l'engagement et la constitution de la société[3].

Les conséquences d'une ratification tardive peuvent être assez dommageables, comme le montre un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 18 avril 2006. Dans le cas d'espèce, un immeuble avait été acquis au nom de la société en formation, et cette société a été formée dans les deux ans de l'acquisition. Seulement, la reprise de l'engagement n'est intervenue que quatorze mois après la constitution.

Cette situation a changé au moment de l'entrée en vigueur de la **directive** visée. En cas de ratification de ces engagements, ils sont censés avoir été pris au nom de la société dès le départ. Cette possibilité est toutefois encadrée dans des **limites de temps** relativement strictes : la ratification doit intervenir dans les deux mois de la constitution de la société. Si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement, les souscripteurs en sont personnellement responsables.

Toute ratification intervenant plus tard ne libérerait pas les personnes qui auraient pris ces engagements[1].

---

1 – M. VAN DER HAEGEN et C. VERBRAEKEN, « L'adaptation de la législation belge à la Première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.*, 1974, p. 129.

2 – C. RESTEAU, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 243.

3 – CA du 29 janvier 2003, ID 26150.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La loi luxembourgeoise (art. 100-17, anc. art. 12*bis* L.S.C.), contrairement à la disposition correspondante du droit belge, fait référence à la gestion d'affaires et au porte-fort. Selon le nouveau système, la société ne sera engagée par les actes ainsi posés que dans les cas où elle ratifie ceux-ci. Ce système a pour résultat de bien protéger les tiers qui traitent avec des promoteurs en évitant ainsi le vide juridique qui peut se produire si la société ne se constitue pas ou ne reprend pas les engagements pris à son compte[1].

La disposition selon laquelle, en cas de ratification, les engagements sont réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ne figure pas dans la directive, mais tient son origine dans l'article 5 de la loi française du 24 juillet 1966. Sur ce point, le législateur luxembourgeois a suivi son homologue belge qui, lui aussi, a introduit cette précision dans la loi du 6 mars 1973. L'utilité de cet ajout (qui en France semblait justifié par des raisons fiscales[1]) a été contestée. En effet, certains auteurs ont fait valoir qu'en cas de gestion d'affaires et d'engagement de porte-fort, la ratification de ces actes par la société emporte en tout état de cause que la société est seule engagée à l'égard des tiers, la ratification ne comportant pas de double taxation[2].

En droit commun, une personne qui prend un engagement au nom d'une tierce personne sans qu'il y ait représentation de cette dernière ne peut jamais être personnellement tenue de l'engagement assumé, mais seulement de réparer le dommage qui, le cas échéant, peut résulter de l'absence de ratification. Cette solution résulte de l'article 1120 C.c. : « *Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement* ». L'article 100-17 (anc. art. 12*bis*) L.S.C. déroge à cette solution en prévoyant une **responsabilité personnelle et solidaire** des signataires de ces engagements, ce qui ne vise pas une responsabilité limitée aux dommages et intérêts en cas de non-ratification[2].

La disposition de l'article 13*bis* L.C.S.C. (qui correspond à l'article 100-17, anc. art. 12*bis* L.S.C.) provient du droit allemand qui comporte une obligation aux engagements. Il est vrai que la possibilité donnée aux promoteurs de conventionnellement exclure ou limiter la responsabilité reste ouverte[2].

On peut noter que l'importance de cette problématique est fortement réduite au Luxembourg, et ceci, pour la raison que la société acquiert la personnalité morale dès le moment de la signature de l'acte de société. C'est donc avec la signature de ce document que la phase de la société en formation s'achève. Dans d'autres États, la personnalité morale n'est souvent acquise qu'avec l'accomplissement d'une formalité ultérieure, telle que l'immatriculation au registre de commerce. La conséquence en est que la phase de la société en formation est souvent de beaucoup allongée par rapport à la situation qui prévaut au Luxembourg. Il en résulte que la nécessité d'organiser la vie d'une société encore dépourvue de la personnalité morale est d'autant plus grande[3].

Au Luxembourg, la seule disposition qui soit applicable en la matière, qui est reprise de la Première directive en matière de droit des sociétés et qui traite de la

1 – M. van der Haegen et C. Verbraeken, « L'adaptation de la législation belge à la Première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.*, 1974, p. 129.

2 – M. van der Haegen et C. Verbraeken, « L'adaptation de la législation belge à la Première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.*, 1974, p. 130.

3 – Pour l'étude de cette matière, il est renvoyé à la doctrine française, notamment P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 177 ; M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, pp. 90 ss.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

reprise des engagements faits pour le compte de la société en formation, est l'article 100-17 [anc. art. 12*bis*] L.S.C. En vertu de cette disposition, toutes personnes qui ont pris des engagements pour le compte d'une société en formation « *en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement* ». Les engagements sont donc des **engagements personnels** des personnes ayant agi pour la société si la société n'est pas constituée dans les deux ans, soit encore si elle est constituée, mais qu'elle ne reprend pas ces engagements à son compte.

Le droit européen règle les effets de la non-acquisition de la personnalité morale. En vertu de l'article 7 de la Première directive, les personnes qui ont accompli des actes au profit de l'entreprise en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf si soit la société reprend à son compte les engagements résultant de ces actes, soit les tiers ont accepté une convention contraire[1]. Cette solution ne vaut que pour les sociétés de capitaux. À l'égard des autres sociétés, le juge national peut considérer qu'ils ont été accomplis au nom d'une société en formation et appliquer la responsabilité solidaire et indéfinie[2].

La jurisprudence prise sur la base de l'article 100-17 L.S.C. insiste sur le caractère non automatique de la reprise des engagements par la société : au contraire, « *il faut un accord formel* » pour assurer cette reprise. Dans le cas d'espèce, les associés de la société ont été assignés pour le paiement de factures correspondant à des services comptables rendus pour la période où la société avait fonctionné comme société de fait[3]. « *Si les statuts d'une société à responsabilité limitée ne comportent ni dans leur texte, ni en annexe un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation et si la personne qui a agi pour la société alors dépourvue de personnalité n'établit pas une approbation par l'assemblée des associés, ni une reprise par la société de l'engagement dans les deux mois de sa constitution, ce fondateur reste personnellement tenu des obligations contractées et il ne saurait exister de solidarité entre lui et la société qu'il déclarait représenter* »[4].

Il y a eu confirmation d'une décision où il est dit pour droit que la reprise par la société des engagements pris par les fondateurs au sens de l'article 100-17 L.S.C. n'est pas automatique et doit se manifester par un accord formel[3].

Il est indispensable que le signataire d'un contrat indique qu'il agit pour le compte d'une société en formation avec mention des renseignements permettant d'identifier la société (dénomination, futur siège). À défaut d'une telle mention, la reprise des engagements souscrits demeure inopposable au cocontractant. Dans le cas d'espèce, *[…]* [XX] (agissant prétendument pour la société en formation) « *n'avait lors de la conclusion du contrat d'achat d'un terrain, à aucun moment soutenu avoir agi pour compte d'une société en formation. Or, il est indispensable que le signataire indique qu'il agit pour le compte d'une société en formation avec mention des renseignements permettant de l'identifier (dénomination, futur siège). A défaut d'une telle mention, la reprise des engagements*

1 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 41.

2 – CJCE, arrêt *Ubbink Isolatie*, 20 septembre 1988, C-136/87, ID 11666.

3 – CA du 30 avril 1997, n° 16.751, *Ann. dr. lux.*, 2002, p. 577, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA du 6 mai 1998, *P.*, n° 31, p. 34, ID 10148.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

souscrits demeure inopposable au cocontractant. » Si la reprise des engagements est faite en dehors du délai de deux mois après la constitution, donc tardivement, le tiers cocontractant aura deux débiteurs à savoir le fondateur mais également la société[1] : le mécanisme de l'article 100-17 L.S.C. est tout à fait remarquable dans le sens qu'il comporte la rétroactivité dans le sens que les fondateurs sont rétroactivement déliés de leurs engagements qui sont donc des engagements de la société dès le début donc même avant que la société ait juridiquement existé[2].

L'article 100-17 L.S.C. (comme la disposition correspondante du droit belge, l'article 13*bis* des lois coordonnées) a une portée très générale dans le sens qu'il s'applique à tous les engagements pris au nom de la société en formation « *de quelque nature qu'ils soient, y compris donc ceux qui résultent de la violation d'un contrat conclu au nom de la société* »[3]. Par conséquent, l'indemnité éventuellement due en cas de résiliation d'un contrat de travail pour un motif grave contesté par le travailleur doit être supportée par la société ; une fois celle-ci formée, elle a repris les engagements du contrat de travail conclu en son nom, même si le licenciement est intervenu avant sa constitution[4].

Le régime de l'article 100-17 L.S.C. (donc celui de l'article 7 de la Première directive) est destiné à assurer la sécurité des tiers, et ceci, en leur garantissant qu'il y ait toujours un débiteur engagé assumant les obligations du contrat. Ce cocontractant est soit la société (sous la double condition qu'elle sera effectivement constituée et qu'elle ratifie les engagements assumés par les fondateurs, et ceci, dans les délais légaux), soit les fondateurs dans les autres cas de figure.

L'effet de la **reprise des engagements** par la société est de dégager les fondateurs sans que les tiers cocontractants n'aient à donner leur accord : la substitution rétroactive de débiteur se produit sans le consentement du créancier.

Le régime de l'article 100-17 suppose qu'un engagement (au lieu d'un acte pour l'article 7 de la Première directive[5]) soit pris pour la société.

L'effet de la reprise des engagements assumés par le promoteur par la société est de libérer le promoteur, mais à condition que la ratification par la société intervienne dans les délais légaux. Il s'agit du délai de **deux mois** à compter de sa constitution ou, si la société n'est pas constituée, du délai de **deux ans** après la prise de l'engagement. Si la société est constituée juste avant que le délai de deux ans n'expire, la reprise reste encore possible dans les deux mois suivant la date de la constitution[6]. Le délai effectif peut donc atteindre 26 mois au maximum.

Qu'en est-il si la reprise intervient après l'expiration de ces délais légaux ? La reprise reste possible, mais ne libère plus les promoteurs : ils restent donc tenus en même temps que la société.

---

1 – CA du 30 novembre 1988, n° 34.097, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CSJ Lux. du 6 mai 1998, *P.*, n° 31, p. 34. V. Steichen, p. 215, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – C. trav. Bruxelles du 24 juillet 1979, *R.P.S.*, 1980, p. 46.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 659.

5 – Cette divergence de terminologie n'est pas considérée comme relevant d'une divergence sur le fond ; v. M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 157.

6 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 158.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La reprise des engagements par la société **doit être certaine**, mais sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle soit expresse : elle peut être **implicite** dans la mesure où elle résulte du comportement adopté par la société[1].

Si les engagements ne sont pas repris par la société, les fondateurs en sont « *personnellement et solidairement responsables* », ce qui ne doit pas être considéré comme signifiant qu'ils ne seront tenus que de dommages-intérêts. La loi doit être comprise dans le sens que les promoteurs assument personnellement les engagements qu'ils ont conclus.

L'article 100-17 L.S.C. est applicable « *sauf convention contraire* », ce qui permet donc des dérogations aux engagements ainsi pris par les promoteurs. On considère que ces dérogations peuvent consister notamment dans la suspension des engagements des promoteurs jusqu'à la non-reprise par la société, à écarter la solidarité, à raccourcir les délais de la loi prévus pour la reprise, etc.

La société juge souverainement de l'opportunité de reprendre tel ou tel engagement, et ceci, en jugeant de son utilité pour la société. Il est toutefois évident que la société est tenue envers les promoteurs si du matériel lui a été livré et que les traites relatives à ce matériel ont été réglées par les promoteurs. Dans de telles hypothèses, il y aurait application des règles de droit commun relatives à la gestion d'affaires et à l'enrichissement sans cause[2].

SECTION III
L'ATTRIBUTION DE LA PERSONNALITÉ MORALE

« *On peut définir la personnalité morale comme l'aptitude à être sujet de droit, conférée à une entité juridique distincte des éléments qui la composent* »[3]. Il résulte de cette définition que la personne morale est titulaire de droits et de devoirs et qu'elle agit comme un sujet autonome de la vie juridique. Plus concrètement encore, la personne morale possède un **patrimoine en propre** et elle agit dans la vie juridique en tant que **sujet de** ces **droits**. Pour les personnes physiques, la personnalité juridique est attachée à la simple naissance d'un être humain. Pour les êtres qui n'ont pas d'existence physique, la question est de savoir en vertu de quels éléments la personnalité morale est attribuée et, le cas échéant, à quel moment précis la personnalité prend naissance.

La personnalité morale des sociétés comporte des conséquences de plusieurs ordres : en premier lieu, elle permet d'éviter le concours des créanciers de la société avec les créanciers personnels des associés. En deuxième lieu, elle permet à la société d'agir en justice (et d'être assignée en justice) sans que les associés ne soient parties à l'instance. En troisième lieu, elle a pour conséquence le gage exclusif des créanciers sociaux sur l'actif social, comportant donc **séparation des patrimoines** au profit des créanciers de la société. Il ne peut donc y avoir compensation légale entre la créance de la société sur un tiers et la dette de ce tiers envers l'associé.

La personnalité morale implique encore le **caractère** purement **mobilier** du droit des associés, quelle que soit la nature des actifs de la société, et ceci, jusqu'à la clôture de la liquidation.

---

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 158.

2 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 161.

3 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 177.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Enfin la personnalité morale entraîne la possibilité pour les sociétés commerciales d'être déclarées en faillite[1].

Si la personnalité morale joue essentiellement dans l'ordre externe de la société, dans le sens qu'elle régit les relations entre la société et les tiers, elle comporte également des conséquences dans l'ordre interne de la société : « *Les associés sont rattachés à un ensemble qui les domine […] le groupe réalise un intérêt distinct des intérêts individuels de ses membres. La société a en effet une vie indépendante de celle des associés ; ceux-ci passent et elle demeure. Le groupe des associés apparaît organisé pour réaliser un intérêt qui lui est propre. Il est donc doué de la personnalité morale. Seule cette idée permet d'expliquer le phénomène de la personnalité morale* »[2].

Les statuts sociaux ont en somme un double caractère : d'une part, il s'agit d'un accord entre les fondateurs et, d'autre part, ils constituent la loi interne d'une personne morale. Ce deuxième point explique que les statuts ne soient pas immuables, mais qu'ils puissent être amendés en fonction des événements de la vie sociale[3]. Il n'en reste pas moins que toutes les modifications statutaires ne sont pas permises à la majorité des associés. En effet, certaines modifications ne peuvent être effectuées qu'à l'**unanimité des voix**[4]. Tel est le cas de l'augmentation des engagements des associés. Les autres modifications sont soumises au vote majoritaire requis pour les modifications des statuts. La limitation existant autrefois en Belgique selon laquelle il n'est pas possible de changer l'objet essentiel de la société n'a pas été reprise au Luxembourg, de sorte qu'en principe toutes les dispositions statutaires peuvent faire l'objet d'une modification. Il existe néanmoins une autre limitation à l'omnipotence de l'assemblée et qui a pour objet de limiter tout arbitraire et toute tyrannie des associés majoritaires à l'encontre des associés minoritaires. Il est question ici des **droits propres** de l'associé dont celui-ci ne peut être privé dans aucun cas et quelle que soit la majorité[4]. Si, de façon générale, cette notion manque certainement de précision, on peut selon les auteurs ranger parmi ces droits les suivants :

– le droit de vote ;
– le droit à l'égalité de traitement[5] ;
– le droit de ne pas être exclu sans compensation quand les autres y restent, le droit de limiter son risque au montant de l'action.

1 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 118.

2 – H. Lechner, *Des droits propres des actionnaires*, p. 24 ; L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 118.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 118.

4 – L. Metzler, Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée, p. 119.

5 – En réalité, ce principe a deux volets : un premier volet qui concerne les relations de la société avec ses actionnaires et un deuxième volet relatif aux relations entre actionnaires. Si le principe d'égalité doit être respecté par la société agissant par rapport à ses associés, il n'en va pas de même dans les relations concernant les actionnaires entre eux. Concernant ce deuxième volet, le tribunal d'arrondissement dans son jugement du 8 juillet 2003 (*Audiolux e.a. c/ Groupe Bertelsmann et RTL Group*, *BIJ*, 2003, p. 149) a dénié à l'obligation du traitement égalitaire la portée d'un principe général de droit et donc rejeté les prétentions des actionnaires minoritaires.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – Base juridique de la personnalité morale

Les discussions doctrinales sur la question de savoir quelles sont les bases juridiques de la personnalité morale ne datent pas d'hier. Essentiellement, on oppose la théorie de la réalité à celle de la **fiction**.

Pour les défenseurs de la **théorie de la réalité**, la personnalité morale résulte de la réalité même des groupements de personnes. Ceux-ci auraient par nature la personnalité morale dans la mesure où ils ont une volonté collective et une activité particulière[1].

La personnalité morale remonte très loin dans le temps, et le législateur et la jurisprudence ont tendance à l'élargir. Elle constituerait une nécessité basée sur l'existence d'une **volonté collective**, orientée vers un but commun s'exprimant par des organes[2]. Cette théorie est reconnue par la Cour de cassation de France[3] : « *[…] la personnalité morale appartient en principe à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective d'intérêts licites, dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés* ».

La capacité de ces personnes morales ne leur est donc pas reconnue par des actes plus ou moins arbitraires de l'État, mais celle-ci doit être la règle soit quant à la jouissance, soit quant à l'exercice des droits. Ces organismes ont donc en principe pleine capacité[4].

On oppose à cette théorie de la réalité la **théorie de la fiction**. Selon cette dernière théorie, tous les biens appartiennent à des personnes physiques, la personnalité morale n'étant donc qu'un mythe, il faut remplacer ce mythe par une notion de droit positif, à savoir celle de propriété collective[5] : la personnalité est une création de la loi et le législateur, par une fiction légale, assimile les personnes morales aux personnes physiques. Étant donné qu'il s'agit d'une fiction, celle-ci est en principe interprétée restrictivement.

Sans nécessairement se rallier à la théorie de la fiction, il semble néanmoins que le droit luxembourgeois, à l'instar du droit belge[6], considère que la personnalité morale ne peut résulter que d'une disposition légale spécifique. En l'occurrence, la personnalité morale des sociétés commerciales résulte directement de l'article 100-2, alinéa 2 (anc. art. 2, al. 2) L.S.C. qui précise que :

« *Chacune d'elles [les sept types de sociétés commerciales] constitue une individualité juridique distincte de celle des associés* […] ». L'article 100-3 (anc. art. 3) L.S.C. attribue la personnalité morale aux sociétés civiles régies par l'article 1832 C.c.

Celles-ci ont donc la personnalité morale, contrairement à la situation qui prévaut traditionnellement en Belgique[6], mais conformément à la France (depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1891[7]). À leur égard, la jurisprudence déduit la personnalité morale de certaines dispositions du Code civil.

---

1 – Pour plus de détails, v. A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 76.

2 – L. Josserand, *Cours de droit positif français*, I, n°s 667 ss. ; L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 117.

3 – Cass. (civ. 2e sect.) du 28 janvier 1954, *D.*, 1954, p. 217, note Levasseur.

4 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 117.

5 – M. Planiol et G. Ripert, I, n° 3017.

6 – P. Van Ommeslaghe, « Les sociétés de fait », *J.T.*, 1957, p. 710.

7 – Cass. du 23 février 1891, *R.P.S.*, 1891, n° 193.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans cette discussion, il ne faut pas perdre de vue que l'attribution de la personnalité morale, si elle peut constituer un avantage indéniable pour la société, est susceptible de gravement nuire aux intérêts de certaines catégories de personnes : ceux des créanciers de la personne morale, des créanciers des associés, des tiers et des associés eux-mêmes[1].

La base de la personnalité morale est donc directement à trouver dans la loi sur les sociétés commerciales.

La conception actuelle est que la personnalité morale « *est du ressort de la technique juridique* », étant entendu que cette technique « *traduit en termes juridiques d'incontestables réalités* »[2].

A – Caractéristiques de la personnalité morale

On ne peut qu'insister sur certaines caractéristiques de la personnalité juridique des sociétés qui sont autant de caractères distinctifs par rapport à la personnalité juridique des personnes physiques. En outre, selon le type de société, le contenu de la notion est plus ou moins large : certains auteurs parlent de personnalité complète ou incomplète. Divers degrés existent dans la séparation établie par la loi entre l'entité juridique appelée société et la personne des associés. Dans ce sens, les sociétés de personnes et, en particulier, les sociétés en nom collectif ont une personnalité morale sous-développée : « *le cordon ombilical n'est pas coupé avec les associés géniteurs* »[3]. En effet, la société en nom collectif est commerçante, mais les associés le sont aussi. Étant donné que les associés sont responsables personnellement des dettes sociales, les intérêts de la société se confondent avec les leurs propres. Il n'y a donc pas d'intérêt social distinct de celui de la personne morale avec donc la conséquence que la personnalité de la société est incomplète.

Certains se sont posé la question de savoir si, *de lege ferenda,* il ne serait pas préférable de ne pas attribuer la personnalité morale à cette forme de société pour se contenter de règles selon lesquelles le patrimoine de la société serait le gage préférentiel des créanciers sociaux[4].

L'autonomie patrimoniale de la société signifie que toute société dotée de la personnalité morale a un patrimoine qui lui est propre et qui constitue le gage exclusif des créanciers sociaux. Dans cette mesure-là, il existe une séparation très nette entre le patrimoine de la société et celui des associés. En réalité, il y a lieu de faire une distinction entre les sociétés dont la responsabilité est illimitée et les autres, du fait que, pour les premières, la séparation des patrimoines est incomplète : elle n'existe qu'au profit des créanciers sociaux. Elle est en revanche complète pour les associés dont la responsabilité est limitée aux apports faits par eux : dans ce cas, elle existe tant au profit des associés et de leurs créanciers éventuels qu'au profit des créanciers sociaux[5].

---

1 – P. Van Ommeslaghe, « Les sociétés de fait », *J.T.*, 1957, p. 710.

2 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, I, n° 352.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 152.

4 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 153.

5 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 171.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les conséquences de cet état de choses sont fort importantes : en particulier, les créanciers personnels d'un associé ne peuvent saisir les biens apportés par leur débiteur à la société. Ils ne peuvent provoquer une dissolution de la société afin de faire ainsi bénéficier le patrimoine de leur débiteur du fait de la distribution du produit de liquidation[1].

Les créanciers personnels de l'associé peuvent uniquement saisir les parts que leur débiteur a reçues en échange de son apport : celles-ci ne peuvent être vendues sans tenir compte des restrictions légales ou statutaires existant quant à la cessibilité de ces parts sociales[1], sans préjudice de l'action paulienne (en cas d'apport fait en fraude des droits des créanciers).

En cas de responsabilité limitée des associés, les créanciers sociaux n'ont aucun droit sur le patrimoine personnel des associés. Néanmoins, ils ont certains droits dans l'hypothèse où les associés n'ont pas entièrement libéré leurs apports, et ceci, selon la distinction suivante :

– si la **libération des apports**, demandée par la société, n'est pas exécutée par les associés et que la société n'entreprend pas les démarches nécessaires pour obtenir cette libération effective, alors les créanciers peuvent exercer **l'action oblique** prévue par l'article 1166 C.c. ;
– si les dirigeants sociaux ne demandent pas la libération des apports, alors les créanciers sociaux peuvent (et ceci vaut pour toutes les sociétés) faire décréter celle-ci dans la mesure nécessaire à la conservation de leurs droits (art. 1400-2 [anc. art. 153] L.S.C.). En réalité, il s'agit d'un appel de fonds décidé par le tribunal[2]. Les dirigeants sociaux sont personnellement tenus de l'exécution des décisions de justice ordonnant l'appel de fonds. Il est loisible aux dirigeants sociaux d'écarter cette action en procédant au remboursement de la créance aux créanciers demandeurs de l'action en décrètement (art. 1400-2, alinéa 1 L.S.C.).

B – Capacité de la personne morale

Il est tout à fait tentant de comparer la situation de la personne morale avec celle de la personne physique. En cette dernière matière, on distingue la **capacité de jouissance** de la **capacité d'exercice**.

Vue de cet angle, on peut constater que la personne morale est frappée par une « *radicale incapacité d'exercice : elle ne peut agir par elle-même ; elle agit nécessairement par l'intermédiaire d'organes qui la représentent (au sens large du mot)* »[2].

Qu'en est-il de la capacité de jouissance ? Les personnes morales bénéficient d'une pleine capacité de principe, solution qui s'oppose à celle « *qui consiste à procéder par voie d'attribution expresse de droits* »[3].

À cette **pleine capacité de droit,** il y a un certain nombre d'exceptions parmi lesquelles se trouvent en premier lieu les droits que la société ne peut faire valoir par la

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 171.

2 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 172.

3 – P. van Ommeslaghe, « Observations sur les limites imposées à l'activité des personnes morales en droit comparé », *R.C.J.B.*, 1958, p. 293.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

nature des choses (droits politiques, droit de la famille)[1]. La **spécialité légale** exclut, d'autre part, certaines fins qui sont interdites à la personne morale. En revanche, le principe de la spécialité statutaire doit être considéré comme abandonné, au moins depuis la Première directive. Les sociétés visées par la directive sont engagées par l'acte dépassant l'objet social, à moins de prouver que le cocontractant connaissait le dépassement de l'objet social. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'objet social limite le seul pouvoir de représentation des organes, mais non la capacité de la société[1].

La loi peut encore interdire certaines activités à certains types de sociétés : tel est le cas des activités d'assurances, de capitalisation et d'épargne qui sont interdites aux sociétés à responsabilité limitée (art. 710-2 [anc. art. 180] L.S.C.). En outre, certaines professions libérales classiques (médecins, par exemple) ne peuvent être exercées par des sociétés.

Finalement, certaines dispositions légales prévoient des limitations non par rapport aux fins que la société peut poursuivre, mais par rapport à ses **moyens**. Ainsi est-il interdit aux S.à r.l. d'émettre par voie d'émission publique des obligations ou de procéder à une émission publique de parts sociales (art. 710-11 L.S.C.).

Les **sanctions de la violation de la spécialité légale** sont variées, et elles sont différentes selon que la société a été constituée en violation des règles de la spécialité légale ou que celle-ci intervient postérieurement à la constitution de la société. Dans le premier cas de figure, il peut y avoir nullité de la société pour objet social illicite ou contraire à l'ordre public[2]. Si la violation n'intervient qu'en cours d'existence de la société, par modification des statuts, alors cette modification statutaire est nulle et la société garde son ancien objet social. En outre, les actes faits en violation de la spécialité légale ne peuvent être imputés à la société qui est incapable d'être titulaire des droits et obligations que ces actes engendrent[3].

■ § 2 – Moment de l'attribution de la personnalité morale

Comme on a vu ci-dessus, c'est la loi qui attribue la personnalité morale. En revanche, la loi est muette quant au moment de l'attribution de la personnalité morale et quant à l'événement qui déclenche cette attribution de la personnalité morale.

Au Luxembourg, il est reconnu que la personnalité morale des sociétés est acquise dès la signature de l'acte de société dans les formes légalement requises. Il s'agit donc de l'acte de société (dans la forme d'un acte notarié pour les sociétés de capitaux). L'acquisition de la personnalité n'est donc pas subordonnée à l'accomplissement de formalités de publicité, notamment donc l'immatriculation au R.C.S. ou encore la publication au RESA. Ces formalités sont utiles, voire indispensables, pour rendre opposables aux tiers la constitution de la société et le contenu de l'acte de société. En revanche, elles n'ont guère d'effet sur la capacité d'exercice de la société : le seul effet à cet égard est que la société, tant qu'elle n'est pas immatriculée au R.C.S., n'a pas la capacité d'assigner en justice, en revanche, et on s'en doute, elle peut bel et bien être assignée en justice, nonobstant le fait que la société ne soit pas encore immatriculée au R.C.S.

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 174.
2 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 177.
3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 178.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Selon une certaine jurisprudence, les choses se passeraient de façon différente et ce serait « *l'immatriculation au registre de commerce qui donnerait la personnalité morale à la société et la publication au* Mémorial *qui rend opposable aux tiers les actes ou extraits d'actes des sociétés* »[1]. Cette jurisprudence est erronée.

Quelle est la **base théorique** de cette position ? L'article 100-2 L.S.C. prévoit, sans autres précisions, que les formes de sociétés commerciales énumérées sous sept points sont dotées de la personnalité morale. En l'absence de la moindre restriction dans la loi qui permettrait de retarder (ou d'avancer) ce moment de l'attribution de la personnalité morale, il faut supposer que la personnalité est attribuée dès la signature de l'acte de société. C'est donc à partir de la réalisation des conditions de l'article 1832 C.c. que la personnalité morale doit être considérée comme acquise.

On peut noter qu'en Belgique la situation était autrefois similaire à celle décrite ci-dessus pour le Luxembourg : dans notre pays voisin, il y avait également attribution de la personnalité morale en raison de la seule conclusion du contrat de société. Cette situation a toutefois changé en 1995 : la loi du 13 avril 1995 a modifié le droit applicable sur ce point en retenant que, dorénavant (à partir du 1er janvier 1996), la personnalité morale est subordonnée à l'immatriculation des sociétés et au dépôt de leurs statuts au greffe du tribunal de commerce. L'acquisition de la personnalité morale est ainsi soumise à un certain formalisme[2].

■ § 3 – Moment de la cessation de la personnalité morale

En application des dispositions combinées des articles 1832 C.c. et 100-2 (anc. art. 2) L.S.C., on pourrait être amené à penser que les effets de la personnalité morale cessent à partir du moment de la dissolution de la société. Une telle conclusion se heurte toutefois à une disposition formelle de la loi : en effet, l'article 1100-1 [anc. art. 141] L.S.C. prévoit que : « Les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés commerciales momentanées ou les sociétés commerciales en participation, sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. […] ». Il est généralement conclu de cette disposition que la personnalité morale est censée subsister (au moins) jusqu'à la clôture de la liquidation.

C'est par une **fiction légale** que la personnalité morale est maintenue au-delà du moment de la dissolution de la société : en effet, la société continue à exister aux fins de sa liquidation.

La personnalité morale ne disparaît pas de façon brutale, mais elle **s'éteint graduellement**. Elle survit pendant la phase de liquidation de la société pendant laquelle le patrimoine de la société doit rester le gage exclusif des créanciers sociaux. Mais la capacité est limitée pendant cette phase dans le sens que la société n'a plus la capacité de réaliser des affaires nouvelles[3], sauf autorisation donnée par l'assemblée générale des associés conformément à l'article 1100-2 (anc. art. 142) L.S.C.[4].

1 – TA Lux. du 15 juillet 1988, n° 356/88, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – M. Coipel, *et al.,* « La société dans tous ses états », *Le droit des sociétés. Aspects pratiques et conseils des notaires*, p. 73.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 154.

4 – V. art. 1100-5 (anc. art. 145) L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La clôture de la liquidation marque la fin des pouvoirs des liquidateurs. Mais ce moment ne constitue pas encore la fin véritable de la personnalité morale : en effet, une **personnalité** réduite et **purement passive** subsiste pendant cinq années suivant la publication de la clôture de la liquidation dans le sens que la société continue à exister pendant cette période afin de répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre la société en la personne des liquidateurs.

« *Il est de principe que l'être moral disparaît avec la clôture de la liquidation. Lorsque celle-ci est terminée, la société perd le bénéfice de l'individualité juridique : elle n'a plus de représentants et ceux-ci ne peuvent plus agir pour elle. Chacun des anciens associés reprend la liberté d'exercer pour son propre compte le commerce ou l'industrie dont l'exploitation avait fait l'objet de la société* »[1].

■ § 4 – Conséquences de l'attribution de la personnalité morale

Du fait que la société jouit de la personnalité morale résulte un certain nombre de conséquences. En premier lieu, la société possède en propre un certain **patrimoine**, **distinct** de la personne des associés, dont l'importance en général sera assez limitée au moment de la constitution, mais qui a vocation à grandir (et surtout à se diversifier) au fil du temps. Il est manifeste que, conceptuellement, la personnalité morale est étroitement calquée sur celle de la personnalité juridique de la personne physique. La société est donc bénéficiaire de droits et d'obligations tout comme n'importe quelle personne physique. En revanche, il existe une différence essentielle entre les deux formes de personnalité juridique : il s'agit de la **nécessité d'être représentée**. La société a la possibilité d'agir par l'organe de ses représentants légaux et notamment d'agir en justice soit comme demandeur, soit comme défendeur.

Les créanciers de la société ont une **situation privilégiée** sur les biens de la société par rapport aux créanciers personnels des associés.

Finalement, la société est directement créancière et débitrice des tiers, de sorte que toute compensation directe avec les créances et les dettes de la société et celles des associés de la société est interdite[2].

Cette attribution de la personnalité morale a également des conséquences en **matière fiscale,** et certains y ont vu une cause pour un tarissement des sources de l'impôt. En effet, n'a-t-on pas considéré qu'en accordant la forme de la société anonyme aux sociétés immobilières, la propriété foncière est immobilisée et l'impôt sur les mutations immobilières deviendrait du même coup improductif[3] ?

« *La personnalité morale est un concept relatif dont il convient de faire application en fonction des objectifs poursuivis par telle ou telle institution indépendamment même de tout abus* »[4].

Ainsi, en droit social (belge), on détermine l'ancienneté à laquelle peut prétendre un travailleur en fonction des services qu'il a rendus dans une entreprise déterminée,

1 – TA Lux. du 12 novembre 1927, *P.*, n° 12, p. 78 ; TA Lux. du 2 mars 1993, n°s 37.019 et 41.406, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 6, ID 11308.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 35, ID 11305.

4 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 261.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

même si celle-ci a appartenu à plusieurs personnes successives, et donc sans considération de la personnalité distincte des différents employeurs successifs[1].

La notion est également à **géométrie variable** dans le sens que, selon le type de société, elle n'aura pas la même étendue : pour la Cour de cassation belge, la personnalité morale de la société en nom collectif « *se confond pratiquement avec celle de ses associés* »[1]. Par conséquent, selon une jurisprudence constante, si le tribunal prononce la faillite d'une société en nom collectif, il peut prononcer également celle des associés en nom, et ceci, sans devoir rechercher si ces associés sont personnellement en état de cessation de paiements et si leur crédit est ébranlé. « *L'état de faillite de la société implique que les associés se trouvent personnellement dans la même situation* ».

Tout comme n'importe quelle personne physique, la personne morale doit être identifiée de façon non équivoque.

A – Identification de la personne morale

La société porte un nom, appelé « dénomination sociale » et autrefois « raison sociale » pour les sociétés de personnes. Dans le premier cas de figure, la dénomination de la société est faite soit par un nom de fantaisie, soit par la désignation du commerce qu'elle poursuit. Art. 100-5 (1) : « *Les sociétés mentionnées à l'article 100-2, alinéa 1, ainsi que les sociétés en commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit la dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise.*

Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société […] ».

La Loi AIFM a aboli à l'égard de toutes les formes de sociétés la notion de raison sociale qui, par le passé, obligeait les sociétés de personnes à s'identifier par les noms d'un ou de plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables. Du fait de ce changement, toutes les formes de sociétés sont désignées par une « dénomination sociale » librement choisie qui peut être « *soit une dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise* » (art. 100-5 L.S.C.).

L'exigence d'une dénomination différente pour chaque société est générale et oblige toute entreprise (et donc pas seulement les sociétés) à éviter toute confusion dans la désignation.

« *Le nom est une propriété dont il ne faut pas permettre à une société nouvelle de se servir, pour tromper les tiers et nuire à une société déjà existante* »[2].

B – Protection de la dénomination sociale

En application de l'article 100-5 (1) L.S.C., le nom de la société (ou la désignation de l'objet de son entreprise) doit être différent de celui de toute autre société[3]. « *Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu* ». Il faut que le nom ait

1 – Cass. b. du 16 juin 1976, *Pas.*, 1977, II, p. 107.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 105, ID 11305.

3 – On peut noter qu'une disposition similaire fait défaut à l'égard des S.à r.l., et ceci, contrairement à ce que prévoit le droit belge (art. 117 L.C.S.C.).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

un caractère distinctif permettant de ne pas le confondre avec une autre personne morale ou entreprise individuelle.

Ces dispositions sont relatives à la dénomination sociale telle qu'elle résulte des statuts ; celle-ci peut être différente du nom commercial utilisé par la société pour l'exploitation de son fonds de commerce[1].

« *La protection de la dénomination sociale n'est pas réservée aux dénominations originales ou qui se caractérisent par un certain degré de créativité. Encore faut-il que la dénomination soit suffisamment distinctive : l'emploi d'un vocable banalisé à force d'emplois répandus par de multiples sociétés n'implique aucune appropriation par l'une d'elles du vocable en cause et il n'est pas susceptible, tel quel, de la protection que dispensent les lois coordonnées sur les sociétés commerciales* »[2].

La protection accordée légalement à la dénomination sociale dépasse le cadre des frontières grand-ducales. « *Le droit pour une société anonyme d'empêcher toute confusion entre sa dénomination et celle d'une autre société n'est pas subordonné à l'établissement de son siège social dans le pays où se crée la société empruntant une dénomination semblable. Il suffit qu'il y ait dans ce pays possibilité d'une confusion entre les deux sociétés pour qu'il y ait lieu à application de l'article 25 de la loi sur les sociétés* »[3].

Dans l'appréciation des **risques de confusion,** il convient de tenir compte également de la désignation choisie par la société qui se prétend victime de la confusion. « *Si une société anonyme se qualifie par la désignation de l'objet de son entreprise, il y a impossibilité d'éviter certains risques de confusion, et cela surtout si un grand nombre de sociétés exercent la même activité. Aussi le juge doit-il faire preuve en ce cas d'une certaine tolérance* »[4].

Si une société anonyme est **désignée par son objet social** ainsi que par une abréviation de cette dénomination, cette abréviation doit être modifiée si elle est identique à celle d'une autre société qui en a usé la première[4]. « *[…] la loi laisse donc à la société anonyme, pour sa qualification le choix entre une dénomination plus ou moins de fantaisie et la désignation de l'objet de son entreprise ; que si elle adopte un nom de fantaisie, elle acquiert sur celui-ci un droit exclusif par cela seul qu'elle a été la première à s'en servir ; que si, comme en l'espèce, elle se qualifie par la désignation de l'objet de son entreprise, elle ne devient pas propriétaire des termes usuels ou génériques servant à désigner un type d'activité économique, sauf si, par une longue durée d'usage, la désignation au début dépourvue d'originalité a fini par s'identifier dans l'esprit du public avec la société ; que hormis ce cas, le droit de toute autre société de se qualifier par la simple désignation de l'objet de son entreprise est égal au sien, mais est limité en ce sens que la désignation doit être différente, c'est-à-dire ne peut être identique ou d'une similitude telle qu'elle puisse créer une confusion dans l'esprit des tiers. Pour apprécier si cette confusion est possible, il faut tenir compte des aptitudes de la clientèle moyenne* »[4].

---

1 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 665.

2 – À propos de l'utilisation du mot « Star », Trib. com. Liège du 20 février 1986, *R.D.C.B.*, 1987, p. 537.

3 – TA Lux. du 12 avril 1962, *P.* , n° 18, p. 510, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA du 29 janvier 1974, *Fiduciaire Générale du Nord c/ Fiduciaire Générale du Luxembourg*, *P.* , n° 22, p. 430, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Par le passé, la société disposait de deux actions exclusives : l'action fondée sur l'article 25 L.S.C. remplacé par l'article 100-5 L.S.C. devant le tribunal d'arrondissement et l'action fondée sur les articles afférents de la loi modifiée du 26 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale devant le président de la chambre commerciale du tribunal d'arrondissement[1].

Pour apprécier si la ressemblance entre les dénominations ou les désignations de deux sociétés commerciales peut induire en erreur, « *le juge doit examiner l'incidence que peut avoir la fréquence d'utilisation d'une dénomination ou d'une désignation sur l'appréciation du risque de confusion et en cas de dénomination composée le juge doit, lorsqu'il examine la ressemblance, confronter les dénominations ou désignations prises dans leur ensemble, eu égard à tous les éléments qui les composent* »[2].

Une **inaction prolongée** peut valoir déchéance de ces droits de protection. Un jugement belge décide « *[…] qu'une société qui estime que la ressemblance entre la dénomination d'une société et la sienne peut induire en erreur, doit agir rapidement sous peine d'être déchue de son droit exclusif sur la dénomination qu'elle s'est choisie ; qu'une inaction prolongée est en effet de nature à démontrer que le danger de confusion n'est pas réel et qu'il a été bénévolement accepté* »[3]. La **déchéance** s'explique par le « droit acquis » de la société à la dénomination qui naît dans le chef de l'autre société à la suite de l'utilisation par elle de la dénomination litigieuse sans protestation[4].

Mais dans cette appréciation de la notion d'inaction prolongée, il convient de tenir compte du fait que celle-ci « *ne se conçoit qu'à partir du moment où la société, qui se prévaut de son droit, a pris connaissance de l'existence de l'autre et non pas, comme le veut faire admettre l'appelante, à partir de sa constitution qui, en l'espèce, se situe en l'an 1991. On ne peut en effet que renoncer à faire usage de son droit tiré de l'article 25.2 si on a pris connaissance de ce qu'une société plus jeune a une dénomination qui ressemble à la sienne au point de rendre une confusion possible* »[5].

L'**action en modification du nom social** est soumise aux deux seules conditions suivantes : l'antériorité de l'usage ou le danger de confusion avec le nom de la défenderesse. Il n'est pas requis que les deux sociétés dont les noms portent des ressemblances soient concurrentes, aient le même objet social ou encore qu'une faute ait été commise[6]-[7]. « *Elle exige l'existence d'un risque de confusion. Ce dernier suppose que l'impression globale que l'homme moyen normalement attentif a de la dénomination sociale incriminée présente de tels points de similitude avec*

1 – TA Lux. du 10 février 1989, *P.*, n° 28, « Sommaire. La concurrence déloyale en jurisprudence luxembourgeoise », pp. 85-90, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cass., 2 mai 1996, *P.*, n° 30. p. 60, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Trib. com. Bruxelles du 25 avril 1983, *R.P.S.*, 1985, p. 60.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1), *R.C.J.B.*, 1992, p. 669.

5 – CA du 11 janvier 2006, n° 29.231, *BIJ*, 2006, n° 3, p. 75.

6 – J. Van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales », *R.C.J.B.*, 1962, p. 368.

7 – CA du 20 mars 2002, *Alliance Capital (Luxembourg) S.A. c/ Allianz Kapitalanlagegesellschaft mbH*, ID 1119.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

l'impression globale qu'il a gardée de la dénomination sociale dont la protection est demandée, qu'il y a dans son esprit une confusion impliquant qu'il prend la société à la dénomination sociale critiquée pour la société qui demande la protection de sa dénomination sociale »[2].

La dénomination doit être changée dès qu'elle peut induire en erreur. Point n'est besoin d'établir un **préjudice présent ou futur**[1].

Ce danger de confusion doit être apprécié *in abstracto*, et donc pas sur la base des éléments concrets de l'affaire.

L'action en modification basée sur les anciens articles 25 et 186 L.S.C. supposait un risque de confusion résultant d'une similitude ou d'une ressemblance de dénomination, peu importe l'objet social des sociétés en présence[2].

Il a été jugé que « *[…] la protection de l'article 25 L.S.C. ne couvre que la protection spécifique tirée de l'article 25 L.S.C. ne concerne que les sociétés constituées en application de la loi luxembourgeoise* »[3]. Cette conclusion ne serait pas énervée par l'article 8 de la Convention d'Union de Paris, ayant trait au nom commercial, notion distincte de la dénomination sociale.

Ce régime de l'article 25 L.S.C. est plus sévère pour la société défenderesse que celui de l'action en cessation qui, elle, est fondée sur l'article 14 de la loi relative aux pratiques commerciales[4].

C – Loi sur la concurrence déloyale

1) La situation traditionnelle sous la loi du 30 juillet 2002

Lorsqu'une société commerciale se considère être victime du fait qu'une autre entreprise fait le commerce sous une dénomination similaire, voire identique, à la sienne, elle peut exercer l'action fondée sur l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 relative aux pratiques commerciales, la concurrence déloyale et la publicité trompeuse (en plus de l'action fondée sur l'article 25 L.S.C. précité)[5].

Le point remarquable est que, d'après cette loi, il suffit pour obtenir la cessation d'actes de concurrence déloyale, de prouver non pas l'existence d'un préjudice, mais la simple possibilité de celui-ci[6].

La jurisprudence sur les actions en protection de la dénomination sociale (portées devant le tribunal d'arrondissement) est très abondante. Si la désignation qu'une société adopte est identique à celle d'une autre ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts s'il y a lieu[7].

---

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 167.

2 – TA Diekirch du 19 juin 1990, n° 72/90.

3 – CA com. du 6 juillet 2005, n° 27.964, ID 11924.

4 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 164.

5 – *P.* , n° 28, « Sommaire. La concurrence déloyale en jurisprudence luxembourgeoise », pp. 85 ss.

6 – Sur ce point, notre droit s'écarte du droit français pour lequel l'action en cessation d'actes de concurrence déloyale est basée sur la responsabilité délictuelle. CA du 26 novembre 2003, n° 27.151, *BIJ*, 2004, n° 2, p. 84.

7 – TA Lux. du 22 mars 1994, n° 195/94 (IV), cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le droit à cette protection n'est pas subordonné à l'établissement de son siège social dans le pays où se crée la société empruntant une dénomination semblable[1].

L'étendue de la protection varie selon la désignation choisie : si la société a opté pour un nom de fantaisie, elle acquiert sur ce nom un droit exclusif par le seul fait de s'en être servie la première. Si la société a adopté la désignation de l'objet de son entreprise, elle ne devient pas propriétaire des termes usuels ou génériques servant à désigner un type d'activité économique, sauf si, par une longue durée d'usage, la désignation, au début dépourvue d'originalité, a fini par s'identifier dans l'esprit du public avec la société. Hormis ce cas, le droit de toute autre société de se qualifier par la simple désignation de l'objet de son entreprise est égal au sien, mais est limité en ce sens que la désignation doit être différente, c'est-à-dire ne peut être identique ou d'une similitude telle qu'elle puisse créer une confusion dans l'esprit des tiers[2].

Encore jugé que, si une société se désigne par l'objet de son entreprise, des risques de confusion sont inévitables, notamment si le nombre des sociétés exerçant la même activité est élevé. Le juge doit donc faire preuve d'une certaine tolérance[3].

Dans cette appréciation des risques de confusion, le juge doit se mettre à la place de la clientèle moyenne[4], d'une personne normalement attentive[5].

Une telle confusion est évitée non seulement par les interventions des entreprises concurrentes (notion plus vaste que celle de société), mais encore par l'effet de l'immatriculation au R.C.S.

« *Le juge saisi par la demande d'une société luxembourgeoise sur base des articles 16 et 17 (f) de la loi sur la concurrence déloyale, peut seulement ordonner l'interdiction d'un acte de concurrence déloyale qui est ou risque d'être posé sur le territoire luxembourgeois, ce qui fait que sa décision reste sans incidence sur la dénomination sociale d'une société étrangère et sur l'usage qu'elle en fait à l'étranger.*

Le juge luxembourgeois est, dès lors compétent ratione materiae *pour connaître de la demande même si la société défenderesse est également protégée par la législation étrangère* »[6].

Pour être protégeable, la dénomination doit avoir un caractère distinctif, c.-à-d. un caractère individualisant suffisant et efficace pour qu'il n'y ait pas de confusion possible avec un signe semblable qui serait employée par ailleurs. « *Créer ou tenter de créer la confusion entre sa personne et la personne d'un concurrent – soit en faisant prendre l'une pour l'autre, soit en faisant croire à des liens inexistants – est un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, donc un acte de*

1 – TA Lux. du 12 avril 1962, *P.*, n° 18, p. 510 et TA Lux. du 20 mars 1994, n° 195/94 (VI), ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 30 mars 1986, n° 36.289 ; TA Lux. du 27 mars 1987, n° 37.150 ; TA Lux. du 29 mars 1994, n° 195/94 (VI) ; CA du 29 janvier 1974, *P.*, n° 22, p. 430, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA Lux. du 12 avril 1962, *P.*, n° 18, p. 510 ; TA Lux. du 27 mars 1987, n° 37.150, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 30 mars 1986, n° 36.289 ; TA Lux. du 27 mars 1987, n° 37.150 ; TA Lux. du 29 mars 1994, n° 195/94 (VI) ; CA du 29 janvier 1974, *P.* , n° 22, p. 430, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – TA Diekirch du 19 juin 1990, n° 72/90, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – CA du 6 février 2002, *Papyrus S.A.* c/ *Papyrus Belgium Papier S.A.*, ID 10411.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

concurrence déloyale. Comme la loi du 30 juillet 2002 a un but de protection contre les pertes de clientèle par des actes de concurrence déloyale, il faut pour apprécier si la confusion est possible, tenir compte des aptitudes de la clientèle. […] Il ne peut être nié qu'il y a de frappantes similitudes sur le plan phonétique et conceptuel entre les deux dénominations.

La clientèle existante ou potentielle de la société Luxlift confrontée à la dénomination « Lift Luxembourg » avec le souvenir global fugitif qu'elle aura gardé de la dénomination « Luxlift » – souvenir qui ne sera pas à même de remarquer ce qui distingue les deux dénominations – aura, en raison des prédites frappantes similitudes, l'impression globale qu'il n'y a pas de réelles différences entre les deux dénominations »[(1)].

L'acte répréhensible au sens de l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 est « *[…] un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, qui enlève ou est de nature à enlever une partie de la clientèle aux concurrents et qui porte atteinte ou tente de porter atteinte à la capacité de concurrence* ». Selon la jurisprudence « *[…] Constitue un tel acte le fait pour une société commerciale de faire précéder sa dénomination sociale de la lettre initiale de la dénomination sociale d'une société concurrente dans le seul but de faire figurer ses propres coordonnées – dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique – sous les localités où est exercé le commerce de ses concurrents* »[(2)].

A encore été jugé un acte de concurrence déloyale le fait pour une entreprise d'obtenir d'un de ses salariés ayant auparavant travaillé chez un de ses concurrents des informations sur le fonctionnement interne de cette entreprise concurrente. « *Les informations difficilement accessibles à un tiers ayant trait à l'organisation commerciale d'une entreprise sont couvertes par le secret des affaires.*

Le personnel de l'entreprise, qu'il soit encore ou qu'il ne soit plus au service de celle-ci ne peut dès lors porter à la connaissance d'autrui les informations protégées par le secret des affaires recueillies pendant son temps de service »[(3)].

2) La situation actuelle depuis l'abrogation de la loi du 30 juillet 2002

Sous l'effet des critiques à l'égard des dispositions luxembourgeoises de la part des instances européennes, la loi du 30 juillet 2002 a été abolie par la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative (après que certaines de ces dispositions, dont l'article 14 ne faisait pas partie, ont été reprises par la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence). Par ailleurs, l'article 25 L.S.C. a également été aboli par la Loi de Modernisation ; cette dernière a toutefois repris l'article 25 dans l'article 100-5 L.S.C. et la Loi de 2002 comporte depuis 2009 des dispositions sur les dénominations, raisons et enseignes commerciales (art. 16 à 19). Si le caractère distinctif de la dénomination sociale reste donc toujours une exigence légale, il est vrai également que les commerçants ne disposent plus d'une disposition correspondant à l'ancien article 14 de la loi du 30 juillet 2002. Cet état des choses avait été critiqué lors de l'élaboration

1 – CA du 15 juillet 2008, n° 33.173, ID 15986.

2 – CA du 12 octobre 2005, ID 11954.

3 – CA du 15 octobre 2003, ID 11975.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de la loi du 23 décembre 2016, notamment par le Conseil d'État et la Chambre de commerce, qui avaient envisagé un élargissement de la loi du 23 octobre 2011 sur la concurrence. À ce jour, tel n'est pas encore le cas.

SECTION IV
LES CAS DE NULLITÉ DES SOCIÉTÉS

En droit commun, on entend par « *nullité la sanction de l'acte juridique qui ne respecte pas les conditions de formation prévues par la loi* »[1]. Le législateur s'est mis à la tâche afin de limiter les cas de nullité en matière de sociétés et ceci pour les raisons suivantes :

« *[…] la nullité qui est toujours une sanction grave, l'est plus que partout ailleurs en matière de sociétés, parce que celles-ci intéressent un plus grand nombre de personnes ; leur anéantissement jette le trouble dans les relations qui ont existé entre les associés et dans les rapports de la société avec les tiers, et amène une liquidation souvent très difficile* »[2].

Les nullités en cette matière ont souvent des **effets pervers** : « *Le législateur de 1807 établit la nullité en cas d'absence de publicité de l'acte de société ; mais frappé par les abus du droit antérieur qui, permettant aux associés d'invoquer la nullité contre les tiers, aboutissait à punir ces derniers pour la faute des premiers, il restreignit la nullité en statuant qu'elle ne pourrait être opposée à des tiers par les associés. Le progrès était incontestable, mais insuffisant En effet, le Code de 1808 donne l'action en nullité aux associés entre eux ; or, la nullité opposée par un associé à un autre associé et prononcée par les tribunaux n'en est pas moins une nullité en suite de laquelle la société disparaît et doit être liquidée. Il n'est pas difficile de concevoir bien des circonstances dans lesquelles les tiers auraient eu le plus grand intérêt à voir la société continuer ses opérations* »[3].

Ou encore : « *Il ne faut pas […] que lorsqu'une société a fonctionné publiquement pendant longtemps, on puisse la faire tomber en arguant d'un vice de forme qui toujours, quand il est tardivement invoqué, n'est qu'une arme à l'usage de la mauvaise foi* »[4]. Il fallait donc conserver aux sociétés leur existence malgré l'irrégularité de leur action lorsqu'elles ont eu pendant cinq ans une possession d'état publique[5].

« *Mieux vaut encore laisser éventuellement, dans des cas exceptionnels, la loi désarmée, que de lui faire frapper à la fois, au hasard des nullités, innocents et coupables* »[6].

On est amené à analyser cette question de la nullité des sociétés d'un double point de vue : celui du droit commun d'abord, et celui du droit de l'Union européenne ensuite, étant entendu que le champ d'application de ce droit européen est en fin de compte relativement limité.

1 – P. Guiho, *Dictionnaire juridique*, V° Nullité.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 41, ID 11305.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 48, ID 11305.

4 – E. Pirmez, *Commentaire législatif de la loi de 1886*, I, n° 5.

5 – E. Pirmez, *Commentaire législatif de la loi de 1886*, I, n° 34.

6 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 72, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – Les nullités en droit commun

La nullité relative peut être couverte par la partie que la règle en question entend protéger. Cette dernière peut renoncer à se prévaloir de cette nullité. Cette confirmation de l'acte nul peut être tacite.

Lorsque la nullité n'affecte qu'une seule clause d'une convention, la question se pose de savoir si cette nullité affecte uniquement ladite clause ou si elle a pour conséquence la nullité de la convention entière. La jurisprudence résout cette question en se référant à la notion « d'indivisibilité ». Il faut analyser dans quelle mesure la clause visée est dans l'**esprit des parties indivisible** de l'ensemble de la convention[1].

L'engagement d'un associé qui ne satisfait pas aux conditions requises pour la validité de tout acte ou encore aux conditions exigées pour le contrat de société est nul[2].

Ceci vise d'abord les vices du consentement de droit commun.

A – Les vices du consentement classiques

Il y a vice du consentement en cas d'erreur, de dol, de violence notamment. Le lecteur est prié de se reporter à la p. 204.

« *On ne pourrait trouver le dol dans tout fait d'un vendeur qui exalte sciemment la valeur de sa chose au-delà de la vérité, mais il y a dol lorsque les affirmations mensongères du vendeur sont assez précises pour qu'on puisse y voir un engagement, qu'elles concernent des éléments essentiels du contrat et qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté* »[3].

En revanche, « *la réticence qui consiste à garder volontairement le silence sur un fait que le cocontractant aurait intérêt à connaître peut constituer un dol* » (à l'occasion de la vente d'un terrain à bâtir sans révéler que, d'après un plan de lotissement de la commune, le terrain ne peut être morcelé)[4].

B – Les causes de nullité spécifiques aux sociétés

Il y a lieu de distinguer selon le caractère bipartite ou multipartite du contrat de société.

1) Les causes affectant tous les associés

Les violations des règles de droit commun ou spécifiques au contrat de société qui affectent tous les associés telles que l'erreur commune à tous les associés, l'absence d'apports, l'illicéité de l'objet ou de la cause du contrat entraînent la nullité

1 – P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations », *R.C.J.B.*, 1988, p. 35.

2 – Th. TILQUIN et V. SIMONART, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 50.

3 – CA com. du 17 octobre 1919, *P.*, n° 11, p. 190, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA du 24 juin 1954, *P.*, n° 17, p. 495, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de la société elle-même[1]. Dans les sociétés dites **bipartites** ayant au moins deux associés, la nullité de l'engagement d'un des associés comporte nécessairement celle de la société elle-même[3].

2) Les causes n'affectant qu'une partie des associés

Même dans les **sociétés pluripartites** (autres que les sociétés par actions), il est en général reconnu que la nullité des engagements d'un des associés entraîne la nullité de la société entière, et ceci, en application du caractère *intuitu personae* de la société. Mais il est possible d'éviter cette conséquence, le caractère *intuitu personae* n'étant pas d'ordre public[2]. Il est par conséquent possible que le contrat de société prévoie que la nullité de l'engagement d'un associé n'entraîne pas la nullité de la société. « *Même en l'absence d'une telle clause, la clause suivant laquelle le décès ou l'interdiction d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société, par dérogation à l'article 1865 du Code civil, constitue un indice de la divisibilité du contrat de société, de sorte que la nullité de l'engagement d'un associé ne provoque pas nécessairement celle de la société* »[3]. De même, il est possible de prévoir que si, par application de l'article 1869 C.c., la dissolution de la société peut être demandée, cette demande ne comporte pas la dissolution de la société, mais seulement le retrait de cet associé et la continuation de la société avec les autres associés[3].

Lorsque le contrat de société comporte une clause illicite, cette clause entraîne la nullité de celle-ci lorsqu'elle a été déterminante pour le consentement des parties. Tel est en général le cas de la clause léonine[4].

■ § 2 – Les nullités de droit européen

Les différentes directives européennes en matière d'harmonisation du droit des sociétés, avec leur préoccupation dominante, celle donc d'assurer la **sécurité juridique** des transactions auxquelles les sociétés sont parties, ont conduit non seulement à strictement limiter les cas de nullité des sociétés, mais encore à en limiter les effets.

A – Les nullités selon la directive

Les cas de nullité sont énumérés limitativement par la directive pour être repris tels quels par l'article 100-18 [anc. art. 12*ter*] L.S.C. La loi luxembourgeoise, conforme à la directive, énumère les cas suivants :

1) l'acte constitutif n'est **pas** établi dans la **forme notariée** ; il faut un acte notarié : un acte authentique ne suffit pas (contrairement à la loi belge). Il est à noter que, selon la loi du 26 décembre 1976 sur le notariat, un acte notarié

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 51.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 51. H. De Page, *Traité élémentaire de droit civil belge*, T. 2, n° 460*bis* et L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. 4, n° 195.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, T. 2, p. 236.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 52.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

peut être nul, et cette nullité rétroagit. Par exception, la nullité de la société n'a pas d'effet rétroactif[1] ;

2) l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit ;
3) l'**objet** social est **illicite** ou contraire à l'ordre public[2] ;
4) la société ne comprend **pas** au moins **un fondateur** valablement engagé.

La jurisprudence et la doctrine françaises semblent procéder à une extension des dispositions européennes allant dans le sens de l'inclusion de la cause illicite au motif que l'ordonnance française ayant rendu la directive applicable en France n'aurait pas exclu les causes de nullité de droit commun[3]. En tout était de cause, la version française de la directive ne comporte pas la moindre ambiguïté à cet égard en ne visant que l'objet social illicite.

Ces cas de nullité sont repris de l'article 11 de la Première directive. Il reste pourtant à ajouter que la directive prévoit de son côté deux cas de nullité qui n'ont pas en tant que tels été repris par la loi nationale.

5) l'inobservation des dispositions de la législation nationale relative à la libération minimale du capital social ;
6) l'incapacité de tous les associés fondateurs.

L'impact de cette reprise seulement partielle des dispositions de la directive paraît en fait fort limité.

La nullité (qui doit être prononcée par décision de justice) acquiert son autorité de la chose jugée *erga omnes*. Elle ne peut donc plus être invoquée par simple voie d'exception[4].

B – La société léonine

L'expression de clause léonine vient de la **fable d'Ésope** dans laquelle un lion part en chasse avec un renard et un âne et s'approprie tout le butin de la chasse[5].

1) Définition de la société léonine

La clause léonine est interdite par l'article 1855 alinéas 1 et 2 C.c. « *La convention qui donnerait à un des associés la totalité des bénéfices est nulle.*

1 – J. Delvaux, *La société anonyme*, p. 133.

2 – Est uniquement visé à cet endroit l'objet illicite qu'il convient de distinguer de la cause illicite. Une partie de la jurisprudence belge semble procéder à une extension de la nullité vers la cause illicite, ce qui serait apparemment facilité par une ambiguïté de la version néerlandaise de la directive qui parle de « *werkelijk doel* » de la société, terme qui serait susceptible de comprendre non seulement l'objet social de la société, mais encore le but poursuivi par les fondateurs, voir J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 240.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 240.

4 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 294.

5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 421.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il en est de même de la convention qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs associés ». On voit que cette disposition ne vise que les cas tout à fait extrêmes : si la clause visée interdit les **cas d'exclusion totale**, elle n'empêche pas des **participations disproportionnées** aux bénéfices (ou aux pertes).

Il convient de noter que la clause léonine en principe ne rend pas nul l'acte de société dans sa globalité, mais que normalement cette clause est simplement considérée non écrite (voir art. 100-18 L.S.C.).

Une autre lacune de cette disposition est qu'elle ne sanctionne que les **vocations exclusives** aux bénéfices et les **affranchissements complets** des pertes. Or elle ne sanctionne pas deux autres cas de figure qui sont tout aussi critiquables au regard de l'égalité existant entre associés, à savoir le cas de l'exclusion complète des bénéfices tout comme le cas de l'attribution totale des pertes à un ou plusieurs associés. Le législateur français a bien remédié à cette insuffisance en adoptant l'article 1844-1 C.c. : « *[…] la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes, sont réputées non écrites* ». (Sur le dernier point, on peut se demander si le changement était absolument nécessaire. En effet, en attribuant à un ou plusieurs associés la totalité des pertes, d'autres associés sont nécessairement exclus de la moindre participation aux pertes : par conséquent, ce cas était déjà couvert par la version antérieure de l'article 1855 C.c).

La question posée est de savoir si, dans notre droit, les situations suivantes sont couvertes. Sans donner tout le bénéfice à un associé, les statuts privent un associé de toute participation aux bénéfices. Une telle situation ne pourrait se produire dans une société à deux associés, mais peut survenir dans une société à plusieurs associés (dans une société multipartite).

En doctrine, il a été souligné que : « *interprétée à la lumière de sa* ratio legis *fondée sur l'intérêt commun, une telle clause paraît également léonine, bien qu'elle ne soit pas explicitement visée par l'article 1855 : l'associé privé de tout bénéfice ne partage pas d'intérêt commun avec les autres, hypothèse que le législateur a entendu interdire dans le contrat de société* »[1].

Une autre particularité de ces sociétés multipartites est la suivante : dans les sociétés comptant deux associés, la clause léonine affecte tous les associés. Il n'en va pas nécessairement de même dans les sociétés à plusieurs associés : si l'un des associés garantit à l'autre qu'il ne doit pas participer aux pertes, leur convention n'intéresse pas nécessairement les autres associés[1].

Il est encore vrai que l'article 1855, alinéa 2, C.c. ajoute en fait à l'article 1832 C.c. dans la mesure où cet article ne prévoit pas que la participation aux pertes serait un élément essentiel du contrat de société[2] : le Code civil ne parle pas de la participation aux pertes. Le Code civil a repris la définition de Pothier. Il semble que les auteurs de cette disposition n'aient pas entendu exclure la participation aux pertes. Les parties ont simplement en vue non pas le partage de pertes, mais celui des bénéfices ; pour cette raison, la définition du Code, qui se fonde sur les intentions

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 432.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 436.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

des associés, ne mentionne pas la participation aux pertes comme élément caractéristique du contrat de société[1]. Il est certain que la participation aux pertes est de l'essence du contrat de société, dans la mesure où l'article 1855 C.c. annule la société qui exclurait un associé de la participation aux pertes.

Selon la jurisprudence, l'article 1855 C.c. n'est pas applicable aux accords relatifs aux bénéfices conclus après la naissance du droit aux bénéfices ou après la dissolution[2].

En pratique, on ne voit guère de clauses qui soit attribueraient tout le résultat à un associé, soit l'excluraient entièrement des pertes. Néanmoins, il peut y avoir des clauses qui ont le même effet, du moins dans un certain environnement. Il peut en être ainsi, notamment, dans le cas d'une clause qui rémunère un associé en fonction du chiffre d'affaires (p. ex., un associé reçoit 5 % du chiffre d'affaires). Il se peut que cet associé, en fait, récupère la totalité du bénéfice.

Il se pose alors la question de savoir si cette clause est léonine. Selon la jurisprudence belge[3], n'est pas léonine la société (une S.p.r.l. conclue entre deux associés à parts égales) constituée en vue de la réalisation de lotissements dans le cadre de laquelle un des associés se voyait attribuer une participation prioritaire égale à 12 % du capital investi. Le tribunal retenait que, dans la mesure où le bénéfice excédait ce taux, l'associé gardait sa vocation au partage des bénéfices ; en outre, l'associé demeurait exposé aux pertes dans la mesure où les statuts ne lui assuraient pas le remboursement de son apport, quels que fussent les résultats de la société[4].

2) Validité des opérations de portage ?

Il y a lieu de distinguer deux périodes, à savoir avant l'entrée en vigueur de la Loi de Modernisation et depuis la Loi de Modernisation.

a) Avant la Loi de Modernisation

La doctrine et la jurisprudence classiques sont unanimes à considérer que l'article 1855 C.c. interdit non seulement les clauses léonines prévues par les statuts, mais également toutes les conventions, fussent-elles extrinsèques aux statuts, antérieures ou postérieures à ceux-ci, par lesquelles un associé affranchit un autre de toute participation aux pertes sociales[5]. Cette position conduit à la question de la validité des opérations de portage.

Par ce terme on entend les « *opérations aux termes desquelles une personne accepte moyennant rémunération, de détenir temporairement la propriété d'actions, soit à l'occasion de la fondation de la société, soit à l'occasion d'une augmentation de*

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 155.

2 – Cass. fr. du 23 mai 1900, *D.*, 1901, 1, p. 101. Cass. fr. (com.) du 12 novembre 1962, *Bull. civ.*, III, p. 365.

3 – Trib. com. Verviers du 22 octobre 1984, *R.P.S.*, 1985, p. 76.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 606.

5 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 607.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

capital, soit à la faveur d'une vente, en s'assurant, aux termes de dispositions contractuelles qui s'analysent le plus souvent en une option de vente ('put'), qu'elle pourra à l'échéance convenue, rétrocéder les titres et en récupérer le prix d'acquisition ou de souscription, éventuellement augmenté d'un intérêt »[1].

Le résultat de cette convention est que le porteur, après l'opération de rachat, n'est pas affecté par la perte éventuellement subie sur les titres qui font l'objet de l'opération, ce qui donne lieu à la question de savoir si ces opérations ne sont pas prohibées par l'article 1855 C.c.

Dans une affaire tranchée par la Cour d'appel de Bruxelles[2], il s'agissait d'une importante opération d'augmentation de capital prévue par une société industrielle, alors qu'un des souscripteurs ne disposait pas des liquidités nécessaires pour couvrir l'intégralité de sa part. La Société Nationale d'Investissement (S.N.I.) avait accepté de prendre une participation à concurrence du montant pour lequel ce souscripteur était défaillant. Quelques jours avant l'assemblée générale, la S.N.I. avait obtenu d'une société de portefeuille un engagement d'acheter à terme toutes les actions qu'elle allait souscrire pour un prix fixé à la valeur de souscription augmenté d'un intérêt. Cette société avait encore accordé au souscripteur défaillant une option d'achat sur ces mêmes titres à l'exercice de laquelle ce dernier s'était engagé aux mêmes conditions de prix. L'autre actionnaire garantissait l'exécution de cet engagement. La cour d'appel, confirmant les juges de première instance, considéra ces différentes conventions, conclues entre personnes différentes, comme une convention unique ayant simplement pour résultat d'affranchir la S.N.I. de toute contribution aux pertes sociales[3].

D'aucuns concluent de cette jurisprudence à une condamnation générale des opérations de portage.

Une partie de la doctrine considère que l'arrêt cité de la Cour de Bruxelles doit recevoir une interprétation limitée aux opérations conclues entre souscripteurs à l'occasion soit de la constitution, soit de l'augmentation de capital de la société. Dans la mesure où les conventions ont pour objet de garantir à l'un d'entre eux qu'il récupère sa mise quels que soient les résultats des activités sociales, elles sont incompatibles avec le contrat de société. En revanche, ces règles ne devraient pas s'appliquer aux transactions portant sur des actions déjà émises par des sociétés anonymes, et ceci, qu'elles soient conclues entre actionnaires ou avec des tiers[4].

b) Depuis la Loi de Modernisation

En 2016, l'article 1855 a été complété par l'alinéa 3 suivant : « *Ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs, organisent la cession ou l'acquisition de droits sociaux, qui n'ont pas pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux* ».

1 – D. Schmidt, « Les opérations de portage de titres de sociétés », *Les opérations fiduciaires*, 1985, p. 29.

2 – CA Bruxelles du 3 décembre 1986, *R.P.S.*, 1987, p. 45.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 608.

4 – En ce sens, P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », R.C.J.B., 1992, p. 609.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« *La matière des clauses léonines a fait l'objet, tant en Belgique qu'en France, de vastes débats doctrinaux. Toutefois les jurisprudences ont, dans ces deux pays, récemment évolué dans le même sens, ce qui a permis de « sauver » un certain nombre de montages mis au point en vue d'assurer le financement de la cession de droits sociaux dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise sociétaire. Les montages les plus fréquemment rencontrés sont les conventions de portage par lesquelles des organismes financiers (banques ou, plus souvent, filiales spécialisées) « souscrivent ou achètent les titres d'une société dont une personne physique ou morale souhaite prendre le contrôle, tout en se faisant promettre par cette dernière (généralement, par le biais d'une promesse unilatérale d'achat) que ces titres leur seront rachetés au terme d'une période déterminée. En contrepartie de cette intervention […] les organismes financiers perçoivent généralement une rémunération fixe, calculée en fonction du taux du marché financier. Le prix de rachat des titres, convenu à l'avance, est ainsi lui-même calculé sur la base du prix d'achat par le porteur, majoré d'un intérêt* prorata temporis*, et éventuellement diminué des dividendes perçus par le porteur ou encore du prix de la cession, en cours de portage, du droit préférentiel de souscription ». Les conventions de portage posent a priori problème au regard de l'article 1855 du Code civil en ce que l'organisme financier bien qu'associé se trouve dispensé de la contribution aux pertes entre son acquisition des titres et leur rétrocession à l'acquéreur ultime ce ces titres* »[1].

Le point décisif tant des jurisprudences française que belge (qui ne sont pas analysées en détail à cet endroit) est que l'interdiction de la clause léonine par le Code civil est limitée au seul cas où la clause porte atteinte à la répartition des résultats telle que prévue par le pacte social. Ainsi donc, une convention entre associés par laquelle un des associés s'engage à racheter à un prix correspondant au prix nominal de ces actions (en garantissant donc au bénéficiaire de cet engagement que ce dernier ne peut subir de perte sur son investissement) ne constitue pas une clause léonine interdite par le Code civil (car elle n'impacte pas la répartition des résultats prévue par le contrat de société). En revanche, si la société s'engageait à racheter à l'un ou l'autre des associés leurs actions à la valeur nominale, alors il y aurait potentiellement clause léonine dans la mesure où certains associés seraient ainsi déchargés de la participation aux pertes, faveur qui serait ainsi financée par les autres associés.

« *L'alinéa 3 proposé pour l'article 1855 du Code civil luxembourgeois codifie les enseignements issus des jurisprudences française et belge précitées et permettra donc que l'élaboration des montages destinés à assurer la cession de droits sociaux puisse se faire dans la sécurité juridique. Il est acquis que l'actuel article 1855 du Code civil est susceptible de poser problème eu égard à la fréquence des conventions de portage au Luxembourg. Il n'est pas question de supprimer cette réglementation, intrinsèquement liée à la définition même du contrat de société (la vocation aux bénéfices et aux pertes) constituant une importante application du principe du traitement égal des associés, mais de fournir au juge un outil lui permettant d'opérer le partage entre les conventions et actes unilatéraux devant demeurer prohibés au regard de l'article 1855 et les dispositions qui échappent à cette interdiction. Dans l'alinéa proposé, le terme "stipulations" vise aussi bien les actes unilatéraux que les conventions, les pactes extrastatutaires que les clauses*

1 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 47, ID 10800.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

statutaires, et l'expression "associés actuels ou futurs" est formulée de manière à viser l'hypothèse des promesses unilatérales de vente ou d'achat. Par ailleurs, le critère validant, à savoir que les stipulations visées n'aient pas pour objet, à distinguer du simple effet incident de la stipulation, de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux est quant à lui directement emprunté aux jurisprudences récentes des Cours de cassation française (chambre commerciale) et belge »[1].

3) Effets de la clause léonine

Sous l'influence du droit européen, les effets de la clause léonine ont été sérieusement limités par l'article 100-17 [anc. art. 12*bis*] L.S.C., qui reprend les dispositions de l'article 11 de la Première directive qui dispose qu'une telle disposition, loin de conduire à la nullité du contrat de société[2], est simplement **réputée non écrite**. Ledit article 11 de la Première directive énumère de façon limitative les six cas qui peuvent donner lieu à la nullité de la société. Parmi ces cas ne figure pas celui de la société léonine.

La sanction de la nullité ne peut donc pas s'appliquer dans ce cas, et ceci, d'autant plus que l'article en question précise encore que, « *en dehors de ces cas de nullité, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d'inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d'annulabilité* ».

Cette disposition a été méconnue par un arrêt belge[3] qui déclarait irrecevable une action en revendication d'objets saisis introduite par une société anonyme considérée comme fictive. De ce fait, la cour en a déduit que la **société** serait **inexistante** et toute action en justice serait partant irrecevable. L'article 11 de la directive a pourtant expressément éliminé du droit des sociétés des États concernés le concept de la société inexistante[4].

■ § 3 – La procédure en annulation

Le champ d'application de cet article 100-18 (anc. art. 12*ter*) est toutefois limité. Il ne concerne que les sociétés visées par la Première directive CEE, donc les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions ainsi que les sociétés à responsabilité limitée. Les autres sociétés sont sujettes à des causes d'annulation plus nombreuses. Ainsi, une société coopérative qui comporterait des parts cessibles à des tiers, et ceci, en violation des dispositions de l'article 811-1 (anc. art. 113) L.S.C. serait, de l'avis de la majorité de la doctrine, nulle en tant que société coopérative[5]. Étant donné qu'une société subsiste néanmoins, celle-ci aura la forme d'une société en nom collectif.

La nullité doit être prononcée par décision judiciaire.

---

1 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 48, ID 10080.

2 – À cet endroit il suffit de se référer au seul contrat de société : un acte d'une société unipersonnelle ne peut jamais être vicié pour cause de son caractère léonin.

3 – CA Anvers du 3 novembre 1975, *R.P.S.*, 1976, p. 74, note Coppens.

4 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 233.

5 – P. Van Ommeslaghe, « Les sociétés de fait », *J.T.*, 1957, p. 713.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

A – Décision judiciaire obligatoire

Cette exigence existe à l'égard de toutes les sociétés dotées de la **personnalité morale** (art. 100-19 [anc. art. 12*quater*] L.S.C.). Ce point est tout à fait remarquable : si le *numerus clausus* des causes de nullité de l'article 100-18 L.S.C. s'applique aux seules sociétés prévues par la directive, les effets des nullités de l'article 100-19 L.S.C. s'appliquent « *à* toutes *les sociétés dotées de la personnalité morale* ». Par conséquent, pour les sociétés autres que les sociétés de capitaux, les causes de nullité ne se limitent pas à celles de l'article 100-18 L.S.C. Une S.e.n.c. peut ainsi être affectée de nullité pour la raison que les statuts prévoient une clause léonine. S'il y a donc deux régimes différents pour les causes de nullité (selon que les sociétés concernées sont ou ne sont pas couvertes par la Première directive), il n'y a qu'un seul régime des nullités applicable à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, à savoir celui de l'article 100-18 L.S.C.

En ce qui concerne les autres formes de sociétés, le champ d'application des nullités est plus large : constitue notamment un cas de nullité, celui de la société léonine. Si, en dehors de ces cas, la nullité de ces sociétés ne pourra être prononcée, cette disposition n'empêche pas que la société puisse être déclarée comme fictive avec la conséquence qu'elle n'est pas opposable à celui qui invoque avec succès ce caractère fictif de la société[1] ; la société reste par ailleurs valablement en existence. La théorie de la société inexistante n'est pour sa part pas exclue non plus à l'égard des sociétés autres que celles visées par la Première directive.

Quant aux sociétés coopératives traditionnelles, l'article 811-3 (anc. art. 115) L.S.C. prévoit que l'acte constitutif doit déterminer, à peine de nullité, les points suivants :

« *1°) la dénomination de la société, son siège ;*

2°) l'objet de la société ;

3°) la désignation précise des associés ;

4°) la manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate.

Toutefois, ces nullités ne peuvent être opposées aux tiers par les associés ; entre les associés, elles n'opèrent qu'à dater de la demande tendant à les faire prononcer ».

Pour les sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, l'article 100-18 (anc. art. 12*ter*) doit donc pouvoir s'appliquer[2].

Aux termes de l'article 12, paragraphe 2, de la Première directive, « *[L]a nullité entraîne la liquidation de la société, comme peut l'opérer la dissolution* ». La société dont la nullité est déclarée par décision de justice se trouve donc exactement dans la même situation que la société dissoute par décision des associés ou encore par l'arrivée du terme. Tel est d'ailleurs le seul effet de cette nullité. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou

1 – Apparemment d'avis contraire, Th. Afschrift, « Simulation et réalité juridique à propos des sociétés étrangères constituées dans le but d'éviter l'impôt belge », p. 12, dans le sens que le caractère fictif de ces sociétés ne pourrait être invoqué à l'égard de sociétés étrangères du moment que ces sociétés existent réellement en application de leur droit national. Cet auteur qualifie d'ailleurs de manifestement erroné, l'arrêt de la CA de Bruxelles du 9 juin 1992 qui avait qualifié de « *simulée […] et donc pas opposable au fisc belge* » une société anglaise au motif qu'elle n'aurait pas d'activités propres, distinctes de celles de sa société mère panaméenne (Afschrift, *op. cit*., p. 11).

2 – J. Delvaux, *La société anonnyme*, p. 135.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de ceux pris envers elle. Cette disposition est prise moins dans un souci de cohérence juridique que dans celui de la protection des tiers et de la sécurité juridique. La remise en cause systématique de toutes les opérations conclues par la société (même si elle ne pourrait en principe être invoquée que par les tiers, et non par la société elle-même) serait une conséquence catastrophique avec des effets désastreux pour la sécurité du commerce. Pour cette raison, la directive a coupé court à toutes hésitations en disposant en somme que les effets de la nullité sont réservés à l'avenir.

L'absence d'effet rétroactif de la nullité de la société a pour conséquence qu'une régularisation de la société annulable peut toujours intervenir valablement même après l'introduction de la demande en annulation, et cette action devient ainsi sans objet[1].

Une fois prononcée, la nullité de la société est opposable aux tiers de la même façon que la liquidation[2].

La directive réglemente également les effets de la décision judiciaire : l'opposabilité de celle-ci à des tiers est subordonnée à la publication prévue à l'article 2 de la même directive (dans le cas du Luxembourg, cette publicité doit être faite au R.C.S. et au RESA).

La **tierce opposition**, si elle est permise par le droit national (ce qui est autorisé par la directive), ne peut être admise que dans un délai de six mois à compter de la date de publication. La tierce opposition, dans la mesure où elle n'est du tout acceptable, est une voie de recours extraordinaire qui permet à une personne qui n'est ni partie ni représentée dans une instance d'attaquer une décision qui lui fait grief et de faire déclarer que celle-ci lui est inopposable. Le court délai qui est ouvert ainsi s'explique bien entendu encore par le désir d'assurer la sécurité juridique. Le délai de la tierce opposition, qui normalement en droit luxembourgeois serait de trente ans à partir de la publication de la décision judiciaire, est ainsi très fortement limité, et ceci, dans le souci de limiter l'insécurité juridique[3].

La Première directive (art. 12, 4) permet encore à chaque État membre de prendre les mesures pour régler les effets de la nullité entre États membres. En outre et nonobstant la prononciation de la nullité, les porteurs de parts ou d'actions restent tenus du versement du capital souscrit et non libéré dans la mesure où les engagements envers les créanciers l'exigent.

« *On assiste parallèlement à un glissement des actions en nullité vers les actions en responsabilité, en raison de la limitation des cas de nullité en matière de sociétés et la responsabilité accrue de régulariser les actes nuls* »[4].

Les conséquences des nullités sont en pratique limitées en vertu de la théorie de la conversion judiciaire en application de laquelle « *le juge peut convertir un acte qui est entaché de vices devant en principe entraîner sa nullité mais qui répond aux conditions de validité d'un autre acte, parfaitement licite, non exclu par les parties et susceptible de répondre aux objectifs qu'elles se sont fixés, en l'acte que les parties auraient vraisemblablement choisi si elles avaient eu connaissance de la nullité de*

1 – J. Delvaux, La société anonyme, p. 130.

2 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 40.

3 – J. Delvaux, *La société anonyme*, p. 131.

4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 139.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

l'acte conclu par elles »[1]. En réalité, le juge va au-delà de la volonté des parties pour donner effet à un acte sur base du principe de bonne foi[2].

Les délais de prescription sont prévus par l'article 1400-6 L.S.C.

Les **actions en nullité** d'une société de capitaux sont **prescrites** si le contrat de société a reçu son exécution pendant cinq années au moins. La même disposition s'applique en substance aux sociétés coopératives avec la précision supplémentaire que ces sociétés coopératives peuvent être déclarées nulles au-delà de ce délai de cinq ans, à condition que leur existence soit contraire à la loi. Mais cette disposition ne concerne que les nullités relatives concernant les deux premiers alinéas de l'article 100-18 (anc. art. 12*ter*) L.S.C., à savoir donc que la société n'est pas établie par acte notarié ou encore que cet acte notarié ne comporte aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit.

Si l'action en nullité est fondée sur les autres causes de nullité, que l'on peut considérer comme **nullité de fond** (à savoir l'objet social illicite ou encore que la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé), alors on revient aux délais de prescription de droit commun, soit donc de dix ans ou de trente ans, délais de prescription dans une association en participation[2].

B – Non-rétroactivité de l'annulation

La décision d'annulation produit ses **effets** à partir de la date de son prononcé. Les engagements pris par la société ou encore ceux pris envers elles restent valables. Cette disposition est une entorse importante au régime traditionnel de la nullité et enlève en fait tout caractère dangereux à la nullité. La sécurité des transactions n'est en rien mise en cause si une société est mise en liquidation avec effets pour le futur par une décision de justice. La situation ressemble à celle des mises en liquidation selon l'article 1200-1 L.S.C.

À l'égard des associés, la nullité aura pour effet qu'ils peuvent reprendre leurs apports exactement comme s'il n'y avait jamais eu de société. Il faudrait donc remettre aux associés leurs apports sans contribution aux pertes ni participation aux bénéfices. Telle est pourtant l'exception : en effet, cette solution ne peut s'appliquer qu'à l'égard des associés incapables. Pour tous les autres, on ne peut faire complètement abstraction du fait que la société a existé pendant des années (en général) et qu'elle a généré des bénéfices ou des pertes. Il faudra tenir compte de ceux-ci dans le remboursement des apports aux associés.

C – Responsabilité en cas d'annulation de la société

L'article 420-19 (1) (anc. art. 31(1)) L.S.C. prévoit une responsabilité spéciale à l'égard des fondateurs d'une société (anonyme)[3] pour le préjudice causé par la

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 336.

2 – Cour 25 mars 1940, *P.*, n° 12, p. 60, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Les articles 600-2 (anc. art. 103) et 710-7 (3), n° 3 (anc. art. 184 (3), n° 3) prévoient des dispositions correspondantes pour les S.C.A. et les S.à r.l., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

nullité de la société ou encore pour la fausseté des indications figurant dans l'acte selon les articles 420-15 (anc. art. 27) et 420-17 (anc. art. 29) L.S.C.

§ 4 – Simulation et droit des sociétés

S'il y a un domaine où la simulation était traditionnellement plus importante que le nombre des décisions de justice ne le laisse supposer, il s'agit de celui des sociétés fictives. En effet, très souvent, les petites entreprises sont dominées par une personne physique qui gère l'entreprise en maître absolu, à quoi il n'y a rien à objecter.

A – Notion de simulation en droit des sociétés

Seulement, pour un certain nombre de raisons, dont la principale est sans doute la limitation de responsabilité, un mouvement considérable s'est fait vers les sociétés et, en particulier, vers les sociétés de capitaux soit donc les sociétés anonymes[1] soit, plus fréquemment encore (et en tous cas pour les sociétés de moindre importance), les sociétés à responsabilité limitée. Malgré ce changement fondamental du cadre juridique, l'ancien exploitant individuel devenu associé et gérant d'une société de capitaux a tendance à continuer comme par le passé à se comporter en **maître absolu** de l'entreprise. En général, l'autre associé (ou les autres associés) n'a qu'un rôle très effacé pour ne pas dire inexistant. Souvent, il n'a même pas payé la somme correspondant à sa minuscule participation au capital et n'a donc pas la prétention de faire valoir des droits dans la société. En d'autres termes, ces sociétés sont souvent des sociétés simulées. « *Ainsi l'hypothèse la plus simple et la plus fréquente est celle d'une société qui ne comporte, à côté du maître de l'affaire, que des prête-noms de celui-ci. Ces derniers, comme l'expression elle-même l'indique, se contentent le plus souvent de prêter leur nom, ils ne font aucun apport et ne libèrent pas eux-mêmes les titres souscrits. C'est le maître de l'affaire qui fournit les fonds* »[2]. Très souvent, les prête-noms signent des cessions de titres en blanc remises au maître de l'affaire et en vertu desquelles celui-ci peut, en cas de mésentente avec les prête-noms, les faire remplacer par quelqu'un d'autre.

Dans le cas extrême, la situation se présente donc de la façon suivante : un associé dominant est le gérant de l'affaire alors que les autres associés n'ont pas libéré leurs apports, se désintéressent totalement de la gestion et ne participent pas à la répartition des résultats[3]. Dans de telles hypothèses, les associés du maître de l'affaire ne sont considérés que comme des prête-noms et la fictivité de la société sera retenue[4].

Certains indices conduiront le juge à conclure à l'absence d'*affectio societatis*. Par cette notion, on entend l'élément intentionnel du contrat de société[5]. Il en est

1 – Ou encore la société en commandite par actions, qui est également une société par actions.

2 – M. Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 67.

3 – Si une telle répartition a lieu elle est à son tour fictive.

4 – Fl. Deboissy, *La simulation en droit fiscal*, p. 93.

5 – P. Soumrami, *Le portage d'actions*, p. 407. Cet auteur souligne le caractère hétéroclite et le déclin de cette notion du fait de la pratique des affaires (notamment pour les sociétés cotées où les actionnaires sont des bailleurs de fonds) et des modifications législatives (en particulier les actions sans droit de vote). Conformément aux thèses développées par M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 71, la notion d'*affectio societatis* se réduirait à un apport ainsi qu'au droit d'intervenir dans les affaires sociales, pour conclure que le porteur des actions serait doté de tous les attributs de l'associé.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ainsi notamment en cas de disproportion des apports[1], de lien de parenté de l'associé dominant avec les associés fortement minoritaires[5], de défaut d'activité de la société[2]. Ce dernier critère est à prendre avec beaucoup de précaution pour la raison que les sociétés de gestion de patrimoine (dont l'objet est, par exemple, la détention d'un portefeuille titres en vue de la succession) qui se sont très développées au cours des dernières années[3], tout en n'étant pas sans activité n'ont qu'une activité très réduite. Dans de tels cas, force est de constater que l'on est assez loin des hypothèses qu'avaient en vue les rédacteurs du Code civil. Il a été souligné, à juste titre, que, dans l'appréciation du caractère fictif d'une société, il faut tenir compte de l'évolution de la société en général[4] : « *La perception de la fictivité est largement contingente : elle est dépendante d'un contexte, d'une époque et d'un état d'esprit : ce qui aurait été jugé fictif hier ne l'est plus forcément aujourd'hui* »[5]. Même si l'activité d'une société est donc des plus réduites, ceci ne suffit pas pour la déclarer fictive. Toutefois, l'absence d'activité sera certainement considérée comme indice de fictivité.

La notion de simulation est étrangère au domaine des **sociétés en participation** : nonobstant le caractère occulte de la participation détenue par l'associé en participation, il n'y a pas le moindre élément de simulation[6], et ceci, pour la raison que les parties ne font pas convaincre les tiers d'autre chose que leurs conventions véritables.

La Cour de cassation belge, qui adopte parfois des conceptions assez extensives de la notion de simulation, considère qu'un juge peut considérer qu'une « *réduction de capital opérée par l'assemblée générale est simulée, lorsqu'il constate que cette même assemblée générale a, par une résolution concomitante, décidé de reconstituer son capital initial en y incorporant des réserves déjà taxées à concurrence d'un montant au moins égal à celui de la réduction de capital* »[7]. La doctrine critique à juste titre cette décision en considérant que, dès lors que les parties ont accepté toutes les conséquences des décisions prises par l'assemblée générale, il ne peut y avoir de simulation, même pas au regard de la loi fiscale[8].

Le champ d'application de la notion de **société fictive** a été considérablement réduit sur la base de l'article 1 de la Première directive CEE. La disposition en question n'admet pas que, sous quelque dénomination que ce soit, ou par quelque technique que ce soit, la personnalité morale distincte d'une société anonyme et son

1 – M. Dagot, *La simulation en droit privé*, p. 68 ; C. Cutajar-Rivière, *La société écran*, p. 310.

2 – C. Cutajar-Rivière, La société écran, p. 311.

3 – Le critère de l'activité est important dans le sens que la poursuite d'une activité régulière et effective est de nature à protéger la société contre les reproches de fictivité ; CA Bordeaux du 20 novembre 1978, *J.C.P.,* 1980, II, 19.381, observ. Prévault.

4 – Cette nécessité de l'évolution du droit est, nous semble-t-il, insuffisamment reconnue par un auteur français : « *Présenter l'EURL comme moyen de diminuer le nombre des sociétés fictives relève d'une dialectique alarmante. Accorder le droit au fait, telle est la nouvelle philosophie législative. Rien de plus simple, pour supprimer la déviance au regard d'une norme en vigueur, il suffit d'ériger la déviance en nouvelle règle de droit. L'EURL ne supprime pas les sociétés fictives, elle les consacre* », P. Diener, « Les sociétés en nom collectif dont tous les associés sont des EURL », *J.C.P.* E, 1992, I, 153.

5 – Fl. Deboissy, *La simulation en droit fiscal*, p. 88.

6 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 41.

7 – Cass. du 20 février 1986, *Pas.*, 1986, I, p. 793.

8 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 683. – V. encore note D. Garabédian sous arrêt cassation du 20 février 1986.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

patrimoine autonome puissent être écartés, et ce, pour éviter l'insécurité juridique que les auteurs de la directive ont voulu supprimer en consacrant la théorie restrictive des causes de nullité et en organisant spécialement les effets de celles-ci[1]. La situation reste évidemment un peu différente pour les sociétés autres que celles dénommées ici sociétés de capitaux, pour la raison que la Première directive ne leur est pas applicable.

B – Les sociétés fictives

Il s'agit en quelque sorte de l'inverse de la société en participation : si cette forme de société existe, mais n'est pas révélée aux tiers[2], la société fictive est révélée aux tiers sans réellement exister. Les sociétés fictives sont à distinguer des sociétés nulles. Sous l'influence notamment du droit européen, les nullités des sociétés ont été sévèrement limitées en droit des sociétés luxembourgeois. En application de l'article 100-18 (anc. art. 12*ter*) L.S.C., la nullité d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans quatre cas limitativement mentionnés (et mentionnés ci-dessus).

En ce qui concerne les autres formes de sociétés, le champ d'application des nullités est plus large. Si, en dehors de ces cas, la nullité de ces sociétés ne pourra être prononcée, cette disposition n'empêche pas que la société puisse être déclarée comme fictive, avec la conséquence qu'elle n'est pas opposable à celui qui invoque avec succès ce caractère fictif de la société[3]. La société continue par ailleurs à exister valablement.

Si l'un des associés détenait en réalité tous les titres, l'autre associé n'étant qu'un prête-nom, il y aurait société fictive (sauf dans les cas où il peut y avoir société unipersonnelle). La conséquence en serait notamment que l'associé principal ne pourrait prétendre au bénéfice de la responsabilité limitée[4]-[5].

Les effets de la fictivité (et des différentes formes de simulation en général) se trouvent singulièrement réduits de nos jours du fait du droit de l'Union européenne. « *Qu'enfin, dire qu'une société est fictive, c'est reconnaître qu'elle n'existe pas ; or, l'article 13*ter *des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne prévoit pas l'absence d'*affectio societatis*, comme étant une cause de nullité d'une société anonyme […]* »[6].

---

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 234.

2 – Cette situation a changé en France où, depuis la loi du 4 janvier 1978, « *la clandestinité n'est plus de l'essence de la société en participation* », v. M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, *Droit des sociétés*, p. 509.

3 – Apparemment d'avis contraire, Th. Afschrift, « Simulation et réalité juridique à propos des sociétés étrangères constituées dans le but d'éviter l'impôt belge », p. 12, dans le sens que le caractère fictif de ces sociétés ne pourrait être invoqué à l'égard de sociétés étrangères du moment que ces sociétés existent réellement en application de leur droit national. Cet auteur qualifie d'ailleurs de manifestement erroné, l'arrêt de la CA de Bruxelles du 9 juin 1992 qui avait qualifié de « *simulée […] et donc pas opposable au fisc belge* » une société anglaise au motif qu'elle n'aurait pas d'activités propres, distinctes de celles de sa société mère panaméenne (Afschrift, *op. cit*., p. 11).

4 – CA Paris, 14 novembre 1932, Sirey, II, 42.

5 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 135.

6 – Jgt du 16 septembre 1986 du juge des saisies de Neufchâteau, n° 5721 du rôle général.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Selon la jurisprudence luxembourgeoise, « *[U]ne société fictive, ou société de façade ou société écran n'est qu'une apparence de société, manipulée par un seul personnage qui est le maître de l'affaire. La fictivité suppose la réunion d'un faisceau d'indices concordants à savoir, entre autres, le défaut de pluralité d'associés, le défaut d'activité sociale, le défaut de vie sociale, le défaut d'autonomie patrimoniale de la société (Cozian, Viandier, Deboissy, Droit des sociétés, Litec, pp. 69 et s. : Cour d'appel de Luxembourg, 14 janvier 2004, n° 27163 du rôle)* »[1].

La question de la fictivité de la société est à distinguer de celle du **siège social fictif**. Notamment en Belgique et en France, il existe une abondante jurisprudence concernant des sociétés qui maintiennent un siège social fictif pour « *des raisons fiscales (sociétés* offshore*, sociétés se résumant à de simples boîtes aux lettres dans des paradis fiscaux), ou encore pour bénéficier d'aides à la création d'entreprises ou pour déroger à des règles de compétence ou de nationalité. Dans le cadre de la fictivité du siège social, les tribunaux ont un pouvoir souverain pour déterminer le siège réel […] Une fois la fictivité établie, les tiers pourront se prévaloir là encore du siège réel ou du siège social fictif. La société ne pourra, quant à elle, pas opposer aux tiers son siège statutaire si celui-ci est fictif. Elle ne pourra pas non plus se prévaloir de son siège réel si les tiers entendent se prévaloir de son siège statutaire* »[2]. En outre, il va de soi que la fictivité du siège social n'entraîne pas la fictivité de la société, question qui ne peut se poser que pour les sociétés autres que les sociétés de capitaux.

SECTION V
LES EFFETS DES NULLITÉS DES SOCIÉTÉS

Il convient ici encore de distinguer selon les effets de droit commun et ceux induits par le droit européen.

■ § 1 – En droit commun

Les effets de la nullité doivent être appréhendés entre associés d'abord, à l'égard des tiers ensuite.

A – Entre associés

La nullité comporte un effet rétroactif se traduisant en principe par la restitution de toutes les prestations des parties[3]. Cette règle se heurte à l'impossibilité de restitution des prestations correspondant à des contrats à exécution successive, tels que les apports en jouissance et en industrie[4]. Le cas échéant, il est possible à un associé d'avoir recours à la théorie de l'enrichissement sans cause pour le cas où un associé ne retrouverait pas son compte par rapport aux autres associés. Il lui serait loisible d'invoquer cette théorie pour la raison que l'enrichissement des autres

1 – A. Bertolotti, note sous CA Luxembourg, 29 avril 2004, *Droit des sociétés*, 2005, n° 74, p. 153.
2 – A. Bertolotti, note sous CA Luxembourg, 29 avril 2004, *Droit des sociétés*, 2005, n° 74, p. 157.
3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 55.
4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 56.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

associés n'aurait pas sa cause dans le contrat de société, ce dernier étant annulé avec effet rétroactif[1].

B – À l'égard des tiers

La nullité d'une société est un **fait juridique** opposable aux tiers[2]. Quant à la question de savoir si la nullité peut avoir des incidences sur les contrats conclus avec les tiers, la réponse dépend du motif de l'annulation. Selon le cas, l'annulation peut avoir un effet uniquement sur le contrat de société ou rejaillir sur les contrats conclus avec les tiers.

Finalement, un aspect décisif dans l'appréciation des effets de la nullité sera le caractère essentiel ou non de la prestation de l'associé dont l'engagement est annulé. Si cette prestation était essentielle dans l'esprit des parties, alors les associés ou le cocontractant pourront invoquer la caducité du contrat[3].

§ 2 – En droit européen

Ces effets sont fort limités dans la mesure où la nullité ne produit effet qu'à partir de la date de la décision qui la prononce, étant entendu qu'elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de cette décision. La nullité a pour effet la liquidation de la société.

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 57 ; P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations », *R.C.J.B.*, 1988, p. 36.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 57.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 58.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE VI
PREUVE DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

Il y a lieu de distinguer les règles prévalant entre associés de celles concernant les tiers.

SECTION I
LES RÈGLES PRÉVALANT ENTRE ASSOCIÉS

La règle de base est énoncée par l'article 1834 C.c. ainsi libellé :

« *Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 3,75 euros.*

La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 3,75 euros ».

La disposition visée est la reproduction textuelle de l'article 1341 C.c. appliqué aux sociétés. Ainsi est assurée la reprise en cette matière du droit des sociétés des règles applicables en matière de preuve testimoniale[1].

L'objet de la reprise des règles de droit commun en cette matière a été d'abolir les **sociétés taisibles**, forme de société ayant existé sous l'ancien droit et qui pouvaient être prouvées par témoins[2] ; en exigeant la preuve littérale dès le moment où l'objet était de 150 francs au moins (montant qui correspond à celui de 3,75 euros), le Code civil condamnait de fait ce genre de sociétés.

Par objet de la société, on entend le montant des apports faits à la société[3]. Le champ d'application de cette disposition est limité aux sociétés civiles[4]. Toutefois, la même exigence existe en matière de sociétés commerciales du fait que l'article 100-4 L.S.C. prévoit à l'égard de chacune de ces sociétés la nécessité d'un acte écrit, « *à peine de nullité* », et ceci, indépendamment du montant du capital social.

SECTION II
LES RÈGLES VALABLES À L'ÉGARD DES TIERS

Pour les tiers, le contrat de société est un simple **fait juridique**. Les tiers peuvent établir l'existence de toute société civile ou commerciale par tous les moyens de preuve.

« *Le contrat de société équivaut à un simple fait juridique pour les tiers, et non à un acte générateur de droits et d'obligations, et les associés peuvent en faire la preuve à l'égard des tiers par toutes voies de droit, quelles que soient la nature (civile ou commerciale) de la société ou la qualité (commerçant ou non-commerçant) des tiers* »[5].

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 172.
2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 173.
3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 178.
4 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 60.
5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 62.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE II
LE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS

CHAPITRE I
RÈGLES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS

« *Au XIXe siècle, le modèle contractuel fondait une organisation qui donnait aux associés tous les pouvoirs. Ces derniers étaient cependant bien obligés d'en déléguer une partie (importante) à des mandataires. Les mandataires n'avaient pas de pouvoir propre, et les associés pouvaient à volonté déterminer l'étendue de ces pouvoirs, et les modifier ou les retirer. […]*

La théorie institutionnelle qui s'est développée en France au XIXe siècle, […] donne un autre sens à la hiérarchie des organes. Aux associés ou membre de la personne morale revient le pouvoir de prendre les décisions les plus importantes. Mais celles-ci sont en nombre limité, et les dirigeants sont investis par la loi (et non un contrat de mandat) de tous les autres pouvoirs. On greffe d'autres organes de contrôle (conseil de surveillance, commissaire aux comptes, comité d'entreprise) à qui la loi confère un rôle spécifique dont ils ne doivent pas sortir »[1].

L'agencement classique des organes de la société repose donc sur une prépondérance très nette de l'assemblée générale des associés. Celle-ci nomme et révoque les autres pouvoirs. En ce qui concerne l'organe d'administration de la société, il convient de distinguer les règles de prise de décision dans la société des règles régissant la représentation de la société à l'égard des tiers. Une société ne peut en effet agir que par l'intermédiaire de personnes physiques auxquelles la loi ou le contrat de société confère le droit de représenter la société en tant qu'organe de celle-ci ou par application des règles sur le mandat.

Dans un souci de protection des tiers, le droit européen a prévu un certain nombre de règles destinées à garantir que la société soit engagée vis-à-vis des tiers (du moins si ceux-ci sont de bonne foi) nonobstant le fait que toutes les règles de prise de décision ou de représentation n'aient pas été respectées.

SECTION I
L'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

En principe, et sauf stipulation contraire, l'administration de la société est assumée par tous les associés.

1 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 270.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – Les règles du droit commun

Ces règles résultent de l'article 1859 C.c. :

« À défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes :

1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.

2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.

3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.

4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent ».

En réalité, ce principe ne s'applique qu'aux seules sociétés en nom collectif et aux sociétés civiles. D'ailleurs, même pour ces types de sociétés, les statuts de la société vont prendre soin de déléguer les pouvoirs de gestion à l'un ou à l'autre des associés.

Art. 1856. *« L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.*

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure ; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat ».

Art. 1857. *Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.*

Art. 1858. *S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.*

Art. 1860. *L'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.*

Art. 1861. *Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société ; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.*

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 2 – Les règles applicables à la société anonyme

En ce qui concerne la **société anonyme**, il existe une certaine **contradiction entre deux dispositions légales**, à savoir l'article 441-5 alinéa 1 [anc. art. 53 alinéa 1] L.S.C. : « *Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale* […] » et, de l'autre côté, l'article 450-1 alinéa 1 [anc. art. 67 alinéa 1] L.S.C. : « *L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société* […] ».

L'on voit que ces deux dispositions sont partiellement incompatibles : si la première accorde le pouvoir général pour la réalisation de l'objet social au conseil d'administration, la deuxième accorde ce pouvoir général à l'assemblée générale. Ce conflit doit être résolu au moyen des principes généraux d'interprétation des normes juridiques.

L'article 53 L.S.C. avait été introduit par la loi du 23 novembre 1972, alors que l'article 67, dans la forme visée ci-dessus, provient de la loi du 7 septembre 1987, postérieure donc à celle de 1972. Par conséquent, c'est l'assemblée qui a les pouvoirs les plus étendus pour faire les actes, pouvoirs qui, en cas de conflit, priment donc ceux du conseil d'administration. Une telle interprétation, pour logique qu'elle puisse paraître à première vue, serait pourtant erronée, et ceci, pour la raison que la première disposition (celle de la loi du 23 novembre 1972) est tirée du droit européen et est donc d'une **source hiérarchique supérieure** qui ne peut être primée par aucune source de droit national, fût-elle postérieure.

En fin de compte, c'est donc le conseil d'administration qui a **plein pouvoir** dans les sociétés anonymes : la L.S.C. lui donne tous les pouvoirs « *[…] à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale* ». Encore faut-il ajouter qu'en ce qui concerne les restrictions apportées par les statuts, celles-ci seront inopposables aux tiers, même si elles sont publiées (art. 441-5, alinéa 3, anc. art. 53, alinéa 3, L.S.C.)[1]. Par conséquent et en définitive, c'est donc le conseil d'administration qui, vis-à-vis des tiers, a tous les pouvoirs, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale des actionnaires.

Il est vrai aussi qu'en ce qui concerne les relations internes de la société, les statuts peuvent limiter de façon très importante les pouvoirs du conseil d'administration. Sans être opposables aux tiers, ces restrictions ont toute leur valeur dans les relations internes. La L.S.C. (contrairement à certaines législations étrangères) n'accorde d'ailleurs aucune **compétence réservée** au conseil d'administration[2].

Il va de soi que la solution accordant à l'assemblée générale les pouvoirs de réaliser les actes de gestion qui intéressent la société n'est guère praticable, et ceci, pour la double raison que, d'une part, la gestion est en général trop complexe pour être exercée par une assemblée comportant un nombre élevé de membres et que, d'autre part, les associés se désintéressent notoirement de cette gestion. Des solutions de rechange sont donc nécessaires. En fin de compte, l'assemblée

1 – En ce sens, I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, p. 363.

2 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, p. 363 qui se réfère à J. Delvaux, *La société anonyme*, p. 113 et pp. 133-134.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

générale se limite donc à prendre les décisions annuelles ou périodiques, notamment l'approbation des comptes annuels, la désignation des membres faisant partie des organes de gestion de la société, ainsi que les décisions comportant modification de l'acte de société[1]. La gestion est confiée à des organes de gestion spécifiques, conseil d'administration (dans les sociétés anonymes), gérant (dans les S.à r.l.), etc.

Le droit européen abandonne aux États membres le soin de choisir entre la **structure moniste** (qui consiste à confier la plénitude du pouvoir de gestion à un seul organe : telle est la solution luxembourgeoise traditionnelle) et la **structure dualiste** (qui revient à confier le pouvoir de gestion à un directoire et à un conseil de surveillance).

Le droit luxembourgeois a repris cette faculté en droit luxembourgeois en permettant donc aux sociétés de choisir entre deux solutions : la solution traditionnelle du conseil d'administration (solution moniste) et la gestion comportant directoire et conseil de surveillance (structure dualiste).

■ § 3 – Nomination et révocation des dirigeants de la société

Les dirigeants sociaux sont nommés par la communauté des associés. Ils peuvent être **nommés** soit dans les statuts soit par un acte postérieur. La différence est que, s'ils sont nommés par les statuts, leur position est plus solide, dans le sens que leur révocation exige une modification de ces statuts, ce qui rend donc leur situation moins précaire. Le cas échéant, ceci signifie qu'il ne peut y avoir de révocation (si le gérant est en même temps associé) : dans certaines sociétés, les statuts ne peuvent être changés que sur la base d'une décision unanime.

■ § 4 – Administrateur nommé par les juridictions

De façon générale, le juge des référés n'intervient dans la vie de la société que lorsqu'un ou plusieurs organes de la société ne fonctionnent pas normalement ou risquent de ne pas fonctionner normalement (qu'il s'agisse du conseil d'administration ou de l'assemblée générale[2]).

« *Le juge des référés ne peut se substituer aux organes sociaux ni s'immiscer dans la gestion sociale. Il peut, en revanche, de la manière la plus large, prêter son assistance en édictant toutes les mesures utiles de sauvegarde ou de surveillance que l'urgence fait fréquemment apparaître dans la vie sociale à l'effet de prévenir un dommage, d'aider au déroulement des actions au fond ou d'éviter l'introduction de ces dernières* »[3].

Il peut encore intervenir en cas de dissentiment entre deux organes, notamment entre l'assemblée des associés et le gérant. Souvent, le juge des référés procède alors à la nomination d'un administrateur provisoire. Les juges constatent qu'en principe ils n'ont pas le droit d'intervenir dans la vie des sociétés. Il est fait exception à ce principe en **cas d'urgence**, de **circonstances exceptionnelles**, particulièrement graves, de péril d'un préjudice irréparable[4].

1 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 43.

2 – G. Horsmans, « Le juge des référés et le droit des sociétés », *R.P.S.*, 1969, p. 47.

3 – G. Horsmans, « Le juge des référés et le droit des sociétés », *R.P.S.*, 1969, p. 62.

4 – G. Horsmans, « Le juge des référés et le droit des sociétés », R.P.S., 1969, p. 50.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il n'est pas possible de définir l'urgence de manière précise[1]. « *Elle échappe à toute définition systématique et logique parce que l'idée qu'elle renferme n'est pas une idée stable, uniforme, absolue et que son contenu varie suivant les circonstances de temps et de lieu* »[2]. Les éléments de l'urgence sont en définitive les suivants : une menace à écarter et un obstacle à franchir[3].

L'urgence, en matière de droit des sociétés, est souverainement appréciée par le juge des référés, non pas dans le chef des membres affiliés, mais dans le chef de la personne morale qui doit se trouver exposée à un préjudice certain et imminent. Littéralement, il n'y a urgence que si le moindre retard peut causer un **préjudice irréparable**[4]. D'une manière générale, la jurisprudence est pratiquement unanime à considérer qu'il y a toujours urgence dans tous les cas où la gestion sociale n'est plus assurée en raison de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l'un ou de plusieurs des organes sociaux. En revanche, lorsque les organes sont encore en état de fonctionner, l'urgence devra être démontrée par les circonstances de l'espèce. Il s'agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d'apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu'un si les choses sont laissées en l'état en attendant que la contestation au fond soit vidée[5].

Le juge des référés ne peut allouer au demandeur plus de droits qu'il n'en possède de par la loi. Une demande tendant à la remise à une société de révision des données comptables d'un exercice dépasse les prévisions et dispositions de l'article 461-6 [anc. art. 73] L.S.C. et doit partant être déclarée irrecevable, quelle que soit la base légale invoquée[6].

La cour d'appel confirma une ordonnance rendue en référé nommant un séquestre portant sur des actions dont le demandeur affirmait que le défendeur s'était engagé à les lui céder, en attendant que la contestation soit vidée au fond. Quant à l'intervention du juge des référés : « *[…] il peut en cas d'urgence prendre toutes mesures utiles et nécessaires à la conservation des droits des parties et notamment ordonner la séquestration d'une chose dont l'usage est litigieux, dès lors que cette mesure provisoire n'est pas dérogatoire au droit de propriété […] qu'en l'espèce l'existence d'une contestation sérieuse, loin de mettre obstacle à la compétence du juges des référés, peut la justifier […]* »[7].

Pour ce qui est de la mission du séquestre, la société défenderesse doit être « *en mesure d'exercer tous les droits attachés aux titres séquestrés, sauf celui de les céder ; que cette mission est entièrement conforme aux pouvoirs du séquestre tels qu'ils sont définis par la jurisprudence, celui-ci pouvant seulement poser des actes conservatoires et de pure administration et ne pouvant notamment pas déroger au droit de propriété […]* »[7].

---

1 – G. Horsmans, « Le juge des référés et le droit des sociétés », *R.P.S.*, 1969, p. 50.

2 – M. Francès, *Essai sur les notions d'urgence et de provisoire dans la procédure du référé*, Thèse, Université de Toulouse, 1935, p. 42.

3 – G. Horsmans, « Le juge des référés et le droit des sociétés », *R.P.S.*, 1969, p. 56.

4 – A. Allard, Rapport de la Commission de Longé, p. 142.

5 – TA Lux. (réf.) du 28 juillet 1986, n° 832/86, ID 11177 ; TA Lux. (réf.) du 27 juillet 1987, n° 811/87, ID 11154 ; TA Lux. (réf.), 3 novembre 1988, n° 1331/88, ID 11164.

6 – TA Lux. (réf.) du 5 décembre 1988, n° 1526/88, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

7 – CA du 14 novembre 1988, n° 10.724, ID 12385.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La nomination d'un séquestre rend provisoirement indisponibles les biens mis sous séquestre, de sorte qu'à cet égard les pouvoirs du conseil d'administration et ceux d'un porteur de procuration générale sont affectés par une telle mesure. À supposer que la demanderesse soit créancière de la société défenderesse à laquelle elle entend faire nommer un séquestre, elle aurait qualité et intérêt pour rendre la décision du juge des référés opposable au conseil d'administration et à la porteuse d'une procuration générale. À cet égard, la demande en référé avec mise en cause de l'actionnaire principal, porteuse d'une procuration générale et des membres du conseil d'administration, est recevable[1].

Suivant l'article 1961 C.c., « *les tribunaux peuvent ordonner le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. Il est admis que cette mesure peut également être ordonnée en référé en cas d'urgence (CSJ, 22 avril 1970, Pas. 21, p. 234) et à condition que cette mesure ne déroge pas au droit de propriété. Cette mesure est encore susceptible d'être ordonnée en référé s'il existe un différend sérieux entre parties (Jurisclasseur, Proc. civ. Référé, fasc. 234, n° 20), étant entendu que le juge des référés ne saurait se livrer à une analyse du fond du droit* »[2].

L'intervention du juge des référés aux fins de désignation d'un administrateur doit reposer sur des faits concrets susceptibles de motiver une telle désignation, étant entendu qu'il n'incombe pas aux juridictions de se substituer aux organes de la société, mais d'aider au redressement de son fonctionnement, si celui-ci est paralysé ou faussé ou risque de l'être[2].

Les « *faits pouvant motiver la désignation d'un administrateur provisoire doivent être de nature à engendrer un péril grave pour la société rendant absolument nécessaire la mesure sollicitée […] si l'urgence est requise pour justifier l'intervention du juge des référés […] elle n'est pas du point de vue du fond du droit, une condition nécessaire à la désignation d'un administrateur provisoire ; que la demande est en effet recevable dès lors que la cause de désignation existe, même si dans l'immédiat il n'est pas nécessaire d'accomplir un acte juridique au nom et pour le compte de la société […]* »[3].

« *Ni la loi luxembourgeoise sur les sociétés ni les statuts de […] S.A. ne prévoient la rédaction par écrit des décisions du conseil d'administration, de sorte que les décisions orales peuvent être prouvées par tous moyens* » (en l'espèce la preuve par témoins a été jugée admissible)[4].

D'après la jurisprudence, une société anonyme n'est pas engagée, alors même que l'acte avait été signé par des administrateurs conformément à une clause relevant du prescrit de l'article 441-5, alinéa 4 (anc. art. 53, alinéa 4) L.S.C., « *[…] s'il est établi, en l'occurrence par une preuve testimoniale, que la dite signature n'était intervenue que sous réserve d'approbation par le conseil d'administration. En l'espèce la Cour retient le témoignage de "simples" administrateurs, qui ne sont ni actionnaires,*

1 – CA du 20 avril 1993, n° 15.179, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Trib. Lux. (réf.) du 28 juin 2002, n° 552/2002, *BIJ*, 2003, p. 26.

3 – CA du 26 octobre 1993, n°s 15.376 et 15.377, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA du 26 novembre 1997, n° 19.214, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ni bénéficiaires d'une quelconque délégation de pouvoirs, et rejette le témoignage du président du conseil d'administration en tant qu'il s'identifie à la partie appelante et doit donc être considéré comme partie en cause »[1].

Quant aux conditions de la désignation d'un « administrateur » provisoire dans le cadre d'une S.à r.l. où règne la mésentente entre les associés, l'appréciation est encore plus rigoureuse en ce qui concerne le critère de l'urgence : nécessité de « *circonstances exceptionnelles et particulièrement graves compromettant le fonctionnement de la société* »[2].

« *Attendu qu'il est admis en jurisprudence luxembourgeoise que si les organes de la société sont en état de fonctionner, le juge des référés n'a à y intervenir par des mesures provisoires qu'au cas de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, hypothèses dans lesquelles l'urgence est toujours sous-entendue et présumée ; que l'intervention du juge des référés est encore admise en général en cas de mésentente entre associés ou entre organes sociaux et qui conduit à la paralysie et au blocage de la vie sociale et qui menace la société dans son existence, situation qui appelle également des mesures urgentes de la part du juge des référés. Attendu que cette jurisprudence classique a évolué en France, en matière de désignation d'administrateurs provisoires, en ce que l'accent est mis plutôt sur le péril encouru par la société en tant qu'être moral, lorsqu'elle est menacée de ruine, que son équilibre financier est compromis et, de façon plus précise, lorsque le gérant commet des actes d'administration qui apparaissent suspects […] ; qu'en référé, des décisions déjà anciennes ont admis la désignation d'un administrateur provisoire à une société où on a relevé des faits d'infidélité ou d'incapacité susceptibles de mettre en péril grave les intérêts sociaux […] ; que la jurisprudence plus récente subordonne la désignation d'un administrateur provisoire à la réunion de deux conditions : l'existence d'un fait susceptible de motiver une telle désignation et l'existence d'un péril grave pour la société, engendré par ce fait […]*

Attendu que l'intervention du juge des référés aux fins de désignation d'un administrateur doit tout d'abord reposer sur des faits concrets susceptibles de motiver une telle désignation, étant entendu qu'il n'incombe pas aux juridictions de se substituer aux organes de la société mais d'aider au redressement de son fonctionnement si celui-ci est paralysé ou faussé ou risque de l'être […] ; qu'en l'espèce et selon toute apparence, telle que celle-ci se dégage du rapport comptable et financier de la société […], la gérance n'est plus assurée normalement et dans l'intérêt social bien compris, mais que tout au contraire il paraît que le gérant a posé dans un passé récent des actes hasardeux, suspects et ruineux pour la société à tel enseigne que ces actes dont l'analyse détaillée a été faite ci-dessus, créent un péril grave pour l'existence même de la société en raison de la répétition de ces actes et de l'importance des sommes mises en jeu ; Attendu que ce danger imminent apparaît sur la toile de fond d'une lutte acharnée pour le contrôle exclusif de la société entre associés majoritaire et minoritaire et respectivement associé majoritaire et gérant, à telle enseigne que la société s'en trouve paralysée dans son fonctionnement, à moins d'une nomination prochaine d'un nouveau gérant loyal et capable ; que le péril grave qui en est né rend

1 – CA du 11 juillet 2001, n° 25.779, commenté par Fr. Fayot, *Ann.dr. Lux*., 2001, p. 546, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA, 16 janvier 1989, n° 10.944, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

recevable la demande en nomination d'un administrateur provisoire […] Attendu que l'intrusion de la justice dans la vie des sociétés doit être limitée au strict nécessaire et qu'ainsi les pouvoirs de l'administrateur provisoire doivent être définis tout comme sa mission doit être limitée dans le temps […]

Attendu que le juge des référés, dont les pouvoirs sont d'ordre public, n'excède pas ses limites en confiant à l'administrateur provisoire la mission de poser les actes d'administration courante […] »[1].

■ § 5 – Représentant permanent obligatoire pour les dirigeants sociétés

Il arrive souvent que des mandats de dirigeants sociaux soient assumés par des personnes morales, en fait par des sociétés de capitaux. Ce choix peut être pris pour des raisons tout à fait légitimes telles que la flexibilité (du fait que cette société peut avoir plusieurs personnes autorisées à signer pour son compte, de sorte qu'il serait plus facile de trouver un signataire pour des actes de la société que tel n'est le cas pour un dirigeant personne physique).

En droit luxembourgeois, il existe une tendance (assez récente) qui consiste à obliger de telles personnes morales à **désigner une personne physique** en tant que représentant permanent pour la personne morale occupant cette fonction de dirigeant de la société. La première manifestation en ce sens remonte au droit européen, à savoir au règlement du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. Dans son article 47, ledit règlement dispose que, dans l'hypothèse où un État permet qu'une entité juridique puisse être membre d'un des organes de la SE, que : « *La société ou autre entité juridique désigne une personne physique pour l'exercice des pouvoirs de l'organe concerné* ». Cette disposition devait par la suite faire tache d'huile en droit luxembourgeois pour être successivement étendu aux S.A., S.à r.l., etc.

Pour la S.A., la disposition pertinente est contenue à l'article 441-3 L.S.C. ainsi libellée : « *Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, membre du comité de direction, ou directeur général, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.*

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre ».

Il existe toutefois une exception récente à cette obligation pour une personne morale gérant une autre société de désigner une personne physique comme représentant permanent, et elle concerne la S.e.c.a. Pour ce type de société, le projet de loi afférant avait proposé de déroger expressément à la solution prévue à l'égard des S.A., à quoi l'avis du conseil d'État a pris position comme suit : « *À la place de ces dispositions, il est proposé d'introduire une nouvelle disposition sous l'article 107, afin de régler la situation de l'administrateur, personne morale, d'une SCA. En effet, selon une jurisprudence*

1 – CA du 30 avril 1990, n° 12.181, ID 11166.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

récente[1]*, l'administrateur, personne morale d'une SCA, aurait l'obligation de nommer un représentant permanent. Par le renvoi de l'article 103 aux dispositions relatives aux S.A., le juge a conclu à l'applicabilité de l'article 51*bis *L.S.C.* ». C'est en réaction à cette jurisprudence et afin de contrecarrer ses effets pour l'avenir que la Loi de Modernisation a ajouté la phrase suivante à l'alinéa 1 de l'article 600-5 L.S.C. : « *Lorsqu'un ou plusieurs gérants sont des personnes morales, elles ne sont pas tenues de désigner une personne physique comme représentant permanent* »[2].

SECTION II
VALIDITÉ DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ

Les engagements de la société sont sujets tant à des limitations légales que conventionnelles.

§ 1 – Limitations légales des engagements de la société

En application du principe de la spécialité des personnes morales en général, et des sociétés commerciales en particulier, la question se pose de savoir si une société est engagée vis-à-vis des tiers dans la mesure où elle excède son objet social. En pure théorie, la réponse à cette question est négative en vertu de la théorie de l'*ultra vires* et des règles sur le droit commun du contrat de mandat : le mandataire n'a aucun pouvoir s'il agit en dehors du mandat qui lui est confié. La théorie de l'***ultra vires*** (expression du principe de la spécialité) surtout appliquée traditionnellement dans les pays anglo-saxons, était très critiquée, et l'évolution se faisait en direction de la solution allemande qui ne permettait pas l'annulation des actes passés en dehors de l'objet social[3].

Avant 1972, la théorie de l'*ultra vires* (telle qu'appliquée au Royaume-Uni) imposait aux tiers de prendre connaissance des statuts pour vérifier les limites résultant de l'objet social. En vertu des dispositions des directives, ceci n'est plus le cas actuellement : toutefois, la société peut établir la mauvaise foi du tiers qui était informé des limitations statutaires ou qui a pu se rendre compte du fait que l'acte accompli dépassait l'objet social[4].

Dans un souci d'assurer la sécurité juridique des transactions commerciales, la Première directive déroge toutefois à ce principe en disposant (dans son article 9) : « *La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social de cette société, à moins que lesdits actes n'excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes* ». Il résulte de cette disposition qu'une société anonyme, dont l'objet social est de tenir et de mettre en valeur des participations, fait le commerce d'immeubles et est tenue vis-à-vis des tiers. Dans ce cas, ni la société ni les tiers ayant contracté

1 – Il est fait référence à l'affaire tranchée par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 11 décembre 2013, n° 142725 du rôle, affaire *Hellas*, ID 21739.

2 – Pour une appréciation critique, voir la note de Y. Prüssen sous la publication du jugement au *Journal des tribunaux*.

3 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.*, 1989, p. 396.

4 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.*, 1989, p. 404.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

avec la société ne peuvent par la suite demander l'annulation des actes posés **en dehors de l'objet** social de la société, donc des opérations immobilières.

En revanche, si les opérations visées ont été signées par le commissaire aux comptes, alors la remise en cause de ces opérations est possible. Dans ce cas, les pouvoirs que la loi permet d'attribuer aux organes de la société ont en effet été dépassés. Cette solution est défendable dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger d'un tiers qu'il ait connaissance de la loi (concrètement l'attribution légale des pouvoirs aux différents organes de la société) ; en revanche, ce même tiers n'est pas obligé de prendre connaissance de l'objet social de la société.

À première vue et sur la base de cette disposition impérative de la loi, la situation est relativement claire. Malheureusement, la directive permet alors aux États membres de « *[…] prévoir que la société n'est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l'objet social, si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve* ».

Cette disposition (prévue de manière facultative par la directive) a été reprise en droit national luxembourgeois. La situation en droit positif est que les actes posés en dehors de l'objet social sont susceptibles d'avoir des conséquences non seulement dans les relations avec les organes (dont la responsabilité personnelle est susceptible d'être engagée si les statuts n'ont pas été respectés), mais encore dans les relations avec les tiers. Les tiers et la société peuvent attaquer les actes passés en dehors de l'objet social (la connaissance du dépassement étant supposée établie).

Pour éviter l'annulation de ces actes, la société doit prouver la connaissance positive de cette violation de l'objet social ou encore que le tiers ne pouvait l'ignorer.

■ § 2 – Limitations statutaires des pouvoirs des organes

Les limitations légales de ces pouvoirs sont évidemment à respecter. Quant à celles qui résultent des statuts ou encore d'une décision des organes de la société, elles sont inopposables aux tiers. En d'autres termes, elles peuvent avoir toute leur validité à l'intérieur de la société (la responsabilité des organes peut être engagée si ceux-ci ne respectent pas ces limitations), mais elles n'ont pas d'effet envers l'extérieur. Elles sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées[1].

La Première directive (art. 9, 3.) permet à la législation nationale d'autoriser les statuts de la société de confier le pouvoir de représentation générale de la société à une personne ou encore à plusieurs personnes agissant conjointement. Cette disposition est opposable aux tiers à condition qu'elle concerne le pouvoir général de représentation (sous la condition additionnelle d'être dûment publiée).

Cette disposition est susceptible d'entrer en conflit avec une disposition spécifique de la loi nationale luxembourgeoise, à savoir celle de l'article 441-10, alinéa 1 (anc. art. 60, alinéa 1) L.S.C. : « *La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs […]* ». La question est donc de savoir si une telle délégation partielle (car limitée à la gestion journalière) du pouvoir de représentation est autorisée par la directive.

1 – Art. 9, 3 de la Première directive.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans une affaire soumise aux juridictions belges, il s'agissait de décider sur la possibilité pour une S.p.r.l. d'attaquer des actes passés par la société pour la raison que ceux-ci se seraient situés en dehors de l'objet social de la société. Tant la cour d'appel que la Cour de cassation rejetèrent cette demande au motif que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions légales basées sur la directive, « *les limitations statutaires aux pouvoirs des organes (conseils d'administration, délégués à la représentation générale ou à la gestion journalière) n'ont plus qu'un effet interne et ne peuvent dès lors être invoqués par les tiers* ». La société **Sarcofebat** faisait valoir qu'une mission de direction et de contrôle était confiée à la défenderesse par des représentants appointés et que la défenderesse percevrait ainsi un certain pourcentage des ventes réalisées par les représentants faisant l'objet de la mission de direction et de contrôle. La demanderesse invoqua l'irrecevabilité de la demande tendant au paiement des commissions, au motif que les personnes habilitées à représenter la société « *avaient excédé leurs pouvoirs car ledit accord concernait une activité étrangère à la réalisation de l'objet social de la société Sarteco* »[1].

Avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, les restrictions résultant de l'objet social étaient opposables aux tiers qui pouvaient également s'en prévaloir. La nouvelle disposition légale ne permet plus à la société de renier ses engagements contractuels en cas de dépassement de l'objet social (sauf circonstances d'exception). La loi ne dit rien sur les options qui sont ouvertes aux tiers[2].

Avant la Première directive, le droit des États membres (en dehors de l'Allemagne), était basé sur la notion de mandat, en attachant une importance tout à fait dominante aux règles d'organisation interne de la société. Dans ce contexte se posait la question de l'opposabilité aux tiers des irrégularités susceptibles de mettre en cause la validité des engagements de la société. En même temps se posait la question de savoir si des tiers qui connaissaient ces irrégularités pouvaient s'en prévaloir[3].

Dans un souci de protection des tiers, la théorie du mandat était appelée au secours : si la société pouvait demander la nullité des actes posés par des représentants légaux de la société pour cause d'irrégularité de leur nomination, les tiers pouvaient écarter l'annulation en établissant qu'ils avaient été trompés par l'apparence et qu'ils pouvaient légitimement croire à l'existence d'un mandat de la part de la société[2].

Deux sortes de limitations étaient ici en cause. D'abord des limitations par des clauses statutaires et des décisions internes : celles-ci pouvaient limiter les pouvoirs des organes. Pour être valables, ces limitations devaient non seulement être publiées, mais encore devaient-elles être d'une interprétation facile. Les cocontractants devaient faire valoir leur bonne foi et se prévaloir d'un mandat apparent ou encore d'une ratification tacite par la société.

En deuxième lieu, il y avait les limitations relatives à l'objet social : l'acte accompli au-delà de l'objet social pouvait être invalidé, la ratification par la société d'un tel acte étant indifférente. En effet, « *pas plus que le conseil d'administration, l'assemblée*

1 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.*, 1989, p. 385.
2 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.*, 1989, p. 389.
3 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.*, 1989, p. 388.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

générale n'a le droit de violer les statuts »[1]. La société comme les tiers pouvaient donc se délier de leurs engagements si ceux-ci étaient pris en dépassement de l'objet social[2].

SECTION IV
LES ASSEMBLÉES DES ASSOCIÉS

Les associés sont, dans toutes les sociétés, groupés en assemblées qui constituent l'organe souverain de la société.

« *Dans toute opération ou entreprise quelconque, il faut une autorité supérieure, qui exerce la haute direction et dont émanent tous les pouvoirs confiés à des agents qui lui sont subordonnés. […] cette autorité suprême appartient naturellement à l'ensemble des associés réunis en assemblée générale* »[3]. Le contrat social et la loi sont les limites à la puissance de l'assemblée générale. À l'intérieur de ces limites, son pouvoir est absolu : elle peut faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société[3]. Comme indiqué ci-dessus, ces propos doivent être mitigés depuis la Première directive en matière de droits des sociétés.

Ces assemblées interviennent rarement, mais elles prennent les **décisions les plus importantes** concernant la vie de la société. Elles interviennent notamment pour nommer les organes de gestion et de contrôle de la société, pour approuver les comptes et décider de l'affectation des résultats. Ces décisions relèvent des décisions ordinaires ou périodiques. Par ailleurs, l'assemblée peut encore intervenir pour **modifier les statuts**, décisions plus rares en principe, en tout cas non périodiques, et qui sont en principe soumises à des majorités spéciales (plus fortes), si ce n'est qu'elles sont soumises à l'unanimité des associés.

Les décisions des assemblées peuvent être affectées de certaines irrégularités. Celles-ci soulèvent la question de la sanction que la loi réserve à ces cas. En premier lieu, se pose la question de savoir par qui ces irrégularités peuvent être invoquées.

En cas de violation des règles d'ordre public, la réponse est claire dans le sens que tout intéressé peut invoquer la nullité, et le juge peut même le faire d'office[4]. Lorsque la violation ne concerne pas des règles d'ordre public, elle ne peut être invoquée que par les personnes que ces dispositions sont supposées protéger (p. ex., les associés) et, de manière exceptionnelle, par les créanciers (par le biais de **l'action oblique**). Encore faut-il noter que seuls certains associés peuvent invoquer la nullité : ceux qui n'ont ni voté ni approuvé la décision litigieuse ; également ceux qui n'ont pas confirmé la décision nulle de façon expresse ou tacite[4].

L'annulation de la décision irrégulière comporte un effet rétroactif.

C'est un phénomène universel que les assemblées des associés des grandes sociétés et surtout celles des sociétés cotées en bourse ne rassemblent qu'une très petite fraction des actionnaires. La plupart des actionnaires se désintéressent totalement de la gestion sociale avec la conséquence que la gestion sociale « *glisse entre les mains d'un groupe d'actionnaires cohérent et organisé qui prend en charge*

1 – C. Resteau, *Traité des sociétés anonymes*, T. II, 1982, n° 887.

2 – A. Benoit-Moury, note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.*, p. 390.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 202, ID 11305.

4 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 210.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

les destinées de la société et ne détenant qu'une faible participation dans son capital. La démocratie que le législateur a entendu assurer à l'assemblée s'est muée en oligarchie de fait »[1].

SECTION V
LES MODIFICATIONS DES STATUTS EN COURS D'EXISTENCE DE LA SOCIÉTÉ

La modification des statuts consiste en une décision qui a pour objet d'amender certains éléments du contrat de société, du pacte originaire tel qu'arrêté lors de l'assemblée de constitution ou encore de celui arrêté par la suite.

Autrefois, cette matière était dominée par la « **théorie des éléments essentiels** » selon laquelle la modification des statuts, même adoptée à l'unanimité, ne pouvait porter sur des « éléments essentiels » sans que ceci n'entraîne une dissolution de la société et la constitution d'une société nouvelle. Il s'agissait de l'objet social, la forme de la société, la nationalité[2].

Cette théorie était considérée en Belgique comme s'inscrivant à l'encontre de la conception contractuelle de la société, dans la mesure où elle s'oppose à ce que lesdits éléments essentiels puissent être modifiés, même sur la base de l'accord unanime des associés, sans qu'il se produise une solution dans la continuité de la personne morale[3].

La théorie des éléments essentiels a été progressivement abandonnée en Belgique, évolution également suivie au Luxembourg où, depuis la loi du 7 septembre 1987, la transformation d'une société commerciale en une autre forme de société commerciale peut se faire sans donner lieu à une personnalité morale nouvelle. La même solution a été retenue à l'égard du changement d'objet social. L'**arrêt *Lamot*** a finalement consacré la possibilité pour une société de changer sa nationalité par transfert de son siège (voir p. 273).

Ces modifications, lorsqu'elles sont décidées à la majorité, soulèvent un problème de fond. « *La majorité des actionnaires peut-elle changer les conventions sociales et imposer sa volonté à la minorité ? Assurément, d'après le droit commun, aucune modification ne pourrait être faite que du consentement de tous les associés. Le contrat existe, il fait loi entre les parties et ne peut être rompu que par un accord unanime. Cette rigueur, on le voit sans peine, se concilierait mal avec l'organisation des sociétés anonymes. Celles-ci comprennent généralement un nombre considérable de membres et, dans la plupart des cas, il serait fort difficile, sinon impossible, d'obtenir le consentement de tous à des modifications que l'intérêt général peut commander. Faut-il donc condamner la société à subir à jamais, par suite du mauvais vouloir ou de la négligence de l'un des actionnaires, des clauses dont l'expérience lui aurait montré les inconvénients, ou la continuation d'opérations désastreuses que les pertes subies lui commanderaient de clore. Telle est cependant la solution du Code de 1808 aussi bien que sous la loi française de 1867. Dans le silence de la loi, la jurisprudence a maintenu le droit commun, en décidant que nulle modification*

1 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 253.

2 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 260.

3 – I. Corbisier, *Droit des sociétés. Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, p. 419.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ne peut être faite que du consentement unanime des actionnaires, sauf disposition contraire dans les statuts »[1]. De nos jours, toutes les législations concèdent le droit à l'assemblée générale de changer les statuts à certaines conditions de majorité (sans exiger l'unanimité).

L'acte de société, qu'il s'agisse d'un contrat (ce qui reste toujours le cas général) ou d'un acte unilatéral (cas de S.A. et de la S.à r.l. unipersonnelle), contient un certain nombre de données qui, tout en connaissant en général une grande stabilité, font l'objet de changements au moins de temps à autre, par exemple afin de s'adapter au monde de la concurrence. Il s'agit notamment des données suivantes :

– le siège statutaire ;
– la forme de la société ;
– les organes de gestion ;
– les organes de representation ;
– le montant et la monnaie du capital social ;
– etc.

■ § 1 – Le caractère évolutif de l'acte de société

De nos jours, toutes les stipulations du contrat de société peuvent faire l'objet de modifications. Il n'en a pas toujours été ainsi.

A – Généralité des modifications des statuts

En effet, par le passé, il était admis qu'un certain nombre de données des statuts ne pouvaient pas être modifiées. Tel était notamment le cas de l'objet social qui faisait partie des **bases essentielles** du contrat de société. L'avant-projet Nyssens contenait également des limites quant aux possibilités de changer l'objet essentiel de la société. La modification de cet objet serait interdite pour la raison que « *celui qui s'est engagé dans une société pour l'exploitation d'un haut fourneau ne peut être contraint de voir ses fonds consacrés à ériger une filature de coton ; celui qui a confiance dans le rapport d'un chemin de fer ne doit pas, sans son consentement, se voir intéressé dans un canal ou dans un chemin de fer autre que celui qu'il a voulu créer. Dans des cas semblables, il y aurait non pas modifications des statuts mais destruction d'une société première pour y substituer une autre dont l'objet sera complètement différent. C'est ce qu'une majorité ne doit pas pouvoir faire* »[2].

La situation en France était fort similaire à celle décrite ci-dessus pour la Belgique. Toutefois, le législateur français, dans sa session de 1906, devait reprendre cette question pour se prononcer en faveur de la solution comportant également la possibilité de changer l'objet social au moyen d'une majorité qualifiée en ne demandant donc plus l'unanimité des associés. Cette solution devait être reprise par la loi luxembourgeoise de 1915[3].

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 202, ID 11305.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 206, ID 11305.

3 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport de la commission spéciale, p. 301, ID 9792.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

B – Formalités de la modification

En cas de modification de ces données, les mêmes formes que celles initialement prévues lors de la constitution de la société doivent être respectées (principe de la **correspondance des formes**). Aux termes de l'article 100-12 (anc. art. 11) L.S.C., « *[T]oute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte de constitution de la société* ». Cette disposition n'exige pas la même forme que celle qui en fait a été employée, mais elle exige la même forme que **celle qui est requise à cet effet**. Il en résulte donc que, si une société en nom collectif a été constituée par acte notarié (alors que la forme requise n'a été que celle d'un acte sous seing privé), la modification de cet acte peut être faite par un simple acte sous seing privé[1].

Il faut donc un acte notarié pour les sociétés de capitaux. Les conditions de majorité sont différentes d'une forme de société à l'autre. Notons que les conditions de quorum et de majorité qui sont prévues par la L.S.C. sont des conditions minimales. Les statuts peuvent prévoir des conditions plus exigeantes que celles y prévues. En revanche, une disposition statutaire qui permettrait la modification des statuts d'une S.A. à une majorité allégée, par exemple la majorité simple, ne serait pas acceptable.

Le législateur peut faire exception à cette obligation d'acte notarié pour procéder à des modifications des statuts. Ainsi, lors du **passage vers l'euro**, la conversion du capital social en euro était soumise à des dispositions spéciales permettant la modification du capital par décision formelle à prendre sous seing privé. La loi du 10 décembre 1998[2] permettait aux entreprises de procéder à la conversion de leur capital social exprimé dans une des devises d'un des États membres ayant adopté la monnaie unique pendant la période s'écoulant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. À cette occasion, il pouvait être procédé à une augmentation de capital portant au maximum sur 1000 euros ou 4 % du montant du capital souscrit avant l'augmentation de capital. Cette faculté concernait également les autres montants exprimés dans les statuts de la société. La décision de convertir du capital social (combinée à une augmentation de capital) était prise par l'assemblée générale ou encore par les associés.

Notons encore que l'acte constitutif de la société comprend en fait deux sortes de données que la pratique d'autres États, notamment anglo-saxonne, distingue soigneusement. Il s'agit en effet de la distinction entre « *articles of incorporation* » et « *articles of association* », ou encore, dans la terminologie des directives européennes, « acte constitutif » et « statuts », s'ils font l'objet d'actes séparés[3]. Parmi les données reprises dans l'acte constitutif, on trouve les données concernant la souscription du capital social par les associés fondateurs, la composition du bureau, etc.

En revanche, les dispositions relatives au fonctionnement des organes, l'approbation des comptes, la répartition des bénéfices, etc. concernent le fonctionnement de la société et font donc partie des « *articles of association* ». Seules les modifications de ces données doivent être soumises aux procédures assez lourdes de la modification des statuts (acte de société).

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 36, ID 11308.

2 – Loi du 10 décembre 1998, ID 9595.

3 – Article 2 (1) de la Première directive, 68/151/CEE.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En principe, toutes les stipulations de l'acte de société peuvent faire l'objet d'un amendement par une décision ultérieure prise à la majorité qualifiée requise. La seule limitation est que les **engagements** des associés à responsabilité limitée **ne peuvent être augmentés.** Il est entendu qu'une telle augmentation des engagements est possible, mais elle suppose **l'unanimité** des associés. Jusqu'en 2016, il en allait de même des changements de nationalité de la société, également soumis à l'unanimité des associés[1]. Les deux points sont quelque part liés : un changement de nationalité qui a pour effet d'assujettir la société à des règles fondamentalement différentes peut avoir pour effet d'augmenter les engagements des associés. Il était donc défendable d'exiger l'unanimité, même si l'on peut avancer que cette exigence n'a pas de raison d'être dans les cas où le changement concret n'a pas pour effet une augmentation des engagements des associés : il se peut que ces engagements ne changent pas, voire qu'ils soient moindres sous la nouvelle législation de la société.

Une autre limitation est celle des **droits acquis** des associés. L'assemblée ne peut toucher aux droits acquis des associés sauf, bien entendu, si les associés concernés sont d'accord[2]. Comme on a pu le dire, lorsqu'il n'y a qu'une catégorie d'actions, la situation est très nette. L'assemblée n'est limitée que par le respect des droits acquis, dont la L.S.C. ne parle même pas, puisqu'il s'agit d'une règle générale du droit. Ne sont pas visés tous les droits individuels dérivant de la qualité d'associé, « *tombant comme tels sous l'exercice et la protection de l'action* pro socio*, mais uniquement ceux de ces droits qui sont accordés par le contrat social à certains associés, à l'exclusion des autres et qui créent ainsi dans le chef de leurs bénéficiaires des intérêts propres et spéciaux, distincts de ceux de leurs co-associés* »[3].

« *L'assemblée générale compétente, en sa qualité d'organe de la collectivité, de représentant légal des actionnaires* ut universi*, pour statuer sur les intérêts communs, sur les droits qui apparaissent les mêmes pour tous, voit sa souveraineté disparaître lorsqu'il s'agit de prononcer entre des intérêts opposés, se présentant* ut singuli »[3]. L'assemblée générale a donc uniquement les pouvoirs de modifier les droits collectifs, sans pouvoir toucher aux droits individuels.

Il en résulte que, si les statuts accordent un droit ou un avantage particulier à un associé ou à un tiers, la majorité ne peut pas revenir sur cette décision et le lui retirer. Cette notion de droits acquis n'est pas clairement définie et n'a pas manqué de donner lieu à des controverses. Pour certains, le pouvoir de l'assemblée serait limité lorsque sont en cause les « avantages particuliers » conférés par les statuts à l'un ou l'autre actionnaire. Cette conception semble confirmée par une citation de Pirmez : « *C'est dans la communauté d'intérêts que l'assemblée trouve son pouvoir de décider ; le droit de l'assemblée existe, quand la question posée a pour tous ceux qui délibèrent les mêmes conséquences, et il disparaît s'il y a des intérêts divergents* »[4]. On en déduit que l'assemblée ne peut prendre que les décisions qui répondent de l'intérêt de la société, c'est-à-dire de l'intérêt *commun* de tous les associés[5].

---

1 – La Loi de Modernisation a assimilé les changements de nationalité à n'importe quel autre changement des statuts.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 204, ID 11305.

3 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, C. de Wiart, p. 369.

4 – E. Pirmez, « Notes posthumes », *R. P.S.*, 1891, p. 274.

5 – Cass. b. du 5 juin 1947, *R.C.J.B.*, 1947, note J. van Ryn, p. 18.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les modifications peuvent être d'importance plus ou moins grande : elles peuvent consister à transformer la forme de la société ou à changer sa dénomination ou encore son siège social. Pour les changements de forme, ceux-ci peuvent avoir pour conséquence qu'un associé ayant au départ une responsabilité limitée, dorénavant subisse une responsabilité illimitée : l'unanimité sera donc requise. Le changement dans le sens inverse se traduit bien évidemment par une diminution des engagements des associés.

L'article 100-3 L.S.C. précise que n'importe quelle société commerciale peut (sauf indication contraire prévue par les statuts) changer de forme pour adopter l'une des autres formes de sociétés énumérées par l'article 100-2 L.S.C. (à l'exception de la forme de la S.à r.l-S.). La même faculté est ouverte aux sociétés civiles qui peuvent donc devenir commerciales par la suite. Tous ces changements n'emporteront pas la constitution d'une personnalité juridique nouvelle.

■ § 2 – Nécessité d'une décision de l'assemblée générale

La question de savoir s'il peut y avoir modification du siège social par simple décision du conseil d'administration a donné lieu à quelques décisions jurisprudentielles. En l'occurrence, les statuts avaient prévu que le siège statutaire de la société pourrait être transféré à n'importe quel autre endroit du Luxembourg par simple décision du conseil d'administration. Pour les juridictions, une telle modification (consistant dans le transfert du siège social de Luxembourg à Esch-sur-Alzette) constituait une modification des statuts. Une telle modification exige un acte notarié[1].

Le siège social, dans la mesure où il est indiqué dans les statuts, ne peut être changé que par décision de l'assemblée des associés. Afin d'échapper à cette formalité assez lourde, il est préférable que les statuts ne mentionnent que la commune du siège social, ce qui permet de modifier le siège social par simple décision du conseil d'administration. La Loi de Modernisation a étendu cette faculté à toutes les modifications de siège ayant lieu au Luxembourg.

■ § 3 – Transferts de siège

La question du transfert de siège rejoint une autre question plus fondamentale, à savoir celle de la « nationalité » des sociétés.

Dans de tels cas, on applique donc (au Luxembourg du moins) les règles du « **siège réel** » auxquelles on accorde une portée bilatérale, tout en acceptant que, si la loi du siège adopte le rattachement à la loi de l'« **incorporation** », un renvoi puisse être fait à cette dernière, ce qui évite donc les conflits négatifs[2].

A – La nationalité des sociétés

C'est un débat classique en doctrine de savoir si les sociétés ont ou n'ont pas de nationalité. Selon Niboyet, la nationalité est et ne peut être qu'un lien juridique

1 – TA du 21 mai 1986, I, S.A., cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 15.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

et politique entre l'individu et l'État, alors que l'allégeance des personnes morales – que la jurisprudence d'avant 1914 qualifiait improprement de « nationalité » – est une notion purement juridique dont la Première Guerre mondiale devait révéler les insuffisances et les dangers[1].

Pour Niboyet, toute société n'est qu'un contrat, et il n'y a pas d'avantage possibilité de parler de nationalité pour une société que pour une vente, un bail ou une créance. Ce serait par abus de langage que l'idée de nationalité s'est fait jour[2]. On peut noter que le débat sur la nationalité devient ainsi un corollaire du débat portant sur la nature contractuelle ou institutionnelle de la société.

En droit positif, on peut retenir que la loi luxembourgeoise retient la nationalité de la société en indiquant dans son article 159, alinéa 2 : « *Lorsqu'une société a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de nationalité luxembourgeoise […]* ».

Par le terme de nationalité, on entend définir les attaches d'une société avec un ordre politique déterminé, et ceci, pour les besoins de certaines règles telles que la protection diplomatique, la discrimination à l'égard de sociétés qui ont une majorité d'associés ennemis, etc.[3].

« *Ce qu'on appelle par un raccourci commode mais impropre, la nationalité de la société, c'est, de façon plus précise, la loi nationale à laquelle elle est rattachée. Il ne s'agit donc pas de conférer à la société-personne morale les prérogatives qui, pour les personnes physiques, découlent de la nationalité. La loi nationale de la société est la loi qui détermine les conditions de son existence et de son fonctionnement* »[4].

Par nationalité d'une société commerciale, on entend « *le lien qui rattache l'être moral au pays dont la loi régit les statuts* »[5]. Il s'agit donc de définir les critères de rattachement[6]. Il faut déterminer un facteur de rattachement pour désigner la ***lex societatis***. La *lex societatis* est définie comme le corps de règles qui régit la constitution, le fonctionnement interne et externe ainsi que la dissolution des sociétés[7].

Plusieurs approches alternatives sont possibles à cet égard. La définition de la nationalité de la société peut être abandonnée à la **liberté contractuelle** (comme dans tout contrat, les parties détermineraient quelle est la loi applicable à la société : ce choix serait en principe à reconnaître, sauf fraude à la loi).

Une deuxième théorie voudrait que la *lex societatis* soit déterminée par la majorité des associés ou encore de la prépondérance des capitaux engagés : il s'agit de la **théorie du contrôle**. Une troisième théorie considère que le critère décisif est celui du **lieu de la rédaction de l'acte** constitutif. Enfin, cette loi de rattachement peut se déterminer par le lieu du **principal établissement (« siège réel »)**[8].

---

1 – J.-P. Niboyet, « Existe-t-il vraiment une nationalité des sociétés ? », R. 1927, p. 402.

2 – L. Levy, *La nationalité des sociétés*, Paris, LGDJ, 1984, p. 34.

3 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 10.

4 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 170.

5 – J. van Ryn, « Conséquences du transfert en Belgique du siège social d'une société étrangère et du transfert à l'étranger du siège social d'une société belge », *R.C.J.B.*, 1966, p. 399.

6 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 9.

7 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 11.

8 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 384, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En fait, de nos jours, ce sont surtout les troisième et quatrième théories qui s'affrontent, même s'il est vrai que la théorie du contrôle est de temps à autre invoquée, surtout en matière fiscale ou en temps de guerre. On a pu constater que, pendant les deux dernières guerres mondiales, les pays belligérants avaient pris des mesures à l'égard non seulement des sociétés ayant la nationalité d'un État ennemi, mais encore des sociétés qui, tout en ayant la nationalité d'un État tiers ou encore de cet État même, étaient contrôlées par des nationaux d'États avec lesquels cet État était en guerre(1).

La théorie du lieu de l'incorporation est originaire de l'Angleterre du XVIIIe siècle et elle avait pour conséquence de permettre la constitution de sociétés actives à travers le monde(2). Le système est toujours appliqué par le Royaume-Uni et notamment encore par tous les États américains, avec toutefois des différences pratiques tout à fait notables.

Certains États, et parmi ceux-ci en premier lieu celui du **Delaware**, appliquent ces règles de façon très pure, dans le sens que l'État du Delaware impose aux sociétés étrangères actives sur son territoire uniquement une obligation de publicité et certaines règles de compétence des tribunaux.

En revanche, pour les États économiquement importants comme New York et la Californie, le rattachement à la loi de l'État d'incorporation est moins strict dans le sens que ces États font une place importante à l'application de la loi locale aux sociétés constituées dans un autre État, mais qui sont actives sur leur territoire. Le résultat est que les États visés appliquent leurs propres règles aux sociétés qui ont des liens d'affaires substantiels avec l'État visé.

Pour la L.S.C., le facteur de rattachement retenu est l'« administration centrale » (autrefois le principal établissement), donc le siège réel ou effectif.

Cette solution est retenue par l'article 1300-2, alinéa 2 [anc. art. 159, alinéa 2] L.S.C. qui, par une modification introduite par la loi du 31 mai 1999, retient que « *lorsqu'une société a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement appliquée* ».

Cette solution doit être bilatéralisée en principe : « *pour le juge belge, la société dont le siège social est situé à l'étranger est donc soumise à la loi de ce pays même si l'acte constitutif a été passé en Belgique (cf. Cass. 12 avr. 1988, Pas. 1988, I, p. 186, […]* »(3).

Le rattachement au **siège réel** consiste à appliquer à une société le droit de l'État sur le territoire duquel elle a son principal établissement ou son administration centrale(4).

La **théorie de l'incorporation** consiste à appliquer à la société la loi du lieu de sa constitution, généralement par l'enregistrement ou le dépôt de l'acte constitutif qui doit en principe correspondre au siège indiqué dans les statuts(4).

Le Luxembourg fait partie du groupe des pays à siège réel (voir article 1300-2 L.S.C.) :

« *Toute société dont l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l'acte constitutif ait été passé*

1 – Fr. Rigaux et M. Fallon, *Droit international privé*, T.II, *Droit positif belge*, Larcier, 1993, p. 743.

2 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 23.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 170.

4 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 13.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

en pays étranger […] »). Cette règle s'applique non seulement au moment de la constitution, mais encore en cas de transfert subséquent du siège réel et, en plus, elle s'applique de manière bilatérale (il en va de même en droit belge[1], voir ci-dessus).

La coexistence de ces deux règles donne lieu à des difficultés pour la raison que les pays à siège réel peuvent être enclins à ne pas reconnaître la personnalité des sociétés constituées dans des États qui appliquent la loi du lieu de constitution. Ceci constitue un des points faibles de cette approche, à savoir la non-reconnaissance d'une société valablement constituée pour bon nombre de juridictions[2].

Il résulte également de cette disposition que les sociétés établies dans un pays étranger sont régies par les lois de ce pays, pour ce qui concerne leur existence, leur organisation et leur fonctionnement. Ceci n'exclut pas que leur personnalité soit reconnue par le droit luxembourgeois et que ces sociétés puissent acquérir des droits et contracter des obligations tout comme elles peuvent ester en justice au Luxembourg[3].

La théorie de l'incorporation peut revendiquer certains avantages, notamment du point de vue de la sécurité juridique. La loi d'incorporation est facile à déterminer, alors que cette détermination peut être très difficile pour le siège réel qui repose en réalité sur l'appréciation d'un élément de fait[4].

À l'inverse, il est souvent considéré que la méthode d'incorporation peut inciter les fondateurs d'une société à la soumettre à une loi différente de celle où elle exerce son activité afin d'échapper ainsi indûment aux dispositions impératives de l'État auquel la société est économiquement le plus étroitement rattachée[5].

La théorie du siège réel peut avoir des conséquences désastreuses au cas où il y a divergence entre la loi de constitution et celle du principal établissement du fait d'un déplacement volontaire de ce principal établissement notamment par la tenue fréquente des réunions des organes sociaux en dehors du pays d'incorporation. La conséquence peut en être la nullité par rapport à la loi du siège réel[6].

Les transferts de siège sont à envisager dans les deux directions, à savoir donc du Luxembourg vers l'étranger, d'abord, et de l'étranger vers le Luxembourg, ensuite.

La réalisation du changement de la *lex societatis* se fait donc par simple transfert de siège.

De tels transferts sont devenus fort fréquents au cours de ces dernières années. La préoccupation majeure est celle de garantir la **continuité de la personnalité morale**. Afin de garantir ce résultat, il faut que tant l'État d'origine que l'État d'arrivée reconnaissent cet effet.

---

1 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 17.

2 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 15.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 675, au sujet de l'article 196 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ID 7520.

4 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 39.

5 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 38.

6 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 40.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

B – Les changements de nationalité

Le transfert du siège social d'un pays à l'autre n'équivaut pas à la dissolution de la personne morale, quand les deux lois compétentes admettent que cette personne survit au transfert de siège. Cette condition est une condition absolument nécessaire dans le sens suivant : si la société est dissoute dans le pays de départ, elle sera nécessairement reconstituée dans le pays d'arrivée, etc.[1]

Telle est encore la solution qui avait été retenue par la **convention de La Haye** concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations étrangères du 1er juin 1956. Son objet tend à la reconnaissance par les États parties de la personnalité juridique acquise par une société, etc. dans les autres États signataires. L'article 3 de la Convention déclare : « *La continuité de la personnalité sera reconnue dans tous les États contractants, en cas de transfert du siège statutaire de l'un des États contractants dans un autre, si cette continuité est reconnue dans les deux États intéressés* ».

Envisageons les deux cas possibles de transfert de siège :

1) Transfert du Luxembourg vers l'étranger

Le droit étranger désigné par le siège réel s'applique en principe aux sociétés qui ont leur principal établissement à l'étranger. Une société qui transfère son principal établissement dans un État appliquant le critère du siège réel est régie par le droit de ce dernier État[2].

Un tel changement de siège, qui emporte donc changement de nationalité, suppose une décision par une assemblée générale extraordinaire prise à une majorité renforcée, à savoir l'unanimité avant la Loi de Modernisation (anc. art. 67-1 L.S.C.), et à une majorité normale d'une assemblée générale extraordinaire depuis 2016, art. 450-3 L.S.C.

Il n'est de nos jours guère contesté[3] que, du point de vue luxembourgeois, le transfert du siège social vers l'étranger puisse se faire sans rupture de la personnalité morale[4].

2) Transfert de l'étranger vers le Luxembourg

Selon la Cour de cassation belge, lorsqu'une société a valablement, en « *suivant les règles du droit anglais, transféré son principal établissement en Belgique et n'ayant pas cessé ainsi, d'après le droit anglais, d'être une personne juridique, alors elle n'a pas cessé au regard de la loi belge d'être une personne juridique* »[5]. En l'occurrence,

---

1 – V. en ce sens également A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 93.

2 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 13.

3 – Par le passé, l'opinion a été défendue que le transfert du siège vers l'étranger entraînerait nécessairement la dissolution de la société, J. Dupong, « Le changement de nationalité d'une société luxembourgeoise », *Diagonales à travers le droit luxembourgeois*, Livre jubilaire de la Conférence Saint-Yves 1946-1986, Luxembourg, Saint-Paul, 1986, p. 175.

4 – I. Corbisier, *Droit des sociétés. Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, p. 73.

5 – Cass. b. du 12 novembre 1965,, *Pas.,* 1966, I, p. 336.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

il s'agissait d'un transfert d'un État d'incorporation vers un État de siège social, ce qui en fait est le cas le plus facile[1].

Un tel transfert sans rupture de la personnalité sociale suppose que les statuts de la société soient adaptés aux exigences de la loi du nouveau siège social.

Si l'État d'origine de la société est également un État « de siège réel », la société est donc soumise uniquement à la loi luxembourgeoise (en abandonnant ainsi la nationalité de son État d'origine). Les choses se compliquent quelque peu si l'État d'origine est un « État du lieu de constitution ». Dans ce cas, la société garde sa nationalité d'origine tout en étant soumise également à celle de son État de destination : il faudra donc adopter des statuts sociaux qui soient **conformes aux législations** respectives **des deux États** en présence (ce qui peut donner lieu à certaines situations difficiles si les dispositions du droit des sociétés des deux États sont incompatibles ou peu compatibles).

Tel était le cas soumis à la Cour de cassation belge dans l'**affaire *Lamot***[2]. La société Lamot Ltd avait été constituée à Londres le 20 octobre 1927. Elle y avait son siège social tout en exerçant son activité industrielle en Belgique. En 1932, une assemblée générale extraordinaire décida de transférer le siège social en Belgique. « *Cette décision pouvait être prise valablement, selon le droit anglais, et n'empêchait la société ni de subsister comme personne juridique, ni de demeurer soumise aux obligations que le droit anglais impose à toutes les sociétés "incorporées" en Grande-Bretagne. Mais en application de l'article 197, la société se trouvait désormais soumise à la loi belge. Elle a donc dû publier ses statuts au* Moniteur*, après les avoir rendus conformes aux dispositions impératives de la loi belge* »[3].

La durée de la société, qui était illimitée sous le droit anglais, était ainsi **limitée à trente ans**. La question soumise était de savoir quel était le point de départ de ce délai : le jour de la constitution ou le jour du transfert du siège en Belgique ? La Cour de cassation optait pour la deuxième solution, qui était la plus favorable en vue de la survie de la société.

Cet arrêt est fort important pour la raison qu'il consacre en droit belge (et par ricochet, en droit luxembourgeois) la continuation de la personnalité morale en cas de transfert de siège. Mais il faut se garder de conclusions hâtives. Cet arrêt a été pris dans une situation spécifique, à savoir le transfert du siège d'un État d'« incorporation » vers un État à « siège réel »[4]. La question était donc de savoir si la société, désormais régie par le droit belge était une société nouvelle prenant la succession de la société ancienne, celle de droit anglais.

En définitive, la réponse à la question de savoir s'il y a **continuité** de la **personnalité morale** dépend non seulement du droit d'un État, mais du droit des deux États en présence : l'État d'origine et l'État d'accueil.

Compte tenu du fait qu'en droit anglais un tel transfert était autorisée sans entamer en rien la personnalité morale reconnue par le droit anglais et qu'en même

1 – Fr. Rigaux et M. Fallon, *Droit international privé*, T. II, *Droit positif belge*, Larcier, 1993, p. 753.

2 – Cass. b. du 12 novembre 1965, *Pas.*, 1966, I, p. 336, *R.C.J.B.*, 1966, p. 392, note J. van Ryn.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1966-1971) », *R.C.J.B.*, 1973, p. 570.

4 – Cass. b. du 12 novembre 1965, *R.C.J.B.*, 1966, note J. van Ryn, p. 400.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

temps aucune disposition de la loi belge ne conduit à la conclusion que le transfert en Belgique d'une société étrangère donne nécessairement lieu à la constitution d'une société nouvelle, la solution était donc acquise dans le cas d'espèce.

La doctrine belge devait déduire de cette décision que, si la situation était inverse, donc qu'il s'agissait du transfert d'une société belge vers le Royaume-Uni, alors on aurait dû « *[…] constater qu'en réalité une telle décision équivalait à la dissolution de la société et à la constitution, entre les associés qui avaient pris la décision contestée, d'une société nouvelle. Celle-ci, en raison même de la localisation de son siège, devrait être considérée en Belgique comme une société étrangère ; la régularité de sa constitution et sa capacité seraient, aux yeux du droit belge, appréciées d'après la loi du pays où le siège serait désormais établi* »[1].

Dans une affaire tranchée par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, une société italienne de la forme d'une S.p.A. avait, en date du 9 janvier 2002, décidé par une assemblée générale le transfert de siège au Luxembourg, décision entérinée par une assemblée générale tenue au Luxembourg en date du 11 mars 2002.

Le tribunal jugea : « *Force est de constater qu'il n'y a pas eu constitution d'une nouvelle société A de droit luxembourgeois, mais que la société S.p.A. A a transféré son siège social à Luxembourg […]* »[2].

C – Les conflits de nationalité

La coexistence sur un plan international de deux systèmes différents attribuant la nationalité peut conduire (et conduit effectivement dans de nombreux cas) à des **conflits** positifs ou négatifs **de nationalité**. Un conflit positif existe lorsqu'en vertu de leurs règles nationales deux États considèrent que la société possède leur nationalité. Un conflit négatif existe lorsqu'un système conduit au choix d'une loi dont la compétence est refusée sur la base de l'autre système.

Tel est le cas d'une société luxembourgeoise qui transfère le siège effectif aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni (États adhérant à la « *theory of incorporation* »). Dans un tel cas, la loi luxembourgeoise donne compétence à la loi de l'État de destination ; toutefois, la loi de cet État rejette cette attribution. Selon ses règles, le Luxembourg sera l'État compétent. Pour résoudre ce conflit, on prend recours à la notion de la **théorie du renvoi**.

Cette notion signification que, si une règle de conflit désigne une loi applicable étrangère, il convient de se référer non seulement au droit interne de cet État étranger, mais encore aux règles de droit international privé de cette loi étrangère, concrètement aux **règles de conflit** de cette loi étrangère. « *Il en résulte que les règles de conflit de cette loi étrangère peuvent conduire à l'application d'une autre loi à laquelle il est ainsi renvoyé* »[3]. La loi luxembourgeoise renvoie donc à la loi anglaise qui, dans ce cas, renvoie à la loi luxembourgeoise (mais pourrait renvoyer à la loi d'un État tiers) ; c'est la loi désignée par les règles de conflit étrangères qui sera donc appliquée.

La théorie du renvoi est surtout appliquée en matière de capacité de personnes physiques, mais elle a été expressément acceptée en matière de sociétés. La Cour

1 – Cass. b. du 12 novembre 1965, *R.C.J.B.*, 1966, note J. van Ryn, p. 400.

2 – TA com. du 6 mars 2002, n° 73.057, *BIJ*, 2005, n° 7, p. 125.

3 – R. Prioux, « L'article 197 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales [ID 7520], disposition méconnue de droit international privé belge », *R.G.D.C.*, 1989, p. 483.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

d'appel de Paris[1] a eu l'occasion d'en confirmer l'application dans l'affaire ***Banque Ottomane*** qui avait été constituée en Turquie, mais dont le siège réel se trouvait à Londres. La Cour d'appel de Paris a confirmé l'application de la loi turque, à la suite du renvoi effectué par la loi anglaise à cette loi turque (en tant que lieu de constitution)[2].

La loi applicable étant ainsi déterminée, il reste à décider quel est son champ d'application. La *lex societatis* régit les conditions de constitution, de fonctionnement, de dissolution (en particulier, la personnalité morale, la capacité d'agir en justice, les pouvoirs des organes, les droits et devoirs des actionnaires). Échappent à la *lex societatis* certaines questions liées aux apports en nature, à la responsabilité des administrateurs, à l'activité des sièges d'opération et des succursales[3].

D – Théorie du siège réel et droit européen

Quelle est la position du droit communautaire sur le choix de l'une ou de l'autre méthode de rattachement ? En réalité, le traité CE ne se prononce ni en faveur de l'une ni en faveur de l'autre théorie. Toutefois, la CJCE précise que ces méthodes ne doivent pas avoir pour effet d'apporter des limites inacceptables aux **libertés fondamentales**, en fait donc à la liberté d'établissement. De ce point de vue, la théorie de l'incorporation semble avoir un net avantage par rapport à la théorie du siège réel[4].

Une affaire soumise au Conseil d'État belge[5] nous permet de décrire la problématique. En l'occurrence il s'agissait d'une requête introduite par une société belge contre le retrait des autorisations administratives utilisées pour l'exploitation d'une entreprise de transport. L'administration belge avait retiré ces autorisations au motif qu'elle soupçonnait la société d'avoir déplacé son siège réel aux Pays-Bas. Sur fondement de ce même motif, elle contestait la validité de la requête en annulation de sa décision, en affirmant que la société requérante n'établissait son existence ni au regard du droit belge ni au regard du droit néerlandais. Le conseil d'État rejetait cette argumentation, arrêtant qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi belge qu'une société qui transfère son siège social à l'étranger cesse d'exister comme personne morale au regard du droit belge. D'autre part, la société ne pouvait pas avoir perdu sa personnalité juridique au regard du droit belge pour en avoir acquis une autre, au motif que le transfert du siège social allégué par l'État belge était purement matériel et n'avait pas été régulièrement décrété par l'organe social[6].

---

1 – Il s'agit de deux arrêts rendus en 1965 et 1984, respectivement CA Paris du 19 mars 1965, *JDI*, 1966, note Goldman et CA Paris du 3 octobre 1984, *Rev. crit. dr. int. pr.*, 1985, p. 526, note Synvet.

2 – R. Prioux, « L'article 197 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, disposition méconnue de droit international privé belge », *R.G.D.C.*, 1989, p. 485.

3 – R. Prioux, « L'article 197 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, disposition méconnue de droit international privé belge », *R.G.D.C.*, 1989, p. 486.

4 – Th. Tilquin, « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998, p. 37.

5 – CE b. du 29 juin 1987, *T.R.V.,* 1988, p. 110 et note K. Lenaerts.

6 – C'est à juste titre que cette dernière affirmation a été critiquée par la doctrine ; v. P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 678, qui font valoir qu'il est erroné de subordonner le transfert de siège à une décision formelle d'un organe social. En effet, c'est la localisation du siège social réel, et non celle du siège social statutaire, qui est décisive et, en cas de divergence entre les deux, c'est le siège social réel qui détermine la nationalité de la société. Ces conclusions valent également pour le Luxembourg.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Plus importante est l'affirmation par le conseil d'État selon laquelle le transfert à l'étranger n'implique pas en soi que la société cesse d'être une personne morale du point de vue du droit belge, en reprenant ainsi une certaine forme de la théorie de la réalité des personnes morales[1].

Cette théorie est en opposition flagrante avec la position de la CJCE qui, dans son arrêt du 27 septembre 1988[2], retient que les sociétés sont des **créatures de la loi nationale**. Elles n'existent qu'en vertu de ces législations qui régissent leur constitution et leur fonctionnement.

Il est à noter que depuis peu la CJCE (dans l'**affaire *Überseering***) considère que du moins certains aspects de la conception du siège réel sont incompatibles avec le droit communautaire, dans la mesure où cette conception revient à refuser à une société constituée dans l'État A (en l'occurrence les Pays-Bas), le droit d'agir en justice dans l'État B (l'Allemagne dans le cas d'espèce), où elle a établi son siège de direction effective[3].

Dans l'**affaire *Inspire Art***, la CJCE a considéré comme non compatible avec le droit communautaire le fait que le droit néerlandais exige qu'une société constituée sous le droit britannique, tout en déployant son activité entière aux Pays-Bas, soit obligée d'avoir un capital minimum selon les dispositions néerlandaises et que le non-respect de ce capital minimum soit sanctionné par la responsabilité indéfinie des associés[4].

La société en commandite simple **Cartesio**[5] constituée en Hongrie avait transféré son siège en Italie avant de demander l'inscription de ce transfert sur le registre hongrois des sociétés. Elle entendait conserver son statut de société de droit hongrois tout en transférant son principal établissement en Italie. Cette demande fut rejetée par les autorités hongroises, au motif que le droit hongrois ne permet pas à une société constituée en Hongrie de transférer son siège à l'étranger en continuant néanmoins à être soumise à la loi hongroise (la Hongrie ayant été un pays à siège réel).

Un tel transfert était considéré comporter la dissolution de la société en Hongrie, puis sa reconstitution dans l'État de destination, soit donc en Italie. Est-ce que cette position du droit hongrois est contraire à la liberté d'établissement ? La CJCE répondit par la négative pour la raison qu'une société créée en vertu d'un ordre juridique national n'a d'existence qu'à travers la législation nationale qui en détermine la constitution et le fonctionnement.

En outre, les conditions du rattachement au territoire national d'une société varient largement d'un État à l'autre, ce que le droit européen reconnaît expressément en son article 48 du traité CE qui se réfère tant au siège statutaire qu'à l'administration centrale et au principal établissement d'une société en tant que liens de rattachement (point 106).

La Cour en déduisit « *qu'un État membre dispose ainsi de la faculté de définir tant le lien de rattachement qui est exigé d'une société pour que celle-ci puisse*

1 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 677.

2 – CJCE du 27 septembre 1988, C- 81/87, *Daily Mail*, ID 11680.

3 – CJCE du 5 novembre 2002, arrêt *Überseering*, C-208/00, ID 11672.

4 – CJCE du 30 septembre 2003, arrêt *Inspire Art*, C-167/01, ID 11668 ; G. Spindler et O. Berner, « Der europäische Wettbewerb um das Gesellschaftsrecht ist endgültig eröffnet », *RIW,* 2003, p. 949.

5 – CJCE du 16 décembre 2008, arrêt Cartesio, C-210/06, ID 20584.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

être considérée comme constituée selon son droit national et susceptible, à ce titre, de bénéficier du droit d'établissement que celui requis pour maintenir cette qualité ultérieurement. Cette faculté englobe la possibilité, pour cet État membre, de ne pas permettre à une société relevant de son droit national de conserver cette qualité lorsqu'elle entend se réorganiser dans un autre État membre par le déplacement de son siège sur le territoire de ce dernier, rompant ainsi le lien de rattachement que prévoit le droit national de l'État membre de constitution » (point 110).

L'arrêt ***Cartesio*** confirme les principes dégagés depuis belle lurette par l'arrêt *Daily Mail and General Trust* (CJCE, 27 septembre 1988, 81/87), qui accordait aux États membres le droit de valablement s'opposer à la reconnaissance d'un transfert de siège dans les conditions qu'ils déterminent sans porter atteinte à la liberté d'établissement (dans ladite affaire, l'intérêt du transfert du siège aux Pays-Bas était exclusivement de nature fiscale. Dans l'affaire *Cartesio*, l'avocat général, soutenu par la Commission européenne, avait proposé à la Cour de conclure à l'incompatibilité du droit hongrois avec l'article 43 CE (conclusions Poiares Maduro présentées le 22 mai 2008).

La Cour réaffirme le droit de tout État membre de définir les critères de détermination de la *lex societatis* ainsi que les conditions requises pour maintenir le lien de rattachement avec cet État. Ce droit inclut la possibilité pour cet État de ne pas permettre à une société de garder la *lex societatis* de cet État si elle transfère son siège à l'étranger (point 110).

Ensuite dans un *obiter dictum* entre-temps devenu célèbre, la Cour ajoute que ce cas de figure est à distinguer de celui d'une société qui transfère son siège vers l'étranger en changeant de cette manière la loi applicable à cette société. Dans un tel cas de figure, cet État membre ne peut exiger de la société qu'elle se mette en liquidation pour ensuite procéder à la réincorporation dans un autre État membre. Une telle exigence constituerait une restriction inadmissible à la liberté d'établissement prévue par l'article 43 du traité (points 111-113).

La CJUE a été saisie de questions préjudicielles dans une autre affaire qui comporte quelques affinités avec *Cartesio*. Il s'agit de la société ***Vale Costruzioni****, Sociéta a responsibilità limitada*[1] inscrite dans le registre de commerce italien en novembre 2000. En février 2006, la société Vale demanda sa suppression dans le registre en procédant à la réincorporation de la société en Hongrie. En novembre 2006, de nouveaux statuts sont adoptés en Hongrie et ceux-ci mentionnent que la société Vale Costruzioni était le prédécesseur de la société hongroise nouvellement constituée. Cet enregistrement fut rejeté par les autorités hongroises au motif qu'il ne serait pas possible pour une société hongroise de spécifier qu'une société étrangère serait le prédécesseur d'une société hongroise nouvellement formée. C'est ce refus qui donna lieu à plusieurs questions préjudicielles posées à la CJUE. Sans aller dans beaucoup de détails, il ne paraît pas évident que cette affaire sera de nature à apporter des éclaircissements importants à cette matière dans la mesure où il s'agit d'un cas assez atypique : une société décide de librement procéder à sa suppression du registre de commerce (sans qu'il soit précisé si la société a été dissoute et liquidée en Italie ou non). Même si les faits de l'affaire ne sont pas très clairs, il semblerait plutôt qu'il s'agisse d'un cas d'une liquidation dans un État suivie d'une nouvelle constitution dans un autre État. Il s'agirait donc d'un cas assez

1 – CJUE du 12 juillet 2012, C-378/10, *Vale*, ID 15877.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

fondamentalement différent des affaires mentionnées ci-dessus, à savoir *Centros*, *Inspire Art*, *Überseering*.

SECTION VI
RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS

Il convient de distinguer la **responsabilité contractuelle** de la **responsabilité délictuelle**.

La société qui s'est engagée à fournir les prestations promises au contrat conclu par le biais de ses organes (ou, le cas échéant, ses mandataires spéciaux) est contractuellement engagée directement pour les fautes commises, le cas échéant, par ces organes dans l'exercice de leur mission. Par ailleurs, l'organe (comme d'ailleurs le mandataire) est directement tenu envers la société du mauvais accomplissement de sa mission[1].

Si le dommage subi par le tiers est imputable à des organes sociaux, alors les fautes des organes sont supposées être celles de la société elle-même, en engageant donc ainsi directement la responsabilité de la société sur la base de l'article 1382 C.c. (et non sur la base de l'article 1384 C.c. comme tel est le cas pour les fautes des commettants de la société, tels les salariés)[1].

Il ne faut pas pousser à l'extrême la théorie de l'organe dans le sens que l'organe n'aurait aucune responsabilité personnelle. En effet, « *[Ê]tre humain, l'organe conserve sa personnalité distincte et responsable non seulement comme "individu", en dehors de sa mission d'organe, mais dans le cadre de cette mission. Ainsi le veulent, d'une part, l'équité, qui ne saurait tolérer que la victime soit frustrée de son action contre l'auteur matériellement responsable sous prétexte que celui-ci n'a agi qu'en tant qu'organe – d'autre part, une vue exacte du mécanisme, en réalité compliqué, de la personnalité morale. La personne morale n'absorbe la personnalité ni de ses membres, ni de ses organes, puisque c'est par eux qu'elle existe et qu'elle fonctionne : elle les met seulement à son service […]* »[2].

Dans une affaire récente, la jurisprudence luxembourgeoise retient que : « *Dans ces conditions, il convient de revenir sur la théorie de l'organe. En effet, dans le cadre du jugement précité, le tribunal, après avoir relevé que cette théorie était susceptible de s'appliquer à la présente espèce dans laquelle est recherchée la responsabilité des personnes physiques ayant qualité de membres du conseil de gérance d'une société à responsabilité limitée, ayant elle-même la qualité d'associé commandité et gérant d'une société en commandite par actions, avait réservée cette question au motif que l'applicabilité de l'article 51*bis *pourrait faire échec à cette théorie de l'organe. Selon la théorie de l'organe telle que consacrée par l'article 12 de la Loi modifiée de 1915, les membres des organes d'une personne morale n'assument aucune responsabilité personnelle pour les actes qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions sociales en engageant directement la personne morale (cf. J-P Winandy, op. cit., page 397-398).*

L'organe de la société étant l'incarnation légale de la société à laquelle il s'identifie, la personne morale est engagée directement par les actes accomplis par son

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 237.

2 – J. Dabin, note sous Cass. du 16 décembre 1848, *R.C.J.B.*, 1949, p. 102.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

organe, ce dernier exprimant directement et immédiatement la volonté du premier. (cf. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Les Personnes, Tome 2, vol. 1, 1990, page 402).

En application de cette théorie de l'organe, la décharge accordée au gérant commandité HELLAS doit nécessairement profiter aux membres de son organe pour autant que ceux-ci ont agi dans le cadre de leurs fonctions, alors qu'en agissant en tant qu'organe de HELLAS, les actes matériellement posés par eux sont les actes accomplis par HELLAS et, en tant que tels, engagent uniquement cette dernière.

L'ensemble des actes posés par les six défendeurs en leur qualité de gérants de HELLAS « du fait de leurs fonctions » sont partant couverts par la décharge, sachant que, même en l'absence d'une telle décharge, ces actes, à les supposer fautifs, auraient tout au plus permis d'engager la responsabilité de HELLAS. HELLAS II n'ayant par ailleurs pas établi, ni même allégué une faute détachable de leurs fonctions dans le chef des six défendeurs, seule susceptible d'engager la responsabilité personnelle des dirigeants d'une personne morale, la demande basée sur les règles de la responsabilité délictuelle doit également être déclarée non fondée »[1].

SECTION VII
DISSOLUTION ET LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS

Les règles instituées par le législateur fondent toutes sur la notion de la personnalité morale qu'elles ont pour effet de faire perdurer pendant le temps nécessaire pour procéder à la liquidation de l'organisme social. Par conséquent, ces règles sont nécessairement inapplicables en matière des anciennes « associations commerciales » (renommées en société en participation et société momentanée), faute de personnalité morale de celles-ci[2].

La conséquence de cette continuation de la personnalité morale pendant la liquidation est que les associés, en raison de la dissolution de la société n'acquièrent aucun droit de propriété sur les avoirs de la société[3]. Quant à savoir quelle est la nature des droits que les associés ont sur le patrimoine social, la réponse est plus difficile. Il peut s'agir d'un **droit de créance classique** ou encore d'un droit d'une nature particulière.

Signalons à cet endroit une importante divergence existant entre les jurisprudences belges et françaises, quant aux effets de la continuation de la personnalité morale. Pour la jurisprudence française, le maintien de la personnalité morale durant la liquidation se justifie à l'égard des tiers, mais non à l'égard des associés. « *On en déduit que les biens sociaux restent la propriété de la société dissoute envers les tiers, mais non dans les rapports réciproques des associés. Leur partage entre ces derniers rétroagit au jour de la dissolution de la société* »[4].

En droit belge, on considère que, si la dissolution affecte la capacité de la société (qui ne peut plus agir que pour les besoins de la réalisation du patrimoine social),

1 – TA Lux. du 23 décembre 2015, n°s 145724 et 145725, ID 24088.

2 – Cass. fr. du 7 février 1881, *S.*, 1881, I, p. 276 ; J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 320, ID 11308.

3 – Cass. du 2 décembre 1952, *R.C.J.B.*, p. 288, note J. Heenen, p. 292.

4 – Cass. du 2 décembre 1952, *R.C.J.B.*, p. 288, note J. Heenen, p. 294.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

celle-ci n'a pas pour effet de signifier que désormais, la société n'aura plus qu'une vie externe « *sous prétexte que sa liquidation ne requiert pas qu'elle existe dans ses rapports avec les associés* »[1].

Un projet de loi déposé en 2003 et dénommé « *projet de loi portant des mesures ponctuelles en matière de prévention des faillites et de lutte contre les faillites organisées* » (n° 5157) avait entendu remédier à cette situation, et ceci, en obligeant les associés s'ils se prononcent en faveur de la continuation de la société de réduire le capital à concurrence de la perte constatée et de procéder à une augmentation de capital, afin que le capital social atteigne à nouveau le minimum légal prévu à l'article 26 (nouv. art. 420-1) L.S.C. Une disposition correspondante était prévue à l'égard des S.à r.l. (article 202-1 du projet de loi visé). Heureusement, ce projet de loi n'a jamais été adopté.

Si une société dissoute continue encore d'exister comme personne morale jusqu'à sa liquidation, « *[…] cette fiction basée sur des motifs de nécessité absolue, doit disparaître avec ces motifs. Cette fiction n'existe donc pas d'une manière générale et absolue mais uniquement du point de vue de la liquidation. En conséquence, et du point de vue des actions des anciens associés, la société dissoute a cessé de durer, et les droits individuels des anciens associés, devenus des communistes, sont substitués au droit de propriété exclusif de la société* »[2].

« *Si la dissolution d'une société met fin à son existence juridique, elle est cependant censée survivre pour les besoins de la liquidation ; il s'ensuit qu'une société en liquidation peut être déclarée en faillite sous son ancienne dénomination et conserve à ces fins le siège social désigné dans son acte constitutif* »[3].

« *[…] la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation. Aussi longtemps que celle-ci n'est pas terminée, la société qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé sera déclarée en faillite, même si plus de six mois se sont écoulés depuis la dissolution et si, pendant ce délai, les liquidateurs n'ont accompli aucun acte commercial […]* »[4].

Si la dissolution de la société met fin à son existence, elle survit néanmoins pour les besoins de sa liquidation. « *Nonobstant la clôture de la liquidation, la société commerciale continue d'exister jusqu'à l'écoulement de la prescription quinquennale pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle* »[5].

« *Si depuis la modification apportée à l'article 179 de la L.S.C. sur les sociétés commerciales par la loi du 28 décembre 1992, la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne plus la dissolution d'une société à responsabilité limitée, il convient de constater qu'en l'espèce c'est avant l'entrée en vigueur de cette loi que P est devenu propriétaire de toutes les parts de la société "et est investi de tout l'actif et de l'intégralité du passif sociaux" […]. L'acquisition par le seul P de toutes les parts sociales de la s.à r.l. F avait entraîné de plein droit la*

1 – Cass. du 2 décembre 1952, *R.C.J.B.*, p. 288, note J. Heenen, p. 295.

2 – Cass. du 13 mars 1901, *Pas.*, III, p. 465, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA Lux. du 18 février 1970, *P.*, n° 21, p. 393, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 18 juillet 1991, n° 40446, ID 10182.

5 – TA Lux. du 15 mai 1992, jgt n° 209/92, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dissolution immédiate de la société et la disparition concomitante de l'être moral. Si selon l'article 141 de la susdite L.S.C. les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation, en l'espèce l'être moral n'avait même pas à survivre pour les besoins d'une liquidation et d'un partage entre les associés qui n'existaient plus. C'est en effet la propriété même des biens composant le fonds social qui selon les stipulations de l'acte de dissolution s'est trouvée directement acquise par le cessionnaire P qui est ainsi devenu débiteur du passif social en tant qu'acquéreur des biens composant le fonds social […] Dès lors que le patrimoine tout entier de la personne morale comportant l'ensemble du passif et de l'actif, des dettes comme des créances, s'est trouvé transféré, ce report de la dette sur la tête du nouveau débiteur, en l'espèce P, a entraîné la libération corrélative du premier débiteur, la société, sans même que soit nécessaire l'accord du créancier […] »[1].

À propos d'une S.à r.l. dissoute suivant un acte notarié mentionnant, au sujet de l'associé dorénavant propriétaire de toutes les parts de la société, qu'il « *se trouve investi de tout l'actif de la société dissoute et répond personnellement de tous les engagements sociaux* » : « *[…] l'acquisition par une seule personne de toutes les parts d'une société entraîne la dissolution de celle-ci, mais non la disparition de l'avoir social, qui demeure dans le patrimoine de la société dissoute mais non liquidée. Cette société conserve sa personnalité juridique dans les limites de l'article 14* »[2].

La nullité de l'acte d'appel d'une S.à r.l. en liquidation condamnée au premier degré envers l'un de ses créanciers était invoquée par le créancier, du fait de l'inexistence juridique de la société dissoute, partie appelante : « *[…] l'article 141 de la L.S.C. […] énonce […]. La règle afférente a pour but de protéger les créanciers sociaux. La société n'est cependant censée exister après sa dissolution que pour la réalisation de l'actif, le paiement du passif et la distribution du solde éventuel. La défense à l'action de la société […] rentre dans le cadre de l'article 141 prémentionné. Il en suit que le moyen de la nullité de l'acte d'appel pour cause d'inexistence juridique de la partie appelante n'est pas fondé* »[2].

« *L'article 143 de la L.S.C. concernant les sociétés commerciales, bien que ne comprenant, à la suite d'une inadvertance du législateur, pas expressément les sociétés à responsabilité limitée est applicable à ces sociétés* »[3]. Cette erreur vient d'être corrigée par le législateur.

« *En vertu de l'article 143, les tiers pourront considérer les gérants en fonction lors de la dissolution de la société comme ayant, à leur égard, la qualité de liquidateurs. L'avantage qui en résulte, pour les tiers, n'est pas de leur permettre d'exercer leurs droits contre la société dissoute mais d'ouvrir à leur profit un recours en responsabilité contre les anciens gérants en cas de faute* »[4].

Une S.à r.l. avait été dissoute sans que des liquidateurs n'aient été nommés, un créancier non payé agissait en responsabilité contre les gérants de la S.à r.l. en leur qualité de liquidateurs, ce que la cour admit sur la base de l'ancien article 143 (nouv. art. 1100-3) L.S.C[5].

---

1 – CA du 28 mars 1996, n° 15.351, ID 10136.

2 – CA du 5 mars 1997, n° 19.932, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 14 juillet 1999, *P.*, n° 31, p. 180.

4 – J.P. Lux. du 12 décembre 1991, LJUS, n° 99114756, ID 10186.

5 – CA du 20 avril 1994, n°s 13.681 et 15.073, ID 10207.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« *À défaut de nomination de liquidateurs, les tiers peuvent, conformément à l'article 143 de la L.S.C., s'en tenir aux dirigeants sociaux qui sont envers eux les garants d'une liquidation de la société ne portant pas préjudice à leurs droits. Ceux-ci ne peuvent échapper à cette garantie en soutenant qu'ils n'ont pas procédé à la liquidation, celle-ci ayant été effectuée et clôturée par les associés au moment de la dissolution de la société*.

En leur qualité de garants, les dirigeants sociaux doivent répondre des fautes commises lors de la liquidation de la société. Constitue une telle faute, le fait de procéder à la répartition de tout l'actif social alors que les créanciers sociaux n'ont pas été intégralement payés, respectivement de procéder à la clôture des opérations de liquidation sans provisionner préalablement une créance litigieuse (Frédéricq, Traité de droit commercial belge, éd. 1950, n° 751 […])»[(1)].

Le tiers agissant contre les dirigeants sociaux garants n'est pas tenu de démontrer l'existence d'un boni de liquidation qui aurait permis de consigner en tout ou en partie le montant réclamé par lui ; la liquidation amiable de la société, qui impose l'apurement intégral du passif, faisant présumer l'existence d'un actif suffisant pour désintéresser tous les créanciers.

La jurisprudence luxembourgeoise définit les pouvoirs des liquidateurs comme suit : « *Les liquidateurs d'une société dissoute représentent seulement celle-ci et non les tiers créanciers sociaux, de sorte qu'ils n'ont pas qualité pour faire valoir des droits propres à ces derniers* »[(2)].

« *Le liquidateur d'une société anonyme n'a pas besoin de l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la société en vue d'exercer l'action en responsabilité pour faute de gestion à l'encontre des administrateurs de la société ; ce faisant, celui-ci ne fait qu'exercer le mandat qui lui a été conféré* »[(3)].

« *Les liquidateurs admettant par conséquent disposer dans le présent litige uniquement de la qualité à agir au nom de la société HELLAS II (et non de la masse de ses créanciers), ce qui se trouve confirmé par le libellé de l'assignation faite à la requête de la société en liquidation "représentée par ses deux liquidateurs actuellement en fonctions", il devient superflu d'examiner plus en avant les différents avis juridiques versés en cause.*

Dans la mesure où la qualité à agir des liquidateurs se trouve cantonnée aux actions intentées au nom et pour le compte de la société HELLAS II, tous les développements des liquidateurs à l'appui de leurs demandes pour autant qu'ils ont trait à une prétendue fraude aux droits des créanciers de la société HELLAS II doivent être déclarés irrecevables en l'absence de qualité à agir au nom de la masse des créanciers.

En revanche, les développements de la requérante ayant trait à une fraude à ses propres droits, voire à une fraude à la loi ne constituent pas une demande nouvelle prohibée et ont d'ores et déjà été déclarés recevables (cf. jugement interlocutoire du 11 décembre 2013, pages 15 et 16) »[(4)].

---

1 – Cour 14 juillet 1999, *P.*, n° 31, p. 184, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 30 juillet 1927, *P.*, n° 11, p. 554, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cass. du 12 juillet 1990, LJUS, n° 99013919, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 23 décembre 2015, n° 145725 du rôle, ID 24088.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'article 1100-4 [anc. art. 144] L.S.C. autorise le liquidateur seul de représenter la société en justice, et il n'appartient pas à un associé d'exercer les actions pour compte de la société en lieu et place du liquidateur[1]. « *Il appartient au seul liquidateur, nommé par le tribunal siégeant en matière commerciale, de conduire les actions judiciaires au nom de la société en liquidation. Le gérant de la société en liquidation est sans pouvoir pour représenter sa société en justice et notamment pour relever appel au nom de ladite société* »[2].

« *D'après l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, le liquidateur seul est qualifié de représenter la société en justice ; qu'il n'appartient pas un co-associé d'exercer les actions pour compte de la société au lieu et place du liquidateur* »[3].

« *L'article 146 de la L.S.C. sur les sociétés commerciales prévoit que liquidateurs sont en droit d'exiger des associés le règlement des sommes qu'ils se sont engagés à verser à la société, non seulement en vue du paiement des dettes et des frais de la liquidation mais également pour la formation de la masse partageable et le règlement des rapports et des droits des créanciers entre eux ; ce droit général est absolu en ce sens que les liquidateurs, érigés en uniques appréciateurs de l'opportunité des versements qu'ils réclament, ont le droit de faire des appels de fonds sans avoir à en établir la légitimité à l'égard des associés et sans que tribunal ait à en contrôler le bien-fondé* »[4]. Il est remarquable que ce droit soit reconnu être absolu. Il est encore à noter que notre droit semble différent du droit belge sur le point que le droit belge ne permet l'appel de fonds que pour le paiement de dettes et de frais de liquidation, alors que le droit luxembourgeois permet cet appel également pour la formation de la masse partageable[4].

L'article 1100-8 [anc. art. 147] L.S.C., en imposant aux liquidateurs l'obligation de payer toutes les dettes non privilégiées proportionnellement, sous peine d'engager leur responsabilité personnelle à l'égard des personnes lésées, montre que le législateur a entendu maintenir l'égalité entre tous les créanciers non privilégiés. Il s'ensuit qu'après la mise en liquidation de la société, la compensation ne peut plus s'opérer entre les dettes et les créances d'un associé envers la société[4].

L'article 1100-8 L.S.C. n'établit pas de responsabilité personnelle des liquidateurs pour les dettes sociales. Ce texte précise simplement l'une des fonctions du liquidateur, celle de payer les créanciers sociaux sur l'actif social qu'il aurait encore entre les mains[5].

Après la dissolution d'une société commerciale, chacun des anciens associés reprend (sauf stipulation contraire), la liberté d'exercer pour son propre compte le commerce ou l'industrie dont l'exploitation avait fait l'objet de la société, et d'entrer en relation avec son ancienne clientèle, à la seule condition de ne pas porter atteinte par des actes de concurrence déloyale au droit similaire des autres associés. La circonstance que l'un des anciens associés renonce à l'exercice de ce droit et que, de ce fait, les autres, voire un seul, profitent exclusivement de la clientèle de la

1 – TA Lux. du 25 février 1950, *P.*, n° 15, p. 9, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 1er juillet 1992, jgt n° 158/92, ID 12327.

3 – TA Lux. du 25 février 1950, *P.*, n° 15, p. 95, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 30 juillet 1927, *P.*, n° 11, p. 554.

5 – J.P. Lux. du 12 décembre 1991, ID 10186.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

société dissoute, ne saurait par conséquent donner lieu à une indemnité quelconque à charge de ceux-ci[1].

« *Attendu qu'en vertu des articles 144 et 149, les liquidateurs d'une société dissoute représentent celle-ci et sont responsables, tant envers les tiers qu'envers la société, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion ; à moins d'établir un comportement fautif du ou des liquidateurs, ou de prouver l'existence d'agissements frauduleux de la part du ou des liquidateurs, l'employé ne saurait agir que contre la société en liquidation qui est seule à condamner au paiement d'arriérés de salaire* »[2].

L'actionnaire minoritaire d'une S.A. où règne la mésentente entre cet actionnaire et l'associé majoritaire tente d'obtenir le remplacement du liquidateur nommé par la majorité, se fondant sur la théorie de l'**abus de majorité**. Cette demande est rejetée par le juge : « *Si le liquidateur non statutaire, tel qu'en l'espèce, est considéré comme un mandataire révocable* ad nutum *la possibilité d'une révocation judiciaire du liquidateur nommé par les actionnaires, n'est généralement pas acceptée en doctrine et en jurisprudence […] La doctrine en Belgique est également partagée, admettant cependant dans sa majorité que les tribunaux peuvent révoquer le liquidateur, nommé par les associés, lorsqu'il y a dol ou violation des statuts, et que l'assemblée générale a repoussé la demande en révocation […]* » (or ni le dol ni la violation des statuts ne furent démontrés en l'espèce)[3].

« *Pendant la durée de la liquidation, le liquidateur n'est pas tenu à fournir des comptes périodiques aux associés ; il doit uniquement soumettre chaque année le résultat de sa liquidation à l'assemblée générale de la société* »[4].

« *Si, en principe, la société commerciale disparaît avec la clôture de la liquidation, cette extinction n'est pas absolue, alors que la société continue d'exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.*

Les liquidateurs sont habilités à représenter la société commerciale dans les actions intentées contre elle par des créanciers sociaux endéans le délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.

Comme, nonobstant la clôture de la liquidation, la société commerciale continue d'exister jusqu'à l'écoulement de la prescription quinquennale pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle, la société en nom collectif doit en pratique et par application de l'article 152 de la L.S.C. concernant les sociétés commerciales être assignée simultanément avec le ou les associés. Au cas où l'action est exercée contre les seuls associés, elle est à déclarer irrecevable »[5].
Cette décision qui prend le contre-pied d'une décision antérieure est importante dans la mesure où elle précise que l'article 1400-1 L.S.C. reste applicable au-delà du moment de la clôture de la liquidation, avec donc la conséquence que la société

1 – TA Lux. du 12 novembre 1927, *P.*, n° 12, p. 78, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – C. arb. Lux. du 17 avril 1985, jgt n° 1171/86, E.

3 – TA Lux. du 13 octobre 1989, n° 38.630, ID 10402.

4 – TA Lux. du 25 février 1950, *P.*, n° 15, p. 95, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – CA du 18 avril 1967, *P.*, n° 20, p. 339, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

doit être assignée en même temps que les associés (et en tout cas pas après l'assignation des associés). La décision a été notamment justifiée par le fait qu'ainsi on évite des contrariétés de jugements[1].

Point n'est donc besoin que les créanciers attendent l'issue défavorable de l'action introduite contre la société. Exiger qu'une telle action s'avère finalement comme infructueuse serait une condition difficilement réalisable en pratique.

Dans un cas d'espèce, la demande en nullité de la clôture de la liquidation d'une société anonyme fut rejetée pour absence de démonstration de fraude dans le chef du liquidateur[2].

Une société en liquidation est représentée exclusivement par son liquidateur. La société survit jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation[3]. À propos d'une société liquidée ayant interjeté appel d'une décision la condamnant : « *La survivance d'une société en liquidation n'est qu'une survivance passive en ce sens que l'individualité juridique n'est fictivement conservée et maintenue que pour l'intérêt et dans la mesure des droits des tiers contre elle. L'être moral est dissous et sans représentant : la société ne peut donc plus agir en justice* ». La société ayant en l'espèce été dissoute et sa liquidation clôturée, il « *s'ensuit qu'en l'absence de personnalité juridique, la société […] ne peut agir activement en justice et interjeter appel* »[4].

Lorsqu'une société en nom collectif a été dissoute et que la clôture de la liquidation a été publiée, les créanciers sociaux n'ont plus à faire condamner la société avant d'obtenir condamnation des associés[5].

Si l'article 1203 C.c. permet au créancier d'une dette solidaire de réclamer le paiement de la dette à celui de ses débiteurs qu'il préfère (donc celui qu'il juge le plus solvable), l'article 1400-1 [anc. art. 152] L.S.C. prévoit en quelque sorte un bénéfice de discussion au profit des associés les empêchant d'être condamnés avant que la société ne l'ait été[6].

Cette règle repose, entre autres, sur la considération que c'est la société en tant que dépositaire des archives de la société qui est de loin mieux armée que les associés individuellement pour mener le débat avec le créancier et pour utilement faire valoir les moyens et les exceptions à opposer à la demande du créancier. Il en résulte encore que si la société est condamnée, l'associé n'est pas admis pour faire valoir de nouveaux moyens ; il ne lui reste qu'à payer en application des principes de la responsabilité solidaire[7].

La règle s'explique encore par la volonté d'éviter la contrariété de jugements. En application de ces principes, il n'est pas nécessaire que la procédure contre la société

1 – CA du 18 avril 1967, *P.*, n° 20, p. 342.

2 – TA Lux. du 4 juin 1981, n° 364/81, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA Lux. du 24 février 1992, LJUS, n° 99215720, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA du 28 avril 1999, n° 21.072, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – TA Lux. du 8 janvier 1958, *P.*, 17, p. 260, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 355, ID 11308.

7 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 358, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

soit terminée avant que ne commence celle dirigée contre les associés. La loi demande simplement que la société soit condamnée en premier lieu avant que le moindre jugement ne puisse être pris contre l'un ou l'autre des associés. Selon la jurisprudence (belge), il est parfaitement possible que les deux actions soient poursuivies dans une seule et même instance et qu'elles soient tranchées par un même jugement[1].

L'article 1400-1[anc. art. 152], qui reproduit l'article 122 de la loi belge de 1873, précise que tous les associés contre lesquels les créanciers sociaux ont une action directe ne sont pas en réalité les débiteurs principaux, mais ne sont obligés que subsidiairement. « *En effet, le débiteur principal, c'est le corps moral, la société. Il est par conséquent rationnel et équitable que la condamnation de la société précède ou du moins accompagne la condamnation de l'associé qui joue en quelque sorte le rôle de caution* »[2].

Si, en principe, la société commerciale disparaît avec la clôture de la liquidation, cette extinction n'est pas absolue, alors que la société continue d'exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation. Les liquidateurs sont habilités à représenter la société commerciale dans les actions intentées contre elle par les créanciers sociaux dans le délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation[3].

L'article 1400-1 pose une règle de fond, mais qui n'est pas d'ordre public[4].

■ § 1 – Particularité d'un seul associé

À cet endroit, il faut encore noter une importante divergence entre le droit belge et le droit français. En droit français, il semble acquis que, lorsqu'en raison d'une cession de droits sociaux il ne reste plus qu'un seul associé, l'être moral disparaît et le cessionnaire devient instantanément propriétaire de tous les biens composant le fonds social[5]. En revanche, l'arrêt de la Cour de cassation belge du 2 décembre 1952 considère que la disparition de l'être moral et le transfert de propriété se font seulement à la clôture de la liquidation.

La jurisprudence luxembourgeoise s'aligne sur la position des juridictions belges. Dans une affaire concernant une S.à r.l. dissoute suivant un acte notarié, la cour d'appel mentionnait, à propos de l'associé dorénavant propriétaire de toutes les parts de la société, qu'il « *se trouve investi de tout l'actif de la société dissoute et répond personnellement de tous les engagements sociaux […] l'acquisition par une seule personne de toutes les parts d'une société entraîne la dissolution de celle-ci, mais non la disparition de l'avoir social, qui demeure dans le patrimoine de la société dissoute mais non liquidée. Cette société conserve sa personnalité juridique dans les limites de l'article 141 (n.d.l.r. L.S.C.)* »[6].

---

1 – *R.P.S.*, 1905, n° 1595, cités par J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 356, ID 11308.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 327, ID 11305.

3 – CA du 18 avril 1967, *P.*, n° 20, p. 339, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 6 décembre 1991, n° 40.743, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cass. fr. du 7 février 1881, *S.*, 1881, I, p. 276.

6 – CA du 5 mars 1997, n° 19.932, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 2 – Caractère automatique du transfert de propriété

La clôture de la liquidation emporte d'office le transfert de propriété vers le ou les associés. « *Les biens composant l'actif net de la société sont entrés dans le patrimoine des défendeurs en raison de la clôture de la liquidation* »[1]. Le transfert de propriété résulte donc d'un mécanisme légal. Point n'est donc besoin d'une convention entre la société représentée par le liquidateur et les associés.

Les associés ne sont pourtant **pas** les **successeurs à titre universel** de la société : ils ne sont que des successeurs à titre particulier, car ils ne sont pas personnellement tenus des dettes de la société[2].

Lorsque la société détient des immeubles, c'est l'acte constatant la clôture de la liquidation qui doit être transcrit[3].

La dissolution, ensemble avec la liquidation, fait partie des événements qui mettent fin à la société, étant entendu que la personnalité juridique ne disparaît pas de façon immédiate. « *La liquidation est l'ensemble des opérations qui, à la suite de la dissolution d'une société commerciale, tendent au paiement des créanciers à l'aide de l'actif social et à la répartition du reliquat éventuel entre les associés* »[3]. Les opérations de liquidation sont en général complexes et prennent un certain temps[4].

Le Code de commerce n'avait pas prévu de dispositions pour le cas de la liquidation des sociétés. On devait vite se rendre compte qu'il s'agissait d'une grave lacune. « *La société qui vient d'un seul coup à sa fin laisse généralement subsister derrière elle – telle une succession à la suite de décès – tout un ensemble de biens, de droits et d'intérêts plus ou moins divers et complexes, issues de cette activité désormais éteinte et dont l'équité comme le droit exigent le règlement méthodique et coordonné* »[5].

« *En droit, la dissolution d'une société détruit l'être moral dans lequel la société se personnifiait, et une simple communauté d'intérêts la remplace. Les conséquences rigoureuses de ce principe seraient graves : chaque associé deviendrait copropriétaire des choses sociales, les actions ne pourraient plus être formées que directement par les associés ou contre eux, les parts sociales perdraient leur caractère exclusivement mobilier, pour prendre la nature des biens possédés en commun ; la transmission des parts pourrait être soumise aux conditions de transmission de ces biens […]* »[6].

Afin de pouvoir réaliser sans difficulté ces opérations de liquidation, et afin de protéger les créanciers sociaux, « *il faut que ces biens, droits et créances ne passent pas immédiatement dans le patrimoine personnel des anciens associés, mais demeurent, au moins provisoirement, groupés en un ensemble distinct* »[7]. Dans le but de garantir ces résultats, le législateur a recouru à la fiction de la survivance de l'être moral,

1 – Cass. du 2 décembre 1952, *R.C.J.B.*, p. 290.

2 – Cass. du 2 décembre 1952, *R.C.J.B.*, p. 288, note J. Heenen, p. 297.

3 – Cass. b. du 8 mai 1930, *Pas.*, 1930, I, p. 202.

4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 2, p. 100.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 313, ID 11308.

6 – E. Pirmez, Commentaire législatif de la loi de 1873, II, p. 75.

7 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 2, p. 101.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

en disposant dans l'article 1100-1 [anc. art. 141] L.S.C. : « *Les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés commerciales momentanées ou les sociétés commerciales en participation, sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. […]* ».

Mais il ne faudrait pas en conclure que rien n'a changé après la décision de dissolution de la société. « *La personnalité ainsi reconnue à la masse de liquidation, par une fiction expresse de la loi, diffère profondément de celle que possédait la société elle-même : c'est uniquement pour la réalisation de l'actif, le paiement du passif et la distribution du solde éventuel qu'elle est censée encore exister* »[1].

La société en liquidation se voit ainsi reconnaître une **capacité limitée** dans le sens que la société n'est maintenue « *que pour les besoins de la liquidation* », ce qui signifie qu'elle ne peut que terminer les opérations commencées sans être à même d'accomplir de nouvelles opérations, même si l'accomplissement de celles-ci se trouvait dans le cadre de l'objet social de la société[2].

Dans quelle mesure une telle société peut-elle agir activement en justice ? Il a été reconnu qu'une société dont la liquidation a été clôturée peut faire appel contre une décision de première instance : « *Il en découle que (la société) conserve sa personnalité juridique pour les besoins du règlement des obligations à caractère social et que le moyen tiré de l'absence de capacité d'agir n'est pas fondé* »[3]. La même décision a néanmoins déclaré l'appel non recevable pour la raison que l'acte d'appel en mentionnant que la société était « *représentée par son gérant actuellement en fonctions* » était mal rédigé dans la mesure où le gérant n'est plus en fonctions à partir du moment où la société est dissoute.

Si la dissolution est en général suivie par la liquidation de la société au cours de laquelle les actifs sont réalisés, les dettes remboursées, etc., il y a parfois dissolution non accompagnée d'une phase de liquidation (**dissolution sans liquidation**). Il s'agit en particulier des opérations de restructuration, telles que les fusions, les scissions, etc. qui sont soumises à des régimes juridiques (et fiscaux) spéciaux. À leur égard, la loi précise régulièrement qu'il s'agit d'opérations comportant « *la dissolution sans liquidation* » des sociétés concernées.

■ § 3 – La liquidation volontaire des sociétés

La loi n'intervient qu'à titre subsidiaire en cas de silence des statuts (art. 1100-2 [anc. art. 142 L.S.C.). En principe, c'est aux intéressés, donc aux associés au moment où s'ouvre la liquidation, qu'appartient la double tâche de nommer les personnes mandatées à procéder à la liquidation et de déterminer la manière dont celle-ci doit se dérouler. Ces décisions sont prises à la majorité dont l'importance dépend du genre de société visée : majorité des deux tiers dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions (la loi renvoie à l'article 450-3 L.S.C.), la **moitié des associés** représentant au moins **trois quarts du capital** pour les S.à r.l. et les S.e.n.c. Pour cette deuxième catégorie de sociétés où la considération des personnalités des associés est dominante, où même

1 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 2, p. 102.
2 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 2, p. 103.
3 – CA du 16 mars 2005, p. 91, ID 11979.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

pendant la durée de vie de la société les organes de gestion ne sont pas nommés par la majorité, on a considéré que la majorité simple serait insuffisante. On a donc eu recours à un système qui emprunte au système du concordat en matière de faillite et qui tient compte à la fois de la personnalité des associés et de la part d'intérêts communs qu'ils représentent. Ceci a conduit au système de double majorité mentionné ci-dessus(1). Pour les sociétés en commandite simple, il faut (sauf dispositions contraires des statuts) la majorité des trois quarts du capital social. Ces règles peu cohérentes mériteraient d'être revues.

Tant une personne physique qu'une personne morale peut faire fonction de liquidateur. Si les associés n'aboutissent pas à un accord sur la personne du liquidateur, alors les tribunaux de commerce procéderont à sa désignation. Si les juridictions sont libres de désigner les personnes de leur choix, il ne faut pas perdre de vue qu'elles n'agissent qu'en lieu et place et finalement pour compte et dans l'intérêt des associés qui sont tout simplement inaptes à trouver un accord sur la personne à désigner. Elles seront donc notamment portées à choisir des personnes qui sont restées étrangères aux dissensions qui peuvent exister entre les associés(2).

Normalement, la liquidation comporte **quatre opérations distinctes** : « *terminer les opérations en cours, réaliser ou faire rentrer l'actif, apurer le passif, et répartir le solde entres les anciens associés* »(3). Si tel est le cas type, il se peut que, dans certains cas, une autre voie soit préférable pour des raisons essentiellement économiques, ce qui peut conduire à la vente en bloc de l'universalité du patrimoine de l'entreprise, ou encore en cas de fusion ou de scission, opérations dont la caractéristique essentielle est la « dissolution sans liquidation ».

Le titre XI (articles 1100-1 à 1100-15, anc. Section VIII, articles 141 à 151) de la L.S.C. est consacré à la liquidation des sociétés commerciales. La dissolution peut arriver en raison de plusieurs événements, dont l'arrivée du terme de la société. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 septembre 1987, les sociétés avaient obligatoirement une durée déterminée qui ne pouvait d'ailleurs pas dépasser trente ans. Cette limitation s'expliquait pour des raisons historiques, largement dépassées de nos jours, à savoir la crainte de la mainmorte(4). Cette limitation a été abandonnée entre-temps, tant en Belgique (en 1984) qu'au Luxembourg (en 1987).

La durée de la société peut donc être **illimitée**. En raison de la prohibition des engagements perpétuels, des règles spécifiques sont applicables en ce cas : celles-ci dépendent de la possibilité pour l'associé de se libérer de la société par une démission ou une cession de parts. Les sociétés civiles à durée indéterminée sont ainsi résiliables à tout moment(5).

Elle peut encore être la conséquence du fait que l'objet spécifique pour la réalisation duquel la société a été constituée a été accompli ou encore que cette réalisation devienne impossible (voir Société du Canal de Suez qui, lors de la nationalisation du canal de Suez, se trouvait sans objet).

---

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 322, ID 11308.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 324, ID 11308.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 136.

4 – A. Benoit-Moury, « Des justes motifs de dissolution des sociétés commerciales de l'article 1871 du Code civil », ID 11337, à l'art. 102 des L.C.S.C., *Liber amicorum Jan Ronse*, Bruxelles, Story-Scientia, p. 160.

5 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 391.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Ce cas est assez fréquent en pratique : interdiction légale, suppression d'une concession administrative, épuisement d'une mine, etc.[1].

La société se trouvant ainsi sans objet social, la dissolution en était donc la conséquence inévitable, sauf à se donner un autre objet, ce qui suppose toutefois l'obtention de la majorité qualifiée requise.

La dissolution peut encore être le résultat d'une décision volontaire des associés : souvent, en raison de la situation non profitable de la société, les associés décident de procéder à la liquidation de celle-ci afin d'arrêter l'hémorragie.

Dans le cas précédent, la dissolution constitue une décision de modification des statuts, qui est décidée aux conditions de quorum et de majorité applicables au genre de sociétés concernées et qui peuvent varier de celles prévues par l'article 1100-2 L.S.C. pour décider du mode de liquidation et de la désignation des liquidateurs. Il est encore à noter que, pour les sociétés anonymes, les conditions de majorité et de quorum sont considérablement allégées en cas de réalisation de pertes substantielles par la société[2].

Pendant la liquidation, le liquidateur est l'organe de la société : « *c'est par lui seul que la société agit* »[3]. À l'égard des tiers, « *c'est elle qu'il représente et non les associés individuellement ou les créanciers sociaux […]. Son rôle est donc fort différent, à cet égard, de celui d'un curateur de faillite, qui représente la masse* »[4].

L'attention des tiers, pour lesquels cette information est des plus importantes, doit être attirée sur la situation de la société : « *Toutes les pièces émanées d'une société dissoute mentionneront qu'elle est en liquidation* » (art. 1100-1 (1) alinéa 3, anc. art. 141 (1) alinéa 3) L.S.C.). La loi ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de violation de cette prescription légale. C'est donc le droit commun qui s'applique avec, le cas échéant, des dommages-intérêts à charge de celui à qui cette omission est imputable.

Qu'il y ait ou non nomination formelle des liquidateurs, la dissolution entraîne la cessation des fonctions de l'organe de gestion de la société. Sur ce sujet, Pirmez s'est exprimé comme suit : « *La dissolution de la société met fin aux pouvoirs des gérants et des administrateurs. Le devoir de ces représentants de la société est, avant de quitter leurs fonctions, de pourvoir à la liquidation. Si les associés n'ont pas pourvu à la liquidation, les tiers trouveront dans les gérants et les administrateurs de la sociétés des représentants contre lesquels ils pourront former toutes les demandes et qui seront les garants de la conservation de l'avoir de la société* »[5].

A – Les liquidateurs

Si la liquidation met fin de plein droit aux fonctions des gérants, administrateurs et des commissaires, le seul organe d'exécution de la société est désormais constitué par le(s) liquidateur(s). Il faut toutefois éviter qu'en l'absence de nomination de liquidateurs, les tiers ne puissent plus agir. À défaut de représentants légaux en place, les tiers ne

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 290.

2 – Art. 480-2 (anc. art. 100) L.S.C., ID 7520 ; pour plus de détails, v. sous chapitre consacré aux sociétés anonymes.

3 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 2, p. 105.

4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 2, p. 111.

5 – Cour 14 juillet 1999, *P.*, n° 31, p. 184, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

pourraient plus agir contre la société. C'est l'article 1100-3 [anc. art. 143] L.S.C. qui évite cette conséquence en retenant à l'égard des tiers comme liquidateurs les organes de gestion de la société[1]. À moins qu'il y ait nomination de liquidateurs *ad hoc* (en général par la même assemblée que celle qui prononce la dissolution de la société), les organes de gestion de la société restent en place pour la réalisation des opérations de liquidation. Telle est la solution retenue par l'article 1100-3 L.S.C. : « *À défaut de nomination de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, les gérants dans les sociétés à responsabilité limitée et les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés coopératives, seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.* ».

L'article 1100-3 L.S.C. introduit ainsi une règle permettant aux tiers de s'adresser à l'organe de gestion de la société. « *À défaut de précision quant à la personne ou l'organe qui a procédé à la liquidation, les tiers peuvent s'en tenir à la présomption résultant de l'article 143 de la loi sur les sociétés* »[2].

Les **commissaires** ne sont pas remplacés : il est vrai qu'une fois la liquidation terminée, des commissaires sont nommés aux fins de contrôle des activités de liquidation[3].

Les liquidateurs, dûment nommés par l'assemblée générale des associés, restent soumis à l'autorité de celle-ci. Mais une fois que la société a été mise en liquidation, les **attributions de l'assemblée** des associés changent : il n'y a plus lieu de procéder annuellement à l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire annuelle[4].

Il est toutefois loisible au liquidateur de réunir les associés annuellement en assemblée. En outre, les liquidateurs doivent annuellement faire rapport à l'assemblée de l'état de la liquidation ; il en est de même lorsque celle-ci est terminée.

Pendant la liquidation, les **titres** de la société **restent cessibles** dans les mêmes conditions qu'avant la dissolution[5].

Ce n'est qu'à l'égard des tiers que les personnes désignées assument les fonctions de liquidateurs. « *Ils ne revêtent nullement ce caractère vis-à-vis des anciens associés qui, d'une part, peuvent se refuser à répondre à leurs actions, et qui d'autre part, s'ils veulent eux-mêmes actionner la société en la personne d'organes légaux réguliers, n'ont qu'à user des moyens que leur procure l'article précédent d'en faire désigner soit par l'assemblée générale soit par les tribunaux* »[6].

Les pouvoirs de ces liquidateurs sont particulièrement limités dans la mesure où ces administrateurs ne deviennent liquidateurs qu'au profit de ces tiers pour les actions que ceux-ci désirent intenter à la liquidation, mais pas à leur détriment. Ces dispositions ne peuvent donc que profiter aux tiers sans jamais pouvoir leur nuire. Les tiers n'ont donc pas d'intérêt à demander la nomination de liquidateurs[7].

---

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 313, ID 11305.

2 – Cour 14 juillet 1999, *P.*, n° 31, p. 183, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 2, p. 104.

4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 2, p. 105.

5 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 2, p. 106.

6 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 324, ID 11308.

7 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 328, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les assemblées des associés qui se tiennent pendant la phase de liquidation des sociétés décident aux conditions de majorité ordinaire[1].

B – Révocation des liquidateurs

Les liquidateurs sont mandataires de la personne morale (art. 1100-13 L.S.C.) qu'est la société et sont donc révocables dans les mêmes conditions que tout **mandataire**. Peu importe qu'ils aient été nommés par les associés ou encore par le tribunal, ils sont en tout état de cause révocables *ad nutum* par les associés dans les mêmes conditions que celles prévues pour la nomination. Ce ne serait que dans le cas où le liquidateur serait nommé par les statuts qu'il tirerait sa nomination d'un véritable contrat synallagmatique que le liquidateur serait irrévocable (en principe)[2].

C – Honoraires des liquidateurs

Ces honoraires constituent des dettes de la masse qui doivent être réglées avant le paiement des créanciers dans la masse[3]. Les honoraires doivent être proportionnés aux travaux accomplis par les liquidateurs. Leur responsabilité serait engagée s'ils fixaient les honoraires à un niveau tel que les créanciers ne pourraient pas être désintéressés dans leur totalité. Dans un tel cas de figure, les créanciers peuvent obtenir du tribunal qu'il fixe le niveau des honoraires à un niveau adéquat, même si l'assemblée générale avait approuvé les honoraires jugés excessifs par le tribunal[4].

D – Mode de liquidation

La loi distingue deux catégories d'opérations : celles que le liquidateur peut faire **sans autorisation** (art. 1100-4 [anc. art. 144] L.S.C.) et celles qui ont un degré d'importance plus élevé et qui ne peuvent donc être réalisées qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale (art. 1100-5 [anc. art. 145] L.S.C.)[5]. Cette autorisation est donnée dans les mêmes conditions de majorité que la nomination des liquidateurs (voir ci-dessus).

Les liquidateurs peuvent ainsi sans autorisation spécifique procéder à la vente des biens mobiliers, défendre à toutes les actions dirigées contre la société, recevoir des paiements, etc.

Au vœu de la loi, les liquidateurs peuvent, au moins pendant un certain temps, « *continuer jusqu'à réalisation l'industrie et le commerce de la société* ».

Cette faculté est toutefois subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale des associés. Cette nécessité d'avoir une telle autorisation des associés est fort

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1966-1971) », *R.C.J.B.*, 1973, p. 562.

2 – Commentaire législatif de la loi de 1873, II, n° 78, p. 142 ; J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 326, ID 11308.

3 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. II, n°s 1108 ss.

4 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 385.

5 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 315, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

logique : les associés ont décidé de la liquidation de la société et, à première vue, il est de leur intérêt que cette liquidation avance le plus rapidement possible. Le cas échéant, tel n'est pourtant pas le cas et il peut être plus intéressant pour les associés que la société procède à la continuation des opérations (ou du moins de certaines de ces opérations) de la société (p. ex., l'exécution de certains contrats à laquelle la société s'est engagée permet d'éviter de lourdes pénalités). Ainsi, une société de réalisations immobilières peut être amenée à compléter les chantiers en cours avant de procéder à la liquidation définitive des actifs sociaux. Ils peuvent encore emprunter, hypothéquer les biens de la société, et faire apport de l'avoir social à d'autres sociétés[1].

Finalement, ce sont les associés qui sont les bénéficiaires des opérations de liquidation (du moins si la société est *in bonis*). Il est donc normal que ce soient eux qui se prononcent sur une continuation éventuelle des activités de celle-ci.

Normalement, la tâche des liquidateurs consiste à liquider les biens de la société aussi vite que possible. Les avoirs de la société sont utilisés pour le paiement des dettes sociales. En l'absence de créanciers privilégiés et hypothécaires, ce paiement des créanciers se fait proportionnellement aux montants de leurs créances et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles[2]. Au vœu de la loi, il est octroyé dans ce cas un **escompte** pour les **dettes non exigibles**. On peut supposer que cet escompte sera substantiellement influencé par le montant du taux d'intérêt dû sur la dette. Selon la jurisprudence, après la mise en liquidation, il ne peut plus y avoir de compensation entre les avoirs et les dettes des associés, et ceci, en raison du principe d'égalité entre créanciers non privilégiés[3].

D'autres opérations sont encore soumises à l'autorisation de l'assemblée générale des associés, en dehors de la continuation des opérations commerciales[4], l'aliénation des immeubles, le fait d'hypothéquer ou de donner en gage les biens de la société, d'emprunter pour payer les dettes sociales, etc.

L'autorisation requise pour s'endetter s'explique surtout par la méfiance vis-à-vis de liquidateurs infidèles[5]. Néanmoins, des emprunts peuvent être utiles, voire indispensables, notamment pour éviter une faillite[6].

Les liquidateurs peuvent même apporter l'avoir social à une nouvelle société contre attribution d'actions aux associés que ces derniers peuvent ensuite vendre, ce procédé ayant donné de bons résultats en pratique[1].

Au fur et à mesure que les opérations de liquidation se réalisent, le liquidateur peut procéder à la **distribution d'avances** sur le produit de liquidation auquel les associés ont droit.

---

1 – Art. 1100-5 (anc. art. 145) L.S.C., ID 7520.

2 – Art. 1100-8 (anc. art. 147) L.S.C., ID 7520.

3 – TA Lux. du 30 juillet 1927, *P.*, n° 11, p. 554.

4 – « *Les affaires sociales doivent prendre fin avec la société ; mais s'il y a utilité à maintenir, avant la vendre, une usine en activité, refuserait-on aux liquidateurs le droit de ne pas la faire chômer ? Faudra-t-il qu'ils éteignent un haut fourneau en marche, et qu'ils renvoient tout le personnel d'une filature, en faisant perdre à la société ce qu'elle obtiendrait de plus en vendant des usines en activité ?* », rapport présenté par la Commission de la Chambre des représentants de la Belgique, cité par A. Nyssens, Avant-projet, p. 315, ID 11305.

5 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 317, ID 11305.

6 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 335, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette distribution suppose toutefois que, soit les créanciers aient été désintéressés au préalable, soit le liquidateur ait effectué des provisions suffisantes pour pouvoir payer toutes les dettes de la société, y compris celles qui ont pris naissance seulement après la décision de dissolution. En tout état de cause, le liquidateur qui paierait des avances aux associés sans s'être assuré au préalable que les avoirs de la société sont suffisants pour payer toutes les dettes de la société risquerait d'engager sa responsabilité personnelle. Il pourrait être tenu de payer les dettes de la société sur ses avoirs personnels.

Dès que les opérations de liquidation sont terminées, une autre assemblée des associés est convoquée et celle-ci désigne un commissaire à la liquidation avec la mission de se prononcer sur les opérations de liquidation. Ce commissaire procède à l'établissement d'un rapport sur les opérations effectuées. Une fois ce rapport établi, une troisième assemblée est convoquée, et celle-ci se prononce sur le rapport de liquidation et sur la mission du (des) liquidateur(s) en accordant décharge aux liquidateurs pour l'exécution de leur mission.

Le liquidateur est tenu de présenter un **rapport à l'assemblée des associés**. Ce rapport doit-il, à l'instar de celui des commissaires, être soumis à l'assemblée générale, être distribué aux actionnaires ou bien être accessible au siège de la société ? La loi est muette sur la question, de sorte qu'il devrait suffire que le liquidateur présente le rapport oralement à l'assemblée générale[1].

Qu'en est-il si, nonobstant la clôture de la liquidation prononcée par cette troisième assemblée, les opérations de liquidation n'ont pas été complètement clôturées ? En effet, il se peut que certains créanciers n'aient pas été désintéressés ou encore que l'un ou l'autre actif ayant appartenu à la société n'ait pas été réalisé lors des opérations de liquidation.

Dans ces cas de figure, le liquidateur reste en fonction pour défendre la société dans une éventuelle procédure engagée par des créanciers. Cette **capacité passive** perdure pendant **cinq années** à partir de la clôture de la liquidation. « *Si en principe la société commerciale disparaît avec la clôture de la liquidation, cette extinction n'est pas absolue, alors que la société continue d'exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture de liquidation* ». Cette solution découle de l'article 1400-6, alinéa 1er, 3° aux termes duquel se prescrivent par cinq ans : « *les actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l'article 1100-15* ».

Durant cinq années, les créanciers ont la possibilité d'assigner les liquidateurs, et ceci, en leur qualité de représentants de la société disparue « *[…] afin de faire reconnaître les droits qu'ils avaient contre elle ou de faire prononcer la nullité des actes de liquidation frauduleux* »[2]. Les recours éventuels des tiers contre la société ne peuvent être exercés contre les associés, car ceux-ci ne continuent pas la personne de la société. La loi permet de les exercer contre le dernier organe de la société, les liquidateurs.

La désignation d'un **commissaire** par application de l'article 1100-15 [anc. art. 151] L.S.C. n'est **pas indispensable** : la doctrine admet en effet que cet

1 – En ce sens, J. Delvaux, A. Wildgen et R. Breininger, « La réunion de tous les titres d'une société anonyme en une seule main », *Ann. dr. lux.*, Vol. 2, 1993, p. 102.

2 – Cass. du 2 décembre 1952, *R.C.J.B.*, p. 288, note J. Heenen, p. 299.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

article 151 n'est pas d'ordre public pour la raison que la mission du commissaire est conçue pour protéger non pas les créanciers, mais les actionnaires. Les actionnaires peuvent y renoncer[1]. Cette possibilité est importante en pratique : elle permet en effet de procéder à la procédure dite de « **dissolution simplifiée** » (en une seule étape) qui permettait de dissoudre une société et d'en clôturer la liquidation dans un seul et même acte notarié.

E – Effet du partage en droit civil luxembourgeois

L'effet du partage consiste à dissoudre la communauté qui a existé entre les partageants, en l'occurrence les « *associés* », au moment de la dissolution de leur association ou communauté. De telles situations de partage surviennent également en matière de succession, d'indivision volontaire, etc.

La solution retenue par le droit français diverge fondamentalement de celle qui avait été retenue par le **droit romain** en cette matière. Pothier, un des auteurs dominants de l'ancien droit, explique à cet égard : « *Pour le droit romain le partage était une espèce d'échange ; chacun des copartageants était censé acquérir de ses copartageants les parts qu'ils avaient, avant le partage, dans les effets compris dans son lot, et leur céder à la place celle qu'il avait, avant le partage, dans les effets compris dans le leur […] Au contraire, selon notre droit français, un partage n'est pas regardé comme un titre d'acquisition, mais comme un acte qui ne fait autre chose que déterminer les parts indéterminées que chacun des copartageants avait, avant le partage, dans la communauté qui était entre eux, aux seules choses échues au lot de chacun d'eux.*

Ces actes de partage ont, selon notre droit français, un effet rétroactif. En conséquence, les choses échues en chaque lot sont censées avoir toujours seules composé la part qu'avait en la communauté celui au lot duquel elles sont échues. Il est censé avoir été seul le propriétaire de ces choses depuis qu'elles ont été mises en la communauté, ou acquises pour le compte de la communauté, et n'avoir jamais eu aucune part, depuis que la communauté a été contractée, dans les choses échues au lot de ses copartageants. Le partage, selon ces principes n'est pas un titre d'acquisition, et chacun des copartageants n'acquiert par le partage rien de ses copartageants. C'est pour cette raison que les partages ne donnent pas d'ouverture aux droits seigneuriaux […] »[2].

Ces lignes ont été écrites avant la Révolution française, et donc avant le Code civil. Le Code civil a repris cette conception du partage, et ceci, notamment dans l'article 883 C.c.

« *Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession* ».

Le législateur de droit privé a donc sans le moindre doute possible repris cet effet déclaratif du partage, en matière de droit de succession, mais également en matière de droit des sociétés.

1 – J. Delvaux, A. Wildgen et R. Breininger, « La réunion de tous les titres d'une société anonyme en une seule main », *Ann. dr. lux.*, Vol. 2, 1993, p. 104.

2 – R.J. Pothier et R.J. Bugnet, *Œuvres de Pothier*, Vol. IV, p. 306.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Reste à voir s'il en va de même en droit fiscal (et plus précisément en matière d'impôt sur le revenu).

F – L'effet du partage en matière d'impôt sur le revenu

Cet effet est également retenu en droit fiscal. On peut en premier lieu citer l'article 37 L.I.R. concernant le transfert à titre gratuit des entreprises. Le Code fiscal comporte la précision suivante, note de bas de page, n° 5, b) : en ne prévoyant pas de mesure spéciale, « *la loi revient en principe au droit commun qui constate l'effet déclaratif du partage* ».

En cas de transmission à titre gratuit (notamment par succession ou donation) d'une entreprise ou d'une partie autonome d'entreprise, le cédant ou ses ayants cause doivent évaluer comme en fin d'exercice les biens constituant l'actif net investi au moment de la transmission. L'acquéreur doit reprendre ces valeurs telles que reproduites au bilan du cédant. La continuation des valeurs comptables est ainsi assurée, empêchant donc toute découverte et imposition des plus-values latentes.

Aucune latitude n'est donc laissée au cessionnaire qui n'a pas la possibilité de découvrir totalement ou partiellement les plus-values latentes. Par conséquent, le transfert est une opération neutre n'impliquant aucune découverte ou imposition d'une plus-value latente. Les plus-values accumulées dans le chef du cédant sont susceptibles de devenir imposables dans le chef du cessionnaire dans les mêmes conditions que si elles avaient été réalisées dans le chef du cédant[1].

Il y a transmission à titre gratuit nonobstant le fait que les cessionnaires soient tenus d'assumer certaines charges leur imposées par le cédant. Ces charges sont considérées comme charges personnelles des cessionnaires et n'entrent donc pas en ligne de compte en tant que charges d'exploitation, pour la raison qu'elles ne sont pas exclusivement provoquées par l'exploitation[2].

Les transmissions à titre gratuit soulèvent des problèmes assez complexes en cas de pluralité de cessionnaires (en général, une pluralité d'héritiers) quant à l'actif dévolu dans l'hypothèse où il est procédé au partage de l'indivision un certain temps après la dévolution de la succession. Il se pose alors la question de savoir quelles seront les conséquences de ce partage. Deux conceptions s'opposent ici : l'effet translatif et l'effet déclaratif du partage.

Le **caractère déclaratif** du partage signifie que l'on doit considérer « *[…] chaque héritier comme propriétaire exclusif de son lot dès l'époque de l'ouverture de la succession et comme n'ayant jamais eu aucun droit sur les autres biens de la succession* »[2]. Cet effet se produit uniquement si le partage intervient dans un délai ne dépassant pas le temps raisonnablement requis pour aboutir au partage et que les cohéritiers ne se comportent pas en coexploitants[1].

La version initiale du projet gouvernemental (de la L.I.R.) avait proposé une solution qui s'écartait de l'effet déclaratif du partage. Du point de vue de l'attributaire de l'entreprise, cette solution consistait dans l'acquisition à titre onéreux des parts viriles des cohéritiers dans l'entreprise et dans l'acquisition à titre gratuit de sa propre

1 – *Doc. parl.*, n° 571/4, p. 65, ID 2692.

2 – Circ. L.I.R. n° 109/5 du 30 mars 1999, p. 2, ID 1041.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

part virile. De cette façon, les attributaires des autres biens de la succession étaient imposés du fait même du partage ; la situation était donc définitive à leur égard.

Dans son avis relatif à la L.I.R., le Conseil d'État[1], en se référant à deux arrêts du BFH[2], se prononça pour supprimer cette solution et pour revenir à l'effet déclaratif du partage. Selon le Conseil d'État, l'article 37, alinéa 1, L.I.R. serait donc applicable, sauf si dès avant le partage une coexploitation avait existé (application de l'article 15 L.I.R.). Si le partage de la masse successorale se fait « *dans un délai assez rapproché de l'ouverture de la succession (un ou deux ans), l'administration pourra présumer un partage entre cohéritiers ; si cependant le partage ne s'opère qu'à une date plus éloignée du décès, elle appliquera la présomption du partage d'une coexploitation* »[3].

Par conséquent, lorsque les cohéritiers en indivision continuent à exploiter l'entreprise en tant que coexploitants, l'effet déclaratif du partage n'est plus reconnu en droit fiscal, et le partage doit être considéré comme ayant un **effet translatif**. Tout partage ultérieur est conçu comme échange (transmission à titre onéreux) de parts indivises[4]. Cette solution a l'avantage que chaque héritier supporte directement l'imposition des plus-values sur sa quote-part de l'exploitation. Cet effet déclaratif du partage est encore retenu par l'article 102, alinéa 3 L.I.R. relatif aux plus-values sur les immeubles du patrimoine privé (la référence par la note de bas de page de l'article 37 à l'alinéa 6 est erronée).

G – Effet déclaratif du partage en cas de paiement de soulte

L'alinéa 3 de l'article 102 L.I.R. consacre l'effet déclaratif du partage même en cas de paiement de soulte. La soulte est dans tous les cas ignorée en matière de partage successoral. La conséquence est que, si la soulte est financée par emprunt, les intérêts acquittés à cette occasion sont des dépenses privées[5] déductibles tout au plus en tant que dépenses spéciales. Tel est le cas même si les biens attribués lors du partage sont des biens qui génèrent des recettes imposables et que donc, intrinsèquement, il s'agirait en principe d'intérêts remplissant les conditions pour être classifiés en tant que frais d'obtention.

Par une motivation manifestement inspirée par la Cour de justice des Communautés européennes, le tribunal administratif a jugé dans un cas d'espèce : « *Considérant que […] sur base des éléments de législation luxembourgeoise spécifiques applicables fondés sur le principe de l'effet déclaratif du partage […] l'équité fiscale est à rechercher au niveau de la cohérence globale du système légal instauré et aucune iniquité ne saurait être induite à partir d'un aspect particulier y afférent considéré de façon isolée* »[1].

En conclusion, on peut sans la moindre hésitation possible affirmer que le droit fiscal luxembourgeois consacre l'effet déclaratif du partage. La question qui en fait

1 – *Doc. parl*., n° 571/16, p. 24, ID 2692.

2 – Datés du 21 août 1962 et du 26 juin 1963.

3 – V. avis du Conseil d'État, *Doc. parl*., n° 571/16, p. 24, ID 2692. V. aussi L. Kunsch, « *La réalisation des réserves occultes par le partage successoral », Etudes Fiscales, 1965, n° 13*.

4 – Circ. L.I.R. n° 109/5 du 30 mars 1999, p. 2, ID 1041.

5 – Tadm. du 19 janvier 2000, n° 11394, ID 306.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

reste ouverte est celle de savoir si l'effet déclaratif s'applique également en cas de soulte ou si, dans cette mesure-là, le partage est translatif. En d'autres termes, la solution de l'article 102, alinéa 3, a-t-elle valeur générale ou non ?

H – Pouvoirs des liquidateurs

Ces pouvoirs sont très étendus. En effet, l'article 1100-4 L .S.C. dispose que : « *À défaut de dispositions contraires dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales* ».

Le mode de liquidation et l'identité du ou des liquidateurs sont déterminés par l'assemblée générale des associés[1]. Si le choix se porte sur plusieurs liquidateurs, ceux-ci forment un collège qui délibère suivant les conditions de l'article 444-3 (anc. art. 64) L.S.C., donc comme le conseil d'administration des sociétés anonymes (en reprenant donc en principe les règles des « **assemblées délibérantes** »). Faute de telles nominations, la loi prévoit que seront considérés comme liquidateurs :

– les associés gérants des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple ;
– les administrateurs des sociétés anonymes par actions et des sociétés coopératives ;
– les gérants des S.à r.l. ;
– les associés commandités des sociétés en commandite par actions.

La nécessité d'établir des **comptes sociaux** lors de la clôture annuelle n'existe plus à l'égard des sociétés en liquidation. Au vœu de l'article 1100-14 [anc. art. 150] L.S.C., les résultats sont annuellement soumis à l'assemblée générale de la société avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. Ce bilan (annuel donc) n'est pas approuvé ; il est simplement soumis à l'assemblée des associés[2] et, dans les sociétés anonymes, il est en outre publié.

Cette règle est rejointe par les dispositions fiscales en la matière qui, selon l'article 1500-8 L.I.R., dérogent au principe de l'**annualité de l'impôt** dans la mesure où les sociétés qui sont en état de liquidation ne sont plus tenues de faire une déclaration annuelle de l'impôt (mais seulement une déclaration qui comprend tous les résultats de la période de liquidation), sauf dans le cas où la liquidation dépasse les trois années. Dans ce cas, on revient au droit commun, soit donc à la déclaration et à l'imposition annuelles.

1 – Art. 1100-2 (anc. art. 142) L.S.C., ID 7520.

2 – En effet, selon la jurisprudence, le liquidateur ne sera pas tenu de fournir des comptes périodiques aux associés, mais seulement de soumettre chaque année le résultat de sa liquidation à l'assemblée générale de la société (Trib. Lux. du 25 février 1950, *P.*, n° 15, p. 95).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

I – Déroulement de la liquidation

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser les biens de la société et d'assurer une distribution égalitaire entre les créanciers du produit de cette réalisation. « *Concours de plein droit et non concours légal : alors que la loi assure, par des règles précises, l'égalité des créanciers en cas de procédure d'ordre après saisie, de faillite ou de concordat, l'article 184 des lois coordonnées ne contient aucune disposition semblable* »[1].

1) Les travaux de liquidation

Les articles 1100-4 et suivants L.S.C. définissent de manière large les pouvoirs des liquidateurs.

a) Différentes catégories d'actes

La loi distingue les actions que le liquidateur peut faire seul de celles pour lesquelles il a besoin d'une autorisation de l'assemblée. Une **autorisation de l'assemblée** est notamment requise pour la continuation de l'industrie et le commerce de la société. Sous la même réserve, les liquidateurs ont le pouvoir d'emprunter pour payer les dettes sociales, de créer des effets de commerce, d'hypothéquer les biens de la société, de les donner en gage, d'aliéner ses immeubles ; ils peuvent encore faire apport de l'avoir social à d'autres sociétés.

Il est encore loisible aux liquidateurs de demander aux associés la libération de la partie non encore libérée du capital. Cette solution est prévue par l'article 1100-7 L.S.C.[2].

Cette disposition (qui permet aux liquidateurs de ne demander que le paiement de sommes qui paraissent nécessaires au règlement de la liquidation) a donné lieu à des difficultés d'interprétation. On a hésité entre trois systèmes différents. La loi luxembourgeoise a retenu celui qui donne aux liquidateurs la faculté de juger de la nécessité de cet appel de fonds[3].

« *Les liquidateurs, bien qu'institués par les associés, sont chargés de veiller aux intérêts des créanciers contre leurs propres mandants. Ils doivent donc exiger que ceux-ci versent dans l'avoir social les sommes dont ils sont redevables et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes sociales. Cette disposition, d'origine anglaise, est aussi juste qu'utile, car elle dispensera le plus souvent les créanciers d'agir contre les associés individuellement* »[4].

Lors de la souscription du capital, les associés se sont engagés à procéder à tout moment à la libération de la partie souscrite mais non libérée du capital. Cette libération n'ayant pas été demandée au cours de la vie de la société, elle peut l'être au moment de la liquidation. Il va de soi que le liquidateur va demander cette

1 – F. T'Kint, « Le concours des créanciers d'une société en liquidation », *R.P.S.*, 1977, p. 178.

2 – Art. 1100-6 (anc. art. 146) Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la liquidation, ID 7520.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 340, ID 11308.

4 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 318, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

libération uniquement si les avoirs de la société sont insuffisants pour désintéresser tous les créanciers de la société. En effet, dans l'hypothèse inverse, la libération de cette partie du capital aura uniquement pour conséquence d'augmenter le produit de liquidation qui sera par la suite versé aux associés.

Le liquidateur d'une société dissoute, tout en ayant le pouvoir de vendre les immeubles de la société (mais seulement avec l'accord de l'assemblée des associés), ne peut pas constituer une nouvelle société pour l'exploitation de ces immeubles. Les liquidateurs ont donc un mandat spécial pour vendre les immeubles : ils dépasseraient leurs pouvoirs en constituant une nouvelle société[1].

b) Paiement des dettes sociales

En application de l'article 1100-8 L.S.C., « *Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payeront toutes les dettes de la société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.*

Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux ».

Les liquidateurs sont donc appelés à payer tous les créanciers en même temps, sans distinguer entre les **dettes exigibles** et celles qui sont **non exigibles** (sauf à tenir compte d'un escompte à l'égard de ces dernières)[2]. Mais le liquidateur peut encore se limiter au paiement des seules dettes exigibles en attendant que les autres arrivent à leur échéance. Dans ce dernier cas, il engage toutefois sa responsabilité pour le cas où les créanciers à terme ne pourraient pas être payés intégralement : ces créanciers disposent même d'une action judiciaire pour garantir la solvabilité personnelle des liquidateurs.

Il résulte encore de cette disposition que les liquidateurs doivent **payer** les créanciers de **façon proportionnelle** pour le cas où le passif social excède l'actif (art. 1100-8 (anc. art. 147) L.S.C.). En d'autres termes, l'égalité entre créanciers doit être respectée. Cette disposition est toutefois à caractère purement interne dans le sens qu'elle impose des devoirs aux liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions sans pour autant modifier la situation juridique des créanciers : ces derniers ne subissent pas de déchéance de leurs droits de recours[3]. La situation des liquidateurs n'est donc pas des plus confortables dans la mesure où, d'une part, il leur est interdit de payer un créancier au-delà du dividende de liquidation qui doit lui revenir et que, d'autre part, ils ne peuvent contraindre les créanciers à se contenter d'un dividende partiel.

La L.S.C. (pas plus que la loi belge) n'impose pas aux liquidateurs de faire des **répartitions partielles** au profit des créanciers. En pratique, celles-ci sont de mise surtout lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier[4].

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 144.

2 – Il est à noter que les créanciers à terme n'ont pas le droit de refuser le paiement immédiat de leurs créances sous déduction d'un escompte, A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 319, ID 11305.

3 – F. T' Kint, « Le concours des créanciers d'une société en liquidation », *R.P.S.*, 1977, p. 163.

4 – Cour Bruxelles du 19 mars 1968, *Pas.*, II, p. 180.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

c) Distribution aux associés du produit de liquidation

Art. 1100-9 [anc. art. 148] L.S.C.
« Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribueront aux sociétaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales ; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.
Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en l'art. 1100-9, racheter les actions ou parts sociales de la société soit à la Bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous les sociétaires seraient admis à participer ».

L'article 1100-9 L.S.C. correspond à l'article 184 des lois coordonnées belges. Selon la Cour de cassation belge, cette dernière disposition consacre l'égalité entre créanciers :

« *que ce texte impératif implique l'égalité qui doit régner dans les répartitions de l'avoir social entre tous les créanciers chirographaires de la société et qu'il détermine de manière irrévocable les droits réciproques de ceux-ci dès l'instant de la mise en liquidation ; que cette disposition trouve sa raison d'être dans le fait qu'une société commerciale dissoute disparaissant par la clôture de sa liquidation ne laisse aux créanciers incomplètement payés aucune possibilité d'obtenir à l'avenir paiement de ce qui leur reste dû* »[1].

Ce texte impose une obligation aux liquidateurs, mais, en même temps, il reconnaît aux créanciers un véritable **droit subjectif** garantissant qu'aucun d'entre eux ne sera payé au détriment des autres, soit le droit à une répartition proportionnelle des actifs en cas d'insuffisance de l'actif.

L'action en paiement des créanciers chirographaires se trouve affectée par l'entrée de la société débitrice dans l'état de liquidation. En effet, s'il est loisible aux créanciers de faire reconnaître leurs droits en justice, l'exécution de leurs droits ne peut avoir pour effet de leur assurer un paiement plus important que celui qui serait accordé aux autres créanciers. La Cour d'appel de Bruxelles refusa d'autoriser à un créancier à procéder à l'exécution de son titre, opération qui aurait risqué de léser les droits des autres créanciers, une fois l'insuffisance des actifs[2] constatée.

La jurisprudence s'est graduellement orientée vers la mise en place d'un système somme toute assez proche de celui applicable en cas de faillite de société, fondé sur la reconnaissance d'une **masse de la liquidation** et sur la reconnaissance de dettes de la masse payables avant toutes les autres et pour lesquelles l'exécution resterait possible[3].

La question s'est posée, dans le contexte de la liquidation de sociétés se trouvant dans une situation financière difficile, de savoir si le liquidateur, valablement désigné par les associés, était ou non obligé de déposer le bilan et de demander la déclaration de la faillite s'il constatait que l'**actif** était **insuffisant** pour payer l'intégralité du passif social.

1 – F. T' Kint, « Le concours des créanciers d'une société en liquidation », *R.P.S.*, 1977, p. 167.
2 – CA Bruxelles du 24 février 1965, *R.P.S.*, 1966, p. 206, observations P.C.
3 – Cette solution a été reconnue dès 1964.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

À cette question, la doctrine répond par la négative : il est vrai qu'on ne peut soutenir le point de vue selon lequel la liquidation exclurait l'état de faillite[1]. Cette opinion serait inacceptable : en effet, si l'insuffisance d'actif n'impose pas le dépôt du bilan, elle ne l'exclut pas non plus. En décider autrement ouvrirait grandement la porte à toutes sortes de fraudes et de liquidations précipitées afin d'échapper aux procédures de faillite et autres procédures collectives[2].

Il en va de même pour la liquidation d'office d'une société sur la base de l'article 1200-1 L.S.C. « *Une liquidation volontaire d'une société commerciale sur le fondement des articles 141 et suivants de la L.S.C. ne fait pas obstacle à une procédure en liquidation judiciaire de la même société sur base de l'art. 203 de la même loi, si, […], il est dans l'intérêt de l'ordre public, eu égard aux circonstances, et, en particulier, à la gravité des infractions à la loi, que le tribunal garde la haute main sur la liquidation et que celle-ci se fasse par un liquidateur indépendant, suivant les règles de la liquidation de la faillite* ». En l'espèce, la dissolution judiciaire fut justifiée en raison des faits suivants : – défaut de dépôt des comptes pour deux années, dépôt tardif pour une troisième (la disposition de l'art. 75 (nouv. art. 461-8) L.S.C. stipulant le dépôt des comptes ne permettant pas la régularisation après plusieurs années suivant la naissance de l'obligation) ; – non-fonctionnement des organes sociaux durant une certaine période[3].

Il s'ensuit qu'une société en liquidation peut être déclarée en faillite sous son ancienne dénomination et conserver à ces fins le siège social désigné dans son acte constitutif. Lorsqu'il existe une confusion caractérisée d'activité et de patrimoine entre deux sociétés et que l'une de ces sociétés a été déclarée en faillite, le tribunal est fondé à prononcer l'extension de la faillite à l'égard de l'autre société[4].

Par contre, l'article 1100-8 [anc. art. 147] L.S.C. permet parfaitement le paiement partiel de toutes les dettes exigibles ou non exigibles, mais à condition que ce soit proportionnellement par rapport aux actifs disponibles. La loi envisage donc effectivement le paiement simplement partiel des créanciers de la société[5].

Si la liquidation a été régulièrement prononcée par l'assemblée générale à un moment où la société n'était pas en état de faillite, alors le liquidateur n'est pas obligé de déposer le bilan, même s'il apparaît que l'actif sera inférieur au passif[6].

Quelle est la **clé de répartition** à appliquer au produit de liquidation distribué aux associés ? Ici encore, une large part est réservée à la **liberté contractuelle**. En général, la répartition du produit de liquidation se fait proportionnellement aux apports faits par les associés. En l'occurrence, les apports faits par deux associés étaient très inégaux, alors que les bénéfices et les pertes devaient se partager par parts égales. « *La part de copropriété de chaque associé dans le fonds commun est*

1 – Telle était la position du tribunal de commerce de Charleroi du 19 avril 1982, jugeant irrecevable la citation de faillite faute d'intérêt, *Rev. rég. dr.*, 1982, p. 31.

2 – M. Mersch, « Note sur la liquidation des sociétés commerciales », *R.D.C.B.*, 1985, p. 346.

3 – CA du 30 juin 1993, n° 14.977, ID 10198.

4 – Lux. du 18 février 1970, *P.*, n° 21, p. 393, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – M. Mersch, « Note sur la liquidation des sociétés commerciales », *R.D.C.B.*, 1985, p. 349.

6 – M. Mersch, « Note sur la liquidation des sociétés commerciales », *R.D.C.B.*, 1985, p. 353.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

en principe en proportion adéquate de ce qu'il a apporté »[1]. Ceci n'empêche pas qu'ils prévoient une autre solution à l'égard des bénéfices et des pertes. « *[…] en stipulant que les bénéfices et les pertes ne seront pas répartis proportionnellement aux apports, les associés n'ont eu en vue que les bénéfices et les pertes proprement dits, c.-à-d. ce qui excède le capital social ou ce qui le diminue, et non le capital social lui-même dont les associés sont copropriétaires dans la proportion des apports qu'ils ont faits* »[3].

Art. 1100-10 [anc. art. 148*bis*] L.S.C.

« ***Par dérogation aux dispositions de l'article 1100-8 et de l'article 1100-9, alinéa 1er, lorsqu'une société anonyme aura fait apport de l'entièreté de sa situation active et passive à une autre société anonyme, les liquidateurs de la société apporteuse pourront, en se conformant suivant le cas, à l'article 420-10, répartir entre les actionnaires les actions qui auront été attribuées en rémunération de l'apport, sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société qui a reçu l'apport étant tenue directement de l'exécution des obligations de la société apporteuse, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des obligataires.***
La société qui a reçu l'apport, et celle qui l'a fait seront de nationalité luxembourgeoise, à moins que la législation du pays de la société apporteuse ne permette de faire l'apport dans les conditions dont s'agit même à une société étrangère [...] ».

La disposition en question n'est pas reprise d'un droit étranger. L'exception prévue par l'article en question ne concerne que les créances obligataires à l'exception des autres créanciers[2].

d) Tenue des assemblées annuelles

Art. 1100 -14 [anc. art. 150] L.S.C.

« ***Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l'assemblée générale de la société, avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. Dans les sociétés anonymes le bilan est, en outre, publié*** ».

Cette disposition est destinée à prévenir la **longueur excessive** des liquidations, fléau difficile à combattre. La loi, plutôt que d'imposer des règles contraignantes, pense arriver à cette fin en imposant aux liquidateurs l'obligation d'exposer annuellement à l'assemblée générale les causes qui ont retardé les opérations de liquidation. Il appartiendra alors à cette assemblée de procéder à des mesures de rigueur[3].

1 – TA du 30 octobre 1920, *P.*, n° 11, p. 152, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – J. Delvaux, A. Wildgen et R. Breininger, « La réunion de tous les titres d'une société anonyme en une seule main », *Ann. dr. lux.*, Vol. 2, 1993, p. 101.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 322, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

e) Tenue de l'assemblée de clôture

La procédure de liquidation est close par une autre assemblée des associés, appelée « assemblée de clôture » et prévue par l'article 1100-15 L.S.C., qui, après avoir entendu les commissaires, se prononcera sur la gestion des liquidateurs. Cette assemblée, contrairement à celles qui ont lieu annuellement et qui prennent note des résultats de la liquidation, a comme mission de décider formellement sur la **régularité de la procédure** de liquidation qui s'est déroulée[1].

2) Concours des créanciers d'une société en liquidation

En application de l'article 1100-13 L.S.C. (art. 178 des lois coordonnées belges), « *les sociétés… sont après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation* ». Cette règle a été prise non seulement dans l'intérêt des associés, mais encore dans celui des créanciers. Si, au moment de la dissolution, la personnalité morale cessait, les avoirs de la société seraient répartis aux différents associés. La situation des créanciers serait alors fort difficile. « *Ils ont traité avec la société. Il serait anormal que celle-ci s'évanouisse et que sa dissolution les contraigne, pour recouvrer leurs créances, d'interpeller les associés. Mais il y a plus : la survie fictive évite que le patrimoine social, qui est leur gage, se confonde avec les divers patrimoines des associés. La règle assure ainsi, sur les biens de la société, le droit de préférence des créanciers sociaux* »[2].

La **réunion de tous les titres en une seule main** n'a pas pour effet d'entraîner par elle-même et par elle seule la clôture de la liquidation (et ceci, même à une époque où il fallait impérativement deux associés au moins pour une société anonyme). En effet, selon la loi, la personne morale subsiste pour les fins de la liquidation même à l'égard du détenteur de toutes les actions[3].

J – Responsabilité des liquidateurs

C'est fort logiquement que la loi prévoit à l'égard des liquidateurs des règles identiques à celles qui sont applicables aux organes de gestion de la société. En effet, en principe, ce sont les membres de cet organe de gestion qui sont en même temps liquidateurs de la société. Par conséquent, la loi dispose que : « *Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers la société, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion* » (art. 1100-13 anc. art. 149 L.S.C.).

Pour les liquidateurs, le vote approbatif de la seconde assemblée comporte décharge de leur responsabilité. L'assemblée peut éviter cet effet en ne donnant son approbation qu'avec réserves. La décharge ne vaut pas en cas de dol ou d'erreur substantielle.

K – Les commissaires de la liquidation

Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs feront un **rapport à l'assemblée générale** sur l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l'appui. Le législateur a prévu un contrôle de l'activité des liquidateurs, et ce contrôle se

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 352, ID 11308.

2 – F. T'Kint, « Le concours des créanciers d'une société en liquidation », *R.P.S.*, 1977, p. 161.

3 – Cass. b. du 22 mars 1962, *R.C.J.B.*, 1963, p. 42, note J.-G. Renauld.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

concrétise par un rapport des commissaires soumis à l'assemblée des associés. Sur la base de ce rapport, les associés déchargent les liquidateurs (art. 1100-15 L.S.C.). L'assemblée nommera des commissaires pour examiner ces documents et fixera une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué, selon le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs.

Par le passé, la question s'est posée de savoir quelle devrait être la qualification de ces commissaires. Sont-ils soumis au régime normal des commissaires (ce qui signifierait qu'il n'y aurait pas la moindre condition de qualification à respecter), ou bien sont-ils soumis au régime des réviseurs d'entreprises ?

La réponse à cette question a finalement été donnée par le législateur dans les termes suivants : « *La qualification de réviseur d'entreprises pour les commissaires n'est requise que pour les sociétés qui dépassent deux des trois critères prévus à l'article 215 et pour les sociétés qui ont dépassé les limites prévues à l'article 215 au cours des trois dernières années ayant précédé le jour de la mise en liquidation* »[1]. Non sans une certaine logique, on continue donc à appliquer lors de la liquidation la même solution que celle qui est applicable en cours d'existence de la société.

L – Publication de la clôture de la liquidation

La clôture de la liquidation n'est pas subordonnée au paiement intégral de tous les créanciers de la société. Dès que tous les actifs de la société ont été liquidés et utilisés au paiement (ne fût-ce que partiel) des créanciers la liquidation sera clôturée.

La clôture de la liquidation produit ses effets tant entre parties qu'à l'égard des tiers dès qu'elle est décidée par les associés, sans égard à la date de la publication[2].

Pour la doctrine belge, l'effet essentiel de la **publication** de la clôture de liquidation est qu'elle **fait courir le délai de cinq ans** prévu par l'article 194, alinéa 4, des lois coordonnées (qui correspond à l'article 1400-6 L.S.C.).

La clôture de la liquidation, à laquelle sont attachées certaines conséquences importantes, doit faire l'objet d'une communication à des tiers, sous la forme d'une publication au RESA.

« *[…] la dissolution de la société ne produit d'effet à l'égard des tiers qu'autant qu'elle a été publiée. Tant que la dissolution n'a pas été publiée, les tiers peuvent se comporter comme si l'existence de la société se trouvait prolongée* »[3].

Cette publication indique encore l'endroit où les livres et documents de la société sont déposés et conservés pendant cinq années au moins. Le cas échéant, la publication indique encore les mesures prises en vue de la **consignation** des **sommes et valeurs** revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pas pu être faite. Cette situation est relativement commune à l'égard des sociétés ayant un grand nombre d'actionnaires (de créanciers) dont

1 – La loi du 31 mai 1999 qui a modifié l'article 151 L.S.C., ID 1694.

2 – Selon la jurisprudence belge, v. Cass. b. du 22 mars 1962, *Pas.*, I, p. 808 ; J. VAN RYN et P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 388.

3 – TA Lux. du 12 mars 1992, jgt n° 115/92, ID 10189.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

l'identité n'est pas nécessairement connue à la société, notamment dans le cas des OPC (SICAV, p. ex.). Dans ce cas de figure, c'est normalement à la caisse des dépôts et consignations qu'est fait le dépôt des sommes qui n'ont pas pu être attribuées aux actionnaires (créanciers) qui ne se sont pas manifestés lors de la procédure de liquidation et dont l'identité était donc restée inconnue aux liquidateurs.

M – Possibilité de réouverture de la liquidation ?

Selon la jurisprudence belge, les sociétés ont, après la clôture de la liquidation, toujours une « survie passive », ce qui ne doit pas être interprétée comme signifiant que la société puisse seulement être défendeur dans des actions judiciaires. En effet, la Cour de cassation belge a reconnu expressément aux liquidateurs d'exercer les recours qui sont accordés aux contribuables au moment de la réception des bulletins fiscaux, et ceci, après la clôture de la liquidation[1].

La société dont la liquidation est clôturée, attaquée dans la personne de ses liquidateurs, peut donc non seulement se défendre dans les instances qui sont introduites contre elle, mais également exercer des recours contre les décisions rendues à sa charge à la requête de ses créanciers[2]. Ceci signifie encore que la survie passive de la société peut durer bien au-delà du délai de cinq ans prévu par la L.S.C.

Au lieu de la conception de la « survie passive », la doctrine belge préconise : « De lege ferenda, *il serait souhaitable d'élargir les cas dans lesquels la réouverture de la liquidation peut être demandée* »[3].

En matière de faillite la jurisprudence semble encore considérer qu'une société dont la liquidation est clôturée depuis moins de six mois ne peut être mise en faillite que si la réouverture de la faillite est ordonnée[4].

Par ailleurs, la jurisprudence belge reconnaît la possibilité pour les créanciers de faire annuler la décision de clôture si elle a eu lieu en fraude de leurs droits[5]. Dans un cas de clôture frauduleuse les créanciers peuvent agir contre le liquidateur et demander la nullité de la clôture et la réouverture de la liquidation[6].

Dans le présent contexte, on peut citer un jugement du tribunal d'arrondissement[7] :

« *Attendu que la demande tend d'abord à l'annulation de la déclaration de clôture de la liquidation faite par le défendeur P.) et ensuite à la nomination d'un nouveau liquidateur qui devra rendre compte au demandeur ;*

[…]

1 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 390.

2 – CA Bruxelles du 17 décembre 1965, *Pas.*, 1966, II, p. 314.

3 – J.Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. II, n° 1120 ; J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 390.

4 – Trib. com. Bruxelles du 23 février 1965, *R.P.S.*, 1966, p. 31.

5 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 2, n° 1123, p. 143.

6 – Trib. com. Bruxelles du 11 avril 1953, *R.A.J.B.*, 1959, V° Sociétés, n° 23.

7 – TA Lux. du 4 juin 1981, n° 22496, ID 21615.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« Attendu que les effets qu'entraîne la clôture de la liquidation et sa publication sont en principe définitifs ;

qu'on admet cependant que les créanciers puissent faire annuler la décision de clôture si elle a eu lieu en fraude de leurs droits (Van Ryn, Principes de droit commercial, tome II, n° 1123, page 143) ;

qu'à supposer frauduleuse la clôture de la liquidation il est loisible aux créanciers d'agir contre le liquidateur et même de demander la nullité de la clôture et la réouverture de la liquidation (Comm. Bruxelles, 5e ch., 11 avril 1953, Recueil annuel de Jurisprudence belge, 1959, verbo Sociétés, n° 23) ;

Attendu qu'en l'espèce le demandeur n'a pas actionné le liquidateur pour voir la responsabilité personnelle de ce dernier engagée ;

qu'il s'est borné à demander la nullité de la clôture de la liquidation ;

[…]

Attendu qu'il y a lieu de constater tout d'abord qu'il n'est pas établi qu'au moment de la dissolution de C.) le défendeur P.) ait, en sachant qu'il existerait encore d'éventuelles créances à l'égard de la société ou un éventuel litige impliquant celle-ci, néanmoins fait une déclaration contraire en pleine conscience du tort qu'il causerait aux éventuels créanciers » ;

[…]

« *Attendu que le demandeur conclut à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la société liquidée C.) ;*

1) Attendu que d'après une certaine doctrine et jurisprudence, la clôture de la liquidation a pour effet la disparition de la personne morale ;

que selon cette théorie la personne morale n'existe plus à l'égard des tiers et qu'il appartient à ses créanciers, conformément à l'article 157 de la loi sur les sociétés commerciales, de faire valoir leurs droits en justice contre les liquidateurs en cette qualité, pendant cinq ans à partir de la publication de l'acte de clôture de la liquidation (Van Ryn, opus cité, t. II, n° 1120 ; Brux. 10e ch., 18 janvier 1963, Pas. belge 1963, II.266) :

2) Attendu que pour d'autres, par la clôture de la liquidation, l'extinction de la société n'est pas absolue, la société continuant d'exister passivement pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle en la personne de ses liquidateurs aussi longtemps que la prescription n'est pas acquise (Cour, 18 avril 1967, Pas. 20.339) ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des deux thèses que la société liquidée, soit qu'elle n'ait plus de personnalité juridique, soit qu'elle continue seulement d'exister passivement, reste représentée dans l'instance par son liquidateur qui n'est assigné qu'en cette seule qualité de représentant de la société ;

qu'il n'y a partant pas lieu de déclarer commun le jugement à la société C.) ».

■ § 4 – La liquidation simplifiée

Il y a lieu de distinguer la situation avant la Loi de Modernisation de la situation prévalant actuellement.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

1) Avant la Loi de Modernisation

La liquidation passe donc en principe par trois phases : la dissolution de la société est décidée par assemblée générale extraordinaire impliquant donc une modification des statuts de la société (première assemblée, en général par acte notarié).

Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs font rapport à l'assemblée sur l'utilisation des valeurs sociales, et cette assemblée nommera des commissaires en fixant une nouvelle assemblée qui, après le rapport des liquidateurs, va se prononcer sur la gestion des liquidateurs (deuxième assemblée).

La troisième assemblée statue sur la gestion des liquidateurs tout en indiquant l'endroit où les livres sont déposés et, le cas échéant, où les fonds non remis sont déposés.

Cette **procédure** en trois phases est assez **lourde**, de sorte que la pratique avait développé une procédure accélérée (ou simplifiée) qui ne comportait qu'une seule assemblée dans laquelle l'associé unique déclarait reprendre à son **compte** la **totalité des actifs et passifs** de la société dissoute, avec donc la conséquence que ce transfert comportait la clôture de la liquidation.

La question était posée de savoir si cette procédure était légale. On pourrait argumenter qu'il n'y a pas à proprement parler de liquidation de la société. En effet, les actifs et les passifs étaient tels quels transférés aux associés sans que le liquidateur ne procède à proprement parler à des opérations de liquidation d'actifs nécessaires au paiement des créanciers.

La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer à l'occasion d'un cas d'espèce dans lequel il y avait application de la procédure simplifiée. Par acte notarié du 20 octobre 1999, l'actionnaire unique A de la société B S.A. a prononcé la dissolution de la société B S.A. en déclarant qu'A est investi de tous les avoirs de B S.A., qu'il réglera tout passif éventuellement inconnu de la société dissoute et que, partant, la liquidation de la société est à considérer comme clôturée. La cour a déclaré les cessions de créance ayant antérieurement appartenu à B S.A. opposables à la société Y S.à r.l. qui était débitrice de B S.A. Cette dernière avait intenté une action judiciaire portant sur la créance que B détenait sur Y S.à r.l.[1].

Dans une autre affaire : « *[…] la fusion comporte pour la société absorbante la réception de tous les biens de la société absorbée avec prise en charge de leur passif ; la société absorbante continue en quelque sorte l'existence de la société absorbée de sorte qu'elle seule a qualité pour figurer comme défenderesse dans la présente instance pour répondre d'éventuels agissements fautifs de la société absorbée* » (en l'espèce une rupture fautive de négociations contractuelles entamées par la société absorbée fut imputée à la société absorbante)[2].

1 – CA du 20 février 2002, n° 25.002, ID 21240, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 25 avril 1986, n° 35.385, ID 10432. Transmission universelle résultant d'une fusion par absorption : les formalités légales en matière de cession de créances n'ont pas à être respectées. CA du 9 février 1994, n° 14.595, ID 12566.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Par acte notarié, l'actionnaire unique d'une S.A. a fait acter la dissolution anticipée de la société et a déclaré, en sa qualité de liquidateur de la société, être investi de tout l'actif de la société et qu'il réglera tout passif éventuellement inconnu de la société dissoute et que, partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

L'actionnaire reprit alors l'instance d'appel dirigée contre la société dissoute par un débiteur de la société, reprise que conteste le débiteur « *à défaut de fusion conforme aux articles 257 et suiv. de la loi sur les sociétés* ». La cour d'appel reconnaît la validité de cette reprise d'instance selon la motivation suivante : par l'effet de l'acte notarié, l'actionnaire unique s'est vu céder l'actif et, partant, la créance de la société vis-à-vis de son débiteur. Par ailleurs, il n'y a pas de disposition légale prescrivant que cette cession de créance d'une société anonyme au profit d'un établissement public se fasse conformément aux articles 257 (nouv. art. 1020-1) et suivants L.S.C., articles régissant la fusion entre sociétés anonymes[1].

La jurisprudence belge adopte la même position : ainsi, la Cour d'appel de Bruxelles, après avoir retenu que la réunion de toutes les actions entre les mains d'un actionnaire unique entraîne la dissolution de la société qui subsiste pour sa liquidation, a arrêté qu'en l'espèce cet actionnaire unique avait en outre manifesté son intention de clôturer immédiatement la liquidation par transfert immédiat du patrimoine social, activement et passivement, dans son patrimoine propre, usant ainsi des pouvoirs de l'assemblée générale qui lui appartenaient[2].

2) Après la Loi de Modernisation

Certaines innovations introduites par la Loi de Modernisation se sont traduites par des modifications du **Code civil**. Il en va ainsi notamment pour le nouvel article 1865*bis* du Code civil. Cette disposition consacre une pratique traditionnelle suivie par les notaires permettant une dissolution sans liquidation pour le cas où la société avait un associé unique et que la société n'avait pas de dettes envers des tiers. Il s'agissait de la pratique dite de « dissolution simplifiée » ou « dissolution turbo », qui consistait en des dissolutions sans liquidation, et ceci, donc sans respecter la procédure complexe en principe obligatoire au vœu de l'ancien article 151 L.S.C. et passant par trois assemblées des associés successives.

Le nouvel article 1865*bis* du Code civil a été inspiré par l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil français, sans toutefois reprendre la dernière phrase de cet article qui permet aux créanciers de s'opposer à cette opération de dissolution. Au lieu de leur permettre de s'opposer à l'opération, le législateur luxembourgeois a étendu les solutions adoptées en matière d'opérations de restructuration de sociétés (fusions et scissions) ou encore de réduction de capital : les créanciers sont autorisés à demander au juge des sûretés, s'ils arrivent à convaincre ce dernier que ces sûretés sont nécessaires pour protéger leurs intérêts[3].

1 – CA du 20 février 2002, n° 25.002, *BIJ*, 2003, p. 9, ID 21240 ;

2 – CA Bruxelles du 20 janvier 1959, *R.P.S.*, 1961, p. 163.

3 – *Doc. parl.,* n° 5730, p. 53, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 1865*bis*. C.c. (version actuelle)

« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d'une société peut dissoudre cette société à tout moment.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal d'arrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l'associé ».

Le terme « parts sociales » utilisé par cet article doit être entendu dans le sens large comme incluant également les actions[1].

La **portée pratique** de cet article n'est pas la même **selon la forme de la société** dont les parts sont réunies en une seule main. S'il s'agit d'une S.à r.l., S.A. ou encore d'une SAS, alors l'alinéa 1er ne peut avoir le caractère de sanction qui lui revient formellement : ces trois formes de sociétés pouvant parfaitement exister en tant que sociétés unipersonnelles, une régularisation obligatoire de la situation ne peut entrer en ligne de compte[2].

Pour les formes de sociétés qui peuvent être unipersonnelles, comme pour toutes les autres, l'alinéa 2 permet de procéder de façon volontaire à la dissolution sans liquidation de la société avec les effets énoncés par le dernier alinéa, à savoir la **transmission universelle de patrimoine sans liquidation**. Contrairement à la situation en France depuis l'introduction de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001, le transfert universel du patrimoine s'applique tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales alors qu'en France, tel n'est pas le cas à l'égard des personnes physiques[3].

La solution prévue par le Code civil est en progrès par rapport à la pratique poursuivie sous la loi ancienne, non seulement en assurant l'effet de « transmission universelle du patrimoine », mais surtout en garantissant les droits des créanciers publics et privés. Certains créanciers publics sont dans une position très enviable dans la mesure où la dissolution simplifiée ne peut se faire (sous **peine de nullité**) que si un **certificat récent de trois administrations publiques** que sont le Centre commun de la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines est obtenu et confirme que la société est en règle par rapport à ses obligations de paiement à l'égard de ces administrations (v. art. 1100-1 (2) L.S.C.).

1 – *Doc. parl.*, no 5730, p. 54, ID 10080.
2 – *Doc. parl.*, no 5730, p. 53, ID 10080.
3 – *Doc. parl.,* no 5730, p. 54, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les autres débiteurs (donc essentiellement les débiteurs privés) peuvent dans les trente jours de la publication de la dissolution demander au président du tribunal d'arrondissement la constitution de sûretés (art. 1865*bis* C.c.).

■ § 5 – Exemple pratique

En date du 1er septembre 2018, deux des trois associés (à parts égales) de la société RTQ S.A., réunis en assemblée générale, ont décidé la dissolution de leur société. Elle a un conseil d'administration composé de trois membres. Le bilan est le suivant :

	Bilan au 31.8.2017		
Actifs		**Passifs**	
Capital non appelé	50.000	Capital	150.000
Immeuble	200.000	Réserve légale	5.000
Stocks	50.000	Report à nouveau	45.000
Banque	200.000	Dettes (dont la moitié à échéance de 3 ans)	600.000
		Pertes de l'exercice courant	(300.000)
Total actifs	500.000	Total passifs	500.000

Il est supposé que les valeurs comptables figurant au dernier bilan correspondent aux valeurs réelles.

Travaux à faire :

1) Décrivez les différentes phases de l'opération de liquidation volontaire d'une S.A.
2) Quel est le statut de la société en phase de liquidation ?
3) Cette dissolution est-elle valablement décidée ?
4) Qui est le liquidateur de la société ?
5) Quelles sont les missions de ce liquidateur ?
6) Comment lui conseillez-vous de procéder par rapport au paiement des créanciers et par rapport aux différents postes d'actifs ?
7) Quelle sera la responsabilité du liquidateur ? Qui peut invoquer celle-ci pendant combien de temps ?

Réponses :

1) Selon l'article 1100-15 L.S.C., une première assemblée décide la dissolution et nomme le liquidateur. Ce dernier procède aux opérations de liquidation proprement dites, paie les créanciers et, en fin de compte, distribue le produit de liquidation aux associés. Une fois la liquidation terminée, il fait un rapport à l'assemblée des actionnaires sur l'emploi des valeurs. L'assemblée va nommer un commissaire à la liquida-

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

tion (un réviseur pour le cas où il s´agit d'une société « moyenne ou grande »). Le commissaire fait un rapport à l'attention de l'assemblée générale qui se prononce sur la liquidation. Une troisième assemblée se prononce sur le rapport et donne décharge aux liquidateurs/commissaires. À la suite à cette assemblée, il y aura la publication de la clôture de liquidation (en même temps que l'indication de l´endroit où les documents sont conservés).

2) La société, après sa dissolution, est réputée exister aux fins de liquidation. Elle garde la pleine personnalité morale sauf que, n'existant plus que pour les fins de liquidation, elle ne pourrait pas en principe s'engager dans de nouvelles affaires.
3) La dissolution requiert en principe la majorité des deux tiers, ce qui est le cas en l'occurrence. Par ailleurs, on peut dire que le capital social étant réduit à moins d'un quart, il suffirait en principe d'un quart des actions pour décider la dissolution.
4) Le liquidateur est nommé par l'assemblée générale des associés, celle qui décide la dissolution de la société. En l'absence de nomination de liquidateurs, l'organe de gestion en place fait fonction de liquidateur : il s'agit donc du conseil d'administration.
5) Les missions sont : faire l'état des actifs et passifs, liquider les actifs et enfin payer les créanciers de la société. Le solde qui resterait après ces opérations est distribué aux associés. Le liquidateur fait un rapport sur la liquidation aux associés pour la deuxième assemblée.
6) En cas d'insuffisance d'actifs, comme en l'occurrence, les créanciers sont à payer au **marc le franc,** indépendamment du fait que certaines créances sont à terme. Un escompte peut être pris en compte pour ces créanciers à terme. Le liquidateur devrait en premier lieu demander le paiement de la partie non appelée du capital. En effet, tous les créanciers ne pouvant être payés, il faudra pour se couvrir demander aux actionnaires la réalisation de leurs engagements. Les actifs sont de 500.000, les dettes de 600.000. Le liquidateur peut donc payer 5/6es du nominal de ces dettes (à supposer qu'il ait appelé et reçu les fonds propres non encore libérés).
7) Le liquidateur est responsable vis-à-vis des créanciers et des actionnaires des fautes commises dans sa mission de liquidation. Sa responsabilité peut être mise en cause pendant 5 ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.

■ § 6 – La dissolution forcée

Souvent, la dissolution et la liquidation d'une société ne sont pas des opérations volontaires. En effet, l'article 1200-1[anc. art. 203] L.S.C. permet la dissolution d'office des sociétés commerciales (en plus des liquidations par faillite de la société).

Cette disposition a été introduite afin de donner aux pouvoirs publics une arme efficace pour veiller au respect des dispositions régissant le fonctionnement des sociétés commerciales, étant donné que les sanctions pénales se révèlent très

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

souvent inefficaces dans la mesure où les administrateurs et responsables des sociétés séjournent souvent hors atteinte des organes judiciaires[1].

La jurisprudence insiste souvent sur les points suivants qui ont trait à la genèse de cet article de la L.S.C. « *Il ressort des travaux parlementaires relatifs à l'introduction de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales que le premier souci du législateur était de préserver "nos intérêts nationaux", ainsi que "le renom de notre place financière", en mettant à la disposition des pouvoirs publics un moyen efficace pour enrayer les abus commis par des sociétés de nationalité luxembourgeoise opérant notamment à l'étranger, sans respecter les règles régissant les sociétés commerciales luxembourgeoises, ou exerçant des activités illégales, pour lutter contre les sociétés "coquille-vide", sans activité et sans organes sociaux, et pour veiller, de manière générale, au respect des lois luxembourgeoises.*

Toutefois, contrairement aux textes pénaux, la formulation même du prédit article 203 révèle que le législateur a laissé au tribunal un pouvoir souverain d'appréciation dans l'application de cet article. En effet, le tribunal a la faculté de prononcer la dissolution et la mise en liquidation d'une société qui a contrevenu aux dispositions du droit pénal, du droit des sociétés ou du droit d'établissement, en appréciant, au cas par cas, si les contraventions constatées justifient une dissolution de la société, et si la dissolution constitue un moyen efficace au sens du texte de loi.

Alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que la société SOC. 1) est une société "coquille-vide" dépourvue d'activité et d'organes sociaux, il s'agit d'apprécier si les contraventions au droit des sociétés constatées justifient une dissolution, et si la dissolution constitue un moyen efficace pour remédier à la situation actuelle »[2]. Dans le cas d'espèce, le tribunal a répondu par la négative à cette question.

A – Dissolution sur la base de l'article 1200-1 L.S.C.

À la requête du procureur d'État, le tribunal d'arrondissement « *[…] peut prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales y compris en matière de droit d'établissement* ». Selon la jurisprudence, « *[…] seul le Ministère public peut dès lors juger de l'opportunité qu'il existe à poursuivre une société en justice sur base de l'article 203,[…], le Procureur d'État étant en effet à considérer comme offrant toutes les garanties pour qu'une demande sur base de l'article 1200-1ne soit pas présentée à la légère* »[3].

Art. 1200-1 L.S.C.
« [...]
(3) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode

1 – V. projet de loi n° 2104, p. 2, ID 9785 ; CA du 25 mars 2003, *BIJ*, 2003, p. 106.
2 – TA Lux. du 13 novembre 2104, n° 164821, ID 24647.
3 – CA du 15 février 2006, n° 28.050, ID 14475.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

(4) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux imprimés au pays, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne.

Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(5) Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(6) En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l'État et liquidés comme frais judiciaires.

(7) *Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation* ».

L'article 1200-2 L.S.C. prévoit l'application analogue des dispositions de l'article 1200-1 aux établissements luxembourgeois de sociétés étrangères.

Le dernier alinéa de cette disposition prévoit des sanctions pénales qui ne sont pas prévues par l'article 1200-1 L.S.C.

« *Est puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 1.250 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article* ».

La référence au droit d'établissement vise la loi du 31 mai 1999[1] régissant la domiciliation des sociétés, qui définit ainsi cette activité : « *Lorsqu'une société établit auprès d'un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit un contrat de domiciliation* ».

Conformément au libellé très large de la loi, il existe une grande variété de cas d'ouverture de cette disposition. Nous citons ci-après certains cas qui sont assez typiques et fréquents en pratique.

Il y a souvent rappel de la *ratio legis* de l'article 1200-1 L.S.C. via citation des travaux préparatoires de la loi du 19 mai 1978 ayant introduit cette disposition[2].

La question de la conformité de l'article 1200-1 L.S.C. par rapport à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est soulevée (la requête en dissolution ne contenant pas d'assignation à comparaître, la procédure serait dénuée de caractère contradictoire, la société n'étant pas à même de présenter ses moyens de défense), mais sans dommage pour l'article 1200-1 (le tribunal d'arrondissement estime que la société est informée de la procédure par la notification de la requête et dispose de la possibilité de

1 – Loi du 31 mai 1999, ID 1694, *Doc. parl.*, n° 4328, ID 9879.

2 – TA Lux. du 18 novembre 1982, n° 29.695, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

prendre connaissance du dossier et de préparer sa défense par la possibilité qui lui est ouverte de former opposition contre le jugement de dissolution)[1].

Les juridictions rappellent que, pour la mise en œuvre de l'article 1200-1 L.S.C., il n'y a pas d'obligation du ministère public de mettre la société en demeure de se conformer aux dispositions de la loi avant d'introduire l'action en dissolution[2].

La solvabilité de la société n'entre, en principe, pas en ligne de compte dans la mesure où la dissolution d'une société n'est pas opérée pour des raisons de manque de liquidités[3]. La régularisation des infractions passées peut également inciter la juridiction à ne pas prononcer la mise en liquidation de la société, surtout évidemment si l'infraction constatée n'était pas excessivement grave (p. ex., un bilan non publié)[4].

Le délai pour faire opposition contre un jugement de liquidation d'une société pris sur la base de l'article 1200-1 L.S.C. ne court pas à partir des publications faites au RESA et dans les journaux, mais uniquement à partir de la notification en bonne et due forme du jugement à la société mise en liquidation (sauf éventuellement s'il était établi que la société a eu connaissance dudit jugement de liquidation)[5].

Les cas les plus fréquents en pratique sont de loin ceux de non-publication des comptes annuels.

1) Cas de non-publication des comptes annuels

Selon la jurisprudence, le rapport de la Commission juridique de la Chambre des Députés sur l'introduction de l'article 1200-1dans la L.S.C. retient comme infraction grave à cette loi (dans le sens de l'article en question) le fait de ne pas tenir les assemblées générales dans les douze mois de la clôture de l'exercice ou le fait de ne pas publier les comptes annuels après leur approbation, la gravité étant fonction du retard apporté à la publication.

Il relève surtout qu'il faut considérer comme graves les infractions aux règles destinées à protéger les intérêts des tiers[6]. Ces tiers englobent en particulier les cocontractants et les créanciers de la société, qui ont intérêt à pouvoir se renseigner sur sa situation financière[7].

Le droit des sociétés tient compte de ces divers états en prévoyant des règles différentes :

– le principe d'égalité et le droit à l'information suffisent pour l'essentiel à protéger les associés en état passif ;
– les règles relatives à l'intervention dans le fonctionnement de la société garantissent les droits des associés en état de simple critique ;
– la contractualisation intéresse surtout les associés qui participent à la gestion. « *La prise en compte de ces divers intérêts aboutit à la reconnaissance*

1 – TA Lux. du 24 juin 1983, n° 692/83, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 20 juin 1984, n° 6.557, ID 10486.

3 – TA com. Lux. du 18 décembre 2003, n° 1103/03, *BIJ*, 2004, n° 9, p. 180.

4 – TA com. Lux. du 18 décembre 2003, n° 1103/03, *BIJ*, 2004, n° 9, p. 180.

5 – TA Lux. du 19 février 2009, n° 119.037, *BIJ*, 2009, n° 6.

6 – TA Lux. du 18 novembre 1982, n° 190/82 et TA Lux. du 27 septembre 1990, n° L-140/90.

7 – TA Lux. du 24 juin 1983, n° 692/83.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de plusieurs "cercles d'intérêts" gravitant autour de la société : ceux purement égoïstes des associés ou actionnaires, ceux de la collectivité des associés ou actionnaires, ceux de l'ensemble des personnes intéressées par le fonctionnement de la société (outre les associés ou actionnaires, les travailleurs, les créanciers, etc.), ceux du public en général »[1].

La disposition en question est souvent appliquée en pratique, notamment à l'égard des sociétés qui vivent en violation continue avec les dispositions sur la publication des états financiers. « *Les dispositions légales dont le non-respect par les sociétés est sanctionné par l'article 203 de la L.S.C. concernant les sociétés commerciales ont essentiellement pour objet la protection des tiers. Les délais prévus pour la publication des documents sociaux en sont un élément essentiel de sorte qu'en vue d'éviter de rendre toute protection efficace illusoire, une régularisation postérieure ne saurait empêcher la mise en œuvre de la sanction de la dissolution et de la liquidation judiciaires* »[2].

Il n'est pas suffisant de déposer des bilans, encore faut-il que ceux-ci répondent aux règles prescrites par la loi. Sinon, le tribunal risque de conclure à la violation grave des dispositions de la L.S.C. (cas de dépôt de formulaires blancs non signés avec la mention « Pas d'activités commerciales » pour les années respectives[3]).

« *La violation des dispositions légales sur l'approbation de ces comptes annuels et leur publication, édictées tant dans l'intérêt des tiers que dans l'intérêt du renom de la place financière, est considérée comme une violation grave de la loi sur les sociétés commerciales. Ces dispositions légales sont impératives et ne permettent pas de régulariser les formalités après un certain temps* »[4].

Les dispositions relatives à la publication des comptes sont instituées dans l'intérêt du public. « *Dans notre législation sur les sociétés commerciales, il convient de faire la distinction entre les prescriptions de la loi qui existent dans l'unique intérêt de l'actionnaire ou d'un souscripteur, et celles qui existent dans l'intérêt du public. D'après le rapport de la commission juridique, le tribunal, en appréciant l'opportunité de la dissolution, devra se limiter aux cas où des règles édictées dans l'intérêt des tiers n'auront pas été respectées* ».

Selon la jurisprudence, « *[…] le terme "tiers" vise toutes les personnes – physiques ou morales – qui traitent ou veulent traiter avec la société ou lui portent un intérêt de quelque nature que ce soit. Ces personnes ont un intérêt manifeste à ce que la société tienne une comptabilité régulière, fasse approuver ses bilans par l'assemblée générale des actionnaires, les dépose au registre de commerce et des sociétés et, d'une manière générale, fonctionne dans le respect des dispositions légales* »[5].

Les délais prévus sont un élément essentiel de ces formalités en vue d'assurer une information, partant une protection, efficace, en sorte que les irrégularités commises ne soient pas susceptibles d'être redressées par l'exécution ultérieure desdites formalités[6].

---

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 138.

2 – CA (com.) Lux. du 19 mai 1993, *P.*, n° 29, p. 267, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA Lux. du 7 février 1991, n° L-1493/91, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA du 26 mars 2003, *BIJ*, 2003, p. 106, ID 26949.

5 – CA du 15 février 2006, n° 28.050, ID 14475.

6 – TA Lux. du 28 mars 1991, n° 1502/91, ID 10180.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans un cas, la dissolution d'une S.A. (sur la base de l'article 1200-1 L.S.C.) fut prononcée, la société n'ayant pas déposé ses comptes depuis sa constitution. Le tribunal rappelle qu'il dispose d'un **pouvoir souverain** à cet effet et qu'il ne doit pas avoir égard au fait que le non-respect du prescrit légal soit ou non dû à une disparition de l'*affectio societatis* ou à une autre cause(1).

Sur la question de l'introduction de l'action en justice de la société-personne morale, voir également la jurisprudence citée sous l'article 1832 C.c., ainsi que la jurisprudence citée ici sous les articles 100-3 et 441-5 L.S.C.

La dissolution (sur la base de l'article 1200-1 L.S.C.) d'une S.à r.l. fut également prononcée à défaut de dépôt des comptes au cours de deux années consécutives et en dépit d'un dépôt ultérieur et de l'allégation selon laquelle la situation financière de la société était saine. Le tribunal relève que la société ne démontre pas que le non-dépôt des comptes serait dû à un « *événement indépendant de sa volonté* »(2).

Les dispositions légales imposant aux sociétés commerciales les diverses formalités dont l'omission est sanctionnée par l'article 1200-1 L.S.C. ont essentiellement pour objet la protection des tiers. Les délais prévus par la loi sont un élément essentiel de ces formalités, et toute possibilité d'information, partant de protection efficace, devient impossible si ces délais ne sont pas respectés. Les dispositions légales qui ont trait à la publication du bilan et du compte de profit et pertes sont impératives et ne peuvent être régularisées après plusieurs années(3). Fut encore prononcée la dissolution d'une S.à r.l. en raison du non-dépôt de ses comptes annuels et de la non-adaptation de son capital au minimum légal. Le juge repousse l'argument tiré de la régularisation ultérieure(4).

La sanction de la dissolution pour non-dépôt des comptes a encore été retenue dans un autre cas dans lequel la société n'avait pas établi que l'inaccomplissement des formalités légales serait dû à un **événement indépendant** de sa volonté(5). En reprochant l'absence, voire le retard considérable, du dépôt au R.C.S. des bilans et des comptes de profits et pertes annuels de la société, le tribunal a constaté une violation grave, selon l'article 1200-1 L.S.C., des dispositions légales ayant essentiellement pour but la protection des tiers, par la publicité. Le tribunal n'a, à ce sujet, pas à rechercher les causes de la contravention constatée. S'il est vrai que les bilans ne peuvent être publiés qu'après avoir été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, qui seule est autorisée à procéder aux nominations des administrateurs et commissaires, le retard considérable pour régulariser ces formalités impératives est dû, selon l'aveu même de l'appelante, au défaut de tenue d'une assemblée générale qui, selon l'article 450-8 alinéa 1er (anc. art. 70 al. 1er) de la loi précitée du 10 août 1915, « *doit être tenue chaque année au moins […]* », et non deux années et demie après sa constitution. Le tribunal reprochait donc à juste titre à la société un manque d'organisation mettant en péril les intérêts des tiers. Décider le contraire reviendrait à faire dépendre l'accomplissement des formalités impératives prévues

1 – TA Lux du 25 mai 1989, n° L-1094/89, ID 10398.

2 – TA Lux du 25 mai 1989, n° L-1095/89, ID 10399.

3 – TA Lux. du 25 octobre 1990, *P.*, n° 29, p. 46, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 29 novembre 1990, n° 39.884, ID 10178.

5 – TA Lux. du 18 juin 1992, n° 266/92, ID 10193.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

à l'article 461-18 (anc. art. 75) L.S.C. du bon vouloir des actionnaires de tenir une assemblée générale[1].

Dans un cas d'espèce, il y a eu confirmation de la dissolution, sur la base de l'article 1200-1 L.S.C., société anonyme demeurée en défaut de déposer son bilan et compte de profits et pertes depuis sa création (six ans auparavant)[2].

La cour d'appel confirma un jugement ayant ordonné la dissolution d'une S.A. demeurée en défaut de déposer ses comptes durant plusieurs années, refusant au passage de tenir compte de l'argument selon lequel l'article 1200-1 L.S.C., figurant dans une section consacrée aux S.à r.l., ne serait pas applicable aux sociétés anonymes[3].

Les dispositions légales dont le non-respect par les sociétés est sanctionné par l'article 1200-1 de la L.S.C. concernant les sociétés commerciales, ont essentiellement pour objet la protection des tiers. Les délais prévus pour la publication des documents sociaux en sont un élément essentiel, de sorte qu'en vue d'éviter de rendre toute protection efficace illusoire, une régularisation postérieure ne saurait empêcher la mise en œuvre de la sanction de la dissolution et de la liquidation judiciaires[4].

Dans un cas d'espèce, la Cour d'appel de Luxembourg a retenu le raisonnement suivant : le but de l'article 1200-1 L.S.C. est de faire disparaître par voie judiciaire les sociétés qui se mettent en position illégale caractérisée (en l'occurrence la non-publication des comptes annuels des années 1986 et 1987). Ce but est atteint à l'égard d'une société qui, en cours d'instance, se met régulièrement en liquidation volontaire, même postérieurement à un jugement ordonnant la dissolution et la liquidation judiciaire[5]. « *Si une société commerciale en situation irrégulière se met régulièrement en liquidation volontaire, même postérieurement à un jugement ordonnant la dissolution et la liquidation judiciaire, ces mesures ne sont plus nécessaires et le jugement en ordonnant la dissolution et la liquidation est à rapporter* »[6].

Cette position est toutefois rejetée par d'autres décisions, notamment : « *[…] le seul fait que l'associé X fait acter le 8 octobre 1991 par un notaire qu'il est devenu actionnaire unique, qu'il a décidé de procéder avec effet immédiat à la dissolution de la société en reprenant tout l'actif et qu'il considère ainsi la liquidation comme terminée, sans qu'intervienne un liquidateur étranger à la société pour confirmer ses dires, à savoir que l'actionnaire devenu titulaire de tous les droits sociaux et, constituant ainsi à lui seul de tous les droits sociaux et, constituant*

1 – CA du 9 novembre 1994, n° 16.550, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 30 avril 1997, n° 19.790, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA du 28 juin 2000, n° 23.346, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA du 19 mai 1993, *P.*, n° 29, p. 267, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – CA (com.) du 20 février 1991, *P.*, n° 28, p. 145, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – TA Lux. du 24 juin 1983, n° 692/83, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ainsi à lui seul l'assemblée générale des actionnaires, est investi de tout l'actif de la société et sera tenu de tous les engagements de celle-ci et que la liquidation est effectivement clôturée, ne suffit pas pour rendre sans objet une liquidation judiciaire. De plus, une liquidation volontaire d'une société commerciale sur le fondements des articles 141 et suivants de la L.S.C. ne fait pas obstacle à une procédure en liquidation judiciaire de la même société sur la base de l'article 203 de la même loi, si, comme en l'espèce, il est dans l'intérêt de l'ordre public, eu égard aux circonstances, et, en particulier, à la gravité des infractions à la loi, que le tribunal garde la haute main sur la liquidation et que celle-ci se fasse par un liquidateur indépendant, suivant les règles régissant la liquidation de la faillite »[1]-[2]-[3].

Sont également sans pertinence l'absence pratiquement totale de **rapports avec des tiers** (en raison du statut de société *holding*) et l'absence de préjudice dans le chef de tierces personnes. Ces circonstances ne sont pas de nature à influer sur la qualification des faits constatés par le ministère public et à en diminuer la gravité[4].

L'absence de préjudice subi par des tiers n'est d'aucune pertinence sur la qualification des faits en cause[5].

Dans une espèce où, en application de l'article 1200-1 (2) L.S.C., le juge avait déclaré applicables à la liquidation d'une S.A. les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, le tribunal avait accueilli la demande visant à modifier le mode de liquidation, au profit des règles de droit commun formulées aux articles 1100-1 à 1100-15 L.S.C., au motif que les règles de la faillite étaient inadaptées à la liquidation en question (la société dénuée de passif était propriétaire d'immeubles, partant une vente des immeubles par le liquidateur en application des règles régissant la faillite eut été hautement préjudiciable aux actionnaires de la société)[6].

2) Absence de domicile de la société

Art. 1300-2, alinéa 4, L. S.C.
« *Le défaut de domicile connu constitue dans le chef d'une société une contravention grave à la loi, susceptible de lui faire encourir la dissolution ou la fermeture judiciaires conformément aux dispositions des articles 1200-1 et 1200-2* ».

Un autre champ d'application fréquent de cette disposition est la loi sur la domiciliation des sociétés du 31 mai 1999. Selon ladite loi, chaque société « *qui établit auprès d'un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet*

1 – CA du 30 juin 1993, n° 14.977, ID 10198.

2 – CA du 27 octobre 1999, n° 23.345, *Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves*, n° 98, avril 2001, pp. 47 ss., cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA du 19 février 1999, n° 22.433, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA du 11 mai 2004, n° 29.563, *BIJ*, 2005, n° 8.

5 – CA du 25 mars 2003, *BIJ*, 2003, p. 106.

6 – TA Lux. du 6 février 2003, n°s 74.169 et 74.190, ID 15676.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité » doit conclure avec ce prestataire de services, appelé domiciliataire, un contrat de domiciliation. Le non-respect des dispositions de cette loi est considéré comme un cas d'ouverture des articles 1200-1 et 1200-2 L.S.C.[1].

La jurisprudence retient que la disposition légale n'oblige pas le ministère public à procéder à une mise en demeure de la société contrevenant aux dispositions légales[2]. Il n'est pas requis non plus que la preuve de la violation de l'intérêt d'un tiers soit apportée[3]. Par ailleurs, le tribunal n'est pas tenu de rechercher les causes de la violation de la loi, en particulier si la violation des articles 461-1 L.S.C. et suivants est due à une disparition de l'*affectio societatis* ou non[4].

Quant au moment où les conditions de l'article 1200-1 L.S.C. doivent être remplies : « *L'existence des contraventions à la loi modifiée du 10 août 1915 fondant la requête en dissolution et liquidation d'une société commerciale du parquet sur la base de l'article 203 de la prédite loi s'apprécie au moment de l'introduction de la requête* »[5].

3) Irrégularité de la dénomination sociale

L'omission du nom du commandité dans la raison sociale, impérativement prévue par la L.S.C. (avant 2013), a été considérée comme une violation suffisamment grave de la L.S.C. pour justifier la mise en liquidation de la société en application de l'article 1200-1 L.S.C. : « *[…] il est d'un intérêt évident des tiers qui traitent avec la société de connaître le nom d'un associé indéfiniment et solidairement responsable des engagements sociaux* »[6].

B – Dissolution forcée pour justes motifs

La dissolution pour justes motifs (prévue par l'article 1871 C.c.)[7] est applicable à toutes les formes de sociétés : il s'agit d'une disposition impérative. Ici, contrairement aux cas visés *sub* 1), l'initiative de la procédure de dissolution n'appartient pas au ministère public, mais à une personne intéressée qui saisit la justice. L'existence de justes motifs est laissée à l'appréciation des juges.

L'article 1871 C.c. mentionne les exemples suivants de tels justes motifs : les cas où l'un des associés manque à ses engagements, où une infirmité habituelle le rend

1 – Art. 5 de la loi du 31 mai 1999, ID 1694.

2 – CA du 20 juin 1984, n° 6.557, ID 10486.

3 – TA Lux. du 14 juin 1990, n° 1352/90, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 25 mai 1989, n° 1094/89, ID 10398.

5 – TA Lux. du 25 mai 1989, n° 1095/89, ID 10399.

6 – TA Lux. du 26 mars 1992, n° 1796/92, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

7 – « *La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges* », ID 11337.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

inhabile aux affaires de la société pour se référer à « *d'autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges* ».

Quels sont les cas de dissolution finalement retenus par les juridictions ? Si les causes de dissolution dans le sens de la disposition visée ne sont pas limitées, on peut classifier les causes les plus communément admises dans les catégories suivantes :

La **mésintelligence entre associés** doit être telle qu'elle compromet la situation de la société et peut entraîner la dissolution de celle-ci. « *La mésentente grave entre associés constitue un motif autorisant la dissolution anticipée d'une société, dès lors qu'elle empêche toute action commune et met en jeu l'existence de la société. De mauvais rapports entre associés qui n'entravent pas le fonctionnement normal de la société sont par contre insuffisants pour justifier une telle décision* »[1]. Le tribunal a entre autres justifié sa décision par le fait que le demandeur ne détenait que 40 parts sociales sur 200 et n'était pas gérant de la société. Par conséquent, la société pouvait parfaitement continuer à fonctionner normalement[2].

Cette mésentente doit être « *assez grave pour paralyser la marche de la société, pour empêcher la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux ; il ne suffit dès lors pas que les associés soient en mauvais rapport entre eux et la dissolution doit être refusée lorsque la société n'est pas en péril* »[3].

Ou encore : « *L'article 1871 du Code civil est à interpréter en ce sens qu'il est exigé que les dissensions entre associés soient assez graves pour paralyser la marche de la société* »[4].

Le décès d'un co-associé détenant la moitié des parts sociales a été considéré comme étant « *de nature à mettre en danger la vie de la société en empêchant la tenue régulière des assemblées et le fonctionnement des organes sociaux et justifie partant une dissolution avant terme pour justes motifs dans le sens de l'article 1871 du Code civil* »[5].

Une mésentente grave constituant une entrave majeure au fonctionnement de la société est considérée établie en vue d'aboutir à la dissolution de la société (application de l'article 710-3, alinéa 3 anc. art. 180-1, alinéa 1er, L.S.C.) sur la base des faits suivants : violation des statuts (divers actes posés par un seul gérant alors que les statuts exigeaient le consentement du co-gérant) et des lois sur les sociétés commerciales (non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels) par l'un des deux gérants (le même gérant refusant communication d'un bilan, faisant ainsi perdre tout moyen de contrôle à l'associé minoritaire, utilisant du matériel de la société à des fins privées) ; en outre, licenciement et éviction des locaux de la société de l'associé gérant minoritaire, constitution d'une autre société située au même siège social avec un objet social identique par l'associé majoritaire avec déclaration d'intention de faire tomber en faillite la première société. La cour précise à cet égard : « *Du moment qu'une juridiction, saisie d'une*

1 – TA Lux. du 2 février 1977, *P.*, n° 24, p. 58, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TALux. du 2 février 1977, *P.*, n° 24, p. 60, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA Lux. du 13 décembre 1991, n° 40.049, ID 10187.

4 – TA Lux. du 14 mai 1993, n° 42.183, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – TA Lux. du 13 juin 1986, n° 36.821, ID 10433.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

demande en dissolution d'une société, constate l'existence d'une mésentente mettant en danger le fonctionnement de la société, elle n'a pas à établir à laquelle des parties au litige la responsabilité de cette situation incombe. N'étant pas saisie d'une demande en dommages-intérêts pour faute contractuelle, mais uniquement d'une demande en dissolution, la cour n'a qu'à apprécier l'existence de justes motifs de cette dissolution, sans avoir à aviser la gravité respective des fautes invoquées de part et d'autre »[1].

La cour prononce la dissolution d'une S.à r.l. dans une espèce où les associés étaient en désaccord quant à la conservation de la qualité d'associé de l'un d'eux, ce qui avait notamment abouti à l'annulation d'une assemblée générale tenue sans l'associé dont on n'avait pu prouver qu'il avait perdu cette qualité. « *Constitue un juste motif la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. En l'espèce, la mésentente entre associés, qui se traduit par le fait que l'associé (X) ne reconnaît plus à (Y) la qualité d'associé, a eu pour conséquence la tenue d'assemblées générales irrégulières.*

Puisque l'un des rouages essentiels de la société ne fonctionne plus, la paralysie de la société est établie »[2].

La même conclusion fut dégagée par une autre décision : « *La mésentente entre associés est une cause de dissolution dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société, et il n'y a pas lieu dans ce cas d'établir à laquelle des parties au litige la responsabilité de cette situation incombe* »[3].

L'article 710-3, alinéa 3 L.S.C. prévoit que la dissolution d'une société à responsabilité limitée constituée pour une **durée illimitée**, tel que cela est le cas en l'espèce, peut être demandée en justice pour de justes motifs.

Une dissolution judiciaire ne doit intervenir à la demande de l'un des associés que pour de justes motifs, c'est-à-dire sérieux et conséquents révélant une situation grave dans la société, de nature à rendre périlleuse la poursuite de son activité pour les intérêts qui y sont engagés. Il est exigé que les dissensions entre associés soient assez graves pour paralyser la marche de la société, pour empêcher la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux ; il ne suffit dès lors pas que les associés soient en mauvais rapports entre eux, et la dissolution doit être refusée quand la société n'est pas en péril[4].

« *La mésentente ou la mésintelligence entre associés ne justifie la dissolution que si les dissentiments sont assez profonds et persistants pour compromettre le fonctionnement normal et l'existence de la société, pour empêcher toute action commune, la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux* »[5]. Dans cette affaire, la cour a retenu que le fait pour un associé de ne pas être convoqué aux assemblées générales et le défaut de publication des

1 – Décision au premier degré en cette affaire (refuse la dissolution) : TA Lux. du 13 décembre 1991, n° 40.049, ID 10187 ; CA du 29 septembre 1993, n° 14197, ID 10202.

2 – CA. du 26 novembre 1997, n° 20.149, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA 16 janvier 2003, ID 10356.

4 – Trib. Lux. du 30 mars 1996, TA Lux. du 10 novembre 2000, n° 49.599, ID 10260.

5 – CA (com.) Lux. du 18 juin 2003, n° 26.917, ID 10373.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

comptes annuels des années 1998 à 2000 dans les délais légaux ainsi que l'infraction de faux bilan (à la supposer établie) ne constitue pas un juste motif de liquidation.

La doctrine et la jurisprudence belges s'expriment dans le même sens : « *Les tribunaux ont toujours considéré que la mésentente à elle seule était insuffisante pour provoquer la dissolution, il faut encore que les faits invoqués soient de nature à compromettre définitivement l'avenir de la société, à paralyser de façon durable la vie sociale* »[(1)].

Le recours à l'article 1871 C.c. a déjà été limité par le passé. Si, dans la conception classique, la notion des justes motifs s'appréciait en considération de l'associé qui demandait la dissolution, les juridictions belges ne prononcent la dissolution que s'ils compromettent irrémédiablement la vie sociale, créant une situation inextricable[(2)].

« *La dissolution judiciaire pour justes motifs est accueillie comme une adaptation au contrat de société de la résolution judiciaire des contrats pour inexécution (cf. Jurisclasseur Droit civil vo. Société* sub *art. 1832 à 1844-17, fasc. 70, n° 38 ; RIPERT et ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, t. I, p. 498, n° 782). On y voit un correctif à l'omnipotence de l'assemblée, une application particulière de la théorie des droits propres de l'actionnaire (cf. PIC et BARATIN,* op. cit*., p. 418, n° 395).*

Cette cause de dissolution est applicable à toutes les sociétés (RIPERT et ROBLOT, loc. cit*.).*

L'article 1871 du Code civil se réfère, il est vrai, aux sociétés à durée limitée. Mais l'on s'accorde à reconnaître qu'en visant les sociétés à terme, cet article a statué de eo quod plerumque fit*, et qu'il doit pouvoir être invoqué même par les membres d'une société à durée illimitée, toutes les fois que ceux-ci ont intérêt à s'en prévaloir (cf. PIC et BARATIN* loc. cit*.).*

Le droit, pour un associé, de demander la dissolution d'une société lorsqu'il existe de justes motifs est considéré par la jurisprudence comme une disposition d'ordre public. Ce droit rentre dans les droits propres et intangibles des associés auxquels nulle restriction ne peut être apportée par les statuts, non plus d'ailleurs que par une décision de l'assemblée générale au cours de l'existence sociale (cf. Dalloz : Sociétés vo. Dissolution n°s 105 et 106 ; Jurisclasseur Sociétés loc. cit*. n° 43 ; Jurisclasseur Droit Civil,* loc. cit*., n° 47 ; PIC et BARATIN, n° 395, p. 418 ; RIPERT et ROBIOT,* op. cit*., n° 794, p. 499). Aucun texte légal précis ne prévoit d'ailleurs une procédure préalable spéciale à suivre dans une telle hypothèse. Le moyen d'irrecevabilité afférent est partant à rejeter comme étant dépourvu de justification* »[(3)].

« *Il est de principe que la société doit prendre fin lorsque la mésintelligence a remplacé l'*affectio societatis *considéré comme un élément essentiel de la société. Mais*

1 – A. Benoit-Moury, « Des justes motifs de dissolution des sociétés commerciales de l'article 1871 du Code civil à l'art. 102 des L.C.S.C. », *Liber amicorum Jan Ronse*, Bruxelles, Story-Scientia, p. 161, qui cite notamment CA Bruxelles du 2 avril 1968, *R.P.S.*, 1968, p. 246 ; CA Bruxelles du 15 octobre 1971, *R.P.S.*, 1972, p. 217 ; Trib. com. Liège du 2 novembre 1971, *Jur. Liège*, 1971-1972, p. 85 ; Civ. Bruxelles du 12 juin 1973, III, p. 72.

2 – A. Benoit-Moury, « Des justes motifs de dissolution des sociétés commerciales de l'article 1871 du Code civil à l'art. 102 des L.C.S.C. », *Liber amicorum Jan Ronse*, Bruxelles, Story-Scientia, p. 165.

3 – TA Lux. du 22 mars 1989, n° 35631, ID 24570.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

l'intention d'être associé qui caractérise l'engagement d'associé ne saurait disparaître au gré des caprices de chacun. La mésintelligence ne doit pas être confondue avec le simple mécontentement ou la mauvaise humeur de quelques associés. La mésentente ou mésintelligence entre associés ne justifie la dissolution que si les dissentiments sont assez profonds et persistants pour compromettre le fonctionnement normal de la société (cf. Jurisclasseur Droit civil, loc. cit., *n° 42 ; Dalloz : Sociétés,* loc. cit., *n° 100).*

Il convient donc aux fins d'apprécier le bien-fondé d'une demande en dissolution d'une société fondée sur le susdit article 1871 du Code civil, de prendre en considération uniquement l'intérêt même de la société. Si celle-ci est en péril et ne peut plus fonctionner, nul doute qu'il soit nécessaire de mettre un terme à son existence. En revanche, lorsque la société est prospère et fonctionne normalement, les dissentiments entre associés ne sont pas suffisamment graves pour légitimer une dissolution (Dalloz : Sociétés, loc. cit., *n° 102)* »[1].

Au sujet de l'inexécution de ses engagements par un des associés, la jurisprudence ne s'arrête pas à une application littérale des conditions légales. Pour être admissible comme cause de dissolution, il faut que cette inexécution des engagements soit à même de compromettre le fonctionnement normal de la société. En général, cette condition ne sera remplie que si l'un des associés omet de faire l'apport d'un bien particulièrement important pour la société (p. ex., un brevet indispensable à l'exploitation de la société)[2].

En cas de défaillance d'un des éléments essentiels du contrat de société, cas d'ouverture de ce principe énoncé par l'article 1867 C.c. qui prévoit que la **perte de l'apport** à effectuer par l'un des associés avant que l'apport n'en soit fait opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. C'était également par application de cette règle que, par le passé, avant la Deuxième directive CEE, l'on procédait à la dissolution de plein droit de la société par réunion de tous les titres en une seule main dans le cas où une règle formelle de la L.S.C. ne s'opposait pas à cette façon de procéder[3].

■ § 7 – Dissolution à des conditions allégées : pertes substantielles

En droit luxembourgeois, la perte d'une partie, voire de la totalité, du capital social ne donne pas lieu à la dissolution et à la liquidation automatique de la société déficitaire. Il n'y a pas non **plus d'obligation** des actionnaires **de renflouer** la société, et ceci, en restaurant le montant du capital social. La seule conséquence est en fait que la question de la continuation de l'exploitation ou de la dissolution de la société doit être posée à l'assemblée générale des associés (en fait l'assemblée générale ordinaire), et que la dissolution de la société peut être prononcée à des conditions fortement allégées par rapport au droit commun.

Les dispositions en question, basées sur la **Deuxième directive** (art. 17), prévues par l'article 480-2 L.S.C., sont d'**ordre public** dans la mesure où elles assurent une

1 – TA Lux. du 25 février 2014, n°s 136113 et 136114.

2 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 245.

3 – J. Delvaux, A. Wildgen et R. Breininger, « La réunion de tous les titres d'une société anonyme en une seule main », *Ann. dr. lux.*, 1993, Vol. 2, p. 83.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

protection minimale des associés : « *Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, convoque, de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l'être, l'assemblée générale qui délibérera, le cas échéant dans les conditions de l'article 450-3, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour* ».

Le dernier alinéa de cet article prévoit la sanction de la violation de cette disposition :

« *En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de l'accroissement de la perte* ».

En réalité, la non-convocation de l'assemblée est à l'origine du préjudice des créanciers uniquement si les associés avaient voté la dissolution de la société en évitant ainsi l'accroissement de la perte.

Quelle est donc la forme de l'AG qui doit être convoquée dans les deux mois de la constatation de « pertes substantielles » ? S'agit-il d'une assemblée à tenir devant notaire ou non ? Étant donné que l'assemblée doit décider sur la dissolution de la société, décision qui ne peut valablement être prise que par une AG extraordinaire, il paraît prudent de convoquer une AG de cette forme-là, sauf s'il était certain que la décision prise par l'assemblée serait de continuer les activités de la société.

Selon un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers, un gérant de S.p.r.l. qui avait omis de convoquer en temps utile l'assemblée générale des associés malgré la perte du capital social avait été déclaré responsable de l'accroissement des dettes de la société. La société avait en fin de compte été mise en liquidation et, après deux mois, le liquidateur avait fait l'aveu de la faillite. Le curateur et un créancier avaient assigné le gérant et le liquidateur pour faire constater qu'ils avaient commis des fautes en ne convoquant pas l'assemblée générale (à partir du moment où la moitié du capital social avait été perdu) et en poursuivant une activité déficitaire dans des conditions ne permettant plus d'effectuer un redressement[1]. En particulier, il était reproché au liquidateur d'avoir retardé le dépôt du bilan de deux mois, alors que la société se trouvait déjà en état virtuel de faillite.

Il est reproché à cet arrêt de ne pas avoir analysé si l'assemblée dûment convoquée avait pris la décision de prononcer la dissolution de la société. La cour a retenu que « *[…] si bien qu'en ce qui concerne les pertes dont il est démontré qu'elles furent subies après la date à laquelle l'assemblée générale aurait dû délibérer de la liquidation, le lien de causalité ne peut être rejeté entre la faute et les pertes établies* ».

Pour la doctrine, le tribunal n'avait pas établi le lien de causalité entre la faute et le préjudice, faute d'avoir démontré que l'assemblée générale, si elle avait été convoquée en temps opportun, aurait décidé la dissolution[2].

Dans quelles circonstances naît l'obligation du conseil d'administration de réunir l'assemblée générale des associés ? Est-il indispensable que cette perte soit

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 390.

2 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 423.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

constatée par un bilan soumis à l'assemblée générale et approuvée par elle ? Cette vue, que certaines décisions de justice[1] semblent adopter, est trop restrictive, et la doctrine admet que le conseil doit convoquer l'assemblée, même en l'absence de tout bilan approuvé, dès que la perte est certaine[2].

La modification des statuts (donc la dissolution de la société) doit se faire aux conditions de l'article 450-3 L.S.C.

Le procès-verbal de la délibération doit être dressé par acte authentique uniquement si l'assemblée décide la dissolution. Sinon, un procès-verbal sous seing privé sera suffisant[3].

■ § 8 – Responsabilité des liquidateurs

Les liquidateurs sont soit des mandataires des associés, soit des mandataires judiciaires en cas de nomination par les tribunaux et, en tant que tels, ils sont soumis aux règles du mandat (art. 1991 C.c.). Mais, aux termes de la loi (art. 1100-13 L.S.C.), les liquidateurs sont responsables également « *envers les tiers* » qui eux, sont évidemment totalement étrangers au mandat[4].

Pour engager cette responsabilité, la société ou encore les tiers doivent établir une **faute** à l'égard des liquidateurs poursuivis[5].

La responsabilité des liquidateurs est recherchée sur la base des articles 1382 et 1383 C.c. pour ne pas avoir respecté les règles relatives à la liquidation formulées aux articles 1100-8 et 1100-9 L.S.C. (en procédant à la liquidation de la société sans payer les créanciers sociaux). Cette responsabilité est retenue sur la base précitée : « *Il est de principe que commet une faute dont il doit réparation, le liquidateur qui procède à la répartition de l'actif social, sans rien conserver par devers lui pour le paiement de l'une ou l'autre créance […] le fait de ne pas distribuer aux associés d'actif en fin de liquidation ne dispensant pas les liquidateurs de payer les dettes de la société, respectivement de prendre les mesures en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et dont la remise n'aurait pu être faite (cf. art. 147 et 151 de la loi sur les sociétés)* »[6].

SECTION VIII
LES ACTIONS EN JUSTICE POUR OU CONTRE LA SOCIÉTÉ

L'objet de la présente section est d'analyser sous quelles conditions la société peut agir en justice en tant que demandeur ou en tant que défendeur : il s'agit donc de déterminer respectivement sa **capacité active et passive**.

---

1 – Bruxelles du 7 janvier 1959, *R.P.S.*, 1963, p. 204 et Bruxelles du 23 juin 1955, *R.P.S.*, 1961, p. 174.

2 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 380.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 423.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 346, ID 11308.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 347, ID 11308.

6 – CA du 20 avril 1994, n°s 13.681 et 15.073, Extension de la faillite au « maître de l'affaire », ID 10207.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Par l'effet de la personnalité morale, toutes les sociétés commerciales interposent entre la personnalité de leurs associés et les tiers une personne morale qui, elle, devient titulaire de tous les droits et de toutes les obligations. Les effets de cette personnification juridique ne se produisent pas avec la même intensité à l'égard des diverses espèces de sociétés[1].

La situation est différente selon que la société a ou n'a pas la personnalité morale.

§ 1 – Les sociétés sans personnalité morale

Les citations émanant de la société devront comprendre **l'indication de l'ensemble des associés**. Les citations adressées contre la société devront de même être établies au nom des associés afin de permettre à ces derniers de se défendre. L'absence de la mention de tous les associés ne devrait pas constituer une cause d'irrecevabilité[2]. Il est à noter que, selon une certaine jurisprudence, cette exigence s'appliquait également aux sociétés civiles, bien que celles-ci soient dotées de la personnalité morale[3]. Cette jurisprudence est cependant dépassée de nos jours[4].

La cour d'appel, en examinant la question de la capacité passive de l'Église protestante, groupement dénué de la personnalité morale, arrêta : « *Attendu que l'affirmation de l'appelante sur incident Église Protestante, suivant laquelle un groupement de personnes non doté de la personnalité juridique ne pourrait défendre en justice, est trop absolue ; qu'une société de fait ne peut trouver dans le vice de sa constitution et dans la circonstance qu'elle s'est soustraite au contrôle officiel une immunité refusée aux sociétés régulièrement organisées face à l'action d'un tiers engagé avec elle ou lésé par sa faute […] que la majorité des auteurs et de la jurisprudence française apportent une atténuation au principe de l'incapacité d'ester en justice des groupements de personnes non constitués ou non autorisés, lorsqu'il s'agit de leur capacité passive […] que cette solution est imposée par les nécessités pratiques et le souci de déjouer une manœuvre trop commode qui, de la part d'un groupement de personnes, consisterait à prendre prétexte de son inexistence juridique pour se soustraire à certains engagements contractés en fait, de sorte qu'on admet, même si la solution est curieuse et si la logique paraît écartée, qu'un groupement dépourvu de toute personnalité peut être assigné en la personne de ses représentants ; que dans le silence des textes la reconnaissance de la personnalité juridique par les tribunaux est possible pourvu qu'on ne puisse hésiter sur l'existence d'intérêts collectifs d'une part et sur la possibilité d'une expression collective organisée de ces intérêts d'autre part […]* »[5].

Fut confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable une demande dirigée contre une association momentanée au motif de l'absence de personnalité juridique distincte de celle des associés. L'appelante s'est prévalue de la doctrine et de la

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 354, ID 11308.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 185.

3 – Cour du 11 mars 1875, *P.*, n° 1, p. 63, cité par I. Corbisier, *Droit des sociétés. Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, p. 60.

4 – CA du 30 juin 1993, *P.*, n° 29, p. 253, ID 10198.

5 – CA du 7 juillet 1992, n° 13.925, E, *Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves*, n° 83, mai 1993, pp. 33 ss., cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

jurisprudence majoritaires en France qui « *apportent une atténuation au principe de l'incapacité d'ester en justice des groupements de personnes non constitués ou non autorisés, lorsqu'il s'agit de la capacité passive. Cette solution est imposée par les nécessités pratiques et le souci de déjouer une manœuvre trop commode qui, de la part d'un groupement de personnes, consisterait à prendre prétexte de son inexistence juridique pour se soustraire à certains engagements contractés en fait […]* ». Cette argumentation est rejetée par la cour, relevant que « *la jurisprudence invoquée ne s'applique qu'à des groupements non constitués ou non autorisés "dont la responsabilité est difficile à déterminer et qui risquent d'échapper à toute condamnation"*, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les deux associés de l'association sont connus et relèvent d'un groupement pour lequel la loi sur les sociétés prévoit un régime de responsabilité solidaire : « *Dès lors, les nécessités pratiques de protection des tiers qui ont amené la jurisprudence à reconnaître une certaine capacité passive à des groupements de personnes ne sont pas données dans la présente affaire […]* »[1].

À propos de l'action dirigée contre un **syndicat** : « *[…] s'il est un fait acquis que le syndicat […] est dépourvu de la personnalité juridique, de sorte qu'en vertu des principes régissant la capacité d'ester en justice, il faudrait, logiquement, lui dénier la capacité d'ester en justice non seulement quand il est demandeur mais aussi quand il est défendeur, il n'en reste pas moins que, pour satisfaire à des nécessités pratiques, l'opinion actuellement dominante en jurisprudence et en doctrine et à laquelle la cour se rallie, admet qu'un groupement dépourvu de toute personnalité a néanmoins la capacité passive d'ester en justice et peut être valablement assigné en la personne de ses représentants […]* »[2].

Dans l'association momentanée, les associés qui ont traité avec les tiers sont personnellement et solidairement tenus des engagements pris conjointement. Aux termes de l'article 1400-4 L.S.C., ils sont individuellement tenus de l'exécution de leurs engagements.

Le même article prévoit que, dans les **sociétés en participation,** ce sont uniquement les associés qui se sont présentés dans les contrats comme parties à ceux-ci qui peuvent être assignés[3].

■ § 2 – Les sociétés avec personnalité morale

Toute personne morale peut agir en justice soit en demandant, soit en défendant : c'est pour cette raison que l'on a reconnu la personnalité morale aux sociétés civiles[4].

La première question est de savoir qui est en droit d'exercer l'action en justice au nom et pour le compte de la société. La réponse à cette question est que cette action peut être exercée par l'organe de gestion de la société ; il s'agit donc soit du gérant de la S.à r.l. qui représente la société à l'égard des tiers en justice, soit

1 – CA du 23 avril 1997, n° 17.938, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 13 mai 1997, n° 204.781, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 368, ID 11308.

4 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 258.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

encore le conseil d'administration de la S.A. Dans les S.A., l'action doit être introduite par le conseil d'administration, et ceci, au vœu de l'article 441-5 (anc. art. 53), alinéa 2 L.S.C. : « *[…] il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule* ». De cette dernière disposition, la jurisprudence a toutefois conclu que : « *Dès lors le recours formé par une société anonyme est valablement introduit au nom de la société seule sans qu'il soit besoin d'indiquer l'organe statutaire par lequel elle est représentée* »[1]. Dans une affaire plus ancienne déjà[2], il a été retenu que si, en droit belge, seul le conseil d'administration a pouvoir de représenter la société, cette règle de droit n'empêche pas la société belge de valablement agir devant les juridictions luxembourgeoises en se soumettant aux lois de procédure et de compétence luxembourgeoises lorsqu'elle veut plaider dans le pays. Par référence à l'article 53 L.S.C. (nouv. art. 441-5 L.S.C.), la cour de cassation a retenu que les exploits sont valablement faits au nom de la société seule.

« *Aux termes à l'article 191*bis*, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, toujours applicable, les exploits pour ou contre la société sont d'abord valablement faits au nom de la société seule (CF. Cassation 15.11.2001, arrêt n° 58/01, numéro du registre 1826). L'acte d'appel doit, en vertu de l'article 153 4) et 5) du nouveau code de procédure civile, auxquels renvoie l'article 585 du même code, contenir, sous peine de nullité, l'indication des nom, prénom, profession et domicile du destinataire ainsi que des formalités de la signification d'un acte. L'article 163 4° du nouveau code de procédure civile dispose enfin que les sociétés sont assignées en la personne de l'organe qualifié pour les représenter en justice. La raison d'être des exigences légales relatives au destinataire d'un acte de procédure est d'assurer que l'acte soit délivré à la personne morale concernée. Il appert des mentions figurant à la dernière page de l'acte d'appel que la signification n'a en réalité pas été faite au gérant, mais au directeur de la société J.R.O. L'erreur commise, en l'espèce, à la première page de l'acte d'appel au regard de la désignation – mention d'ailleurs superflue – de l'organe de représentation que la société destinataire de l'acte est, en l'absence de tout doute quant à l'identité de la société existante visée et d'un grief démontré dans le chef de la partie intimée, comparant par la suite par l'organe de représentation régulier, sans incidence* »[3].

Aux termes de l'article 631 C.com., les tribunaux de commerce connaissent « *[…] des contestations entre associés ou entre administrateurs et associés pour raison d'une société de commerce* ».

Par le terme « *associés* », la loi entend tant les associés individuellement que la société elle-même (Frédéricq, Principes de droit commercial belge, T. 1, n° 325)[4].

« *Attendu que les litiges visés par cet article sont ceux relatifs à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution de la société ; que sont notamment étrangères à la société les contestations destinées à régler des rapports de droit non prévus par*

1 – CE du 24 novembre 1992, n° 8.670.

2 – Cass. civ. du 2 février 1956, *P.*, n° 16, p. 425, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA du 20 décembre 2001, n° 24936, Art. 192, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 2 février 1977, *P.*, n° 24, p. 59, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

les statuts »[1]. Cette condition n'est notamment pas remplie à l'égard d'une action tendant au remboursement d'un prêt servant au financement d'une maison d'habitation réservée à son usage que la société avait accordé à ses associés[2].Le tribunal a admis l'action de curateurs, fondée sur les articles 59 (nouv. art. 441-9) et 192 (nouv. art. 710-16) L.S.C., tendant à engager la responsabilité d'une personne, contrôlant diverses S.A. et S.à r.l., qui s'était rendue coupable de fautes de gestion telles que : l'absence de fonctionnement régulier des organes sociaux et de comptabilité, un manque de soin quant à la tenue de postes débiteurs et leurs justificatifs, le maniement fautif de fonds sociaux (prélèvements ou virements mal identifiés ou sans contrepartie), le remboursement anticipé de crédits bancaires pour lesquels le défendeur avait donné sa garantie personnelle, le non-paiement de fournitures de première nécessité pour la société. Le juge a estimé que ces faits ont constitué la faute génératrice de la faillite de la société pour laquelle il y a lieu de condamner le défendeur au montant total des créances admises[2].

Dans une affaire a été soulevée l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action en responsabilité exercée contre l'administrateur délégué au motif que l'article 631 C.com. serait d'interprétation restrictive, dans le sens qu'il s'appliquerait uniquement aux administrateurs de société à l'exclusion de tous les autres organes ou préposés d'une société[3]. Cette argumentation n'avait guère de chances de succès pour la raison que la cour argumenta que l'administrateur délégué n'avait pas cessé d'être administrateur et, comme tel, il était responsable envers la société au titre de l'article 59 (nouv. art. 441-9) L.S.C.

La participation à une société à responsabilité limitée et l'exercice des fonctions de gérant d'une telle société n'ont qu'un caractère purement civil et ne sont pas de nature à conférer à l'associé gérant la qualité de commerçant[4].

Dans une affaire, il y a eu engagement de la responsabilité, sur la base des articles 59 (nouv. art. 441-9) et 192 (nouv. art. 710-16) L.S.C., de deux associés-gérants d'une S.à r.l. dont ils avaient détourné les fonds (stocks transférés sans contrepartie pour la société) en vue de s'enrichir personnellement. Le juge observe au passage que les trois éléments classiques constitutifs de la responsabilité civile doivent être réunis lors de la mise en œuvre des articles 59 (nouv. art. 441-9) et 192 (nouv. art. 710-16) précités, à savoir la faute (application du critère du « bon père de famille »), le dommage et le lien de causalité (résultant en l'espèce de ce que le dépouillement de la société de son actif tout en l'endettant auprès des fournisseurs et autres créanciers est à l'origine tant de la création que de l'accroissement du passif, aboutissant finalement à sa mise en faillite). Les défendeurs furent condamnés à supporter le passif alors non couvert de la société[5].

Les actes de procédure doivent obligatoirement mentionner l'organe compétent pour représenter la société, mais sans nécessairement avoir à mentionner les noms

1 – CA du 4 juin 1975, *P.*, n° 23, p. 177, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 29 mars 1985, n°s 35.483, 35.484, 35.582, ID 10489.

3 – Cour 27 février 1973, *P.*, n° 23, p. 481, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA du 4 juin 1975, *P.*, n° 23, p. 175, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – TA Lux. du 3 juillet 1987, n° 36.875, ID 10442.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

des personnes physiques chargées de représenter la société. Voir article 163, 4 du NCPC[1].

La représentation en justice des sociétés étrangères doit être déterminée par la loi qui régit la société, soit donc par la loi où la société maintient son principal établissement[2].

En revanche, la question de savoir si l'exploit identifiait suffisamment les membres du syndicat pour que le pourvoi puisse être considéré comme régulièrement introduit en leur nom relevait de la procédure civile belge. En l'espèce, cette identification fut jugée insuffisante, et le pourvoi a été déclaré irrecevable.

La capacité des sociétés (ou associations) étrangères d'ester en justice en Belgique est déterminée par la loi étrangère[3]. Du cas d'espèce soumis, il résultait que le syndicat d'assureurs de la place de Londres n'avait pas cette capacité, le droit anglais[4] ne la reconnaissant pas.

« *Les formalités prévues pour la validité des exploits introductifs d'instance sont régies par la* lex fori *; il s'ensuit que, lorsqu'une société étrangère veut ester en justice dans le Grand-Duché, les formalités de l'assignation sont celles prescrites par la loi luxembourgeoise* »[5].

À propos d'un acte d'appel introduit par deux sociétés de droit étranger, qui y déclaraient être représentées par un organe qui, d'après leur droit national applicable, n'avait pas le pouvoir de représentation en justice, la cour décide que : « *tout exploit fait à la requête d'une société commerciale doit, à peine de nullité et sauf exceptions prévues par la loi, désigner la personne ou l'organe qualifié pour la représenter en justice* ». « *La nullité qui résulte de l'indication erronée de la personne ou de l'organe qualifié est une nullité de fond à laquelle ne s'applique pas l'article 173, alinéa 2, du code de procédure civile, la personne ou l'organe faussement désigné comme étant celui qui représente la société n'ayant aucun pouvoir juridique de représentation* »[6].

« *[…] un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 1996 […] a décidé que tout exploit fait à la requête d'une société commerciale doit, à peine de nullité […], désigner la personne ou l'organe qualifié pour la représenter en justice […] L'hypothèse visée est celle de l'irrégularité d'un exploit fait à la requête d'une société commerciale qui agissait comme partie demanderesse […] lorsqu'une société est assignée comme défenderesse […] la société assignée comme telle et dont l'identité est suffisamment précisée par l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social, a toute possibilité de comparaître par ses organes compétents* »[7].

---

1 – Th. Hoscheit, « La représentation en justice des personnes morales de droit privé, à propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 1996 *Parfumerie Douglas Nederland N.V.- Parfumerie Douglas S.à r.l.* », *P.*, n° 31, p. 53.

2 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 312.

3 – Cass. b. du 11 janvier 1979*, Pas.*, 1979, I, p. 521.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 675.

5 – CA du 25 janvier 1956, *P.*, n° 16, p. 430, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Cass., 21 mars 1996, *P.*, n° 30, p. 5, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

7 – CA du 5 mars 1997, n° 18.340, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« *La capacité d'ester en justice est requise de toute personne qui se trouve liée à une instance, qu'elle soit demanderesse, défenderesse ou partie intervenante ; cette capacité est une condition de la régularité et de la validité de l'instance. Les associations ou groupements n'ont pas la capacité d'ester en justice par le seul fait de leur existence et ne peuvent obtenir la personnalité juridique que par une attribution individuelle résultant d'une loi ou par l'adoption de l'une des formes sociales prévues par la loi. Si certains textes légaux habilitent, dans certains cas, des organisations professionnelles à exercer une action en justice, ces règles sont exceptionnelles et partant d'interprétation stricte* »[1].

Une société en nom collectif, dotée en tant que telle de la personnalité juridique, peut être assignée en tant que telle sans que les associés le soient, et elle peut ester en justice sans que les associés n'aient à intervenir personnellement à l'instance[2].

Les sociétés en tant que personnes morales sont de véritables personnes et, en tant que telles, elles sont susceptibles d'être titulaires de droits comme d'obligations. Elles sont donc exposées aux actions auxquelles ces droits et obligations peuvent donner lieu. De façon tout à fait logique, la loi (art. 1400-5 (anc. art. 156) L.S.C.) prévoit que ces actions sont soumises aux mêmes délais de prescription que ceux applicables aux personnes physiques[3].

Les sociétés dotées de la personnalité morale sont valablement représentées en justice par leurs organes et ceux-ci s'identifient à la personnalité morale. « *Il est donc très généralement admis que la société comparaît personnellement par ses organes devant les tribunaux de l'Ordre judiciaire […]* »[4].

Dans une société anonyme, cet organe sera en général le conseil d'administration. Pourtant, le délégué à la gestion journalière est également un organe qui peut agir en justice dans le cadre des actes qui rentrent dans son champ d'activité[5].

L'appel interjeté par une société anonyme est valablement formé au nom de la société seule, sans qu'il soit besoin d'indiquer le nom des administrateurs, ni de justifier de leur qualité d'agir au nom de la société[6].

« *L'article 53, alinéa 2, de la L.S.C. concernant les sociétés commerciales dispose, contrairement à l'article 54 de la loi belge correspondante, que les exploits pour ou contre la société anonyme sont valablement faits au nom de la société seule*.

Cette disposition de procédure est applicable non seulement aux sociétés indigènes, mais également aux sociétés étrangères, agissant en justice au Luxembourg, lesquelles ne sont tenues que de se soumettre aux lois de procédure et de compétence luxembourgeoises, lorsqu'elles veulent plaider dans le pays »[7]. Dans le cas

1 – Trib. arb. Lux. du 13 juillet 1973, *P.*, n° 22, p. 450.

2 – CA (civ.) du 30 juin 1993, *P.*, n° 29, p. 253, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 369, ID 11308.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1), *R.C.J.B.* 1992, p. 653.

5 – CE du 3 août 1984, *R.P.S.*, 1985, p. 18, note Benoît-Moury.

6 – CA du 8 mai 1962, *P.*, n° 18, p. 535, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

7 – CA du 19 novembre 1970, *P.*, n° 21, p. 426, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

d'espèce, la défenderesse avait soutenu que l'action aurait dû être introduite par l'administrateur délégué ainsi que cela serait prévu par l'acte constitutif de la société.

« *Si la constitution et le fonctionnement d'une société étrangère restent soumis à la loi de son pays, il n'en reste pas moins que les lois luxembourgeoises sont applicables en ce qui concerne la compétence et la procédure aux instances introduites au Grand-Duché* » (en l'espèce, l'exploit introductif d'instance était conforme notamment à l'article 53 [nouv. art. 441-5] L.S.C.)[1].

« *Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales énonçant que les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule ; attendu qu'en refusant d'appliquer à l'acte introductif d'instance la disposition légale susvisée, la cour d'appel a violé celle-ci* »[2].

Cet arrêt concerne un débat classique opposant différentes juridictions luxembourgeoises sur la question de savoir si l'acte introductif d'instance présenté au nom de la société doit ou non indiquer l'organe habilité à représenter la société en justice.

L'arrêt cassé avait retenu que l'article 163 NCPC qui prévoit à l'égard des sociétés commerciales que celles-ci sont à assigner « *en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice* », disposition qui, selon la cour d'appel, devait primer certains textes spéciaux, dont notamment l'article 53, alinéa 2, (nouv. art. 441-5) L.S.C. L'indication de l'organe social dans l'acte introductif d'instance est partant indispensable.

La cour de cassation ne confirma pas cette approche : elle accueillit favorablement l'argument des parties demanderesses en cassation selon lequel l'article 53, alinéa 2, (nouv. art. 441-5, alinéa 2) L.S.C. serait précisément une des exceptions légales dérogeant à l'application pure et simple de l'article 163 NCPC.

Il reste à savoir dans quelle mesure cet arrêt est susceptible de s'appliquer aux sociétés commerciales autres que les sociétés anonymes[3].

« *Sur la question de l'introduction de l'action en justice de la société-personne morale, voy. également la jurisprudence citée sous l'art. 1832 C. civ. (supra "Sociétés civiles") ainsi que la jurisprudence citée ici sous les arts. 3 et 191*bis *L.S.C. de savoir si les membres du conseil d'administration, mandataires de la société, peuvent aussi, même en l'absence d'une disposition statutaire (comme c'est le cas en l'espèce) déléguer des pouvoirs spéciaux, comme ceux de fixer les rémunérations du comité de direction, à d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir si les mandataires peuvent, en vertu de l'article 1994 du Code civil, se substituer un mandataire spécial. […] la question posée appelle une réponse affirmative […] le conseil d'administration peut, par application des principes généraux régissant le mandat (articles 1984 à 2010 du Code civil), avec ou sans autorisation explicite des statuts, conférer des mandats spéciaux comme celui de fixer les rémunérations des membres du comité de direction, à d'autres personnes, administrateurs ou non (cf. Cour de cass. belge – 17 mai 1962 – Revue critique de jurisprudence belge – 1974*

1 – TA Lux. du 15 juillet 1993, n° 41.214, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cass. du 15 novembre 2001, n° 58/10, n° 1826 du registre (cassation d'un arrêt de la CA du 29 novembre 2000). Ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – V. en ce sens également Fr. Fayot, « Chronique. Droit des sociétés (1997-2002) », *Ann. dr. lux*., 2002, p. 570.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

pages 72 et suivantes ; Note SIMONT et VAN OMMESLAGHE N°s 13 à 16) que cette faculté ne consacre pas un "abus de majorité" contraire à l'esprit de la loi du 6 mai 1974 sur la cogestion »[1].

Chaque administrateur est doté d'un **pouvoir d'investigation individuelle**, de manière à lui permettre de participer aux délibérations du conseil en connaissance de cause ; ce droit est par ailleurs un corollaire nécessaire de la responsabilité que la loi met à sa charge. Il ne peut toutefois être détourné de sa fin et doit être exercé de manière telle à ce qu'il ne trouble pas le fonctionnement de la société (le tribunal se réfère à l'étude belge classique de L. SIMONT, « L'administrateur d'une société anonyme agissant isolément a-t-il un droit d'investigation individuelle ? », *R.P.S.*, 1963, n° 5148)[2]. En appel : « *Attendu que si, en principe, un droit d'investigation individuel est reconnu à chaque administrateur, toujours est-il que l'administrateur qui veut exercer ce droit doit pouvoir justifier que l'investigation individuelle à laquelle il veut procéder est nécessaire pour l'exercice diligent de son mandat et tend à mettre cet administrateur à l'abri d'une action en responsabilité ; qu'il ne suffit donc pas que l'administrateur en question invoque en termes généraux et abstraits la diligence et la responsabilité attachées à son mandat, mais qu'il doit indiquer correctement et avec précision en quoi le renseignement demandé est nécessaire au regard de la diligence et de la responsabilité ; que la charge de la preuve lui incombe* » (la cour se réfère à nouveau à l'étude de L. Simont invoquée au premier degré par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg)[3].

La jurisprudence belge a repris la même théorie dans un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, ordonnance du 21 juin 1968, *R.P.S.*, 1968, p. 268[3].

■ § 3 – Procédure civile ou commerciale

Art. 547 NCPC

« La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix. »

Il n'existe au Luxembourg aucun tribunal civil ou commercial proprement dit. « *Conformément à l'article 20 NCPC le tribunal d'arrondissement est, en matière civile et commerciale, juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction […]. Il appartient au tribunal d'énoncer dans quelle matière il prononce alors même que le demandeur n'aurait pas qualifié la nature de la demande dans son assignation ou l'aurait qualifiée erronément* »[4].

1 – CA du 10 juillet 1991, n° 10.974, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 21 janvier 1988, n° 37.823, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – J. VAN RYN et P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 377.

4 – TA Lux. du 26 février 2015, n° 136378 du rôle, *P.*, n° 37, p. 624.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 548.

« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 547, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 153 et 154 : les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ».

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a jugé que[1] :

« En effet, s'il est admis qu'une demande en matière commerciale peut être introduite suivant la procédure civile, toujours faudrait-il que le demandeur fasse un choix à ce sujet et ne mélange pas les deux procédures, comme le demandeur l'aurait fait en l'espèce.

XX conclut à la recevabilité de sa demande et conteste l'argumentation du défendeur en soutenant que, conformément à l'article 547 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, le demandeur serait libre de choisir à son gré pour les litiges de nature commerciale entre la procédure civile et la procédure commerciale.

Par ailleurs, "au demeurant si la procédure commerciale devait être respectée – quod non – cette règle n'est pas une formalité substantielle et n'échappe donc pas à l'article 1253 du NCPC qui dispose qu'aucun exploit ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi".

Le Tribunal retient que le présent litige est de nature commerciale pour le défendeur YY qui est commerçant et qui a "chargé" XX de l'exécution de travaux dans le cadre de son activité commerciale.

L'article 547 du Nouveau code de procédure civile prévoit que "la procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix".

Cette disposition légale, entrée en vigueur le 16 septembre 1996 et s'appliquant à toutes les affaires introduites à partir de cette date, a mis fin aux incertitudes jurisprudentielles antérieures en consacrant les dernières élaborations de la jurisprudence.

En ce qui concerne la compétence judiciaire, il convient également de rappeler qu'il n'existe pas de "tribunal de commerce" autonome au Luxembourg, de sorte que le caractère civil ou commercial d'une affaire est sans incidence en ce qui concerne la compétence des différentes chambres du tribunal d'arrondissement, ledit tribunal étant le juge de droit commun en matière civile et commerciale qui connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction » (Diekirch, 9 janvier 2001, n° 7/2001).

Le nouvel alinéa deux de l'article 547 du Nouveau code de procédure civile permet donc au demandeur de porter un litige en toute hypothèse devant le tribunal selon la procédure civile, que la contestation soit de nature commerciale ou civile, sans encourir l'irrecevabilité de sa demande au cas où elle se révèle

1 – TA Lux. du 15 juillet 2008, n° 81/2008, n° 13501 du rôle, ID 19978.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

être commerciale, sauf à supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix.

En l'espèce, XX a valablement pu assigner YY devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, en observant la procédure civile, sans encourir la sanction d'irrecevabilité de sa demande ».

SECTION IX
LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Le titre XIV de la L.S.C. dénommé « *Des actions et des prescriptions* » contient les dispositions relatives aux actions pour ou contre la société. Nous allons d'abord prendre en compte ces actions avant d'aborder les dispositions relatives à leur prescription.

■ § 1 – Les actions exercées par la société

La Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ayant été créée par les pouvoirs publics qui ont réglé toutes les questions concernant son patrimoine, sa gestion et la surveillance de ses activités, cette Société, qui est appelée à exercer sous le contrôle de l'État un service d'intérêt général, doit être considérée comme un organisme de droit public[1].

L'exploitation d'une minière, lorsqu'elle a lieu par le propriétaire lui-même, est une opération essentiellement civile, aux termes de l'article 32 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières ; elle ne change pas de nature lorsque le propriétaire, au lieu d'exploiter lui-même, s'est substitué un tiers, commerçant ou non ; la loi ne considère pas comme un commerce cette perte de jouissance d'un immeuble, à moins qu'elle ne soit exercée par une société constituée dans les formes de l'une des sociétés commerciales énumérées à l'article 100-2 [anc. art. 2] de la L.S.C., ces opérations étant alors réputées commerciales en vertu de l'article 100-3 de cette loi. Spécialement, sont de nature civile les opérations d'extraction et de vente de minerais faites, par rapport à une minière appartenant à autrui, par des exploitants qui ont formé à ce sujet une simple association ne revêtant pas les formes de l'une des sociétés commerciales visées par la L.S.C.[2].

Il est à noter qu'en Belgique, il n'existe pas de concessions de carrières. C'est le propriétaire du terrain qui exploite lui-même la carrière ou qui cède à d'autres le droit à l'exploitation moyennant redevance. Il n'est donc pas possible de parler de concession dans cette matière[3].

« *La mine étant une propriété foncière, le particulier ou la société qui l'exploite fait valoir son héritage, et rien de plus* »[4]. Une telle exploitation d'une mine devient toutefois commerciale quand elle est combinée à une industrie de transformation

1 – CA du 6 janvier 1969, *P.*, n° 21, p. 91, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 15 mai 1928, *P.*, n° 11, p. 289, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Ch. Resteau, *Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913*, p. 199.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 243.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de produits naturels de la mine à l'aide d'acides et de réactifs qui, combinés aux minerais extraits, produisait les marchandises mises en vente[1].

Sur la question de l'application de l'article 109 du Code de commerce au motif que les experts-comptables n'étant pas commerçants, la société les regroupant demeurerait, malgré sa forme commerciale, une société civile. La cour se basa sur l'article 100-3 L.S.C. pour établir le caractère commercial des sociétés d'experts-comptables concernées et des opérations réalisées[2].

Quant au cas inverse, les sociétés à objet commercial ne peuvent pas prendre les formes du droit civil, et ceci, au vœu exprès de l'article 100-3 L.S.C.

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg[3] a jugé que : « *Ils font valoir qu'il appartiendrait aux demandeurs de leur fournir des documents leur permettant de s'assurer que les mentions relatives à leurs représentants légaux sont exactes. En l'espèce, l'acte introductif d'instance contient bien l'indication des représentants légaux des requérants.*

Cependant ni l'article 153 du Nouveau code de procédure civile, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'exige l'indication de l'organe qualifié pour représenter une personne morale en justice (cf. Cour d'appel, 23 mai 2001, n° 23.825 du rôle ; Cass. 2 avril 2009, n° 2622 du registre) et a fortiori *impose aux personnes morales, demanderesses dans une action en justice, de prouver que les indications fournies relatives à leur représentation en justice sont correctes.*

Il est vrai néanmoins que pour certaines formalités, d'une nature et d'une importance telle que leur défaut ne permettrait plus à l'acte de remplir sa fonction, leur omission peut être sanctionnée par la nullité, même si ces formalités ne sont imposées par aucun texte et même, a fortiori, sans qu'un texte légal n'édicte la sanction de la nullité à l'égard de leur omission.

Le projet de loi sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant modification de certaines dispositions du Code de procédure civile prévoyait initialement également d'exiger l'indication par la partie demanderesse de l'organe qui la représente.

Cependant, adoptant une proposition en ce sens du Conseil d'État qui ne voyait aucune utilité pour que l'organe qui représente une société doive être indiqué dans les actes de procédure (cf. documents parlementaires n° 3771-5 pp. 15 et 19), la commission juridique de la Chambre des députés a estimé qu'n'y a pas lieu de mentionner l'organe qui représente la société dans un acte d'huissier » *(cf. le rapport de cette commission du 3 juillet 1996, documents parlementaires n° 3771-9, p. 18). Par la suite, cette exigence ne fut effectivement pas reprise dans la loi du 11 août 1996 ayant modifié profondément les dispositions légales applicables à la rédaction des exploits d'huissier, et notamment l'article 61 du Code de procédure civile devenu par la suite l'article 153 du Nouveau code de procédure civile.*

Il est vrai que dans le passé certaines décisions de justice ont cru pouvoir s'appuyer sur l'article 163 du même code, qui concerne cependant la question de

1 – Colmar du 4 juin 1862, *D.*, 1862, 2, 163, cité par Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 243.

2 – CA du 13 mai 19198, n° 20.549, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA Lux. du 30 novembre 2011, n° 113 681, ID 24553.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

savoir par quel organe sont assignées certaines parties défenderesses, pour justifier une nullité (de fond) de l'exploit introductif d'instance dans l'hypothèse d'un défaut ou d'une erreur dans l'indication de l'organe qualifié pour représenter une société en justice.

Cette position ne peut, au vu notamment des travaux préparatoires de ladite loi du 11 août 1996, écartant expressément l'exigence de l'indication du représentant légal, et des arrêts récents de la Cour de cassation, plus être soutenue aujourd'hui.

Ainsi, le défaut d'indication de l'organe représentant une société en justice ou une indication erronée de l'organe représentatif, ne peuvent aujourd'hui être qualifiés comme absence d'une formalité substantielle voire comme nullité et n'entraînent donc pas la nullité de l'exploit introductif d'instance (cf. Cass. 2 avril 2009, n° 2622 du registre ; Trib. d'arr. Lux. 1er décembre 2010, n° 111.689 du rôle ; Cour d'appel 19 janvier 2011, n° 36.147 du rôle), étant encore précisé que les exploits pour ou contre une société sont ***valablement faits au nom de la société seule*** *(cf. Cass. 15 novembre 2001, n° 1826 du registre)* »[1].

Il s'ensuit que ce moyen de nullité manque de substance et est à rejeter.

« *Étant donné qu'au Luxembourg, la chambre commerciale n'est qu'une chambre spécialisée du tribunal d'arrondissement et que depuis l'introduction du Nouveau Code de procédure civile, les affaires commerciales peuvent aussi être introduites devant les chambres civiles, le Conseil d'État ne voit pas la pertinence d'****ouvrir*** *cette option obligatoire, ceci d'autant plus que le juge des référés peut statuer indistinctement en matière civile et en matière commerciale. Il propose par conséquent de donner compétence au président du tribunal d'arrondissement statuant comme en matière de référé pour les deux matières* »[2].

■ § 2 – Les actions exercées contre la société

En principe, les créanciers de la société ne sont pas les créanciers des associés, tout comme les créanciers des associés n'ont aucun droit sur le patrimoine social[3].

Les créanciers sociaux ont un droit de gage général sur le patrimoine de la société. Cette formulation est celle de la Cour de cassation française depuis un arrêt de 1898[4]. Elle est en effet correcte et de loin préférable à celle qui consiste à dire que le capital social est le (seul) gage des créanciers. Cette formulation est incorrecte.

A – Action directe des créanciers contre les associés ?

Si les créanciers des associés n'ont donc pas de droit sur les avoirs de la société, ils sont néanmoins dans certains types de sociétés à même de faire valoir des droits sur les associés dans la mesure où, dans certaines sociétés, les associés sont

1 – TA Lux. du 11 décembre 2013, n° 142725 du rôle.

2 – TA Lux. du 11 décembre 2013, n° 142725 du rôle.

3 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 262.

4 – Cass. Req., 22 février 1898, *D.P.*, 1899, n° 1, p. 593.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

indéfiniment responsables des dettes sociales. Il y a dans ce sens « **transparence passive** » de la société[1].

Dans les sociétés en nom collectif, les associés sont tenus solidairement avec la société et solidairement entre eux. Il s'agit d'une **solidarité** légale (art. 1202 C.c.) et **parfaite**. En droit civil, le créancier peut diriger ses poursuites contre le codébiteur de son choix. La loi déroge à ce principe dans l'article 1400-1 L.S.C.[2].

L'article 1400-1 L.S.C. contient une disposition importante à cet égard dans la mesure où il prévoit que : « *Aucun jugement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés solidaires dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les sociétés en commandite par actions et les coopératives à engagement illimité, ne peut être rendu avant qu'il n'y ait condamnation contre la société* ». Au vœu de cet article, les associés qui subissent une responsabilité illimitée dans le sens que celle-ci peut dépasser le montant de leurs apports ne peuvent se voir directement mis en cause en raison d'engagements de la société avant qu'un jugement n'ait été pris à l'égard de la société. La situation est donc la même que si les associés étaient cautions solidaires accessoires de la société pour la raison qu'un créancier n'est pas libre d'emblée et à son choix, d'assigner la société ou l'un ou l'autre de ses associés[3].

Il a été jugé que cette disposition ne vaut plus à l'égard des sociétés en nom collectif qui ont été dissoutes et dont la clôture de la liquidation a été publiée. Dans ce cas, les créanciers n'ont plus besoin d'obtenir un jugement à l'égard de la société[4]. À première vue cette décision pourrait surprendre dans le sens que l'on pourrait considérer que la société n'existant plus, on ne verrait pas comment un jugement pourrait être pris à l'égard de la société. Pourtant, il convient de ne pas perdre de vue que les sociétés, dont la liquidation est achevée et dûment publiée, sont pendant un délai de cinq ans exposées aux actions en justice que les tiers peuvent intenter contre la société. En effet, selon la jurisprudence, l'extinction de la personne morale (à la suite de la publication de la clôture de la liquidation) n'est pas absolue dans la mesure où « *[…] la société continue d'exister pour répondre des actions que les créanciers peuvent exercer contre elle jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation* »[5]. On parle encore « d'existence passive » de la société dont la liquidation a été clôturée.

D'autres décisions prennent justement la position opposée sur ce point : « *Il y a, à l'intérieur de la période quinquennale, obligation d'assigner la société en nom collectif simultanément avec les associés. L'action intentée contre les seuls associés est irrecevable* »[6]. Cette solution, directement déduite de

1 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 262.

2 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 290.

3 – V. L. Frédéricq, *Précis de droit commercial*, p. 329.

4 – TA Lux. du 8 janvier 1958, *P.*, n° 17, p. 260, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cour du 18 avril 1967, *P.*, n° 20, p. 339, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Cour du 18 avril 1967, *P.*, n° 20, p. 339. Ce jugement a été confirmé en appel : CSJ, app. com. du 18 avril 1967, *P.*, n° 21, p. 339.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

l'article 1400-1 L.S.C. se justifierait notamment par le souci d'éviter les cas de contrariété de jugement.

La question de savoir dans quelle mesure les créanciers sociaux peuvent ou doivent d'abord assigner la société ou les associés est clairement résolue à l'égard des sociétés commerciales par l'article 1400-1 L.S.C. Une disposition correspondante fait défaut pour les sociétés civiles à l'égard desquelles exactement les mêmes questions surgissent en pratique. Dans ce contexte, on peut encore se référer à l'article 1863 C.c. qui prévoit que les associés de la société civile sont tenus indéfiniment des dettes sociales, chacun pour sa part virile et sans prévoir de solidarité entre les associés, d'une part, et la société, d'autre part.

« *À l'époque où la société civile ne constituait pas encore une personne juridique, ses associés – par ailleurs propriétaires par indivis des biens qui constituaient le fonds social – étaient par conséquent les seuls débiteurs des dettes sociales à l'égard des tiers.*

L'attribution ultérieure de la personnalité juridique aux sociétés civiles a eu pour effet de conférer aux créanciers de la société civile un nouveau débiteur tenu des dettes sociales, la société elle-même qui, disposant d'un patrimoine autonome, répondra de ses dettes sur les biens sociaux dont elle est seule propriétaire, l'associé n'étant plus copropriétaire des biens sociaux, mais n'étant à l'encontre de la société que titulaire d'un droit de créance…

La législation luxembourgeoise ne prévoit pas que ce nouveau débiteur qu'est la société civile, personne morale, vient se substituer aux débiteurs définis à l'article 1863 précité, ni même qu'il place ceux-ci dans un ordre de subsidiarité quelconque par rapport à la société, aucun texte ne stipulant que l'engagement des associés serait accessoire à celui de la société, respectivement de garantie par rapport à l'engagement »[1].

À s'en tenir à ces dispositions légales, il faudrait en conclure que, dans les sociétés civiles, les **créanciers** pourraient à leur choix poursuivre la société ou les associés. En effet, le Code civil luxembourgeois ne contient pas de disposition similaire à l'article 1958 C.c. français introduit lors de la réforme de 1978. Mais la cour d'appel n'a pas accepté cette conclusion en arrêtant que ce serait nier la personnalité morale de la société que de permettre aux créanciers sociaux de directement se retourner contre les associés sans assigner en premier lieu la société personne morale, interposée entre les créanciers et les associés[2].

L'article 1400-1 L.S.C. n'est pas de portée générale, mais il se limite aux types de sociétés y énumérés. Il n'est notamment pas applicable aux sociétés civiles, comme rappelé par un arrêt de la Cour d'appel[3]. « *L'engagement personnel des associés est considéré comme étant principal et non seulement subsidiaire par rapport à celui de la société. L'engagement des associés existe concomitamment avec celui de la société. Les créanciers peuvent par conséquent poursuivre simultanément la société et ses associés ou, à leur choix, la société ou ses associés. Le créancier peut demander le paiement de son dû aux associés sans qu'il ait préalablement à mettre la société en demeure ou à poursuivre celle-ci* »[4].

---

1 – Cour du 11 mars 1999, n° 21.955, *P.*, n° 31, p. 124, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 11 mars 1999, n° 21.955, *P.*, n° 31, p. 128, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA du 1er avril 2009, *P.*, n° 34, p. 512, ID 11818.

4 – CA du 1er avril 2009, *P.*, n° 34 p. 517, ID 11818.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Mais, il existe au moins une décision en sens contraire. Dans cette affaire, les défendeurs faisaient valoir que les créanciers devraient en premier lieu se retourner contre la société avant de pouvoir assigner les associés. « *Ce moyen, qui est un moyen d'irrecevabilité, n'est en tout état de cause pas fondé, puisque le code civil luxembourgeois ne contient pas un article 1858 identique à celui qui se trouve depuis la réforme de 1978 dans le code civil français et aux termes duquel les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales qu'après avoir vainement poursuivi la personne morale. Antérieurement à cette réforme la jurisprudence permettait également en France aux créanciers des sociétés civiles de poursuivre, à leur choix, la société ou les associés (cf. Jurisclasseur civil, art. 1845 à 1870-1, Fasc. 48-10, n° 64)* »[1].

Par la suite, la cour d'appel est revenue à la jurisprudence de 1999, réaffirmant l'obligation des créanciers de réclamer d'abord leurs créances à la société avant de pouvoir se retourner contre les associés sur la base de l'article 1863 C.c.[2]. Encore dans le même sens de la jurisprudence de 1999, un arrêt de la Cour d'appel de 2005[3].

Le but de la disposition de l'article 1400-1 L.S.C. (qui correspond à celle de l'article 189 L.C.S.C. belge) est d'éviter des jugements contradictoires « qui auraient pu être rendus si les créanciers avaient attaqué l'un ou l'autre des associés avant qu'il n'eût été statué sur l'obligation contractée par la société. La fin de non-recevoir qui en résulte n'est pas d'ordre public et ne peut donc être soulevée d'office : Bruxelles, 14 mai 1949, *R.P.S.*, 1950, 42. »[4].

Mais la controverse est loin d'être close : un nouvel arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg (confirmant d'ailleurs une décision du tribunal d'arrondissement), qui se réfère essentiellement aux décisions françaises, estime « *ne pouvoir subordonner cette action, telle qu'elle est instituée par l'article 1863 du Code civil, à une condition qui n'est pas prévue par la loi et qui ne résulte par ailleurs pas inéluctablement de la reconnaissance de la personnalité morale aux sociétés civiles* »[5].

Les délais de prescription des actions contre la société sont les mêmes que ceux des actions contre les particuliers. Le délai est en principe de cinq ans (art. 1400-6 L.S.C.) pour les actions suivantes : les actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication de leur sortie de la société, que cette sortie consiste dans leur retraite, d'un acte de dissolution ou de l'arrivée du terme de la société. Cette disposition suscite deux commentaires. Elle montre l'importance pour l'associé de bien documenter la sortie de la société ; en effet, le délai court à partir de la date de la publication du retrait. En outre, l'associé en nom n'est responsable que des dettes ayant existé au moment de sa sortie de la société, et non de l'augmentation de ces dettes en raison des pertes subies après cette sortie. Cette règle montre donc encore une fois l'intérêt qu'il peut y avoir pour un associé de quitter la société le plus vite possible. Même s'il reste sous le couperet d'une action

1 – TA Lux. du 28 novembre 2002, *BIJ*, 2003, p. 10.

2 – CA du 7 décembre 2005, *BIJ*, 2006, n° 1, p. 5.

3 – CA (civ.) du 7 décembre 2005, n° 29.262, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 290.

5 – CA (civ.) du 27 avril 2006, *BIJ*, 2006, n° 7, p. 181.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

en justice pendant un délai de cinq ans, il n'en reste pas moins que l'augmentation du passif social ne peut lui être attribuée.

Sont nommément visés par la loi :

– les actions en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution ;
– les actions contre les liquidateurs, en cette qualité ;
– les actions en nullité contre les sociétés de capitaux et fondées sur l'article 12*ter* ;
– les actions en nullité d'une société coopérative.

B – Action des créanciers en cas d'apports non libérés

Art. 1400-2 [anc. art. 153] L.S.C.

« Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits ; la société peut écarter l'action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

Les gérants ou administrateurs sont personnellement obligés d'exécuter les jugements rendus à cette fin.

***Les créanciers peuvent exercer, conformément à l'art. 1166 du Code civil, contre les associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements* ».**

Cette disposition prévoit en fait **deux types d'actions** au profit des créanciers sociaux et destinées à leur permettre de sauvegarder leurs droits à l'égard de la société. L'action prévue par le deuxième alinéa est la reprise en droit des sociétés de l'**action oblique** de l'article 1166 C.c. Cette action suppose l'existence d'une créance : elle permet donc aux créanciers sociaux d'agir directement contre les créanciers « ordinaires » de la société, et ceci, pour le cas où les dirigeants se désintéressent du recouvrement de ces créances.

Les créanciers ont donc : une **action indirecte** contre les associés tendant à l'exécution de leurs versements exigibles et une **action contre la société** tendant à faire **décréter l'exigibilité des versements** soit par mesure préparatoire à l'exécution de ceux-ci au profit des créances échues, soit par mesure conservatoire au profit des créances à terme[1].

Cette action est inefficace à l'encontre des associés qui n'ont pas encore procédé à la libération de leurs titres. En effet, en l'absence de date de libération obligatoire fixée par les statuts, il n'y a pas de créance et donc l'action oblique ne peut pas être exercée.

Dans les sociétés de personnes, les associés sont personnellement responsables des engagements sociaux et sont en tant que tels toujours exposés à l'action directe des créanciers ; la seule limitation qui leur est imposée est de faire condamner les associés avant la société (voir art. 1400-1 L.S.C.).

Dans les sociétés de capitaux, la situation est toute différente dans la mesure où les créanciers n'ont en principe pas la moindre action directe contre les associés. Mais il importe que les créanciers sociaux qui ont traité avec la société sur la base

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 362, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de la seule garantie de son capital social soient à même de forcer ces associés à exécuter leurs **engagements** en souscrivant le capital social. C'est ce moyen qu'accorde le dernier alinéa de l'article 1400-2 L.S.C.[1]

S'agissant d'une application de l'article 1166 C.c., les tiers peuvent agir contre les actionnaires uniquement si la société refuse ou au moins néglige d'exercer ses droits[2].

C'est à cet endroit qu'entre en jeu la deuxième action de l'article 1400-2 L.S.C., celle prévue par l'alinéa 1 : il s'agit de l'**action en décrètement** qui permet à tout créancier « *de faire* ***décréter par justice les versements stipulés aux statuts*** » dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires à la conservation de leurs droits[3].

Cette disposition a été introduite par l'avant-projet Nyssens afin de résoudre une difficulté née sous le Code de commerce de 1808 : sous l'empire de ce dernier s'est posée la question de savoir si les tiers avaient une action directe contre les actionnaires qui n'avaient pas encore fait leur mise. La Cour de cassation belge en date du 18 mars 1843 avait dénié une telle action directe[4]. L'action oblique de l'article 1166 C.c. se heurte à des difficultés insurmontables dans le sens que les versements des associés sont subordonnés à un appel de fonds par un organe de la société. Mais cet organe peut bien ne pas **procéder à un tel appel de fonds**, en empêchant ainsi les créanciers d'agir[1].

Les dispositions précédentes sont complétées par des mesures applicables aux associations sans personnalité morale.

C – Les créanciers de certaines sociétés commerciales sans personnalité morale

L'article 1400-4 [anc. art. 155] L.S.C. vise les anciennes associations commerciales donc les sociétés momentanées et les sociétés en participation. Il est libellé comme suit : « *Les associés momentanés seront assignés directement et individuellement. Il n'y a entre les tiers et le participant, qui s'est tenu dans les termes d'une simple participation, aucune action directe* » (art. 1400-4 [anc. art. 155] L.S.C.). La deuxième phrase fait référence à l'association en participation.

D – Limitation des actions dans le temps

Aux termes de l'article 1400-5 L.S.C., les actions contre les sociétés se prescrivent dans le même temps que les actions contre les particuliers.

Art. 1400-6 [anc. art. 157] L.S.C. :

« Sont prescrites par cinq ans :

1° toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication, soit de leur retrait de la société, soit d'un acte de dissolution, soit de l'arrivée de son terme contractuel ;

2° toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution ;

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 359, ID 11308.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 360, ID 11308.

3 – A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 196.

4 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 328, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

3° toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l'article 1100-15 ;

4° toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres du comité de direction, directeurs généraux, membres du conseil de surveillance, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits ;

5° toutes actions en nullité d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions, d'une société civile, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite spéciale et d'une société coopérative fondées sur les articles 100-4, 100-18, paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, 320-1, paragraphe 8, point 1° et 811-3, paragraphe 2, point 1°, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus ;

6° toutes actions en nullité d'une société coopérative à partir de la publication lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus.

Toutefois, la nullité des sociétés coopératives dont l'existence est contraire à la loi peut être demandée, même après la prescription accomplie.

Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d'actes et délibérations postérieures à la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l'être, compte tenu des circonstances ».

La **prescription quinquennale** de l'article 1400-6 de la L.S.C. n'est applicable qu'aux sociétés commerciales proprement dites et ne peut être invoquée par une association en participation[1].

Dans la matière régie par la L.S.C., la prescription commence à courir à partir des faits qui donnent lieu à responsabilité, et non à partir de la date à laquelle le préjudice engendré par la faute a été consommée. Le juge peut et doit, pour l'appréciation des faits de négligence ou de défaut de surveillance, pendant les cinq années précédant l'action, faire état de faits antérieurs qui seraient la cause et l'origine de la situation désastreuse qui a été maintenue et aggravée par les fautes commises pendant ces cinq ans. Si les fautes des administrateurs résultent de plusieurs faits indivisibles, la prescription ne court que depuis le dernier de ces faits[2].

La matière est dominée par une uniformisation tout à fait bienvenue des délais de prescription applicables.

1) Les actions contre les associés

La prescription quinquennale (prévue par l'article 1400-6 L.S.C.) applicable à cet endroit trouve sa raison d'être dans l'existence de l'être moral qui a traité avec les

1 – CA du 25 mars 1930, *P.*, n° 12, p. 60, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 30 mai 1980, *Bulletin du Cercle François Laurent*, II, 1987, pp. 67 ss., cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

créanciers. Les associés n'étant en quelque sorte que les cautions de la société, il serait excessif de les laisser pendant trente ans sous le coup d'actions dont souvent ils ignorent la cause et les origines[1].

La disposition visée s'applique à toutes les formes de sociétés commerciales en incluant tous les associés (et actionnaires), mais à **l'exclusion** donc des sociétés momentanées et des sociétés en participation. À leur égard, il n'y a pas de raison de faire exception au droit commun : il n'y a que des obligés personnels qui ont traité eux-mêmes en leur propre nom.

2) Les actions en restitution de dividendes fictifs

La distribution de dividendes fictifs implique par définition un **remboursement de capital** (sous couvert du paiement de dividendes). Une telle opération est directement préjudiciable aux intérêts des créanciers qui voient ainsi leur gage diminuer. La restitution est due même si les fruits sur lesquels l'action porte avaient été perçus et consommés en toute bonne foi. Cette solution peut paraître très rigoureuse, de sorte qu'un adoucissement a été cherché dans la durée pendant laquelle l'action en remboursement peut être intentée ; ce délai a été limité à cinq ans.

3) Actions contre les liquidateurs

Sont visées ici les actions qui sont intentées aux liquidateurs « en cette qualité », c.-à-d. en tant que représentants légaux de la société dissoute et détenteurs de son patrimoine[2]. Le délai court à partir de la clôture de la liquidation.

4) Actions en responsabilité contre les mandataires sociaux

Il y a lieu de distinguer la responsabilité envers la société de celle envers les associés.

a) La responsabilité contractuelle

En application du droit commun du mandat, qui est applicable par analogie, les dirigeants sociaux sont responsables des fautes commises dans la mission leur confiée, c.-à-d. donc des fautes de gestion. La responsabilité est individuelle, même s'il s'agit d'un organe collégial : en effet, chaque administrateur reçoit personnellement la mission de gérer la société[3].

En dehors de cette responsabilité contractuelle, le dirigeant est susceptible d'encourir une responsabilité délictuelle.

b) La responsabilité délictuelle

Lorsque la responsabilité de la société est engagée à l'égard des tiers en raison des fautes commises par les dirigeants sociaux, la société peut exercer l'action

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 371, ID 11308.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 377, ID 11308.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 215.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

récursoire en se retournant contre les dirigeants dont la responsabilité personnelle est engagée du fait de ces fautes[1].

c) Exercice de l'action sociale

Dans les sociétés qui ont une **personnalité** morale **complète,** l'action sociale appartient à la société incarnée par la majorité des associés[3]. Elle ne peut être exercée si décharge régulière a été accordée.

Dans les sociétés n'ayant qu'une **personnalité** morale **incomplète**, l'action sociale appartient à chaque associé individuellement[2].

Vis-à-vis des associés à titre individuel, les dirigeants ne sont tenus que dans la mesure où ceux-ci ont subi un préjudice personnel distinct du préjudice de la société. Telle est en tout cas la situation pour les sociétés à personnalité morale complète. À l'égard de celles-ci, chaque associé peut mettre en cause la responsabilité des dirigeants en invoquant soit un préjudice personnel soit le préjudice éprouvé par la société[3].

À l'égard des tiers, les fautes délictuelles commises par les organes engagent la responsabilité de la personne morale sur la base de l'article 1382 C.c. En outre, la responsabilité personnelle des organes peut être engagée. Reste à voir si les fautes de gestion des organes sont susceptibles d'engager la responsabilité personnelle à l'égard des tiers. En principe, tel n'est pas le cas dans la mesure où la mauvaise gestion consiste dans l'inexécution du mandat : il s'agit d'une faute contractuelle dont les dirigeants ne répondent que vis-à-vis de leur mandant, la société[2].

Certaines décisions de justice ont écarté cette approche en retenant que les administrateurs auraient vis-à-vis des tiers une **obligation générale de prudence et de vigilance,** et donc une obligation de bonne gestion[4].

À noter encore qu'il y a aggravation de la responsabilité envers les tiers dans les sociétés de capitaux (S.A., S.à r.l., S.e.c.a.) dans la mesure où les dirigeants sont solidairement responsables envers les tiers du préjudice causé en raison de la violation de la loi sur les sociétés et des statuts.

Sont visées les actions contre les organes sociaux (administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs) en leur nom personnel, en raison donc de la responsabilité qu'ils ont pu encourir dans l'accomplissement de leurs fonctions au service de la société[5]. Le délai assez raccourci s'explique entre autres par le souci de ne pas atteindre les héritiers beaucoup moins aptes que les auteurs des faits à se défendre et à en donner la justification et à discuter des faits à une époque rapprochée de leur déroulement effectif.

5) Actions en nullité

Sont frappées de la prescription quinquennale toutes les actions en nullité contre les sociétés. La loi (belge) de 1873 avait montré très clairement les inconvénients

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 215.

2 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 215.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 216.

4 – Trib. com. Charleroi du 12 octobre 1976, *R.P.S.*, 1976, p. 162.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 377, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de la sanction brutale qui consiste à déclarer nulle une société qui a existé pendant un laps de temps prolongé. La réaction contre les excès de cette situation consistait d'abord à limiter les cas de nullité et, en même temps, à limiter le délai de prescription dans lequel cette action pouvait être exercée[1].

SECTION X
LA PUBLICITÉ DES ACTES DE SOCIÉTÉS

Une des obligations des commerçants est de se faire immatriculer au R.C.S. Ce registre est tenu à Luxembourg Ville par un GIE (pour plus de détails, voir p. 59) et il est destiné à assurer la sécurité du commerce en publiant un certain nombre d'informations susceptibles d'intéresser au plus haut degré les acteurs économiques susceptibles d'entrer en contact (ou déjà en contact) avec le commerçant en question. Ces dispositions concernent tous les commerçants et donc également, et pour identité de motif, les sociétés commerciales.

Le registre de commerce recueille les inscriptions suivantes telles que spécifiées par la Loi de 2002. L'article 1er mentionne les personnes et entités qui sont tenues de se faire immatriculer alors que l'article 6 énumère les informations dont la publication est requise pour une société commerciale.

■ § 1 – Personnes et entités à immatriculer

Art. 1er de la Loi de 2002
« *Il est tenu un registre de commerce et des sociétés, dans lequel sont immatriculés sur leur déclaration ou sur la déclaration d'un mandataire :*

1° les commerçants personnes physiques ;
2° les sociétés commerciales à l'exception des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en participation ;
3° les groupements d'intérêt économique ;
4° les groupements européens d'intérêt économique ;
5° les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique, relevant du droit d'un autre État ;
6° les sociétés civiles ;
7° les associations sans but lucratif ;
8° les fondations ;
9° les associations d'épargne pension ;
10° les associations agricoles ;
11° les établissements publics de l'État et des communes ;
12° les associations d'assurances mutuelles ;
13° les sociétés en commandite spéciale ;
14° les fonds communs de placement ;
15° les autres personnes morales et entités dont l'immatriculation est prévue par la loi.

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 378, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Seules les personnes ou les entités dont l'immatriculation est prévue à l'alinéa précédent sont immatriculées au registre de commerce et des sociétés.
Les inscriptions prescrites par la loi de même que toute modification se rapportant aux faits dont la loi ordonne l'inscription doivent être portées sur le registre.
Le registre de commerce et des sociétés est public.

§ 2 – Informations à publier

Art. 6 de la Loi de 2002
« Toute société commerciale dotée de la personnalité morale est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique :

1° la dénomination sociale ou la raison sociale et, le cas échéant, l'abréviation et l'enseigne commerciale utilisées ;

2° la forme juridique et, le cas échéant, l'indication d'une mention supplémentaire prévue par la loi ;

3° l'adresse précise du siège social ;

4° l'indication de l'objet social ;

5° le montant du capital social ou l'indication du caractère variable du capital, ou, en cas de société agréée en tant que société d'impact sociétal, le nombre respectif de parts d'impact et de parts de rendement dans le capital social ;

6° dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, l'identité des associés, leur adresse privée ou professionnelle précise et le nombre de parts sociales détenues par chacun ;

s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l'État dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation ;

6bis° dans le cas des sociétés à responsabilité limitée simplifiées, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des associés, leur adresse privée ou professionnelle précise, le nombre de parts sociales détenues par chacun et le numéro de l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;

7° dans le cas des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, l'identité des associés solidaires et leur adresse privée ou professionnelle précise ;

s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l'État dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation ;

8° l'identité, l'adresse privée ou professionnelle précise des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société en leur qualité de mandataires légaux, le régime de signature, la date de nomination et la date d'expiration du mandat, la fonction et l'organe social auquel elles appartiennent le cas échéant ;

s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou

s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l'État dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou

s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation.

Doivent également être indiqués les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle ou privée précise des représentants permanents, personnes physiques, désignées par celles-ci ;

9° l'identité, l'adresse privée ou professionnelle précise du commissaire aux comptes ou du réviseur d'entreprises agréé, la date de nomination et la date d'expiration du mandat ;

s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou

s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l'État dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou

s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation ;

10° la date de constitution de la société ainsi que sa durée ;

11° pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission ou y ayant participé ou celles ayant bénéficié d'un transfert d'actifs, de branche d'activités et d'universalité ou d'un transfert du patrimoine professionnel, leur raison sociale ou leur dénomination sociale, leur forme juridique, l'adresse précise du siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ainsi que le nom du registre de toutes les sociétés y ayant participé ;

s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation ;

12° pour les sociétés commerciales soumises à publicité de leurs comptes annuels, la date de début et de clôture de l'exercice social ;

13° pour les sociétés agréées en tant que sociétés d'impact sociétal, la date et les références de l'agrément ministériel visé par la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. »

L'article 9 de la Loi de 2002 mentionne les indications correspondantes à faire par les sociétés qui relèvent de la législation d'un autre État tenues de requérir l'immatriculation de leurs succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La publicité des actes de société comporte une fonction essentielle dans le système du droit des sociétés. Dans l'optique d'assurer la sécurité juridique dans les opérations avec la société, il est indispensable que les tiers puissent avoir accès à des informations à jour sur la situation de la société, qu'il s'agisse des organes représentant la société ou des informations financières (notamment les comptes annuels).

Parfois, la publication des actes concernant la société a un effet constitutif, dans le sens que la publication **purge les vices** qui peuvent s'être produits dans la nomination ou la révocation des organes de la société. La désignation ou la révocation d'un représentant légal valablement faite est réputée régulière. Cette disposition légale est prise dans l'intérêt de la protection des tiers et les dispense donc de rechercher si une certaine nomination ou révocation a été faite de manière régulière.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
SANCTIONS PÉNALES DU DROIT DES SOCIÉTÉS

Si la L.S.C. détaille dans son Titre XV les sanctions pénales, il ne faudrait pas en conclure que celles-ci seraient les seules sanctions susceptibles d'atteindre les dirigeants sociaux. En effet, le Code pénal reste applicable en matière ; telle est la solution prévue par l'article 1500-13 [anc. art. 172] L.S.C. « *Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale, sur les circonstances atténuantes, sont rendues applicables aux infractions prévues par la présente loi* ».

Les actions en **responsabilité civile** peuvent, le cas échéant, être beaucoup plus lourdes dans la mesure où elles sont proportionnées aux dommages causés, mais à condition bien entendu d'arriver à prouver le dommage (en dehors du lien de causalité avec la faute).

La justification du droit pénal des sociétés est la protection des tiers et des associés. Le recours exclusif à des **sanctions civiles** est insuffisant lorsqu'il existe une inégalité de fait entre les acteurs économiques, comme tel est le cas en matière de droit des sociétés.

« *Or les actionnaires et obligataires spoliés, gens inexpérimentés, faciles à éblouir, dispersés et dans l'impossibilité de faire prévaloir une volonté commune méritent une protection pénale* »[1].

Le droit pénal des sociétés est caractérisé par certaines particularités. En premier lieu, on peut noter que la découverte des faits constitutifs de l'infraction est particulièrement difficile et qu'ils sont souvent découverts beaucoup de temps après la commission de l'infraction[2].

Une autre particularité est que, lorsqu'une infraction est commise par une personne morale, le juge doit déterminer quelle est la personne physique qui est tenue pour pénalement responsable. C'est la question de **l'imputabilité**, c.-à-d. la détermination du lien entre l'infraction et son auteur. « *Lorsque l'infraction est détachable de l'activité sociale (exemple le vol) elle est imputable à l'auteur matériel. Dans cette hypothèse la question de l'imputabilité ne présente guère de difficultés puisque la solution adoptée est celle du droit pénal commun* »[3].

En revanche, lorsque l'infraction se situe dans le cadre de l'activité sociale, deux solutions sont possibles. Soit la loi elle-même désigne la personne pénalement responsable (c'est **l'imputabilité légale**). Cette solution n'est guère envisageable que pour les infractions d'omission. Dans un tel cas, d'autres personnes ne peuvent pas être condamnées, sauf comme coauteurs ou complices. Cette solution est notamment celle prévue à l'égard de la non-publication des comptes annuels.

La deuxième solution est que la loi ne désigne pas la personne responsable : c'est l'imputabilité judiciaire qui doit permettre au juge de déterminer la personne en faute. Il va de soi qu'il ne suffit pas de suivre les règles du droit commercial et de retenir systématiquement comme responsables les administrateurs et gérants de la société[4].

---

1 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 124.
2 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 118.
3 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 122.
4 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 123.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le Code de commerce de 1808 ne prévoyait pas la moindre disposition pénale particulière, de sorte que les différentes infractions aux dispositions du droit des sociétés commerciales n'étaient sanctionnées que par les dispositions générales du Code pénal, situation jugée insuffisante dès l'élaboration de la L.S.C.[1]. Le fait qu'une section spéciale (la section XI, articles 1500-1 à 1500-15 L.S.C. qui regroupe les différentes infractions pénales et les sanctions y attachées) a été introduite dans la L.S.C. ne signifie aucunement que le Code pénal soit écarté en cette matière. Le droit pénal garde son caractère de droit commun à cet égard.

La particularité de cette section est que la plupart de ses dispositions ont été assez récemment réformées, si ce n'est qu'elles n'ont été introduites que depuis peu de temps. Tel est en particulier le cas de l'infraction dite de « l'abus de biens sociaux » (art. 1500-11 L.S.C.), expression qui n'est d'ailleurs pas utilisée par la loi elle-même, mais qui nous vient de la pratique française.

C'est à cet endroit que se manifeste encore le conflit fondamental (signalé à la p. 25), à savoir que le droit des sociétés, comme tant d'autres branches du droit, oscille continuellement entre deux tendances opposées, le **dirigisme autoritaire,** d'une part, et la **liberté,** d'autre part, entre tendance libérale et tendance dirigiste.

Dans une phase de dirigisme, on a pu se poser la question suivante : « *Est-il bien indispensable de créer tous ces nouveaux délits ? […] Faire de mauvaise foi des rapports inexistants ! Cela paraît horrible* in abstracto*, mais en fait un commissaire qui se sera laissé aller à donner aux actionnaires un peu trop d'espérance et aux créanciers un peu trop de confiance, mérite-t-il bien cette pénalité sévère ? Les illusions sont si faciles en affaires ! J'ai vu souvent des gens d'ailleurs capables se tromper très honnêtement, mais à tel point qu'après l'événement personne n'eût pu croire à leur bonne foi*.

Y a-t-il, du reste, des faits qui réclament qu'un nouveau délit soit créé ? J'en doute. Or, qu'on n'oublie pas qu'il y a danger à créer des infractions sans nécessité. On éloigne les gens prudents de fonctions qu'on ne remplirait qu'en marchant entre des précipices correctionnels »[2].

On constate au Luxembourg une tendance fort semblable à celle observée en Belgique et en France, à savoir celle de la pénalisation croissante du droit des sociétés. Par la loi du 3 mars 2010 a été introduite la responsabilité pénale des personnes morales.

SECTION I
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES SOCIÉTÉS

Traditionnellement, le droit pénal luxembourgeois a rejeté la responsabilité pénale des sociétés[3]. Cette approche correspond à la jurisprudence ancestrale prise en la matière et selon laquelle : « *La responsabilité pénale étant, dans le système de notre législation, individuelle, une peine ne peut être prononcée que contre un être réel,*

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 396, ID 11308.

2 – E. Pirmez, *Observations présentées sur l'avant-projet de loi sur les sociétés commerciales* [rédigé par A. Nyssens], p. 29, ID 11305.

3 – D. Spielmann, « La responsabilité des personnes morales en droit pénal luxembourgeois », *Ann. dr. lux*., Vol. 4, p. 127.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

auteur de l'infraction, mais pas contre un être moral, telle qu'une société anonyme »[1]. Ce ne sont donc que les personnes physiques qui peuvent être sanctionnées pénalement.

■ § 1 – Absence de responsabilité pénale des sociétés

Cette immunité pénale des personnes morales est basée sur l'adage ***societas delinquere non potest***. Elle se justifie en particulier par les raisons suivantes :

– la personne morale n'a **pas de volonté propre,** elle ne peut donc commettre de faute ;
– le choix des peines fait par le Code pénal n'est pas adapté dans la mesure où la société ne peut ni être rééduquée, ni se repentir ;
– le principe de la **personnalité des peines**[2] : la peine doit directement atteindre le coupable et elle doit être adaptée à sa personnalité[3].

La peine est traditionnellement considérée comme un instrument d'intimidation et de rééducation, de sorte que punir la personne morale serait en tout état de cause non adapté[4].

La responsabilité pénale étant, dans notre système législatif, individuelle, « *une peine ne peut être prononcée que contre un être réel, auteur de l'infraction, mais pas contre un être moral, telle qu'une société anonyme. À moins d'une disposition contraire non équivoque, ce principe doit trouver son application même dans les matières réglées par des lois spéciales* »[1].

Par conséquent, en cas d'infraction commise pour le compte de la personne morale, il y a lieu d'identifier et de sanctionner la personne physique qui a commis l'infraction pour le compte de la personne morale. Ceci est encore conforme à la jurisprudence : « *Si une société coopérative ne peut, en raison de sa qualité de personne morale de droit privé, commettre une infraction, l'auteur pénalement responsable de cette infraction est la personne physique par l'intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu'organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l'acte illicite* »[5].

Cette situation contrastait avec celle qui, entre-temps, prévalait en France où les personnes morales, tout comme les personnes physiques, pouvaient être pénalement appréhendées. En effet, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal au 1er mars 1994, la responsabilité pénale des personnes morales a été généralisée[6]. Selon l'article 121-2 Code pénal (français) : « *Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont pénalement responsables, […], dans les cas prévus par la loi ou le*

1 – CA du 10 janvier 1948, *P.*, n° 14, pp. 307 ss., cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 18 décembre 1992, n° 308/92, cité par D. Spielmann, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – D. Spielmann, « La responsabilité des personnes morales en droit pénal luxembourgeois », *Ann. dr. lux.,* Vol. 4, p. 129.

4 – J. Dabin, note sous cass. du 16 décembre 1948, *R.C.J.B.*, 1949, p. 102.

5 – Cass. du 29 mars 1962, *P.*, n° 18, p. 450, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 259.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

Cette disposition n'a pas connu un enthousiasme sans partage : « *Ce principe de responsabilité, s'il vient satisfaire les "faiseurs de systèmes" dénote pourtant une repénalisation du droit des sociétés qui n'était ni indispensable, ni souhaitable. Il se cumule avec la responsabilité des dirigeants – qui ont vainement espéré pouvoir se défausser sur la structure qu'ils dirigent. L'article 121-2, dernier alinéa, énonce en effet que la responsabilité pénale de personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits* »[1].

Les personnes morales n'encourant pas de responsabilité pénale, les infractions commises par celles-ci doivent être réprimées dans le chef des personnes physiques par lesquelles elles agissent, notamment leurs organes et leurs préposés[2]. Mais, en vertu du **caractère subjectif** de la responsabilité pénale, ceci suppose que l'infraction puisse être personnellement imputée à la personne physique poursuivie. Il n'est donc pas suffisant de constater qu'une telle personne physique est un organe ou un préposé de la société en charge d'une certaine activité pour que cet organe ou cette personne doive automatiquement répondre des infractions constatées.

« *Il ne suffit pas d'être l'administrateur-délégué ou le directeur d'une société pour se voir* ipso facto *déclarer pénalement responsable des manquements commis par la société ; le juge doit en outre vérifier si l'agent était, de fait, tenu d'accomplir lui-même l'obligation légale qui fait l'objet de la prévention. Il doit déterminer parmi les personnes concernées le responsable, c.-à-d. la personne qui dans la réalité des choses est cause de l'état infractionnel* »[3]. En l'occurrence, A avait démissionné de son poste d'administrateur en date du 15 juin 1994 pour être remplacé par un autre administrateur en date du 22 juin 1994. Ces changements n'ont pourtant pas été publiés, de sorte qu'ils étaient inopposables aux tiers. Néanmoins, à partir de sa démission, A n'était plus tenu de veiller, dans le sein de la société, à ce que les comptes soient soumis à l'assemblée générale et publiés dans le R.C.S.[5].

Conformément à ces principes, la jurisprudence a retenu que le préposé chargé de l'application sur un chantier des mesures de sécurité arrêtées par l'administrateur-délégué d'une société anonyme soit pénalement responsable des accidents dus à un défaut de surveillance, à l'exclusion de cet administrateur-délégué « *[…] dès lors que ce dernier était* in specie *fondé à croire à une diligence normale de la part de son subordonné* »[4]. Toutefois, la délégation à une autre personne de tâches qui sont sanctionnées pénalement ne fait pas nécessairement échapper aux sanctions pénales les organes normalement en charge de ces tâches. En effet, l'infraction leur demeure imputable s'ils ont omis de donner les instructions nécessaires ou encore s'ils se sont désintéressés de leur exécution ou ont manqué à leur obligation de surveillance[5].

---

1 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 260.

2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1), *R.C.J.B.*, 1992, p. 662, et les nombreuses indications de jurisprudence y données.

3 – CA du 6 novembre 2001, *BIJ*, 2003, p. 45.

4 – Bruxelles du 26 juin 1980, *R.W.*, 1980-1981, col. 2008, P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 663.

5 – Corr. Bruxelles du 14 janvier 1986, *Pas.*, 1986, III, p. 22 – Corr. Bruges du 30 avril 1980, *J.T.T.*, 1983, p. 120.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Ces principes s'appliquent également aux dirigeants de fait : « *Les infractions commises dans ou à l'occasion de la gestion d'une société commerciale peuvent avoir comme auteurs pénalement responsables ceux qui, en fait, gèrent cette société, même s'ils n'en sont pas les organes* »[1].

Si une société coopérative ne peut, en raison de sa qualité de personne morale de droit privé, commettre une infraction, l'auteur pénalement responsable de pareille infraction est la personne physique par l'intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier. Cette personne physique est responsable non pas en tant qu'organe compétent de la société, mais en tant qu'individu ayant commis l'acte illicite. Les juges du fond constatent souverainement, à l'aide des éléments de fait de la cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l'être fictif de la société a été amené à contrevenir à la loi pénale[2].

Lorsqu'une infraction est commise par une personne morale, la responsabilité pénale de cette infraction pèse sur la personne physique par l'intermédiaire de qui cette personne a agi. Il faut rechercher la personne physique qui, dans la réalité des choses, est fautive, est cause de l'état infractionnel dans lequel a été mise la société ou l'association visée[3].

Le chef d'entreprise est tenu d'assurer l'observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et est pénalement **responsable** de l'acte délictueux commis par un **préposé**. « *Le principe de la responsabilité du chef d'entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d'un préposé, ni la faute d'un tiers (C.A. du 8 février 2002, n° 46/02)* »[4].

■ § 2 – Introduction de la responsabilité pénale des sociétés

Par suite de l'adoption du projet de loi n° 5718 par la loi du 3 mars 2010 modifiant un certain nombre de dispositions du Code pénal, la situation de droit ayant prévalu en droit luxembourgeois depuis l'introduction du Code pénal en droit luxembourgeois a profondément changé en raison de l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en notre droit. « *Par l'introduction de ce régime, une personne morale engage sa responsabilité pénale lorsqu'un crime ou un délit est commis en son nom et dans son intérêt par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs des membres de ses organes* »[5].

Ce changement fondamental d'orientation de notre droit est motivé avant tout par les obligations internationales encourues par le Luxembourg, notamment au niveau de l'Union européenne, de l'OCDE, du Conseil de l'Europe et de l'ONU.

La loi du 3 mars 2010 entrée en vigueur en début mars 2010 s'applique dans les cas où « *un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne*

1 – Cass. b. du 23 mai 1990, *Rev. dr. pén.*, 1990, p. 1101.

2 – TA Lux. du 22 avril 1999, *P.*, n° 31, p. 81, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA corr. du 3 juin 2003, n° 26.824, *BIJ*, 2004, n° 7, p. 129.

4 – TA Lux. du 24 mars 2005, ID 12019.

5 – *Doc. parl.*, n° 5718, Exposé des motifs, p. 9, ID 10078.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait »[1] ; c'est la personne morale qui peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par le Code pénal (art. 34 du C. pén.).

Cette disposition précise encore que la personnalité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices de ces mêmes infractions. Les peines applicables sont adaptées à la situation des personnes morales. Il s'agit de :

– l'amende (entre 500 et 750 000 euros, dans certains cas augmentée à 3 750 000 euros) ;
– la confiscation spéciale ;
– l'exclusion de la participation à des marchés publics ;
– la dissolution de la société suivie de sa liquidation.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010, une société ne pouvait commettre des infractions pénales ; si une société était directement concernée par des opérations pénalement répréhensibles, c'étaient les personnes physiques par lesquelles elle agissait qui étaient considérées comme les auteurs des infractions et poursuivies (en l'espèce, la responsabilité pénale d'un gérant de droit et d'un gérant de fait d'une S.à r.l. est retenue)[2]. La situation est désormais différente dans le sens qu'il y a en quelque sorte cumul des poursuites et des peines : « *la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions* »[3].

SECTION II
PARTICIPATION NON AUTORISÉE AUX ASSEMBLÉES

La participation aux assemblées est réservée aux associés, au moins en ce qui concerne l'exercice du droit de vote. Toute personne qui n'est pas associé n'a en principe pas accès à une telle assemblée, ce qui fait que la participation à une telle assemblée est considérée comme frauduleuse et donc sanctionnée pénalement.

■ § 1 – Éléments constitutifs de l'infraction

« *[…] ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions ou d'obligations qui ne leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous l'empire de la présente loi, pris part au vote dans une assemblée générale d'actionnaires ou d'obligataires ; ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l'usage ci-dessus prévu* ».

L'infraction prévue par l'article 1500-1 [anc. art. 162] L.S.C. consiste à prétendre être détenteur de titres (actions ou obligations) donnant en principe un droit d'accès à une assemblée générale des porteurs de titres en question, alors qu'en réalité tel n'est pas le cas. Sont passibles des mêmes sanctions ceux qui ont remis les actions ou obligations aux fins de l'usage visé.

1 – Art. 34 du Code pénal, nouvellement introduit par la loi du 3 mars 2010, ID 13361.
2 – TA Lux. du 2 décembre 1987, n° 2022/87, ID 11911.
3 – Art. 34, alinéa 2, du Code pénal.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Ces derniers font donc figure de complices de l'infraction. S'agissant d'une disposition pénale, une intention criminelle est néanmoins nécessaire, donc la conscience d'agir de manière criminelle. On peut noter que le genre d'inculpation en question est assez facile à éviter. Il suffit en effet que le véritable propriétaire entre dans une opération de mise en pension (ou de « *repurchase agreement* ») avec la personne désireuse de participer à l'assemblée en question. Le même effet est atteint en passant par une opération fiduciaire : le fiduciant peut sans le moindre doute et sans la moindre hésitation affirmer être le propriétaire (juridique sinon économique) des titres de la société.

Avec la mesure ici commentée, la loi a entendu prévenir les fraudes résultant de la « *constitution de majorités factices* »[1]. L'importance pratique de cette disposition est de nos jours fort limitée. Pour comprendre son utilité passée, il faut se reporter au temps où le nombre de titres avec lesquels tout associé pouvait voter était limité à 20 % du capital. Cette limitation « *[…] serait par trop aisée à tourner si les titulaires d'un nombre de titres supérieur au maximum légal pouvaient impunément, pour la quotité ainsi frappée d'indisponibilité entre leurs mains, recourir à l'intermédiaire complaisant ou intéressé de personnes tierces devenues pour la circonstance propriétaires fictifs de cet excédent* »[2]-[3].

Pour que la sanction s'applique, il est nécessaire que la personne visée ait « *pris part au vote* ». Il résulte notamment de cette condition (qui relève d'une disposition pénale et qui doit partant être interprétée de façon stricte) que la participation en tant qu'actionnaire fictif à une assemblée n'aurait pas de conséquence dommageable si l'assemblée n'aboutit à aucun vote sur une décision à prendre[4]. Il résulte encore de cette disposition que son application est limitée aux cas où une personne « *se présente comme propriétaire d'actions […]* », ce qui exclut la participation à l'assemblée qu'en tant que mandataire, même si elle participe sur la base d'un mandat qu'elle sait non valable. En outre la participation à une assemblée générale exclut celle à l'assemblée constitutive[5].

■ § 2 – Sanctions de l'infraction

L'infraction est punie seulement d'une amende, variant de 500 à 25 000 euros.

SECTION III
DISTRIBUTION DE BÉNÉFICES FICTIFS

La préoccupation d'éviter la distribution de bénéfices fictifs fait partie des principaux objectifs du droit des sociétés de capitaux. À cet égard, les règles applicables ont été considérablement renforcées et précisées ces dernières décennies, en particulier depuis l'entrée en vigueur de la Quatrième directive (2013/34/UE) prise en matière de droit des sociétés.

1 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 95.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 400, ID 11308.

3 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 256.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 401, ID 11308.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 414, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette infraction est sanctionnée par l'article 1500- 6 [anc. art. 167] L.S.C.

« *Cette disposition assure la protection pénale de l'intangibilité du capital social, principe fondamental dans toutes les sociétés qui ont un capital social distinct de celui des associés ou actionnaires. La répartition de dividendes fictifs contredit le but du contrat de société qui est décrit comme le partage des bénéfices. Elle mène la société à la ruine en la dépouillant de ses ressources indispensables. Elle prive surtout les créanciers d'une partie de leur gage. Elle induit le public en erreur et peut servir à des spéculations frauduleuses. Car la distribution de dividendes constitue la preuve la plus convaincante de la prospérité d'une société commerciale et du succès de sa gestion. Dès lors la distribution de dividendes fictifs apparaît comme le moyen le plus sûr de tromper tout le monde, actionnaires et tiers, tant sur la situation financière que sur la capacité de ses dirigeants* »[1].

Ce sont uniquement les gérants et administrateurs qui peuvent être sanctionnés comme auteurs de cette infraction. Il n'est pas nécessaire que le **dirigeant** (gérant ou administrateur) soit toujours **en fonction** au moment de la distribution des dividendes qui résulte directement du bilan. Si le bilan a été établi sans inventaire ou sur la base d'un inventaire frauduleux, alors le dirigeant sera responsable de la distribution, même s'il a démissionné depuis lors. En revanche, cette disposition ne peut s'appliquer aux commissaires ou aux directeurs qui ne font qu'exécuter les décisions du conseil d'administration[1].

Depuis la Quatrième directive (2013/34/UE actuellement) notamment, les règles d'évaluation applicables aux sociétés de capitaux ont essentiellement pour but et pour objet de garantir la **réalité du capital social** comptable, en particulier donc d'assurer que les bénéfices distribués au maximum ne dépassent pas le montant qui puisse être distribué sans justement entamer le montant du capital social statutaire.

■ § 1 – Éléments constitutifs de l'infraction

Bon nombre de règles du droit des sociétés sont destinées à garantir que le montant des bénéfices distribués ne puisse excéder celui que la société a effectivement réalisé.

À cet égard, le législateur a prévu une infraction spéciale *sui generis* détachée de celle de l'escroquerie[2].

Art. 1500-6 [anc. art.167] L.S.C.

« *Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en l'absence d'inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou d'intérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi que les administrateurs qui contreviennent aux dispositions des articles 461-3 et 710-25* ».

Cette disposition vise les sociétés anonymes et, par ricochet, les sociétés en commandite par actions ainsi que les sociétés à responsabilité limitée (depuis 2016).

1 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 101.

2 – J. Corbiau, « Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales », p. 415, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'élément matériel de l'infraction est la distribution de dividendes non prélevés sur des bénéfices réels. L'existence d'un dol spécial ou d'un but frauduleux[1] n'est pas requise. Souvent, la distribution de dividendes ne sera que la conséquence plus ou moins directe de l'infraction de **faux bilan**[1].

La question de savoir à quel **moment** précis cette **infraction est réalisée** a donné lieu à des controverses. Trois positions ont été adoptées sur ce point :

1) le délit n'est consommé que le jour où le dividende est effectivement payé à l'associé. Il s'agissait notamment de la position adoptée par la jurisprudence du Tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 6 décembre 1926[2]. Il a été objecté contre cette position qu'elle opérerait une confusion entre répartition et paiement dans la mesure où la loi se réfère à la répartition, par laquelle on entend « partager entre plusieurs en attribuant à chacun ce qui lui revient tandis que payer signifie acquitter ce que l'on doit »[3] ;
2) le délit est consommé par le **vote** de l'assemblée générale. Pour les tenants de cette position, c'était par le vote du bilan que les associés avaient un droit certain sur les dividendes ;
3) le délit est consommé au moment où les administrateurs procédaient à la **mise à disposition du dividende** aux associés. C'est cette décision qui exécutait la résolution de l'assemblée générale des associés. Cette position est celle de la jurisprudence et de la doctrine françaises[4]. Elle a le mérite d'exiger un acte positif de la part des dirigeants sociaux, et est défendue par Van Ryn pour la Belgique :

   « *la décision de l'assemblée générale ne constitue pas un acte des administrateurs. Les administrateurs ont en effet la possibilité de ne pas exécuter une décision de l'assemblée générale qui serait illégale. Dès lors il serait inique de faire peser sur eux la responsabilité d'une décision qui n'a pas été prise par eux* »[3].

L'infraction n'est constituée que s'il y a distribution de « *dividendes ou d'intérêts non prélevés sur les bénéfices réels* ». Il y a bénéfice dans le cas où « *les opérations sociales ont fait entrer des valeurs nouvelles dans la société, et qu'elle se trouve posséder ainsi un excédent sur son capital […]* »[5].

Il suffit que ce bénéfice soit certain : point n'est besoin qu'il soit encaissé ou liquide. L'appréciation consistant à savoir si le dividende est prélevé sur des bénéfices réels doit se faire au moment où le bilan est établi.

Tel est le problème en cas **d'acomptes sur dividendes**. Par définition, il s'agit en l'occurrence de la distribution de dividendes prélevés sur des bénéfices réalisés au cours de l'exercice et répartis avant la clôture de cet exercice. La loi prévoit la possibilité de procéder à la répartition de tels acomptes sur dividendes pour les sociétés anonymes et, depuis 2016, pour les sociétés à responsabilité limitée.

---

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 415, ID 11308.

2 – *R.P.S.*, 1927, p. 90, Trib. civ de Bruxelles du 6 décembre 1926.

3 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 103.

4 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 105.

5 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 107.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En respectant les procédures légales, les administrateurs échappent évidemment à toute responsabilité. Mais qu'en est-il des autres formes de sociétés ? La réponse est que, si le gérant d'une autre forme de société procède à la répartition d'un acompte sur dividende prélevé sur les bénéfices dégagés sur les mois de janvier à septembre 2017 et que ceux-ci sont distribués en novembre, les dirigeants sociaux courent un risque fort conséquent dans le sens qu'ils n'ont aucune certitude que ces bénéfices ne seront pas éliminés par l'activité sociale du dernier trimestre de l'année 2017 : si cette éventualité se réalise, alors les conditions objectives de l'infraction de répartition de dividendes fictifs sont réalisées.

Théoriquement, cette situation pourrait se dénouer dans le sens inverse. Aucun bénéfice n'est réalisé sur les neuf premiers mois de l'année, néanmoins une répartition est faite en novembre de la même année. Heureusement, pendant le dernier trimestre, l'activité sociale est profitable, de sorte que le bilan clôturé au 31 décembre 2017 montre un résultat supérieur au bénéfice distribué.

La doctrine n'est pas unanime pour considérer que, dans un tel cas, les dirigeants sociaux seraient exempts de tout reproche. En effet, pour van Ryn, « *la répartition d'un acompte ne peut échapper aux sanctions pénales qu'à la double condition qu'au moment des paiements, il existe un inventaire sincère faisant apparaître un bénéfice réel et que l'existence de ce bénéfice soit confirmée par le bilan approuvé ultérieurement par l'assemblée générale* »[1].

La jurisprudence belge, contrairement à la française, considère qu'il n'est point besoin du dol général et que la **négligence suffit** pour constituer l'infraction[2]. A ainsi été condamné l'administrateur qui, sans avoir fait la moindre vérification, a signé le bilan et le compte de profits et pertes sous la simple assurance de ses collègues qui lui en affirmaient l'exactitude[3]. Cette décision a été critiquée par une partie de la doctrine pénale dans le sens qu'elle néglige que l'intention criminelle est un élément constitutif de toute infraction, à moins que la loi en dispose autrement[4], ce qui en l'occurrence n'est pas le cas (voir l'article 1500-6 L.S.C.).

Déjà la loi belge de 1873 punissait pénalement les administrateurs qui, sur la base de faux bilans, procédaient à la distribution de dividendes fictifs. Mais restait ouverte la question de savoir si l'infraction de faux bilan, non accompagnée de la distribution de dividendes fictifs, ne devrait pas à son tour être sanctionnée pénalement. La Cour de cassation belge devait, par deux arrêts presque concomitants[5], répondre négativement à cette question. Il est évidemment intenable que les administrateurs puissent impunément publier des bilans qui contiennent des indications fausses, et ceci, avec une intention frauduleuse[6].

La jurisprudence luxembourgeoise récente a retenu que « *[l]es défendeurs YY et ZZ contestant que les articles 72-1 et 167 de la Loi modifiée de 1915 puissent être qualifiés de règles d'ordre public sanctionnées par une nullité absolue, il convient*

1 – J. van Ryn, *Principes de droit commercial,* T. 1, p. 779.

2 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 107.

3 – Corr. Liège du 12 octobre 1911, *Pand. pér.*, 1912, n° 266.

4 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 111.

5 – Cass. b. du 24 juin et du 8 juillet 1878, *Pas.*, 1878, I, pp. 309 et 408.

6 – A. Nyssens, Avant-projet sur les sociétés commerciales, p. 345, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

d'examiner en premier lieu si ces dispositions peuvent réellement être qualifiées de dispositions d'ordre public ou s'il s'agit de dispositions simplement impératives censées protéger certaines catégories de personnes lesquelles ont pu renoncer à cette protection en accordant décharge.

Les dispositions litigieuses de la Loi modifiée de 1915 ont la teneur suivante :

*"**Article 72-1** : (1) Sauf les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.*

(2) Le montant du capital souscrit visé sous (1) est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.

(3) Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément à la loi ou aux statuts.

(4) Le terme 'distribution', tel qu'il figure dans les dispositions qui précèdent, englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions (Loi du 24 avril 1983).

Article 167 (Loi du 11 juillet 1988) : Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en l'absence d'inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou d'intérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi que les administrateurs qui contreviennent aux dispositions de l' article 72-2".

Ces dispositions visent, d'une part, à encadrer la distribution de dividendes aux actionnaires pouvant intervenir uniquement en présence de bénéfices distribuables et, d'autre part, à sanctionner pénalement toute distribution de dividendes fictifs, c'est-à-dire intervenue en l'absence de tels bénéfices distribuables tels que définis à l'article 72-1.

*La distribution de dividendes fictifs est non seulement sanctionnée sur le plan de la responsabilité civile du gérant par l'*actio mandati *pour faute de régularité (violation de la loi), mais également sur le plan pénal par l'application de peines sévères (un emprisonnement d'un mois à deux ans et une amende de 5.000.- à 125.000.- EUR ou une de ces peines seulement), ce qui plaide à première vue en faveur d'une qualification de disposition d'ordre public.*

Pour les défendeurs, le simple fait que la violation de la loi soit pénalement sanctionnée ne changerait pas la nature de l'obligation légale (en l'occurrence une simple disposition impérative visant à préserver l'intangibilité du capital social et partant à protéger les créanciers de la société) pour la transformer en une disposition d'ordre public.

Ils citent à cet égard l'auteur Henri de Page précisant notamment que "[…] nombre d'infractions pénales sanctionnent la violation de règles simplement impératives destinées à assurer la protection d'intérêts privés […] Les nullités absolues doivent être appliquées lorsque la règle violée est d'intérêt public" (Henri DE PAGE, Traité de droit civil belge, t. 2, Les Obligations, Vol. 2, éd. 2013, n°s 628 et 630).

Ces considérations rejoignent la distinction classique en droit des sociétés entre ordre public de protection visant à protéger certaines catégories de personnes, tels les tiers en relation contractuelle avec la société et les associés en leur assurant un équilibre minimal entre eux, lesquels peuvent renoncer à cette protection, et ordre public de

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

direction visant à préserver l'intérêt propre de la société, c'est-à-dire son fonctionnement, auquel le législateur ne permet pas de déroger (cf. A. Steichen, op. cit.*, pages 22-23).*

Le caractère d'ordre public de direction d'une disposition légale ne pouvant être déduit de la seule existence d'une sanction pénale, il faut s'attacher au but poursuivi par le législateur au moment de l'introduction de cette loi.

On peut à cet égard se référer aux développements effectués par Jean Corbiau dans l'avant-projet de Loi de 1915 au sujet de l'article 167, alors que l'article 72-1 a uniquement été introduit en notre droit par une loi du 24 avril 1983 dans le cadre de la transposition de la 2e directive 77/91/CEE *du Conseil du 13 décembre 1976. "La répartition entre les actionnaires de dividendes non prélevés sur des bénéfices réels est un fait dont les conséquences apparaissent tout particulièrement graves et pernicieuses. Comme le disait M. Pirmez dans son rapport, cet acte 'porte atteinte à la vérité' en allant à l'encontre du but essentiel et fondamental du contrat de société, qui est de partager des bénéfices (art. 1832, C. civ.) ; il mène la société à la ruine, en la dépouillant des ressources nécessaires à la réalisation de son objet ; il prive les créanciers d'une partie de leur gage, en diminuant subrepticement le capital qui, patrimoine de l'être moral, forme la garantie commune et même, dans les sociétés anonymes, la seule garantie des tiers ; enfin, il induit le public en erreur et peut servir à des spéculations frauduleuses sur les actions, en faisant briller devant les capitaux en quête de placement le mirage d'une prospérité trompeuse et en les incitant à acheter des titres sociaux à un taux supérieur à leur valeur véritable. Il y a là plus de motifs qu'il n'en faut pour justifier l'interdiction du fait dont s'agit et sa répression par voie de sanction pénale" (cf. J. Corbiau,* op. cit.*, pages 411-412).*

La préservation du gage des créanciers n'est partant qu'un but parmi d'autres de portée plus générale ayant incité le législateur à interdire la distribution de dividendes fictifs, de sorte que les dispositions litigieuses doivent être considérées comme relevant de l'ordre public de direction sanctionné par une nullité absolue.

L'existence d'une décharge valable par l'assemblée générale est partant sans effet sur le droit de HELLAS II d'agir en nullité des résolutions litigieuses pour violation des articles 72-1 et 167 de la Loi modifiée de 1915 »[(1)].

■ § 2 – Sanctions de l'infraction

L'infraction est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5000 à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement.

SECTION IV
RACHAT DES ACTIONS ET PARTS PROPRES

Art. 1500- 7 [anc. art. 168] L.S.C.

« Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment :

1° racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de l'article 430-15

1 – TA Lux. du 23 décembre 2015, nos 145724 et 145725, ID 24088.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dans le cas des sociétés anonymes et de l'article 710-5, paragraphes 2 à 7 dans le cas des sociétés à responsabilité limitée ;

2° *fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de l'acquisition d'actions ou de parts sociales de la société ou pris en gage des actions ou des parts sociales propres et ce, contrairement aux articles 430-19 et 430-21 dans le cas des sociétés anonymes ;*

3° *ordonné, autorisé ou accepté qu'une autre société telle que définie à l'article 430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, souscrive, acquière ou détienne des actions dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et ce en violation de l'article 430-15 ;*

4° *fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts sociales ou admis comme faits des versements qui ne seront pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites ».*

Le rachat de titres propres peut avoir des effets tout à fait comparables à ceux d'une distribution de bénéfices fictifs dans la mesure où l'une comme l'autre de ces opérations est susceptible **d'entamer le capital** social de la société. Si cet effet est toujours et par définition donné pour les distributions de dividendes fictifs, il n'en va pas toujours ainsi pour les rachats d'actions. Il en résulte également que le rachat d'actions n'est pas toujours une opération critiquable. Tel est le cas uniquement si le rachat n'est pas fait au moyen des bénéfices accumulés et distribuables de la société. C'est donc à juste titre que les auteurs des directives européennes n'ont pas interdit les opérations de rachat des titres propres de la société, mais ne les autorisent qu'à des conditions qui garantissent que l'effet de ces opérations ne puisse pas être de faire descendre les fonds propres de la société en-dessous du niveau des fonds propres non distribuables.

Ce ne sont pas seulement les gérants et administrateurs qui peuvent être tenus pour coupables de ces infractions, mais encore les **commissaires** et les membres du **conseil de surveillance**.

L'article 1500-7 L.S.C. vise quatre catégories d'opérations différentes, dès lors qu'elles sont faites « **sciemment** »[1] :

– le rachat des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire. La référence aux parts sociales (reprise de la loi belge de 1873) avait pour objet d'inclure sous le champ d'application non pas les S.à r.l. qui n'existaient pas encore à l'époque, mais les parts de commanditaires des sociétés en commandite simple. Mais les sanctions étaient de ce fait inapplicables aux parts d'associés de commandités et d'associés en nom collectif : ces deux catégories d'associés étant responsables de manière illimitée des engagements de la société, ces opérations de rachat sont inoffensives à l'égard des tiers[2] ;

– les **prêts** et avances consentis par la société aux associés **sur mise en gage des titres** de la société. Cette façon de procéder n'est qu'une modalité de restitution des apports des associés, qui n'a que pour particularité de devenir

1 – Cette spécification se réfère au dol général ou dol ordinaire, v. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 427, ID 11308.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 423, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

effective au moment du non-remboursement du prêt. Il s'agit d'une vente éventuelle en cas de non-paiement du prêt[1]. Il est à noter que ne sont visées que « *les stipulations antérieurement ou simultanément au prêt, de la constitution de gage en titres sociaux. Par contre la loi n'interdit pas la remise de titres en garantie faites postérieurement au prêt* »[2]. La loi luxembourgeoise, qui par le passé différait de la loi belge sur ce point dans le sens que la L.S.C. (en son article 168) ne visait que les prêts ou avances, et non le fait « *d'accorder des sûretés* » s'est en 2016 alignée sur la loi belge sur ce point ;

– le fait d'avoir « *ordonné, autorisé ou accepté* » qu'une autre société dans laquelle la société visée détient la majorité des droits de vote acquière ou détienne des actions en application des dispositions de l'article 430-23 (anc. art. 49*bis*) L.S.C. Il est à noter que cette disposition se limite aux actions ;

– les versements faits par la société en exécution des engagements sociaux des associés. Par hypothèse, ces versements sont faits au moyen non pas des fonds des associés, mais de ceux de la société elle-même.

La dernière disposition de cet article 1500-7 L.S.C. vise deux faits de nature différente et en quelque sorte opposés. En premier lieu, sont visés les versements fictifs faits sur les actions aux frais de la société ; en deuxième lieu, des versements prétendument faits au profit de la société, alors que tel n'a pas été le cas en réalité. Le point commun de ces deux cas est que la société apparaît plus riche qu'elle ne l'est en réalité. Il s'agit donc de versements fictifs, cas de **simulation d'une situation prospère** qui n'existe pas en réalité.

Un cas d'application de ce deuxième cas de figure est celui du conseil d'administration qui constate dans le bilan des apports qui n'ont pas été faits en réalité, ou encore qui permet au souscripteur de reprendre ses fonds[3].

SECTION V
NON-PUBLICATION D'INFORMATIONS DANS LES DÉLAIS LÉGAUX

Selon les directives européennes prises en matière d'harmonisation du droit des sociétés, il est obligatoire pour toutes les sociétés de capitaux (soit donc les S.A., les S.e.c.a. et les S.à r.l.) de publier les comptes annuels et de communiquer ainsi au public une information pertinente, fiable et constamment tenue à jour. L'efficacité de ces mesures, qui sont évidemment sources de coûts considérables pour les entreprises, ne peut être garantie que si leurs violations sont sanctionnées pénalement et si ces sanctions sont effectivement appliquées. Sont sanctionnées par les mêmes peines les non-publications d'autres informations, notamment celles prévues par les articles 420-1, 420-15, 420-17 et 420-19 L.S.C.

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 424, ID 11308.

2 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 112.

3 – CA Bruxelles du 26 avril 1899, *Pas.*, 1899, II, p. 193.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – Éléments constitutifs de l'infraction

L'article 1500-2 [anc. art. 163] L.S.C. dispose que :

« Sont punis de la même peine :

1° ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises par les articles 420-1, 420-15 et 420-19 dans les actes, projets d'actes de sociétés ou notices publiés au Recueil électronique des sociétés et associations *ou déposés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis *de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dans les souscriptions, prospectus, circulaires adressées au public, dans les affiches et insertions publiés par les journaux ;*

2° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;

*3° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fit publier le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ou le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements et ce en infraction aux prescriptions de l'article 1760-4 de la présente loi et de l'article 72*septies *de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;*

*4° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas publié la déclaration non financière ou la déclaration sur le gouvernement d'entreprise visée à l'article 1730-1 de la présente loi et aux articles 68*bis *et 68*ter *de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;*

5° les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, l'assemblée générale prévue par l'article 450-8, alinéa 2 ;

6° ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de l'article 813-9, alinéa 1er, concernant le contrôle des sociétés coopératives ;

7° les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles, et, dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui n'ont pas fait publier les modifications survenues dans la personne des associés conformément à l'article 100-13, paragraphe 2, point 3° ;

8° les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à des parts bénéficiaires d'une société à responsabilité limitée, de même que les dirigeants d'une société par actions simplifiée qui ont ouvert une souscription publique à des actions ;

9° les administrateurs de sociétés anonymes qui n'ont pas présenté le rapport visé à l'article 430-18, paragraphe 2, ou qui ont présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par cet article ;

10° les personnes visées à l'article 1300-12 qui n'ont pas accompli les formalités de publicité prescrites aux articles 1300-5 à 1300-7, 1300-9, 1300-10 ».

Sous cette rubrique sont en fait visées un nombre important d'infractions dépassant en réalité la publication des comptes annuels, et concernant toute la procédure d'approbation des comptes jusqu'à leur publication.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La question qui se pose est de savoir si les peines de non-publication des comptes annuels peuvent être appliquées à l'égard de **comptes non encore approuvés** par les associés.

Un arrêt de la Cour de Gand[1] avait condamné un administrateur-délégué, en retenant que le fait que le bilan n'ait pas été arrêté par le conseil, n'ait pas été soumis à l'assemblée et n'ait pas été approuvé par elle ne constituait pas une excuse pour ne pas avoir publié le bilan. « *Cet arrêt ne peut être approuvé. L'infraction de non-publication ne peut se concevoir que pour un bilan approuvé par l'assemblée générale qui, seul est susceptible de publication* »[2].

Traditionnellement était punissable uniquement le fait de ne pas publier un bilan dûment approuvé. En revanche, la non-soumission du bilan à l'assemblée des associés était non sanctionnée. Telle était la solution consacrée par la Cour de cassation belge[3] et qui a prévalu jusqu'à la loi du 6 mars 1973[4] qui a remédié à cette lacune évidente de la loi. En l'occurrence, il suffisait donc de ne pas dresser le bilan ou de ne pas le soumettre à l'assemblée[5].

Cette solution est également consacrée au Luxembourg (depuis la loi du 2 décembre 1993), dans la mesure où la L.S.C. punit non seulement les gérants qui n'ont pas procédé à la publication des comptes, mais également ceux qui n'ont pas soumis à l'approbation des associés les comptes annuels dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice (en dehors du fait de ne pas avoir publié ces comptes approuvés dans le délai d'un mois à partir de leur approbation : art. 1500-2, point 2°, [anc. art. 163, point 2°])

À l'égard de ces mesures (plus encore à l'égard d'autres), il faut insister sur le fait que les dispositions pénales ne sont finalement pas les seules à s'appliquer, et peut-être même pas celles que les dirigeants/associés ont le plus à craindre. En effet, ce n'est pas une hypothèse d'école que la publication retardée des comptes annuels soit de nature à engager la responsabilité civile des dirigeants d'entreprise. En outre, l'article 1200-1 L.S.C. est fréquemment appliqué en ce domaine avec pour conséquence que la société peut être dissoute par voie judiciaire, si tant est que les juridictions concluent que la publication est suffisamment retardée pour constituer une violation grave de la L.S.C. (pour plus de détails, voir p. 352).

L'infraction de non-publication des comptes annuels (art. 1500-2, point 2 L.S.C.) ne peut être commise **que par les gérants ou administrateurs** de société : elle ne peut être commise par les associés, il s'agit d'une infraction liée à la fonction[3].

Non-dépôt des comptes annuels[6] : « *Il ne suffit pas d'être l'administrateur-délégué ou le directeur d'une société pour se voir* ipso facto *déclaré pénalement responsable*

1 – Cour de Gand du 6 novembre 1964, *R.P.S.*, 1965, p. 69.

2 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965) », R.C.J.B. 1965, p. 353.

3 – Cass. b. du 13 décembre 1965, R.P.S., 1966, p. 238.

4 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 92.

5 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 120.

6 – TA Lux. du 13 juillet 1998 et CA du 27 avril 1999, *Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves*, n° 91, décembre 1998, pp. 59 ss., ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

des manquements commis par la société : le juge doit en outre vérifier si l'agent était, de fait, tenu d'accomplir lui-même l'obligation légale qui fait l'objet de la prévention. Il doit déterminer parmi les personnes concernées le responsable, c'est-à-dire la personne qui dans la réalité des choses est cause de l'état infractionnel. Il est constant en cause que A a non seulement démissionné en date du 15 juin 1994 de ses fonctions d'administrateur mais qu'en plus une autre personne du nom de B a été appelée à sa place aux fonctions d'administrateur par décision de l'assemblée générale du 22 juin 1994. Même si cette décision n'a pas été portée à la connaissance des tiers par sa publication au Mémorial *et qu'elle leur demeurait dès lors inopposable, il n'en reste pas moins que A n'était plus à partir de cette date tenue au sein de la société de veiller à ce que les comptes annuels de* b*la société soient soumis à l'assemblée générale et déposés au registre de commerce et des sociétés dans le mois* »[1].

À propos de l'infraction de non-publication des comptes annuels portée par l'article 1500-2, point 3°, L.S.C., tout gérant a, de par l'article 1500-2 de la L.S.C., l'obligation de prendre l'initiative des démarches nécessaires pour éviter la commission de l'infraction, et il ne saurait se décharger de cette responsabilité qu'en établissant l'existence de l'une des causes d'excuse ou de justification prévues par la loi, le refus ou la négligence des cogérants de remplir à leur tour leurs obligations ne pouvant tout au plus constituer qu'une circonstance atténuante selon les circonstances particulières de chaque espèce. Le prévenu invoque vainement une impossibilité matérielle de procéder à la publication en arguant de ce qu'il n'aurait plus eu le moindre contact d'affaires avec la société, alors que l'initiative de publication n'est nullement le monopole de la société en cause, mais appartient bien à tout intéressé et notamment au gérant démissionnaire qui pourra ainsi dégager sa responsabilité pour des opérations futures. Les prévenus ne contestent pas la prévention mise à leur charge par le parquet et se bornent à expliquer leur négligence par le peu d'importance de la société par rapport au volume d'affaires qu'ils traitent habituellement, ainsi que par leur rôle de simples administrateurs de pure forme, faisant pleine confiance au véritable maître de l'affaire, d'ailleurs administrateur-délégué. Aucune de ces explications ne saurait amoindrir la responsabilité pénale des trois prévenus alors qu'aux termes de l'article 1500-2 (anc. art. 163) L.S.C. – en cas de non-respect des textes visés par cet article – elle est supportée solidairement par l'ensemble des administrateurs, qu'ils exercent ou non leur mandat de façon effective[2].

Il a été fait application de l'article 1500-2, point 3°, L.S.C. dans un cas d'espèce où il était reproché aux prévenus de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale les comptes sociaux dans les douze mois de la clôture de l'exercice et de ne pas avoir déposé au R.C.S. les comptes sociaux dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale. Le juge pose que le délai de prescription (trois ans) n'a commencé à courir qu'à partir du dernier jour des différentes échéances successives[3].

La démission d'un administrateur qui n'a pas été portée à la connaissance des tiers conformément aux dispositions de la Loi de 2002 est inopposable aux tiers et,

1 – CA du 6 novembre 2001, n° 375/01, *BIJ*, 2003, p. 45.

2 – TA corr. Lux. du 18 décembre 1991, n° 1951/91, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA Lux. du 13 juillet 1998 et CA du 27 avril 1999, *Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves*, n° 91, décembre 1998, pp. 59 ss., ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

partant, au ministère public (requérant en l'espèce l'application de la disposition pénale figurant à l'article 1500-2 L.S.C.). « *Si depuis la modification apportée à l'article 179 de la L.S.C. sur les sociétés commerciales par la loi du 28 décembre 1992, la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne plus la dissolution d'une société à responsabilité limitée, il convient de constater qu'en l'espèce c'est avant l'entrée en vigueur de cette loi que P est devenu propriétaire de toutes les parts de la société "et est investi de tout l'actif et de l'intégralité du passif sociaux" […] L'acquisition par le seul P de toutes les parts sociales de la s.à r.l. F avait entraîné de plein droit la dissolution immédiate de la société et la disparition concomitante de l'être moral. Si, selon l'article 141 de la susdite L.S.C. les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation, en l'espèce l'être moral n'avait même pas à survivre pour les besoins d'une liquidation et d'un partage entre les associés qui n'existaient plus. C'est en effet la propriété même des biens composant le fonds social qui selon les stipulations de l'acte de dissolution s'est trouvée directement acquise par le cessionnaire P qui est ainsi devenu débiteur du passif social en tant qu'acquéreur des biens composant le fonds social […] Dès lors que le patrimoine tout entier de la personne morale comportant l'ensemble du passif et de l'actif, des dettes comme des créances, s'est trouvé transféré, ce report de la dette sur la tête du nouveau débiteur, en l'espèce P, a entraîné la libération corrélative du premier débiteur, la société, sans même que soit nécessaire l'accord du créancier […]* »[1].

■ § 2 – Sanctions de l'infraction

Selon la L.S.C., il existe deux degrés dans la gravité de l'infraction : la **simple omission** de publier les comptes annuels dans le délai légal du mois après la date de leur approbation (en dehors du fait de ne pas les avoir soumis à l'assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice) est punie d'une amende de 500 à 25 000 euros (en application de l'article 1500-2, 2, L.S.C.).

■ § 3 – Alourdissement des peines en cas de but frauduleux

Art. 1500-5 [anc. art. 166] L.S.C. :

« Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5000 euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans l'état des obligations en circulation visé à l'article 470-12 ;

2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n'ont pas fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux articles 461-8, 813-4 et 1770-1, ainsi qu'à l'article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;

3° les administrateurs qui contreviennent à l'article 420-13 ».

1 – CA du 28 mars 1996, n° 15351, ID 10136.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'article 1500-5, point 2, L.S.C. sanctionne donc par des amendes nettement plus lourdes (5000 à 125 000 euros) et surtout par des peines d'emprisonnement (d'un mois à deux ans) les gérants et les administrateurs qui, **dans un but frauduleux**, n'ont pas procédé à ces publications dans les délais légaux.

Selon la jurisprudence, chaque non-soumission à l'assemblée est une infraction distincte, de sorte que les différentes infractions sont en situation de concours réel qui donnent donc lieu à l'application de l'article 60 du Code pénal[1]. La situation est la même en cas de non-publication des états financiers : infractions distinctes qui se trouvent en **concours réel**[2].

La responsabilité personnelle de *tous* les gérants et administrateurs est engagée au cas où les comptes annuels n'ont pas été dûment publiés. Selon la jurisprudence, ceux-ci sont à considérer comme co-auteurs au sens de l'article 66 du Code pénal « *ayant tous participé au même degré au délit matériel constitué par la non-représentation ou le non-dépôt des comptes sociaux, et cela, quelle que soit leur désignation (« technique » ou « administratif ») la loi n'opérant pas une telle distinction* »[3].

En cas de pluralité de gérants ou d'administrateurs, « *la responsabilité pénale est supportée solidairement par l'ensemble des administrateurs, qu'ils exercent ou non leur mandat de manière effective* »[4].

SECTION VI
ESCROQUERIE

La loi se réfère aux conditions de l'escroquerie telle que définie à l'article 496 du Code pénal.

■ § 1 – Éléments constitutifs de l'infraction

Il s'agit de l'infraction qui consiste dans l'emploi de **manœuvres frauduleuses** pour se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, décharges, etc. et spolier ainsi autrui. Pour pouvoir donner lieu à l'application des peines prévues, il faut que soient réunies certaines conditions précises. Il faut en premier lieu que les manœuvres soient de **nature à tromper** ceux à qui elles s'adressent et soient employées dans le désir précis de s'approprier le bien d'autrui. Ce délit vise des actes mensongers destinés à obtenir des souscriptions et des versements[5]. Les éléments constitutifs sont donc :

– le dol spécial : le but de s'approprier une chose appartenant à autrui ;
– la remise ou la délivrance d'objets ou de fonds (l'escroquerie est un délit de résultat) ;

1 – TA Lux. du 20 mai 1992, n° 714/92, ID 10191, confirmé par CA du 5 mars 1993, n° 68/93.

2 – TA Lux. du 6 janvier 1992, n° 8/92 et n° 10/92 ; TA Lux. du 15 janvier 1992, n° 65/92 ; TA Lux. du 9 mars 1992, n° 300/92, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA Lux. du 18 décembre 1991, n° 1951/91, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 20 août 1992, n° 714/92, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – J. Corbiau, Avant -projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 406, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– par la victime ;
– grâce à l'emploi de moyens frauduleux consistant soit dans l'usage de noms ou de fausses qualités soit dans des manœuvres frauduleuses […] (art. 496[1] du Code pénal).

Sont visées (par l'article 164 introduit par la loi du 11 juillet 1988, devenu article 1500-3 en 2016) les actions suivantes dans la mesure où elles ont provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d'actions, d'obligations ou d'autres titres de sociétés :

– par simulation de souscriptions ou de versements à une société ;
– par publication de souscription ou de versements qui n'existent pas ;
– par publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors que ceux qui y ont procédé savaient ces désignations contraires à la vérité (« *La disposition légale vise ainsi non seulement la personnalité des fondateurs et des administrateurs, mais également celle de tous les autres collaborateurs – hommes de science ou de métier, conseils, techniciens, spécialistes, etc. – dont le nom, l'honorabilité, la compétence ou le talent peuvent par la confiance qu'ils sont susceptibles d'inspirer aux tiers, être cause déterminante de la résolution de ceux-ci de s'intéresser dans la société et de lui confier des fonds* »[2].
– par publication de tous autres faits que ceux qui y ont procédé savaient être faux (en guise d'exemple, la diffusion de déclarations proclamant libre de charges un apport immobilier grevé d'hypothèques, la reproduction altérée ou tronquée de rapports d'expertise ou de mémoires techniques, la mention de cours fictifs ou de fantaisie, etc., etc.[1]).

La disposition en question concerne en premier lieu les sociétés anonymes, mais elle s'applique également aux autres formes de sociétés du fait qu'elle se réfère non seulement aux souscriptions d'actions, mais encore à celles d'autres titres de sociétés.

Par le passé, la tentative d'escroquerie n'était pas punissable, alors que telle était encore la solution de l'avant-projet Corbiau[3]. Elle l'est devenue en 1993.

S'agissant d'une disposition pénale, cet article doit être **interprété strictement** avec pour conséquence de ne viser que les **seuls apports d'espèce,** et non les apports en nature ou encore en industrie[4].

La Cour d'appel de Luxembourg[5] a retenu que les promoteurs locaux d'un fonds d'investissement ayant recours à une société des BVI (et au conseil d'administration duquel siégeaient les promoteurs) dont les parts étaient offertes au public pour investir dans l'immobilier à Dubaï et qui, dans un prospectus d'investissement, donnaient des informations clairement fausses (et dont la fausseté était connue aux administrateurs de la société des BVI) étaient soumis à l'article 164 (nouv. art. 1500-3) L.S.C. « *[…] qui sanctionne pénalement toute personne qui provoque des souscriptions ou*

1 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 86.

2 – CA (civ.) du 21 décembre 2016, nº 193/16 – II-CIV.

3 – Arrêt cité, p. 8.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 407, ID 11308.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 409, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

des versements par des informations fausses ». La Cour retenait que les directeurs engageaient leur responsabilité délictuelle en écartant les multiples avertissements donnés dans le prospectus sur le caractère risqué de l'investissement. « *De même l'information dispensée aux souscripteurs sur les risques encourus en relation avec leur investissements ne dispense pas les personnes offrant des titres à la souscription de leur obligation de diffuser des informations correspondant à la réalité* »(1).

■ § 2 – Sanctions de l'infraction

Les peines sont celles prévues par le Code pénal à l'égard de l'infraction de l'escroquerie. Il s'agit donc des peines suivantes : emprisonnement de un mois à cinq ans et/ou une amende de 251 à 30 000 euros (art. 496 C. pén.).

Selon une jurisprudence luxembourgeoise : « *Cet article exige cependant que l'auteur ait qualité de gérant, d'administrateur ou de commissaire et qu'il ait agi en cette qualité* »(2). Il s'agit donc encore d'une infraction **liée aux fonctions** que ces organes exercent dans la société.

SECTION VII
MANIPULATION DES COURS DES TITRES

■ § 1 – Éléments constitutifs de l'infraction

Aux termes de l'article 1500- 4 [anc. art. 165] L.S.C., sont punissables « *ceux qui par des moyens frauduleux quelconques auront opéré ou tenté d'opérer […]* » (ou de tenter d'opérer, la tentative est donc punie comme l'infraction réalisée) « *[…] la hausse ou la baisse du prix des actions ou des obligations ou des autres titres de sociétés* ». La manipulation n'est punie que si des moyens frauduleux ont été utilisés. Sont visés notamment les moyens suivants : « *la diffusion de fausses rumeurs, de faux bruits, la publication d'articles mensongers et même des actes qui ne constituent pas en soi des manœuvres illicites tels que la formation d'un syndicat d'émission, mais qui le deviennent en ce qu'ils peuvent, en certains cas, avoir été formés pour provoquer une hausse ou une baisse factice par des achats, ventes, reports dépourvus de caractère réel* »(3). Il n'est pas requis que les titres soient cotés en bourse(4).

■ § 2 – Sanctions de l'infraction

Les sanctions consistent en une peine d'emprisonnement d'**un mois à deux ans** et/ ou une amende de 5000 à 125 000 euros.

Les applications pratiques de cette disposition sont inexistantes.

---

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 410, ID 11308.

2 – TA Lux. du 18 octobre 1984, n° 1581/84, ID 10487.

3 – F. Passelecq et J.-F. Cambier, « Traité des sociétés commerciales », *Les Novelles, corpus juris Belgici. Droit commercial 3*, Bruxelles, Larcier, 1934, n°s 5378 et 5379.

4 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 98.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION VIII
LE FAUX BILAN

Art. 1500-8 [anc. art.169] L.S.C.

« Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5000 euros à 250 000 euros, les personnes qui ont commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts :

1° soit par fausses signatures ;

2° soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;

3° soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leurs insertions après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes ;

4° soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater ».

Par analogie avec la solution retenue par le Code pénal, celui qui fait usage de ces actes sera puni comme s'il était l'auteur du faux (art. 1500-9 [anc. art. 170] L.S.C.).

Art. 1500-10 (anc. art. 171) L.S.C.

« Le bilan existe, au point de vue de l'application des articles précédents, dès qu'il est soumis à l'inspection des actionnaires ou des sociétaires ».

Les sanctions prévues par les dispositions précédentes sont applicables dès la soumission du bilan aux associés. *« À ce moment, en effet il forme un acte complet […] Les constatations deviennent publiques, les actionnaires les font connaître partout et la presse les enregistre. Le mal que le faux peut produire est consommé »*[1]. Il y aura donc application des sanctions même si le bilan falsifié était retiré par ses auteurs au moment de l'assemblée générale ou encore si cette dernière le rejetait ou le rectifiait[2].

La *ratio legis* de cette disposition est identique à celle des articles 196 et suivants du Code pénal : il s'agit de la **protection de la confiance du public** dans certains documents écrits[3].

La loi belge de 1873 imposait aux sociétés par actions et aux sociétés coopératives d'établir annuellement un bilan, mais sans assortir cette obligation de sanctions pénales lorsqu'il s'avérait que ce bilan n'était pas correctement établi. Les sanctions étaient donc recherchées dans le droit commun et, plus particulièrement, dans l'infraction du **faux en écriture**. La Cour de cassation belge devait toutefois s'opposer à étendre cette notion à un document qui, comme le bilan, ne constitue qu'un compte rendu par des mandataires à leurs mandants.

La doctrine et la jurisprudence semblaient divisées quant à la possibilité de **sanctionner** pénalement le **faux** dans les bilans. Le bilan n'apparaissait en effet que

1 – Commentaire législatif de la loi de 1881, I, n° 22.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 437, ID 11308.

3 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 113.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

comme une proposition des administrateurs et, même après approbation, ce compte entaché de faux ne pouvait être criminel, parce que cette approbation était distincte du projet et que les deux actes émanaient d'auteurs différents. De plus, on considérait que « *le bilan n'a pas pour objet de recevoir les clauses, déclarations ou faits qu'il mentionne, et, dès lors, l'altération de ces indications ne peut constituer un faux* »[1]. C'est sur la base de cet arrière-fond que le législateur a introduit cette infraction spécifique du **faux bilan**.

« *La doctrine et la jurisprudence ont déterminé laborieusement ce qui constitue un faux. Trois éléments sont nécessaires : l'altération de vérité, la fraude ou la méchanceté, et la possibilité d'un préjudice.*

En quoi consiste la possibilité de préjudice ? En ce que l'altération de vérité doit porter sur un document consistant un titre qui, s'il était vrai, serait un acte probant, établissant un droit.

C'est ainsi qu'il a été jugé que si on énonce faussement dans un acte de naissance que les père et mère de l'enfant sont époux, il n'y a pas faux, parce que l'acte de naissance ne fait pas foi du mariage ; il n'est pas un titre à ce point. De même le faux compte qu'un mandataire présente ne constitue pas un faux, parce qu'il ne prouve rien contre le mandant. Ce fait peut, suivant les cas, être une tentative d'escroquerie, mais la matière du faux manque, et même, si le mandant l'approuve et paye, l'escroquerie pourra être consommée, mais ni le compte qui n'est pas un titre, ni l'approbation qui est vraie, ne constituent le faux.

C'est cette doctrine évidente que la Cour de cassation a appliquée. Elle a décidé que le bilan n'est pas un titre. Les administrateurs ne font que le présenter à l'assemblée ; il ne fait pas foi ; l'assemblée peut l'examiner, le modifier, le rejeter ; si les administrateurs tirent un profit de ces fausses énonciations, il peut constituer une manœuvre frauduleuse ; mais cette approbation, annulable à cause du dol employé, n'en sera pas pour cela un faux, puisqu'elle n'en est pas moins réellement donnée »[2].

Depuis lors, la jurisprudence sur le faux en écriture a évolué de façon importante : l'application de l'article 196 du Code pénal « *[…] ne présuppose pas nécessairement un écrit destiné à faire preuve complète et absolue* erga omnes*, il faut toutefois que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure de faire preuve des faits y énoncés pour ou contre un tiers […]* »[3]. En fait, depuis lors, la doctrine et la jurisprudence ont évolué dans le sens que, de nos jours, elles admettent qu'il n'est plus requis que l'écrit objet de la falsification soit considéré comme un titre. Il suffit désormais « *qu'il fasse preuve de quelque manière que ce soit, des faits qu'il constate* »[4].

L'élément moral du crime de faux bilan correspond au **dol spécial,** à savoir l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire. La question s'est posée de savoir si l'intention de sauver l'entreprise en surévaluant des actifs et en maintenant ainsi le crédit de l'entreprise répondait à cette condition du dol spécial. La jurisprudence répond affirmativement à cette question sur la base de la considération que ce souci

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 25.

2 – E. Pirmez, *Observations présentées sur l'avant-projet de loi sur les sociétés commerciales* [rédigé par A. Nyssens], p. 31, ID 11305.

3 – Cour du 20 mai 1950, *P.*, n° 15, p. 13, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA Bruxelles du 8 décembre 1967, *Pas.*, 1968, II, p. 117, cité par H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 84.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de défendre les intérêts de l'entreprise néglige les intérêts des créanciers actuels et futurs, voire ceux des associés qui sont ainsi induits en erreurs et empêchés de prendre en temps opportun et en connaissance de cause les décisions qui s'imposent à cet égard[1].

Est applicable aux **faux commis dans les bilans** des sociétés réprimés par l'article 1500-8 de la L.S.C. concernant les sociétés commerciales la règle générale en la matière selon laquelle l'infraction est constituée non seulement quand l'altération cause un préjudice actuel, mais encore quand elle est simplement susceptible d'en produire un[2].

SECTION IX
ABUS DE BIENS SOCIAUX

C'est par la loi du 21 juillet 1992 qu'a été introduite en droit luxembourgeois l'infraction de l'abus de biens sociaux, et cette loi a été fortement influencée par la loi française.

Art. 1500-11 [anc. art. 171-1] L.S.C.

« Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi :

1° auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

2° auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ».

§ 1 – Éléments constitutifs de l'infraction

Les éléments constitutifs de cette infraction sont donc :
– les dirigeants de droit ou de fait de sociétés, qui ;
– de mauvaise foi ;
– font un usage des biens et du crédit de la société ;
– qu'ils savent contraire à l'intérêt de celles-ci, et ceci ;
– à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

« *Par usage, il y a lieu d'entendre non seulement l'appropriation ou la dissipation d'un bien, mais encore la simple utilisation ou administration de ce bien […] Cet usage est abusif lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte atteinte à son patrimoine social ou s'il expose la société, sans*

1 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 115.

2 – CA du 19 avril 1988, n° 133/88, ID 12049.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves. À cet égard, il y a lieu de relever que l'affectation de fonds issus d'un marché de la société à un compte privé constitue une appropriation de biens portant atteinte au patrimoine social. En outre, la loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l'intérêt de la société de ses agissements et qu'il exprime ainsi la volonté d'enfreindre la loi. Enfin, il faut que le dirigeant agisse à des fins personnelles ou dans l'intérêt d'une société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement »[(1)].

La jurisprudence rappelle constamment que la preuve des éléments constitutifs de l'infraction est à charge de l'accusation, avec la conséquence que l'accusation est souvent rejetée pour être non fondée[(2)].

■ § 2 – Sanctions de l'infraction

Les peines sont celles de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5000 à 250 000 euros ou d'une des peines seulement.

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que « *l'assentiment des associés ne saurait faire disparaître le caractère délictueux de prélèvements abusifs des biens sociaux, la loi protégeant le patrimoine de la société et les intérêts des tiers au même titre que l'intérêt des associés (Cass. crim., 5 novembre 1963, D., 1964, II, p. 52 ; Cass. crim., 8 mars 1967, D., 1967, II, p. 586 […]). En effet, il convient de faire la distinction entre l'intérêt des différents associés et celui de la personne morale, distinction souvent négligée dans les petites sociétés où existe un accord unanime des voix. Un quitus donné après l'opération, pas plus qu'une autorisation donnée avant, n'empêchera le délit d'être réalisé. Sinon les majorités dans les sociétés par actions pourraient faire exactement ce qu'elles voudraient (note A. Dalsace, sous Cass. 8 mars 1967 précité)* »[(3)].

SECTION X
PREUVE DES IMPUTATIONS DÉSHONORANTES

Art. 1500-14 [anc. art. 173] L.S.C. :

« ***La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leur gestion ou à la surveillance contre les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés en commandite ou par actions, des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, sera admise, soit à l'égard de ces personnes, soit à l'égard de la société, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies, conformément à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias*** ».

En premier lieu, il y a lieu de noter le champ d'application très spécifique de cette disposition qui s'applique uniquement à trois types de sociétés dont la S.à r.l. ne fait pas partie. Selon l'article 447 du Code pénal, l'auteur **d'imputations déshonorantes**

1 – TA Lux. du 22 avril 1999, M.-S.-D.F., P. 31, p. 81, cette decision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA. Corr. du 3 juin 2003, n° 26.824, BIJ 7/2004, p. 129.

3 – TA Lux. du 24 mars 2005, ID 12019.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

à l'adresse d'autrui et qui est poursuivi de ce chef en répression du délit de diffamation ou de calomnie n'est admis pour se défendre à produire la preuve des faits par lui avancés que si lesdites imputations visent, pour faits de leurs fonctions, soit des fonctionnaires publics soit des corps constitués. Contre des particuliers, les allégations ne se rapportant qu'à des faits de la vie privée, aucune autre preuve n'est admise en termes de défense que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique. Les dirigeants de sociétés n'étant pas fonctionnaires publics, cette disposition du Code pénal leur aurait aisément procuré une véritable garantie d'impunité en les protégeant contre la divulgation de leurs manœuvres frauduleuses[1]. Il s'agit en l'occurrence d'un renforcement des droits de la surveillance privée.

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 441, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE III
COMPTES ANNUELS DES SOCIÉTÉS

Dans le présent chapitre sont données un certain nombre d'informations concernant le contenu des comptes annuels d'une société et la façon de les présenter.

SECTION I
LES PRINCIPES D'UNE COMPTABILITÉ RÉGULIÈRE

Les principes d'une comptabilité régulière (en allemand, « *Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung* » GoB) font partie des notions indéterminées et à l'égard desquelles aucune définition légale n'existe. Il s'agit un peu du pendant en matière comptable de la notion de **principes généraux du droit**. Il est vrai que la Loi de 2002 a introduit quelques dispositions nouvelles ayant pour objet de concrétiser le contenu de la notion de **comptabilité régulière** et de moderniser les dispositions du titre II des livres de commerce, art. 8 à 21 C.com.

Sont considérés comme tels notamment les principes de l'exhaustivité, de l'interdiction de compensation, de l'évaluation individuelle, de l'application identique des principes d'évaluation, de prudence, d'« imparité », d'évaluation à la date clé, de valeur nominale, etc.

Ci-après, nous allons distinguer entre les principes directeurs, d'une part, et les principes comptables, d'autre part. Les premiers (contrairement aux seconds) ne disent en principe rien sur les évaluations concrètes à effectuer. La distinction manque de rigueur, mais nous y procédons néanmoins pour montrer que les principes directeurs ont un degré d'abstraction plus élevé que les principes comptables.

■ § 1 – Les principes directeurs

Pour les entreprises soumises à la Quatrième directive (entre-temps remplacée par la directive 2013/34/UE), l'agencement des principes comptables peut, depuis 1985, être représenté par une pyramide au sommet de laquelle se trouve le principe de **l'image fidèle** (**et honnête**) et en-dessous de laquelle s'agencent certains principes comptables qui soit se fondent directement sur la directive et sont repris par les diverses dispositions du titre II du Code de commerce « De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises », soit se basent sur des principes dégagés pour partie au Moyen Âge. Parmi ces principes, certains ont une qualité en quelque sorte supérieure annoncés par l'article 26 de la Loi de 2002. Il s'agit des principes de **clarté** et de **régularité** (de conformité aux règles légales) qui, ensemble, avec les principes de l'image fidèle et de la prééminence du fond sur la forme, forment les principes directeurs.

A – Régularité des comptes

Le principe de la conformité avec les règles du chapitre II (« Des comptes annuels ») du titre II de la Loi de 2002, principe qualifié de **régularité,** ne soulève

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

guère de problème dans la mesure où il est entendu que, si la loi prévoit des règles de présentation des comptes et des règles d'évaluation, celles-ci doivent être respectées. Ce principe ne s'oppose pas à l'exercice de certaines options par l'entrepreneur, étant entendu que ce choix est strictement encadré par les dispositions matérielles ainsi que par le **principe de consistance** qui est notamment prévu à l'égard des règles d'évaluation et aux termes desquels les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre.

En France, ce principe est épaulé par une autre notion, celle de la **sincérité**, notion objective et qui, selon le Plan Comptable Général (art. 120-2) consiste à « *traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relatives des événements enregistrés* ». Le caractère objectif de cette notion est affirmé par la COB (française) « *la sincérité résultera de l'évaluation correcte des valeurs comptables, ainsi que d'une appréciation raisonnable des risques et des dépréciations de la part des dirigeants* »[1].

B – Clarté des comptes

La doctrine retient que les comptes annuels présentés de façon claire et complète « *doivent permettre aux tiers d'avoir une opinion satisfaisante de la situation de l'entreprise et des risques potentiels encourus* ». On voit aisément que, au-delà des nuances sémantiques, ce qui est visé, c'est le principe de clarté des comptes annuels.

Lorsque la loi permet diverses solutions alternatives, le principe de clarté doit permettre de décider laquelle de ces solutions il faut retenir : ce sera celle qui donne le plus d'informations, et ceci, dans la forme la plus accessible aux différents groupes de personnes intéressées par les comptes annuels : il s'agit des associés, des fournisseurs, des créanciers, etc.[2].

C – Image fidèle

La notion d'image fidèle témoigne de l'influence anglo-saxonne sur la Quatrième directive (entre-temps remplacée par la directive 2013/34/UE) : il s'agit en effet de la reprise de la notion de « *true and fair view* ». Ce concept est apparu la première fois dans un texte légal anglais en 1844, en exigeant des sociétés par actions anglaises « *a full and fair balance sheet […] (showing) a true statement of the assets and liabilities and a distinct view of the profit or loss (of the period)* »[3]. Le Companies Act de 1848 a affiné comme suit cette notion : « *every balance sheet of a company shall give a true and fair view of the states of affairs of the company at the end of its financial year, and every profit and loss account of a company shall give a true and fair view of the profit or loss of the company for the financial year* ». Le concept n'a toutefois jamais été défini par une norme quelconque[4].

1 – *Mémento pratique Francis Lefebvre. Comptable 2002*, n° 354.

2 – *Répertoire de droit commercial*, 2e éd., Paris, Dalloz, 1974, p. 21.

3 – F. Pasqualini, *Le principe de l'image fidèle en droit comptable*, Paris, Litec, 1992, p. 20.

4 – F. Pasqualini, *Le principe de l'image fidèle en droit comptable*, Paris, Litec, 1992, p. 21.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En Europe continentale, la notion n'a pas toujours été accueillie à bras ouverts. On a surtout regretté le caractère **vague et imprécis** de la notion qui serait une notion **dangereusement subjective**. Il s'agit assurément d'une de ces notions indéterminées dont les différentes branches du droit ne peuvent apparemment pas se passer : le droit civil connaît la notion de bon père de famille ou encore le principe de bonne foi.

Littéralement, on devrait traduire comme suit ces expressions : true, **«** *vrai* **»,** mais aussi **«** *fidèle* **» ;** fair, **«** loyal **».**

La traduction de ces termes par « image fidèle » ne rend probablement pas toutes les nuances de l'expression anglaise correspondante dans la mesure où l'exigence de « *loyauté* » n'en ressort pas. Lors de la reprise des normes comptables internationales IAS/ IFRS, la traduction a changé en y ajoutant l'épithète « *honnête* », ce qui, sans être exactement identique à l'expression de « *loyal* », s'en rapproche dans le sens qu'il s'agit de ne pas déformer intentionnellement les informations fournies.

Plus concrètement, par référence au travaux du comité d'études de l'Institute of Chartered Accountants[1], on a pu définir comme suit ce concept : synonyme d'une « *présentation des comptes établis conformément aux principes comptables acceptés, utilisant des chiffres exacts dans la mesure du possible ou des estimations raisonnables et justifiées, cette présentation devrait être mise en œuvre de façon à offrir, en fonction des limites de la pratique courante, une image pure ne comportant pas de déformations intentionnelles, de manipulations ou d'omissions de faits significatifs* ».

Le concept de l'image fidèle est destiné à porter une appréciation globale sur les comptes annuels, étant entendu que ces comptes ne doivent pas donner une image trompeuse, mais une vue raisonnablement conforme à la réalité du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société. L'image fidèle constitue l'objectif à atteindre dans l'établissement des comptes annuels, et ce principe domine l'ensemble des autres principes comptables[2].

L'image fidèle est un **test final** : dans l'hypothèse où les règles matérielles de la directive (de la loi nationale) ne permettent pas, dans un cas concret, de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, deux conséquences sont susceptibles d'en résulter :

– des **informations complémentaires** doivent être données (article 26, (4), Loi de 2002) ;
– dans des cas exceptionnels, si les dispositions matérielles de la directive (de la loi) sont de nature à ne pas donner une image fidèle de la situation de l'entreprise, il convient de **déroger** à ces **dispositions légales**. S'il est fait fruit de cette possibilité, il y a lieu de mentionner cette dérogation dans l'annexe avec l'indication de l'influence de celle-ci « *sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise* ». Par conséquent, et compte tenu de ces indications chiffrées, un lecteur assidu et attentif des comptes sera toujours à même de reconstituer les comptes annuels établis selon la méthode correspondant à

1 – Comité d'études de l'institut des Chartered Accountants, Doc. n° 6, p. 48, cité par F. Pasqualini, *Le principe de l'image fidèle en droit comptable*, p. 27.

2 – *Lamy sociétés commerciales 1993*, Lamy GF, 1993, n° 1.914.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

une application stricte de la loi simplement en ajoutant ou en retranchant le montant correspondant à l'ajustement résultant de la dérogation par rapport aux règles matérielles de la loi (directive). Il résulte de cette disposition que le principe en question est un principe dominant qui **prime le principe de régularité** (de conformité aux règles du titre II du Code de commerce « De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises » [chapitre II sur les comptes annuels]).

Il faut insister sur le caractère **exceptionnel** de ces dispositions. Ceci signifie qu'il ne serait pas possible de considérer de façon générale que, par exemple, le principe du coût historique ne correspond pas au principe de l'image fidèle, nonobstant le fait qu'il est bien entendu possible de soutenir que ce principe ne parvient pas à donner une image fidèle de la situation de fortune de la société.

Cette conclusion ne se conçoit que par rapport à la situation particulière d'une entreprise[1]. Si le principe des coûts historiques est retenu par la loi, il est évident que le législateur entend que ce principe, de façon générale du moins, satisfait à l'exigence de l'image fidèle. Des dérogations dans des cas individuels, si elles paraissent ne pas être exclues de façon catégorique, doivent au moins être fort bien justifiées, ce qui voudrait dire en particulier qu'il y obligation de justifier la particularité du cas visé, c.-à-d. donc en quoi ce cas se distingue de tous les autres au point qu'il nécessite la dérogation aux règles comptables applicables de façon générale. En décider autrement, en permettant donc à l'interprète d'écarter l'une ou l'autre disposition légale sans justification particulière, ouvre la porte à **l'arbitraire** et à **l'insécurité juridique** la plus totale.

Pour être susceptibles de refléter une image fidèle de la situation de l'entreprise, il faut que les comptes sociaux contiennent des informations significatives. Il faut éviter que le lecteur des comptes annuels ne soit étouffé par une foule de détails anodins. Si tel est le cas, il est obligé de trier l'important de ce qui ne l'est pas, exercice pour lequel les personnes extérieures à l'entreprise, contrairement aux dirigeants de celle-ci, sont mal placées. Il y a donc lieu de se concentrer sur l'information pertinente, dont la production (ou l'omission de la produire) est susceptible d'avoir une **influence sur le jugement** porté par l'utilisateur ; ceci vaut d'autant plus que, au vœu de l'article 26 Loi de 2002 les comptes annuels doivent être établis avec clarté (ce principe de clarté n'est pas retenu par la loi française).

De cette obligation, on déduit le principe d'importance relative[2] (ou significative). Selon la norme IAS 1 : « *tout élément significatif doit faire l'objet d'une présentation séparée dans les états financiers (§ 29). Une information est significative si le fait de ne pas l'indiquer pourrait avoir une incidence sur les décisions économiques prises par les utilisateurs sur base des états financiers (§ 31)* ». Il est du propre de cette notion que ce qui est significatif pour une entreprise (p. ex., une petite entreprise) ne l'est pas pour une autre (p. ex., une grande entreprise). Cette constatation conduit à fixer des **seuils de signification** pour les différentes entreprises, seuils qui sont chiffrés en fonction des grandeurs pertinentes (les résultats, p. ex.)[3] de ces entreprises.

1 – F. Pasqualini, *Le principe de l'image fidèle en droit comptable*, Paris, Litec, 1992, p. 303.

2 – Également introduit dans le Plan comptable général 1999 (art. 120-2).

3 – F. Pasqualini, *Le principe de l'image fidèle en droit comptable*, Paris, Litec, 1992, pp. 52 ss.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

D – Prééminence de la réalité sur l'apparence, du fond sur la forme (« *substance over form* »)

Ce principe n'est pas formellement mentionné par la directive. La traduction sous le terme « *prééminence de la réalité sur l'apparence* » est fort critiquable, car de nature à induire en erreur sur sa véritable portée. En effet, sous ces termes-là, il est suggéré une hiérarchie entre, d'une part, la réalité économique et financière et, d'autre part, l'apparence juridique.

L'apparence juridique (au sens de l'article 1321 C.c. sur la notion de simulation) est une notion protectrice des intérêts des **tiers de bonne foi** : ces tiers bénéficient ainsi de l'option de se prévaloir soit de l'apparence soit, si cela leur est plus favorable, de la réalité qui leur a été cachée, souvent pour des raisons frauduleuses. Lorsqu'il s'agit de s'interroger sur le traitement comptable des opérations de *leasing* ou encore des opérations fiduciaires, il ne s'agit pas de protéger des tiers, mais de donner la meilleure information possible compte tenu des caractéristiques juridiques, économiques et financières de l'opération.

Supposons qu'en raison des caractéristiques intrinsèques d'une opération de *leasing*, il soit décidé de comptabiliser le bien en tant qu'actif du preneur de *leasing*, ce ne sera pas en raison du principe d'apparence que le traitement juridique de l'opération sera écarté au profit de sa substance économique, mais afin de faire bénéficier les tiers d'une meilleure information comptable sur les opérations réalisées.

Le principe de la prééminence du fond sur la forme est prévu par la norme IAS-1 (§ 9-b), où il est exprimé de façon beaucoup plus nuancée dans les termes suivants : « *transactions and other events should be accounted for and presented in accordance with their substance and financial reality and not merely with their legal form* ». Plutôt que d'établir une hiérarchie entre l'apparence et la forme juridique, « *ce principe institue en réalité une dualité des règles d'analyse des faits économiques et de traduction comptable de ces derniers ; à l'analyse formelle respectant les catégories juridiques préalables, se superpose une analyse substantielle, qui tantôt confirme, tantôt invalide cette première analyse formelle ou supplée les carences de cette dernière* »[1].

Ce qui est certain est que ce principe, entendu non comme instituant une primauté de l'économique sur le juridique, mais comme invitant à analyser les opérations et situations tant sous leur forme que sous leur substance, est promis à un grand avenir. En effet, on assiste à « *une lente modification du droit de propriété, évoluant d'une conception monolithique à une définition protéiforme selon la distribution des attributs du droit de propriété* »[2]. Le bilan est traditionnellement fondé sur une optique de patrimonialité dans la mesure où il reprend les biens et uniquement ceux dont l'entreprise est propriétaire. Cette attitude semble dépassée : lorsque l'entreprise est preneur de *leasing* dans le cadre d'une opération dite de ***leasing* financier**, il paraît pour le moins défendable de porter ce bien à son actif, bien qu'elle n'en soit pas juridiquement propriétaire. En sens inverse, les biens que l'entreprise possède en tant que fiduciaire pour d'autres personnes ne semblent pas devoir être repris à

1 – J.-L. Medus, « De quelques problématiques contemporaines de droit comptable (1re partie) », *Les Petites Affiches*, 4 février 1999, nº 25, p. 18.

2 – J.L. Medus, « De quelques problématiques contemporaines de droit comptable (1re partie) », *Les Petites Affiches*, 4 février 1999, nº 25, p. 15.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

l'actif du fiduciaire, bien que celle-ci en soit formellement propriétaire, mais ce droit est vidé de sa substance par les obligations assumées par elle dans le cadre de ce contrat fiduciaire.

Le critère qui devrait servir pour décider de l'inscription à l'actif semble donc devoir être non pas celui du droit de propriété, mais celui des risques assumés par l'entreprise. « *les rédacteurs des comptes sont invités à prendre en considération la réalité et l'apparence, et non pas la première à la place de la seconde* »[1].

Avec les changements apportés par la Loi de 2002, qui a rendu applicables **à tous les commerçants** les règles sur la tenue des comptes jusqu'alors réservées aux sociétés de capitaux, il n'y a plus lieu de distinguer (à l'occasion de la présentation de ces principes) entre ceux applicables aux sociétés de capitaux et ceux applicables aux autres commerçants.

Depuis le 1er janvier 2005, une harmonisation bienvenue de ces règles a été atteinte. Toutefois, par une certaine ironie, le jour même où cette harmonisation est finalement atteinte à nouveau, vingt ans après la Quatrième directive qui fut à l'origine de cette « *disharmonie* », un autre acte juridique, européen cette fois, entre en vigueur et qui sera à l'origine d'un nouveau clivage quant aux règles comptables, à savoir les normes IAS/IFRS (normes applicables de façon obligatoire qu'aux seuls **comptes consolidés des sociétés de capitaux cotées**).

Ce règlement, par définition, est directement applicable dans tous les États membres. Toutefois, pour permettre à ces règles de s'intégrer de façon harmonieuse dans la loi luxembourgeoise, il est indispensable que le législateur national prenne certaines décisions quant aux comptes annuels non touchés par ce règlement.

Il existe en effet quatre catégories de comptes :

Sociétés cotées	Sociétés non cotées
Comptes individuels	Comptes individuels
Comptes consolidés	Comptes consolidés

Les seuls comptes consolidés des sociétés cotées sont directement (et impérativement) soumis aux normes IAS/IFRS. En l'absence de dispositions prises par le législateur luxembourgeois prévoyant autre chose, la situation est la suivante à l'égard des sociétés cotées : elles doivent établir leurs comptes consolidés sur la base des normes IAS/IFRS et leurs comptes individuels sur la base des règles luxembourgeoises traditionnelles fondées sur la Quatrième directive (ce qu'on appelle encore souvent Lux GAAP en pratique).

Cette solution de la « double comptabilité » est évidemment source de frais supplémentaires. Il serait donc utile que le législateur national prenne des décisions quant à savoir si les comptes individuels de ces sociétés peuvent être établis sur la base des normes IAS/ IFRS ou non. Ceci serait évidemment la solution idéale pour les groupes consolidés, dans la mesure où cela leur éviterait de devoir appliquer deux corps de règles différents (et malheureusement, sur un certain nombre de points, contradictoires). Il est vrai que, malgré les apparences, ceci ne résoudrait pas vraiment le problème du point de vue fiscal (sauf pour les groupes composés de sociétés défiscalisées). Pour les autres, le problème est simplement déplacé d'un

1 – F. Pasqualini, *Le principe de l'image fidèle en droit comptable*, p. 44.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

cran. En effet, actuellement, on applique au Luxembourg le « principe de l'accrochement du bilan fiscal par rapport au bilan commercial ». Ceci signifie que le bilan commercial (dûment approuvé et publié) sera la base de l'établissement des déclarations fiscales.

■ § 2 – Les principes comptables

Ces principes sont d'origines fort diverses. Certains ont entre-temps (depuis la transposition en droit national de la Quatrième directive (entre-temps remplacée par la directive 2013/34/UE) pour la plupart), acquis rang légal. En tant que tels, ces principes légaux sont incontestables : toutefois, ceux-ci ne sont applicables sans contestation possible qu'aux seules entreprises soumises à la Quatrième directive, c.-à-d. donc les sociétés de capitaux. Au-delà de ces principes légaux (A), il y en a d'autres qui ne sont pas prévus directement par les dispositions de la loi, parfois sans avoir été expressément désignés comme principes comptables proprement dits. Il est possible de conclure à l'existence de tels principes par référence à certaines mesures spécifiques prévues dans la loi. Dans d'autres cas, il faut remonter à des pratiques immémoriales (B).

A – Principe du « *going concern* »

Ce principe signifie que l'entreprise est présumée continuer ses activités (art. 51 Loi de 2002) et s'oppose donc à une optique de liquidation de l'entreprise.

Selon la norme française CNCC n° 2-435, une entité est « *présumée poursuivre ses activités dans un avenir prévisible sans avoir ni l'intention ni la nécessité de cesser son exploitation, de procéder à sa liquidation ou de déposer son bilan*[1] ». Selon IAS n° 1 : « *L'entreprise est normalement considérée comme étant en activité, c.-à-d. comme devant continuer à fonctionner dans un avenir prévisible. Il est admis que l'entreprise n'a ni l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités* »[2].

Il est évident qu'un certain bien peut avoir une valeur fort différente selon qu'on l'envisage dans une optique de liquidation ou dans une optique de continuation de l'exploitation. Prenons le cas d'une raffinerie pétrolière où les différentes parties de l'usine sont reliées par des installations de tuyauterie importantes. Ces installations ont une valeur certaine dans la mesure où, sans elles, l'usine ne pourrait pas tourner : tout acquéreur de l'usine devrait en faire installer de nouvelles si celles-ci n'y figuraient plus.

Dans une optique de liquidation, la valeur en est probablement négative : il s'agit de la valeur de ferraille (à la casse), compte tenu des frais de main-d'œuvre importants nécessaires pour enlever les installations en question. Par conséquent, dans une optique de « *going concern* », la valeur de ces installations correspond en réalité à leur coût de remplacement (compte tenu de leur vétusté). Du côté des passifs de l'entreprise, on peut noter la même divergence existant entre optique de continuation et optique de liquidation. Si l'entreprise est évaluée dans une optique de liquidation, il y a lieu de prendre en compte d'importantes provisions pour charges destinées

1 – *Mémento pratique Francis Lefebvre. Comptable 2002*, n° 261.

2 – *Lamy sociétés commerciales 1993*, Lamy GF, 1993, n° 1891.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

à couvrir notamment le passif social de l'entreprise, sous forme d'indemnités de licenciement, de couverture du coût du plan social, d'indemnités pour résiliation unilatérale de différents contrats en cours (contrat de bail, p. ex.), etc.

En revanche, pour d'autres catégories d'actifs et de passifs (surtout les comptes financiers), il se peut qu'il n'existe aucune différence entre les deux évaluations : une somme d'argent placée en compte bancaire a la même valeur dans une optique de continuité d'exploitation que dans une optique de liquidation.

B – Principe de la comptabilité d'engagement

Ce principe est en fait consacré par l'article 51 (1) d) de la Loi de 2002 qui exige la prise en compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel les comptes se rapportent sans prise en considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits. La méthode de comptabilisation ainsi retenue obligatoirement s'oppose donc à la méthode de comptabilisation des recettes dépenses (« *cash accounting* »).

La comptabilité des flux de fonds, malgré son caractère simpliste et susceptible de donner lieu à des manipulations de toutes sortes, peut revendiquer l'avantage de la certitude. Il est en effet facile de constater à quel moment les recettes encaissées et les dépenses sont décaissées. Cette méthode étant à abandonner au profit de celle qui comptabilise les charges et les produits, il y a lieu de définir avec précision à partir de quel moment il convient de tenir compte respectivement des charges et des produits. Lorsqu'une vente (p. ex.) est effectuée, le vendeur réalise un produit, et l'acheteur est grevé d'une charge. La vente est parfaite dès qu'il y accord sur la chose et le prix (art. 1583 C.c). Il n'en reste pas moins que le débiteur n'est tenu de payer (et donc la dette n'est certaine[1]) qu'à partir du moment où la livraison du bien est faite (à partir de la délivrance, art. 1604 C.c.) ou que la prestation de service est effectuée. C'est bien entendu à ce moment également que le vendeur réalise son produit et qu'il enregistre son résultat sur cette opération (et que l'acheteur enregistre son obligation comme charge certaine). De ces règles, il résulte que les entreprises encourent des engagements notamment sous la forme de commandes d'immobilisations ou encore de l'octroi de garanties (de cautionnements) au profit d'autres entreprises, voire de particuliers. Ces engagements, malgré le fait qu'ils puissent, le cas échéant, être d'une envergure suffisante pour influencer de façon significative la situation financière de l'entreprise, ne sont pas repris au bilan (sauf si l'entreprise risque de devoir payer sans avoir un recours équivalent). Afin de remédier à cette situation, ces engagements encourus sont à reprendre dans l'annexe.

C – Principe de rattachement des charges aux produits

Ce principe n'est pas prévu tel quel par le titre II de la Loi de 2002 « De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises ». Il peut être dégagé de manière déductive de plusieurs dispositions spécifiques de la loi ou encore des pratiques comptables du « bon père de famille », dont le caractère incontestable est au-delà de tout doute sérieux. Il nous paraît qu'il puisse être déduit directement

1 – *Mémento pratique Francis Lefebvre. Comptable 2002*, p. 236.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de l'article 51, 1, d) Loi de 2002 qui enjoint de « *[…] tenir compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel les comptes se rapportent […]* ». Il est encore prévu par la norme IAS 1 (§ 26). En vertu de ce principe, les frais sont rattachés à un **exercice donné** ou aux exercices ultérieurs selon que les produits correspondants sont reconnus dans l'exercice ou non[1].

On peut retenir les exemples suivants :

– l'inscription à l'actif des stocks de produits finis tant qu'ils ne sont pas vendus ;
– l'inscription des frais de mise en place de l'entreprise en tant que frais d'établissement ;
– l'inscription à l'actif des frais de recherche et de développement (du moins pour ceux qui ont des perspectives sérieuses de réussite commerciale).

Il faut reconnaître que les deux derniers exemples explicités ci-dessus, qui font référence à des options accordées par la directive de porter ces frais à l'actif (ce qui signifie que ces frais peuvent également être passés en charge au moment où ils sont encourus) et donc sans attendre les produits correspondants, montrent que ce principe a un certain caractère facultatif[2].

D – Principe de permanence des méthodes

Il est énoncé par l'article 51 (1), b), Loi de 2002 en termes très lapidaires : « *les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiées d'un exercice à l'autre* ». Cette disposition ne peut pas être lue comme signifiant que, dans aucun cas, une entreprise ne pourrait modifier ces méthodes d'évaluation : en effet, selon le paragraphe (2) de cet article « *des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l'annexe et être dûment motivées avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats* ».

Ce paragraphe accorde donc l'autorisation de déroger par rapport aux méthodes d'évaluation utilisées par le passé, même s'il prévoit des conditions fort restrictives : caractère exceptionnel, motivation à fournir dans l'annexe avec indication de l'incidence sur la situation patrimoniale, financière et les résultats. Ce principe conduit notamment à l'inscription à l'actif des frais d'établissement (empêchant ainsi de grever un exercice de charges se rapportant à un certain nombre d'exercices), l'inscription en stocks de produits non vendus, l'inscription en immobilisation de dépenses de Recherche et de Développement.

E – Principe de prudence

De façon générale, le principe de prudence peut être défini comme « *l'appréciation raisonnable des faits afin d'éviter le risque de transfert sur l'avenir d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et les résultats de l'entreprise* »[3]. Faisant partie des principes traditionnels les plus incontestés, il est mentionné par

1 – *Mémento pratique Francis Lefebvre. Comptable 2002*, p. 54.
2 – *Mémento pratique Francis Lefebvre. Comptable 2002*, p. 54.
3 – *Lamy sociétés commerciales 1993*, Lamy GF, 1993, n° 1893.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

l'article 51, c), Loi de 2002 qui spécifie qu'il doit « *en tout cas être observé* ». En tant qu'applications de ce principe, cet alinéa mentionne :

– le principe de réalisation (seuls les bénéfices réalisés sont pris en compte) ;
– qu'il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles ayant pris naissance au cours de l'exercice (même s'ils ne sont connus qu'après la date de clôture) ;
– qu'il doit être tenu compte des dépréciations (dans tous les cas).

1) Le principe de prudence sous la Quatrième directive

Si ce principe est affirmé avec force par la directive (et la loi luxembourgeoise prise en application de celle-ci), il est néanmoins vrai que la directive ne reprend pas la conception traditionnelle de prudence telle que pratiquée par certains États européens (notamment par la Suisse qui traditionnellement retenait une approche extrême, revenant à encourager délibérément la formation de **réserves cachées**).

Dans cette discussion sur l'attitude à adopter à l'égard des réserves occultes, il convient de ne pas perdre de vue que les **objectifs** de la comptabilité **varient** selon les catégories de personnes auxquelles celle-ci s'adresse. Le droit commercial est certes préoccupé du sort des créanciers. Mais il s'intéresse aussi à la situation des associés, des salariés, des pouvoirs publics, etc.

Dans l'optique de protection des créanciers, la principale préoccupation est de déterminer le revenu qui peut être distribué sans danger. Dans cette dernière optique, les règles de la comptabilité commerciale sont destinées avant tout à éviter les surévaluations de résultat ; toute sous-évaluation, pour ne pas être recherchée, est en tout cas considérée comme moins problématique ; le commerçant peut donc sous-évaluer ses actifs et surévaluer ses passifs au-delà des montants qui auraient été retenus même par des commerçants prudents[1].

Il est vrai que cette approche traditionnelle a été infléchie par la Quatrième directive (entre-temps remplacée par la directive 2013/34/UE) en matière de droit des sociétés dans le sens que celle-ci, suivant en cela l'approche anglo-saxonne, cherche en principe à éviter non seulement les surestimations du résultat, mais encore les sous-estimations. La conséquence a été que les règles d'évaluation prévoient non pas simplement des maxima d'évaluation à ne pas dépasser, mais des évaluations à des montants déterminés ; dans le même sens, ces dispositions visent à éviter que des provisions, une fois établies, soient maintenues après avoir perdu leur raison d'être. Dans l'intérêt de la vérité des bilans, l'extourne de ces provisions est obligatoire.

Si les entreprises peuvent constituer des réserves cachées importantes, une telle possibilité peut à première vue paraître conforme aux intérêts des créanciers. À supposer que tel soit effectivement le cas, il convient encore de noter que les comptes annuels ne sont pas établis uniquement au profit des créanciers, mais s'adressent à d'autres groupes de personnes ayant des liens de nature tout à fait différente avec l'entreprise : il s'agit notamment des associés, des salariés, des pouvoirs publics, des clients, etc.

1 – B. Knobbe-Keuk, *Bilanz-und Unternehmenssteuerrecht*, p. 18.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans l'évaluation des intérêts de ces différents groupes de personnes, le législateur ne s'est jamais prononcé en faveur d'une catégorie au détriment d'une autre. Les comptes annuels doivent satisfaire aux intérêts de tous ces groupes, ce qui est impossible, puisque les intérêts de ceux-ci sont en fait opposés. Il faut donc retenir celle des approches qui concilie le mieux les intérêts divergents en présence. On peut considérer qu'il est admis qu'il s'agit de la conception qui permet de dégager le **résultat qui peut sans dommage être distribué** par l'entreprise.

Par ailleurs, si l'on ne se réfère qu'aux seuls créanciers, il n'est pas sûr que la formation de réserves occultes soit nécessairement dans l'intérêt de ceux-ci : de telles réserves sont régulièrement constituées pendant les années prospères, pendant lesquelles les résultats montrés sont donc sous-estimés. Au moment où la tendance s'inverse, l'entreprise va donc montrer des résultats surestimés (le cas échéant, des résultats record) et ceci en puisant dans les réserves occultes accumulées auparavant (notamment en extournant les provisions excessives formées antérieurement). Il arrive que, sur la base de tels résultats à première vue favorables, des créanciers (notamment des fournisseurs ou des banquiers) décident de faire crédit à l'entreprise apparemment prospère, mais qui en réalité connaît déjà des difficultés sérieuses (sans que ceci n'apparaisse dans les comptes annuels).

Sur la base de ces considérations, les règles d'évaluation de la Quatrième directive visent à restreindre la constitution de réserves occultes[1], même si, comme souvent sur un plan européen, ces intentions sont diluées par des compromis indispensables pour obtenir les accords politiques nécessaires.

2) Prise en compte des risques prévisibles et des pertes éventuelles

La prise en compte des risques prévisibles et des pertes éventuelles a trait, d'une part, à la constitution de provisions (pour des pertes futures prévisibles) et, d'autre part, à des corrections de valeurs relatives à des pertes d'ores et déjà constatées, même si elles ne sont pas encore réalisées.

L'article 44 (1) Loi de 2002 se réfère aux **provisions pour risques et charges** qui ont pour objet de couvrir les pertes ou dettes qui sont ou « *probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance* » (cette définition rejoint celle de la norme IAS 37 qui définit la provision comme une obligation résultant d'un événement passé dont le paiement est probable et dont le montant peut être évalué de façon fiable).

Les provisions pour risques et charges se distinguent des dettes provisionnées par le fait que, pour les provisions, le caractère de dette n'est pas définitivement et irréversiblement acquis. En d'autres termes, des événements postérieurs pourraient rendre ces provisions inutiles. Si la charge est irréversible, elle constitue une dette provisionnée (des dettes nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'échéance ou le montant est incertain[2].

Exemples
Provisions pour risques : provisions pour garanties données aux clients, pour pertes de change.

1 – Les normes IAS/IFRS ne font que renforcer cette tendance.

2 – *Mémento pratique Francis Lefebvre. Comptable 2002*, n° 2557.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

3) Corrections de valeur

La notion de correction de valeur dépasse le cadre traditionnel des provisions du fait que la notion comprend tant les dépréciations définitives que celles qui ne le sont pas. Cette notion inclut donc les provisions pour dépréciations sans se limiter à celles-ci. Des corrections de valeur sont prévues tant à l'égard des immobilisations (art. 55 (1), c) aa Loi de 2002), qu'à l'égard des éléments de l'actif circulant (art. 61, (1) aa) Loi de 2002). La différence entre ces deux dispositions est que la première ne prévoit qu'une **faculté** (« *peuvent* »), mais limitée aux immobilisations financières, alors que la deuxième ne laisse pas de liberté aux sociétés (« *font l'objet* »). En outre, pour les immobilisations, des corrections de valeur ne sont à faire que si l'on prévoit que la dépréciation est durable.

Quant au **montant de la provision** qui est à constituer, il existe une différence entre les deux dispositions : pour les immobilisations, il s'agit de faire correspondre la valeur comptable à la valeur qui est à leur attribuer à la clôture de l'exercice, tandis que la loi est plus précise en ce qui concerne les **actifs circulants.** Il s'agit de ramener la valeur comptable à la valeur du marché ou, le cas échéant, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la clôture du bilan.

La loi permet d'aller plus loin en anticipant en quelque sorte sur l'avenir, ce qui est tout autant remarquable que dangereux, car susceptible d'ouvrir la porte à des évaluations arbitraires. La base légale de cette approche est donnée par l'article 61 (1), b) à l'égard des actifs circulants : des corrections de valeur « *afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan* ». Par exemple, un détaillant de matériel informatique a en stock des PC qui ont une valeur de 800 euros au 31 décembre 2018 et, compte tenu des nouveaux modèles annoncés pour mi-janvier 2019 par le fabricant, il est certain de ne pouvoir écouler ces stocks qu'à des prix très fortement dépréciés. Il évalue donc ces ordinateurs à 600 euros à la fin 2018.

À notre sens, cette disposition ne devrait pas servir à faire des pronostics sur l'évolution future des cours de change ou des cours de matières premières : l'expérience prouve à suffisance que ceux-ci sont par nature imprévisibles. Par ailleurs, il convient de noter que ces corrections de valeur exceptionnelles ne sont pas acceptables fiscalement.

4) Interdiction de l'évaluation à la valeur d'exploitation supérieure (« *Imparitätsprinzip* »)

Du principe de prudence, on peut directement déduire un autre principe qui est le principe dit de « *l'imparité* ». Il résulte de ce principe que, si la valeur d'exploitation d'un bien est inférieure au prix d'acquisition ou de revient, l'évaluation doit se faire à cette valeur inférieure. En revanche, lorsque la valeur d'exploitation dépasse le prix d'acquisition ou de revient, (c.-à-d. donc qu'on se trouve en présence de réserves occultes), l'évaluation ne pourra pas être effectuée à cette valeur supérieure. Cette **règle dissymétrique** consistant à tenir compte des moins-values non réalisées, alors que les plus-values non réalisées sont ignorées, porte le nom de principe de l'imparité (« *Imparitätsprinzip* »).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

F – Principe du nominalisme

Ce principe[1], encore connu sous le terme de stabilité de l'unité monétaire, consiste à ne pas tenir compte des variations du pouvoir d'achat de la monnaie, unité de compte et de paiement. Encore connue sous la formule concise de « *un franc est un franc* »[2], elle a pour effet que, dans les comptes, une unité monétaire de l'année 1970 et une unité monétaire de 2008 sont à additionner sans tenir compte du fait que, en raison de l'inflation

endémique, ces deux unités n'ont pas la même valeur. On additionne en quelque sorte des pommes et des poires.

1) Contenu du principe

Comme le dit le Code de commerce français (art. 12) : « *À leur date d'entrée dans le patrimoine, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale, et les biens produits à leur coût de production* ». Ce principe est directement à l'origine de réserves bilantaires cachées. Afin de préciser les idées, on peut distinguer les réserves cachées involontaires des réserves cachées volontaires ; les premières ne sont que le fruit des principes comptables fondés sur le coût historique combinés à l'inflation rampante, deux éléments qui font que les actifs réels (autres que les actifs monétaires) sont inévitablement sous-évalués. À l'opposé, se trouvent les **réserves cachées volontaires** constituées par des provisions excessives pour risques, des amortissements trop rapides par rapport à la dépréciation effective du bien.

Une autre règle conduisant au même résultat est celle qui consiste à comptabiliser des amortissements dépassant la dépréciation réelle. Ces diverses pratiques conduisent à des réserves constituées intentionnellement. Parfois il est considéré que de telles pratiques seraient à l'avantage des actionnaires et plus encore des créanciers. Cette problématique est assez complexe. En effet, dans une optique statique, une sous-évaluation est clairement dans l'intérêt des créanciers : le gage des créanciers est de cette façon maximisé (du fait que les bénéfices non reconnus comptablement ne peuvent être distribués en tant que dividendes). Dans cette appréciation, il est toutefois fait abstraction d'un créancier particulier qui est le fisc : la particularité de ce créancier est en effet que le montant de sa créance est moins important, du fait que les réserves occultes sont maximisées. Quant aux actionnaires, il faut distinguer deux cas de figure :

– si l'on fait abstraction des aspects fiscaux, la formation de réserves occultes, dûment cachées par des provisions excessives, par exemple, n'est pas dans l'intérêt des associés actuels, mais dans celui des associés futurs. Il en est ainsi pour deux raisons : les réserves occultes sont soustraites aux actionnaires actuels dans la mesure où elles ne peuvent être distribuées sous forme de dividendes. Les diminutions artificielles des résultats actuels et passés (qui

1 – À moins qu'il s'agisse d'un vœu pieux plutôt que d'un principe.

2 – Tôt ou tard ce dicton deviendra « un euro est un euro », mais le langage populaire n'a pas encore procédé à cette adaptation.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

échappent aux associés actuels) sont contrebalancées par les augmentations artificielles des résultats futurs (qui reviennent donc aux associés futurs) ;
– si l'on tient compte des aspects fiscaux, les conclusions sont les mêmes, sauf que les avantages et inconvénients sont mitigés dans le sens que les inconvénients dont pâtissent les associés actuels sont diminués des économies fiscales, et que les avantages des associés futurs sont diminués des charges fiscales correspondantes.

La constitution de réserves occultes débouche sur un autre problème, celui de la répartition des compétences entre les organes sociaux (du moins dans les sociétés dans lesquelles il n'y a pas d'identité personnelle entre le capital et la gestion). En effet, si le bilan est établi par l'organe de gestion, qui procède aux évaluations bilantaires, l'affectation des résultats est (en règle générale) de la compétence des associés. Il peut donc y avoir une tendance des organes de gestion visant à minimiser les résultats afin de garder un maximum de liquidités à l'intérieur de l'entreprise[1].

2) Dérogations au principe du coût historique

Il va de soi que le principe du coût historique est à l'origine de la formation de réserves cachées (ou occultes) dans le chef de la société. La Quatrième directive (telle que transposée) permet de déroger à ce principe, en prévoyant dans l'article 54 de la Loi de 2002 qu'un règlement peut introduire la possibilité d'autres principes d'évaluation, notamment l'évaluation sur la base de la **valeur de remplacement** des immobilisations corporelles ou encore la réévaluation des immobilisations corporelles et des immobilisations financières. Un tel règlement n'a toutefois pas encore été pris à ce jour, et il y a peu de chances qu'il soit pris dans un avenir prévisible.

Si tout le monde est d'accord sur le point que la **réévaluation des postes de bilan** pourrait améliorer la qualité de l'information financière fournie par un tel bilan, il ne faut pas se cacher non plus les difficultés pratiques d'une telle méthode, et ceci, à une époque où les sociétés (même les plus grandes) ont avant tout tendance à se présenter plus riches qu'elles ne le sont en réalité[2]. Compte tenu des liens ténus existant entre comptabilité et fiscalité, en particulier au Luxembourg, il convient de ne pas perdre de vue non plus que toute possibilité de réévaluation des actifs est susceptible d'avoir des implications fiscales. Dans l'état actuel de la législation fiscale, il n'est pas possible de dépasser le coût historique. La conséquence directe de cette disposition serait qu'il conviendrait d'établir un **bilan fiscal divergent** du bilan commercial. D'où un surcroît de travail pour les entreprises.

En général, il est retenu que la plus-value de réévaluation ne peut être distribuée, car elle ne présenterait pas les caractéristiques pour constituer un bénéfice distribuable[3]. Cette solution traditionnellement retenue par la doctrine a été confirmée par la **directive 2013/43 /UE** qui a remplacé la Quatrième directive (art. 54 de la Loi de 2002) qui interdit toute distribution de la réserve de réévaluation, à moins qu'elle ne corresponde à une plus-value réalisée.

1 – H.J. Martens, *Réserves et provisions apparentes et non apparentes*, p. 207.

2 – Voir les scandales boursiers de ces dernières années, du genre de *Enron*, *Parmalat*, *Worldcom*, etc.

3 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 352.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

La réévaluation des bilans peut être réalisée au moins de deux manières différentes : elle peut se faire par le passage direct par le compte de profits et pertes. La différence de réévaluation sera donc comprise dans le résultat de la société. Alternativement, elle peut être comptabilisée en une réserve de réévaluation au passif du bilan, ce qui empêche l'inclusion de la différence de réévaluation dans le résultat annuel.

La conséquence en est de grossir les amortissements futurs, et ce surplus d'amortissement sera en fait contrebalancé par l'amortissement de la réserve de réévaluation. Le résultat sera donc en fin de compte de n'amortir que les seuls frais d'acquisition. La situation patrimoniale sera plus proche de la réalité, et la situation du résultat ne sera pas affectée. Il convient de ne pas perdre de vue la situation des **impôts latents** : au moins dans le cas où la réévaluation est contrebalancée par une réserve de réévaluation, le résultat ne sera pas affecté en raison de la réévaluation. Mais la plus-value reconnue au bilan est exposée à une imposition ultérieure au titre des impôts sur les résultats, avec la conséquence qu'il conviendra de tenir compte des impôts, et que donc la réserve de réévaluation ne peut être considérée comme représentant un poste de fonds propres : ce poste doit être diminué des impôts futurs restant dus.

Les **impôts latents** sont ceux qui sont dus à une comptabilisation différente dans le bilan commercial et le bilan fiscal. Il s'agit de faire correspondre au résultat du bilan commercial les impôts y afférents sans que ces impôts ne soient effectivement dus. L'objectif est de ne pas montrer un résultat commercial excessif en tenant donc compte d'une charge fiscale qui, bien que non encore due, deviendra due à l'avenir. Les critères sont donc :

– **comptabilisation différente** entre bilan commercial et bilan fiscal ;
– **décalage dans le temps** qui n'est que **temporaire**. Si le décalage est permanent, il n'y a pas lieu de tenir compte d'impôts latents.

Il peut s'agir de charges fiscales latentes ou de recettes fiscales latentes[1].

On peut noter que les distorsions dues au principe des coûts historiques sont d'autant plus importantes que l'inflation est forte. Avec la diminution généralisée des taux d'inflation, la problématique a beaucoup perdu de son acuité.

G – Principe de la spécificité (indépendance) des exercices

Pour un certain nombre de raisons (essentiellement de nature pratique, notamment la nécessité pour les utilisateurs de l'information financière de bénéficier d'informations périodiques et actuelles), la vie des entreprises (qui se déroule en continu et donc sans interruption) est découpée, et ceci, artificiellement en exercices comptables. L'information financière fournie par l'entreprise doit être **actuelle**, faute de quoi elle perd toute utilité pour le destinataire de cette information. Elle doit donc être fournie avec une périodicité dont la fréquence est relativement élevée. Est ainsi soulevée la question de la durée de l'exercice (A) et des possibilités de modifier les dates de début et de fin d'exercice (B).

1 – G. Frey, *Die Behandlung steuerlicher Sachverhalte nach der 4. EG-Richtlinie*, Betriebs-Berater, 1978, p. 1225.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

1) La durée de l'exercice social

Ni la loi sur les sociétés commerciales ni le Code de commerce ne contiennent des dispositions spécifiques sur la durée de l'exercice social. On peut toutefois inférer d'un certain nombre de dispositions que la durée de l'exercice ne devrait pas dépasser douze mois.

Aux termes de l'article 15 du Code de commerce luxembourgeois « *Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l'an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.*

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. » Il en va de même de l'article 461-1 (anc. art. 72) L.S.C. qui oblige l'administration des sociétés anonymes à dresser chaque année un inventaire des actifs et des dettes et à établir le bilan et le compte de profits et pertes.

Il résulte donc de cette exigence qu'un **inventaire** doit être établi, que les opérations correspondant à un inventaire en bonne et due forme doivent être exécutées. Ces opérations d'inventaire sont synthétisées par un bilan. Cette obligation de la tenue d'un inventaire annuel est confirmée par la L.S.C. pour les sociétés de capitaux, notamment donc les sociétés anonymes, pour lesquelles un inventaire contenant (entre autres) l'indication des valeurs mobilières et immobilières doit être établi conformément à l'article 461-1 de cette loi.

On peut encore noter que la fiscalité poursuit la même approche, dans le sens qu'elle est basée sur les principes des finances publiques de **l'annualité du budget** des recettes et dépenses de l'État et de **l'annualité de l'impôt**[1]. C'est par la loi budgétaire annuelle que la chambre des députés autorise le pouvoir exécutif de procéder au prélèvement des impôts d'après les dispositions légales en vigueur[2]. L'alinéa 2 de l'article 1 constitue le reflet du principe de l'annualité de l'impôt ; de plus, il est précisé que l'année d'imposition cadre avec l'année de calendrier.

Le principe de l'annualité répond à des impératifs de technique fiscale, mais il est vrai que, dans une certaine mesure, il constitue une approche artificielle qui n'est pas directement compatible avec le principe de l'égalité devant l'impôt. En effet, de deux contribuables à revenus moyens annuels égaux (sur une période pluriannuelle), celui qui a des revenus variant fortement sera soumis à une charge fiscale plus lourde que celui dont les revenus ne varient pas ou ne varient que peu d'une année sur l'autre.

La loi fiscale indique qu'en principe l'exercice d'exploitation se termine avec l'année civile pour ne continuer que sous les conditions fixées par règlement grand-ducal : « *peuvent clôturer régulièrement à une date annuelle*[3] *autre que le 31 décembre* ». Il résulte donc de ce passage que la durée de l'exercice ne doit pas dépasser douze mois. Le principe que l'exercice d'exploitation ne devrait pas dépasser douze mois est encore précisé expressément pour le cas de changement de la date régulière de

1 – Article 104 de la Constitution : « Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. – Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes ».

2 – Chaque année, la loi budgétaire contient un article 2 intitulé « Prorogation des lois établissant les impôts » et ainsi libellé « Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre [de l'année n] sont recouvrés pendant l'exercice [n + 1] d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles […] ci-après », ID 15306.

3 – Termes soulignés par nous.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

clôture : dans ce cas, « *aucun exercice d'exploitation ne peut contenir plus de douze mois consécutifs* »[1].

2) Modification de la date de l'exercice social

Si ce principe de l'annualité est donc clairement acquis, il n'est pas impératif qu'il y ait correspondance entre l'exercice social et **l'année de calendrier**. En effet, le choix d'une date de clôture différente est possible tant en droit des sociétés (et en droit comptable) qu'en droit financier.

Les statuts des sociétés contiennent la date de clôture de l'exercice. Toute modification de cette date (c.-à-d. en cas de passage d'un exercice social correspondant à l'année de calendrier à un exercice divergent) nécessite une modification des statuts de la société pour retenir la nouvelle date de clôture[2]. Fiscalement, aucune formalité supplémentaire n'est à faire pour les sociétés de capitaux. En revanche, pour les autres entreprises, une autorisation doit être obtenue pour le cas où l'entreprise entend se départir de l'exercice correspondant à l'année civile.

3) Contenu du principe de la spécificité des exercices

Ce principe exprime l'évidence qu'il faut affecter à chaque période le résultat qui lui revient, ni plus ni moins. Ce principe peut se rattacher à celui de **l'image fidèle** se rapportant à la représentation du résultat de la société. Il est vrai que ce principe suscite maintes difficultés, notamment en relation avec la constitution des provisions, avec les comptes de régularisation et même avec les amortissements des immobilisations.

Selon l'article 51 (1), d) Loi de 2002, il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel les comptes se rapportent sans prise en considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges. Une comptabilisation sur la base des flux de recettes et de dépenses est donc écartée. « *On peut définir la spécialisation des exercices comme l'ensemble des règles et des techniques qui permettent d'imputer à un exercice donné les produits et les charges qui lui sont propres afin de dégager le résultat qui y trouve son origine. Il s'agit d'imputer à chaque exercice tout ce qui lui revient et rien d'autre. Cette spécialisation liée à la notion d'exercice est à l'origine de la plupart des difficultés que rencontrent les comptables pour déterminer les résultats […]* »[3].

En clair et très concrètement, ce principe signifie que les produits réalisés du début à la fin de l'exercice doivent être pris en compte dans le résultat ; la même chose est applicable aux charges : celles qui sont encourues pendant l'exercice doivent être prises en considération dans leur intégralité. Sauf disposition légale contraire, il n'est possible ni d'anticiper les charges ni de retarder les produits. Ce principe doit être complété par un autre principe, celui du rattachement des charges aux produits qui permet de dire quelles charges sont spécifiquement à rattacher à un

1 – Art. 17 L.I.R., ID 1.

2 – La même chose est bien entendu vraie en cas de modification dans le sens inverse.

3 – Recommandation n° 7 de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, cité par M. Cozian, *Les grands principes de la fiscalité des entreprises*, p. 97.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

exercice donné. Le principe de l'indépendance des exercices servira alors à déduire celles-ci des produits de cet exercice. Par exemple, par application du principe du rattachement, il y a lieu d'étaler les frais d'établissement sur les cinq années suivant celle pendant laquelle ils ont été encourus. Par conséquent, les frais en question affecteront les résultats de ces cinq années pour 20 % de leur montant, en principe.

Il est vrai qu'on pourrait parfaitement considérer que le principe de **l'indépendance des exercices** inclut celui du rattachement des charges aux produits. La spécialisation des exercices se fait en pratique par le biais des **comptes de régularisation**, qui sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps de manière à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent effectivement, et ceux-là seulement[1].

Ce principe s'oppose encore à tenir compte de ce qu'on appelle en langage anglo-saxon « *post balance sheet events* », soit des événements qui se sont produits après la date de clôture du bilan, mais avant la date d'établissement de celui-ci (et à plus forte raison, avant la soumission de celui-ci aux associés).

4) Cas particulier des événements postérieurs à la clôture de l'exercice

En application de l'article 51 (1), c, bb) de la Loi de 2002 qui explicite une des conséquences du principe de prudence énoncé par l'article 51 (1), c) de la Loi de 2002, il est demandé qu'il soit tenu compte « *de tous les passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces passifs ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi* ». Deux conséquences découlent de cette disposition :

1. il n'y a pas lieu de tenir compte de risques qui ne se sont **produits qu'après la date de clôture** ;

2. il convient de tenir compte des passifs qui se sont produits avant la date de clôture et qui ne sont **connus qu'après**. Il s'agit en somme de ce qu'on appelle en allemand de « *wertaufhellende Tatsachen* », c.-à-d. donc des faits dont la connaissance contribue à mieux évaluer les avoirs de l'entreprise.

H – Principe de non-compensation

Aux termes de l'article 51 (1), e) de la Loi de 2002 : « *les éléments des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément* ». Le Code de commerce français, en son article 123-19, reprend la même disposition tout en y ajoutant : « *Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat* ». On peut considérer que la formulation même abrégée de la loi luxembourgeoise comporte en fait ce principe de non-compensation. Cette interdiction générale de principe n'empêche pas que, dans certains cas, la loi prévoie qu'il y a lieu de reprendre les montants nets, en procédant donc à la compensation de deux grandeurs qui pourraient également être reprises séparément : tel est notamment le cas de l'article 48 de la Loi de 2002 qui ordonne de reprendre le montant net du chiffre d'affaires, c.-à-d. donc déduction faite des réductions sur ventes.

1 – *Mémento pratique Francis Lefebvre. Comptable 2002*, n° 262.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

I – Principe de la continuité des exercices

Ce principe se retrouve à différents endroits, tant en droit comptable qu'en droit fiscal. Il fait référence tantôt à la forme tantôt au fond.

1) La forme

La structure du bilan, quant à la forme retenue, ne peut pas être modifiée d'un exercice à l'autre (selon l'article 28 Loi de 2002). Il est toutefois entendu que des dérogations à ce principe sont possibles, à condition d'être dûment motivées et mentionnées dans l'annexe.

2) Le fond

Au regard du fond, le principe signifie que : « *Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent* »[1]. Cette égalité ne doit pas exister globalement, mais être donnée poste par poste : en d'autres termes, le bilan d'ouverture de l'exercice est la copie conforme du bilan de fermeture de l'exercice n-1. Cette correspondance est d'autant plus logique qu'en fait les deux situations se réfèrent au **même moment** : en effet, le bilan de clôture du 31 décembre 2014 reflète la situation de l'entreprise de cette journée à 24 heures, tandis que le bilan d'ouverture de l'exercice suivant représente la même situation à la date du 1er janvier 2015, à zéro heure du matin. Il s'agit en fait du même instant. Ainsi, une divergence quant aux éléments compris dans cette situation ou à leur évaluation ne serait guère compréhensible. Ce principe est encore désigné par le terme de principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture. En France, ce principe est considéré signifier que les écritures comptables passées dès l'ouverture d'un exercice ne modifient pas les comptes de l'exercice précédent[2].

J – Principe de l'évaluation individuelle

Ce principe, également connu en droit fiscal, est énoncé par l'article 51 (1), e) de la Loi de 2002. Il signifie que les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément : il faut donc procéder à autant d'évaluations qu'il y a de biens ou de catégories distinctes de biens. Il rejoint le principe de l'évaluation séparée.

En même temps, ce principe signifie qu'il y a lieu de maintenir à l'actif et au passif les postes séparés sans procéder à la compensation des postes en question. En France, ce principe interdit la compensation, sauf quand elle est explicitement prévue par les dispositions légales en vigueur. Il en est ainsi des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats. Il peut par ailleurs en principe ne pas y avoir de compensation entre deux éléments comptables concernant un même tiers (TVA en amont et TVA en aval, p. ex.). Exception est faite à cette règle en matière de convention de compte courant.

1 – Art. 51 (1), f, Loi de 2002, ID 1779.

2 – *Mémento pratique Francis Lefebvre. Comptable 2002*, n° 270.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

1) Énoncé du principe

L'évaluation doit se faire distinctement pour chaque bien faisant partie de l'actif net investi au jour de la clôture de l'exercice d'exploitation. Une évaluation en bloc de plusieurs biens est donc, en principe, exclue. Une des conséquences de ce principe est que la constitution d'une provision pour **dépréciation générale de l'entreprise**, par exemple en raison d'un changement considérable de la situation du marché, n'est pas permise. La compensation de plus-values sur certains biens avec des moins-values sur d'autres biens n'est pas possible non plus.

Exemple

Une entreprise a acheté deux types de marchandises A et B au prix de 100 euros chacun. À la date d'évaluation, le bien A vaut 110, alors que le bien B vaut 90. Globalement, la valeur du marché n'a pas changé. Toutefois, en raison du principe de l'imparité (qui exige la prise en compte de pertes non réalisées, mais non des bénéfices non réalisés), l'évaluation de ces biens n'est que de 190.

2) Exception au principe de l'évaluation individuelle

L'évaluation peut être effectuée en bloc s'il s'agit :

– de biens semblables quant à l'espèce et quant à la valeur et

– de biens de moindre importance.

Des biens sont semblables lorsqu'ils ne divergent pas beaucoup quant à la nature et quant à la valeur ; l'évaluation en bloc signifie qu'un prix moyen est mis en compte. Cette faculté d'évaluation en bloc constitue une mesure de simplification destinée à faciliter les travaux d'inventaire.

Exemple

Un commerçant de détail détient en stock les produits suivants :

500 produits A dont le prix de revient moyen varie de 1,80 à 2,20 euros
100 produits B dont le prix de revient moyen varie de 2,90 à 3,10 euros
100 produits C dont le prix de revient moyen varie de 3,90 à 4,10 euros.

Évaluation du stock :

Produits A : 500 x 2,00 =	*1.000 euros*
Produits B : 100 x 3,00 =	*300 euros*
Produits C : 100 x 4,00 =	*400 euros*
	1.700 euros

K – Non-récupération des amortissements obligatoires

L'article 51, (1), c, cc) trouve son pendant dans la loi sur les sociétés commerciales : la comptabilisation des amortissements (l'article visé parle de « dépréciations ») est obligatoire à l'égard des sociétés anonymes (art. 461-1 L.S.C.). L'interdiction de récupérer les amortissements vise seulement les amortissements

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

obligatoires, c.-à-d. l'amortissement normal, non l'amortissement extraordinaire. Cette interdiction constitue une dérogation au principe de continuité des bilans prévu par l'article 18, alinéa 2, L.I.R.

Exemple

L'exploitant A achète en janvier 2018 une camionnette au prix de 20 000 euros, amortissable sur 4 années en principe. Compte tenu de la situation peu profitable de l'exploitation, A omet de comptabiliser des dotations pour amortissements au cours de l'année 2018, de sorte qu'à la fin de cette année, la valeur comptable est toujours de 20 000 euros. Comme il s'agit d'amortissement « sciemment omis », la valeur comptable à des fins fiscales n'est plus que de 15 000 euros au 1er janvier 2019 (alors que dans le bilan clôturé à la fin 2018, la valeur comptable était encore de 20 000 euros). Il y a donc dérogation au principe de continuité des bilans.

La portée de cette disposition est finalement assez réduite, et ceci, pour la raison que la période de récupération des **pertes fiscales** est, depuis 1991, illimitée (pour être limitée à 17 années depuis 2018, ce qui reste un laps de temps extrêmement long). Le fait pour une entreprise de comptabiliser des amortissements n'a pas d'inconvénients (d'un point de vue purement fiscal). Ainsi, les reports de pertes n'étant guère limités dans le temps, il n'y a pas d'inconvénient fiscal à comptabiliser un maximum d'amortissements. Il est vrai que cette comptabilisation des amortissements ne va pas améliorer le résultat commercial de l'entreprise.

Dans ce chapitre sont regroupés un certain nombre de sujets de nature non fiscale et qui ont trait à la présentation des états fiscaux au contrôle des comptes et à la publicité des états financiers des entreprises.

SECTION II
LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENTREPRISES

Les articles 35 et 47 de la Loi de 2002 prévoient des dérogations pour des entreprises qui ne dépassent pas certains seuils déterminés par rapport à trois grandeurs supposées constituer des critères pertinents de l'appréciation de l'importance économique des sociétés, à savoir :

– le total du bilan ;
– le chiffre d'affaires ; et
– le nombre des salariés occupés par l'entreprise.

De l'application de ces dispositions, il résulte une division en trois des sociétés selon leur importance économique en fonction du critère suivant : les sociétés (depuis 2005, il faut dire les entreprises) qui ne dépassent pas les seuils de l'article 35 de la Loi de 2002, celles qui les dépassent, mais sans dépasser les seuils plus élevés de l'article 47 de la Loi de 2002 et, finalement, celles qui dépassent également les seuils de ce dernier article. Bien que la directive ne suive en rien cette pratique, il est commode et habituel de désigner ces trois catégories de sociétés par les termes de « petites » entreprises (celles ne dépassant pas les seuils de l'article 35 de la Loi de 2002), les « *moyennes* » entreprises (celles les dépassant, mais sans dépasser les seuils de l'article 47 de la Loi de 2002) et les « *grandes* » entreprises (celles dépassant les seuils de l'article 47 de la Loi de 2002).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les seuils inférieurs en question sont fixés par l'article 35 de la Loi de 2002 tels qu'ajustés par la directive 2013/43/UE en ce qui concerne les montants exprimés en euros :

Total du bilan	4.400.000 EUR
Chiffre d'affaires	8.800.000 EUR
Nombre des membres du personnel employé (en moyenne) au cours de l'exercice	50

Aux termes de l'article 47 de la Loi de 2002 sont donc considérées comme grandes entreprises celles qui dépassent deux au moins des trois critères suivants :

Total du bilan	20.000.000 EUR
Chiffre d'affaires	40.000.000 EUR
Nombre des membres du personnel employé (en moyenne) au cours de l'exercice	250

Afin d'éviter que des entreprises se situant tout juste au-dessus ou au-dessous de ces seuils ne basculent tous les ans d'une catégorie à l'autre, il est prévu que le dépassement ou le non-dépassement de deux de ces trois seuils ne produise effet que si celui-ci se produit pendant **deux exercices consécutifs**.

SECTION III
LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS DES COMPTES ANNUELS

Aux termes de l'article 26 (1) de la Loi de 2002, « *Les comptes annuels visés à l'article 15 du Code de commerce comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe : ces documents forment un tout […]* ». Nous allons voir successivement ces trois documents. En outre, d'autres documents, tout en ne faisant pas partie des comptes annuels proprement dits, nous occupent néanmoins dans ce contexte : il s'agit du rapport de gestion et de l'attestation de la personne chargée du contrôle des comptes. Le lien avec les comptes annuels est que ces documents doivent être déposés en même temps que les comptes annuels et être publiés ensemble avec ceux-ci.

Il est remarquable que, jusqu'à récemment, aucun **plan comptable** n'ait été imposé au Luxembourg. Cette situation a changé avec la loi du 19 décembre 2002 qui, dans son article 12, avait introduit l'obligation pour les entreprises d'utiliser un plan comptable approprié dans lequel les comptes ouverts par l'entreprise sont définis. Ce plan comptable doit être tenu en permanence au siège de l'entreprise. Il est encore prévu par ce même article que la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé soient déterminées dans un règlement grand-ducal qui définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan comptable normalisé.

C'est le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 qui a déterminé la teneur et la présentation d'un **plan comptable normalisé** (P.C.N.) applicable aux exercices débutant après le 31 décembre 2010.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – Le bilan

Entre associés et dirigeants, le bilan n'est qu'une **reddition de comptes**. Il va sans dire qu'à l'égard des mandants, il est impératif que ce document soit correct. Cette nécessité est encore beaucoup plus grande à l'égard des tiers qui sont appelés à traiter avec la société, si ce n'est qu'ils sont susceptibles d'acheter les actions de la société. « *Envisagé sous cet aspect […] le bilan sort de la notion d'un simple compte d'exécution du contrat entre parties, pour revêtir les caractères d'un véritable document de publicité. Comme tel encore, comme tel surtout, il doit éclairer loyalement et exactement sur la situation de la société les tiers qui veulent y entrer comme ceux qui veulent traiter avec elle* »[1].

Une question d'importance théorique fondamentale est celle de savoir quelle est la conception du bilan qu'il convient de retenir.

A – Différentes conceptions du bilan

Schématiquement, deux conceptions s'opposent ici : selon une optique patrimoniale qui est en somme la conception traditionnelle, surtout axée sur la protection des créanciers, le bilan reflète ce que l'entreprise (la société) possède à un moment donné. L'entreprise est un patrimoine comportant activement les avoirs et passivement les dettes envers des tierces personnes ; dans cette optique, les postes de fonds propres représentent les dettes de la société « *envers elle-même* » ou envers les associés. Cette formule est assez ambiguë, mais elle répond à la conception traditionnelle retenue par les auteurs en ce domaine. De nos jours, le bilan ne correspond plus à une telle **optique patrimoniale** pure : les frais d'établissement, notamment, sont repris à l'actif du bilan, et ceci, tout en ne correspondant pas à des actifs réalisables et capables de garantir les dettes de l'entreprise. De même, le poste « *perte de l'exercice* » n'est pas un actif réalisable.

Ici se profile une évolution d'une portée plus large, à savoir l'évolution du droit de propriété et des sûretés. La validité de la clause de réserve de propriété est reconnue en cas d'ouverture des procédures collectives à l'encontre des entreprises. Pour les créanciers d'une entreprise, la propriété de celle-ci n'est donc pas nécessairement leur gage. « *La faiblesse des droits réels accessoires amène les créanciers à se prémunir contre les dangers d'insolvabilité de leurs débiteurs à l'aide du "plus absolu" des droits réels. Dès lors, parallèlement à la réserve de propriété, d'autres techniques juridiques ne méritant d'ailleurs pas la qualification de sûreté, comme la fiducie ou le crédit-bail, vivent des jours euphoriques* »[2]. Ces tendances conduisent à remettre en cause le caractère patrimonial du bilan. Le droit de propriété est ainsi rattaché au créancier.

À cette conception traditionnelle s'oppose une conception plus financière de l'entreprise : les actifs constituent les emplois des ressources de l'entreprise consistant dans les dettes de l'entreprise ainsi que dans les fonds propres de celle-ci.

1 – Commentaire législatif de la loi de 1881, I, n°s 4 à 7.

2 – F. Pasqualini, *Le principe de l'image fidèle en droit comptable*, p. 320.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

B – L'établissement du bilan : les opérations d'inventaire

Aux termes de l'article 15 du Code de commerce luxembourgeois, « *Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l'an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.*

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. »

Il résulte donc de cette exigence qu'un inventaire doit être établi et que les opérations correspondant à un inventaire en bonne et due forme doivent être exécutées ; celles-ci sont décrites en détail ci-après.

Cette obligation de la tenue d'un inventaire annuel est confirmée par la L.S.C. (telle que modifiée par la suite) pour les entreprises de capitaux, notamment donc les sociétés anonymes, pour lesquelles un inventaire contenant (entre autres) l'indication des valeurs mobilières et immobilières doit être établi conformément à l'article 461-1 (anc. art. 72) L.S.C.

Selon la doctrine, l'établissement de l'inventaire annuel comporte deux séries d'opérations :

« *a) Une opération de recensement : l'établissement du relevé détaillé de tous les éléments mobiliers et immobiliers de l'actif et du passif social, etc.*

b) Une opération d'évaluation : l'indication de la valeur réelle et actuelle que présente chaque article »[1].

On distingue donc l'inventaire extra-comptable, qui a pour objet de faire le recensement des divers éléments du patrimoine de l'entreprise, de l'inventaire comptable comprenant notamment les écritures d'inventaire dont les écritures rectificatives et complémentaires[2].

Une différenciation est faite en pratique selon la nature du système d'inventaire retenu par l'entreprise : elle applique soit un système d'inventaire intermittent soit un système d'inventaire permanent.

Lorsque le système de **l'inventaire intermittent** (ou inventaire périodique) est retenu, les données nécessaires à l'établissement de l'inventaire ne figurent pas encore en comptabilité, et il convient de les obtenir par une constatation matérielle des existants[3], c.-à-d. donc par inventaire physique.

Pour citer la définition du plan comptable français qui a valeur générale et est donc également transposable dans notre contexte : « *L'inventaire comptable permanent est une organisation des comptes qui par l'enregistrement des mouvements d'entrées et de sorties permet de connaître de façon constante en cours d'exercice, les existants chiffrés en quantité et en valeurs* »[4]. Les entrées sont représentées par les reports de stocks provenant de la période antérieure et par les entrées en stock réalisées au cours de la période. La comptabilité permet donc à tout moment de connaître le nombre théorique et la valeur des différents produits que l'entreprise a en stock.

Si le système de l'inventaire permanent fournit en principe toutes les données requises, rendant théoriquement inutiles des constatations matérielles des

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. 5, p. 761, Gand, 1950.

2 – *Rép. dr. com.*, V° Inventaire et comptes annuels, n° 6.

3 – *Rép. dr. com.*, V° Inventaire et comptes annuels, n° 99.

4 – *Rép. dr. com.*, V° Inventaire et comptes annuels, n° 100.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

marchandises en stock, la doctrine considère qu'il n'est pas conforme à la prudence commerciale de se limiter à la tenue d'un tel inventaire permanent : « *Tantôt le montant recherché est déjà inscrit dans les comptes mais la prudence exige qu'il soit contrôlé et éventuellement rectifié de façon que les comptes donnent une image fidèle de la réalité constatée par l'inventaire physique des éléments du patrimoine ; c'est le cas lorsque la comptabilité est tenue selon le système de l'inventaire permanent où par suite d'erreurs ou de coulage, il n'y a pas concordance parfaite entre le stock théorique […] et le relevé établi au moment de l'inventaire physique* »[1].

Ou encore : « *Il est souvent procédé au recensement […] par voie de raisonnement théorique, et non par des constatations effectives : on se borne à prendre les chiffres des livrées d'entrées et sorties, les écritures relatives aux achats et aux ventes : la différence qu'ils constatent est indiquée comme chiffre des existences. Une telle pratique est contraire au vœu de la loi. Elle laisse place à toutes les erreurs. Ce qui doit exister n'existe pas nécessairement : des pertes ou des vols ont pu se produire* »[2]. L'établissement d'un **inventaire physique** au moins sur une base annuelle semble donc obligatoire.

■ § 2 – Présentation schématique du bilan

Au point de vue juridique, le bilan d'une entreprise représente à un instant donné, l'état de ses actifs, de ses passifs tiers et de ses fonds propres. Dans la présentation traditionnelle sous forme de tableau, le côté gauche reprend les actifs de l'entreprise, c.-à-d. les éléments qui ont une valeur économique positive pour celle-ci ; le côté droit énumère les dettes de l'entreprise envers les tiers (le passif externe) et les droits des associés sur le patrimoine de l'entreprise[3] (passif interne). Cette convention comptable ne correspond à la réalité que pour les sociétés, non pour les entreprises individuelles. En effet, pour celles-ci, le bilan de l'entreprise reflète non le patrimoine de l'exploitant, mais l'état des biens affectés à cette exploitation. La différence entre les actifs et les passifs envers des tiers représente le montant net des capitaux affectés à l'entreprise.

Par application des principes de la comptabilité en partie double, il y a automatiquement identité entre les actifs, d'une part, et les passifs (dans le sens de passifs tiers et fonds propres), d'autre part. On peut souligner que l'exigence de la tenue d'une comptabilité en partie double (déjà prévue par l'article 8 du Code de commerce en vertu de la disposition introduite par une loi du 22 décembre 1986) vient d'être confirmée par la loi du 19 décembre 2002 (nouvel article 11 C. com.).

L'article 461-1 L.S.C., en conformité avec la loi belge, parle de dettes de la société envers elle-même. Cette présentation est évidemment à prendre avec beaucoup de circonspection dans la mesure où, s'il est vrai que les fonds propres appartiennent aux associés (l'on peut donc considérer que ceux-ci leur sont dus), il n'en est pas moins vrai que la société doit aux associés non pas un certain montant comptable arrêté à un moment donné, mais, en cas de liquidation, le solde réel après paiement de toutes les dettes de la société. Ce solde n'est pas nécessairement égal au montant du capital social, voire au total des fonds propres[4].

1 – *Rép. dr. com.*, V° Inventaire et comptes annuels, n° 99.

2 – P. Wauwermans, *Manuel pratique des sociétés anonymes*, Bruxelles et Paris, 1924, p. 357.

3 – *Répertoire de droit commercial*, 2e éd., Paris, Dalloz, 1974, p. 21.

4 – E. Folliet, *Le bilan dans les sociétés anonymes*, Paris, Payot, 1937, p. 19.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Au point de vue économique, le bilan donne la représentation chiffrée des ressources et des emplois mis en œuvre au sein de l'entreprise. Le passif du bilan représente l'origine du financement (crédits bancaires, crédits fournisseurs) tandis que le côté actif indique l'emploi qui est fait de ses ressources (immobilisations, biens du réalisable et du disponible).

Les éléments actifs et passifs de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Aucune compensation entre postes actifs et passifs n'est possible.

Les différents schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes sont prévus par les annexes du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015.

Depuis 2005 a disparu l'option prévue par la directive et, dans son sillage, celle de la loi luxembourgeoise donnant aux entreprises le choix de procéder à une présentation sous forme de liste conformément à la pratique anglo-saxonne (anc. art. 214 L.S.C.). En ce qui concernait le bilan, la présentation sous forme de liste avait l'avantage de montrer les fonds propres en un seul endroit à la fin de la liste. La présentation sous forme de compte ne permet de déterminer le montant des fonds propres qu'en additionnant différents postes de bilan repris en haut (les fonds propres du début d'exercice) et en bas du bilan (le résultat annuel). En outre, le résultat annuel se trouve en un endroit différent selon qu'il est positif ou négatif. Depuis 2005, seule la présentation sous forme de compte est admise.

Nous reprenons successivement les différents postes de l'actif avant de nous consacrer à ceux du passif.

1) Les postes d'actif

Les principaux postes sont repris ci-après.

a) Les frais d'établissement

L'article 53 de la Loi de 2002 oblige les sociétés de capitaux à amortir ce poste au plus tard après cinq années. Cette disposition mentionne les « ***frais d'établissement*** », ce qui, selon l'article 53 (3) de la Loi de 2002, vise également les frais en relation avec l'extension d'une entreprise, d'une partie autonome d'entreprise ou d'une branche d'activité. L'administration des contributions ne s'oppose toutefois pas à étendre le traitement mentionné ci-dessus aux frais d'établissement en ce sens plus large. Il reste que les **durées d'amortissement** ne sont pas identiques : ainsi une société de capitaux doit amortir au plus tard dans les cinq années, alors que fiscalement la durée de dix années est théoriquement possible.

b) Les terrains et les constructions

Initialement, ces biens sont à comptabiliser à leur prix d'acquisition ou de revient, y compris les frais d'intermédiaire, les droits d'enregistrement, la TVA (sauf pour la partie récupérable).

Lorsqu'un **immeuble bâti** est acquis, il convient de ventiler le prix d'acquisition en une partie relative au **terrain** et une partie relative à la **construction**. En effet, il s'agit de deux biens différents : seule la construction est amortissable ; l'amortissement dégressif n'est d'ailleurs pas admis à son endroit. La quote-part

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

imputable au terrain doit, le cas échéant, être estimée : il est considéré que la quote-part du prix d'acquisition afférente au terrain est (sauf circonstances exceptionnelles) égale à 20 %. En cas de détermination de la valeur réelle de l'immeuble, « *il convient d'envisager l'immeuble dans son ensemble, c.-à-d. et le sol et le bâtiment* »[1].

À noter encore que les terrains constitués par des masses de **substances minérales** ou fossiles (mines, carrières) font l'objet d'un amortissement pour diminution de substance.

c) Les installations techniques

La comptabilisation se fait encore au prix d'acquisition ou de revient et, à chaque fin d'exercice, les amortissements normaux en diminuent la valeur comptable. L'amortissement dégressif est admis à l'égard de ces immobilisations. Lorsqu'une correction de valeur (« *Teilwertabschreibung* ») a été effectuée à l'égard de ces biens, elle ne peut pas être annulée : étant donné que l'article 55 1, c) sous dd) de la Loi de 2002 exige une telle annulation, l'établissement d'un bilan fiscal divergeant du bilan commercial est inévitable.

d) Les opérations de *leasing*

La Quatrième directive ne contient pas la moindre disposition au regard de cette catégorie d'opérations. Selon une approche purement juridique, les biens pris en *leasing* seraient à attribuer au donneur de *leasing* uniquement. Reste la question de savoir si une telle approche serait entièrement satisfaisante compte tenu des aspects économiques et financiers de ces opérations. En effet, et surtout s'il s'agit d'opérations de *leasing* financier (opérations caractérisées par une période de location irrévocable pendant laquelle tout le prix du bien, y compris les frais de financement, sont payés), le preneur de *leasing* est économiquement dans une position proche de celle du propriétaire du bien (il dispose de la jouissance du bien pendant toute la durée de vie utile du bien et en subit donc également les risques d'appréciation et de dépréciation).

C'est en reconnaissance de cette réalité que la norme I.A.S. 17 permet, en cas d'opérations de location-financement, de les traiter en fonction de leur substance économique, ce qui signifie que le preneur va les porter à l'actif de son bilan et, le cas échéant, les amortir. En contrepartie de ce poste d'actif figure au passif du bilan une dette correspondant à toutes les mensualités de *leasing* : ce poste de dette diminue au fur et à mesure du paiement des mensualités de *leasing*.

e) Le *goodwill*

Par définition il représente « *la plus-value de l'exploitation entière par rapport à la somme des valeurs d'exploitations des autres biens de l'actif net investi* »[2]. Seul le *goodwill* **acquis à titre onéreux** (dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise, partie d'entreprise, etc.), peut être porté à l'actif du bilan. Le *goodwill* créé par l'entreprise

1 – H. Dostert, « L'impôt sur le revenu III », *Études fiscales*, p. 267.

2 – *Doc. parl.*, n° 571/4, p. 38, ID 2692.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

elle-même ne peut être repris à l'actif. À cet endroit, il est renvoyé aux développements détaillés faits sous la Partie II au sujet de cette notion[1].

f) Les immobilisations incorporelles

Sont visés à cet endroit les frais de recherche et de développement, les concessions, brevets, licences, marques ainsi que les droits et valeurs similaires. Lors de l'introduction des dispositions de la Quatrième directive sur les comptes annuels des sociétés de capitaux (entre-temps remplacée par la directive 2013/34/UE), la solution suivante a été retenue : ces différents éléments sont **facultativement** à **porter à l'actif du bilan** s'ils ont été créés par l'entreprise elle-même ; s'ils ont été acquis à titre onéreux, ils sont obligatoirement à porter à l'actif du bilan.

En ce qui concerne la durée d'amortissement, selon la L.S.C., en principe cinq ans, mais possibilité d'amortir sur une durée plus longue lorsque les biens en question peuvent être utilisés sur une plus longue période.

g) Les participations

On distingue les participations dans des sociétés de capitaux de celles dans des sociétés de personnes (plus rares en pratique).

i) Principes d'évaluation

Les participations détenues dans des sociétés de capitaux sont à porter à l'actif au prix d'acquisition (y compris tous les frais accessoires) ; le prix n'augmente pas en fonction des résultats de la société filiale. Par exception, en cas d'application de la « *méthode de mise en équivalence* », prévue à l'article 58 de la Loi de 2002 ci-après, il peut y avoir dépassement du coût d'acquisition historique. Cette méthode n'est toutefois pas acceptable fiscalement.

Le prix d'acquisition augmente en fonction de **nouveaux apports** ouverts ou cachés effectués par la société mère. Le prix d'acquisition diminue en raison des réductions de capital, mais non en fonction des distributions de dividendes. Toutefois, en cas de distribution massive de réserves déjà existantes au moment de l'acquisition (et donc comprises dans le prix d'acquisition de la participation par la société mère), il se peut que la valeur d'exploitation de la participation devienne inférieure à sa valeur comptable, de sorte qu'une correction de valeur à la valeur d'exploitation inférieure soit requise.

Lorsque la participation est détenue dans une **société de personnes**, il faut considérer que la société mère, en tant qu'associé de la société de personnes, est censée directement détenir les biens appartenant à la société de personnes. La valeur comptable de la participation reflète donc le compte associé du coexploitant dans la société de personnes, c.-à-d. qu'elle fluctue tous les ans en fonction des résultats (positifs ou négatifs), d'une part, ainsi que des apports de l'associé à la société (retraits de la société), d'autre part. Les règles fiscales dominent à cet endroit les règles proprement comptables et, afin d'éviter l'obligation d'établir un bilan fiscal divergent, ces règles sont également à suivre en comptabilité.

1 – V. sous V° *goodwill*.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ii) Mise en équivalence

À l'égard des participations dans des entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles une influence notable est exercée, ce qui est présumé être le cas si le taux de participation (au droit de vote) est **de 20 % au moins**, la société détentrice de la participation dispose de l'option suivante :

– évaluer la participation au coût historique ;
– évaluer celle-ci au montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentés par cette participation.

Si cette deuxième option est choisie, alors la différence par rapport à celle qui correspond à la méthode classique est mentionnée séparément au bilan ou dans l'annexe.

Dans un cas d'espèce tranché le 27 juin 1996 (affaire **Tomberger**[1]) la CJCE a arrêté qu'il n'est pas contraire au droit communautaire que la société mère reconnaisse un dividende déclaré par la société filiale si, à la date de clôture des comptes de la société mère, cette déclaration n'a pas encore eu lieu. La Cour a insisté sur le caractère spécifique des circonstances qui résultaient de la question préjudicielle et de l'ordonnance de renvoi, à savoir :

– la société mère est l'unique associé de la société filiale et la contrôle ;
– selon le droit national, la société mère et la filiale forment un groupe ;
– les exercices des deux sociétés coïncident ;
– les comptes annuels de la filiale pour l'exercice en cause ont été arrêtés par son assemblée générale avant que la vérification des comptes annuels de la société mère pour ce même exercice n'ait été terminée ;
– il ressort des comptes annuels de la filiale pour l'exercice en cause, tels qu'adoptés par son assemblée générale, qu'au jour retenu pour la clôture du bilan de la filiale, à savoir le dernier jour de cet exercice, celle-ci a affecté des bénéfices à la société mère.

Dans ces circonstances, la cour a retenu que le juge national peut estimer « *que le droit de la société mère à participer au bénéfice en cause est suffisamment concrétisé au jour retenu pour la clôture des bilans des deux sociétés pour que l'on puisse considérer que ce droit fait partie, ce même jour, du patrimoine de la société mère* ».

À notre sens, la portée de cet arrêt (qui en tout état de cause est limitée à la matière comptable et ne peut notamment pas être étendue à la fiscalité, par exemple) est fort limitée, et ceci, en raison des circonstances très spécifiques du cas d'espèce soumis à la cour.

iii) Particularités des sociétés financières

Il y a lieu de noter que ces sociétés ont certaines particularités. La loi distingue entre les sociétés d'investissement (art. 30 de la Loi de 2002) et les sociétés de participation financière (art. 31 de la Loi de 2002). Par société d'investissement, on entend « *les sociétés dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées et en d'autres valeurs, dans le seul but*

1 – Arrêt C-234/94, ID 11677.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs avoirs ».

Les sociétés de participation financière sont des sociétés « *dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés* ».

Les sociétés d'investissement, étant soumises à la loi sur les OPC, sont tenues d'établir leurs comptes selon les dispositions de la loi sur les OPC (art. 30 de la Loi de 2002). Les sociétés de participation financière sont en revanche soumises au droit commun de la directive avec la particularité que la présentation des comptes peut se faire selon un schéma particulier (à savoir un schéma abrégé) déterminé par règlement grand-ducal (art. 31 de la Loi de 2002).

Dans l'annexe, il n'est pas obligatoire de reprendre les données requises par le paragraphe (1), 2°, à savoir les noms des sociétés dans lesquelles une participation de 20 % dans le capital au moins est détenue.

Une dernière particularité des sociétés de participations est que celles-ci sont en pratique toujours à considérer comme des petites sociétés dans le sens de la classification ici retenue. La raison en est la suivante : pour ne pas être considérée comme telle, il faut que la société dépasse au moins deux des trois seuils de l'article 35 de la Loi de 2002. Étant donné que ce genre de sociétés ne compte guère, loin s'en faut, plus de 50 membres de personnel, il en résulte que les deux autres limites (chiffre d'affaires et total du bilan) doivent être excédées pour que la société soit considérée comme société moyenne ou grande. Le chiffre d'affaires étant défini comme le résultat de la vente de produits et de prestations de services, il en résulte que les sociétés de participation financière sont considérées comme n'ayant pas de chiffre d'affaires (puisque leurs revenus proviennent d'intérêts, de dividendes et de plus-values en capital).

h) Les créances

Les créances sont à évaluer à leur prix d'acquisition (qui correspond au montant nominal) et, le cas échéant, à leur valeur d'exploitation inférieure. L'acquisition de la créance correspond à l'aliénation des marchandises : le coût d'acquisition est le montant que l'aliénation de la marchandise rapporte[1]. Le montant nominal de la créance correspond aux frais engendrés par la production des biens aliénés, y compris une marge bénéficiaire.

Les créances sont, en principe, à évaluer individuellement et, par conséquent, des provisions individuelles doivent, le cas échéant, être effectuées. Les créances libellées en devises sont à évaluer en euros, et ceci, en appliquant à leur valeur nominale le cours de change applicable au moment où la créance est née, c.-à-d. où la marchandise est livrée ou encore où le crédit accordé au débiteur est mis à sa disposition.

Le cours de change est ainsi un des éléments qui influent sur la valeur d'exploitation de la créance au bilan fiscal. En d'autres termes, en cas de dépréciation

1 – E. Littmann, *Das Einkommensteuerrecht*, 13e éd., Stuttgart, Schäffer, par. 6, p. 433.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de la devise étrangère (par rapport à l'euro), une correction de valeur peut devenir nécessaire, et ceci, en dehors de tout risque d'insolvabilité du créancier.

Lorsque l'entreprise a non seulement des créances en une devise donnée, mais encore des dettes libellées dans la même devise, une compensation de ces deux postes n'entre pas en ligne de compte (en raison du principe de l'évaluation individuelle).

i) Les stocks

L'évaluation des stocks devant se faire au prix d'acquisition, il y a lieu de déterminer ce prix d'acquisition, ce qui ne va pas sans soulever des problèmes à l'égard des stocks. En effet, ces stocks ont été constitués par des achats successifs, plus ou moins récents, à des prix différents, alors qu'ils font l'objet de prélèvements continus pour alimenter la production ou la vente. Le droit comptable admet les différentes méthodes développées par la théorie, à savoir donc LIFO, FIFO, CMP, etc.

2) Les postes de passif

Comme l'actif, le passif est subdivisé en 4 positions :
A. Capitaux propres ;
B. Provisions ;
C. Dettes ;
D. Comptes de régularisation.

a) Les capitaux propres

Sont repris à cet endroit les différents postes de fonds propres que sont :

I. Capital souscrit
II. Prime d'émission
III. Réserve de réévaluation
IV. Réserves
    1. Réserve légale
    2. Réserve pour actions (parts) propres
    3. Réserve de réévaluation
    4. Autres réserves, dont réserve de juste valeur
V. Résultats reportés
VI. Résultat de l'exercice
VII. Acomptes sur dividendes
VIII. Subventions d'investissement en capital

Le capital social souscrit est celui qui figure dans l'acte de société. Pour connaître le montant du capital effectivement à disposition de la société, il faut se reporter à l'actif (position A : capital souscrit non versé) afin de déduire du capital souscrit celui qui n'est pas encore versé (qu'il soit appelé sans être versé par les associés, ou qu'il ne soit pas encore appelé et donc non versé).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La **prime d'émission** représente en principe le montant que les souscripteurs d'actions nouvelles doivent verser pour compenser les réserves libres et cachées qui sont attachées aux titres de capital émis antérieurement. Néanmoins, la pratique luxembourgeoise (qui n'est en rien critiquable) prévoit souvent une prime d'émission même pour des sociétés nouvellement créées.

L'article 54 (1) de la Loi de 2002 autorise un règlement grand-ducal de **permettre ou d'imposer la réévaluation** des immobilisations corporelles et des immobilisations financières. En d'autres termes, de tels postes pourraient à l'avenir faire leur apparition dans les bilans.

Les **réserves**, avec les différents sous-comptes que sont la réserve légale, la réserve pour actions et parts propres, les réserves statutaires, les autres réserves, correspondent à des postes de bénéfices sociaux accumulés, dus à l'autofinancement pratiqué par la société – l'autofinancement étant dû au fait que les résultats générés ne sont pas distribués ou ne sont distribués que partiellement. Ces réserves sont des réserves imposées, ce qui signifie qu'en cas de liquidation de la société, aucune charge financière ne serait à subir du fait de ces réserves.

La **réserve légale** correspond à une exigence légale (de droit commercial) selon laquelle les sociétés de capitaux doivent constituer une certaine réserve supplémentaire (de 10 % au maximum) par rapport au capital social. Cette réserve est créée par prélèvement sur les bénéfices annuels dans la limite de 5 % de ce bénéfice annuel et jusqu'à 10 % du capital social nominal. Ces dispositions légales ne font que prévoir des minima, ce qui signifie que la société pourrait sans aucun problème décider de doter plus rapidement, par exemple en dotant immédiatement, la première année, la totalité de la réserve légale afin que celle-ci atteigne donc dès le départ les 10 %. Une autre possibilité consiste, au moment de la constitution, de tout de suite doter le poste réserve légale. Si cette pratique est suivie, la réserve légale sera dotée non par prélèvement sur les résultats annuels de la société, mais par les apports des associés. Ceci n'empêche pas que cette façon de faire soit irréprochable.

La **réserve pour actions propres** (ou parts propres), telle que prévue par l'article 430-22 L.S.C., applicable aux sociétés anonymes. Aux termes de cet article il faut que :

- le rachat soit autorisé par les statuts ;
- les actions soient entièrement libérées ;
- les conditions du rachat soient fixées par les statuts ;
- le rachat ait lieu à l'aide de sommes distribuables selon l'article 430-22 ou à l'aide du produit d'une nouvelle émission ;
- un montant égal à la **valeur nominale** (pair comptable) de toutes les actions achetées doit être incorporé dans une réserve qui, en principe, ne peut être distribuée aux actionnaires. Cette condition ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide d'une nouvelle émission effectuée dans ce but.

Si la réserve légale est une réserve dont la constitution est imposée par la loi, les réserves statutaires, pour leur part, sont décidées par les associés qui, en rédigeant les statuts (la loi de la société), peuvent être amenés à décider de l'utilisation des résultats futurs de la société en décidant que ceux-ci devront être partiellement ou entièrement affectés à des réserves statutaires. Bien entendu, les associés peuvent échapper à ces contraintes qu'ils se sont imposés eux-mêmes en changeant les statuts de la société (ce qui suppose évidemment une majorité qualifiée).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« *Autres réserves* » : ce poste comporte en particulier la réserve prévue par l'article 64*bis* Loi de 2002 pour les entreprises qui optent en faveur de l'évaluation à leur **juste valeur** « *des instruments financiers, y compris les instruments dérivés* ».

b) Les provisions

Le schéma du bilan adopte une subdivision des provisions selon leur nature, en trois catégories :

– provisions pour pensions et obligations similaires ;

– provisions pour impôts ;

– autres provisions.

Les deux premières catégories sont évidemment des provisions à caractère de dette (au sens de l'article 44 (1) de la Loi de 2002). Ceci vaut en premier lieu pour les provisions pour pensions. Le régime des pensions donne lieu à des provisions dont le montant peut être extrêmement important.

Les **impôts**, dans la mesure où ils ne sont pas encore payés à la clôture de l'exercice, constituent des dettes de la société à la fin de l'exercice. Il convient de tenir compte de ces dettes dont le montant effectif n'est souvent pas connu avec la dernière précision et peut toujours faire l'objet de redressements de l'administration. La prise en compte de ces dettes est faite par les provisions pour impôts.

Dans la catégorie des autres provisions figurent donc les provisions pour risques et charges autres que celles pour pensions et pour impôts, notamment celles visées ci-dessus, telles que la provision décennale, la provision pour procès et la provision pour grosses réparations (qui risque de ne pas être reconnue fiscalement).

Par suite d'un changement de terminologie (consistant à supprimer le terme de provision pour risques et charges), les provisions admises sont définies comme suit par l'article 44 de la Loi de 2002. L'objet des provisions du paragraphe (1) est de « *couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance* »[1].

« *Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à leur date de survenance* »[2].

Ces deux catégories de provisions ne peuvent avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments d'actifs.

Comme exemple de telles provisions, on peut citer les provisions **pour malfaçon** (litige avec un client pour un travail mal exécuté), provisions **pour procès en cours**, provisions pour garantie décennale des architectes et entreprises de construction, provisions **pour pensions** accordées au personnel qui font l'objet d'une réglementation à part. La caractéristique primaire de ces provisions est qu'elles ont le **caractère de dettes**, ce qui les distingue de la catégorie suivante où il s'agit de provisions

1 – Art. 44 (1) de la Loi de 2002, ID 1779.

2 – Art. 44 (2) Loi de 2002, ID 1779.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ayant le caractère de charges d'exploitation et dont la justification est de montrer le résultat correct de l'exercice.

La mesure dans laquelle cette catégorie de provisions est déductible dépend de la **conception** qu'on se fait **du bilan**. Si l'on adopte la conception selon laquelle le bilan enregistre la **fortune** de l'entreprise à la date de clôture du bilan, l'objet des provisions sera de comptabiliser les dettes qui ne sont pas encore certaines quant à leur existence ou quant à leur montant (conception statique du bilan).

Par contre, si le bilan a pour objet de montrer le **résultat** généré pendant la période écoulée, les provisions servent à assurer la comparabilité de la détermination des résultats et conduisent à une approche plus large par rapport à de telles provisions (**conception dynamique** du bilan). Dans ce cas, les provisions sont à comptabiliser pour des dépenses qui économiquement se rapportent à l'exercice en cours, mais qui ne conduiront à des recettes ou des dépenses qu'ultérieurement. Exemple : provisions pour **grosses réparations**. De telles provisions pour grosses réparations (acceptées commercialement pour les sociétés de capitaux) ne sont pas admises par l'administration fiscale qui « *n'autorise pas les entreprises à constater à l'avance des charges annuelles des exercices à venir sous forme de provisions* »[1]. Le cas échéant, un bilan fiscal divergent est à établir.

c) Dettes

Différentes catégories de dettes sont reprises sous ce poste, notamment :
– emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles ;
– dettes envers les établissements de crédit ;
– acomptes reçus sur commandes ;
– dettes sur achats et prestations de services ;
– dettes envers des entreprises liées ;
– dettes envers les entreprises liées avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation ;
– autres dettes dont les dettes fiscales et celles de sécurité sociale.

Pour chacun de ces postes, le montant des dettes doit être ventilé en un montant dont la durée résiduelle est supérieure à un an et un montant dont la durée résiduelle est inférieure à un an.

Les dettes sont à évaluer au montant net touché par l'entreprise soit sous forme de prêt soit sous forme de livraisons de biens ou de prestations de services. Le montant en diminue en fonction des paiements effectués pour s'acquitter de sa dette ; il augmente en fonction des intérêts, éventuellement chargés par le créancier.

d) Comptes de régularisation

Au poste du compte de régularisation passif figurent les produits perçus avant la date de clôture et comptabilisés pendant l'exercice, mais imputables à un exercice ultérieur[2].

1 – Circ. L.I.R. n° 101 du 5 novembre 1985, ID 8172.

2 – *Guide des comptes annuels pour le Luxembourg*, T.1, Actif E. I- 01.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION IV
COMPTE DE RÉSULTAT OU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Depuis la Quatrième directive, il n'existe plus qu'un seul compte de résultat alors que, dans la tradition française, deux comptes de résultat ont été établis, à savoir un compte d'exploitation et un compte de profits et pertes (proprement dit).

■ § 1 – Notion

Le compte de profits et pertes récapitule les produits et charges de l'exercice sans prise en considération de leur date d'encaissement ou de paiement. Certaines charges et certains revenus ne donnent d'ailleurs **pas** lieu à des **mouvements de fonds** (voir amortissements et provisions). Le compte de profits et pertes fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant (provenant des activités ordinaires) et le résultat exceptionnel. Toute compensation entre postes de charges et de produits est interdite en principe.

Du point de vue de la présentation, les sociétés bénéficient traditionnellement de l'option d'adopter soit la forme de la liste soit la forme traditionnelle du compte (produits d'un côté, charges de l'autre). Depuis 2005, cette faculté de choix a disparu : la loi ne retient **plus qu'un seul schéma** de compte de profits et pertes qui est donc obligatoire. Le schéma est reproduit à l'annexe du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015.

Des regroupements sont possibles à l'égard des sociétés qui ne sont pas des grandes sociétés, donc celles qui ne dépassent pas deux des trois critères suivants :

Total du bilan :	20.000.000[(2)] EUR
Chiffre d'affaires :	40.000.000[(2)] EUR
Total des employés occupés :	250

■ § 2 – Étude détaillée du compte de profits et pertes

Ci-après, nous nous basons sur le schéma de la loi, prévu par l'article 46 de la Loi de 2002, avec une présentation des frais par nature. Conformément à la tradition française notamment, le compte de profits et pertes repose sur une répartition des charges par nature qui sont ainsi classées selon leur nature en frais de personnel, etc. Les produits quant à eux sont ventilés en opérations d'exploitation, en opérations financières et en opérations exceptionnelles.

1 – Augmentation des montants selon la loi du 18 décembre 2015, *Mém*. A258 du 28 décembre 2015, p. 6228.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

A – Montant net du chiffre d'affaires

Cette notion comprend « *le montant résultant de la vente des produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur vente, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires* »[1].

Le chiffre d'affaires est donc une grandeur nette des éléments suivants :

– les remises, ristournes et rabais obtenus : il s'agit donc en quelque sorte d'une compensation prévue par la loi ;
– les impôts liés au chiffre d'affaires : concrètement, il s'agit de la TVA à laquelle on peut ajouter les autres impôts sur la consommation, tels que les accises.

B – Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication

En l'absence de la moindre précision donnée par la loi elle-même, on est limité à se tenir au libellé même de cette position : une augmentation de ces postes a un effet positif sur le résultat.

C – Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif

Sont visés tous les travaux faits par l'entreprise pour elle-même et repris aux rubriques frais d'établissement, immobilisations corporelles, immobilisations incorporelles.

D – Autres produits d'exploitation

Sont repris sous cette rubrique les produits provenant de tiers qui ne résultent pas de l'activité habituelle de l'entreprise et ne font partie ni des produits financiers ni des produits exceptionnels.

Exemples
Plus-values sur biens, indemnités d'assurance, loyers, etc.

E – Charges de matières premières et consommables et autres charges externes

Sont visées les achats de marchandises de matières premières et de fournitures qui ont été englobées dans le processus de production. Le poste « autres charges externes », dans sa globalité, constitue la valeur de la consommation des matières premières et secondaires et, le cas échéant, de celle des marchandises vendues en l'état. Sous a), on reprend les achats de l'année en marchandises et en matières premières et fournitures qui ont été englobées dans le processus de production. Les autres charges externes représentent notamment les fournitures de gaz et d'électricité ou encore la fourniture des sous-traitants[2].

1 – Art. 48 Loi de 2002, ID 1779.
2 – *Guide comptable luxembourgeois*, T. 1, p. 15.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

F – Frais de personnel

– Salaires et traitements
– Charges sociales avec mention séparée de celles couvrant les pensions

Sont repris dans cette rubrique tous les frais en relation avec le personnel de l'entreprise. Sont donc visées :

– les rémunérations en espèce et les avantages en nature ;
– les pensions de retraite et de survie.

G – Corrections de valeur

a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles
b) Corrections de valeurs sur éléments de l'actif circulant.

Les corrections de valeur comprennent toutes les entrées comptables destinées à tenir compte de la dépréciation des éléments faisant partie du patrimoine de l'entreprise à la date de clôture du bilan. Elles contiennent donc tant les amortissements sous toutes leurs formes que les corrections de valeur exceptionnelles. Les corrections de valeur « *normales* » seraient celles qui reviennent avec une certaine régularité[1]. Les litt. a) et b) consistent à subdiviser ces entrées comptables en celles se rapportant aux immobilisations (y compris les frais d'établissement) et celles se rapportant aux actifs circulants de l'entreprise. Voir encore le point 12 ci-après.

H – Autres charges d'exploitation

Sont reprises ici les autres charges relatives à l'exploitation qui :

– ne résultent pas de prestations de services ou de livraisons de biens par des tiers, relevant de l'activité habituelle de l'entreprise ;
– ne relèvent pas de la catégorie de charges financières ou des charges exceptionnelles.

Il s'agit donc d'une catégorie résiduelle dans l'ensemble des charges d'exploitation.

I – Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées

Sont visés les revenus courants (dividendes) ainsi que les plus-values en capital.

J – Produits provenant d'autres valeurs mobilières

Il y a lieu de mentionner de manière séparée ceux provenant d'entreprises liées. Sous cette rubrique tombent non seulement les dividendes et les intérêts, mais

1 – *Beck'sches Steuerberaterhandbuch 2004/2005*, Munich et Frankfurt, Beck C. H., 2004, p. 574.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

encore les plus-values en capital relatives à des valeurs mobilières autres que des participations.

K – Autres intérêts et produits financiers

Il y a encore lieu de mentionner de manière séparée ceux provenant d'entreprises liées. Il s'agit d'intérêts et de plus-values sur créances.

L – Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence

Il s'agit de l'application de l'article 58 de la Loi de 2002 qui permet aux sociétés d'inscrire les participations dans le capital d'entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles elles exercent une influence notable, de comptabiliser les participations en question (20 % des droits de vote au moins en principe) à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation.

M – Corrections de valeur sur immobilisations financières

En cas de perte de valeur d'actifs, des corrections de valeur sont à faire. Celles sur les participations doivent être reprises séparément.

N – Intérêts et autres charges financières

Sont visés les intérêts débiteurs sous toutes les formes. Il y a lieu de mentionner de manière séparée ceux provenant d'entreprises liées.

O – Impôts sur le résultat

Il s'agit donc de l'IRC et de l'ICC.

P – Résultat après impôts sur le résultat

Il s'agit du résultat intermédiaire qui sera très proche du résultat final (voir sous R).

Q – Autres impôts que ceux figurant sous les postes précédents

Sont visés donc les impôts autres que les impôts sur le résultat déduits *sub* O. Il s'agit des impôts autres que ceux calculés sur le résultat, notamment donc ceux sur la fortune, l'impôt foncier, etc.

R – Résultat de l'exercice

Il s'agit du résultat net de tous frais, dont le montant également repris au bilan.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION V
L'ANNEXE

« *L'annexe des comptes annuels a pour finalité d'éclairer la lecture du bilan et du compte de résultat par des explications, des ventilations et des compléments appropriés. Étroitement liée aux deux autres documents des comptes annuels, l'annexe en est indissociable* »[1].

Le contenu de l'annexe est décrit par l'article 65 de la Loi de 2002. Aux 18 points prévus par la loi, il convient de rajouter les « *mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente section* » (voir alinéa 1 de l'article 65 de la Loi de 2002). En effet, dans un grand nombre d'endroits, la loi renvoie à l'annexe. Une des mentions les plus importantes prévues par la loi est celle de l'article 26 (5) de la Loi de 2002, c.-à-d. dans le cas où les dispositions légales ne reflètent pas une **image fidèle** du patrimoine, etc. de l'entreprise et qu'il y a lieu de déroger à ces règles : il y aura mention dans l'annexe de cet état des choses avec l'indication de son influence sur le patrimoine, etc.

La liste reproduite ci-après (qui est non exhaustive) est aussi longue que diversifiée :

- description des modes d'évaluation et des méthodes de calcul des corrections de valeur ;
- indication des filiales (ces informations peuvent être omises dans certains cas) ;
- montant des actions souscrites dans les limites du capital autorisé ;
- description des différentes catégories d'actions émises, des parts bénéficiaires, obligations convertibles émises, etc. ;
- montant des dettes ayant une échéance supérieure à cinq années, les sûretés accordées par la société ;
- montant des engagements non repris au bilan de la société ; sont visées en particulier les cautions, avals, garanties par la société. Les cautionnements sont repris hors bilan tant que la garantie n'a pas été invoquée et même si elle l'a été, à condition toutefois que la personne bénéficiaire de la garantie soit solvable. En effet, dans ce cas, le garant bénéficie d'un recours contre le bénéfice de la garantie, de sorte que l'opération ne se traduira en principe pas par une perte dans le chef du garant ;
- ventilation du chiffre d'affaires par catégories d'activités et marchés géographiques ;
- nombre des membres du personnel ; cette donnée est pertinente pour décider de la classifier en tant que « *petite* », « *moyenne* » ou « *grande* » société (en application des articles 35 et 47 Loi de 2002) ;
- montant des rémunérations accordées aux organes d'administration ou de surveillance en raison de leurs fonctions et des engagements contractés en matière de pensions de retraite ;
- montant des avances et crédits accordés aux membres des organes d'administration ou de surveillance avec indication du taux d'intérêt ;
- informations concernant les produits (charges) se rapportant à l'exercice, exigibles (payables) après la clôture de l'exercice, lorsque ceux-ci sont d'une certaine importance ;

1 – *Lamy sociétés commerciales 1993*, Lamy GF, 1993, n° 1909.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– nom et siège de l'entreprise qui établit les comptes consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, etc. ; ces données servent à vérifier les raisons pour lesquelles l'entreprise en question n'établit pas des comptes consolidés.

SECTION VI
LE RAPPORT DE GESTION

Parmi les documents qui sont à établir par les organes de gestion de la société et qui doivent être remis aux associés figure le rapport de gestion[1]. Tout en ne faisant pas partie des comptes annuels proprement dits, celui-ci doit en principe faire l'objet d'une publication, en même temps que les comptes annuels. Ce rapport doit contenir « *un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles elle est confrontée* ».

Le contenu de ce document est encore à compléter par les mentions prévues par l'article 68 (2) de la Loi de 2002. Les indications suivantes doivent y figurer : « *l'évolution prévisible de la société ; les activités en matière de recherche et de développement ; en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres, les indications visées à l'article 430-18, paragraphe (2) ; l'existence de succursales de la société […]* ».

Le rapport de gestion est destiné à permettre aux associés et aux tiers d'avoir une appréciation des organes de gestion sur l'évolution prévisible de la société. Il s'agit donc d'un document établi par des personnes qui, en principe, doivent être considérées comme étant bien placées pour cet exercice. En effet, ce sont eux qui vivent dans la société au quotidien. En outre, il s'agit d'un document essentiellement prospectif et qui, à ce titre, est complémentaire des comptes annuels. Ces derniers, par nature, sont rétrospectifs dans la mesure où ils indiquent une situation existante (le patrimoine ou le résultat) à un certain moment du passé.

Il est précisé que les petites sociétés ne sont pas tenues d'établir un rapport de gestion, à condition qu'elles reprennent dans l'annexe les informations visées sous d) relatives aux acquisitions d'actions propres.

La ou les personnes chargées du contrôle des comptes doivent vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de la société (art. 69 Loi de 2002). Ces personnes n'ont pourtant pas à exprimer un avis critique sur le caractère fidèle et sincère du rapport de gestion. Leur opinion sur le rapport de gestion ne fait pas partie de l'attestation des comptes annuels[2].

SECTION VII
LA PUBLICITÉ DES COMPTES

Les objectifs de la directive ne peuvent être atteints que si les comptes annuels connaissent une publicité suffisante. Il convient d'insister sur le fait que les comptes annuels, s'ils s'adressent d'abord aux associés de la société (qui eux, bénéficient

1 – En cas de non-remise et de non-publication dans les délais légaux, ce sont les peines de nature pénale de l'article 1500-2 (anc. art. 163) L.S.C., ID 7520, qui trouvent application.

2 – A. Benoit-Moury, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », *R.P.S.*, 1986, p. 24.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

depuis toujours de la possibilité de pouvoir consulter les comptes annuels qui sont d'ailleurs obligatoirement soumis à leur approbation) s'adressent également aux salariés, aux créanciers (fournisseurs), aux clients, à diverses administrations publiques, etc. C'est notamment à l'égard de ces diverses catégories de tiers qu'une publicité plus large doit être organisée.

L'article 77 de la Loi de 2002 (tel qu'amendée par la loi du 30 juillet 2013) définit les types de sociétés dont les comptes annuels doivent être accessibles au public. Il s'agit des sociétés suivantes :

« *1° les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, à l'exclusion des sociétés d'épargne-pension à capital variable ;*

2° les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple lorsque ***tous leurs associés indéfiniment responsables sont*** *des sociétés telles qu'indiquées à l'article 1er paragraphe (1) premier alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE du 25 juillet 1978* […] » *(donc des* ***sociétés de capitaux****)*

3° les formes de sociétés visées au point 2° lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés dans une des formes indiquées au point 1° ou au point 2° ou à l'article 1er paragraphe (1), premier alinéa ou deuxième alinéa, de la directive 78/660/CEE » ; il s'agit donc à nouveau des sociétés de capitaux.

Les points 2° et 3° sont des **mesures « anti-contournement »** du fait qu'elles ont pour but d'assurer que des sociétés de personnes ne puissent éviter de publier leurs comptes annuels même si tous leurs associés sont des sociétés de capitaux et que donc, en réalité, personne n'assume une responsabilité illimitée. Le point 3 vise des types de structure ayant un étage de plus que ceux du point 2 : donc, par exemple, une S.e.n.c. avec deux associés qui sont eux-mêmes des S.e.n.c. ayant chacune deux associés tous les deux de la forme de la S.à r.l. Dans un tel cas, aucun associé ultime n'assume en définitive une responsabilité illimitée à l'égard des dettes sociales de la S.e.n.c. opérationnelle. Il est à noter que cette réglementation n'entend que frapper les situations où aucun des associés n'a la responsabilité illimitée (et solidaire).

Aux termes de l'article 69 de la Loi de 2002, les comptes annuels doivent être déposés dans le mois de leur approbation. Cette obligation de publier concerne toutes les sociétés, petites, moyennes ou grandes. Ce qui varie en revanche, c'est l'étendue des informations publiées dans le sens que, en application du paragraphe (2), les petites sociétés ne sont tenues de publier qu'un bilan et une annexe abrégée, ce qui signifie donc qu'elles sont dispensées de publier le compte de profits et pertes, le rapport de gestion et le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes.

SECTION VIII
LA QUATRIÈME DIRECTIVE ET LES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

L'effort d'harmonisation des normes comptables effectué depuis plus de quarante ans sur le plan européen a certainement porté ses fruits. En même temps, les limites de cette approche sur un plan international sont également bien visibles. Sur

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

les marchés américains et asiatiques, les comptes sont établis en application de normes différentes. Il en résulte que les sociétés européennes désireuses de placer leurs titres sur les marchés américains, par exemple, sont tenues de préparer deux jeux de comptes, ce qui est nécessairement source de coûts supplémentaires et de confusion dans le chef des investisseurs.

Dans une communication du 13 juin 2000, intitulée « Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière : la marche à suivre », la Commission a proposé que toutes les sociétés européennes cotées sur un marché réglementé soient tenues de publier leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables IAS à partir de 2005 au plus tard. Les normes IAS (*International Accounting Standards*) ont été élaborées par l'International Accounting Standards Committee (IASC), qui s'est engagé dans un processus d'élaboration et de révision de normes comptables destinées aux entreprises désireuses d'internationaliser la cotation de leurs titres. Si ces normes sont donc en principe réservées aux entreprises cotées, il est certain que, au moins à moyen et à long terme, elles sont susceptibles d'exercer une influence des plus importantes sur toutes les sociétés.

L'International Accounting Standards Committee (IASC) a été constitué le 29 juin 1973 à Londres par les représentants des principales organisations comptables des différents pays. Le Comité des normes comptables internationales a reçu pour mission d'élaborer des normes comptables internationales imposant la fourniture d'informations financières transparentes et comparables destinées aux différents lecteurs des comptes sociaux et qui seraient acceptées par le monde entier (p. 50). Le nom de ce comité a été changé en International Accounting Standards Board (IASB) le 1er avril 2001.

La nouvelle organisation mise en place en mai 2001 est composée

– d'une fondation IASC, la International Accounting Standards Committee Foundation ;
– d'un conseil, le Board, International Accounting Standards Board ;
– d'un comité d'interprétation, l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ;
– d'un comité dénommé Standards Advisory Council (SAC).

Le règlement CE n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil européen du 19 juillet 2002 (*JO* du 11 septembre 2002) prévoit l'obligation pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne d'établir les comptes consolidés selon les normes IAS à partir du 1er janvier 2005.

Avec effet en mai 2002, les normes émises par le IASB sont appelées **IFRS** (*International Financial Reporting Standards*), expression qui désigne à la fois les **normes IAS existantes et les futures normes** à adopter après cette date[1].

À l'origine, les normes IFRS sont publiées en langue anglaise. En application de l'article 3 du règlement 1606/2002, les normes comptables adoptées sont publiées intégralement au Journal officiel de l'Union européenne, dans chacune des langues officielles des Etats membres, sous la forme d'un règlement de la Commission. Cette tâche a été accomplie pour les normes existantes par le règlement CE n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003[2].

1 – R. Obert, *Pratique des normes IAS/IFRS*, Paris, Dunod, 2003, p. 15.
2 – *J.O.*, 13 octobre 2003, n° 261, pp. 1-420.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

■ § 1 – Conditions pour pouvoir être adoptées

Selon l'article 3 du règlement CE 1606/2002, les normes comptables internationales ne peuvent être adoptées que :

– si elles ne sont pas contraires au principe énoncé à l'article 2 (3) de la Quatrième directive 78/660/CEE (2013/34/UE actuellement), c.-à-d. de la célèbre « *image fidèle* » ;
– elles répondent à l'intérêt public européen ;
– elles satisfont aux quatre critères suivants : intelligibilité, pertinence, fiabilité et comparabilité (« *[…] exigés de l'information financière nécessaire à la prise de décisions économiques et à l'évaluation de la gestion des dirigeants de la société* »).

■ § 2 – Possibilité d'extension du champ d'application de ces normes

Si le champ d'application de ces normes est à première vue assez limité (seuls les comptes consolidés des sociétés faisant appel public à l'épargne), le règlement 1606/2002 dans son article 5 laisse la porte ouverte aux États membres pour soit autoriser, soit obliger à une application plus large de ces normes. Dans le tableau suivant, seuls les comptes marqués en gras sont obligatoirement soumis aux nouvelles normes.

Sociétés faisant appel public à l'épargne :	Autres sociétés :
– Comptes annuels individuels	– Comptes annuels individuels
– **Comptes consolidés**	– Comptes consolidés

Par application de l'article 5 dudit règlement, les États membres peuvent d'abord autoriser ou obliger les sociétés faisant appel à l'épargne à établir les comptes annuels selon ces normes. En réalité, il faut supposer que, si le choix est laissé aux groupes de sociétés, ce choix sera exercé dans le sens de l'extension des normes IFRS aux comptes annuels. Toute autre solution est inefficace dans la mesure où elle oblige les sociétés à faire un double travail. En effet, les comptes consolidés étant basés sur les comptes annuels des différentes sociétés du groupe, le choix naturel des opérateurs sera d'établir les comptes annuels également sur la base des normes IFRS.

En principe, les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent être laissées complètement hors du champ d'application de ces dispositions. Toutefois, les législateurs nationaux peuvent également leur permettre d'établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels sur la base des normes IFRS. Les législateurs nationaux peuvent également les obliger à établir soit les uns soit les autres (soit les deux) sur la base des normes IFRS.

Si le législateur ne va pas jusqu'à imposer (ou au moins à autoriser) l'établissement des comptes selon les normes comptables internationales, par exemple en imposant l'établissement des comptes sociaux seulement pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, à l'avenir, des comptes sociaux seront établis selon des **normes comptables différentes**. Une telle situation est loin d'être satisfaisante : elle rend difficile la comparaison des états financiers, est source de maintes confusions

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dans l'esprit du public et pose de nombreux problèmes au niveau de la formation des professionnels du secteur. Dans la mesure où le législateur considérerait qu'une telle situation serait inévitable, il devrait du moins veiller à réduire au minimum la durée de cette période qui ne peut être qu'une période de transition.

■ § 3 – Structure des normes IFRS

En principe, ces normes contiennent la subdivision suivante :
– les objectifs ;
– le champ d'application ;
– les définitions ;
– les développements spécifiques ;
– les informations à fournir ;
– les dispositions transitoires ;
– la date d'application.

Souvent, les normes prévoient des options, c.-à-d. plusieurs traitements alternatifs. Dans ce cas, les différentes possibilités ne se situent pas sur un même niveau, mais la norme distingue un traitement de référence des autres traitements autorisés. Quand un traitement divergeant de celui de référence est utilisé, ce point doit être signalé dans l'annexe, afin de permettre au lecteur des comptes le rapprochement entre le traitement autorisé et le traitement de référence[1].

■ § 4 – Tableau des normes adoptées

N° norme	Objet de la norme	Première date d'application
IFRS 1	Présentation des états financiers *(remplace Publicité des méthodes comptables à partir de 1.7.1998)*	1.1.1975
IFRS 2	Stocks	1.1.1976
IFRS 3	Les états financiers consolidés *(remplacée par IAS 27 à partir du 1.1.1990)*	1.1.1977
IFRS 4	Comptabilisation des amortissements *(non applicable 1.1.2001, intégrée dans IFRS 16 et IFRS 37)*	1.1.1977
IFRS 5	Les informations que doit fournir l'entreprise dans ses états financiers *(remplacée par IFRS 1 à partir du 1.7.1998)*	1.1.1977
IFRS 6	L'information reflétant les effets de variations de prix *(remplacée par IFRS 15 à partir du 1.1.1983)*	1.1.1978
IFRS 7	Tableaux de flux de trésorerie	1.1.1979

1 – R. Obert, *Pratique des normes IAS / IFRS*, p. 16.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

N° norme	Objet de la norme	Première date d'application
IFRS 8	Changements de méthodes comptables et erreurs *(le titre de la norme avant 2003 était « Résultat de l'exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables »)*	1.1.1979
IFRS 9	Frais de recherche et de développement *(remplacée par IFRS 38 à partir du 1.7.1999)*	1.1.1980
IFRS 10	Événements postérieurs à la date de clôture *(remplacée partiellement par IFRS 37 à partir du 1.7.1999)*	1.1.1980
IFRS 11	Contrats de construction	1.1.1980
IFRS 12	Impôts sur les bénéfices	1.1.1981
IFRS 13	La présentation de l'actif à court terme et du passif à court terme *(remplacée par IFRS 1 à partir du 1.7.1998)*	1.1.1981
IFRS 14	Information sectorielle	1.1.1983
IFRS 15	L'information reflétant les effets de variations de prix *(remplace IFRS 6)*	1.1.1983
IFRS 16	Immobilisations corporelles	1.1.1983
IFRS 17	Contrats de location	1.1.1984
IFRS 18	Revenus des activités ordinaires	1.1.1984
IFRS 19	Avantages du personnel	1.1.1985
IFRS 20	Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique	1.1.1984
IFRS 21	Effets des variations des cours des monnaies étrangères	1.1.1985
IFRS 22	Regroupements d'entreprises	1.1.1985
IFRS 23	Charges d'emprunt	1.1.1986
IFRS 24	Information relative aux parties liées	1.1.1986
IFRS 25	Comptabilisation des placements *(remplacée par IFRS 32 et 39 et IFRS 40)*	1.1.1987
IFRS 26	Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite	1.1.1988
IFRS 27	États financiers consolidés et individuels *(le titre avant 2003 était « États financiers consolidés et comptabilisation des participations dans les filiales ») (remplace IFRS 3)*	1.1.1990
IFRS 28	Comptabilisation des participations dans les entités associées	1.1.1990

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

N° norme	Objet de la norme	Première date d'application
IFRS 29	Information financière dans les économies hyper-inflationnistes	1.1.1990
IFRS 30	Information à fournir dans les états financiers des banques et des établissements financiers assimilés	1.1.1991
IFRS 31	Information financière relative aux participations dans les co-entreprises	1.1.1992
IFRS 32	Instruments financiers : informations à fournir et présentation	1.1.1996
IFRS 33	Résultat par action	1.1.1998
IFRS 34	Information financière intermédiaire	1.1.1999
IFRS 35	Abandon d'activités	1.1.1999
IFRS 36	Dépréciation d'actifs	1.7.1999
IFRS 37	Provision, passifs éventuels et actifs éventuels	1.7.1999
IFRS 38	Immobilisations incorporelles	1.7.1999
IFRS 39	Instruments financiers : comptabilisation et évaluation	1.1.2001
IFRS 40	Immeubles de placement	1.1.2001
IFRS 41	Agriculture	1.1.2003

Ces normes peuvent être regroupées de la manière suivante :
– Normes relatives à la présentation : n° 1,
– Normes relatives à l'évaluation : nos 8, 10, 18, 21,
– Normes relatives à l'information : nos 7, 14, 15, 24, 29, 33, 34,
– Normes relatives à la consolidation : nos 27, 28, 31,
– Normes spécifiques nos 2, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40[1].

Une confrontation précise de ces normes avec le contenu des directives européennes dépasserait le cadre de cet ouvrage[2].

SECTION IX
POSSIBILITÉ D'EXONÉRATION DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE

En application de l'article 70 de la Loi de 2002, il est possible aux sociétés filiales de ne pas appliquer les règles concernant le contenu, le contrôle ainsi que la publicité des comptes annuels si certaines conditions sont réunies dont l'essence est de s'assurer que les comptes en question soient intégrés dans les comptes consolidés

1 – Le tableau ci-dessus est extrait de R. Obert, *Pratique des normes IAS/IFRS*, pp. 17 ss.

2 – Pour une étude détaillée, il est renvoyé aux *Comptes annuels Luxembourg*, Doc. B. 5-01, Examen de la concordance entre les normes comptables internationales IAS 1 à 41 et les directives comptables européennes.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

d'une autre société soumise aux dispositions de la directive. De plus, ce régime est subordonné à certaines conditions de publicité. Enfin, la société mère doit se porter **garant des engagements pris** par la société filiale, en d'autres termes, l'avantage de la responsabilité limitée dont bénéficient les sociétés de capitaux est perdu.

En détail :
– l'entreprise mère relève du droit d'un État membre ;
– tous les associés de la société filiale se sont déclarés d'accord sur l'exemption des dispositions de la directive ;
– l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par la société filiale ;
– les déclarations visées aux deux points précédents font l'objet d'une publicité conformément à l'article 79, alinéa 2, de la Loi de 2002 ;
– la société filiale est incluse dans les comptes consolidés établis par l'entreprise mère conformément à la section XVI de la L.S.C. ;
– l'exemption est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés de l'entreprise mère ;
– les comptes consolidés de l'entreprise mère, le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d'entreprises chargé du contrôle de ces comptes font l'objet d'une publicité de la part de la filiale dans les formes de l'article 9 L.S.C.

D'après l'article 71, Loi de 2002, les sociétés mères peuvent également échapper à l'obligation de faire contrôler et publier leurs comptes annuels si certaines conditions sont remplies, notamment :
– la société mère établit des comptes consolidés sur la base de la directive 2013/34/UE ;
– l'exemption est mentionnée dans l'annexe des comptes annuels de la société mère et dans l'annexe des comptes consolidés établis par la société mère ;
– le résultat de la société mère, calculé conformément aux règles de la Loi de 2002, figure au bilan de la société mère.

En application de l'article 72 de la Loi de 2002, les dispositions de la Loi de 2002 ne s'appliquent pas aux sociétés de capitaux qui sont les associés indéfiniment responsables de l'une des sociétés de l'article visées par la Quatrième directive et qui établissent, font contrôler et publient avec leurs propres comptes et en conformité avec les dispositions du titre II de la Loi de 2002. Les comptes de ces sociétés doivent être établis, contrôlés et publiés conformément à la Quatrième directive, et ces sociétés doivent être intégrées dans les comptes consolidés établis en conformité avec la Septième directive. La loi du 19 décembre 2002 reprend ces dispositions à l'égard de toutes les entreprises.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE III
RÈGLES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS

Malgré les différences indéniables et très importantes qui peuvent exister entre les différentes catégories de sociétés, il convient de ne pas perdre de vue qu'il existe un grand nombre de règles communes à toutes les sociétés ou du moins à la plupart d'entre elles. C'est à ce tronc commun que nous consacrons le présent titre.

CHAPITRE I
LA THÉORIE DE L'ORGANE

La personne morale n'a pas réellement d'existence, expression entendue dans le sens qu'il s'agirait d'un être capable d'exprimer sa volonté, afin de poursuivre son activité économique. Elle doit donc être incarnée par des personnes physiques, capables de décider et d'agir à sa place. Ces personnes sont les organes de la société. S'il est généralement admis qu'une personne morale puisse être l'organe d'une autre personne morale (ce qui vient d'être confirmé par voie législative au Luxembourg), il n'en reste pas moins qu'en définitive ce seront les personnes physiques qui agissent pour la première personne morale et qui incarnent la seconde[1].

SECTION I
CONTENU DE LA NOTION D'ORGANE

Une société, en tant qu'abstraction juridique ne peut, contrairement aux personnes physiques, agir par elle-même : elle doit, inévitablement agir par des personnes physiques, et ceci, que ce soit sur le plan de la **prise des décisions** sociales ou encore sur le plan de la **représentation** de la société à l'égard des tiers.

Traditionnellement, on avait recours au concept de **mandat** pour encadrer juridiquement les relations existant entre les personnes agissant pour le compte et au nom de la personne morale. Cette théorie a également été adoptée par les auteurs de la L.S.C., au moins en ce qui concerne les relations des administrateurs avec la société.

Au fil du temps, cette approche a été supplantée par la **théorie de l'organe** selon laquelle la société agit par ses organes qui engagent directement la société. L'organe, plutôt que de représenter la personne morale, se confond avec cette dernière. Les dirigeants n'agissent pas pour le compte des associés, mais pour le compte de la société. En outre, le contrat de mandat suppose qu'il y ait deux volontés qui s'expriment, celle du mandant et celle du mandataire. Or, la société n'a pas de volonté propre ; la seule volonté qu'elle puisse avoir est celle des dirigeants.

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 184.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« *La théorie de l'organe repose sur l'idée fondamentale que les actes accomplis par les organes sont les actes de la personne morale. La théorie de l'organe est à distinguer de la notion du mandat dans la mesure où elle aboutit à des résultats pratiques fort différents. Le mandataire doit produire une procuration pour établir le principe et le contenu des pouvoirs lui confiés par l'autre personne qui est le mandant. Par opposition à cette situation, il suffit pour l'organe d'établir sa simple qualité d'organe et en cette qualité elle exprime la volonté de la société* »[1].

C'est la loi (et seulement la loi) qui définit quels sont les organes sociaux ainsi que leurs pouvoirs. L'organe ne peut engager la société que dans le cadre de ses compétences. Les parties ne pourront donc pas prévoir des organes autres que ceux prévus par la loi[2].

Conformément à la théorie de l'organe, les dirigeants de la société n'ont pas à produire de **procuration** pour montrer l'étendue de leurs pouvoirs. La seule chose qui puisse leur être demandée est d'établir que leur nomination a été régulièrement publiée. Même à supposer leur nomination irrégulière, cette irrégularité serait purgée par cette publication (art. 100-16 [anc. art. 12] L.S.C.).

Cet article prévoit en son alinéa 1er que « *les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs, membres du directoire ou président, selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou l'acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif* ».

Si le mandataire ne peut accomplir des actes que le mandant doit accomplir en personne, l'organe exprime la volonté propre de la personne et agit à sa place. Une des conséquences de cet état de choses est que la société comparaît en personne par ses organes. De même, l'appel dirigé contre l'organe de la personne morale en cette qualité d'organe est considéré comme dirigé contre la personne morale elle-même[3].

Finalement, les fautes aquiliennes commises par un organe dans l'exercice de ses fonctions engagent directement la responsabilité de la société sur la base de l'article 1382 C.c., alors que cette catégorie de fautes commises par le mandataire n'engage en principe pas la responsabilité du mandant[4].

Il est intéressant de noter que la théorie de l'organe est peu compatible avec l'absence de responsabilité des personnes morales. En effet, selon la théorie de l'organe, les membres de ses organes n'assument aucune responsabilité personnelle pour les actes qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions sociales en engageant directement la personne morale. La situation est opposée en matière pénale où, traditionnellement, seuls les dirigeants assument la responsabilité pénale[5]. Cette situation vient de changer avec la loi du 3 mars 2010 sur la responsabilité pénale des personnes morales.

SECTION II
LIMITES DE LA NOTION D'ORGANE

Les activités des organes sont celles de la société, qui peut donc exercer des activités non seulement commerciales, mais encore agricoles, etc. On pourrait parfaitement

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 185.

2 – En ce sens, v. A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 111.

3 – Cass. b. du 22 décembre 1977, *Pas.,* 1978, I, p. 469.

4 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 186.

5 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1967, p. 312.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

concevoir que ces principes valent également à l'égard des professions libérales notamment celles des médecins, avocats, notaires. Agissant en tant qu'organes de la société, la société serait elle-même médecin, avocat, notaire, p. ex. « *On refuse cependant de pousser aussi loin la théorie de l'organe et la fiction de la personnalité morale. Selon l'opinion généralement reçue, il est certaines professions qui ne peuvent être exercées que par des personnes physiques : si elles le sont par les organes d'une société, cette activité ne peut être celle de la personne morale. De la sorte, les personnes physiques en question ne peuvent en aucune façon échapper à leur responsabilité professionnelle : ce sont elles et non la société qui exercent la profession* »[1].

De même, la jurisprudence retient que les **infractions pénales** de l'organe ne doivent pas être imputées à la société et en tout cas ne doivent pas entraîner de sanctions pénales à l'encontre de la société. La théorie de l'organe conduirait pourtant directement à cette conséquence[2].

Comme l'affirme la jurisprudence luxembourgeoise, l'auteur pénalement responsable de l'infraction est la personne physique par l'intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, « *cette personne physique étant responsable non pas en tant qu'organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l'acte illicite* (CSJ, 29 mars 1992, *Pas.,* 18, p. 450) »[3].

Dans une affaire soumise à la Cour d'appel de Luxembourg, un notaire était critiqué pour avoir versé le produit de vente d'un immeuble ayant appartenu à une société anonyme sur le compte bancaire personnel d'un administrateur (B) de la société. La société A invoquait que le notaire ne pouvait être considéré comme libéré étant donné que les pouvoirs de représentation de la société étaient confiés conjointement à deux administrateurs (double signature). La Cour d'appel rejetait cette argumentation en faisant valoir que B agissait non pas comme mandataire de la société, mais en tant **qu'organe** de celle-ci.

« *À la différence d'un mandataire, l'organe ne représente pas la personne morale, il "est" la personne morale* ». Aucun mandat d'encaissement n'avait donc à être fourni par l'administrateur. L'administrateur B, lorsqu'il fournissait les coordonnées bancaires au notaire agissait tant en nom personnel qu'en tant que mandataire du second administrateur[4].

SECTION III
DIVERSITÉ DES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

Durant la vie de la personne morale (que constitue la société), la prise de nombreuses décisions concernant son activité sociale est nécessaire. La société doit donc avoir des organes qui vont décider tant sur son fonctionnement interne que sur la façon de réaliser l'objet social dans ses contacts avec des tiers. L'ensemble de ces décisions prises par tous les organes sociaux font partie de la gestion au sens large de la société[5]. Afin de pouvoir agir à l'égard du monde extérieur, la société doit

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 175.

2 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 186.

3 – TA corr. du 31 mars 2004, jugt 1196/04, *BIJ*, 9/2004, p. 187.

4 – CA du 4 juin 2008, n°s 31.798 et 32.953, ID 15890.

5 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 184.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

encore pouvoir compter sur des **organes de représentation**. Souvent, les mêmes personnes sont chargées de la gestion et de la représentation de la société. Dans d'autres cas, il existe une **séparation fonctionnelle** dans la mesure où certaines personnes sont chargées uniquement de la représentation de la société.

La société doit encore et sur une base continue vérifier que sa gestion est bien faite : il lui faut des **organes de contrôle**. Cette fonction est parfois exercée par des organes spécifiques (commissaires).

SECTION IV
LA NOTION D'ORGANE STATUTAIRE

Cette expression semble avoir été utilisée pour la première fois par la Cour de cassation belge en 1940[1]. En réalité, les organes statutaires ne sont pas de véritables organes dans la mesure où la loi seule peut prévoir de tels organes. Juridiquement, ces organes statutaires sont donc des **mandataires** qui représentent la société et qui dans les relations internes tiennent leurs pouvoirs du conseil d'administration par l'effet d'une subdélégation conformément à l'article 1994 C.c.[2].

Cette question doit être séparée de celle de savoir si une société peut ponctuellement déléguer ses pouvoirs pour l'une ou l'autre opération déterminée à un tiers. La réponse à cette question est positive sans la moindre hésitation.

« *Le conseil d'administration peut aussi, même en l'absence d'une disposition statutaire, et en vertu de l'article 1994 du Code civil, déléguer ses pouvoirs à un administrateur et même à une personne étrangère à la société, mais seulement pour une ou plusieurs affaires déterminées ou pour une série d'affaires du même ordre ; le délégué ne devient alors le mandataire de la société que dans la limite des pouvoirs spéciaux conférés* »[3].

Les statuts de la société peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement (art. 441-5 [anc. art. 53], L.S.C.)[4]. La Cour de cassation belge admet expressément que la société anonyme peut agir en justice à l'intervention d'un « organe statutaire »[5].

La notion d'organe statutaire doit être distinguée de celle de **délégué à la gestion journalière**. Celui-ci est un organe non pas statutaire mais **légal**, bien que **facultatif**.

Dans quelle mesure les associés peuvent-ils doter leur société d'organes autres que ceux prévus par la loi ? La question est donc de savoir si en dehors d'organes qui sont facultativement prévus par la loi et qui n'existent que dans la mesure où ils sont décidés par les statuts (tels que la gestion journalière), les statuts peuvent valablement prévoir un organe qui ne remplit pas une fonction prévue par la loi.

---

1 – Cass. du 8 janvier 1940, *Pas*., I, 2.

2 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 311.

3 – Houpin et Bosvieux, T. 2, n° 1095.

4 – Les dispositions correspondantes applicables aux S.C.A. et aux S.à r.l. sont prévues respectivement aux articles art. 600-6 (anc. art. 103) et 710-15 (5) (anc. art. 191*bis* (5)) L.S.C., ID 7520.

5 – Cette notion a apparemment été utilisée la première fois par un arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1940 (*Pas*., 1940, I, 2).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Pour la doctrine, « *le prétendu organe statutaire d'une société anonyme n'est en réalité que le mandataire désigné par cette société à l'intervention de son conseil d'administration pour l'accomplissement d'une catégorie d'actes déterminés par les statuts* »[1].

Cette possibilité, et donc le concept « d'**organe statutaire** », est majoritairement rejetée par la doctrine : « *Les conséquences de la théorie de l'organe sont exorbitantes du droit commun du mandat. Elles ne doivent donc jouer que dans le cadre des fonctions prévues par la loi : fonctions qui sont indispensables au fonctionnement de la personne morale. Les soi-disant "organes" statutaires doivent donc être traités comme des mandataires sociaux désignés dans les statuts* »[2].

Une voix plus nuancée s'exprime comme suit : « *Sans doute, cette idée est-elle liée à la conception même que l'on peut se faire de la personnalité morale. Si l'on admet que les personnes morales existent indépendamment de toute intervention de la loi positive, comme des réalités susceptibles de s'exprimer elles-mêmes à l'exemple des êtres humains, dès qu'existe un groupement doté d'une possibilité d'expression collective constitué pour des intérêts légitimes, on pourra être enclin à admettre assez aisément qu'il appartient aux membres du groupement de déterminer eux-mêmes quels seront les organes qui assureront l'expression de leur volonté…* A fortiori*, nous paraît-il devoir en être ainsi si l'on considère comme les derniers développements de la doctrine moderne paraissent devoir y conduire, que la personnalité morale résulte d'un procédé de pure technique juridique dont les effets sont essentiellement relatifs et limités et qui constitue en définitive une application du procédé de l'assimilation fictive* »[3].

En général, on entend par organe « *les personnes dont le pouvoir de représenter la société dérive d'une fonction prévue par la loi*. *Dans cette conception, il n'y a pas d'autres organes que ceux qui sont prévus par la loi : les organes sont des organes légaux* »[4].

Malgré l'utilisation par la Cour de cassation belge de la notion d'organe statutaire, il faut à notre sens considérer que les personnes morales ne peuvent se voir attribuer d'autres organes que ceux que la loi leur attribue, étant donné que certains organes peuvent être purement facultatifs.

SECTION V
ORGANE INDIVIDUEL – ORGANE COLLÉGIAL

Le caractère d'organe collégial du conseil d'administration résulte en premier lieu de l'article 444-3 [anc. art. 64] L.S.C. qui dans sa version actuelle prévoit que : « *Les administrateurs, les membres du directoire ou du le conseil de surveillance et les commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes […]* ». Les décisions doivent donc être prises comme corps[5].

1 – L. Simont et P. van Ommeslaghe, « Cour de cassation du 17 mai 1962 », *R.C.J.B.*, 1964, p. 86.

2 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 187.

3 – L. Simont et P. van Ommeslaghe, « Cour de cassation du 17 mai 1962 », *R.C.J.B.*, 1964, p. 80.

4 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 186.

5 – V. J. Guillery, *Commentaires législatifs*, T. II, n° 60.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La première conséquence de ce caractère collégial de ces organes est le **principe délibératif** qui a valeur absolue, notamment au sein du conseil d'administration. « *Consultés individuellement, les administrateurs ne peuvent arrêter de résolution, ce même en cas d'unanimité* »[1]. Un autre auteur s'exprime dans le même sens : « *Le conseil d'administration est conçu et organisé en vue de la délibération. C'est dans l'affrontement des idées, des théories, que doit se dégager la volonté du conseil ; cet affrontement est positif et créateur ; il permet à chacun de se faire une opinion motivée et de se prononcer en pleine connaissance de cause* »[2], et surtout « *Le fait que tous les administrateurs paraissent au départ d'accord n'y change rien, car c'est parfois au cours de la discussion que se présentent des arguments susceptibles d'entraîner un changement d'opinion* »[3].

Si l'article 444-3 L.S.C. retient ainsi ce principe délibératif, il abandonne aux statuts d'en organiser le fonctionnement. Dans le silence des statuts, ce sont les règles des **assemblées délibérantes** qui s'appliquent. Selon la doctrine, cette liberté d'organiser le mode de délibération a toujours permis aux sociétés de prévoir la délibération par écrit (ce qui est en pratique très lourd) ou encore par conférence téléphonique (la seule condition étant finalement de permettre l'échange de vues entre administrateurs)[4].

La Loi de Modernisation, tout en maintenant le concept des assemblées délibérantes, a contribué à préciser les **conditions de prise de décision** (du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance), et ceci, dans l'article 444-4 qui introduit des **règles supplétives** (applicables donc sauf dispositions contraires des statuts) :

- **quorum** : la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés ;
- **prise de décision** : elle se fait à la majorité des membres présents ou représentés, étant entendu que si un président a été élu, la **voix du président est prépondérante** en cas de partage des voix (sauf disposition contraire des statuts).

La Loi de Modernisation (art. 444-3 L.S.C.) a permis aux statuts d'autoriser la prise de décision unanime par écrit des organes visés.

Le législateur luxembourgeois a par ailleurs tenu compte de l'évolution technique en ce domaine en introduisant dans la L.S.C. un nouvel article 64*bis* (par la loi du 25 août 2006) qui permet au règlement intérieur, sauf interdiction par les statuts, de réputer présents aux réunions, les administrateurs, etc. qui participent à la réunion par visioconférence ou autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants (actuellement art. 444-4 (3) L.S.C.).

Si ledit article dispose qu'une telle réunion est réputée se dérouler au siège de la société, il ne faut pas oublier qu'une telle disposition n'est certainement pas

1 – V. P.-E. Partsch, « Dans quelle mesure le conseil d'administration d'une société anonyme peut-il adopter des décisions sans réunion physique de ses membres ? », *R.P.S.*, 1995, p. 198.

2 – P.-G. Gourlay, *Le conseil d'administration de la société anonyme, Organisation et fonctionnement*, p. 155, cité par P.-E. Partsch, « Dans quelle mesure le conseil d'administration d'une société anonyme peut-il adopter des décisions sans réunion physique de ses membres ? », *R.P.S.*, 1995, p. 198.

3 – P.-G. Gourlay, *Le conseil d'administration de la société anonyme, Organisation et fonctionnement*, p. 155, cité par P.-E. Partsch, « Dans quelle mesure le conseil d'administration d'une société anonyme peut-il adopter des décisions sans réunion physique de ses membres ? », *R.P.S.*, 1995, p. 198.

4 – V. P.-E. Partsch, « Dans quelle mesure le conseil d'administration d'une société anonyme peut-il adopter des décisions sans réunion physique de ses membres ? », *R.P.S.*, 1995, p. 205.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

opposable à une administration fiscale étrangère ; p. ex., tous les 5 administrateurs de la S.A. luxembourgeoise participent à la réunion du conseil à partir de leurs bureaux parisiens respectifs.

Cet article implique donc indiscutablement que les membres du conseil d'administration ou du collège des commissaires, pris individuellement, n'ont aucun pouvoir de décision, le conseil d'administration et le collège des commissaires ne pouvant agir que collégialement[1]. Les administrateurs pris individuellement n'ont donc pas d'autre pouvoir que celui de participer au collège que constitue le conseil d'administration[2].

De même, dès qu'il y a pluralité de commissaires, ceux-ci forment nécessairement un collège délibérant et dès lors ne peuvent agir isolément en l'absence d'un mandat que le collège conférerait à certains de ses membres[3].

Mais la doctrine dominante considère que ce caractère collégial n'affecte que les pouvoirs de décision de ces organes et nullement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Quant aux commissaires, leur pouvoir individuel d'investigation a pu être fondé sur la loi même qui leur reconnaît « *un droit illimité de surveillance et de contrôle* ». De cette disposition on a déduit que si ce **droit est illimité**, il ne pouvait être limité par le veto de certains membres du collège et devait donc pouvoir être exercé individuellement[4].

Cette disposition applicable aux commissaires doit, selon la doctrine, être étendue aux administrateurs. Il en est ainsi pour la raison que les membres d'un collège délibérant doivent pouvoir prendre individuellement toutes les informations nécessaires pour pouvoir participer en connaissance de cause aux délibérations du collège auxquelles ils participent[5]. Finalement, ce droit d'investigation peut évidemment se déduire de la responsabilité qu'assume chaque administrateur relativement aux décisions du conseil d'administration qui est même solidaire en ce qui concerne les violations des lois et des statuts. Cette solution est confirmée par la jurisprudence française : « *qu'un administrateur de société tient de sa qualité le droit de prendre connaissance de tous documents de la société et qu'il a un intérêt manifeste à connaître exactement les actes qu'on lui demande de couvrir de son autorité personnelle ; que ni le principe de responsabilité du mandant, ni le principe du secret des affaires sociales ne peuvent faire échec à ce droit absolu* »[6].

L'organe individuel est habilité à incarner seul la société alors que l'organe collégial ne peut incarner la société que par **l'action conjointe** de ses membres. La question se pose alors de savoir s'il suffit d'une majorité ou s'il faut que tous les membres soient concernés. Il faut dans ce cas distinguer selon qu'il s'agit d'un organe de gestion ou d'un organe de représentation.

---

1 – V. L. Simont, « L'administrateur d'une société anonyme agissant isolément a-t-il un droit d'investigation individuelle ? », *R.P.S.*, 1963, p. 191.

2 – V. L. Simont, « L'administrateur d'une société anonyme agissant isolément a-t-il un droit d'investigation individuelle ? », *R.P.S.*, 1963, p. 190.

3 – V. L. Simont, « L'administrateur d'une société anonyme agissant isolément a-t-il un droit d'investigation individuelle ? », *R.P.S.*, 1963, p. 191.

4 – V. L. Simont, « L'administrateur d'une société anonyme agissant isolément a-t-il un droit d'investigation individuelle ? », *R.P.S.*, 1963, p. 193.

5 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, T. IV, p. 135.

6 – Trib. com. Seine du 11 juillet 1952, *Journal des sociétés*, 1955, p. 350.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'organe de gestion, selon des conditions souvent imposées par la loi, prend des décisions à la majorité. L'organe de représentation collégial, s'il représente la société dans les actes, est nécessairement collégial[1] [2].

SECTION VI
POUVOIR LÉGAL ET POUVOIR STATUTAIRE DE REPRÉSENTATION

Depuis l'entrée en vigueur de la **Première directive** en matière de droit des sociétés, il est important de distinguer entre le pouvoir légal de représentation et le pouvoir statutaire de représentation. La différence entre les deux est que l'organisation légale du pouvoir de représentation est opposable aux tiers qui sont censés connaître la loi. En revanche, les aménagements apportés par la société à cette organisation légale sont en principe inopposables aux tiers : ils ne concernent que la responsabilité des organes dans les relations internes de la société[3].

Le pouvoir légal de représentation appartient aux organes directement prévus par la loi (p. ex., conseil d'administration, gérant de la S.à r.l.), y compris ceux qui sont prévus par les statuts dans les conditions établies par la loi (tel le délégué à la gestion journalière).

Le **pouvoir légal de représentation** est général avec donc la conséquence que les administrateurs chargés de représenter la société ont nécessairement ce pouvoir général (de représentation). Il en va de même du délégué à la gestion journalière mais, en ce cas, en ce qui concerne cette gestion journalière seulement[4].

Il est possible de procéder à des aménagements de ce pouvoir de représentation, et ceci, dans des limites légalement prévues ; ces aménagements doivent faire l'objet d'une publicité adéquate faute de quoi ils ne sont pas opposables aux tiers[5]. Sont visées notamment les clauses qui prévoient un organe individuel de représentation de la société anonyme alors que dans ce genre de société la représentation est en principe collégiale. Il en va de même de la clause qui crée un organe collégial ou individuel de représentation en matière de gestion journalière.

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 187.
2 – J. van Ryn, *Principes de droit commercial*, 1re éd., p. 384.
3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 219.
4 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 219.
5 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 220.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
LES DIFFÉRENTS ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

Dans chaque société, il existe plusieurs organes par le biais desquels la société agit. Ces organes sont prévus limitativement par la loi. Parfois, les statuts de la société prévoient d'autres organes qui sont alors souvent désignés par le terme d'**organes statutaires**.

SECTION I
L'ASSEMBLÉE DES ASSOCIÉS

Dans toutes les sociétés, il existe une assemblée des associés, organe de décision final de la société, qui a le pouvoir de nommer et de révoquer les autres organes de la société, de procéder à des décisions importantes de gestion ou de contrôle dans la mesure où elle est habilitée à approuver les comptes, de décider de l'utilisation des résultats, etc.

Dans le schéma classique de fonctionnement de toutes les formes de sociétés, les associés délibèrent pour prendre certaines décisions (celles qui sont les plus importantes) concernant la société. Dans les sociétés de personnes, le petit nombre d'associés fait qu'il n'est pas besoin d'organiser des réunions formelles d'une assemblée générale des associés. Dans les autres sociétés, les décisions sont en principe prises en assemblée générale.

■ § 1 – Pouvoirs de l'assemblée générale

Avec la Première directive (article 53 L.S.C. dans la forme introduite par la loi du 23 novembre 1972 transposant les articles 9.2 et 9,3 de la Première directive, actuellement art. 441-5 L.S.C.), l'assemblée générale des sociétés de capitaux a perdu son pouvoir résiduaire qui lui était reconnu auparavant. Ce pouvoir résiduaire a été transféré au conseil d'administration ou aux gérants.

« *Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale […]* » (art. 441-5, al. 1er, L.S.C.).

Néanmoins, certains pouvoirs lui sont attribués impérativement par la loi. Il s'agit notamment du pouvoir de modifier les statuts, de l'approbation des comptes annuels, de l'affectation des résultats, de la décharge des organes de gestion et de contrôle, de l'émission d'actions convertibles (dans le cas des sociétés anonymes). Les statuts pourraient confier d'autres pouvoirs à l'assemblée[1].

■ § 2 – Exercice du droit de vote

Il faut noter en premier lieu que les dispositions relatives à l'exercice du droit de vote sont **d'ordre public**, toute dérogation est donc prohibée.

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 188.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La loi institue d'abord le suffrage universel en faveur de tout associé. Aucun actionnaire ne peut être éliminé de l'assemblée : il suffit qu'il ait une seule action. Aucun minimum d'action n'est donc imposé.

Autrefois, la loi contenait des limitations du droit de vote au détriment des actionnaires importants : ainsi la Loi de 1915 contenait la limitation qu'aucun actionnaire ne pouvait voter pour plus de 20 % du nombre des actions émises. Cette mesure était destinée à éviter que la foule des petits actionnaires ne soit écrasée par quelques gros porteurs[1]. Une telle règle n'allait pas sans donner lieu à certains résultats surprenants et peu justifiables. Les incongruités inhérentes à ce système peuvent être montrées au moyen de l'exemple suivant : supposons un actionnaire qui détient 500 actions avec lesquelles il participe à l'assemblée générale. En face de lui se trouvent deux actionnaires ayant ensemble trois actions. Ces trois actions représentent 3/5e des actions participant au vote. Le gros actionnaire qui vote avec deux actions est ainsi mis en minorité par les deux autres actionnaires détenant ensemble trois actions[2]. Ainsi, cette règle conduisait directement à de véritables bouleversements ridicules des majorités.

Cette disposition a entre-temps été abolie, et ceci, par la loi du 24 avril 1983[3]. Lors de l'adoption de cette loi, dont l'objet était la transposition de la Deuxième directive CEE qui renforçait la protection des actionnaires minoritaires, il a été considéré qu'une protection spéciale de ces minoritaires n'était plus nécessaire[4].

La version initiale du projet de loi n° 5730 (art. 71) avait autorisé les statuts à limiter volontairement le nombre de voix dont chaque titulaire pouvait disposer dans les assemblées générales des titulaires de parts bénéficiaires avec droit de vote. Cette disposition n'a pas été adoptée. En revanche, a été adoptée par la Loi de Modernisation la faculté pour les statuts de prévoir « *que le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d'engagement* ».

Une autre innovation de la Loi de Modernisation (prévue en son article 450-1 (9) [anc. art. 67] L.S.C.) est que tout associé « *peut à titre personnel s'engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l'associé renonçant et s'impose à la société dès la notification à cette dernière* ».

Une telle renonciation peut, à première vue, surprendre, car on aurait tendance à croire que chaque actionnaire serait désireux de voter avec le maximum de droits de vote possible. La renonciation au droit de vote à titre personnel par les actionnaires a été non prévue dans la version initiale du projet de loi n° 5730, mais elle a été introduite seulement en 2015 par la voie d'un amendement par la Commission juridique de la Chambre des députés. Le commentaire de cette disposition se lit comme suit : « *Un autre exemple de nécessité à voir limiter l'exercice des droits de vote dans le chef de certains actionnaires est celui d'investisseurs qui, pour des raisons réglementaires, comptables ou fiscales, ne peuvent dépasser certains seuils*

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 217, ID 11305.

2 – Projet de loi portant révision de la loi sur les sociétés commerciales, *Doc. parl.*, n° 5730/4, Avis du Conseil d'État, p. 104, ID 13321.

3 – Loi du 24 août 1983, *Mém. A* 35 du 16 mai 1983, p. 864, ID 12178.

4 – V. avis du Conseil d'État, *Doc. parl.*, n° 2474-3, p. 3, ID 9798.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de droits de vote. Ceci peut notamment être le cas pour des institutions financières soumises à un contrôle prudentiel. Pour étayer la sécurité juridique entourant de tels arrangements légitimes, il paraît utile de voir reconnaître par voie législative la validité et l'opposabilité de telles renonciations librement consenties. Le texte proposé précise qu'une telle renonciation est faite à titre personnel, et n'affecte donc pas les droits attachés à l'action ou la part en tant que telle. En cas de cession à un autre actionnaire ou associé, la renonciation à l'exercice du droit de vote ne suit pas l'action ou la part […] »[1].

Une autre innovation prévue par la version initiale du projet de loi n° 5730 a été, en vue de la fidélisation des actionnaires, d'introduire un double droit de vote en faveur des actionnaires qui conservent leurs actions pendant **plus de deux ans** : cette solution inspirée de l'article 225-123 C.com. fr. qui permet aux statuts de prévoir un tel droit de vote double à l'égard des actions pour lesquels l'actionnaire justifie d'une inscription nominative de deux années au moins au nom du même actionnaire. Cette possibilité n'a pas été retenue dans la version finalement adoptée de la Loi de Modernisation. Sans doute les critiques (en fait l'opposition formelle) du Conseil d'État à l'égard de cette solution ont-elles été à l'origine de cet abandon. Selon le Conseil d'État, le double droit de vote serait contraire au principe que dans la société anonyme le droit de vote est attaché aux actions et non pas à la personne de l'actionnaire. Par cette proposition serait « *introduit par un mélange de genres entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux une incongruité juridique [qui] se heurte dès lors à un principe général du droit des sociétés qui attache les droits à la personne de l'associé dans la société de personnes et aux titres dans les sociétés de capitaux* »[2].

A – Vote par mandataire

En principe, l'associé se présente en nom à l'assemblée des associés et exerce son droit de vote proportionnellement au nombre des titres qu'il détient dans la société dont il fait partie. « *Il convient de rappeler que la qualité d'actionnaire doit s'apprécier au moment de la décision litigieuse. En effet, le nouvel actionnaire adhère lors de la souscription aux statuts de la société en cause tels qu'ils existent à ce moment. Il entre dans la société dans l'état où celle-ci se trouve à la date de l'acquisition et ne peut, dans un souci de sécurité juridique, remettre en cause toutes les décisions prises par les organes de la société avant qu'il ne devienne actionnaire* (*cf.* Trib. com. Bruxelles, 6 juin 1977*, Rev. prat. des soc.*, 1977, p. 202 *;* TA Lux., 1er décembre 2010, n° 111.689 du rôle) »[3]. Au cas où l'associé est empêché, il lui est loisible de désigner un mandataire qui pourra voter à sa place. Cette possibilité d'exercer son droit de vote par un mandataire est d'**ordre public**, et ne peut donc pas faire l'objet de limitations par les statuts. Telle est la solution retenue par l'article 450-1 (3) [anc. art. 67] L.S.C. : « *Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le droit de voter par lui-même ou par mandataire […]* ».

1 – *Doc. parl*., n° 5730/5, p. 40, ID 23099.

2 – *Doc. parl*., n° 5730/4, Avis du Conseil d'État, p. 18, ID 13321.

3 – TA Lux. du 25 février 2014, nos 136113 et 136114 du rôle, ID 24357.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'intention du législateur a été de faciliter au maximum l'expression du droit de vote par l'actionnaire en lui permettant d'exprimer sa volonté même s'il est empêché[1].

Traditionnellement, il était admis que les actions de la S.A. doivent obligatoirement être à valeur égale ; pour écarter tout doute sur ce point l'article 47 L.S.C. disposait : « *Le capital des sociétés anonymes se divise en actions d'égale valeur, avec ou sans mention de valeur* ». La Loi de Modernisation a supprimé le passage souligné de la phrase précédente en permettant ainsi l'émission d'actions de valeur inégale. Ce changement induit une autre modification, à savoir celle de l'article 450-1 (5) [anc. art. 67] L.S.C. relatif à la tenue des assemblées générales ; une fois le principe des parts d'égale valeur abandonné, il fallait déterminer les droits de vote attachés à ces actions désormais (et le cas échéant) de valeur inégale. Comme souvent, les auteurs de la Loi de Modernisation se sont inspirés du droit belge (concrètement de l'article 451 du Code belge des sociétés en adoptant la nouvelle version du paragraphe 5 de cet article ainsi libellé : « *Lorsque les actions sont de valeur inégale ou que leur valeur n'est pas mentionnée, sauf disposition contraire des statuts, chacune d'elle confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible ; il n'est pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à l'article 450-4* ».

En clair, ceci signifie que, sauf si les statuts prévoient autre chose, les actions de valeur inégale confèrent un droit de vote proportionnel à leur participation dans le capital social, la quotité la plus faible comptant pour une voix. Cette règle n'est que supplétive (dans le silence des statuts). Lesdits statuts peuvent donc parfaitement maintenir la règle traditionnelle « une action une voix ». Avec des actions à valeur inégale, cette règle qui paraît comme l'incarnation du principe d'égalité entre associés s'avère être le contraire de cette égalité. Supposons que A souscrit 10 actions à un euro chacune alors que B souscrit 1 action à 10 euros. Si les statuts prévoient le principe une action une voix, alors A aura en définitive un droit de vote multiple (10 pour 1) par rapport à B[2].

Il ne s'agit finalement que de l'application d'un principe général en vertu duquel tout acte juridique peut être exercé par un mandataire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un droit indissolublement attaché à la personne. Tel n'est évidemment pas le cas des droits des associés dans les sociétés de capitaux[3].

Si les statuts ne peuvent interdire le vote par mandataire, ils peuvent l'aménager. Ainsi est-il fréquent que les statuts prévoient que la procuration ne puisse être donnée qu'à un actionnaire. Cette solution se comprend dans la mesure où elle évite qu'un tiers ne soit impliqué dans les affaires sociales.

Les procurations pourront soit être « *en blanc* », soit comporter des instructions plus ou moins précises qui imposent au mandataire de voter dans un sens donné.

La pratique des mandats en blanc est licite bien que nullement réglementée au Luxembourg (contrairement à la situation prévalant en Belgique).

1 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 245.

2 – Selon l'exemple donné par L. Schummer et S. Weydert, *Le nouveau régime des titres, La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, p. 180.

3 – L. Maeyens et P. Roose, « Syndicats d'actionnaires de société anonyme », *R.P.S.*, 1964, p. 63.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Beaucoup plus rare est la clause qui interdit d'être porteur de **plus d'une procuration**. En pratique, le conseil d'administration profite très largement des procurations qui sont émises par des actionnaires peu intéressés par la marche des affaires sociales en en réunissant un très grand nombre et en leur permettant ainsi d'écarter les votes qui leur seraient néfastes[1].

En pratique, les dirigeants en place essaient de collecter un maximum de mandats en joignant à la convocation un formulaire de procuration les invitant à le renvoyer dûment signé[2]. Ainsi les administrateurs en place disposent d'un nombre important de voix qu'ils pourront utiliser à leur guise. S'agissant d'une procuration en blanc, rien ne garantit que ce droit de vote soit exercé dans l'intérêt du mandant, de l'actionnaire.

Lors des assemblées extraordinaires les procurations seront **jointes à l'acte notarié** et signées *ne varietur*, mais sans qu'elles ne fassent l'objet d'une publication au RESA (voir article 100-10 [anc. art. 8] L.S.C.). Lorsque certains des associés figurent à l'acte par l'intermédiaire d'un mandataire, leur consentement ne peut être constaté que si la preuve est faite du consentement du mandataire et de celui du mandant. La publication doit donc comprendre non seulement le texte du pacte social, mais encore celui de toutes les procurations annexées[3].

La possibilité de voter par mandataire est utilisée de manière particulièrement fréquente au Luxembourg. Elle est encore beaucoup facilitée par la flexibilité de la pratique :

– même lors des assemblées à tenir devant notaire (donc les assemblées constitutives ou celles qui modifient les statuts), il est suffisant de produire une procuration **sous seing privé** ;
– pour procéder à la constitution de la société (ou encore à la modification des statuts sociaux), les notaires se satisfont d'une procuration par fax ou fichier PDF, étant entendu que l'original de la procuration devra suivre peu de temps après la passation de l'acte.

Le mandat peut être **irrévocable** (malgré l'entorse à la libre expression du droit de vote que certains ont pu y voir[4]) et il peut être permanent pour la raison que le droit de vote est un droit aliénable au moins dans les relations entre cédant et cessionnaire[5] : conférer un mandat irrévocable et permanent ou aliéner ce droit de vote revient à la même chose[6]. Ce droit n'est pas absolu et il ne peut notamment pas être exercé contrairement aux règles organiques concernant le suffrage universel « *au profit de ceux qui cherchent à dominer la société par une autre voie que la représentation du capital investi* »[7].

B – Droit de vote en cas d'indivision et d'usufruit

Dans ces assemblées d'associés (dans lesquelles le principe est que tous les associés ont le droit de vote), il y a lieu de déterminer qui est le titulaire de ce droit

1 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 246.
2 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 246.
3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 23, ID 11308.
4 – V. P. Demeur, note sous Cour de cass. b. du 13 janvier 1938, *R.P.S.*, 1938, p. 88.
5 – V. P. Demeur, note sous Cour de cass. b. du 13 janvier 1938, *R.P.S.*, 1938, p. 88.
6 – V. P. Demeur, note sous Cour de cass. b. du 13 janvier 1938, *R.P.S.*, 1938, p. 88.
7 – V. P. Demeur, note sous Cour de cass. b. du 13 janvier 1938, *R.P.S.*, 1938, p. 90.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dans les cas d'indivision ou de démembrement de propriété, concrètement en cas de séparation entre usufruit et nue-propriété. La loi luxembourgeoise prévoit une disposition au moins partiellement applicable à ces cas, à savoir l'article 430-2 [anc. art. 38] L.S.C. (dont le champ d'application est toutefois limité aux sociétés par actions) et selon laquelle, en cas de pluralité de propriétaires d'une action, la société a le droit de suspendre ce droit jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée et qui soit propriétaire à l'égard de la société. Cette solution peut s'appliquer aux cas d'indivision.

La solution de l'article 430-2 [anc. art. 38] L.S.C. est destinée à éviter à la société les complications d'écritures et de comptabilité inhérentes à la situation où un titre est détenu par plusieurs propriétaires, et ceci, en cas de divergence de vues entre actionnaires. Ceci ne signifie pas que l'indivisibilité cesse dès que les copropriétaires ont désigné un représentant unique. Une telle solution reviendrait en effet à autoriser les débiteurs à céder leurs obligations sans le consentement de leur créancier. La société conserve donc le droit de réclamer à celui des copropriétaires qu'elle choisit les versements devenus exigibles. En décider autrement permettrait « *aux ayants cause d'un actionnaire de compromettre la situation de la société en désignant celui d'entre eux qui serait le moins solvable* »[1].

Le vote ne peut être divisé : il appartiendra aux actionnaires de régler les divergences[2].

Quant aux cas d'**usufruit** (et donc de nue-propriété), la loi était muette. La doctrine enseignait en général que, dans ces cas, les statuts régleront qui est à l'égard de la société le seul à pouvoir exercer le droit de vote attaché à ces titres[3]. Pour partie, la doctrine semblait également préconiser de reprendre la solution française selon laquelle le droit de vote serait attribué à l'un ou à l'autre selon la nature des décisions à prendre. Lorsqu'il s'agit de décider de l'utilisation des résultats annuels (assemblée générale ordinaire), alors l'usufruitier serait appelé à voter. En revanche, quand il s'agissait de décisions concernant la substance (et non pas les revenus courants), alors le nu-propriétaire aurait le droit de vote (assemblées extraordinaires)[4].

Il est vrai que cette règle est très loin d'être d'une application facile dans la mesure où beaucoup de décisions touchent à la fois au capital et au revenu. Ainsi en est-il lorsque l'assemblée se prononce sur l'affectation du bénéfice annuel[5]. En principe, cette décision concerne le revenu courant, mais a directement une incidence sur le capital de la société en affectant donc les résultats annuels de la société. Les exemples montrant cette connexion entre revenu et capital pourraient facilement être multipliés.

Ces incertitudes appartiennent au passé dans la mesure où la Loi de Modernisation a introduit un nouvel article 1852*bis* C.c. ainsi libellé :

Sauf dispositions contraires des statuts, si un titre est grevé d'un usufruit notifié à la société ou accepté par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 :

1° le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier, et

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 165, ID 11305.

2 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 249.

3 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 249.

4 – V. en ce sens, A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 306.

5 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 250.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2° l'usufruitier a droit au bénéfice que la société décide de distribuer.
En cas de rachat par la société de ses propres titres, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont respectivement droit à la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit portant sur ces titres.
Lors de la dissolution de la société, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit exercé conformément à l'article 587 sur les sommes versées au nu-propriétaire ou sur la valeur des biens qui lui ont été remis.

Cette disposition est de nature supplétive (du moins dans ses deux premiers alinéas) ; il est loisible aux parties de prévoir d'autres solutions de répartition des droits démembrés.

C – Droit de vote en cas de gage sur titres

Lorsque les actions sont données en gage, le droit de vote reste chez le débiteur. Le créancier gagiste n'est que le détenteur précaire des titres. La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière permet toutefois de déroger à cette règle en accordant le droit de vote au créancier gagiste (art. 9 de la loi). Une difficulté pratique surgit du fait que l'actionnaire désireux de voter à l'assemblée générale est tenu de déposer les titres au siège de la société ou encore auprès d'une banque. Le gage subsiste si d'un commun accord les titres sont remis dans les mains d'un tiers[1].

D – Vote par correspondance

La loi du 25 août 2006 a introduit la possibilité pour les statuts de prévoir le vote par correspondance dans la L.S.C., et ceci, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts (art. 450-1 (4) [anc. art. 67 (3*bis*)] L.S.C.).

E – Suspension du droit de vote

Lorsqu'un actionnaire ne remplit pas ses obligations (en l'occurrence celle de répondre aux appels de fonds faits sur les actions non entièrement libérées), son droit de vote sera suspendu jusqu'à la libération des fonds (art. 450-1 (8) [anc. art. 67, (7)] L.S.C.). « *Le législateur sanctionne une faute dans le souci de protéger la société – et indirectement les autres actionnaires et ses créanciers* »[2].

F – Assistance d'un avocat à l'assemblée

La question de savoir si un actionnaire peut se faire assister par un avocat à une assemblée générale des actionnaires a été répondue par l'affirmative par la jurisprudence[3].

1 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 250.
2 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 251.
3 – V. notamment Trib. com. Anvers du 6 avril 1984, *R.S.C.*, 1984, p. 645.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

G – Présence des administrateurs à l'assemblée

Par décision de référé (confirmée en appel) il a été décidé qu'il ne serait pas critiquable que les administrateurs ne soient pas convoqués à une assemblée générale. Ce moyen avait été invoqué par des administrateurs dans une situation où la présence ou la représentation de tous les associés à l'assemblée dispensait des formalités usuelles de convocation (notamment que l'assemblée est réunie par le conseil d'administration).

« *De même, il n'y a aucun texte qui prévoie la présence obligatoire des administrateurs pour garantir la validité des délibérations prises ; l'absence des administrateurs n'est encore sanctionnée par aucun texte. Aucun texte n'exige la convocation des administrateurs avant leur révocation* »[(1)].

■ § 3 – Cas de nullité des assemblées

A – Avant la Loi de Modernisation

Il y a lieu de distinguer les assemblées modificatives des statuts des autres assemblées. En ce qui concerne les premières, la loi (art. 100-19 [anc. art. 12*quater*] L.S.C.) précise que les règles de forme de *prononciation* de la nullité sont applicables (dans les mêmes termes que celles applicables en matière de constitution). En clair, ceci signifie que la nullité doit être prononcée par décision judiciaire et qu'elle ne produit aucun effet rétroactif.

Signalons une différence importante par rapport à la loi belge dont l'article 13*quater* retient que la nullité ne produit ses effets qu'à partir du moment où elle est « demandée » (alors qu'il s'agit du moment où elle est prononcée au Luxembourg). Il peut y avoir un laps de temps considérable entre les deux événements.

La nullité des délibérations d'une assemblée peut être invoquée par tous ceux à qui cette délibération peut être opposée ou aux intérêts personnels desquels elle peut porter préjudice[(2)].

Certaines décisions sont prises au terme d'une **délibération** d'un organe collégial. Tel est le cas notamment des assemblées générales ou du conseil d'administration de la société anonyme. Une telle délibération peut le cas échéant être **viciée** à plusieurs points de vue. Les formes de la délibération sont arrêtées par la loi, les statuts et à leur défaut par les règles ordinaires des assemblées délibérantes. Parmi les règles de forme, on peut citer que les membres de l'organe doivent être convoqués à la délibération ; la convocation doit indiquer l'ordre du jour, il ne peut y avoir de délibération sur un point étranger à l'ordre du jour, etc.[(3)].

La jurisprudence retient que la publication de l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une société anonyme n'est qu'une formalité de convocation prescrite dans **l'intérêt exclusif des actionnaires** ; ceux-ci sont partant les seuls à pouvoir se prévaloir

1 – Référés n[os] 475/99 et 476/99 du 18 juin 1999 ; CA du 26 octobre 1999, n[os] 23.801 et 23.803, commenté par F. Fayot in *Ann. dr. lux.*, 2001, p. 558, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, I, n[os] 371 et 579.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 199.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de l'omission à l'ordre du jour d'un point sur lequel l'assemblée a été appelée ensuite à délibérer[1].

En cas de **non-respect de ces formalités** se pose la question de savoir quelles sont les sanctions à appliquer. Il serait excessif de retenir la nullité des décisions pour n'importe quelle violation de ces formes. Une telle sanction est retenue en cas de fraude[2]. Dans les autres cas, la solution est tout sauf certaine : quelques décisions retiennent qu'il y a nullité uniquement s'il peut être établi que la décision aurait été différente si les formalités avaient été respectées.

La solution qui fait dépendre la sanction de l'influence du vice sur la décision est dite « **appréciative** » est celle qui est défendue majoritairement en doctrine belge[3]. Cette approche se distingue encore de la solution dite « **mathématique** » selon laquelle il suffit de vérifier si la décision aurait été mathématiquement différente si les personnes empêchées avaient pris part au vote[4].

Selon une jurisprudence luxembourgeoise récente : « *Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que l'annulation d'une résolution est seulement à prononcer s'il est établi que sans l'irrégularité, l'organe aurait pris une autre décision. En cas de défaut de convocation, seules seront en effet annulées les décisions où l'intéressé non convoqué aurait pu exercer une influence sur la délibération du conseil, soit en raison du résultat du scrutin, soit en raison des connaissances particulières dans les domaines où les décisions ont été prises (cf.* Ch. Resteau précité, *page* 165 ; *Précis de Droit des sociétés*, A. Steichen, *3ème édition,* p. 726*).*

En l'occurrence, le requérant était minoritaire au sein du Conseil d'administration et sa participation n'aurait pas influé sur la délibération du Conseil, comme en atteste la réunion du 18 mai 2011 lors de laquelle les décisions prises le 11 octobre 2010 ont été confirmées, nonobstant les réclamations formulées par le requérant. Il est encore établi que les deux autres administrateurs, à savoir le sieur YY et la société POLE INVEST ne se sont pas abstenus de prendre part aux votes litigieux (ni en date du 11 octobre 2010, ni le 18 mai 2011), nonobstant un éventuel conflit d'intérêts »[5].

Dans un cas d'espèce[6], il fallait déterminer dans quelle mesure l'exclusion illicite d'un associé entraînait la nullité des délibérations générales auxquelles cet associé n'avait pas pris part. La Cour de cassation rejeta la solution « mathématique » suivant laquelle la nullité devrait être refusée uniquement si la participation de l'actionnaire irrégulièrement exclu n'avait pas pu modifier le résultat du vote. La cour sanctionna les juges du fond qui avaient retenu que la désignation des liquidateurs avait été décidée par la moitié des associés possédant les trois quarts du capital social et « *qu'il ne pouvait pas être tenu compte de la simple supposition que si le demandeur avait été présent à l'acte, il aurait convaincu un ou plusieurs associés de prolonger la société* ». Selon la Cour de cassation, les juges du fond

1 – Cass. civ du 18 mai 1933, *P.* , 13, p. 101.

2 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 199.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 199.

4 – Cette approche a notamment été retenue par un arrêt de la Cour de cassation belge du 4 avril 1975, *R.C.J.B.*, 1977, p. 551, note J. Heenen, V. M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 200.

5 – TA Lux. du 25 février 2014, n°s 136113 et 136114 du rôle, ID 24357.

6 – Cass. b. du 11 mars 1966, *Pas.,* I, 896 et note.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

auraient encore dû vérifier si les intérêts du demandeur (soit donc ceux de l'associé exclu indûment) n'avaient pas été lésés. L'assemblée générale suppose que tous les associés aient eu l'occasion de prendre part à l'assemblée « *afin de veiller à la protection de leurs intérêts personnels, notamment par des communications à leurs co-associés qui pourraient éventuellement influencer les décisions de la majorité précitée* »[1]. Et encore : « *L'obligation faite au juge du fond de vérifier si les intérêts du demandeur n'ont pas été lésés implique nécessairement que la seule constatation du caractère irrégulier de l'exclusion et, partant, de l'absence du demandeur ne suffit pas à entraîner, en soi, l'annulation de l'assemblée. En effet, cette réserve n'aurait, sinon, pas de signification* »[2].

L'approche mathématique est évidemment une invitation donnée à toute majorité solide d'associés à ne pas faire grand cas des formes sociales. À partir du moment où leur majorité est acquise il sera impossible aux minoritaires d'établir que le respect des formes aurait conduit à une majorité différente.

B – Depuis la Loi de Modernisation

L'article 100-22 [anc. art. 12*septies*] introduit par la Loi de Modernisation innove en droit luxembourgeois en prévoyant pour la première fois[3] des cas de nullité des décisions prises par les assemblées générales. Sont concernées toutes les personnes morales soumises à la L.S.C. et toutes les assemblées générales visées par la L.S.C., donc également les assemblées des obligataires. Les cas de nullités sanctionnés sont encore les mêmes que ceux de l'article 64 du Code belge des sociétés.

Art. 100-22 [anc. art. 12*septies*] L.S.C.

« Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale visée par la présente loi :

1° lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ;

2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse ;

3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir ;

4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis ;

5° pour toute autre cause prévue dans la présente loi.

(2) La nullité d'une décision d'assemblée générale doit être prononcée par une décision judiciaire.

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 301.

2 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 302.

3 – Si l'on fait abstraction du cas de nullité des modifications statutaires pour défaut d'acte notarié (*Doc. parl.*, n° 5730, p. 55, ID 10080).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.
*(3) L'action en nullité est dirigée contre la société. Le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à dater de la décision qui les prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 11bis, paragraphe 1er, point 6) et aux conditions prévues par les dispositions du chapitre V*bis *du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.*
(4) Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu ».

On peut donc constater que, dans son point 1° du paragraphe 1er, la L.S.C. se remet au pouvoir d'appréciation du juge pour décider de la nullité éventuelle de la décision de l'assemblée. Le Conseil d'État avait commenté comme suit les passages précédents : « *Les paragraphes 2 et 3 règlent la procédure. La commission parlementaire soulève à juste titre la question des conditions de compétence du juge des référés, alors que les auteurs, en recopiant la loi belge, introduisent la condition du motif grave, tandis que les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile prescrivent l'urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite. Comme la jurisprudence en matière de référé a jusqu'à présent toujours trouvé sa compétence pour prescrire les mesures urgentes que demandait la situation, le Conseil d'État est d'avis qu'il y a lieu de supprimer le premier bout de la 2e phrase du paragraphe 3 qui se lirait comme suit : "Le demandeur en nullité peut solliciter en référé […]". De cette façon, le droit commun restera applicable* ». Comme on peut le voir, le Conseil d'État n'a pas été entendu sur ce point.

SECTION II
L'ORGANE DE GESTION

Les décisions de gestion qui doivent être prises par les sociétés sont soit de nature essentiellement interne, soit nécessitent pour être exécutées l'accomplissement d'actes qui mettent la société en relation avec des tiers en créant à leur égard des droits et des obligations. Ces décisions ont donc tant un effet interne qu'un effet externe. « *Du point de vue interne elles sont un acte de gestion. Du point de vue externe, elles nécessitent un acte de représentation. Leur validité en tant qu'acte de gestion est une chose ; leur validité en tant qu'acte de représentation en est une autre* »[1]. La validité des décisions de gestion doit être analysée de ce double point de vue avec pour conséquence de procéder à la **dissociation** des fonctions de **gestion** et de **représentation** de la société.

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 193.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette dissociation est selon le cas plus ou moins difficile. En cas de gérant unique, la dissociation est impossible. L'acte de prise de décision et la représentation en ce qui concerne cette décision sont pris par la même personne au même moment. Dans d'autres cas, les deux fonctions ne sont pas assumées par le même organe. L'assemblée des associés prend un certain nombre de décisions qui elles, sont mises en œuvre par le conseil d'administration[1].

Le pouvoir de gestion (ou d'administration) comporte en même temps le pouvoir de représentation de la société afin de mettre en œuvre les décisions prises par les assemblées des associés.

Selon le cas, l'organe de gestion sera soit un organe collégial, soit constitué par une personne seule, en général un individu. En tout état de cause, il convient de décider comment et par qui les décisions de la société sont prises dans les relations internes, d'une part, et comment cette prise de décision doit se manifester vers le monde extérieur, d'autre part. En d'autres termes, il convient de décider comment et sous quelles conditions la société en tant que personne morale est engagée. Cette question a trait au pouvoir de **représentation** de la société. À cet égard, il existe un clivage, désormais classique, entre les sociétés soumises aux directives CE et celles qui ne le sont pas. Les premières font l'objet d'une réglementation tout à fait détaillée, alors que les secondes sont à même d'organiser comme elles l'entendent ce pouvoir de représentation.

■ § 1 – La nomination de l'organe de gestion

Dans les **sociétés en nom collectif**, il faut distinguer selon qu'il y a ou non désignation d'un gérant par les associés.

En l'absence de dispositions statutaires sur le fonctionnement de la gestion de la société, on applique les règles du Code civil, à savoir l'article 1859 C.c. ainsi libellé :

« *[…] Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit conclue […]* ».

En clair, cette disposition signifie qu'en principe, tous les associés sont gérants de la société, que leurs actes engagent la société, sans préjudice du droit des autres associés de s'opposer à une opération donnée, mais à condition que celle-ci soit préalable à cette opération.

Il va de soi que la réalité est autre dans la mesure où les associés entendent confier la gestion non pas à tous les associés, mais veulent la réserver à certains d'entre eux qui sont supposés particulièrement compétents pour assumer cette tâche, voire la confier à des personnes non-associés, donc à des gestionnaires professionnels.

Dans le premier cas de figure, celui donc où les statuts confient ces pouvoirs à un ou plusieurs associés, c'est l'art. 1856 C.c. qui trouve à s'appliquer : « *L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude* ». Le même article continue par préciser que ce pouvoir peut être révoqué à tout moment sans cause légitime.

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 194.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le Code civil envisage encore le cas de la pluralité de gérants.

Art. 1857 C.c. : « *Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration* ».

Il répond aux principes de base de l'organisation des sociétés que la nomination de l'organe de gestion est confiée à l'organe souverain, à savoir donc la communauté des associés.

C'est donc à la communauté des associés, le cas échéant regroupée en assemblée générale, qu'il appartient de nommer l'organe de direction, de définir ses pouvoirs, les conditions de sa révocation et de fixer sa rémunération. En principe, on leur applique les règles du mandat.

Si un gérant est désigné par les associés, il a en principe, le pouvoir d'accomplir tous les actes qu'ils soient d'administration ou de disposition exigés par la marche de l'entreprise(1). En cas de pluralité de gérants, les statuts déterminent s'ils doivent agir individuellement ou collectivement.

Dans les sociétés en commandite, la gestion appartient aux **commandités** exclusivement.

■ § 2 – Conditions requises pour être dirigeant

La L.S.C. ne prévoit guère de limitations à la nomination des dirigeants. La première question qui se pose à cet égard est celle de savoir si les gérants doivent ou non avoir la **pleine capacité**. Une première réponse à cette question peut consister à se référer à la **théorie du mandat** : en divers endroits notre droit des sociétés mentionne que les règles de gestion font référence au contrat de mandat (voir notamment : art. 1856 C.c., art. 441-9 [anc. art. 59] L.S.C). Par rapport au droit commun de l'institution du mandat on devrait conclure que le dirigeant n'a pas besoin d'avoir la pleine capacité, car, aux termes de l'article 1990 C.c., le mineur émancipé pourra être mandataire(2).

Mais il faut bien admettre que la mission du gérant exige un **pouvoir autonome** contrairement à la situation d'un mandataire ordinaire qui ne fait qu'exécuter un mandat spécial. En outre, sa mission ne se limite pas à des actes juridiques, mais inclut des actes matériels qui ne sont pas couverts par le concept de mandat.

Il est d'ailleurs dans l'intérêt des associés de nommer des personnes ayant pleine capacité, car, de cette manière, ils peuvent, en cas de faute des administrateurs, se retourner contre ceux-ci. En revanche, la responsabilité des mineurs émancipés est à cet égard limitée (voir art. 1990 C.c.).

■ § 3 – Pouvoirs des dirigeants

L'organe de gestion, dûment nommé, est le seul à pouvoir gérer la société à l'exclusion des associés. Ces derniers ne peuvent donc exercer ces pouvoirs en

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 189.
2 – En ce sens également : A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 232.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

concurrence avec les gérants désignés par la société, pas plus qu'ils ne peuvent annuler les actes posés par l'organe de gestion[1].

Pour engager la société, encore faut-il que les gérants agissent au nom de celle-ci et non **en leur propre nom**. Cette question doit être résolue en fonction des données du cas d'espèce.

La loi fait une distinction entre pouvoirs de gestion proprement dits (et qui concernent les relations internes de la société) et pouvoirs de représentation (relatifs aux relations avec les tiers). C'est la Première directive (68/151/CEE) qui oblige à faire cette distinction qui trouve son origine dans le droit allemand[2].

A – Pouvoirs de gestion

Il est entendu que, dans les relations internes, les pouvoirs de gestion sont régis par les statuts, et sont donc de nature contractuelle. Ce sont donc les dispositions de ces statuts qui doivent être respectées. Rien ne s'oppose donc à ce que les statuts prévoient que les dirigeants doivent obtenir l'accord des associés (à une certaine majorité, le cas échéant à une majorité qualifiée) avant de pouvoir entrer dans certaines opérations.

Exemple

L'achat et la vente de participations doivent être autorisés par une majorité de trois quarts des associés.

De telles clauses sont sans aucun doute valables. Mais elles ne concernent que les **relations internes** de la société, soit donc les relations existant entre associés et son organe de gestion. Elles ne concernent pas les relations avec les tiers, à l'égard desquels la situation est différente et, depuis les directives de l'Union européenne, plus simple, car orientée vers la sécurité juridique.

B – Pouvoirs de représentation

Sous cette rubrique sont visées les conditions sous lesquelles la société est valablement engagée envers les tiers. Selon la loi du 23 novembre 1972 (prise sur la base de la Première directive), les statuts des sociétés de capitaux peuvent créer des **organes chargés** spécifiquement de **la représentation** de la société. Cette délégation doit être générale avec donc la conséquence que des restrictions statutaires à cette généralité seraient inopposables aux tiers[3]. Telle est la solution retenue par l'article 441-5, anc. art. 53, alinéa 4, L.S.C. : « […] *les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre V*bis [de la Loi de 2002] ». La même possibilité existe à l'égard des S.e.c.a. et des S.à r.l.

1 – V. Cour du 10 juillet 2002, n° 23.054, *BIJ*, 2004, p. 27.

2 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 192.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 191.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La portée de cette distinction peut être résumée comme suit : la loi prévoit des organes de représentation ou elle autorise les statuts d'en créer tout en déterminant les pouvoirs de ces organes de représentation. « *L'organe qui agit dans le cadre de son pouvoir de représentation engage la société vis-à-vis des tiers ; qu'il ait ou non le pouvoir de décider de l'acte juridique qu'il accomplit, qu'il exécute ou non une décision de l'organe de gestion compétent, ces considérations n'importent pas. La société est engagée ; la violation des règles de gestion interne entraîne seulement la responsabilité de l'organe indélicat à l'égard de la société* »[1].

Il est bien évident qu'à cet égard des limites sont à respecter dans la mesure où la société ne peut être considérée comme engagée que dans le cadre de ces limites.

1) La répartition légale des pouvoirs entre organes

« *Sous réserve des délégations spéciales de pouvoirs à des mandataires, dans la mesure où la loi ne les interdit pas, la volonté de la personne morale est exprimée par les organes dont elle est dotée par le législateur et il appartient à ce dernier d'organiser la répartition des compétences entre les différents organes de la société* »[2].

La loi (notamment la L.S.C.) prévoit une certaine répartition des pouvoirs entre les différents organes légaux. Cette répartition doit être respectée tant par la société que par les tiers. La loi prévoit ainsi que les **associés désignent et révoquent l'organe de gestion** et de contrôle de la société, qu'ils **approuvent les comptes annuels**, etc. De même les gérants (administrateurs) exercent la gestion de la société, préparent les comptes annuels, convoquent les assemblées annuelles, etc. Il n'est pas possible de bousculer cette répartition fondamentale des tâches dans la société pour décider par exemple que l'approbation des comptes et l'affectation des résultats seraient de la compétence de l'organe de gestion.

Ces principes ont notamment été enfreints dans une affaire soumise au Tribunal de commerce de Liège[3]. Dans ce cas d'espèce, une société anonyme avait augmenté son capital par des apports en nature consentis par un premier groupe d'actionnaires et pour partie par une souscription en espèces partiellement libérée faite par un autre groupe. Deux années plus tard, le conseil d'administration avait accepté que la libération du solde de l'apport en espèces soit faite par la dation en paiement d'une ligne de déroulage.

Le tribunal devait considérer que cette décision était dénuée de toute validité : en effet, seule l'assemblée générale est compétente pour déterminer les conditions de l'augmentation de capital qu'elle décide. Par conséquent, les « *actionnaires ne peuvent invoquer les décisions du conseil d'administration pour aller à l'encontre de ce que l'assemblée générale a décidé* ». Il a à juste titre été souligné que, en dehors de ce problème de répartition des pouvoirs entre les organes de la société, cette façon de procéder soulève un autre problème à savoir celui du non-respect des formalités liées aux apports en nature. La seule façon de réaliser correctement

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 193.

2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 643.

3 – Trib. com. Liège du 21 décembre 1982, *R.P.S.*, 1983, p. 93.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

cette opération serait par conséquent de réduire le capital social selon les formalités légales prévues à cet effet, en dispensant les apporteurs de faire leur apport et à l'augmenter à nouveau par la souscription en nature[1].

2) La limitation de l'objet social

Traditionnellement, l'objet social constituait une autre limitation des pouvoirs à l'égard des tiers. La société n'était engagée que dans la mesure où l'opération se situait dans le cadre de l'objet social. Les dirigeants qui se plaçaient en dehors de ce cadre en concluant des contrats avec des tiers, risquaient d'être considérés agir hors pouvoir (« ***ultra vires*** »). Le mandataire ayant excédé les pouvoirs attribués par les mandants agissait sans pouvoirs. Il risquait donc d'être considéré comme ayant agi pour son propre compte.

Exemple

Une société en nom collectif a été constituée pour réaliser des opérations de recherche dans le domaine pharmaceutique, à l'exclusion de toutes opérations immobilières. Le gérant de la société, en ignorant cette interdiction, procède à l'acquisition d'un terrain limitrophe à l'immeuble loué par la S.e.n.c. Cette opération dépassant clairement l'objet social, la société pourrait considérer cette opération comme ne lui étant pas opposable avec donc la conséquence que c'est le gérant lui-même qui est considéré comme engagé et ayant donc contracté pour son propre compte.

Il est vrai que ce dépassement de l'objet social n'empêche pas les associés de la société de **ratifier** ultérieurement l'acte posé par un de ses dirigeants avec pour conséquence que la société sera néanmoins obligée par l'acte posé par le gérant et pour lequel il n'avait initialement pas le pouvoir. Cette possibilité de ratification ne fait que correspondre au droit commun du contrat de mandat. Il faut être conscient du fait que pour être pleinement valable, il est nécessaire que la ratification soit faite par la **totalité des associés.** En effet, un associé qui n'aurait pas donné son accord pourrait, au moins théoriquement, par la suite demander l'annulation judiciaire de l'acte pris pour le compte de la société[2].

Il est clair que si la règle de l'*ultra vires* protège bien les associés contre des dirigeants un peu trop aventuriers, cette approche va bien au détriment de la **sécurité** des opérations commerciales. En effet, tout tiers envisageant de traiter avec la société est obligé de soigneusement analyser les statuts de la société pour ne pas voir son opération remise en question au motif que le cocontractant a excédé ses pouvoirs et pour éviter d'avoir comme cocontractant une personne physique financièrement assez démunie au lieu d'une société éventuellement prospère.

Pour éviter ces inconvénients, la règle susvisée de la limitation par l'objet social a été très sérieusement mitigée, en fait renversée, par les dispositions du droit communautaire (Première directive).

1 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 644.
2 – V. Cour du 10 juillet 2002, n° 23.054, *BIJ*, 2004, p. 27.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

3) L'importance relative de l'objet social dans les sociétés de capitaux

L'article 9 de la Première directive dispose que :

« *1. La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ces organes, même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social de cette société, à moins que lesdits actes n'excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes.*

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la société n'est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l'objet social, si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

2. Les limitations aux pouvoirs des organes de la société, qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents, sont toujours inopposables aux tiers, même si elles sont publiées […] ».

Il résulte donc de ces dispositions, qui valent à l'égard de toutes les **sociétés de capitaux**, que l'objet social n'est en définitive pas un obstacle aux engagements que prennent les sociétés dans leurs opérations quotidiennes. Mais il est vrai que, même dans les relations externes (donc avec les tiers), il reste une place résiduelle à cet objet social dans la mesure où cet objet social peut être opposé aux tiers dans un cas bien précis, celui où le tiers connaissait ce dépassement (ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances). Il est évident qu'à cet égard se pose un problème de preuve consistant à savoir comment la société peut prouver cette connaissance. La loi donne un seul élément de réponse, à savoir que la simple publication des statuts est insuffisante pour établir cette preuve.

Cette précision est importante, car elle montre que la société ne peut se référer aux devoirs de diligence normale dont devrait faire preuve le cocontractant. Il appartiendra effectivement à la société d'établir une connaissance subjective de ce dépassement de l'objet social par le cocontractant si elle veut pouvoir renier l'engagement pris par ses propres dirigeants.

Ce système a été introduit par la directive, et ceci, dans l'intérêt de la sécurité des opérations commerciales.

Au-delà de cette considération purement pratique, on peut soutenir que cette solution peut se justifier également au point de vue moral. S'il est vrai que le contractant qui n'a pas vérifié si l'objet social n'a pas été dépassé a agi de manière imprudente, il n'en reste pas moins que la société a également des reproches à se faire. Elle a choisi des dirigeants qui eux ne respectent pas les statuts de la société à la tête de laquelle ils sont placés. Ne pas permettre à cette société de se délier des engagements pris par les dirigeants est une solution moralement défendable.

SECTION III
LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Cette notion de contrôle est ambiguë et elle comporte de **multiples significations**, parfois totalement en dehors du domaine dans lequel la notion est envisagée ici. Une personne ou un groupe de personnes a le contrôle d'une société lorsqu'elles sont, en droit ou en fait, à même d'imposer leur volonté à une société. Ce n'est pas dans ce sens que le terme est utilisé ici.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans le présent contexte, le terme « *contrôle* » comporte soit le contrôle des comptes, contrôle patrimonial, soit le contrôle dans le sens de surveillance de la gestion. On parle encore de contrôle interne, notion à distinguer de celle de contrôle de gestion : « *le contrôle interne est un instrument de gestion entre les mains des dirigeants sociaux grâce auquel ils s'assurent de la fiabilité du réseau d'informations mis en place* »[1].

Le contrôle des sociétés traduit en quelque sorte une tendance relativement récente en droit des sociétés : en effet, le Code civil n'en parle point. En fait, le contrôle des sociétés a toujours existé, seulement il n'a pas été confié à des organes spécifiques.

Dans certaines sociétés, la création d'un tel organe spécifique est imposée par la loi. Tel est, notamment et surtout, le cas des sociétés anonymes pour lesquelles ce pouvoir de contrôle est confié aux commissaires.

Dans les sociétés de personnes (y compris la société civile) souvent caractérisées par le nombre peu élevé des associés, ce pouvoir appartient à tous les associés.

■ § 1 – Notion de « *corporate governance* »

Depuis quelques années, une nouvelle notion s'est développée et a pris sa place en droit des sociétés. Elle a trait à la répartition des pouvoirs et à leur contrôle au sein de l'entreprise[2].

Cette notion s'est surtout développée dans le contexte de quelques **scandales financiers** retentissants et qui ont défrayé la chronique au cours de la dernière décennie. Il s'agit en particulier des affaires *Enron*, *Parmalat*, *Worldcom*, etc.

Certains observateurs pourraient être amenés à penser que de tels scandales financiers sont un phénomène récent qui aurait épargné le « bon vieux temps ». Pourtant rien ne serait plus faux. Il suffit notamment de se rapporter à l'histoire parlementaire de la loi belge de 1913 pour se convaincre de la réalité vécue à cette époque-là. Dans la séance du 30 janvier 1884, un certain député Janson a brossé le tableau suivant :

« *Tous les jours nous voyons des gens qui ont inventé une affaire quelconque, qui se prétendent concessionnaires d'une opération imaginaire, un chemin de fer dans la lune, par exemple. Ils s'assemblent à sept ; ils déclarent solennellement et authentiquement devant un notaire que l'opération est excellente. Ils font une évaluation exorbitante de leurs actions ; ils en organisent la hausse par la publicité et des manœuvres de bourse, et les malheureux viennent acheter des actions qui tombent bientôt à zéro.*

On voit répandre les prospectus les plus invraisemblables, pour tromper le public. C'est ainsi, pour ne citer qu'un seul exemple, qu'on publie à Bruxelles un de ces prospectus triomphants, à propos d'une société qui s'intitulait 'Société de Baïa de Arama' et qui devait exploiter des mines de cuivres en Roumanie, mines délaissées par les Roumains ! Cette opération, disait-on, devait donner, en attendant le reste, quatre millions de bénéfices. Or il résulte d'un rapport publié au Moniteur*, qu'il n'existe pas en Roumanie de mines de cuivre.*

1 – A. Benoit-Moury, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », *R.P.S.*, 1986, p. 2.

2 – Pour une appréciation doctrinale luxembourgeoise, V. M.-P. Gillen-Snyers, « Les banques luxembourgeoises et le corporate governance », *Droit bancaire et financier*, Vol. 3, pp. 1115 ss.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

On punit ceux qui émettent de la monnaie ayant l'apparence de l'or ou de l'argent, mais cette émission de papier représentant une valeur imaginaire a libre cours ! Elle fait du même coup la fortune des uns et la ruine des autres »[1].

À la suite des scandales visés ci-dessus, des efforts ont été faits de toutes parts afin de rendre la gestion des grandes entreprises plus transparente et de faire de cette notion un élément important du droit des sociétés moderne.

La « *corporate governance* » s'est développée à partir de la constatation que les correctifs classiques, tels que la « démocratie » de l'actionnariat ou le contrôle des gestionnaires par le « marché du contrôle » ne suffisent plus à assurer l'harmonie entre les gestionnaires et les autres composantes de l'activité économique. « *[…] [la* corporate governance*] désigne la recherche de mécanismes d'équilibre et de contrôle, internes ou externes, qui concilient les objectifs des gestionnaires et ceux des autres composantes de l'activité économique, en analysant le problème en termes de responsabilité sociale de la société et en ayant égard à l'évolution des structures contemporaines de l'actionnariat et de la gestion* »[2].

Le gouvernement d'entreprise est le système par lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées. Selon les principes de l'OCDE de 1999 : « *[…] le gouvernement d'entreprise […] fait référence aux relations entre la direction d'une entreprise, son conseil d'administration, ses actionnaires et d'autres parties prenantes à ses activités […] Le gouvernement d'entreprise détermine également la structure par laquelle sont définis les objectifs d'une entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et d'assurer un suivi des résultats obtenus* ».

■ § 2 – La *corporate governance* – gouvernement d'entreprise – sur un plan international

Les États-Unis, sous le choc d'une vague de scandales financiers, ont réagi par la voie législative en adoptant la **loi Sarbanes-Oxley** en date du 30 juillet 2002.

Les institutions internationales ne sont pas restées inactives non plus.

A – La Commission européenne

La Commission des CE, en premier lieu, a constaté que l'élaboration d'un **code européen** de gouvernement d'entreprise était une solution à écarter, car elle ne ferait qu'ajouter une strate supplémentaire à tous les instruments existant déjà tant sur le plan national qu'international (OCDE, p. ex.)[3].

En 2003, la Commission a lancé un **Plan d'Action** visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne, évidemment très impliquée dans le développement de cette notion. Dans les communications consacrées à la matière, la Commission fait généralement référence aux mécanismes par lesquels une entreprise commerciale dotée de la responsabilité limitée est dirigée et contrôlée. Sont en particulier visés les mécanismes par lesquels les dirigeants d'entreprise sont rendus responsables de la conduite et des performances de l'entreprise.

1 – Passage cité par A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 132, ID 11305.

2 – T. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 122.

3 – V. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, COM(2003)284 final, p. 14.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Ces activités font suite notamment à un rapport Cadbury émis au Royaume-Uni en 1992 traitant des problèmes dans les performances des sociétés et dans les rapports financiers, du manque de surveillance des conseils d'administration. Ce rapport a été suivi par la publication de 10 codes nationaux sur la période 1992 à 1997 dans les États membres de l'Union européenne.

En juillet 2001, la Commission institua un groupe d'experts en matière de droit des sociétés, dit groupe Winter, ayant pour mission de fournir des propositions à la Commission sur une nouvelle proposition de directive relative aux acquisitions et sur la promotion des marchés financiers européens.

Dans le rapport Winter, présenté le 4 novembre 2002, les actions suivantes ont été proposées :

– renforcement des **obligations d'information** en matière de gouvernement d'entreprise ;
– renforcement du rôle des membres indépendants des conseils d'administration et de surveillance, en particulier dans les domaines où les administrateurs peuvent être confrontés : nomination et rémunération des administrateurs, contrôle des comptes sociaux ;
– mise en place d'un régime approprié en matière de rémunération des dirigeants, avec l'obligation de divulguer la politique de rémunération des principaux dirigeants ainsi que l'accord préalable des actionnaires sur les régimes d'actionnariat et d'options sur les actions dont bénéficient les dirigeants ;
– confirmation par le droit de l'Union européenne de la responsabilité collective des membres du conseil d'administration pour ce qui concerne l'état financier ;
– mise en place d'une structure de coordination des efforts en matière de gouvernement d'entreprise des États membres.

Au lieu de proposer un code européen de gouvernement d'entreprise, notamment en raison d'une harmonisation insuffisante du droit des sociétés de l'Union européenne, le rapport Winter préconise une coordination active des efforts des États membres à travers leur droit des sociétés et leur droit financier afin de faciliter la convergence et d'éviter les distorsions tout en favorisant un apprentissage mutuel. Les États membres sont ainsi appelés à désigner le code national de gouvernement d'entreprise dans la juridiction duquel tombent les entreprises. Elles devront se conformer à ce code tout en expliquant le cas échéant les divergences par rapport à ce code. Les États membres doivent participer au processus de coordination au niveau de l'Union européenne.

En date du 21 mai 2003, la Commission a adopté un **plan d'action** destiné à améliorer les règles de gouvernement d'entreprise en mentionnant un certain nombre d'initiatives.

– la publication obligatoire par les entreprises cotées d'un rapport annuel sur le gouvernement d'entreprise détaillant les structures et les pratiques de la société en cette matière ;
– le développement d'un cadre réglementaire régissant les droits des actionnaires (notamment celui de poser des questions ou de s'abstenir de voter) ;
– l'adoption d'une recommandation visant à favoriser le rôle indépendant des administrateurs internes et externes de la société ;
– l'adoption d'une recommandation concernant la rémunération des dirigeants favorisant plus de transparence et d'influence pour les actionnaires ;

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– la responsabilité renforcée des administrateurs notamment au moyen de l'introduction de la « responsabilité collective » de l'ensemble du conseil d'administration pour les états financiers et les principaux documents non financiers. Celle-ci devra être introduite en droit de l'Union européenne (p. 19 du rapport cité).

La Commission a proposé un certain nombre de mesures supplémentaires toutes reprises dans le rapport cité.

B – L'OCDE

Dès 1998, l'OCDE s'est saisie du problème en publiant en 1998 le **rapport Millstein**, suivi par la publication en 1999 des Principes de gouvernance d'entreprises de l'OCDE en 1999.

Les principes de l'OCDE en cette matière ont été développés à la suite de la crise financière asiatique de 1997 et la première version en a été publiée en 1997. Les principes en question sont en premier lieu destinés à assister les gouvernements des États membres (et non-membres) dans leur effort d'évaluer et d'améliorer leur cadre légal et réglementaire pour le gouvernement d'entreprise dans leur État respectif[1]. Les principes se concentrent sur les résultats et, par conséquent, ils admettent que différentes solutions puissent conduire aux mêmes résultats. Les principes se concentrent sur des sociétés cotées financières et non financières.

Ces **principes** sont les suivants :

5) les règles du gouvernement d'entreprise devraient promouvoir le fonctionnement de **marchés transparents** et efficaces, dans le cadre de l'État de droit (« *rule of law* ») et clairement définir le partage de responsabilité entre les autorités de surveillance, de contrôle et « *enforcement* » ;
6) les **droits des actionnaires** devraient être **protégés** et leur exercice être facilité ;
7) le **traitement équitable** des actionnaires, y compris des actionnaires minoritaires, devrait être facilité. L'actionnaire devrait avoir la possibilité d'obtenir un dédommagement efficace en cas de violation de ses droits.
8) les **droits** des « ***stakeholders*** » devraient être reconnus. Par ce terme on entend les personnes fournisseurs de ressources à la société. En font partie les investisseurs, les employés, les créanciers, les fournisseurs, etc. Ces relations avec la société sont souvent de nature contractuelle. Le rôle de ces tiers dans le cadre de la réussite à long terme de la société est reconnu ;
9) la **publication rapide** et complète de toutes informations pertinentes concernant les domaines de leur situation financière, la performance, l'actionnariat et le gouvernement d'entreprise doit être assurée ;
10) la **conduite stratégique** de la société par le conseil d'administration, le contrôle effectif de la gestion par le conseil et la responsabilité du conseil envers les actionnaires et la société doivent être assurés.

1 – V. L. Bouchez, Principles of corporate governance : the OECD perspective, publié dans Ondernemingsrecht, 2006-10/11, p. 378.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 3 – Les principes de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Luxembourg

Conformément au courant international décrit ci-dessus, la Bourse de Luxembourg a également procédé à l'élaboration de principes de gouvernance d'entreprise (GE). On peut s'interroger sur la valeur juridique et la force contraignante de telles règles. On peut considérer qu'il s'agit de « ***soft law*** » ou encore d'un code de conduite défini comme suit :

« *Un code de conduite est un ensemble de recommandations édictées par un organisme international, une organisation professionnelle ou une organisation multinationale, qui n'a pas de caractère obligatoire, mais joue le rôle d'un instrument de persuasion morale grâce à l'autorité des organisations concernées et la force de l'opinion publique* ».

La Bourse de Luxembourg dans les dix principes de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Luxembourg (décembre 2017*)* définit comme suit la notion : « *La gouvernance d'entreprise, ou "corporate governance", est constituée par le corps des principes, règles et usages organisant la gestion et le contrôle des entreprises. Elle couvre donc l'articulation des pouvoirs entre les actionnaires et la direction d'une société, et principalement le fonctionnement du conseil d'administration de la société.* »[1].

« *Principe 1 – Régime de gouvernance d'entreprise*

La société adopte un régime de gouvernance d'entreprise clair et transparent auquel elle assure une publicité adéquate.

Principe 2 – Mission du conseil d'administration

Le conseil d'administration est en charge de la gestion de la société. Il agit comme organe collégial dans l'intérêt social et sert l'ensemble des actionnaires en veillant à assurer la réussite à long terme de la société. Conscients de leur responsabilité sociale, sociétale et environnementale, ils considèrent dans leurs délibérations l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes.

Le conseil d'administration évalue régulièrement son mode de fonctionnement et ses relations avec la direction.

Principe 3 – Composition du conseil d'administration et comités spécialisés

Le conseil d'administration est composé de personnes compétentes, intègres et avisées. Le choix de celles-ci est fait en tenant compte des spécificités de la société.

Le conseil d'administration veille à instaurer les comités spécialisés nécessaires au bon accomplissement de sa mission.

Principe 4 – Nomination des membres du conseil d'administration

La société instaure une procédure formelle de nomination des membres du conseil d'administration.

1 – Les dix principes de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Luxembourg, https://www.bourse.lu/corporate-governance, 2017, p. 6.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Principe 5 – Déontologie

Les administrateurs doivent faire preuve d'intégrité et d'engagement. Représentant chacun l'ensemble des actionnaires, ils prennent leurs décisions dans l'intérêt de la société et libres de tout conflit d'intérêts.

Principe 6 – Direction

Le conseil d'administration met en place une direction efficace de l'entreprise. Il définit de façon claire les attributions et les devoirs de la direction et lui délègue les pouvoirs nécessaires au bon accomplissement de ceux-ci.

Principe 7 – Politique de Rémunération

La société établit pour ses administrateurs et les membres de sa direction une politique de rémunération équitable et conforme aux intérêts à long terme de la société.

Principe 8 – Reporting financier, contrôle interne, et gestion des risques

Le conseil d'administration arrête des règles rigoureuses en matière de reporting financier, de contrôle interne et de gestion des risques visant à protéger les intérêts de la société.

Principe 9 – Responsabilité sociale, sociétale et environnementale (RSE)

La société définit sa politique en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Elle précise les mesures prises pour la mise en oeuvre de sa politique et leur donne une publicité adéquate.

Principe 10 – Actionnaires

La société respecte les droits de ses actionnaires et leur assure un traitement égal.

Vis-à-vis de ses actionnaires, la société définit une politique de communication active et établit une pratique d'échange structuré. »

■ § 4 – Les instances de contrôle en droit positif

A – Mandat du commissaire

Dans plusieurs types de sociétés, il existe (au moins) un commissaire ; tel est le cas de la S.A., de la S.e.c.a., de la coopérative et, parfois, de la S.à r.l. En fait, il s'agit d'un « commissaire aux comptes », mais notre loi n'utilise pas cette expression qui a le mérite d'être un peu plus explicite. Conformément à l'article 443-1 [anc. art. 61] L.S.C. applicable aux sociétés anonymes, les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Sauf disposition contraire dans l'acte de société, les commissaires sont rééligibles. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans ; ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.

C'est l'assemblée générale (non pas les statuts) qui détermine le nombre des commissaires et, en outre, elle fixe leurs émoluments. Si le **nombre** des commissaires est **réduit**, par suite de décès ou autrement, de plus de la moitié, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La **rémunération** des commissaires est fixée par l'assemblée générale. Aucun mode de rémunération n'est donc exclu, contrairement au système retenu en Belgique où l'on a précisé que les commissaires touchent un montant fixe établi au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale en écartant ainsi la rémunération fixée au prorata des bénéfices de l'exercice social. Un tel système est évidemment à proscrire dans le sens qu'il peut avoir pour effet d'obliger le commissaire de choisir entre ses intérêts et sa conscience : il peut ainsi être porté à grossir les bénéfices pour augmenter le montant de sa rémunération(1).

De ces dispositions résulte un parallélisme étroit entre le statut de l'administrateur et celui du commissaire. Tous deux sont nommés par l'assemblée et révocables par elle.

Les commissaires, comme les administrateurs, sont choisis *intuitu personae* et ne peuvent donc déléguer les pouvoirs à des personnes qui n'auraient pas été choisies par l'assemblée des associés. En cas de pluralité de commissaires, ceux-ci forment également un collège agissant donc de concert.

En cas de vacance de poste de commissaire, la **cooptation** des commissaires est **exclue**. C'est uniquement l'assemblée des associés qui peut pourvoir au remplacement des commissaires lorsque le nombre de ceux-ci « *est réduit de plus de la moitié* » (art. 443-1 [anc. art. 61] L.S.C.).

Aucun **cautionnement** n'est exigé (pas plus que pour les administrateurs). La justification de cette règle est difficile à contester et elle montre le dilemme constant d'un tel cautionnement : « *Une caution de minime importance est illusoire, tandis qu'un cautionnement considérable pourrait rendre difficile le choix des personnes les plus capables* »(2).

Si un cautionnement est donné par un dirigeant, celui-ci sera en général non pas de **nature civile,** mais de nature commerciale, et ceci, pour la raison que le cautionnement perd son caractère civil si celui qui l'a consenti avait un intérêt direct et immédiat dans l'opération commerciale garantie. « *Le cautionnement souscrit par les dirigeants est très généralement considéré comme commercial au motif qu'ils ont un intérêt personnel dans la bonne marche de leur société […]* »(3).

B – Attributions du commissaire

C'est la L.S.C. qui, dans son article 443-2 [anc. art. 62] L.S.C., définit comme suit leur mission : « *Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société* ».

Il leur est remis chaque semestre, par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l'assemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions

1 – L. Frédéricq, « Innovations introduites par la loi du 1er décembre 1953 dans la surveillance des sociétés », *R.P.S.*, 1954, p. 279.

2 – Vidari, cité par A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 197, ID 11305.

3 – TA Lux. du 4 février 2005, n° 86.013, ID 12281.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

qu'ils croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires […] ».

La mission des commissaires est des plus larges. La loi parle d'un « *droit illimité de surveillance et de contrôle* ».

Il est important de noter que la mission du **commissaire** est (en théorie du moins) une mission de **surveillance de la gestion**, au même titre qu'une mission purement comptable. Elle consiste principalement à veiller à ce que les administrateurs s'acquittent fidèlement de leurs fonctions et ne sortent pas des limites de leur mandat. « *Ils ne peuvent pas entraver l'administration ni commander à ceux qui en sont investis, mais ils doivent pouvoir obtenir une connaissance entière des affaires sociales, afin de mieux réaliser leur mission* »[1]. En effet, l'article 443-2 L.S.C. précise que les commissaires ont un « *droit illimité de surveillance et de contrôle* » (alors que l'article 443-1 L.S.C. prévoit que la « *surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires […]* » sans donc faire référence à la notion de contrôle).

En outre, la loi précise qu'ils « *formulent les propositions qu'ils croient convenables* ». C'est à juste titre que la doctrine belge a retenu que : « *Ce petit bout de phrase pouvait passer inaperçu et il est passé inaperçu ; il est resté lettre morte* »[2]. Cette conclusion vaut également pour le Luxembourg.

Par ailleurs, dans certains cas, les commissaires sont appelés à intervenir dans la gestion de la société : il en est ainsi en cas de vacance d'un administrateur ou encore lorsque les statuts le prévoyaient : les commissaires agissaient alors ensemble avec les administrateurs en donnant ainsi lieu à un nouvel organe de la société, le **conseil général**[3].

Les commissaires peuvent se faire assister par un **expert** en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société. L'expert doit être agréé par la société. À défaut d'agréation, le président du « *tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale* » sur requête des commissaires signifiée avec assignation à la société, fait le choix de l'expert. Le président entend les parties en son cabinet et statue en audience publique sur la désignation de l'expert. Sa décision ne doit pas être signifiée à la société et n'est pas susceptible de recours.

Cette faculté pour le commissaire de se faire assister par un expert a fait l'objet de violentes **critiques**. On a en effet considéré que, si le commissaire est une personne qualifiée et capable, alors il n'a pas besoin d'un expert pour faire le travail pour lequel il est rétribué. Il est vrai également que personne ne peut être expert en tout, de sorte que le fait de se faire assister par une personne dans un domaine bien particulier peut être justifié également.

C – Responsabilité du commissaire

Traditionnellement, la responsabilité des commissaires est régie par les règles du **mandat**. Les administrateurs sont mandatés par les associés afin de gérer la société dans l'intérêt des associés. Ils rendent compte annuellement de l'exécution de leur mandat en obtenant la décharge pour l'exécution de leur mission. Mais les

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 198, ID 11305.

2 – A. Benoit-Moury, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », *R.P.S.*, 1986, p. 4.

3 – A. Benoit-Moury, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », *R.P.S.*, 1986, p. 7.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

associés sont mal équipés et mal informés pour pouvoir faire valoir leurs droits dans de bonnes conditions.

« *Le commissaire leur servira d'intermédiaire, il jouera le rôle d'informateur, sera les yeux, les oreilles de l'assemblée* »[1].

Les commissaires sont les mandataires de la société, comme les administrateurs, mais il s'agit de mandataires d'un autre type dans le sens qu'ils ne sont pas chargés de **l'exécution de tâches** (comme les administrateurs), mais du contrôle d'autres mandataires de la société, à savoir les administrateurs.

« *Leur responsabilité, en tant qu'elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle, est déterminée d'après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs.*

Vis-à-vis de la société, il y a donc responsabilité sur base du contrat de mandat ; à l'égard de la société et des tiers, il y a responsabilité solidaire pour cause de violation de la loi ou des statuts ; finalement il y a responsabilité de droit commun sur base de l'article 1382 C.c. envers tout tiers ou encore des actionnaires individuellement »[2].

En droit belge, des dispositions légales spécifiques sont consacrées à cette question de la responsabilité des commissaires, dispositions que ne connaît pas la L.S.C. En particulier, en droit belge, l'article 64*octies*, alinéa 1, L.C.S.C., dispose que les commissaires sont responsables envers la société des fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions. L'alinéa 2 précise que les commissaires sont responsables tant envers les tiers qu'envers la société des manquements qu'ils commettent aux lois coordonnées ou aux statuts[3].

Relevons encore que, même si la responsabilité des commissaires est souvent invoquée en même temps que celle des administrateurs, il n'existe **pas de solidarité** entre administrateurs et commissaires. Leurs fautes ne peuvent être communes dans la mesure où ils poursuivent des missions différentes[4].

D – Nomination et révocation du commissaire

Le commissaire est nommé par la communauté des associés dans l'intérêt desquels il exerce sa mission de contrôle (et de surveillance). Dans le souci d'assurer l'indépendance du commissaire, il est prévu que celui-ci ne peut exercer aucune autre fonction dans la société soumise à son contrôle[5].

En cas de réduction du nombre des commissaires (notamment pour cause de décès), de plus de la moitié, le conseil d'administration ou le directoire doit « *convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants* » (art. 443-1 L.S.C.). La solution est donc fondamentalement différente de celle prévue à l'égard des administrateurs qui eux, peuvent procéder à la **cooptation** des administrateurs empêchés.

---

1 – A. Benoit-Moury, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », *R.P.S.*, 1986, p. 4.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 144, ID 11308.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence, 1979-1990 », *R.C.J.B.*, 1993, p. 821.

4 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 407.

5 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 96.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Aux termes de l'article 443-1 L.S.C., les commissaires sont toujours révocables par l'assemblée générale. La loi belge (art. 64*quater* L.C.S.C) spécifie que le commissaire ne peut être révoqué que pour de justes motifs, tels que l'incapacité physique, la négligence, etc.[1].

En ce qui concerne la **rémunération** du commissaire, la loi se limite à mentionner que « *l'assemblée détermine le nombre de commissaires et fixe leurs émoluments* » (art. 443-1 L.S.C.). La loi belge prévoit des règles plus précises à cet égard en spécifiant que les commissaires, en dehors de leurs émoluments, ne peuvent toucher de la part de la société aucun avantage de quelque nature qu'il soit[2]. Cette disposition a été critiquée de toutes parts et n'a d'évidence pas sa place dans la loi[3].

La rémunération du commissaire est donc fixée librement par l'assemblée générale.

■ § 5 – Le commissaire spécial

Dans certaines sociétés, la loi (art. 1400-3 [anc. art. 154] L.S.C.) prévoit la possibilité de faire « *[…] poser par écrit à l'organe de gestion des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés contrôlées au sens de l'article 1711-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt des sociétés comprises dans l'obligation de consolidation. Une copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du contrôle légal des comptes.*

À défaut de réponse dans un délai d'un mois, ces associés peuvent demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite […] ». La demande doit être supportée par des associés représentant 10 % au moins du capital social ou des droits de vote. Avant la Loi de Modernisation, elle n'était ouverte que pour les **sociétés par actions** ainsi que pour les sociétés coopératives, mais elle a été étendue à toutes les formes de sociétés par ladite loi. Le jugement doit préciser les points sur lesquels les commissaires doivent se prononcer. L'art. 1400-3 alinéa 4 prévoit que le juge détermine si le rapport doit faire l'objet d'une publicité.

Pour les associés minoritaires, le recours à l'article 1400-3 [anc. art. 154] L.S.C. est souvent le seul moyen de connaître les rouages internes de l'affaire et de découvrir, dans certains cas, des pratiques de gestion susceptibles de les dépouiller. Il suffit, pour qu'il puisse y avoir désignation d'experts, qu'à raison du désordre des affaires sociales, de négligences des administrateurs et d'inobservation des prescriptions légales, il y ait lieu de soupçonner l'existence d'irrégularités graves de nature à motiver ce recours[4].

---

1 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 819.

2 – H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 97.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 197, ID 11305.

4 – TA Lux. du 3 février 1989, n° 62/89, *Bulletin du Cercle François Laurent*, III, 1989, pp. 69 ss., cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

■ § 6 – Le réviseur d'entreprises indépendant

Le système du commissaire est caractérisé par le fait que le commissaire, pas plus que l'administrateur, ne doit faire état de qualifications professionnelles qui devraient lui permettre d'exercer sa mission. Ce système, qui avait existé dans plusieurs États de l'Union européenne, a donné lieu à maintes critiques. Finalement, les instances européennes ont opté (au moins pour certaines sociétés) pour un système de **contrôle externe** par une **personne indépendante** et qualifiée professionnellement. Les qualifications requises pour cette personne sont régies par la **Huitième directive** communautaire.

Selon la loi antérieure à la transposition de la Quatrième directive, les comptes des sociétés de capitaux devaient faire l'objet d'un contrôle obligatoire par les commissaires aux comptes, toujours pour les sociétés par actions et exceptionnellement seulement pour la société à responsabilité limitée, à savoir si cette société avait plus de 25 associés.

Ce contrôle devait s'avérer d'une utilité douteuse dans la mesure où il pêchait par une absence flagrante d'indépendance des commissaires par rapport à la société et par le fait que les commissaires n'étaient soumis à aucune condition de qualification. Juridiquement, les commissaires étaient à maints égards assimilés aux administrateurs de la société, notamment du point de vue de la responsabilité.

En cette matière, notre pays avait pris un retard considérable par rapport aux autres pays de l'Union européenne, notamment la Belgique, dans la mesure où celle-ci avait déjà dès 1953 (par la loi du 22 juillet 1953) instauré un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant légalement le révisorat[1]. Avec ces réformes, l'option a été prise de s'éloigner de la surveillance de la gestion pour se limiter à un simple contrôle de celle-ci. Dans les faits, cette évolution n'avait rien de fondamental : en effet, « *à l'instar du réviseur, le commissaire ordinaire faisait du contrôle des comptes l'objet unique de sa mission* »[2].

Cette situation devait changer avec la **Quatrième directive**. L'obligation de contrôler les comptes était prévue à l'égard des sociétés de capitaux. Cette obligation est dans la logique des directives prises en matière de droit des sociétés d'une certaine importance. En effet, si les Première et Deuxième directives adoptées en cette matière étaient destinées à assurer que le capital de ces sociétés était effectivement toujours maintenu, le respect de ces règles ne pouvait pas être abandonné à la discrétion des dirigeants de la société : un contrôle devait être instauré. Contrairement à la situation ayant existé auparavant au Luxembourg, ce contrôle a été confié à un prestataire de services indépendant de la société, à savoir donc un réviseur d'entreprises externe. Au Luxembourg, cette innovation législative devait donc donner lieu à la naissance d'une profession nouvelle.

A – Notion de réviseur d'entreprises (RE) et de réviseur d'entreprises agréé (REA)

Cette matière qui a fait l'objet de maints changements depuis la création de la profession des réviseurs d'entreprises en 1984 est actuellement régie par la loi du 23 juillet 2016 « *relative à la profession de l'audit portant transposition de la directive 2014/56/UE*

1 – Il est à noter une nuance orthographique : alors qu'au Luxembourg la loi se réfère aux « réviseurs d'entreprises » en Belgique on parle des « reviseurs d'entreprises » et de « revisorat ».

2 – A. Benoit-Moury, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », *R.P.S.*, 1986, p. 9.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés […] », en abrégé la « *loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit* »[1]. À la même date, « *le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés* » a été pris.

La profession de réviseur d'entreprises est organisée à l'instar des professions libérales classiques (médecins, avocats, notaires, etc.) exigeant donc pour l'accès à la profession des conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle satisfaites notamment par des diplômes universitaires, des cours complémentaires en droit luxembourgeois, des stages de formation pratique, etc., regroupant les membres en un **ordre professionnel** (l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, IRE) auquel des pouvoirs disciplinaires sont accordés en plus, le cas échéant, d'un pouvoir réglementaire (depuis la réforme constitutionnelle du 19 novembre 2004).

Les titres de RE et de REA sont attribués (et retirés) par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) qui est « *l'autorité compétente pour la supervision publique de la profession de l'audit, pour exécuter les missions prévues par le règlement UE n° 537/2014 et veiller à l'application de ses dispositions* » (art. 36 (2)). Pour obtenir le titre de RE, il faut remplir les conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle prévues par règlement grand-ducal en plus d'être inscrit en tant que membre de l'IRE (art. 3 (2) de la loi sur la profession de l'audit). Pour pouvoir exercer les activités confiées par la loi sur la profession de l'audit (autres que les activités de contrôle légal des comptes), le RE doit avoir au Luxembourg un établissement professionnel ou exercer son activité en tant que salarié d'un cabinet de révision.

1) Les activités respectives des RE et des REA

Ces notions de RE et de REA, qui concernent les personnes physiques, trouvent leur pendant dans la loi sur la profession de l'audit par l'extension aux firmes dont ces personnes physiques font partie ; il est question des notions de « cabinet de révision », de « cabinet de révision agréé », et de « cabinet d'audit ». Précisons quelques notions utilisées par la loi (art. 1er) :

« **cabinet de révision** » : une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, membre de l'IRE remplissant les conditions définies à l'article 3, paragraphe 4 ;

« **cabinet de révision agréé** » : une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, membre de l'IRE qui est agréée conformément à l'article 5 ;

« **cabinet d'audit** » : une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est **agréée** conformément à la directive 2006/43/CE **par les autorités compétentes d'un autre État membre** pour réaliser le contrôle légal des comptes ;

« **contrôle légal des comptes** » : le contrôle des états financiers annuels ou des états financiers consolidés dans la mesure où il est requis par la loi ou par le droit de l'Union directement applicable.

1 – Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, *Mém. A*. 141 du 28 juillet 2007, ID 24809 ; projet de loi n° 6969, ID 24307.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La loi sur la profession de l'audit accorde un champ d'activité plus étendu aux REA (par rapport à celui des RE) : **les REA sont les seuls à pouvoir effectuer le contrôle légal des comptes**. En outre, ils peuvent exercer toutes autres activités accordées par la loi aux RE, y compris celles qui sont visées par le point 35 de l'article 1er de la loi sur la profession de l'audit.

La loi du 23 juillet 2016 définit ces notions comme suit (art. 1er) :

« *(33) "**réviseur d'entreprises**", une personne physique, membre de l'IRE, qui a la qualification professionnelle visée à l'article 3, et qui peut exercer les activités visées au point 34 à l'exclusion de l'activité visée à la lettre a) ;*

*(34) "**réviseur d'entreprises agréé**", un réviseur d'entreprises, membre de l'IRE, agréé conformément à la présente loi pour faire : a) le contrôle légal des comptes ; b) toutes missions qui sont confiées par la loi à titre exclusif aux réviseurs d'entreprises* ».

Les REA, les cabinets de révision agréés et les cabinets d'audit sont inscrits dans un registre public tenu par la CSSF, en français et en anglais sous forme électronique.

2) Déontologie des acteurs de la profession de l'audit

Le chapitre IV de la loi de la profession de l'audit est consacré à la déontologie, l'indépendance, l'objectivité, la confidentialité, le secret professionnel et aux obligations professionnelles.

Deux notions se trouvent ainsi mises en avance : le **scepticisme professionnel** (a) et **l'indépendance** de la profession (b).

a) Lors du contrôle légal des comptes, les réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés et cabinets d'audit font preuve constamment de scepticisme professionnel « *tout au long de l'audit, en reconnaissant la possibilité d'anomalies significatives dues à des faits ou des comportements entachés d'irrégularités, notamment une fraude ou une erreur, quelle qu'ait pu être leur expérience antérieure de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance* ».

Les réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés et cabinets d'audit « *font preuve constamment de scepticisme professionnel notamment lorsqu'ils examinent les estimations de la direction concernant les justes valeurs, la dépréciation des actifs, les provisions et les flux de trésorerie futurs, qui sont pertinentes pour se prononcer sur la continuité d'exploitation* » (art. 18).

Art. 19 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit : « *Indépendance des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés.*

« *(1) L'exercice par le réviseur d'entreprises, le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit d'une de leurs activités respectives visées à l'article 1er, point 34, est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte aux principes de l'indépendance de la profession.*

(2) Lorsqu'il exerce les activités visées au paragraphe 1er, le réviseur d'entreprises ou le réviseur d'entreprises agréé ne peut occuper un emploi salarié si ce n'est qu'auprès d'un cabinet de révision, d'un cabinet de révision agréé ou d'un cabinet d'audit ».

D'après l'article 20 de la loi relative à la profession de l'audit : « *(1) Lorsqu'ils effectuent un contrôle légal des comptes, les réviseurs d'entreprises agréés, les*

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

cabinets de révision agréés, les cabinets d'audit ainsi que toute personne physique qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat du contrôle légal des comptes, doivent être indépendants de l'entité contrôlée. Ils ne peuvent pas être associés au processus décisionnel de l'entité contrôlée ».

L'indépendance est exigée au minimum, à la fois pendant la période couverte par les états financiers à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal des comptes est effectué.

Les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés et les cabinets d'audit prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que, lorsqu'ils effectuent un contrôle légal des comptes, leur indépendance n'est affectée par **aucun conflit d'intérêts** ni **aucune relation d'affaires** ou autre relation directe ou indirecte, existant(e) ou potentiel(le), impliquant le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, son réseau, ses dirigeants, ses auditeurs, ses employés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle du réviseur d'entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d'audit ou toute autre personne directement ou indirectement liée au réviseur d'entreprises agréé, au cabinet de révision agréé ou au cabinet d'audit par une relation de contrôle.

Le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit n'effectue pas un contrôle légal des comptes s'il existe un risque d'autorévision, d'intérêt personnel, de représentation, de familiarité ou d'intimidation lié à une relation financière, personnelle, d'affaires, d'emploi ou autre entre :

– le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé, le cabinet d'audit, son réseau et toute personne physique en mesure d'influer sur le résultat du contrôle légal des comptes, et
– l'entité contrôlée, qui amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure, en tenant compte des mesures de sauvegarde appliquées, que l'indépendance du réviseur d'entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d'audit est compromise ».

Le contrôle légal des comptes se fait conformément aux **normes d'audit internationales** telles qu'adoptées par la Commission européenne. En outre, la CSSF peut, en matière de contrôle légal des comptes, émettre des normes pour des matières non couvertes par les normes d'audit adoptées par la Commission européenne (art. 33 de la loi sur la profession de l'audit).

La loi prend encore soin de réglementer le **contenu du rapport d'audit** (art. 35).

Sont soumises à des dispositions spéciales les « **entités d'intérêt public** », notion définie comme suit par le paragraphe (20) de l'article 1er de la loi sur la profession de l'audit :

« *a) les entités régies par le droit d'un État membre dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE,*

b) les établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, autres que ceux visés à l'article 2 de la directive 2013/36/UE,

c) les entreprises d'assurance et de réassurance telles que définies à l'article 32, paragraphe 1er, points 5 et 9 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances […] ».

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Comme indiqué à un autre endroit, le législateur de 2016 a permis l'institution de comités spéciaux en donnant ainsi un cadre légal à différents comités prévus entre-temps par différentes lois spéciales. Parmi ceux-ci figure notamment le comité d'audit.

Avec l'introduction du réviseur d'entreprises dans notre loi nationale, le législateur ne s'est pas limité à simplement remplacer le commissaire traditionnel par un réviseur professionnel qui aurait repris les mêmes fonctions. En réalité, la loi a procédé à l'introduction d'une fonction nouvelle. Cette fonction nouvelle s'est notamment traduite par la disparition des fonctions de surveillance et de gestion dont le commissaire était (en théorie du moins) investi.

Si le commissaire était traditionnellement chargé de la protection de l'actionnaire, le réviseur est chargé non seulement de la protection des intérêts des associés, mais encore de la protection de l'intérêt du public en général, en particulier des tiers (notamment en cas d'évaluation des apports en nature)[1].

B – Conditions requises dans le chef du réviseur

L'organisation du contrôle des comptes dans les différents États membres n'est pas abandonnée au bon vouloir des États membres : la Huitième directive du Conseil (prise sur la base de l'article 54, § 3, point g) du traité instituant la Communauté économique européenne) datée du 10 avril 1984 a pris soin « *d'harmoniser les qualifications des personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des documents comptables et d'assurer qu'elles soient indépendantes et honorables* »[2].

1) Agrément administratif

Un agrément de la CSSF atteste que toutes les conditions requises sont remplies. Cet agrément peut également être obtenu par des **personnes morales** mais, dans ce cas, il faut que la **majorité** des **administrateurs** ou **gérants** soient des personnes physiques qui sont des réviseurs d'entreprises agréés.

Il est encore nécessaire que le réviseur soit **indépendant de l'entreprise** qu'il s'apprête à contrôler. Ni lui ni un membre de sa proche famille ne peut donc être associé dans cette entreprise, avoir un contrat de travail avec celle-ci ou avoir d'autres relations économiques d'une certaine importance avec celle-ci.

2) Nomination du réviseur

Le cas général est celui de la nomination par ceux qui profitent surtout du travail de contrôle des réviseurs, soit donc par les associés.

a) Nomination par les associés

Le réviseur d'entreprises est en principe obligatoirement désigné par l'assemblée des associés. Tel est le vœu de l'article 69 Loi de 2002 (anc. art. 256 L.S.C.) qui ne

1 – A. Benoit-Moury, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », *R.P.S.*, 1986, p. 11.
2 – Préambule de la directive, *J.O.* L. 126 du 12 mai 1984.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

prévoit pas d'exception, même pour la première qui ne peut être faite par les statuts de la société. La mission du réviseur consiste à contrôler essentiellement les résultats comptables de la gestion de l'entreprise, et ce contrôle se fait très essentiellement au profit des associés : il est donc logique que le bénéficiaire du contrôle désigne le contrôleur et que le rapport décrivant les travaux de contrôle et ces résultats lui soit remis.

b) Nomination par le tribunal ou l'organe de gestion

Par exception à ce principe général, la nomination du réviseur peut être faite par quelqu'un d'autre que l'assemblée des associés.

Exceptionnellement, le réviseur peut être désigné par le tribunal. En effet, lorsqu'une entreprise qui satisfait aux critères d'importance pour être obligée de faire réviser ses comptes annuels ne satisfait pas aux obligations légales, toute personne intéressée est en droit de demander au président du tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référés, de désigner un réviseur aux frais de la société pour une durée de 5 ans au maximum.

Plus surprenantes sont les règles de nomination applicables dans le secteur financier. En effet, la loi du 5 avril 1993 (art. 10 et 22) attribue le pouvoir de nomination du ou des réviseurs d'entreprises au **conseil d'administration**. La même solution est retenue pour les organismes de titrisation : le réviseur est désigné soit par l'organe d'administration de la société de titrisation soit par la société de gestion du fonds de titrisation (art. 48 de la loi du 22 mars 2004).

Dans le secteur des OPC, les règles de nomination du réviseur ne sont pas très précises. Les différentes lois successives (actuellement celle du 17 décembre 2010) applicables non seulement aux FCP, mais encore aux OPC ayant adopté une forme sociétaire n'ont jamais précisé comment le réviseur était désigné. En pratique, la nomination se faisait donc par la **société de gestion**.

C – Missions du réviseur

La mission du réviseur d'entreprises est définie par la loi, et ceci, en différents endroits qui attribuent des missions différentes : en premier lieu, il s'agit du « *contrôle des comptes* » (art. 256 L.S.C. devenu art. 69 de la Loi de 2002) qui définit la mission essentielle du réviseur et dont la particularité est de représenter une **tâche continue** du réviseur. Ce contrôle est complété par un contrôle des comptes de la liquidation de la société (art. 1100-15, anc. art. 151 L.S.C). Après beaucoup d'hésitations sur la question de savoir si cette mission devait ou non être réservée aux réviseurs d'entreprises, l'Institut des Réviseurs d'Entreprises a finalement décidé que la réponse dépendait de la dimension de l'entreprise (donc moyenne ou grande société selon la terminologie utilisée à un autre endroit, voir p. 265). Si la société avait besoin d'un réviseur avant sa mise en liquidation, alors le commissaire de liquidation sera obligatoirement réviseur d'entreprises.

D'autres missions du réviseur sont plus ponctuelles : en cas d'émission de parts bénéficiaires (art. 430-1, anc. art. 37 L.S.C.), le contrôle des apports autres qu'en numéraire (art. 420-10, anc. art. 26-1 L.S.C.), des opérations de fusion et de scission (art. 1021-6 et art. 1031-6, anc. art. 294 L.S.C.).

En dehors de ces missions confiées par la L.S.C., d'autres entités ont également recours aux services des réviseurs et, en général, sans avoir recours à des

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

critères de taille de ces entités (voir p. 265) ; tel est le cas des articles 100 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, des articles 10 et 22 la loi du 5 avril 1993 sur les établissements de crédit, de la loi du 20 décembre 2002 sur les OPC et les sociétés de gestion, de la loi du 8 juin 1999 sur les fonds de pension, de la loi du 15 juin 2004 sur les SICAR, de la loi du 20 mars 2004 sur les organismes de titrisation.

On voit donc que la liste des lois spéciales attribuant une mission de contrôle des comptes aux réviseurs d'entreprises s'est considérablement allongée ces dernières années. En fait, à chaque fois que de nouveaux véhicules juridiques ont été créés (et Dieu sait si le législateur luxembourgeois n'a pas chômé en cette matière pendant les dernières années), le choix du législateur a été de systématiquement rendre obligatoire le contrôle des comptes par un réviseur d'entreprises.

En tout état de cause, la mission du réviseur est une mission de **contrôle,** et non une mission de **surveillance**. Les fautes de gestion échappent à l'investigation du réviseur d'entreprise. La loi n'a pas entendu organiser un contrôle de gestion, ce qui explique précisément que le terme de surveillance soit absent de la terminologie L.S.C. dans la définition de la mission du réviseur[1].

D – Rapport de contrôle

L'article 69*bis* de la Loi de 2002 précise le contenu du rapport d'audit (ou rapport de révision). Le rapport, établi conformément aux normes d'audit internationales, décrit les résultats du contrôle légal des comptes, contient une description de l'étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l'indication des **normes d'audit** conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué ; en outre, « *il contient un avis qui est soit sans réserve, soit assorti de réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés :*

i) quant à la ***fidélité de l'image donnée par les comptes annuels*** *conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu ; et*

ii) le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.

Si le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ne sont pas en mesure de rendre un avis, le rapport contient une déclaration indiquant l'impossibilité de rendre un avis […] ».

Art. 69*ter.* « *Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l'obligation collective de veiller à ce que les comptes annuels, le rapport de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise, ainsi que le rapport visé à l'article 68*bis*, paragraphe (5), soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002* ».

La Loi de 2002 prévoit une **exemption du contrôle révisoral** à l'égard, d'une part, des sociétés filiales et, d'autre part, à l'égard des sociétés mères. Le motif de ces deux types d'exemption est le même, à savoir le souci d'éviter le double emploi :

1 – A. Benoit-Moury, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », *R.P.S.*, 1986, p. 23.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

à condition d'être soumis à un contrôle au niveau supérieur (cas des filiales) ou dans ses propres comptes consolidés (cas de la société mère), les comptes sociaux de l'entité visée sont exemptés de l'obligation de révision.

Cette exemption est subordonnée au respect des conditions suivantes dans le **cas des filiales** (art. 70 Loi de 2002) :

« *a) l'entreprise mère relève de la législation d'un État membre des Communautés européennes ;*

b) tous les actionnaires ou associés de la société filiale se sont déclarés d'accord sur l'exemption indiquée ci-dessus ; cette déclaration est requise pour chaque exercice ;

c) l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par la société filiale ;

*d) les déclarations visées sous b) et c) font l'objet d'une publicité de la part de la société filiale dans les formes prévues à l'article 11*bis*, § 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre V*bis *du titre I*er *de la présente loi ;*

e) la société filiale est incluse dans les comptes consolidés établis par l'entreprise mère conformément à la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les comptes consolidés (dite "septième directive") ou conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;

f) l'exemption indiquée ci-avant est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par l'entreprise mère ;

*g) les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé de gestion et le rapport de la ou des personnes chargées du contrôle de ces comptes font l'objet d'une publicité de la part de la société filiale dans les formes prévues à l'article 11*bis*, § 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre V*bis *du titre I*er *de la présente loi* ».

Dans le cas des **sociétés mères**, les conditions de l'exemption sont (art. 71 Loi de 2002) :

« *a) la société mère établit des comptes consolidés conformément à la directive 83/349/CEE ou conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales et elle est comprise dans la consolidation ;*

b) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes annuels de la société mère ;

c) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par la société mère ;

d) le résultat de l'exercice de la société mère, calculé conformément au présent chapitre, figure au bilan de la société mère ».

E – Différences entre réviseur d'entreprises et commissaire

Dans la catégorie des sociétés de capitaux, caractérisée par le fait que les associés n'assument qu'une responsabilité limitée, le législateur prévoit souvent

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

(mais pas toujours !) que la surveillance de la société soit assurée par un commissaire (parfois désigné par l'expression « commissaire aux comptes », même si ce terme n'est pas conforme à la terminologie légale). En outre, la réglementation de l'Union européenne prévoit le contrôle des comptes annuels de ces mêmes sociétés. Il résulte de ces réglementations un certain double emploi potentiel en matière de contrôle des comptes.

La directive prévoit une **exemption** à l'obligation de contrôle à l'égard des **« petites sociétés »** (terminologie utilisée ni par les directives ni par les lois luxembourgeoises (L.S.C. et Loi de 2002)) et qui vise les sociétés ciblées par l'article 35 de la Loi de 2002, disposition libellée comme suit :

Art. 35. « *Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :*
– *total du bilan : 4,4 millions d'euros*
– *montant net du chiffre d'affaires : 8,8 millions d'euros*
– *nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : 50,*

peuvent établir un bilan abrégé dont la forme et le contenu sont déterminés par un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables.
[...]

Art. 36. (1) Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites de deux des trois critères indiqués à l'article 35, cette circonstance ne produit des effets pour l'application de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs ».

Cet article 36 est parfois mal interprété par certains praticiens qui considèrent que cet article signifierait qu'une société moyenne ou grande nouvellement créée pourrait échapper au contrôle révisoral pendant ces deux premières années d'existence. Or, cet article ne prévoit l'absence de contrôle révisoral que si une société « *vient soit de dépasser soit de ne plus dépasser les limites […]* » et il ne vise donc que les cas où un basculement d'une catégorie à une autre se produit. Donc, une société moyenne (ou grande) dès le départ n'est pas en droit de retarder l'application des dispositions de la directive de deux années sur la base de cette disposition.

Les « petites sociétés » (donc celles ne dépassant pas 2 des 3 critères de l'article 35) n'étant donc pas obligées de faire réviser leurs comptes annuels, ces sociétés sont en principe donc soumises au **contrôle du commissaire** prévu par l'article 443-1 L.S.C. lorsqu'il s'agit d'une S.A. Les sociétés dépassant au moins deux des trois seuils prévus par l'article 35 de la Loi de 2002 sont obligées de faire réviser leurs comptes annuels par un REA avec donc en principe le double contrôle, donc par le REA en plus de celui exercé par le commissaire.

C'est à cet endroit qu'intervient la Loi de 2002 en donnant en fait priorité au contrôle par le REA (donc en fait le contrôle imposé par la législation de l'Union européenne). « *L'institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée dans les sociétés qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé conformément au paragraphe 1* » (art. 69 (3) Loi de 2002).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cet article prévoit donc que les sociétés autres que les petites sociétés (définies par l'article 35 de la Loi de 2002) qui sont donc obligées d'avoir recours à un réviseur d'entreprises n'auront plus de commissaire. Il y a lieu d'insister sur le fait que la version susvisée de l'article 69 (3) L.S.C. diverge de la version antérieure : alors que la version de la loi du 19 décembre 2002 visait les « sociétés qui ont l'obligation légale de faire contrôler leurs comptes annuels », la version actuelle (applicable depuis la loi du 12 juillet 2013) se réfère aux « sociétés qui font contrôler leurs comptes annuels par un REA ». La différence est importante dans la mesure où, par le passé, une petite société qui volontairement faisait réviser ses comptes par un REA était obligée de maintenir le commissaire en fonction au motif qu'il n'appartient pas aux sociétés de déroger aux choix imposés par le législateur : en fait, il y avait donc double contrôle. La situation est différente sous la nouvelle réglementation : la petite société a la possibilité de « se débarrasser » du commissaire tout simplement en chargeant un REA du contrôle légal des comptes (même si ce contrôle n'est pas imposé par la loi).

À l'égard des **sociétés en commandite par actions**, la loi du 12 juillet 2013 a encore innové en revenant sur la position antérieure qui était effectivement critiquable. En effet, la Loi de 2002 prévoyait à l'égard de la S.e.c.a. exactement la même solution que pour les S.A. en prescrivant que la nomination du réviseur (même si elle n'était pas obligatoire) emportait la suppression du commissaire pour ce genre de société. Cette solution était peu appropriée pour la raison que, dans la S.e.c.a., les commissaires ont une fonction de vraie surveillance des associés commandités auxquels ils étaient appelés à faire contrepoids. La loi du 12 juillet 2013 a donc reconnu cette différence par rapport à la S.A. en rendant **la suppression du conseil de surveillance facultative** dans tous les cas de nomination d'un réviseur d'entreprises : art. 69 (3*bis*) « *Une société en commandite par actions, qui fait ou doit faire contrôler ses comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé, peut décider de ne pas instituer un conseil de surveillance* ».

Le résultat de la mission du contrôleur (qu'il s'agisse du commissaire ou du réviseur indépendant) se concrétise dans un **rapport** tenu à disposition des associés au siège de la société, et ceci, au moins 15 jours avant l'assemblée annuelle. Le rapport fait l'objet des mêmes mesures de publicité que les comptes annuels (voir art. 79 Loi de 2002). Si, traditionnellement, la loi était muette sur le contenu du rapport (celui établi par le commissaire), il n'en va plus ainsi dans le cadre du rapport du réviseur. Le rapport du réviseur doit être écrit et circonstancié en se terminant par une **conclusion** par laquelle le réviseur résume clairement la portée de son attestation des comptes annuels[1].

Trois formes de conclusion sont envisageables : **l'attestation** sans réserve, l'attestation avec réserve et le refus d'attestation[2]. Dans ce contexte, on utilise encore le terme de « *certification* ».

« *Par certification, il faut entendre* l'attestation*, faite par le réviseur, après avoir effectué les contrôles d'usage conformément aux règles de la profession et compte tenu des prescriptions légales et réglementaires en la matière, que les documents présentés et les informations fournies donnent une image fidèle de la situation qu'ils entendent refléter* »[3].

1 – A. Benoit-Moury, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », *R.P.S.*, 1986, p. 26.

2 – A. Benoit-Moury, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », *R.P.S.*, 1986, p. 27.

3 – Rapport G. Verhaegen, *Doc. parl.*, Ch., 1982-1983, 552, n° 35, pp. 14-16.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

F – Différences entre réviseur et commissaire

Le remplacement du commissaire par le réviseur d'entreprises dans les sociétés de capitaux d'une certaine importance pourrait amener à conclure que les deux fonctions seraient identiques. Tel n'est pourtant pas le cas.

Alors que le commissaire est un organe de la société, le réviseur doit être indépendant de la société et il est lié à celle-ci par un contrat de louage de service ; les relations sont donc de **nature contractuelle**. Le commissaire peut être lié à la société notamment en étant associé de celle-ci. Le contrat qui lie le réviseur ne peut être résilié que pour des motifs graves (voir art. 69 (1) a), troisième alinéa Loi de 2002).

Si le commissaire a un pouvoir de contrôle général, le réviseur pour sa part n'a que la mission de contrôler les comptes (en plus d'une mission de surveillance). Il n'est donc pas amené à intervenir dans la gestion.

G – Responsabilité du réviseur d'entreprises

Celle-ci est de **nature contractuelle**, étant donné qu'il est lié à la société contrôlée par un contrat de prestation de services.

1) Nature de la responsabilité

Le contrôle exercé par le réviseur résulte obligatoirement en une conclusion dans la mesure où le réviseur considère, par exemple, que les comptes annuels donnent une image fidèle de la situation de la société. Si cette conclusion se révèle ne pas être correcte, la responsabilité du réviseur peut être engagée par des personnes lésées du fait que les comptes annuels se sont montrés par la suite être incorrects en traduisant une réalité moins brillante.

Il se pose alors la question de savoir si le réviseur dans le cadre de sa mission légale assume une **obligation de moyen** ou **de résultat** (c.-à-d. que le débiteur est tenu de procurer le résultat attendu au créancier). La jurisprudence retient que cette obligation est de moyen seulement. Cette conclusion est notamment basée sur le fait que le réviseur, dans la grande majorité des cas, n'est pas à même de vérifier de façon exhaustive toutes les opérations faites par la société. Il est donc réduit à opérer par **sondages** et, à partir de ceux-ci, à procéder par **extrapolation** pour conclure avec une certaine probabilité à une conclusion donnée.

Dans l'appréciation consistant à vérifier si le réviseur a commis une faute dans l'exercice de sa mission, il convient encore de se référer aux normes de révision émises par **l'Institut des Réviseurs d'Entreprises** (IRE). Celles-ci, sans nécessairement s'imposer au juge (ou aux tiers qui auraient subi un dommage et qui chercheraient indemnisation), auront en fait un poids considérable : en d'autres termes, le réviseur qui peut montrer avoir scrupuleusement suivi les instructions de l'IRE relatives à l'exécution de sa mission aura de bonnes chances d'échapper à la mise en cause de sa responsabilité. À l'inverse, le tiers lésé va essayer d'établir que le réviseur n'a pas suivi les normes qui s'imposent à lui, ce qui est déjà en soi constitutif d'une faute, le cas échéant cause du dommage subi par lui.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2) Partage de la responsabilité

Souvent, ce ne sera pas la responsabilité du seul réviseur d'entreprises qui sera engagée, mais d'autres seront dans la même situation. Ainsi, en particulier en cas d'évaluation d'apports en nature, trois types de responsabilité pourront être engagés :

– celle des fondateurs (administrateurs/directoire) ; ils doivent évaluer l'apport en nature ;
– celle du réviseur : sa mission est de contrôler l'évaluation faite par les fondateurs (administrateurs/directoire) ;
– celle du notaire chargé de la rédaction de l'acte ; il doit vérifier si l'évaluation a été faite sur la base des dispositions légales applicables[1].

3) Prescription de l'action en responsabilité

Aux termes de l'article 11 (2) de la loi du 23 juillet 2016 sur la profession de l'audit :

« *Les actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d'entreprises, un réviseur d'entreprises agréé, un cabinet de révision, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit se prescrivent* ***par cinq ans*** *à compter de la date de la fin de la prestation de son service. Dans le cadre d'un contrôle légal des comptes, les actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d'entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit se prescrivent* ***par cinq ans*** *à compter de la date du rapport d'audit* ».

La loi distingue donc les actions en responsabilité concernant le contrôle légal des comptes (deuxième phrase des autres actions). Si le délai de prescription est le même, le point de départ de ce délai change légèrement.

Dans un litige soumis à la Cour d'appel de Luxembourg[2], la question était de savoir si cette même disposition devait s'appliquer également lorsque le travail du réviseur portait non pas sur la révision des comptes annuels (donnant donc lieu à un rapport de révision), mais sur un rapport portant sur l'évaluation d'un apport en nature (art. 420-10, anc. art. 26-1 et art. 420-23 (6), anc. art. 32-1 (6)). Les défendeurs argumentaient que tel n'était pas le cas et que la responsabilité du réviseur ne pouvait être engagée que dans le cas d'un rapport de révision. Le tribunal n'accepta pas cette argumentation et retint que constitue « *un rapport de révision au sens de l'article 5, alinéa 3, de la loi modifiée du 28 juin 1984, tout rapport établi par un réviseur d'entreprises dans l'accomplissement d'une des fonctions légales lui réservées à titre de monopole en vertu de l'article 1er de la loi modifiée du 28 juin 1984 et qui sont caractéristiques des fonctions légales du réviseur d'entreprises* »[3].

4) Les clauses restrictives de la responsabilité

En pratique, les contrats de prestations de services conclus avec les clients prévoient souvent des clauses limitant les dommages-intérêts éventuellement dus par le

1 – Note interprétative de l'article 26-1 L.S.C., ID 7520, établie par le groupe de travail « Droit des sociétés » de la Commission d'études législatives, de 1994.

2 – CA du 15 juillet 2003, ID 10335.

3 – CA du 15 juillet 2003, ID 10335.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

réviseur. Ainsi peut-on voir des contrats en vertu desquels le montant des dommages est limité à un maximum de **dix fois les honoraires** encaissés pour l'exécution de la mission litigieuse.

Par application des principes généraux applicables en matière de responsabilité, cette limitation de responsabilité ne peut jouer qu'entre parties (entre la société et le réviseur et, le cas échéant, entre le réviseur et les tiers exerçant l'action oblique au nom de la société contre le réviseur) et en aucun cas elle ne peut servir à limiter la **responsabilité à l'égard des tiers**. Ces derniers peuvent donc ignorer ce genre de conventions pour demander l'indemnisation totale de leur préjudice[1].

Pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, le tiers devra donc établir la **faute** du réviseur (et non pas seulement le résultat[2], donc que les comptes annuels n'étaient pas tels que certifiés par le réviseur), le **dommage** ainsi que le **lien de causalité** entre la faute et le préjudice.

La faute du réviseur est établie s'il est prouvé qu'il n'a pas pris toutes les diligences qu'il aurait dû prendre dans la situation donnée, notamment donc s'il n'a pas travaillé selon les normes de révision de l'IRE.

Le préjudice peut évidemment prendre de multiples formes. Prenons le cas d'un fournisseur ou d'un banquier qui, sur la base des bons chiffres repris par les comptes annuels, accorde des crédits supplémentaires à la société. La situation financière de la société étant pourtant beaucoup moins bonne qu'annoncée par les comptes annuels certifiés par le réviseur d'entreprises, ces crédits ne sont pas remboursés par la suite, la société étant tombée en faillite. Dans ce cas, le dommage consiste dans la perte des crédits accordés. Reste à établir le lien de causalité : les crédits n'auraient-ils pas été accordés si la situation de la société avait été mieux évaluée par le réviseur ? Il s'agit ici dans une très large mesure d'appréciation de circonstances spécifiques au cas d'espèce.

H – Obligation de collaboration avec les autorités de surveillance

C'est surtout dans les différents domaines du secteur financier que le réviseur s'est vu attribuer certaines tâches destinées à assister les autorités de surveillance dans leur mission de surveillance du secteur financier. Ainsi, de par la loi, le réviseur d'entreprises est tenu de signaler à la CSSF tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l'exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d'un OPC ou d'une autre mission légale auprès d'un OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à :

- constituer une **violation substantielle** des dispositions de la loi du 17 décembre 2010 relative aux OPC ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou
- porter **atteinte** à la **continuité** de **l'exploitation** de l'OPC, ou
- entraîner le **refus** de la **certification** des comptes ou l'émission de réserves y relatives.

Le réviseur d'entreprises est également tenu d'informer rapidement la CSSF, dans l'accomplissement des missions visées à l'alinéa précédent auprès d'un OPC, de

1 – C. Delvaux, *Les sociétés anonymes*, p. 378.

2 – Comme mentionné ci-dessus, le réviseur n'assume qu'une obligation de moyens (et non de résultat).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

tout fait ou décision concernant l'OPC et répondant aux critères énumérés à l'alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s'acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d'une autre mission légale auprès d'une autre entreprise liée à cet OPC par un lien de contrôle (art. 154 (3) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif[1]).

SECTION IV
REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ PAR DES MANDATAIRES

Comme mentionné ci-dessus, les sociétés dotées de la personnalité morale agissent par leurs organes légaux. Ceci n'exclut en rien que les sociétés puissent avoir recours à des mandataires, pour les représenter sur la base de procurations. Il est entendu qu'un organe légal ne pourrait pas déléguer la totalité de ses pouvoirs à un tiers[2].

La qualification de mandat n'est pas particulièrement adaptée à la situation des dirigeants de société. « *En effet, le mandat est limité à l'accomplissement d'actes juridiques avec représentation à l'égard des tiers. Or à l'égard des tiers, les gestionnaires ne sont pas des mandataires mais des organes de la société. Leur prétendu mandat ne concerne donc que la prise des décisions dans la sphère interne de la société, décisions qui, au demeurant, ne sont pas toutes destinées à être mises en œuvre par des actes de représentation. On dénature donc le mandat en l'amputant de sa caractéristique essentielle qui est la représentation à l'égard des tiers* »[3].

En application du droit commun du mandat, le mandataire n'est pas engagé personnellement, à condition d'avoir contracté au nom du mandant. Dans la négative, la représentation ne joue pas, et le tiers n'a d'action que contre le mandataire.

Dans certains cas, la société peut, nonobstant l'absence d'un mandat ou d'un mandat insuffisamment large, être tenue, et ceci, sur la base de la théorie du **mandat apparent**[4].

1 – ID 5288.

2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 651.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 212.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 652.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

3

PARTIE III – LE DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

L'intérêt de regrouper en catégories les sociétés soumises à des règles similaires est double : l'appartenance d'une société à une catégorie déterminée renseigne immédiatement sur son régime juridique ; l'analyse des règles applicables aux sociétés d'une même catégorie permet de dégager des principes généraux[1].

Par droit spécial des sociétés, nous entendons le **droit des différentes formes de sociétés commerciales** prévues par l'article 100-2 L.S.C. L'archétype de la société commerciale étant de nos jours la société par actions, nous allons commencer par ce type de société qui, tout en n'étant pas la forme la plus ancienne de société commerciale, est de nos jours le type le plus important et, en tout cas, le type le plus exposé au droit européen, et donc également le type le plus réglementé.

1 – T. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 199.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE I
LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

« *L'actionnaire est agneau quand les affaires vont bien, il est tigre quand elles vont mal, mais il est toujours une bête* »[1].

Si l'article 410-1 L.S.C. définit la S.A. comme étant « *[…] constituées par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée* », cette caractéristique n'est en réalité pas distinctive pour les sociétés par actions et encore moins pour les sociétés anonymes. La forme des sociétés par actions se distingue des autres sociétés de capitaux non pas par la responsabilité limitée, mais par le fait qu'elle émet des actions, donc des titres librement transmissibles. Si ce point peut paraître en tant que tel assez anodin et en fin de compte sans grande importance réelle, il ne faut pas perdre de vue qu'en réalité cette caractéristique a donné lieu au capitalisme moderne et aux grands groupes boursiers qui ont changé le monde.

CHAPITRE I
LES SOCIÉTÉS ANONYMES

« *Les sociétés anonymes sont les fléaux des temps modernes, plus néfastes que les guerres, les tremblements de terre et les famines* », Rudolf von Jhering[2].

« *La société anonyme est le type parfait de société de capitaux : la personnalité des associés y apparaît non seulement distincte mais indépendante de la personnalité de l'être moral. En aucune façon les associés ne sont garants des engagements de celui-ci, les tiers étant dépourvus de toute action directe contre eux et ne pouvant, même dans les limites de leur mise, que les poursuivre au nom et pour compte de la société, par le circuit de l'action indirecte de l'article 1166 C.c.* »[3].

Alors que tant l'associé commanditaire que l'actionnaire ne sont tenus aux dettes et pertes sociales qu'à concurrence de leur apport, la situation des deux diffère en ce que l'actionnaire n'est tenu que vis-à-vis de la société ; le commanditaire en tant que membre d'une société de personnes se trouve directement tenu de son obligation vis-à-vis des tiers[3].

La société anonyme, en définitive, se distingue par la combinaison de deux caractéristiques de toutes les autres formes de sociétés. Il s'agit de :

– la responsabilité limitée de tous les associés,

– l'émission d'actions.

1 – C. Resteau, *Traité des sociétés anonymes*, T. 1., p. 17.

2 – Cité par Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport de la commission spéciale, p. 262, ID 9787.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 68, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Si la responsabilité limitée de tous les associés permet de distinguer la société anonyme de toutes les sociétés de personnes et de la S.e.c.a. (mais non des sociétés à responsabilité limitée), l'émission d'actions permet de distinguer ce genre de sociétés des sociétés à responsabilité (en plus de la distinguer par rapport aux sociétés de personnes et autres sociétés coopératives).

À l'époque de l'élaboration de la Loi de 1915, on pouvait encore se satisfaire d'une définition plus simple : « *La société anonyme est celle dans laquelle aucun des associés n'est tenu au-delà de sa mise* » (art. 27 de l'avant-projet)[1]. Cette définition n'est évidemment plus suffisamment distinctive depuis que la loi de 1933 sur la S.à r.l. a été adoptée.

L'article 24 L.S.C. précisait encore que la S.A. n'a **pas de raison sociale** et qu'elle n'est désignée par le nom d'aucun associé. Avec Pirmez, on peut se poser la question de l'utilité de cette deuxième restriction dans la mesure où il existe bon nombre de sociétés anonymes dont le nom comporte justement celui d'un associé (ou de la famille des associés). La question se pose donc de savoir si un administrateur engagerait sa responsabilité si le nom d'un associé figurait dans la dénomination ; on peut fortement douter que tel soit le cas ; (en effet, même les grandes sociétés portent souvent les noms patronymiques : Siemens, Peugeot, Renault, Paul Würth[2]. La jurisprudence consacre cet usage constant dans tous les pays en admettant que la société anonyme soit connue par le nom d'un de ses fondateurs[3].

Quant au fonctionnement de la société anonyme, certains ont constaté une analogie avec un État moderne : « *Les rouages d'une société anonyme sont comparables à ceux d'un État moderne. Le conseil d'administration constitue le pouvoir exécutif, le Gouvernement. Les attributions du conseil de surveillance sont pour partie celles dévolues au Conseil d'État et pour partie celles de la Chambre des comptes. Enfin, l'assemblée générale représente le Parlement de la société anonyme. La société a sa constitution, ce sont les statuts […]* »[4].

SECTION I
L'ACQUISITION DE LA FORME DE SOCIÉTÉ ANONYME

Sous le Code de commerce de 1808, la constitution de la société anonyme était soumise à une autorisation gouvernementale. Cette condition « *considérée à la fois comme vexatoire, inutile et dangereuse* »[5] ne fut reprise ni par la loi belge de 1873 ni par la loi luxembourgeoise de 1915.

La société anonyme est l'une des sociétés commerciales, en fait la plus réglementée, du droit des sociétés luxembourgeois. L'esprit de la réglementation tourne autour de considérations majeures comme la protection des tiers (notamment des créanciers de la société), ainsi que celle des actionnaires minoritaires. Ceci est dû également aux directives de l'Union européenne : la société anonyme est soumise non seulement à la **Première directive** qui s'applique aux sociétés anonymes et aux

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 102, ID 11305.

2 – E. Pirmez, Observations sur Avant-projet de loi rédigé par A. Nyssens, p. 11, ID 11305.

3 – M. Coipel, Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés, p. 163.

4 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, Discussion, p. 306.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 70, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

S.e.c.a. et aux S.à r.l., mais également à la Deuxième directive qui, elle, est applicable aux seules sociétés anonymes. En d'autres termes, la forme de la société anonyme est la plus exposée aux velléités d'harmonisation du droit européen.

Il existe deux façons d'acquérir la forme de la société anonyme. La première est celle de la constitution d'une société de cette forme, la seconde est la transformation d'une société constituée sous une autre forme.

§ 1 – La constitution d'une société anonyme

La L.S.C. distingue selon que la société fait ou non appel public à l'épargne. Le nombre des sociétés faisant appel public à l'épargne est très limité au Grand-Duché de Luxembourg. Les particularités des sociétés faisant appel public à l'épargne seront envisagées dans la Partie II, au Titre I « Notion de société ».

A – Acte de constitution

La loi se réfère en deux endroits différents à l'exigence d'un acte notarié. Dans l'article 100-4 [anc. art. 4], la L.S.C. dispose que les sociétés anonymes, etc. soient constituées par **actes notariés spéciaux**. Est donc requise la forme authentique pour l'acte qui contient les stipulations sociales. La disposition de l'article 420-1 (2) (anc. art. 26 (2)) L.S.C. pour sa part exige la constatation authentique de l'accomplissement des conditions légales, à savoir que le capital social minimum soit atteint, que ce capital soit entièrement souscrit et que chaque action soit libérée à concurrence d'un quart au moins[1].

Le notaire se borne-t-il à acter les affirmations des comparants ou bien doit-il lui-même vérifier l'accomplissement de ces conditions ? L'avant-projet Corbiau retient encore la première solution en mentionnant que l'acte de société prouve uniquement l'affirmation des comparants, et ceci, jusqu'à inscription de faux[1]. Telle n'est plus la situation actuellement, dans la mesure où la loi précise que « *le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera l'existence de ces conditions et en constatera expressément l'accomplissement* »[2]. Le notaire ne peut donc pas se contenter d'acter les affirmations des comparants.

Traditionnellement, la constitution d'une société anonyme requérait qu'il y eût au moins deux associés. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 août 2006, il suffit d'un seul associé (alors dénommé « *associé unique* ») pour constituer une société anonyme : « *La société anonyme est celle […] qui est constituée par une ou plusieurs personnes* ». La L.S.C ne prévoit pas de nombre maximum d'associés. Le nombre des associés de la société anonyme est donc illimité (contrairement à celui de la S.à r.l.).

Le capital de la société doit être de 30 000 euros au moins, montant qui a remplacé le montant minimum antérieur de 30 986,69 euros. Ce dernier montant était évidemment le résultat d'un calcul de conversion, à savoir donc celui ayant consisté à convertir le montant de capital minimum de 1 250 000 francs en euros. Ce dernier montant était lui-même le résultat d'une disposition communautaire : selon la

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 71, ID 11308.

2 – V. Projet de loi portant révision de la loi sur les sociétés commerciales, Avis du Conseil d'État, p. 73, ID 13321.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Deuxième directive, le capital minimum des sociétés anonymes devait atteindre au moins 25 000 unités de comptes.

En outre, le Conseil, sur proposition de la Commission, soumet en principe à examen, et, le cas échéant, à révision tous les 5 ans le montant de ce capital minimum « *compte tenu d'une part de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté et d'autre part des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés visées à l'article Ier, paragraphe 1, aux grandes et moyennes entreprises* » (art. 6).

Le capital social doit être **intégralement souscrit** et chaque action doit être libérée d'un quart au moins par versement en numéraire ou par apport en nature. Le notaire rédacteur de l'acte doit vérifier l'existence de ces conditions et doit expressément en constater l'accomplissement.

Le montant apporté pour libérer le capital social peut être utilisé pour payer les frais de constitution avec le résultat que le capital social se trouvera immédiatement entamé en raison de ces frais de constitution.

Il est à noter que, sur cette question, le droit européen a entre-temps considérablement évolué. En effet, la tendance n'est plus à imposer des montants minima de fonds propres importants, et dans plusieurs États membres, il est de nos jours possible d'avoir des sociétés de capitaux avec des montants de fonds propres symboliques. Ainsi peut-on voir dans l'affaire *Centros Ltd*[1] que le capital minimum d'une société *limited* anglaise était de 100 LSG dont aucune fraction n'avait été libérée. De même, une SAS française peut être constituée avec un montant de capital très réduit.

Plus proche de chez nous, la S.à r.l.-S peut avoir un capital de 1 euro.

Le fait que le capital social minimum soit **exprimé en euros** ne fait pas obstacle à la possibilité qu'ont les sociétés d'exprimer leur capital en une monnaie autre que l'euro. En pratique, il est d'ailleurs souvent profité de cette possibilité.

La question qui est souvent posée est de savoir si le fait que le capital social est exprimé en une certaine devise (donc l'euro, p. ex.) signifie nécessairement que le bilan doit également être tenu en euros. La réponse à cette question est en fait affirmative, et ceci, pour des raisons essentiellement pratiques.

Exemple

Supposons que le capital social tel que repris à l'article correspondant des statuts sociaux soit de 100 000 euros. Ce montant doit également être repris au bilan. Nous supposons maintenant que le bilan est exprimé en une autre devise, mettons le $US, et que le cours de change entre les deux devises est initialement de 1 contre 1. À supposer encore que celui-ci ait varié de 10 % à la fin du premier exercice, alors on serait obligé en raison du principe de la fixité du capital social d'adapter ce montant pour l'ajuster soit à 110 000 euros ou encore à 90 000 euros.

Or, le capital social exprimé dans les statuts doit rester fixe (sauf à changer les statuts) ; le capital social exprimé au bilan va donc varier, mais sans que l'on sache comment comptabiliser la différence au bilan et à quel titre ajuster le capital social tel que repris au bilan de la société.

La L.S.C (art. 420-15) énumère les indications minimales qui doivent figurer dans l'acte de société. L'objectif est d'assurer la sécurité des participants au pacte social.

1 – CJCE, aff. *Centros*, 9 mars 1999, C-212/9, ID 11674.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Ces mentions obligatoires sont reprises essentiellement des articles 2 et 3 de la Deuxième directive 77/91/CEE du 13 décembre 1976, étant précisé que l'article 2 reprend les données obligatoirement incluses dans les statuts tandis que l'article 3 énumère celles qui sont comprises soit dans les statuts soit dans un document séparé. Comme au Luxembourg il n'existe pas de tel document séparé, le législateur a obligé d'insérer toutes ces indications dans l'acte de formation (appelé acte constitutif).

L'acte de société doit indiquer (art. 420-15 L.S.C.) :

i) l'identité des personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom desquelles il a été signé ;
ii) la forme de la société et sa dénomination ;
iii) son siège social, son objet social ;
iv) le montant du capital souscrit et, le cas échéant, celui du capital autorisé ;
v) le montant initialement versé du capital souscrit, les catégories d'actions, lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories ;
(vi) le nombre d'actions souscrites et, en outre, dans le cadre d'un capital autorisé, les actions à émettre de chaque catégorie et les droits afférents à chacune de celles-ci, ainsi que la valeur nominale des actions ou le nombre des actions sans mention de valeur nominale et les conditions particulières qui limitent la cession des actions ;
(vii) la forme nominative, au porteur ou dématérialisée des actions ainsi que toute disposition complémentaire ou dérogatoire à la loi relative à la conversion des titres ;
(viii) la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l'apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d'entreprise prévu à l'article 420-10 L.S.C. ;
(ix) la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société ;
(x) le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales ;
(xi) dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ;
(xii) la durée de la société ; et
(xiii) le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution.

B – Les apports

La première question que l'on peut se poser est celle de savoir si l'opération d'apport constitue un contrat entre l'apporteur et la société.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Selon une partie de la doctrine au moins, elle doit s'analyser en tant qu'acte juridique unilatéral[1].

1) Composition des apports

Aux vœux de la Deuxième directive (art. 7) « *le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique* ». Cette disposition explique la suivante : « *Toutefois, ces éléments d'actif ne peuvent être constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services* » (anc. art. 26-3 repris par l'article 420-12 L.S.C.).

Le capital de la société anonyme doit être intégralement souscrit. Ce principe est tout à fait général, car il est applicable non seulement à la constitution, mais également à l'occasion d'augmentations de capital ultérieures. Il est par conséquent interdit **d'émettre** des actions **au-dessous** de la **valeur nominale** ou encore du pair comptable des actions émises (art. 420-14 (1) L.S.C.). La Loi de Modernisation a repris cette exception dans son article 420-22 L.S.C. tout en la précisant davantage.

La justification de cette règle, qui existe également dans nos pays voisins, est la suivante : « *Il ne faut pas accorder la forme privilégiée des sociétés par actions à des entreprises si peu sérieuses que l'on ne parvient pas à faire souscrire le capital jugé nécessaire pour leur exploitation. Permettre le contraire, ce serait favoriser l'agiotage et les entreprises téméraires ; car si tel capital a été estimé nécessaire, la société serait exposée à la ruine si elle se constituait avec des ressources moindres* »[2]. En outre, cette règle protège les premiers souscripteurs qui sont ainsi assurés que les fonds investis ne pourront être investis qu'avec les autres, donc à condition que le capital social prévu puisse être réuni.

La loi, en son article 420-14 (anc. art. 26-5) L.S.C., fait exception à cette règle dans le sens qu'elle permet à des intermédiaires professionnels de payer moins pour les actions que le prix correspondant à la valeur nominale des actions.

Malgré ces règles, il y a lieu de mentionner qu'il peut y avoir des raisons fort valables pour émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes.

Exemple

La société anonyme Lux Invest a émis un capital de 150 000 euros représenté par 1500 titres de 100 euros. En raison des pertes d'exploitation subies en 2007, les fonds propres effectifs ont diminué à 90 000 euros et le pair comptable des actions est réduit à 60 euros. La société décide d'augmenter son capital de 150 000 à 300 000 euros. Si l'augmentation doit se faire au pair comptable des actions anciennes, alors on devra en émettre 1500. Une telle augmentation se traduit par un transfert de richesses des nouveaux actionnaires vers les anciens actionnaires. Une nouvelle action émise au prix de 100 euros sera immédiatement réduite à une valeur de 80 euros (240 000 euros/3 000 titres). À l'inverse, la valeur des actions

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 238.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 113, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

anciennes va augmenter de 60 euros à 80 euros. Il va sans dire que, dans ces circonstances, il ne sera pas possible d'attirer des actionnaires nouveaux.

Pour éviter ces effets, il serait possible d'émettre les actions nouvelles au pair comptable de 60 euros : tout transfert de valeur est ainsi évité.

Une autre solution à ce problème consiste dans la réduction du capital social à 90 000 euros, avec la conséquence de faire correspondre le capital social aux fonds propres effectifs de la société. Les nouveaux titres pourront être émis au pair comptable de 60 euros.

La possibilité d'émettre des actions sans valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie, prévue par l'article 420-22 (6) L.S.C., constitue une autre innovation de la Loi de Modernisation tout en prévoyant un certain nombre de règles destinées à protéger les anciens actionnaires contre les risques inhérents à une telle émission.

Le cas où une telle émission est envisageable est celui où une société a réalisé des pertes qui ont pour conséquence que le capital social est entamé et qu'une émission de nouvelles actions au pair comptable des actions anciennes n'est plus économiquement possible pour la raison que les actions nouvelles seraient émises à un prix dépassant la valeur des actions anciennes de la même catégorie.

En premier lieu, la loi précise que, si une telle émission est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la convocation à cette assemblée doit le mentionner expressément. Ensuite, le législateur procède selon le schéma désormais bien connu que les dirigeants doivent rédiger « un rapport détaillé » qui doit faire l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises auquel les actionnaires peuvent toutefois renoncer à l'unanimité. Faute de telle renonciation unanime, l'absence de rapport de réviseur entraîne la nullité de l'opération. Quel est le contenu de ces rapports ? Selon la L.S.C., le rapport des dirigeants porte sur les caractéristiques financières de l'opération, en particulier sur « le prix d'émission et sur les conséquences financières pour les actionnaires ». Le rapport du réviseur d'entreprises doit « *déclarer que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition* ». Ces rapports sont déposés conformément aux règles prévues par la Loi de 2002. Il est encore à noter que, si les actionnaires peuvent renoncer (à l'unanimité) au rapport du réviseur d'entreprises, cette faculté n'existe pas pour le rapport du conseil d'administration. L'absence du rapport de réviseur sans renonciation valable (donc à l'unanimité) entraîne la **nullité de la décision** de l'assemblée générale.

Aux termes de l'article 420-22 (7) L.S.C. l'émission d'actions sans valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes peut encore avoir lieu dans le cadre du capital autorisé, à condition que l'autorisation accordée au conseil d'administration (directoire) le prévoie.

L'avis de l'IRE sur cette disposition est très réservé sur l'objet de ce rapport. « *En effet, il est demandé au réviseur d'entreprises de se prononcer sur le caractère fidèle et suffisant des informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration destiné à éclairer l'assemblée générale appelée à voter l'opération. Or, décrite d'une façon aussi large, une telle mission est difficilement compatible avec les recommandations professionnelles de l'IRE selon lesquelles un*

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

réviseur d'entreprises ne peut émettre une opinion que sur base d'une analyse d'une situation donnée par rapport à un référentiel. Concernant notamment le caractère suffisant ou non des informations financières et comptables, et au vu de la complexité des situations pouvant se présenter en pratique, l'IRE est d'avis que cette appréciation peut être fonction d'une multitude d'éléments, tels que les intérêts concrets des différents actionnaires dans l'opération donnée, leur connaissance et compréhension de la société et des implications à moyen ou long terme de l'opération envisagée, etc. Une simple référence à un actionnaire-type p. ex. satisfera-t-elle à l'exigence de s'assurer du caractère suffisant des informations ? L'IRE est d'avis qu'il ne devrait pas appartenir aux réviseurs d'entreprises d'apprécier si les informations fournies aux actionnaires sont suffisantes, mais que cette appréciation incombe aux actionnaires eux-mêmes. D'autre part, quelle sera par exemple la mission du réviseur d'entreprises dans le cas d'une émission d'actions sans valeur nominale en dessous du pair comptable mais accompagnée d'une prime d'émission qui amène l'ensemble à au moins le pair comptable des actions ? Au regard de ce qui précède, l'IRE est d'avis que le paragraphe (6) devrait faire l'objet de réflexions supplémentaires sinon être retiré du projet de loi »[1].

Ce dernier exemple (souligné par nous) est « tiré par les cheveux » ; il n'y a pas de raison d'émettre des actions au-dessous du pair comptable si en même temps on prévoit une prime d'émission qui en annule l'effet. Dans ce cas, le résultat des courses est donc qu'il n'y a pas d'émission en dessous du pair comptable, et donc l'intervention du réviseur d'entreprises n'est tout simplement pas nécessaire.

L'inverse du cas d'émission au-dessous de la valeur nominale, donc l'émission au-dessus de la valeur nominale (pair comptable), reste évidemment possible ; tel est le cas notamment si une **prime d'émission** est prévue. La prime d'émission « *constitue de par sa nature, tout comme le montant de l'augmentation de capital, un apport en société* »[2].

Il y a prime d'émission lorsque de nouvelles actions confèrent les mêmes droits que les actions anciennes : la prime d'émission est donc la différence entre le prix d'émission de l'action nouvelle et le pair de l'action ancienne[3].

Il est vrai que cette raison ne peut jouer qu'en cas de prime prévue en cours d'existence de la société, et non pas au moment de la constitution. S'il y a souscription en numéraire au même moment de tous les titres, il n'y a pas lieu d'équilibrer par une prime d'émission les titres anciens et les titres nouveaux.

Toutefois, on peut trouver une justification pour une telle prime même au moment de la constitution de la société. Il suffit de penser au cas où A et B constituent une société dans les circonstances où A fait un apport en nature à hauteur de 120, mais ne reçoit des titres que pour une valeur nominale de 100 et B apporte des liquidités pour 120. Pour respecter l'égalité avec l'associé A, il reçoit des titres pour un nominal de 100 avec une prime d'émission (ou prime d'apport) de 20. Ici la prime d'émission retrouve sa justification traditionnelle d'instrument permettant de rétablir l'équilibre entre les associés.

1 – Avis de l'IRE, *Doc. parl.*, n° 5730/1, p. 2, ID 10079.

2 – Cass. b. du 3 juin 1969, *R.C.J.B.*, 1971, p. 370.

3 – J. Kirkpatrick, « La prime d'émission et la notion de capital social en matière d'impôts sur le revenu », *R.C.J.B.,* 1971, p. 370.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La doctrine n'a pas été toujours favorable à la prime d'émission prévue lors de la constitution de la société ; « *[…] un fait qui se produit journellement, celui de l'émission publique avec une forte prime, le lendemain de la constitution de la société, d'actions qui ont été immédiatement libérées moyennant paiement en numéraire. Il est incontestable que lorsqu'on émet à 150 fr., le lendemain de la constitution de la société, une action qui a été payée à raison de 100 fr., la prime réalisée n'a aucune raison d'être* »[1].

Notons encore que la pratique luxembourgeoise applique la notion de prime d'émission dans un sens tout à fait différent, totalement en déphasage par rapport à la finalité de cette notion dans la mesure où, dans beaucoup de cas, les sociétés au moment de leur constitution ont à leur bilan un montant de prime d'émission fort important. En d'autres termes, au lieu d'affecter la totalité de leurs apports au poste de capital social, une partie de ceux-ci est comptabilisée en prime d'émission. L'objectif de cette pratique est alors de permettre à cette société de pouvoir distribuer des « *dividendes* » indépendamment des résultats annuels de la société (concrètement : même en l'absence de bénéfices).

Alain Steichen attribue à la prime d'émission une deuxième justification en y voyant un « instrument de souplesse dans la mise à disposition de fonds propres supplémentaires »[2]. Il ne nous paraît pas certain que cette approche corresponde à celle des directives européennes. L'article 32-2 (nouv. art. 420-25) L.S.C. pris sur la base de l'article 26 de la Deuxième directive prévoit que si, lors d'une augmentation de capital, une prime d'émission est prévue, alors cette prime doit être intégralement versée, bien que le montant correspondant au nominal puisse être versé partiellement seulement. La raison d'être de cette exigence ne peut être que celle que la prime étant la contrepartie demandée aux nouveaux associés pour le paiement des réserves occultes dont les anciens titres sont affectés, il faut, dans un souci de respect d'égalité des créanciers, prévoir que la prime soit entièrement versée, pour la raison que les réserves latentes sont également « dans la société » au moment du versement de la prime d'émission. Une telle exigence n'existe pas pour le montant correspondant au capital nominal de la société : il se peut que le capital nominal correspondant aux titres anciens ne soit pas entièrement libéré non plus.

Compte tenu du libellé de l'article 24 de la directive qui se réfère uniquement aux **augmentations de capital**, on peut considérer que, lors de la souscription du capital au moment de la constitution, la règle de la libération intégrale ne joue pas[3]. Il est vrai qu'entre-temps cette question est tranchée par le législateur qui dispose que la prime d'émission est toujours à libérer dans son intégralité.

Quel organe social peut-il disposer de la prime d'émission ? Si, en pratique, il paraît que les statuts prévoient souvent qu'il s'agit du conseil d'administration[4], il est permis de douter de la validité de cette pratique. En effet, s'agissant d'apports d'associés, il faut conclure que c'est uniquement l'assemblée des associés qui est en droit de disposer de ces réserves.

1 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, Dupont, p. 290.

2 – V. A. Steichen, « La prime d'émission », *BDB*, n° 25, 1996, p. 48.

3 – Apparemment d'un avis contraire, A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 773.

4 – V. A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, p. 773.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La prime peut recevoir différentes affectations : elle peut en premier lieu être portée à un compte de réserve disponible. « *En ce cas, cette réserve est susceptible d'être affectée ultérieurement à des distributions de dividendes au gré de l'assemblée générale ordinaire. Pareille distribution, qui profite nécessairement aux porteurs d'actions anciennes aussi bien qu'aux porteurs d'actions nouvelles, n'est nullement incompatible avec le but de la prime d'émission, qui est de réaliser l'égalité entre les actionnaires* »(1). Elle peut encore être portée à un poste de réserve indisponible ou être incorporée au capital.

Si les titres nouveaux étaient émis au même montant que les titres anciens, les anciens associés seraient gravement lésés et devraient subir la répartition des réserves accumulées sur les nouveaux titres. La prime d'émission a pour **objet d'assurer l'égalité** entre les deux catégories de titres, et ceci, en obligeant les associés nouveaux à payer sous forme de prime la différence entre la valeur nominale des titres et la valeur réelle de ceux-ci.

2) Libération des actions pour un quart au moins

Chaque action doit être libérée d'un quart au moins par versement en numéraire ou par des apports en nature.

Cette règle trouve son pendant dans toutes les législations étrangères. À sa base se trouve en premier lieu la volonté de mettre à disposition de la société une partie au moins des sommes que les associés ont promis d'apporter. En deuxième lieu, cette règle : « *écarte les coureurs de primes, c'est-à-dire ceux qui souscrivent des actions dans l'intention de s'en défaire après avoir profité de la prospérité factice des sociétés naissantes, sans être exposés à éprouver des pertes en cas de désastre* »(2).

Une fois le principe de la **libération partielle** acquis, il reste à fixer le **taux** de cette libération minimale. En Belgique, cette question a donné lieu à des discussions passionnées légèrement disproportionnées par rapport à son importance réelle. La loi de 1873 fixait le taux de libération à 5 %, taux porté à 10 % en 1886. Au moment où cette loi devait être réformée au début du XXe siècle, cette question avait donné lieu à d'âpres discussions devant le Parlement belge.

En fixant un taux de libération élevé, on établit non seulement un frein pour ceux qui fondent inconsidérément des sociétés, mais on fournit encore une certaine garantie pour les souscripteurs eux-mêmes qui, obligés de verser une somme assez importante au moment de la souscription, y regarderont peut-être de plus près avant de prendre un engagement que par la suite ils ne pourront guère tenir(3).

Il résulte de la règle de libération partielle au moment de la souscription qu'il ne suffit pas que la société ait à sa disposition un certain pourcentage du montant du capital social souscrit, mais que chaque action soit libérée pour partie : « *Ce qu'on a voulu en imposant cette condition, c'est bien moins encore assurer à la société certains fonds pour commencer les opérations qu'empêcher les souscriptions faites par des personnes qui n'ont pas l'intention de les réaliser. Or, […] la libération par*

1 – J. Kirkpatrick, « La prime d'émission et la notion de capital social en matière d'impôts sur le revenu », *R.C.J.B.*, 1971, p. 371.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 114, ID 11305.

3 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 198.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

un actionnaire ne saurait être la preuve que la souscription de l'autre a de la valeur. L'admettre, ne serait-ce pas attribuer aux lanceurs d'affaires qui veulent récolter sans semer, le bénéfice de la crédulité de leurs dupes, en les exemptant de verser parce que leurs manœuvres auraient déterminé celles-ci à faire des versements dépassant le minimum légal ? »[1].

La loi ne fait que fixer une libération minimale pour chaque action. À supposer que cette libération minimale soit atteinte, il n'est pas exclu que différents titres soient **libérés à des degrés divers**.

Les apports en numéraire et les apports en nature vont former le capital social de la société anonyme.

Le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique. Les apports en nature doivent par conséquent être susceptibles d'évaluation suivant des critères objectifs et représenter une valeur économique. La L.S.C exclut expressément les **apports en industrie,** de sorte que les engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services ne peuvent constituer la contrepartie de titres de capital de la société anonyme.

Le droit pour les dirigeants de procéder à l'appel de fonds qui doit être fait à la société est pratiquement un droit discrétionnaire. Ce droit n'a d'autre fondement que celui de l'intérêt de la société dont les administrateurs sont les seuls juges[2]. On pourrait imaginer que cette faculté soit exercée dans des circonstances où les administrateurs sont conscients du fait qu'un actionnaire n'est pas en mesure d'y répondre. L'appel de fonds aurait alors comme résultat de priver cet actionnaire du droit de vote (v. art 450-1 (8) [anc. art. 67 (7)] L.S.C.). La preuve du caractère abusif de cet appel de fonds serait alors très délicate à apporter[1].

3) Appel de fonds par la société

La L.S.C ne prévoit pas de délai pour la libération des apports en numéraire (contrairement à ce qui se passe pour les apports en nature). Toutefois, sous réserve des dispositions relatives à la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de leur obligation de fournir leur apport.

La libération des apports dans les sociétés de capitaux doit avoir lieu de la même manière que celle pour laquelle ils ont été souscrits ; donc s'il y a eu souscription en numéraire, la libération doit avoir lieu en numéraire : une **dation en paiement** est donc exclue[3].

Il appartient au conseil d'administration de décider des époques auxquelles les actionnaires doivent effectuer des libérations complémentaires ainsi que du montant de celles-ci. La société est « *créancière* » potentielle de ses actionnaires à concurrence de la partie non libérée de leurs actions. Le conseil d'administration décidera en fonction des intérêts de la société, notamment de ses besoins financiers, de l'époque des appels de fonds. En réalité, il y a créance uniquement dès le moment de l'appel de fonds de la part de la société. L'actionnaire qui resterait en défaut

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 115, ID 11305.

2 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 249.

3 – T. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 365 ; Comm. Liège du 21 décembre 1982, *Rev. prat. soc.*, 1983, p. 93.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de donner suite à un appel de fonds verrait l'exercice de ses droits de vote suspendu conformément à l'article 450-1 (8) (anc. art. 67 (7)) L.S.C. En outre, les statuts peuvent prévoir d'autres sanctions telles que le rachat forcé par la société ou encore la suspension des droits économiques des actions concernées.

L'actionnaire défaillant est redevable envers la société d'intérêts sur le montant d'un appel de fonds non honoré à compter de la date de paiement spécifiée dans la décision du conseil d'administration.

L'actionnaire sollicité pourra se soustraire à l'obligation de libérer les fonds appelés en prouvant qu'il a transféré les actions concernées à un tiers, que le transfert est régulier, fait de bonne foi et effectué avant l'appel de fonds en question.

Par ailleurs, un tiers créancier de la société peut, en vertu de l'article 1400-2 L.S.C., intenter une action en justice pour faire ordonner judiciairement le versement de fonds non libérés stipulé aux statuts dans la mesure où le conseil d'administration ne procéderait pas aux appels de fonds nécessaires à la conservation de ses droits. La société peut faire écarter cette action en remboursant la créance du créancier concerné à sa valeur, le cas échéant, sous déduction de l'escompte.

La Cour d'appel de Luxembourg a statué à propos de l'appel de fonds, prenant position quant au caractère libératoire ou non d'un versement spontané effectué par un actionnaire : « *En principe, ce sont les organes chargés de représenter la société qui procèdent à l'appel du non-versé et l'actionnaire ne peut, à défaut de clause statutaire prévoyant une telle faculté, pas imposer à la société une libération anticipée du non-versé. Dès lors, si les fonds versés par des actionnaires à la société pour libérer le solde dû sur des actions de numéraire l'ont été avant qu'une décision régulière d'appel du non-versé ait été prise, les actionnaires ne peuvent prétendre s'être valablement libérés de leurs obligations envers la société (*Cass. com., 15 juill. 1992 : Dr. Sociétés nov. 1992, n° 234 ; Rev. sociétés 1993, p. 103, note J.-F. Barbiéri*). Cette solution s'explique par le fait que le terme pour libérer les actions est stipulé non en faveur du débiteur, mais en faveur de la société. En effet, en concluant le contrat de société, les parties ont voulu que la société apprécie elle-même quand il conviendrait de réaliser les apports et de verser les sommes promises, afin de ne pas lui donner la charge et lui imposer les risques de la gestion de capitaux dont elle n'aurait pas l'emploi pour réaliser son objet (cf.* Resteau, *Traité des sociétés anonymes, tome II édition 1982 n° 798) »*[1]*.*

Le curateur de la faillite d'une S.A. agit à l'encontre de l'un de ses associés en versement du solde de libération de ses actions demeurées partiellement libérées. La défenderesse objecte qu'une partie de ces actions ont été cédées : « *Il est en effet admis par la jurisprudence que le souscripteur d'actions libérées partiellement ne peut se soustraire à son obligation de payer les sommes demeurant à verser sur ces actions qu'en prouvant soit sa libération, soit le transfert de ces actions à un tiers, opéré régulièrement et de bonne foi et avant cet appel de fonds (cf.* CA, 22 novembre 1898, *P.*, 5, p. 96*)* ». Le curateur fit valoir que la cession ne serait pas valable dans la mesure où elle n'aurait pas été transcrite au registre en vertu des articles 430-3 et 430-4 L.S.C. alors que, non entièrement libérées, les actions demeuraient nominatives en vertu de l'article 430-8 L.S.C. Le tribunal rappelle que la portée de l'article 430-4 L.S.C. n'est pas d'imposer que la cession se fasse selon une forme déterminée, mais de préciser les modalités selon lesquelles la cession pourra être rendue opposable

1 – CA du 14 mai 1997, n° 18.168, commenté par F. Fayot in *Ann. dr. lux*., 2001, p. 562, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

aux tiers. Or, le curateur agissant aux droits de la masse doit incontestablement être considéré comme un tiers. Dès lors, seuls l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil ou la transcription au registre des actions en vertu des articles 430-3 et 430-4 L.S.C. auraient pu rendre la cession opposable au curateur[1].

4) Les apports en nature

Les apports en nature ont de tout temps été à l'origine de multiples abus et fraudes. En Belgique, on a essayé d'y remédier au moyen de dispositions sur la négociabilité des actions reçues en rémunération des apports effectués.

Lorsque quelqu'un procède à la vente d'un bien, il reçoit un prix, et ce prix, produit de la vente, est à sa libre disposition sans la moindre restriction. En cas d'apport, l'apporteur **reçoit des titres** qui, bien que représentant la contrepartie des biens, constituent un prix d'une nature particulière dans la mesure où ces titres sont affectés de risques considérables. « *L'apporteur, dès qu'il a reçu les titres, s'empresse de les jeter dans le public grâce à des réclames bruyantes ; il se débarrasse ainsi au plus vite de tous les risques et recueille du numéraire. Cette manœuvre, pour réussir, demande de la célérité, et en interdisant la négociation des titres pendant deux ans par les modes d'aliénation expéditifs du Code de commerce, nous lui enlevons cet élément indispensable du succès* »[2].

Conformément aux dispositions de l'article 420-10 de la L.S.C, les apports en nature doivent faire l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société anonyme par un réviseur d'entreprises indépendant de la société, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ce réviseur indépendant sera désigné par les fondateurs de la société. Par fondateur, il convient d'entendre les personnes physiques ou morales qui ont signé l'acte de société ou au nom desquelles il a été signé, et non les fondateurs visés à l'article 420-10 L.S.C.

Art. 420-10 L.S.C.

« *(1) Les actions émises en contrepartie d'apports en nature doivent être libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution.*

(2) Les apports en nature font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société par un réviseur d'entreprises de celle-ci désigné par les fondateurs.

(3) Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports projetés ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l'acte prévu par l'article 420-15 ou au projet d'acte prévu par l'article 420-17. Ses conclusions sont à reproduire dans les documents susdits.

(4) [...] ».

1 – TA Lux. du 12 juin 1998, n° 46.703, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, Wauwermans, p. 290.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Notons d'abord que la Loi de Modernisation ne précise pas que le réviseur doit être indépendant de la société. Cette précision est de nos jours superflue pour la raison que le réviseur d'entreprises est, selon la loi sur la profession de l'audit, nécessairement indépendant de tous ses clients.

Cette obligation de vérification des apports en nature a été introduite dans notre législation sous l'impulsion du droit de l'Union européenne et par la transposition de la Deuxième directive afin de prévenir la surévaluation des apports autres qu'en numéraire et, par conséquent, la fictivité du capital social, partie du gage des créanciers. La surévaluation équivaut à l'absence de souscription pour le montant exagéré[1]. Elle n'entraîne pas la nullité de la société, mais la responsabilité des fondateurs à l'égard des tiers.

a) Contenu du rapport de révision

Le rapport de révision doit porter sur la **description** de chacun des apports projetés ainsi que sur les **modes d'évaluation** adoptés. En outre, ce rapport doit indiquer si les valeurs auxquelles conduisent les modes d'évaluation adoptés correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de l'apport en question.

Deux situations différentes peuvent se présenter. 1) Ce sont les fondateurs, ou bien en cas d'augmentation de capital, le conseil d'administration (directoire) qui procèdent à la description des apports. Dans ce cas, le réviseur doit contrôler l'exactitude de la description faite et il est tenu d'exprimer son avis sur cette évaluation et affirmer s'il l'accepte ou non. 2) Alternativement, c'est le réviseur qui procède à cette évaluation et, dans ce cas, celle-ci doit figurer dans le corps de son rapport. Quelle que soit l'hypothèse retenue, le réviseur sera responsable du contenu de la description faite soit par les fondateurs, soit par le conseil d'administration (directoire)[2].

Le rapport de révision doit être un document différent de celui à établir par les fondateurs ou le conseil d'administration (directoire).

Le rapport de révision aura au minimum deux parties bien distinctes : une première consacrée à la description des apports et une deuxième à l'attestation, qui contient la conclusion du réviseur d'entreprises.

i) Description de chacun des apports projetés

Cette partie comporte la description des apports, l'énoncé des méthodes d'évaluation, l'évaluation proprement dite. Une simple description matérielle n'est pas suffisante. Le réviseur doit décrire et relever tout élément permettant d'influer par la suite sur la valeur des apports projetés. Il doit donc procéder à une évaluation « *qui est à la fois une évaluation économique, technique et financière* ». Cette évaluation se doit d'être exhaustive, car elle doit permettre de déterminer la valeur des biens dont l'apport est projeté[1].

1 – *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, Paris, Bruxelles et Luxembourg, Sirey, Bruylant et Bruck, 1933, p. 24.

2 – V. la note interprétative de l'article 26-1 L.S.C., ID 7520, établie par le groupe de travail « Droit des sociétés » de la Commission d'études législatives, de 1994.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette partie sera évidemment différente selon la nature des biens concernés : En cas d'apport de **biens immobiliers** :

– la nature du droit apporté (droit de propriété, usufruit, etc.) ;
– la nature de l'immeuble (de bureau, d'habitation, industriel) ;
– sa situation précise avec les indications de surface (références cadastrales) ;
– l'utilisation susceptible d'en être faite (de rapport, développement immobilier) ;
– les charges dont il est grevé (hypothèques, droit de passage) ;
– etc.

En cas d'apport de **titres** :

– l'émetteur des titres (forme juridique, nationalité, siège, etc.) ;
– la nature des titres apportés (actions : classe d'actions, obligations : convertibles, etc.) ;
– la nature des droits apportés ;
– l'évaluation (cours boursiers, prix sur les transactions récentes) ;
– etc.

En cas d'apport de **créances** :

– la description du débiteur (statut juridique : société à responsabilité limitée ou non, domicile ou siège social) ;
– la solvabilité du débiteur ;
– les caractéristiques de la créance (créance certaine ou contestée, liquide ou indéterminée, exigible ou à terme, portant intérêt ou non : taux d'intérêt convenu) ;
– le montant nominal de la créance ;
– etc.

Le réviseur n'a pas à se prononcer sur **l'opportunité** d'un apport : celle-ci relève des décisions à prendre par les actionnaires et ne peut engager la responsabilité ni des administrateurs ni du réviseur.

ii) Attestation du réviseur

Par cette expression, on entend la conclusion du rapport de révision. Cette partie est par conséquent beaucoup plus courte que la première tout en étant bien plus importante. La conclusion doit être reproduite dans l'acte notarié. Elle doit indiquer si l'évaluation faite par les fondateurs (conseil d'administration/directoire) est juste et correcte et si les modes d'évaluation adoptés sont appropriés. Le réviseur doit encore porter une appréciation sur ces modes d'évaluation et, le cas échéant, évaluer lui-même les apports selon d'autres méthodes d'évaluation si celles-ci lui paraissent plus adéquates, en indiquant donc à chaque fois le montant auquel aboutit sa propre évaluation.

Le réviseur doit non seulement évaluer de manière abstraite les biens apportés, mais il doit encore se faire une appréciation « *de la valeur des actions à émettre en contrepartie des apports. Le fait pour le réviseur d'avoir à se faire une idée personnelle de la valeur des actions à émettre en contrepartie des apports implique qu'il évalue le patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport* »[1]. La comparaison entre les deux

1 – Note interprétative de l'article 26-1 L.S.C., ID 7520, établie par le groupe de travail « Droit des sociétés » de la Commission d'études législatives, de 1994.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

grandeurs lui permettra de conclure si, oui ou non, les modes d'évaluation adoptés conduisent à une valeur des apports au moins égale à celle des actions émises en contrepartie.

Le fait de devoir évaluer les actions à émettre en contrepartie des apports en nature complique considérablement le travail du réviseur : en effet, il lui incombe en fait d'évaluer, en plus des apports en nature, la société bénéficiaire des apports.

Il se peut en effet que, dans un cas donné, la valeur de la société soit **négative,** de sorte que la conclusion du réviseur sera facile dans la mesure où tout apport d'un bien ayant une valeur positive correspond à une situation où la valeur des apports correspond au moins à la valeur des actions à émettre en contrepartie.

Bilan Société XY

Actif		**Passif**	
Liquidités :	100	Capital :	300
Pertes :	400	Dettes :	200
Total :	500	Total :	500

Lorsqu'un apport en nature portant sur des actions de 50 est projeté, il sera évident que la valeur des apports est au moins égale à la valeur des actions émises en contrepartie. La raison en est que la valeur des actions émises est de zéro (valeur comptable négative), de sorte que la conclusion sera facile à tirer.

Pour faire l'objet d'un apport en nature, un bien doit être susceptible d'évaluation économique[1]. Il n'est pas nécessaire que le bien apporté soit susceptible de réalisation forcée. Il faut encore qu'il s'agisse d'un apport autre qu'en numéraire.

L'apport d'une somme d'argent exprimée en une devise non librement convertible au Luxembourg est un apport en numéraire lorsque le capital est exprimé dans la même devise que celle de la somme apportée.

En revanche, l'apport est à considérer comme apport en nature lorsque la somme apportée est exprimée en une devise non librement convertible au Luxembourg et apportée à un capital exprimé en une devise librement convertible ou en une monnaie ayant cours légal au Luxembourg[2]. En d'autres termes, les cas où un apport en espèces est considéré comme un apport en nature devraient être très rares en fait.

b) Exonération du contrôle

Aux termes de la Deuxième directive (art. 10, 4.), l'obligation de vérification des apports en nature n'est pas applicable lorsque 90 % de la valeur nominale ou du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d'apports autres qu'en

1 – C. Delvaux, *La société anonyme*, p. 172.

2 – Cette interprétation résulte d'une note interprétative de l'article 26-1 L.S.C., ID 7520, établie par le groupe de travail « Droit des sociétés » de la Commission d'études législatives, de 1994.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

numéraire faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies (reprises à l'article 420-10 (9) L.S.C.) :

(i) en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques ou morales qui ont signé l'acte de société ou au nom desquelles il a été signé ont renoncé à l'établissement du rapport d'expert ;

(ii) cette renonciation demeure annexée à l'acte ;

(iii) les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire ;

(iv) les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes jusqu'à concurrence du montant indiqué sous (iii) des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai ;

(v) la garantie visée sous (iv) doit être donnée dans une annexe à l'acte de société ;

(vi) les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué sous (iii) dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée sous (iv) et faites pendant ce délai auront été réglées.

5) Les quasi-apports

Conformément à l'article 11 de la Deuxième directive, l'article 420-11 (1) L.S.C soumet en outre à contrôle, dans les **deux ans** qui suivent sa **constitution**, les acquisitions faites par la société lorsque le cédant est un associé ou plus précisément « *une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif* ». La désignation du réviseur est alors faite par l'organe d'administration en place, donc par le conseil d'administration ou le directoire. Cette solution est logique et elle a été prise afin d'éviter le **contournement** de la loi suivant : les associés dans une première étape constituent la société au moyen d'un apport en espèces et, peu de temps après, se font racheter des biens par la société. Une fois cet achat fait, l'argent correspondant à l'apport en numéraire est sorti de la société et la situation est exactement la même que si l'on avait procédé à un apport en nature. Il est donc cohérent d'étendre l'obligation de vérification des apports en nature également aux cas de ventes de biens des associés à la société. Mais ceci suppose que la vente porte sur des biens d'une certaine importance. Il faut que les biens visés aient au moins une valeur correspondant à un **dixième du capital** souscrit.

Toutefois, certaines acquisitions sont exclues de cette obligation. En effet, l'article 420-11 (2) L.S.C. exclut les acquisitions faites par la société dans le cadre « *de ses opérations courantes* », celles faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire ainsi que celles faites en bourse.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La loi ne donne pas de définition des **opérations courantes**. Il convient par conséquent d'apprécier *in concreto* si une acquisition relève de l'activité courante de la société.

C – La responsabilité des fondateurs

La loi prévoit un régime de responsabilité renforcée à l'égard des personnes ayant la qualité de fondateurs.

1) Définition

Cette définition, encore reprise de la Deuxième directive CEE, par l'article 420-16 L.S.C. : « *la société peut être constituée par un ou plusieurs actes notariés dans lesquels comparaissent tous les associés en personne ou par porteurs de mandats authentiques ou privés. Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société* ».

Cette responsabilité peut toutefois être limitée à une partie seulement des comparants aux actes de formation : l'article 28[1], deuxième alinéa, prévoit en effet que, si les actes désignent comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir aucun avantage particulier sont considérés comme simples souscripteurs.

La loi prévoit que ceux qui s'arrogent exclusivement la qualité de fondateurs souscrivent un tiers du capital « *de façon à empêcher l'intervention de fondateurs professionnels, d'autant plus disposés à accepter le fardeau de toutes les responsabilités qu'ils présentent moins de solvabilité* »[2]. En outre faut-il que ceux qui ne veulent pas être considérés comme fondateurs ne fassent que des apports en numéraire et ne reçoivent aucun avantage particulier.

« *L'article* [28[3]] *atténue en un point la rigueur de l'authenticité : c'est en ce qui concerne la comparution par mandataire. L'acte de constitution devant constater authentiquement l'adhésion de chaque associé au contrat social, et le consentement du mandataire ne valant que par celui du mandant qui le soutient, l'acte devrait logiquement constater authentiquement la manifestation concordante des deux volontés dont la réunion seule constitue le consentement valable de l'associé ; en d'autres termes le mandat devrait tout comme l'acte de société lui-même, être authentique* »[4]. C'est par exception à ce principe que la loi permet que le mandat soit « *authentique ou privé* ». Le mandat verbal est en tout état de cause interdit.

2) Responsabilité

En application de l'article 420-19 (anc. art. 31) L.S.C., les fondateurs sont **tenus solidairement** envers tout intéressé, notamment de la partie du capital souscrit qui

1 – Nouvellement art. 420-16 L.S.C.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 75, ID 11308.

3 – Nouvellement art. 420-16 L.S.C.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 74, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence existant entre le capital social minimum et le montant des souscriptions, de la libération d'un quart des souscriptions au moins, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 27 [nouv. art. 420-15] et 29 [nouv. art. 420-17] L.S.C.

Selon la jurisprudence(1), il n'y a en revanche pas de solidarité entre fondateurs lorsque ceux-ci ont souscrit la totalité des actions : ce cas n'étant pas visé par l'article 420-19 alinéa 1er (anc. art. 31, alinéa 1er) L.S.C., il n'y a pas de solidarité entre fondateurs, de sorte que ceux-ci sont tenus de payer le solde du capital non libéré à hauteur seulement de la quote-part souscrite par chacun.

L'ancien article 49-1, devenu article 430-14 L.S.C., a fait l'objet d'un toilettage destiné à le rendre conforme à la Deuxième directive (art. 18, 3) en ce qui concerne les personnes concernées (dans la version ancienne, le texte ne visait que les comparants aux actes de constitution par souscription) et par la responsabilité, désormais solidaire, énoncée à l'article 430-14 (3) (anc. art. 49-1 (3)) L.S.C.

D – Libération au moyen de fonds empruntés

Le simple fait que les fonds servant à la libération soient des fonds empruntés ne suffit pas à conclure à l'absence d'*affectio societatis*. La provenance des fonds est indifférente dans la mesure où les souscripteurs ont l'intention réelle d'assumer les obligations résultant de la souscription et de devenir associés en subissant les risques sociaux(2).

■ § 2 – La constitution par voie de souscription publique

La deuxième forme de constitution qui, de nos jours, est peu pratiquée dans la vie des affaires (au Luxembourg comme dans les pays voisins) consiste lors de la constitution à faire **appel public** à l'épargne. Le cas visé est celui où les fondateurs à eux seuls, n'ayant pas suffisamment de capitaux nécessaires pour réaliser le projet social, font appel au **concours du public**. Il est normal que, dans ce cas de figure, le législateur prenne soin de protéger le public et d'empêcher qu'il puisse être trompé par ceux qui font appel à son épargne. La procédure visée comporte trois phases(3).

A – La publication de l'acte de société

Dans ce cadre, il est en premier lieu procédé à la rédaction et à la publication d'un acte de société sous forme notariée qui est un simple projet (art. 420-17 L.S.C.), et ceci, à la demande des fondateurs.

Cet acte doit contenir toutes les clauses et conditions de la future société, sans ce que les souscripteurs y ajouteront ultérieurement, donc la liste des souscripteurs

1 – TA du 28 janvier 2005, jgt com., n° 117/05, n° 91.260, *BIJ*, 5/2005, p. 91.

2 – CA Anvers du 3 novembre 1975, *R.P.S.*, 1976, p. 44.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 76, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

et des versements faits. Évidemment cet acte, comme tout acte constitutif, doit être dressé en la forme notariée (art. 100-4 L.S.C.).

B – La période de souscription

Cette (deuxième) phase est celle où les futurs associés prennent des engagements en s'obligeant les uns vis-à-vis des autres et à l'égard de la société en état de formation à faire apport d'une partie donnée du capital social en échange d'un nombre donné d'actions à émettre.

À la suite à cette publication, les bulletins de souscription sont recueillis : ceux-ci sont faits en double et doivent contenir certaines indications destinées à informer les souscripteurs sur le contenu exact des obligations qu'ils assument tout en évitant les fraudes et les erreurs. Les actes de souscription doivent contenir quittance du versement en espèce sur chaque action du quart au moins de la valeur souscrite. Si, en général, le souscripteur verse immédiatement le montant qui doit être libéré dès le départ, ceci n'est pas obligatoire. Il suffit que la libération se fasse au moment de la constitution définitive[1].

Ces souscriptions sont constatées par des actes sous seing privé soumis à l'obligation de l'établissement en double exemplaire et devant obligatoirement contenir un certain nombre de clauses du pacte socia[2].

Cet acte de souscription avertit les souscripteurs que l'assemblée générale qui procédera à la constitution de la société se tiendra dans les **trois mois** de la publication de l'acte. Ce délai a été fixé afin d'éviter les inconvénients d'une souscription qui serait ouverte indéfiniment[3].

C – La tenue de l'assemblée constitutive

Lors de cette troisième phase (qui fait l'objet de l'article 420-18 L.S.C.), l'assemblée générale des souscripteurs se réunit et les fondateurs présentent à l'assemblée (tenue devant notaire) la justification de l'accomplissement des conditions requises pour la formation de toute société anonyme prévues par l'article 420-1 L.S.C. « *Ce point établi, l'assemblée générale a le droit et le pouvoir discrétionnaire, sans avoir à fournir de motifs de sa décision, mais aussi sans pouvoir apporter de changements au projet d'acte, de s'opposer à la constitution définitive de la société. C'est donner là aux souscripteurs, par dérogation au droit commun un moyen de se dégager d'une obligation valablement prise* »[4]. La raison d'être de cette disposition est l'intérêt public de permettre aux futurs associés de se retirer tant qu'il est encore temps.

Les souscripteurs ont en quelque sorte un **droit de repentir** dans la mesure où la société ne sera pas constituée si la majorité des souscripteurs s'oppose à la constitution. Les fondateurs, de leur côté, n'ont pas le droit de participer à ce

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 146, ID 11305.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 77, ID 11308.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 147, ID 11305.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 79, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

vote[1]. « *Le législateur belge n'a pas voulu, dans l'intérêt des sociétés à venir, que la majorité des associés fût hostile au moment même où le contrat en arrivait à la conclusion définitive et où les opérations allaient commencer. Il est incontestable que l'affaire présentera plus de garanties si, après une souscription qui a pu être l'effet d'un entraînement, la majorité des associés, mieux éclairée, persiste dans sa volonté d'entamer l'opération dans les conditions déterminées* »[2]. Et dans le même sens : « *Comme les fondateurs ont un intérêt par trop évident à la constitution de la société dont ils sont les promoteurs, il eût été dangereux de leur laisser voix délibérative en semblable occurrence* »[3].

L'assemblée générale ne peut pas apporter (fût-ce à la majorité) le moindre changement à l'acte de société publié ; en effet, les souscripteurs ont souscrit sur la base de ces statuts publiés. La seule manière de les modifier serait un vote à l'unanimité.

Si le capital initialement annoncé n'a pas été atteint, la constitution peut néanmoins avoir lieu avec un capital moindre, mais à condition que cette possibilité ait été prévue dans l'acte notarié publié.

La constitution effective de la société est réalisée par cette assemblée générale. La société est constituée à moins que les associés présents ou représentés à la majorité des voix ne s'opposent à la constitution de celle-ci. Dans cette assemblée, les fondateurs n'ont pas droit de vote.

La société n'est pas constituée non plus si l'assemblée n'est pas tenue dans les trois mois de l'établissement du projet d'acte.

L'article 420-18 (4) (anc. art. 30 (4)) prévoit que le procès-verbal authentique de l'assemblée des souscripteurs, qui contiendra la liste des souscripteurs et l'état des versements faits, constituera définitivement la société.

Il y a donc deux actes qui concourent indispensablement à la constitution de la société. « *C'est d'abord le projet de statuts présenté par les fondateurs qui est de leur part une pollicitation ; puis c'est le procès-verbal de l'assemblée des souscripteurs décidant de constituer la société. Il faut que ces deux actes soient notariés, sinon l'existence des éléments essentiels de cette constitution ne serait pas prouvée authentiquement* »[4]. Dans une espèce où il était discuté de la question de savoir si une S.A. avait été constituée par la voie de souscriptions (art. 29, nouv. art. 420-17 L.S.C.), un prospectus imprimé avait été mis en circulation invitant toute personne désireuse de participer à la création de la société à signer les bulletins de souscription recueillis par une banque déterminée ; la mention « confidentiel » était apposée sur ces prospectus : « *[…] la mention "confidentiel" apposée sur ces prospectus est dépourvue de toute valeur et ne saurait enlever le caractère de publicité à l'appel, puisque la circulaire, loin d'exclure le public, l'invite formellement à souscrire […] les sollicitations à titre personnel n'éliminent […] pas le fait […] que le prospectus ouvre la souscription à tout venant* »[5].

---

1 – « *Les fondateurs ne peuvent voter sur la constitution de la société ; ils sont trop directement intéressés pour qu'on leur reconnaisse le droit d'imposer leur volonté, ou du moins de contribuer à l'imposer* », A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 147, ID 11305.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 147, ID 11305.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 79, ID 11308.

4 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 229.

5 – CA du 11 décembre 1928, *Pas.*, 11, 375, 2, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION II
TITRES ÉMIS PAR LES SOCIÉTÉS ANONYMES

Comme indiqué ci-dessus, l'élément distinctif de la société anonyme est en définitive le fait que celle-ci émet des actions.

§ 1 – Les actions

Par définition même, le capital social d'une société anonyme est représenté par des titres (des actions) qui sont librement négociables et qui donnent à leurs détenteurs certains droits en dehors de certaines obligations (peu nombreuses en fait).

L'action est une créance *sui generis*. En tant que créance, elle n'existe pas dans la nature et naît par la seule volonté des parties contrairement à un objet naturel[1]. « *S'il appartient à la volonté commune des parties de créer un bien ou de le laisser dans le néant, il doit lui appartenir de l'exclure du courant économique, puisqu'elle aurait pu ne pas lui donner naissance* »[1]. On en déduit donc que l'article 1598 C.c. « *Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque les lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation* » n'est pas applicable en l'occurrence pour la raison qu'il s'applique uniquement aux **biens corporels**. Par conséquent, la liberté des conventions primerait le principe de négociabilité des biens. La libre négociabilité n'est donc que de la nature et non pas de l'essence des actions, de sorte que les clauses de non-négociabilité sont reconnues valables[2].

« *L'action n'est pas autre chose qu'une part sociale rendue transmissible par les formes faciles et rapides du droit commercial* »[3]. Si les actions sont obligatoirement d'égale valeur, elles ne doivent pas nécessairement indiquer « *la subdivision du capital dont elles sont la représentation par la mention d'une somme déterminée. Elles peuvent parfaitement représenter une quote-part ou fraction de ce capital. Les actions doivent être d'égale valeur : toute autre solution entraînerait des difficultés inextricables quant à la computation des droits sociaux* »[4].

A – Formes et variétés

Souvent, les promoteurs des affaires sont amenés à créer et à combiner dans une même société plusieurs catégories d'actions auxquelles sont attribués des droits différents. « *Cette pratique, due aux différences de nature et de valeur que présentent souvent entre eux les divers apports qui concourent à la formation du capital social, et justifiée par le désir légitime des intéressés d'établir entre les uns et les autres une équitable pondération d'avantages et d'influence, ne se trouve consacrée par aucun texte de loi. Mais la légitimité en a été formellement reconnue dans les travaux préparatoires de la loi belge, au cours desquels a été proclamé sur ce point le principe de la liberté des conventions* »[5].

1 – L. Maeyens et P. Roose, « Syndicats d'actionnaires de société anonyme », *R.P.S.*, 1964, p. 59.

2 – V. notamment L. Frédéricq, T. IV, nº 391.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 90, ID 11308.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 91, ID 11308.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 92, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le capital des sociétés anonymes se divise impérativement en actions. La précision que ces actions doivent être d'égale valeur (art. 37) n'a plus été reprise par la Loi de Modernisation (art. 430-1 L.S.C.). En pratique, elles sont d'égale valeur (afin de faciliter l'estimation et la négociation de celles-ci et l'exercice des droits attachés à celle-ci[1]).

Chaque action représente une quote-part du capital social, valeur qui peut être mentionnée sur l'action, il s'agit alors d'une action avec valeur nominale, ou ne pas être mentionnée sur l'action, il s'agit alors d'une action sans désignation de valeur nominale. Dans ce cas, la valeur de l'action s'obtient en divisant le capital statutaire par le nombre d'actions qui le représentent : c'est le **pair comptable**[2].

Les actions peuvent être divisées en coupures (soit donc des subdivisions d'actions) qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action ; ces coupures doivent encore être d'égale valeur. Les actions et les coupures portent un numéro courant.

On procède à l'émission de **coupures d'actions** lorsque l'action entière a atteint une valeur exceptionnellement élevée et que l'on considère qu'il est désirable de pouvoir la subdiviser afin de la rendre accessible aux petits investisseurs[3].

Traditionnellement, la valeur nominale ne pouvait être inférieure à 1,24 euro (contrepartie de 50 francs). Une telle exigence d'un montant minimum ne rencontre plus beaucoup de compréhension de nos jours. À l'époque, il s'agissait en réalité d'une mesure de protection importante à l'égard du grand public qui, fort naïf, risquait de se faire abuser par quelques brasseurs d'affaires peu scrupuleux. Selon le rapporteur de la loi française M. Langlois : « *La faculté de fractionner indéfiniment le capital social a conduit à émettre des coupons de la plus étrange exiguïté. Il y a des sociétés dont les actions sont de 25, de 15, de 10, de 5 francs, on dit même de 1 franc. Ces actions s'adressent aux plus petites bourses, à cette partie de la population qui est la moins instruite, la plus accessible aux entraînements […] Les vraies sociétés ne comportent pas de tels titres : ce ne sont plus des actions : ce sont des billets de loterie* »[4].

Ce minimum qui avait été introduit par la Loi de 1915 (et qui ne figurait pas dans la loi belge de 1873) et qui, de nos jours, ne servait plus à grand-chose a été aboli par la loi du 21 décembre 2006[5].

Lorsque les coupures sont réunies en un nombre suffisant d'actions, elles donnent les mêmes droits que l'action (art. 430-1 L.S.C.). Il n'est pas nécessaire que les coupures soient une subdivision de la même action : il suffit qu'elles soient en nombre suffisant[6].

La réunion en un nombre suffisant pour donner lieu à une action n'est requise que pour l'exercice des droits indivisibles, tel que le droit de vote. En revanche, rien ne s'oppose à l'exercice par une coupure isolée de la partie ou fraction correspondante d'un **droit divisible**, tel le droit aux dividendes, ou encore à une part du produit de liquidation[6].

---

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 157, ID 11305.

2 – A. Vandeplas et J.P. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 66.

3 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 274.

4 – *Pandectes françaises*, v° sociétés, n° 7981, T. 52, p. 547, cité par Projet de loi portant révision de la loi sur les sociétés commerciales, Avis du Conseil d'État, p. 83.

5 – Loi du 21 décembre 2006, ID 9442, *Doc. parl.*, n° 5562, ID 9971.

6 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 94, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

L'article 430-1 L.S.C. retient le principe de **l'indivisibilité de l'action**, principe qui est destiné à éviter d'inextricables difficultés en cas de successions. Cet objectif limité conduit à en limiter l'étendue. Il n'est applicable qu'à l'exercice des droits et non pas l'exécution des obligations. En application de ce principe, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents à une action détenue en propriété indivise jusqu'à la désignation par les indivisaires d'un mandataire unique[1]. Lorsqu'il s'agit de demander des paiements non encore effectués sur l'action indivise, alors la société ne peut poursuivre *chacun* des indivisaires que pour la quote-part détenue par lui[2].

Les actions peuvent être au porteur, nominatives ou dématérialisées. En outre, il serait parfaitement possible que les statuts stipulent que les actions libérées ne seraient transmissibles que par voie d'endossement (actions à ordre).

Chaque coupure, comme chaque action, doit porter un numéro d'ordre (sauf si elles sont dématérialisées) avec donc la conséquence que le numérotage pour chaque coupure est double : il comprend à la fois le numéro de l'action dont elle est la subdivision et le numéro de cette fraction elle-même parmi les autres fractions de la même unité[3].

1) Actions au porteur

« *Le titre au porteur a été l'un des principaux moyens tout à la fois du succès des sociétés anonymes et des déceptions des associés* »[4]. Et encore : « *L'action au porteur est bien de l'essence de la société anonyme, elle doit pouvoir passer de la main à la main jusqu'à ce qu'elle arrive chez celui qui s'occupe le plus ou qui est le plus capable de mener la société à bonne fin* »[5].

Plutôt que d'abolir les titres au porteur (comme tel a été le cas en France dès l'année 1795, par la loi du 25 avril 1795) dans un souci de protection des petits actionnaires (et peut-être surtout dans le souci d'éviter les évasions ou encore les fraudes fiscales), les législateurs belge et luxembourgeois ont entendu assurer une certaine transparence afin de permettre ainsi le contrôle par les actionnaires.

Cette transparence devrait être atteinte par l'indication de certaines informations clés concernant la société sur le titre au porteur.

Selon l'article 430-5 L.S.C., l'action au porteur doit (au minimum) comporter les données suivantes :

– la date de l'acte constitutif de la société et de sa publication ;
– le montant du capital social, le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu'ils représentent ;
– la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits ;
– les avantages particuliers attribués aux fondateurs ;

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 95, ID 11308.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 159, ID 11305.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 94, ID 11308.

4 – E. Pirmez, Commentaire législatif, II, 46, cité par A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 166.

5 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, A. Vercruysse, p. 138.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– la durée de la société.

Autrefois, l'action au porteur était signée par deux administrateurs.

Depuis la loi du 25 août 2006, la signature d'un seul administrateur (membre du directoire) suffit si celui-ci ne comporte qu'un seul membre. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe (art. 430-5 L.S.C.). Il est également possible que l'une des deux signatures soit apposée par une personne déléguée par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie de l'acte portant cette délégation doit être déposée au R.C.S.

Traditionnellement, la cession de l'action au porteur s'opère par la simple **tradition** du titre. La commodité de cette voie de cession de ces titres comportait un prix élevé dans la mesure où le porteur court les risques importants de la dépossession involontaire des titres : titres volés, égarés, détruits par incendie, inondation, etc.[1] Afin de diminuer ces risques, le législateur permet toujours au détenteur des titres au porteur de demander leur **conversion** en titres nominatifs, à condition d'en supporter les frais (art. 430-8 L.S.C.). La conversion dans le sens inverse (donc de titres nominatifs en titres au porteur) est également possible en principe, à moins qu'elle ne soit prohibée par les statuts (et sous la condition que les actions soient entièrement libérées, v. art. 430-8 L.S.C.).

L'action au porteur est une chose **non fongible** individualisée par son numéro (art. 430-1 L.S.C.). Le caractère fongible ou non de l'action est un élément important dans la détermination du moment où l'acheteur est devenu propriétaire de la chose, et donc du moment à partir duquel il assume les risques de la chose. « *Le seul consentement suffit à opérer le transfert de la propriété de même que le transfert des risques afférents à une chose non fongible (art. 1138 du Code civil). Par contre, pour les choses fongibles, il faut, en vue d'atteindre le résultat prédécrit, attendre l'individualisation, laquelle ne sera généralement réalisée que par la livraison. En matière de transaction hors Bourse, le transfert de propriété entre parties résulte donc de la seule spécification du numéro des actions au porteur vendues dans le cadre d'une convention écrite* ».

Il est encore à noter que l'action au porteur reste nominative jusqu'à son entière libération.

Selon la jurisprudence, des titres au porteur peuvent être créés en dehors des cas prévus et réglementés par la loi. Un arrêt de la Cour d'appel du 12 juillet 2006 a retenu qu'une banque dépositaire qui émet des attestations dans lesquelles elle s'engage à l'égard du détenteur (auquel elle certifie la propriété des titres sous-jacents) à échanger ces attestations contre des certificats matériels au porteur représentant les actions de la SICAV procède en fait à l'émission de titres au porteur incorporant des droits pour leurs porteurs[2]. Si les titres au porteur continuent à exister au Luxembourg, le régime applicable a toutefois changé fondamentalement par la loi du 28 juillet 2014 qui impose l'obligation de déposer les actions au porteur auprès d'un dépositaire agréé.

Sous la pression du groupe d'action financière (GAFI) armé de ses « *normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme* », le législateur national se devait de réagir par rapport aux reproches

1 – Il est vrai également que cette forme comporte des avantages appréciables dans les relations de l'associé vis-à-vis du fisc.

2 – CA, 4e chambre siégeant en matière commerciale du 12 juillet 2006, ID 15995, confirmée par arrêt de cassation du 12 juin 2008, (no 30/08, no 2486 du registre), *BDB*, n° 42, p. 56, note N. Kayser.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

adressés au système luxembourgeois des actions au porteur des S.A. ce qui a été fait par la **loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur**[1]. En substance, ces normes requièrent (entre autres) la transparence au regard de l'identité des bénéficiaires effectifs de personnes morales. Conformément aux recommandations du GAFI, le législateur national avait le choix entre quatre solutions alternatives relatives aux actions (parts) au porteur : les interdire (1), les convertir en actions nominatives (2), obliger les actionnaires ayant une participation de contrôle de la notifier à la société qui enregistre leur identité[2] (3), les immobiliser auprès d'un intermédiaire professionnel réglementé (4), dont la loi du 28 juillet 2014 a retenu la dernière. Sont visées par cette loi les actions au porteur des S.A. (y compris la SE) et des S.e.c.a., y compris les SICAR, les SICAF[3], aux organismes de titrisation sous forme de S.A. ou de S.e.c.a. Sont encore visées les parts des FCP luxembourgeois, mais pas les parts des fonds de titrisation[4].

Sont en revanche **exclues** du champ d'application de la loi du 28 juillet 2014 les parts des sociétés de personnes, de sociétés civiles, des S.à r.l., de sociétés coopératives, les parts bénéficiaires et, de façon sans doute étonnante, les obligations, y compris les obligations convertibles en actions (ou celles à warrant).

L'article 430-6 (1) L.S.C. exige le **dépôt des actions au porteur** (de sociétés luxembourgeoises) auprès d'un dépositaire « indépendant » (ne pouvant donc être associé de la société émettrice) nommé par le conseil d'administration ou le directoire sur la liste des professions réglementées de l'alinéa 2 du paragraphe 2, à savoir les établissements de crédit, les gérants de fortune, les distributeurs de parts d'OPC, les PSF […], les avocats […], les notaires, les réviseurs d'entreprises et les REA, les experts-comptables.

Aux termes du paragraphe 3 de l'article 430-6 L.S.C. « *Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg ; ce registre contient :*

– la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre des actions ou coupure ;

– la date du dépôt ;

– les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres nominatifs […] ».

Contrairement au registre des actions nominatives (qui est accessible aux seuls actionnaires, mais à tous les actionnaires de la société), ce registre n'est que d'une accessibilité limitée : « *chaque actionnaire au porteur est en droit de prendre connaissance uniquement des inscriptions qui le concernent* ».

La loi du 28 juillet 2014 avait prévu des **dispositions transitoires** destinées à permettre aux actionnaires des sociétés de pouvoir s'adapter aux dispositions de la loi en leur accordant un délai de grâce de **dix-huit mois** de l'entrée en vigueur de la présente loi pour déposer les titres visés auprès du dépositaire nommé. Les actions ou parts au porteur non immobilisées dans un délai de dix-huit mois à compter de

1 – *Mém.* A 161 du 14 août 2014, ID 22196.

2 – Il peut paraître surprenant que cette solution aurait paru acceptable pour le GAFI étant donné qu'elle est loin d'assurer une transparence totale quant à l'identité des détenteurs des titres au porteur.

3 – « Société d'investissement à capital fixe », terme non utilisé par les lois sur les OPC, mais très fréquent en pratique.

4 – En ce sens, P. Dupont et P. Hoss, « La loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur », *BDB*, nº 55, p. 8.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

l'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2014 doivent être **annulées** et il doit être procédé à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. « *L'annulation des actions ou parts est opérée à un prix obtenu en divisant le montant des capitaux propres de la société tels qu'ils ressortent du dernier bilan de la société établi à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision d'annulation, par le nombre d'actions ou parts émises par la société, ledit prix devant être diminué du montant des primes et réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ainsi que des frais et commissions relatifs à l'acte de réduction de capital.*

Les fonds correspondant aux actions ou parts ainsi annulées ou, à défaut, d'autres actifs d'une contre-valeur équivalente aux actions ou parts annulées sont déposés à la Caisse de consignation jusqu'à ce qu'une personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande la restitution ».

On voit donc que le calcul de la valeur d'annulation des actions est simpliste et, dans beaucoup de cas, il aurait sans doute abouti à une spoliation importante d'actionnaires. Il s'agissait sans doute encore d'un moyen de pression sur les actionnaires qui pouvaient éviter l'application de ces dispositions en déposant leurs titres auprès du dépositaire professionnel choisi par la société.

Certains commentateurs des dispositions de la loi du 28 juillet 2014 ont pu s'interroger sur la question de savoir si les actions déposées auprès d'un dépositaire professionnel sont encore de véritables actions au porteur. « *Si on ajoute à cette réflexion celle défendue par la doctrine au Luxembourg, à savoir qu'un titre se caractérise par trois éléments constitutifs – l'*instrumentum*, le droit et l'émetteur – et que l'*instrumentum *n'est pas nécessairement en papier, mais peut être scriptural ou électronique, alors on peut concevoir un* instrumentum *au porteur inscrit ou enregistré qui, pour autant, ne perd ni sa qualité matérielle ni celle d'être au porteur. Si on tire la conclusion ultime de cette réflexion, le titre au porteur enregistré ne devient pas une quatrième catégorie juridique de titre en droit luxembourgeois – en plus des titres au porteur "classiques" (qui subsistent bien pour des titres autres que les actions ou parts de sociétés), des titres nominatifs et des titres dématérialisés – mais reste bien dans la catégorie des titres au porteur matérialisés ou scripturaux. L'enregistrement du titre relève ainsi de son formalisme, et non pas de sa nature juridique. L'action immobilisée reste bien un titre au porteur* »[1]. Cette position nous paraît parfaitement indiquée : l'alternative consistant à dire que les titres au porteur sont des titres *sui generis* (échappant donc à la classification traditionnelle entre titres au porteur et titres nominatifs) soulève une pléthore de questions nouvelles que l'on peut éviter en considérant que les titres en question restent des titres au porteur.

La tendance vers plus de transparence sur l'identité des associés des sociétés sera encore augmentée d'un nouveau chapitre avec la transposition au Luxembourg de la réglementation européenne sur le **registre des bénéficiaires effectifs (RBE)**.

La loi du 13 janvier 2019[2] transposant l'article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs est entrée en vigueur le 1er

1 – CE, *Doc. parl.*, 6625/4, p. 2, ID 22031.

2 – Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, *Mém.* A 15 du 15 janvier 2019, ID 27908.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

mars 2019. À partir de cette date, toute entité concernée disposera d'un délai de 6 mois pour se mettre en règle avec ses nouvelles obligations légales.

Un règlement grand-ducal détaillant le processus de dépôt a été pris le 15 février 2019[1].

Les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le Registre des bénéficiaires effectifs :

– nom ;
– prénoms ;
– date de naissance ;
– lieu de naissance ;
– adresse précise ;
– numéro d'identification national ou étranger ;
– nature et étendue des intérêts détenus.

Ces données doivent être transmises par l'entité concernée (par la société qui a émis les titres) au *Luxembourg Business Registers* (au R.C.S.) dans le mois de la connaissance de l'information ou de la modification de cette information. Le respect de ces obligations est sanctionné par des amendes.

2) Actions nominatives

L'action nominative n'est pas un titre nominatif, et ceci, pour la raison qu'elle n'est pas un titre. Le certificat prévu par l'article 430-3 L.S.C. qui est émis à la demande de l'actionnaire ne fait que constater l'inscription dans le registre des actions, de même que l'inscription dans le registre des actions ne constituerait qu'un moyen de preuve[2]. Il semblerait que la solution serait différente pour la société coopérative dans le cadre de laquelle l'acte constitutif et le registre des associés ont une force probante exclusive[3]. Entre associés, le transfert se fait par le simple consentement, alors que l'opposabilité à l'égard des tiers peut résulter de l'accomplissement soit des formalités de l'article 1690 C.c. (concernant le transport des créances), soit de celles de l'article 430-4 L.S.C. Il est loisible à la société d'accepter un transfert constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

Si l'action nominative fait l'objet d'une donation, le transfert entre parties nécessitera la passation d'un acte authentique, en plus bien entendu du consentement du donateur et du donataire[4].

Si le choix se porte sur des actions nominatives, il doit être tenu un registre de ces actions nominatives au siège social. Ce registre, inconnu au Code de commerce de 1808, a été repris de la loi belge de 1873 et il contient :

– l'indication précise de chaque actionnaire ainsi que l'indication du nombre des actions qu'il détient ;

1 – Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs, *Mém. A* 73 du 19 février 2019, ID 28075.

2 – V. K. Geens, « Quelques aspects de la clause d'agrément dans la société anonyme », *R.P.S.*, 1989, p. 324.

3 – Cass. b. du 12 novembre 1903, *Pas.*, 1904, I, p. 47.

4 – V. K. Geens, « Quelques aspects de la clause d'agrément dans la société anonyme », *R.P.S.*, 1989, p. 325.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– l'indication des versements effectués ;
– les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur si les statuts l'autorisent (art. 430-3 L.S.C.).

La propriété de l'action nominative s'établit par l'inscription au registre des actions nominatives (de l'article 430-3 L.S.C.).

« *L'action nominative est celle qui appartient à une personne déterminée, connue et reconnue comme actionnaire par la société. Pour cela, l'article exige que celle-ci détienne, au siège social, un registre où doivent être inscrits tous les actionnaires en nom* »[1].

Dans le registre des actions (qui est plutôt un registre des actionnaires), il n'est pas nécessaire d'indiquer chaque action individuellement. Il suffit que les inscriptions soient faites par actionnaire (dont il faut indiquer la désignation précise). L'inscription faite pour chaque actionnaire indique qu'il possède les actions en un compte unique dans une inscription totale[2].

Les actions (qu'elles soient nominatives ou au porteur) sont nécessairement **numérotées** (art. 37 L.S.C., nouv. art. 430-1 L.S.C.). Il y a lieu d'indiquer pour chaque actionnaire les numéros des actions (ou coupures d'actions) détenues par lui. Le registre contient encore l'indication des **versements** faits par chaque actionnaire de manière à faire preuve, au profit de chaque actionnaire, de l'exécution de leurs obligations à l'égard de la société[3].

Le registre contient encore la **conversion** des actions **nominatives** en actions au **porteur**, conversion qui ne peut intervenir qu'après la libération complète de chaque action.

Le registre des actionnaires est institué dans l'intérêt respectif de la société et des actionnaires. Les actionnaires seuls sont en droit de le consulter, à l'exclusion des créanciers, obligataires ou autres[4]. Il est vrai que ces tiers trouvent dans la publication annuelle de l'état du capital suffisamment d'informations sur la situation de la société et des associés[5].

L'inscription au registre des actions nominatives constitue un moyen de preuve de la propriété, mais « *il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable et l'inscription qui n'a pas de caractère sacramentel, n'est pas à considérer en elle-même comme titre de propriété* »[6].

Malgré cette forme non physique des titres, des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux actionnaires. Il y a lieu de noter que ces certificats n'ont pas de valeur juridique et, en tout cas, ne prouvent en rien la propriété des actions (contrairement au cas des titres au porteur).

L'article 430-8 L.S.C. prévoit que les actions doivent demeurer nominatives jusqu'à leur entière libération : le tribunal prononce la nullité de trois certificats au porteur représentatifs d'actions de la société, émis lors de la constitution de la société alors que seulement un quart du capital social avait alors été libéré[7].

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 96, ID 11308.
2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, ID 11308.
3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, ID 11308.
4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 96, ID 11308.
5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 97, ID 11308
6 – CA du 30 octobre 2002, *BIJ*, 2003, p. 26.
7 – TA Lux. du 26 juin 1998, n°s 44612, 44613 et 44614, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La **cession** de ces actions nominatives se fait par une **inscription** sur ledit registre. Qui a **accès** à ce registre ? Chaque actionnaire et seulement les actionnaires. L'avant-projet de loi de Nyssens, en suivant l'exemple anglais, avait entendu donner accès au registre à « *tout intéressé* ». Cette proposition n'a toutefois pas été retenue[1].

Il ressort de la discussion devant le Parlement belge portant sur le projet de loi de 1913 que, sur ce point, deux considérations s'opposaient : en premier lieu, certains considéraient que l'intérêt pour le créancier de la société serait de pouvoir consulter le registre afin de connaître l'identité des actionnaires n'ayant pas encore libéré entièrement leurs actions. Il est vrai que la liste des souscripteurs qui restent débiteurs doit être publiée annuellement à la suite du bilan. En dehors du fait qu'à l'époque du moins, certaines sociétés ne publiaient pas leur bilan, l'inconvénient est que la publication du bilan se fait toujours avec un certain retard par rapport à la date de clôture de l'exercice, avec donc la conséquence que le créancier n'a connaissance de la situation réelle qu'avec retard[2].

Il est indéniable que ce système comporte **certaines failles** dans la mesure où les souscripteurs initiaux peuvent disparaître et être remplacés par des insolvables, étant entendu que cette substitution n'apparaîtra qu'après la publication du prochain bilan[3].

« *Au point de vue pratique, la loi autorise par son article 123 les créanciers à faire décréter les appels de versement et à en poursuivre la rentrée par application de l'article 1166 du Code civil si le conseil d'administration se refuse à le faire. Pourrait-on m'indiquer comment un créancier pourrait exercer ce droit s'il ne peut consulter le registre des actionnaires ? X a souscrit tant d'actions d'une société. Il n'a pas payé. Je puis le poursuivre, mais je risque que, la condamnation prononcée, il me justifie, livre des actions nominatives en mains qu'il s'est libéré […]* »[3].

Les actionnaires ont une responsabilité limitée à leur mise, donc aux apports qu'ils ont faits ou encore qu'ils se sont engagés à faire à la société. Ils sont donc tenus de la partie du capital qu'ils ont souscrite, mais non libérée au moment de la souscription. Comment donc procéder en cas de cession des titres non encore entièrement libérés ?

Avec Corbiau, on peut résumer le système retenu comme comportant une règle et une exception : la règle est que les souscripteurs d'actions sont personnellement tenus du montant total des actions qu'ils ont souscrites. Mais il serait excessif de déclarer que le souscripteur serait, après la cession des titres, indéfiniment tenu de faire des versements rendus nécessaires par des événements auxquels depuis sa retraite de la société il est totalement étranger[4]. « *Un associé dans une société de commerce ne peut se retirer de la société au préjudice des tiers qui ont traité avec la société ; mais les tiers n'ont aucun droit de l'empêcher de mettre fin pour l'avenir à ses engagements, en publiant, conformément à la loi, qu'il se retire* »[5]. Ces considérations sont à la base de l'exception au principe : le souscripteur, impérativement tenu des engagements passés de la société, est dégagé de ceux que la société a

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 159, ID 11305.

2 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 274.

3 – C. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, Wauwermans, p. 275.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 112, ID 11308.

5 – E. Pirmez, Commentaire législatif de la loi de 1873, II, n° 159.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

contractés postérieurement à la cession de ses actions. En fait le législateur consacre ici le même système que celui retenu à l'égard du commandité de la société en commandite simple. « *Voilà donc en deux mots le système de l'article* [49] *: en principe, responsabilité de l'actionnaire jusqu'à libération intégrale des titres qu'il a souscrits ; toutefois, par exception s'il vient à céder ses titres, décharge de cette responsabilité quant aux dettes sociales contractées postérieurement à la publication de la cession* »[1].

Il se pose encore la question de savoir vis-à-vis de qui existe cette situation ambiguë de l'actionnaire qui est **tenu des dettes sociales antérieures** à la publication de la cession tout en étant dégagé des dettes postérieures. Existe-t-elle au même titre à l'égard de la société et à l'égard des créanciers sociaux ? Selon la Cour de cassation belge, cet article a été inspiré du seul intérêt des tiers au profit desquels la publicité de la cession est exigée.

La loi retient que, vis-à-vis de la société, la cession produit ses effets dès la signature par les parties sur le registre de la société avant la publication, alors qu'à l'égard des tiers elle ne produit ses effets qu'à partir de la publication (art. 430-13, alinéa 2, anc. art. 49, alinéa 2, L.S.C.). Le cédant est donc libéré dès la publication de la cession et dégagé de tout versement devenu exigible ultérieurement[2].

Si le cédant a été tenu de payer en vertu de la disposition analysée ici afin de payer des dettes sociales antérieures à la cession (ou à la publication de celle-ci), il s'est acquitté d'une dette que le cessionnaire s'était en fait engagé à prendre à sa charge. Le cédant dispose donc d'un recours non seulement contre son cessionnaire, mais également contre les différents cessionnaires successifs. Ces différents cessionnaires sont solidairement tenus envers le cédant[3].

Lorsque les actions sont au porteur, elles passent d'un actionnaire à l'autre sans qu'il y ait la moindre intervention par la société émettrice des titres : le dépositaire agréé met à jour le registre des actions déposées. Quand il s'agit de titres nominatifs, la société intervient, mais celle-ci fait uniquement acter l'accord des cédant et cessionnaire. Mais il peut en aller autrement : il est loisible à la société de prévoir un agrément du transfert par le conseil d'administration. En effet, certaines sociétés, dans le but d'exercer un contrôle sur les actionnaires et afin notamment d'éviter l'intrusion d'un groupe rival, prévoient par une clause statutaire que ces cessions doivent être soumises à l'agrément du conseil d'administration.

Une telle clause statutaire est-elle valable ? Malgré certaines prises de position divergentes en doctrine[4], la position de loin dominante est qu'une telle clause est en principe valable[5]. La Cour de cassation belge confirme cette position dans les termes suivants : « *qu'il est loisible aux parties de stipuler toute clause qui n'est pas contraire aux lois ou à l'ordre public ; qu'on ne peut pas considérer comme telle la clause qui attribue au conseil d'administration d'une société le pouvoir discrétionnaire*

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 113, ID 11308.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 117, ID 11308.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 96, ID 11308.

4 – P. Coppens, *J.T.*, 1949, p. 216 ; la clause visée serait nulle pour la raison qu'elle serait contraire aux dispositions d'ordre public qui exigent que les actions soient cessibles : la soumission de la cession au pouvoir arbitraire du conseil équivaudrait à une telle interdiction de céder.

5 – F. Gilson de Rouvreux, « De la clause des statuts d'une société anonyme subordonnant le transfert des actions nominatives à l'agrément du conseil d'administration », *R.P.S.*, 1956, p. 56.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de refuser l'admission de cessionnaires d'actions nominatives non libérées ; que loin d'être contraire à l'essence des associations commerciales, elle se justifie par les mêmes motifs que ceux qui ont inspiré la règle écrite dans l'article 1861 du Code civil pour les sociétés civiles »[1].

La Loi de Modernisation a mis fin à tout doute éventuel sur ce point en validant expressément ce type de clause dans son article 430-1 L.S.C.

La **clause d'agrément** instaure un élément d'*intuitu personae* entre la société et les actionnaires. Elle ajoute une condition matérielle aux conditions formelles d'opposabilité. En ce sens, le transfert n'est opposable qu'à condition qu'elle y ait consenti.

Toutefois, ces clauses sont soumises à certaines limites : « *Si la libre cessibilité n'est pas de l'essence de l'action et qu'il est donc certain que des restrictions peuvent être apportées à la circulation de celle-ci, il y a lieu d'admettre, en revanche, qu'il n'est pas possible d'abolir le droit de l'actionnaire de céder son titre, car ceci est contraire à la nature même de la société anonyme* »[2]. En d'autres termes, le refus systématique d'agréer tout cessionnaire proposé par un actionnaire désireux de céder ses actions serait constitutif d'un **abus de droit** de nature à engager la responsabilité de la société[3].

À supposer que l'agrément soit requis par une disposition statutaire valablement prise, et à supposer que cet agrément n'ait pas été obtenu, alors la cession prévue ne constitue qu'un simple projet au regard de la société et ne lui est pas opposable[4].

Quelle est la solution si le cédant et le cessionnaire sont tombés d'accord sur la cession de l'action, mais que par la suite l'agrément n'est pas obtenu ? Dans l'hypothèse où la clause d'agrément est prévue par les statuts, celle-ci est opposable aux associés nouveaux comme à tous tiers au moins après un délai de 15 jours (v. art. 9, § 4, L.S.C.).

Entre parties, la situation peut être résolue de plusieurs manières : en premier lieu, il peut y avoir demande d'annulation de la part du cessionnaire lorsque celui-ci peut se prévaloir du fait qu'il n'a pas été informé de la nécessité de l'agrément. Il se prévaut du vice de consentement sous la forme soit du dol, soit de l'erreur substantielle.

Les parties peuvent prévoir que l'obtention de l'agrément constitue une condition suspensive ou, à l'inverse, que le refus de l'agrément constitue une clause résolutoire.

Le transfert peut avoir lieu sans agrément à l'égard de la société : dans ce cas, recours peut être pris à la notion de **croupier** dans la mesure où le cédant conserve la qualité d'actionnaire alors que le cessionnaire est associé à la part du cédant, mais non pas à la société elle-même.

3) Les actions dématérialisées

Introduites par la **loi du 6 avril 2013** relative aux titres dématérialisés[5], les actions dématérialisées s'ajoutent (sans les remplacer) aux actions nominatives et

1 – Cass. b. du 30 janvier 1869, *Pas.*, 1869, I, 116.

2 – Trib. com. Bruxelles du 1er décembre 1948, *R.P.S.*, 1949, n° 4092.

3 – F. Gilson de Rouvreux, « De la clause des statuts d'une société anonyme subordonnant le transfert des actions nominatives à l'agrément du conseil d'administration », *R.P.S.*, 1956, p. 57.

4 – V. CA Orléans du 12 février 1952, *R.P.S.*, 1955, n° 4458.

5 – Loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, *Mém. A* 71 du 15 avril 2013, ID 19749.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

aux actions au porteur (en suivant ainsi le droit belge qui, dès l'année 1995, avait introduit les titres dématérialisés à côté des actions au porteur et des actions nominatives[1]). « *Dans une approche comparative, coexistent en Europe des systèmes juridiques sans dématérialisation de titres, des systèmes mixtes, et des systèmes ne connaissant plus que les titres dématérialisés. Le Luxembourg se situera donc dans la classe des régimes à dématérialisation facultative, dans la mesure où des émetteurs spécialisés émettront ces titres, ou appliqueront une procédure de conversion à des titres matérialisés si telle est la volonté de l'émetteur* »[2].

La **loi du 6 avril 2013** (reprise en particulier à l'art. 430-7 [anc. art. 42*bis*] L.S.C.) a d'ailleurs un champ d'application nettement plus étendu que celui des actions de sociétés par actions, mais elle est relative aux titres de telles sociétés, la notion de titres devant être entendue dans un sens très large en incluant notamment, en plus des actions visées ci-dessus les parts de FCP, les parts bénéficiaires et les titres de créances (obligations notamment) émis par des sociétés (ou encore les FCP) luxembourgeois.

Le Luxembourg avait déjà connu avant la loi du 6 avril 2013 ce qu'on a convenu d'appeler une **dématérialisation *de facto*** (consistant dans le dépôt de titres au porteur auprès d'un dépositaire professionnel émettant un certificat global au bénéfice des dépositaires et en inscrivant les titres sur un compte : à partir de ce compte, les titres peuvent ensuite circuler par simple **transfert scriptural**, en somme donc de façon « dématérialisée »)[3]. Dans le souci de protection des investisseurs, l'émission de titres dématérialisés est réservée aux professionnels spécialement agréés à cet effet.

« *En matière de modes de transfert de titres, on distingue entre transfert physique et transfert scriptural. D'après l'article 3 de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d'autres instruments fongibles, le transfert scriptural est celui qui se réalise par le virement des titres d'un compte à un autre. Il est évident que ce type de transfert s'opère facilement sur des titres dématérialisés. S'agissant de titres matérialisés, le transfert scriptural suppose la fongibilité des titres concernés. Il s'ensuit que fongibilité et dématérialisation ne doivent pas être confondues. Si la fongibilité est une condition nécessaire pour le transfert scriptural d'un titre matérialisé, on peut par contre imaginer l'existence d'un titre dématérialisé non fongible, d'autant plus que le projet sous avis fait des titres dématérialisés un type particulier de titres, à côté des titres au porteur et des titres nominatifs, dont la dématérialisation pourra continuer sur base des techniques préexistantes au présent projet, telles que développées* de facto *par la pratique (cf. l'exposé des motifs). On aura dès lors à l'avenir des titres dématérialisés "en soi", émis sur base du projet sous avis, et des titres nominatifs ou au porteur "techniquement dématérialisés", sur base de législations ou de pratiques antérieures, et dont la dématérialisation potentielle, à un moment ou l'autre de leur existence, n'est pas irréversible, s'agissant simplement d'un moyen de circulation ou d'inscription en compte* »[4].

---

1 – *Doc. parl.*, n° 6327/1, p. 3.

2 – *Doc. parl.*, n° 6327/1, p. 3.

3 – Le Conseil d'État (*Doc. parl.*, n° 6327/1, p. 2) précise d'ailleurs expressément que ces pratiques antérieures continueront à coexister à l'avenir avec le régime nouveau tel qu'introduit par la loi du 6 avril 2013.

4 – *Doc. parl.*, n° 6327/1, Avis du Conseil d'État, p. 2.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La loi du 6 avril 2013 ne vise pas seulement les émissions de titres dématérialisés dès le départ (art. 4-7), mais encore ceux qui initialement sont des titres nominatifs (ou au porteur) et qui, par la suite, sont convertis en titres dématérialisés (art. 8-12). Dans ce deuxième cas de figure, la possibilité et les modalités de conversion doivent être prévues par les statuts et, le cas échéant, le règlement de gestion.

Dans son avis sur le projet de loi de dématérialisation des titres, le Conseil d'État constate que, tout comme la doctrine, « *[…] la jurisprudence luxembourgeoise a reconnu la dématérialisation de titres. Ainsi, dans un arrêt du 16 mars 2005, la Cour d'appel a retenu que "la pratique luxembourgeoise des affaires admet le procédé de dématérialisation des titres nominatifs dans laquelle elle voit la substitution à l'inscription existant dans le registre tenu par l'émetteur ou un tiers au nom d'une personne d'une nouvelle inscription au nom d'une autre personne"* »[1].

Aux termes de l'article 2 (1) de ladite loi « *Les titres dématérialisés ne sont représentés que par une inscription en compte-titres* ». Cette formulation marque un net progrès par rapport à celle proposée par le projet de loi n° 6327 : « *Les titres dématérialisés ne sont matérialisés* (sic) *que par une inscription en compte-titres* ». Toutefois, la Loi de Modernisation est revenue sur la version du projet de loi n° 6327. Quoi qu'il en soit, la phrase citée exprime l'essence des titres dématérialisés « *qui n'existent qu'en vertu d'une inscription en compte […] Le principe est que ces titres existent sans aucun support papier* »[2].

Chaque émission de titres dématérialisés (qu'ils soient cotés ou non cotés) doit obligatoirement (dans sa totalité) et à tout moment faire l'objet d'un **enregistrement dans un seul compte**, tenu par un seul organisme de liquidation ou un seul teneur de compte central (l'option du teneur de compte central n'existant que pour les titres non cotés).

L'article 430-8. L.S.C. réglemente les conversions d'actions ou de titres au porteur et nominatifs en titres dématérialisés, et vice versa. « *Les propriétaires d'actions ou de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs ou, si les statuts le prévoient, en actions ou titres dématérialisés* ».

Si les statuts le prévoient, « *les propriétaires d'actions ou titres nominatifs peuvent en demander la conversion en actions ou titres dématérialisés […]* » et « *Les porteurs d'actions ou de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs sauf si les statuts prévoient la dématérialisation obligatoire des actions ou titres* ».

4) Actions sans droit de vote

Les actions sans droit de vote étaient autrefois appelées « actions privilégiées sans droit de vote ». Le caractère privilégié n'est plus un critère distinctif de ce type d'actions (même s'il n'est pas interdit de leur accorder une compensation pour le fait de ne pas avoir de droit de vote). En revanche, l'émission d'actions sans droit de vote ne peut avoir lieu « *[…] qu'à la condition que le droit à un dividende en cas de*

1 – Le Conseil d'État fait ici référence à l'arrêt de la Cour d'appel du 16 mars 2005, n° 27915 du rôle, ID 11979.

2 – *Doc. parl.*, n° 6327, p. 20.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

répartition des bénéfices, le droit au remboursement de l'apport et, le cas échéant, le droit à la distribution d'un bénéfice de liquidation soient fixés par les statuts ».

L'introduction de ce type d'actions est basée sur des arguments assez convaincants tirés du comportement typique des actionnaires. L'absentéisme des actionnaires aux assemblées témoigne du fait qu'ils ne considèrent pas leur droit de vote comme important. Néanmoins, les titres qui n'ont pas le droit de vote font souvent l'objet d'une décote par rapport à ceux qui en sont pourvus. Si ces actions dénuées du droit de vote sont dotées d'un droit à un dividende privilégié, alors la protection du droit de propriété de l'actionnaire qui, dans une première étape, est entamé par l'abandon du droit de vote se trouve réassuré[1].

Selon les anciens articles 44 à 46 L.S.C. (introduits par une loi du 8 août 1985[2]), il est possible d'émettre des actions privilégiées représentatives du capital sans droit de vote. Ce régime fut instauré dans le cadre de la crise aiguë qu'a connue la sidérurgie luxembourgeoise dès la deuxième moitié des années 1970. Il fallait s'assurer que **l'État luxembourgeois** puisse prendre une participation dans une entreprise sidérurgique du pays, mais ceci, sans prendre le contrôle de la société au regard des droits de vote. Ce résultat fut donc atteint au moyen de l'introduction d'une nouvelle forme d'actions, les actions privilégiées sans droit de vote.

En renonçant à leur droit de vote (droit fondamental des associés dans toute société), les associés détenant de telles actions se voyaient en contrepartie dotés d'un **droit privilégié aux dividendes** (et au boni de liquidation). Ce droit était en outre récupérable. Le projet de loi n° 2890 (qui a donné lieu à la loi du 8 août 1985) s'est inspiré de régimes similaires introduits par nos pays voisins, notamment en Belgique (arrêté royal n° 245) et en France (art. 289-1 de la loi du 24 juillet 1966).

Si la loi de 1985 avait prévu un régime assez strict et qui comportait obligatoirement un droit privilégié aux dividendes et/ou au boni de liquidation, la Loi de Modernisation n'impose plus un tel caractère privilégié et elle a abandonné aux statuts de la société de prévoir les conditions de participation aux répartitions de bénéfices, au remboursement des apports et au bénéfice de liquidation. D'ailleurs, la Loi de Modernisation ne parle plus que d'actions sans droit de vote.

Aux termes de l'article 430-9 L.S.C., l'émission d'actions sans droit de vote peut avoir lieu dans trois cas précis :

1. lors de la constitution de la société si les statuts le prévoient ;
2. lors d'une augmentation de capital ;
3. lors de la conversion d'actions ordinaires en actions privilégiées sans droit de vote.

Dans les deux premiers cas, l'assemblée générale délibère selon les règles prescrites à l'égard des assemblées générales extraordinaires.

Dans le dernier cas, la loi prend soin de garantir l'égalité entre actionnaires (ordinaires) en donnant à tous les actionnaires l'opportunité de convertir dans les mêmes proportions leurs actions en actions privilégiées sans droit de vote.

« *L'offre de conversion est faite en même temps à tous les actionnaires et à proportion de leur part dans le capital social. Le droit de souscription peut être exercé*

1 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 285.

2 – *Doc. parl.*, n° 2890, ID 9801.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

pendant un délai fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à partir de l'ouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant le délai de souscription et publié au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information ».

Une telle émission est soumise à des conditions qui sont les suivantes :

a) Fixation d'un taux maximum

Si autrefois les actions sans droit de vote ne pouvaient pas représenter plus de la moitié du capital social, une telle contrainte n'est plus imposée par la loi qui se limite simplement à disposer que « *l'assemblée détermine le maximal des actions à émettre* » (paragraphe 3 de l'article 430-9 L.S.C.).

b) Droit à un dividende privilégié et récupérable

Si un tel droit à un dividende privilégié et récupérable existait autrefois, tel n'est plus le cas depuis la Loi de Modernisation qui dispose lapidairement que les statuts doivent obligatoirement préciser « *le droit à un dividende en cas de répartition des bénéfices, le droit au remboursement de l'apport et, le cas échéant, le droit à la distribution d'un bénéfice de liquidation* » (paragraphe 2 de l'article 430-9 L.S.C.).

c) Droit de vote de ces actions

L'article 430-9 L.S.C. introduit en 2016 dispose que les actions sans droit de vote disposent exceptionnellement d'un droit de vote, et ceci, lorsque la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier les droits attachés à ces actions sans droit de vote. Il en va de même de toute assemblée appelée à se prononcer sur la réduction du capital social ou sur la dissolution anticipée de la société.

5) Actions rachetables

En application de l'article 430-22 [anc. art. 49-8] L.S.C., il est loisible aux sociétés de procéder à l'émission d'actions rachetables, et ceci, aux conditions suivantes :

« *Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'émission d'actions rachetables est autorisée pourvu que le rachat de ces actions soit soumis aux conditions suivantes :*

1° le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des actions rachetables ;

2° ces actions doivent être entièrement libérées ;

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

3° les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ;

4° le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 461-2 ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat

5° un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves ;

6° le point 5° ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat ;

7° lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 461-2, paragraphe 1er ;

*8° le rachat fait l'objet d'une publicité conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis *de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».*

Les conditions prévues par la loi sont très similaires à celles retenues pour le cas de **rachat d'actions propres**, opération prévue par les articles 430-15 à 430-18 L.S.C. Les objectifs de ces deux réglementations sont encore identiques : assurer le **maintien du capital social.** En d'autres termes, le rachat d'actions n'est possible que si (et dans la mesure où) la société a généré des bénéfices suffisants, au moins équivalents aux montants qui doivent être versés aux actionnaires détenteurs des actions à racheter. Il s'agit en réalité d'une approche extrêmement prudente : en somme, la réglementation en question garantit que le capital social soit intact même si les titres acquis n'ont **aucune valeur**. Il s'agit de l'approche du « *worst case scenario* ».

Le système en question est à double détente : en premier lieu, il convient de s'assurer que les acquisitions de titres sont faites au moyen de bénéfices distribuables : cette condition est remplie si la société dispose de bénéfices suffisants, donc au moins équivalents à la valeur de marché des titres rachetés. En deuxième lieu, un montant correspondant au nominal (pair comptable) des titres rachetés doit être comptabilisé dans une réserve non distribuable.

Finalement on peut noter que les actions rachetables se distinguent du **rachat d'actions propres** par le fait que ce rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des actions rachetables. On a pu considérer cette possibilité comme une « forme douce » d'exclusion dans la mesure où le rachat ne porte pas nécessairement sur la totalité des actions rachetables[1].

6) Différentes classes d'actions

Après avoir retenu le principe de la possibilité d'émettre plusieurs classes d'actions offrant des droits différents, nous allons aborder une innovation récente du législateur national, les actions traçantes.

1 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, p. 454.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

a) Reconnaissance de principe

La L.S.C. reconnaît explicitement la possibilité pour les sociétés anonymes (et entre-temps aussi pour les S.à r.l.) d'émettre plusieurs catégories d'actions et la pratique, souvent pour des raisons fiscales, ne se prive pas de profiter amplement de cette faculté. En effet, le point 7 de l'article 420-15 qui énumère les indications que l'acte de société doit contenir est libellé comme suit : « *les catégories d'actions lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories […]* ». La liberté des statuts de définir les droits relatifs de ces différentes classes d'actions n'est donc en rien limitée.

b) Les actions traçantes (*tracking shares*)

Par ces termes, la Loi de Modernisation a introduit une notion inconnue jusqu'ici en droit luxembourgeois qui, comme le nom le suggère, parvient des États-Unis. En France, cette innovation financière a donné lieu à un rapport d'un **groupe de travail mandaté par la COB** (Commission des opérations de bourse) française présidé par René Barbier de la Serre, auquel les auteurs de la Loi de Modernisation se sont également référés. Selon ce rapport, qui date de l'année 2000 déjà, cet instrument peut être défini ainsi : « *Le* tracking stock *est un titre de capital qui suit les performances d'une activité à l'intérieur du groupe. Ce produit tire sa spécificité du fait qu'il représente une quote-part du capital de l'émetteur mais non de celui de l'activité qu'il a pour objet de retracer […] L'émetteur américain peut ainsi aisément insérer dans un cadre juridique particulièrement souple un produit dont l'utilité se comprend avant tout d'un point de vue économique et financier. À cet égard, la relative pureté du produit américain permise par ce cadre juridique est souvent mise en exergue* »[1].

Au Luxembourg, la notion de *tracking shares* a été adoptée par la pratique, surtout dans le domaine des fonds d'investissement non réglementés ou encore dans les grands groupes de sociétés[2]. Les actions traçantes constituent un instrument utilisé pour permettre une certaine isolation d'une partie de l'activité de la société tout en faisant l'économie des coûts inhérents à des mesures de restructuration plus incisives telles que la filialisation d'une certaine activité ou encore la scission (« totale » ou « partielle ») de la société. En acquérant des actions traçantes le détenteur de ces titres participe non pas aux performances de l'ensemble de la société (du groupe), mais il est traité comme étant associé d'une certaine partie de cette activité (d'une branche d'activité seulement).

Au Luxembourg, le point de départ de la consécration législative des actions traçantes a été l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi n° 5730. Dans ledit avis, celle-ci a regretté l'absence d'un cadre légal pour ces actions qui serait une source d'insécurité. À la suite de cette intervention, **l'article 1853** C.c. s'est vu augmenté d'un alinéa 3 pour prendre la version suivante consécutive à l'adoption de la Loi de Modernisation : Art. 1853.C.c. : « *Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.*

1 – Rapport du groupe de travail de la COB, p. 7.

2 – St. Guers, « Les actions traçantes en droit luxembourgeois », *ACE*, 2015/9, p. 19.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

À l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est, sans clause contraire, réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

Lorsqu'il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits financiers respectifs à la performance d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société » (c'est la partie soulignée qui a été ajoutée par la Loi de Modernisation).

Ce passage étant la seule et unique trace des *tracking shares* dans le droit luxembourgeois, certains ont pu regretter son caractère insuffisant. « *Cependant, de par sa formulation générale et l'absence de dispositions spécifiques dans la Loi de 1915, la modification proposée ne semble pas constituer une innovation majeure et certaines dispositions de notre droit des sociétés priveront toujours les actions traçantes d'intérêt dans certaines formes sociales […]* »[(1)].

Comme mentionné par le rapport du groupe de travail français précité (p. 14) : « *De manière générale et pour reprendre l'une des conclusions de l'analyse du professeur Germain, au regard de la répartition des bénéfices annuels, il existe une solidarité relative de la "partie parcellaire" et de la partie ordinaire. Elles sont dans une autonomie partielle jusqu'à ce que les difficultés de l'une atteignent l'autre. C'est une situation "d'indépendance dans l'interdépendance". Cette interdépendance est la manifestation de l'*affectio societatis *dans une situation originale* ». En clair, ceci signifie (notamment) que, si la « partie parcellaire » (celle qui détermine la performance des actions traçantes) est déficitaire (le cas échéant, ces déficits absorbant les profits des autres activités de la société), alors (en l'absence de réserves accumulées) aucun dividende ne pourra être distribué sur les actions ordinaires de la société : un dividende éventuel versé serait un **dividende fictif** tombant sous la prohibition de l'article 1500-6 L.S.C. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les actions traçantes n'aboutissent pas à une « **compartimentalisation** » de la structure émettrice, alors qu'une telle division en compartiments est effectivement possible pour les OPC et pour les sociétés de titrisation. La loi du 22 mars 2004 sur la titrisation spécifie que : « *Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment […]* » (art. 62). Les mêmes précisions sont contenues dans la loi du 17 décembre 2010 sur les OPC qui, notamment dans l'article 181, dispose : « *Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment […]* ». L'article 1853 C.c. ne permet pas de tels effets.

Le rapport du groupe de travail mandaté par la COB mentionné ci-dessus s'est prononcé également sur le **caractère potentiellement léonin** des actions traçantes. « *Le dividende prioritaire, calculé en fonction des résultats d'une activité du groupe, ne tombe pas sous le coup de cette prohibition. En effet, il est prélevé par préciput sur le dividende distribuable arrêté par l'assemblée générale mais les actionnaires ordinaires ne sont pas pour autant privés de toute participation aux bénéfices […] Il pourrait toutefois ce faisant, se trouver que, dans des hypothèses extrêmes, le dividende prioritaire absorbe la totalité du dividende distribuable. Si les perspectives de résultats du groupe et de l'activité tracée devaient montrer une forte probabilité en ce sens, il pourrait alors être considéré que la clause de dividende prioritaire a eu un tel objet et qu'elle constitue, pour ce motif, une clause léonine* » (p. 13 du rapport).

1 – St. Guers, « Les actions traçantes en droit luxembourgeois », *ACE*, 2015/9, p. 20.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En d'autres termes, la question de savoir s'il peut y avoir infraction à l'article 1855 C.c. dépend des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, dans un cas extrême, il se pourrait que, si les actions traçantes suivent une activité structurellement déficitaire (p. ex., pour être dépassée par le progrès technique) alors que les autres activités sont hautement profitables (et le resteront de manière prévisible), alors il serait possible que l'argument de la clause léonine puisse être invoqué avec succès. Il est évident que la charge de la preuve incombe au demandeur qui invoque le caractère léonin de cette clause.

L'article 450-4 [anc. art. 68] L.S.C. est relatif aux changements des droits en cas de pluralité de classes d'actions. Le projet de Loi de Modernisation (en se référant au droit belge, art. 560 Code des sociétés) avait prévu d'y apporter d'importants changements, notamment en l'étendant au cas de **plusieurs catégories de parts bénéficiaires**. En outre, chaque modification aurait exigé un rapport du conseil d'administration (directoire) donnant la justification détaillée des modifications, etc. Faute de tel rapport, la décision du conseil d'administration serait nulle. Ces propositions n'ont pas été adoptées, de sorte que l'article en question a survécu la Loi de Modernisation sans le moindre changement.

B – Le droit préférentiel de souscription

Art 420-26 L.S.C.

« *(1) Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement, à la partie du capital que représentent leurs actions.*

(2) Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe 1er ne s'applique pas aux actions pour lesquelles les droits de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents. De même, les statuts peuvent permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.

(3) Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Luxembourg. Toutefois lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information.

(4) Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans qu'il puisse être apporté de restrictions à cette négociabilité. Par exception au premier alinéa, les restrictions applicables aux titres auxquels le droit de souscription est attaché seront également applicables à ce droit.

(5) Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence [...] ».

Un des droits fondamentaux des actionnaires d'une société anonyme est de ne pas pouvoir perdre en importance relativement aux autres actionnaires de la société, donc de pouvoir s'opposer à la **dilution** de sa participation par rapport à celles des

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

autres associés. Il s'agit évidemment d'un cas d'application du principe d'**égalité des associés**. Cette égalité est préservée au moyen du droit préférentiel de souscription, le DPS.

« *Le DPS des actionnaires a pour but de leur conserver la même influence relative au sein des organes sociaux et de leur éviter une perte patrimoniale résultant de ce que, le plus souvent, les actions nouvelles sont émises à leur valeur intrinsèque et au cours boursier des titres anciens* »[1].

En d'autres termes, un associé qui détient p. ex. 10 % des titres de la société ne pourra pas contre son gré et en raison d'une augmentation de capital, voir sa participation diminuer par rapport à celles des autres associés. Il aurait le droit de souscrire autant d'actions pour maintenir sa participation de 10 % dans le capital social. La condition est toutefois que l'actionnaire soit disposé et à même de souscrire à l'augmentation de capital décidée par l'assemblée des actionnaires.

1) Notion de droit préférentiel de souscription

Le moyen qui est au service de cet objectif est le droit préférentiel de souscription (**DPS**) qui a fait son entrée en droit des sociétés luxembourgeois en 1983 : le DPS a été introduit par la loi du 24 avril 1983 transposant la Deuxième directive en droit luxembourgeois qui, en son article 420-26 [anc. art. 32-3 (1)] L.S.C., prévoit que : « *Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions* », reproduction presque littérale de l'article 29, alinéa 1, de la Deuxième directive. Il s'agit du **droit de souscription à titre irréductible**.

Il peut paraître curieux qu'un droit aussi important n'ait été reconnu en droit luxembourgeois que si tardivement. Ce droit préférentiel est d'ordre public : « *(5) Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence […]* ».

Il est vrai que le droit de ne pas voir sa participation diluée ne joue que dans la mesure où l'actionnaire est effectivement disposé et à même d'exercer les droits dont il dispose ainsi en vertu des dispositions légales ; en d'autres termes, il faut que l'actionnaire ait les moyens de souscrire les nouvelles actions. Si tel n'est pas le cas, deux conséquences s'en suivent :

– en premier lieu, l'actionnaire en question sera bel et bien dilué par rapport aux autres actionnaires de la société ;

– en deuxième lieu, la loi prend garde qu'au moins l'associé ne soit pas spolié, et ceci, au moyen de la possibilité de procéder à la négociation de ces droits prévue par le paragraphe 4 de l'article 420-25 L.S.C. ainsi libellé : « *Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans qu'il puisse être apporté de restrictions à cette négociabilité. Par exception au premier alinéa les restrictions applicables aux titres auxquels le droit de souscription est attaché seront également applicables à ce droit* ». Il peut s'agir de restrictions statutaires ou encore de restrictions conventionnelles entre actionnaires ou groupes d'actionnaires. Ces deux types de restrictions sont autorisés à condition toutefois de ne pas rendre les titres incessibles.

1 – A. Vandeplas et J.P. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 75.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

a) Exercice du DPS

Art. 420-26, paragraphe 3 L.S.C. :
« *(3) Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Luxembourg. Toutefois lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information* ».

En pratique, le DPS s'exerce en deux étapes : chaque actionnaire a le droit de souscrire un nombre d'actions exactement proportionnel au nombre d'actions qu'il possède par rapport à l'augmentation de capital des titres nouveaux par rapport aux titres anciens. Ainsi, si le capital est augmenté de 50 %, chaque actionnaire peut souscrire une action nouvelle pour toutes les deux actions qu'il possède. C'est le DPS **à titre irréductible**. En général, toutes les actions émises ne sont pas souscrites par l'exercice du DPS à titre irréductible. En effet, un certain nombre d'actionnaires n'exercent pas leur droit, de sorte que les actions non souscrites peuvent être offertes à la souscription aux actionnaires qui avaient exercé leur droit à titre irréductible (et qui sont donc disposés et à même de souscrire des actions supplémentaires). Les demandes ainsi faites étaient alors proportionnellement réduites si elles dépassaient le nombre d'actions encore disponibles[1].

Ce système est pourtant critiquable dans la mesure où il revient à **spolier** les actionnaires qui n'ont pas souscrit le quota des actions leur offert à titre irréductible. La perte patrimoniale ainsi subie par ces actionnaires non-souscripteurs (qui sont en général les petits actionnaires) trouve sa contrepartie dans un gain réalisé par d'autres actionnaires (qui sont en général les actionnaires les plus importants). Pour mieux protéger les intérêts des petits actionnaires, la Commission bancaire belge a recommandé d'abandonner cette souscription à titre irréductible « *afin d'y substituer l'organisation d'un marché de vente des droits de souscription non exercés matérialisés par des "scripts", le produit de réalisation des scripts revient aux actionnaires qui n'ont pas exercé leur droit* »[1]. C'est ce système qui a été également retenu par la directive ainsi que par l'article 420-26 L.S.C.

« *(8) Pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la cote officielle d'une bourse située au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ou négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, à défaut de dispositions statutaires, les tiers pourront à l'issue du délai de souscription préférentielle fixé au paragraphe 3 participer à l'augmentation du capital, sauf au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire de décider que les droits de préférence seront exercés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit durant la période de souscription préférentielle. Les modalités de la souscription par les actionnaires anciens sont dans ce cas définies par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire* ».

1 – A. Vandeplas et J.P. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 76.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

b) Champ d'application du DPS

Si le DPS est un droit « *qui ne peut être ni supprimé, ni limité* » (art 420-26 (5) L.S.C.) son champ d'application est néanmoins limité. En premier lieu, il ne s'applique qu'aux titres « *représentatifs du capital social* ». Se trouvent ainsi écartés de ce droit les détenteurs de parts bénéficiaires. Il en est ainsi pour la raison que, si les détenteurs de ces titres avaient droit aux DPS, alors ce droit réduirait d'autant le droit des détenteurs d'actions représentant le capital social. Or, ceci est expressément prohibé par l'article 29, alinéa 1, de la Deuxième directive[1].

Dans la même ligne de raisonnement, le DPS peut, conformément aux dispositions de l'article 29, alinéa 2, de la directive être aménagé comme suit :

« (2) *Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe 1er ne s'applique pas aux actions pour lesquelles les droits de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents. De même, les statuts peuvent permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises* »[2].

Une autre question est de savoir si des aménagements du DPS sont autorisés en cas **d'apport en nature**. Selon le texte de la directive (et L.S.C.), le DPS s'applique uniquement aux actions à souscrire par numéraire.

Les États membres sont libres de l'étendre éventuellement vers les apports en nature[3], ce qui n'a donc pas été fait par le législateur luxembourgeois.

La Commission bancaire belge a pris la position que le DPS serait applicable également en cas d'apport en nature non spécifiques, soit donc des apports susceptibles d'être fournis par quiconque[4]. Le raisonnement de la Commission est facile à suivre : en fait, elle considère que, si la directive limite le DPS aux apports en numéraire, la raison en est que l'apport en nature ne peut être fourni que par l'un ou l'autre apporteur déterminé, de sorte que la limitation du DPS est inévitable. En revanche, pour les apports en nature de biens non spécifiques, il existe un risque que l'apport en nature soit un moyen commode de limiter les droits de souscription des actionnaires existants. Le texte de la directive ne semble toutefois pas permettre cette interprétation de la Commission bancaire. Néanmoins, il reste aux actionnaires la possibilité d'agir, le cas échéant, contre la société sur la base d'une action reposant sur l'adage « *fraus omnia corrumpit* ».

Pour le cas où les actions ayant donné droit au DPS étaient affectées d'un démembrement de propriété, la Loi de Modernisation (art. 420-26 [anc. art. 32-3] (9) L.S.C.) a prévu la solution suivante : « *Quant à l'exercice du droit préférentiel de souscription lors d'une augmentation de capital, il est décidé de suivre la solution formulée par le droit français, attribuant l'exercice de celui-ci au nu-propriétaire (les actions alors attribuées revenant au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour*

1 – A. Vandeplas et J.P. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 77.

2 – Art. 420-26 (2), anc. art. 32-3 (2) L.S.C., ID 7520.

3 – CJCE, du 19 novembre 1996, arret *Siemens AG* / *Henry Nold*, C-42/95, ID 11678.

4 – A. Vandeplas et J.P. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 77.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

l'usufruit), l'usufruitier disposant de la faculté de se substituer au nu-propriétaire négligeant d'exercer son droit préférentiel de souscription. À l'instar du droit français, le même traitement est prévu en cas d'attribution d'actions gratuites. Enfin il est expressément précisé que la solution légale est supplétive »[1].

2) Notion de capital autorisé

L'institution dite du « capital autorisé » en droit luxembourgeois (prévue par l'art. 420-22 [anc. art. 32] L.S.C.) remonte à l'année 1983, lorsque le projet de loi n° 2474 a transposé en droit national les dispositions de la Deuxième directive en matière de droits des sociétés. Le capital autorisé consiste dans une **délégation** par laquelle l'assemblée générale des actionnaires accorde **à l'organe de direction** de la société l'autorisation (limitée dans le temps, mais renouvelable) de procéder à une augmentation de capital par l'émission de nouveaux titres de capital. Une fois cette autorisation accordée, l'augmentation de capital échappe complètement à l'assemblée générale des actionnaires et elle est exercée par l'organe de direction tout en restant dans les limites fixées par l'autorisation accordée (notamment quant au montant de l'augmentation).

Par le passé, l'augmentation de capital et ses modalités et conditions ne pouvaient être décidées que par l'assemblée des actionnaires qui conférait habituellement au conseil les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation, alors que la technique du capital autorisée consiste à ce que « […] *le conseil d'administration décide lui-même de l'augmentation de capital avec l'ensemble de ses modalités et conditions et qui la réalise sans que l'assemblée n'intervienne à aucun stade de l'opération* »[2].

Un des points remarquables (et dangereux pour les actionnaires existants) de l'institution du capital autorisé est la possibilité qui est donnée à l'assemblée d'autoriser l'organe de direction de procéder à la **limitation ou la suppression du droit préférentiel de souscription** en cas d'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé (v. art. 420-26 (5) L.S.C.).

Si le droit préférentiel de souscription est un droit fondamental de l'associé et s'il est d'ordre public, la loi prévoit elle-même une entorse à ce principe, et ceci, dans la notion de capital autorisé.

a) Limitation du DPS

En application du paragraphe 5 de l'article 420-26 L.S.C., les statuts « […] *peuvent néanmoins autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à supprimer ou à limiter ce droit lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à l'article 420-22* ». Cette autorisation ne peut avoir une durée supérieure à 5 ans. Mais elle peut être renouvelée successivement.

Le fait qu'une telle autorisation d'augmenter le capital social est donnée ne signifie pas que les augmentations futures du capital soient nécessairement faites par le

1 – *Doc. parl.*, n° 5730, Commentaire des articles ad 20), ID 10080.

2 – A. Vandeplas et J.P. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, Swinnen, Bruxelles, 1985, p. 52.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conseil d'administration. En d'autres termes, nonobstant cette autorisation donnée au conseil d'administration, l'assemblée peut procéder à des augmentations de capital « *classiques* ». Si l'assemblée générale procède ainsi à des augmentations de capital, celles-ci ne réduisent pas à due concurrence l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital social.

La possibilité d'avoir un tel capital autorisé est donc une option relativement dangereuse pour les actionnaires : une émission de nouvelles actions est offerte à des actionnaires extérieurs à la société, avec pour conséquence possible de conduire à des bouleversements de majorité, de sorte que les actionnaires qui soit individuellement soit collectivement avaient la majorité des deux tiers (permettant donc de dominer non seulement dans les assemblées générales ordinaires, mais encore dans les assemblées générales extraordinaires, celles donc permettant de modifier les statuts de la société et qui sont donc ainsi les maîtres absolus de la société) se voient du jour au lendemain écartés de cette position au profit soit de nouveaux arrivants soit encore d'actionnaires existants qui souscrivent à l'augmentation de capital.

De même, les actionnaires minoritaires qui, le cas échéant, pouvaient faire état d'une **minorité de blocage** (soit donc plus d'un tiers des titres ayant droit de vote) en jouant ainsi un rôle stratégiquement important dans la société peuvent voir leur participation diminuer à 25 ou 20 % et devenir ainsi, dans le vrai sens du terme, « *quantité négligeable* ».

Des **intérêts purement fiscaux** peuvent encore être en jeu : un associé dans la forme d'une société de capitaux détenant 10 % au moins des titres d'une société anonyme peut se voir passer en dessous de cette limite fatidique, avec donc comme conséquence de ne plus bénéficier du privilège des sociétés mères et filiales garantissant l'exonération des revenus de la participation (dividendes et plus-values en capital).

Si, malgré ces inconvénients, le législateur s'est néanmoins prononcé en faveur de l'introduction du capital autorisé, il faut supposer que la raison en est que, nonobstant ces inconvénients, la possibilité d'avoir un tel capital peut être dans **l'intérêt de la société**. Compte tenu de ces enjeux de divers ordres, certaines limites et formalités destinées surtout à protéger les intérêts des actionnaires existants de la société ont été introduites.

b) Formalités du capital autorisé

Afin d'attirer l'attention des actionnaires sur l'importance de la question, il est spécifiquement prévu que l'assemblée appelée à délibérer aux conditions requises pour la modification des statuts soit sur l'augmentation du capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 420-22 (1), peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser le conseil à le faire. La proposition doit être « *spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission proposé et présenté à l'assemblée*[1] ».

La loi belge pour sa part, et contrairement à la directive, exige que toute dérogation soit justifiée par l'intérêt social[2].

1 – V. art. 420-26 (5) L.S.C.

2 – A. VANDEPLAS et J.P. SPREUTELS, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 85.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le texte de la directive exige que l'organe de direction établisse « *un rapport écrit indiquant les raisons de limiter ou de supprimer le droit préférentiel et justifiant le prix d'émission proposé* ».

La directive n'exige donc pas que le prix d'émission soit fixé à un certain niveau, en prévoyant notamment une prime d'émission destinée à éviter la spoliation des anciens actionnaires : il est satisfait aux exigences légales quand le prix d'émission est justifié, à suffisance, par le rapport du conseil d'administration. Les auteurs de la directive considèrent sans doute que, dûment informés, les actionnaires seront à même de veiller à leurs intérêts pour le cas échéant, ne pas donner leur accord lorsque le prix d'émission des actions nouvelles est fixé à un niveau peu élevé.

Ce rapport n'est pas exigé seulement à l'occasion de l'introduction du capital autorisé dans les statuts, mais s'applique à chaque *renouvellement* de l'autorisation de procéder au moyen d'un capital autorisé[1].

Ces diverses décisions du juge des référés, dont le commentaire détaillé dépasserait l'importance pratique de la question, soulèvent quelques questions qui actuellement sont à considérer comme non clarifiées. Il s'agit d'abord de la question du **contenu de ce rapport** : les décisions de référé critiquent l'absence de caractère suffisamment précis et circonstancié d'un rapport préparé lors de l'adoption d'un capital autorisé. En deuxième lieu, il s'agit de la question de savoir si une assemblée d'actionnaires peut de façon unanime renoncer au DPS. Sur cette question, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait retenu que, du fait de la renonciation unanime des actionnaires à leur DPS, l'article 32-3, paragraphe 5 L.S.C. ne trouvait pas application.

La Cour d'appel, dans son arrêt du 26 février 2002, avait retenu une position opposée en arrêtant « *qu'en cas de renonciation collective des actionnaires lors de l'entrée en société d'un nouveau partenaire ou de l'accroissement de la participation d'un des actionnaires, le formalisme prévu à l'article 32-3 (5) précité est d'application. Comme il est acquis en cause que l'augmentation de capital en question est intervenue sans présentation d'un rapport établi par le conseil d'administration, c'est à raison que le premier juge a suspendu les effets de cette augmentation de capital* ».

À notre sens, c'est la position de la cour qu'il faut retenir.

« *(6) Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel au sens du paragraphe (4) lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes (1) et (3)* ».

L'hypothèse est celle où des institutions financières prennent ferme les émissions d'actions résultant d'une augmentation de capital : les droits des actionnaires d'obtenir satisfaction de leur DPS à titre irréductible est sauvegardé. En revanche, les titres non souscrits seront offerts au public. Le preneur ferme doit avoir le statut de banque (ou autre établissement financier). La règle ne s'appliquera donc pas à l'actionnaire principal même s'il s'engageait à offrir les titres aux autres actionnaires proportionnellement aux actions détenues[2].

1 – Référés n°s 639/2000 du 8 décembre 2000 et 5/2001 du 5 janvier 2001, ID 10266 ; TA Lux., 28 juin 2002, n°s 49.978 et 50.935, ID 10388 ; CA (référé) du 26 février 2002, n° 25.779, ID 10413.

2 – A. Vandeplas et J.P. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 92.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La question des formalités auxquelles le capital autorisé est soumis est directement liée à la question de la nature de l'augmentation du capital. Concrètement, la question est de savoir quelles formes cette augmentation de capital peut prendre : apport en espèces, apport en nature et, le cas échéant, augmentation par incorporation de réserves ? La loi luxembourgeoise (pas plus que la directive en son article 25.2) ne donne le moindre indice sur l'étendue exacte de ces dispositions.

Le premier projet belge admettait uniquement les apports en espèces pour la raison que la procédure de vérification des apports en nature aurait fait perdre à la technique du capital autorisé ses avantages de rapidité et de souplesse. Par la suite, le projet a été élargi pour permettre également les apports en nature et même les augmentations de capital par incorporation de réserves[1].

La Commission spéciale de la Chambre a maintenu les apports en nature, mais exclu l'incorporation de réserves, au moyen des justifications suivantes :

– la technique du capital autorisé est destinée à permettre au conseil d'administration (directoire) « *de réagir promptement face à l'évolution du marché des capitaux et d'ainsi attirer des capitaux extérieurs* », ce qui n'est en rien le cas pour l'incorporation de réserves ;

– l'incorporation de réserves au capital relève de l'affectation des bénéfices, c.-à-d. de la compétence exclusive de l'assemblée générale[2].

Finalement, cette incorporation des réserves a néanmoins été retenue en raison d'un amendement au projet de loi[3].

c) Motivation du capital autorisé

Le conseil d'administration doit **justifier la dérogation au DPS** et, à cette fin, il ne peut pas « *se limiter à des généralités peu significatives* »[4].

L'institution du capital autorisé a donné lieu à un important contentieux en Belgique à l'occasion de l'OPA lancée sur la Société Générale de Belgique en 1988. Dans cette affaire, le juge des référés avait estimé que « *la procédure du capital autorisé a pour objet essentiel de permettre au conseil d'administration de réagir promptement face à l'évolution du marché des capitaux et d'attirer des capitaux extérieurs* »[5]. Il s'agissait d'apprécier si la décision du conseil d'administration d'augmenter le capital, hors droit de préférence, dans le seul but de diluer le droit de vote d'un actionnaire minoritaire qui tentait de prendre le contrôle de la société était conforme à l'intérêt social[6].

Cette approche a été jugée trop étroite par la cour d'appel qui devait retenir que c'est en fonction de l'**intérêt social** qu'il appartient au conseil d'administration de prendre la décision qu'il estime opportune, et celle-ci ne peut être sanctionnée par les juridictions que si « *aux termes de l'appréciation marginale à laquelle il doit se limiter, le juge estime que la décision critiquée est entachée de faute ou d'abus,*

1 – A. Vandeplas et J.P. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 55.

2 – A. Vandeplas et J.P. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 56.

3 – *Doc. parl.*, Sén., 1982-1983, n° 390/2, pp. 16 à 18.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 664.

5 – Ordonnance du Président du Tribunal de Bruxelles du 9 février 1988.

6 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.*, 1991, p. 232.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conformément aux principes qui gouvernent la responsabilité des administrateurs ou la théorie de l'abus de majorité »[1].

Qu'est-ce qu'on entend par **appréciation marginale** ? Cette conception part du constat qu'il est relativement facile pour un juge appelé à apprécier le comportement d'un dirigeant d'entreprise d'indiquer quelle aurait été la bonne attitude : « *[…] il dispose d'informations dont ne disposaient pas les gestionnaires au moment où ils ont agi et, notamment, il connaît la suite des événements […] ; il dispose aussi du temps dont souvent ne disposaient pas les gestionnaires pour réfléchir au problème à tête reposée. D'où la notion d'appréciation marginale grâce à laquelle on invite le juge à ne retenir que la faute ou l'abus manifestes, flagrants* »[2].

Dans l'application de ce concept, le juge est appelé à identifier d'abord les diverses solutions alternatives qui auraient pu être prises à la place de celle qui a été adoptée par le dirigeant concerné. Le juge devra ensuite se demander si les différentes solutions se trouvaient à l'intérieur d'une marge où elles devaient apparaître comme étant de qualité similaire et, en tout cas, pas nettement différente.

Si les solutions étaient à l'intérieur de la marge, il n'y a pas faute ou abus. Si, au contraire, les solutions alternatives possibles étaient franchement différentes, la solution choisie devant apparaître déjà au moment de la prise de décision comme moins bonne que d'autres, alors cette solution est en dehors de la marge d'erreur ou d'appréciation, avec donc la conséquence qu'un dirigeant raisonnable aurait pu se rendre compte qu'elle était une mauvaise solution. Dans ce cas, il y a faute ou abus[2].

En vertu de cette théorie, le tribunal n'a qu'un pouvoir d'appréciation limité. Il n'est pas une instance d'appel des décisions des organes sociaux. Ne sont sanctionnés que les comportements **manifestement injustifiés**[3].

Est critiquable la décision du Tribunal de Charleroi condamnant le recours par la société au financement par **factoring** en raison de son coût excessif. En effet, le conseil d'administration, en choisissant le financement par factoring, a finalement utilisé un moyen de financement généralement reconnu, et ceci, en choisissant parmi différents moyens de crédit[3].

d) Le droit de priorité aux actionnaires anciens

Cette possibilité a été introduite par l'article 420-26 [anc. art. 32-3] (8) L.S.C.[4]. Ce droit de priorité ne concerne que les titres de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la cote officielle d'une bourse de valeur ou négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier. « *Il est proposé d'introduire, à l'instar du droit belge, le principe d'un droit de priorité en cas d'augmentation de capital hors droit de préférence sans toutefois limiter expressément dans le temps la période de souscription […]. Le présent projet retient cette possibilité de créer un droit de priorité dans une société de droit luxembourgeois, estimant qu'il s'agit là d'une faculté qui*

1 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 658.

2 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 209.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 384.

4 – *Doc. parl.*, n° 5730/00, Commentaire des articles, Ad 20) Article 32-3, paragraphe 8, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

pourrait s'avérer utile même si, à l'heure actuelle, la nécessité pratique d'un tel droit ne se pose pas dans les mêmes termes qu'en droit belge (le droit luxembourgeois ne formulant pas une règle équivalente à l'art. 594 Code belge des sociétés) ». Le cas visé ici est celui où, lors d'une augmentation de capital d'une S.A., il reste (après l'expiration de la période de souscription préférentielle) une partie du capital qui n'est pas encore souscrite.

Pour ce cas, le paragraphe 8 de l'article 420-26 L.S.C. prévoit que, si à la fin de la période de souscription préférentielle prévue par le paragraphe 3 (délai qui ne peut être inférieur à 14 jours), toutes les actions ne sont pas souscrites (sauf disposition contraire des statuts), alors les tiers peuvent participer à l'augmentation de capital, sauf si le conseil d'administration (directoire) décide que les droits de préférence seront exercés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions par les actionnaires anciens qui avaient exercé leurs droits lors de la période de souscription préférentielle.

C – Opérations sur les actions

Ces opérations sont de natures fort diverses et peuvent soit concerner des transformations de la nature des titres, soit porter uniquement sur un changement de propriété.

1) Cessions et autres transmissions

Art. 430-3 [anc. art. 39] L.S.C.

« *II est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance ; ce registre contient :*

1° la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions ou coupures ;

2° l'indication des versements effectués ;

***3° les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés, si les statuts l'autorisent* ».**

La cession de l'action nominative s'effectue au moyen d'une déclaration de transfert inscrite sur le registre des actionnaires. Cette déclaration de transfert comporte trois éléments : la date, la signature du cédant et celle du cessionnaire ou encore celles de leurs fondés de pouvoir respectifs[1].

L'expression selon laquelle le transfert se fait par la déclaration de transfert est à prendre avec une certaine précaution : en effet, la cession de l'action comme toute vente se fait par le consentement des parties. Afin de rendre cette cession opposable aux tiers, certaines formalités sont à respecter[2].

La cession de droits sociaux peut être annulée pour dol si elle a été conclue sur la foi d'écritures comptables inexactes majorant le chiffre d'affaires ou l'actif de la société.

« *La lésion vicie le contrat lorsqu'elle résulte d'une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise par une des parties*

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 98, ID 11308.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 99, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

et la contrepartie de l'autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation d'une position de force en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience de l'autre partie »[1].

La loi (art. 430-4 L.S.C. dernier alinéa) prévoit encore une disposition spéciale pour le cas de transmission d'actions par décès de son détenteur. Il est ainsi permis à la société d'admettre le transfert sans responsabilité pour elle en cas d'erreur. Pour effectuer la transmission, il suffit d'un acte de décès de l'actionnaire, du certificat d'inscription remis antérieurement par la société à cet actionnaire et d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix ou par un notaire du domicile du défunt. En cas de fraude les véritables héritiers devraient agir contre l'usurpateur[2].

a) Actions au porteur

L'ancien article 42 L.S.C. était libellé comme suit : « *La cession de l'action au porteur s'opère par la seule tradition du titre* ». Cette disposition, reprise de l'article 2279 C.c., a été étendue aux titres au porteur qui se transmettaient par simple tradition manuelle. En vertu de la portée de cette règle, une veuve ayant la possession de titres au porteur n'a pas à prouver à l'égard de la succession l'origine de ces meubles, sa seule possession valant titre[3].

b) Cession d'actions avant la constitution

L'ancien article 43 L.S.C. était libellé comme suit : « *Les cessions d'actions ne sont valables qu'après la constitution définitive de la société et le versement du quart du montant des actions.*

Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération […] ».

La loi, en interdisant la cession d'actions avant la constitution de la société, dérogeait ainsi au droit commun dans la mesure où le Code civil permet la vente de choses futures (art. 1130 C.c.) : « *Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation* ». Selon ce principe, la cession des actions d'une société non encore constituée devait être considérée comme valable.

La L.S.C. (avant 2016) prévoyait un certain nombre de mesures ayant pour objet d'éviter un marché sur les actions de sociétés avant que celles-ci ne soient constituées. Ces mesures étaient destinées à freiner la spéculation en interdisant la cession de titres avant que la société ne soit constituée.

L'attitude restrictive L.S.C. de la version avant 2016 s'expliquait par la volonté de prévenir l'**agiotage**, soit donc la spéculation sans borne portant sur les titres de sociétés dont la valeur réelle ne peut pas encore être établie avec la moindre fiabilité[4]. « *On évite par là des reventes à primes de valeurs problématiques ; le législateur ne peut admettre que des négociations sérieuses sur des valeurs négociables* »[5].

1 – TA Lux. du 15 février 2008, jugement civil n° 44/08, n° 103.193, ID 15891.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 101, ID 11308.

3 – Civ. 1re, 11 juin 1991 *Bull. civ.*, I, n° 199.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 105, ID 11308.

5 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 168, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette nullité est absolue, car elle repose sur des motifs d'ordre public. Elle existe tant entre parties qu'à l'égard de la société[1].

Étaient ainsi frappées de **nullité** les cessions faites avant la constitution de la société, même celles qui seraient faites sous la condition suspensive de la constitution ultérieure de la société. Cette nullité (analogue à celle introduite par le Code civil à l'égard des **pactes sur successions futures**), **d'ordre public,** pouvait donc être invoquée par tous les intéressés, y compris les parties elles-mêmes (nullité absolue)[2].

Cette disposition ne faisait toutefois pas obstacle aux arrangements entre futurs actionnaires relativement à la constitution projetée, notamment concernant la répartition des actions entre eux. Ce point a été expressément reconnu au cours des discussions de la loi belge.

Le système retenu par la loi était donc le suivant : tant que la société n'est pas constituée, toute cession d'actions est nulle. Une fois la société constituée et la libération du quart effectuée, la cession est valable. Tant que les titres ne sont pas intégralement libérés, ils sont nominatifs.

Ledit article 43, alinéa 1, L.S.C. ancien qui interdisait les cessions d'actions avant la constitution définitive de la société fut supprimé par la Loi de Modernisation. Le commentaire des articles a justifié cette suppression comme suit : « *Le droit belge comportait par le passé une disposition identique à celle de l'article 43, alinéa 1er, laquelle a été abrogée voici quelques années (loi du 13 avril 1995) dans la mesure où sa* ratio legis*, à savoir la prévention de l'agiotage, se trouve aujourd'hui rencontrée par la surveillance désormais assurée du secteur financier en ce qui concerne les émissions publiques. Cette observation valant incontestablement également pour le droit luxembourgeois, il n'existe donc aucune raison de maintenir une disposition faisant obstacle à la cession d'actions futures. Par l'effet de cette abrogation, le droit commun gouvernant la vente de choses futures (à savoir l'art. 1130 du Code civil) trouvera également à s'appliquer ici* ».

Cette vision optimiste des choses n'est pas partagée par tout le monde. L'argumentation citée du commentaire des articles peut tout au plus concerner les émissions publiques (v. ci-dessus), alors que l'article 43 L.S.C. ancien visait toutes les sociétés anonymes. À supposer même que les émissions publiques soient à considérer comme suffisamment surveillées pour permettre l'abolition de l'article 43 L.S.C., quel est alors l'argument à l'égard des émissions privées (c.-à-d. de presque toutes) ? La réponse est qu'il n'y en a aucun, en tout cas s'il existe, il n'est pas exprimé par le projet de loi n° 5730.

En outre, il convient de noter que la « surveillance du secteur financier » n'a empêché ni la faillite de la banque Lehmann ni l'affaire *Madoff*, événements qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années et non pas dans les bas-fonds de l'Histoire. Finalement, la disposition discutée ici concerne les sociétés non encore formées, sociétés qui ne sont jamais dans le collimateur des autorités de surveillance du secteur financier.

Ce cas de l'abolition de l'article 43 L.S.C. fait partie des nombreux cas critiqués non seulement par le Conseil d'État, mais également par d'autres institutions ayant avisé le projet de loi n° 5730, à savoir que les modifications proposées sont souvent

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 168, ID 11305.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 105, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

insuffisamment motivées ou encore que ces modifications sont justifiées par de simples renvois à une législation étrangère (en fait très souvent à la législation belge).

Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle aux arrangements entre futurs actionnaires relativement à la constitution projetée, notamment concernant la répartition des actions entre eux. Ce point a été expressément reconnu au cours des discussions de la loi belge.

Selon une théorie classique, la garantie contre les **vices cachés** établie par les articles 1641 et suivants du Code civil n'est pas applicable en matière de cession de parts sociales, celle-ci n'étant pas assimilable à une vente de biens corporels, mais à une cession de créance.

Or, en matière de cession de créance, le cédant est seulement tenu de garantir l'existence de la créance suivant l'article 1693 du Code civil aux termes duquel « *celui qui vend une créance ou un autre droit corporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie* ».

« *Selon une théorie moderne, le cédant doit garantir le cessionnaire contre les vices cachés affectant les parts sociales. Cependant l'objet de la vente étant constitué par les parts sociales elles-mêmes et non par la quote-part qu'elles représentent dans les éléments constitutifs du patrimoine de la société elle-même et plus particulièrement sur les droits qu'elles confèrent. Seul le vice occulte empêchant ou restreignant l'usage des titres vendus est susceptible d'être garanti. Il en est ainsi du vice occulte empêchant le cessionnaire de prendre part au fonctionnement interne de la société, de recevoir une part des bénéfices sociaux éventuels, ou encore de participer au partage de l'avoir social* »[(1)].

Cette situation de droit n'empêche pas que les parties au contrat de vente conviennent de garanties portant en particulier sur le caractère complet des comptes annuels établis avant la cession des titres. La Cour d'appel de Bruxelles a retenu que de telles garanties ne sont pas exorbitantes du droit commun et en les donnant, les vendeurs « […] *ne font qu'assumer expressément une obligation incombant de droit à tout vendeur, celle de délivrer une chose conforme à la chose vendue* »[(2)]. En argumentant ainsi, la cour devait rejeter la thèse du vendeur qui prétendait qu'en matière de vente d'actions il est de jurisprudence et de doctrine qu'il n'est point dû de garantie de la valeur des actions, car « *une moins-value de l'action n'est pas un vice qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue celui-ci* ».

L'inscription au registre des actions nominatives constitue un moyen de preuve de la propriété (art. 430-4, anc. art. 40 L.S.C.). Il ne s'agit cependant **pas** d'une **présomption irréfragable** et l'inscription n'est pas à considérer en elle-même comme titre de propriété.

Lorsque la société a inscrit sur son registre la mention qu'une personne est actionnaire, celle-ci peut s'en prévaloir, et l'inscription fait preuve contre la société. Ce serait à cette dernière d'établir que l'inscription a été faite par erreur ou à la suite de manœuvres dolosives (cf. C. Resteau, *Traité des sociétés anonymes*, n° 626)[(3)].

1 – TA Lux. du 11 mars 1994, n°s 40.279 et 40.845. Trib. réf. Lux du 28 juin 2002, n° 552/2002, *BIJ*, 2003, p. 26.

2 – CA Bruxelles, 5 juin 1980, *J.T.*, 1981, p. 140.

3 – CA du 30 octobre 2002, n° 25762, *BIJ*, 2003, p. 26.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le système retenu par la loi est donc le suivant : tant que la société n'est pas constituée, toute cession d'actions est nulle. Une fois la société constituée et la libération du quart effectuée, la cession est valable. Tant que les titres ne sont pas intégralement libérés, ils sont nominatifs ; la transmission par simple tradition manuelle est donc exclue[1].

Comme toujours, il sera parfaitement possible de se montrer plus sévère que le législateur, et ceci notamment en prohibant les actions au porteur, de n'autoriser la cession des actions nominatives qu'à partir d'une certaine date après la constitution de la société, ou encore de l'autoriser uniquement « […] *moyennant l'assentiment du conseil d'administration ou qu'à des cessionnaires agréés par lui* »[2].

La disposition selon laquelle les actions sont **nominatives jusqu'à leur entière libération** est prise essentiellement dans l'intérêt des tiers. En effet, ceux-ci sont en droit de compter sur l'existence effective du capital social. Si les titres non encore entièrement libérés pouvaient être au porteur, il y aurait en fait dispense accordée aux actionnaires de faire les versements, surtout au cas où la santé financière de la société serait mauvaise.

« *Quel est en effet le porteur qui ne préférerait détruire ses actions plutôt que de faire les versements pour conserver un titre désormais sans valeur ? Lorsque le capital social comprend l'intégralité de la somme à verser sur les actions, il est un mensonge, si les actions ne demeurent nominatives jusqu'à leur entière libération* »[2]. Dans une telle situation où la société est déficitaire, ceci reviendrait à la création de **titres de dettes au porteur**, solution qui ne peut fonctionner en pratique.

2) Conversion

On peut parler de « conversion » dans deux cas différents : il y a soit conversion d'actions nominatives en actions au porteur, soit conversion d'un titre de dette en titre de capital (conversion d'obligations), ou, plus rarement (le cas inverse), conversion de titres de capital en titre de dette.

Quant à la conversion de titres nominatifs en titres au porteur (ou vice versa), la situation est la suivante : « *Les propriétaires d'actions ou de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs […].*

À moins d'une défense formelle exprimée dans les statuts, les propriétaires d'actions ou de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en actions ou titres au porteur[…] » (art. 430-8 L.S.C.).

Quant à la conversion des obligations convertibles en actions, il y a lieu de noter que c'est cette conversion qui, en soi, donne lieu à l'augmentation du capital de la société. On pourrait donc être porté à croire que cette opération est soumise à un droit préférentiel de souscription, ainsi qu'à l'intervention du réviseur d'entreprises : il n'en est rien en réalité, et la loi accorde un DPS aux actionnaires, mais qui concerne non pas la souscription des actions, mais la souscription d'obligations convertibles.

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 107, ID 11308.

2 – E. Pirmez, Commentaire législatif de la loi de 1873, II, n° 46, cité par Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 162, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 420-27 [anc. art. 32-4] L.S.C. :

« *Les articles 420-22, 420-23 à l'exception de son paragraphe 6 et 420-26 sont applicables à l'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre. L'article 420-23, paragraphe 6, est toutefois applicable à l'émission d'obligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital lorsque le prix de souscription de tels instruments est libéré en nature.*

L'article 420-25 est applicable à la conversion d'obligations convertibles et de tous autres instruments de créance convertibles en capital ainsi qu'à l'exercice de droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre. Les articles 420-22, 420-23 et 420-26 ne sont pas applicables dans les cas visés au présent alinéa.

La conversion d'obligations convertibles est à considérer comme un apport en numéraire libérable par compensation avec une créance sur la société et sera soumise aux mêmes conditions qu'un tel apport. [...] »

3) OPA/OPE

L'offre publique d'achat est l'opération par laquelle une personne (ou un groupe) déclare publiquement vouloir acquérir les titres d'une société à un prix déterminé. **L'offre publique d'échange** (OPE) n'est qu'une variante de cette opération dans la mesure où, dans cette opération, la contrepartie offerte ne consiste pas en monnaie, mais en titres (en fait en actions d'une des sociétés du groupe qui est à l'origine de l'offre).

Afin de garantir les droits des actionnaires d'une société qui a fait l'objet d'un changement de contrôle, celui qui a repris le contrôle est obligé de faire une telle offre d'achat en permettant ainsi aux actionnaires minoritaires de sortir d'une telle société qui n'est plus à leur goût, et ceci, sans être financièrement spoliés.

La base juridique de ces mesures protectrices réside dans la « *directive du parlement européen et du Conseil européen du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition* », directive prise encore sur la base de l'article 44, § 2, point g).

La protection des intérêts minoritaires est organisée « *en imposant à l'acquéreur qui a pris le contrôle d'une société l'obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres de cette société d'acquérir la totalité de leurs participations à un prix équitable, conformément à une définition commune* »[(1)].

La directive visée a fait l'objet d'un projet de loi daté du 16 février 2006 (*Doc. parl.*, n° 5540, adopté par la loi du 19 mai 2006) qui a fixé le pourcentage de contrôle à un tiers des droits de vote de la société. C'est donc au moment où l'acquéreur atteint ou dépasse ce seuil qu'il est tenu de faire une offre à tous les actionnaires de leur racheter la totalité de leurs actions de la société, et ceci, à un prix « équitable ».

Ce prix est encadré par les dispositions de la directive (article 5, paragraphe 4) reprises au même article du projet de loi.

Le prix équitable est le **prix le plus élevé** payé pour les mêmes titres par l'offrant ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période de 12 mois (entre 6 et 12 mois selon la directive) précédant l'offre.

1 – Point 9 du préambule de la directive 2004/25/CE.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le prix offert peut consister en espèces, mais également en titres et, finalement, en une combinaison des deux (art. 5, § 5, du projet de loi).

Toutefois, lorsque les titres offerts ne sont pas cotés sur un marché réglementé, alors la contrepartie doit porter à titre d'option sur des espèces.

La décision de faire une offre doit être rendue publique immédiatement après la prise de décision par l'offrant, et la CSSF doit être informée avant que cette offre soit rendue publique.

4) Exclusion, rachat et retrait

Le projet de loi n° 5730 dans sa version initiale avait envisagé d'introduire (dans les articles 98*bis* à 98*quinquies*) un régime généralisé pour les exclusions d'actionnaires des S.A. avec la motivation suivante dans le commentaire des articles : « *Il est tout d'abord proposé d'introduire un régime général d'exclusion ou de rachat pour juste motif dans toutes les S.A. (s'écartant en cela du droit belge où l'exclusion et le retrait ne sont disponibles que dans les S.A. "privées" au sens de ce droit) inspiré du droit belge en la matière (art. 635 et suiv. du Code belge des sociétés) reconnaissant la validité des clauses contractuelles en la matière. Il a d'autre part été décidé d'introduire le* « ***squeeze-out*** » ***(retrait obligatoire) et le*** « ***sell out*** » ***(rachat obligatoire****) à 95 % du capital assorti du droit de vote et 95 % des droits de vote. Le modèle adopté est inspiré du texte belge formulé pour les sociétés faisant appel public à l'épargne en le limitant aux sociétés anonymes dont les titres assortis d'un droit de vote sont cotés ou l'ont été dans le passé et ne le sont plus et du texte prévu dans la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition. Cette limitation est justifiée par le fait que les situations que l'on entendait viser sont aussi bien les situations qui sont nées à l'occasion d'une cotation ou au moment où une société s'est retirée de la cote. Le retrait obligatoire permettra notamment à des sociétés qui ont cessé de faire coter leur titre après une opération d'offre publique d'échange de titre au terme de laquelle un actionnaire a acquis la quasi-totalité des titres de racheter le résidu de titres. Inversement, le retrait obligatoire permet aux actionnaires d'une société très largement dominée par un actionnaire de sortir de cette société alors qu'il se peut qu'il soit devenu difficile de céder ces titres puisqu'il n'y a plus de cotation ou que le marché est devenu illiquide* ».

Suivant amendements de la commission juridique de la Chambre des députés, les deux articles 98*bis* et 98*ter* du projet gouvernemental ont été supprimés. Quant aux articles 98*quater* et 98*quinquies* qui visaient le retrait obligatoire et le rachat obligatoire, ils ont fait l'objet d'un autre projet de loi plus récent, à savoir celui du n° 5978 qui a conduit à la loi du 21 juillet 2012 « *relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet d'une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998* ».

L'exposé des motifs du projet de loi n° 5978 (p. 3) précise encore que : « *Il a cependant été également constaté que ces dispositions ne trouvent pas non plus leur vraie place dans la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les*

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

offres publiques d'acquisition puisque le droit de retrait obligatoire et le droit de rachat obligatoire ne sont pas liés à l'acquisition d'un contrôle donnant lieu à une offre publique d'acquisition à laquelle il est loisible à tout actionnaire de souscrire ou non, mais à une situation de fait, quelle que soit son origine, suivant laquelle un actionnaire vient à détenir, directement ou indirectement, la quasi-totalité des titres d'une société ».

Ladite loi du 21 juillet 2012 a introduit pour les actionnaires d'une société anonyme dans une situation de forte domination de l'actionnariat par un actionnaire « majoritaire » (c.-à-d., en simplifiant, ayant au moins 95 % des actions avec droit de vote[1]) la possibilité de sortir de cette situation en permettant donc à l'actionnaire majoritaire de racheter toutes les actions des actionnaires très minoritaires (**retrait obligatoire**) soit aux minoritaires d'offrir individuellement leurs titres à (aux) l'actionnaire(s) majoritaire(s) (**rachat obligatoire**).

Comme expliqué par l'exposé des motifs du projet de loi n° 5978, p. 2 : « *Il* [le projet de loi] *répond ainsi à la motion du 4 mai 2006 de la Chambre des Députés invitant le Gouvernement à prévoir un dispositif permettant aux actionnaires largement minoritaires d'une société à la suite de changements importants intervenus dans la structure du capital de sortir du capital de ladite société moyennant rachat de leurs titres par le ou les actionnaires majoritaires à un prix équitable.*

Inversement, il permet également à l'actionnaire largement majoritaire d'une société d'acquérir, toujours à un prix équitable, le reste des titres dans l'hypothèse où les titres ont cessé d'être cotés ou doivent cesser de l'être ».

Retrait obligatoire (art. 4 (1) de la loi du 21 juillet 2012)

« *Lorsqu'un détenteur de titres d'une société visée par la présente loi est ou devient actionnaire majoritaire au sens de la présente loi, il peut exiger de tous les détenteurs de titres restants de lui vendre leurs titres à condition que l'information à la CSSF conformément au paragraphe 3 intervienne à une date à laquelle les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1er sont remplies. Un actionnaire majoritaire qui décide d'exercer son droit de retrait obligatoire doit s'assurer qu'il peut fournir entièrement la contrepartie en espèces* ».

Rachat obligatoire (art. 5 (2) et (3) de la loi du 21 juillet 2012)

« (2) *Un détenteur de titres qui décide d'exercer son droit au rachat obligatoire doit en informer l'actionnaire majoritaire par lettre recommandée. Une copie de la lettre devra être adressée à la CSSF et à la société concernée.*

L'information transmise doit reprendre les éléments suivants : a) l'identité et les coordonnées de contact du détenteur de titres qui exerce le droit au rachat obligatoire ; et b) la preuve de la qualité de détenteur de titres, le nombre de titres détenus, ainsi que la catégorie de titres à laquelle ces titres appartiennent.

(3) Le *rachat obligatoire doit être exercé à un juste prix sur base de méthodes objectives et adéquates* ».

Le prix accepté comme juste prix par la CSSF est valablement publié sur son site internet.

---

1 – La loi définit cette notion comme suit : « *actionnaire majoritaire : toute personne physique ou morale, qui détient, seule ou ensemble avec des personnes agissant de concert avec elle, directement ou indirectement, des titres lui conférant au* ***moins 95 pour cent du capital assorti de droits de vote et 95 pour cent des droits de vote d'une société*** ».

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

D – Rachat de ses propres actions

« *Le rachat par une société de ses propres actions est une opération dangereuse à de multiples points de vue. Elle permet d'affecter des fonds sociaux à des fins en réalité étrangères à l'objet social ; elle peut porter atteinte au capital social ; elle fait courir des risques aux actionnaires dans la mesure où ils ne peuvent tous participer également à l'opération. Elle permet au conseil d'administration de renforcer sa position dans la société et cela à l'aide de fonds sociaux* ».

Le rachat de ses propres actions étant une des opérations susceptibles de mettre en péril le maintien du capital social des sociétés de capitaux, il n'est pas surprenant que[1] la Deuxième directive se soit consacrée à cette matière dans le sens d'éviter que le capital social ne puisse être entamé en raison de ces opérations. À ce titre, une réglementation complète a été mise en place dans la directive d'abord et dans la L.S.C. ensuite.

Un deuxième inconvénient de cette technique est de conduire à un **verrouillage de la société** dans la mesure où cette acquisition perturbe le fonctionnement normal de la société. En effet, dans la mesure où les titres sont possédés par la société il ne peut que difficilement y avoir un renversement de majorité : les dirigeants en place peuvent voter dans le sens de leurs intérêts à eux et ils sont en fait inamovibles dans la mesure où leurs propres titres d'associés, augmentés des actions possédées par la société, comptent pour la majorité du capital social.

La pratique du rachat des actions propres est souvent critiquée en doctrine où il est reproché que celle-ci est souvent suivie non pas dans l'intérêt de la société, mais dans celui d'un actionnaire ou d'un groupe d'actionnaires. Le **principe d'égalité** des actionnaires est donc enfreint, et ceci, d'autant plus que l'évaluation du prix d'achat est extrêmement difficile en pratique[2].

Les modifications portées par la Loi de Modernisation au régime du rachat des actions propres sont en substance de peu d'importance et ont trait uniquement à la question de l'égalité de traitement des actionnaires. « *Prenant acte de ce que la loi luxembourgeoise ne transpose pas explicitement le principe du traitement égal des actionnaires voulu par l'art. 42 de la seconde directive communautaire, il est décidé d'y remédier par l'ajout d'un 5°[4° dans la version définitive] en ce sens au (1) de l'art. 49-2 L. 10 août 1915 (portant les conditions générales sous-tendant le rachat d'actions propres). La disposition proposée s'inspire de l'art. 620 Code belge des sociétés […]* »[3].

Les acquisitions d'actions propres ne peuvent avoir pour effet que l'actif net ne devienne inférieur au montant du capital souscrit augmenté des réserves non distribuables. Article 49-2, (3) L.S.C. : « *En ce qui concerne la distribution d'actions rachetées en vue d'être rétrocédées au personnel, on notera tout d'abord que le texte actuel vise déjà la distribution à une partie seulement du personnel de sorte qu'il n'y pas lieu de modifier le texte sur ce point. Par ailleurs étant donné que l'art. 19, 2, de la seconde directive permet que l'on puisse se passer de l'intervention de l'assemblée générale pour l'acquisition d'actions en vue de la distribution au personnel d'une société liée à celle dont les actions sont concernées, il est décidé de compléter le texte de l'article 49-2, paragraphe*

1 – J. Van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 329.

2 – V. en ce sens I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, p. 279.

3 – *Doc. parl.*, n° 5730/00, Commentaire des articles, Ad 22) Article 37, p. 69, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

(3), pour y énoncer que les actions rachetées pourront être destinées au personnel d'une "société liée" à la société concernée. Quant à la notion de "société liée", le texte proposé se réfère à titre fonctionnel à l'article 309 L. 10 août 1915 […] »[1].

La loi du 10 juin 2009 sur les fusions transfrontalières a également amendé l'article 49-2 (nouv. art. 430-15) L.S.C., et ceci, sur deux points : d'abord la durée de la période pendant laquelle l'autorisation donnée par l'assemblée générale au conseil d'administration est valable a été étendue d'une période de 18 mois à une période de 5 ans. En deuxième lieu, la limite de 10 % du capital social que les rachats ne pouvaient pas dépasser n'est plus applicable (et ceci, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 77/91/CEE, tel que modifié par l'article 1, paragraphe 4, de la directive 2006/68). Désormais la seule limite est que les rachats ne peuvent avoir pour effet que l'actif net ne devienne inférieur au montant du capital souscrit augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (selon l'article 461-2 L.S.C.).

1) Possibilité de rachats d'actions propres

L'article 430-15 L.S.C. fait exception à l'interdiction de principe en précisant les conditions auxquelles la société agissant soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de cette société, peut acquérir ses propres actions.

L'autorisation d'acquérir doit être accordée par l'assemblée générale (à la majorité simple, faute d'indication contraire[2]) qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et notamment :

- le nombre maximum d'actions à acquérir ;
- la durée pour laquelle l'autorisation est accordée (qui ne peut excéder 5 ans) ; et
- en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs minimales et maximales ; cette condition n'est pas applicable si l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil d'administration, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.

  Cette condition n'est pas applicable non plus s'il s'agit d'actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette société en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci.

  La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions.
- les acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté des réserves non distribuables (elles doivent donc être faites a moyen de sommes susceptibles d'être distribuées) ;

1 – *Doc. parl.*, n° 5730/00, Commentaire des articles, Ad 26) Article 37, p. 69 ID 10080.

2 – En ce sens, I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, p. 282.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées ;
– le **rapport de gestion** annuel doit comporter certaines indications concernant le rachat de ses actions propres.

Conformément à la directive, la L.S.C. n'interdit non pas seulement les acquisitions d'actions propres effectuées par la **société elle-même** (ou « *par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société* »), mais encore les acquisitions qui sont faites par des sociétés visées par la Première directive dans lesquelles la société détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer une influence dominante. Les acquisitions faites par de telles filiales sont traitées comme des acquisitions d'actions propres faites par la société elle-même (art. 49*bis* L.S.C.).

Cette extension aux filiales atteint même celles qui sont établies dans les États tiers à condition d'avoir une forme comparable aux « sociétés de capitaux » visées par la Première directive.

Le régime des actions propres acquis en application des dispositions des articles 430-15 et 430-16 L.S.C. est spécifié par l'article 430-18 L.S.C. qui précise les points suivants :

– le **droit de vote** des actions propres est **suspendu**. La loi est muette quant aux droits patrimoniaux attachés à ces titres. J. Delvaux semble être d'avis que tous les droits attachés à ces titres seraient suspendus[1]. Cette conclusion ne nous semble pas s'imposer. En particulier, il nous paraît plus conforme au principe d'égalité des actionnaires que la société vende les DPS attachés aux actions propres détenues par elle que de les laisser périmer en faisant ainsi profiter les seuls actionnaires souscrivant les actions nouvelles (au détriment de ceux qui ne souscrivent pas aux actions nouvelles) ;
– si les titres sont comptabilisés à l'actif, une **réserve indisponible** de même montant doit être maintenue au passif du bilan. Le montant de cette réserve représente le montant des sommes susceptibles d'être distribuées dont la présence au bilan était une condition indispensable à l'acquisition des actions propres par la société (v. art. 430-15 L.S.C.).

2) Exception à la réglementation de l'article 430-15 L.S.C.

Le régime prévu par l'article 430-15 L.S.C. ne s'applique pas dans les cas des acquisitions suivantes retenus par l'article 430-16 L.S.C. :

«

(1) [...]

1° l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut dépasser cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Le conseil d'administration ou le directoire veillent à ce que, au

1 – J. Delvaux, p. 74, cité par I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français,* Études du Laboratoire de droit économique, p. 295.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

moment de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points 2° et 3° soient respectées ;

2° les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant indiqué à l'article 461-2, paragraphes 1er et 2 ; 3° l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées ;

3° [...]

4° l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires se trouvant dans la même situation sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés ; de même, les sociétés cotées peuvent acheter leurs propres actions en bourse, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires.

(2) Lorsque l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, la condition au paragraphe 1er, point 1°, n'est pas applicable. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.

(3) La condition au paragraphe 1er, point 1°, n'est pas applicable non plus s'il s'agit d'actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une société mère et une filiale dans les cas visés à l'article 1711-1.

La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions ».

Lorsque le rachat est autorisé, il se pose la question de savoir quelle est l'appréciation à apporter à cette opération. Traditionnellement, la doctrine belge considérait qu'il s'agissait d'une liquidation par la société des droits des actionnaires vendeurs impliquant l'annulation des titres avec ou sans réduction de capital[1]. Cette analyse ne fut pas partagée par la Cour de cassation belge qui arrêta que l'opération s'analysait en une vente dans le chef de l'acquéreur et dans le chef de la société[2].

À l'appui de sa décision, la cour argumenta que la société, acquéreur des titres, pourrait les garder dans son portefeuille et les revendre ensuite sans procéder à leur annulation[3].

Art. 430-17 L.S.C.

« *Les actions acquises en violation des dispositions des articles 430-15 et 430-16, paragraphe 1er, point 1°, doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur*

1 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 329.

2 – Cass. b. du 6 octobre 1959, *Pas.*, 1960, I, p. 161, *R.P.S.* 1960, p. 65.

3 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 330.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 430-16, paragraphe 3, s'applique ».

Art. 430-18 L.S.C.

« *(1) Dans les cas où l'acquisition d'actions propres est possible conformément aux articles 430-15 et 430-16 la détention de ces actions est soumise aux conditions suivantes :*

1° les droits de vote afférents aux actions détenues par la société sont suspendus. Les actions rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorum et majorité dans les assemblées.

Si le conseil d'administration décide de suspendre le droit aux dividendes des actions détenues par la société, les coupons de dividendes y restent attachés. Dans ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre de titres détenus et les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusqu'à la vente des actions, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant le bénéfice distribuable et le répartir entre les actions dont l'exercice des droits n'est pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits ;

Si la société détient des parts bénéficiaires rachetées, elle ne peut en exercer le droit de vote ;

Si la société détient des parts bénéficiaires ayant droit à des dividendes, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent ;

2° si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant.

(2) Lorsqu'une société a acquis ses propres actions conformément aux dispositions des articles 430-15 et 430-16, le rapport de gestion doit mentionner :

1° les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice ;

2° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent ;

3° en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions ;

4° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent ».

3) Limitations aux financements des acquisitions d'actions propres

a) Régime légal

Encore dénommée interdiction de l'assistance financière (*financial assistance*), cette interdiction est prévue par l'article 430-19 [anc. art. 49-6] L.S.C.

Les conditions introduites sur la base de la directive 2006/68/CE, reprises dans l'article 430-19, paragraphe 1er, sont les suivantes : « *1°. Ces opérations ont lieu sous la responsabilité de conseil d'administration ou le directoire à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés ci-dessus. La situation financière du tiers ou, dans le cas d'opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée.*

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

*2°. Le conseil d'administration ou le directoire soumet l'opération, pour accord préalable, à l'assemblée générale, qui statue aux conditions requises pour la modification des statuts. Le conseil d'administration ou le directoire remet à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle représente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est déposé au registre de commerce et des sociétés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V*bis *de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et fait l'objet d'une publication au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l'article 100-13, paragraphe 3.*

3°. L'aide financière totale accordée aux tiers n'a pas pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 461-2, paragraphes 1er et 2, compte tenu également de toute réduction de l'actif net que pourrait avoir entraînée l'acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l'article 430-15, paragraphe 1er. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière.

4°. Lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière d'une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l'article 430-15, paragraphe 1er ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix ».

Un accord préalable de l'assemblée des actionnaires est requis, cette assemblée « statuant aux conditions prévues pour les **modifications des statuts** ». Cette dernière exigence peut paraître difficilement compréhensible, étant donné que l'on ne voit pas en quoi la décision à prendre par l'assemblée pourrait conduire à une modification statutaire. Afin d'orienter le débat qui doit avoir lieu devant les actionnaires, le conseil d'administration (directoire) « *remet à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions* ». Ce rapport est déposé au registre de commerce et des sociétés conformément aux dispositions de la Loi de 2002 et publié au RESA.

La troisième condition posée par la L.S.C. est que la société doit inscrire au passif de son bilan une **réserve indisponible** correspondant à l'aide financière totale. L'aide financière totale ne peut avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant du capital souscrit augmenté des réserves non distribuables (art. 461-2 L.S.C.). Ceci signifie en clair que la société doit disposer de fonds propres disponibles (donc autres que le capital social et les réserves non distribuables) suffisants pour ne pas entamer les fonds propres indisponibles, même si les fonds utilisés pour l'assistance financière étaient entièrement perdus.

La dernière condition est que l'acquisition par le tiers des actions propres de la société doit être faite à un juste prix.

Selon cette disposition, une société anonyme « *ne peut directement ou indirectement avancer des fonds, accorder des prêts ou donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers* » que sous des conditions très restrictives mentionnées ci-dessus. Est assimilée à une telle acquisition de ses propres titres

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la **prise en gage** par la société de ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette société (art. 430-21 L.S.C.).

Il est donc interdit à la société de donner un prêt (avance) à une personne si ce prêt est destiné à acquérir les titres de la société prêteuse. Quelle est la **raison** de cette **interdiction** ? Les textes (et les auteurs) ne sont pas très bavards sur la *ratio* de cette disposition et on ne peut que spéculer sur les raisons objectives de cette interdiction de l'assistance financière. On peut penser que les prêts accordés pour financer les achats d'actions propres peuvent avoir les mêmes effets que le rachat d'actions proprement dit[1] : en effet, la valeur de la créance est étroitement liée à la valeur des titres de la société, de sorte que si, pour une raison ou une autre, la valeur des titres de la société « prend un coup », il y aura un contrecoup (potentiellement fatal) sous forme de perte de valeur d'un actif, ce qui est susceptible d'aggraver les difficultés de la société ; un **cercle vicieux** pourrait ainsi être déclenché. Cette conséquence est ainsi évitée par la réglementation légale visée. Les sociétés ne pourraient obtenir le remboursement de leurs prêts au moment où elles en auraient le plus besoin. Dans la réalité, un prêt fait par la société sur ses actions serait un prêt dans lequel le prêteur serait son propre garant. Même à supposer que ceci soit correct, ceci ne serait jamais plus grave que si la société accordait des crédits non garantis. Or, ceci n'est pas interdit, en principe. Il n'y a donc guère de raison d'interdire de façon absolue les prêts gagés par les propres titres de la société.

Il reste que cette disposition a dans le droit positif actuel un champ d'application assez limité. Elle ne s'applique qu'aux sociétés anonymes (et par ricochet aux sociétés en commandite par actions). En d'autres termes, les S.à r.l. y échappent. Il s'agit encore d'une des multiples raisons qui font que, ces dernières années, cette forme de société est devenue nettement plus attractive que n'importe quelle autre forme.

Si le champ d'application de la règle commentée est limité, la raison tient encore au fait que la disposition légale vise uniquement les garanties faites « *en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers* ». Cette formulation permet donc de donner les garanties, par exemple dans le cas où ces garanties sont accordées uniquement *ex post* c.-à-d. après l'acquisition des titres par ce tiers. En revanche, si cette chronologie avait été prévue dès le départ ou encore si les actions de la société étaient substituées à d'autres gages, alors cette disposition serait enfreinte[2].

Finalement, la loi ne vise que les prêts, etc. en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers. Rien n'est dit au sujet du financement d'actions d'autres sociétés du même groupe, (v. cependant *sub* c) ci-après).

Dans ce contexte, il est primordial de noter que la disposition de l'article 430-19 L.S.C. est sanctionnée pénalement par les dispositions de l'article 1500-7

1 – C'est pour cette raison qu'on considère que cette disposition n'est que le corollaire de la disposition qui interdit le rachat d'actions propres, v. A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 168, ID 11305. Cet argument a évidemment perdu de sa valeur de nos jours, dans la mesure où le rachat d'actions propres est expressément autorisé (sous certaines conditions).

2 – V. en ce sens notamment, H. D. Bosly, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974, p. 112.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L.S.C. Elle doit donc être interprétée de **façon stricte** sans pouvoir faire l'objet d'extension à des cas non expressément prévus par la loi (donc à une application par analogie des dispositions légales à des cas autres que ceux que la loi aurait directement visés).

b) Exception à l'application de ces règles

Les dispositions interdisant les transactions sur actions propres ne sont, au vœu de la loi, pas applicables aux « *transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer* ».

C'est surtout l'exception concernant le personnel de la société qui pose problème. En effet, en l'occurrence, les dispositions de la directive ont été reprises en droit national tout en l'ayant été de façon incomplète. En effet, la directive permet d'excepter non seulement les opérations faites en faveur du personnel de la société, mais encore celles effectuées en faveur du personnel des filiales de cette société.

c) Extension de ces règles aux opérations des filiales

Aux termes de l'article 430-23 L.S.C., les opérations de souscription, d'acquisition ou de détention d'actions de la S.A. qui sont effectuées par une autre société ayant la forme d'une S.A., d'une S.à r.l. ou d'une S.e.c.a. d'un État membre détenues directement ou indirectement par une S.A. tombent sous la même interdiction. Ces opérations sont en effet considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même. L'assimilation de ces actions aux actions propres entraîne que le droit de vote afférent à ces actions est également suspendu (art. 430-23 (2) L.S.C.).

Cette interdiction s'étend même aux sociétés non européennes dans la mesure où les sociétés sur lesquelles l'influence est exercée se trouvent dans un État non membre et que celle-ci a une forme juridique comparable à celles visées par la Première directive (en clair donc, s'il s'agit d'une société de capitaux d'un tel État tiers).

Exemple

La S.A. Luxco détient 80 % de la société Worldwide Ltd des BVI qui elle-même détient 95 % de la S.A. belge BelCo qui à son tour détient 100 % des actions de la S.A. luxembourgeoise Lux Investments. Cette dernière acquiert 25 % des actions émises par la Luxco avec pour conséquence que cette acquisition est additionnée aux titres que la Luxco peut détenir en propre : le résultat sera donc que le montant maximum des titres que la Luxco peut détenir est excédé.

d) Critiques des règles relatives à l'assistance financière

« *Tel est l'effet des mauvaises lois qu'il en faut de plus mauvaises encore pour arrêter les malheurs des premières* », Montesquieu, T. II, La Pléiade, Paris, Gallimard, p. 1011.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En général, peu de temps est perdu pour expliquer les raisons qui sont à la base de cette interdiction prévue par l'article 23 de la Deuxième directive. Les auteurs se limitent à décrire les conditions du régime et ses conséquences.

Il y a lieu de noter que le régime actuel constitue une amélioration notable par rapport au régime initial qui consistait en une interdiction pure et simple de telles opérations, régime à juste titre critiqué. En réagissant aux critiques adressées contre cette mesure, la Commission a introduit une proposition tendant à permettre aux sociétés d'accorder des crédits jusqu'au montant des fonds propres disponibles pour la distribution[1].

Mais cet allégement est assorti d'une série de conditions qui sont tellement contraignantes que l'on peut avoir l'impression que ce qui est donné d'une main est repris de l'autre[2].

Il est vrai que le régime en question n'est pas très cohérent. L'origine de la notion d'assistance financière se trouve dans le **droit anglais**. L'interdiction de l'assistance financière n'était pas prévue par la version originale de la directive et elle a été introduite seulement après que le Royaume-Uni avait rejoint la Communauté européenne en 1973[3].

La disposition est étrange dans le sens suivant : la directive n'interdit pas de faire des crédits aux associés ; elle n'interdit pas non plus le rachat des actions par la société (même si cette opération est soumise à des restrictions, dont l'opportunité ne sera d'ailleurs contestée par personne)[4]. En revanche, la combinaison de ces deux opérations résulte dans une interdiction formelle.

Il y a lieu d'insister sur le fait que le rachat (direct) des actions par une société, d'une part, et les opérations d'assistance financière, d'autre part, ne sont guère comparables. Dans le second cas, les actions sont acquises par quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'une société (ou une personne) apparentée ou d'un tiers. Si l'on veut assimiler l'opération à une opération de rachat d'actions, alors on considère nécessairement que cet acheteur est un simple « *nominee* » (un « *homme de paille* ») agissant pour la société émettrice des titres.

Ce scénario peut bien entendu se produire, mais sera exceptionnel et, en général, il n'en sera rien.

À supposer même que cette situation se présente effectivement, il est vrai que l'on se trouverait dans une hypothèse de rachat de ses propres actions par une société : pourquoi alors ne pas appliquer les règles adaptées à ce cas de figure ? Ceci voudrait dire qu'il serait possible de racheter les titres, mais dans les limites connues de 10 % de capital et dans la limite des fonds propres disponibles (de façon à éviter que l'actif net de la société ne soit entamé). Le principe du maintien du capital social nominal serait sauvegardé.

La règle de l'interdiction de l'assistance financière est incohérente pour la raison qu'elle considère que ces opérations sont des opérations de rachat d'actions (ce

1 – COM (2004) finale.

2 – Pour une appréciation critique de cet allègement, v. E. Ferran, « Simplification of European company law on financial assistance », *European Business Organization Law Review*, p. 95.

3 – E. Wymeersch, « Article 23 of the second company law directive : the prohibition on financial assistance to acquire shares of the company », *Festchrift für Ulrich Drobnig*, p. 741.

4 – Dans la plupart des États membres la prohibition de l'assistance financière est basée sur son assimilation avec les rachats d'actions, v. E. Wymeersch, « Article 23 of the second company law directive the prohition on financial assistance to acquire shares of the company », *Festschrift für Ulrich Drobnig*, p. 730.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

qui en fait n'est qu'exceptionnellement le cas), mais tout en les interdisant, alors que les rachats d'actions sont en réalité autorisés. Pour le moins, la règle manque au **principe de proportionnalité**.

E – Modification du capital des sociétés anonymes

Tout changement du capital comporte une modification des statuts et, en tant que telle, elle doit respecter les conditions (de fond et de forme) qui sont prévues pour ce type d'opérations.

Le régime des modifications des statuts tel qu'appliqué au Luxembourg a toujours dévié par rapport à celui applicable en Belgique. En effet, sur ce point, le Luxembourg a suivi le législateur français de 1913. Ce système repris au Luxembourg devait toutefois faire l'objet de modifications législatives successives, et ceci, par les lois du 13 avril 1922 et du 15 janvier 1927[1].

Les conditions de majorité et de convocation d'une telle modification des statuts sont donc en tout état de cause à respecter. Elles sont traitées à un autre endroit de ce manuel (v. p. 268).

1) Augmentation de capital

La L.S.C., dans son article 420-23, précise que les formalités et conditions requises pour la constitution des sociétés anonymes s'appliquent également à l'augmentation de capital par apports nouveaux. Cette disposition était destinée à éviter une controverse très importante qui avait sévi en Belgique et selon laquelle les conditions de la souscription intégrale et de la libération pour un quart (un dixième à l'époque) ne seraient pas requises en cas d'augmentation de capital. Supportée par un arrêt de la Cour de cassation belge[2]-[3], cette thèse a été à juste titre fortement critiquée dans le sens qu'il serait trop facile de constituer une société avec le capital minimum en respectant les garanties prévues par la loi pour ensuite augmenter le capital en échappant ainsi aux garanties légalement prévues lors de la constitution.

C'est afin d'éviter de telles discussions que l'avant-projet Corbiau reprend spécifiquement cette solution de bon sens[4]. Cette exigence concerne donc tant l'obligation de souscription intégrale que celle de libération d'un quart.

a) Différentes catégories d'augmentation du capital

Il existe différentes catégories d'augmentations de capital dont les effets économiques sont très différents : une augmentation de capital par incorporation de réserves ne se traduit pas par un renforcement de la surface financière de

1 – L. Metzler, « Le régime légal des sociétés et des associations en droit luxembourgeois », *R.P.S.*, p. 245.

2 – Cass. b. du 4 juin 1886, *Pas.*, 1886, I, p. 253.

3 – La Cour de cassation française a tranché dans un sens opposé dans un arrêt du 27 janvier 1873 : « qu'une distinction ne saurait être faite entre le capital originaire et le capital nouveau ; que l'un et l'autre sont la garantie des tiers et doivent être constitués dans les mêmes conditions […] », v. Projet de loi portant révision de la loi sur les sociétés commerciales, Avis du Conseil d'État, p. 77, ID 13321.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 81, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la société. En effet, les fonds propres de cette dernière restent rigoureusement identiques. Il est vrai que l'on pourrait argumenter que la situation des créanciers s'améliore (et que, de façon correspondante, celle des associés se détériore). En effet, celle des créanciers s'améliore dans la mesure où les fonds propres intégrés dans le capital de la société sont plus difficilement distribuables et ont donc plus de chances de servir encore de garantie aux créanciers au moment où ceux-ci en ont vraiment besoin.

Celle des associés se détériore dans le sens qu'ils ont beaucoup moins de chances d'obtenir la distribution des bénéfices accumulés lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une intégration dans le capital social. Il est bien entendu vrai que les bénéfices en question restent toujours exposés à une distribution ultérieure, même si celle-ci devrait se faire par une réduction du capital social.

Une augmentation de capital par une telle incorporation de réserves peut se traduire par l'attribution d'actions gratuites aux actionnaires, lesquels se verront attribuer des actions nouvelles (dites **actions gratuites**) sans que, bien entendu, la valeur totale de leur portefeuille titres n'ait augmenté : il y a simplement prélèvement sur les réserves libres (voire la réserve légale) de fonds qui seront transférés au capital pour donner lieu à des actions nouvellement émises.

À l'opposé, les augmentations du capital social qui sont faites par apports de biens nouveaux se traduisent par un renforcement de la surface financière de la société. La société se renforce donc économiquement. Une telle augmentation de capital soulève des problèmes de traitement égalitaire entre associés lorsque tous ne participent pas à l'augmentation ou encore lorsque tous y participent, mais pas dans les mêmes proportions.

b) Responsabilité des administrateurs

L'article 420-20 [anc. art. 31-1] L.S.C. rend responsable envers tous les intéressés les fondateurs (entre autres) de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite et de la libération d'un quart au moins de chaque action. Ces dispositions s'appliquent en cas de constitution d'une société.

L'article 420-23 L.S.C. étend ces règles aux cas d'augmentation de capital.

Aux termes de cet article : (2) « *Les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement des obligations prévues par l'article 420-19 à charge des fondateurs* ».

Les administrateurs se voient ainsi soumis à une responsabilité calquée sur celle des fondateurs. Cette solution (reprise de l'article 18 de la Deuxième directive) est identique à celle retenue en Belgique : l'article 35 L.C.S.C. est d'ordre public. La responsabilité des administrateurs en fonction au moment de l'augmentation de capital est absolue et de plein droit. Elle joue donc également à l'égard des administrateurs absents lors de l'acte d'augmentation de capital[(1)].

Selon la jurisprudence belge, la responsabilité à charge des administrateurs par l'article 35 L.C.S.C. en cas d'augmentation du capital « *de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite relève d'une fiction légale expressément consignée dans les textes, les assimilant, de par leur seule qualité*

1 – Trib. com. Bruxelles du 30 septembre 1937, *R.P.S.*, 1940, n° 46.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

d'administrateurs en fonction au moment de l'augmentation, aux souscripteurs […] ils en sont de plein droit réputés souscripteurs et qu'il est dès lors évident que cette responsabilité est indépendante d'un fait quelconque de la fonction »[1].

La jurisprudence luxembourgeoise a eu l'occasion de prendre position sur l'application de l'ancien article 32-1 L.S.C. Dans une affaire soumise au tribunal d'arrondissement de Luxembourg[2], il avait été retenu que, malgré l'émission d'un **certificat de blocage** par une banque de la place, les fonds en question ne se trouvaient pas véritablement à disposition de la société. Le tribunal condamna donc les administrateurs à payer au curateur de la société, entretemps tombée en faillite, 25 % du montant du capital souscrit d'un montant de 153 000 000 francs[3].

De telles situations sont fréquentes pour des raisons juridiques et pratiques. Juridiquement, aucun actionnaire ne peut être tenu d'augmenter ses engagements (à moins qu'il soit d'accord avec une telle augmentation, d'où la règle de l'article 450-3 [anc. art. 67-1] L.S.C. qui exige l'unanimité pour de telles décisions). Même si cette règle n'existait pas, il serait, dans les faits, inévitable que certains associés ne puissent participer à une augmentation, faute de moyens.

Afin d'assurer donc **l'égalité entre associés**, les associés anciens bénéficient d'un droit préférentiel de souscription qui leur permet de participer à l'augmentation de capital dans la proportion existant entre l'ancien capital et l'augmentation de capital. En d'autres termes, lorsque le capital social augmente de 50 %, alors chaque associé détenant X titres a en principe droit de souscrire 0,5 fois X titres nouveaux. S'il n'entend pas exercer ces droits (et comme indiqué ci-dessus, il ne peut y être obligé), il peut monnayer ses droits préférentiels de souscriptions en les cédant à ceux qui entendent souscrire plus de titres que ceux auxquels ils ont droit en fonction de leur participation existante.

La valeur économique de ces DPS est fonction de la différence existant entre la valeur nominale des actions « *anciennes* », existant donc avant l'augmentation de capital et celle des actions nouvelles (donc nouvellement émises). Une telle différence de valeur est fréquente, et ceci, pour un certain nombre de raisons tenant aux réserves cachées dans les entreprises, à la notion de *goodwill*, etc.

Essayons d'expliquer la situation au moyen d'un exemple simplifié.
Le DPS oblige la société qui entend augmenter le capital social par apports nouveaux à offrir par préférence les actions nouvelles aux détenteurs des actions anciennes dans la proportion existant entre les actions anciennes et les actions nouvelles à émettre en représentation des apports nouveaux. Le DPS est lié à toutes les actions, qu'il s'agisse d'actions ordinaires ou d'actions sans droit de vote, dans la mesure où celles-ci représentent le capital social. En revanche, les titres non représentatifs du capital social ne donnent logiquement pas droit à un DPS. Tel est le cas en particulier des parts bénéficiaires.

1 – Cass. b. du 29 mai 1980, *R.P.S.*, 1981, p. 21.

2 – TA du 27 juin 2005, n° 649/05, ID 10296.

3 – V. M. DI STEFANO et C. COUSQUER, « La responsabilité solidaire des membres du conseil d'administration tenus de la libération effective d'un quart du capital souscrit », *Tax Today*, octobre 2005.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le DPS ne vaut pas pour les apports en nature, de sorte que de tels apports faits par une partie seulement des actionnaires existants, voire par des non-actionnaires, ont pour résultat de conduire à la « *dilution* » des anciens actionnaires.

En ce qui concerne l'émission d'obligations convertibles (ou encore des obligations à warrant), il faut noter que le DPS est accordé au moment de la souscription des obligations, et non pas au moment de l'émission des actions (réalisée lors de la conversion des obligations en actions).

Cette solution résulte directement de l'article 420-27 [anc. art. 32-4] L.S.C. (introduit par la loi du 23 novembre 1972).

c) Intéressement des salariés

Les entreprises décident souvent de permettre à leurs salariés de devenir actionnaires (ou associés) à des conditions avantageuses. À première vue, une telle façon de procéder est dommageable aux associés. La Commission bancaire belge a pris position sur cette question en constatant qu'il appartient aux organes sociaux d'apprécier l'opportunité d'associer le personnel de l'entreprise au capital social et que « *s'il est décidé de faire bénéficier le personnel d'un prix de souscription avantageux par rapport à la valeur de marché des actions de la société, tant le principe de cet avantage que son importance doivent être justifiés par l'objectif poursuivi de l'intéressement, spécialement par l'amélioration escomptée du rendement et de la productivité* ».

La Commission devait conclure que, dans une telle hypothèse, il n'y a pas à proprement parler de transfert de patrimoine au détriment des actionnaires, étant donné que « *l'avantage immédiat que représente pour le personnel un prix de souscription peu élevé […] sont compensés avec le temps par le profit que procure à l'entreprise et à ses actionnaires l'accroissement de motivation du personnel, de son dévouement et de sa productivité* »[1].

La Commission envisage également que l'émission des titres à un prix avantageux puisse être faite non pas seulement aux salariés de la société émettrice, mais encore au profit des salariés d'autres sociétés du même groupe, en consacrant ainsi la notion d'**intérêt de groupe**[2].

Des actions de bonus peuvent encore être attribuées, c'est-à-dire donc d'actions gratuites émises à l'occasion d'une augmentation de capital par incorporation de réserves.

En France, des dispositions légales prévoient la constitution d'une réserve dénommée « réserve de participation » et dont l'incorporation au capital donne lieu à l'émission d'actions gratuites au bénéfice des membres du personnel[3].

2) Réductions de capital

On peut distinguer deux sortes de réductions de capital : les unes sont des opérations symétriques aux augmentations de capital par apports de biens nouveaux et

1 – Rapport 1984-1985 cité par P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990), *R.C.J.B.*, 1993, p. 647.

2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 671.

3 – Ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conduisent donc à un **remboursement de capital** aux associés, alors que les autres ne sont que la traduction juridique d'une situation de fait, celle où les fonds propres réels de la société sont, en raison des pertes d'exploitation, inférieurs au capital social figurant dans les statuts, et donc dans le bilan de la société.

a) Réduction par remboursement aux associés

Art. 450-5 [anc. art. 69] L.S.C.
« *(1) L'assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée.*
(2) Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de ceux-ci de libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations du procès-verbal de délibération peuvent, dans les trente jours à compter de cette publication demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société.
(3) Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.
(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d'être absorbées par d'autres fonds propres ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 % du capital souscrit réduit.
Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des paragraphes 2 et 3, ni être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.
(5) Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l'assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la transformation de la société ».

Aucun changement n'a été apporté par la Loi de Modernisation, celui qui avait été proposé par le projet de loi ayant été écarté. « *Conformément à l'art. 42 de la seconde directive communautaire (précitée) relatif au principe de traitement égal des associés, il est décidé, à l'instar du droit belge (art. 612 Code des sociétés) d'insérer le membre de phrase suivant dans l'art. 69 L. 10 août 1915 : «moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques », tout en observant que le traitement résultant de l'application de ce principe peut être écarté sur la base d'un accord unanime des actionnaires* »[1].

1 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 85, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Depuis longtemps, il est reconnu que la réduction de capital n'est pas une modification des statuts ordinaire comme, par exemple, un changement de nom ou une modification du siège statutaire. « *La réduction de capital est une modification des statuts d'une importance tout à fait particulière. En effet, cette opération affecte directement les droits des tiers : les créanciers voient ainsi leur gage diminuer de sorte que la question se pose si l'avoir net sera encore suffisant pour couvrir les engagements de la société. S'il ne l'est plus, les créanciers sont privés d'une partie de leur gage par la volonté même de leur débiteur. Ce qui serait un abus et une injustice* »[1].

Cette opération suppose une modification des statuts, corrigeant à la baisse le montant du capital social, décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (art. 450-5 L.S.C.). La réduction peut se faire soit par annulation d'une partie des actions émises, soit par une diminution du montant nominal des actions.

Est assimilée à cette opération celle consistant à dispenser les associés de la libération de leurs actions compte tenu du fait que l'assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée.

La Cour de cassation belge a arrêté qu'en cas de réduction de capital par remboursement aux actionnaires, ces derniers « *deviennent créditeurs de la somme affectée au remboursement, mais que leur droit est subordonné à la condition qu'aucun créancier ne s'oppose au remboursement dans le délai de six mois […]* »[2].

Cette décision a été prise sous l'ancienne version de la loi belge et, par conséquent, cette solution n'est plus nécessairement applicable. Sous la nouvelle loi, les créanciers ont le droit d'empêcher le remboursement aux actionnaires. La conséquence en est la suivante : entre associés, la réduction de capital s'opère à dater de la décision de l'assemblée générale, la décision de réduction n'est pas soumise à une **condition suspensive** ou à une **condition résolutoire.** Le seul effet en est de provisoirement maintenir dans le patrimoine de la société les sommes dont l'attribution aux associés a été décidée en remboursement de leur mise[3]. Les créanciers ne peuvent plus s'opposer à la réduction du capital social comme tel était le cas autrefois. La seule conséquence de l'opposition des créanciers est que le remboursement est suspendu[4].

« *Les créanciers dont la créance n'est pas échue lors de la publication de la décision de réduire le capital ont le droit d'exiger, à charge de la société, une sûreté garantissant leur créance. Cette disposition de la loi est impérative. Il ne peut donc y être valablement renoncé par un créancier qu'une fois prise la décision de réduire le capital* »[5].

---

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 211, ID 11305.

2 – Cass. b. du 22 mai 1987, *Pas.*, 1987, I, p. 1171.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990), *R.C.J.B.*, 1993, p. 680, qui citent la commission bancaire belge.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990), *R.C.J.B.*, 1993, p. 681.

5 – A. Vandeplas et J.P.. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 104.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

b) Garanties accordées aux créanciers

La réduction de capital est une opération susceptible d'affecter les intérêts des créanciers. Ceux-ci peuvent avoir traité avec une société ayant un capital élevé (et peut-être justement en raison de ce capital élevé) et, du fait de la réduction du capital, ils voient maintenant leur gage diminuer substantiellement. Pour cette raison, le législateur a pris soin des intérêts des créanciers en leur accordant la possibilité de demander des garanties. En vertu de cette faculté, les créanciers « *[…] dont la créance est antérieure à la date de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations du procès-verbal de délibération peuvent, dans les trente jours à compter de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société* ».

Afin de donner l'occasion aux créanciers de se rendre compte de la réduction de capital projetée, la loi (art. 450-5 L.S.C.) prévoit : « *Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête […]*

(5) *Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l'assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la transformation de la société* ».

La réduction de capital ne soulève pas les mêmes problèmes que l'augmentation de capital : l'obligation de respecter l'égalité entre associés conduit à une solution toute simple et directe ; la réduction de capital se traduit par une annulation des actions (ou une réduction de la valeur nominale de celle-ci) qui, en pourcentage, est la même pour tous les actionnaires.

À cet endroit, se pose la question des **effets vis-à-vis des tiers** d'une telle réduction de capital. Il peut en effet paraître assez contestable que des créanciers qui ont traité avec une société fortement capitalisée voient leur débiteur procéder à une importante réduction de capital en diminuant ainsi le gage de ses créanciers. La jurisprudence ancienne tenait compte de ces intérêts légitimes des créanciers en arrêtant que : « *Une réduction du capital social valable en la forme n'est cependant opposable qu'aux créanciers dont les créances sont nées postérieurement à la décision de l'assemblée générale, tandis que les créanciers antérieurs ont le droit de la tenir pour nulle et non avenue* »[(1)].

L'action appartenant à ces créanciers est une action individuelle, de sorte qu'en cas de faillite de la société, le curateur n'a pas qualité pour l'exercer[(1)].

Il va de soi que cette jurisprudence n'est plus nécessairement applicable de nos jours, compte tenu des modifications législatives intervenues récemment.

1 – CA du 13 juin 1928, *Pas.*, 11, p. 426.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

c) Réduction du capital par apurement des pertes

« *Une société ne peut pas réduire son capital en remboursant ses actionnaires ou, ce qui revient au même, en les libérant des versements à effectuer lorsqu'elle a des créanciers […] Une pareille réduction serait préjudiciable à leurs droits et pourrait être attaquée par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent élever aucune critique, au contraire, contre une diminution du capital qui n'aboutit pas à une réduction effective de l'avoir social et encore moins contre les réductions qui se font au moyen des bénéfices sociaux, puisqu'elles n'entament pas le capital maintenu intact, tels les rachats d'actions opérés très licitement sur les bénéfices annuels* »[1].

Dans ce cas de figure, il s'agit simplement de porter les pertes bilantaires en déduction du capital social statutaire de la société afin de faire correspondre à nouveau le capital bilantaire au capital réel.

Fort logiquement, la L.S.C. (art. 450-5 (4) L.S.C.) précise elle-même que : « *Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d'être absorbées par d'autres fonds propres* », disposition commentée comme suit par la doctrine belge : « *Il est difficile de critiquer ces procédés lorsque la réduction du capital se produit sans diminution des capitaux effectifs, sans remboursement aux actionnaires. Dans ce cas, il s'agit en réalité d'enregistrer une situation de fait, de constater un changement d'état survenu dans l'existence sociale* »[2]. Néanmoins, il est vrai qu'une telle réduction aura pour effet qu'à l'avenir la société (par hypothèse redevenue profitable) sera à même de distribuer la totalité de ces bénéfices, alors que, en l'absence de réduction du capital, il aurait d'abord fallu reconstituer le capital avant de pouvoir procéder à des distributions de bénéfices.

Comme accessoire à cette opération de réduction de capital, il est encore possible de doter une réserve qui ne peut toutefois pas « *dépasser 10 % du capital souscrit réduit.* En outre, « *elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des paragraphes 2 et 3 ni être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves* » (art. 450-5 (4), anc. art. 69 (4) L.S.C.).

3) Amortissement du capital

Par application d'une faculté laissée par la Deuxième directive des CE, les sociétés ont la possibilité d'émettre des actions amortissables (art. 450-6 [anc. art. 69-1] L.S.C.).

Cette faculté doit être prévue par les statuts qui autorisent alors l'assemblée générale, sujette à publication conformément à la Loi de 2002, d'affecter tout ou partie des bénéfices et réserves distribuables à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci. Dans la deuxième hypothèse (remboursement partiel), les titres amortissables sont désignés par **tirage au sort.**

1 – Ch. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 375.

2 – Ch. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, Wiener, p. 371.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« *Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui jouissent des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties* »[1]. Cette dernière précision est évidemment indispensable pour assurer l'égalité entre actionnaires. Si une partie des titres seulement est remboursée, seuls certains actionnaires ont été remboursés (ils n'encourent donc plus de risque de perdre leur apport et ils peuvent placer ailleurs les fonds correspondants), tandis que d'autres ont leurs fonds toujours bloqués dans la société visée. Il est donc indispensable de verser à cette partie des actions un dividende préférentiel auquel ne peuvent prétendre les actions remboursées.

La pratique des actions amortissables ne s'est pas vraiment développée au Luxembourg : la raison principale devrait être que fiscalement ces remboursements sont traités en tant que dividendes (soumis à retenue à la source, au taux de 15 %).

Cet article concerne une institution peu utilisée par la pratique luxembourgeoise, celle de l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair. Le changement apporté par la Loi de Modernisation est relatif au droit d'usufruit au sujet duquel le commentaire des articles explique : « *En cas d'amortissement du capital, il a été estimé souhaitable de reprendre la solution exprimée en droit français, à savoir que "[L]orsque les actions amorties sont grevées d'usufruit, l'opération d'amortissement a pour effet de rembourser le nu-propriétaire de tout ou partie du montant nominal de son titre, et de priver l'usufruitier du premier dividende à concurrence du montant remboursé. Dès lors, le nu-propriétaire doit faire bénéficier l'usufruitier du quasi-usufruit de la somme remboursée, c'est-à-dire de la possibilité d'en disposer, sauf à devoir la restituer en fin d'usufruit"* »[2].

F – Preuve de la qualité d'actionnaire

L'actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour établir sa qualité, donc pour prouver qu'il est le propriétaire légitime d'un certain nombre d'actions de la société.

En premier lieu, **l'acte** d**e société** constitue le titre de sa qualité d'actionnaire. C'est sur ce contrat que la société doit se fonder si elle entend réclamer de lui l'exécution de ses obligations, concrètement le paiement des montants non encore libérés.

Le deuxième moyen pour établir sa qualité d'actionnaire (détenant des actions nominatives) vis-à-vis de la société réside dans son inscription dans le **registre** des actionnaires (art. 430-4, alinéa 1, L.S.C.).

Un troisième moyen est constitué par l'article 430-4, alinéa 2, L.S.C. Un **certificat** constatant l'inscription au registre est remis à l'actionnaire. « *L'associé, qui ne peut opposer ce titre aux tiers, peut l'invoquer contre la société et s'en servir notamment pour établir et reconstituer vis-à-vis de celle-ci ses droits en cas de perte ou de destruction du registre social* »[3]. Ce système ne peut fonctionner correctement que si, à chaque transfert d'actions, la société demande la restitution du certificat qui est ainsi devenu

1 – Certains auteurs assimilent ces actions de jouissance à des parts bénéficiaires. V. en ce sens Van Ryn, *Principes de droit commercial*, 1re éd., p. 367.

2 – Selon le *Doc. parl.*, no 5730, p. 86, ID 10080.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 98, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

sans objet et procède à l'émission d'un nouveau certificat au profit du cessionnaire. Si la loi utilise le terme de certificats au pluriel, la raison en est à trouver dans le fait que ce papier est destiné à constater non pas seulement l'inscription première, mais encore les inscriptions successives à la suite des diverses cessions de titres[2].

La preuve de la détention des actions au porteur est faite conformément à l'article 420-6 L.S.C., à savoir par le registre détenu par le dépositaire des actions au porteur nommé par l'organe de direction de la société.

Quant aux actions dématérialisées la preuve en est faite par l'inscription en compte courant au nom du titulaire du compte (v. article 430-7 L.S.C.).

■ § 2 – Les obligations

La caractéristique essentielle de l'émission obligataire se situe plus dans sa forme externe que dans sa substance juridique : il s'agit de la subdivision de l'emprunt en un grand nombre de titres souscrits par une foule de petits porteurs[1].

« *Tandis que l'action, née d'un apport, n'est qu'un titre de créance fictive, basée sur la notion abstraite de la personnalité juridique mais en réalité représentative d'une part du capital social, l'obligation, née d'un prêt fait à la société, est un titre de créance véritable, représentative d'une charge sociale* »[1].

On peut en premier lieu se demander pourquoi la loi prend soin de fixer un cadre légal spécial à l'égard des émissions d'obligations. En effet, ne s'agit-il pas simplement de créanciers détenant des créances sur la société avec la seule particularité que celles-ci sont matérialisées par des titres ? Si l'obligataire est un créancier de la société, il n'en demeure pas moins différent des autres, et la loi entend tenir compte des particularités que sa situation de créancier obligataire comporte.

« *L'argument traditionnel que le droit de l'obligataire a nature de créance, et qu'il faut traiter l'obligataire à l'égal de tout créancier n'a pas cours. En fait, ce droit est d'une nature spéciale ; simple fragment ou coupure d'une dette collective, ce droit prend naissance dans des conditions différentes, du tout au tout, de la genèse du droit de créance individuel ; il se trouve constaté par un titre négociable d'après des formes spéciales ; son titulaire ne peut prendre contact avec le débiteur et il ne lui sera que d'un maigre secours de pouvoir, à l'heure de la débâcle, assigner son débiteur en faillite, soit encore de pouvoir exercer contre lui, individuellement, les actions visées par les art. 1166 et 1167 du Code civil – la jurisprudence refusant aux obligataires la faculté de plaider par mandataire* »[2].

L'émission d'obligations présente certains points communs avec l'émission des actions, tout en dénotant également un certain nombre de différences par rapport à celle-ci.

« *Les créanciers ordinaires, quand même il s'agirait d'un marché à fournitures successives ou d'un crédit de banque de certaine durée, sauront presque toujours s'arranger de façon à cesser en temps utile les relations avec la société, à limiter le crédit accordé ou à demander des garanties spéciales, lorsque la situation de la société commence à péricliter […]. Tout autre est la situation des obligataires. Une fois engagés avec la société, leur sort sera celui de la société. La prospérité de celle-ci leur*

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 186, ID 11308.

2 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport de la commission spéciale sur les sociétés coopératives, p. 250.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

assurera le paiement périodique des intérêts, ainsi que le remboursement du capital quand il sera échu ; par contre la ruine de la société sera la ruine de leur créance »[1].

On peut encore noter que les créanciers ordinaires réussiront de façon très générale à limiter leurs crédits à la société lorsque celle-ci montre les premiers signes de défaillance financière. Tel n'est pas le cas pour les détenteurs d'obligations.

A – Émission de l'emprunt obligataire

Il y a émission d'un emprunt obligataire « *lorsque les droits des prêteurs sont incorporés dans des titres négociables qui leur sont attribués en contrepartie de leurs avances et qui confèrent à chacun des avantages identiques* »[2]. La double caractéristique d'un tel emprunt obligataire est d'être un **emprunt collectif,** d'une part, et d'être **représenté par des titres négociables** conférant à chaque titre des droits identiques dans la mesure où ils ont le même montant nominal, d'autre part[3]. Si ces conditions sont remplies, on est en présence d'un emprunt obligataire, quelle que soit la dénomination donnée à cette émission[1].

En premier lieu, elle ne comporte pas de modification des statuts : si le capital social est une donnée statutaire, le montant du « *capital obligations* » émis n'est pas une donnée faisant l'objet d'une insertion dans les statuts.

Si les obligataires sont des créanciers et non des associés, leur situation est particulière dans la mesure où, compte tenu de la durée de l'emprunt qui est souvent à très long terme, leur sort est lié à celui de la société ; il est vrai que, du fait de la négociabilité de ces titres, l'obligataire individuel peut se défaire de ses titres et, en quelque sorte, obtenir le remboursement prématuré de son prêt.

« *Aussi le législateur est-il intervenu dans une double intention : donner à ces créanciers liés à la vie de la société un certain droit de regard sur l'activité sociale ; organiser la "masse" des obligataires pour permettre à l'opinion de leur majorité de s'exprimer et de s'imposer à tous* »[4].

Avant la Loi de Modernisation, la L.S.C. précisait qu'il ne pouvait pas y avoir émission d'obligations avant la constitution de la société (art. 79, L.S.C. : « *Il ne peut être émis d'obligations d'aucune nature avant la constitution de la société* ». Il s'agissait d'une consécration des principes de droit commun que l'on ne peut créer une obligation juridique sans l'existence d'une personne tenue du lien de droit qui doit naître. Contrairement à la disposition existant pour les actions, il n'était en revanche pas interdit de négocier les obligations avant leur création[5]. Cette disposition a été abolie en 2016.

L'organisation des obligataires **en masse** est une opération indispensable : si une société n'a qu'un seul créancier, ou un nombre très réduit de créanciers, elle peut, lorsqu'elle connaît une période difficile, obtenir des concessions importantes contre certains avantages ou certaines sûretés nouvelles. Sous la loi belge de 1873 notamment, de telles négociations avec les créanciers obligataires étaient impossibles en

1 – Projet de loi portant révision de la loi sur les sociétés commerciales, Avis du Conseil d'État, p. 123, ID 13321.

2 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 270.

3 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 371.

4 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 371.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 192, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

raison de l'impossibilité pratique de pouvoir les réunir tous et de pouvoir donc négocier avec eux[1].

B – La masse des obligataires

Aux termes de l'article 470-3 L.S.C., tous les obligataires qui détiennent des titres faisant partie d'une même émission forment d'office une masse organisée selon les dispositions légales prévues par la L.S.C. Il peut donc parfaitement y avoir au même moment plusieurs masses d'obligataires au sein d'une même société anonyme si la société maintient simultanément plusieurs catégories d'obligations en circulation.

1) Changement des dispositions légales

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2005, la L.S.C. contenait un certain nombre de dispositions relatives aux émissions publiques d'emprunts obligataires. Ces dispositions des articles 80-83 ont été abrogées par ladite loi. Les dispositions afférentes à ces émissions publiques de valeurs mobilières se trouvent regroupées dans les lois sur le secteur financier.

Art. 470-1 [anc. art. 84] L.S.C.

« *Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives.*

L'obligation au porteur est signée par un administrateur ou membre du directoire ou une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

*Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du titre I*er*, chapitre V*bis *de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.*

Les titres d'obligation collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d'un système de règlement des opérations sur titres peuvent être signés par une ou plusieurs personnes autorisées par la société émettrice. Le nombre de titres représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.

Les dispositions des articles 430-4, 430-7 et 430-8, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables aux obligations »

Art. 470-2 [anc. art. 85] L.S.C.

« *Les porteurs d'obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées en conformité de l'article 461-6. Sauf disposition contraire des statuts, ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement* ».

Art. 470-3 [anc. art. 86] L.S.C.

« *Les obligataires, porteurs de titres faisant partie d'une même émission, forment une masse organisée conformément aux dispositions qui suivent* ».

1 – Ch. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 132.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2) Les représentants de la masse

Art. 470-4 [anc. art. 87] L.S.C.

« *(1) Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société lors de l'émission ou, pendant la durée de l'emprunt, par l'assemblée générale des obligataires.*

(2) Si aucun représentant n'a été désigné de la manière prévue à l'alinéa précédent, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège peut, en cas d'urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers intéressé désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs.

(3) Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires :

1° la société débitrice ;

2° les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital social ;

3° les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;

4° les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les réviseurs d'entreprises agréés et les préposés de ces sociétés.

(4) L'assemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils peuvent être révoqués également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège, à la requête de la société ou de tout obligataire ».

Art. 470-5 [anc. art. 88] L.S.C.

« *(1) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société lors de l'émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après :*

1° ils exécutent les décisions prises par l'assemblée générale des obligataires ;

2° ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la société.

Ils peuvent donner mainlevée totale ou partielle des inscriptions d'hypothèques, en cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d'aliénation des biens à dégrever, de même qu'en cas de remboursement total ou partiel des obligations ;

3° ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires ;

4° ils assistent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l'exécution régulière du plan d'amortissement et au paiement des intérêts ;

5° ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite, gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font toutes déclarations de créance au nom et dans l'intérêt des obligataires et rapportent la preuve de l'existence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit.

Ils peuvent être autorisés lors de leur désignation à accepter tout paiement et répartition aux obligataires ;

6° ils peuvent ester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l'intérêt des obligataires représentés, sans qu'il soit nécessaire de les appeler en cause.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

(2) L'assemblée générale des obligataires peut, après un délai de six mois, restreindre ou élargir les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires désignés par la société lors de l'émission.
(3) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par l'assemblée générale des obligataires pendant la durée de l'emprunt, celle-ci peut fixer librement les pouvoirs de ces représentants **».**

Afin de pouvoir valablement défendre les intérêts de la masse des obligataires, il peut y avoir désignation d'un ou de plusieurs représentants de la masse. Leur mode de désignation dépend du moment de leur nomination : s'ils sont nommés lors de l'émission, alors ils le sont par la société ; en revanche, s'ils sont désignés après seulement, pendant la durée de l'emprunt, ils le sont par l'assemblée générale des obligataires (art. 470-4 L.S.C.). À défaut de nomination par un des deux modes mentionnés, c'est le président du tribunal d'arrondissement qui peut, en cas d'urgence, nommer un ou plusieurs représentants de la masse. Cette désignation peut avoir lieu à la requête soit de la société, soit de tout obligataire ou d'un tiers intéressé (art. 470-4, anc. art. 87 L.S.C.).

La **révocation des représentants** de la masse peut avoir lieu soit par la masse, soit par le président du tribunal d'arrondissement (en ce dernier cas seulement pour justes motifs et à la requête de la société ou de tout obligataire).

Les attributions des représentants de la masse ont trait à la défense des intérêts des obligataires ayant souscrit à l'emprunt en question. À ce titre, les représentants exécutent les décisions de la masse des obligataires.

– ils acceptent les sûretés destinées à garantir les intérêts de la masse ;
– ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires ;
– ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de faillite, gestion contrôlée, etc. ;
– ils estent en justice en demandant ou en défendant au nom et dans l'intérêt des obligataires représentés sans qu'il soit nécessaire de les appeler en cause.

C – Les pouvoirs de la masse des obligataires

L'assemblée des obligataires a essentiellement les pouvoirs suivants :

– nommer et révoquer les représentants de la masse ;
– décider des actes conservatoires qui sont dans l'intérêt commun ;
– accepter la substitution aux obligations d'actions de la société ;
– accepter la substitution aux obligations d'actions ou d'obligations d'autres sociétés ;
– décider la constitution d'un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs ;
– décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l'exercice de leurs droits.

Les décisions de nomination et de révocation des représentants de la masse se font à la simple majorité des voix exprimées par les porteurs des titres visés. Pour la plupart des autres décisions, une délibération ne peut avoir lieu valablement que dans la mesure où les membres présents représentent la moitié au moins des titres en circulation (art. 470-14, anc. art. 94-3 L.S.C.). Si ce quorum n'est pas réalisé, il y a lieu de procéder à une nouvelle convocation qui délibère et décide quelle que

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

soit la fraction des titres représentés (art. 470-14, anc. art. 94-3 L.S.C.). Dans les deux cas de figure, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs de titres représentés.

Il a été considéré, à juste titre selon nous, qu'il ne serait pas opportun d'exiger la majorité en nombre des intéressés. L'obligation étant un titre au porteur, il serait facile de créer une majorité factice en répartissant les titres entre des hommes de paille[1].

D – La situation de la masse des obligataires en cas de faillite

Aux termes de l'article 470-19 L.S.C., la masse continue à exister après la faillite de la société (v. sous le chapitre consacré à la faillite).

E – Droits des obligataires

Les obligataires, en dehors des droits de créance qu'ils détiennent sur la société, n'ont que des droits très limités dans la société.

En premier lieu, ils peuvent prendre connaissance des pièces déposées au siège social conformément à l'article 461-6 L.S.C. en vue de l'assemblée générale des actionnaires.

En deuxième lieu, ils peuvent assister aux assemblées générales d'actionnaires, mais seulement avec voix consultative, ce qui leur permet donc de poser des questions ou de faire des observations, mais sans participer au vote[2].

■ § 3 – Les autres titres non représentatifs du capital social

La pratique d'abord et la loi ensuite ont toujours permis la création de titres autres que ceux qui représentent le capital social.

A – Parts bénéficiaires (parts de fondateurs)

Traditionnellement, la L.S.C. était très lapidaire sur ce sujet : « *Indépendamment des actions représentatives du capital social, il peut être créé des titres ou parts bénéficiaires. Les statuts définissent les droits qui y sont attachés* »[3], mais ce libellé est suffisamment explicite pour permettre de conclure que la L.S.C. reconnaît leur existence tout en laissant une liberté considérable pour définir les droits y attachés. En substance, cette situation a été laissée inchangée par la Loi de Modernisation.

1) Notion de parts bénéficiaires

« *La méfiance du législateur à l'égard des parts bénéficiaires, qu'elles soient créées à la constitution de la société […] ou en cours de vie sociale, a toujours été vive. La crainte traditionnelle – celle d'un écrémage des bénéfices au détriment*

1 – Ch. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 137.

2 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 379.

3 – Art. 37 (nouv. art. 430-1) L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

des actions représentatives du capital – a été avivée par l'attribution fréquente à ces parts d'un droit de souscription préférentielle en cas d'augmentation de capital […] »[1].

La qualification de cette catégorie de titres a de tous temps donné lieu à des problèmes. S'agit-il de **titres d'associés** ou de titres **de créance** ? Ou bien doit-on, avec la doctrine française traditionnelle, retenir qu'il s'agit de titres d'une « *nature propre* »[2] ou encore donnant à leurs titulaires la qualité d' « *associés-créanciers* »[3] ? Ces opinions divergentes ne doivent pas étonner, compte tenu du fait que ces titres sont effectivement d'une nature hybride[4]. Compte tenu encore de la grande latitude laissée aux sociétés désireuses d'émettre de telles parts, il existe de grandes variétés entre les titres effectivement émis de sorte que, selon le cas, on sera en présence d'un titre qui est essentiellement soit un titre d'associé soit plutôt un titre de créance. L'attribution d'un droit de vote est évidemment un élément faisant nettement pencher la balance dans le sens des titres d'associés.

Il résulte de cette définition que les parts bénéficiaires ne peuvent être représentées par le capital social. « *Leur caractère commun est de ne pas être attribués en échange d'un apport entré dans la composition du capital social* »[5]. En revanche, il n'est pas exclu que des apports (dont les apports en industrie) soient faits en contrepartie de l'émission de ces titres. Tel est surtout le cas des **parts de fondateur** (ou parts bénéficiaires proprement dites), terme d'ailleurs non utilisé par la L.S.C. Les parts de fondateur rémunèrent les services que les fondateurs ont rendus à la collectivité des associés[6].

On distingue généralement ces parts bénéficiaires des parts de jouissance : ces dernières remplacent les parts de capital dès le moment où la société, au moyen des résultats accumulés, procède au remboursement du capital des actions émises (en application de l'article 450-6 L.S.C.) ; il y a amortissement du capital étant entendu que les parts de jouissance continuent de faire partie du capital de la société. Les détenteurs de ces parts de jouissance continuent à faire partie de la société (notamment en ce qui concerne le droit de vote), avec pour seule différence que les détenteurs de parts de capital proprement dits se verront attribuer par priorité un intérêt fixe sur leurs titres et, au moment de la liquidation, la somme leur accordée tiendra compte du fait que ces associés ont déjà obtenu le remboursement de leurs apports[7].

L'explication de cet état des choses réside dans l'application de l'article 420-12 L.S.C., selon lequel « *Les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services* ». C'est précisément pour cette raison que les parts bénéficiaires ne donnent pas lieu à une augmentation

1 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 257.

2 – G. Ripert, *Traité élémentaire de droit commercial*, éd. 1954, n° 622.

3 – V. E. Escarra, *Cours de droit commercial*, éd. 1952, n° 1.229.

4 – Pour plus de détails, v. P. Demeur, « La part bénéficiaire confère-t-elle la qualité d'associé ? », *R.P.S.*, 1957, pp. 57 ss.

5 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 366.

6 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 367.

7 – *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 76.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

du capital : en effet, la raison de l'émission de parts bénéficiaires est très généralement un apport en industrie, donc de travail. Le capital ne peut être constitué par des engagements concernant l'exécution de travaux. De tels engagements ne peuvent faire l'objet d'une réalisation forcée et ne constituent donc qu'une garantie tout à fait relative. L'esclavage étant aboli, de tels engagements ne sont pas réalisables de force.

2) Intervention obligatoire du réviseur d'entreprises

Avant 2016, la L.S.C. comportait la disposition suivante : « *Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, sont soumis aux dispositions de l'article 26-1* ». La signification de cette phrase, qui se référait aux dispositions concernant les apports en nature, était plutôt mystérieuse. En effet, le rapport du réviseur visé à l'article 26-1 concernait les **apports en nature** qui devaient être évalués par une personne spécialisée afin d'éviter que les actifs ne soient surévalués en entraînant ainsi que le capital ne devienne (au moins partiellement) fictif. En revanche, les parts bénéficiaires ne sont pas émises en contrepartie d'apports de biens susceptibles d'évaluation économique. La nécessité d'un **rapport de révision** a donc paru tout sauf évidente et, en tout cas, l'objet de ce rapport est tout à fait différent de celui des apports en nature.

Pour certains, il fallait appliquer l'article 26-1 L.S.C. par analogie[1]. L'exigence d'un rapport de révision se justifie par la nécessité de vérifier la correspondance entre les apports (en industrie) et les droits financiers qui sont accordés en rémunération de ces apports. Si cette approche paraît compréhensible, il n'en reste pas moins qu'il serait de loin préférable que la loi précise elle-même l'objet de l'intervention du réviseur et les obligations de ce dernier. **L'objet du rapport** serait donc de protéger en fait les associés (détenant les titres représentatifs du capital) contre des émissions excessives de parts bénéficiaires (et comportant des droits disproportionnés), ce qui conduirait donc à une ponction trop importante des résultats annuels.

En supprimant le passage correspondant à l'ancien alinéa 3 de l'article 37 L.S.C. disposant que « *Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, sont soumis aux dispositions de l'article 26-1* », la Loi de Modernisation a corrigé une erreur manifeste. Le commentaire des articles constate à juste titre : « *Le renvoi opéré par la disposition existante à l'art. 26-1 […] ne se justifie pas pour assurer la préservation des droits des créanciers puisque l'apport effectué en contrepartie de l'attribution de parts bénéficiaires n'entre pas en ligne de compte pour la constitution du capital social* »[2].

3) Publication de la situation du capital social

Inconnue dans le Code de commerce de 1808, la disposition de l'article 430-12 [anc. art. 48] L.S.C. a été reprise du droit belge (art. 41 de la loi de 1873). L'objet de cette publication est de permettre aux tiers de se faire une idée de la situation du capital : le montant des versements effectués et surtout les noms des associés n'ayant pas encore

1 – C. Delvaux, *La société anonyme*, p. 268.

2 – *Doc, parl*., n° 5730/00, Commentaire des articles, Ad 22) Article 37, p. 65, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

libéré l'intégralité de leurs titres avec l'indication des sommes dont ils sont redevables. Les tiers peuvent ainsi apprécier la valeur réelle de la partie non libérée du capital[1] (étant entendu que ces créances seraient encore garanties par les fondateurs).

L'alinéa 2, a, pour objet de mettre au clair que la publication faite annuellement a le même effet que la publicité spéciale qui est faite en vertu de l'article 100-13 L.S.C. Cette disposition est utile quand les titres ne sont que partiellement libérés, et la publicité du retrait par l'associé permet donc à cet associé de se dégager de sa responsabilité à l'égard des tiers[2]. La publication de cette liste entraîne pour l'actionnaire la décharge de ses engagements pour la responsabilité future du cédant[3].

B – Obligations convertibles

L'obligation convertible est celle dont le propriétaire peut demander la conversion sans mise de fonds supplémentaire en une ou plusieurs actions de la société émettrice de l'emprunt soit pendant une période d'option déterminée, soit à tout moment pendant la durée de l'emprunt émis.

D'une part, le détenteur de l'obligation bénéficie en un premier temps de tous les avantages attachés à une obligation ordinaire. D'autre part, il a la possibilité de devenir (à son choix) actionnaire en abandonnant sa qualité d'obligataire. Dorénavant, il aura donc le statut d'actionnaire.

Les obligations convertibles (en actions) sont un instrument de **financement hybride** dans la mesure où, tout en détenant des obligations (donc des instruments de dette), celles-ci ont vocation à devenir (éventuellement) des actions plus tard. Cette possibilité de conversion a une incidence considérable sur l'évaluation des titres en question. La faculté de conversion fait que les titres visés sont des actions potentielles dans la mesure où, tant qu'elles ne sont pas converties, elles ont tout le potentiel d'appréciation de ces actions, mais sans en avoir le potentiel de perte (de dépréciation).

Les obligations convertibles peuvent donc être émises par la société ; une telle émission donne lieu à certaines formalités pour la raison que les obligations sont potentiellement des actions, avec donc la conséquence qu'une telle émission doit respecter les droits des actionnaires existants qui doivent pouvoir être protégés contre une dilution des droits qu'ils ont dans la société.

L'article 420-27 [anc. art. 32-4] L.S.C. prévoit que « *les articles 420-22, 420-23 à l'exception de son paragraphe 6 et 420-26 sont applicables à l'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre […]* ».

À première vue, cette disposition peut surprendre dans la mesure où elle rend applicables les dispositions concernant l'augmentation du capital social aux cas où, en fait, il n'y a pas d'augmentation de capital : cette augmentation se produit en effet plus tard seulement, donc au **moment de la conversion**. Toutefois, à la réflexion, cette solution se justifie entièrement dans la mesure où le moment auquel il convient de protéger les actionnaires actuels est bien celui où les obligations convertibles sont

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 173, ID 11305.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 173, ID 11305.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 110, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

émises. En effet, c'est à ce moment-là que la décision de la dilution potentielle est prise. Une fois cette émission d'obligations faite, la réalisation de l'augmentation de capital échappe aux actionnaires, et la question de savoir jusqu'à quel point cette augmentation aura effectivement lieu dépend de facteurs incontrôlables, en tout cas par les associés existants. Il s'agit des décisions des différents détenteurs des obligations qui, chacun pour soi, décideront de convertir ou non. Ces décisions sont avant tout influencées par les évolutions actuelles et prévues du cours boursier des actions de la société.

« *En effet, lors de l'émission d'obligations convertibles ou de warrants, on prend déjà la décision d'augmenter le capital, mais la réalisation aura lieu ultérieurement. On pourrait donc comparer cette situation avec une augmentation de capital en deux phases où le courant majoritaire estime que la décision d'augmenter le capital, tout comme la réalisation de l'augmentation de capital, doit être constatée dans un acte authentique* »[1].

La décision de l'assemblée générale (le cas échéant, celle du conseil d'administration) doit être constatée dans un acte authentique en application de l'article 32-4 L.S.C.

L'émission d'obligations convertibles se traduisant par une possible augmentation de capital (au moment de la conversion effective des obligations), les actionnaires existants bénéficient d'un droit préférentiel de souscription en application de l'article 420-26 (anc. art. 32-3) L.S.C. rendu applicable à ce cas de figure par l'article 420-27 (anc. art. 32-4) .S.C.

Le DPS peut être limité de la même manière qu'en cas d'émission d'actions supplémentaires.

L'émission d'obligations convertibles peut être décidée par le conseil d'administration, mais à condition que les statuts lui accordent expressément ce pouvoir. Il s'agit d'une application de la notion de capital autorisé.

Par le passé, l'émission d'obligations convertibles a donné lieu à une difficulté portant sur la nécessité (ou non) d'un rapport du réviseur d'entreprises. Certains argumentent que l'article 32-4 L.S.C., en rendant les articles 32, 32-1 et 32-3 L.S.C. applicables en matière d'émission d'obligations convertibles, exigerait l'établissement d'un rapport du réviseur d'entreprises. En effet, l'article 32-1 L.S.C. exige, en cas d'augmentation de capital par apport en nature, qu'il y ait un rapport du réviseur d'entreprises (conformément à l'article 26-1 L.S.C.). En cas de conversion d'obligations convertibles, il y aurait conversion en capital-actions d'une créance sur la société : l'établissement d'un rapport de révision serait donc nécessaire.

L'opération consistant dans la conversion en capital d'une **créance certaine, liquide et exigible** que l'apporteur possède contre la société était à considérer comme un apport autre qu'en numéraire[2].

La Loi de Modernisation (en suivant le projet de loi 5730 avec son commentaire relatif à l'article 32-4 L.S.C.) a pris soin de préciser que désormais les émissions d'obligations convertibles ne sont pas à considérer comme apport en nature et

1 – C. Croes, « Obligations convertibles et warrants : description du cadre juridique belge », *R.P.S.*, 1995, p. 359.

2 – V. la note interprétative de l'article 26-1 L.S.C., ID 7520, établie par le groupe de travail « Droit des sociétés » de la Commission d'études législatives, de 1994.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

échappent donc à l'obligation de l'intervention d'un réviseur d'entreprises. « *La conversion d'obligations convertibles est à considérer comme un apport en numéraire libérable par compensation avec une créance sur la société et sera soumise aux conditions d'un tel apport* » (alinéa 3 de l'article 420-27 L.S.C.). De ce fait a été reprise la solution qui a depuis longtemps prévalu tant en Belgique (art. 592 Code belge des sociétés) qu'en France (art. L. 228-7 Code de commerce).

Il est précisé par cet article que l'émission d'obligations convertibles est traitée comme une augmentation de capital (ce qui rend donc applicables les articles 420-22 L.S.C. [concernant les règles sur les augmentations de capital], l'article 420-23 L.S.C. et l'article 420-26 L.S.C. [droits préférentiels de souscription], et ceci, **au moment de l'émission des obligations,** et donc pas au moment de la conversion de ces obligations. Même si l'augmentation de capital se réalise uniquement au moment de la conversion effective, il convient de ne pas perdre de vue que la décision d'augmentation de capital est prise déjà au moment de l'émission des obligations convertibles : c'est donc à ce moment que les conditions de fond d'une telle augmentation de capital doivent être réunies. Cette solution (qui au demeurant est logique) est en fait imposée par le droit de l'Union européenne : l'article 29 de la Deuxième directive traite les émissions d'obligations convertibles comme des émissions d'actions : aux termes de l'article 33, paragraphe 6, de la directive 2012/30/UE « *Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription* ».

Pour le cas où l'émission des obligations convertibles a lieu en application d'une décision relative au capital autorisé, la L.S.C. précise que la décision d'émettre les obligations convertibles doit être prise pendant la période de l'autorisation, alors que la conversion de ces obligations en actions ou encore l'exercice des droits de souscription peut avoir lieu après la fin de la période d'autorisation. Cette décision diminuera à due concurrence le montant disponible du capital autorisé (art. 420-27, dernier alinéa L.S.C.). Il y a lieu de noter que cette disposition ne résout pas tous les problèmes[1].

La Loi de Modernisation (art. 420-27, alinéa 1, L.S.C.) a encore introduit la possibilité d'émettre des **droits de souscription autonomes**, donc non attachés nécessairement à un titre, cette possibilité ayant encore été reprise du droit belge (art. 496-592 du Code des sociétés relatifs aux droits de souscription qui peuvent, selon l'article 496, être attachés à un titre ou isolés, donc autonomes).

L'émission de « **bons de caisse** » permet à un commerçant, particulier ou société de se procurer les fonds nécessaires à sa trésorerie ou au financement de certaines opérations, chaque titre représentant un prêt déterminé, isolé et remboursable à échéance fixe. Les bons de caisse ne peuvent être assimilés aux obligations du fait que, d'une part, ils ne font pas partie d'une émission globale d'un montant total déterminé et que, d'autre part, ils ne sont pas offerts au public pour un montant uniforme, tel que chacun d'eux constituerait une fraction égale de l'ensemble de l'émission. Bien qu'émis en même temps et pour les mêmes échéances, ils ne portent cependant nullement sur des montants identiques, et

1 – Pour plus de détails, v. P. Hoss et L. Schummer, *Les obligations convertibles, Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, 2016, pp. 443 *ss*.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

les taux d'intérêt diffèrent. Ces bons représentatifs de dépôt à court ou à moyen terme sont en réalité de véritables prêts, dont la conclusion évite au commerçant, moyennant le versement d'un montant plus élevé, les aléas de la restitution des dépôts à vue et lui permet de mobiliser facilement ces emprunts. Un tel bon à échéance fixe est un **effet de commerce,** et non pas une valeur mobilière. Si le titre est au porteur, il faut en principe que le débiteur s'en soit dessaisi. Il s'ensuit que, si le signataire d'un tel titre l'avait conservé jusqu'à la faillite, son engagement ne pourrait être invoqué par le bénéficiaire. La situation serait différente si le bénéficiaire avait été informé par le débiteur de la souscription de l'engagement constaté par le titre. Dans cette hypothèse, la volonté du débiteur se serait, en effet, suffisamment extériorisée[1].

Cette opération soulève encore de redoutables problèmes d'évaluation, notamment dans le cas où la société bénéficiaire de cet apport est dans une situation financière difficile, notamment en raison de pertes subies avant cette opération.

Bilan XY S.A.

Actif	**Passif**	
Participation : 1500	Capital :	1 000
	Dettes :	500

Il est prévu de convertir en capital la créance de 500 détenue par une personne non actionnaire actuellement, mais qui deviendra actionnaire en raison de cette conversion, étant entendu que l'intention est que le réviseur doit évaluer la valeur de la société, concrètement donc la valeur du seul actif, la participation d'une valeur de 1500. Si cette valeur est de 1500 (au moins), on peut en conclure que la créance a une valeur de 500, car elle sera sans problème remboursée dans son intégralité par la vente de la participation. Même si la valeur de la participation est légèrement inférieure, la créance aura une valeur de 500 pour la raison que les créanciers sont privilégiés par rapport aux actionnaires, et ils seront donc servis avant ces derniers.

La conclusion sera différente seulement à partir du moment où la valeur de la participation est inférieure à 500 : dans ce cas, la créance ne sera plus entièrement payable, mais payable seulement pour trois cinquièmes (si tant est que la valeur de la participation est de 300 seulement). Certains concluent de cette situation qu'il faudrait considérer que l'augmentation de capital sera de 300. Cette conclusion est néanmoins erronée pour la raison que ceci voudrait dire que l'on aurait des actifs de 300 qui sont à partager par des actionnaires ayant des actifs correspondant à 1 300.

Le taux de couverture sera donc de 300/1 300 = 0,2308 (ou 23,08 %)

Ce taux étant nettement inférieur à 60 %, il y a eu émission de trop de capital par rapport aux actifs qui sont ceux de la société.

1 – TA Lux. du 23 décembre 1987, n° 643/87, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La solution de ce problème est donnée par la résolution d'une équation au deuxième degré :

$\frac{300}{1\,000 + 500x} = x$	
	X = nominal à émettre
$300 = x\,(1\,000 + 500x)$	
$300 = 1000x + 500x^2$	: 500
$0{,}6 = 2x + x^2$	
$x^2 + 2x - 0{,}6 = 0$	$X = \frac{+b +/- \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
$X = \frac{+2 +/- \sqrt{4 - 4(-0{,}6)}}{2}$	
$X = \frac{+2 - \sqrt{6{,}4}}{2}$	
$X = \frac{-2 + 2{,}529}{2}$	
X = 0,2645	
Titres à émettre : 500 x 0,2645 = 132,25	
Donc 1.132,25	
Preuve : 300/1,13225 = **26,50 %**	

Pour répéter la même chose dans un langage moins ésotérique : l'équation au second degré nous a servi à déterminer le nombre de titres de capital à émettre afin que les anciens titres et les nouveaux titres à émettre représentent exactement la même proportion dans les actifs de la société. En l'occurrence, cette proportion est de 26,50 %. En émettant des actions dans cette proportion-là (appliquée au montant nominal de la créance), on arrive à une émission d'actions qui correspond à 132,25 (26,50 % du nominal de créance de 500). Ce taux est exactement celui qui permet de traiter les actions nouvelles et anciennes de la même façon, en leur accordant donc des actifs dans les mêmes proportions. Si l'on émettait moins de titres, les actionnaires nouveaux seraient spoliés, car ils n'auraient pas eu suffisamment de titres par rapport aux actifs de la société.

C – Obligations à warrants

Par warrant, on entend une **option d'achat** qui permet de souscrire des actions. Par obligations à warrant, on entend donc des obligations comprenant un « *equity kicker* » et dont le cours boursier est dans une large part tributaire

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de l'évolution des cours boursiers des actions que les warrants permettent de souscrire.

Le détenteur de l'obligation convertible ne peut devenir actionnaire que s'il abandonne sa qualité d'obligataire. La situation est différente à l'égard des obligations à warrant. Elles sont composées de deux éléments distincts qui peuvent parfaitement être séparés, dans la mesure où le warrant, représenté par un coupon détachable, peut circuler séparément de l'obligation et même faire l'objet d'une cotation distincte. Une autre différence avec l'obligation convertible est que, lors de la conversion, aucune mise supplémentaire n'est exigée de la part du détenteur de l'obligation. Le détenteur du warrant est tenu de payer le prix d'exercice du warrant pour pouvoir prétendre à la qualité d'actionnaire de la société émettrice de l'obligation à warrant.

En droit luxembourgeois, il n'existe pas de réglementation spécifique consacrée à ce type d'instruments. Il reste néanmoins possible d'émettre de telles obligations, et ceci, en profitant de la liberté contractuelle. La loi en reconnaît expressément la validité en se référant, dans son article 420-27 L.S.C., « *à la conversion d'obligations convertibles et de tous autres instruments de créance convertibles en capital ainsi qu'à l'exercice de droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre* ». Cet article rend donc applicables aux obligations à warrant exactement le même régime juridique que celui accordé aux obligations convertibles (v. ci-dessus).

D – Autres titres de créances (PECs, bonds et notes)

En application de la liberté contractuelle il est loisible à toute société d'émettre des titres autres que des actions ou des obligations. La L.S.C. (pas plus que les lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales) ne comporte aucune limitation relative aux titres qui peuvent être émis par une société. La jurisprudence n'applique pas une théorie du genre de celle des « *cadres légaux obligatoires* ».

Les droits attachés à ces titres ne dépendent que des conditions d'émission. Les seules limites à respecter sont donc celles des dispositions d'ordre public ou impératives[1].

La pratique a surtout recours à ce qu'on appelle, de façon fort inopportune d'ailleurs, les ***Preferred Equity Certificates***. Cette désignation est inopportune pour la raison que ces « *Equity Certificates* » sont en fait des titres de dette, et donc des « *Debt Certificates* », lorsqu'on les envisage du point de vue luxembourgeois : or, l'émetteur étant une société luxembourgeoise, il va de soi que tel est le point de vue qui devrait être adopté pour dénommer cet instrument.

Ces certificats peuvent d'ailleurs être convertibles, ce qu'on exprime alors par le terme de CPECs (*Convertible PECs*). Le fait qu'ils puissent être convertis en fonds propres prouve bien qu'au départ il ne s'agit pas de fonds propres.

De tels instruments sont émis non seulement par des sociétés anonymes, mais plus souvent encore par des sociétés à responsabilité limitée. La raison de cet état des choses est que ce sont souvent les investisseurs américains qui ont recours à

1 – C. Croes, « Obligations convertibles et warrants : description du cadre juridique belge, *R.P.S.*, 1995, p. 347.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ces instruments et que ceux-ci constituent presque toujours des sociétés à responsabilité limitée[1].

Par cette expression, on désigne des instruments de nature hybride qui ont tant des caractéristiques de dettes que de fonds propres. Par conséquent, ils peuvent être considérés comme des instruments de dettes (à l'instar des obligations au Luxembourg), alors que, dans l'État du souscripteur de ces instruments, ils sont considérés comme des titres de capital (en tant qu'actions). Il s'agit de titres de dettes émis par une société luxembourgeoise, souvent subordonnés par rapport aux autres débiteurs, et qui sont parfois liés (« *stapled* ») aux titres de capital. Concrètement, pour chaque action d'un nominal de X, il y a également émission de 10 ou 100 PECs. Le cas échéant, ces titres sont convertibles, ce qui les rapproche encore des fonds propres.

Par conséquent, ces titres de dettes, dans la mesure où il s'agit du prolongement des titres de capital, permettent en fait d'obtenir un traitement correspondant à un traitement de dettes au Luxembourg pour la plus grande partie de l'investissement effectué, tout en évitant en fait les inconvénients normalement liés à des investissements en titres de dettes. En effet, ces titres de dettes étant le prolongement de titres de capital, chaque associé subit exactement la même « *dilution* », de sorte que tout un chacun se trouve dans la même situation, comme si l'intégralité des investissements avaient été faits en titres de capital. La déduction dans le chef de la société émettrice luxembourgeoise de la rémunération de ces certificats est de façon générale acquise. En outre, en tant que titres de dettes, ces certificats échappent à tout droit d'apport et à tout impôt sur la fortune (dans le chef de l'émetteur). Le statut juridique de ce type d'instrument financier a fait récemment l'objet d'une procédure judiciaire dans l'**affaire *Hellas***[2].

La loi belge, contrairement à celle du Luxembourg, connaît la notion de **Certificats de participation au capital (CPC**). Il s'agit de valeurs mobilières prévues par l'article 47 des lois coordonnées, sans droit de vote, et émises en rémunération d'un apport en espèces qui n'est pas incorporé au capital social, mais qui donne droit à un dividende, qui peut être préférentiel, et à une quote-part du boni de liquidation[3].

SECTION III
LES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

En tant que personne morale, la société anonyme ne peut agir que par ses organes. Dans la structure classique sont visés le conseil d'administration (ou encore le directoire et le conseil de surveillance), le cas échéant, l'administrateur délégué, l'assemblée des actionnaires, le commissaire (dans la mesure où il n'est pas écarté au profit du réviseur d'entreprises).

La **loi du 25 août 2006** (projet de loi n° 5352) a repris en droit luxembourgeois les dispositions de la SE en laissant aux sociétés anonymes le choix entre la structure

1 – Pour des raisons fiscales : la réglementation dite « *check the box* » est la cause de cette préférence.

2 – TA Lux du 23 décembre 2015, n° 145724 et 145725 du rôle, ID 24088.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990), *R.C.J.B.*, 1993, p. 744.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

moniste traditionnelle (le conseil d'administration) et la structure dualiste comprenant un directoire (« *Vorstand* ») et un conseil de surveillance (« *Aufsichtsrat* »).

Ce système s'ajoute donc au système moniste traditionnel dans la mesure où, par le passé, il n'existait qu'un **seul organe de gestion** de la société. Actuellement, les fondateurs de la société ont donc le **choix** entre les deux solutions pour organiser la gestion de leur société. Nous allons décrire ci-après les deux solutions.

■ § 1 – Le conseil d'administration

Il convient de noter d'emblée que c'est le conseil d'administration qui est l'organe de gestion de la société, et non pas les administrateurs pris individuellement[1]. En effet, l'administrateur agissant isolément n'a aucun pouvoir d'action individuelle, seul le collège des administrateurs est un organe de la société. « *Il s'ensuit que la seule qualité qui puisse être reconnue à la personne physique, administrateur ou non, à qui les statuts confèrent des pouvoirs spéciaux est celle de mandataire de la société*.

Mandataire de la société, car cette dernière seule est la personne juridique susceptible de conclure la convention de mandat »[2].

A – Composition du conseil d'administration

L'administration de la société est confiée à un seul organe qui est le conseil d'administration comprenant au moins **trois administrateurs** (article 441-2 [anc. art. 51] L.S.C.), alors qu'une société à responsabilité limitée peut être gérée par un ou plusieurs gérants (article 710-14 L.S.C.).

Le minimum de trois administrateurs (sauf exception) se comprend facilement : s'agissant d'un **organe délibérant**, un minimum de participants est requis et un nombre impair est utile pour éviter les situations de blocage.

1) Le choix des administrateurs

La L.S.C. soumet l'accès aux fonctions d'administrateurs à une seule condition, à savoir celle d'être nommé par une assemblée générale à laquelle tous les associés sont convoqués. Cette condition est d'ordre public avec la conséquence que toute clause qui réserverait la désignation à une seule catégorie d'actions serait nulle[3]. Il est loisible aux statuts de préciser que seules les personnes remplissant des conditions déterminées (p. ex. celles d'exercer une profession donnée ou encore d'appartenir à une nationalité déterminée) puissent devenir administrateurs.

Les clauses régissant (c.-à-d. donc limitant) le choix des administrateurs doivent, selon la doctrine belge, répondre à deux conditions :

– respecter **l'esprit de collaboration** et d'égalité entre associés (*jus fraternitatis*) ; une clause statutaire incompatible avec cette exigence serait nulle[4] ;

1 – Cass. b. du 15 octobre 1959, *Pas.*, 1960, I, p. 193.

2 – L. Simont et P. van Ommeslaghe, Cour de cassation du 17 mai 1962, *R.C.J.B.*, 1964, p. 83.

3 – V. J. Heenen, « Le choix des actionnaires », *R.P.S.*, 1956, p. 65.

4 – V. J. Heenen, « Le choix des actionnaires », *R.P.S.*, 1956, p. 69.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– laisser un **choix effectif** à l'assemblée générale[1].

Il faut que l'assemblée dispose toujours d'un choix effectif. La nomination d'un administrateur exige une délibération préalable, condition qui ne serait pas remplie si les statuts définissaient les personnes éligibles en termes tellement restrictifs que tout choix véritable serait exclu.

Est-ce qu'une **personne morale** peut être administrateur de société ? Par le passé, cette question était controversée, controverse qui fut toutefois éliminée par la Cour de cassation belge en 1962[2]. Selon la haute juridiction, ni la loi ni la nature de la société anonyme n'excluent que celle-ci soit administrateur dans une autre société anonyme. Cette solution peut être étendue à toutes les autres formes de sociétés, et ceci, par identité de motif[3].

Cette société agit donc par ses propres organes qui sont donc des personnes physiques.

Le législateur luxembourgeois vient de consacrer expressément cette possibilité pour les sociétés anonymes de devenir administrateur de sociétés, et ceci, en amendant l'article 51*bis* (nouv. art. 441-13) L.S.C. en précisant que, dans ce cas de figure, la personne morale nommée comme administrateur est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. La même solution est consacrée par l'article 60*bis* (nouv. 441-13) L.S.C. à l'égard des membres du directoire.

2) Nombre d'administrateurs

À l'instar de la loi belge, notre loi demande traditionnellement trois administrateurs (au moins). Cette solution est pourtant loin d'aller de soi. En effet, l'avant-projet de Nyssens n'avait pas repris la solution de la loi belge de 1873 (minimum de trois) pour rejoindre les lois française, hollandaise, allemande, suisse, italienne, etc. qui n'avaient pas prévu un tel minimum. Cette proposition ne fut pas retenue par la Loi de 1915.

Cette règle traditionnelle a été assouplie par la loi du 25 août 2006 qui a permis à une **S.A. unipersonnelle** constituée en tant que telle depuis le départ d'avoir un « *conseil* » d'administration n'ayant qu'un **seul membre**. Il en va de même dans le cas d'une assemblée générale des actionnaires pour laquelle il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique (art. 441-2 L.S.C.).

La Loi de Modernisation dans sa version initiale avait entendu reprendre la disposition de droit belge permettant à une société anonyme ayant deux actionnaires de n'avoir que **deux administrateurs** (au lieu de trois selon la version antérieure de cet article). Cette solution n'a toutefois pas été retenue par la version finalement adoptée, et ceci, à juste titre (selon nous).

Lorsque le nombre des administrateurs en fonction n'atteint pas le nombre prévu par les statuts (en l'occurrence, les statuts exigent un minimum de 5 administrateurs alors que, suite à la démission de trois administrateurs et la cooptation d'un administrateur, seul le minimum légal mais non le minimum statutaire était atteint),

1 – V. J. Heenen, « Le choix des actionnaires », *R.P.S.*, 1956, p. 68.

2 – Cass. b. du 17 mai 1962, *R.P.S.*, 1962, p. 253.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 176.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la conséquence en est l'annulation des décisions prises par le conseil d'administration[1].

3) Nomination des administrateurs

Le conseil d'administration est nommé par l'organe souverain de la société, à savoir donc par **l'assemblée des actionnaires** (art. 441-2 L.S.C.), sauf que le premier conseil d'administration peut être désigné par l'acte constitutif. La nomination des administrateurs est faite par l'assemblée générale ordinaire, celle qui approuve les comptes annuels, décide de l'affectation des résultats et accorde décharge aux administrateurs pour leur gestion passée. Par exception à ce principe, les administrateurs peuvent, pour la première fois, être nommés par l'acte de constitution de la société. Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans. Le législateur a fixé une durée maximale du mandat en considérant que la possibilité de révocation par l'assemblée pourrait ne pas suffisamment protéger les actionnaires. En effet, ces derniers hésitent à révoquer un administrateur, mais décident beaucoup plus facilement de ne pas renommer un administrateur dont le mandat arrive à sa fin[2].

Leur mandat peut toutefois être renouvelé, sauf dispositions contraires des statuts (art. 441-4 L.S.C.). Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins en principe (depuis la loi du 25 août 2006, cette règle n'est plus absolue).

Il a été jugé que, si les **publications** des nominations d'administrateurs (prévues par les articles 100-10 et 100-13 L.S.C.) n'ont pas été effectuées dans les délais légaux, les tiers ont le droit de leur dénier le pouvoir d'engager la société. Selon la cour d'appel, cette règle de rigueur ne serait toutefois applicable que si la société intente une action. En revanche, lorsque la société est assignée, elle est habilitée à se défendre même si les publications légales ne sont pas encore faites[3].

Ils peuvent n'avoir qu'une capacité limitée (mineur, p. ex.). La loi ne prévoit pas de limite d'âge ; en outre, il n'existe pas de limite au nombre de mandats d'administrateurs qu'une personne peut détenir, contrairement à ce qui est la règle dans d'autres États. Ainsi, en France, une personne physique ne peut appartenir à plus de 8 conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en France[4].

a) Nomination d'une partie des administrateurs par le personnel

Pour les sociétés anonymes occupant habituellement au Grand-Duché au moins 1 000 salariés au cours des trois dernières années, l'article L. 426-1 du Code du travail exige que le personnel soit représenté au conseil d'administration. Les

1 – TA Lux. du 30 janvier 1998, n° 46.142, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 184, ID 11305.

3 – CA du 12 juillet 2006 (réf.), n° 31.092, *BIJ*, n° 9, 2006, p. 234.

4 – Art. 91-1 de la loi de 1966. V. I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, p. 493.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

salariés peuvent désigner un représentant par tranche de 100 salariés sans que leurs représentants puissent excéder un tiers du total des membres du conseil (article L. 426-3(2) du Code du travail). Il est à noter que ces sociétés ont obligatoirement un conseil d'administration de **9 personnes** au moins (de sorte que le plafond fixé pour les administrateurs désignés par les salariés est de trois administrateurs au moins). Ils cessent leurs fonctions au moment où la **personne morale de droit public** qui les a fait désigner aura notifié au conseil d'administration la révocation de leur mandat.

La personne morale de droit public assume les responsabilités qui incombent aux personnes désignées à sa demande en leur qualité d'administrateurs, sauf son recours contre elles en cas de faute personnelle grave. Les émoluments leur revenant sous quelque forme que ce soit sont touchés par l'État ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner ; il appartient au gouvernement en conseil ou à l'organe dirigeant de la personne morale de droit public d'arrêter les indemnités à allouer à ces administrateurs pour l'accomplissement de leur mission.

Le même régime de participation s'applique aux sociétés anonymes dans lesquelles l'État détient une participation financière d'au moins 25 % ou encore celles auxquelles l'État a consenti une concession « *portant sur l'activité principale* ». Les sociétés visées par cette disposition sont désignées par arrêté grand-ducal. Il s'agit actuellement de la CEGEDEL, LUXAIR, CLT et SES.

Les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la ou les délégations d'entreprise « *par vote secret à l'urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle, parmi les travailleurs occupés dans l'entreprise* »[(1)].

Par dérogation à ces règles, trois des administrateurs représentant le personnel des entreprises relevant de la sidérurgie sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives (art. L. 426-5 du Code du travail).

b) Statut des administrateurs représentant le personnel

En dehors de leur mode de nomination qui déroge à l'article 441-2 L.S.C., les administrateurs désignés par le personnel ont un statut identique à celui des autres administrateurs. Ils ont donc les mêmes droits et obligations que ceux désignés par le mode normal, donc par les actionnaires regroupés en assemblée générale. La loi précise expressément que leur responsabilité se détermine selon le droit commun et notamment selon l'article 441-9, alinéa 2, L.S.C.[(2)].

Il est encore précisé par la loi que le salarié siégeant en tant qu'administrateur ne peut être licencié sans l'autorisation de la juridiction compétente pendant la durée de son mandat d'administrateur (sauf la possibilité, en cas de faute grave, de faire l'objet d'une procédure de mise à pied en attendant la décision de justice tranchant le cas)[(3)].

1 – Art. L. 426-4 du Code du travail, ID 2555.

2 – C. Delvaux, *La société anonyme*, p. 285.

3 – Art. 30 de la loi du 6 mai 1974.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

4) Possibilité de cooptation d'administrateurs

Sauf disposition contraire des statuts, en cas de vacance d'un poste d'administrateur, la loi (art. 441-2 L.S.C.) prévoit une procédure spéciale de cooptation afin de pouvoir provisoirement nommer un administrateur en remplacement de celui qui a abandonné son poste. Peu importe la cause, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement à la place vacante. « *Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive* ». L'administrateur coopté achève alors le terme de celui qu'il remplace. D'après une certaine jurisprudence (il est vrai antérieure à la L.S.C.), « *si les statuts prévoient que le conseil peut coopter un administrateur, elles lui attribuent non pas la faculté de le faire mais l'obligation de ce faire si avant la réunion de l'assemblée générale le conseil est appelé à prendre une mesure qui exige une délibération en règle* »[1].

Cette faculté peut être exercée dans tous les cas de vacance de poste, quelle qu'en soit la cause ; il n'est pas nécessaire qu'il y ait urgence[2]. La cooptation est **obligatoire** dans le cas où, par suite de la vacance, le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal de trois administrateurs (pour autant qu'il s'applique encore, compte tenu de la loi du 25 août 2006).

Si la prochaine assemblée ne confirme pas le choix des administrateurs, l'administrateur coopté aura néanmoins valablement occupé son poste, et tout ce qu'il a pu faire dans le cadre de son mandat reste valable, que ce soit dans les relations internes ou externes de la société.

Comment faut-il procéder si **plusieurs postes** sont **vacants** ? Convient-il à ce moment de procéder par étapes ou faut-il procéder en une fois à la nomination de tous les administrateurs aux postes vacants ? Ainsi, s'il ne reste plus qu'un seul administrateur (et que le nombre requis est de trois), est-ce que ce dernier va procéder à la nomination d'un administrateur pour ensuite, ensemble avec l'administrateur coopté, procéder à la nomination du deuxième administrateur dans une deuxième étape ? La différence tient à ce que, dans le deuxième cas de figure, le premier administrateur coopté a le droit de participer à la désignation de l'autre membre coopté du conseil d'administration[3]. Le libellé de la loi est restrictif, de sorte qu'il est probablement prudent de procéder en deux étapes pour coopter deux administrateurs.

La cooptation n'est plus possible lorsqu'une assemblée d'actionnaires a été convoquée avec, à l'ordre du jour, la nomination d'administrateurs pour compléter justement le conseil d'administration. Dans un tel cas, la cooptation d'administrateurs par le conseil d'administration est exclue, et toute nomination faite dans ces conditions doit être considérée comme nulle[4]. C'est en quelque sorte le droit commun (selon lequel les associés désignent l'organe de gestion) qui reprend le dessus sur la solution de la cooptation qui est une solution d'exception, et donc applicable de façon restrictive.

1 – Trib. arb. du 2 avril 1898, *P.*, 4, p. 545.

2 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 384.

3 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 384.

4 – TA Lux. du 30 janvier 1998, n° 46.142, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

5) Rémunération des administrateurs

Aux termes de l'article 441-1 L.S.C. les administrateurs sont des mandataires à temps, salariés ou gratuits. Cette disposition doit être lue ensemble avec l'article 1986 C.c. selon lequel « *[L]e mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire* ». Nonobstant ce principe posé par le Code civil, il a de tout temps été reconnu que les mandats les plus importants sont en fait salariés et « *le salaire devient ainsi une condition essentielle du contrat de mandat de la même manière que le salaire est une condition essentielle du contrat de louage* »[(1)].

Comment la rémunération des administrateurs est-elle fixée ? Il y a quatre possibilités : soit les statuts précisent que les administrateurs sont rémunérés, soit ils fixent directement le montant de leur rémunération, soit ils excluent toute rémunération, soit enfin ils sont muets.

Lorsque les statuts se bornent à préciser que les administrateurs sont rémunérés, il appartient à un organe de la société de concrètement en déterminer le montant : cet organe peut être soit l'assemblée, soit le conseil d'administration lui-même. Dans l'hypothèse où les statuts fixent directement le montant de la rémunération, il peut encore y avoir plusieurs possibilités : soit il y attribution d'un **montant fixe** qui passe par frais généraux, soit il y a attribution de **jetons de présence** pour chaque assistance effective aux réunions, soit encore les administrateurs ont droit à une **part des bénéfices**, appelée « tantièmes ». Ces tantièmes sont répartis entre les administrateurs selon leurs convenances personnelles, à moins que les statuts n'en disposent autrement[(2)].

L'attribution de tantièmes (donc une partie des bénéfices), qui est rare en pratique, a pour avantage d'intéresser à la bonne marche des affaires ceux des administrateurs qui ne sont pas actionnaires. L'inconvénient en est de leur faire prendre souvent une attitude de maximisation des résultats à court terme, ce qui est dangereux.

Lorsque les statuts précisent que le mandat est gratuit, ni le conseil d'administration ni l'assemblée des actionnaires ne peuvent prendre de décision contraire. Si des rémunérations étaient payées en contravention aux statuts, tout actionnaire pourrait demander l'annulation de ces paiements[(3)].

En cas de **silence des statuts**, on considère majoritairement que l'assemblée générale a le droit d'allouer une rémunération aux administrateurs et d'en déterminer les modalités[(4)].

En application de l'article 1999 C.c., le salaire du mandataire n'est dû que s'il n'y a ni faute ni dol dans l'exercice du mandat. Par conséquent, l'administrateur d'une société n'a droit à une rémunération qu'après avoir obtenu la **décharge** de sa gestion (en théorie)[(5)].

Toujours selon l'article 1999 C.c., le salaire est dû même si l'affaire faisant partie du mandat n'a pas réussi, donc, par exemple, si la société est en perte.

1 – P.-A. Franck, « De la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes », *R.P.S.*, 1956, p. 145.
2 – P.-A. Franck, « De la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes », *R.P.S.*, 1956, p. 148.
3 – P.-A. Franck, « De la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes », *R.P.S.*, 1956, p. 149.
4 – P.-A. Franck, « De la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes », *R.P.S.*, 1956, p. 151.
5 – P.-A. Franck, « De la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes », *R.P.S.*, 1956, p. 152.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En principe, l'administrateur ne consacre pas son activité entière à la société. Il est donc parfaitement envisageable qu'un administrateur, pour des services déterminés qui ne font pas l'objet du mandat d'administrateur, reçoive une rémunération en plus des émoluments alloués par les statuts et l'assemblée générale.

Les administrateurs peuvent même toucher des rémunérations spéciales pour des actes relevant normalement de l'accomplissement de leur mandat (p. ex., le procès mené pour la société par l'avocat indépendant qui siège au conseil d'administration d'une société anonyme), à condition que les décisions de l'assemblée générale ou les statuts ne s'y opposent[1] pas.

B – Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration est l'organe de gestion de la société qui, en principe, concentre en ses mains la plénitude des pouvoirs de gestion.

1) Contenu de ces pouvoirs

Selon l'article 441-5, alinéa 1er, L.S.C., « *Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale […]* ».

Cette formule, introduite par la loi du 23 novembre 1972, basée sur la Première directive CEE en matière de droit des sociétés, est beaucoup plus large que celle contenue antérieurement dans la loi : l'ancien article 53 L.S.C. présumait que les fondateurs donnaient aux administrateurs seulement le « *pouvoir de faire tous les actes d'administration et de soutenir toutes actions au nom de la société* ». Le conseil d'administration n'avait donc que le pouvoir de faire les seuls **actes d'administration,** notion assez restrictive ayant pour conséquence que ses pouvoirs étaient beaucoup moins étendus que ceux des gérants des sociétés de personnes[2].

L'article 1988 C.c. fonde une distinction entre actes d'administration et actes de disposition en matière de mandat. Dans le sens de cette disposition, « *l'acte d'administration est tout acte qui tend à gérer, à administrer, à l'exclusion de tout acte impliquant à un titre quelconque, une disposition de la chose elle-même*. *Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration*. *S'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès* ».

La délimitation exacte de cette notion (question de fait dont la solution dépendait de la nature de l'entreprise[3]) donnait souvent lieu à des difficultés, de sorte qu'en pratique les statuts donnaient aux organes d'administration les pouvoirs d'accomplir **tous les actes** intéressant la société[4].

En vertu de la disposition légale actuellement applicable (art. 441-5 L.S.C.), la distinction entre actes d'administration (autorisés) et actes de disposition (non autorisés), qui était souvent fort malaisée, n'est plus de mise. « *Le conseil*

1 – V. P. Demeur sous Trib. com. Bruxelles du 22 mars 1930, *R.P.S.*, 1932, p. 143.

2 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 393.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 182, ID 11305.

4 – M. van der Haegen et C. Verbraeken, « L'adaptation de la législation belge à la Première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.*, 1974, p. 131.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale […]

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil d'administration et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de [la Loi de 2002] ».

L'article 9 de la Première directive dispose que : « *1. La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ces organes, même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social de cette société, à moins que lesdits actes n'excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la société n'est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l'objet social, si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 2. Les limitations aux pouvoirs des organes de la société, qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents, sont toujours inopposables aux tiers, même si elles sont publiées […]* ».

La société est donc tenue par les actes accomplis par les organes, à moins que ceux-ci n'excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes. Les limites imposées sont donc celles que trace la loi : les compétences irréductibles que la loi réserve à l'assemblée générale « *sont la nomination et la révocation des administrateurs et des commissaires, la décharge à leur donner ou au contraire la décision d'exercer l'*actio mandati*, le vote du bilan et de l'emploi des bénéfices, la modification des statuts et l'émission d'obligations convertibles. Comme antérieurement, l'assemblée générale ne peut ni se substituer au conseil d'administration ni écarter ses actes* »[1].

Par conséquent, sont devenues inopposables aux tiers (tout en restant valables dans les relations internes) les limitations suivantes qui, dans le droit antérieur à la Première directive, étaient parfaitement valables :

- celles qui restreignent les pouvoirs du conseil d'administration en tant qu'organe collégial ;
- celles qui prévoient une répartition des tâches entre les différents administrateurs ;
- celles qui limitent les pouvoirs d'administration journalière si cette administration est confiée à une personne ;
- celles qui subordonnaient certains actes relevant du conseil d'administration à une approbation préalable de l'assemblée générale[1].

1 – M. VAN DER HAEGEN et C. VERBRAEKEN, « L'adaptation de la législation belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.*, 1974, p. 131.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En premier lieu, ces limitations sont entièrement valables dans les relations internes qui lient les administrateurs à la société : en ne respectant pas les limitations ainsi prévues, les administrateurs engagent leur responsabilité personnelle.

Ces limitations sont **inopposables aux tiers,** avec donc la conséquence que la société ne peut se prétendre déliée par les engagements pris, dans la mesure où ceux-ci auraient été pris en dépassant les pouvoirs accordés aux administrateurs.

Reste la question de savoir si les tiers, dans l'hypothèse d'un contrat qui leur est défavorable, ne peuvent pas se prévaloir du dépassement des pouvoirs pour sortir du contrat. Dans la L.S.C., dans sa forme précédant les directives européennes, la société pouvait empêcher cette conséquence que le tiers renie les engagements contractuels en **ratifiant** rétroactivement l'acte accompli par son conseil d'administration. Cette ratification était en principe valable, sauf si l'acte visé devait intervenir dans un délai de rigueur[1].

Sous la nouvelle réglementation, il paraît que les tiers ne peuvent pas se prévaloir de ce dépassement des pouvoirs : plus que d'une inopposabilité, il s'agirait d'une inefficacité vers l'extérieur. Tout effet leur serait donc dénié dans les relations externes ; les seuls effets de telles limitations se situeraient donc sur le plan interne[2].

2) Délégation générale des pouvoirs de représentation

Alors que, sous la législation antérieure, on considérait que toute délégation générale du pouvoir de représentation du conseil d'administration était interdite et que seules des délégations spéciales étaient autorisées[3], la possibilité d'une telle délégation générale est expressément prévue par la directive et reprise par la loi luxembourgeoise (comme par la loi belge). Il est toutefois requis que cette délégation soit **générale**[4]. De plus, elle doit être faite à l'un ou l'autre **administrateur**, selon le texte de la loi. Par conséquent, la clause des statuts prévoyant la délégation à un administrateur et à un directeur ne devrait pas être conforme à la loi dans la mesure où elle implique une limitation du pouvoir de délégation à l'administrateur par l'intervention nécessaire d'un directeur. En réalité, la directive a permis d'autoriser la délégation du pouvoir de représentation également à des personnes autres que le directeur. Cette faculté n'a pas été utilisée par le législateur luxembourgeois, pas plus que par son homologue belge[3]. Néanmoins, la Cour de cassation belge a considéré comme conforme à la loi belge la disposition selon laquelle la société est représentée par la signature conjointe d'un administrateur et d'un directeur sous les termes suivants : « *la loi permettant de confier le pouvoir de représentation d'une société anonyme à un seul administrateur, rien ne s'oppose à ce que les statuts de la société prévoient pour cette représentation une garantie*

1 – M. van der Haegen et C. Verbraeken, « L'adaptation de la législation belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.*, 1974, p. 131.

2 – L. Simont et P. van Ommeslaghe, « Revue de jurisprudence belge », *R.C.J.B.*, 1964, p. 78.

3 – M. van der Haegen et C. Verbraeken, « L'adaptation de la législation belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.*, 1974, p. 131.

4 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 375.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

supplémentaire, consistant dans la signature d'un agent, tel un directeur »[1]. C'est à juste titre que cet arrêt est critiqué en doctrine pour être non conforme aux objectifs de la directive dont le but était de protéger les tiers en les dispensant de recherches complexes sur les pouvoirs de représentation des organes des sociétés avec lesquelles ils ont des contacts. « *En principe, le pouvoir de représentation appartient en totalité au conseil d'administration suivant l'article 53, alinéa 1er et il ne peut être délégué que dans les conditions restrictives prévues par l'article 54, alinéa 3*[2]*. On ne peut s'écarter de ces conditions, ni modifier la délégation du pouvoir de représentation* »[3].

On considère que la disposition de l'article 441-5 quatrième alinéa (anc. art. 53 (2)) L.S.C. qui donne pouvoir de représentation « *dans les actes ou en justice* » *serait à lire* « *dans les actes et en justice* »[4] : l'interprétation littérale ne conduirait pas à une délégation générale.

D'après la jurisprudence luxembourgeoise[5] : « *La personne morale est, par conséquent, engagée par les actes accomplis par son organe, ce dernier exprimant directement et immédiatement la volonté de la société.*

À la différence d'un mandataire, l'organe ne représente pas la personne morale, il "est" la personne morale. Par application de la théorie de l'organe, les dirigeants sociaux agissant au nom de la société n'ont, par conséquent, pas à produire de procuration pour établir leurs pouvoirs, mais il leur suffit de prouver que leur qualité de dirigeant social est régulièrement publiée (cf. art. 12, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915). Lorsque les statuts font usage de la faculté prévue à l'article 53, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, et donnent qualité à un ou plusieurs des administrateurs de la société pour représenter celle-ci dans ses actes – tel en l'espèce l'article 5 des statuts de GAUDAN S.A. –, les administrateurs concernés n'ont, de même, pas à prouver l'existence d'un mandat spécial que le conseil d'administration leur aurait conféré, leurs pouvoirs de représentation résultant directement de la publication afférente au Mémorial*. Toujours dans le souci de la sécurité des relations juridiques, le pouvoir de représentation générale de l'article 53, alinéa 4, de la loi porte nécessairement sur la totalité des pouvoirs de représentation du conseil d'administration, et ne peut être limité à certains actes seulement.*

Il est vrai que l'article 53, alinéa 4, de la loi modifiée du 10 août 1915 ne confère aucun pouvoir de gestion autonome à l'administrateur, la décision continuant à devoir être prise par le conseil d'administration, l'administrateur ne faisant que transposer cette décision dans l'ordre externe.

Les tiers, par contre, n'ont pas à vérifier si le conseil d'administration a effectivement pris la décision en question, cette décision étant présupposée dans la loi ».

---

1 – Cass. du 22 décembre 1977, *R.P.S.*, 1978, p. 191, et *Pas.*, 1978, I, p. 472.

2 – La disposition correspondante au Luxembourg est l'article 441-5 L.S.C., ID 7520.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 376.

4 – Cette interprétation résulterait des travaux préparatoires de la loi belge (identique à loi luxembourgeoise sur ce point) ; M. van der Haegen et C. Verbraeken, « L'adaptation de la législation belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.*, 1974, p. 131.

5 – Arrêt de la Cour d'appel du 4 juin 2008, nos 31798 et 32953 du rôle, ID 15890.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

3) Limitations aux pouvoirs des organes

Art. 441-13 [anc. art. 60*bis*] L.S.C. :
« *La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 441-5, alinéa 4, par les membres du comité de direction ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 441-11, alinéa 3, par le directeur général ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve* ».

Quant aux actes accomplis par les organes, les limitations statutaires ou conventionnelles sont déclarées sans effet, et ceci, sans la moindre réserve. La société est tenue même si le tiers connaissait les restrictions résultant du pacte social. Reste le cas de la **mauvaise foi du tiers**. Contrairement au texte de la directive, tel que modifié par le Parlement européen, la version définitive de la directive ne prévoit pas d'exception pour ce cas de figure. Néanmoins, en doctrine belge du moins, il existe un certain courant qui préconise que les dispositions de droit commun restent applicables, même en l'absence de mention expresse dans la directive[1]. Pour ces auteurs, le dépassement des pouvoirs pourra donc toujours être invoqué à l'encontre de tiers qui ont agi de mauvaise foi. Reste encore à décider quelles conditions doivent être remplies dans le chef du tiers. La société devra-t-elle prouver que ce tiers savait que l'organe dépassait ses pouvoirs au détriment de la société ou qu'il devait le savoir ? Certains auteurs considèrent qu'il faut que le tiers soit complice d'une fraude[1].

Ceci n'empêche pas que la clause de la « double signature » est parfaitement valable, et ceci, pour la raison que la loi prévoit que le pouvoir de représentation de la société peut être délégué à un ou plusieurs administrateurs.

Par le passé, les statuts des sociétés comportaient souvent une clause selon laquelle la société était « *valablement engagée par la signature donnée par deux administrateurs qui ne devront pas justifier à l'égard des tiers d'une délibération préalable du conseil d'administration* »[2].

Il reste à préciser que les restrictions légales, contrairement aux limitations statutaires, restent opposables aux tiers. Ce principe résulte de l'article 9.1, alinéa 1er, de la Première directive[3]. Les personnes qui contractent avec la société « *sont censées connaître la loi et avoir vérifié la manière dont s'exerce la représentation sociale* »[3].

Le fait que des actes sont faits en ne respectant pas la **répartition légale des pouvoirs** entre les différents organes est-il une cause d'annulation des actes ainsi posés ? Une source de difficulté propre aux droits belge et luxembourgeois est celle de la **gestion journalière**. Cette gestion journalière, ainsi que la représentation en ce qui concerne cette gestion, peut être valablement confiée à une personne qui n'est

1 – A. Benoit-Moury, Cour de cassation 12 novembre 1987, note, *R.C.J.B.*, 1989, p. 406.
2 – L. Simont et P. van Ommeslaghe, Cour de cassation du 17 mai 1962, *R.C.J.B.*, 1964, p. 77.
3 – A. Benoit-Moury, Cour de cassation 12 novembre 1987, note, *R.C.J.B.*, 1989, p. 408.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

pas nécessairement administrateur (art. 441-10, anc. art. 60 L.S.C). La société peut invoquer le dépassement de ce pouvoir par le délégué. Il est vrai que la notion de gestion journalière n'est pas définie par la loi, ce qui est une source non négligeable d'insécurité juridique.

Quid si la procédure interne de prise de décision n'a pas été respectée, mais que les organes de représentation générale de la société sont intervenus[1] ?

Le droit de vote de l'administrateur (qui sans aucun doute est un droit-fonction qui doit être exercé dans l'intérêt exclusif de la société) signifie que toute stipulation ou convention qui aurait pour objet de supprimer ou de restreindre la liberté d'appréciation des administrateurs aux délibérations du conseil serait nulle[2].

Souvent, les statuts prévoient la nécessité d'une contresignature : les statuts de la société reconnaissent à chaque administrateur la faculté de représenter individuellement la société, mais prévoient que l'administrateur doit obtenir la contresignature d'un non-administrateur, un directeur, par exemple. Il se peut encore que, pour tel acte de gestion journalière, le délégué à la gestion journalière doive obtenir la contresignature d'un administrateur ayant signature sociale[3].

La signature du directeur n'est dans ce cas pas un acte de représentation de la société, mais il s'agit en fait uniquement d'une sorte de visa à usage interne. Le non-respect de cette formalité est susceptible d'engager la responsabilité de ce dirigeant social, mais reste sans effet à l'égard des tiers.

Si ces clauses sont en tant que telles valables, elles sont toutefois inopposables aux tiers.

Selon une décision contestable de la Cour d'appel de Luxembourg, une société anonyme n'est pas engagée, alors que l'acte avait été signé par des administrateurs conformément à une clause relevant du prescrit de l'article 441-5, alinéa 4, L.S.C., s'il est établi, en l'occurrence par une preuve testimoniale, que ladite signature n'était intervenue que sous réserve d'approbation par le conseil d'administration. En l'espèce, la cour retient le témoignage de « *simples* » administrateurs, qui ne sont ni actionnaires ni bénéficiaires d'une quelconque délégation de pouvoirs, et rejette le témoignage du président du conseil d'administration en tant qu'il s'identifie à la partie appelante et doit donc être considéré comme partie en cause[4]. Cette décision n'est pas conforme aux dispositions de la Première directive, entièrement basée sur la séparation entre le pouvoir de gestion interne et le pouvoir de représentation externe des organes sociaux. La directive a précisément pour objet de protéger les tiers en les dispensant de recherches fastidieuses afin de déterminer les pouvoirs de représentation de l'organe de représentation avec lequel ils traitent. La nécessité de ratification d'un acte par cet organe de représentation n'est pas de nature à enlever le pouvoir de représentation à cet organe. La connaissance d'un dépassement des pouvoirs par l'organe de représentation ne prête à conséquence que pour le cas de dépassement de l'objet social.

1 – A. Benoit-Moury, Cour de cassation 12 novembre 1987, note, *R.C.J.B.*, 1989, p. 409.

2 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.*, 1991, p. 249.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 215.

4 – CA du 11 juillet 2001, n° 25.779, commenté par F. Fayot *in Ann. dr. lux.*, 2001, p. 546, article 59, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

4) Distribution d'acomptes sur dividendes

La possibilité de procéder à de telles distributions de **dividendes intérimaires** a été reprise de la Deuxième directive. Toutefois, les conditions retenues avaient initialement été fixées de manière plus restrictive que la directive ne le demandait avant d'être simplifiées par la suite.

a) Conditions prévues par la L.S.C.

Art. 461-3 [anc. art. 72-2] L.S.C.

« (1) *Il ne peut être procédé à un versement d'acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent le conseil d'administration [...] à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes :*

1° il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants ;

2° le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire ;

3° la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé au point 1° ci-dessus ;

4° le commissaire ou le réviseur d'entreprises agréé dans son rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.

(2) *Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant* ».

Cette possibilité de procéder à de tels dividendes a été introduite par la loi du 24 avril 1983 sur base de la Deuxième directive (et amendée par la loi du 25 août 2006) : le pouvoir de procéder aux distributions de tels acomptes a été attribué au conseil d'administration tel que la directive le permettait.

La technique de la distribution d'acomptes sur dividendes est connue depuis fort longtemps, même si sa consécration par des dispositions législatives est assez récente, celle-ci remontant à la Deuxième directive[1]. Avant la consécration légale, on considérait que la distribution n'était possible que si elle était prévue par les statuts[2]. Elle avait lieu sous la responsabilité des dirigeants. En l'absence de bénéfices réels, la responsabilité civile et pénale des administrateurs pouvait être retenue. Les dirigeants qui procédaient à une distribution de dividendes devaient établir une situation leur permettant d'apprécier l'existence d'un bénéfice distribuable à ce moment-là. Cette existence ne préjuge pas de l'existence de ce bénéfice à la fin de l'exercice.

1 – V. le rapport Verhaegen en Belgique, *Doc. parl.*, Ch., 1981-1982, n° 210/9, p. 55.

2 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 411.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Telle était évidemment la véritable difficulté en l'absence de dispositions légales spécifiques leur permettant de couvrir leur responsabilité : les dirigeants devaient avoir l'assurance que ce bénéfice existait également à la fin de cet exercice social[1]-[2].

Dans la négative, les dispositions sur la distribution de **dividendes** fictifs trouvaient application. En tout état de cause, les actionnaires ne sauraient être tenus de rembourser les dividendes intérimaires (du moins, s'ils ont encaissé les dividendes de bonne foi)[3].

Même une assemblée générale des actionnaires ne pourrait pas obliger les actionnaires à restituer leurs dividendes. Cette solution se justifie par le fait qu'à partir du moment de la décision d'attribution des dividendes, les actionnaires sont créanciers de la société avec la conséquence qu'une assemblée générale des actionnaires est incapable de porter atteinte aux droits que ces actionnaires ont sur la société en tant que créanciers[5].

De prime abord, on doit noter que le terme « *avance* » ou « *acompte* » n'est pas approprié : en effet, dès la déclaration du dividende intérimaire, les actionnaires ont une véritable créance sur la société et ne bénéficient nullement d'une simple avance[4]. S'il s'agissait d'une simple avance, il leur faudrait comptabiliser une dette envers la société, ce qui n'est nullement le cas.

La disposition légale de l'article 461-3 L.S.C. est basée sur l'article 15, alinéa 2, de la Deuxième directive du 13 décembre 1976 ainsi libellé :

« *Lorsque la législation d'un État membre admet le versement d'acomptes sur dividendes, elle le soumet au moins aux conditions suivantes : a) il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants ; b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été arrêtés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire* ».

Le conseil d'administration doit être expressément autorisé par les statuts de procéder à une distribution d'acomptes sur dividendes.

Si une telle autorisation lui est donnée, il appartient au conseil d'administration (directoire) de décider, d'une part, de l'opportunité de cette distribution et, d'autre part, de ces modalités pratiques : le montant, le moment, etc.

Il reste à préciser que toutes les règles comptables concernant la distribution des bénéfices annuels restent applicables : il s'agit en particulier des dispositions interdisant les distributions tant qu'il n'y a pas d'amortissement des frais d'établissement, des frais de recherche et de développement, etc. (v. art. 53 et 59 L de 2002).

Il est par ailleurs à noter que la formulation adoptée par la L.S.C. (reprise de la Deuxième directive) est plus large que celle de la loi belge qui ne permet que de puiser dans le « *bénéfice reporté* »[5] au lieu de « *réserves disponibles à cet effet* ».

---

1 – J. Van Ryn et P.. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 412.

2 – A. Vandeplas et J.P. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 174.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 413.

4 – M. Flamée, « Le régime des acomptes sur dividendes », *R.P.S.*, 1987, p. 103.

5 – M. Flamée, « Le régime des acomptes sur dividendes », *R.P.S.*, 1987, p. 105.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans l'hypothèse où la dotation de la réserve légale n'atteint pas encore le montant légalement requis, il y a lieu de procéder à la dotation au prorata du montant du dividende déclaré[1].

b) État comptable établi

Conformément à la directive, la procédure de versement de ces acomptes est sujette à l'établissement d'un **état comptable** attestant du montant des fonds disponibles qui représentent donc le plafond de la distribution autorisée.

Le montant maximal de l'acompte est équivalent « *aux résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire* ».

Le dividende qui peut ainsi être distribué comporte deux parties bien distinctes.

– en premier lieu, il s'agit des résultats réalisés depuis le début de l'exercice et qui n'ont donc pas fait l'objet d'un bilan définitivement arrêté, approuvé par les associés et dûment déposé au R.C.S. La possibilité de distribuer un tel résultat est en fait la seule originalité de l'institution des dividendes intérimaires (en dehors du fait que la décision de distribuer n'est pas prise par l'assemblée générale des actionnaires) ;
– en deuxième lieu, il s'agit des résultats reportés et des réserves disponibles.

La distribution de cette partie des résultats, qui en fait représente des résultats des exercices passés, ne relève nullement d'un monopole du conseil d'administration (directoire) dans la mesure où l'assemblée des associés pourrait à tout moment provoquer la distribution de ces réserves bilantaires existant déjà au début de l'exercice social. Sur ces réserves, il existe donc en fait une compétence concurrente entre le conseil d'administration (directoire), d'une part, et l'assemblée, d'autre part.

L'état comptable établi préalablement à toute distribution d'acomptes sur dividendes doit faire l'objet d'un rapport au conseil d'administration (directoire) et doit permettre de vérifier si les conditions légales sont effectivement réalisées.

Comme indiqué ci-dessus, la déclaration de tout dividende intérimaire est en principe finale. Le paragraphe 2 de l'article (nouv. art. 461-3 L.S.C.) se limite à constater que, si le montant de l'acompte excède le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée, alors il est considéré comme avance sur le dividende suivant.

Art. 461-5 [anc. art. 72-4] L.S.C.

« *Toute distribution faite en contravention aux articles 461-2, 461-3, 461-4 ainsi qu'à l'article 72*ter *[de la Loi de 2002] doit être restituée par les actionnaires qui l'ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances* ».

1 – M. Flamée, « Le régime des acomptes sur dividendes », *R.P.S.*, 1987, p. 107.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette disposition est reprise de la Deuxième directive (art. 16). Ainsi est consacrée l'obligation de rembourser les dividendes fictifs, mais sous des conditions très restrictives tenant à la **mauvaise foi** des actionnaires, mauvaise foi qui se trouve ainsi sanctionnée par l'obligation de remboursement des dividendes fictifs.

Ceci signifie notamment que le remboursement n'est pas possible dans le cas décrit ci-dessus où la distribution concerne des bénéfices réalisés au début de l'année, mais qui sont plus que compensés par des pertes ultérieures concernant le même exercice financier.

Une autre question qui se pose à cet égard est celle de savoir s'il existe une **compétence exclusive** au profit du conseil d'administration ou bien si l'assemblée dispose d'une compétence concurrente à cet égard. Avec la doctrine belge, nous considérons que c'est le conseil d'administration qui a une compétence exclusive à cet égard[1]. Cette solution peut se prévaloir non seulement d'arguments juridiques (la loi accorde ce pouvoir au conseil d'administration, v. art. 461-3 L.S.C.), mais encore d'arguments pratiques : le conseil d'administration, qui est chargé non seulement de la préparation des comptes mais encore de la gestion de la société, est l'organe le mieux placé pour apprécier sous sa responsabilité si la marche des affaires de la société permet de procéder à un acompte sur dividendes[1].

Lors de la transposition de la Deuxième directive, le législateur luxembourgeois (en imitant son homologue belge) avait prévu des délais stricts et contraignants (v. art. 461-3 L.S.C.), non prévus par la directive et destinés à limiter le nombre de distributions auxquelles une société peut procéder pendant une année[2].

Ces dispositions ont été changées dans le sens d'une plus grande flexibilité par la loi du 23 mars 2007 ; les délais de 6 mois (pas de distribution dans les 6 mois après la dernière clôture) et de 3 mois (pas de distribution dans les 3 mois après la première distribution) ont été **supprimés**.

Conformément à l'article 15 de la directive, la L.S.C. prévoit des mesures dérogatoires à l'attention des sociétés d'investissement à capital fixe (et donc non pas à l'égard de celles à capital variable).

Art. 461-4 L.S.C.

« (1) L'article 461-2, paragraphe 1er, n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital fixe.

(2) Sont considérées comme sociétés d'investissement à capital fixe les sociétés anonymes :

1° dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs, et

2° qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, à condition :

a) de faire figurer les termes "société d'investissement" sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents ;

1 – V. L. SIMONT et P.-A. FORIERS, « La distribution de réserves disponibles en cours d'exercice », *Liber amicorum J.-P. De Bandt*, Bruxelles, 2004, p. 611.

2 – A. VANDEPLAS et J.P. SPREUTELS, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 178.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

b) que le total de leur actif tel qu'il résulte des comptes annuels à la clôture du dernier exercice ne soit ou ne devienne par l'effet d'une telle distribution, inférieur à une fois et demi le montant total des dettes de la société envers les créanciers tel que ce montant résulte des comptes annuels ;

c) de le préciser dans une note dans les comptes annuels ».

Sur la question de savoir si (avant la Loi de Modernisation) les règles sur la distribution de dividendes pouvaient être appliquées également aux S.à r.l., la doctrine luxembourgeoise penchait en faveur de cette possibilité malgré certaines hésitations de la doctrine belge et malgré le fait que le projet de loi n° 5730 ne se prononçait pas en faveur de l'extension vers la S.à r.l. de ces dispositions applicables à la S.A. uniquement, en application de l'article 72-2 L.S.C.[1]. La Loi de Modernisation dans sa version finale a procédé à étendre cette possibilité vers les S.à r.l.

C – Nomination et révocation

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les premiers administrateurs de la société peuvent être nommés **par les statuts** de la société. La pratique est fixée dans la mesure où ces premiers administrateurs sont nommés par une assemblée générale tenue tout de suite après l'assemblée générale constitutive qui a procédé à la constitution de la société devant notaire. Par la suite, les nominations se font par l'assemblée générale annuelle qui procède aux nominations dites « *statutaires* » à la suite de l'approbation des comptes annuels.

Les administrateurs relevés de leur mandat par suite d'une révocation restent compétents en vue de pourvoir aux **actes d'administration** courante jusqu'à ce que leurs successeurs aient pu prendre possession de leurs fonctions. Il ne se concevrait pas qu'une société n'eût plus de représentants légaux qui puissent prendre en son nom toutes mesures conservatoires urgentes. Les administrateurs d'une société anonyme sont (au moins dans les relations internes) des mandataires (*cf.* article 441-1 L.S.C.) et sont soumis aux règles qui les régissent. Il est un principe général, dont les dispositions des articles 1991, alinéa 2, et 2010 du Code civil ne sont qu'une application, que, malgré la cessation du mandat, peuvent et doivent être prises par les mandataires toutes mesures urgentes commandées par les circonstances en vue de sauvegarder tous les intérêts. La question de savoir si un acte posé par un administrateur constitue un acte conservatoire et d'administration ou, en revanche, s'il s'agit d'un acte de disposition doit être appréciée dans chaque cas particulier suivant les circonstances de l'espèce. Le fait d'intenter une action en justice peut, selon les circonstances, constituer un acte conservatoire et d'administration[2] ou encore un acte de disposition.

Dans un cas d'espèce, la question s'est posée de savoir si l'action judiciaire intentée par un conseil d'administration dont le mandat était venu à échéance sans être renouvelé était recevable. La cour d'appel arrêta : « *La durée du mandat de l'administrateur est limitée afin de protéger les actionnaires et l'assemblée générale*

1 – D. Boone, « The distribution of interim dividends by a société à responsabilité limitée, » *BDB*, 41, p. 33.

2 – TA Lux. (ch. cons.), *Euro Mediterranean Estates SAH*, 11 mars 1993, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC), confirmé par CA (ch. cons.), 25 mai 1993, n° 100/93, ID 24661.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

vis-à-vis de la puissance des administrateurs. Conçue comme protection devant jouer à l'intérieur de la société, la limitation n'a pas d'effet vis-à-vis des tiers. À l'égard de ceux-ci, le mandat de l'administrateur perdure au-delà de la durée légale de 6 ans tant que l'administrateur n'a pas déposé et publié sa démission »[1].

D – Contrat de mandat

Selon l'article l'article 441-1 [anc. art. 50] L.S.C. : « *les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps, associés ou non, révocables, salariés ou gratuits* ». Selon la L.S.C., les administrateurs sont donc les mandataires de la société. Mais il ne s'agit là que d'une **fiction** pour la raison que « *les administrateurs et gérants ne tiennent pas leurs pouvoirs d'un véritable mandat, mais d'une nomination faite dans les statuts ou par un autre organe social statuant le plus souvent à la majorité […] Mais cette fiction traduit d'une manière commode, en assimilant les gérants et administrateurs à des mandataires, la situation qui leur est faite dans le cadre interne de la société* »[2].

Les administrateurs sont les mandataires de la société, et ce mandat est soumis aux dispositions du Code civil sur le contrat de mandat. Le mandat est en principe **gratuit** (art. 1986 C.c.), ce qui signifie que, sauf dispositions contraires, aucune rémunération n'est prévue. Il est bien entendu possible de déroger à cette disposition et de prévoir la rémunération du mandataire.

La durée du mandat est de 6 ans au maximum, mais les administrateurs sont rééligibles sans limitation. Pour le cas où le nombre des administrateurs tombe en dessous du minimum légal (ou le cas échéant en dessous du minimum statutaire fixé à un nombre plus élevé), il peut être procédé à la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs par cooptation des administrateurs en fonction. En principe, l'administrateur ainsi coopté continue le mandat de l'administrateur qui se retire du conseil d'administration sous réserve toutefois de la confirmation de sa désignation par la prochaine assemblée générale des associés.

Les administrateurs sont librement **révocables** à tout moment. Cette faculté de révocation (qui résulte de l'article 441-2 L.S.C. : « *[…] ils sont toujours révocables par l'assemblée générale* ») est **d'ordre public** : toute dérogation destinée à restreindre cette faculté est nulle. On parle de droit de révocation *ad nutum*, donc sans raison.

Il est à noter que, si cette révocation sans raison est conforme au droit commun du mandat, elle est en fait dérogatoire au droit commun des sociétés. En effet, en application de l'article 1856 C.c. selon lequel le pouvoir d'administration donné à un associé « *ne peut être révoqué sans cause légitime tant que la société dure ; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat* ». En d'autres termes, le mandataire désigné dans les statuts n'est révocable que pour cause légitime.

Contrairement à cette règle générale, les administrateurs de sociétés anonymes sont *toujours* révocables. « *Ici encore, la dérogation aux principes généraux se justifie par l'absence de toute obligation personnelle des administrateurs et par l'intérêt primordial qu'ont dès lors les actionnaires à se débarrasser aisément et rapidement*

1 – CA com. du 5 novembre 2003, n° 27.263, *BIJ*, 2004, n° 2, p. 33.

2 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 262.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

d'administrateurs qui souvent pour la première fois se seront nommés eux-mêmes, s'ils apparaissent infidèles ou seulement incapables »[1].

D'après un jugement du Tribunal d'arrondissement du 30 mars 2007[2] : « *Conformément à ce jugement, le contrat conclu entre parties le 17 décembre 2001 n'est* ***pas à considérer comme un contrat de travail*** *et il convient d'examiner les relations entre parties au regard des dispositions relatives au mandat d'administrateur de société, étant donné que les administrateurs d'une société anonyme sont des mandataires et sont soumis aux règles qui les régissent.*

En vertu de l'article 51, alinéa 3, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, les administrateurs sont toujours révocables par l'assemblée générale.

Contrairement à ce que prétend le requérant, il est admis que le mandat d'administrateur est révocable ad nutum *au gré de la société et sans que celle-ci soit tenue de justifier sa décision ou d'octroyer un préavis à l'intéressé (Dalloz, Rép. Sociétés, v° Administrateur ; TA, 1er juin 1990, numéro 38 688 du rôle).*

Cette faculté de révocation ad nutum *est absolue en raison de son caractère* ***d'ordre public****, de sorte qu'il n'est pas permis d'y déroger par une convention privée (Dalloz, Rép. Sociétés, v° Administrateur ; Juris-Classeur Fasc. 40 : Sociétés, v° Actions contre les dirigeants).*

En conséquence, il y a lieu à annulation de toute clause d'une convention qui serait contraire à la faculté de libre révocation ou d'en restreindre l'exercice, à condition toutefois qu'il soit établi, dans chaque cas d'espèce, que la clause en question peut avoir une incidence réelle sur la décision de révocation du dirigeant (Juris-Classeur Fasc. 40 : Sociétés, v° Actions contre les dirigeants ; Juris-Classeur Fasc. 1050 : Dirigeants sociaux, v° Révocation discrétionnaire).

La stipulation contractuelle d'un préavis en cas de révocation d'un administrateur n'est en conséquence pas prohibée d'une manière absolue, mais uniquement dans la mesure où le préavis stipulé a un effet dissuasif certain en ce sens qu'il est manifestement susceptible d'influencer la décision de révocation à intervenir.

Ainsi, a notamment été annulée une clause instituant une période de préavis d'un an au cas où il serait mis fin aux fonctions d'un administrateur désigné en qualité de PDG (Cass. Fr., 17 janvier 1984, Bull. civ. IV, n° 21).

[…] l'indemnité de préavis de 6 mois correspondant à un montant de 51.048,60 EUR [serait] *suffisamment important*[e] *pour avoir une incidence réelle sur la décision de révocation, de sorte que le préavis stipulé est de nature à restreindre la libre révocabilité de W.*

Il s'en déduit que la clause précitée du contrat liant les parties encourt l'annulation ».

Ce jugement a été réformé en appel[3] au motif que :

« *C'est à bon droit que les juges de première instance se sont orientés vers la jurisprudence française qui ne prononce la nullité de ces conventions que si, de par leurs conséquences financières importantes, elles dissuadent les actionnaires d'exercer leur faculté de révocation. Néanmoins, en l'occurrence, aucun élément du dossier ne renseigne concrètement la Cour sur la question de savoir*

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 121, ID 11308.

2 – TA du 30 mars 2007, n° 101625 du rôle, ID 24544.

3 – CA du 21 mai 2008, n° 32550 du rôle, ID 26090.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dans quelle mesure la clause litigieuse prévoyant une indemnité de six mois de préavis, d'un montant total de 51.048,60 €, a pu restreindre ou entraver la décision de libre révocabilité par la société anonyme SOC.1.) S.A. de son administrateur-délégué X.).

On ne sait pas dans quelle proportion l'indemnité en question a constitué pour la société anonyme SOC. 1.) S.A., en rapport avec sa situation financière, une charge telle qu'elle était de nature à dissuader la société de son droit de libre révocation.

À défaut de tels renseignements, il n'est pas établi que l'indemnité en question a pu influencer la décision de la société anonyme SOC.1.) S.A. Dans de telles circonstances, on ne saurait procéder à l'annulation de la clause litigieuse.

Le jugement dont appel est partant à réformer en ce sens qu'il y a lieu d'allouer à X.) le montant de 51.048,60 € correspondant à six mois de préavis ».

1) Attributions du conseil d'administration

Le conseil d'administration est un organe collégial, distinct de ses membres, qui discute, délibère et décide ensemble. Il ne s'agit donc pas de trois administrateurs qui se partagent le travail, mais d'un organe collégial qui décide en commun. Cet organe est **distinct des membres** qui le composent. Il en résulte que, à supposer que des procurations à des tiers aient été données par le conseil d'administration (pour des opérations spécifiques), celles-ci restent valables même si les administrateurs ont changé entre-temps[1].

Le conseil d'administration ne peut déléguer les pouvoirs lui attribués à des tiers (en dehors bien entendu de la gestion journalière qui peut être déléguée en application de l'article 441-10 L.S.C.). Ceci n'empêche pas que le conseil puisse donner des procurations limitées à des tiers leur permettant d'engager la société en tant que mandataires[2].

En outre, l'assemblée générale des actionnaires en tant qu'organe souverain de la société peut parfaitement procéder à des délégations spéciales aux administrateurs de la société de tel ou tel de ses pouvoirs propres. De telles délégations ne pourront toutefois être que **partielles** quant à leur étendue et à durée : l'assemblée ne peut se décharger de façon générale de la mission qui lui est confiée[3]. Cette approche a encore été confirmée par la Loi de Modernisation (art. 441-11, alinéa 1, L.S.C.).

2) Mode de fonctionnement des conseils d'administration

Les statuts peuvent librement déterminer le mode de fonctionnement du conseil d'administration au sujet, notamment, de la convocation des réunions du conseil, de la tenue de celles-ci, du vote, du droit de l'administrateur de se faire représenter, des procès-verbaux, etc.

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 121, ID 11308.

2 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 385.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 124, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En général, les statuts ne consacrent que peu de dispositions à ces questions, de sorte que les règles applicables sont celles des **assemblées délibérantes**. Ceci signifie concrètement que le président du conseil d'administration convoque la réunion en communiquant un ordre du jour, et ceci, avec un délai d'avance raisonnable, par exemple 7 jours avant la réunion. Mais le délai minimum requis est fonction des circonstances et des distances que les administrateurs ont à parcourir pour assister à la réunion (sauf à profiter des nouvelles possibilités de tenir les réunions par visioconférence ou par téléconférence, art. 444-4, anc. art. 64*bis* L.S.C.).

« *[…] Sont ainsi des actes juridiques collectifs […] toutes les décisions majoritaires d'assemblée de droit public comme privé (lois votées par les parlements, résolutions des assemblées générales d'actionnaires et des conseils d'administration, décisions de l'assemblée des créanciers en matière de concordat, actes de collèges, juridictionnels ou non […]).*

Le Doyen Hauriou […] a démontré que tout acte juridique collectif est le fruit d'une procédure.

Les différentes volontés individuelles s'imbriquent, s'incorporent les unes aux autres, parce qu'elles s'insèrent dans un même processus décisionnel. C'est l'existence d'une procédure qui constitue le « ciment » entre les vouloirs et permet leur transmutation en une volonté collective.

Schématiquement, le processus décisionnel d'une assemblée comporte en général au moins quatre phases : convocation, discussion, vote et authentification du résultat du vote.

D'abord, tous les membres du groupement doivent avoir été convoqués en temps utile […].

Un ordre du jour, […] définissant le programme des travaux du groupement, est joint à la convocation. Le cas échéant, les informations nécessaires à la préparation de la séance sont également communiquées […].

Ensuite, se tient l'assemblée. Une présentation des projets de décision, voire un débat destiné à ce que les participants s'éclairent mutuellement, précède le vote […]

Enfin, la décision de la collectivité, telles qu'elle ressort du vote, est figée dans un instrument. La résolution résultant du concours d'un certain nombre de personnes il est en effet nécessaire de la matérialiser […] afin d'éviter toute contestation sur sa teneur […][(1)]».

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce **quorum** n'est pas atteint, une nouvelle réunion sera convoquée en accordant à nouveau un délai similaire.

Après délibération de chaque point à l'ordre du jour, une décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Cette règle est destinée à éviter le blocage du conseil d'administration. En principe, ce ne sont que les questions reprises à l'agenda qui peuvent faire l'objet des discussions du conseil. Il peut en aller autrement dans le cas où tous les administrateurs en décident autrement.

Une assemblée générale ne peut délibérer sur des points étrangers à l'ordre du jour « car l'ordre du jour permet aux actionnaires d'apprécier s'il est opportun pour

1 – V. P.-E. Partsch, « Dans quelle mesure le conseil d'administration d'une société anonyme peut-il adopter des décisions sans réunion physique de ses membres ? », *R.P.S.*, 1995, p. 192.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

eux d'assister à l'assemblée et de prendre éventuellement tels avis que de conseil sur les délibérations prévues »[1]. Cette solution est transposable aux conseils d'administration.

Ce même arrêt de la Cour de Liège refusa aux actionnaires présents à la réunion et participant au vote le droit de solliciter ensuite l'annulation des résolutions prises en dehors de l'ordre du jour. Cette solution a fait l'objet de critiques justifiées en doctrine : « *La présence à la réunion n'exclut nullement que l'actionnaire soit victime d'une surprise qu'il aurait pu éviter si l'ordre du jour avait été annoncé. Tout au plus peut-on admettre que l'actionnaire qui vote en faveur des résolutions n'est plus fondé à les contester, car ce faisant il renonce à invoquer la nullité* »[2].

Pour le cas où l'assemblée délibère sur des points étrangers à son ordre du jour, tout associé intéressé peut agir en nullité de la délibération, sans avoir à établir que le vote des associés absents aurait pu en modifier le résultat. « *Le vice est substantiel et un associé absent ou même un associé présent mais mieux informé auraient pu modifier les opinions des autres associés sur le point discuté* »[3].

L'ordre du jour permet de délibérer sur les points y exprimés et sur ceux qui raisonnablement y sont implicitement compris[3]. Tel n'est pas le cas de l'annulation des actions consécutive à une réduction du capital à zéro, alors que seule la réduction du capital est annoncée dans l'ordre du jour[4].

Le droit de vote de l'administrateur a le caractère d'un **droit-fonction** dans la mesure où ce droit est conféré pour gérer la société de sorte que l'administrateur ne peut avoir en vue son intérêt propre, mais uniquement celui de la société[5].

Chaque réunion du conseil fait l'objet d'un **procès-verbal** qui est signé soit à la fin de la réunion, soit à la prochaine réunion par tous les membres qui étaient présents ; ces procès-verbaux sont consignés dans un cahier ou classeur. En cas de désaccord entre les associés, le ou les administrateurs minoritaires peuvent faire inscrire ce désaccord dans le procès-verbal : ceci est surtout utile afin d'écarter la mise en cause de leur responsabilité personnelle dans le cas où les décisions prises se situent en dehors des statuts ou de la loi.

Lors des réunions du conseil, un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur, mais non pas par un non-administrateur. En principe, un administrateur ne peut pas représenter plus d'un administrateur.

Lorsque la violation concerne une **règle non substantielle** (par exemple, en cas de non-respect des règles légales concernant le libellé des convocations et des délais prévus par la loi et les statuts ou encore les règles sur la composition du bureau), alors il y application de la règle « *pas de nullité sans grief* »[6]. Dans de tels cas, il n'y aura pas de nullité des résolutions si aucune intention frauduleuse n'est

1 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 342, en référence à l'arrêt de la Cour de Liège du 12 janvier 1961, *Pas.*, II, p. 234, *R.P.S.*, 1962, p. 146, note Coppens.

2 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 343.

3 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 364.

4 – Cette décision du Tribunal de Mons (réf.) du 23 mars 1989, *R.D.C.*, 1990, p. 326, a été à juste titre jugée sévère (P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 797.

5 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.*, 1991, p. 239.

6 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 364.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

établie ou encore si les associés n'ont pas été réellement empêchés d'exercer leurs droits, si le vote eût été exercé dans le même sens et si une assemblée ultérieure avait procédé à la ratification des résolutions critiquées[1].

3) Conflit d'intérêt entre un administrateur et la société

En raison de changements introduits en 2016, nous abordons cette question sous deux rubriques distinctes, avant la Loi de Modernisation et depuis cette loi.

a) Avant La Loi de Modernisation

La notion du conflit d'intérêt relève d'une idée plus générale selon laquelle il existe une interdiction générale (non écrite, mais dont le droit positif connaît certaines applications) prohibant le contrat conclu par une seule personne agissant en une **double qualité**. Cette interdiction serait fondée sur l'opposition d'intérêts inhérente à ces situations[2].

Un tel conflit d'intérêts peut exister notamment si un administrateur passe un contrat avec la société dont il est administrateur. De telles opérations comportent le risque que, pris entre son devoir et son intérêt personnel, l'administrateur ne fasse prévaloir son intérêt personnel sur celui de la société qu'il représente[3]. Néanmoins, le législateur n'a pas opté pour une interdiction générale de ce type d'opérations, mais il en a simplement réglementé les conditions[4] afin d'éviter que la société ne soit lésée par celles-ci.

Les dispositions afférentes L.S.C. sont copiées de la loi belge (art. 50 de la loi de 1873), elles-mêmes reprises de la loi française du 23 mai 1863[5].

Sont visées par l'article 57 (nouv. art. 441-7) L.S.C. les situations où l'administrateur a un intérêt opposé à celui de la société, et ceci, « *dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration* ». Dans une telle situation, la loi commande à l'administrateur de procéder comme suit :

1) faire connaître ce fait aux autres administrateurs ;

2) faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance ;

3) s'abstenir de prendre part à la délibération (et bien entendu au vote).

En outre, le conseil d'administration (et non pas le ou les administrateurs concernés) doit rendre spécialement compte à la première assemblée générale, avant tout vote, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société[6].

Différentes conceptions de **l'intérêt opposé** ont été défendues : pour certains, la conception de la loi est étroite et elle ne viserait que les seuls contrats qui présentent un intérêt pour l'administrateur en lui accordant un avantage au détriment de

1 – Trib. Com. Bruxelles du 7 octobre 1960, *R.P.S.*, 1961, p. 241.

2 – V. De Page, T. 2, n° 448.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 104.

4 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 101.

5 – L. Simont, « Conflits d'intérêt : les implications des nouveaux articles 60 et 60*bis* », *R.P.S.*, 1996, p. 369.

6 – L. Simont, « Conflits d'intérêt : les implications des nouveaux articles 60 et 60*bis* », *R.P.S.*, 1996, p. 370.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la société. Pour la majorité de la doctrine et de la jurisprudence, il y a intérêt opposé dès lors que l'opération comporte pour l'une des parties un avantage d'autant plus grand que l'avantage de l'autre est moindre. « *Ce ne sont point les conditions de l'opération qui sont à considérer, mais la position qu'occupe l'administrateur vis-à-vis de la société au point de vue de la décision à prendre. À telle enseigne que, le contrat projeté fût-il des plus onéreux pour l'administrateur et des plus avantageux pour la société, le seul fait que l'administrateur y est intéressé suffit à imposer l'abstention* »[(1)].

L'approche du législateur est donc la suivante : les opérations dans lesquelles les administrateurs ont un intérêt opposé (on pense immédiatement aux ventes de biens entre la société à un administrateur ou par l'administrateur à la société) sont en tant que telles parfaitement **licites** et régulières, mais elles sont potentiellement dangereuses pour la société, ce qui oblige au respect de certaines formes. Elle doit donc se décider sans le concours de l'administrateur, et ceci, en toute transparence.

Les **garanties prévues** par la loi sont doubles :

En premier lieu, l'article 441-7 L.S.C. enjoint à l'administrateur qui se trouve ainsi en situation de conflit de signaler l'existence de celui-ci à la société et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. En outre, il ne peut prendre part à la délibération portant sur ce sujet. L'administrateur concerné n'est pas tenu de faire connaître en quoi consiste cet intérêt et quelle en est l'importance en termes financiers[(2)].

En deuxième lieu, comme les autres administrateurs pourraient encore rester sous l'influence de leur collègue, malgré son abstention, et si l'opération s'est néanmoins réalisée, la loi exige qu'il soit rendu compte des opérations de cette nature à la première assemblée, et avant tout vote sur d'autres résolutions[(3)]. « *L'intervention des actionnaires, intéressés directs, jointe à la responsabilité si large qui incombe aux administrateurs suffit pour écarter toute crainte de malversation* »[(4)-(5)].

L'opération passée en violation des dispositions de l'article 441-7 L.S.C. reste valable. La seule sanction consiste à l'obligation de réparation du préjudice subi par la société sur la base de l'article 441-9 L.S.C.

L'administrateur qui ne tiendrait pas compte des dispositions de l'article 441-7 L.S.C. commettrait une faute qui le rendrait passible de dommages-intérêts envers la société à condition que celle-ci arrive à établir son préjudice.

Que l'intérêt de l'administrateur soit direct ou indirect, il faut qu'il soit suffisamment important pour pouvoir influencer son vote. Cette circonstance de fait est soumise à l'appréciation du juge[(6)].

Reste encore à déterminer l'étendue de l'obligation d'indemnisation. Suffit-il que l'opération tourne au désavantage de la société pour pouvoir engager la responsabilité de l'administrateur ?

« *Aucunement. Les administrateurs ne sont pas responsables des conséquences désavantageuses des actes accomplis par eux en vertu de leur mandat,*

1 – V. P. Demeur sous Trib. com. Bruxelles du 22 mars 1930, *R.P.S.*, 1932, p. 144.

2 – Commentaire législatif de la loi belge de 1873, II, 122.

3 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 391.

4 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 189, ID 11305.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 129, ID 11308.

6 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 130, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ils ne sont responsables que des conséquences, et des conséquences directes de leurs fautes. Pour que leur responsabilité soit engagée, il ne suffira donc pas d'établir que l'opération traitée en infraction à l'art. [57] a causé une perte à la société ; il faudra établir que cette perte est due à l'inobservation même des prescriptions légales »[1]. Le fait que l'administrateur n'a pas signalé l'existence du conflit d'intérêt et qu'il a participé au vote ne prête donc pas à conséquence si tant est que ces circonstances n'aient eu d'influence sur le vote du conseil d'administration.

Pour que l'article 441-7 L.S.C. soit du tout applicable, il faut que l'opération soit soumise à **l'approbation du conseil d'administration** (au vœu même de la loi). Les actes qui relèvent de la gestion journalière de la société échappent donc aux mesures prévues par l'article 441-7 L.S.C. En l'absence de sanction spéciale prévue par l'article visé, il faut appliquer les sanctions de la responsabilité des administrateurs en raison des actes commis par eux en violation des lois ou des statuts[2].

Il n'y a pas lieu de distinguer entre **intérêt direct et indirect** « *puisque l'intérêt opposé peut exister dans les deux cas* »[3].

La sanction de la violation des dispositions de l'article 441-7 L.S.C. concernant les opérations conclues par le conseil d'administration dans lesquelles un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société n'entraîne **pas la nullité** de cette opération[4]. La conséquence est uniquement d'engager la responsabilité des administrateurs[5].

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 441-7 L.S.C., il doit être rendu compte « *à la première assemblée générale* » des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société. Ici encore se pose la question de la sanction du non-respect de ces dispositions. Le défaut de dénonciation ne comporte en principe aucun préjudice pour la société et ne se soldera donc pas par la responsabilité spéciale de l'administrateur (sauf le cas exceptionnel où le contrat pourrait encore être résilié sans dommages-intérêts par la société, etc.).

La principale critique adressée à ce système est celle de **l'insuffisance des sanctions** en cas de non-respect des dispositions légales. L'inobservation des conditions de l'article 441-7 L.S.C. ne comporte pas la nullité de la délibération du conseil d'administration, mais simplement la mise en œuvre de la responsabilité solidaire de l'administrateur consécutive à la violation de la loi. Cette responsabilité solidaire de l'article 441-9, alinéa 2, L.S.C. se heurte souvent à des difficultés de preuve la plupart du temps insurmontables, en particulier quant au lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi par la société[6].

---

1 – P. Demeur sous Trib. com. de Bruxelles du 22 mars 1930. *R.P.S.*, 1932, p. 145.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 130, ID 11308.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 188, ID 11305.

4 – Cass. b. du 21 juin 1956, *Pas.*, I, p. 1158.

5 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 367.

6 – L. Simont, « Conflits d'intérêt : les implications des nouveaux articles 60 et 60*bis* », *R.P.S.*, 1996, p. 370.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il reste à insister sur le fait que le droit belge s'est entre-temps éloigné du droit luxembourgeois dans la mesure où la matière a fait l'objet de réformes en Belgique, et ceci, en premier lieu par la loi du 18 juillet 1991, elle-même réformée par la loi du 13 avril 1995[1].

On peut noter à cet endroit qu'avant 2016 il n'existait en droit luxembourgeois aucune disposition concernant le conflit d'intérêt dans le chef des liquidateurs des sociétés commerciales[2].

On peut encore mentionner dans ce contexte que la CJCE a également pris position sur cette problématique au regard du droit européen. Dans une affaire tranchée en 1997[3], la CJCE arrêta que « *le régime d'opposabilité aux tiers des actes accomplis par les membres d'organes sociaux dans la situation de conflits d'intérêts avec la société représentée échappe au cadre normatif de la première directive […]* ». Par conséquent, les États membres demeurent libres de réglementer comme ils l'entendent le régime du conflit d'intérêts « […] *même si l'application de ce régime semble, en première analyse, faire échec aux dispositions de la première directive tendant à garantir au maximum l'engagement de la société vis-à-vis des tiers de la société pourvu que l'acte ait été conclu par l'organe formellement compétent pour ce faire* »[4].

b) Depuis la Loi de Modernisation

L'article 441-7 [anc. art. 57] L.S.C. reprend le régime amendé du conflit d'intérêt opposant les dirigeants à la société. La Loi de Modernisation y a apporté certains changements inspirés essentiellement du droit belge. La nature de l'intérêt visé par la loi a été précisée dans la mesure où il doit s'agir d'un « intérêt de nature patrimoniale », ce qui exclut donc l'intérêt moral. En sens inverse, la notion a été formellement étendue pour viser également « l'intérêt indirect ». Il y a conflit direct si l'opération se fait avec le dirigeant lui-même et conflit indirect si l'opération se fait avec une société dans laquelle ce dirigeant est intéressé en tant qu'associé. En revanche, il n'y a pas de conflit si l'opération se fait avec une société dans laquelle le même dirigeant est également administrateur[5]. On notera une autre nuance du nouveau texte par rapport à l'ancien : si autrefois l'article 57 L.S.C. visait les opérations « *soumises à l'approbation du conseil d'administration* », la nouvelle version de cette disposition se réfère aux « *opérations relevant du conseil d'administration* », ce qui implique donc qu'il n'appartient plus aux dirigeants de définir le champ d'application de cette disposition.

Avant comme après la Loi de Modernisation, le dirigeant concerné doit prévenir le conseil d'administration de l'existence d'un conflit d'intérêt et il doit faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il lui est interdit de prendre part à cette délibération et à plus forte raison de voter à ce sujet. Ensuite : « *Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres*

1 – L. Simont, « Conflits d'intérêt : les implications des nouveaux articles 60 et 60*bis*, *R.P.S.*, 1996, p. 372.

2 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, p. 76.

3 – CJCE du 16 décembre 1997, Aff. C-104/96, ID 11662.

4 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du laboratoire de droit économique, p. 521.

5 – En ce sens, J.-P. Spang, « Les organes de gestion », *in La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, p. 146.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société ».

Le projet de loi n° 5730 dans sa version initiale avait prévu l'obligation de donner dans le rapport de gestion une description et une justification de la décision prise et des conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport du réviseur (commissaire) devait comporter une description séparée des conséquences patrimoniales pour la société des décisions prises. En outre, la société devait pouvoir agir en nullité contre les décisions prises en violation des dispositions de l'article 441-7 L.S.C.[1].

Ces points n'ont pas été repris dans la version adoptée de la Loi de Modernisation. Dans les alinéas 3 et 4 de l'article 441-7 L.S.C., celle-ci a en revanche résolu les problèmes qui peuvent se poser lorsque, du fait du conflit d'intérêt, l'administrateur concerné par le conflit d'intérêt se retire des délibérations et que le nombre des administrateurs requis par les statuts pour délibérer n'est plus atteint : la décision est alors déférée à l'assemblée générale[2].

En définitive, en ce domaine, le principal apport de la Loi de Modernisation est d'avoir considérablement **étendu les dispositions sur les conflits d'intérêt** à d'autres organes et à d'autres formes de sociétés que celles qui y ont été soumises par le passé. Ces dispositions sont désormais applicables non seulement aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, mais encore au délégué à la gestion journalière, au(x) liquidateur(s) de la S.A. ou de la SE, au président de la SAS, au(x) gérant(s) de la S.à r.l., etc.

E – La responsabilité des administrateurs, etc.[3]

La conception d'un bon système permettant d'engager la responsabilité des administrateurs n'est pas facile. A. Nyssens a bien résumé la difficulté de la tâche au regard du droit de la responsabilité. « *Fixer d'une manière nette et précise les devoirs des administrateurs et en garantir l'accomplissement par une sanction juste et efficace n'est pas chose aisée. Les législations des divers pays, en essayant de résoudre la question, n'ont pas toujours échappé à l'un ou à l'autre de ces écueils : soit une rigueur excessive et pouvant aboutir à des injustices, soit l'inefficacité d'une sanction vague, mal définie, à laquelle les administrateurs négligents ou coupables parviennent trop facilement à se soustraire* »[4].

Aux termes de l'article 441-8 [anc. art. 58] L.S.C., « *les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société* ». Cette disposition n'est que le reflet du droit commun du mandat (tel que défini par l'article 1984 C.c. qui ne vise que le mandat avec représentation) selon lequel c'est le mandant et non pas le mandataire qui est légalement partie aux contrats passés par l'intermédiaire de ce dernier.

---

1 – La question de la sanction de la violation des dispositions sur les conflits d'intérêt reste donc ouverte. Selon J.-P. Spang, en se référant à la doctrine belge : « On admet traditionnellement que de telles violations ne sont pas frappées de nullité », *op. cit.*, p. 152.

2 – Pour plus de détails, J.-P. Spang, *op. cit*., pp. 148 ss.

3 – Les explications données sous ce titre sont valables également à l'égard des commissaires. Selon le cas elles peuvent valoir également pour les « membres du comité de direction » et « le directeur général ».

4 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 190.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Si les administrateurs sont en même temps actionnaires (ce qui n'est plus une obligation depuis l'abolition du système des actions de garantie), ils se trouvent donc dans la même situation que les autres actionnaires dans la mesure où ils ne sont pas tenus au-delà de leur mise, quelle que soit l'importance des engagements contractés au nom de la société[1].

Cette disposition soulève la question dite de **l'absorption** : « *la responsabilité civile de la personne morale absorbe-t-elle celle de ses organes (en d'autres termes, la personne morale répond-elle seule des agissements de ses organes en sorte que ces derniers ne devraient pas voir leur responsabilité engagée pour leur fait personnel dans l'accomplissement de leurs fonctions)* ? »[2]. La réponse à cette question est toutefois négative : en effet, l'article art. 441-8 (anc. art. 58) L.S.C. ne fait que rappeler la responsabilité directe de la personne morale sans régler la question de l'absorption. La responsabilité civile des administrateurs à l'égard des tiers reste entière[3].

L'article art. 441-8 (anc. art. 58) L.S.C. n'empêche pas que, si les administrateurs commettent une faute dans l'accomplissement de cette tâche et que cette faute est à l'origine d'un dommage causé soit à la société, soit à des tiers ils peuvent être tenus de réparer celui-ci[4].

La responsabilité des administrateurs est à multiples facettes et elle est susceptible d'être exercée tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers. À cet endroit de la définition de cette responsabilité, le législateur ne s'est pas contenté de renvoyer simplement aux règles du mandat. « *Les fonctions que remplissent les administrateurs d'une institution autonome comme la société anonyme comportent des responsabilités plus diverses et plus étendues que celles d'un mandataire ordinaire. Les fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, dans certains cas, engager leur responsabilité envers les tiers* »[5]. Il est encore remarquable que la simple responsabilité civile soit jugée une sanction insuffisante avec donc la conséquence que certaines fautes sont sanctionnées pénalement.

La **faute de gestion** (de nature contractuelle) est à distinguer de la violation des statuts ou de la loi, souvent appelée **faute de régularité** (censée une faute quasi-délictuelle). La faute de gestion engendre la responsabilité des administrateurs envers la société. Cette simple faute de gestion ne se conçoit pas en dehors de l'existence d'un mandat. « *Un commerçant qui commettrait une telle faute dans ses propres affaires ne pourrait encourir aucune responsabilité envers les tiers qui ont contracté avec lui (Bruxelles 28 décembre 1966, J.T. 1967, p. 97)* »[6]. « *Puisque la faute de gestion ne constitue pas la violation d'une obligation légale ou statutaire bien précise mais un manquement à une norme générale de comportement, sa qualification laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge* »[7]. Selon la jurisprudence sont notamment à considérer comme simple faute de gestion :

– absentéisme aux réunions du conseil d'administration ;

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 190.

2 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, p. 76.

3 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, p. 76.

4 – O. Ralet, *Responsabilité des dirigeants de sociétés*, Larcier, 1996, p. 57.

5 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 394.

6 – O. Ralet, *Responsabilité des dirigeants de sociétés*, Larcier, 1996, p. 88.

7 – O. Ralet, *Responsabilité des dirigeants de sociétés*, Larcier, 1996, p. 88.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– dépenses de publicité exagérées ;
– paiement de dettes non exigibles ;
– ne pas poursuivre les débiteurs de la société avec la diligence nécessaire ;
– conclusion de contrats à des conditions défavorables pour la société ;
– abstention de demander un subside auquel la société avait droit ;
– non-contestation en temps opportun d'une facture erronée ;
– licenciement d'un salarié sans motif avec la conséquence de devoir payer des indemnités ;
– surveillance insuffisante du délégué à la gestion journalière ;
– désignation d'un délégué à la gestion journalière incompétent ;
– etc.[1]

L'imputabilité de la faute à chacun des administrateurs doit être établie. Selon la jurisprudence : « *S'il est vrai que toute opération malheureuse ne constitue pas nécessairement une faute il ne suffit toutefois pas que la bonne foi de l'administrateur soit établie pour le soustraire à la responsabilité du mandataire* »[2].

1) Responsabilité contractuelle à l'égard de la société

L'article 441-9, alinéa 1er, [anc. art. 59, alinéa 1er] L.S.C. dispose : « *Les administrateurs, les membres du comité de direction et le directeur général sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion* ».

Les modifications portées par la Loi de Modernisation à cet article concernent d'abord les conséquences du fait de l'introduction de nouveaux organes (comité de direction et directeur général) dans la L.S.C. Par conséquent, l'alinéa 1 de l'article visé mentionne désormais, en plus des administrateurs, « les membres du comité de direction et le directeur général » pour leur appliquer le régime de la responsabilité applicable traditionnellement aux seuls administrateurs. De façon surprenante, l'alinéa 2 ne reprend pas les mêmes personnes que celles visées à l'alinéa 1, mais les seuls « administrateurs et les membres du comité de direction ». Par conséquent, le directeur général n'est pas soumis à la responsabilité aggravée en cas de violation, de la_L.S.C. ou des dispositions statutaires. On peut supposer qu'il s'agit d'une simple inadvertance du rédacteur de cette disposition.

Le point important de ce premier alinéa est que les administrateurs sont responsables *envers la société* (**et donc non pas envers les actionnaires individuels,** sauf exception) de cette exécution du mandat leur confié (même si ceci ne fait encore que confirmer que la responsabilité contractuelle ne s'exerce qu'entre les cocontractants, donc entre le mandat et le mandataire) et de faute de gestion commises à cette occasion.

Selon cette disposition de la loi, « *les administrateurs sont donc soumis à la responsabilité contractuelle bien qu'il n'y ait pas de contrat entre la société et ses*

1 – O. Ralet, *Responsabilité des dirigeants de sociétés*, Larcier, 1996, p. 89.
2 – Cour 27 février 1973, *P.*, 23, p. 485.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

administrateurs ; il s'agit plutôt d'une fiction ou d'une assimilation imposée par la loi »[1].

La responsabilité des administrateurs, qu'elle trouve sa base dans les fautes de gestion ou dans une violation de la loi (ou des statuts) donne lieu à **l'*actio mandati***[2]. Conformément aux principes juridiques généralement applicables, il faut conclure que, dans ce cas de figure, c'est la **seule assemblée des actionnaires** qui est maîtresse de l'action sociale et qui décide de l'exercer ou de ne pas l'exercer.

Telle était la situation sous la Loi de 1915 dans sa version initiale jusqu'à la Loi de Modernisation de 2016. À cette action sociale classique (*litt*. a) ci-après) ladite loi a ajouté une nouvelle modalité permettant d'engager la responsabilité des administrateurs : c'est l'action minoritaire (*litt*. b) ci-après).

a) L'action sociale classique

L'action sociale appartient en principe exclusivement à la société (soit donc à l'assemblée générale des actionnaires décidant à la majorité) et elle ne peut donc être intentée que par elle et, le cas échéant, par le liquidateur ou, en cas de faillite, par le curateur[3]. C'est pour préciser ce point que l'article 441-9 [anc. art. 59], alinéa 1, L.S.C. mentionne que les administrateurs sont responsables « *envers la société* ». « *Dérivant du mandat, exercée par* l'actio mandati*, cette responsabilité n'existe qu'au regard de la société mandante ; elle ne peut donc être invoquée par les tiers, sauf exercice de l'action indirecte de l'article 1166 du Code, ni par les actionnaires individuellement, lesquels n'ont d'action individuelle que dans le cas exceptionnel de l'article 62* »[4].

Cette action n'appartient donc ni aux créanciers de la société, ni aux autres tiers, ni aux actionnaires individuellement, *ut singuli*[5]*.* Il en va différemment si la société s'abstient d'exercer l'action sociale et si cette inaction est de nature à compromettre leurs intérêts ; dans ce cas, ils peuvent, sur la base de l'article 1167 C.c., exercer leur action subrogatoire et donc exercer l'action sociale contre les administrateurs fautifs. Dans cette hypothèse, les administrateurs peuvent faire valoir contre les créanciers les exceptions et moyens qu'ils auraient pu opposer à la société[6]. « *La juridiction du premier degré a retenu à raison que le critère permettant de distinguer le préjudice social du préjudice individuel réparable consiste dans le fait que ce dernier va directement affecter la valeur des titres ou la situation patrimoniale de l'actionnaire sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier. Le préjudice individuel ne doit pas constituer une simple répercussion du préjudice social et doit, par conséquent, être déconnecté d'une perte qui affecterait l'actif social. Elle a encore dit à raison que même si un actionnaire dispose d'une action individuelle en*

1 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 395. L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 96.

2 – Ch. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 493.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 132, ID 11308.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 132, ID 11308.

5 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 100.

6 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 101.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

réparation d'un préjudice distinct de celui de la société et des autres actionnaires, la recevabilité d'une telle action en responsabilité est soumise à l'allégation de ce préjudice personnel distinct et que le demandeur doit caractériser ce préjudice distinct »[1].

La responsabilité des administrateurs est une responsabilité contractuelle, en principe **sans solidarité**. La commission par plusieurs administrateurs d'une faute commune ou de fautes concurrentes justifie une responsabilité *in solidum* qui ne peut toutefois être mise en œuvre que par la société[2]. « *[…] ils ne répondent que de leur faute, savoir du manquement aux devoirs du bon père de famille, apprécié d'autant plus sévèrement qu'ils sont salariés* »[3]. Ils sont en faute si, en vertu des règles du droit commun, ils manquent des soins du bon père de famille, d'un commerçant prudent et diligent[4]. Cette action dite action sociale tend à la réparation du préjudice qu'a causé à la société la faute de l'administrateur (commissaire).

Dans le cadre d'un tel mandat, ce n'est en effet pas le mandataire qui est engagé, mais le mandant au nom duquel (et pour le compte duquel) agit le mandataire. Tout mandataire est responsable de l'exécution de ce contrat sur la base de la responsabilité contractuelle dans les conditions et limites qui sont spécifiques au contrat nommé en question. « *Comme le mandataire, l'administrateur sera donc responsable toutes les fois qu'il ne se sera pas acquitté de ses fonctions "en bon père de famille", c'est-à-dire comme l'eût fait un homme d'une prudence et d'une intelligence moyennes, placé dans les mêmes circonstances* »[5].

Les administrateurs étant placés sous le régime de la responsabilité contractuelle, l'article 1150 C.c. est applicable et seuls les **dommages prévisibles** (sauf en cas d'inexécution dolosive) sont donc visés, ce moyen de l'imprévisibilité du dommage devant toutefois être soulevé par le défendeur et non d'office par le juge[6].

b) L'action sociale minoritaire

Sous l'article 444-2 [anc. art. 63*bis*] L.S.C. est repris une importante innovation de la Loi de Modernisation inspirée du droit belge tout en introduisant une solution différente par rapport à celle de notre pays voisin : il s'agit de l'action sociale minoritaire qui permet aux actionnaires (et aux titulaires de parts bénéficiaires avec droits de vote) minoritaires d'une société qui seuls ou ensemble atteignent un certain **seuil minimum d'actions d'exercer l'action sociale**. Cette innovation est un des rares cas où la situation des minoritaires ait été réellement améliorée en 2016 (ceci malgré de nombreuses déclarations contraires dans les commentaires des articles, point également soulevé à juste titre par le Conseil d'État). Même si l'action sociale minoritaire peut être exercée par des actionnaires et titulaires de parts bénéficiaires avec droit de vote ne représentant que **10 % des droits de vote,** la L.S.C. prend soin de préciser que cette action est exercée « pour le compte de la société ».

1 – Arrêt de la Cour d'appel du 15 juillet 2014, n° 38115 du rôle, ID 23767.

2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 782.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 96.

4 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 194.

5 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 395.

6 – Cour du 9 juin 1993, *P.*, 29, p. 269.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le législateur tient ici compte du fait que, pour diverses raisons, les actionnaires majoritaires sont souvent réticents à exercer l'action sociale, et ceci, pour la raison que ces actionnaires ont désigné les dirigeants sociaux (parfois ce sont eux-mêmes les dirigeants de la société), ce sont des membres de leur famille, des amis, etc. Par conséquent, souvent, les actionnaires majoritaires ont tendance à ne rien faire du tout. Les actionnaires minoritaires, s'ils n'ont pas les mêmes hésitations, n'ont par définition pas les droits de vote requis pour écarter le blocage qui leur est opposé par les majoritaires dans l'assemblée générale délibérant sur la question de l'action sociale.

Si le projet de loi n° 5730 dans sa version initiale avait fixé le seuil requis des actionnaires minoritaires **à 1 %** ou à une fraction du capital de 1 250 000 euros, la disposition finalement adoptée a retenu le seuil des « *actionnaires ou titulaires de parts bénéficiaires possédant à l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des titres ayant le droit de voter à cette assemblée représentant au moins 10 % des droits de vote attachés à l'ensemble de ces titres* ». En se référant aux droits de vote, le traitement des actions sans droit de vote a du même coup été résolu dans le sens que ceux-ci sont pris en considération, mais à condition d'avoir exceptionnellement été admis à voter à l'assemblée ayant décidé sur la décharge[1]. L'action minoritaire peut être dirigée non seulement contre les administrateurs, mais encore contre les membres du directoire ou du conseil de surveillance (mais pas contre les commissaires, ni contre les membres du comité de direction, ni contre le directeur général).

c) Mise en jeu de la responsabilité

Il est nécessaire qu'il y ait **faute**. Celle-ci peut consister en un acte positif, notamment un contrat conclu, des instructions données, ou dans un acte négatif, soit donc dans le fait d'avoir omis d'accomplir un acte nécessaire, de ne pas avoir agi alors que telle action aurait été nécessaire dans l'intérêt de la société[2]. A encore été jugé que « *[…] la personne qui accepte d'être administrateur d'une société doit nécessairement en accepter les obligations et le seul fait de laisser une autre personne diriger la société à sa place constitue déjà une faute (v. C.A., 20 octobre 2006, n° 34813 et n° 35149 du rôle qui considère même que ce fait constitue une faute grave et caractérisée). Il appartient par ailleurs à tout administrateur de contrôler la tenue régulière des livres comptables de la société. Ce désintérêt et cette absence de contrôle doivent être considérés comme fautifs dans le chef de A […]* »[3]. Afin d'échapper à sa responsabilité, il ne suffit pas d'établir sa bonne foi, mais il faudra apprécier si, avec une vigilance normale, la faute aurait pu être évitée.

Conformément au droit commun du mandat, l'*actio mandati* appartient au seul mandant, donc à la seule société. Il en irait différemment si les actes critiqués constituaient à la fois une faute contractuelle (mauvaise exécution du mandat) et un délit : dans ce cas, les tiers lésés pourraient agir, les actionnaires en revanche ne le pourraient pas[4]. Il appartient aux juges de qualifier de moyens ou de résultat les obligations

1 – *Doc. parl*., n° 5730, commentaire des articles, ID 10080.

2 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 96.

3 – TA Lux. du 25 avril 2014, *P.*, 37, p. 400.

4 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 395.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

assumées par les parties contractantes sur la base des critères tels que l'aléa dans l'exécution du contrat et la participation plus ou moins active du créancier dans l'exécution de l'obligation. « *Par application de la théorie de la causalité adéquate, la preuve d'un lien de causalité direct entre la faute et le dommage subi est requise. En effet, seul le dommage direct est réparable […] En d'autres termes, il s'agit d'opérer une sélection parmi les faits qui ont joué un rôle dans la réalisation du dommage et ne retenir comme causes directes que les faits qui, virtuellement, pouvaient rendre le dommage probable d'après le cours habituel des choses (G. Ravarani, op. cit. p. 700, n° 907)* »[1].

L'action dérivant du mandat est une **action sociale** qui existe au profit de la seule société, la mandante. Selon la jurisprudence, une intervention de l'assemblée générale des actionnaires est nécessaire : « L'actio mandati *n'est dès lors recevable qu'en présence d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires autorisant la société à l'exercer […] l'action introduite par l'assignation […] est à déclarer irrecevable* »[2].

Une action ne peut être introduite par des **actionnaires individuellement** que s'ils subissent un **préjudice personnel spécifique** distinct du préjudice subi par le patrimoine social dont ces actionnaires individuels subiraient les effets indirectement. « *Dès lors, les actionnaires agissant à titre individuel ne pourraient mettre en œuvre la responsabilité du conseil d'administration pour avoir accepté de réaliser un apport de branche d'activités suivi de fusions à des conditions défavorables pour la société. Seule celle-ci pourrait intenter cette action* »[3].

C'est à elle seule qu'il appartient de donner **décharge**. La décharge met en principe fin à cette action, même lorsqu'elle est intentée par les curateurs ou les liquidateurs[4]. Cette société s'exprimant par sa majorité, la décharge lie nécessairement les actionnaires de la minorité qui ne peuvent intenter l'action *ut individui*. L'action individuelle dérivant du mandat est donc écartée. Mais elle continue à exister pour tout dommage illicite causé aux associés dans le domaine de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l'article 1382 C.c.

Comme déjà souligné ci-dessus l'assemblée n'est en général pas portée à exercer une action contre les administrateurs en place, et ceci, pour la raison que les administrateurs ont en général un poids considérable dans l'assemblée des actionnaires soit pour la raison qu'ils sont actionnaires (ou proches parents d'actionnaires), soit qu'ils aient le support des personnes qui les ont élus dans une première phase. Il en résulte que les procès intentés par l'assemblée générale sont fort rares et que les procès intentés par la société le sont en général par le **curateur** de la faillite ou encore par les **liquidateurs**[5].

L'article 444-1 [anc. art. 63] L.S.C. contient une **disposition facultative** destinée à mettre en œuvre la responsabilité fondée sur l'action sociale contre les administrateurs et commissaires. Cette mise en œuvre peut se faire par la désignation d'un ou de plusieurs mandataires chargés de l'exécution de la délibération.

---

1 – TA Lux. du 7 novembre 2014, *P.*, 37, pp. 404 ss.

2 – TA Lux. du 26 février 2015, n° 136378 du rôle, *P.* 37, p. 624.

3 – Trib.com. Bruxelles du 6 juin 1977, cité par J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 389.

4 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 379.

5 – Ch. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, Wiener, 495.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2) Responsabilité délictuelle aggravée

L'article 441-9 [anc. art. 59], alinéa 2, L.S.C. introduit la **responsabilité solidaire** des administrateurs tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de la société en cas de violation des dispositions de la loi sur les sociétés et des statuts par eux commises. Celle-ci s'applique en cas d'infractions à la L.S.C. ou encore aux statuts. En effet, l'article 441-9 L.S.C. dispose : « *Les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux* ».

« *L'article 59, alinéa 2, ne s'applique que dans les cas où la faute des administrateurs provient d'une violation de la Loi de 1915 ou les statuts de la société. Il ne s'agit pas de simples fautes de gestion, mais de fautes beaucoup plus graves, d'atteintes portées au pacte fondamental de la société ou à une des disposition de la Loi de 1915, dispositions commandées par le souci de protéger et le public et les actionnaires eux-mêmes.*

Afin de pouvoir aboutir dans leur demande en réparation, les associés doivent dès lors établir que les dirigeants de la société ont commis des infractions et que ces infractions leur ont causé un préjudice qui leur est propre et ne se confond pas avec celui de la société elle-même »[1]

En raison de la violation particulièrement grave des obligations découlant de son mandat, cette responsabilité est aggravée en raison de la **solidarité**[2]. Le champ d'application de cette disposition de façon assez étrange (et en tout cas de façon inexpliquée) est différent de celui de l'alinéa 1er : si la Loi de Modernisation y a ajouté « *les membres du comité de direction et le directeur général* » aux administrateurs comme responsables envers la société, l'alinéa 2e se contente d'ajouter les seuls membres du comité de direction. Il s'agit sans doute d'une simple inadvertance, dont la correction dans un prochain projet de loi ne devrait pas soulever de discussions.

En droit commun de la responsabilité des mandataires, il n'y a en principe pas de solidarité : « *Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée* » (art. 1995 C.c.). Néanmoins, si le dommage résulte d'une faute commune et si elle se révèle imputable en totalité à plusieurs administrateurs, il peut y avoir condamnation *in solidum* de chacun à la réparation entière du préjudice[3]. « *[…] [s]i tous ont collaboré dans une même mesure aux actes culpeux, que la faute apparaît comme commune et indivisible, en sorte qu'il est impossible de déterminer la part de responsabilité de chacun et qu'au contraire, chacun d'eux peut être considéré comme ayant causé tout le dommage* »[4]. Cette solidarité a été instituée « *à raison du dol ou du moins de la faute grave qu'implique l'infraction à la loi ou au contrat social* ».

À l'égard de la société, cette responsabilité est encore une fois fondée sur le mandat.

« *Vis-à-vis de la société, cette responsabilité ne peut, encore une fois, être que la responsabilité* ex mandato*, encourue par le mandataire à l'égard du mandant, pour*

1 – TA Lux. du 26 février 2015, nº 142277 du rôle, ID 24652.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 132, ID 11308.

3 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 99.

4 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 100.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

une faute tout particulièrement grave commise par le premier dans l'exercice de son mandat et que, pour ce motif, l'article aggrave du poids de la solidarité »[1].

Le législateur n'a pas entendu rendre automatique l'application ce régime de la responsabilité solidaire. En effet, l'un ou l'autre administrateur peut être déchargé de cette responsabilité solidaire si trois conditions sont remplies :

– il n'a pas participé aux infractions visées ;
– aucune faute ne lui est imputable ; et
– il a dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après en avoir eu connaissance ; lorsqu'il s'agit des membres du comité de direction la dénonciation doit se faire lors de la première séance du conseil d'administration après qu'ils en auront pris connaissance[2]. Cette disposition avait été prise par opposition à la loi belge qui, elle, exigeait dans un tel cas que l'administrateur donne sa démission. Cette solution de la loi belge devait être critiquée par Pirmez dans les termes suivants : « *L'administrateur a autre chose à faire quand il voit violer les statuts qu'à déserter son poste, et s'il l'abandonne sans même signaler cette infraction, il manque évidemment à son devoir* »[3]. Dans l'avant-projet, la dénonciation devait encore se faire au commissaire avec la conséquence que celui-ci pouvait, en cas de besoin, convoquer d'urgence une assemblée générale avec l'objet de discuter sur cette question.

La seconde particularité de cette responsabilité en vertu de l'article 441-9 [anc. art. 59], alinéa 2, L.S.C. est qu'elle n'existe pas seulement envers la société, mais également envers le public en général, donc **envers les tiers**. Il s'agit de la responsabilité dérivant de tout acte dommageable illicite commis par les administrateurs, responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle fondée sur l'article 1382 et suivants C.c. Elle est encourue à l'égard de quiconque a souffert de l'acte dommageable, non seulement à l'égard des tiers, notamment les créanciers sociaux, mais également à l'égard des actionnaires pris individuellement[4].

Un tiers, le cas échéant lésé par l'exécution fautive ou simplement négligente du mandat, ne peut se réclamer de la responsabilité contractuelle, responsabilité qui ne vaut qu'à l'égard des cocontractants. Heureusement, il lui reste une autre voie de recours, à savoir celle de droit commun, **d'ordre délictuel,** basée sur l'article 1382 C.c. qui oblige l'auteur de tout acte (il s'agit de ceux qui se placent en dehors de relations contractuelles), qui cause un dommage à quelqu'un, à le réparer. Les administrateurs en violant la loi ou les statuts commettent un fait illicite et sont par conséquent tenus de réparer le dommage qui en résulte. Dans cette hypothèse, l'action appartient non seulement à la société, mais encore aux tiers. Cette formulation n'exclut pas les actionnaires : les droits des associés sont indépendants de ceux de la société, de sorte qu'une décision de l'assemblée ne pourrait avoir pour effet de l'éteindre[5].

---

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 132, ID 11308.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 193.

3 – Commentaire législatif à la loi de 1873, II, 54 cité par A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 193.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 136, ID 11308.

5 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 192.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette action est encore appelée **action personnelle** (par opposition à l'action sociale). « *Elle appartient à tous tiers qui ont éprouvé un préjudice par la violation des statuts ou de la loi, imputable aux administrateurs, aux gérants, aux commissaires* »[1].

La responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle (à l'égard des tiers) se rejoignent dans le sens suivant : « *Il se peut que les faits constitutifs de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse [du mandat] soient d'une nature telle qu'ils apparaissent aussi comme un manquement à l'obligation générale de prudence, de diligence et de compétence qui s'impose à chacun. En pareil cas, le tiers préjudicié qui invoque ce manquement à l'appui de son action, ne se prévaut pas de l'effet interne du contrat à son profit, – ce qui demeure interdit. Il se borne à invoquer l'existence de l'obligation contractuelle inexécutée comme un fait, pour en déduire en ce qui le concerne des conséquences fondées en droit, non sur la responsabilité particulière dont la convention est la source entre parties, mais sur la responsabilité aquilienne comme telle source distincte de droits et d'obligations* »[2].

Par tiers, on entend en premier lieu **l'actionnaire** qui exerce non pas ses droits d'actionnaire, mais les droits de créancier, et pour autant seulement qu'il ait subi un préjudice par la violation des statuts distinct du dommage social collectif ; il faut donc un **dommage individuel** et propre à l'actionnaire.

La notion de tiers vise en deuxième lieu les créanciers sociaux qui sont victimes d'actes qui relèvent d'une violation de la loi ou des statuts. On peut, par exemple, imaginer le cas où un tiers achète des actions de la société à un prix exagéré sur la base de bilans mensongers gonflant les bénéfices de la société.

Finalement sont encore visés les tiers autres que les créanciers sociaux qui ont subi un préjudice du fait des actions du conseil d'administration[3].

Si la violation des statuts n'est pas de nature à donner lieu aux moindres discussions (il s'agit des statuts de la société dans leur version applicable au moment des faits), la violation de la loi soulève des questions. S'agit-il seulement de la loi des sociétés ? La loi en se référant à « la présente loi » ne permet guère d'autre interprétation. Ne sont donc visées ni les dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil[4] ni les dispositions du Titre II de la Loi de 2002 « De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises » initialement comprises à la section XIII « Des comptes sociaux » L.S.C. et qui, avec effet, au 1er janvier 2005 ont été transférées à ladite Loi de 2002. Le projet de loi n° 5730 dans sa version d'origine avait voulu ajouter à l'alinéa 2 une référence « *aux normes comptables de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés […]* ». Il est vrai que les dispositions auxquelles cette proposition de modification faisait référence concernait les dispositions de l'ancienne section XIII L.S.C. qui avait été abrogée par la loi du 19 décembre 2002 pour être reprise en bloc par les chapitres II et IV du titre II de cette même loi. On ne peut que regretter que cette proposition n'ait pas été reprise dans la version définitivement adoptée de la Loi de Modernisation – ce qui signifie donc que la violation de ces normes comptables n'est en principe pas atteinte (pas plus que par le passé récent) par les dispositions de l'article 441-9 L.S.C.

1 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 101.

2 – J. van Ryn et X. Dieux, « La responsabilité des administrateurs ou gérants d'une personne morale à l'égard des tiers », *J.T.*, 1988. p. 401.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 101.

4 – P. Berna, *Statut des administrateurs de sociétés anonymes*, p. 38.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

3) La responsabilité de droit commun

Non prévue par les alinéas 1er et 2 de l'article 59 [nouv. art. 441-9] L.S.C., elle se trouve, en effet, tout entièrement dans le droit commun. « *C'est la responsabilité dérivant de tout acte dommageable illicite commis par les administrateurs, que cet acte constitue ou non une violation de la loi ou des statuts. C'est, encore une fois, la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l'article 1382 du Code civil, mais appliquée cette fois sans modification des principes généraux. C'est dire qu'elle est encourue à l'égard de quiconque a souffert de l'acte illicite dommageable, par conséquent non seulement vis-à-vis de la société et de tous tiers, que ceux-ci soient créanciers sociaux ou* penitus extranei *n'ayant nullement traité avec la société, mais même à l'égard des actionnaires individuellement […].*

Ici encore, la responsabilité sera donc engagée par la simple imprudence et elle obligera à la réparation de tout dommage résultant directement et immédiatement de l'acte commis. Mais comme le droit commun est ici seul en cause, la condamnation ne pourra être solidaire que dans les cas exceptionnels où le droit commun autorise cette aggravation de rigueur, c'est-à-dire dans les seuls cas où, l'acte illicite étant commis par plusieurs de telle façon qu'il soit impossible de préciser la part de chacun dans la perpétration du fait comme dans ses conséquences dommageables, force est bien, de par la nature même des choses, de les condamner tous et chacun à la réparation entière »[1].

Dans l'arrêt de la Cour d'appel du 15 juillet 2014[2], la Cour a retenu : « *La juridiction du premier degré a retenu à raison que le critère permettant de distinguer le préjudice social du préjudice individuel réparable consiste dans le fait que ce dernier va directement affecter la valeur des titres ou la situation patrimoniale de l'actionnaire sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier. Le préjudice individuel ne doit pas constituer une simple répercussion du préjudice social et doit, par conséquent, être déconnecté d'une perte qui affecterait l'actif social.*

Elle a encore dit à raison que même si un actionnaire dispose d'une action individuelle en réparation d'un préjudice distinct de celui de la société et des autres actionnaires, la recevabilité d'une telle action en responsabilité est soumise à l'allégation de ce préjudice personnel distinct et que le demandeur doit caractériser ce préjudice distinct (Cass. com. française, 7 mars 2006, n° de pourvoi 04-16536, Bulletin 2006 IV, n° 61, p. 61).

C'est au regard de ces deux principes qu'il y a lieu d'analyser la recevabilité des demandes en indemnisation. Sont partant à écarter tous les développements des intimés et notamment des dirigeants sociaux et du réviseur d'entreprises relatifs aux autres éléments constitutifs de la responsabilité civile, à savoir les caractères de la faute de nature à engager leur responsabilité et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

C'est à raison que le tribunal a, par une motivation exhaustive que la Cour adopte, déclaré irrecevable la demande principale de l'institution A.) en réparation du préjudice subi en raison de la perte de la valeur des parts détenues dans le

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 136, ID 11308.
2 – N° 38115 du rôle, ID 23767.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

capital de O.), évalué à 12.986.376,49 €, dès lors que ce dommage constitue non pas un dommage propre à chaque associé, mais un dommage subi par la société elle-même. Le dommage causé à l'actionnaire n'est que le corollaire de ce préjudice social.

Il a encore, à bon droit, déclaré irrecevable la demande de l'institution A.) qui réclame à titre de gain manqué suite à la demande de rachat, l'indemnisation de la perte des intérêts à compter du 9 décembre 2008 jusqu'au 22 mai 2009 sur la valeur nette d'inventaire de ses parts, étant donné que ce préjudice constitué par l'immobilisation de sa créance dans la procédure collective de son débiteur ne constitue pas un préjudice distinct de ceux des autres créanciers (Cour de Cassation française, 23 mai 2000, n° de pourvoi 97-19.817) ».

4) Appréciation de la faute par les juridictions

Qu'il s'agisse de la matière contractuelle ou de la matière délictuelle, toute faute, même la plus légère, engage la responsabilité de son auteur. L'appréciation de la faute se fait par référence à un administrateur abstrait (le **bon père de famille** de l'article 1137 C.c.). Par conséquent, le juge est tenu de comparer le comportement concret de l'administrateur dans le cas litigieux à celui d'un administrateur normalement diligent placé devant les mêmes circonstances de fait[1].

Il incombe au juge qui est confronté aux demandes en responsabilité d'analyser de manière circonstanciée les fautes alléguées. Dans cette appréciation de la réalité de la vie des affaires et du mode de fonctionnement usuel des entreprises, les juges sont amenés à définir le comportement du dirigeant normalement compétent et diligent. En tout état de cause, les juges doivent se placer dans les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles les dirigeants avaient à prendre les décisions critiquées, et ceci, sans juger *a posteriori* en prenant en compte des informations dont ne disposaient pas les dirigeants au moment de la prise de leurs décisions[2].

Conformément à la jurisprudence belge, les juridictions appelées à se prononcer sur le caractère fautif du comportement des dirigeants de sociétés appliquent la méthode dite de **l'appréciation marginale**[3]. Il s'agit d'un contrôle assez sommaire (qui exclut que le juge ne substitue son appréciation à celle des dirigeant sociaux en place et ne considère comme fautif que le comportement qui n'aurait pas pu être raisonnablement adopté par un homme normalement prudent et diligent se trouvant dans la même situation).

La deuxième règle à observer par le juge, non moins importante que la première, est la **méthode d'appréciation *a priori***. Elle signifie que le juge, dans son appréciation du comportement du dirigeant, doit se placer au moment où la décision est prise, et non pas au moment où l'affaire est discutée devant les juridictions plusieurs années plus tard. « *Il est essentiel que le juge s'efforce de se replacer dans les circonstances dans lesquelles les dirigeants se sont trouvés, en faisant abstraction de*

1 – P. Berna, *Statut des administrateurs de sociétés anonymes*, p. 22.

2 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 382.

3 – Pour plus de précisions sur cette expression, v. sous ce verbo.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ce qui n'a été révélé que par des faits ou des analyses postérieures : il doit apprécier si le comportement du dirigeant est a priori *raisonnable* »[1].

Cet effort de se resituer à l'époque où les décisions critiquées ont été prises est surtout important dans le cas très fréquent en pratique où la société dont la gestion est critiquée est entre-temps tombée en faillite. Dans un tel cas de figure, il est particulièrement tentant pour le juge (ou, le cas échéant, pour l'expert appelé à donner son appréciation sur les faits du cas d'espèce) de conclure de la faillite au caractère fautif du comportement des dirigeants. L'arrêt de la Cour d'appel de Liège peut servir d'avertissement dans ce contexte : « *C'est s'exposer à mal apprécier les faits et surtout les intentions que de remonter dans le cours d'événements en partant de leur point d'aboutissement : on a alors une vue d'ensemble sur leur suite, qui n'était pas celle qu'avaient ceux qui s'y sont trouvés engagés et dont le comportement a été commandé à divers moments successifs, par des faits mouvants qui ne suivaient pas toujours le cours que leur volonté souhaitait leur donner* »[2].

« *Dans tous les cas où la faute consiste dans un manquement à une règle de conduite et non pas dans la violation d'une norme légale, réglementaire ou statutaire, le juge doit appliquer la méthode de l'appréciation marginale. Le droit de la responsabilité, contractuelle ou aquilienne, ne repose pas sur le postulat de l'infaillibilité, en sorte que toute erreur d'appréciation n'est pas constitutive de faute* »[3].

En tout état de cause, il faut analyser le comportement visé au moment et dans le contexte où celui-ci a eu lieu. Dans ce cadre-là, il convient de voir si les administrateurs ont fait preuve de légèreté ou d'inconscience blâmable. Sinon, leur responsabilité ne peut être engagée, quel que soit par ailleurs l'ampleur de l'échec de leur gestion[4].

Les administrateurs ou gérants sont de véritables organes de la société avec la conséquence qu'ils expriment immédiatement la volonté de celle-ci. La faute commise par cet organe implique donc directement la responsabilité de la personne morale sur la base des articles 1382 et 1383 C.c. et non pas sur la base de l'article 1384, alinéa 3 C.c. Mais cet organe reste néanmoins une personne juridiquement distincte de la société. Dès lors, la responsabilité aquilienne de la personne morale en raison de la faute des organes n'exclut nullement la responsabilité personnelle de ces organes tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis de la société[5].

Souvent, la mise en cause de la responsabilité est faite dans le cadre de la **faillite** de la société. Il existe une certaine tendance des tribunaux (belges) à rendre les dirigeants sociaux responsables de la différence entre le produit de réalisation de l'actif et le passif social[6]. La mise en cause de la responsabilité des dirigeants exige cependant de déterminer quels sont les dommages liés aux fautes commises. Ainsi, si le reproche est d'avoir continué indûment une activité déficitaire, il faut déterminer quel aurait été le dommage si l'arrêt des activités avait eu lieu en temps utile. Dans ce

1 – O. Ralet, *Responsabilité des dirigeants de sociétés*, Larcier, 1996, p. 80.

2 – Liège du 31 mai 1958, cité par Parmentier, *R.D.C.B.*, 1986, p. 748.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence, 1979-1990 », *R.C.J.B.*, 1993, p. 786.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence, 1979-1990 », *R.C.J.B.*, 1993, p. 751.

5 – J. van Ryn et X. Dieux, « La responsabilité des administrateurs ou gérants d'une personne morale à l'égard des tiers », *J.T.*, 1988. p. 403.

6 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 390.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

cas de figure, quels auraient été les coûts subis par la société notamment au regard du passif social encouru au moment du licenciement du personnel[1] ?

Pour pouvoir invoquer la responsabilité d'un administrateur sur la base de l'article 1382 C.c., un tiers doit établir une faute dépassant la simple faute de gestion. « *Le principe reste toutefois que la responsabilité aquilienne des administrateurs ne peut être engagée que si leur comportement peut être jugé fautif, indépendamment de leur position de mandataires de la société : ils ne sont donc responsables à l'égard des tiers des fautes commises dans la gestion de la société que dans la mesure où un commerçant pourrait être jugé fautif s'il agissait de la sorte dans la gestion de ses propres affaires (cf. Responsabilité des dirigeants de sociétés, 2ème édition, éditions Larcier 2004, p. 121 et suivantes).*

De même, la doctrine française retient que l'immunité dont bénéficie le dirigeant à l'égard des tiers trouve sa limite dans la notion de faute détachable, séparable des fonctions de dirigeant.

Elle recouvre les hypothèses dans lesquelles le dirigeant a agi en dehors du cadre normal de ses attributions : l'acte du dirigeant ne peut dès lors être rattaché à l'activité de la société.

Par un arrêt du 20 mai 2003, la Cour de Cassation française a indiqué que la ***faute détachable ou séparable des fonctions*** *« est une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales » (Cass. Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092. D 2003.2623, note B. Dondero, JCP. Ed.E.2003.1398).*

En l'espèce, bien que la société CEL recherche la responsabilité personnelle de XX, elle n'invoque à l'appui de sa demande que des actes commis par cette dernière en sa qualité d'administrateur de la société EOI et reste ainsi en défaut de rapporter la preuve de fautes d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales exercées par la partie défenderesse.

À défaut d'avoir rapporté la preuve d'une faute détachable de sa fonction sociale, la demande de la société CEL à l'égard de XX n'est pas fondée »[2].

Lorsque le manquement reproché est sanctionné **pénalement**, les juridictions concluent que la faute est non seulement une faute contractuelle, mais en même temps une faute délictuelle : ainsi en est-il notamment du défaut d'aveu de faillite dans les trois jours de la connaissance de la cessation de paiements[3]-[4].

5) Responsabilité des administrateurs en application de dispositions légales spécifiques

Certaines dispositions légales imposent des **sanctions spécifiques** en cas de comportements critiquables de la part des administrateurs.

a) En cas d'augmentation de capital, les administrateurs se voient exposés aux mêmes règles que les fondateurs lors de la constitution de la société (art. 420-23 L.S.C.).

---

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 390.

2 – Jugement TA du 24 octobre 2008, Jugement civil II, n° 1309/08, nos 84 529 et 106 650 du rôle, ID 15893.

3 – Liège du 7 décembre 1988, *T.R.V.*, 1989, p. 441 ; Civ. Anvers du 8 mars 1982, *R.D.C.*, 1983, p. 288.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990), *R.C.J.B.*, 1993, p. 785.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

b) L'article 480-2 L.S.C. : si, en cas de pertes importantes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, convoque, de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l'être, l'assemblée générale qui délibérera, le cas échéant, dans les conditions de l'article 450-3, sur la dissolution éventuelle de la société. En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent (p. ex., les administrateurs s'abstiennent de convoquer l'assemblée générale des actionnaires), les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de l'accroissement de la perte. La jurisprudence a retenu la responsabilité des administrateurs d'une SA notamment sur la base de la violation de l'art. 100 [ancien] L.S.C. « *Ils ont violé l'article 100 sur les sociétés commerciales pour ne pas avoir soumis à l'assemblée générale la question de la dissolution de la société dès lors que celle-ci avait perdu la moitié de son capital social* » (TA Lux du 23 décembre 1987, n°s 29.975, 29.977, 29.978, 31.024, 31.533, 32.225, 33.672 et 33.673). Cette faute ne constituait qu'une parmi de multiples obligations légales violées par les administrateurs concernés qui, en outre, avaient commis de graves fautes de gestion, suffisantes à engager leur responsabilité à l'égard des tiers sur la base des articles 1382-1383 C.c. La problématique du lien de causalité ne fut pas abordée par le tribunal qui se contenta de relever que les fautes constatées étaient imputables aux administrateurs concernés.

« *Le juge répond à une allégation, fondée sur le texte de l'art. 100 L.S.C. (les administrateurs peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société), selon laquelle le non-respect des dispositions de cet article ne pourrait être invoqué que par les actionnaires et non pas par des tiers (en l'occurrence un créancier de la société) : Force est de constater que cette disposition n'exclut pas l'action des tiers pour violation de l'article 100. Cette action ne semble d'autant plus pas exclue par la loi sur les sociétés commerciales eu égard à l'article 59, alinéa 2, qui, de manière tout à fait générale, ouvre aux tiers une action en dommages et intérêts contre des administrateurs non respectueux de la législation sur les sociétés commerciales et des statuts sociaux* ». La cour d'appel a finalement rejeté la demande du créancier de la société fondée sur l'article 100 L.S.C. pour défaut de lien causal avec le préjudice[(1)].

c) En matière d'impôts directs (relevant de la compétence de l'administration des contributions directes), la Loi générale des impôts (*Abgabenordnung*) permet, en cas de comportement fautif des administrateurs, etc. de mettre à charge de ces mêmes dirigeants les impôts impayés par la société. Une disposition similaire a été introduite par la loi du 23 décembre 2016 en matière de TVA (art. 67-3 LTVA).

d) La réglementation du Code de commerce relative à la faillite permet dans certains cas d'étendre la faillite de la société aux dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes (art. 495 C. com.) ou encore de mettre à charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, apparents ou occultes, une insuffisance d'actif (art. 495-1 C. com.).

1 – TA Lux. du 26 juin 1998, n° 46458 et CA du 19 décembre 2001, n° 22.771, commentés par F. Fayot *in Ann. dr. lux.*, 2001, p. 565

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 2 – La structure dualiste : directoire-conseil de surveillance

Sous l'influence du droit de l'Union européenne, le législateur national a introduit sur une base volontaire la structure dualiste de gestion des sociétés anonymes, ce qui signifie donc que, dans chaque cas concret, les actionnaires fondateurs disposent du choix entre soit constituer une S.A. avec conseil d'administration, soit constituer une S.A. avec conseil de surveillance et directoire. La même alternative est ouverte en cours d'existence de la société, dans la mesure où il est toujours possible de changer de structure de gestion dans un sens ou dans l'autre.

À l'époque de l'introduction des premières directives prises en matière d'harmonisation du droit des sociétés, le Luxembourg, en retenant comme système de gestion unique le modèle avec conseil d'administration, n'avait pas fait fruit de cette possibilité de donner l'option aux entreprises de pouvoir choisir l'un ou l'autre système. Ce n'était qu'au moment où la SE a été introduite en droit national que cette option a donc été ouverte aux sociétés anonymes.

Le projet de loi n° 5352 reprenant les diverses options laissées par le règlement CE sur la SE s'exprime comme suit : « *Il a semblé opportun de faire usage de cette option, sans réserver le bénéfice de l'exercice de celle-ci aux seules SE mais au contraire de profiter de l'occasion pour rendre un tel régime dualiste de gestion disponible également aux sociétés non européennes, à l'instar du droit français qui ouvre aux sociétés anonymes locales la faculté de faire le choix d'un tel régime de gestion* »[1].

Cette innovation législative a été reprise dans la section II (« *Du directoire et du conseil de surveillance* ») du chapitre IV L.S.C. dénommée « *De l'administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)* ».

Aux termes de l'article 442-1, les statuts de toute S.A. peuvent prévoir que celle-ci est réglée par les dispositions de la section 2, ce qui implique donc que la société reste soumise à l'ensemble des règles des S.A., à l'exception de celles des articles 441-1 à 441-13.

La société est dirigée par un directoire dont les membres sont désignés par le conseil de surveillance, sauf si ce pouvoir est attribué à l'assemblée générale des actionnaires et, dans ce cas, l'assemblée est seule compétente[2]. Cette solution a été amendée par la Loi de Modernisation qui a précisé que ce point est résolu par les statuts et, à défaut, par le conseil de surveillance. Dans les sociétés unipersonnelles ou celles ayant un capital inférieur à 500 000 euros, une seule personne peut exercer les fonctions attribuées au directoire ; cette disposition a un champ d'application plus large que celle applicable aux sociétés anonymes pour lesquelles l'administrateur unique est strictement limité aux sociétés unipersonnelles.

Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Ils peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que par l'assemblée (si les statuts le prévoient).

1 – *Doc. parl.*, n° 5352, p. 32, ID 9952.

2 – Art. 442-3 [anc. art. 60*bis*-3], L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les statuts d'une SE doivent préciser les actes qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance (art. 442-8 L.S.C.). Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale.

A – Le directoire

Le directoire (« *Vorstand* » en allemand) est l'organe de gestion proprement dit. Ses membres sont désignés par le conseil de surveillance (et donc non pas par les actionnaires comme tel est le cas pour les administrateurs dans le cadre de la structure moniste). Mais cette disposition n'est pas impérative : les statuts peuvent attribuer à l'assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire, et celle-ci sera alors seule compétente pour le faire.

La **révocation** des membres du directoire se fait par le conseil de surveillance ainsi que par l'assemblée générale (dans ce dernier cas, uniquement si cette solution est prévue par les statuts sociaux, art. 442-5 L.S.C.).

1) Composition du directoire

Le **nombre des membres** du directoire est laissé ouvert par la loi, étant entendu que cette liberté est encadrée comme suit par les dispositions légales. L'article 442-2 L.S.C. prévoit que le nombre des membres et les règles de sa détermination sont fixés par les statuts pour la SE, alors que dans la S.A., ils sont fixés par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.

Par ailleurs, dans les S.A. unipersonnelles ou encore dans celles dont le capital est inférieur à 500 000 euros, **une seule personne** peut exercer les fonctions dévolues au directoire.

Si une personne morale peut être membre du directoire, celle-ci sera tenue de désigner un représentant chargé d'exécuter cette mission au nom et pour compte de la personne morale (art. 442-4 L.S.C.).

2) Durée des fonctions des directeurs

Les règles légales sont étroitement calquées sur celles applicables aux membres du conseil d'administration. Ce parallélisme se reflète notamment dans la **durée maximale** de leur mandat (6 ans), la possibilité de réélection, la possibilité de coopter provisoirement un membre du directoire (sauf interdiction par les statuts), ainsi que la confirmation obligatoire de cette cooptation par la prochaine assemblée.

3) Pouvoirs du directoire

Ici encore, le législateur s'aligne directement sur les solutions retenues à l'égard du **conseil d'administration** : le directoire « a *le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance et à l'assemblée générale* ». Il s'agit

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

donc d'une copie fidèle de la disposition prévue par l'article 441-5 L.S.C. à l'égard du conseil d'administration.

4) Obligations du directoire

Tous les trois mois au moins, le directoire fait un rapport écrit au conseil de surveillance portant sur la marche des affaires et leur évolution prévisible. En outre, le directoire est tenu de communiquer au conseil de surveillance toute information portant sur des événements qui pourraient avoir des répercussions sur la situation de la société.

B – Le conseil de surveillance

La mission du conseil de surveillance est « *d'exercer le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion* » (art. 442-11 L.S.C.). Quant au mode de désignation du conseil de surveillance, il est encore une fois renvoyé aux règles applicables au conseil d'administration dans la mesure où les règles des articles 441, 441-2, 441-3, 441-4 et 441-6 L.S.C. sont déclarées applicables à son égard (art. 442-14 L.S.C.). Il en résulte donc que le conseil de surveillance est composé de 3 membres au moins (en principe et sauf société unipersonnelle ou capital ne dépassant pas 500 000 euros), que la durée de leur mandat ne peut dépasser 6 ans, qu'ils sont en principe rééligibles, qu'en cas de vacance de poste d'un membre, il peut y avoir cooptation par les autres membres, le membre nouvellement coopté achevant le mandat du membre empêché.

C – Exercice en commun du pouvoir

Ces pouvoirs sont, le cas échéant, exercés en commun avec le conseil de surveillance sous le contrôle duquel le directoire agit.

1) Actes soumis à autorisation du conseil de surveillance

Les statuts énumèrent les opérations que le directoire ne peut effectuer qu'en raison d'une autorisation du conseil de surveillance. Dans la SE, les **statuts doivent obligatoirement** mentionner les opérations pour lesquelles une telle autorisation est requise. En cas de refus du conseil d'accorder l'autorisation, le différend peut être soumis à l'assemblée générale des associés.

Le directoire représente la société à l'égard des tiers et en justice. Les limitations apportées aux pouvoirs qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. Ceci signifie tout simplement qu'une fois de plus, les tiers n'ont pas à se soucier des décisions que les actionnaires entendent soumettre à l'autorisation du conseil de surveillance. La liste des opérations qui sont soumises à autorisation est en fait sans importance à leur égard.

Si dans une SE un acte de représentation a été ainsi posé dans les formes prévues, mais que cet acte aurait dû être autorisé par le conseil de surveillance sans que cette autorisation n'ait été obtenue, la société sera néanmoins engagée (art. 442-7 L.S.C.) (tout en étant susceptible d'engager la responsabilité des membres du directoire dans les relations internes).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2) Possibilité de confier le pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres

Tout à fait en ligne avec la possibilité de confier le pouvoir général de représentation à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, la loi accorde la possibilité de confier le pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du directoire. Cette clause, dûment publiée, est opposable aux tiers.

3) Étendue des actes des organes de la société

Aux termes de la loi, la société est liée par les actes posés par le directoire, les membres du directoire ayant qualité pour le représenter conformément à l'article 442-7 L.S.C., ou encore par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes **dépassent l'objet social**, à moins qu'elle n'arrive à prouver que le tiers savait qu'il dépassait cet objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que cette publication ne suffise à constituer cette preuve (art. 442-9 L.S.C.).

Les règles relatives à la responsabilité des membres du directoire ou du conseil de surveillance sont étudiées ensemble avec les règles sur la responsabilité des administrateurs et des commissaires des sociétés anonymes.

4) Pouvoir général du conseil de surveillance

Le pouvoir général de contrôle se manifeste de différentes manières. En premier lieu, l'information courante du conseil de surveillance est assurée au moyen des rapports trimestriels qui sont adressés au conseil de surveillance (art. 442-11 L.S.C.) flanquée de l'obligation imposée au directoire de devoir spontanément informer le conseil en raison de toute information ayant une certaine importance. En outre, le conseil peut demander des informations de toute nature nécessaires à l'exercice de son contrôle. Finalement, le conseil peut procéder à toutes les vérifications qu'il considère nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

5) Organisation du pouvoir dans le conseil de surveillance

Il est loisible au conseil de surveillance d'organiser son travail dans le sens qu'il peut donner à un ou plusieurs de ses membres des mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut y avoir création de commissions spéciales dont le conseil de surveillance fixe la composition et les attributions. Il est toutefois précisé que ces attributions ne peuvent avoir pour effet de déléguer des pouvoirs qui sont ceux du conseil de surveillance attribués par la loi ou les statuts ni de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire (art. 442-15 L.S.C.).

6) Indépendance entre directoire et conseil de surveillance

Une personne ne peut en même temps être membre du directoire et du conseil de surveillance (art. 442-17 L.S.C.). Néanmoins, en cas de vacance de poste au sein du directoire, le conseil de surveillance peut désigner l'un de ses membres pour

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

exercer les fonctions de membre du directoire. Ses fonctions en tant que membre du conseil de surveillance sont alors suspendues.

§ 3 – La gestion journalière

Le conseil d'administration qui se compose en principe de plusieurs personnes ne se réunit que périodiquement, ce qui peut ne pas suffire à l'accomplissement des actes qui incombent quotidiennement à la société. Ces tâches peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes présentes dans l'entreprise sur une base permanente[1].

Aux termes de l'article 441-10 L.S.C., la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion **peuvent être déléguées** à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seul ou conjointement. Cette faculté légale ne fait que consacrer la pratique selon laquelle un des administrateurs se voit confier des attributions qui sont normalement dévolues à un directeur-gérant. Il y a donc dans son chef un cumul de fonctions. Ce directeur-gérant n'est en général chargé que des détails de l'administration journalière. Son activité reste insérée dans le cadre tracé par le conseil d'administration.

A – Délégué à la gestion

En vertu de l'article 441-10 [anc. art. 60] L.S.C. (initialement introduit par la loi du 23 novembre 1972), « *La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.* »

Cet article, relatif à la gestion journalière, est maintenu dans sa version antérieure tout en étant augmenté d'un alinéa supplémentaire (alinéa 6) qui précise que les dispositions relatives aux conflits d'intérêt s'appliquent aux délégués à la gestion journalière. Ainsi se trouve comblée une lacune qui a existé pendant des décennies.

S'il est fait fruit de cette possibilité, alors *la* « *nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées* ».

Il appartient donc aux statuts de déterminer l'étendue des pouvoirs du délégué à la gestion journalière. Les statuts peuvent donc restreindre ces pouvoirs sans la moindre limitation, du moins dans les **relations internes** : comme pour les pouvoirs du conseil d'administration, la loi ne prévoit pas la moindre compétence réservée pour le délégué à la gestion journalière. Il est vrai que ces limitations sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules, soit conjointement, est **opposable aux tiers**

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 137, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dans les conditions prévues par la Loi de 2002. La délégation à un membre du conseil d'administration était traditionnellement subordonnée à **l'autorisation préalable** de l'assemblée générale et le conseil était obligé de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. Toutefois, l'autorisation préalable a été supprimée par la loi du 25 août 2006. La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

Dans un cas d'espèce, le litige portait sur la clause en vertu de laquelle un administrateur A était autorisé à engager la société par sa seule signature en matière de constructions métalliques, alors qu'en matière de génie civil l'administrateur B ne pouvait le faire qu'avec la signature conjointe d'un autre administrateur. Le tribunal a retenu que cette limitation de pouvoir était inopposable aux tiers et que B avait donc valablement pu engager la société en application du principe selon lequel « *dès que certains pouvoirs sont délégués, conformément aux statuts, à une personne, celle-ci est investie de tous les pouvoirs de gestion normale rentrant dans l'activité poursuivie par la société sans que les limitations éventuellement mises à la délégation soient opposables aux tiers* »[1].

Le délégué à la gestion journalière peut-il être lié par un contrat de travail à la société ?

B – Gestion journalière et contrat d'emploi

L'article 441-10 [anc. art. 60] L.S.C. est à l'origine d'une situation quelque peu ambiguë, du fait qu'il prévoit dans son dernier alinéa : « *La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles du mandat* ». De cette disposition, on a pu inférer que, tout comme l'administrateur, le délégué à la gestion journalière serait nécessairement un mandataire, et donc il serait révocable *ad nutum* à tous les coups[2]. « *Cependant, il résulte des termes mêmes de l'article [60] que le rôle du délégué ne se limite pas à l'accomplissement d'actes juridiques au nom et pour compte de la société – ce qui constitue, à proprement parler, le seul objet du mandat tel qu'il est défini par l'article 1984 du Code civil – mais comprend également une activité interne de gestion* »[3].

De cet état des choses, une partie de la doctrine a déduit que le délégué n'est pas seulement un mandataire, mais qu'il est presque toujours un employé lié à la société par un contrat de louage de services[4]. Par opposition à cette position, une autre partie de la doctrine[5] a considéré que l'article 63 des lois coordonnées (qui correspond totalement à l'article 60 L.S.C.) interdit de considérer que le délégué serait dans le cadre des fonctions de gestion journalière reconnu comme salarié de la société. Pour ce dernier, le **cumul** d'un mandat de délégué à la gestion journalière et d'un contrat d'emploi n'est donc envisageable que dans le cas où le délégué exerce, en dehors de ses attributions sociales, « […] *une fonction totalement différente, celle de directeur technique ou de chef*

1 – CA du 2 avril 2003, n° 26100, *BIJ*, 2003, p. 106.

2 – V. J. Van Ryn, Principes de droit commercial, T. 1, 1re éd., n° 644. L. Frédéricq, *Traité de droit commercial*, T. V, n° 456.

3 – S.J. Nudelhole, note sous arrêt Cass. du 22 janvier 1981, *R.C.J.B.*, 1981, p. 513.

4 – V. Ch. Resteau, T. II, nos 1090 à 1103.

5 – V. De Page, T. V, n° 470.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de la fabrication, par exemple »[1]. C'est cette opinion de De Page qui est suivie par la majorité de la doctrine. Selon cette opinion, il ne suffit pas d'un lien de subordination effectif pour que le délégué puisse être considéré comme salarié : il faut encore qu'il exerce des **fonctions techniques ou administratives distinctes** de la gestion générale de la société.

Si la jurisprudence, notamment luxembourgeoise, fait sienne cette position, elle est mise en doute par la doctrine belge qui considère que le délégué à la gestion journalière étant un organe de la société, il ne saurait par conséquent se trouver dans un **lien de subordination** envers cette personne morale. Par conséquent, la responsabilité civile de la société serait engagée directement sur la base des articles 1382 ou 1383, mais non sur la base de l'article 1384, C.c.[2].

En application de l'article 1384, alinéa 3, C.c. la responsabilité des commettants est retenue en raison des dommages causés par les préposés « *dans les fonctions auxquelles ils ont été employés* ». Il résulte de cette disposition que « *si l'acte du préposé est étranger à ses fonctions, le commettant ne saurait être responsable des conséquences de cet acte* »[3].

La jurisprudence belge[4] avait à trancher le cas suivant : en 1962, J.M. Cession fut engagé par la Société Générale des Conduites d'Eau comme directeur, et le conseil d'administration lui délégua les pouvoirs nécessaires pour « *[…] diriger, gérer et administrer toutes les affaires courantes de la société* ». Quelques années plus tard, la société mit fin aux fonctions du directeur, et ce dernier assigna la société en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive. Devant les juridictions, le directeur fit valoir qu'il avait exercé pour le compte de la société des fonctions techniques et administratives distinctes de la gestion des affaires journalières tout en se trouvant dans l'exercice de ses fonctions, dans un rapport de subordination effectif sous l'autorité d'un comité de direction et d'un administrateur délégué.

Dans le silence des statuts, le délégué à la gestion journalière est nommé par le conseil d'administration. Il peut cependant être désigné par l'assemblée générale soit en vertu d'une clause spéciale, soit en vertu d'une clause des statuts[5].

Selon la jurisprudence luxembourgeoise, est à considérer comme mandataire et non comme employé au sens de la loi du 31 octobre 1919 le directeur d'une société commerciale qui représente celle-ci et qui est chargé de la gestion des affaires courantes dans les limites des attributions du conseil d'administration. Dès lors, la dite loi ne lui est pas applicable et les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les contestations relatives à son engagement[6]. Il est loisible aux parties de stipuler dans l'acte de nomination du directeur chargé de la gestion des affaires journalières d'une société anonyme, conformément à l'article 441-10 L.S.C., qu'il ne sera pas **révocable sans motifs** ; comme il s'agit d'un mandat salarié, cette restriction de

1 – V. De Page, T. V, cité par Nudelhole, p. 510.

2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990), *R.C.J.B.*, 1993, p. 751.

3 – Just. de paix de Luxembourg du 8 mars 1979, *P.*, 24, p. 240, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cass. b. du 22 janvier 1981, *R.C.J.B.*, 1981, p. 495, note S.J. Nudelhole.

5 – S.J. Nudelhole, note sous arrêt Cass. du 22 janvier 1981, *R.C.J.B.*, 1981, p. 508 ; Cass. b. du 18 mai 1967, *Pas.,* I, p. 1079.

6 – CA du 10 mai 1929, *Pas.*, 12, p. 174.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la révocabilité au seul cas d'existence de motifs légitimes peut même être tacite et s'inférer des circonstances et points de fait à décider dans chaque cas particulier. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un administrateur délégué comme directeur, la cessation des fonctions d'administrateur entraîne nécessairement de plein droit celle des fonctions de directeur[2].

Aucune disposition de la législation luxembourgeoise sur les sociétés commerciales ni aucun autre texte de loi ni aucun principe de droit ne prohibent le **cumul** dans une même personne des fonctions d'administrateur d'une société anonyme et de celles d'employé de cette même société. « *La seule condition exigée pour la validité du cumul est que le contrat de louage de services soit une convention réelle et sérieuse et non pas une convention simulée dans l'unique but, soit d'échapper à la règle d'ordre public de la révocabilité ad nutum du mandat d'administrateur, soit de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable. Ce ne serait qu'en cas d'une pareille manœuvre frauduleuse que les tribunaux devraient, en appréciant librement les faits, déclarer nul et de nul effet le contrat de louage de services par application du principe* "fraus omnia corrumpit" »[1].

Si, tout comme l'administrateur ordinaire d'une société anonyme, l'administrateur-délégué peut être lié à la société par un contrat de louage de services, ce qui lui donne alors la double qualité d'administrateur-délégué et d'employé, il en est autrement, lorsque la personne en question est le seul et unique administrateur-délégué de la société. Dans ce cas, le rapport de subordination, qui est un élément essentiel du contrat d'emploi, est, en effet, exclu, alors qu'il est inconcevable qu'une personne se donne des ordres à elle-même[2].

Il est remarquable que, dans l'affaire visée, c'est justement le cas qui se présentait : un administrateur-délégué unique qui, en même temps, avait la qualité de secrétaire-dactylo. Néanmoins, la cour d'appel conclut à la validité du contrat de travail sur la base d'une argumentation faisant état notamment du caractère temporaire de la délégation de la gestion journalière (l'intéressée étant entre-temps redevenue simple administrateur) et du fait que cette dernière restait affiliée à la sécurité sociale[4].

En cas de cumul des fonctions d'administrateur d'une société anonyme et de celles d'employé de cette société, les deux activités sont régies chacune par des règles qui leur sont propres. En conséquence, si le mandat d'administrateur est révocable *ad nutum* par l'assemblée générale des actionnaires, il ne peut être mis fin au contrat de louage de services que pour des motifs qui ont trait à la fonction d'employé et qui sont suffisamment graves pour justifier la résolution immédiate du contrat[3].

Dans un cas d'espèce, il était reproché au salarié qui était en même temps administrateur de la société d'avoir résilié son contrat de travail. La cour d'appel de Luxembourg refusa d'engager la responsabilité de l'administrateur sur la base de l'article 59 [nouv. art. 441-9] L.S.C. au motif qu'un salarié est « *toujours libre de*

1 – CA du 5 novembre 1968, *P.*, 21, p. 82, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 5 novembre 1968, *P.*, 21, p. 82, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA du 5 novembre 1968, *P.*, 21, p. 87, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

résilier son contrat de travail et on ne saurait l'empêcher de ce faire au motif qu'il est administrateur de la société employeuse »[1].

Cette décision retient la possibilité pour un administrateur-délégué unique, par ailleurs membre du conseil d'administration, de **cumuler son mandat social** avec un **contrat d'emploi** dans la mesure où une fonction technique distincte est exercée dans les liens du contrat d'emploi sous la surveillance et l'autorité permanente d'un organe ayant une existence propre (en l'occurrence, le conseil d'administration même si, en l'espèce, l'intéressé en fait partie) et en mesure d'exercer sur le préposé les pouvoirs qui caractérisent le lien de subordination[2].

Dans une espèce où une employée revêtant en même temps, aux termes des statuts de la société, la qualité d'administrateur-délégué unique contestait avoir marqué son accord quant à cette dernière nomination, le tribunal arbitral de Luxembourg fit observer que « *rien n'empêche le juge de constater, en cas de coexistence d'un mandat social et d'un contrat d'emploi, que c'est en fait le mandat social qui constitue la fiction comme ne correspondant à aucun pouvoir réellement exercé, et que les fonctions attribuées au demandeur sont celles d'un employé subordonné* »[3].

La jurisprudence belge est quelque peu différente : elle retient qu'il n'existe aucune incompatibilité de principe entre la qualité d'administrateur ou de délégué à la gestion journalière et celle d'employé de la société[4].

Le contrat de travail doit avoir une existence réelle à côté des fonctions d'administrateur. Il faut vérifier si concrètement l'administrateur dans ses fonctions d'employé exerce des *fonctions différentes* de celles qu'il accomplit comme administrateur (et en particulier comme administrateur délégué), sous peine de quoi les fonctions d'administrateurs « *absorbent* » l'activité exercée à un autre titre et c'est le statut d'administrateur qui s'applique exclusivement[5]. En outre, « *il faut que l'administrateur se trouve dans un lien de subordination effective à l'égard de la société qui est représentée à cet effet par l'un de ses organes : conseil d'administration, administrateur-délégué, exerçant son autorité sur un de ses collègues agissant comme administrateur-directeur, par exemple, ou encore assemblée générale des actionnaires – particulièrement dans une société de petite importance* ».

La question controversée en Belgique est celle de savoir si un administrateur d'une société peut cumuler son mandat d'administrateur avec un contrat d'emploi qui n'aurait pas d'autre objet que les fonctions de délégué à la gestion journalière.

Pour la doctrine belge dominante, le cumul d'un mandat de délégué à la gestion journalière et d'un contrat d'emploi n'est possible que si le délégué exerce, outre ses

1 – CA du 30 octobre 2002, *BIJ*, 2002, n° 2, p. 36.

2 – CA du 29 mai 1986, n° 8259 (en ce sens également : CA du 27 mars 1986, n° 8.568) (Cumul entre contrat d'emploi et fonction d'administrateur-délégué). Cumul exclu, car il s'agit en l'espèce d'un administrateur-délégué unique (impossibilité d'un lien de subordination). Trib. arb. Lux. du 10 mars 1989, *Rép. fisc*., n° 934/89, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Trib. arb. Lux. du 12 janvier 1990, *Rép. fisc*., n° 146/90, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – V. Cass. b. du 11 septembre 1959, *Pas.*, 1960, I, p. 36 ; Cass. du 24 décembre 1964, *Pas.*, 1965, I, p. 418 ; Cass. du 4 mars 1965, *Pas.*, I, p. 675.

5 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 368.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

attributions sociales, une fonction totalement différente, celle de directeur technique ou de chef de fabrication, par exemple[1].

Cette position se fonde encore sur la dernière phrase de l'article 63 des lois coordonnées (qui correspond à l'article 441-10 L.S.C.) selon lequel « *la responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat* ». La question est alors de savoir si le législateur a de ce fait entendu écarter toute qualification autre que celle du mandat (position de De Page) ou si cette disposition se limite à la question de la responsabilité du délégué à la gestion journalière[2]. Cet alinéa peut recevoir une interprétation étroite en le cantonnant à la question de la responsabilité du délégué, avec donc la conséquence que le législateur n'aurait pas entendu exclure toute qualification autre que celle du mandat[3].

L'arrêt annoté par Nudelhole, contrairement à la doctrine et la jurisprudence dominantes, admet que la gestion journalière ne puisse tant que telle faire l'objet d'un contrat d'emploi[4].

Signalons encore que la situation est différente en droit français dans la mesure où, dans ce pays, il est acquis que le directeur général de la société anonyme ne peut être qu'un mandataire révocable *ad nutum*, au même titre que les administrateurs. Cette règle était déjà admise sous la loi du 24 juillet 1867 et fut expressément consacrée par les lois des 16 novembre 1940 et 4 mars 1943[5].

C – Définition de gestion journalière

La notion de gestion journalière n'est pas définie par la loi. Pour la Cour de cassation belge, la gestion journalière comprend, d'une part, les actes qui sont commandés par les besoins de la **vie quotidienne** de la société et, d'autre part, ceux qui, tant en raison de leur **peu d'importance** que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration[5]. Cette définition manquant de précision, il est fréquent en pratique que les statuts tentent de préciser le contenu de la notion, mais il est certain que les statuts ne sauraient donner à la notion de gestion journalière un contenu différent de celui donné par la loi. Ainsi, par exemple, la gestion journalière ne pourrait être définie de façon excessivement large dans le sens qu'elle embrasserait la quasi-totalité des pouvoirs du conseil d'administration. Une telle délégation est prohibée pour la raison que la loi interdit toute délégation générale des pouvoirs autres que ceux de l'administration journalière. Même si la Cour de cassation belge en date du 6 février 1953[6] en décida autrement en retenant que le conseil d'administration pourrait consentir une délégation plus extensive que celle prévue par la loi, les statuts pourraient néanmoins élargir la notion de gestion journalière en vertu du principe d'autonomie de la volonté. Cette réserve n'est plus acceptable de nos jours. « *En effet, c'est la loi qui autorise la délégation de la gestion journalière et*

1 – Selon De Page, T. V, n° 470.

2 – Telle est la position de S.J. Nudelhole, note sous arrêt Cass. du 22 janvier 1981, *R.C.J.B.*, 1981, p. 513.

3 – V. S.J. Nudelhole, note sous arrêt Cass. du 22 janvier 1981, *R.C.J.B.*, 1981, p. 513.

4 – V. S.J. Nudelhole, note sous arrêt Cass. du 22 janvier 1981, *R.C.J.B.*, 1981, p. 514.

5 – V. S.J. Nudelhole, note sous arrêt Cass. du 22 janvier 1981, *R.C.J.B.*, 1981, p. 508.

6 – *Pas.*, I, p. 436.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

il n'appartient pas aux statuts de prévoir d'autres organes que ceux prévus par la loi ni de définir leurs pouvoirs dans des conditions différentes de celles que la loi autorise. En conséquence, seule la loi définit le contenu de la gestion journalière et il n'appartient pas aux statuts de modifier celle-ci. […] Cette interprétation nous paraît s'imposer tout particulièrement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 1973 qui organise de manière impérative la répartition des pouvoirs entre les organes de la société anonyme »[1]. L'énumération des pouvoirs donnés aux administrateurs ne peut avoir d'effets que dans la mesure où elle se borne à expliciter le concept légal, mais non à l'étendre. Lorsque les pouvoirs attribués sont trop étendus par rapport au concept légal, il y a lieu de les réduire, et non pas de considérer la délégation comme nulle[2].

Les engagements et les licenciements de personnel relèvent-ils de la gestion journalière ? Selon la Cour de travail de Bruxelles[3], la nomination, la révocation et la destitution des membres du personnel d'une société a, par son importance, un caractère exceptionnel. Selon cette cour, ces opérations ne peuvent donc pas relever de la gestion journalière. D'une part, une telle position doit être rejetée pour être trop générale ; d'autre part, elle ne correspond pas aux besoins de la pratique, surtout pour les sociétés d'une certaine importance[4].

Les actes accomplis au-delà des pouvoirs de gestion journalière pourront toujours faire l'objet d'une ratification par le conseil d'administration ; celle-ci peut même être tacite.

Depuis la Première directive, il convient de distinguer les relations internes de celles avec les tiers. Dans les relations internes, les pouvoirs du délégué peuvent être limités. Dans les relations avec les tiers, les limitations aux pouvoirs de représentation à l'égard des tiers ne sont plus opposables à ces tiers[5]-[6]. Les pouvoirs du délégué à la gestion journalière sont limités par la loi. Lorsque les attributions accordées au délégué sont plus larges, elles seront d'office réduites aux limites prévues par l'article 441-10 L.S.C. : en effet, cet article prévoit une limitation légale aux pouvoirs de l'organe. En tant que telle, elle est non seulement applicable en interne, mais encore opposable à l'égard des tiers[2].

Le premier critère d'appréciation des pouvoirs du délégué à la gestion journalière est **l'objet social** de la société. L'étendue de cette notion dépend pour une large part de la nature de l'entreprise. En deuxième lieu, les pouvoirs du délégué représentent une portion des attributions du conseil d'administration[7]. À ce titre, le conseil d'administration peut toujours intervenir dans la gestion journalière, et il peut agir de sa propre initiative à l'exclusion du délégué. Il en résulte que plus les pouvoirs du conseil d'administration sont étendus, plus les attributions du délégué seront étendues également.

---

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 397.

2 – V. J. Van Ryn, *Principes de droit commercial,* T. 1, n° 649.

3 – C. trav. Bruxelles du 5 mai 1976, *R.P.S.*, 1976, p. 57.

4 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 398.

5 – TPI Bruxelles du 26 juillet 1974, *R.P.S.,* 1974, p. 195.

6 – S.J. Nudelhole, note sous arrêt Cass du 22 janvier 1981, *R.C.J.B.*, 1981, p. 508.

7 – J. Lehrer, « La notion de gestion journalière. Recherche d'une méthode », *R.P.S.*, 1957, p. 72.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En troisième lieu, le délégué est limité par la **ligne tracée par le conseil**. En dehors de celle-ci, il ne saurait ni engager ni représenter la société[1].

Finalement, sont visés uniquement les actes de pratique courante. Il s'agit des actes qui doivent être accomplis au jour le jour et qui « *en raison de leur peu d'importance et de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil* »[4]-[2].

Une dernière limitation résulte de l'article 441-10 L.S.C. : toute délégation excédant le cadre de la gestion journalière serait interdite pour la raison que le législateur a voulu que l'administration générale soit confiée au conseil d'administration qui bénéficie de la confiance des actionnaires[3].

La doctrine considère que sont visés les actes d'exploitation accomplis dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration ou des directives arrêtées par lui[4].

Concrètement, le délégué peut toujours procéder aux actes conservatoires s'ils ne préjugent pas du fond des droits, et aux actes d'exploitation (à l'exclusion des actes judiciaires), etc.[5]

L'intérêt de la distinction entre gestion journalière et actes dépassant celle-ci réside dans le fait que la société n'est pas engagée pour les actes accomplis par le délégué dans la mesure où ceux-ci excèdent celle-ci et que la société ne saurait pas non plus s'en prévaloir à l'égard des tiers[5].

Si l'action en justice reste dans les limites de la gestion journalière, la société peut agir par l'intermédiaire de son administrateur-délégué à la gestion journalière dans les limites de cette gestion journalière[6].

La jurisprudence luxembourgeoise retient également que le délégué peut agir en justice même si, dans le cas d'espèce, le tribunal considéra, qu'au « *vu des circonstances et de l'envergure de l'affaire* », il ne s'agissait pas d'une décision de gestion journalière[7].

Dans cette affaire, le tribunal retint que : « *la personne morale n'est pas obligée de prouver à l'occasion d'une action en justice que la décision de l'introduction de l'action a été ordonnée par l'organe compétent, la régularité de cette décision étant présumée* »[8].

Si la délégation dépasse les actes de gestion journalière, alors les actes pris sur la base d'une telle délégation pourront être déclarés non valables. Ainsi, dans une affaire soumise à la Cour de cassation belge, des pouvoirs d'administration dépassant cette gestion journalière avaient été accordés à une dame Marchand qui

1 – J. Lehrer, « La notion de gestion journalière. Recherche d'une méthode », *R.P.S.*, 1957, p. 73.

2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990), *R.C.J.B.*, 1993, p. 780.

3 – J. Lehrer, « La notion de gestion journalière. Recherche d'une méthode », *R.P.S.*, 1957, p. 72.

4 – J. van Ryn, T. 1, 1re éd., n° 649.

5 – J. Lehrer, « La notion de gestion journalière. Recherche d'une méthode », *R.P.S.* 1957, p. 76.

6 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990), *R.C.J.B.*, 1993, p. 781. – V. P. Demeur, *R.P.S.*, 1961, p. 657 et J. Lehrer, *R.P.S.*, 1957, n° 4657.

7 – TA Lux. du 16 mai 2002, v. Fr. Fayot, *Ann. dr. lux.*, 2002, p. 571, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

8 – Cass., 15 novembre 2001, n° 58/10, n° 1826 du registre (cassation d'un arrêt de la CA du 29 novembre 2000, ID 14464).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

en avait usé pour donner congé à un locataire et pour refuser de renouveler le bail commercial demandé par ce locataire[1].

La **jurisprudence** proprement **luxembourgeoise** consacrée à cette matière est tout au plus clairsemée. Ce qui ressort tant de la doctrine que de la jurisprudence étrangère est que cette notion doit être appréciée *in concreto* en connaissance de la situation spécifique de la société visée. Il en résulte donc que ce qui peut dépasser la gestion journalière dans une entreprise donnée continue à en faire partie dans une autre entreprise (et vice versa). Concrètement, l'acquisition d'un immeuble peut soit être un acte de gestion journalière, soit clairement dépasser le cadre d'une telle gestion journalière selon l'envergure de l'entreprise et selon le domaine des activités poursuivies par cette entreprise.

« *Par les termes : affaires courantes on comprend la gestion journalière consistant dans l'accomplissement des actes qui ne sont que l'exécution quotidienne de la ligne de conduite tracée par le conseil* »[2].

Dans un cas d'espèce, la Cour d'appel de Luxembourg se prononça sur l'étendue des pouvoirs d'un administrateur délégué à la gestion journalière qui avait posé un acte dépassant manifestement le cadre de la notion de « gestion journalière » (celui-ci avait cédé 95 % de la participation que détenait la société dans un groupe pour une somme de 80 000 000 LUF). « *Les statuts de la société prévoyaient notamment : que la société pouvait être engagée soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration soit par la signature conjointe de deux administrateurs (application de l'art. 53, alinéa 4, L. 10 août 1915) ; que le conseil d'administration pouvait déléguer ses pouvoirs dans le cadre de la gestion journalière. Par une résolution subséquente, le conseil d'administration décida que, conformément à la disposition statutaire permettant une délégation de signature, "la société se trouvera engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué"* ». La cour d'appel décida que, par l'effet de la résolution précitée du conseil d'administration, l'administrateur-délégué se trouvait implicitement nommé président du conseil d'administration qui, en cette qualité, pouvait bénéficier de la délégation individuelle de signature, laquelle ne se trouvait pas enfermée par les limites inhérentes à la notion de « gestion journalière »[3].

Dans une affaire tranchée par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg[4], référence est faite à la jurisprudence belge citée. « *La Cour de cassation belge définit cette notion comme les actes "qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ou les actes qui, en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration" (Cass. 17 septembre 1968, Pas. 1969, I. p. 66). La Cour distingue ainsi deux catégories d'actes, ceux qui concernent le fonctionnement quotidien de la société et qui sont posés régulièrement et habituellement, et ceux plutôt exceptionnels et qui, en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration. Dans son arrêt du 26 février 2009,*

1 – L. Simont et P. van Ommeslaghe, « Cour de cassation du 17 mai 1962 », *R.C.J.B.*, 1964, p. 89.

2 – CA du 10 mai 1929, *Pas.*, 11, p. 459, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA du 14 juillet 1998, nº 17.583, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 5 novembre 2014, nº 19067 du rôle, ID 24046.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la même Cour a encore précisé que les deux conditions, faible importance et urgence, devaient être remplies cumulativement (CA 4e, 6 avril 2011, n° rôle 34274[1]*) […].*

Or, en l'espèce, le tribunal constate que l'accord du 6 janvier 2012 par lequel T.) déclare que toutes les dettes de R.) auprès de la société SOC. 1) sont effacées avec effet immédiat, au motif que "M. R.) a transféré son contrat personnel et les fruits économiques de ce contrat qu'il avait avec SIM Spa […], et que M. R.) ne réclame plus des dédommagements financiers pour le loyer et les salaires non récupéré auprès de la SOC. 1) S.A. ", constitue d'une part un acte unique dont la nature et l'envergure dépasse le cadre de la vie quotidienne et que d'autre part il ne s'agit pas d'un acte de moindre importance pris dans l'urgence.

Comme l'accord du 6 janvier 2012 ne relève pas de la gestion journalière de la société SOC. 1), T.) n'avait pas qualité pour signer seul cet acte, de sorte que l'accord est frappé de nullité.

L'annulation de l'acte lui ôte toute efficacité juridique ; les effets produits dans le passé sont en principe effacés, la situation devant être remise dans l'état antérieur à la passation de l'acte. L'annulation de l'acte aura donc comme conséquence que la société SOC. 1) dispose toujours d'une créance de 442 150,49 euros envers R.) »[2].

1) Licéité des comités spéciaux délégués à la gestion journalière

La question de la licéité des comités de direction introduits par le passé dans certaines grandes sociétés anonymes locales ne pouvait se poser qu'avant l'entrée en vigueur de la Loi de Modernisation qui a introduit un certain nombre d'organes facultatifs (dont précisément le comité de direction). Pour une étude de ces organes facultatifs, voir sous ce verbo.

Dans une espèce[3] où le pouvoir de fixer la rémunération des membres du comité de direction de la S.A. avait été délégué par le conseil d'administration à un comité restreint composé des président, vice-président, un administrateur belge et un administrateur luxembourgeois, des administrateurs membres du personnel, dont la nomination avait été effectuée en application de la législation luxembourgeoise relative à la cogestion, tentèrent d'obtenir l'annulation de la décision du conseil d'administration portant la délégation précitée. Le tribunal s'étendit à cette occasion sur la licéité du « comité restreint » : « *[…] le comité restreint a été créé dans le cadre d'une sorte de répartition des tâches entre les administrateurs ; ce comité, n'ayant aucune existence légale sur le plan juridique, et encore moins la qualité d'organe de société, n'est pas opposable aux tiers. Pareille "répartition des tâches", si elle n'est pas réglementée dans la loi luxembourgeoise des sociétés à l'instar de la loi belge (art. 54 modifié par la loi du 6 mars 1973) se pratique cependant couramment dans les grandes sociétés sous forme de comités portant sur les objets les plus divers. Elle n'est pas contraire aux dispositions légales en matière de sociétés et, en particulier, ne met pas en cause le caractère collégial du conseil d'administration. En effet, le fonctionnement de la société se verrait paralysé si le conseil d'administration ne pouvait agir que tous*

1 – ID 17729.

2 – Dans le même sens, TA Lux. du 2 avril 2014, *P.*, 37, p. 392, avec note I. Corbisier.

3 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Etudes du Laboratoire de droit économique, p. 515 ; TA Lux. du 11 juin 1987, n° 36722, ID 17459.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

membres réunis […] Si dans ses rapports avec les tiers, le conseil d'administration n'est pas obligé d'agir collectivement compte tenu de la possibilité qu'il a de déléguer la gestion journalière […] et de conférer des mandats particuliers […] a fortiori *faut-il laisser au conseil d'administration la liberté d'organiser ses structures internes selon les besoins de son fonctionnement. Car le principe de la délibération en collège est sauvegardé pour autant puisque ce sera en réalité le collège tout entier, déléguant ou mandant, qui agira par l'intermédiaire du délégué ou du mandataire spécial* ».

2) Impact de la législation sur la représentation des salariés

En outre, la loi du 6 mars 1974 relative à la cogestion (entre-temps reprise dans le Code du travail : art. 426-1 ss.) ne prévoit qu'une représentation minoritaire du personnel (un tiers des membres du conseil d'administration), cantonnant de ce fait le personnel à un « *rôle subalterne de consultation, de contrôle et de surveillance sur les activités du conseil* ». Par conséquent, « *tant que le législateur ne réglemente pas la création et l'organisation des comités internes au conseil d'administration en imposant aux sociétés de prévoir dans les statuts qu'un tiers des membres composant ces dits conseils soit constitué par les administrateurs représentant le personnel, il ne pourra être reproché aux majoritaires d'avoir commis un abus de droit si le résultat du vote fait apparaître que les administrateurs représentant le personnel se trouvent en fait écartés de la composition des comités internes, dont l'existence se justifie par des considérations pratiques qui ne sont pas inconciliables avec le droit des sociétés* ».

La nomination d'un administrateur, président du conseil d'administration, aux fonctions d'administrateur-délégué, n'empêche pas qu'il soit à considérer comme administrateur au sens de l'article 441-2 L.S.C. et responsable comme tel envers la société de l'exécution de son mandat. L'administrateur ne cesse en effet pas d'être mandataire, lorsqu'il est chargé de la gestion journalière des affaires ; d'où la conséquence que l'action en responsabilité dirigée contre lui du chef de fautes de gestion relève de la compétence des tribunaux de commerce[(1)].

3) Responsabilité contractuelle

Le tribunal a admis l'action de curateurs, fondée sur les articles 441-9 et 710-16 L.S.C., tendant à engager la responsabilité d'une personne, contrôlant diverses S.A. et S.à r.l., qui s'était rendue coupable de fautes de gestion telles que l'absence de fonctionnement régulier des organes sociaux et de comptabilité, un manque de soin quant à la tenue de postes débiteurs et leurs justificatifs, le maniement fautif de fonds sociaux (prélèvements ou virements mal identifiés ou sans contrepartie), le remboursement anticipé de crédits bancaires pour lesquels le défendeur avait donné sa garantie personnelle, le non-paiement de fournitures de première nécessité pour la société. Le juge estima que ces faits constituaient la faute génératrice de la faillite de la société pour laquelle il y avait lieu de condamner le défendeur au montant total des créances admises »[(2)].

1 – Cour, 27 février 1973, *P.*, 23, p. 481, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 29 mars 1985, n°s 35.483, 35.484, 35.582, ID 10489.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans un autre cas d'espèce, il y avait engagement de la responsabilité, sur la base des articles 441-9 et 710-16 L.S.C., de deux associés-gérants d'une S.à r.l. dont ils avaient détourné les fonds (stocks transférés sans contrepartie pour la société), en vue de s'enrichir personnellement. Le juge observe au passage que les trois éléments classiques constitutifs de la responsabilité civile doivent être réunis lors de la mise en œuvre des articles 441-9 et 710-16 précités, à savoir la faute (application du critère du « bon père de famille »), le dommage et le lien de causalité (résultant en l'espèce de ce que le dépouillement de la société de son actif tout en l'endettant auprès des fournisseurs et autres créanciers était à l'origine tant de la création que de l'accroissement du passif, aboutissant finalement à sa mise en faillite). Les défendeurs furent condamnés à supporter le passif alors non couvert de la société[(1)].

Chaque fois que les actionnaires ont éprouvé un dommage *ut universi*, c'est à la collectivité des actionnaires qu'il appartient d'en demander réparation et, dans ce cas, l'action doit être refusée à l'actionnaire *ut singulus* ; si, au contraire, le préjudice ne frappe qu'un ou plusieurs actionnaires *ut singuli*, ils sont en droit d'agir individuellement et leur demande est recevable[(2)].

En l'occurrence, l'action avait été introduite par un actionnaire de la Banque Nationale tombée en faillite contre l'État au motif que les agents que l'État aurait préposé à la direction et à la surveillance de la société faillie n'auraient pas rempli leurs devoirs et auraient compromis les intérêts des actionnaires. Cette action fut rejetée comme non recevable en tant qu'action *ut singuli*, car d'évidence elle intéressait l'universalité des actionnaires. En outre, et à titre superfétatoire, l'action fut déclarée irrecevable, car l'actionnaire demandeur à l'instance avait voté la décharge du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire[(3)].

Si toute opération malheureuse ne constitue pas nécessairement une faute dans le chef de l'administrateur d'une société, il ne suffit cependant pas que celui-ci établisse sa **bonne foi** pour pouvoir se soustraire à sa responsabilité de mandataire[(4)]. Les administrateurs de société doivent à l'exécution de leur mandat les soins d'un bon père de famille et répondent envers la société de toutes les fautes de gestion consistant dans des actes de mauvaise administration, alors même que les actes accomplis dans les limites de leurs pouvoirs n'impliqueraient ni une infraction à la loi ni une infraction aux statuts. Pour que la faute de gestion de l'administrateur donne lieu à dommages-intérêts, il faut un acte positif ou négatif contraire aux obligations de son mandat, qu'il en soit résulté un dommage immédiat et direct pour la société, et qu'il existe un rapport de causalité entre la faute et le préjudice.

Se rend notamment coupable d'une telle faute de gestion l'administrateur qui, sans s'assurer d'une garantie quelconque, investit, pour compte de sa société, des sommes importantes dans une autre société dont la situation financière est précaire[(1)]. Dans une affaire, la responsabilité d'un gérant unique a été engagée pour

1 – TA Lux. du 3 juillet 1987, nº 36.875, ID 10442.

2 – TA Lux. du 10 août 1891, *P.* , 3, p. 537, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA Lux. du 10 août 1891, *P.*, 3, p. 539, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour, 27 février 1973, *Pas.*, 23, p. 481, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

avoir développé son activité commerciale personnelle en détournant des affaires de la S.à r.l. dont il avait la gestion. Le gérant est condamné au passif social non couvert, le juge prenant soin de relever que cette faute est bien la cause du dommage dans la mesure où le dépouillement progressif de la société l'a conduite à la faillite[1].

La faute d'un dirigeant s'apprécie *in abstracto*, c'est-à-dire par référence à la conduite d'un bon père de famille, en d'autres termes, d'un dirigeant prudent, diligent et actif. Il incombe aux dirigeants une obligation générale de compétence, de diligence et de bonne foi. Ceux-ci doivent en toutes circonstances agir dans l'intérêt de la société, et non dans leur intérêt personnel[2].

Concernant la faute du dirigeant consistant en une violation de la loi ou des statuts : constitue une violation des statuts sociaux le fait pour une société holding de procéder à des opérations bancaires, telles qu'elles sont définies par l'arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire[3].

Diverses fautes constituant des violations de la loi ou des statuts sont relevées à charge d'un gérant unique de S.à r.l. (notamment en matière comptable, absence de délibérations de l'assemblée générale sur une série de points, facturations non justifiées, etc.[2].

L'octroi d'un prêt à intérêt, même documenté par des billets à ordre, n'entre pas dans l'objet social d'une société exerçant l'activité d'agent de change. Les administrateurs de cette société sont donc responsables, sur la base de l'article 441-9, alinéa 2, L.S.C. (responsabilité solidaire pour infraction aux statuts) du préjudice subi par la société à la suite d'une telle opération. En vue de s'exonérer de cette responsabilité, les administrateurs concernés doivent rapporter la triple preuve de leur non-participation à l'infraction, de l'absence de toute faute personnelle de leur part et de la dénonciation de l'infraction à l'assemblée générale la plus proche. À cet égard, la négligence de l'administrateur qui signe aveuglément des documents préparés par un autre administrateur est établie sans que sa qualité de salarié de la société et le fait que l'autre administrateur soit presque exclusivement propriétaire du capital de la société puissent aucunement l'exonérer de sa responsabilité : tout administrateur doit en effet veiller à agir en connaissance de cause (TA Lux., 15 juillet 1993, *BDB*, nº 21, p. 51). L'article 441-9, alinéa 2, prévoit que les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou aux statuts sociaux. Il est admis que l'action en responsabilité visée par l'article 441-9, alinéa 2, L.S.C. peut être intentée tant par la société que par tous tiers. Par tiers, il faut comprendre tous ceux ayant traité avec la société ainsi que tous autres qui sont complètement étrangers à la société. Par tiers, il faudra également comprendre les actionnaires lorsque ceux-ci démontrent que la faute délictuelle ou quasi-délictuelle des administrateurs leur a causé un préjudice personnel indépendant et distinct de celui qui a pu être causé au patrimoine de la société[4]. Le tribunal a encore rejeté l'argument soulevé par un des administrateurs selon lequel il était non seulement administrateur, mais encore salarié en charge

1 – TA Lux. du 9 juin 1989, nº 38.792, ID 11930.

2 – TA Lux. du 15 mars 2001, nº 48.959, ID 20049.

3 – TA Lux. du 30 mai 1980, *Bulletin du Cercle François Laurent*, II, 1987, pp. 67 ss., cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 10 novembre 2000, nº 49.599, ID 10260.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de la gestion journalière. Les fautes qu'il avait éventuellement commises l'auraient été en sa qualité de salarié, et non pas en celle d'administrateur. Le salarié n'engagerait sa responsabilité qu'en cas de « *faute lourde équipollente au dol* ». Le tribunal rejeta ce moyen en faisant valoir que la décision pour la société de faire des avances à des tiers dans des conditions irrégulières ne serait manifestement pas une décision que le simple salarié pouvait prendre sans être en même temps administrateur de la société[1].

L'acceptation fictive d'un mandat et le fait de ne pas veiller à la confection des comptes sociaux en s'abstenant de toute participation à la vie sociale, imposée à toute personne ayant accepté les fonctions d'administrateur, constitue de la part de M.P. une faute au sens de l'article 59, alinéa 2, de la loi sur les sociétés. M.O. n'est pas déchargé de la responsabilité solidaire qui pèse sur les administrateurs en raison d'infractions aux dispositions de la loi sur les sociétés, étant donné qu'il n'est pas établi qu'aucune faute dans l'utilisation des avoirs sociaux à des fins contraires à l'objet social et l'intérêt social ne lui soit imputable, qu'au contraire il est établi qu'il a commis une faute en s'abstenant d'assumer ses fonctions d'administrateurs, de sorte qu'il n'a pas pris connaissance des comptes sociaux et a laissé agir les deux administrateurs[2].

« *Le dirigeant de fait d'une société est celui qui exerce en fait la direction de la société aux lieu et place de son organe légal ou sous son couvert* ». En l'espèce, la cour estima que le dirigeant de fait engageait sa responsabilité envers la société qu'il « représente », pour autant que ses décisions prises dans le cadre de l'administration avaient eu une influence directe sur le sort financier de celle-ci. Une opération de désengagement (dégagement d'une société de ses engagements désastreux au détriment des autres sociétés engagées) entraîne une faute civile si elle intervient au détriment de tierces personnes trompées sur le but réel des actes juridiques posés[3].

La résiliation intempestive du **contrat de travail** qui lie un administrateur/actionnaire à la société ne constitue ni une faute de gestion au sens de l'article 59 L.S.C. [ancien] ni un manquement au devoir de loyauté/obligation de bonne foi auquel l'intéressé est tenu envers la société sur la base des articles 1834 et 1134 du Code civil. Si préjudice il y avait du fait de la résiliation intempestive du contrat de travail, résiliation que la cour qualifia d'abusive, ce préjudice était à indemniser sur la base du droit applicable au contrat de travail[4].

Le fondé de pouvoir d'une société commerciale, capable d'engager celle-ci pour les affaires courantes, a qualité pour approuver valablement les extraits de compte envoyés à la société par une banque, avec laquelle le conseil d'administration avait conclu un contrat d'ouverture de crédit, puisque, par les termes « affaires courantes », on comprend la gestion journalière consistant dans l'accomplissement des actes qui ne sont que l'exécution quotidienne de la ligne de

1 – TA Lux. du 15 juillet 1993, *BDB*, p. 53, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 14 août 2001, n° 69.686, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA du 1er octobre 1997, nos 12.583, 12.771, 12.859, 12.896 et 20.243, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA du 30 octobre 2002, *BIJ*, n° 2, 2002, p. 36.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conduite tracée par le conseil[1] (décision se référant à l'arrêt de la cour d'appel du 10 mai 1929 et précisant que la doctrine et la jurisprudence belge vont dans le même sens).

En Belgique, l'arrêt du 17 septembre 1968 (*Pas.*, 1969, I, p. 61) de la Cour de cassation définit la gestion journalière comme étant le pouvoir de poser des actes d'administration ne dépassant pas les besoins de la vie quotidienne de la société ou qui, en résultant de leur peu d'importance ou de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration lui-même. Il en résulte que les décisions du délégué à la gestion journalière doivent être la suite et la conséquence de décisions prises antérieurement par le conseil d'administration. En d'autres termes, toute initiative véritable lui est refusée[2].

« *[…] l'avance de fonds ou l'octroi de crédits importants à une tierce société constitue un acte qui sort de la gestion journalière d'un administrateur délégué et ne doit être réservé qu'aux seuls organes de la société que sont les administrateurs* »[3]. Dans le même arrêt, la cour d'appel explique que « *[…] la gestion journalière dont est chargé un administrateur-délégué consiste dans l'accomplissement des actes qui ne sont que l'exécution quotidienne de la ligne de conduite tracée par le conseil d'administration ; que l'administrateur-délégué est plutôt un agent d'exécution à qui toute initiative véritable est refusée, alors que c'est le conseil d'administration seul qui a l'administration de la société et qui en porte vis-à-vis de celle-ci la responsabilité* »[4]**,** et pour la cour de conclure que l'avance de fonds ou l'octroi de crédits importants à une tierce société constitue un acte qui sort de la gestion journalière d'un administrateur-délégué et ne doit être réservé qu'aux seuls administrateurs.

4) Responsabilité délictuelle

Dans un cas d'espèce fut soulevée la question de la responsabilité délictuelle de l'administrateur-délégué (ci-après X) d'une S.A. (Y) auquel il fut reproché, par un cocontractant (Z) de la dite S.A., d'avoir manqué à un devoir de conseil (Z avait effectué un dépôt à terme auprès d'une banque au sein de laquelle X travaillait à l'époque en qualité de directeur ; X quitta la banque dépositaire pour devenir administrateur-délégué de la S.A. Y ; à cette occasion, X convainquit Z de résilier son dépôt à terme auprès de la première banque et de conclure un nouveau contrat de dépôt de son argent auprès de la S.A. Y ; de ce fait, Z dut s'acquitter d'une pénalité de liquidation prématurée auprès de la première banque ; Z y vit un dommage dont X devait à son sens être rendu responsable en raison d'un manquement à son obligation de conseil), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg décida de ne pas retenir une telle responsabilité, s'inscrivant dans une ligne de raisonnement proche de l' « *absorption* » de l'organe par la personne morale qu'il représente : « *Chargé de la gestion journalière, l'administrateur-délégué […] est, vis-à-vis des tiers, l'organe de la société […] Il en résulte que le tiers lésé par l'acte illicite que l'administrateur-délégué a commis assignera la société comme*

1 – CA, 10 mai 1929, *Pas.*, 11, p. 459.

2 – CA du 18 mars 1993, nº 13.501, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour, 27 février 1973, *P.*, 23, p. 483.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

directement responsable de cet acte, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil […] La sollicitation faite par X rentre parmi les actes faisant partie de l'exécution de la gestion journalière de la société […]. L'acte régulièrement posé par l'organe qui fait connaître sa qualité est à imputer à l'être moral pour lequel l'organe agit […]. Il suit des considérations qui précèdent que l'action […] à l'encontre de (X) n'est pas fondée »[1].

Dans une affaire soumise aux juridictions, il était reproché à une personne contrôlant la société diverses fautes de gestion gouvernées par la satisfaction de son intérêt personnel (fixation unilatérale d'une rémunération excessive payée rétroactivement et à titre anticipatif, remboursement d'un crédit accordé à la société, comptabilité insuffisante, virements effectués au profit de diverses sociétés faisant partie du groupe contrôlé par le défendeur). Le tribunal reconnut la demande fondée, notamment sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil (montant du préjudice à fixer par la voie d'une expertise)[2].

Les administrateurs d'une S.A. se sont rendus coupables de graves fautes de gestion (ils ne se sont pas souciés du sort de fonds prêtés à la société par les demandeurs ; ont investi l'intégralité du capital social dans l'acquisition d'actions d'une société espagnole à un prix exorbitant et en violation des dispositions légales et statutaires applicables à cette société, en sorte que les droits sociaux afférents à ces actions ne peuvent être exercés) : « *Les défendeurs ont partant gravement failli à leur devoir de gérer et d'administrer la société […] . Ils sont partant responsables des dommages que cette carence a causé non seulement à la société mais également aux tiers qui ont contracté avec elle* »[3].

Espèce où la responsabilité délictuelle (art. 1382 C.c.) du gérant d'une S.à r.l. est retenue à l'égard d'un tiers cocontractant de la société (le gérant avait, pour le compte de la société, vendu une arme au tiers pour ensuite la vendre sans l'autorisation du propriétaire, alors que celui-ci l'avait ramenée au magasin pour transformation)[4].

La question posée est de savoir si la société, déjà titulaire de l'*actio mandati* gouvernée par le droit commun du mandat, peut invoquer les articles 1382 et suivants du Code civil pour poursuivre les administrateurs en responsabilité. Une réponse affirmative semble s'imposer. Il y a lieu toutefois d'appliquer les règles générales dégagées par la doctrine et la jurisprudence en matière de concours de responsabilités aquilienne et contractuelle. La société pourrait fonder son action sur les dispositions du droit commun pour autant que la faute alléguée **ne constitue pas une faute indépendamment du mandat** qui lie les administrateurs à la société (Ch. Resteau, *Traité des sociétés anonymes*, 3e éd., T. II, n° 967*bis*). Les administrateurs sont tenus, vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice qui est la conséquence immédiate et directe d'une faute commise par eux ; cette responsabilité repose sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Si le curateur peut, lorsque la société a été déclarée en faillite, en tant que représentant de la société faillie, exercer l'*actio mandati* à l'encontre des

1 – TA Lux. du 14 juillet 1982, n° 25458, ID 11172, confirmé par CA du 4 mai 1988, n° 6.998.

2 – TA Lux du 29 mars 1985, nos 35.483, 35.484, 35.582, ID 10489.

3 – TA Lux du 23 décembre 1987, nos 29.975, 29.977, 29.978, 31.024, 31.533, 32.225, 33.672 et 33.673, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC) ID 23159.

4 – TA Lux du 17 décembre 1992, jgt n° 232/92, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

mandataires sociaux, il représente également la masse des créanciers et est habilité à ce titre pour réclamer la réparation d'un préjudice commun (Ch. RESTEAU, *loc. cit*., n° 978*ter*). Sont communs à l'ensemble des créanciers les droits résultant de dommages causés par la faute de toute personne, qui a eu pour effet d'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif, qu'en raison du dommage ainsi causé à la masse des biens et des droits qui forment le gage commun des créanciers, cette faute est la cause du préjudice collectif qui pèse sur ceux-ci et lèse les droits qui leur sont par nature communs (Cass. b., 12 février 1981, *J.T.,* 1981, p. 270)[1].

D – Absence de responsabilité des administrateurs

Conformément à la théorie des mandataires substitués et en application de l'article 1994 C.c., la jurisprudence retient que les administrateurs ne sont pas responsables des fautes commises par un gérant auquel ils ont délégué la gestion journalière de la société. Les administrateurs ne répondent que de la désignation d'un mandataire manifestement

incompétent ainsi que, le cas échéant, d'un défaut de surveillance, cette dernière ne devant toutefois pas être entendue d'une manière étroite et rigoureuse[2].

La question de savoir si cet article est applicable, dans le cas où l'administrateur de la société est une personne morale, à l'égard de la personne qui agit au nom de la société administrateur est controversée en doctrine belge. Pour certains, l'article 1994 C.c. s'applique avec la conséquence que la responsabilité du mandataire principal est limitée et que le mandant a une action directe contre le mandataire substitué[3].

Pour d'autres, cette interprétation est à écarter, au moins pour le cas où la personne physique désignée pour exercer le mandat d'administrateur serait un salarié de la personne morale administrateur. Un tel employé ne pourrait être qualifié de mandataire substitué et ne serait donc qu'un mandataire simple de la société[4].

■ § 4 – Les assemblées d'actionnaires

Ce sont les actionnaires regroupés en assemblées générales qui ont le pouvoir souverain dans la société en désignant et en révoquant les organes de celle-ci. Ces principes peuvent, le cas échéant, être quelque peu mitigés lorsque la structure dualiste a été choisie. En réalité et dans tous les cas, il existe plusieurs catégories d'assemblées avec des attributions différentes.

A – Règles communes aux assemblées des actionnaires

L'assemblée générale des actionnaires est **l'organe suprême** de la société. Il est donc indispensable que cet organe se réunisse périodiquement pour prendre les

1 – TA Lux du 24 janvier 1992, n° 40.774, ID 10188.

2 – J. VAN RYN et P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1966-1971) », *R.C.J.B.*, 1973, p. 532.

3 – O. RALET, « L'administrateur personne morale et le mandataire substitué », *R.P.S.*, 1994, p. 465.

4 – I. CORBISIER, « Quelques réflexions en filigrane des développements récents qu'a connus le droit de responsabilité des administrateurs d'une personne morale », *R.P.S.*, 1994, p. 57.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

décisions qui s'imposent. Cette réunion annuelle ne peut être ignorée par aucun associé dans la mesure où :

1) la date de la réunion figure dans les statuts de la société (ce qui n'est plus obligatoire depuis la Loi de Modernisation) ;
2) les titres au porteur reprennent les indications obligatoires de l'article 430-5 L.S.C. (dont la date et le lieu de réunion ne font plus partie) ;
3) l'assemblée fait l'objet de convocations (avec indication de l'ordre du jour précis). En dehors de cette assemblée annuelle, les actionnaires peuvent être convoqués toutes les fois que l'intérêt de la société le demande.

1) Tenue de l'assemblée

L'article 450-1 [anc. 67 L.S.C.] prévoit un certain nombre de règles qui ont une portée générale dans le sens qu'elles s'appliquent tant aux assemblées ordinaires qu'extraordinaires. Ces règles ont trait à la façon dont les assemblées délibèrent et décident.

a) Convocation de l'assemblée

La convocation est l'œuvre de tout le conseil d'administration ou du directoire selon le cas ainsi que du conseil de surveillance (ou du collège des commissaires) dans leur ensemble, et non pas des administrateurs, etc. individuels. Dans les sociétés pour lesquelles aucun commissaire n'existe plus, c'est le conseil d'administration seul qui peut convoquer l'assemblée.

En cas de carence du conseil d'administrateur ou des commissaires de convoquer l'assemblée, cette convocation peut être demandée par des actionnaires représentant le **dixième du capital** social au moins (art. 450-8, alinéa 2, L.S.C.). Dans un souci d'éviter des demandes de convocation irréfléchies, la loi prend une double précaution : la demande doit être signée par les actionnaires qui sont à son origine et elle doit indiquer l'**ordre du jour** de l'assemblée dont la convocation est demandée[1]. En cas de carence des organes invités à convoquer l'assemblée (afin d'être tenue dans le délai d'un mois), la convocation de l'assemblée peut encore être **demandée au tribunal**. Cette action est adressée contre les administrateurs (commissaires) personnellement. Le ou les actionnaires possédant 10 % des actions devront établir qu'ils ont fait une demande en vue de la convocation de l'assemblée, mais que cette demande n'a pas été suivie d'effet. Le tribunal peut désigner un tiers pour le faire[2]. Ce refus peut engager la responsabilité des administrateurs sur la base de l'article 441-9 L.S.C.

Quant à la forme de ces **convocations** : elles doivent contenir l'ordre du jour et elles sont faites par des annonces déposées auprès du R.C.S. et publiées 15 jours au moins au RESA et dans un journal de Luxembourg (art. 450-8 L.S.C.). Ce mode de publication est le seul à devoir être suivi lorsque toutes les actions sont au porteur. Il est justifié de l'exécution de cette formalité lors de l'assemblée par le dépôt sur

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 214, ID 11305.
2 – C. Delvaux, *La société anonyme*, p. 336.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

le bureau de la réunion d'un exemplaire du numéro des journaux qui contiennent la convocation[1].

Lorsque la société comporte en dehors des actions au porteur des actions nominatives, alors un mode de convocation supplémentaire est requis dans la mesure où des lettres missives personnelles leur sont envoyées, mais sans que celles-ci ne doivent être recommandées. Cette formalité n'étant qu'un simple supplément par rapport à la convocation par la voie de la presse, il ne doit pas être justifié de cette formalité[2].

En revanche, si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées (art. 450-9 L.S.C.). Étant donné que, dans ce cas, il n'y a pas de convocation par le RESA ni par le biais d'un journal, il y a lieu de supposer qu'il doit être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

b) Sanctions en cas de convocation défectueuse

À supposer qu'une convocation ne satisfasse que partiellement aux conditions prévues par la loi, il se pose la question de savoir quelles sont les sanctions de ces manquements. Il est certain que la sanction n'en sera pas nécessairement la nullité de l'assemblée. « *Tout dépend de l'importance de l'irrégularité, les tribunaux ne devant prononcer cette sanction rigoureuse que si le fait a été suffisamment grave pour vicier essentiellement la décision de l'assemblée et ainsi donner lieu à un grief sérieux* »[2]. Ces formalités n'étant prescrites que dans l'intérêt des actionnaires, il est normal que ceux-ci seuls soient en droit de se prévaloir de la violation de ces règles.

Dans un cas d'espèce tranché par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la convocation a été faite sans qu'il ait été possible de déterminer qui en était l'auteur étant donné qu'il était certain qu'il ne s'agissait ni du conseil d'administrateur ni du commissaire. Par conséquent, la juridiction saisie de l'affaire devait annuler l'assemblée générale en retenant que, le droit de convocation étant limitativement attribué par la loi à des organes précis, l'usurpation de droit devait nécessairement avoir ladite conséquence[3].

Dans un autre cas, il a encore été jugé « *[…] qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une assemblée pour défaut de convocation d'un associé lorsque le gérant justifie avoir adressé à celui-ci une convocation par courrier électronique avec mention de l'ordre du jour, l'associé ayant ainsi été informé de la date et de la teneur de l'assemblée (CA Paris, 6 déc. 2007 : Juris-Data n° 2007-357792 ; Dr sociétés 2008, comm. 103, note J. Monnet).*

Par ailleurs, les règles relatives aux formes de convocation sont impératives et les décisions d'une assemblée dont les associés n'ont pas été convoqués dans les formes et délai imposées peuvent être annulées, sauf lorsque tous les associés étaient présents ou représentés (C. com., art. L. 223-27, dern. al. – CA Paris, 22 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-021619 ; Dr sociétés nov. 1992, n° 228 ; JCP E 1992, pan. 896 ; Rev. sociétés 1992, p. 559 ; Bull. Joly 1992, n° 354, p. 1087. – Sur ce point, V. Fasc. 32-40 et infra n° 138).

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 161, ID 11308.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 161, ID 11308.

3 – TA Lux. du 19 juin 2015, *P.*, 37, p. 732.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il est en outre admis que la non-observation des exigences relatives à la convocation de l'assemblée générale constitue un vice de forme qui n'entraîne une sanction qu'en cas de grief »[1].

L'assistance sans protester à une assemblée générale convoquée irrégulièrement implique une renonciation à invoquer ladite irrégularité. Par contre, le seul fait de ne pas avoir protesté lors d'une assemblée générale contre une décision contre laquelle on a voté n'implique pas une renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité de la décision prise[2].

c) Règles de tenue des assemblées

Il est loisible aux statuts d'organiser en détail la tenue des assemblées. Ceci n'est que très rarement le cas. Il n'est pas évident que ceci soit souhaitable en fait, dans la mesure où une règlementation très détaillée de ces modalités aura pour conséquence de lier les mains à la société, tenue de respecter ses propres règles (au prix d'exposer les administrateurs aux conséquences de la responsabilité renforcée de l'article 441-10 L.S.C.) et d'abandonner ainsi la flexibilité qui en principe est inhérente à cette matière.

Faute de telles règles statutaires (ou extra-statutaires) spécifiques, il y a lieu d'appliquer les règles des assemblées délibérantes.

Quant au mode de délibération, notamment en ce qui concerne le minimum de présence, la présidence, la composition du bureau, les règles du vote, etc. les statuts ont toute la **liberté** pour les fixer[3].

Dans le silence des statuts « *les nominations se font et les décisions se prennent d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes* ». « *Lorsque la nécessité de faire préciser cette notion se fait sentir*, *l'on se réfère tout naturellement […] au règlement-type de la principale et la plus haute assemblée délibérante du pays : la Chambre des députés de la Nation* »[4].

Le projet de loi n° 5730 dans sa version initiale avait prévu d'éliminer la référence à la notion de « règles ordinaires des assemblées délibérantes », considérée comme « trop imprécise ». Cette proposition d'élimination a été justifiée par le fait qu'il serait trop contraignant de devoir constamment suivre le règlement intérieur de la chambre des députés. Cet avis ne nous paraît pas très fondé. Même si l'archétype des assemblées délibérantes est la chambre des députés (en tant qu'assemblée démocratique la plus élevée du pays), ceci ne signifie pas que le règlement intérieur de celle-ci serait toujours à suivre à la lettre. Si telle avait été la volonté du législateur, il l'aurait dit. La référence au genre des assemblées délibérantes plutôt qu'à l'espèce de l'assemblée de la chambre des députés permet justement de retenir uniquement les éléments communs de ce genre d'assemblées plutôt que de se concentrer sur les particularités de l'une ou de l'autre espèce de ce genre. Cette proposition d'élimination de la référence aux assemblées délibérantes n'a toutefois pas été reprise,

1 – TA Lux. du 26 février 2015, n° 142277 du rôle, ID 24652.

2 – CA du 2 juin 1999, ID 10241.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 163, ID 11308.

4 – Namur, T. II, n° 1.088.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

et donc la référence aux « règles ordinaires des assemblées délibérantes » a été maintenue.

La formule faisant référence aux **assemblées délibérantes** désigne un certain nombre de règles plus ou moins précises, parmi lesquelles on peut relever les suivantes :

– les décisions sont prises à la majorité absolue des voix ;
– la majorité doit être présente ;
– en cas de partage des voix, la proposition est rejetée ;
– le conseil constitue son bureau au début de la réunion de l'assemblée ; il se compose d'un président, d'un secrétaire et de deux scrutateurs. La fonction de président est utilement assumée par le président du conseil d'administration.

Le président désigne un secrétaire qui, dans la pratique des choses, est souvent un employé de la société. Son rôle consiste à rédiger le procès-verbal de la réunion. Pour compléter le **bureau**, on désigne un ou plusieurs **scrutateurs** qui ont pour fonction de vérifier la qualité des personnes participant à l'assemblée et de se convaincre de la validité de leurs procurations.

– les élections et les nominations se font au scrutin secret ;
– le conseil ne peut délibérer que sur les objets repris à l'ordre du jour ;
– tous les membres doivent avoir été régulièrement convoqués[1].

De façon générale, les règles de forme et de fond sont destinées à protéger les intérêts des associés. Dans cette mesure-là, la loi institue un contenu minimum que les statuts peuvent augmenter, mais non diminuer. En d'autres termes, il est possible de se montrer plus exigeant, par exemple en augmentant les majorités, les délais de convocation, les pourcentages de quorum, etc., mais il n'est pas possible de les alléger.

L'intention initiale des auteurs du projet de loi n° 5730 était d'introduire une règle supplétive : « *Elle statue sans quorum à la majorité des voix exprimées* » en s'inspirant de la règle de l'article L. 225-98 du Code de commerce français : « *Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés* ». Mais par la suite, on se rendait compte que « *[…] l'adoption d'une telle règle modifierait la pratique suivie au Grand-Duché de Luxembourg selon laquelle les abstentions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise, il a été jugé préférable de retenir la règle proposée. Sa formulation est conforme aux art. 57 et 58 du Règlement N° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne et la règle pourra donc également leur être appliquée* »[2].

Cette proposition n'a pas été retenue, et donc la L.S.C. reste muette sur la question du calcul exact des voix et du **traitement des abstentions**. En revanche, en matière d'assemblées générales extraordinaires, la Loi de Modernisation a bien clarifié la situation en retenant à la fin de l'article 450-3 L.S.C. « *Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul* ».

Les auteurs du projet de loi n° 5730 avaient encore proposé que, si l'assemblée générale est tenue par visioconférence, etc., alors un actionnaire doit être

1 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 390.
2 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 81, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

physiquement présent au Luxembourg. Le Conseil d'État s'est montré sceptique sur « *l'utilité de cette disposition destinée à ancrer davantage la localisation de l'assemblée générale au Grand-Duché. Le Conseil d'État est convaincu ni de cette approche ni de son importance […]* »[1]. Cette proposition exigeant la présence physique obligatoire d'un associé au moins au Luxembourg n'a pas été reprise dans le texte définitivement adopté.

Un autre point d'importance est que les règles de convocation ne sont pas à respecter dans la mesure où les titulaires de **toutes les actions sont présents** ou représentés. Dans cette mesure-là, il est donc possible de passer outre au respect de ces règles protectrices[2]. Pour que tel soit le cas, il faut en deuxième lieu que tous les actionnaires confirment avoir connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée en question. Le procès-verbal de l'assemblée va constater que cette condition est également remplie. La raison d'être de cette deuxième exigence est facile à saisir : elle est destinée à éviter que les actionnaires ne soient pris par surprise et doivent donc délibérer et décider sur des points sur lesquels ils n'avaient pas la possibilité de se préparer de façon adéquate.

Toujours selon l'article 450-1 (2) L.S.C., les **procès-verbaux** sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent ; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l'original dans les cas où les délibérations de l'assemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts ou, à défaut, par le président du conseil d'administration (directoire) ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages pouvant résulter de l'inexactitude de leur certificat.

Le droit de voter à ces assemblées est d'ordre public. Ce droit s'exerce soit par l'actionnaire, soit par son mandataire. Conformément aux règles des sociétés de capitaux, le droit est proportionnel au nombre d'actions détenues, et ceci, sans limitation.

La Loi de Modernisation a introduit la possibilité de **renonciation volontaire aux droits de vote** (art. 430-6 [anc. art. 42] L.S.C.). La version initiale du projet de loi n° 5730 (art. 71) avait autorisé les statuts de limiter volontairement le nombre de voix dont chaque titulaire pouvait disposer dans les assemblées générales des titulaires de parts bénéficiaires avec droit de vote. Cette disposition n'a pas été adoptée. Autrefois, il existait en notre droit des sociétés une limitation légale obligatoire aux termes de laquelle aucun actionnaire ne pouvait exprimer plus de 20 % des droits de vote de toutes les actions en circulation. Cette disposition donnait lieu à de multiples problèmes (et à des situations grotesques du genre de celle où un actionnaire détenant 78 % des actions avec droits de vote est mis en minorité par deux actionnaires détenant chacun 11 % des actions avec droits de vote), de sorte que le législateur a aboli cette limitation qui était difficilement compatible avec le caractère capitalistique de la société anonyme.

En revanche, a été adoptée par la Loi de Modernisation la faculté pour les statuts de prévoir « *que le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les*

1 – *Doc. parl.*, n° 5730/4, Avis du Conseil d'État, p. 17, ID 13321.

2 – Il ne s'agit bien entendu pas d'une véritable entorse à ces principes, mais dans la mesure où les objectifs de cette réglementation sont atteints, le respect scrupuleux de la réglementation n'apporterait plus aucun avantage supplémentaire.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d'engagement ».

Une autre innovation de la Loi de Modernisation (prévue en son article 450-1 (9) [anc. art. 67] L.S.C.) était que tout associé « *peut à titre personnel s'engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l'associé renonçant et s'impose à la société dès la notification à cette dernière* ».

Une telle renonciation peut, à première vue, surprendre, car on aurait tendance à croire que chaque actionnaire serait désireux de voter avec le maximum de droits de vote possible. La renonciation au droit de vote à titre personnel par les actionnaires a été non prévue dans la version initiale du projet de loi n° 5730, mais elle a été introduite seulement en 2015 par la voie d'un amendement par la Commission juridique de la Chambre des députés. Le commentaire de cette disposition se lit comme suit : « *Un autre exemple de nécessité à voir limiter l'exercice des droits de vote dans le chef de certains actionnaires est celui d'investisseurs qui, pour des raisons réglementaires, comptables ou fiscales, ne peuvent dépasser certains seuils de droits de vote. Ceci peut notamment être le cas pour des institutions financières soumises à un contrôle prudentiel. Pour étayer la sécurité juridique entourant de tels arrangements légitimes, il paraît utile de voir reconnaître par voie législative la validité et l'opposabilité de telles renonciations librement consenties. Le texte proposé précise qu'une telle renonciation est faite à titre personnel, et n'affecte donc pas les droits attachés à l'action ou la part en tant que telle. En cas de cession à un autre actionnaire ou associé, la renonciation à l'exercice du droit de vote ne suit pas l'action ou la part […]* »[(1)].

Comme on l'a vu ci-dessus, la référence aux assemblées générales délibérantes continue de s'appliquer. Mais la Loi de Modernisation permet aux statuts d'éviter toute délibération et de procéder par des **résolutions circulaires** (terme non utilisé par la loi, mais très usuel en pratique). À condition que les statuts le permettent expressément, « *les décisions des conseils d'administration, directoire et conseil de surveillance* » peuvent être prises par « *consentement unanime* » (art. 444-3 (1) L.S.C.). La loi ajoute que ces décisions prises sans délibération effective sont réputées prises au siège de la société. La L.S.C. est muette sur la question de savoir si cette procédure doit respecter exceptionnelle ou non. La doctrine est (à juste titre) clairement fixée dans le sens que cette solution doit rester l'exception. Le principe des assemblées délibérantes reste la règle, et à chaque fois que des questions complexes et controversées doivent être décidées, il y a lieu de passer par la « procédure des assemblées délibérantes ». Il est vrai que (du moins en théorie) chaque dirigeant auquel une « résolution circulaire » est soumise peut mettre en route cette procédure normale en refusant simplement sa signature sous le texte de la décision proposée.

2) Personnes autorisées à participer à l'assemblée

Tout actionnaire a droit de vote ; aucun associé ne peut être exclu de la délibération avec la conséquence que toute clause statutaire exigeant un nombre minimum d'actions est nulle.

1 – *Doc. parl.*, n° 5730/5, p. 40, ID 23099.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le titulaire du droit de vote est uniquement le propriétaire de l'action, à l'exclusion du créancier gagiste[1]. La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière permet toutefois de déroger à cette règle en accordant le droit de vote au créancier gagiste (art. 9 de la loi). De même, en cas d'opération fiduciaire, c'est au fiduciaire que revient le droit de vote : il est propriétaire des titres, nonobstant les charges qui lui sont contractuellement imposées dans ses relations avec le fiduciant.

Le droit de vote peut être exercé par mandataire, faculté qui ne peut être prescrite par les statuts qui restent toutefois libres d'en réglementer l'usage ; il est en particulier loisible aux statuts d'exiger que le mandataire soit choisi par les actionnaires (afin d'éviter l'intrusion de tiers non personnellement intéressés dans les assemblées)[2].

3) Effets des décisions des assemblées

La participation au vote, dans l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme, d'une personne non qualifiée n'entraîne pas nécessairement la nullité de la délibération. Celle-ci est valable si, abstraction faite des votes irréguliers, la majorité prescrite est acquise et si la présence des personnes privées du droit de vote n'a pas donné lieu à fraude[3].

Est irrecevable une demande en suspension des effets d'une assemblée générale lors de laquelle une société a été dissoute eu égard au fait que la société est dissoute et qu'il appartient au juge du fond saisi de la demande en annulation de l'assemblée générale de prendre les mesures appropriées au cas où il prononcera sa nullité[4].

La doctrine et la jurisprudence récentes considèrent qu'il y a abus de majorité lorsqu'une décision de l'assemblée générale des actionnaires a été prise « *contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité (Jurisclasseur Sociétés fasc. 139, n° 153 et 155 ainsi que les références y citées), l'action fondée sur l'abus de majorité conduisant, soit à la nullité de la résolution abusive, soit à une condamnation à des dommages et intérêts, et exceptionnellement à la désignation d'un administrateur provisoire* » (TA Luxembourg, 13 octobre 1989, R. n° 319/89). Dans le cadre d'une action en annulation de résolutions prises par l'assemblée générale d'une S.A. sur la base d'un abus de majorité : « *Pour qu'il y ait abus de majorité, il faut […] que soit établi qu'une décision a été prise contrairement à l'intérêt général, dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité et au détriment des membres de la minorité* »[5].

Rejet d'une demande tendant à l'annulation de décisions d'assemblée générale d'une S.à r.l. ayant fixé puis augmenté un loyer : « *Pour être abusive, une décision sociale doit remplir deux conditions, à savoir elle doit être prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de*

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 164, ID 11308.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 165, ID 11308.

3 – CA du 13 juin 1928, *Pas.*, II, p. 426, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. (réf.) du 30 juillet 1986, n° 834/86, ID 11308.

5 – TA Lux. du 5 décembre 1997, n°s 46.403 (rôle civil) et 54.800 (rôle commercial), cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la majorité au détriment de la minorité […] L'abus de la majorité suppose que les actionnaires majoritaires s'avantagent eux-mêmes en spoliant les actionnaires minoritaires et les tribunaux ne peuvent intervenir que si cette circonstance est manifeste – et non point pour trancher des débats d'opportunité entre les différents groupes d'actionnaires […] »[1].

L'abus de majorité peut également concerner les décisions du conseil d'administration. La jurisprudence prise à l'égard des décisions prises par les assemblées générales a été étendue aux décisions des conseils d'administration[2]. Cette jurisprudence procède à l'annulation d'une décision du conseil d'administration lorsque « *la majorité a délibérément sacrifié les intérêts de la société aux siens propres ou à ceux de tiers, et que la décision ait causé un préjudice à la société ou ait été tout le moins susceptible d'en causer un* »[3]. En l'occurrence, tel ne fut pas le cas dans la mesure où les minoritaires n'établissaient pas à suffisance de droit que les décisions critiquées auraient été prises en vue de sacrifier les intérêts de la société.

Dans un cas d'espèce, les faits étaient les suivants : une assemblée générale de S.A. fut convoquée par le conseil d'administration pour le 7 novembre 1995 avec, parmi les points à son ordre du jour, « *la désignation et la révocation d'administrateurs* ». Cette AG n'eut pas lieu et fit l'objet d'une prorogation au 5 décembre 1995. Le 22 novembre 1995, le conseil d'administration se réunit pour notamment acter la démission de trois administrateurs, la cooptation temporaire d'un nouvel administrateur fut effectuée (portant alors le nombre d'administrateurs à trois, alors que les statuts en exigent cinq), le capital fut augmenté par l'utilisation de la technique du capital autorisé avec pour effet de faire basculer la majorité en place dans la société. L'AG qui se tint le 5 décembre 1995 ratifia essentiellement les décisions du CA, l'actionnaire minoritaire se réserva le droit d'attaquer la validité de l'AG et des décisions qui y furent prises. Les demandeurs sollicitaient notamment l'annulation de la décision du conseil d'administration ne cooptant qu'un seul administrateur contrairement aux statuts.

Le jugement consécutif a retenu :

– en ce qui concerne la décision de cooptation par le conseil d'administration, contrairement aux statuts et en présence de la convocation antérieure, d'une AG portant la désignation et la révocation d'administrateurs à son ordre du jour : « *Il est admis que si une délibération est prise contrairement aux statuts, soit quant au fond, soit quant à la forme, cette délibération n'engage pas la société et son annulation peut être demandée même par un actionnaire individuellement, car la convention sociale est la loi de tous que chacun a le droit de faire respecter (cf. Traité des sociétés, Ch. Resteau, T. 2, p. 163, n° 919)* ». Par ailleurs, « *Le tribunal d'Anvers a décidé que lorsque les actionnaires d'une société anonyme ont demandé régulièrement la convocation d'une assemblée générale extraordinaire et qu'à l'ordre du jour indiqué par eux figure ce point "Nomination d'administrateurs et de commissaires" pour compléter leur nombre jusqu'à celui requis par les statuts, le conseil d'administration n'a plus le droit, lorsque cette assemblée n'a pas eu lieu*

1 – CA du 10 février 1999, n° 19.248, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – V. notamment Bruxelles du 13 janvier 1971 et Bruxelles du 16 juin 1981, *R.P.S.*, 1981, p. 5.

3 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 769.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

[…] Toutes nominations ainsi faites par le conseil doivent être considérées comme nulles (cf. Anvers 11.2.1894, Rev. droit C. com. belge 1894 p. 107) ». Par conséquent, le tribunal déclare nulle la décision de cooptation prise par le conseil d'administration ;

– en ce qui concerne la décision d'augmentation du capital, prise par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé, par laquelle la société demanderesse est devenue minoritaire : la décision est annulée aux motifs d'irrégularité de la composition du conseil d'administration qui l'a prise et en tant qu'excédant les pouvoirs d'un conseil d'administration dans lequel il a été provisoirement pourvu au remplacement de démissionnaires (il ne doit être usé de cette faculté de remplacement que « *pour permettre le fonctionnement régulier de la société, c'est-à-dire les actes rentrant dans la gestion journalière des affaires sociales (cf. Traité des sociétés anonymes, Ch. Resteau T. 2 p. 88)* »);
– en ce qui concerne la décision de l'AG tenue sur prorogation le 5 décembre 1995 : si l'ordre du jour initialement prévu pour l'AG du 7 novembre a été formellement respecté, la composition de l'AG était différente et a permis, du fait du changement de majorité opéré, d'entériner les décisions irrégulières prises le 22 novembre 1995 par le conseil d'administration. Or, « *Une prorogation d'assemblée permet une remise dans le temps de cette assemblée, toutes choses restant par ailleurs égales. Dans la mesure où l'AG en l'espèce n'était certainement pas la continuation de celle projetée initialement, il faut conclure que celle-ci a été irrégulièrement tenue et que ses décisions sont par conséquent à invalider* »[1].

Dans une action qui tend à voir constater la nullité d'une délibération de l'assemblée générale d'une société, il faut mettre en cause tous ceux qui veulent faire usage de la délibération et la société elle-même, car c'est surtout elle que la nullité intéresse et c'est d'elle qu'émane la délibération. Une mise en cause des associés est valablement faite au moyen d'une demande en déclaration de jugement commun qui a pour effet de leur rendre le jugement opposable et de les empêcher de faire usage de la déclaration dont l'annulation sera le cas échéant ordonnée. Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'une mise en cause régulière des associés fait partie des exceptions de procédure par lesquelles le défendeur tient l'action du demandeur en échec jusqu'à ce qu'un certain délai soit expiré ou une formalité déterminée accomplie. Elles conduisent à une paralysie temporaire de la demande formée irrégulièrement. Cette dernière peut être validée *a posteriori* et sa régularité au regard de l'exception de procédure invoquée s'apprécie au moment de la prise en délibéré.

À l'occasion d'une demande en suspension des effets d'assemblées générales (où tous les associés étaient présents et où les décisions furent prises à l'unanimité) de sociétés anonymes qui avaient décidé de la révocation d'administrateurs, les dits administrateurs soulevaient, entre autres moyens (v. également décision de la Cour d'appel du 26 octobre 1999, R. n°s 23801 et 238031), le fait que les actions de la société n'avaient pas été déposées au siège de celle-ci préalablement à l'assemblée : « *la formalité du dépôt des actions est prévue afin de faciliter l'établissement*

1 – TA Lux. du 30 janvier 1998, n° 20.972, commenté par Fr. Fayot *in Ann. dr. lux.*, 2001, p. 573, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de la feuille de présence. Le non-respect de cette formalité, en cas d'accord des actionnaires, ne saurait entraîner la suspension ou nullité des délibérations de l'assemblée générale »[1].

Ci-après un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel[2] en appel contre un jugement du tribunal d'arrondissement qui avait prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 16 août 2005, assemblée générale ayant le même ordre du jour que l'assemblée générale ordinaire du 4 août 2005 prorogée au 1er septembre 2005, ainsi tenue en violation de la décision de prorogation qui a entièrement dessaisi l'assemblée :

« *Comme la prorogation dessaisit l'assemblée générale, il est interdit de tenir avant la date de l'assemblée générale prorogée une autre assemblée générale ayant le même objet que l'assemblée générale prorogée. Rien n'interdit cependant de tenir avant l'assemblée générale prorogée une autre assemblée générale ayant un ordre du jour différent. Tant l'assemblée générale ordinaire du 4 août 2005 que l'assemblée générale extraordinaire du 16 août 2005 avaient pour objet l'approbation des comptes annuels 2002 et 2003 et le renouvellement d'organes sociaux. […] L'assemblée générale extraordinaire du 16 août 2005 n'a donc pas pu être régulière en ce qui concerne ces deux points de son ordre du jour. Le transfert du siège social était également prévu à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 16 août 2005. La régularité de l'assemblée générale extraordinaire du 16 août 2005 n'a pas pu être affectée par ce point de l'ordre du jour qui n'a pas figuré à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 4 août 2005. La nullité ne peut donc être encourue en raison de ce point de l'ordre du jour* ». Par conséquent, une assemblée générale convoquée avant la date de l'assemblée prorogée est irrégulière quant aux points de son ordre du jour qui sont identiques à ceux de l'assemblée générale prorogée, mais est régulière quant à d'autres points qui peuvent éventuellement figurer à son ordre du jour (dans le cas d'espèce, il s'agissait du transfert de siège). Par conséquent les actionnaires feraient bien de ne pas considérer que l'assemblée intermédiaire serait de toute façon nulle, de sorte qu'il ne vaudrait pas la peine de se déplacer. Une comparaison soignée de l'ordre du jour avec celui de l'assemblée prorogée lui est à conseiller : s'il comporte des points supplémentaires, ceux-ci peuvent être valablement décidés.

En application de l'article 450-1(2) L.S.C., les statuts déterminent les modalités de délibération de l'assemblée générale et des formalités nécessaires pour y être admis. C'est en application de cette disposition que le dépôt préalable des titres était souvent exigé[3]. En pratique, ce dépôt se faisait auprès des banques qui délivraient un récépissé de dépôt : c'est ce récépissé qui permettait à l'actionnaire de participer à l'assemblée[4].

Depuis l'introduction de l'obligation de déposer les titres au porteur auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administrateur (directoire), ce dépositaire est à même d'établir un tel certificat à chaque actionnaire qui en fait la demande.

---

1 – Référés nos 475/99 et 476/99 du 18 juin 1999, commenté par Fr. Fayot *in Ann. dr. lux.*, 2001, p. 558, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 4 juillet 2007, n° 31678 du rôle (arrêt commercial), ID 15895.

3 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 369.

4 – C. Delvaux, *La société anonyme*, p. 345.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le juge des référés a, à la demande d'un administrateur, suspendu les effets d'une décision prise par le conseil d'administration d'une société anonyme au motif que les informations nécessaires à la bonne préparation du conseil d'administration n'ont pas été communiquées en temps utile. Le juge fait observer à cette occasion : « *Contrairement aux développements de la partie défenderesse qui plaide que la demande d'informations doit venir de l'administrateur et que la fourniture d'information n'est pas automatiquement due de la part de la société ou du président qui convoque le conseil, l'initiative de l'information préalable revient au président du conseil d'administration qui ne peut se borner à attendre les demandes des administrateurs (Yves REINHARD : « Information des membres du conseil d'administration » dans Rev. Trim. Droit Com. 1990, p. 416, portant commentaire d'un arrêt Cass. com. 24 avril 1990 […]).*

Il s'ensuit que l'absence de communication aux administrateurs des documents nécessaires à la préparation du conseil d'administration litigieux dans le délai de communication […] constitue un trouble manifestement illicite de nature à vicier la régularité du conseil d'administration […] de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. T […] tendant à la suspension des effets du conseil d'administration […] »[(1)].

B – L'assemblée générale annuelle

Il s'agit de l'assemblée annuelle, donc récurrente, qui joue un rôle indispensable dans la vie de la société.

Les modifications de la Loi de Modernisation apportées à l'ancien article 70 L.S.C. (article 450-8 L.S.C.) : à l'alinéa 1[er] a été supprimée l'exigence que l'assemblée générale « *doit avoir lieu dans la commune aux jours et heure indiqués par les statuts* ». Depuis la Loi de Modernisation, la L.S.C. se contente de préciser que l'AG doit avoir lieu au Grand-Duché « ce qui permet d'assurer l'ancrage de la société au Grand-Duché »[(2)].

– « *Il a été estimé souhaitable que la loi précise expressément que les administrateurs et les commissaires sont habilités à participer aux assemblées. Quant à la participation des réviseurs, le texte instituera ce droit pour le réviseur d'assister à l'assemblée uniquement dans l'hypothèse où il a été nommé par l'assemblée* ». Cette distinction entre réviseurs nommés par l'assemblée et ceux nommés par l'organe de direction est pour le moins malencontreuse. On ne trouve pas de trace dans la législation afférente qu'il y aurait des différences entre les attributions ou encore le statut des réviseurs selon l'organe qui les a nommés.

Lorsque la nouvelle version L.S.C. fait référence aux « actionnaires qui n'y sont pas physiquement présents », elle vise non seulement les actionnaires participant à l'assemblée à distance en raison de l'utilisation de techniques modernes de communication, mais également ceux qui y prennent part par la voie du **vote par correspondance** également introduit dans le cadre de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE).

1 – Prés. TA Lux. ff. (réf.), 17 octobre 2002, n° 77.421, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 85, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le commentaire des articles souligne encore le point important suivant : selon l'alinéa 4 de cet article, l'assemblée est « réputée être tenue au lieu du siège de la société » ce qui permet d'assurer que le droit applicable à la société est le droit luxembourgeois (art. 1300-2 [anc. art. 159] L.S.C.). « *Le procédé de technique juridique utilisé ici est celui de la fiction juridique et non de la présomption (conséquence que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu), sachant que cette dernière serait éventuellement susceptible de preuve contraire* »[1].

De nos jours, les infractions aux dispositions exigeant la tenue dans les délais stricts de cette assemblée ont tendance à être sanctionnées pénalement.

1) Convocation de l'assemblée annuelle ordinaire

Aux termes de l'article 450-8 L.S.C., « *[l]l doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale au Grand-Duché de Luxembourg. L'assemblée toit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut être tenue dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société* ».

2) Convocations d'autres assemblées ordinaires

L'assemblée annuelle ordinaire n'est pas nécessairement la seule assemblée ordinaire. En effet, d'autres assemblées peuvent à tout moment être convoquées. La convocation d'une assemblée est possible à partir du moment où le conseil d'administration (directoire) le considère opportun. Cette convocation est requise si l'intérêt de la société est en jeu[2].

L'assemblée doit alors être tenue de manière à se tenir effectivement dans un délai d'un mois au plus tard à partir de la date de la demande.

De telles situations, dans lesquelles la convocation d'une assemblée s'impose, sont prévues par différents articles L.S.C. Tel est le cas notamment dans les situations suivantes :

- réduction du nombre des commissaires de plus de la moitié, art. 443-1 L.S.C. ;
- acquisition dans les deux ans de biens de la part des personnes ayant souscrit l'acte de constitution (quasi-apports), art. 420-11 L.S.C. ;
- acquisition de propres actions (convocation requise avant le rachat de celles-ci), art. 430-15 L.S.C. ;
- amortissement des actions (art. 450-6 L.S.C.).

La convocation d'une assemblée est encore obligatoire en cas de demande par des actionnaires représentant **10 % du capital** social au moins. L'assemblée doit alors être tenue dans le délai d'un mois ; en outre, les actionnaires demandeurs doivent indiquer l'objet de la réunion de cette assemblée, à savoir son ordre du jour. La première de ces deux dispositions est destinée à éviter les retards exagérés dans l'exécution de cette demande ; la deuxième trouve sa raison d'être dans le désir d'éviter des convocations irréfléchies ou vexatoires[3].

1 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 86, ID 10080.

2 – C. Delvaux, *La société anonyme*, p. 337.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 3, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Lorsque les administrateurs (commissaires) sont ainsi invités à procéder à la convocation d'une assemblée par le nombre requis d'actionnaires, alors ils ne sont pas juges de l'opportunité de cette mesure. Ils sont tenus de répondre positivement à cette demande, sauf le cas où la convocation serait de toute évidence dénuée du moindre motif sérieux[1].

3) Attributions de l'assemblée annuelle ordinaire

Art. 450-1 [anc. art. 67] L.S.C.
« *(1) L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société* ».

Cette disposition n'est pas entièrement compatible avec celle de l'article 441-5 L.S.C. La loi luxembourgeoise n'accorde pas de pouvoirs réservés aux organes de gestion ; en effet, l'article 441-5 L.S.C. accorde au **conseil d'administration tous les pouvoirs** à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. En d'autres termes, les statuts peuvent fort bien restreindre les pouvoirs des administrateurs. Toutefois, ces restrictions ne sont plus opposables aux tiers (depuis 1972).

a) Approbation des comptes annuels

L'assemblée annuelle a comme fonction essentielle **d'approuver les comptes** annuels préparés par l'organe de gestion soit donc, dans les sociétés anonymes, le conseil d'administration (le directoire). La gestion des dirigeants (ou plutôt les résultats tangibles et chiffrés de celle-ci[2]) est reflétée dans les comptes sociaux, les comptes annuels.

L'assemblée générale annuelle constitue en quelque sorte **l'heure de vérité** pour les dirigeants de la société, car c'est elle qui juge et apprécie la gestion des dirigeants sur l'année écoulée.

Afin de pouvoir prendre leur décision en connaissance de cause, l'assemblée des associés (ou plutôt les associés individuellement) ont accès à certains documents destinés à leur permettre de porter un jugement éclairé. Si la gestion des dirigeants en place l'année précédente était bonne, ou du moins satisfaisante, décharge leur est accordée.

Si, en règle générale, l'assemblée procède à l'approbation docile des comptes annuels, l'approbation pure et simple n'est toutefois pas la seule issue possible. En effet, si l'assemblée peut approuver les comptes annuels purement et simplement, elle peut encore soit les **rejeter** et demander à l'administration d'en établir de nouveaux, soit procéder elle-même à leur modification[3].

1 – Bruxelles du 26 octobre 1874, *Pas.*, 1875, II, p. 30 ; *R.P.S.*, 1998, n°s 884, p. 1151.

2 – Il est vrai qu'il peut y avoir un gouffre entre la qualité de la gestion, d'une part, et la qualité des chiffres, d'autre part. La gestion d'une année peut être mauvaise et les résultats bons, et vice versa.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 176, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

De nos jours, l'approbation des comptes annuels, d'une part, et la décharge accordée à l'organe de gestion, d'autre part, se font par deux actes séparés. Tel n'était pas le cas autrefois où l'approbation du bilan comportait nécessairement la décharge. L'inconvénient de ce système était que, souvent, les associés votaient l'approbation du bilan et donc la décharge tout en ayant de sérieux griefs contre les administrateurs. La raison en était qu'en n'approuvant pas les comptes annuels, les actionnaires ajournaient en fait la répartition des bénéfices à leur profit[1].

En outre, l'assemblée procède aux **nominations statutaires** qui s'imposent : l'organe de gestion et l'organe de contrôle sont en principe nommés par l'assemblée ; les administrateurs sont nommés pour une période de 6 années au plus.

b) Rectification d'un bilan antérieur

Il se peut qu'un bilan approuvé par une assemblée antérieure soit affecté d'une erreur. La question se pose alors de savoir si une assemblée ultérieure peut procéder à la rectification de cette erreur.

« *Le caractère définitif de l'approbation du bilan suppose que celui-ci soit régulier au regard des exigences de la loi comptable, laquelle tend en principe à la correcte information des tiers et revêt à ce titre un caractère d'ordre public. Par conséquent, toute irrégularité dans le bilan doit être au plus vite rectifiée, sans qu'il faille distinguer les erreurs matérielles et les erreurs substantielles* »[2].

Il faut conclure de la jurisprudence belge qu'il convient de distinguer selon le type d'erreur. La Cour de cassation retient qu'une assemblée générale peut en principe, sans violer l'article 79 L.C.S.C., « *rectifier un poste qui, par erreur, a été formellement mal comptabilisé dans un bilan par une assemblée générale précédente* »[3].

Dans cette espèce, il s'agissait de la comptabilisation d'une plus-value réalisée sur la vente d'un immeuble et qui avait été, par erreur, comptabilisée à un compte de réserve disponible alors qu'elle aurait dû être comptabilisée à un compte indisponible dès lors que les sommes en question avaient été utilisées à un remploi d'une plus-value réalisée. Le contribuable avait effectué toutes les formalités requises pour pouvoir procéder au remploi fiscalement neutre de la plus-value.

La **rectification d'une erreur purement matérielle** qui apparaît directement des comptes annuels peut se faire sous la responsabilité du conseil d'administration. Les autres erreurs nécessitent la convocation immédiate d'une nouvelle assemblée générale sans attendre l'assemblée générale suivante[4].

c) L'affectation des résultats

Une autre fonction de l'assemblée des associés s'exerce directement au profit des associés eux-mêmes : il s'agit de l'affectation des résultats, résultats qui, s'ils sont positifs, peuvent être soit mis en réserve, soit distribués, soit partiellement mis en

1 – Ch. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, Carton de Wiart, p. 495.

2 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 821.

3 – Cass. b. du 12 mai 1989, *R.C.J.B.*, 1992, p. 317.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 822.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

réserve et partiellement distribués. En cas de perte, il s'agit simplement d'en assurer le traitement comptable (p. ex., en les compensant avec les réserves libres de la société).

L'assemblée possède un pouvoir souverain pour décider au sujet de la distribution des résultats. En réalité, cette assemblée ne décide pas seulement des résultats de l'année écoulée, mais, en fait, elle décide de l'affectation des résultats (positifs) de la société depuis son origine (dans la mesure où ceux-ci n'ont pas déjà été distribués auparavant). En d'autres termes, toutes les réserves non distribuées de la société et accumulées depuis une vingtaine d'années, par exemple, peuvent être intégralement distribuées par chaque assemblée générale régulièrement tenue.

La Deuxième directive a, pour la première fois, apporté à notre droit des sociétés une définition de la notion de **bénéfice distribuable**. Cette définition est comprise à l'article 15 de la directive. Tournée de manière négative, elle est libellée ainsi. « *Sauf les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer* ». Cette définition est reprise à l'article 461-3 L.S.C.

À première vue, l'alinéa 461-1 L.S.C. reprend en substance en son alinéa 3 la même chose que ce qui a déjà été dit dans l'alinéa 1 :

« *Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément à la loi ou aux statuts* ».

Malgré les apparences, ces deux propositions se complètent, comme nous allons le montrer au moyen de l'exemple suivant.

Exemple

La société XY a établi le bilan suivant :

Bilan au 31.12. 2017

Actifs 322	*Capital 100*	
	Réserve légale : 2	
	Réserves libre s : 20	
	Bénéfice exercice : 200	

D'après la première partie de la définition, on peut considérer que la société peut distribuer tout ce qui excède le capital social souscrit (sauf la réserve légale), soit donc 220. Or il n'en est rien : une telle distribution négligerait le fait que la société est tenue de mettre en réserve légale une partie de son bénéfice, en l'occurrence, un montant de 8 sera doté en réserve légale pour atteindre ainsi le montant légalement requis. Ce point résulte du paragraphe 3 de l'article 461-2 (3).

En réalité, cette définition du revenu distribuable n'est pas la seule que la société anonyme soit légalement tenue de respecter. En effet, si la Quatrième directive ne prévoit pas une définition divergente de celle retenue par l'article 15 de la Deuxième directive, elle comporte des dispositions qui influent sur les dispositions légales

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

prévues ci-dessus. Ainsi, lorsque la société comporte à son bilan des frais d'établissement (art. 53 L. de 2002) ou encore des frais de recherche et de développement (art. 59 L. de 2002), alors les distributions de bénéfices sont à réduire de la partie non amortie de ces postes. En d'autres termes, les auteurs de la Quatrième directive ont adopté l'approche la plus prudente qui soit envisageable en considérant que, même si ces postes représentent effectivement une valeur de zéro, le capital souscrit sera toujours intact (le « trou » créé par le fait que l'actif comporte de telles non-valeurs serait en fait bouché par des bénéfices et réserves non distribuables).

d) La décharge des dirigeants

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires.

i) Notion de décharge

La décharge (ou ***quitus***) est l'acte par lequel « *le mandant reconnaît que le mandataire a parfaitement exécuté sa mission et, à tout le moins, renonce à exercer* l'actio mandati *du chef d'éventuels manquements* »[1].

« *La décharge libère le mandataire de toute responsabilité vis-à-vis du mandant pour les actes et faits qu'il lui a révélés ou que celui-ci doit connaître, mais laisse entière sa responsabilité pour tout ce qui n'a pas été révélé. Il importe peu que l'absence de révélation résulte d'un dol, d'une imprudence ou même d'une omission de bonne foi* »[2].

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Normalement, la décharge entraîne la ratification des actes accomplis à l'égard des tiers. Ceci n'est toutefois pas automatique. Le mandant peut en effet renoncer à engager la responsabilité du mandataire tout en ne reprenant pas à son compte les actes accomplis par le mandataire en dehors des limites du mandat. Le mandant peut encore ratifier les actes accomplis hors des limites du mandat tout en engageant la responsabilité de son mandataire. C'est la volonté du mandant qui, dans chaque cas, sera décisive[3].

ii) Portée de la décharge

En premier lieu convient-il de noter que la décharge n'a d'effet **qu'entre parties** (mandant et mandataire) et qu'elle reste donc sans le moindre effet à l'égard des tiers. Elle est « *res inter alios acta* », ne pouvant ni nuire ni profiter aux tiers (art. 1165 C.c.). Entre parties, la décharge déploie ses effets, mais seulement dans la mesure où l'assemblée des associés a agi en connaissance de cause, donc seulement dans la mesure où les comptes sociaux reflètent la gestion des dirigeants.

1 – P. A. Foriers, « Décharge, réception et quittance », *in La fin du contrat*, Bruxelles, A.B.J.E., V.P. et C.J.B., 1993, p. 135.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 164.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 2, p. 165.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les tiers peuvent, par conséquent, continuer à invoquer la violation de la loi ou des statuts à l'appui de l'action qu'ils pourraient intenter contre les administrateurs, à condition de démontrer le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute commise[1].

À cet égard, la société statue par sa majorité, de sorte que la décharge lie nécessairement les minoritaires qui ne peuvent exercer **l'action à titre individuel**[2]. En droit belge, il était fait exception à cette règle dans la mesure où les actionnaires disposaient de l'action individuelle : il s'agit du cas où les actionnaires ont été absents à l'assemblée sous la double condition qu'il s'agisse d'actes faits en dehors des statuts et que les actes n'aient pas été spécialement indiqués dans la convocation[3]. Cette faculté a été supprimée en notre droit par l'avant-projet Corbiau qui a réservé cette action individuelle aux cas de responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle[4].

« *[…] l'erreur ou la fraude dans la confection du bilan laissent toujours les administrateurs à découvert : toute omission, toute fausse indication empêchent la décharge. Rien n'est plus juste : une approbation accordée sur des documents inexacts ou faux est viciée et ne peut être opposée à celui qui l'a donnée. Dans ce cas, les droits de la société aussi bien que ceux des actionnaires considérés individuellement restent intacts* »[4].

La décharge donnée aux administrateurs n'est pas non plus opposable au curateur, dans la mesure où « *celui-ci agit comme représentant de la masse des créanciers* »[5]. D'où l'importance de savoir en quelle qualité le curateur agit. S'il agit en tant que représentants des tiers, la décharge est essentiellement sans efficacité, puisque le représentant des tiers peut invoquer les fautes mêmes que la décharge couvre dans les rapports avec la société[6].

D'après une jurisprudence luxembourgeoise (aff. *Hellas*)[7] : « *Aux termes de l'article 74, alinéa 2, de la Loi modifiée de 1915, applicable aux sociétés en commandite par actions en raison du renvoi général opéré par l'article 103 de ladite Loi, après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la* ***décharge*** *des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation*.

Il est admis que le vote de la décharge, qui vaut ratification par l'assemblée générale de la gestion des administrateurs, a ***pour effet d'empêcher l'exercice de*** **l'actio mandati** *à l'égard de ces derniers, que l'action en responsabilité soit basée sur l'article 59, alinéa 1er, de la Loi modifiée de 1915 pour fautes de gestion ou sur l'article 59, alinéa 2, de ladite Loi pour fautes de régularité consistant en une violation de la loi ou des statuts.*

1 – Cour de Bruxelles du 7 janvier 1959, *R.P.S.*, 1963, p. 204.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 177, ID 11308.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 178, ID 11308.

4 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 226, ID 11305.

5 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 794.

6 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 383.

7 – TA Lux. du 23 décembre 2015, nos 145724 et 145725 du rôle, ID 24088.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Tel que prévu par l'article 74, alinéa 2, précité, cette décharge doit faire l'objet d'un vote spécial après l'adoption des comptes annuels. L'assemblée peut soit accorder, soit refuser la décharge, soit la soumettre à des réserves ou à des conditions, c'est-à-dire, en somme l'ajourner (Pascale Hainaut-Hamende et Gilberte Raucq, Les Sociétés Anonymes, Constitution et Fonctionnement n° 531).

Cette décharge n'est cependant valable que si les actionnaires ont pu effectivement se rendre compte de la gestion des dirigeants, de sorte que le bilan ne doit contenir ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société. En d'autres termes, l'assemblée ne peut valablement décharger les dirigeants sociaux de leurs fautes de gestion que si elle se prononce en pleine connaissance de cause. Lorsqu'il s'agit de la violation de la loi ou des statuts, il en est de même en principe (J.-P. WINANDY, Manuel de droit des sociétés, édition 2011, page 542) ».

Décharge et violation de lois impératives et d'ordre public

« L'argument des liquidateurs de HELLAS II qu'une décharge ne serait pas valable en présence d'une violation de lois impératives et d'ordre public, sanctionnées pénalement, prend appui sur les développements suivants effectués par Jean Corbiau : "l'approbation éventuellement donnée au fait délictueux par l'assemblée générale des associés ne pourrait être invoquée par les gérants ou administrateurs auteurs de ce fait comme élisive dans leur chef de l'existence du délit" (J. CORBIAU, Des Sociétés Commerciales, Avant-Projet de loi élaboré pour le G-D de Luxembourg, édition 1905, page 417, pièce n° 22 de Maître Schaeffer).

Ce passage doit cependant être replacé dans le contexte de l'examen de l'actuel article 167 de la Loi modifiée de 1915, disposition pénale.

À cet égard, il est évident qu'un gérant ou administrateur, poursuivi sur cette base, ne saurait échapper à sa responsabilité pénale en invoquant la décharge.

L'actio mandati est cependant une action en responsabilité civile, et plus précisément une action en responsabilité contractuelle dirigée par le mandant contre son mandataire.

Tel que relevé par YY et ZZ, la décharge ne vise pas à ratifier des actes illégaux (à supposer une telle illégalité établie), mais à "décider du sort à réserver aux conséquences de ces actes, en termes de demandes éventuelles en réparation pécuniaire à diriger contre la gérance" (cf. conclusions récapitulatives de Maître Trevisan, page 176).

Ainsi un auteur a-t-il pu préciser que sans doute il ne peut appartenir à personne d'autoriser les administrateurs à commettre des fautes de gestion ou des violations à la loi ou aux statuts. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de renoncer à poursuivre la réparation d'un dommage causé. Quelle que soit la cause du préjudice, la personne lésée peut toujours renoncer à réclamer réparation et, par le fait même, à exercer toute action dans ce but (P. WAUWERMANS, Manuel pratique des sociétés anonymes, 3e éd., Bruxelles, 1921, n° 719, p. 381).

Par conséquent, peu importe la gravité ou la nature de la faute commise par le gérant (faute de gestion ou de régularité) et même en présence de la violation d'une loi d'ordre public sanctionnée pénalement, l'assemblée, si elle agit en connaissance de cause, peut valablement renoncer à rechercher la responsabilité de son organe de gestion en lui accordant décharge ».

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

4) Possibilité de prorogation de l'assemblée

L'hypothèse visée par l'article 450-1 (6) L.S.C. est celle où une assemblée est convoquée et, au moment où elle a lieu, le conseil d'administration décide de la **reporter** à plus tard, compte tenu de l'identité des actionnaires présents ainsi que de la tournure des débats.

Cette disposition a pour objet d'éviter qu'une minorité d'actionnaires ne devienne, par l'effet du hasard, majoritaire au sein d'une assemblée et soit donc à même de prendre des décisions qui en réalité iraient contre la volonté de la majorité qui serait empêchée de s'exprimer dans l'assemblée en question (p. ex., en raison de l'empêchement pour cause de maladie de l'associé détenant la majorité du capital).

Au Luxembourg, le droit de proroger l'assemblée s'applique tant aux assemblées ordinaires qu'extraordinaires, le délai de report étant de quatre semaines[1] (alors qu'en droit belge, ce droit est limité aux assemblées annuelles chargées d'approuver les comptes[2]).

Le pouvoir de prorogation appartient au conseil d'administration (directoire) qui décide en âme et conscience, sauf si des actionnaires représentant **au moins le dixième du capital** social demandent le report, en quel cas le conseil doit décider dans ce sens. Il faut donc une minorité sérieuse pour que les actionnaires puissent demander la prorogation de l'assemblée.

Selon la jurisprudence luxembourgeoise[3], la disposition légale de l'article 451-1 (6) L.S.C. est à interpréter de façon stricte dans le sens qu'elle ne s'applique pas aux **liquidateurs**. En l'espèce, une assemblée générale convoquée pour décider sur la dissolution de la société sur la base de l'article 480-2, alinéa 2, L.S.C. avait d'abord décidé la dissolution de la société et la nomination des liquidateurs avant que des associés représentant plus de 20 % du capital ne demandent la prorogation de l'assemblée. Le tribunal d'arrondissement se posait donc la question de savoir si la disposition de l'article visé s'adressant aux administrateurs pouvait être étendue aux liquidateurs. À cette question, le tribunal répondit par la négative, pour la raison qu'il s'agirait d'une mesure tout à fait exceptionnelle, la disposition visée devant être interprétée de façon stricte et ne pas être appliquée à d'autres cas que ceux qui sont expressément visés par la loi. Les minoritaires auraient dû demander la prorogation avant de décider la dissolution de la société : dans ce cas, le conseil d'administration (toujours en place) n'aurait pas pu écarter la demande.

Selon une décision plus ancienne, le droit « *des actionnaires d'une société anonyme d'obtenir la réunion de l'assemblée générale est d'ordre public en ce sens que les statuts ne peuvent ni le supprimer ni le restreindre, une extension du droit des actionnaires au-delà de ce minimum légal peut résulter des libres dispositions du pacte social* »[4].

---

1 – L. Metzler, « Le régime légal des sociétés et des associations en droit luxembourgeois », *R.P.S.*, p. 250.

2 – C. Duro, *Tax today*, 14 décembre 2007.

3 – TA du 13 juin 2007, ID 13765. V. C. Duro, *Tax today*, 14 décembre 2007. Le jugement est frappé d'appel.

4 – Cass. civ. du 7 juillet 1950, *P.*, 15, p. 40, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En cas de prorogation de l'assemblée, toutes les **décisions** prises par l'assemblée sont considérées comme **non avenues**[1]. Cette deuxième assemblée doit obligatoirement être tenue et elle ne peut faire l'objet d'un nouveau report.

La Cour d'appel de Luxembourg a retenu qu'en cas de prorogation demandée par au moins un cinquième du capital social l'assemblée générale est dessaisie par la prorogation, de sorte qu'il est interdit de tenir avant la date de l'assemblée générale prorogée une autre assemblée générale ayant le même objet que l'assemblée générale prorogée. En revanche, la tenue d'une assemblée générale ayant un ordre du jour différent avant l'assemblée prorogée est parfaitement possible[2]. Cette décision est à approuver.

C – Assemblées distribuant des résultats en dehors des assemblées statutaires annuelles

La question s'est posée si, en dehors de l'assemblée générale annuelle prévue par les statuts qui décide sur l'affectation des résultats de la société, il est possible de convoquer d'autres assemblées générales pour procéder à des distributions de bénéfices. Cette question doit être analysée ensemble avec la possibilité existant depuis quelques années pour le conseil d'administration de procéder à des distributions d'acomptes sur dividendes (art. 461-3 L.S.C.).

Exemple

Le 10 mai 2017, l'assemblée générale de la société ABC S.A. a approuvé le bilan au 31 décembre 2016. Le résultat net de 400 000 euros de ce premier exercice a été affecté de la façon suivante :

- *dotation à la réserve légale de 20 000 euros,*
- *distribution d'un dividende de 100 000 euros,*
- *dotation aux réserves libres de 280 000 euros.*

La question qui se pose ici est de savoir si une deuxième assemblée convoquée en septembre 2017 peut procéder à la distribution d'un dividende supplémentaire prélevé sur les réserves libres dotées en mai 2017.

Il est certain qu'aucun texte n'interdit spécifiquement qu'une assemblée générale autre que l'assemblée générale annuelle décide de procéder à la distribution d'un dividende prélevé sur les réserves bilantaires constatées par l'assemblée générale annuelle ordinaire précédente.

Une partie de la doctrine avait pris la position que le système prévu par la loi constituerait un **système fermé** dans lequel aucune distribution ne pourrait avoir lieu par l'assemblée générale en dehors du cas expressément prévu par la loi[3].

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 220, ID 11305.

2 – CA du 4 juillet 2007, 4e ch., n° 31.678, ID 15895.

3 – L. Simont et P.-A. Foriers, « La distribution de réserves disponibles en cours d'exercice », *Liber amicorum J.-P. De Bandt*, Bruxelles, 2004, p. 599 pour les références à la doctrine visée.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La Cour de cassation belge[1] trancha finalement dans le sens opposé. Pour la cour, « *l'assemblée générale peut, à tout moment au cours de l'exercice, décider de distribuer aux actionnaires un dividende prélevé sur les réserves disponibles […] Que, d'autre part, les conditions auxquelles l'article 77*ter *des lois coordonnées soumet la distribution par le conseil d'administration d'un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice sont étrangères au pouvoir de l'assemblée générale de disposer en tout temps des réserves disponibles […]* »[2].

Il est vrai que, si une assemblée générale autre que l'assemblée statutaire décide de procéder à une distribution de résultats, il est prudent de s'assurer que les réserves bilantaires n'ont pas été entamées par des pertes afin d'éviter que la distribution de résultats ne soit pas en fait financée par prélèvement sur le capital ou les réserves indisponibles. L'établissement d'un bilan intérimaire est donc à conseiller[3].

Si l'assemblée générale peut ainsi, à tout moment, procéder à des distributions de dividendes prélevées sur les réserves disponibles, elle ne peut en revanche pas procéder à des distributions **d'acomptes sur dividendes** (ou de dividendes intérimaires). La distribution d'acomptes sur dividendes est soumise à des conditions strictes, et elle est de la seule compétence du conseil d'administration (directoire).

D – Ordre du jour standard d'une assemblée ordinaire

Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, l'ordre du jour standard de l'assemblée annuelle est le suivant :

– l'approbation des comptes ;

– l'affectation des résultats ;

– la décharge donnée aux organes de la société ;

– les nominations statutaires (conseil d'administration, commissaires, etc.). Par ailleurs, l'assemblée prend connaissance des documents suivants :

– le rapport de gestion du conseil d'administration ;

– le rapport du commissaire (du réviseur).

Si l'assemblée annuelle peut décider de la distribution d'un dividende (et si donc la mise en paiement effective en appartient aux dirigeants de la société), il se peut également qu'il y ait nécessité de distribuer un second dividende. La jurisprudence belge est fixée dans la mesure où de telles assemblées supplémentaires peuvent procéder à des distributions supplémentaires, et ceci, dans la limite des bénéfices distribuables (v. *sub* C. ci-dessus).

La situation tirée de l'exemple précédent ne doit pas être confondue avec celle d'une distribution de dividendes intérimaires : la particularité de ceux-ci est en effet de pouvoir distribuer des bénéfices qui ne sont pas encore arrêtés par une assemblée.

1 – Cass. b., 23 janvier 2003, n° C 01.0536, contre arrêt de la Cour de Mons du 17 mai 1997.

2 – L. Simont et P.-A. Foriers, « La distribution de réserves disponibles en cours d'exercice », *Liber amicorum J.-P. De Bandt*, Bruxelles, 2004, p. 602.

3 – L. Simont et P.-A. Foriers, « La distribution de réserves disponibles en cours d'exercice », *Liber amicorum J.-P. De Bandt*, Bruxelles, 2004, p. 605.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

E – Les assemblées générales extraordinaires

Dans la société anonyme, la plupart des décisions importantes, c.-à-d. celles qui modifient les statuts, sont prises par l'assemblée générale des actionnaires représentant au moins les **deux tiers** des actionnaires présents ou représentés (art. 450-3 L.S.C.). (Pour la société à responsabilité limitée, la majorité des trois quarts est requise ; art. 710-18 L.S.C. [anc. art. 194 L.S.C.]). En réalité, il est fait exception à ces règles pour certains cas, à savoir ceux qui augmentent les engagements des associés. Dans ce cas, l'unanimité est requise.

1) Assemblées générales extraordinaires de droit commun

Les formalités de convocation de ces assemblées sont les mêmes que celles utilisées pour les assemblées ordinaires : elles doivent contenir l'ordre du jour.

Le fonctionnement des assemblées extraordinaires est, en principe, identique à celui des assemblées ordinaires. En revanche, si une première assemblée n'a pas pu être tenue, faute de quorum suffisant, alors il y aura convocation d'une deuxième assemblée, et ceci, selon les mêmes formalités que celles applicables lors de la première assemblée (depuis la Loi de Modernisation, art. 450-8 L.S.C.).

a) Délais et formes de la convocation

Elles contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces déposées au R.C.S. et publiées 15 jours avant l'assemblée au RESA et dans un journal du Luxembourg (article 450-8 L.S.C.). Pour les assemblées concernant l'objet ou la forme de la société, il y a obligation d'indiquer dans les convocations **le texte des modifications des statuts** proposées. Pour les autres assemblées extraordinaires, il suffit que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées (art. 450-3 L.S.C.).

b) Condition de quorum

Alors qu'aucune condition de quorum n'est exigée pour une assemblée ordinaire, un tel quorum existe pour les assemblées extraordinaires, mais, en fait, tel n'est le cas que pour une première assemblée. « *La modification des statuts est toujours une chose grave ; pour que la majorité puisse l'imposer à la minorité, il convient que cette majorité représente une portion assez considérable du capital* »[1]. Ce quorum est de la moitié du capital (qui doit être présent ou représenté).

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par une procédure identique à celle utilisée pour la première convocation. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée.

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 207, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

c) Conditions de majorité

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. « *Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul* » (art. 450-3 (2) L.S.C.).

d) Accord des obligataires

Un des changements de la Loi de Modernisation est la suppression de l'accord des obligataires (en plus de celui des actionnaires) lorsqu'il s'agit d'augmenter les engagements des actionnaires (anc. art. 67-1 L.S.C.). La justification de ce changement va de soi s'il s'agit d'obligations ordinaires. En revanche, la situation est différente pour les **obligations convertibles** (ou, le cas échéant, d'obligations à warrant ou autres « *equity kickers* ») qui dans leur ensemble font de leurs détenteurs des actionnaires potentiels et qui auraient donc un intérêt à connaître l'augmentation potentielle de leurs engagements)[1]. À leur égard, la L.S.C. aurait donc dû maintenir le droit des obligataires de participer au vote de l'assemblée générale.

Finalement, il est désormais possible aux statuts **d'autoriser le conseil d'administration (directoire) de transférer le siège social** d'une commune à une autre ou à l'intérieur de la même commune. Ainsi donc, il sera possible de faire l'économie de la tenue d'une assemblée générale (pas de convocation, pas de réunion des actionnaires), mais ce changement devra toujours être acté par acte notarié[2].

2) Assemblées générales extraordinaires exigeant l'unanimité

Au vœu de l'article 450-3(1) L.S.C. : « *Néanmoins l'augmentation des engagements des actionnaires ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime des associés* ». L'unanimité sera encore exigée à chaque fois que l'objet de la modification est de toucher aux **droits acquis** d'un actionnaire ou d'une catégorie d'actionnaires[3].

Avant la Loi de Modernisation, les changements de nationalité faisaient partie des décisions qui ne pouvaient être prises qu'à l'unanimité des voix (anc. art. 67-1 L.S.C.). La Loi de Modernisation a supprimé l'exigence de l'unanimité pour les modifications des statuts portant changement de nationalité de la société, et ceci, au moyen de la justification suivante : « *Dans la mesure où l'heure est à la mobilité des sociétés, il importe de supprimer l'exigence d'unanimité que les statuts pourraient néanmoins maintenir* »[4]. Ceci paraît léger comme justification et, comme souligné par le Conseil d'État, peu cohérent dans la mesure où le projet de loi se soucie par ailleurs de mieux ancrer les sociétés au Luxembourg. « *Dans leurs propositions de modification relatives aux articles 67, paragraphe 3 et 70, alinéa 1 concernant les assemblées générales, les auteurs exigent la présence d'actionnaires au Luxembourg*

1 – Ce point a également été souligné par l'avis de la Chambre des Notaires, p. 18, *Doc. parl.*, n° 5730/08, ID 24209.

2 – *Doc. parl.*, n° 5730/08, Avis de la Chambre des Notaires, p. 18, ID 24209.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 204, ID 11305.

4 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 84, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

afin "d'assurer l'ancrage de la société au Grand-Duché". Le Conseil d'État a des difficultés pour suivre les auteurs dans leur raisonnement. En effet, n'est-il pas illogique d'insister, d'une part, sur la nécessité de la présence physique des actionnaires au Luxembourg et l'obligation d'y tenir les assemblées générales tout en facilitant, d'autre part, le changement de la nationalité des sociétés par la suppression de la condition de l'unanimité ? »[1].

Par ailleurs, cette approche est peu compatible avec la déclaration de protéger les actionnaires minoritaires. Le changement de nationalité d'une société est toujours un acte d'une importance fondamentale qui conduit à soumettre la société à un environnement légal qui, généralement, est fondamentalement différent de celui dans lequel la société a vécu par le passé. Sur certains points, les exigences de la loi du pays de destination sont moins strictes que celles du Luxembourg, sur d'autres, elles sont plus strictes et finalement, sur d'autres encore, elles sont identiques. Par conséquent, il est parfaitement fréquent que, sur l'un ou l'autre point, le changement de nationalité conduit à une modification des droits des actionnaires qui seront diminués, alors que, sur d'autres points, ils seront augmentés. Il se peut également qu'il y ait une augmentation des engagements des actionnaires (qui requièrent toujours l'unanimité). Si un changement de nationalité implique une augmentation des engagements des actionnaires, le changement de nationalité non approuvé par l'unanimité des actionnaires peut toujours être attaqué ; il n'en sera pas de même si le changement comporte uniquement une diminution des droits des actionnaires.

La Chambre des Notaires s'est également montrée critique en soulignant qu'elle « *[…] craint qu'une telle suppression, malgré l'argument de la mobilité des sociétés, ne favorise un "tourisme" en la matière au gré des actionnaires majoritaires désireux de trouver une législation étrangère qui leur serait favorable, alors qu'elle risque d'être préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par ailleurs, une telle disposition est-elle dans l'intérêt de la place financière ? La Chambre des Notaires plaide en faveur du maintien de l'unanimité en cas de changement de nationalité* »[2].

3) Assemblées extraordinaires décidant à une majorité allégée

L'article 480-2 L.S.C. prévoit qu'en cas de perte diminuant l'actif net à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire sont tenus de **convoquer l'assemblée** générale « *qui délibérera dans les conditions de l'article 450-3 L.S.C. sur la dissolution éventuelle de la société* ».

Le texte de la loi indique clairement qu'il ne suffit pas de convoquer l'assemblée dans le délai de deux mois, mais elle doit encore être effectivement **tenue** dans ce délai. La considération qu'il y a urgence d'agir est évidemment à la base de ces règles.

Cette disposition est indubitablement **d'ordre public** : s'il est interdit de prévoir des conditions moins strictes, l'alinéa 1 permet d'introduire dans les statuts des

1 – *Doc. parl.*, n° 5730/4, Avis du Conseil d'État, p. 18, ID 13321.

2 – *Doc. parl.*, n° 5730/08, Avis de la Chambre des Notaires, p. 18, ID 24209.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dispositions plus restrictives, par exemple donc, des majorités moins élevées ou encore des pertes de capitaux moins importantes.

La question se pose alors de savoir si cette assemblée doit être tenue **devant notaire**. Cette question est assez controversée en pratique[1].

Le problème est que, si l'assemblée se prononce en faveur de la dissolution, celle-ci ne pourra pas être actée par une assemblée ordinaire. En revanche, si l'assemblée décide de continuer l'exploitation en ignorant la perte de la partie prépondérante de son capital social, alors la tenue de l'assemblée notariée aura été inutile.

Si l'assemblée n'est pas tenue devant notaire et si elle se décide en faveur de la dissolution de la société, alors il faudra ensuite passer par une assemblée générale sous forme notariée, capable donc de décider la dissolution de la société. Pourtant, rien ne garantit que la deuxième assemblée décidera dans le même sens que la première, pour la raison déjà que la composition ne sera pas forcément la même.

Un autre inconvénient de cette procédure est qu'en cas de tenue de l'assemblée devant notaire, le procès-verbal de l'assemblée relatant donc les discussions devra être publié au RESA. En pratique, cette publicité est évitée lorsque l'assemblée décide de ne pas dissoudre la société en faisant valoir qu'en l'absence de modification des statuts, il n'y aurait aucun besoin de publier le procès-verbal[2].

« *Le juge répond à une allégation, fondée sur le texte de l'art. 100 L.S.C. (les administrateurs peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société), selon laquelle le non-respect des dispositions de cet article ne pourrait être invoqué que par les actionnaires et non pas par des tiers (en l'occurrence un créancier de la société). Force est de constater que cette disposition n'exclut pas l'action des tiers pour violation de l'article 100.*

Cette action ne semble d'autant plus pas exclue par la loi sur les sociétés commerciales eu égard à l'article 59, alinéa 2, qui, de manière tout à fait générale, ouvre aux tiers une action en dommages et intérêts contre des administrateurs non respectueux de la législation sur les sociétés commerciales et des statuts sociaux ».

La Cour d'appel rejeta finalement la demande du créancier de la société fondée sur l'article 100 L.S.C. [ancien] pour défaut de lien causal avec le préjudice[2].

■ § 5 – Les assemblées des obligataires

En droit luxembourgeois, tous les détenteurs d'obligations d'une même émission sont groupés en une **masse** qui est organisée conformément aux dispositions L.S.C. (art. 470-3 L.S.C.).

L'objectif de cette disposition est que la société puisse avoir un interlocuteur représentant les obligataires et que cette masse puisse décider sur la base du principe majoritaire[3].

1 – A. Schwachtgen, « L'interprétation de l'article 100 sur les sociétés », *Tax today*, *Mélanges de droit des sociétés*, 18-19 avril 2007.

2 – TA Lux. du 26 juin 1998, n° 46458 et CA du 19 décembre 2001, n° 22.771, commentés par Fr. Fayot *in Ann. dr. lux.*, 2001, p. 565, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – C. Delvaux, *La société anonyme*, p. 357.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

A – Désignation et pouvoirs des représentants de la masse

Aux termes de l'article 470-4 L.S.C., un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société lors de l'émission ou, pendant la durée de l'emprunt, par l'assemblée générale des obligataires.

La désignation peut encore avoir lieu par le président de la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale.

Art 470-5 [anc. art. 88] L.S.C.

« *(1) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société lors de l'émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après :*

1° ils exécutent les décisions prises par l'assemblée générale des obligataires ;

2° ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la société. Ils peuvent donner mainlevée totale ou partielle des inscriptions d'hypothèques, en cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d'aliénation des biens à dégrever, de même qu'en cas de remboursement total ou partiel des obligations ;

3° ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires ;

4°ils assistent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l'exécution régulière du plan d'amortissement et au paiement des intérêts ;

5° ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite, gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font toutes déclarations de créance au nom et dans l'intérêt des obligataires et rapportent la preuve de l'existence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit. Ils peuvent être autorisés lors de leur désignation à accepter tout paiement et répartition aux obligataires ;

6° ils peuvent ester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l'intérêt des obligataires représentés, sans qu'il soit nécessaire de les appeler en cause [...] ».

B – Convocation de l'assemblée des obligataires

Les assemblées générales des obligataires sont convoquées par les représentants de la masse des obligataires, le conseil d'administration (directoire) ainsi que le commissaire ou le collège des commissaires (art. 470-9 L.S.C.).

L'assemblée regroupe les obligataires qui font partie d'une même masse (d'une même émission). Toutefois, lorsqu'une question est commune aux obligataires appartenant à plusieurs masses, ceux-ci sont convoqués en une assemblée unique.

Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par l'article 450-8 L.S.C. applicable aux assemblées des actionnaires (art. 94 L.S.C.).

Conformément à l'article 470-12 L.S.C., tous les obligataires ont, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux conditions de l'émission, le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires. Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Peuvent assister à l'assemblée avec voix consultative les membres des organes de la société ainsi que les personnes qui y seraient autorisées par l'assemblée elle-même.

L'assemblée est présidée par les représentants de la masse des obligataires s'il en a été désigné. Celui qui s'est conformé aux prescriptions de la loi et aux conditions de l'émission en vue de participer à l'assemblée peut, si son droit est contesté, prendre part au vote sur son admissibilité. Son mandataire porteur d'une procuration écrite a le même droit. La société doit mettre à disposition des obligataires, au début de la réunion, un état des obligations en circulation.

Le mode de délibération est déterminé par les statuts, les conditions de l'émission et les dispositions de l'article 450-1 L.S.C.

Art. 470-13 [anc. art. 94-2] L.S.C.

Parmi les attributions de l'assemblée figurent les suivantes :

1° « nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l'article 470-4, les représentants de la masse ;

2° révoquer les mandataires spéciaux visés à l'article 470-6 ;

3° décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun ;

4° modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d'obligations ;

5° proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou en modifier les conditions de paiement ;

6° prolonger la durée de l'amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu ;

7° accepter la substitution aux obligations d'actions de la société ;

8° accepter la substitution aux obligations d'actions ou d'obligations d'autres sociétés ;

9° décider la constitution d'un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs ;

10° décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l'exercice de leurs droits [...] ».

■ § 6 – Le contrôle et la surveillance de la société

Celui-ci est confié en principe aux commissaires (aux comptes) avec la restriction que, pour les sociétés d'une certaine importance, un système différent plus performant en principe (mais plus cher également) est mis en place : ce système alternatif mise sur l'indépendance d'une personne professionnellement qualifiée.

L'institution du commissaire depuis fort longtemps ne donne pas satisfaction et a donné lieu essentiellement à des **critiques** : « *Aussi longtemps qu'on fera des fonctions de commissaires des places permanentes auxquelles seront attachées des tantièmes de bénéfices, et où on arrivera par la grâce des administrateurs, on aura une institution absolument stérile. N'est-il pas absurde que les administrateurs participent au choix de leurs contrôleurs et que ceux-ci aient une part dans les bénéfices qui doit les porter à en enfler la distribution, alors que leur rôle principal est de la maintenir dans la stricte vérité ? J'appelle toute l'attention sur ce point. Il y a là une révolution à faire. En Angleterre, les commissaires n'existent pas comme une institution fixe, mais on charge des comptables étrangers à la société de vérifier ou même de dresser le bilan en examinant la comptabilité. C'est vers une situation analogue*

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

qu'il faudrait tendre »[1] ou de façon plus lapidaire : « *En général, les commissaires font peu de choses et les sociétés qu'ils ont sauvées du désordre sont rares* »[2].

A – Le commissaire (aux comptes)

La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.

1) Nomination des commissaires

Les dispositions légales applicables sont étroitement calquées sur celles de l'organe de gestion, à savoir donc le conseil d'administration.

a) Statut du commissaire

Le commissaire est nommé par **l'assemblée générale** des actionnaires pour une durée de **6 ans au maximum** tout en étant rééligible. Comme les administrateurs, ils sont **révocables** par l'assemblée générale. C'est encore l'assemblée générale qui détermine le nombre des commissaires et fixe leurs émoluments. Si le nombre statutaire est réduit, « *[…] par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants* ». En pratique, le commissaire n'existe plus que pour les petites sociétés (pour les raisons expliquées ailleurs) et celles-ci n'ont en réalité qu'un seul commissaire.

b) Absence de condition de qualification

Une des grandes faiblesses de l'institution du commissaire aux comptes est celle de ne pas soumettre les commissaires aux moindres conditions de **qualification professionnelle**. Le législateur national, sous l'influence du droit européen, a réagi contre cet état de choses en instituant la profession de réviseur d'entreprises.

2) Mission du commissaire

Selon la jurisprudence : « *Le rôle des commissaires ne consiste pas uniquement à pointer les comptes, à examiner la concordance des écritures et pièces comptables avec ceux-ci, à une vérification de correspondance et d'exactitude purement matérielle. Ils doivent se mettre en mesure de faire un rapport sur la situation de la société* »[3].

Le commissaire a non seulement un rôle de contrôle, mais encore un rôle de surveillance de la société (pour plus de détails, voir sous Attributions des commissaires, p. 463).

---

1 – E. Pirmez, Observations sur avant-projet de loi rédigé par A. Nyssens, p. 18, ID 11305.

2 – E. Pirmez, Observations sur avant-projet de loi rédigé par A. Nyssens, p. 17, ID 11305.

3 – Corr. Seine du 2 août 1923, *Gaz. trib*., 1923, II, p. 575.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

3) Révocation et responsabilité du commissaire

Aux termes de l'article 443-1 L.S.C., les commissaires sont toujours **révocables** par l'assemblée générale. C'est donc dans la loi même que l'assemblée générale puise son droit de révoquer le commissaire, quelle que soit la durée qui ait été fixée à son mandat. Le mandat du commissaire aux comptes, comme celui de l'administrateur, est révocable *ad nutum*, au gré de la société et sans qu'elle soit tenue de justifier d'une manière quelconque la mesure qu'elle prend. La révocation peut donc intervenir sans que le conseil d'administration n'ait à notifier un préavis à l'intéressé ni à lui en préciser les motifs. « *L'abus de droit (ou l'abus de révocation) ne peut trouver sa cause dans le vote proprement dit de l'assemblée générale ou dans la motivation retenue par l'assemblée générale, mais dans les circonstances injustifiées qui accompagnent cette révocation : publicité abusive de griefs, atteinte à l'honneur ou aux droits des personnes, intention de nuire à l'homme à travers l'administrateur […] En l'occurrence, le commissaire ne peut fournir une telle démonstration* »[(1)].

Comme le mandat des commissaires aux comptes est essentiellement civil et par nature, sa gratuité du mandat est présumée comme dans tout mandat non commercial et « *il appartient au mandataire de prouver le caractère salarié du mandat et l'engagement du mandant au paiement d'un salaire, en l'occurrence, un engagement de la part de l'assemblée générale des actionnaires, organe seul compétent pour statuer en la matière de la fixation des émoluments des commissaires* »[(2)].

« *Les commissaires aux comptes doivent agir avec le soin des bons pères de famille […] en veillant toutefois à ne pas s'immiscer dans la gestion de la société. Les obligations du commissaire découlent toutes de l'idée que le commissaire doit exercer ses contrôles avec la diligence et l'impartialité que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel qualifié. Le commissaire a donc l'obligation de faire tout ce qui est nécessaire pour accomplir sa mission dans des conditions satisfaisantes* ». En l'espèce, le juge relève :

– le fait que l'un des défendeurs ait été à la fois administrateur de la société contrôlée et associé de la société civile. Avoir la qualité de commissaire aux comptes de la société contrôlée n'est ni prohibé ni fautif en soi dans la mesure où la société civile concernée est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses associés ;
– le fait que l'un des défendeurs ait été à la fois actionnaire et commissaire n'est pas fautif, ceci étant expressément envisagé par l'article 61 [ancien] L.S.C. La responsabilité des commissaires est néanmoins retenue en l'espèce dans la mesure où il est apparu, en ce qui concerne la société contrôlée ;
– qu'aucun des documents comptables prévus par la loi n'avait été établi ;
– que la surveillance et le contrôle des livres, valeurs et comptes de la société ont été inexistants pendant toute la vie de la société ;
– que ni l'absence de comptabilité ni la perte du capital social n'ont motivé les commissaires à agir.

« *Commettent des fautes les commissaires qui ne signalent pas à l'assemblée générale, fût-ce en la convoquant extraordinairement, notamment l'absence de*

1 – TA Lux. du 1er juin 1990, n° 38.688, ID 10175.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

publication d'un bilan, l'absence de proposition de dissolution de la part des administrateurs en cas de perte du capital social, l'absence d'organes de gestion de la société […]. Il s'agit là d'une violation des obligations incombant en vertu de l'article 62 de la loi sur les sociétés commerciales aux commissaires. Les commissaires ne sont en principe pas responsables des fautes des dirigeants de la société, sauf s'ils ont par leurs agissements contribué à en aggraver les conséquences. Cette condition est remplie en l'espèce ». Plus spécifiquement, le juge retient une responsabilité solidaire (art. 441-9, alinéa 2, L.S.C.) dans la mesure où il est question de violation de la loi sur les sociétés commerciales et d'obligations statutaires[1].

B – Le réviseur d'entreprises

L'institution du réviseur d'entreprises est relativement récente au Luxembourg. Comme tant d'innovations de ces dernières décennies, elle vient du droit européen. Placés devant le choix de savoir quel est le meilleur système de contrôle des comptes des sociétés, les instances européennes ont opté en faveur d'un système basé sur le contrôle contractuel par une personne indépendante plutôt qu'un contrôle administratif. C'est la loi du 23 juillet 2016[2] relative à la profession de l'audit qui réglemente le statut des réviseurs. Le lecteur est renvoyé à la Partie II pour plus de détails, voir p. 469.

■ § 7 – Possibilité d'avoir un conseil général

Art. 444-5 L.S.C.

« Les statuts peuvent disposer que les administrateurs et les commissaires réunis formeront le conseil général ; ils en détermineront les attributions ».

Cette institution, peu fréquente en pratique, est également très critiquée : « *C'est à mon sens une mauvaise institution. Elle confond l'administration et le contrôle. Elle permet d'engager les commissaires dans certaines décisions sur lesquelles ils n'ont plus ensuite la liberté de s'exprimer, sans se compromettre. Elle permet d'énerver la responsabilité de l'administration. On doit chercher les commissaires parmi les personnes qui peuvent examiner une comptabilité, y découvrir les fraudes et les irrégularités. C'est fausser l'institution que de les appeler à délibérer sur des mesures d'administration auxquelles ils peuvent n'avoir aucune aptitude* »[3].

On a fait valoir qu'un contrôle efficace de la gestion exige de ceux qui en sont en charge d'être libres et indépendants dans l'accomplissement de leur mandat ; il serait dangereux d'intervertir les rôles en permettant l'immixtion des commissaires dans la gestion des affaires sociales : les commissaires doivent être indépendants de la gestion sociale[4].

---

1 – TA Lux. du 23 décembre 1987, n°s 29.975, 29.977, 29.978, 31.024, 31.533, 32.225, 33.672 et 33.673, ID 23159.

2 – *Doc. parl.*, n° 5872, ID 10127.

3 – E. Pirmez, Observations sur avant-projet de loi rédigé par A. Nyssens, p. 18, ID 11305.

4 – Ch. Resteau, Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913, p. 26.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette institution a d'autre part **vocation à disparaître**, car le nombre des sociétés qui ont encore un commissaire a tendance à diminuer du fait qu'au-delà de certains seuils d'importance, c'est le réviseur qui remplace le commissaire traditionnel. Un conseil général ne peut fonctionner avec un tel réviseur dont l'indépendance par rapport à la gestion de la société doit être assurée.

■ § 8 – Les organes facultatifs

Sous le présent intitulé sont regroupés les trois organes suivants :
– le comité de direction ;
– le directeur général ;
– les comités spéciaux.

Si le comité de direction était déjà connu en pratique avant l'entrée en vigueur de la Loi de Modernisation[1], il ne faisait pas partie des organes légaux, ceux dont le régime juridique est organisé par la loi. Sa consécration légale donne évidemment une sécurité juridique bien plus grande, notamment au regard des pouvoirs de représentation à l'égard des tiers[2].

A – Le comité de direction

La faculté d'introduire un comité de direction est prévue par l'article 441-11 [anc. art. 60-1] L.S.C., disposition applicable aux S.A. (y compris aux SE), mais seulement à l'égard des sociétés ayant opté pour le modèle de gestion moniste, celui donc avec conseil d'administration. Cette conclusion résulte du simple fait qu'aucune disposition correspondant à l'article 441-11 L.S.C. n'est contenue à la « *section 2 – Du directoire et du conseil de surveillance (articles 442-1 à 442-19)* ».

Un comité de direction peut-il être introduit dans une société en commandite par actions ? Bien que l'article 600-2 [anc. art. 103] L.S.C. renvoie aux dispositions de la société anonyme, il n'est pas certain que ce renvoi inclue nécessairement le renvoi à l'article 441-11 L.S.C. Il paraît donc que, malgré certaines hésitations, on doive conclure avec la doctrine qu'un tel comité de direction doit être considéré comme exclu dans la S.e.c.a.[3].

Il est encore acquis qu'un comité de direction est exclu à l'égard de la S. à r.l. En dehors du fait que les dispositions afférentes ne prévoient pas la possibilité d'un tel comité, il s'y ajoute que le projet de loi n° 5730 (en son article 191*bis* (5)) prévoyait un tel comité à l'égard de la S. à r.l. Cette disposition a été retirée par la suite sur demande du Conseil d'État.

Un comité de direction (qui n'est jamais obligatoire) n'est valablement institué que si les statuts l'autorisent expressément (art. 441-11 L.S.C.). L'effet d'une telle autorisation est que « *le conseil d'administration délègue ses pouvoirs de gestion à un comité de direction […]* » non pas dans sa totalité, étant donné que la L.S.C. précise

1 – J.-P. Spang, « Les organes de gestion », *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 109 ss.

2 – J.-P. Spang, *op. cit*, p. 113.

3 – J.-P. Spang, *op. cit*, p. 116.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

que la « politique générale » ne peut faire l'objet de délégation. Il existe par ailleurs des pouvoirs réservés au conseil d'administration qui ne peuvent pas être délégués[1].

Au vœu de l'article 441-11 L.S.C., le comité de direction est composé de plusieurs membres[2] qui peuvent être administrateurs sans que ceci ne soit obligatoire. Ledit article L.S.C. dispose encore que le mode de désignation, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission, le mode de fonctionnement sont déterminés par les statuts ou à défaut par le conseil d'administration.

L'étendue des pouvoirs délégués par le conseil d'administration (ou selon la forme de la société concernée par un autre organe social) peut encore varier selon la forme de la société : ainsi, pour la SE, il s'agit de tenir compte du droit communautaire qui ne permet que de déléguer la seule « gestion courante », notion non définie par le règlement 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), mais certainement plus large que celle de la gestion journalière[3].

La Loi de Modernisation a encore pris soin de noter (art. 441-11, dernier alinéa L.S.C.) que « *les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué* ». Toutefois, il est précisé que ces restrictions n'ont qu'une portée purement interne : « *ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont convenus, ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées* ». Cette solution est parfaitement conforme au droit européen[4].

À l'instar du délégué à la gestion journalière, le comité de direction, auquel le pouvoir de gestion est attribué, est chargé également de la **représentation** en ce qui concerne cette gestion. Par conséquent, l'article 10 de la directive 2009/101/CE est applicable : la société est engagée à l'égard des tiers par les actes posés par ses organes de représentation, même si ceux-ci **dépassent l'objet social,** à moins que lesdits actes excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes. Toutefois, la société n'est pas engagée en raison des actes dépassant l'objet social si elle prouve que le tiers savait que l'objet social était dépassé ou ne pouvait l'ignorer, la seule publication des statuts étant insuffisante pour établir cette preuve.

Il va de soi que la multiplication des organes de gestion soulève des problèmes de délimitation des compétences entre ces organes. Ces problèmes ont été abordés par la Loi de Modernisation. En premier lieu, l'article 441-1, alinéa 1er, précise que le comité de gestion est chargé de surveiller la gestion du comité de direction. Ensuite se pose la question de savoir si le pouvoir de gestion, dans la mesure où il a fait l'objet de la délégation au comité de direction, est exercé de façon exclusive par ce dernier. Cette question doit être répondue par la négative. Dans sa version initiale, la Loi de Modernisation avait précisé que le comité de direction « *exerce ses pouvoirs de manière exclusive* ». Par suite des critiques adressés en particulier par le Conseil d'État à cette solution, cette phrase a été retirée. Par conséquent, l'existence d'un comité de direction signifie que les pouvoirs de gestion peuvent être exercés de façon concurrente, et que donc le conseil d'administration est parfaitement en droit d'exercer ses pouvoirs en posant des actes de gestion.

1 – J.-P. Spang, *op. cit*, p. 124.

2 – La LSC ne précise pas s'il s'agit d'un organe collégial ou non. Ce point est décidé par les statuts ou par une décision du conseil d'administration.

3 – J.-P. Spang, *op. cit*., p. 125.

4 – L'article 10 de la directive 2009/101/CE impose cette solution.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le comité de direction exerce ses pouvoirs sous la surveillance du conseil d'administration.

B – Le directeur général

Au lieu de prévoir un comité de direction, les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration de déléguer ses pouvoirs de gestion à un individu, appelé directeur général, qui constitue alors « *l'équivalent unipersonnel du comité de direction* »[1]. En revanche, le cumul dans une même société d'un comité de direction avec un directeur général paraît exclu[2]. Il est vrai que, par le passé déjà, il était possible pour le conseil d'administration d'appointer un délégué à la gestion journalière. L'apport de la Loi de Modernisation est alors de permettre une délégation plus large de ses « pouvoirs de gestion », dans la mesure où peut être déléguée non seulement la gestion journalière, mais la gestion dans son ensemble. Par conséquent, il paraît possible de cumuler dans une même société le directeur général et le délégué à la gestion journalière, le champ d'application de ces deux délégations n'étant pas identique.

C – Les comités spéciaux

Parfois désignés par le terme de « comités consultatifs »[3], la Loi de Modernisation utilise le terme de « comités » dont la composition et les attributions sont fixés par l'organe qui les a créés (p. ex., le conseil d'administration, art. 441-6 L.S.C.). Pendant ces dernières années, de tels comités ont fait leur apparition en droit luxembourgeois non seulement dans la L.S.C. (art. 442-15 relatif au conseil de surveillance dans le type de gestion dualiste et qui lui permet de créer en son sein des « commissions »), mais surtout dans différentes lois spéciales énumérées ici de façon non exhaustive :

- la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier[4] a rendu obligatoire à l'égard de certaines sociétés un comité de nomination et un comité de rémunération ;
- les « X Principes de gouvernance d'entreprise » de la Bourse de Luxembourg (introduits en 2006) imposent un comité de nomination, un comité d'audit et un comité de rémunération ;
- la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit (entre-temps remplacée par la loi du 23 juillet 2016) a introduit un comité d'audit pour les entités d'intérêt public ;
- etc.

Ces comités, dont l'introduction était soit obligatoire soit facultative, manquaient ainsi de base légale dans la L.S.C. (abstraction faite « des commissions » créées à l'intérieur du conseil de surveillance de l'article 442-15 L.S.C.). Si la L.S.C. consacre donc la possibilité de tels comités, c'est le conseil d'administration qui en décide la création, en fixe la composition et les attributions ; ils exercent leurs attributions sous sa responsabilité.

---

1 – Selon la formule de J.-P. Spang, *op. cit*, p. 134.

2 – En ce sens, Rapport de la Commission juridique du 11 juillet 2016, *Doc. parl.*, n° 5730/14, p. 49.

3 – J.-P. Spang, *op. cit*., p. 136.

4 – ID 1086.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'article 52 de la loi du 23 juillet 2016 est consacré aux comités d'audit. « *(1) Chaque entité d'intérêt public doit être dotée d'un comité d'audit. Le comité d'audit est soit un comité indépendant, soit un comité de l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée. Il est composé de membres non exécutifs de l'organe de gestion et/ou de membres de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée et/ou de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ou, pour les entités qui ne comptent pas d'actionnaire, par un organe équivalent.*
Le comité d'audit compte au moins un membre compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.
Les membres du comité dans leur ensemble sont compétents dans le secteur d'activité de l'entité contrôlée.
Les membres du comité d'audit sont, en majorité, indépendants de l'entreprise contrôlée. Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité ou par l'organe de surveillance de l'entité contrôlée, et est indépendant de l'entité contrôlée [...] ».

SECTION IV
LES PACTES D'ACTIONNAIRES

Le syndicat d'actionnaires est une simple association civile qui, en l'absence de la mise en commun d'apports, vise uniquement à acquérir au profit des syndicataires certains avantages ou à éviter certains dommages d'ordre matériel ou moral[1].

Les pactes d'actionnaires relèvent du phénomène de contractualisation des sociétés, notion définie comme « *le phénomène qui consiste à aménager les structures liées à la gestion ou au capital de la société par des conventions extrastatutaires entre des associés ou actionnaires, ou d'autres personnes intéressées par son fonctionnement* »[2]. Les conventions extrastatutaires dressées en conséquence traduisent la recherche de la flexibilité en cette matière du droit des sociétés, matière qui est devenue de plus en plus réglementée pendant les dernières décennies.

« *L'intérêt des conventions extrastatutaires croît à mesure que s'amenuise le caractère contractuel de la société et que se multiplient les règles de fond et de forme applicables* »[3]. Ce point explique que les pactes d'actionnaires concernent **surtout** les **sociétés anonymes**.

Les conventions extrastatutaires ont une nature **hybride** dans la mesure où elles sont de nature contractuelle, d'une part, et de nature sociétaire, d'autre part. En tant que conventions, elles trouvent leur source essentiellement dans l'article 1134 C.c. (principe de l'autonomie de la volonté).

« *La possibilité pour les associés ou actionnaires d'aménager leurs relations par des conventions extrastatutaires varie en fonction de la théorie sous-jacente de la société. Dans la théorie contractuelle, les parties peuvent librement régler leurs relations, sous réserve des lois impératives ou d'ordre public. En revanche dans une*

1 – L. Maeyens et P. Roose, « Syndicats d'actionnaires de société anonyme », *R.P.S.*, 1964, p. 57.

2 – Simonart, « La contractualisation des sociétés ou les aménagements contractuels des mécanismes sociétaires », *R.P.S.*, 1995, p. 77.

3 – Simonart, « La contractualisation des sociétés ou les aménagements contractuels des mécanismes sociétaires », *R.P.S.*, 1995, p. 82.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conception stricte de la théorie institutionnelle, la possibilité même de conclure des conventions extrastatutaires doit être mise en doute. Même si la théorie institutionnelle n'a jamais été appliquée avec une telle rigueur, elle invite à condamner les clauses qui portent directement ou indirectement atteinte aux règles institutionnelles non écrites de la société »[1].

La validité de principe de ces pactes ne fait plus de doutes[2]. « *D'une part, la liberté contractuelle s'applique en matière de sociétés ; d'autre part, le champ d'application de ces pactes est nettement plus étendu que le domaine propre du droit des sociétés. Cela dit, il est difficile de déterminer ce qui est impératif dans le droit des sociétés, et à qui les règles impératives peuvent s'appliquer. L'ordre public est presque toujours un ordre public de protection, et l'on peut se demander dans quelle mesure les actionnaires, ou les autres porteurs de titres, peuvent renoncer aux dispositions qui les protègent* »[3].

Les pactes d'actionnaires servent à compléter les statuts de la société par des **accords externes** qui modifient le jeu des règles légales ou des clauses statutaires soit pour prendre le pouvoir, soit pour le conserver, soit pour organiser une collaboration, soit pour sortir de la société[4]. La pratique visée fonde sur la liberté contractuelle ; il est vrai que la prévisibilité des solutions est moins grande et les sanctions des défauts d'exécution sont moins efficaces[5].

La **durée** des pactes d'actionnaires ne peut en principe pas excéder celle de la société. En revanche, elle peut être plus courte, notamment du fait que le pacte n'est conclu que longtemps après la constitution de la société. Les conventions entre actionnaires peuvent heurter les impératifs du **droit de la concurrence** et créer ainsi des ententes interdites[5].

Alors que les statuts de la société concernent tous les associés, les pactes d'actionnaires peuvent être conclus entre **certains seulement** des actionnaires ou encore lier d'autres personnes que les actionnaires actuels de la société, à savoir les titulaires d'autres titres, les bénéficiaires de promesse de cession, etc.

Quant à l'objet des pactes d'actionnaires, il y a lieu de noter que celui-ci peut être très varié dans la mesure où les actionnaires s'engagent notamment :

– à voter ensemble sur telle ou telle question ;
– à ne pas acquérir de nouveaux titres ;
– à proposer leurs titres aux autres signataires du pacte s'ils décident de céder leurs titres ;
– à rendre leurs actions inaliénables pour une certaine durée ;
– à imposer à un acheteur l'acquisition des titres de plusieurs actionnaires (clause de sortie conjointe)[6] ;
– à désigner un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du collège des commissaires.

---

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 141.

2 – Ph. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 567 et les références y données notamment pour la France ; G. Parléani, « Les pactes d'actionnaires », *Rev. soc.*, 1991, n° 1.

3 – Ph. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 567.

4 – Ph. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 23.

5 – Ph. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 569.

6 – Ph. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 568.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Plus précisément, on peut classer les pactes d'actionnaires en différentes catégories :

– ceux ayant pour objet de « bétonner » la composition de l'actionnariat (on parle également de **cristallisation du capital**[1]) ;
– ceux portant sur la gestion de la société.

§ 1 – Pactes d'actionnaires portant sur le capital social

Les actionnaires veulent maintenir **l'équilibre existant** entre les actionnaires (ou groupes d'actionnaires), tel qu'il existe à un moment donné, et ceci, en empêchant donc les cessions d'actions entre actionnaires d'abord et à des tiers ensuite.

Ces clauses répondent à la préoccupation d'assurer la stabilité de l'actionnariat, objectif qui est notamment très fréquent dans les sociétés familiales. Dans ces dernières, cette préoccupation prend surtout de l'importance lorsque l'entreprise familiale passe à la deuxième ou la troisième génération, que les liens personnels qui ont pu exister entre les fondateurs se sont relâchés[2] et que les titres se sont dispersés sur un nombre de personnes plus important.

L'importance relative de deux groupes d'actionnaires ne pourra pas être affectée si aucun groupe ne procède à des acquisitions supplémentaires. Si tous les actionnaires font partie du pacte d'actionnaires et si tous respectent les stipulations du contrat, la composition du capital se trouvera effectivement solidifiée.

En revanche, de telles clauses sont d'une efficacité limitée à l'égard des tiers. En effet elles ne font pas obstacle à la cession des actions à un tiers, elles ne constituent donc pas une parade à des agressions externes. Ces différents objectifs sont donc atteints au moyen des clauses suivantes.

A – Clauses d'inaliénabilité des actions

Un moyen très radical pour assurer la stabilité de l'actionnariat consiste à prévoir l'inaliénabilité absolue des titres. Par rapport aux droits des actionnaires décrits dans la première partie du présent ouvrage, cette solution soulève un problème dans le sens qu'elle est de toute évidence en conflit avec un droit fondamental des actionnaires, à savoir donc celui de la **libre négociabilité** des biens consacré par l'article 537 C.c. « *Les clauses rendant des biens, mobiliers ou immobiliers, totalement inaliénables sont généralement considérées comme contraires à l'ordre public. Une clause d'inaliénabilité doit dès lors être limitée dans le temps et être justifiée par un intérêt légitime* »[3].

En revanche, des clauses **d'inaliénabilité limitée** dans le temps sont en général reconnues comme licites, du moins dans la mesure où elles sont motivées par la nécessaire collaboration des associés au sein de la filiale commune.

La Loi de Modernisation (art. 430-1 (2) L.S.C.) a réglementé les clauses d'inaliénabilité (en fait, elles sont relatives à l'agrément, à la préemption et à l'aliénabilité) en disposant qu'elles doivent être **limitées dans le temps**. En outre, lorsque l'inaliénabilité

1 – G. Parleani, « Les pactes d'actionnaires », *Rev. Soc.*, n° 7 .
2 – P. Van Ommeslaghe, « Les conventions d'actionnaires en droit belge », *R.P.S.*, 1989, p. 290.
3 – P. Van Ommeslaghe, « Les conventions d'actionnaires en droit belge », *R.P.S.*, 1989, p. 294.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

résulte d'une clause d'agrément ou d'un droit de préemption, ces clauses ne peuvent avoir pour effet de prolonger l'indisponibilité de plus de douze mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption. Lorsque ces clauses prévoient un délai supérieur à douze mois, celui-ci est de plein droit réduit à douze mois.

Faute de dispositions statutaires précisant la détermination du prix de cession et faute d'accord entre les parties, ce prix est fixé par le président du tribunal d'arrondissement siégeant en *matière commercial*e et comme en matière de référé.

Le projet de loi n° 5730 avait prévu que les clauses d'inaliénabilité ne doivent pas être contraires à l'intérêt social. « *Le texte vise les clauses d'inaliénabilité. Il est proposé de remplacer la justification par l'intérêt social à tout moment figurant dans le texte belge par une exigence de non-contrariété à l'intérêt social, en telle sorte que les clauses poursuivant un intérêt étranger à l'intérêt social – personnel ou familial, par exemple – mais neutre par rapport à celui-ci ne puissent être contestées. Une autre option consisterait à suivre le droit français formulé par la SAS qui semble permettre de faire l'économie de toute justification au regard de quelque intérêt que ce soit mais encore faut-il observer : – que cette flexibilité est acquise au prix d'une limitation dans le temps établie de manière quelque peu arbitraire à un maximum de dix ans ; – que l'éventualité d'une contrariété à l'intérêt social se trouve réduite du fait que la décision d'introduction d'une telle clause doit être prise à l'unanimité des associés. Or, il apparaît déraisonnable d'exiger que la clause d'inaliénabilité soit adoptée à l'unanimité dans le cadre des sociétés anonymes en général car une telle règle compliquerait considérablement l'instauration d'une inaliénabilité par la voie d'une modification statutaire* ».

La condition de l'intérêt social prévue dans la version initiale du projet de loi n° 5730 n'a pas été retenue, et ceci, après avoir été sévèrement critiquée par l'avis du Conseil d'État qui critiquait surtout la modification de la condition de conformité à l'intérêt social, celle-ci devant être changée en condition de non-contrariété à l'intérêt social. « *Le Conseil d'État constate aussi que la justification de l'intérêt de la société est continuellement éliminée par une non-contrariété à l'intérêt de la société. Il ne peut pas suivre les auteurs, car une non-contrariété constitue un renversement de la charge de la preuve rendant celle-ci sinon impossible, du moins très difficile face à un intérêt abstrait et non défini. Il s'agit ici d'une innovation introduite par les auteurs, car ni la législation belge ni la législation française ne connaissent une limitation des droits des actionnaires. Le Conseil d'État propose par conséquent de prévoir que de telles limitations devront être prouvées par l'intérêt de la société, afin d'éliminer tout abus* »[1].

Selon la loi finalement adoptée, les clauses de limitation de la cessibilité peuvent avoir un champ d'application très large, car elles ne concernent pas seulement les actions de toute nature, les parts bénéficiaires, les droits de souscription, mais encore tous les titres donnant droit à l'acquisition d'actions (les obligations convertibles, celles avec droit de souscription, celles remboursables en actions, etc.).

La violation des clauses visées est la nullité de la cession, à condition qu'il s'agisse de clauses statutaires. Ainsi, la L.S.C. « *[…] reprend la sanction formulée*

1 – Avis du Conseil d'État, *Doc. parl.*, n° 5730/4, p. 2, ID 13321.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

à l'art. L. 228-23 C. com. fr. pour les cessions réalisées au mépris de clauses statutaires d'agrément dans les S.A. et à l'art. L. 227-15 C. com. fr. pour les cessions réalisées en violation de clauses statutaires d'agrément ou d'inaliénabilité dans les SAS. Le champ d'application de la sanction est donc étendu ici aux clauses de préemption de même qu'aux autres clauses statutaires restreignant la cessibilité des actions »[1].

Dans son avis relatif au projet de loi n° 5730, le Conseil d'État a souligné certaines des difficultés auxquelles ces nouvelles dispositions sont susceptibles de donner lieu. « *Le dernier alinéa prescrit la nullité de toute cession effectuée en violation des clauses statutaires. À l'analyse du texte, le Conseil d'État note que cette nullité ne s'applique qu'aux seules cessions à l'exclusion des transmissions dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial ou pour cause de mort. Il observe ensuite que seules les cessions en violation des clauses statutaires sont visées à l'exclusion des limitations prévues par les actes d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription et de toutes autres conventions. Si telle est l'intention des auteurs, le Conseil d'État peut, tout en tenant compte des observations qui précèdent, marquer son accord avec le texte de cet alinéa. Finalement, il se pose la question quelles autres conventions pourraient limiter la cessibilité et la transmissibilité des actions, des droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions. Les statuts font la loi entre actionnaires, tout comme les actes d'émission fixent notamment les règles de cession des titres émis. Ces documents sont publics et les actionnaires et porteurs de titres les connaissent au moment où ils souscrivent. Le Conseil d'État ne peut pas marquer son accord à ce que de simples conventions introduisent des limitations, alors qu'elles ne lient que les parties contractantes. Dans ce cas, elles relèvent du droit général des obligations et il n'y a pas d'utilité d'inscrire ces règles dans la loi concernant les sociétés. Quant au paragraphe 3, le Conseil d'État doute que la loi puisse permettre aux statuts de prescrire l'incessibilité pure et simple et l'intransmissibilité des parts bénéficiaires en toutes circonstances et notamment dans le cadre de la liquidation de régimes matrimoniaux ou de successions. Il ne peut marquer son accord avec de telles restrictions, sauf à prévoir une clause de rachat obligatoire ou de limiter celles-ci à une clause de préemption ou d'agrément, limitées dans le temps afin que les porteurs de titres ne deviennent pas les prisonniers de la société. Le Conseil d'État est d'avis que ce texte est trop général. Du point de vue contractuel, il lie à vie et même au-delà, et du point de vue propriété, il prévoit la possibilité d'annulation du droit de propriété. Le Conseil d'État propose le maintien du texte actuel, sous peine d'opposition formelle, car la nouvelle disposition est contraire au principe que personne ne pourra se lier contractuellement à vie* ». Ces commentaires n'ont pas donné lieu à des conséquences concrètes relativement aux textes définitivement adoptés.

En revanche, des clauses **d'inaliénabilité limitée** dans le temps sont en général reconnues comme licites, au moins dans la mesure où elles sont motivées par la nécessaire collaboration des associés au sein de la filiale commune.

1 – *Doc. parl.*, n° 5730/00, Commentaire des articles, Ad 22) Article 37, p. 68, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

B – Clauses d'orientation du capital

Lorsqu'on désire éviter l'intrusion de nouveaux actionnaires dans la société, les actionnaires se réservent volontiers un **droit de préemption** sur les actions mises en vente. Si tant est que l'intrusion de nouveaux actionnaires ne peut être évitée, ils n'acceptent telle intrusion que moyennant **l'agrément** préalable de ce nouvel associé[1].

Cet objectif peut encore être atteint au moyen de la clause de non-acquisition de titres supplémentaires.

Ces clauses ont pour objet d'influencer l'accès à la société. On distingue les clauses d'agrément des clauses de préemption.

1) Les clauses d'agrément

Par ces clauses, les actionnaires soumettent la faculté d'aliéner la participation des membres aux organes de la société (conseil d'administration ou assemblée générale des associés), soit encore des actionnaires sans passer par l'assemblée générale[2].

Par les clauses d'agrément, les actionnaires se mettent d'accord pour soumettre à leur consentement réciproque les cessions opérées par les actionnaires existants. Ces clauses sont susceptibles d'entrer en conflit avec le principe de libre négociabilité des actions. En effet, si un actionnaire entend vendre ces titres à un tiers de son choix, et que ce tiers n'est pas agréé par les autres actionnaires, il serait **prisonnier de ses titres**. Pour échapper à ce reproche, il faudrait que la clause d'agrément de l'actionnaire soit accompagnée de la clause que, en cas de refus d'agrément, il y a achat par les autres actionnaires des actions offertes à la vente. La sortie de l'actionnaire est ainsi assurée. À l'inverse, ces clauses ne constituent qu'un des aspects de la liberté contractuelle et de la liberté d'association[3].

Ces clauses peuvent être de type discrétionnaire : l'avantage de cette solution est d'éviter toute discussion possible sur les motifs du refus avec un actionnaire désireux de sortir de la société. Selon la doctrine, de telles clauses **discrétionnaires** sont pourtant discutables pour la raison qu'elles peuvent être considérées comme contraires au principe de la **négociabilité des actions**. Il est vrai que l'on peut considérer avec une autre partie de la doctrine que ce qui compte, c'est davantage l'usage qui est fait de cette clause que la clause elle-même[4].

Serait au contraire licite la clause prévoyant les motifs pour lesquels l'agrément pourrait être refusé avec la conséquence que cette décision de refus pourrait être soumise à un contrôle juridictionnel en cas de contestation du motif invoqué[5].

« *La validité de la clause de type discrétionnaire n'est pas contestée par la Cour. Malgré cette clause discrétionnaire, le conseil d'administration procéda à la motivation*

1 – L. Maeyens et P. Roose, « Syndicats d'actionnaires de société anonyme », *R.P.S.*, 1964, p. 58.

2 – P. Van Ommeslaghe, « Les conventions d'actionnaires en droit belge », *R.P.S.*, 1989, p. 295.

3 – CA Bruxelles du 15 mars 1991, *R.P.S.*, 1992, p. 227, note I. Corbisier.

4 – E. Escarra et J. Rault, *Traité théorique et pratique de droit commercial*, T. III, n° 1227 : ces auteurs considèrent que la clause est nulle si l'usage qui en est fait par l'organe compétent à statuer sur l'agrément a pour conséquence de rendre les actions incessibles.

5 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 346.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de sa décision de refus. En doctrine, il a été avancé non sans raison, qu'il paraît que le juge serait dénué de tout pouvoir de contrôle sur les motifs de la décision d'admission[1].

De telles clauses d'agrément doivent être prises dans l'intérêt social des actionnaires qui ne se limite pas aux seuls actionnaires existants mais inclut celui des actionnaires futurs »[2].

Les conditions de cessibilité entre actionnaires et tiers sont souvent différentes. Dans une affaire soumise à la Cour d'appel de Bruxelles[3], la cour admit la validité d'une clause d'agrément discrétionnaire d'un pacte syndicataire portant sur toute cession à des tiers, alors que les cessions entre actionnaires étaient libres. Il est loin d'être certain que la possibilité de céder les actions entre actionnaires soit suffisante pour permettre aux actionnaires de garantir la négociabilité effective de leurs actions. « *En conclusion, si des clauses d'agrément discrétionnaires sont insérées dans une convention syndicataire, il faut que la convention comporte une issue permettant la négociabilité des actions si l'agrément est refusé et si le cédant désire effectivement vendre ses titres. À peine de quoi, ces clauses doivent être considérées comme sans valeur* »[4]. Par pacte syndicataire, on entend une convention ayant pour objet de subordonner le vote individuel à une décision préalable prise par un groupe auquel certains actionnaires se sont liés.

2) Les clauses de préemption

Ces clauses consistent à ce qu'une personne qui envisagerait de vendre ses titres s'engage à en faire l'**offre à des personnes nommément désignées** (en fait les autres actionnaires). En concluant une telle convention, on procède en réalité à une désignation anticipée de la personne de l'acheteur. En cas de violation d'une telle clause, la sanction est en principe l'allocation de dommages et intérêts, étant donné qu'il s'agit de la violation d'une obligation de faire.

Si la **validité de principe** de ces clauses n'est en réalité pas contestée (entretemps, elle est expressément confirmée par la Loi de Modernisation), il est recommandable de prendre quelques précautions. La clause doit prévoir la fixation du prix auquel la vente doit être faite, à défaut de quoi elle sera considérée comme nulle faute d'objet déterminé ou déterminable, conformément à l'article 1129 C.c.

Les clauses de préemption impliquent que, si le droit de préemption n'est pas exercé par les bénéficiaires de cette clause, alors l'actionnaire désireux de céder ses titres peut les céder au cessionnaire de son choix[5].

3) Les clauses de sortie

En premier lieu, l'objet d'une telle clause de sortie peut être d'assurer la **sortie forcée** de l'actionnaire. Le moyen en est une promesse de vente unilatérale par laquelle l'actionnaire s'engage irrévocablement à vendre les actions aux bénéficiaires du pacte : la levée de l'option assure la sortie de l'actionnaire de la société.

1 – CA Bruxelles du 15 mars 1991, *R.P.S.*, 1992, note I. Corbisier, p. 238.

2 – CA Bruxelles du 15 mars 1991, *R.P.S.*, 1992, note I. Corbisier, p. 239.

3 – CA Bruxelles du 21 juin 1952, *R.P.S.*, 1964, p. 75.

4 – P. Van Ommeslaghe, « Les conventions d'actionnaires en droit belge », *R.P.S.*, 1989, p. 297.

5 – P. Van Ommeslaghe, « Les conventions d'actionnaires en droit belge », *R.P.S.*, 1989, p. 300.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La clause de **sortie simultanée** consiste à ce que l'actionnaire désireux de céder ses actions soit obligé de faire acquérir les titres des cocontractants du pacte d'actionnaires. Si le tiers acquéreur refuse, aucune cession ne peut se faire en principe.

On connaît par ailleurs la **clause de sortie prioritaire** qui permet au bénéficiaire de celle-ci de céder ces titres par priorité aux autres : ces derniers, lorsqu'ils se proposent de vendre, devront en informer le bénéficiaire de la clause en lui laissant ainsi la possibilité de céder ses actions avant les autres.

La **clause de non-acquisition** ne rencontre pas d'hésitations par rapport au principe de la libre disponibilité des actions. Elle impose aux signataires de la convention une simple obligation de ne pas faire.

Souvent, les pactes d'actionnaires comportent des clauses relatives à la **cession de contrôle** dans la mesure où le groupe de contrôle s'engage à associer le groupe minoritaire à toute cession de la participation à des tiers. Par ces clauses, le groupe de contrôle s'engage à l'extension aux membres du groupe minoritaire des offres d'acquisition du contrôle émanant de tiers. Dans le cadre de ces clauses, le groupe de contrôle s'engage à ne pas traiter avec les tiers pour le cas où ceux-ci n'accorderaient pas cette extension[1]. La validité de ces clauses n'est pas douteuse.

■ § 2 – Pactes d'actionnaires portant sur la gestion de la société

A – Conventions de vote

Traditionnellement, la doctrine et la jurisprudence tendaient à considérer que les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage juridiquement envers un autre actionnaire à voter dans un certain sens à l'occasion d'assemblées générales futures étaient **illicites ou nulles**.

L'argument invoqué par la doctrine majoritairement hostile à ces conventions de vote était que l'assemblée générale est une assemblée délibérante, et les actionnaires doivent former leur opinion à la lumière des débats à l'assemblée et, en particulier, des réponses données par les administrateurs aux conditions posées. La jurisprudence traditionnelle se ralliait à ces positions doctrinales en déclarant nulles les conventions de vote[2].

Cette opinion fut contredite par la Cour de cassation belge[3]. Celle-ci arrêta que : « *[…] si les stipulations relatives à l'exercice du droit de vote dans les assemblées générales des sociétés commerciales sont illicites et, partant, frappées de nullité, lorsqu'elles sont inspirées par la fraude ou qu'elles sont contraires à l'intérêt social, elles doivent au contraire être tenues pour licites lorsqu'elles ne suppriment pas le droit de l'actionnaire de participer aux décisions sociales, qu'elles sont conformes à l'intérêt de la société et qu'elles sont exemptes de toute idée de fraude* »[4].

En général, la doctrine se montre soucieuse de garantir à l'actionnaire sa pleine indépendance lors de **l'expression** de son **droit** de **vote**. Les conventions faisant

1 – P. Van Ommeslaghe, « Les conventions d'actionnaires en droit belge », *R.P.S.*, 1989, p. 307.

2 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.*, 1991, p. 218.

3 – Cass. b. du 13 avril 1989, *Pas.*, 1989, I, p. 825.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 805.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

entorse à cette libre expression de la volonté de l'actionnaire sont donc appréciées avec une méfiance qui, en particulier, est due aux raisons suivantes :

– elles substituent à la majorité réelle la majorité dans la majorité ;
– elles empêchent que l'opinion des actionnaires se forme au sein même de l'assemblée, en toute liberté, et ceci, conformément au vœu du législateur ;
– elles peuvent empêcher la dépendance dans laquelle doivent se trouver les administrateurs vis-à-vis de la majorité des actionnaires[1].

Par la suite, le législateur belge consacra dans la loi des sociétés (art. 74*ter* des lois coord.) la licéité des pactes de votation.

Est encore prohibée la convention par laquelle un organe de la société s'engage à **voter conformément aux instructions d'un autre organe** de la société, spécialement le conseil d'administration. Un tel engagement est considéré comme illicite pour la raison qu'il constituerait « *une ingérence inadmissible d'un organe dans la sphère de compétence d'un autre organe et porterait ainsi atteinte à l'équilibre des pouvoirs et des compétences voulu par le législateur* »[2].

La sanction des conventions de vote nulles n'est pas nécessairement la nullité du vote exprimé en application d'une telle convention. En effet, un tel vote n'est pas nécessairement contraire à l'intérêt social. Il est par exemple possible que le vote aurait été exactement le même en l'absence de la convention visée. En appliquant toujours la sanction de la nullité, on dépasserait clairement le but qui est d'assurer la réalisation des fins de la règle violée[3].

Quant à la licéité des conventions de vote : « *en l'absence de tout texte législatif relatif aux conventions de vote, leur licéité est à apprécier au cas par cas par la jurisprudence. […] La licéité […] a été reconnue dès lors qu'ils sont limités dans le temps ou quant aux décisions concernées* », que « *de façon plus générale, les conventions de vote paraissent devoir être tenues pour licites dès lors qu'elles ne suppriment pas totalement le droit de l'actionnaire de participer aux décisions sociales, qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt social et qu'elles sont exemptes de toute idée de fraude* », et que « *la doctrine souligne que la jurisprudence en la matière se caractérise par son empirisme, tout est affaire de mesure, de circonstances de fait* ».

La Loi de Modernisation a, pour la première fois, entrepris de se prononcer sur les conventions de vote entre actionnaires pour « *les institutionnaliser et en fixer les cas de nullité* »[4]. Sont nulles celles qui sont **contraires à la L.S.C. ou à l'intérêt social**, celles par laquelle les actionnaires s'engagent à voter conformément aux directives données par la société, par la filiale ou leurs organes et celles par lesquelles les actionnaires s'engagent envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société. Les votes émis en violation de ces conventions sont nuls et entraînent la nullité des décisions prises, à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu (p. ex., une résolution est acceptée avec un vote de 80 % des voix exprimées, y compris des actionnaires représentant 10 % des voix émises ayant agi selon les directives du conseil d'administration ; la résolution aurait donc été acceptée même en l'absence du vote

1 – P. Demeur, note sous Cass. b. du 13 janvier 1938, *R.P.S.*, 1938, p. 84.

2 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.*, 1991, p. 247.

3 – Cass. b. du 13 avril 1989, note J.M. Nelissen Grade, *R.C.J.B.*, 1991, p. 251.

4 – *Doc. parl.*, n° 5730/4, Avis du Conseil d'État, p. 18, ID 13321.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de ces actionnaires). L'action en annulation se **prescrit six mois après le vote**. Ce délai très court est justifié par l'effet rétroactif de la nullité (contrairement à la nullité de la société, qui est dénuée d'effet rétroactif)[1].

B – Conventions de désignation des dirigeants

Souvent, ces conventions consistent à permettre aux actionnaires significatifs de se **répartir les postes d'administrateurs** ou encore de permettre aux actionnaires importants de proposer à tour de rôle un candidat.

Les clauses comportant l'obligation pour les actionnaires d'exercer leur droit de vote de manière à assurer l'élection de telle ou telle personne au poste d'administrateur de la société sont licites en principe, à condition de ne pas être inspirées par la fraude, la contrariété à l'intérêt social ou qu'elles privent les actionnaires de leur droit de participer aux délibérations[2].

■ § 3 – Pactes d'actionnaires dérogeant aux statuts ?

Les clauses des pactes d'actionnaires peuvent-elles aller jusqu'à déroger aux statuts ? Certaines décisions de justice françaises l'ont effectivement admis[3], même si la doctrine dans sa grande majorité semble y être opposée. Cette possibilité doit être écartée.

■ § 4 – Durée des conventions d'actionnaires

Les conventions d'actionnaires, pas plus que n'importe quelle autre convention, ne peuvent selon le droit commun être conclues pour une durée éternelle[4]-[5].

En cas de conclusion sans mention de durée, les conventions entre actionnaires peuvent être résiliées à tout moment par chacune des parties. « *Tel serait le cas en particulier d'accords qui auraient été conclus pour toute la durée de la société à laquelle ils se rapportent alors surtout que les sociétés anonymes peuvent actuellement être constituées pour une durée indéfinie* »[6].

■ § 5 – Sanctions des pactes d'actionnaires

Les pactes d'actionnaires sont *res inter alios acta*, ayant des effets donc uniquement entre leurs signataires. Ces derniers sont donc tenus de les appliquer, faute de quoi ils s'exposent aux sanctions de la responsabilité contractuelle. Par conséquent, ils sont tenus de **réparer le dommage** par eux causés du fait du

1 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 112, ID 10080.

2 – P. Van Ommeslaghe, « Les conventions d'actionnaires en droit belge », *R.P.S.*, 1989, p. 316.

3 – Cass. civ. du 17 mars 1982, *RTD civ*., 1982, pp. 438-440 et Rouen du 27 février 1991, *RTD com*., 1992, p. 401.

4 – P. Van Ommeslaghe, « Les conventions d'actionnaires en droit belge », *R.P.S.*, 1989, p. 319.

5 – L'article 1780 C.c. dispose que l'on ne peut engager ses services qu'à temps. « Cette nullité n'est pourtant acquise que si la durée de l'engagement est telle que celui qui engage ses services se trouve selon toute probabilité lié pour sa vie entière », Cass. civ. du 18 mai 1933, *P*., 13, p. 101, ID 13626.

6 – P. Van Ommeslaghe, « Les conventions d'actionnaires en droit belge », *R.P.S.*, 1989, p. 319.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

non-respect des dispositions du pacte. Établir ce dommage sera en fait difficile, et cette circonstance est susceptible de nuire gravement à l'efficacité de ce genre de conventions. Pour éviter cet obstacle, il est donc à conseiller de prévoir des **clauses pénales** qui établissent le dommage de façon forfaitaire, même s'il est vrai que celles-ci peuvent, le cas échéant, être réduites si elles sont manifestement excessives.

Dans une affaire tranchée par le juge de référé, il s'agissait des actionnaires uniques V et M d'une société anonyme luxembourgeoise, par ailleurs signataires d'un pacte d'actionnaires prévoyant la répartition des postes d'administrateurs entre eux au sein des conseils de la société et d'une filiale de celle-ci. L'opposabilité de ce pacte au conseil d'administration était contestée, moyen rejeté par le juge : « *Il y a […] lieu de noter que les deux actionnaires uniques de la société, à savoir la société V et la société M, ont signé l'accord de convention et partant la clause de votation. Il s'ensuit que la clause litigieuse lie les deux actionnaires de la société et a valeur para-statutaire. Le conseil d'administration de la société est lié par la volonté de ses actionnaires. Il y a dès lors lieu d'écarter le moyen d'inopposabilité du pacte d'actionnaires au conseil d'administration de la société* »[1].

L'action en nullité est ouverte à tout intéressé et donc aussi aux actionnaires non signataires de la convention. En l'espèce, la validité de la convention, indispensable en vue d'assurer l'efficacité d'une décision prononcée par une juridiction étrangère et exempte de toute idée de fraude, fut retenue[2].

SECTION V
LES CONFLITS ENTRE ACTIONNAIRES DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES

Dans une affaire soumise aux juridictions françaises, la question s'était posée de savoir quelle était la sanction adéquate face à une situation de conflit grave entre actionnaires. Dans le cas d'espèce, il s'agissait de la société anonyme **Meubles Gasperini** dont le capital était divisé entre deux groupes familiaux, les Gasperini et les Blan, chaque groupe détenant 1000 actions, étant entendu que le groupe Gasperini était dominant au niveau du conseil d'administration[3].

Un conflit ouvert opposant les deux groupes familiaux conduisit dès 1984 à une situation de blocage complet empêchant la prise de toute décision dans l'assemblée des actionnaires. Le Tribunal de commerce de Troyes procéda à la nomination d'un administrateur provisoire dont le mandat fut renouvelé à plusieurs reprises. La Cour de Reims considéra que, confrontée à une situation de blocage qui ne pouvait durer, elle avait le choix entre la dissolution de la société et l'exclusion du groupe qu'elle considérait être à l'origine de la mésentente.

D'abord, la cour retint le caractère subsidiaire de la solution de la dissolution de la société à laquelle il convient de ne pas procéder lorsqu'il existe d'autres moyens

1 – Référé n° 945/99 du 6 décembre 1999, commenté par Fr. Fayot, *Ann. dr. lux.*, 2001, p. 579, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Commenté par Fr. Fayot *in Ann. dr. lux.*, 2001, p. 552, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Th. Tilquin, « Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé », *R.P.S.*, 1991, p. 2.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

permettant la reprise d'une vie sociale normale. La cour retint ensuite « *[…] qu'il est conforme à la notion institutionnelle de la société de prendre en considération l'intérêt social, de constater que les actionnaires n'ont pas un droit intangible à faire partie de la société et, en conséquence, d'exclure l'actionnaire qui reconnaît que toute entente est désormais impossible et est à l'origine de cette mésentente* »[1].

■ § 1 – La clause de rachat forcé

La clause de rachat forcé est une adaptation du **pacte commissoire** ou une condition résolutoire affectant le contrat de société. La licéité des clauses de rachat forcé se justifie par l'objectif d'assurer la pérennité de la société. Ces clauses sont licites lorsqu'elles n'ont pas pour effet de priver les associés de leurs parts sans indemnité ou de leur dénier le droit de demander la dissolution pour justes motifs[2].

Les juridictions françaises retiennent de façon générale que les tribunaux ont toujours le droit de prononcer, selon les circonstances, soit l'exclusion d'un associé, soit la dissolution de la société[3]. Certaines juridictions déclarent « *préférer l'exclusion à la mort de la société* »[4].

■ § 2 – La dissolution pour justes motifs

La L.S.C., contrairement aux lois coordonnées belges (art. 102), ne prévoit pas de dispositions spécifiques à l'égard des sociétés anonymes qui écarterait l'article 1871 C.c. de sorte qu'au Luxembourg cette disposition reste toujours applicable, et ceci, à l'égard de toutes les formes de sociétés.

Sont donc applicables les trois chefs de dissolution retenus sous l'article 1871 C.c. que sont l'inexécution par un associé de ses engagements, la difficulté de continuer l'exploitation sociale et la mésintelligence entre associés[5].

La matière des conflits entre actionnaires fait partie de celles où la notion d'*affectio societatis* est souvent invoquée par les juges. La condition posée par les juges est que « *la mésentente paralyse le fonctionnement de la société* » ou encore que « *les faits invoqués sont de nature à compromettre définitivement l'avenir de la vie sociale* »[6].

La dissolution de l'article 1871 C.c. a un caractère subsidiaire dans la mesure où cette solution sera écartée lorsqu'il est possible de trouver des solutions moins radicales. Parmi ces solutions permettant d'éviter la dissolution de la société se trouve notamment celle de la nomination d'un administrateur provisoire.

« *Ce caractère subsidiaire est également invoqué en partant de la constatation que le but du législateur a depuis toujours été d'offrir aux associés une porte de sortie,*

1 – Th. Tilquin, « Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé », *R.P.S.*, 1991, p. 3.

2 – Th. Tilquin, « Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé », *R.P.S.*, 1991, p. 13.

3 – CA Caen du 11 avril 1927, *D.*, 1928, II, p. 65, note Lepargneur.

4 – Trib. com. Poitiers du 30 juin 1975, *RTD com.*, 1976, p. 373.

5 – Th. Tilquin, « Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé », *R.P.S.* 1991, p. 15.

6 – Th. Tilquin, « Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé », *R.P.S.*, 1991, p. 16 et les multiples références y indiquées.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dont la plus logique est la cession de ses parts. Certaines décisions en matière d'action en dissolution, qui font songer à la solution adoptée par une abondante jurisprudence relative à l'article 1869 du Code civil ont ainsi exigé que l'associé mécontent prouve d'abord que ses coassociés ont refusé de racheter ses parts »[1]. Ainsi une juridiction française a-t-elle refusé la dissolution au motif que ses associés lui avaient offert de racheter ses parts à un prix fixé par expertise[2].

Toutefois, l'associé qui est à l'origine de la mésentente ne peut demander la dissolution[1].

Le tribunal auquel la demande de dissolution est soumise est appelé à se prononcer sur la rupture ou non de « l'intérêt commun » pour lequel la société a été contractée. À cet égard, on peut encore noter une évolution vers la prise en compte d'un certain **ordre public économique** en application duquel les juridictions refusent de prononcer la dissolution de sociétés prospères[3].

Il existe par ailleurs des cas qu'on pourrait appeler « d'exclusion incidente » telle qu'elle se produit dans les cas du **coup d'accordéon**, technique selon laquelle le capital est réduit (à l'extrême jusqu'à zéro) par réduction de la valeur nominale ou annulation des actions, puis augmenté pour le ramener au-dessus du minimum légal ayant pour effet d'évincer les actionnaires qui ne participent pas à cette augmentation de capital[4]-[5].

Une société qui a subi des pertes (avec la conséquence que son actif net sera inférieur à son capital social nominal) aura beaucoup de difficultés à attirer de nouveaux actionnaires dans la mesure où les titres qui sont émis le seront à la même valeur nominale que les titres anciens. Pour éviter les difficultés que nous avons abordées en un autre endroit (voir à la p. 483), la société devra d'abord procéder à l'assainissement de son bilan, et ceci, par réduction du capital par absorption des pertes comptables. En fonction de l'importance des pertes accumulées, il se peut que l'on doive réduire le capital en dessous du capital social minimum légal, voire à zéro. Cette pratique se heurtait à des obstacles théoriques dans la mesure où la doctrine faisait valoir que la réduction en dessous du minimum légal impliquerait qu'il n'y ait plus d'apports, et donc plus de société. « *La pratique avait toutefois surmonté ces obstacles en faisant décider par les assemblées d'actionnaires que pareilles réductions du capital ne produiraient leurs effets que par la décision subséquente d'augmenter le capital* »[5].

La Deuxième directive a consacré cette pratique reprise dans l'article 450-5 L.S.C.

« *(5) Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l'assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la transformation de la société* ».

L'article 1871 C.c. a connu une véritable mutation quant à son champ d'application. Autrefois, il s'agissait d'une disposition trouvant un lointain écho dans l'article 1184 C.c. dont l'application était limitée aux seuls cas d'inexécution fautive des

1 – Th. Tilquin, « Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé », *R.P.S.*, 1991, p. 18.

2 – CA Paris du 13 avril 1964, *J.C.P.*, 1965, II, p. 14133.

3 – Th. Tilquin, « Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé », *R.P.S.*, 1991, p. 21.

4 – Th. Tilquin, « Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé », *R.P.S.*, 1991, p. 4.

5 – A. Vandeplas et J.P. Spreutels, *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*, p. 113.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

engagements d'un associé[1]. À ce titre, la disposition avait pour objectif d'éviter qu'un associé ne soit en toutes circonstances enchaîné jusqu'au terme de la société. On peut considérer qu'il s'agit d'une application de la théorie de la cause et du principe d'exécution de bonne foi des conventions.

Cette approche traditionnelle a connu une importante mutation dans la mesure où la jurisprudence française y voit « *un droit à l'euthanasie des sociétés pour des raisons d'ordre public économique* »[2]. Pour la doctrine : « *Au départ, l'art. 1871 envisage la seule protection des intérêts individuels de l'associé. Ce dernier peut demander la dissolution des intérêts individuels de l'associé. Ce dernier peut demander la dissolution de la société s'il y a de justes motifs dont le juge apprécie la gravité et la légitimité. Ces justes motifs trouvent leurs racines dans le contrat de société. Il s'agira d'un manquement par un associé à ses obligations lorsque l'apport promis n'a pas été effectué, l'apport en industrie n'a pas été presté, l'associé s'est révélé ne pas avoir la compétence escomptée, l'obligation de non-concurrence n'a pas été respectée […] ; d'une inexécution fautive : c'est surtout dans le chef du gérant que l'on reprochera une gestion défectueuse ou contraire à l'objet social, des négligences graves, son incurie, le refus de reddition des comptes […]* »[3].

La jurisprudence devait lui donner un caractère d'**ordre public économique.** Les sociétés ne peuvent plus être dissoutes pour des motifs purement juridiques, même s'ils sont considérés comme des règles d'ordre public sauvegardant la liberté individuelle[4].

Le juge est ainsi amené à apprécier des données économiques. « *Au critère subjectif difficilement appréciable se substitue un critère objectif : "la gravité de la situation de l'exploitation sociale" qui, en elle-même, devient cause de dissolution, et non plus un simple qualificatif de la notion de justes motifs. De même, la légitimité ne sera plus envisagée sous l'angle de la bonne foi, la gravité de la situation sociale va en elle-même constituer la preuve de la légitimité de la demande en dissolution* »[5].

Au moment où l'on a aboli la limitation de durée des sociétés qui était autrefois de 30 années (par la loi du 7 septembre 1987), l'article 480-1 L.S.C. nouvelle version a eu pour effets, d'une part, d'écarter l'application de l'article 1871 C.c. et, d'autre part, de rendre applicable la cause de dissolution des « justes motifs » aux sociétés à durée indéterminée.

Dans le droit antérieur, on procédait à des prorogations successives de la société, ce qui en fait ôtait toute portée pratique à cette limitation dans le cas général, sauf que, parfois, l'arrivée du terme ayant échappé aux personnes concernées, il y avait une dissolution non intentionnelle de la société par l'arrivée de l'échéance (de 30 ans, p. ex.). Avec la modification de la loi de 1987, la situation est donc que le principe

1 – A. Benoit-Moury, « Des justes motifs de dissolution des sociétés commerciales de l'article 1871 du Code civil [ID 11337] à l'article 102 des L.C.S.C [ID 7520] », *Liber amicorum Jan Ronse*, Bruxelles, Story Scientia, p. 152.

2 – E. Schaeffer, « Des causes d'ordre public de dissolution de sociétés », *Mélanges J. Hamel*, Paris, 1961, p. 230.

3 – B. Bouloc, *Encyclopédie Dalloz, Répertoire des Sociétés*, V° Dissolution, pp. 191 ss.

4 – E. Schaeffer, « Des causes d'ordre public de dissolution de sociétés », *Mélanges J. Hamel*, Paris, 1961, p. 240.

5 – E. Schaeffer, « Des causes d'ordre public de dissolution de sociétés », *Mélanges J. Hamel*, Paris, 1961, p. 246.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

est que la société est à durée illimitée : telle est la solution retenue pour le cas où les statuts sont muets.

Il se pose par conséquent la question de savoir si la notion de justes motifs est la même que celle de l'article 1871 C.c. Le législateur a-t-il simplement entendu étendre la notion de l'article 1871 C.c. aux sociétés anonymes ? Contre cette interprétation, on peut invoquer que le texte de loi ne contient aucune référence à ce texte et que l'on n'y « *trouve pas non plus les critères de gravité ou de légitimité, fondés […] sur le principe de l'exécution de bonne foi des contrats* »[1].

On peut ainsi considérer que les justes motifs peuvent résulter de circonstances diverses indépendantes des relations conventionnelles entre associés.

SECTION VI
MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LES DOCUMENTS DE LA SOCIÉTÉ

Sur base des directives européennes, toutes les **sociétés de capitaux** sont soumises à un certain nombre de règles fort précises qui doivent être respectées par celles-ci dans leurs relations avec le monde externe à la société. Ainsi la loi (art. 462-1 L.S.C) prévoit obligatoirement que les écrits (et plus précisément « *tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents* ») émanant de la Société anonyme doivent contenir les mentions suivantes :

« *1° la dénomination sociale ;*
2° la mention "société anonyme" ou, le cas échéant, "société par actions simplifiée" en toutes lettres ou le sigle "SA" ou, le cas échéant, le sigle "SAS" ou le sigle "SE", reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;
3° l'indication précise du siège social ;
4° les mots "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" ou les initiales "R.C.S. Luxembourg" suivis du numéro d'immatriculation ».

Ces indications ont donc pour objet non seulement d'attirer l'attention du tiers sur la forme de la société anonyme (et surtout sur la responsabilité limitée de ses associés), mais encore de permettre l'accès facile au R.C.S., offrant la possibilité aux tiers de pouvoir facilement se rendre compte du mode de représentation de la société, de son objet, en un mot de la manière dont la société est engagée et de l'étendue de ces engagements.

Quelles sont les sanctions du non-respect de ces dispositions ?

■ § 1 – Sanctions de ces dispositions

Celles-ci sont extrêmement lourdes et elles sont indiquées par l'article 462-1 L.S.C. qui déclare que tout agent d'une société anonyme qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la prescription de l'article précédent ne sera pas remplie, peut […] être déclaré **personnellement responsable** des engagements qui y sont pris par la société.

1 – A. Benoit-Moury, « Des justes motifs de dissolution des sociétés commerciales de l'article 1871 du Code civil [ID 11337] à l'article 102 des L.C.S.C [ID 7520] », *Liber amicorum Jan Ronse*, Bruxelles, Story Scientia, p. 161.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La loi (dans son article 462-1 L.S.C.) prévoit une sanction purement civile dont la sévérité dépend de la nature de l'infraction commise.

En cas de représentation de la société par une personne dans un acte qui ne comporte pas la mention « *société anonyme* », le tiers peut agir directement contre cette personne ayant conclu l'acte. Selon les circonstances, cette faculté est « *[…] subordonnée à la fois à la gravité de la faute commise, à l'étendue du préjudice souffert et au rapport de causalité à effet existant entre l'infraction et le dommage, le tiers demandeur ayant au surplus, conformément aux principes généraux du droit, à prouver ces fondements de sa réclamation* »[1]. Lorsque le reproche fait à la société est de ne pas avoir mentionné le montant correct du capital social alors la sanction sera également proportionnée au préjudice ainsi causé, le représentant de la société est condamné à indemniser le tiers cocontractant à concurrence de la différence existant entre ce que le tiers a reçu réellement et ce qu'il aurait obtenu si le capital énoncé avait été le capital réellement existant[2]. Pour obtenir une indemnisation, le tiers doit encore établir qu'il a subi un préjudice ainsi que le lien de cause à effet entre l'infraction visée par l'article 462-1 L.S.C. et son préjudice[3].

« *En cas d'exagération du capital, de défaut de mention de la partie non encore versée ou souscrite, ou d'inexactitude de cette mention, le tiers aura le droit de réclamer de cet agent, à défaut de la société, une somme suffisante pour qu'il soit dans la même situation que si le capital énoncé avait été le capital réel et avait été versé ou souscrit intégralement ou dans la proportion mentionnée* ».

Dans un cas soumis aux juridictions, un contrat sous seing privé avait été conclu par la société étant entendu que les pièces soumises à la juridiction contenaient uniquement la dénomination sociale ainsi que l'adresse de la société, les autres indications requises faisant défaut, le tribunal jugea que le gérant de la société qui avait signé le contrat en question, devait être déclaré personnellement responsable des engagements pris par la société aux termes de ce contrat[4].

■ § 2 – Indication du montant du capital social

Parmi ces indications obligatoires ne figure pas le montant du capital social, contrairement à ce qui est la règle dans d'autres pays, en France notamment. Rien n'empêche une société d'indiquer le montant de ce capital social. Mais si elle opte pour cette solution, quel doit être le montant indiqué ? Le capital social nominal figurant aux statuts ou le capital social réel ? Évidemment, cette question n'est pertinente que si le capital social retenu par les statuts de la société a été entamé par des pertes, de sorte que le capital social réel est inférieur, le cas échéant négatif. Si, dans une telle situation, les documents émanant de la société continuent à mentionner le capital social nominal, cette indication du capital social, au lieu d'informer les tiers, ne fait que les induire en erreur. « *Si la société, dans ses documents, énonce un capital, il importe qu'elle indique le capital qu'elle possède réellement, qui constitue*

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 183, ID 11308.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 184, ID 11308.

3 – J. Guillery, *Commentaires législatifs*, T. II, n°s 805 et 806.

4 – TA civ. du 20 février 2002, n°s 65.986, *BIJ*, 2004, n° 8, p. 155. – Ce jugement a été rendu à l'égard d'une S. à r.l. à l'encontre de laquelle l'article 77 [ancien] L.S.C., ID 7520, est également applicable (art. 187 [ancien] L.S.C.).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

le véritable et le seul gage de ses créanciers. C'est donc avec raison que la loi belge statue que le capital mentionné devra être celui qui résulte du dernier bilan »[1]. Il va de soi qu'en cas de situation financière favorable, la société peut mentionner les réserves libres figurant à son bilan[2].

Dans le même ordre d'idées se pose la question de savoir si la société peut indiquer le capital social nominal des statuts si ce **capital n'est que partiellement libéré**. À notre sens, la réponse est que cette circonstance ne devrait pas faire obstacle à l'indication du capital social. En effet, la société peut à tout moment demander la libération du solde de capital non encore libéré. Une restriction serait à apporter à cette conclusion dans le cas où la solvabilité des associés est tellement peu garantie qu'il existe de sérieux doutes sur la réalité des créances potentielles sur les associés. Dans ces cas de figure, il vaudrait mieux pour la société ne pas indiquer de capital social sur les pièces émanant d'elle plutôt que de se faire reprocher par la suite d'avoir indiqué un capital excessif.

■ § 3 – Indication de la qualité du signataire d'un acte de la société

Afin de se protéger contre une mise en cause éventuelle de sa responsabilité civile personnelle, la L.S.C. oblige le dirigeant social à spécifier qu'il n'agit pas en sa qualité personnelle, mais en tant qu'organe de la société, donc pour le compte de la société.

Art. 462-3 [anc. art. 78] L.S.C. :
« *Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des administrateurs, membres du directoire et du comité de direction, du directeur général, et selon le cas, directeurs, gérants et autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent* ».

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 107, ID 11305.
2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 183, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS

La société en commandite par actions est celle que contractent un ou plusieurs **actionnaires indéfiniment** et **solidairement responsables** des engagements sociaux avec des actionnaires qui n'engagent qu'une mise déterminée.

La société en commandite par actions est d'abord une commandite, c.-à-d. une société alliant la responsabilité illimitée à la responsabilité limitée, mais une commandite dont le capital social se trouve divisé en actions[1].

Tout comme pour la société en commandite simple, la société en commandite par actions trouve son origine historique dans le **commerce maritime**. « *Au lieu de créer une société en participation (société interne), des investisseurs passifs, à qui parfois le commerce était interdit (gens de robe, membres de la noblesse…) confiaient leurs fonds à un associé actif, qui n'agissait plus en nom personnel comme dans la société en participation mais dans le cadre d'une société dont la raison sociale comportait son nom suivi des mots "et compagnie"* »[2].

Comme en Belgique, la S.e.c.a. au Luxembourg ne fait pas partie des formes de sociétés les plus utilisées en pratique. En 1989 en Belgique, on comptait six sociétés de ce type. Elle connut un certain renouveau par la suite, et ceci, notamment pour des raisons fiscales. Cette forme de société permettait en effet aux associés commanditaires de procéder à des **dons manuels** des titres de commanditaires en exonération de droits de donation (droits de succession)[3].

Toujours en Belgique, M. Ronse, dans son commentaire de la loi de 1973, considérait qu'il n'était plus utile d'examiner les caractéristiques de cette forme de société dont d'autres considéraient qu'elle « *s'éteint lentement, et dans l'indifférence générale* »[4].

Les **deux catégories d'associés** de la S.e.c.a. sont donc actionnaires et, en cette qualité, ils ont droit à des dividendes et bénéficient de la possibilité de céder leurs titres. Par le passé, la question s'est posée de savoir si la société est « par actions » à l'égard de tous les associés. À cette question, la doctrine a répondu comme suit : dans la S.C.A. tous les associés, y compris les commandités, reçoivent des actions en contrepartie de leurs apports. La loi luxembourgeoise a procédé à la clarification requise par rapport à la loi belge de 1873. Les associés commandités restent toutefois personnellement tenus sans limitation de leurs engagements sociaux, même après avoir cédé leurs titres de sociétés à des tiers[5].

Du point de vue **fiscal**, la situation des associés commanditaires résidents ne soulève pas de problème dans la mesure où ils touchent des dividendes et que ces dividendes sont donc imposables à l'instar des dividendes de S.à r.l. ou encore de S.A. Par conséquent, il y a soit application du privilège des sociétés mères et filiales, soit exonération de la moitié des dividendes (si la société en commandite est pleinement imposable).

---

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 212, ID 11308.

2 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 757.

3 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 759.

4 – A. Viandier, J. Hilaire, H. Merle et H. Serbat, *La société en commandite entre son passé et son avenir*, Paris, Librairies Techniques, 1983, p. 1.

5 – J. van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 516.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La situation des commandités est un peu plus complexe dans la mesure où les rémunérations versées aux commandités par la société, en raison de loyers, d'avoirs en compte ou d'une activité au service de la société sont déductibles dans le chef de la société en commandite par actions (art. 167, 1, 2, L.I.R.). Ces rémunérations sont imposables dans le chef du commandité mais non pas dans les catégories respectives de loyers, d'intérêts ou de salaires, mais dans la catégorie du bénéfice commercial (art. 14, n° 3, L.I.R.)[1]. Telle est la solution de l'article 14 L.I.R. qui retient que les versements en question font partie du bénéfice commercial de l'associé en question.

Le titre VI de la L.S.C. (*Des sociétés en commandite par actions*) comporte un **nombre très limité de dispositions** consacrées à la société en commandite par actions (art. 600-1 à 600-10 L.S.C.). L'explication essentielle de cet état de choses est qu'en principe la L.S.C. renvoie à la réglementation de la société anonyme pour le fonctionnement, etc. de cette forme de sociétés[2]. Il suffit donc que le législateur réglemente les quelques points sur lesquels il est prévu de diverger par rapport aux solutions retenues à l'égard des sociétés anonymes, fût-ce par choix politique ou par la nature des choses. Certaines des solutions divergentes peuvent se justifier par le simple fait que la structure de la S.C.A. est plus complexe que celle des sociétés anonymes classiques, et ceci, en distinguant deux catégories d'associés, à savoir ceux qui ont une responsabilité limitée de ceux qui ont responsabilité illimitée.

Quant à la **dénomination**, la Loi AIFM a fondamentalement amendé la matière en supprimant l'ancien article 104 L.S.C. : « *La société existe sous une raison sociale qui ne comprendra que le nom d'un ou de plusieurs associés responsables. Il peut y être ajouté une dénomination particulière ou la désignation de l'objet de son entreprise* ». Ainsi, la partie L.S.C. consacrée à la S.e.c.a. ne comportant plus de disposition spécifique sur la désignation de cette forme de société, les dispositions correspondantes des sociétés anonymes[3] sont entièrement applicables à leur égard. Donc, la S.e.c.a. est désignée par une dénomination sociale comme les sociétés anonymes.

SECTION I
LES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

Dans les grandes lignes, on retrouve les mêmes organes que pour les autres sociétés commerciales.

■ § 1 – Les associés

L'essence de ce genre de sociétés est qu'il y a association d'associés **commandités** et d'associés **commanditaires**. À l'égard des commandités, la S.e.c.a. est assimilée à une société de personnes. Les commandités répondent solidairement du passif social et sont en leur qualité de commandités titulaires de parts d'intérêts qui sont en principe incessibles[4].

1 – G. Heintz, « L'impôt sur le revenu des collectivités », *Études fiscales*, 1999, p. 80.

2 – Art. 600-2 L.S.C., ID 7520.

3 – Applicables aux S.e.c.a. au vœu de l'article 600-2 L.S.C.

4 – Th. Tilquin, « Le renouveau de la société en commandite par actions », *Rev. banque*, 1991, p. 89.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Tant les commandités que les commanditaires peuvent être des **personnes morales**. Cette possibilité est souvent utilisée par les commandités qui, en constituant une société de capitaux unipersonnelle, réussissent en fait à limiter leur responsabilité de commandités qui, en principe, est illimitée.

Les commandités peuvent se limiter à faire un apport **en industrie** en apportant donc exclusivement leur travail[1] (tel sera en tout état de cause l'essentiel de son apport lorsque la gestion de la société leur est confiée, ce qui n'est plus obligatoire depuis la Loi AIFM). Dans ce cas, ils reçoivent des **parts d'intérêts**.

Il importe de noter que tant les commandités que les commanditaires sont **actionnaires**[2] avec la seule particularité que cette qualité n'implique pas la responsabilité illimitée pour les associés commanditaires. Selon l'article 600-1 L.S.C., il suffit d'un associé commandité, indéfiniment et solidairement responsable, avec un associé commanditaire, qui n'engage qu'une mise déterminée.

C'est essentiellement la situation des commanditaires qui distingue la société en commandite simple de la société en commandite par actions : dans la S.e.c.s. les parts des commanditaires sont des parts d'intérêts qui sont cessibles uniquement avec l'accord de tous les associés (sauf disposition contraire des statuts). Dans la S.e.c.a., les commanditaires sont détenteurs d'actions librement négociables[3].

■ § 2 – L'organe de gestion

L'article 600-5 L.S.C. est le pendant direct des articles 310-4 et 310-5 L.S.C. applicables aux sociétés en commandite simple dans la mesure où ces dispositions, ont pour objet de confier la **gestion** (sans que ce soit obligatoirement le cas) à « *un ou plusieurs gérants, actionnaires commandités ou non* **»**, qui sont désignés conformément aux statuts[4]. S'ils sont commandités, ils endossent non seulement la responsabilité illimitée, mais ils sont encore responsables comme fondateurs de la société. Si les gérants ne sont pas commandités, ils sont responsables conformément à l'article 441-9, soit donc comme les administrateurs de la société anonyme. Dans la société anonyme, les administrateurs sont de simples mandataires qui, en tant que tels, ne contractent aucune obligation personnelle. Avant la Loi AIFM, le gérant de la commandite par actions (ainsi que celui de la commandite simple) était, en même temps que mandataire, **associé** qui était directement et indéfiniment tenu des engagements sociaux. Si la société devenait incapable de faire face à ses obligations, c'est lui qui devrait les exécuter personnellement. « *On peut dire en quelque sorte que la société c'est lui* »[5].

Cette attribution des pouvoirs de gestion était **sans partage** dans la mesure où un actionnaire commanditaire qui, pour le compte de la société, aurait signé le moindre acte, même si c'était en vertu d'une procuration spéciale, eût été responsable de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'article précédent. Cette disposition trouvait son pendant direct dans la disposition de l'ancien article 18 L.S.C. applicable aux sociétés en commandite

1 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 760.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 266, ID 11305.

3 – Th. Tilquin, « Le renouveau de la société en commandite par actions », *Rev. banque*, 1991, p. 89.

4 – Depuis la Loi AIFM, le gérant ne doit plus obligatoirement être commandité.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 218, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

simple. À l'égard de ces dernières, l'exécution d'un acte pour le compte de la société était également interdite.

L'article 600-6 L.S.C. rend applicables aux actionnaires commanditaires s'immisçant dans la gestion les mêmes sanctions que celles édictées par l'article 310-3 L.S.C. à l'égard des commanditaires d'une S.e.c.s. : ne pouvant faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers, ils sont indéfiniment et solidairement responsables à l'égard des tiers des actes auxquels ils auraient participé. Cette responsabilité est même étendue aux engagements auxquels l'associé commanditaire n'aurait pas participé, s'il a **habituellement géré les affaires de la société**.

Contrairement à la situation antérieure (donc avant la Loi AIFM), le commanditaire procédant à des actes de gestion sur la base d'une **procuration** n'encourt pas une responsabilité indéfinie et solidaire, à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.

Quant aux indications que doivent comprendre les « *actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés* », l'article 600-3 L.S.C. contient en substance les mêmes dispositions identiques que celles prévues à l'égard des autres sociétés qui sont à responsabilité limitée, sauf que l'indication « sociétés en commandite par actions » doit être donnée **en toutes lettres**.

Le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg dans l'affaire ***Hellas Telecommunications*** *(Luxembourg) IIe S.C.A.* a été pris en compte dans la procédure d'élaboration de la Loi de Modernisation. Dans son avis complémentaire de 2016[1] (au projet de loi n° 5730), le Conseil d'État rappelle que l'article 107 L.S.C. (devenu par la suite l'article 600-5 L.S.C.) prévoit que « *"[L]a gérance de la société appartient à un ou plusieurs associés, commandités, désignés par les statuts". La question posée est celle de savoir si une personne morale, gérant de la société, doit désigner une personne physique comme* ***représentant permanent****. L'amendement se propose de compléter l'article 107 en consacrant une réponse négative. Les auteurs font état d'un "arrêt du 13 décembre 2013 n° 145725" où le juge aurait, par référence à l'article 51*bis*, imposé l'obligation de nommer un représentant permanent. Le Conseil d'État relève que les auteurs font référence non pas à un arrêt de la Cour de cassation ou de la Cour d'appel, mais à un jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, qui a dit que l'article 51*bis *a vocation à s'appliquer aux sociétés en commandite par actions*[2]*. Le Conseil d'État relève que le législateur ne saurait donner une portée rétroactive à des dispositions nouvelles en relation avec des procédures judiciaires en cours. Une telle façon de procéder serait contraire aux principes du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans la mesure où la recevabilité d'une action en application de la théorie de l'organe s'analyse en fonction de la loi applicable au moment de l'introduction de l'action, un effet rétroactif devrait être écarté dans le cas présent. En ce qui concerne la formulation, le Conseil d'État relève le caractère "tarabiscoté" de la phrase à ajouter qui autorise les sociétés à ne pas poser un acte. Si l'idée est de rendre l'article 51*bis *inapplicable, autant le dire en des termes plus clairs en écrivant " […], elles ne sont pas tenues de désigner une personne physique comme représentant permanent"* ».

1 – *Doc. parl.*, n° 5730/09, ID 24236.

2 – Note de l'auteur : TA Lux. du 23 décembre 2015, n°s 145724 et 145725 du rôle.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

C'est cette formulation proposée par le Conseil d'État qui a finalement été adoptée par la Loi de Modernisation.

■ § 3 – L'organe de surveillance

Malgré la similitude qui existe entre société anonyme et S.e.c.a., des différences importantes existent à cet égard en ce qui concerne les commissaires. D'abord, la S.e.c.a. dispose obligatoirement d'une pluralité de commissaires (trois au moins), selon l'article 600-7 L.S.C., alors que la société anonyme se contente d'un seul. À première vue, une telle disposition peut surprendre : pourquoi faut-il dans une S.e.c.a. trois commissaires, alors qu'un seul suffit dans une société anonyme ? La raison de cette divergence tient au fait que le gérant de la S.e.c.a. reçoit par sa nomination par les statuts un **caractère** spécial **d'irrévocabilité,** et donc d'indépendance. En raison de sa responsabilité illimitée, il exerce une influence prépondérante sur les décisions de l'assemblée générale. Le but du législateur était donc de contrebalancer cette position dominante par un surplus de contrôle et de surveillance[1]. « *Le motif de la différence c'est que les gérants ont une position beaucoup plus indépendante que les administrateurs d'une société anonyme. En effet, nommés par les statuts, ils ne peuvent être révoqués que pour cause légitime, tandis que le mandat des administrateurs d'une société anonyme est essentiellement révocable* »[2].

En outre, ceux-ci ont des pouvoirs non pas seulement de contrôle mais de conseil, voire d'autorisation, à l'égard des associés commandités. Comme leur nom le suggère, il s'agit donc d'un véritable conseil de surveillance. Aux termes de l'article 600-8 L.S.C. : « *Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes qui sortent de leurs pouvoirs* ».

Si la situation des commissaires est largement calquée sur celle des commissaires de la société anonyme (ceci vaut pour la nomination, la durée du mandat, la mission de surveillance et leur responsabilité)[3], elle dénote en même temps des **différences importantes** par rapport à ceux-ci. La différence essentielle par rapport à ce type de société réside dans le fait que les commissaires peuvent donner leur **avis** sur les affaires que les gérants leurs soumettent et **autoriser** les actes que les statuts subordonnent à leur approbation préalable sans que ces interventions puissent être considérées comme une immixtion dans la gestion[4].

■ § 4 – Commissaires et réviseur de la S.e.c.a.

Il est bien vrai que cette justification traditionnelle est mise à mal par des dispositions législatives plus ou moins récentes. En effet, la Loi de 2002 avait prévu que la solution applicable aux sociétés anonymes serait à transposer telle quelle à la S.e.c.a. avec la conséquence qu'une S.e.c.a. qui fait contrôler ses comptes (même si c'était volontairement, donc dans le cas d'une « petite société ») par un réviseur d'entreprises agréé n'avait plus de commissaires. Par la suite, le législateur national

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 223, ID 11308.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 271, ID 11305.

3 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 518.

4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 518.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

est revenu sur ses pas et, à la suite de la loi du 13 juillet 2013, la situation actuelle est la suivante : une S.e.c.a. qui fait ou doit faire contrôler ses comptes annuels peut décider de ne pas instituer un conseil de surveillance (art. 69, 3*bis*, Loi de 2002). Cette loi introduit donc un droit d'option en faveur des S.e.c.a. au prix d'avoir donc en même temps à la fois un REA et un conseil de surveillance.

SECTION II
LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ

La particularité essentielle de cette forme de société réside dans la disposition de l'art. 600-9 L.S.C., ainsi libellée : « *Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts que d'accord avec les gérants* ». Dans la société anonyme comme dans la société en commandite par actions, l'assemblée générale des actionnaires constitue en principe l'organe souverain de la société. Mais ce principe doit subir certains aménagements, et ceci, en raison de la situation spéciale des associés commandités gérants. « *Il fallait éviter que le gérant, personnellement responsable des actes sociaux, ne pût être entraîné malgré lui à la ruine sous l'impulsion d'associés ayant soigneusement limité d'avance le chiffre de leurs pertes. Pour cela il était nécessaire de l'élever au-dessus de la condition d'un mandataire ordinaire, obligé d'accepter et d'exécuter les résolutions de son mandant* »[1].

Dans la société en commandite par actions « *la gérance de la société* [selon l'article 600-5 L.S.C.] *appartient à un ou plusieurs gérants, actionnaires commandités ou non désignés conformément aux statuts* », et il y a en quelque sorte gestion conjointe entre les actionnaires et les gérants : l'accord des gérants est en tout état de cause requis pour les actes faits à l'égard des tiers « *ou qui modifient les statuts* ». Cette disposition institue un véritable **droit de veto** en faveur des gérants qui peuvent toujours s'opposer à des modifications des statuts. Parmi celles-ci figurent celles qui révoquent les associés commandités pour en nommer d'autres. Le résultat est donc que l'associé commandité, même s'il ne possède qu'une faible participation au capital de la société, peut s'opposer à toute décision dont l'objet serait de le faire remplacer en tant qu'actionnaire commandité. Il est donc **inamovible**. La disposition de l'article 600-9 L.S.C. s'explique facilement : l'associé commandité étant le seul à engager sa responsabilité personnelle, et ceci, de façon illimitée, il doit pouvoir s'opposer aux décisions des actionnaires qui eux n'engagent que leur mise.

Cette disposition n'est toutefois **pas d'ordre public** ; les statuts peuvent donc l'écarter. En pratique, il n'est guère fait fruit de cette possibilité dans la mesure où c'est précisément cette possibilité qui souvent constitue la raison principale pour le regain d'intérêt porté à la forme de S.e.c.a. En effet, cette solution permet à un gérant d'être protégé contre une éviction à la tête de la société, et ceci, quelle que soit la composition de l'actionnariat de la société. Il est donc tout à fait indépendant des états d'âme que peuvent avoir les commanditaires ou encore des cessions de leurs actions à des tiers conduisant à des renversements de majorité dans la société.

Dans les sociétés anonymes notamment, une telle protection est en pratique impossible à réaliser dans la mesure où les administrateurs (directeurs) sont toujours révocables *ad nutum*.

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 225, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

En cas **d'incapacité du gérant** d'exercer ses fonctions (décès, incapacité légale, empêchement), la société est en principe **dissoute** (à moins que les statuts n'aient stipulé qu'elle continue). Dans ce cas, il est prévu que « *les commissaires peuvent, s'il n'y est autrement pourvu par les statuts, désigner un administrateur, actionnaire ou non* » (art. 600-10 L.S.C.). Toutefois, il ne pourra faire que les seuls **actes** urgents et **de simple administration**[1]**,** et ceci, jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale. Du fait de cette limitation sévère portée aux pouvoirs du gérant, il est indispensable que la convocation de l'assemblée générale des actionnaires ait lieu dans un délai rapproché.

Dans ce cas, l'administrateur *« dans la quinzaine de sa nomination » convoquera l'assemblée générale suivant le mode déterminé par les statuts. « [Il] n'est responsable que de l'exécution de son mandat. »* (art. 600-10 L.S.C.).

Les interdictions d'exercer les fonctions dirigeantes ne s'opposent pas à ce que des personnes exercent des fonctions purement internes, p. ex. au titre de conseiller, ce qui leur permet de parfaitement influencer les décisions en évitant soigneusement de signer le moindre document pour le compte de la société[2].

1 – Les actes de disposition ne peuvent donc pas être exercés par lui.

2 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 366 ; CA Bruxelles du 22 juin 1977, *J.T.*, 1977, p. 657, *R.P.S.*, 1977, p. 197.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE III
LA « SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE » (SAS)

Le régime de cette variante de la société anonyme, introduit par la Loi de Modernisation, est prévu par le titre V L.S.C. qui reprend les articles 500-1 L.S.C. à 500-9 L.S.C. Le législateur national a ainsi introduit un régime simplifié de la forme ancienne de la S.A., forme de société qui entre-temps est devenue très réglementée (pour ne pas dire excessivement réglementée), notamment sous l'influence des directives européennes[1]. Le pendule s'étant trop écarté dans le sens du « dirigisme », le législateur revient à une conception plus libérale en permettant aux opérateurs économiques d'opter en faveur de la SAS, l'espèce simplifiée du genre de la société anonyme. Tout comme pour la société en commandite spéciale, l'introduction de cette forme de société s'explique par le **contexte concurrentiel** dans lequel le droit des sociétés se meut aujourd'hui et qui incite le législateur national à multiplier les options ouvertes aux promoteurs de sociétés[2].

Le modèle suivi pour l'introduction de la SAS en droit luxembourgeois a été celui de la **SAS française** qui, adoptée dès l'année 1994 (par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994) a connu un succès remarquable. Le législateur luxembourgeois, tout comme son homologue français, a en particulier procédé par « *renvoi sélectif au régime de la société anonyme* »[3]. En outre, il est fait application d'une condition de « compatibilité » prévue par l'article 500-1, 3e alinéa : « *Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent titre, les règles concernant les sociétés anonymes […] sont applicables* ». Cette disposition crée inévitablement une certaine insécurité juridique qui est toutefois amoindrie du fait que certaines dispositions du régime de la S.A. sont formellement exclues de ce renvoi : il s'agit des « *sections 1re et 2 du chapitre IV du titre IV sous réserve de ce qui est dit à l'article 500-6, ainsi que des articles 444-3 à 450-4, 450-8 à 450-10* ».

L'objectif à atteindre au moyen de l'application de cette condition de compatibilité est « *d'exclure les règles relatives à la gestion moniste ou dualiste de la S.A. "simple", la SAS étant soumise à cet égard au régime – simplifié – qui lui est propre* »[4] .

La définition de la société anonyme simplifiée est identique à celle de la société anonyme. Sa particularité résulte de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 500-1, à savoir d'être soumise au statut simplifié du titre V L.S.C.[5].

La L.S.C. précise que la SAS ne peut procéder à une **émission publique d'actions** (art. 500-2 L.S.C.). La question de savoir si l'émission publique d'actions par la SAS devait être autorisée a été débattue en France, et il y a été répondu par la négative, et ceci, pour la raison que la SAS ne contient que peu de règles de protection des associés. En outre, une telle émission publique peut facilement être réalisée en passant de la forme de la SAS à celle de la S.A. classique. Le financement de

1 – Lorsque la SAS a été introduite en France en 1994, c'était déjà le caractère trop contraignant du cadre légal de la société anonyme qui était la principale justification invoquée.

2 – I. Corbisier et A. Prüm, « De nouveaux espaces de liberté dans le droit des sociétés luxembourgeois », *in La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, p. 66.

3 – I. Corbisier et A. Prüm, « De nouveaux espaces de liberté dans le droit des sociétés luxembourgeois », *in La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, p. 66.

4 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 104, ID 10080.

5 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 104, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la SAS peut être assuré par un appel public à l'épargne en procédant à une **émission publique d'obligations** (y compris les obligations convertibles), cette option étant ouverte à toute forme de sociétés à condition d'être dotée de la personnalité juridique[1].

Le deuxième alinéa de l'article 500-6 L.S.C. contient la disposition suivante : « *Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux directeurs de la société par actions simplifiée* ». Cette disposition est indispensable, car l'article 441-9 L.S.C. qui prévoit le régime de responsabilité à l'égard des dirigeants de la S.A. fait partie de la section 1re du chapitre IV du titre IV, section en principe exclue pour les SAS. En outre, les règles sur la **responsabilité des fondateurs** sont également applicables aux SAS, car elles ne sont pas exclues par l'article 500-1 L.S.C.

La **simplification** qui est l'objectif poursuivi par l'introduction de la SAS en droit luxembourgeois se situe **au niveau de la gestion**. Cette gestion est en effet grandement simplifiée en remplaçant le régime de gestion moniste ou dualiste par le « président » qui se voit ainsi attribuer la tâche de représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. En toutes circonstances, le président a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les **actes qui ne relèvent pas de l'objet social,** à moins que le tiers n'ait su que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant entendu que la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes (directeur(s)) peuvent exercer les pouvoirs attribués au président (art. 500-4 L.S.C.). « *Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Le directeur dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président* ». La SAS permet la dissociation entre gestion et détention du capital. Il est prévisible que ces possibilités seront utilisées pour arriver aux mêmes résultats que ceux qui sont atteints par une S.e.c.a. où l'associé commandité peut se voir reconnaître un statut d'irrévocabilité, même si c'est au prix de la responsabilité illimitée, qui peut alors être évitée *de facto* en lui conférant la qualité de société à responsabilité limitée. L'utilisation de la SAS permet d'arriver à ce résultat de façon plus directe (par la rédaction des statuts) et sans avoir à créer de société de capitaux prenant la qualité de commandité pour le gestionnaire de la société en commandite.

En somme, le système de gestion de la société est « à la carte », donc librement fixé par les rédacteurs des statuts de la société : « *Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée* » (art. 500-3 L.S.C.).

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés « dans les formes et conditions qu'ils prévoient » (art. 500-7 L.S.C.). À cet égard, la liberté des rédacteurs des statuts n'est toutefois pas sans limites, l'alinéa 2 de l'article 500-7 L.S.C. précisant « *[que] les attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une autre forme, de nomination de commissaires, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercés collectivement par les*

1 – *Doc. parl.*, nº 5730, p. 105, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

associés ». Ces attributions forment donc le **« noyau dur » des compétences des associés**. Il est remarquable que, si cette liste de l'article 500-7 L.S.C. contient la nomination de commissaires, elle ne comprend ni la nomination du président/directeur(s) ni la révocation de ces trois catégories d'organes. Elle ne vise pas non plus les changements de nationalité. Il serait inapproprié de conclure que ces décisions pourraient échapper à la compétence des associés pour la seule raison que l'énumération de l'article 500-7 L.S.C. n'en fait pas mention.

Pour les opérations relevant de la compétence du président à l'occasion desquelles ce dernier aurait « *un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société* », il en sera fait mention dans le procès-verbal de l'opération. Lorsque cet intérêt opposé concerne un directeur, c'est le président qui en décide tout en mentionnant ce fait dans le procès-verbal de la décision.

Lorsque le président est concerné par le conflit d'intérêt, il en est spécialement rendu compte à la première assemblée générale (avant tout vote sur d'autres résolutions) des opérations dans lesquelles le président aurait eu un intérêt à celui de la société. Ce régime du conflit d'intérêt est très étroitement calqué sur celui de la société anonyme (tel qu'il a été modifié par la Loi de Modernisation).

En application de l'article 500-9 L.S.C. : « *Toute cession d'actions effectuée en violation des clauses statutaires est nulle* ». Ainsi, il est possible de conférer un caractère très fermé à la SAS en introduisant des clauses limitant la cessibilité des actions dans les statuts. Des violations de telles clauses sont sanctionnées par la nullité de la cession.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE IV
LES SICAV ET LES SICAF

Ces deux types de sociétés relèvent du domaine des organismes de placement collectif (**OPC**) luxembourgeois. Ceux-ci peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) ou la **forme statutaire** (**société d'investissement**). Ces deux catégories d'OPC sont juridiquement très différentes l'une par rapport à l'autre.

On entend par FCP[1] : « *[…] toute masse indivise de valeurs mobilières et/ou d'autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe (1), composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée* ».

La gestion de cette masse indivise est donc obligatoirement confiée à une société de gestion[2] qui, en général, adopte la forme de la société anonyme[3]. Ces FCP ne sont pas couverts par les développements suivants limités aux OPC à forme statutaire.

SECTION I
BASES JURIDIQUES

Les organismes de placement collectif luxembourgeois (OPC) sont régis par la loi du 17 décembre 2010 (telle que modifiée par la suite) relative aux OPC, portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et portant modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés[4] (FIS).

Les **OPC à caractère statutaire**, notamment les SICAV, sont des sociétés commerciales dotées de la personnalité morale et ayant leurs propres organes par lesquels elles agissent. Fiscalement, il s'agit de collectivités qui sont, en principe, soumises à l'impôt sur le revenu des collectivités, étant entendu que cet impôt n'est pas dû effectivement du fait que ces organismes bénéficient d'une exonération personnelle des impôts directs[5].

■ § 1 – Sociétés d'investissement

Les OPC luxembourgeois peuvent revêtir la forme statutaire d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) ou une autre forme statutaire.

1 – Art. 5 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ID 15288.

2 – Art. 7 de la loi du 17 décembre 2010, ID 15288.

3 – La société de gestion touche des commissions en contrepartie des services de gestion qu'elle rend à la communauté des investisseurs en gérant leurs avoirs.

4 – ID 9604.

5 – Pour plus de détails, v. J.-P. Winandy, *Les impôts sur le revenu et sur la fortune*, pp. 808 ss.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Par SICAV, on entend les sociétés qui ont adopté la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois (pour un OPCVM, un OPC Partie II ou un FIS), d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme (pour un FIS), dont l'objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société.

Les SICAV sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par la loi du 17 décembre 2010 ou la loi sur les FIS. Le capital social d'une SICAV ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai qui varie selon que la SICAV est soumise à la Loi de 2002 ou à la Loi sur les FIS. Les variations du capital social de la SICAV se font de plein droit et sans les mesures de dépôt au R.C.S. et de publicité au RESA prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés commerciales.

Les SICAV ne sont pas soumises à l'obligation de constituer une **réserve légale**. La loi du 17 décembre 2010 comporte deux parties prévoyant des régimes d'OPC très différents.

■ § 2 – OPCVM coordonnés – OPC partie I

La première partie de la loi du 17 décembre 2010 gouverne les OPC en valeurs mobilières (OPCVM) qui bénéficient du « **passeport européen** ». Par conséquent, les OPCVM peuvent librement distribuer leurs parts/actions dans les autres États membres de l'Union européenne. Tout OPCVM peut faire de la publicité dans l'État membre de distribution, mais il doit respecter les dispositions régissant la publicité dans cet État. Est réputé OPCVM dans le cadre de la loi du 17 décembre 2010 tout organisme dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 41, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010, des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme.

■ § 3 – OPC Partie II

La deuxième partie de la loi du 17 décembre 2010 gouverne les OPC **non coordonnés** (OPC Partie II) dont la politique d'investissement n'entre pas dans le champ d'application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 (p. ex., les investissements immobiliers) et qui, par conséquent, ne bénéficient pas du « passeport européen ».

Les OPC Partie II sont soumis aux formalités d'enregistrement dans la juridiction où ils sont distribués.

■ § 4 – FIS

La loi du 13 février 2007 sur les FIS régit les OPC situés au Luxembourg dont l'objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

les risques d'investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, qui **réservent** leurs **titres** à un ou plusieurs **investisseurs avertis** et dont les documents constitutifs ou d'émission prévoient qu'ils sont soumis aux dispositions de la Loi FIS.

Les FIS ne bénéficient pas du « passeport européen » et ils sont soumis aux formalités d'enregistrement dans la juridiction où ils sont distribués.

Est « **investisseur averti** » au sens de la loi sur les FIS l'investisseur institutionnel, l'investisseur professionnel ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes :

a) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti, et

b) il investit un minimum de 125 000 euros dans le fonds d'investissement spécialisé ou (ii) il bénéficie d'une appréciation, de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d'investissement spécialisé.

Ces conditions ne s'appliquent pas aux dirigeants et aux autres personnes qui interviennent dans la gestion des FIS.

SECTION II
RÉGIME APPLICABLE

S'adressant au public, ces entités sont soumises à des règles relativement contraignantes.

■ § 1 – Restrictions d'investissement et d'endettement

Les OPCVM et les OPC Partie II sont soumis à des restrictions d'investissement et d'endettement de nature légale. Les FIS ne sont soumis qu'à un principe de diversification.

■ § 2 – Compartiments

Les OPC peuvent être constitués avec des **compartiments multiples** correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de l'organisme de placement collectif. Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux **actifs de ce compartiment**, sauf clause contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif.

Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et à ceux des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif.

Autrefois, la pratique de l'institution de plusieurs compartiments dans le sein d'un OPC s'était instaurée, mais sans base légale précise, ce qui pour certains posait la

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

question de savoir si cette pratique était conforme à la notion *d'affectio societatis* devant présider dans toute société.

§ 3 – Promoteur

La création d'un OPCVM ou d'un OPC Partie II est sujette à l'agrément par la CSSF du promoteur de l'organisme de placement collectif.

Le promoteur, qui est à l'origine de la création de l'organisme de placement collectif, doit rassurer la CSSF sur sa réputation, son expertise et son assise financière. La notion de « promoteur » n'a pas de source légale. Elle résulte de la pratique administrative de la CSSF qui considère le promoteur comme responsable ultime vis-à-vis des investisseurs.

L'exigence de promoteur n'est pas applicable à la création d'un FIS.

§ 4 – Gestion

La gestion d'une société d'investissement peut être assurée par une société de gestion de droit luxembourgeois répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 13 ou 14, de la loi du 17 décembre 2010 et soumise à l'agrément de la CSSF. La société de gestion doit avoir un capital social supérieur ou égal au minimum légal. Le **capital** minimum est de **125 000 euros** pour la société de gestion d'un OPC Partie II ou d'un FIS. Le montant du capital minimum de la société de gestion d'un OPCVM est déterminé sur la base des capitaux qu'il a sous son contrôle. La société de gestion est soumise à des contraintes et obligations juridiques plus ou moins strictes selon le type d'organisme de placement collectif qu'elle gère.

Les sociétés de gestion peuvent déléguer tout ou partie de leurs fonctions à des tiers agréés par la CSSF. La délégation ne doit pas empêcher l'efficacité de la surveillance effectuée sur les sociétés de gestion. Des fonctions de gestion de portefeuille peuvent uniquement être déléguées aux entités qui sont autorisées ou enregistrées pour la gestion de patrimoine et qui sont sujettes au contrôle étroit d'une autorité de surveillance coopérant avec la CSSF.

La société de gestion gère la société en conformité avec le règlement de gestion et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts.

Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu'elle agit pour le compte de la société.

Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se compose le portefeuille de la société.

La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié ; elle répond, à l'égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

La société de gestion doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs.

SECTION III
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Dans un souci de **protection** des **investisseurs**, la loi prévoit des dispositions de la garde des avoirs de l'OPC.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

■ § 1 – Garde des actifs

La garde des actifs d'un organisme de placement collectif luxembourgeois doit être confiée à un **dépositaire** agréé par la CSSF.

Le dépositaire doit soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi s'il a son siège statutaire dans un autre État membre de l'Union européenne. Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier[1].

Le dépositaire peut confier à des tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par cette délégation.

L'étendue des obligations du dépositaire varie selon le type d'organisme de placement collectif dont il a la garde des actifs. Par exemple, s'il a la garde des actifs d'un fonds, le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l'administration courante des actifs du fonds commun de placement.

■ § 2 – Administration centrale

L'administration centrale de tout organisme de placement collectif luxembourgeois doit être située au Luxembourg.

La condition selon laquelle l'administration centrale doit être située au Luxembourg implique, entre autres, que les **documents comptables** de l'organisme de placement collectif soient disponibles au Luxembourg, que le registre des investisseurs de l'organisme de placement collectif soit gardé au Luxembourg, que les documents destinés aux investisseurs soient établis en coopération avec l'administration centrale au Luxembourg et que le calcul de la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif luxembourgeois soit effectuée au Luxembourg.

Il résulte de l'énumération précédente que l'exigence d'une administration centrale au Luxembourg implique exclusivement la **comptabilité** et les **fonctions administratives**. Cela n'exclut par conséquent pas la possibilité pour les OPC luxembourgeois de se faire assister par des prestataires établis à l'étranger pour toutes les autres prestations.

■ § 3 – *Reporting* et révision

Les OPC luxembourgeois doivent établir et mettre à disposition des investisseurs les documents de constitution, les documents d'émission et les rapports financiers selon les modalités et les délais légaux.

Les OPC luxembourgeois doivent faire contrôler, par un réviseur d'entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel.

■ § 4 – Liquidation

La société se trouve en état de liquidation :

a) si l'actif net du fonds commun placement est devenu inférieur au minimum légal pendant le délai légal ;

b) dans tous les autres cas prévus par les documents constitutifs.

1 – ID 1086.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 5 – Fiscalité

Après l'abolition en 2009 du droit d'apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales, la taxe d'abonnement est le seul impôt non dû par les OPC.

A – Taxe d'abonnement

Le taux de la taxe d'abonnement annuelle due par les OPC est de minimum 0,01 %

et de maximum 0,05 % des actifs nets. Le taux varie selon le type d'OPC concerné.

Des exemptions sont admises. Ainsi, est exonérée de la taxe d'abonnement la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d'autres OPC, pour autant que ces parts aient déjà été soumises à la taxe d'abonnement.

B – Fiscalité des revenus de l'épargne

Sans préjudice des dispositions de la loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, les distributions effectuées par les OPC se font sans retenue à la source. Elles ne sont pas imposables (au Luxembourg) dans le chef des contribuables non-résidents.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE V
LA TITRISATION

La loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation[1] fait partie des nombreuses innovations législatives induites par la place financière.

SECTION I
NOTION DE TITRISATION

La titrisation est l'opération qui consiste à transformer les créances (ou des actifs non liquides) en titres incorporant les droits qu'ils constatent. Envisagée du point de vue de l'entité juridique indépendante qui reçoit l'actif cédé, il s'agit d'une copropriété de créances (actifs) gérées par une société commerciale, appelée société de gestion et contrôlée par un dépositaire[2]. Les titulaires des parts émises par le fonds ne sont en rien impliqués dans la gestion du fonds et ne sont tenus des dettes qu'à concurrence de la quote-part de leur actif[3]. Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion du fonds. Bien que déposées auprès du dépositaire, les créances cédées sont recouvrées par le cédant qui agit pour le compte de la société de gestion avec laquelle une convention est conclue.

Celui qui est à l'origine de l'opération de titrisation est le cédant (« *originator* ») qui détient les actifs faisant l'objet de l'opération de titrisation[4]. En cas d'utilisation d'une structure fiduciaire, les actifs titrisés ne rentrent pas dans le bilan du fiduciaire. Dans le chef de ce dernier, les actifs constituent une **masse distincte** figurant au hors-bilan.

La titrisation consiste à transformer les actifs en titres en nécessitant ainsi l'isolement des actifs titrisés dans un **patrimoine séparé**, détaché des autres risques de l'ancien détenteur des actifs. La loi du 22 mars 2004 est calquée sur le modèle de la loi sur les OPC en permettant donc tant la création de sociétés de titrisation que de fonds de titrisation, (sur une base purement contractuelle dans ce deuxième cas). Par ailleurs, la division en plusieurs compartiments est possible.

Toute opération de titrisation repose sur le fait que les actifs titrisés doivent sortir de l'actif du bilan du cédant et entrer dans le bilan du véhicule de titrisation en contrepartie du paiement du prix de cession des actifs. Il convient d'établir une **séparation juridique étanche** entre l'actif titrisé et le cédant afin de permettre l'évaluation des actifs titrisés sur la base du bilan de l'organisme de titrisation indépendamment de la valeur du cédant[5]. Ceci nécessite une vente véritable (« *true sale* ») : le bien doit sortir définitivement du patrimoine du cédant dans la mesure où les créanciers de celui-ci n'y ont plus recours, le cédant étant encore empêché de racheter ces mêmes actifs (au moyen d'une option d'achat notamment). Est ainsi exclue toute technique de cession temporaire, telles qu'une vente à réméré ou une opération de portage, etc.[6].

1 – ID 1775.

2 – N. Diab et I. Boustany, *La titrisation des actifs*, Bruxelles, Jdeidet-el-Metn et Paris, Bruylant, Delta et L.G.D.J., 2003, p. 30.

3 – N. Diab et I. Boustany, *La titrisation des actifs*, p. 41.

4 – N. Diab et I. Boustany, *La titrisation des actifs*, p. 128.

5 – N. Diab et I. Boustany, *La titrisation des actifs*, p. 259.

6 – N. Diab et I. Boustany, *La titrisation des actifs*, p. 261.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION II
LA LOI SUR LA TITRISATION

Le législateur luxembourgeois, suivant en cela les initiatives prises par certains autres États européens, a adopté la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation qui réglemente dorénavant le régime juridique et fiscal de l'opération de titrisation. La titrisation est un **(re)financement d'un ensemble de droits** – le plus souvent un portefeuille de créances isolées pour l'occasion dans une structure *ad hoc* – basé sur une estimation des flux financiers prévisionnels de ce portefeuille (voir exposé des motifs du projet de loi).

SECTION III
LA FISCALITÉ DE LA TITRISATION

Le régime fiscal de ces instruments de titrisation est largement fondé sur celui des OPC, tout en dénotant certaines caractéristiques particulières et originales. Contrairement aux OPC, les sociétés de titrisation ne sont pas personnellement exemptées des impôts directs, mais il leur est permis de déduire en tant que **dépenses d'exploitation** « *les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation* » (voir art. 46 L.I.R. amendé par l'ajout d'un numéro 14). La notion « *d'engagements* » est tout sauf claire, en particulier lorsqu'il s'agit des bénéfices de l'organisme de titrisation.

La loi précise également que, dans le chef des investisseurs, « *les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers d'un organisme de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux mobiliers au sens de l'alinéa 1er numéro 5 […]* » de l'article 97 L.I.R. Par cette disposition, les revenus sont **assimilés à des intérêts**, ce qui assure, d'une part, leur imposition dans le chef du bénéficiaire et, d'autre part, l'exonération de la retenue à la source.

Les **fonds de titrisation** sont exonérés non pas seulement de l'impôt sur le revenu, mais encore de la taxe d'abonnement.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE VI
LA SICAR

Avec la loi du 15 juin 2004 sur la « société d'investissement à capital à risque » SICAR, le Luxembourg a mis en application un moyen prometteur destiné à stimuler l'investissement en **capital à risque,** stimulant ainsi – en théorie – le marché de l'emploi en permettant aux États membres de faciliter les sociétés d'investissement en capital à risque à l'intérieur de l'Union européenne. La notion de capital à risque se réfère aux modes de financement désignés par « *venture capital* » et par « *private equity* ».

« *Venture capital* » est synonyme de financement de sociétés nouvelles, souvent dans les secteurs de la haute technologie.

« *Private equity* » est une expression encore moins précise et signifie donc **investissement** dans une **société privée** non cotée. Cette notion inclut également des schémas de « *leveraged buy-out* » (LBO) ainsi que de « *management buy-out and buy-in* ».

Selon l'exposé des motifs du projet de loi cité ci-dessus (n° 5201), les points marquants de ce genre d'investissement sont les suivants :

a) un engagement dans une opération à risque ;

b) l'espoir d'un rendement conséquent ;

c) l'absence de liquidité des titres souscrits ;

d) un terme relativement lointain avant de toucher les premières distributions (remboursements).

De cette description, il résulte clairement qu'il ne s'agit pas d'un investissement de bon père de famille, au contraire. Cette caractéristique comporte des conséquences sur le régime légal prévu par le législateur luxembourgeois et qui contraste fondamentalement avec celui prévu à l'égard des fonds d'investissement.

Le « *Private Equity* » et le « *Venture Capital* » ont en commun le caractère plus risqué de l'investissement, potentiellement compensé par des bénéfices plus conséquents. Ces types d'investissement offrent encore une liquidité limitée quant aux titres souscrits et requièrent dès lors des engagements à long terme. Ces caractéristiques ont incité le législateur luxembourgeois à imposer certaines restrictions aux investisseurs, destinées à assurer la protection des investisseurs inexpérimentés.

Avant cette nouvelle loi, les investisseurs en « *joint venture* » et « *private equity* » ayant opté pour le Luxembourg pour ce genre d'investissements avaient le choix entre deux structures d'investissement. Les investisseurs pouvaient, d'un côté, réaliser leur projet par le biais d'une **société à capital fixe**, imposable selon le droit commun, bénéficiant ainsi d'une structure fiscale et légale plus flexible et attractive, ou bien, d'un autre côté, ils pouvaient engager leurs avoirs financiers dans un fonds spécialisé de « *Venture Capital* », exempté d'impôt, destiné aux investissements collectifs soit sous la forme d'une société d'investissement (avec un capital variable ou fixe – SICAV ou SICAF), soit sous la forme d'un fonds commun de placement (FCP). Bien qu'il manque encore à la première option la flexibilité légale et fiscale généralement requise dans les opérations sur les investissements en capital à risque, la seconde option demeure très largement peu attractive en raison de dispositions rigides quant à la diversification des risques, de restrictions à l'investissement et de l'accès limité aux traités en matière fiscale. Aucune des deux structures n'offre ainsi un cadre entièrement satisfaisant tant au niveau juridique qu'au niveau fiscal.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La législation sur les SICAR cherche à remédier aux déficits visés en combinant les caractéristiques les plus marquantes des deux plates-formes existantes. La loi combine les notions connues de notre droit des sociétés et de la législation sur les OPC pour donner lieu à une structure d'investissement flexible, mettant les dispositions légales et fiscales existantes au service d'une nouvelle structure d'investissement.

La SICAR répond à quatre conditions, dont trois sont de fond et la dernière de forme :

- elle a la forme d'un des 5 types légaux visés ;
- le placement de ses actifs est un capital à risque ;
- les titres sont réservés à des investisseurs avertis du risque qu'ils prennent ; et celle de forme, qui exige que la SICAR,
- prévoie expressément dans ses statuts qu'elle se soumet aux dispositions de la loi (sur les SICAR).

■ § 1 – SICAR, fonds d'investissement et sociétés de participations financières

Le projet de loi correspondant à la loi du 15 juin 2004[(1)] présente une parenté certaine avec un autre instrument ayant un nom fort semblable, à savoir la SICAV. Malgré l'affinité terminologique indéniable, il convient de ne pas perdre de vue que la SICAR représente sans aucun doute possible l'expression la plus large. En effet, si la SICAV est une société anonyme avec la particularité d'avoir un capital variable, la SICAR est une notion plus large pouvant prendre des formes plus variées, notamment celle de la société de personnes. Ainsi le législateur a-t-il ouvert la voie aux sociétés en commandite simple luxembourgeoises, inspirées des « *Limited Partnerships* » de droit anglais, pour qu'elles deviennent un véhicule d'investissement de premier plan pour les investisseurs non-résidents.

En tant que témoin de l'affinité qui existe entre les SICAR, d'une part, et les OPC, d'autre part, on peut encore noter que des passages entiers de la loi sont repris des dispositions existantes de la **réglementation sur les OPC** telles que figurant aux lois successivement applicables, à savoir celles du 30 mars 1988, du 20 décembre 2002 et du 17 décembre 2010. Ceci vaut en particulier pour les dispositions relatives à la surveillance, la publication du prospectus (rapport annuel), la dissolution, la liquidation, etc. Ces dispositions n'ont en fait subi qu'une simple adaptation pour les SICAR. En revanche, la SICAR est un concept moins large que celui d'OPC : comme son nom l'indique, la SICAR est toujours une société et elle ne peut donc pas être organisée sous forme de fonds commun de placement.

Le titre II de la Loi de 2002 sur « la comptabilité et des comptes annuels des entreprises », distingue les sociétés d'investissement (art. 30 [ancien] L.S.C.) des sociétés de participation financière (art. 31 [ancien] L.S.C.).

Par société d'investissement, on entend « *les sociétés dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées et en d'autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs avoirs* ».

Aux termes de la loi sur les SICAR, la SICAR, pour autant que son objet soit concerné, est définie comme suit : l'objet est le placement de ses fonds en valeurs représentatives

1 – *Doc. parl.*, n° 5201, ID 9940.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de capital à risque dans le but de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de ses actifs en contrepartie du risque qu'ils supportent. Par conséquent, et ceci est un point clé du régime introduit, une SICAR ne se voit soumise à aucune disposition quant à la **diversification des risques** et peut ainsi limiter ses investissements à une seule entité. Par ailleurs, la loi n'impose aucune restriction géographique.

On voit donc que la définition de la SICAR retient le deuxième élément de la définition de la société d'investissement (le bénéfice aux associés des résultats de la gestion), mais en laissant de côté le premier (la répartition des risques).

L'objectif des auteurs de la loi sur la SICAR était d'instituer un régime plus libéral que celui prévu par la loi du 30 mars 1988 sur les OPC. Néanmoins, les SICAR sont soumises à la surveillance de la CSSF. Elles sont également tenues de nommer une banque dépositaire et un réviseur d'entreprises.

Le Loi de 2002 donne également une définition de la société de participation : « *Les sociétés de participation financière […] sont des sociétés dont l'objet unique est la prise de participation dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s'immiscent directement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés* » (art. 31 L de 2002). On voit que cette définition est plus proche de celle de la SICAR que celle des sociétés d'investissement.

Les sociétés de capital à risque qui se soumettent aux dispositions de la nouvelle loi sont soumises au contrôle de la CSSF ; les **dirigeants** font l'objet d'un **agrément** par la CSSF, mais le promoteur et le gestionnaire ne font pas l'objet d'un agrément par cet organisme de supervision. En revanche, elles sont tenues de nommer une **banque dépositaire** et un **réviseur** d'entreprises.

Le caractère allégé de ces contraintes de nature réglementaire trouve sa justification dans le fait que ces véhicules s'adressent à des investisseurs qui, *a priori*, sont plus sophistiqués que le grand public ; ils sont désignés par le terme d'**investisseurs avertis** et sont les seuls à pouvoir investir dans un tel organisme. Ceci suppose que cet investisseur déclare par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti et qu'il investisse un minimum de 125 000 euros (art. 2) ou alternativement, si cette limite n'est pas atteinte, qu'il bénéficie d'une appréciation de la part d'un établissement de crédit ou d'un autre professionnel du secteur financier ou d'une société de gestion certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate un placement en capital à risque.

■ § 2 – Caractéristiques juridiques des SICAR

En principe, la SICAR est constituée en tant qu'entité ayant une personnalité juridique distincte de celle de ses associés. À ce titre, il ne s'agit donc pas d'une nouvelle forme ni d'un nouveau type de société. Au contraire, la SICAR peut prendre chacune de ces formes connues de sociétés :

– la société anonyme ;
– la société à responsabilité limitée ;
– la société en commandite par actions ;
– la société en commandite simple ; ou
– la société coopérative sous forme de société anonyme.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Par conséquent, toutes les formes de sociétés commerciales (sauf la société en nom collectif) sont autorisées, donc également des structures **fiscalement transparentes** telles que les sociétés en commandite simple[1].

Cette dernière, à maints égards, fait bande à part dans la mesure où les dispositions qui lui sont applicables sont souvent assez fondamentalement différentes de celles qui s'appliquent aux autres entités qui sont en fait toutes des sociétés de capitaux. Notamment, il est précisé que les dispositions sur les investisseurs avertis ne sont pas applicables aux associés commandités des sociétés en commandite simple. De même, les dispositions sur les **libérations partielles** des titres émis (de 5 % au moins) ne sont pas applicables à ce genre de société. Il en va encore de même des dispositions sur le capital variable des SICAR qui n'ont pas été déclarées applicables à la S.e.c.s au motif qu'elle n'a pas de capital social.

A – Conditions légales

La loi sur la SICAR précise que les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales sont en principe applicables, sauf dérogations expresses spécifiques. Il nous suffira donc de mentionner ci-après les dérogations par rapport à la L.S.C.

1) Conditions relatives au capital

a) Capital minimum

Le régime des SICAR nécessite que les sociétés mentionnées ci-dessus disposent d'un capital social souscrit d'un montant minimum de **1 million** d'euros. Ce montant peut être augmenté par règlement grand-ducal, mais sans pouvoir dépasser 2 millions d'euros. Ce minimum doit être atteint endéans un délai de 12 mois.

b) Souscription et libération des actions

Si le capital doit être intégralement souscrit, il suffit que chaque action ou part soit libérée à concurrence de **5 % au moins** par un versement en numéraire ou par un apport autre qu'en numéraire dès la souscription (à l'exception des sociétés en commandite).

Ces dispositions sont nettement plus favorables que celles applicables aux S.A. et plus encore aux S.à r.l. (pour lesquelles la libération au moment de la souscription doit être intégrale). Ceci facilite grandement l'appel de fonds aux investisseurs.

c) Réserve légale

La législation sur les SICAR diverge encore des dispositions légales relatives aux sociétés ordinaires en supprimant l'obligation de constitution d'une réserve légale. Le but de cette mesure est de permettre la distribution intégrale du résultat de l'exercice. Dans la mesure où une obligation de doter un poste de réserve par prélèvement sur le résultat annuel n'existe plus, cet objectif est atteint.

1 – Pour plus de détails, v. J.-P. Winandy, *Les impôts sur le revenu et sur la fortune*, pp. 493 ss.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2) Possibilité d'avoir un capital variable

La SICAR peut avoir un capital variable, ce qui la rapproche davantage encore de la SICAV visée par la loi sur les OPC. Techniquement, ceci signifie que les statuts, au lieu de prévoir que le capital social s'établit à un montant fixe donné, contiennent une disposition selon laquelle « *le montant du capital est à tout moment égal à la valeur de leur actif net* » (art. 4 (2)).

B – Évaluation à la valeur estimée de réalisation probable

Il s'agit encore d'une dérogation par rapport au droit commun : le titre II de la Loi de 2002 intitulé « *de la comptabilité et des comptes annuels des entreprises* » retient le principe du prix d'acquisition historique combiné avec celui de l'imparité. De cette combinaison de ces deux principes, il résulte que les valeurs sont à évaluer au prix historique, sauf si la valeur réelle tombe en-dessous de cette valeur, ce qui rend nécessaire une correction de valeur vers le bas.

Une augmentation de valeur par rapport au prix historique n'est en revanche pas prise en compte. Cette règle ne vaut pas de façon générale pour les sociétés d'investissement : en effet, celles-ci sont autorisées, par dérogation au principe général, d'évaluer leurs avoirs à leur valeur réelle (art. 31 L de 2002). Ce principe est connu sous le nom de « ***mark to market*** ». Donc, on suit le prix du marché lors de l'évaluation.

Il va de soi qu'un tel principe a une raison d'être certaine pour les investissements en titres cotés en bourse et qui pourraient donc facilement être réalisés sur un marché organisé. Ce principe est légèrement amendé pour les SICAR dans le sens qu'à leur égard on retient la **valeur estimée** de réalisation probable (établie de bonne foi). Malgré ces différences, il est évident que ce principe, tout comme celui du « *mark to market* » signifie en fait l'abandon du principe de l'évaluation historique qui, en droit commun, constitue la règle.

D'un côté, les politiques de versement des dividendes (par exemple, la périodicité) peuvent être librement déterminées par les documents de constitution ou par le prospectus. D'un autre côté, les dispositions relatives aux transferts d'actions ainsi que les règles relatives à la direction de la société suivront en principe les dispositions légales applicables aux sociétés ordinaires et ne donneront pas lieu à des commentaires spécifiques.

C – Dividendes et rachats de titres

Aux termes de l'article 6 de la loi sur la SICAR, les remboursements et dividendes aux investisseurs ne sont pas soumis à d'autres **restrictions** que celles **prévues aux statuts**. Il est encore précisé que les versements d'acomptes sur dividendes ne sont pas soumis aux dispositions légales concernant les distributions, ils sont seulement soumis aux règles prévues par les statuts.

Quelle est la nature des dividendes de sociétés ? S'il est incontesté que la créance de dividende ne naît que le jour de la décision de l'assemblée des associés, il n'en résulte pas que le dividende a été produit ce jour-là et non pas pendant toute la durée de l'exercice. Les dividendes sont la contrepartie de la jouissance par

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la société des apports mis en commun par les associés et représentés par les associés. Il s'agit de **fruits civils** et, en tant que tels, ils sont soumis en matière d'usufruit à l'article 586 C.c.[1].

§ 3 – Conditions de fonctionnement et de liquidation

A – Fonctionnement

La SICAR est tenue de publier un prospectus et un rapport annuel par exercice (art. 23 de la loi sur les SICAR). Le rapport annuel doit être publié dans le délai de 6 mois après la fin de l'exercice auquel il se rapporte. Le rapport doit contenir un bilan (ou un « *état du patrimoine* »), un compte de résultat et un rapport sur les activités de l'exercice écoulé ainsi que toute information significative permettant de porter un jugement sur l'évolution future de la société (art. 24 de la loi sur les SICAR). Une annexe aux comptes annuels n'est donc pas prévue, pas plus qu'un schéma précis pour le rapport annuel.

Le prospectus, préparé à l'adresse des investisseurs, doit contenir les renseignements nécessaires pour permettre aux investisseurs de porter un jugement fondé sur l'investissement leur proposé et les risques y associés (art. 24 de la loi sur les SICAR). Les données contenues dans le rapport annuel doivent faire l'objet d'un contrôle par le réviseur d'entreprises. L'attestation du réviseur et, le cas échéant, ses réserves doivent être reproduits en intégralité dans chaque rapport annuel.

En dehors des données contenues dans ce rapport annuel de l'exercice, la SICAR doit au moins tous les six mois informer les investisseurs qui le demandent de la valeur nette des titres évalués conformément à leur valeur probable de réalisation (art. 30 de la loi sur les SICAR).

Toute invitation à acheter des titres d'une SICAR doit indiquer l'existence d'un prospectus et mentionner les endroits où il peut être obtenu. Aucune société ne peut faire état de l'appellation de SICAR si elle n'a pas obtenu l'agrément de la CSSF au préalable.

B – Dissolution et liquidation

Il y a lieu de distinguer la liquidation judiciaire de la liquidation volontaire.

1) Liquidation d'office

La décision de la CSSF portant retrait de la liste des SICAR autorisées entraîne le sursis à tout paiement et l'interdiction de procéder, à peine de nullité, à tous actes autres que conservatoires. Un commissaire de surveillance est institué à ce moment et il doit donner son accord pour tous les actes et décisions de la SICAR. La fonction de commissaire de surveillance est d'office assumée par la CSSF, à moins que, à sa requête, le tribunal d'arrondissement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance.

1 – Cass. b. du 10 septembre 1963, *Pas.*, 1964, I, p. 42.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

À l'égard des SICAR dont le retrait de la liste de l'article 13 a été définitivement prononcé, le tribunal, sur demande du procureur d'État, agissant d'office ou à la requête de la CSSF, prononce la dissolution et la liquidation des SICAR. La décision de procéder à la liquidation est accompagnée par la nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs qui arrêtent le mode de liquidation. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs de la SICAR et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Après le rapport des commissaires, il est statué sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.

2) Liquidation volontaire

En cas de liquidation non judiciaire de la SICAR, le ou les **liquidateurs** doivent être **agréés** par la CSSF. Ils doivent présenter les garanties d'honorabilité et de qualification professionnelles.

Que la liquidation soit judiciaire ou non, les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de consignation au profit des associés non présents lors de la clôture.

■ § 4 – Acteurs en présence

A – Les investisseurs

Il est important de souligner le fait qu'un investissement dans une SICAR est exclusivement réservé à trois catégories d'investisseurs, respectivement les investisseurs institutionnels, les professionnels et les « *investisseurs avertis* ». Cette dernière catégorie est une création de la législation sur les SICAR. Pour obtenir la qualification d'« *investisseur averti* », l'investisseur doit (i) adhérer au statut d'investisseur averti et (ii) soit investir un montant minimum de 125 000 euros, soit bénéficier d'une recommandation expresse émise par un professionnel du secteur financier qui certifie l'expérience, l'expertise et la connaissance dudit investisseur désireux de s'engager dans des projets d'investissement en capital à risque. Cette disposition est une disposition clé de tout le système prévu : les dispositions relativement strictes prévues à l'égard des OPC qui font appel à un public d'investisseurs souvent peu sophistiqué et peu fortuné (et qui doit donc être protégé par des mesures adéquates) peuvent être considérablement allégées dans la mesure où les SICAR se bornent à vendre leurs titres à un public plus sophistiqué et mieux loti et qui n'a donc pas besoin du même degré de protection.

B – La banque dépositaire

Par ailleurs, la SICAR luxembourgeoise se distingue d'autres sociétés d'investissement en capital à risque (par exemple, la PRICAF en Belgique) par son obligation de confier ses actifs à une banque dépositaire établie au Luxembourg. Par cette mesure, le législateur vise clairement à accentuer le niveau de protection des investisseurs. La banque dépositaire est une institution coutumière des **fonds d'investissements** basés au Luxembourg. Sous la législation sur les SICAR, le rôle du

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dépositaire est toutefois réduit substantiellement. Le dépositaire doit, entre autres choses, s'assurer que les fonds souscrits sont reçus dans les délais prévus par les documents constitutifs, vérifier que la contrepartie est libérée ou payée sur les actifs et il doit, en outre, s'assurer que l'affectation des actifs est réalisée dans le respect des documents constitutifs de la SICAR. Ainsi, il peut être important de noter que le dépositaire opère indépendamment dans l'intérêt exclusif des investisseurs[1].

La garde des avoirs doit être confiée à un dépositaire qui, en principe, doit avoir son siège au Luxembourg, sinon y être établi s'il a son siège dans un autre État. Il doit être un établissement de crédit au sens de la loi du 5 avril 1993. Le dépositaire est tenu en particulier de :

– veiller à ce que le prix de souscription des titres de la société soit perçu par celle-ci dans les délais prévus par ses documents constitutifs ;
– contrôler si dans les opérations portant sur les actifs de la société une contrepartie lui est payée ou livrée ;
– veiller à ce que les produits de la société soient affectés conformément à ses documents constitutifs.

Le dépositaire est responsable vis-à-vis de la société et des investisseurs de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de l'exécution fautive de ses obligations. Il exerce ses fonctions de façon indépendante et dans l'intérêt exclusif des investisseurs (art. 9 [ancien] L.S.C.). Ces fonctions prennent fin :

– soit volontairement, donc de l'initiative de la SICAR ou de celle du dépositaire : le remplacement doit avoir lieu dans les deux mois, étant entendu que le dépositaire doit en attendant son remplacement prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs ;
– soit en cas de déclaration de mise en faillite, de mise en concordat, etc. ou d'autres mesures similaires ;
– soit que l'autorité de surveillance retire son agrément à la SICAR ou au dépositaire ;
– soit dans les cas prévus par les statuts.

C – Autorité de surveillance

À l'instar des OPC, les SICAR nécessitent un agrément qui leur est délivré sur demande par l'autorité de surveillance, la CSSF. Cet agrément conditionne l'autorisation de pouvoir agir de ces entités. La législation SICAR s'applique sous réserve de sa désignation formelle et est sujette à l'approbation préalable de la Commission de surveillance du secteur financier (en abrégé CSSF). La CSSF exerce encore une surveillance continue sur les SICAR dans le sens qu'elle veille à l'application par les SICAR et les dirigeants des dispositions légales et conventionnelles applicables.

La CSSF ne se limite pas à accorder un agrément à la SICAR, au dépositaire et au réviseur, mais elle exerce encore une **surveillance permanente** sur la SICAR.

Lors de la soumission de leur demande d'agrément à la CSSF, les représentants légaux de la SICAR (par exemple, ses gérants et administrateurs) ainsi que

1 – V. annexe à la circulaire CSSF 2000/15 : *Mise en œuvre de l'article 11 de la directive sur les services d'investissement. Catégorisation des investisseurs pour les besoins de l'exécution des règles des affaires*, Forum des Études européennes, mars 2000.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

le dépositaire doivent attester de leur honorabilité professionnelle ainsi que de leur expérience. Tout remplacement est subordonné à l'approbation préalable de la CSSF. La délivrance d'un agrément par la CSSF est conditionnée par la nécessité d'apporter la preuve que l'administration centrale de la SICAR est située à Luxembourg. De plus, le prétendant doit certifier que les différentes activités (par exemple, management, comptabilité, tenue du registre des actionnaires, rachats et souscriptions, etc.) sont exercées à Luxembourg. En règle générale, ces activités sont organisées par la SICAR elle-même ou déléguées à un prestataire de service local spécialisé. La gestion de l'investissement peut toutefois être déléguée dans n'importe quel lieu dans lequel est établi le gérant ou le conseiller expert. Le promoteur ainsi que cette tierce partie, gérant ou conseiller, ne seront pas soumis à l'approbation par la CSSF.

Une fois autorisée, la SICAR figurera dans la liste officielle SICAR établie par la CSSF. Un des effets fort importants de l'admission sur la liste est que celle-ci dispense la SICAR de se conformer aux formalités requises pour **l'obtention** d'un **visa** des **prospectus** relatifs à des offres publiques de valeurs mobilières.

La SICAR doit respecter plusieurs exigences de transparence. Elle doit, entre autres, publier un prospectus et un rapport annuel. Le rapport annuel doit être publié dans les six mois de la fin de l'année comptable à laquelle il se réfère. Bien que les obligations concernant les rapports annuels soient calquées sur le régime commun des obligations des sociétés commerciales, la SICAR n'est pas sujette à la tenue de comptes consolidés. Même si la SICAR n'est pas obligée de dévoiler la valeur nette de ses actifs (par classe d'action/catégorie de titres) au public, elle doit en revanche communiquer de telles informations à chaque investisseur à chaque demande spéciale à au moins six mois d'intervalle. La méthode d'évaluation doit être détaillée dans les statuts et doit être basée sur la valeur de la réalisation probable.

La loi, en reprenant en substance les dispositions relatives aux OPC, précise que toutes les personnes exerçant une activité pour la CSSF ainsi que les réviseurs ou experts mandatés sont tenus au secret professionnel (art. 15 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR)). Dans un certain nombre de cas de figure, ce secret est néanmoins levé, comme tel est le cas à l'égard des OPC également.

D – Le réviseur d'entreprises

Les comptes annuels doivent en outre être révisés par un réviseur agréé au Luxembourg. Le réviseur est nommé et rémunéré par la SICAR. Le réviseur doit **informer** rapidement la **CSSF** de tout fait ou de toute décision dont il a pris connaissance dans l'exercice de son contrôle lorsque ce fait est de nature à :

– constituer une violation grave des dispositions légales ou réglementaires ; ou
– de porter atteinte à la continuation de l'exploitation de la SICAR ; ou
– d'entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves y relatives.

Cette obligation d'information (ou de dénonciation) qui incombe au réviseur s'étend également aux informations que le réviseur a pu obtenir lors de l'exercice du contrôle des données comptables ou d'une autre mission légale auprès d'une autre entreprise liée à cette SICAR par un lien de contrôle. Ce lien de contrôle est défini

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

par la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit.

Il est évident que de telles obligations de divulgation sont susceptibles d'exposer le réviseur aux sanctions de la violation de ces obligations au secret professionnel, légalement prévues, ou obligations de nature contractuelle qui le lient à son client. Pour éviter de placer le réviseur dans une situation de dilemme à l'égard de son client, la loi sur la SICAR en reprenant les dispositions prévues pour les OPC, prévoit que la divulgation de bonne foi par le réviseur de faits ou de décisions visés par la loi ne constitue pas une violation des restrictions à la divulgation d'information de nature contractuelle et n'expose le réviseur à aucune sorte de responsabilité.

■ § 5 – Dispositions pénales

Sont punis d'une **amende** :

– ceux qui ont fait état d'une appellation ou d'une qualification donnant l'apparence d'être soumis à la loi sur les SICAR, s'ils n'ont pas obtenu l'agrément de l'article 12 ;
– les dirigeants qui n'ont pas fait établir la valeur nette des titres selon l'article 30.

Sont punis d'un emprisonnement et/ou d'une amende :

– les dirigeants d'une SICAR qui n'ont pas respecté les dispositions statutaires d'émission des titres et ceux qui n'ont pas respecté les dispositions sur l'évaluation des titres (art. 5 (3) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR)) ;
– ceux qui ont procédé à la collecte de l'épargne auprès des investisseurs visés sans que la SICAR pour laquelle ils ont agi ait été inscrite sur la liste prévue à l'article 13 ;
– ceux qui ont fait des actes autres que conservatoires sans y être autorisés par le commissaire de surveillance.

La SICAR, avec son vaste choix d'options légales la rendant assez **flexible** et son **traitement fiscal favorable** (voir ci-après), complète la gamme de possibilités d'investissements déjà antérieurement disponibles au Luxembourg. La législation sur les SICAR ne remplace toutefois aucune des structures existantes, mais comble un vide en délivrant un outil sur mesure pour les moyens d'investissements en capital à risque destinés autant aux investisseurs nationaux qu'internationaux.

■ § 6 – Dispositions fiscales

Une SICAR peut prendre la forme d'une S.e.c.s., d'une S.e.c.a., d'une S.à r.l., d'une S.A. ou d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme. Toutes les formes de sociétés commerciales (sauf la société en nom collectif) sont donc admises. Par conséquent, sont autorisées également des structures fiscalement transparentes telles que les sociétés en commandite simple. Du fait de la transparence fiscale de celles-ci, l'imposition des revenus et de la fortune se fait dans le chef des associés. Telle est en tout cas la solution pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune.

En revanche, la situation est différente pour l'impôt commercial communal : pour cet impôt, c'est la société qui est redevable de l'impôt. Afin d'éviter que les sociétés

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

ne deviennent imposables au titre d'un établissement stable maintenu au Luxembourg en raison du simple fait que leurs associés commandités sont des sociétés de capitaux, il est précisé que la théorie de « l'empreinte » (« *Gepräge* ») n'est pas applicable à l'égard des SICAR sous forme de S.e.c.s. Ainsi, ces entités n'auront donc pas de revenu commercial en raison de la nature de leurs associés (étant donné que les associés commandités sont des sociétés de capitaux).

Les SICAR sous forme de sociétés de capitaux sont dotées d'un régime fiscal spécifique fortement inspiré de celui prévu à l'égard des SEPCAV, dans la mesure où, dans le chef de celles-ci, les **revenus** de **valeurs mobilières** sont exonérés d'impôt sur le revenu : il n'y a donc **pas d'exonération personnelle** de l'impôt, mais seulement une **exonération réelle** basée sur la catégorie des revenus touchés. Sont encore exonérés les revenus de fonds qui sont en attente pour être placés en capital à risque : cette exonération n'est applicable que pour une **période de 12 mois** au maximum, et que pour une période de 12 mois précédant immédiatement ce placement en capital à risque.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE VII
LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE (SE, *SOCIETAS EUROPAEA*)

Introduite par le Règlement communautaire du 8 octobre 2001[1], la société européenne (SE) existe dans tous les États membres de l'Union européenne, ainsi que dans les 3 États de l'Espace économique européen, soit donc dans un total de 31 États européens. Si le règlement est d'application directe, la mise en place de la SE suppose que les États concernés transposent en droit national une directive sur la participation des salariés[2].

Une SE est une société publique, à responsabilité limitée, par actions, dotée de la personnalité morale séparée de celle des associés et ayant un capital souscrit de **120 000 euros** au moins. Sa gestion est centralisée et ses actions sont librement transmissibles. Le nom de la société européenne doit être suivi ou précédé de l'abréviation « SE ». Il s'agit d'un **régime par option,** ce qui signifie que personne ne sera obligé d'avoir recours à cette forme de société.

Le règlement communautaire du 8 octobre 2001 relatif au statut de la SE (règlement entré en vigueur le 8 octobre 2004) a créé et mis en place le cadre légal relatif à la SE.

Le Luxembourg, par la loi du 25 août 2006 a intégré le statut de la SE dans sa législation nationale en procédant à une modification L.S.C. La SE doit en principe être immatriculée dans le pays de son siège statutaire, celui-ci devant coïncider avec le lieu de son administration centrale.

SECTION I
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION

Au vœu de l'article 420-2 L.S.C., la constitution d'une SE ne peut se faire que de quatre manières différentes :

- soit par **fusion** : de sociétés « anonymes » d'au moins deux États membres différents qui, par fusion, constituent une SE établie dans un État membre ;
- soit par constitution d'une société ***holding*** : les associés de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés anonymes d'au moins deux États membres différents apportent leurs titres à une société *holding* (SE) établie dans un troisième État membre ;
- soit par **formation d'une filiale** : celle-ci est constituée par des sociétés et autres personnes morales de droit public ou privé d'au moins deux États membres différents qui constituent une filiale commune dans un autre État membre ;
- soit par **transformation** en SE : une société de droit luxembourgeois ayant eu depuis deux années au moins une filiale dans un autre État membre peut se transformer en SE.

On voit donc que, dans tous les cas prévus, il faut un élément étranger, donc une présence dans au moins un autre État membre.

Une SE peut encore **transférer son siège** statutaire dans un autre État membre sans perdre sa personnalité morale. Il n'est pas possible de transférer uniquement

1 – N° 2157/2001, *J.O.C.E.*, L 294, 10 novembre 2001, p. 1.

2 – Directive du Conseil du 8 octobre 2001, 2001/86/CE, *J.O.*, L 294, 10 novembre 2001, pp. 22 ss.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

le siège statutaire ou le principal établissement d'un État membre à un autre[1], les deux devant donc être transférés en même temps.

Les conditions de constitution varient en fonction du mode de constitution.

■ § 1 – Constitution par fusion

Pour la constitution par fusion, il est nécessaire que les sociétés fusionnées aient la forme de la S.A., qu'elles aient la nationalité d'un État de l'Union européenne, et deux au moins doivent relever d'États membres différents (art. 420-2 (1) L.S.C).

La constitution par fusion peut avoir lieu par absorption, auquel cas la société européenne prend la forme de la société nouvelle, ou encore par fusion par création d'une société nouvelle qui adopte la forme souhaitée[2]. Le Règlement, en renvoyant à la Troisième directive, se réfère à la loi nationale harmonisée pour les points qu'il ne couvre pas. Les organes de direction ou d'administration établissent un **projet de fusion** comprenant, en dehors des indications usuelles, les statuts de la future société. Des experts doivent établir un rapport pour compte de chaque société qui fusionne.

■ § 2 – Constitution d'une société *holding*

La constitution d'une société *holding* requiert que les sociétés aient la forme de la S.A. ou celle de la S.à r.l., qu'elles possèdent la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, qu'au moins deux d'entre elles relèvent du droit d'États membres différents, qu'elles possèdent depuis au moins deux ans une filiale relevant du droit d'un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre (art. 420-2 (2) L.S.C.). Dans ce cas de figure, les sociétés promotrices subsistent, mais les sociétés actionnaires sont invitées à apporter les titres qu'elles détiennent à une société *holding*. L'opération ne réussit que si les titres apportés atteignent 50 % au moins des droits de vote de la société dont les titres sont apportés[3].

Un rapport de réviseur indépendant est requis ; celui-ci fait l'objet d'une publication. Ce rapport indique les difficultés particulières d'évaluation et se prononce sur la question de savoir si le **rapport d'échange** d'actions et de parts envisagé est ou non « *pertinent et raisonnable* ». La constitution de la SE est décidée par les différentes assemblées qui approuvent le projet de constitution. Dans les trois mois de l'établissement de l'acte constitutif, les actionnaires et porteurs de parts communiquent aux sociétés leur intention d'apporter leurs titres en vue de la constitution de la SE (voir art. 33-36 du Règlement, art. 420-2 (2) L.S.C.).

■ § 3 – Constitution de filiale

Pour la constitution d'une filiale, les fondateurs (qui doivent avoir la nationalité d'un État membre de l'Union européenne) peuvent être des sociétés de n'importe quelle forme de l'article 48 du traité ou d'autres entités juridiques de droit public ou

1 – M. Wenz, « The European Company (*Societas Europaea*). Legal concepts and tax issues », *Euro Tax*, 2004, Vol. 44, n° 1, p. 9.

2 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 95.

3 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 97.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

privé ; la condition de diversité est la même que celle décrite pour la constitution de la société *holding*[1].

■ § 4 – Constitution par transformation

Si la SE résulte de la transformation d'une S.A., alors il est requis que la société transformée ait la forme d'une S.A., qu'elle soit une société constituée selon le droit d'un État membre, qu'elle ait son siège statutaire et son administration centrale dans l'Union européenne et, comme élément de droit européen, qu'elle ait depuis au moins deux ans une filiale dans un autre État membre (art. 100-3, alinéa 7, L.S.C.).

En application de l'article 37 du Règlement, la transformation comporte la **continuation de la personnalité morale**. La transformation est précédée d'un projet et d'un rapport établi par l'organe d'administration et de direction. La publication du projet est prescrite un mois avant la date de l'assemblée générale. Ce rapport « *explique et justifie les aspects juridiques et économiques de la transformation et indique les conséquences pour les actionnaires et les travailleurs de l'adoption de la forme de la SE* ». Un rapport d'experts indépendants doit, selon une procédure similaire à celle applicable en matière d'apport en nature, attester avant l'assemblée « *que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer* »[2]. L'assemblée des actionnaires décide sur la fusion dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en matière de fusions nationales. Le Règlement précise que la loi nationale peut subordonner la transformation à l'approbation de l'organe social pour lequel la participation des travailleurs est organisée.

SECTION II
LE TRANSFERT DE SIÈGE DE LA SE

Par le biais du Règlement, notre droit national prévoit pour la première fois une réglementation très complète du transfert de siège. Le projet de loi 5352 concernant la SE (entre autres) en introduisant les articles 101-1 à 101-17 dans la L.S.C. reprend ces dispositions en droit national. Celles-ci figurent aux articles 490-1 à 492-7 L.S.C.

L'article 490-1 [anc. art. 101-1] L.S.C. précise que ce transfert de siège ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

La procédure de transfert, telle que prévue par l'article 490-1 L.S.C. est calquée sur la procédure des fusions et des scissions. Avant le transfert, le **projet de transfert** accompagné d'une justification est publié, et ceci, afin d'informer les tiers et de leur permettre de demander des garanties pour le cas où leurs créances seraient mises en danger du fait que la SE change de pays, et donc de législation applicable. Une fois que le délai visé est écoulé et que les garanties sont obtenues, le transfert de siège peut être voté par l'assemblée générale décidant aux conditions de quorum et de majorité qui sont celles des assemblées modifiant les statuts.

Avant la Loi de Modernisation (qui a aboli l'exigence de l'unanimité pour les changements de nationalité de sociétés), la décision du transfert de siège de la SE

1 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 92.

2 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 94.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

constituait donc une exception à la règle de l'unanimité requise en cas de changement de nationalité d'une société. Depuis 2016, le droit national s'est donc aligné sur le Règlement (art. 8, §§ 6 et 14).

SECTION III
RÉGIME JURIDIQUE

La SE est une S.A. relevant du droit de l'État membre de son siège statutaire. Elle peut elle-même constituer des filiales sous forme de SE, auquel cas les dispositions nationales exigeant plusieurs associés ne sont pas applicables ; en revanche, sont applicables les dispositions de la loi nationale transposant la Douzième directive (société unipersonnelle) en droit national.

Aux termes du Règlement[1], les actes qui auraient été accomplis au nom de la SE avant son immatriculation et qui n'auraient pas été repris par la société engendrent une obligation solidaire et indéfinie dans le chef de ceux qui les ont accomplis (sauf convention contraire).

La dénomination de la SE doit être suivie ou précédée obligatoirement du sigle SE. La société est gérée par l'organe d'administration sous forme soit d'un conseil d'administration, soit d'un directoire. Le terme de **directoire** n'est pas utilisé par le Règlement, mais il est utilisé par le législateur national qui reprend ainsi la terminologie française. Il est précisé que la **gestion journalière** peut être attribuée à des membres du directoire, et ceci, dans les mêmes conditions que celles qui prévalent pour les sociétés anonymes de droit commun.

Les fonctions de membre de l'organe de gestion et celles de l'organe de surveillance sont incompatibles (ce qui va presque de soi). En cas de vacance de poste, il est toutefois possible que le conseil de surveillance désigne un de ses membres pour remplacer un des membres de l'organe de gestion : dans ce cas, ses fonctions en tant que membre de l'organe de surveillance sont suspendues. Les États membres peuvent prévoir des limites de durée pour cette période, ce que le Luxembourg n'a pas fait.

Le régime de gestion dualiste initialement réservé aux S.E. en droit luxembourgeois a donné lieu à un sous-paragraphe supplémentaire L.S.C. dénommé « *Du directoire et du conseil de surveillance* » et qui comporte les articles 442-1 à 442-19 [anc. art. 60*bis*-1 à 60*bis*-11] L.S.C.

■ § 1 – Contenu des dispositions légales

Aux termes de l'article 442-1 L.S.C., les statuts de toute S.A. peuvent prévoir que celle-ci est régie par les dispositions du sous-paragraphe 2, ce qui implique donc que la société reste soumise à l'ensemble des règles des S.A. à l'exception de celles des articles 441-1 à 441-13 L.S.C.

L'article 442-2 2 fait une distinction entre les sociétés anonymes et les SE. Les règles applicables sont très largement identiques, mais il existe certaines nuances.

1 – Art. 16. du Règlement.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

A – Le système de gestion proposé

Le **système dualiste** repose sur la séparation de la gestion (qui est attribuée à un organe de gestion, au conseil d'administration) et la surveillance (attribuée à l'organe de surveillance) qui contrôle la gestion, mais sans pouvoir exercer lui-même ce pouvoir de gestion.

La société est dirigée par un directoire dont les membres sont désignés par le conseil de surveillance, sauf que ce pouvoir peut être attribué par les statuts à l'assemblée générale des actionnaires et, dans ce cas, l'assemblée est seule compétente[1].

Dans les **sociétés anonymes unipersonnelles** ou celles ayant un **capital** inférieur à **500 000 euros,** une seule personne peut exercer les fonctions attribuées au directoire. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Ils peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que par l'assemblée (si les statuts le prévoient).

Les statuts d'une SE doivent préciser les **actes** qui **donnent lieu à autorisation** du directoire par le conseil de surveillance (art. 442-7 (2) L.S.C.). Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale.

B – Surveillance de la gestion

La surveillance exercée par le conseil de surveillance est double :

– en premier lieu, les membres de l'organe de gestion sont nommés et révoqués par l'organe de surveillance ; il est toutefois loisible aux statuts de prévoir que ce pouvoir est (comme dans la structure classique) exercé par l'assemblée des associés ;
– en deuxième lieu, une série d'actes de gestion (obligatoirement spécifiés par les statuts), doivent être expressément autorisées par le conseil de surveillance.

En outre, le conseil de surveillance bénéficie d'un droit illimité de regard sur les opérations et, en particulier, du fait que, sur une base trimestrielle, l'organe de gestion doit informer l'organe de surveillance de la marche des affaires et de son évolution future prévisible (art. 442-12 L.S.C.).

Le conseil de surveillance est **nommé** par l'assemblée générale, sous la réserve des dispositions concernant l'implication des travailleurs et d'une première désignation par les statuts de la société. Le nombre minimum et maximum des membres est fixé par la loi nationale.

■ § 2 – Règles communes aux deux organes

Les membres des deux catégories d'organes sont désignés pour une période prévue aux statuts qui ne peut excéder 6 ans ; leur mandat est, sauf disposition contraire, renouvelable. Les statuts de la SE peuvent permettre à une société (ou

1 – Art. 442-3 L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

encore une autre personne morale) d'être membre d'un de ses organes, à moins que ceci ne soit interdit (comme pour les sociétés anonymes de l'État).

Les règles de compétence visées pour la nomination des organes ne dérogent pas aux lois nationales qui permettent à une minorité d'actionnaires ou encore d'autres personnes telles que les travailleurs de nommer une partie des membres des organes.

La représentation de la société se fait selon les dispositions harmonisées telles que prévues par les Première et Deuxième directives en matière d'harmonisation du droit des sociétés.

La responsabilité des membres des organes envers la SE en cas de violation de leurs obligations est régie par la loi des sociétés anonymes de l'État du siège.

SECTION IV
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Aux termes du Règlement, l'assemblée générale est compétente pour prendre les décisions pour lesquelles elle a la seule compétence soit en vertu du Règlement, soit en vertu de la loi nationale. Pour la convocation, le déroulement de l'assemblée, les procédures de vote, etc., il est renvoyé à la loi nationale en matière de société anonyme. En principe, les décisions sont prises à la majorité des votes exprimés (avec un quorum portant sur la moitié des titres présents ou représentés), sauf majorités plus élevées pour certaines décisions, notamment les modifications des statuts.

Une minorité détenant 10 % des actions peut demander la convocation d'une assemblée ; aux mêmes conditions, elle peut demander l'ajout d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

SECTION V
IMPLICATION DES SALARIÉS (DIRECTIVE)

C'est la loi du 25 août 2006 « *1. complétant le statut de la SE pour ce qui concerne l'implication des travailleurs […]* »[1] qui a procédé à l'adaptation de la loi nationale sur le point de l'implication des travailleurs. Les dispositions de cette loi ont été introduites dans le Code du travail (titre IV) par le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 procédant à la consolidation du Code du travail. Dans un langage familier, on pourrait dire qu'il s'agit d'une véritable « usine à gaz », dans le sens qu'il s'agit d'un régime extrêmement complexe et qui ne contribue certainement pas à rendre le régime de la SE plus attractif.

Ce règlement a instauré un cadre juridique uniforme dans lequel des entreprises de différents États membres peuvent planifier et réorganiser le cas échéant leurs activités au niveau de l'Union européenne. La participation des salariés ne se fait pas au niveau de la gestion, mais au niveau de la surveillance et du développement des stratégies de l'entreprise.

La Directive offre le choix entre plusieurs modèles de participation :

– le modèle intégrant les travailleurs au sein de l'organe de surveillance ou de l'organe d'administration (**modèle allemand**) ;

1 – *Mém.* A 152 du 31 août 2006, p. . 2706.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– le modèle de l'organe distinct représentant les travailleurs de la société européenne (**modèle anglo-saxon**) ;
– les autres modèles sont à établir par voie d'accord conclu entre les organes de direction ou d'administration des sociétés fondatrices et les travailleurs de la société, tout en respectant le niveau d'information et de consultation prévu pour le modèle de l'organe distinct. Aucune SE ne peut être constituée par l'assemblée générale tant qu'un modèle de participation décrit par la directive n'a pas été choisi.

Des locaux, des moyens matériels et financiers doivent être mis à la disposition des représentants des salariés pour leur permettre l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque, à l'expiration du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun accord n'a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de référence continuent à s'appliquer.

Dans le cas d'une SE issue d'une fusion, les principes standards concernant la participation des travailleurs s'appliqueront si 25 % au moins des salariés bénéficiaient d'un droit de participation aux décisions avant la fusion. C'est sur ce point qu'un accord politique s'était avéré impossible jusqu'au sommet de Nice de décembre 2000. Le compromis adopté par les chefs d'État et de gouvernement permet à un État membre de ne pas appliquer la directive aux SE constituées dans le cadre d'une fusion, auquel cas la SE ne pourra être immatriculée dans l'État membre considéré que pour autant que soit un accord soit conclu entre la direction et les salariés, soit qu'aucun salarié de la SE n'ait bénéficié d'un droit de participation avant la création de la SE.

La loi du 25 août 2006 complétant le statut de la SE pour ce qui concerne l'implication des travailleurs est fondée sur la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001.

La création d'une SE présuppose en principe la mise en place d'une structure d'implication des travailleurs, la négociation relative à l'implication des travailleurs dans la future SE constituant une condition de recevabilité à l'immatriculation de la SE.

■ § 1 – La représentation des travailleurs

Les dispositions concernant la représentation des travailleurs sont obligatoirement adoptées dans les différents États membres afin de garantir que la création d'une SE ne puisse affaiblir, voire anéantir le régime d'implication des travailleurs existant dans les sociétés participant à la création d'une SE. On a voulu éviter que la SE ne devienne le moyen servant à contourner les dispositions concernant la participation des salariés existant dans nombre de pays de l'Union européenne.

La directive 2001/86/CE constitue un complément indissociable du susdit règlement. La directive prend soin de préciser que son but est de « *promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté* ». Elle ajoute dans son considérant 4 que les objectifs de cette action ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, raison pour laquelle des mesures communes doivent être prises au niveau de l'Union européenne conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du Traité instituant la Communauté européenne.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

A – Le principe d'avant-après

La directive n'entend pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il est en effet apparu que la grande diversité des régimes d'implication des travailleurs dans les États membres **excluait** l'instauration d'un **modèle européen unique** d'implication, que ce soit dans le Règlement ou dans la Directive. La Directive se limite dès lors à fixer des standards minima. Elle prévoit également que la constitution d'une SE ne peut comporter une **atteinte aux droits acquis** des travailleurs en matière d'implication.

« *Par ce principe de l'acquis ou du dit "avant-après" on entend l'idée que le droit communautaire cherche à éviter que l'autonomie contractuelle des acteurs n'aboutisse à priver de façon substantielle, par la création de la société européenne, les travailleurs d'un pays de droits de participation qu'ils tiendraient de leur droit national avant la création de l'entité juridique européenne.*

Le respect de ce principe s'applique également aux modifications ultérieures d'une SE ainsi qu'aux sociétés concernées par le processus de modifications structurelles.

Cependant si aucune des sociétés participantes n'est régie par des règles de participation, alors la SE n'est pas tenue d'instaurer des dispositions en matière de participation. Il semble ainsi aisé de contourner le principe "avant-après" en créant d'abord une société sans participation des travailleurs et de la transformer ensuite en SE ».

Deux obligations s'imposent vis-à-vis de l'organisme de représentation du personnel de la SE : une **obligation de négociation** par des consultations régulières et une **obligation d'information**, notamment en matière de stratégie d'entreprise, de niveaux de production et de vente, de gestion des changements, de risque de fermeture et de licenciements.

Dans la directive 2001/86/CE, l'article 2, paragraphe i) définit pour la première fois en droit européen ce que l'on entend par information des travailleurs. Cependant, la définition donnée est volontairement large afin de laisser l'autonomie aux États membres. Le choix leur est ainsi laissé de fixer une liste exemplative ou exhaustive des faits qui rentrent dans l'obligation d'information.

L'obligation de consultation est la deuxième composante importante de ce chapitre. La définition de consultation, contrairement à celle de l'information, était déjà connue avant la Directive, cependant la nouvelle définition est différente.

B – Le groupe spécial de négociation

Aussitôt après la publication d'un projet de constitution de SE, les négociations doivent être engagées au sein d'un « *groupe spécial de négociation* » (GSN), spécialement constitué à cette fin selon les règles prévues par la Directive, lui assurant une représentation proportionnelle du nombre de salariés concernés dans chaque État membre. Certains détails quant aux modalités de nomination de ses membres et de leur statut sont réglés par le droit national.

Trois possibilités existent :

1) soit le GSN aboutit à un **accord** ;

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2) soit il décide (avec la majorité qualifiée des 2/3 de ses membres, représentant au moins les 2/3 des salariés[1], ce chiffre incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres) de ne pas entamer des négociations sur ce point ou de clore les négociations ouvertes et d'appliquer la **réglementation** relative à **l'information** et la consultation applicable dans **chaque État membre** où la SE emploie des salariés ;
3) soit, à l'issue de la période de négociation de **six mois** prévue par la directive 2001/86/CE, prorogeable d'une durée équivalente, **aucun accord** n'a pu être conclu.

Dans ce dernier cas seulement, les dispositions supplétives prévues par la directive 2001/86/CE s'appliquent impérativement.

Par contre, si la SE est constituée par **transformation**, ces dispositions ne s'appliquent que si les règles d'un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l'organe d'administration ou de surveillance étaient déjà en vigueur dans la société transformée en SE.

Ceci montre bien le caractère de mesure anti-évasion de ces dispositions : les auteurs de ces textes ont voulu éviter que la SE ne devienne l'instrument servant sur un plan européen à contourner les dispositions nationales de participation des salariés à la gestion de l'entreprise. Or, un tel risque est exclu si, au départ, la société n'est pas soumise à un tel régime de participation et qu'il ne peut donc pas y avoir de contournement de ces dispositions.

Dans les trois autres hypothèses de constitution, ces règles ne jouent que si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs sociétés ayant directement participé à l'opération en couvrant au moins 25 % du nombre total de l'effectif de l'ensemble de ces dernières (50 % en cas de SE *holding* ou filiale) ; si le nombre total de l'effectif reste en dessous de ces seuils, il faut une décision du GSN pour rendre les dispositions de référence de la directive 2001/86/CE applicables.

La création d'un groupe spécial de négociation (GSN) est régie par l'article 3, paragraphes 1 et 2. L'article 3, paragraphe 1, de la directive définit quand la création d'un GSN doit avoir lieu : il s'agit du moment de la publication du projet en ce qui concerne la fusion et la SE-*holding* et l'adoption du projet par les organes d'administration ou de direction des sociétés considérées en ce qui concerne la transformation et la SE-filiale commune.

La **tâche du GSN** est celle de négocier et de conclure un accord avec les organes compétents des sociétés participantes sur les modalités de l'implication des travailleurs au sein de la future SE.

La directive 2001/86/CE laisse aux États membres la possibilité de transposer ou non dans leur droit national les dispositions relatives à la participation des travailleurs applicables aux SE constituées par fusion.

Les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre du Règlement figurent dans le projet de loi n° 5352 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle, modifiant

1 – Art. 5, (5), de la loi.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales.

§ 2 – Règles concernant le GSN

Le nombre des membres du GSN est fonction du nombre de salariés occupés dans les différentes sociétés participantes à travers tous les États membres. La détermination des sièges se fait d'abord par pays, sachant que l'ensemble des sièges ainsi déterminés donne le nombre total des membres du GSN.

A – Détermination du nombre de sièges par pays

Un siège est attribué à l'État membre en question par tranche (ou fraction de tranche) de travailleurs employés dans son État et représentant **10 % du nombre total de travailleurs** occupés à travers tous les États dans les sociétés et entités participant au projet de constitution de la SE.

Du fait que les fractions de tranches comptent pour une fraction entière, il résulte que chaque pays dans lequel les sociétés participantes possèdent des salariés a donc le droit de disposer d'au moins un représentant au sein du GSN.

Exemple[1]

Deux sociétés A et B décident de créer une SE-*holding*. La société A compte 6070 salariés répartis sur 4 pays et la société B 930 salariés, aussi répartis sur 4 pays.

Sièges au sein du GSN

Belgique : 1000 + 500 = 1500, soit 21 % = 3 sièges

France : 30 + 90 = 120, soit 1,7 % = 1 siège

Espagne : 5000 + 320 = 5320, soit 76 % = 8 sièges Luxembourg : 40 + 20 = 60, soit 0,85 % = 1 siège

Total : 13 sièges.

	Société A	Société B	Total	Sièges
Belgique	1000	500	1.500	3
France	30	90	120	1
Espagne	5.000	320	5320	8
Luxembourg	40	20	60	1
				13

En ce qui concerne **l'attribution des sièges** parmi les sociétés participantes d'un même État membre (article L. 442-2 du Code du travail), il convient d'appliquer la règle générale suivante :

Règle générale

Au niveau de chaque société ou entité concernée, les membres du GSN sont élus/désignés suivant leurs règles nationales.

1 – L'exemple est repris du projet de loi n° 5435.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Au Luxembourg

La désignation des membres du GSN représentant des travailleurs occupés au Luxembourg se fait d'après les dispositions de l'article L. 442-2 du Code du travail de la manière suivante :

- les représentants des travailleurs luxembourgeois au GSN sont élus/désignés par les membres des délégations du personnel en place ;
- les membres ainsi élus/désignés sont ou bien des salariés de l'entreprise ou bien des représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et signataires de la convention collective applicable dans la société participante, la filiale ou l'établissement concerné ;
- chaque poste de représentant au GSN sera pourvu d'un membre effectif et d'un membre suppléant, ce dernier remplaçant d'office l'effectif en cas d'empêchement ou de vacance de poste définitive ;
- le mandat du membre représentant au GSN prendra fin en cas de fin du contrat de travail (membre salarié) ou en cas de cessation d'appartenance à l'organisation syndicale (membre non salarié) ;
- si une délégation centrale d'entreprise existe : elle désigne les représentants au GSN ;
- si une délégation centrale ouvriers et employés existe :
  - le 1er membre effectif est désigné par la délégation représentant la majorité des salariés de l'entreprise, son suppléant étant désigné par l'autre délégation ;
  - si la catégorie de travailleurs majoritaire représente au moins les 2/3 des travailleurs occupés au Luxembourg, alors les 2 premiers représentants effectifs seront élus par la délégation centrale représentant cette catégorie de travailleurs et les 2 suppléants par l'autre délégation, etc. ;
- s'il n'y a pas de délégation centrale : la délégation principale procède à la désignation des représentants au GSN ;
- si une délégation principale ouvrier et employés existe : idem que lorsque délégation centrale ouvrier et employés ;
- si les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises, les représentants au GSN seront élus par l'ensemble des délégués du personnel réunis en AG :
  1) le 1er représentant sera désigné par les membres des délégations représentant la majorité des travailleurs, et son suppléant par les membres des délégations représentant l'autre catégorie de travailleurs ;
  2) si la catégorie de travailleurs majoritaire représente au moins les 2/3 des travailleurs occupés au Luxembourg, alors les deux 1ers représentants au GSN lui reviennent, les 2 suppléants revenant à l'autre catégorie de travailleurs ;
- si aucune délégation du personnel n'existe : alors, c'est l'ensemble des salariés qui procèdent à l'élection des représentants au GSN ;
- si les travailleurs occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le GSN, alors ceux-ci sont élus/désignés de sorte que chaque société participante occupant des travailleurs au Luxembourg soit représentée sans

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

que le nombre total de membres du GSN ne soit augmenté (article 5(10) du projet de loi).

Admettons que trois sociétés A, B et C, situées au Luxembourg, participent à la création d'une SE et qu'il n'y ait que deux sièges à pourvoir au sein du GSN pour ces trois sociétés.

Les délégations du personnel des trois sociétés réunies en assemblée générale décideront de l'attribution des sièges.

B – Constitution de SE par fusion

Si, en application des règles nationales de désignation des membres du GSN, il n'y avait pas de représentant pour les travailleurs des sociétés qui cessent d'avoir une identité juridique propre après la constitution de la SE par fusion, le GSN doit être complété de membres supplémentaires représentant les travailleurs de ces sociétés, mais à la double condition que :

1) le nombre de ces membres supplémentaires n'excède pas 20 % du nombre des membres désignés en vertu de la règle classique (1 représentant par tranche ou fraction de tranche de travailleurs représentant 10 % de l'ensemble des travailleurs) ;
2) la composition du GSN n'implique pas une double représentation des travailleurs en question. Si le nombre des sociétés devant perdre leur identité juridique dépasse le nombre de sièges supplémentaires disponibles en vertu de la règle des 20 %, alors ils sont attribués aux sociétés d'États membres différents selon l'ordre décroissant des travailleurs employés.

Exemple

Reprenons les données de l'exemple précédent, sauf que A et B créent une SE par fusion.

Il s'agit de vérifier si toutes les sociétés sont représentées au GSN. La Belgique a droit à 3 sièges. Elle n'éprouvera aucune difficulté à attribuer un siège par société. Idem pour l'Espagne.

La France n'a droit qu'à un seul siège. Mais les salariés des 2 sociétés A et B sont concernés par la future SE. La France aura partant droit à un siège supplémentaire au GSN.

Idem pour le Luxembourg.

Le GSN comportera donc 2 sièges supplémentaires. Les 20 % (2,6) des membres ordinaires du GSN ne sont pas dépassés.

Belgique : 1000 + 500 = 1500, soit 21 % = 3 sièges

→ Aucun siège supplémentaire

France : 30 + 90= 120, soit 1,7 % = 1 siège

→ 1 siège supplémentaire

Espagne : 5000 + 320= 5320, soit 76 % = 8 sièges

→ Aucun siège supplémentaire

Luxembourg : 40 + 20 = 60, soit 0,85 % = 1 siège

→ 1 siège supplémentaire

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Total : 13 sièges et 2 sièges supplémentaires.

	Société A	Société B	Total	Sièges
Belgique	1.000	500	1.500	3
France	30	90	120	1
Espagne	5.000	320	5.320	8
Luxembourg	40	20	60	1
				13

Si, en cas de modification du projet de constitution de SE, un membre du GSN ne représente plus les travailleurs des sociétés concernées par le projet, alors son mandat prendra fin. Si le projet de constitution de SE est modifié de telle manière que le nombre total ou la répartition des sièges du GSN est modifié de plus de 25 %, alors le GSN doit être intégralement recomposé.

Les négociations doivent être entamées dès la constitution du GSN et peuvent durer au plus 6 mois. Les parties peuvent décider d'un commun accord de prolonger les négociations jusqu'à au plus 1 an.

■ § 3 – Cas particulier de la SE constituée par transformation

Suivant la loi, l'implication des travailleurs doit être d'un niveau sensiblement équivalent à celui existant au niveau de la société à transformer.

Le niveau de participation est censé équivalent lorsque les organes d'administration (régime moniste) ou de surveillance (régime dualiste) comprennent une proportion de membres désignés ou élus par les travailleurs égale à celle existant au sein de la société qui doit être transformée.

Pour avoir force obligatoire, l'accord doit revêtir la forme écrite. Il oblige alors :

– la SE ;
– les sociétés participantes, leurs filiales et établissements ;
– les travailleurs des sociétés participantes ;
– les organisations syndicales impliquées dans les négociations ou concernées par l'accord.

Les dispositions des articles 9 à 14 du projet de loi n° 5435 (reprises entre-temps dans le Code du travail, art. L. 443-1 et suivants) constituent des **dispositions supplétives** sur lesquelles on retombe dans certains cas de figure. Elles visent aussi bien l'information et la consultation des travailleurs dans la SE que la participation des travailleurs dans la SE.

Les dispositions de référence s'appliqueront aux SE qui établissent leur siège au Luxembourg dans les cas suivants : si les parties (organes dirigeants et GSN) en décident ainsi ou si, dans le délai de 6 mois, voire dans le délai de prolongation, aucun accord n'a été trouvé et que l'immatriculation de la SE est néanmoins poursuivie et que le GSN n'a pas décidé de clore les négociations ou de ne pas les entamer (car s'il y a décision de clore ou de ne pas entamer les négociations, les dispositions nationales joueront) ou si l'accord fixé entre parties est frappé de nullité.

Les règles antérieures de participation existantes doivent être maintenues.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La loi précise encore que la **transformation** d'une SE en société anonyme luxembourgeoise n'emporte pas modification de la personnalité morale. La transformation dans l'autre sens, (transformation d'une société anonyme luxembourgeoise en SE) est possible si la société luxembourgeoise a possédé depuis au moins deux ans une filiale dans un autre État membre. La transformation en S.A. d'une SE ayant son siège statutaire au Luxembourg (art. 3, alinéa 6) ne peut toutefois intervenir avant deux ans depuis l'immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels n'aient été approuvés.

Qu'en est-il si la S.A. transformée en SE passe d'un système de gestion moniste à un système dualiste ? Les représentants des travailleurs ayant siégé auparavant dans le conseil d'administration siégeront dorénavant dans le conseil de surveillance.

Or la mission d'un conseil de surveillance n'est pas la même que celle d'un conseil d'administration : suivant les dispositions nationales luxembourgeoises, le conseil de surveillance ne fait que contrôler la gestion de la société effectuée par l'organe de direction, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion.

Il n'aura que pouvoir de décision pour les questions limitativement énumérées par les statuts de la société.

Dans un tel cas de figure, le principe dit du « avant-après » sera-t-il respecté ? Il y a lieu de résoudre ce problème.

■ § 4 – Dispositions concernant l'organe de représentation des travailleurs (OR) de SE

L'OR est compétent pour décider :

- de la répartition par pays des sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ;
- de la façon dont les travailleurs peuvent **recommander la désignation des membres de ces organes** ou s'y opposer, le tout en fonction de la proportion des travailleurs de la SE occupés dans les différents États.

A – Dispositions de référence pour la composition de l'OR

En vertu de la loi, les membres de l'OR sont des salariés de la SE, de ses filiales et établissements, élus ou désignés par les représentations des travailleurs ou à défaut par les travailleurs eux-mêmes suivant les règles nationales. Les règles relatives à l'élection/désignation des membres de l'organe de représentation prévoient que chaque État membre aura droit à un membre dans l'OR par tranche (ou fraction de tranche) du nombre de salariés occupés dans son pays et représentant 10 % du nombre de travailleurs employés par les sociétés participantes dans tous les pays.

Si le siège de la SE est au Luxembourg, alors les membres de l'organe de représentation seront élus pour 5 ans. L'organe de représentation comporte au moins **neuf membres** : le projet prévoit l'élection d'un comité restreint de trois membres au plus, dont le président. Ce comité restreint se chargera des affaires courantes.

B – Statut des membres du GSN, de l'OR et des représentants des travailleurs

Ce statut des membres du GSN, de l'OR et des représentants des travailleurs siégeant dans l'organe d'administration ou de surveillance est régi par l'article 16 la

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

loi du 25 août 2006 complétant le statut de la SE pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.

Les membres du GSN, de l'OR et des représentants des travailleurs siégeant dans l'organe d'administration ou de surveillance jouissent d'une protection contre le licenciement similaire à celle dont bénéficient les délégués du personnel, l'article L. 443-3 (1) du Code du travail faisant un renvoi aux articles L. 415-11 et L. 415-12 du Code du travail.

Les membres du GSN, de l'OR et des représentants des travailleurs siégeant dans l'organe d'administration ou de surveillance ont le droit d'être libérés de leur poste de travail sans perte de rémunération, afin de pouvoir remplir leurs obligations en tant que membres du GSN, de l'OR ou encore de l'organe d'administration ou de surveillance.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE II
LES SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

La S.à r.l. a toujours été une sorte de « **société anonyme *bis*** ». Ceci tient à des raisons tant historiques qu'à des raisons plus actuelles ayant trait au droit de l'Union européenne. Historiquement, la S.à r.l. a été introduite seulement en 1933 en droit luxembourgeois, et ceci, encore une fois en suivant les modèles étrangers.

La société de ce type avait déjà fait l'objet de certains commentaires lors de l'élaboration de la Loi de 1915, mais sans emporter l'accord des auteurs de cette loi. « *La société à responsabilité limitée, accueillie dans la législation allemande par la loi du 20 avril 1892 et dans la législation autrichienne par celle du 15 mars 1906, était appelée à faire contrepoids au rigorisme des dispositions régissant la société anonyme. L'expérience qui en a été faite n'est guère concluante. Excellente à plus d'un point de vue, cette institution peut constituer une des solutions de l'avenir. […] Sa généralisation semble prématurée* »[1].

Au début de l'année 1929, la Chambre de commerce du Luxembourg avait élaboré un projet de loi, calqué sur la loi française du 7 mars 1929 tout en s'inspirant du projet de loi belge qui était en voie d'instance à l'époque, visant à l'institution de la Société à responsabilité limitée[2].

Le recours à ce type de société permettait aux promoteurs de bénéficier de la responsabilité limitée tout en évitant certains des désavantages de la société anonyme : « *nombre minimum d'associés (sept), absence d'une raison sociale, appareil compliqué, large publicité […]* »[3].

Au Luxembourg, le résultat de l'introduction de la S.à r.l. a été similaire à celui constaté en France auparavant[4], à savoir une diminution rapide du nombre des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple en même temps que de celui des sociétés anonymes.

Par ailleurs, ce type de société est également soumis au **droit européen,** mais encore une fois à un degré moindre : la Première directive s'applique à toutes les sociétés de capitaux, alors que la Deuxième directive est applicable aux seules sociétés anonymes. La plupart des directives suivantes sont également limitées aux S.A.

Relevons de prime abord que la désignation même de « société à responsabilité limitée » est malencontreuse pour ne pas dire qu'elle est carrément erronée. En effet, ce n'est **pas la société qui est à responsabilité limitée,** mais les engagements des associés : ces derniers sont limités à leurs apports. La société n'est pas à

1 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport de la commission spéciale, p. 265, ID 9792.

2 – L. Metzler, « Le régime légal des sociétés et des associations en droit luxembourgeois », *R.P.S.*, p. 252.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 11.

4 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 12.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

responsabilité limitée pour la raison que le patrimoine social dans son intégralité constitue le gage des créanciers et, dans n'importe quel litige, c'est ce patrimoine dans son intégralité qui est engagé. En cas de mauvaise issue du litige, ce patrimoine sera perdu sans être le moins du monde limité au capital social, aux apports des associés, etc. La société ne peut faire valoir aucune limitation de responsabilité vis-à-vis de ces créanciers.

CHAPITRE I
NATURE DE LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

L'article 710-1 L.S.C. définit la S.à r.l. comme suit : « *(1) Les sociétés à responsabilité limitée sont celles où des associés en nombre limité n'engagent qu'une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être cédées que conformément aux modes et conditions prescrits par le présent titre.*

(2) La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. De même, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société ».

Contrairement à ce que pourrait faire croire cette définition et la désignation de ce type de société par la responsabilité limitée, cette dernière n'en est pas le caractère distinctif ; en effet, les sociétés anonymes sont également des sociétés à responsabilité limitée tout comme les sociétés coopératives peuvent, de manière facultative, également adopter cette caractéristique. En réalité, la S.à r.l. est une société assez originale qui comporte des traits tant de sociétés de capitaux que de sociétés de personnes (dont elle emprunte le caractère fermé et la difficulté de transmission des parts), de sorte que l'on doive considérer qu'il s'agit d'une **forme hybride de société**. Son attrait pratique tient notamment à la simplicité de son fonctionnement qui contraste fortement avec celui des sociétés par actions.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Une société à responsabilité peut être constituée par plusieurs associés ou par un seul associé ; dans ce dernier cas, elle est appelée société à responsabilité limitée **unipersonnelle**. Elle obtient ce statut de société unipersonnelle également si, en cours d'existence, le nombre des associés diminue à une seule personne.

SECTION I
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION

On peut distinguer les conditions de forme des conditions de fond.

■ § 1 – Conditions de forme

En premier lieu, un **acte notarié** est requis. Tel n'était pas le cas à l'origine où la société à responsabilité limitée pouvait être créée par acte sous signature privée[1]. Aux termes de l'article 100-18 L.S.C., l'absence d'un tel acte notarié serait d'ailleurs une des rares causes de **nullité** de ce type de société.

Pour la constitution de la société, les associés peuvent être représentés par un mandataire. Dans ce cas, ils n'ont pas l'obligation de se présenter en personne devant le notaire. Des procurations en ce sens seront présentées au notaire instrumentant. Ces procurations doivent être annexées à l'acte de société dont elles forment une partie intégrante et sont enregistrées avec cet acte[2], mais sans être publiées en même temps (art. 100-10 L.S.C.).

Quelles sont les sanctions si les **procurations** ne sont pas annexées à l'acte notarié ? La nullité de l'acte est l'exception, et elle s'applique uniquement en cas d'acceptation d'une donation par un mandataire conformément à l'article 933 C.c. Abstraction faite de ce cas, l'article 17 de l'ordonnance sur le notariat du 3 octobre 1841 punit le défaut d'annexe à l'acte notarié d'une peine d'amende[3].

Conformément à l'article 420-16 L.S.C. applicable aux sociétés anonymes, qui permet également la constitution de la société anonyme par des porteurs de procurations, l'irrégularité concernant les procurations n'est pas sanctionnée par la nullité de la constitution. Dans ce cas, la sanction prévue est celle de l'article 420-19 (1) L.S.C. : en cas de mandat non valable, ceux qui ont pris des engagements pour des tiers nommément désignés dans l'acte sont réputés personnellement obligés s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement de porte-fort n'est pas ratifié dans les deux mois.

Si la loi belge concerne les sociétés privées à responsabilité limitée, cet adjectif n'a été repris ni par la loi luxembourgeoise ni par la loi française afférente à ce genre de sociétés[4]. Néanmoins, il ne peut y avoir de doute que le législateur luxembourgeois (comme son homologue français) entendait bien exclure les appels publics

1 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 11.
2 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 35.
3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 35.
4 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 73.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de fonds. Cette caractéristique résulte directement de l'article 188 L.S.C. qui interdit l'émission publique d'obligations et les émissions publiques de parts sociales.

§ 2 – Conditions de fond

La constitution d'une société à responsabilité limitée requiert :

– un nombre d'associés qui est de **1** au moins et de **100** au plus, les associés pouvant être des personnes physiques ou des personnes morales ;

Une S à r.l. peut encore être une société unipersonnelle. Introduite par les dispositions de la **Douzième directive**, elle a été réservée à la S.à r.l. (par la loi du 28 décembre 1992) dans une première étape, étant entendu que, pour les S.A., la réduction à un seul associé a cessé d'être une cause de nullité de ce type de sociétés. La loi du 25 août 2006 (projet de loi n° 5352 dont l'objet principal est la SE) a étendu le concept de société unipersonnelle aux sociétés anonymes.

– que le capital soit **intégralement souscrit**.

Au moment de la constitution de la société, le notaire doit obtenir la preuve que le montant du capital social a été déposé sur un compte au nom de la société auprès d'une banque luxembourgeoise. À cet effet, la banque doit fournir un **certificat de blocage** à présenter au notaire, le jour de la constitution. La procédure est identique à celle suivie pour les autres sociétés (voir chapitre sur apports en numéraire, p. 139).

– un capital social de **12 000 euros**[1] subdivisé en parts sociales dont la valeur nominale, qui autrefois ne pouvait être inférieure à la valeur de 25 euros (en réalité 24,79 euros, conversion exacte du montant de 1 000 francs), n'est plus soumise à la moindre limitation légale ; la loi du 21 décembre 2006[2] a aboli le montant minimum existant auparavant. Le capital social peut être libellé dans une autre monnaie librement convertible ;

– que les parts sociales soient **entièrement libérées** au moment de la constitution de la société (art. 710-7 L.S.C.).

Par le passé, la question s'est posée si la constitution d'une S.à r.l. était pour l'associé constitutif d'un **acte de commerce**. Lors de l'élaboration de la loi du 18 septembre 1933, cette question a donné lieu à des prises de position tant de la Chambre de commerce que du Conseil d'État qui ont d'abord souligné le traitement différent de cette question dans nos deux pays voisins. Si, en France, la position était que la prise de participation d'une telle société à responsabilité limitée était un acte de commerce, il n'en allait pas de même en Belgique où l'on considérait qu'un tel acte n'avait pas cette nature[3]. Après de longues discussions dans la Chambre des députés qui avait préconisé la solution française (retenant le caractère commercial de la prise de participation dans une telle société), le Conseil d'État eut finalement gain de cause, et ceci, en ajoutant dans l'article 2, après l'énumération des six espèces de sociétés commerciales, que : « *La prise de participation dans une de ces sociétés ne constituera pas, par elle-même, un acte de commerce* »[4]. La prise de participation dans une telle société ne sera donc commerciale que si elle se rattache à une activité

1 – Fixé à ce niveau par la loi de Modernisation.

2 – Loi du 21 décembre 2006, ID 9442, *Doc. parl.*, n° 5562, ID 9971.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 15.

4 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 20.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

commerciale en tant que telle. Cette question est toutefois distincte de celle de la capacité civile requise pour être valablement associé dans une S.à r.l.

Aux termes de l'article 710-2 L.S.C., « *[e]lles peuvent être constituées pour un objet quelconque. Toutefois les sociétés d'assurances, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter cette forme* ».

L'exclusion des opérations d'assurances, de capitalisation et d'épargne est reprise du droit belge.

A – Les époux associés de la S.à r.l.

Dans la loi de 1933, la question de savoir si des époux pouvaient, soit seuls soit ensemble avec d'autres personnes, être associés dans une société à responsabilité limitée était controversée, notamment au regard de la jurisprudence de l'époque qui considérait qu'une telle société serait contraire à la puissance maritale et au principe de l'immutabilité du régime matrimonial[1]. Cette position était toutefois très critiquée par une doctrine autorisée qui insistait surtout sur le fait qu'on ne pourrait décider *a priori* si les sociétés formées entre deux époux étaient ou non valables. Aucune incompatibilité de principe n'existait entre le contrat de société et le contrat de mariage. La question de savoir s'il y avait conflit ou pas dépendrait du résultat concret de la confrontation des stipulations des deux contrats dans un cas d'espèce donné[2].

Pour ne pas se voir reprocher d'ériger la fraude en présomption irréfragable, le législateur introduisit une solution beaucoup plus nuancée dans le sens qu'il a déclaré la **validité de principe** des sociétés entre époux, même celles qui ne comprennent que les époux comme associés, mais tout en faisant exception pour le cas où les conditions du contrat de société modifient les effets du régime matrimonial entre époux.

Un tel cas d'incompatibilité existerait dans un cas proche de celui jugé par la Cour de Paris le 9 mars 1859. L'affaire portait sur une société formée entre mari et épouse où le mari, qui avait des enfants d'un premier lit, faisait, sous prétexte d'un partage des bénéfices, des libéralités déguisées excessives au profit de sa deuxième épouse[3].

B – Responsabilité des fondateurs

Une responsabilité spéciale est instituée à l'égard des « *fondateurs* », soit donc ceux qui sont les **souscripteurs** à l'acte constitutif. Il est toutefois loisible aux souscripteurs à cet acte constitutif de limiter la responsabilité de certains de ces souscripteurs, et ceci, en désignant « *comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs* » (art. 710-6 (1) L.S.C.).

---

1 – V. avis de la Chambre de commerce relatif à la loi sur les sociétés à responsabilité limitée cité par L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 44.

2 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 46.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 44. *D.P.*, 1860, II, p. 12 et Req., 7 février 1860, *D.P.*, 1860, I, p. 115.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Ces fondateurs assument une responsabilité spéciale pour ce qu'on pourrait appeler les « *vices de constitution* ».

En effet, ils sont impérativement **tenus solidairement** envers les intéressés (art. 710-6 L.S.C.) :

– de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence entre le capital minimum requis par l'article 710-5 L.S.C. et le montant des souscriptions ; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ;

– de la libération effective des parts sociales ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu des dispositions au premier tiret ;

– de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 100-18 L.S.C., soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 720-15 L.S.C. (acte de société).

Selon les auteurs de la loi belge : « *Ceux qui déclarent qu'une société qu'ils fondent est au capital d'un million de francs garantissent au public l'existence de ce capital. S'il n'y a que 500 000 francs souscrits nominativement, cette garantie implique pour eux l'obligation de fournir le surplus. Le mode le plus simple de faire exécuter cette obligation est de déclarer que les fondateurs sont de plein droit réputés souscripteurs de la partie du capital non souscrite. En rendant les fondateurs solidairement garants du versement d'un dixième sur les actions […] sans qu'ils puissent jamais se dégager de cette obligation, on a certainement un moyen efficace de s'assurer qu'il sera fait. Les fondateurs n'auront évidemment jamais intérêt à supprimer le versement, puisqu'en le supprimant ils engagent leur responsabilité* »[1].

La troisième source de responsabilité pour les fondateurs naît de l'absence ou de la fausseté des **énonciations** prescrites par les articles 420-15 et 420-17 L.S.C. ainsi que de la nullité de la société. Mais, dans ce cas, les fondateurs ne sont pas responsables pour tous les dommages naissant notamment de la nullité de la société. Leur responsabilité est limitée au « *préjudice qui est une suite directe et immédiate* » de la nullité, etc. « *On a cependant vu prétendre que, lorsqu'une société vient à faire faillite, si l'on découvre qu'une nullité vicie sa constitution, les fondateurs peuvent être condamnés à payer toutes les dettes sociales et à rembourser les mises. La conséquence d'une pareille décision serait de rendre la position des créanciers et des actionnaires meilleure dans une société nulle que dans une société valable, et d'obliger les fondateurs à réparer non seulement les conséquences de leur faute, mais celles des mauvaises opérations de la société* »[2].

La disposition commentée ici trouve sa source dans le droit commun de la responsabilité[3] et s'explique par le désir de restreindre l'obligation des fondateurs aux seules conséquences de leurs fautes, sans les obliger à réparer en outre les

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 150, ID 11305.

2 – Exposé des motifs de la loi belge, 1883, cité par A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 151, ID 11305.

3 – En l'occurrence, dans l'article 1151 C.c ainsi libellé : « Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention », ID 11695.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conséquences de faits ou de circonstances auxquels ils seraient complètement étrangers[1]. Les fondateurs sont encore responsables de la validité des mandats et de la ratification des engagements des porte-fort.

En droit commun (art. 1120 C.c.), le **porte-fort** est celui qui promet le fait d'un tiers : cette promesse consiste dans la ratification d'un acte par un tiers. Si le tiers ratifie cet acte, le porte-fort est libéré sans être garant de l'exécution[2].

En cas d'augmentation de capital, cette responsabilité est assumée par les gérants de la société.

Dans la réalité des choses, cette responsabilité est moins effrayante qu'elle ne pourrait le paraître à première vue. En effet, la constitution de la société requiert l'intervention d'un notaire qui vérifie que les conditions de souscription et de libération du capital social sont bien remplies. Faute de remplir toutes les conditions requises, la société ne sera pas constituée, et la responsabilité des fondateurs ne jouera pas. Il est vrai que, dans le cas d'apport en nature, la responsabilité des fondateurs pourra entrer en ligne de compte en cas de mauvaise évaluation des apports faits.

Selon la jurisprudence : « *L'article 184 [actuellement art. 710-7] L.S.C. institue une responsabilité des fondateurs à l'égard des tiers, mais pas d'un fondateur à l'égard de l'autre* »[3].

■ § 3 – La mise en œuvre de la responsabilité limitée

A – Les recours des créanciers des associés

Si, selon le Code civil, les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers (art. 2093 C.c.), cette disposition est fortement aménagée par la L.S.C. qui, en renvoyant dans son article 710-31 à l'article 812-10 L.S.C. (applicable aux sociétés coopératives et aux sociétés à responsabilité limitée), prévoit que : « *Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et les dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société* »[4]. Cette solution, qui est reprise du droit belge, est justifiée de la façon suivante : « *D'autre part, la société privée avec responsabilité limitée des associés est une société mixte, à la fois de personnes et de capitaux, mais dans laquelle cependant l'élément personnel domine ; les droits sociaux sont incessibles à des tiers ; on ne peut donc concevoir que les créanciers des associés puissent saisir ces droits, les faire vendre et se payer sur le prix. Ce serait permettre la cession à des tiers, cessions que la nature de la société condamne de façon absolue* »[5].

Ces mêmes commentaires ajoutent que, permettre aux créanciers de réaliser les parts des associés, reviendrait à permettre à tout associé de sortir des engagements sociaux avant l'arrivée du terme de la société. Il suffirait de laisser impayée une dette

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 87, ID 11308.

2 – CA du 17 janvier 2001, *P.*, n° 32, p. 191.

3 – TA Lux. du 30 novembre 1988, n° 571, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 154.

5 – Commentaires du Comité permanent du Conseil de la législation de Belgique, cités par L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 155.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

en priant le créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par la réalisation de sa part sociale.

Il va de soi qu'il est tout à fait envisageable que des débiteurs peu scrupuleux abusent de cette disposition protectrice de l'avoir de la société pour mettre à l'abri des poursuites des créanciers certains biens saisissables en les apportant à une S.à r.l. Heureusement, dans un tel cas, les créanciers ne sont pas sans défense.

B – Les moyens de défense des créanciers personnels des associés

L'apport de biens à une S.à r.l. dans le but de faire échapper ces biens à l'emprise des créanciers est susceptible d'être attaqué sur la base de la théorie de l'abus de droit : concrètement, le droit d'association (droit subjectif) est exercé de façon illicite, non conforme à ses objectifs[1] [2].

En dehors de cette action, il reste au créancier l'**action paulienne**, fondée sur l'article 1167 C.c., action qui permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits. La fraude doit être établie par les créanciers.

■ § 4 – Société en formation

Quant aux engagements pris pour le compte d'une société en formation, la L.S.C. contient à l'endroit des S.à r.l. des dispositions similaires à celles qu'elle comprend pour les sociétés anonymes, dans la mesure où l'article 710-7 L.S.C. déclare que « *[c]eux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements* ». Il est renvoyé au régime de la société en formation, voir p. 215.

■ § 5 – Désignation de la société

Le **caractère hybride** de la S.à r.l. se manifeste également par les dispositions concernant la désignation de la société. Traditionnellement, les sociétés de personnes étaient désignées par une **raison sociale** (comprenant les noms d'un ou de plusieurs associés indéfiniment responsables), alors que les sociétés de capitaux étaient désignées par une dénomination particulière. À l'égard de la S.à r. l., la loi a laissé aux associés le choix entre ces deux solutions en disposant : « *La société est soit qualifiée par une dénomination particulière ou par la désignation de l'objet de son entreprise, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d'un ou de plusieurs associés* ».

La Loi AIFM a supprimé toute référence à la notion de « raison sociale », et ceci, à l'égard de toutes les formes de sociétés.

Selon une jurisprudence prise sous la loi applicable avant la Loi de Modernisation, si une société à responsabilité limitée est qualifiée entre autres par une raison sociale comprenant les noms d'un ou de plusieurs associés, « *[…] il ne lui est pas permis d'y comprendre le nom de personnes qui ne font pas partie de la société. En*

1 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 157.

2 – L. Campion, *La théorie de l'abus des droits*, p. 169.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conséquence si l'un des associés dont le nom figure dans la raison sociale vient à ne plus faire partie de la société pour une cause quelconque, dont la cession de ses parts sociales, son nom doit disparaître de la raison sociale et la société est tenue de modifier le libellé de cette dernière suivant les formes prévues par la loi en ce qui concerne la modification des statuts »[(1)].

Il a été jugé que, si le gérant d'une société à responsabilité limitée accepte des traites sans faire précéder sa signature des mots « S.à r.l. », il commet une faute grave et devient personnellement responsable du paiement de ces traites vis-à-vis du tireur, lorsque ce dernier n'a pas connu l'existence de la S.à r.l. En l'espèce, le créancier ignorait qu'il avait traité avec une société à responsabilité limitée. « *Par ailleurs, il est exact que ni les virements opérés par le défendeur, ni sa signature sur les bons de livraison ne portent ou ne sont précédés de l'inscription "société à responsabilité limitée" telle que l'exige l'article 187 L.S.C. Il s'ensuit qu'en ne respectant pas les prescriptions prévues par l'article 187 L.S.C., le défendeur a commis une faute qui engage sa responsabilité dans la mesure où il doit être déclaré personnellement tenu des factures dont le paiement est réclamé* »[(2)].

Le gérant d'une S.à r.l. […] exploitant un restaurant avait signé un contrat sous la seule indication « Lu et approuvé », contrat conclu avec un fournisseur du restaurant. Le juge de paix tint le gérant comme personnellement obligé des obligations découlant de ce contrat. Le tribunal confirme cette décision, sur la base des articles 76, 77 et 78 [anciens] L.S.C. auxquels l'article 187 [ancien] de la même loi renvoie : « *En l'espèce (le sieur X, gérant de la S.à r.l.) n'ayant pas fait suivre la dénomination* […] *de la mention "S.à r.l.", et n'ayant pas non plus fait, comme l'exige l'article 78, précéder sa signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle il a agi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il était personnellement engagé par le contrat conclu avec la S.A. […] , alors qu'il n'est pas été établi en l'espèce que la S.A. […] aurait connu l'existence de la société à responsabilité limitée […] la dénomination* […] *pouvant apparaître au cocontractant comme l'enseigne d'un commerçant agissant en nom personnel* »[(3)].

Un débiteur confronté à une **saisie-arrêt** pratiquée par le gérant d'une S.à r.l. pour une créance impayée tente de faire déclarer l'irrecevabilité de la demande au motif que la saisie était faite au nom de la société, mais que le contrat avait été signé par le gérant sans indication qu'il était conclu pour la société. Ce moyen fut accueilli en première instance, mais rejeté en appel sur la base de la motivation suivante : « *[…] l'article 187 […] Le but de cette disposition est d'informer les tiers sur la vraie nature juridique de la société et de leur permettre de recueillir de plus amples renseignements. La responsabilité personnelle de celui qui agit pour la société dans un document où la prédite mention fait défaut ne sera engagée que si les tiers avec qui la société a contracté ont été réellement trompés sur la nature juridique de la société et ont subi de ce fait un préjudice. Les intimés n'affirment pas en l'espèce avoir été trompés sur la vraie nature juridique de la société ni avoir subi un préjudice de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 77 de la loi précitée* »[(4)].

---

1 – TA Lux. du 25 mars 1966, *P.*, n° 20, p. 150, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 5 mai 1994, n° 41972, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA Lux. du 28 mars 1997, n° 44.773 ; *Ann. dr. lux.*, 2001, p. 582, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA (civ.), 10 juillet 2002, n° 25835, *BIJ*, 2002, n° 1, p. 14.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

■ § 6 – Apports en nature

Conformément à l'article 184 [ancien] L.S.C. tel que modifié par la loi du 28 avril 1988, « *Les dispositions de l'article 27 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve de celles se rapportant au capital social et à l'intervention d'un réviseur d'entreprises dans la spécification des apports autres qu'en numéraire* ».

Par conséquent, il n'y a **pas d'obligation** de soumettre les apports en nature faits à une S.à r.l. à une **procédure de contrôle** similaire à celle qui existe pour les S.A. Pour plus de détails, voir à la p. 141.

SECTION II
LES PARTS SOCIALES

La différence de nature existant entre les sociétés par actions, d'une part, et les S.à r.l., d'autre part se manifeste essentiellement au niveau des parts de capital émises par ce genre de sociétés. En premier lieu, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une émission publique.

D'un point de vue terminologique, on peut retenir que : « *le droit d'associé s'appelle intérêt dans la société de personnes, action dans la société de capitaux, part sociale dans la société à responsabilité limitée, forme intermédiaire entre l'un et l'autre de ces deux types de sociétés* »[1].

Tout comme elle l'a fait pour les S.A., la Loi de Modernisation a aboli pour les S.à r.l. l'obligation pour les titres de capital d'être de valeur égale, et ceci, en supprimant à l'article 710-5 L.S.C. la mention « *[…] en parts égales […]* ». Contrairement à ce qui est le cas pour la S.A., les dispositions concernant la forme de la S.à r.l. n'ont pas précisé que, sauf stipulation contraire des statuts, chacune des parts confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente (art. 450-1 (5) L.S.C.).

Par ailleurs, la S.à r.l. ne peut toujours pas émettre de parts sans droit de vote, une proposition de permettre l'émission de tels titres prévue dans le projet de loi initial (*Doc. parl.*, n° 5730) n'ayant pas été retenue.

■ § 1 – Interdiction d'une émission publique de titres sociaux

D'après l'article 710-11 [anc. art. 188] L.S.C., il ne pourra être procédé à « *une émission publique de parts sociales ou de parts bénéficiaires* ». Cette version de cet article remonte à la Loi de Modernisation et dévie de la version antérieure en ajoutant les parts bénéficiaires, mais en retranchant les obligations. Par conséquent, depuis 2016, l'émission publique d'obligations par une S.à r.l. n'est plus interdite. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables nominatifs, au porteur ou à ordre, mais seulement par des certificats de participation à personne déterminée. Elles ne peuvent être cédées que dans les conditions de fond et de forme prévues par les deux articles ci-après.

La jurisprudence belge a retenu que ne constitue pas une ouverture d'une souscription publique la publication dans un journal quotidien d'une annonce

1 – L. METZLER, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 72.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

par laquelle le gérant d'une S.p.r.l. recherchait un associé pour développer sa société, en invitant celui-ci à apporter quatre millions de francs au moins[1]. De même, pour la doctrine, « *[R]ien ne s'oppose toutefois à ce que la société s'enquière par voie d'insertion dans les journaux de la possibilité de trouver des fonds ailleurs que dans les rangs de ses membres et de réserver aux offres de capitaux une tranche de parts nouvelles. Mais ce n'est pas là ce qu'il faut entendre par souscription publique, laquelle ne se conçoit que moyennant une procédure spéciale, qui est prévue en matière de société anonyme et qui fait défaut dans la nouvelle loi* »[2].

« *Les termes "émission publique" visent une véritable souscription de titres à créer qui n'existeront que par le fait qu'il se rencontrera des bailleurs de fonds* »[3].

Aux termes de la jurisprudence belge relative à cette matière, l'expression **souscription publique** implique nécessairement l'existence d'une société en voie de formation ou d'une société antérieurement formée désireuse d'augmenter son capital social[4]. Par conséquent, un jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles[5] acquitta l'associé d'une S.p.r.l. qui avait fait apparaître des annonces en vue de trouver un acheteur pour les parts sociales dont il était titulaire.

Qu'en est-il si la souscription de l'émission se fait à **l'intervention d'un banquier** qui souscrit la totalité de l'émission suivie par une rétrocession au public de ces titres ? En doctrine, il a été retenu que cette interdiction de l'appel public à l'épargne aurait pour conséquence également l'interdiction de la souscription privée des titres d'obligations non destinés à être répandus dans le public, mais négociables en bourse ou susceptibles de l'être. Il faudrait donc que les titres ainsi émis soient créés à personne dénommée susceptibles d'être cédés seulement par les voies de l'article 1690 C.c.[6].

La jurisprudence belge acquitta également une personne qui avait fait paraître une annonce déclarant offrir une association à toute personne possédant une voiture en vue de la constitution d'une S.p.r.l., aucun concours personnel n'était sollicité du public[7].

Dans les deux espèces visées, les juridictions retinrent que « *quelle que soit l'acception du mot "émission", elle ne peut couvrir la simple recherche d'un associé en vue de participer avec lui à la constitution ultérieure d'une société […]* »[8].

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1994, le cessionnaire est saisi à l'égard des tiers non pas seulement par la signification du transfert par acte d'huissier ou par l'acceptation par acte authentique, mais également par la simple notification du transport faite au débiteur.

---

1 – V. CA Bruxelles du 1er décembre 1970, *Rev. prat. soc.*, 1971, p. 113.

2 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 124.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 73.

4 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 356.

5 – Trib. corr. Bruxelles du 5 janvier 1960, *R.P.S.*, 1960, p. 288, confirmé par Cour de Bruxelles du 31 mars 1961, *R.P.S.*, 1961, p. 259.

6 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 74.

7 – Trib. corr. Bruxelles du 14 novembre 1961, *R.P.S.*, 1963, p. 82, confirmé par Cour de Bruxelles du 24 septembre 1962, *R.P.S.*, p. 84.

8 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 357.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

■ § 2 – Limitations des cessions de parts

Art. 710-12 [anc. art. 189] L.S.C.

« *(1) Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être cédées entre vifs à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l'agrément donné conformément à l'article 710-17 par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts sociales [...]* ».

La S.à r.l. étant par nature une société hybride (comportant donc des éléments d'une société de personnes), les parts ne peuvent être cédées à des tiers que de l'accord des autres associés (ainsi protégés contre des cessions à des personnes avec lesquelles ils ne voudraient pas être associés). La loi n'a pas voulu exiger l'unanimité des associés comme dans une société de personnes proprement dite. Dans son article 710-12 L.S.C., elle prévoit que les parts sociales ne peuvent être cédées que sous l'accord des autres associés, et ceci, en faisant une distinction entre les **cessions entre vifs** et les **cessions à cause de mort.** Selon l'article 710-12 L.S.C., les cessions entre vifs à des non-associés exigent « *l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social* ». Il en va de même des cessions de parts sociales à des non-associés pour cause de mort.

Cette disposition doit être entendue à la fois au sens large et au sens strict. Elle doit être entendue au **sens large** dans la mesure où elle vise non seulement les cessions de titres existants, mais encore l'entrée dans la société d'étrangers qui souscrivent à une augmentation de capital[1]. La disposition doit être comprise au sens strict dans la mesure où il est nécessaire de convoquer les associés en **assemblée générale** (même si, en principe, de telles assemblées ne sont pas indispensables tant que le nombre des associés n'atteint pas 60 [anc. 25] associés), ce qui leur permet d'échanger leurs vues avant de passer au vote[2].

Il est entendu que ce taux est un minimum et qu'une majorité plus forte (à la limite, l'unanimité) peut être introduite par les statuts ; la fixation d'une majorité moins élevée serait nulle[3].

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'article 710-26 L.S.C., soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Cet article, qui concerne la cession de parts soit entre vifs, soit à cause de mort à des non-associés, est une des dispositions les plus importantes du titre VII L.S.C., titre consacré aux S.à r.l. Cette disposition est le reflet du caractère fermé (*intuitu personae*) de ce type de société. Par conséquent, si **les cessions de parts entre associés restent libres** (ce qui va de soi), celles à des personnes non associées sont (comme par le passé) soumises à des **conditions d'agrément**. Les changements à

1 – L. Metzler, *op. cit.*, p. 125.
2 – L. Metzler, *op. cit.*, p. 78.
3 – L. Metzler, *op. cit.*, p. 78.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

cet article faits par la Loi de Modernisation sont nombreux et importants ; l'énumération qui en est faite ci-après n'est pas exhaustive.

La Loi de Modernisation a étendu le mécanisme d'agrément, applicable aux parts sociales, aux « ***parts bénéficiaires*** *portant droit de vote* ». En outre, les transferts de parts sociales **ne sont plus obligatoirement soumis à l'assemblée générale** des associés ; le vote en assemblée générale n'est requis que sous les conditions très exceptionnelles de l'article 710-17 L.S.C., ce qui signifie en clair que l'assemblée générale ne sera pratiquement jamais requise (seulement en cas de plus de 60 associés). L'agrément du nouvel associé requiert **l'accord de 75 % des parts sociales** (et non du capital social, comme tel est le cas pour les décisions d'associés prévues par l'article 710-18 L.S.C.), étant entendu que les statuts peuvent abaisser ce seuil jusqu'à 50 % des parts sociales au moins. La solution retenue (et décrite ci-dessous) a encore été étendue aux cas de constitution d'un **usufruit** et à la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété.

La nouvelle version de l'ancien article 189 L.S.C. (il s'agit de l'article 710-12 L.S.C.) comble une lacune de la loi ancienne : si celle-ci « *prévoyait une procédure pour les transmissions à cause de mort non agréées, cette procédure fait défaut en ce qui concerne les cessions entre vifs non agréées, de sorte qu'il convient de remédier à cette lacune par une extension de la procédure de l'article 189 de la loi de 1915 à cette dernière situation* »[1]. Par conséquent, la nouvelle version dudit article prévoit pour chaque cas de sortie (entre vifs ou à cause de mort) par un associé de la société une procédure détaillée destinée à permettre une sortie de la société tout en évitant, sauf exception, la solution extrême de la dissolution de la société. La solution finalement retenue par la L.S.C. est inspirée par l'article L. 223-13 C. com. français.

1) La cession entre vifs de parts sociales ou de parts bénéficiaires portant droit de vote : le projet de cession est **notifié à la société** (et non aux associés), l'agrément des associés détenant au moins 75 % des parts sociales est requis. Si la société (en fait, les associés) refuse de consentir à la cession, les associés peuvent acquérir ou faire acquérir les parts dans le délai de trois mois du refus à un prix fixé selon les conditions du paragraphe 3. Une solution alternative est la **réduction de capital** de la société à hauteur de la valeur nominale de ses parts et le **rachat de ces parts,** toujours au prix déterminé selon le paragraphe 3. Pour le cas où aucune des solutions envisagées par la L.S.C. ne se réalise dans les délais légaux, la cession initialement prévue peut être exécutée.
2) La **transmission pour cause de mort** « *de parts sociales ou de parts bénéficiaires portant droit de vote* » en pleine propriété ou en nue-propriété à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote nécessite l'agrément des associés détenant au moins **75 % des parts sociales des survivants**. Ce taux peut encore être abaissé à 50 % des parts sociales des survivants au moins. Sauf disposition contraire des statuts, l'agrément n'est pas requis en cas de transmission des parts sociales soit à des héritiers réservataires soit au conjoint ou partenaire survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

1 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 121, ID 10080.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les héritiers qui n'ont pas été agréés ou n'ont pas trouvé de cessionnaires qui seraient acceptables peuvent **provoquer la dissolution anticipée de la société** trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants et aux associés.

On constate donc que les cessions pour cause de mort peuvent, contrairement aux cessions entre vifs, conduire à la dissolution de la société. Pendant le délai de trois mois, les parts sociales et les parts bénéficiaires portant droit de vote peuvent être acquises soit par les associés, soit par les tiers agréés, soit par la société.

La **détermination du prix de cession** se fait par deux dispositions différentes.

– selon le **paragraphe (2)** : en cas de transmission pour cause de mort, il y a application du système traditionnel, donc le prix de rachat est fixé sur la base du bilan moyen des 3 derniers exercices (ou, le cas échéant, sur les 1 ou 2 seuls exercices écoulés de la société).
– selon le **paragraphe (3)** : en cas de cession entre vifs, les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ; en cas de désaccord sur le prix de cession, celui-ci sera fixé par le président de la chambre du tribunal d'arrondissement « *siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé* ».

Toute clause contraire aux dispositions de l'article 710-12 L.S.C. est réputée non écrite.

L'article 710-16 L.S.C. est relatif aux modalités de prise de décisions dans les assemblées générales extraordinaires, celles modifiant les statuts. Comme pour les S.A., le changement de nationalité de la société ne requiert plus l'unanimité des associés (sauf disposition des statuts exigeant une telle unanimité). L'unanimité reste toujours requise pour augmenter les engagements des associés, ce qui va de soi. Heureusement, la version définitive a amendé la formulation du projet de loi n° 5730 qui avait retenu que, dans « *aucun cas la majorité ne peut obliger un associé à augmenter sa part sociale* » (formule beaucoup plus restreinte que celle de l'augmentation des engagements).

Les autres décisions de modification des statuts sont prises par les associés représentant les trois quarts du capital social (sauf disposition contraire des statuts). La **« double majorité »** antérieurement applicable (« majorité des associés représentant les trois quarts du capital social ») n'est donc **plus exigée**, atténuant ainsi encore davantage le caractère de société hybride de la S.à r.l. pour l'aligner un peu plus sur celui de la société anonyme. La différence importante existante entre les décisions des assemblées générales dans les S.à r.l. et dans les S.A. est que, dans les S.à r.l., les décisions sont prises par les associés représentant **75 % du capital social** alors que, dans les S.A., les décisions « doivent réunir **deux tiers des voix exprimées** » (art. 450-3 (2) L.S.C.). La différence entre les deux est considérable, et elle signifie que, dans la S.à r.l., le résultat du vote ne dépend en rien de l'absentéisme éventuel à l'assemblée générale : la résolution ne peut être acceptée que si ceux qui votent en sa faveur détiennent trois quarts des parts sociales représentatives du capital social, indépendamment de la présence ou non des autres associés à l'assemblée extraordinaire. Une des conséquences de cette solution retenue par la L.S.C. est qu'en cas d'engagement de ne pas exercer ses droits de vote (art. 710-19 L.S.C.), le seuil des 75 % sera de plus en plus difficile à atteindre et, à un certain point, toute modification statutaire devient impossible…

Le troisième alinéa de cette disposition rend applicables à la S.à r.l. les dispositions des sociétés anonymes concernant le **capital autorisé** (ce qui constitue encore

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

une innovation de la Loi de Modernisation). C'est à juste titre que la doctrine s'est prononcée contre cette extension de l'institution du capital autorisé aux S.à r.l. « *En effet, il ne paraît pas possible de transposer tel quel le régime de la S.A. sur son point essentiel : la liberté pouvant être donnée à l'organe de gestion d'émettre des titres de capital à des tiers. Adopter une telle solution pour la* S.à r.l. *aurait sans doute été un pas de trop vers la dénaturation de ce type de société et son assimilation à la S.A.* »[1]. Le législateur n'a pas suivi cette remarque.

Pour les S.à r.l., la L.S.C. avant 2016 ne prévoyait pas la possibilité du capital autorisé, ce qui soulevait la question de savoir si, en l'absence de dispositions légales, une telle société peut y recourir.

La doctrine suivante, de loin antérieure à l'introduction du concept de capital autorisé dans la société anonyme, pensait que oui : « *La clause statutaire conférant à la gérance le pouvoir de procéder à l'augmentation de capital aux époques et dans les conditions qu'elle jugerait convenables, est-elle licite ? Oui, à la condition que la délégation ne soit pas générale, c'est-à-dire qu'elle soit limitée quant au montant de l'augmentation de capital à réaliser par la gérance* »[2]. En tout état de cause, la variabilité du capital est exclue (car un tel capital ne peut exister que dans la société coopérative en dehors de la forme tout à fait particulière qu'est la SICAV).

La pratique se rallie nettement à cette position en prévoyant très souvent un capital autorisé pour les S.à r.l. Dans ce cas de figure, on se rallie en général aux conditions prévues par la loi à l'égard de la S.A.

SECTION III
LES ORGANES DE LA S.À R.L.

La S.à r.l. dispose d'une structure simple convenant davantage aux petites entreprises (souvent de nature familiale) que la forme de la société anonyme. Conformément à cet objectif de simplicité, la S.à r.l. peut en outre consister une seule personne.

■ § 1 – Les assemblées des associés

Comme pour les sociétés par actions, il convient de distinguer les assemblées ordinaires de celles qui sont extraordinaires. Les indications suivantes ne trouvent pas application dans le cas des sociétés unipersonnelles où, bien entendu, il n'existe pas d'assemblées des associés.

La loi, dans son article 710-28 L.S.C., tient compte des spécificités applicables aux sociétés unipersonnelles, et ceci, en disposant que « *les articles 710-18 à 710-21 et l'article 710-26 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé* ». Une société unipersonnelle est une S.à r.l. à part entière, et les aménagements de son régime juridique sont en fait des plus limités. Pour l'essentiel, il s'agit de l'article 710-29 L.S.C. qui déclare que « *[l]'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés. Les décisions de l'associé unique prises dans*

1 – P. Reckinger et P. Schleimer, « Le régime de la S.à r.l. sous l'influence de la S.A. », *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 435.

2 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 125.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

le domaine visé à l'alinéa 1er sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales ».

L'article 710-17 L.S.C.[anc. art. 193] L.S.C. pose d'abord comme principe que les décisions des associés sont prises en assemblées générales. Ce principe est strictement appliqué pour les **décisions de modifications des statuts,** et ceci, quel que soit le nombre des associés de la société. Quant aux autres assemblées générales, celles-ci ne sont obligatoires que si le nombre des associés est **supérieur à 60**. Lorsqu'il est décidé de ne pas tenir d'assemblée générale, « *chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit* ». Il s'agit donc du système dit des « **résolutions circulaires** ».

A – Les assemblées ordinaires

Les assemblées ordinaires annuelles sont étroitement calquées sur celles des assemblées ordinaires des sociétés anonymes. En dehors de l'assemblée annuelle, il peut y avoir d'autres assemblées qui, elles, sont convoquées par les gérants.

1) Droit de convoquer l'assemblée

Art. 710-21 [anc. art. 196] L.S.C.
« *Dans les sociétés comptant plus de soixante associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l'époque fixée par les statuts.*
D'autres assemblées générales peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil de surveillance, s'il en existe un, à défaut de celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital social ».

La procédure d'approbation des comptes est encore proche de celle des sociétés anonymes. Les règles fixées par l'article 710-22 L.S.C. sont en fait largement primées par les dispositions prises postérieurement par le législateur national, actuellement pour partie reprises dans la Loi de 2002.

Les dispositions sur la **réserve légale** sont applicables, tout comme celles qui prévoient qu'il doit y avoir approbation des comptes annuels ainsi que décharge de la gérance (et, le cas échéant, du commissaire) sur la base d'un vote spécial des associés.

Le droit d'information des associés est encore assuré de la même façon que dans les sociétés anonymes (art. 710-23 L.S.C.).

2) Droit de vote à l'assemblée

Tout associé peut prendre part au vote sans que ce droit ne puisse être limité, par exemple en le subordonnant à la détention d'un nombre minimum de parts. L'associé participe au vote avec un nombre de voix exactement **proportionnel** au **nombre des parts** sociales qu'il détient. « *Le vote plural est proscrit dans les S.à r.l.* »[(1)].

1 – L. METZLER, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 113.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le droit de vote est, en principe et dans une certaine mesure du moins, un droit discrétionnaire[1]. Le droit de vote de l'actionnaire se compare au droit de vote du créancier au concordat du débiteur. Par conséquent, l'actionnaire n'est jamais tenu de prendre part au vote ni même d'assister à la réunion. En outre, il n'aura jamais l'obligation de s'abstenir lorsqu'il a un intérêt propre à la délibération[2].

La L.S.C. contient des dispositions pour les S.à r.l. qui, au moins traditionnellement (soit donc avant la loi du 25 août 2006), étaient tout à fait spéciales dans la mesure où, pour ce genre de sociétés, il est prévu la possibilité du vote par correspondance, et ceci, pour les sociétés qui n'ont **pas plus de 60 associés**. Au vœu de la loi, la consultation des associés est obligatoire dans tous les cas où le serait la convocation de l'assemblée générale, soit donc pour l'approbation annuelle des comptes, pour les autorisations à donner au gérant et pour les actes excédant ses pouvoirs[3].

Les associés doivent recevoir communication du texte de chacune des résolutions proposées à leur vote par le gérant. Dans le délai qui leur est imposé, ils répondent par écrit, par oui ou par non. « *Le résultat du vote doit être consigné au registre des délibérations ou dans un procès-verbal dressé* ad hoc*, auquel seront annexées les réponses des associés* »[4].

Selon l'article 710-18 L.S.C.[anc. art. 194] L.S.C., une décision, qu'elle soit prise en assemblée générale ou par « résolution circulaire », n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée « *par des associés représentant plus de la moitié du capital social* ». Sous réserve de stipulation contraire des statuts, si ce chiffre n'est pas atteint la première fois, une deuxième réunion ou consultation par lettres recommandées aura lieu et, à cette occasion, la décision est prise à la **majorité des votes émis**. La solution retenue à l'égard des S.à r.l. est donc très différente de celle applicable aux S.A. : dans le cas des S.à r.l., les résolutions doivent être approuvées sur la base des actions détenues par les actionnaires présents ou représentés.

L'article 710-20 L.S.C. introduit par la Loi de Modernisation a étendu aux S.à r.l. la réglementation des **conventions de vote** nouvellement introduite pour les S.A. (art. 450-2 L.S.C. au commentaire duquel il est renvoyé).

B – Les assemblées extraordinaires

De façon générale, ces assemblées sont calquées sur celles des sociétés anonymes. Est encore reprise de la S.A. la règle selon laquelle les assemblées décidant sur l'augmentation de l'engagement des associés requièrent **l'unanimité** des voix. Les autres modifications des statuts sont, sauf stipulations contraires, décidées à la **majorité** des **associés** représentant les **trois quarts du capital** social[5]. Ainsi se trouvent amalgamés des éléments de sociétés de personnes (le vote par tête) avec ceux des sociétés de capitaux (le vote par parts sociales). Il est à noter qu'aucune référence n'est faite au **capital présent** ou représenté, de

1 – F. T'Kint, « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, p. 242.

2 – Sur ce point, le droit français prévoit des solutions différentes, v. art. 103 et 145 de la loi du 24 juillet 1966.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 113.

4 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 113.

5 – Art. 199 [ancien] L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

sorte que la majorité requise est celle du capital **émis** (et non celle qui plus ou moins accidentellement est présente ou représentée à une assemblée générale des associés).

Dans une espèce où un associé, n'ayant pu assister à l'assemblée générale, se plaignait de ne pas avoir reçu, préalablement à la tenue de l'assemblée, les textes proposés de résolutions et le projet de modification des statuts, le tribunal trancha comme suit : « *[…] force est de constater que l'article 193 [art. 710-17] de la loi sur les sociétés commerciales ne prévoit l'exigence d'une communication du texte des résolutions ou des décisions à prendre que pour les cas de figure du vote par écrit admis pour les assemblées générales de sociétés à responsabilité limitée au nombre d'associés inférieur à 25. Aucune autre disposition légale concernant les assemblées générales de sociétés à responsabilité limitée ne prévoit la nécessité d'une communication préalable des résolutions à prendre* »[1].

En cas de réduction de capital par remboursement aux actionnaires de leurs apports dans une société anonyme, aucun paiement ne peut être effectué avant l'expiration d'un délai de trente jours à compte de la publication de la décision de l'assemblée générale de réduire le capital (art. 450-5 L.S.C.). Cette période d'attente n'existe pas pour la société à responsabilité limitée.

C – Délégation des pouvoirs des associés

Si la version définitive L.S.C. faisant suite à la Loi de Modernisation est inchangée par rapport à celle de l'article 202.-2 L.S.C., le projet de loi n° 5730 avait prévu d'innover en précisant que l'associé unique peut déléguer les pouvoirs attribués à l'assemblée générale, ce qui était contraire tant à la loi belge (art. 267 Code belge des sociétés) que française (art. 1223-31 C.com.) qui interdisent justement toute délégation. La version définitive ne reprend pas la possibilité de délégation, ce qui nous ramène à la case de départ (c.-à-d. à la situation où la loi est muette sur la question). Le Conseil d'État s'est demandé si une telle précision était nécessaire, « *car la délégation de pouvoirs est de droit en matière civile et commerciale, sauf certaines restrictions attachées aux personnes* »[2]. Cette question est de peu d'intérêt pratique, la charge de travail de l'associé n'étant pas si absorbante qu'elle requière une délégation, contrairement, par exemple, à la gestion journalière d'une entreprise opérationnelle d'une certaine importance.

■ § 2 – L'organe de gestion

Aux termes de l'article 710-14 L.S.C. : « *les [S.à r.l.] sont gérées par un ou plusieurs mandataires, associés ou non, salariés ou gratuits. Ils sont nommés par les associés, soit dans l'acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. Sauf stipulations contraires des statuts ils ne sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes* ».

1 – TA Lux. du 29 janvier 1999, n° 47.813, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – *Doc. parl.*, n° 5730/4, p. 37, ID 13321.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

A – Pouvoirs du gérant

Comme dans toutes les sociétés ayant un (ou des) organe(s) de gestion, il se pose dans la S.à r.l. la question de savoir comment se **répartissent les pouvoirs entre l'assemblée des associés et l'organe de gestion**. La solution est donnée par l'article 710-14 L.S.C. qui dispose que, sauf dispositions contraires des statuts, chaque gérant peut faire tous les **actes nécessaires ou utiles** à l'objet social, sauf ceux que la loi réserve aux associés. En d'autres termes, les pouvoirs légalement attribués aux associés ne peuvent pas être limités. En revanche, les statuts pourraient augmenter le nombre d'actes qui relèvent de la compétence des associés en diminuant ainsi le domaine de compétence des gérants. En outre, les statuts pourraient prévoir que les gérants doivent agir en commun pour l'accomplissement de leurs actes.

À l'instar des administrateurs de la société anonyme, les gérants sont nommés par les associés soit dans l'acte de société, soit dans un acte postérieur. Contrairement à la situation des administrateurs de la société anonyme, leur mandat ne connaît pas légalement de limitation de durée obligatoire. Sauf stipulations contraires des statuts, ils ne sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes.

Les gérants ont le pouvoir d'accomplir tous les **actes nécessaires ou utiles** à l'accomplissement de l'objet social, « *sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés* ». En outre, chaque gérant **représente** la société à l'égard des tiers et en justice, en demandant ou en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci ne sont pas nécessairement groupés en conseil d'administration (pas de caractère collégial obligatoire). Quant aux limitations statutaires des pouvoirs des gérants, les solutions sont identiques à celles prévues pour les sociétés anonymes dans la mesure où « *les restrictions apportées aux pouvoirs des gérants par les statuts ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées* ». En revanche, le **pouvoir de représentation** de la société peut valablement être confié à un (ou plusieurs) gérant(s), et cette délégation est opposable aux tiers sous condition de publication.

Le gérant (tout comme le conseil d'administration de la société anonyme) engage la société même pour les **actes excédant l'objet social,** à moins que la société « *ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve* ». Cette règle est absolument identique à celle prévue en matière de sociétés anonymes.

La responsabilité des gérants est encore calquée sur celle des administrateurs de la société anonyme (art. 710-16 L.S.C.), ce qui signifie qu'ils sont responsables à l'égard de la société pour l'exécution fautive de leur mandat (*actio mandati*) tout en subissant une responsabilité solidaire envers la société et envers les tiers en cas de violation des dispositions légales et des statuts.

Avant la Loi de Modernisation, il n'existait pas dans les S.à r.l. de disposition correspondant à l'article 441-10 L.S.C. qui, dans les S.A., permet d'accorder la **gestion journalière** (et la représentation relativement à cette gestion journalière) à une ou plusieurs personnes. Dans une S.à r.l., une telle délégation n'est donc possible que si les statuts l'autorisent ; en outre, le délégué à la gestion journalière n'est pas un organe de la société, mais un simple mandataire[1].

1 – J. VAN RYN et P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 360.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

À la suite de la Loi de Modernisation, l'article 710-15 [anc. art. 191*bis*] L.S.C. a introduit la faculté pour les statuts de prévoir que, en cas de **pluralité de gérants**, ceux-ci forment un collège. Lorsque cette faculté est exercée, elle n'a pas pour effet d'assimiler la situation de la S.à r.l. (avec collège de gérants) au conseil d'administration de la société anonyme dans la mesure où, dans la S.à r.l., les limitations aux pouvoirs des gérants ont un **effet purement interne**. Cette conclusion résulte directement de l'article 9, 2, de la Première directive : « *Les limitations aux pouvoirs des organes de la société, qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents, sont toujours inopposables aux tiers, même si elles sont publiées* »[1].

Le paragraphe 4 introduit par la Loi de Modernisation qui étend aux S.à r.l. la solution prévue autrefois pour la S.A. (anc. art. 60 L.S.C.) permet de prévoir la **délégation de la gestion journalière** (et la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière) à un ou plusieurs gérants, directeurs, etc. « agissant seuls ou conjointement ».

Les actes réservés par la loi aux associés sont essentiellement les suivants : la **nomination** et la **révocation** des organes sociaux, **l'approbation** des **comptes** dans le cadre des décisions annuelles prévues par les statuts, les modifications des statuts sociaux.

B – Le mandat du gérant

Le mandat est **gratuit** à moins qu'il n'y ait convention contraire (art. 1968 C.c.). Il va sans dire que, la plupart du temps, le mandat sera rémunéré ; « *[…] la rémunération consistera en un traitement fixe, porté aux frais généraux, ou dans une part des bénéfices sociaux, ou encore dans une combinaison de ces deux éléments* »[2].

Il est encore non contesté que la gérance puisse être assumée par une société.

C – Statut du gérant

Une question de grande importance pratique est celle du statut du gérant de la S.à r.l. au regard du droit privé, de la sécurité sociale et du droit fiscal. Concrètement, la question est de savoir s'il s'agit d'un salarié ou d'un mandataire. L'on sait que le critère distinctif essentiel du contrat de travail est le **lien de subordination**. On peut envisager la situation par analogie avec celle de la société anonyme[3] : « *directeur-gérant d'une société commerciale, agissant conformément aux décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration : ce dernier a la qualité de mandataire non de salarié* »[4].

La pratique au Luxembourg est fermement arrêtée dans la mesure où le gérant se voit soumis à un contrat de travail et, à ce titre, bénéficie d'un salaire comportant donc essentiellement une rémunération fixe (indépendante donc du bénéfice de la société), le cas échéant complétée par une rémunération variable tenant dans une

1 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 127, ID 10080.

2 – L. METZLER, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 88.

3 – CA du 14 juin 1929, *P.*, n° 12, p. 137, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – L. METZLER, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 93.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

certaine mesure au moins compte de la *profitabilité* de la société. Selon la jurisprudence : « *C'est à tort que le gérant d'une société à responsabilité limitée soutient avoir la qualité d'ouvrier au sens de la loi, alors qu'il est établi en cause qu'en sa qualité de gérant-associé de la société il prend part aux délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et participe aux pertes et bénéfices de la société. Le fait que les parts sociales détenues par le gérant soient inférieures à celles du co-associé ne confère pas au gérant la qualité de subordonné par rapport au co-associé. Pour le surplus, le fait de percevoir un salaire ne suffit pas non plus à conférer aux relations de travail la nature d'un contrat d'emploi* »[1]. Et encore : « L'associé gérant statutaire d'une société à responsabilité limitée ne se trouve *pas dans une situation de subordination […] une certaine inégalité des droits entre les associés ne permet cependant pas de conclure à l'existence d'un lien de subordination. Le lien de subordination ne résulte pas non plus de la révocabilité du gérant par l'assemblée générale […] Par ailleurs, si le gérant se trouve dans un état de dépendance à l'égard de la société, en ce sens qu'il doit rendre compte de sa gestion à l'assemblée générale, cette obligation découle de son mandat social […]* »[2].

Les auteurs envisagent la situation d'un gérant qui, aux termes des limitations introduites dans les statuts, serait cantonné à des décisions tout à fait subalternes, les décisions de quelque importance étant réservées aux associés. Dans un tel cas de figure, les juridictions du fond apprécieraient souverainement s'il y a ou non lien de subordination[3].

Une autre question qui se pose dans ce contexte est celle de savoir sous quelles conditions le ou les gérants sont autorisés à s'adjoindre des fondés de pouvoir. De telles délégations sont possibles, mais la signature sociale ne peut leur être attribuée que si les statuts l'autorisent. « *Si la société est libre de nommer des employés, elle ne peut leur conférer la signature sociale que si les statuts l'y autorisent. La nomination de fondés de pouvoir doit émaner de l'assemblée des associés* »[4]. C'est cette assemblée qui restreint les pouvoirs ainsi attribués de la manière dont elle l'entend.

L'arrêt de la Cour d'appel du 3 mars 2011[5] retient d'abord, de façon non surprenante, que le contrat de travail s'analyse en substance comme composé de trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination.

« *La doctrine et la jurisprudence française ont dégagé deux critères qui permettent d'admettre qu'il y a cumul entre un contrat de travail et un mandat social, à savoir d'une part, des fonctions et des rémunérations distinctes, et, d'autre part, un lien de subordination, c.à.d. un contrôle continu, générateur de dépendance exercé par la société sur la personne qui se prétend salarié (cf. Jurisclasseur, Travail, Vol. I, Fasc. 2-14, n°s 32 et s).*

La réalité des fonctions distinctes est rarement admise dans une entreprise de petite taille. Les fonctions sociales auront une inévitable tendance à absorber

1 – C. prudh. Esch-sur-Alzette, 9 février 1984, *LJUS*, n° 98404669.

2 – C. arb. Lux. du 17 janvier 1986, *LJUS*, n° 98608127.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 93.

4 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 93.

5 – Arrêt de la Cour d'appel du 3 mars 2011. Exempt – appel en matière de droit du travail, n° 35701 du rôle, ID 15973.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

*les fonctions salariales, par, notamment, l'atténuation, voire la disparition, du lien de subordination, cette hypothèse valant essentiellement pour les sociétés à responsabilité limitée. Le plus souvent, les fonctions salariales antérieures sont absorbées par le mandat social lorsque le salarié est nommé gérant (*op. cit. *n° 43).*

*Le dirigeant qui exerce l'ensemble de ses activités, y compris ses fonctions techniques, en toute indépendance et en vertu de pouvoirs de direction dont il a été investi, sans être soumis aux instructions de la société, ne peut prétendre au maintien de son contrat de travail (*op. cit. *n° 48).*

*Certains auteurs admettent que dans une société à responsabilité limitée le gérant ne peut jamais exercer de fonctions subordonnées puisqu'étant personnellement titulaire du pouvoir hiérarchique du chef d'entreprise, il se trouve même, dans l'exercice de ses éventuelles fonctions techniques, affranchi de toute subordination envers un autre que sa propre personne. En la matière, la Cour de Cassation française se montre fréquemment hostile à admettre la réalité du cumul. Une telle solution est manifestement justifiée dans l'hypothèse d'une entreprise dont l'activité consiste en des opérations d'achats-ventes et où les directions commerciale et générale se confondent inévitablement (*op. cit. *n° 52).*

Dans la société à responsabilité limitée Pro-Immo Nord l'appelant C.) était salarié en qualité d'agent commercial à partir de mars 2006. Par acte notarié du 14 juillet 2006, G.), qui était à ce moment-là gérant administratif de la société, a cédé à C.) les 25 parts sur 100 qu'elle détenait dans la société et elle a été déchargée de la gestion administrative, qui a été confiée à partir de cette date à C.).

Ce dernier était gérant administratif et associé, tout en maintenant son statut de salarié, de la société Pro-Immo Nord. Monsieur T.), également détenteur de 25 parts sociales, remplissait la fonction de gérant technique. Les statuts de la société n'ont pas clairement déterminé les pouvoirs incombant à chacun des deux gérants. Il y est seulement précisé qu'à l'égard des tiers ils ne peuvent engager la société que par leurs signatures conjointes.

Au vu des pièces du dossier et des explications fournies par les parties la Sàrl Pro-Immo Nord est une agence immobilière, même si son objet social tel que défini par les statuts englobe l'exploitation d'une entreprise de construction. Il y a lieu d'admettre, à défaut de tout élément d'appréciation fourni à ce sujet par les parties, qu'une agence immobilière établie à Wiltz, est une entreprise de taille réduite dont il est loin d'être établi qu'à part les deux gérants, elle employait des salariés. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier si C.) touchait une rémunération du chef de sa fonction de gérant administratif. Par ailleurs, à part un compromis de vente signé le 20 novembre 2006, C.) n'a pas établi avoir exécuté une quelconque activité d'agent commercial pour le compte de la partie intimée. En outre, même si tel avait été le cas, il y aurait lieu d'admettre que dans une petite agence immobilière, les fonctions de direction et les fonctions commerciales se confondent. Mais en tout état de cause, C.) est resté en défaut de prouver qu'en tant que salarié, il se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis d'un organe de direction de la société Pro-Immo Nord.

Il faut déduire de ce qui précède que C.) n'était pas à considérer comme salarié de la sàrl Pro-Immo Nord au moment de son licenciement, de sorte que la Cour, par réformation du jugement entrepris, doit se déclarer incompétente ».

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

D – Le mandat du gérant

Le gérant est nommé soit par les statuts, soit par un acte postérieur. L'acte postérieur est un acte pris à la majorité simple du nombre des parts sociales (voir art. 710-18 L.S.C.). L'inconvénient de la solution consistant en une **nomination par les statuts** est que tout changement de gérant requiert une modification du pacte social, ce qui demande donc un acte notarié actant la décision prise à la majorité spéciale requise. En même temps, cette procédure plus lourde peut constituer une protection voulue pour le gérant en place.

1) Cessation des fonctions

Les fonctions du gérant prennent fin par l'**arrivée du terme** pour lequel il est nommé, par la survenance d'un empêchement propre (décès, incapacité), par la **révocation** ou encore par sa **démission**.

Les conditions de révocation des gérants peuvent faire l'objet de clauses statutaires, ce qui, en général, ne sera pourtant pas le cas. Sauf dispositions contraires, ils ne sont révocables que pour des causes légitimes, et ceci, quel que soit leur mode de désignation (art. 710-14 L.S.C.).

L'action en **révocation** du gérant est en principe une **action sociale** appartenant à la collectivité des associés, et non une action appartenant aux associés *ut singuli*[(1)].

La jurisprudence fait exception à cette dernière règle pour le cas où la société ne se compose que de deux associés à parts égales, dont l'associé gérant. L'associé d'une société à responsabilité limitée a le droit d'agir individuellement en révocation du gérant et, dans ces conditions, l'avis d'une assemblée générale n'assurerait aucune majorité de voix en vue d'intenter une action sociale. Pour les mêmes motifs, il n'est pas besoin de mettre en cause la société elle-même, lorsqu'il n'est pas justifié, par l'une des parties d'un intérêt à cette mise en cause[(2)].

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits susceptibles de constituer des motifs légitimes de révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée.

Selon l'article 710-14 L.S.C., les gérants ne sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes. « *[…] ces faits devant, par eux-mêmes, être probants et présenter un caractère de gravité suffisant pour légitimer une mesure pouvant avoir des répercussions sur la vie et même sur l'existence de la société […]* »[(3)].

Le gérant statutaire d'une S.p.r.l. peut renoncer à son mandat par la simple notification de sa démission à la société. Telle fut la décision de la Cour de cassation belge[(4)] qui cassa un arrêt de la cour de Gand décidant que le mandat du gérant statutaire faisait partie du pacte social et que, par conséquent, l'acceptation de sa décision devait réunir la majorité requise pour modifier les statuts.

---

1 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 89.

2 – CA du 20 mars 1991, nº 11.451, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA Lux. du 4 mars 1970, *P.*, nº 21, p. 398, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cass. b. du 27 juin 1969, *R.P.S.*, 1971, note J.-M. Nélissen, p. 233.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Une autre question qui se pose dans ce contexte est celle de savoir si la démission, une fois notifiée à la société, peut être retirée. En principe, la réponse est négative : les **actes unilatéraux** sont **irrévocables**, ceci ne préjugeant pas de la possibilité pour l'assemblée d'accorder un nouveau mandat au gérant[1].

Une question d'une certaine importance pratique est celle de savoir si la **démission** d'un gérant doit être **acceptée** (par la société) pour devenir juridiquement effective. Tel n'est pas le cas. La démission est un acte unilatéral qui n'a pas à être acceptée par l'assemblée générale des associés. Cette solution est unanimement acceptée[2].

En ce qui concerne la **révocation** du gérant, certaines décisions ont admis que l'action puisse être introduite par un associé agissant individuellement dans le cadre d'une société où chaque associé, dont le gérant, détenait 50 % des parts et où, partant, il aurait été inutile de convoquer une assemblée générale qui n'aurait pu réunir aucune majorité[3].

Contrairement aux administrateurs de la société anonyme, le gérant de la S.à r.l. n'est pas révocable *ad nutum*, mais les statuts peuvent déroger à cette règle (« *sauf stipulation contraires des statuts* ») en prévoyant donc que les gérants sont révocables sans avoir à justifier de raisons (en s'alignant donc sur la solution prévue impérativement pour la S.A.) ce qui, en pratique, est souvent le cas.

En dehors de ce cas, la révocation d'un gérant peut donner lieu à une obligation à des dommages-intérêts de la part de la société à son gérant.

2) Cumul du mandat avec un contrat d'emploi

Le gérant statutaire, associé et membre fondateur d'une S.à r.l., n'est pas admis à revendiquer être dans les liens d'un contrat d'emploi au motif, d'une part, que sa qualité d'associé exclurait le lien de subordination caractérisant le louage de services (les associés n'étant pas subordonnés les uns aux autres). D'autre part, le fait pour l'intéressé de percevoir un salaire ne suffit pas non plus à lui faire acquérir le statut recherché[4].

Cette question rejaillit sur le problème du **cumul** du mandat de **gérant** d'une S.à r.l. et d'un **contrat d'emploi.** Dans une espèce où le gérant unique détenait par ailleurs un cinquième des parts de la société, le tribunal lui refusa la qualité d'employé sur la base des considérations suivantes : « *S'il n'y a qu'un seul gérant, qui par surcroît est encore associé de la société, qu'il représente […] , il est inconcevable qu'il soit le préposé de la société dont il est l'unique organe ; le rapport de subordination est évidemment exclu en pareil cas : on ne conçoit pas qu'une personne puisse se donner des ordres à elle-même (cf. Van Ryn, Droit commercial belge, tome 2, n° 933). En l'espèce la gérante qui revendique la qualité d'employée privée n'a pas démontré que ses activités de gérante se différenciaient de celle d'employé et qu'elle se trouvait dans un lien d'autorité et de subordination caractéristique du contrat de travail […]* »[5].

1 – Cass. b. du 27 juin 1969, *R.P.S.*, 1971, note J.-M. Nélissen, p. 236.

2 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, n° 589, p. 387 ; C. Resteau, *Traité des sociétés anonymes*, T. 2, p. 80.

3 – TA Lux. du 4 mars 1970, P., n° 21, p. 398, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC) ; TA Lux. du 23 mars 1995, ID 10230.

4 – TA Lux. du 19 décembre 1986, jgt n° 490/86, ID 12003.

5 – TA Lux. du 30 octobre 1987, jgt commercial n° 425/87, ID 12040.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« *[…] pour qu'un gérant cumulant les qualités de mandataire et d'employé au service de la même société soit considéré comme exécutant son contrat sous l'autorité de la société, trois conditions sont requises : […]*

1) la société à responsabilité limitée doit être pourvue d'un conseil de gérance apte à exercer sur le gérant-directeur administratif l'autorité requise pour que celui-ci soit lié à la société par un lien de subordination ;

2) les pouvoirs conférés au gérant doivent être limités ; que cette condition implique que l'intéressé soit privé de pouvoirs importants ;

3) le gérant doit détenir une participation minoritaire dans la société »[1].

Un des gérants d'une S.à r.l. réclamait un « *salaire* » qui lui était versé de juin 1984 à avril 1985 en raison de la prospection des marchés étrangers qu'il effectuait. Les défendeurs contestaient l'existence d'un mandat salarié pour la période se situant au-delà d'avril 1985, date à partir de laquelle la société a cessé en fait son activité commerciale (mise en liquidation survenant ultérieurement) : « *L'article 1986 du Code civil dispose que le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. Il appartient donc aux gérants, en cas de contestation, d'établir par les statuts, l'acte de nomination, ou de toute autre manière, le principe et le mode de la rémunération […]. En l'espèce, il ne résulte ni des statuts de la société, qui d'ailleurs ne prévoient pas de mandat salarié du gérant, ni de l'acte de nomination du gérant, ni d'une autre pièce versée en cause que les associés ont alloué à […] une rémunération mensuelle brute de […]. Le paiement par la société d'un émolument à […] de juin 1984 à avril 1985 […] n'est pas de nature à établir le principe et le mode de rémunération du gérant arrêtés par les associés après le mois d'avril 1985, date à laquelle […] la société […] a cessé en fait son activité commerciale, de sorte que […] n'a plus en fait exercé le mandat qui lui a été confié* »[2].

La question de l'existence d'un contrat de travail dans le chef d'un gérant de S.à r.l. par ailleurs associé de cette même société est laissée ouverte par le juge (le cumul est admis à condition que le contrat de travail ait un caractère sérieux, c'est-à-dire qu'il corresponde à une fonction réellement exercée caractérisée par un lien de subordination et qu'il ne soit pas une « *apparence destinée à tourner les dispositions d'ordre public concernant la révocabilité* ad nutum *des mandataires sociaux* »), une comparution personnelle des parties étant ordonnée en vue de leur permettre de s'expliquer sur la nature de leurs relations[3].

Un gérant statutaire associé et membre fondateur n'est pas admis à invoquer un contrat d'emploi. Ici, c'est la situation **d'associé majoritaire** de l'intéressé qui est considérée comme exclusive du lien de subordination qui est de l'essence du louage de services. Ici encore la perception d'un « salaire » est indifférente[4].

« *Le cumul entre les fonctions de gérant de S.à r.l. et celles de salarié de cette société est possible à condition que ces dernières correspondent à un emploi effectif en contrepartie duquel l'intéressé reçoit une rémunération et que, dans leur exercice, il soit dans un état de subordination à l'égard de la société. Lorsque le gérant d'une société à responsabilité limitée était, avant sa nomination, lié à celle-ci par un contrat*

1 – Trib. arb. Lux. du 13 juillet 1989, jgt n° 2419.

2 – TA Lux. du 26 janvier 1990, n° 38934, ID 12024.

3 – Prés. Trib. trav. Lux. (réf.), 17 janvier 1992, n° 272/92.

4 – TA Lux. du 28 février 1992, jgt n° 62/91, ID 12033.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de travail et qu'il a continué par la suite à recevoir son salaire, c'est à la société qu'il incombe d'apporter la preuve que ce contrat a été résilié ou nové, en établissant qu'à partir de sa nomination, les activités de l'intéressé n'ont été que celles d'un gérant »[1].

Le tribunal refuse le caractère privilégié au titre des salaires impayés d'une créance déclarée dans le cadre de la faillite d'une S.à r.l., au motif que le prétendu « salarié » était associé et gérant unique de la S.à r.l., tout lien de subordination étant alors exclu « *alors que (l'intéressé) était en fait et en droit seul maître des affaires menées par la S.à r.l.* »[2].

Par le passé, la question de savoir si les S.à r.l. pouvaient ou non distribuer des **acomptes sur dividendes** était controversée[3]. Le nouvel article 198*bis* introduit par la Loi de Modernisation coupe court à toute controverse en copiant simplement le régime des acomptes sur dividendes prévu pour les S.A. Intrinsèquement, un acompte sur dividende comporte deux caractéristiques distinctives par rapport aux distributions ordinaires de dividendes : en premier lieu, il s'agit d'une **délégation des associés à l'organe de direction** l'autorisant à distribuer un dividende et, en deuxième lieu, un dividende qui peut également inclure le résultat de l'exercice en cours (ou plus précisément du résultat de l'exercice ou des exercices non encore approuvés par les associés)[4].

La procédure mise en place (copiée sur celle de la S.A.) précise que « *le commissaire ou le réviseur d'entreprises, s'il y en a* » vérifie si les conditions prévues par la loi sont remplies. Si la S.A. est nécessairement toujours dotée d'un commissaire ou d'un réviseur d'entreprises, tel n'est pas le cas pour les S.à r.l. qui, la plupart du temps, n'ont ni l'un ni l'autre. Rien que pour procéder au paiement d'un acompte sur dividendes, la S.à r.l. devra donc avoir recours à un commissaire (ou réviseur d'entreprises) – ce qui constitue donc un alourdissement par rapport à la pratique antérieure[5].

La directive 2012/30/UE impose uniquement un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants tout en restant muet sur un éventuel contrôle. Par conséquent, on aurait pu faire abstraction du contrôle de cet état soit par le réviseur soit par le commissaire. En effet, les distributions ordinaires des dividendes des S.à r.l. qui n'ont ni commissaire ni réviseur d'entreprises sont faites sur la base d'états comptables (de bilans donc) non contrôlés. Pourquoi faudrait-il être plus sévère en cas de distribution d'acompte sur dividendes ?

■ § 3 – L'organe de contrôle

Les fonctions de commissaires ne sont exercées que de manière plus ou moins exceptionnelle dans les sociétés à responsabilité limitée, et ceci, pour deux raisons.

1 – CA du 17 décembre 1992, n° 13.470, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 14 novembre 1997, jgt commercial n° 716/97, faillite n° 170/9, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – P. Reckinger et P. Schleimer, « Le régime de la S.à r.l. sous l'influence de la S.A. », *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 436.

4 – Ceci ne serait pas possible pour un dividende ordinaire décidé par l'assemblée des actionnaires.

5 – P. Reckinger et P. Schleimer, « Le régime de la S.à r.l. sous l'influence de la S.A. », *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, 2016, p. 436.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

D'une part, les sociétés visées n'ont légalement besoin d'un commissaire que si la société compte **plus de 60 associés** (plus de 25 avant 2016). Compte tenu du fait qu'une S.à r.l. ne peut avoir plus de 100 associés (40 avant 2016), il sera plutôt rare d'avoir affaire à une telle société. Ces sociétés ont en général un nombre très réduit d'associés, souvent un seul. En deuxième lieu, la fonction de commissaire n'existe pas dans l'hypothèse où la société dépasse certains **seuils** d'importance exprimés en termes de chiffre d'affaires, de somme du bilan et du nombre de salariés (voir p. 397).

Les fonctions de commissaires (comme celles de gérant) ne sont pas incompatibles avec la qualité d'associé de la société.

Comme pour les gérants, **aucun terme** maximal n'est prévu pour le mandat des commissaires. Les dates de réélection sont librement déterminées par les statuts. « *Les pouvoirs des membres du conseil de surveillance et leur responsabilité sont déterminés par l'art. 443-2, alinéas 1 et 3 de la loi* ».

Les commissaires sont-ils révocables *ad nutum* ? La question semble controversée[1].

SECTION IV
DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA S.A.

La forme de la société anonyme a fait l'objet de développements très étendus ci-dessus. Il peut être utile pour le lecteur de rappeler quelques-unes des principales différences qui peuvent exister entre ces deux formes de sociétés qui, du moins selon notre terminologie, font toutes les deux parties de la famille des sociétés de capitaux – même s'il est vrai que cette qualification peut être mise en doute pour la S.à r.l.

Le capital de la société à responsabilité limitée doit être libéré en totalité lors de la constitution (art. 710-6 L.S.C.), alors que les actionnaires d'une société anonyme peuvent différer la libération de trois quarts de la valeur des actions qu'ils détiennent (art. 420-1 L.S.C.). Le nombre d'associés d'une société à responsabilité limitée doit être compris entre 1 et 100, alors qu'il n'y a aucune limite supérieure pour la société anonyme. Qu'en est-il en cas de dépassement de ce maximum ? Selon la doctrine, la violation de la disposition légale ne donne pas directement lieu à une action en dissolution, mais elle pourrait être invoquée à l'appui d'une action en dissolution judiciaire fondée sur l'article 1200-1 L.S.C.[2].

Les **apports en nature** à une société anonyme doivent faire l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprise (art. 420-10 L.S.C. lors de la constitution et 420-23 L.S.C. lors d'une augmentation de capital). Une telle obligation n'existe pas dans le cas d'une société à responsabilité limitée.

La société à responsabilité limitée n'est pas autorisée à émettre des parts **sans droit de vote** (art. 710-19 L.S.C.) ou des parts au porteur (art. 710-11 L.S.C.).

Selon l'article 710-19 L.S.C. introduit par la Loi de Modernisation qui reprend pour la S.à r.l. la solution prévue pour la S.A., les statuts peuvent autoriser les gérants à **suspendre les droits de vote** de tout associé qui est en défaut de remplir ses

1 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 134.

2 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, p. 37.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription. Une autre innovation de la Loi de Modernisation est encore copiée sur la solution prévue pour les S.A. (art. 450-1 (9) L.S.C.) : tout associé peut, à titre personnel, **s'engager à ne pas exercer ses droits de vote** temporairement ou définitivement, en tout ou en partie. Une telle renonciation lie l'associé renonçant et s'impose à la société dès la notification à cette dernière.

Les parts d'une société à responsabilité limitée ne sont pas librement cessibles. Une cession doit être préalablement approuvée par l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts. Ensuite, la cession doit être notifiée à la société (art. 710-12 L.S.C.).

Une société à responsabilité limitée ne peut procéder à une émission publique de parts sociales (art. 710-11 L.S.C.).

Par le passé, il n'était pas certain qu'une société à responsabilité limitée soit autorisée à **racheter ses propres parts**. La Loi de Modernisation a mis fin à toute hésitation sur ce point en prévoyant dans son article 710-5 L.S.C. la possibilité de racheter ses parts sociales propres.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE II*bis*
LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SIMPLIFIÉE (S.À R.L.-S)

Cette variante de la société à responsabilité limitée (dont la dénomination est obligatoirement suivie par la mention « *société à responsabilité limitée simplifiée* » ou « S.à r.l.-S » a été instituée par la loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Cette loi de 2016 a prévu **l'entrée en vigueur retardée** des dispositions de ladite loi jusqu'au 16 janvier 2017, de sorte que ce genre de société n'a pu être constituée qu'à partir de cette dernière date.

Ce type de société est en principe soumis aux dispositions d'une S.à r.l. classique sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre VII L.S.C. contenant les articles 720-1 à 720-6 L.S.C. (six articles en tout).

Contrairement à ce que sa désignation laisse entendre, les avantages de ce type de société se situent non pas au niveau de la simplification (celle-ci étant inexistante ; toutes les dispositions de la S.à r.l. étant applicables, l'élément particulier d'où pourrait venir la simplification[1] est mystérieux), mais uniquement au nouveau du **coût de leur constitution** : en premier lieu, la constitution peut se faire par acte sous seing privé (art. 100-4 L.S.C.) en permettant donc de faire l'économie des coûts de l'acte notarié de constitution. En outre, le **capital social minimum** est fixé à un montant qui « doit être compris entre 1 euro et 12 000 euros » (art. 720-4 L.S.C.). Si le plafond ainsi fixé est dépassé, il incombe aux associés de changer le statut de la société en S.à r.l. classique (dont le montant de capital minimum est ainsi atteint)[2].

En contrepartie de ces avantages, il existe des **contraintes spécifiques** qui n'existent pas pour les S.à r.l. classiques (et qui, plutôt que de conduire à la simplification, conduisent à la complication considérable de ce régime). Ceci concerne en particulier l'objet social de la société. Seules les activités rentrant dans le champ d'application de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peuvent être exercées par la S.à r.l.-S. La référence à cette loi du 2 septembre 2011 exclut donc notamment les activités de pure gestion de fortune (du genre de celles de prise de participation dans d'autres sociétés, détention d'immeubles, etc.).

1 – Il est vrai que la S.à r.l. simplifiée peut être constituée par acte sous seing privé, simplification qui est plus que compensée par d'autres dispositions spécifiques à ce type de société.

2 – Si l'exposé des motifs du projet de loi (*Doc. parl.*, n° 6777, p. 6, ID 22920) estime le coût de constitution de la S.à r.l. S à 191 euros et ceux de la S.à r.l. classique à 13 000 euros. Cette comparaison est intenable pour la raison qu'elle traite le capital social minimum de 12 000 euros comme « coûts » de constitution. Or, tel n'est pas le cas : l'argent qui sert à libérer le capital constitue une réserve qui sert à payer les frais de fonctionnement de cette société. Pour s'en convaincre, il suffit de s'imaginer que le lendemain de la constitution de la S.à r.l. classique, la société est dissoute : dans ce cas, le capital social sera remboursé aux associés. Or, tel ne serait pas le cas si ces sommes étaient des coûts qui, eux, ne pourraient pas être remboursés.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Seules les personnes physiques peuvent être « associés » ou « gérants » de ce type de société. En outre, aucun individu ne peut être associé de plus d'une S.à r.l.-S. La violation de cette exigence entraîne le **cautionnement solidaire** par l'associé fautif de tous les engagements de la deuxième S.à r.l.-S dont il est, le cas échéant, associé (dans la mesure où ces engagements sont nés après le moment où il est devenu associé de cette deuxième S.à r.l.-S., cette conséquence n'étant toutefois pas applicable en cas d'acquisition des parts par cause de mort. Art. 720-2 L.S.C.). Cette **sanction paraît disproportionnée** par rapport à la gravité de l'infraction. La loi luxembourgeoise ne prévoit la responsabilité d'un associé pour les engagements de la société que dans des cas d'infractions d'une gravité certaine (p. ex., en cas de banqueroute de la société). Devenir associé d'une deuxième S.à r.l.-S. ne paraît pas d'une gravité similaire, ceci d'autant plus que les avantages qu'offre ce type de société ne sont pas si importants que cela. Par ailleurs, ce qui est encore plus étonnant, c'est le bénéficiaire de cette sanction : il s'agit des créanciers qui ont fait des opérations avec la société après que l'associé fautif soit devenu associé d'une deuxième S.à r.l.-S. Ces créanciers se trouvent donc bénéficier d'une garantie supplémentaire sans qu'ils y soient pour quoi que ce soit et sans avoir subi le moindre dommage du fait de la violation par l'associé de la disposition légale visée : c'est comme s'ils avaient gagné à une loterie sans même avoir acheté de lot. En conclusion, cette disposition légale ne donne pas beaucoup de sens[1].

L'article 720-4 L.S.C. relatif au **capital social** oblige les S.à r.l.-S de doter une « réserve » par un prélèvement du bénéfice net. Il s'agit donc d'une version amendée de l'obligation de la dotation à la réserve légale applicable à toutes les formes de société à responsabilité limitée (S.A., S.e.c.a., S.à r.l. y compris les S.à r.l.-S). En effet, si toutes ces sociétés doivent doter annuellement la réserve légale d'un montant de 5 % du bénéfice annuel, ce prélèvement s'arrête lorsque la réserve atteint le montant de 10 % du capital social. Ce plafond ne s'applique pas pour la S.à r.l.-S., et ceci, pour la raison évidente que, du fait de la modicité du capital social de cette espèce de la S.à r.l. (1 euro, p.ex.), une telle limitation ne donnerait évidemment pas de sens. L'article 720-4 L.S.C. prévoit une autre limitation spécifique qui elle donne du sens : « *ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant du capital augmenté de la réserve atteint le montant visé à l'article 710-5* ». Toutefois, le régime de la réserve légale reste applicable à toutes formes de S.à r.l.

Compte tenu du fait que la plupart des S.à r.l.-S optent en faveur d'un capital très faible (en fait, 1 euro), la réserve légale selon le régime normal (art. 710-23 L.S.C.) est *de facto* abolie, car la dotation obligatoire s'arrête lorsque la réserve atteint 10 % du capital social. Donc la dotation de 0,1 euro sera faite la première année, et la société sera pour toujours en règle par rapport à cette disposition tant que son capital social n'augmentera pas. Il eût été préférable d'appliquer à la S.à r.l.-S. un régime amendé (déplafonné) de la réserve légale plutôt que de créer une deuxième réserve qui s'ajoute à la réserve légale (qui a perdu toute raison d'être). Bonjour la simplification !

L'avenir montrera si ce régime de la S.à r.l.-S. sera un succès. Le succès est tout sauf garanti (même si les premières statistiques portant sur le nombre de créations sont prometteuses : il paraît que le nombre de sociétés créées en 18 mois soit de

1 – Cette solution a encore été copiée de la Belgique (comme précisé par le document parlementaire 6777). Or, copier sur les voisins n'est pas (ou ne devrait pas) être une justification suffisante pour n'importe quelle solution proposée.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

près de 1300 unités). Mais le nombre de créations n'est qu'un des critères du succès de cette initiative. Un autre critère (celui-là plus important) de cette réussite (éventuelle) est le taux de survie après un certain nombre d'années : il est parfaitement possible que le seul effet mesurable de ce type de société sera de conduire encore à davantage de faillites que tel n'est le cas pour les S.à r.l. classiques.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE III
LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Le terme de sociétés de personnes n'est pas utilisé par la L.S.C. Il est néanmoins fréquemment utilisé en doctrine et en jurisprudence. « *La doctrine opère généralement une division entre les sociétés de personnes et de capitaux, selon que l'élément personnel ou patrimonial domine et que la responsabilité des associés soit illimitée ou limitée à leur apport* »[(1)].

Ces sociétés sont appelées ainsi pour la raison que chacun de leurs membres n'y entre qu'*intuitu personae* en vue et en **considération** de la **personnalité des coassociés**, de leur honnêteté et de leur solvabilité. La personnalité des co-associés, bien que distincte de celle de la personne morale, n'en est pas indépendante[(2)]. Les associés viennent apporter à la garantie des engagements sociaux l'appoint de leur responsabilité, indéfinie chez les uns, limitée à un certain chiffre chez les autres, mais personnelle chez tous, « *de telle façon que tous, commanditaires aussi bien que commandités, puissent être directement tenus vis-à-vis des tiers et directement assignés par ceux-ci dans les limites différentes où ils se sont respectivement liés* »[(3)].

Dans les sociétés de personnes, l'associé compte plus que les apports. Les sociétés de personnes sont dominées par la **personnalité des associés,** et ceci, avant tout en raison de la responsabilité limitée d'une partie au moins des associés. Sont visées les sociétés en nom collectif ainsi que les sociétés en commandite simple.

« *Les sociétés de personnes, dans lesquelles* l'intuitus personae *joue un rôle important, doivent, en principe, adopter l'une des formes que le Code de commerce leur réserve : la société en nom collectif ou la société en commandite simple […] Le trait commun à toutes les sociétés de personnes est que l'un au moins des associés a la qualité de commerçant – ce qui marque la prépondérance de l'élément contractuel sur l'élément institutionnel* »[(4)].

La jurisprudence luxembourgeoise eut l'occasion de se prononcer sur la notion de « société de personnes ». Un associé minoritaire tenta d'obtenir l'annulation d'une décision d'AG d'une société en commandite simple par laquelle, selon une majorité de 83 %, il fut décidé de transformer la société en société anonyme (l'associé agissant avait voté contre). Les statuts de la SCS ne comportant pas de disposition quant à la modification des statuts, la règle de l'unanimité (droit commun des contrats) aurait donc normalement dû être suivie. Se basant sur une doctrine belge (L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, éd. 1950, T. IV, n°s 89 ss.), la cour estima toutefois que ce principe d'unanimité « *se dégage du caractère* intuitu personae *inhérent aux sociétés de personnes* » et examina la présence en l'espèce des critères qui, dans l'esprit de l'auteur précité, caractérisent la société dite « de personnes », à savoir :

1 – T. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 276.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 55, ID 11308.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 56, ID 11308.

4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 287.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

1) l'**incessibilité des parts** dans la société, sauf accord unanime ;
2) lorsqu'un associé décède, les autres associés ne peuvent, sauf convention contraire, prendre sa place dans la société ;
3) les statuts ne peuvent, sauf clause contraire, être modifiés qu'à **l'unanimité des membres**.

En l'espèce, lorsque la société fut constituée, elle répondait aux 1er et 3e critères précités (les statuts prévoyant par ailleurs une clause de continuation en cas de décès de l'associé). En 1992, ses statuts furent modifiés en vue de permettre la cession des parts à des tiers moyennant le consentement des associés détenant 75 % du capital social. La cour estima par conséquent que la société s'était départie de sa caractérisation de société de personnes dès 1992 et qu'il fallait considérer que, dans l'intention des parties, les modifications statutaires étaient désormais permises à une majorité de 75 %[1].

Dans la société en nom collectif, tout comme dans la société en commandite simple, apparaît ainsi la **fusion des personnalités** individuelles des associés en une **personne morale**. Dans la société en nom collectif, celle-ci se fait sans aucune limitation chez tous les associés indistinctement, alors qu'elle se fait de façon rigoureuse dans la commandite simple et chez les commandités. Dans le chef des commanditaires, celle-ci ne s'effectue que dans certaines limites[2]. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que l'engagement des commanditaires est solidaire, comme celui des commandités. « *En effet, […] l'engagement indéfini n'est pas l'engagement solidaire. Plusieurs personnes peuvent être tenues chacune* in solidum*, pour le tout, aussi bien lorsque ce total est restreint à un chiffre déterminé que lorsqu'il est illimité* »[3]. En d'autres termes, tant que les associés commanditaires n'ont pas tous apporté tout ce qu'ils ont promis d'apporter, il y a solidarité, quoique limitée aux apports qu'ils ont promis d'apporter.

Lorsque les commanditaires sont ainsi tenus à l'égard des tiers, ils ne peuvent invoquer contre ceux-ci les faits de la société ou de leurs co-associés[4].

CHAPITRE I
LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

La société en nom collectif est le type **classique** le plus **pur** non seulement de la société de personnes, mais de la société commerciale tout court. Elle était déjà mentionnée par l'Ordonnance de 1673 sous le nom de « société générale ». Forme de société la plus simple, elle se rattache étroitement au contrat de société du Code civil dont elle se distingue pourtant par la solidarité existant entre les associés (voir article 1862 C.c.)[5].

En effet, ce type de société est caractérisé par le fait que tous les associés sont commerçants et tous sont solidairement et indéfiniment responsables. Elle consiste

1 – CA du 2 juin 1999, ID 10241.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 56, ID 11308.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 56, ID 11308.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 56, ID 11308.

5 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 287.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

donc simplement dans la multiplication de la situation du commerçant personne physique.

Archétype de la société de personnes, elle constitue le **droit commun** en la matière, ce qui signifie que, si plusieurs personnes s'associent pour réaliser certaines opérations commerciales, et ceci, sans préciser davantage leurs relations réciproques, elles sont censées avoir formé une société en nom collectif[1] (voir sous « société de fait »).

La L.S.C. est particulièrement lapidaire à ce sujet en ne consacrant plus qu'un seul article à ce type de sociétés (deux avant la Loi de Modernisation) comprenant deux lignes. L'article 200-1 L.S.C. définit la société en nom collectif comme « *celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société* ».

La définition se réfère donc à un seul élément (depuis que la Loi AIFM a aboli la notion de raison sociale à l'égard de toutes les sociétés) qui, en fait, se situe sur des plans fondamentalement différents : d'une part, la forme de l'exercice de l'activité et, d'autre part, les conséquences de cette association quant à la répartition des dettes sociales. Cette définition a donné lieu justement à des critiques de la part de Pirmez, qui disait que cette société se définit par un élément essentiel (la raison sociale) et par une conséquence imposée par la loi (responsabilité vis-à-vis des tiers)[2]. Cet auteur avait donc proposé d'inclure dans cette définition (en lieu et place de ce deuxième élément) que la société a pour objet de faire le commerce, à savoir donc une série indéterminée d'opérations. Ces remarques n'ont toutefois pas été entendues.

Contrairement à la définition donnée par le Code de commerce de 1808 (article 200-1 L.S.C.), auquel on reprochait à la fois de dire trop et trop peu[3], cette définition a le mérite de se limiter à l'essentiel et de bien dégager les caractères distinctifs de la société en nom collectif : tous les associés ont une responsabilité solidaire, ce qui la distingue des sociétés en commandite simple de même que des sociétés civiles. C'est cette caractéristique qui distingue la S.e.n.c. des autres et donc, en tant que telle, elle était suffisante pour définir cette société.

SECTION I
LES CONDITIONS DE FORMATION DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Il est frappant de noter le contraste qui existe entre le **volume des dispositions** consacrées par la L.S.C. à la société anonyme, par exemple, en comparaison avec celui qu'elle dédie aux sociétés en nom collectif. Si la loi consacre actuellement plus de 40 pages à la société anonyme (y compris la SE), elle « réglemente » la S.e.n.c. avec un seul article (article 200-1 L.S.C.) contenant deux lignes. Pourtant, cette divergence s'explique : cette forme de société, qui est la plus ancienne de toutes, trouve ses sources dans les usages de commerce qui se sont développés dès le Moyen Âge avec donc la conséquence que la doctrine et jurisprudence en ont

1 – L. Frédéricq, *Précis de droit commercial*, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 328.

2 – E. Pirmez, *Observations présentées sur l'avant-projet de loi sur les sociétés commerciales* [rédigé par A. Nyssens], p. 7, ID 11305.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 79, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

depuis longtemps déjà arrêté les règles[1]. Il ne faut pas oublier non plus que cette forme de société, comme les autres, est régie également par les conventions des parties et, subsidiairement, par les dispositions du Code civil.

Finalement, la principale raison expliquant la divergence entre le degré de réglementation entre la S.A. et la S.e.n.c. réside dans le fait que la situation de l'une est fondamentalement différente de celle de l'autre. D'un côté se trouve une société à caractère ouvert où les associés n'ont qu'une responsabilité limitée (avec la conséquence que les créanciers n'ont pour gage que le patrimoine social) et, de l'autre, se trouve une société à caractère fermé où les associés ont tous la responsabilité illimitée et solidaire, avec donc la conséquence que les créanciers ont comme gage non seulement les avoirs de la société, mais l'intégralité du patrimoine de ses associés.

Cette différence explique le caractère beaucoup plus réglementé, plus institutionnel que contractuel, de la société anonyme par rapport à celui de la S.e.n.c.

■ § 1 – Les conditions de forme

A – La nécessité d'un écrit

Ces sociétés (ensemble avec les sociétés en commandite simple, les sociétés civiles, les sociétés coopératives) sont « à peine de nullité » constituées par écrit (soit par acte notarié spécial soit par acte sous seing privé). En cas de formation par acte sous seing privé, les conditions de l'article 1325 C.c. sont à respecter. « *Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct […]* ».

Malgré les critiques adressées à cette exigence par Nyssens dans son avant-projet de loi (cette nullité serait inutile et même dangereuse pour ceux qu'elle entend protéger, à savoir les tiers), l'exigence de l'écrit a été maintenue.

Reste à voir quel est le sens exact de cette nullité. S'agissant du défaut d'accomplissement d'une **formalité substantielle**, la question se pose de savoir s'il s'agit d'une nullité absolue. D'abord, cette nullité ne peut être opposée à des tiers par les associés et, entre associés, elle n'opère qu'à dater de la demande. Il ne s'agit donc que d'une **nullité relative**[2]. Elle est absolue sur deux points : elle n'est susceptible d'aucune ratification ou confirmation ultérieures et elle peut être invoquée par toute personne qui a intérêt à s'en prévaloir[3]. Mais la nullité est relative dans le sens qu'elle ne peut être opposée par la société ou par un associé aux tiers (voir art. 100-19 L.S.C.), à moins d'avoir été constatée par une décision judiciaire dûment publiée.

B – Publication de l'acte de société

L'utilité pour les tiers de la publication de l'acte de société ne peut être contestée. Les tiers doivent être à même de connaître les conditions du contrat de société. Néanmoins, la loi luxembourgeoise, dans la ligne du Code de commerce de 1808 et

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 78, ID 11305.

2 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 41, ID 11305.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 11, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de la loi belge, n'exige la publicité que partielle, **par extrait**. Traditionnellement, cette faculté est due à des raisons pratiques (de coût de publication). L'extrait doit contenir les clauses que les tiers ont intérêt à connaître[1]. Les indications que cet extrait doit comprendre sont mentionnées par l'article 100-8 L.S.C. : il s'agit de la désignation « précise » des associés, la dénomination de la société, la désignation des gérants, la nature et la limite de leurs pouvoirs, l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.

C – Les sanctions de l'absence de publicité

La loi organise une série de sanctions tout en écartant à juste titre la sanction absolue et disproportionnée de la nullité de la société. La sanction est donc l'inopposabilité de l'acte, l'incapacité de pouvoir agir activement en justice, en plus d'une amende. Pour plus de détails, voir à la p. 64.

■ § 2 – Les conditions de fond

A – Qualité de commerçant des associés

Tout associé de la S.e.n.c. est commerçant. Par conséquent, il doit avoir la capacité pour devenir commerçant. Tout en étant commerçants, les associés (dont l'activité s'exerce par l'intermédiaire de la société de personnes) ne sont pourtant requis ni de se faire immatriculer au R.C.S. ni de tenir une comptabilité commerciale[2].

Le contrat de société comporte généralement la clause selon laquelle la société n'est pas dissoute par le **décès** d'un associé, mais qu'elle **continue** entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé (clause de continuation avec les héritiers de l'associé prédécédé). Cette clause soulève des difficultés lorsque des **mineurs** figurent parmi ces héritiers. S'agissant d'une société en nom collectif, les associés ont la qualité de commerçants, il faudrait donc que les conditions permettant à un mineur d'exercer le commerce soient remplies. Si ces conditions ne sont pas remplies, la jurisprudence française a tendance à considérer que le mineur, tout en étant associé, ne serait pas commerçant et ne serait tenu des dettes sociales qu'à concurrence des actifs compris dans sa succession. Cette jurisprudence, très critiquée pour ne pas trouver de base dans les textes, n'est pas suivie par la jurisprudence belge : celle-ci considère que si le mineur ne peut devenir commerçant, la clause ne peut sortir ses effets, et la société sera dissoute[3].

La solution à cette conséquence non désirée est de prévoir que les héritiers qui ne pourraient devenir associés en nom deviennent associés commanditaires, de sorte que, le cas échéant, la société continuera donc à fonctionner en tant que société en commandite simple[4].

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 48, ID 11305.

2 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 289.

3 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 324.

4 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 324.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

B – Le capital de la S.e.n.c.

La L.S.C. ne contient aucune disposition sur le capital social ; en particulier elle ne fixe aucun capital minimum. La raison en est évidente : « *[…] dans la société en nom collectif le capital social, s'il existe, n'ajoute ni ne retranche rien à l'obligation des associés de répondre indéfiniment et solidairement des engagements sociaux* »[1].

Il résulte toutefois des dispositions générales du Code civil (art. 1832) qu'il faut que « quelque chose » soit mis en commun. Mais si les statuts indiquent un capital social, il faut qu'il soit souscrit valablement et intégralement, donc qu'il y ait des engagements à hauteur du fonds social fixé par les statuts. Ces engagements doivent être distingués des versements : « *Dans les sociétés en nom collectif, est-ce qu'il est nécessaire, pour que la société existe, qu'il y ait un capital versé ? […] Ne confondons pas, il faut qu'il y ait des engagements pour constituer une société en nom collectif […] La société existe sans que nous ayons versé un centime, l'engagement forme le fonds social* »[2].

La L.S.C. ne contient pas de dispositions non plus concernant l'évaluation des apports qui constituent le « *capital social* ». La raison en est que cette évaluation n'est d'importance que dans les **relations entre associés**. Le montant du capital n'indique pas comme dans les sociétés de capitaux « *le montant de l'actif net minimum que la société s'oblige à l'égard des tiers, à conserver intact en un avoir réel* »[3].

C – Répartition des résultats

La répartition des résultats est faite librement par les statuts sociaux, avec la seule restriction inhérente à la prohibition de la société léonine (c.-à-d. qu'il sera défendu d'allouer à un associé la totalité des bénéfices et/ou de l'exclure de la contribution aux pertes). « *Les statuts peuvent prévoir la périodicité des répartitions ; elles ont lieu, en pratique, chaque année, à la fin de l'exercice social, pour autant que les écritures sociales fassent apparaître un excédent réel de l'actif net, par rapport au capital initial. Ils prévoient parfois aussi la possibilité de consacrer tout ou partie des bénéfices à la constitution de réserves ; même si les statuts sont muets sur ce point, les associés peuvent décider la constitution de réserves, s'ils sont tous d'accord* »[4].

En l'absence de dispositions statutaires régissant la répartition des résultats, ce sont les règles supplétives de l'article 1853 C.c. qui sont applicables, c.-à-d. que la répartition se fait en proportion des apports faits à la société.

Les bénéfices distribués sont définitivement acquis aux associés en nom collectif dès leur répartition, quels que soient les résultats des exercices ultérieurs[5]. Cette solution s'explique par le fait que l'obligation éventuelle de devoir rembourser les bénéfices fictifs n'aurait en rien pour effet d'augmenter le gage des créanciers[6].

1 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 21.

2 – E. Pirmez, *Commentaire législatif de la loi de 1873*, T. III, p. 417.

3 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 291.

4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 291.

5 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 290.

6 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 291.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Quant à la répartition des pertes, elle se fait en général selon les mêmes règles que celles applicables aux bénéfices, mais ceci n'est pas une obligation. « *En pratique, c'est seulement à la dissolution de la société qu'il y a lieu d'y procéder* »[1].

D – Caractère incessible des parts d'intérêts

Le caractère *intuitu personae* de la société veut qu'en principe les parts ne soient cessibles ni à un tiers ni à un autre associé[2], sans préjudice de la possibilité pour un associé d'user de la faculté de s'associer une tierce personne relativement à sa part[3]. Les statuts peuvent **déroger** à cette situation non pas en donnant aux parts un caractère négociable, mais en permettant la cession, notamment sous certaines conditions de majorité ou encore en prévoyant un **droit de retrait** ou un droit de préemption au profit des autres associés[4].

Lorsqu'une telle cession des parts se produit, le cédant reste tenu envers les créanciers de tout le passif né d'engagements contractés avant la publication de la cession. Le nouvel associé, pour sa part, n'est tenu que du **passif né après** la cession. La question qui se pose est de savoir s'il est également tenu du passif qui existait déjà lors de son entrée dans la société. Sur ce point, la situation ne semble pas être la même en Belgique et en France : en France, il semble qu'on tienne le nouvel associé pour responsable des dettes sociales antérieures alors que tel ne serait pas le cas en Belgique[5].

E – Rapports entre associés et tiers

Le caractère illimité et solidaire des engagements des associés est un élément essentiel de la définition de la société. C'est ce caractère qui conduit à la fusion des personnalités individuelles des associés en une personne morale collective réunissant en elle les garanties de ces personnalités individuelles[6].

La situation des associés est donc très rigoureuse dans la mesure où ils doivent subvenir aux dettes de leurs co-associés même si, en fait, ils ne sont pas directement à l'origine des actes ayant contribué à ces dettes. En outre, chaque associé est susceptible de pâtir non seulement en raison de la gestion déficiente de ses co-associés, mais encore de la situation de fortune de ceux-ci. En effet, moins ceux-ci sont fortunés, plus le montant que l'associé solvable sera tenu d'apporter comme contribution aux dettes sociales sera élevé.

Cette situation contraste avec celle des créanciers qui eux, confrontés à différents associés, sont à même de s'adresser à celui (ou à ceux) qui a (ont) le plus de moyens. Si la responsabilité indéfinie et solidaire est un élément essentiel de la société en nom collectif auquel les associés ne peuvent pas déroger, il n'est en revanche pas exclu que les tiers, chacun pour ce qui le concerne, dans leurs

1 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 292.
2 – J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 205.
3 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 298.
4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 292.
5 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 292.
6 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 48, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

relations avec la société déclarent renoncer à cette garantie que leur assure la responsabilité indéfinie et solidaire[1].

Pour être tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales, il est nécessaire que celles-ci aient été **contractées** sous la **raison sociale** (depuis la Loi AIFM, il convient sans doute de dire « sous la dénomination sociale »), même si elles ont été contractées sous la signature d'un seul associé[2]. Il en est ainsi si la société n'a pas nommé de gérant : dans cette hypothèse, seul le gérant peut engager la société dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. Tel n'est en particulier pas le cas si la société est « *irrégulière* »[3].

F – Administration de la société

L'administration des sociétés en nom collectif est, sauf indication contraire des statuts, exercée par chaque associé, et ceci, de manière individuelle. Ces pouvoirs d'administration sont généraux et incluent donc non seulement les actes d'administration, mais encore les **actes de disposition.** « *Suivant une doctrine et une jurisprudence à peu près unanimes, le mandat donné au gérant d'une société en nom collectif a un objet très général ; il est chargé de faire tous les actes nécessaires à la réalisation du but social : diriger l'exploitation commerciale ou industrielle, gérer le patrimoine de la société, la représenter* »[4]. Comme dans les sociétés anonymes, le mandat est personnel ; le gérant ne peut donc se substituer à une autre personne pour exercer ses fonctions[5].

G – Pouvoirs de gestion des associés

En général, les statuts prennent soin de préciser les pouvoirs de gestion de chaque associé et de les limiter. Ces limitations de pouvoirs, si elles sont dûment publiées, sont opposables aux tiers avec la conséquence que la société ne sera pas engagée si les limitations internes n'ont pas été respectées : par exemple, si les statuts exigent pour une opération donnée la signature conjointe de deux gérants, alors la société ne sera pas engagée si une seule signature a été apposée sur un acte.

En absence de règle générale édictée par la loi, les dispositions portant modifications statutaires d'une société de personnes sont prises à l'unanimité, sauf si les associés se sont antérieurement départis[6].

« *L'associé en nom collectif a la qualité de commerçant en raison de sa responsabilité personnelle et solidaire ; les héritiers d'un tel associé, qui sont tenus pour leur part virile, peuvent être assignés devant le tribunal de commerce* »[7]. En l'espèce, les

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 48, ID 11308.

2 – Cour de Bruxelles du 20 juin 1972, *J.T.*, 1972, p. 749, *R.P.S.*, 1973, p. 30.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 298.

4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 292.

5 – Liège, 16 janvier 1901, *Pas.*, 1901, II, 175 ; 10 juin 1932, *Jur. Liège*, 1932, p. 235.

6 – CA du 2 juin 1999, ID 10241.

7 – TA Lux. du 8 novembre 1952, *P.*, n° 15, p. 396, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

héritiers concluaient à l'absence de la qualité de commerçant dans le chef du *de cujus* pour la raison que celui-ci ne passait pas les actes de commerce à titre personnel, mais uniquement en tant qu'associé de la firme « […] et fils »[1].

Un associé qui signe pour une société en nom collectif en utilisant son papier et son cachet engage la responsabilité sociale, spécialement s'il a été interdit aux associés, par les statuts, de faire des opérations commerciales pour leur compte personnel et que la société a ratifié le contrat par la suite[2].

La société en nom collectif, comme toute autre société commerciale, a la personnalité juridique, en ce sens qu'elle peut être assignée en tant que telle en son siège sans que les associés ne le soient et qu'elle peut ester en justice sans que les associés aient à intervenir personnellement à l'instance[3].

SECTION II
LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Il faut en premier lieu identifier la société d'une façon non ambiguë.

§ 1 – La dénomination sociale

Autrefois, la raison sociale était le nom sous lequel la société contractait ses engagements et sous lesquels elle était connue du public. Elle se composait obligatoirement des noms des associés. « *La raison sociale, c'est le nom de la société, de l'individualité juridique, et loin de pouvoir induire en erreur, elle doit constituer le premier et le plus sûr élément de publicité. La perfection en ce domaine serait une raison sociale composée des noms de tous les associés. Suivant un usage ancien, le nom de tous les associés ne doit pas y figurer ; on ajoute, en ce cas, la mention : "et compagnie"* »[4].

C'est la Loi AIFM qui a **aboli** à l'égard de toutes les formes de sociétés **la notion de raison sociale** (en suivant ainsi le droit belge) qui, par le passé, obligeait les sociétés de personnes de s'identifier par les noms d'un ou de plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables. À la suite de ce changement, toutes les formes de sociétés sont désignées par une « dénomination sociale » librement choisie qui peut être « soit une dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise » (art. 100-5 L.S.C.).

Il y a lieu de distinguer la dénomination sociale de **l'enseigne.** Il s'agit d'un nom de fantaisie qui sert à identifier l'entreprise ou l'établissement commercial. Cette enseigne fait partie du fonds de commerce et peut être cédée avec ce fonds de commerce, et ceci, contrairement à la **raison sociale** qui, elle, **est incessible**[5].

---

1 – TA Lux. du 8 novembre 1952, *P.*, n° 15, p. 397, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA Lux. du 8 novembre 1952, *P.*, n° 15, p. 398, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA (civ.) du 30 juin 1993, *P.*, n° 29, p. 254, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 295.

5 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 296.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Selon les documents préparatoires de la loi du 10 août 1915, il n'est pas interdit de laisser figurer dans le nom de la firme le nom d'un associé décédé, s'il ne reste aucun associé de même nom ; seuls ceux de ces parents qui, portant le même nom que lui, peuvent être exposés à la responsabilité solidaire ont un intérêt matériel (un intérêt moral serait insuffisant) pour exercer une telle action[1].

§ 2 – Nomination et révocation des gérants

En cas de silence des statuts, chaque associé peut accomplir seul les actes d'administration, mais ceci sous réserve du droit de veto des co-associés[2]. Chaque associé dispose ainsi de la signature sociale. À la recherche d'une solution plus pratique, les associés désignent en général un ou plusieurs gérants qui ont alors seuls le pouvoir de **gestion** dans la société.

Le gérant ne sera pas nécessairement un associé, et il peut être choisi en dehors de la société. Ce **tiers**, qui n'est pas commerçant, sera un simple **mandataire** qui n'est pas personnellement **engagé** par les actes qu'il pose pour le compte de la société[3].

§ 3 – Pouvoirs des gérants

Les gérants ont des pouvoirs très larges, comprenant tous les actes nécessaires à la réalisation de l'objet social. Ce mandat est plus vaste que celui du droit civil dans la mesure où il comprend non seulement les actes d'administration, mais encore **les actes de disposition,** en tout cas dans la mesure où ceci est nécessaire pour la marche des affaires[4].

En cas de pluralité de gérants, les statuts déterminent les pouvoirs respectifs de ceux-ci. Dans le silence des statuts, chacun peut agir comme s'il était gérant unique (art. 1857 C.c.), sous réserve du droit de veto des associés (art. 1859 C.c.).

Le gérant seul est qualifié pour agir au nom de la société. L'acte accompli par une autre personne, fût-elle un associé, n'engage pas la société, sauf ratification ou dans la mesure où l'acte aurait tourné à son profit[5].

Pour que la société soit engagée par les actes du gérant, il faut que le gérant ait agi au nom et pour compte de la société et qu'il ait agi dans le cadre des pouvoirs tels que fixés par le droit commun ou, le cas échéant, par les statuts. Les actes faits au-delà de ces limites n'engagent pas la société (et ceci, en vertu du droit commun du mandat, art. 1998 C.c.)[6].

§ 4 – Pouvoirs des non-gérants

Ceux-ci ne peuvent peser sur la gestion qu'au moyen de leurs **avis** et **conseils**. S'ils posent eux-mêmes des actes juridiques relevant de la gestion sociale, la société

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 52, ID 11308.
2 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 297.
3 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 297.
4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 298.
5 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 299.
6 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 300.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ne sera pas engagée, mais l'associé en question sera lui lié (sur la base de l'application de l'article 1864 C.c.). Les associés peuvent, en cas d'accord de tous, autoriser le gérant à accomplir un acte qui excède ses pouvoirs[1].

1 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 301.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE

Historiquement, la société en commandite simple est partiellement due à l'influence de l'Église qui, en prohibant le prêt à intérêt, poussait les commerçants à rechercher des placements d'argent échappant à cette prohibition. La forme de la commandite s'est développée pour cette raison[1]. La Loi AIFM a apporté de nombreuses modifications ponctuelles au régime de la S.e.c.s., et ceci, d'abord en légiférant dans des domaines qui, par le passé, étaient restés non abordés par la loi, notamment sur l'approbation des comptes sociaux, la cession et la mise en gage de parts sociales, le remplacement de l'associé commandité unique en cas de décès, de démission, etc.

Aux termes de l'article 310-1 (1) [anc. art. 16] L.S.C., « *La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée, constitutive de parts d'intérêts, représentés ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social* ».

La particularité de la société en commandite simple (la même chose étant vraie de la société en commandite par actions et de la société en commandite spéciale) est d'associer deux sortes d'associés se trouvant dans une situation juridique fondamentalement différente : les commandités et les commanditaires. À l'égard des tiers, les associés commandités se trouvent exactement dans la même situation que les associés en nom collectif, ceux de la S.e.n.c. Ils sont **indéfiniment et solidairement responsables** des dettes sociales.

L'enseignement traditionnel est que la société en commandite (qu'il s'agisse de la S.e.c.s. ou de la S.e.c.a.) permet aux commanditaires de s'intéresser à une entreprise commerciale ou industrielle en n'y engageant qu'un capital limité et aux commandités de se procurer des moyens financiers sans les priver de la direction des affaires[2].

Il n'y a solidarité que dans l'hypothèse où il y a plusieurs commandités. Le Code de commerce mentionnait que « *la société est en nom collectif à leur égard* » (art. 24).

SECTION I
LES APPORTS DES ASSOCIÉS

L'apport des associés qui, en général, est fait en argent, mais qui peut également être fait en nature, fait partie du capital social, qui a la même fonction que dans les sociétés à responsabilité limitée : le capital indique l'actif net minimum que la société s'oblige, à l'égard des tiers, à **conserver** intact en un avoir réel[3]. En outre, l'apport en industrie est également possible. L'apport ne doit pas être réalisé immédiatement. Il est suffisant que soit pris un **engagement irrévocable** et inconditionnel de le fournir dans les délais convenus[4].

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial*, p. 14.

2 – Th. Tilquin, « Le renouveau de la société en commandite par actions », *Rev. banque*, 1991, p. 89.

3 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 290.

4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1,p. 304.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Aux termes des articles 100-8 et 100-10 L.S.C., la publication par extrait doit contenir la « *désignation précise des associés solidaires* ». Contrairement à ce qui était le cas avant 2013, la société doit tenir un registre comportant « *une liste de tous les associés*[1]*, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés […]* » (art. 310-1 (5) L.S.C.). La société peut émettre des titres de créance.

SECTION II
CONTRIBUTION ET OBLIGATION AUX DETTES DE LA SOCIÉTÉ

Le tiers créancier de la société dont la créance n'est pas honorée à son échéance a une action qu'il devra exercer en premier lieu contre la société avant de pouvoir se retourner contre les associés personnellement. Cette solution est prévue par l'article 1400-1 [anc. art. 152] L.S.C. à l'égard de toutes les formes de sociétés.

La disposition visée n'empêche pas que les créanciers puissent assigner par un même exploit la société et les associés et demander leur condamnation par un seul et même jugement[2]. « *Toutefois, lorsqu'une société en nom collectif a été dissoute et que la clôture de la liquidation a été publiée, les créanciers sociaux n'ont plus à faire condamner la société avant la condamnation des associés* »[3].

Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que la situation des **deux catégories d'associés** est foncièrement différente. Si, en cas de pluralité d'associés commandités, les créanciers peuvent assigner n'importe lequel de ceux-ci en paiement de l'intégralité des sommes dues, ils ne peuvent assigner les commanditaires que dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore effectué leurs mises. Dans cette mesure-là, les créanciers ont une **action directe** contre les commanditaires. En plus, ils ont la possibilité d'exercer l'action oblique par application de l'article 1166 C.c. en exerçant ainsi les droits de la société elle-même à l'égard de ces commanditaires.

La question de la contribution et de l'obligation aux dettes de la société est un peu plus complexe qu'on ne le croit généralement. En effet, ce ne sont pas que les associés commandités qui sont solidairement responsables des dettes de la société, mais encore les associés commanditaires. La seule différence est que, pour ces derniers, la responsabilité est limitée au montant de ce qu'ils ont promis d'apporter à la société. « *Les commanditaires sont tenus solidairement envers les tiers, bien que leur engagement soit limité. Autre chose, en effet, est la solidarité, autre chose l'engagement indéfini. Les commanditaires sont solidaires parce que chacun d'eux peut être assigné par un tiers pour toute sa créance, quel que soit leur nombre ; il n'y a pas de division de dettes entre eux à l'égard du créancier ; c'est ce qui constitue la solidarité* »[4]. Bien entendu, ces associés ne sont tenus qu'à concurrence du montant qu'ils ont promis d'apporter.

1 – Donc les commandités et les commanditaires.

2 – Cette solution est encore prévue par le droit belge (art. 189 L.C.S.C). V. Trib. Com. Anvers du 2 septembre 1960, *J. P. A.*, 1961, p. 236.

3 – TA du 8 janvier 1958, *P.*, n° 17, p. 260, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – E. Pirmez, *De la définition légale et des caractéristiques essentielles de la société en commandite simple*, Un écrit posthume, p. 130.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La **solidarité** existe surtout à l'égard des **associés commandités.** Par conséquent, les créanciers ont deux catégories de débiteurs : le commandité, qui lui est tenu pour le tout, et le commanditaire, qui n'est tenu qu'à concurrence d'une certaine somme seulement. À concurrence de cette somme, le créancier peut s'adresser à l'un ou à l'autre de son choix[1].

Sous le Code de commerce de 1808, il était controversé de savoir si le créancier avait une action directe contre l'associé commanditaire qui n'aurait pas complètement libéré l'apport qu'il avait promis de faire ou bien si le créancier ne pouvait exercer que l'action subrogatoire sur la base de l'article 1166 C.c.

En doctrine, il était souvent soutenu que les commanditaires ne pouvaient être contraints au paiement de leur mise que par la société elle-même et tout au plus au nom de celle-ci par le biais de l'article 1166 C.c.

Lors de l'élaboration de la loi belge du 18 mai 1873, il avait été jugé que la solution de **l'action directe** résultait à suffisance du fait que l'extrait à publier doit comporter les noms des associés commanditaires qui n'ont pas encore procédé à la libération de la totalité de leurs apports[2]. Tout doute subsistant a été éliminé par un amendement introduit dans le texte de l'article 21 de ladite loi en ajoutant le mot « *dettes* » au mot « *pertes* »[3]. C'est cette formulation qui a été reprise dans la L.S.C. (pour être supprimée en 2013).

SECTION III
LES POUVOIRS DE GESTION DANS LA SOCIÉTÉ

La principale modification de la Loi AIFM concerne la gestion de la société. Si, autrefois, celle-ci était obligatoirement réservée aux associés commandités, tel n'est plus le cas actuellement : la gérance appartient à « *un ou plusieurs associés commandités ou non* » désignés conformément au contrat social (art. 310-2 L.S.C.). Si les gérants ne sont pas associés commandités, alors ils sont responsables dans les conditions des administrateurs des S.A. Comme pour les S.A. toujours, les restrictions aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

En revanche, les **délégations du pouvoir de représentation** de la société données conformément aux statuts **sont opposables aux tiers** sous condition de la due publication (art. 19-1 etc. de la Loi de 2002). En principe, la S.e.c.s. sera encore engagée pour les actes des gérants dépassant l'objet social (sauf à prouver que le tiers connaissait ce dépassement, etc.).

Du point de vue procédural, on notera que « *les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule* ». Dans les actions judiciaires, il n'est donc pas nécessaire de spécifier l'organe agissant pour le compte de la société.

Si, autrefois, ce pouvoir appartenait exclusivement à l'associé (aux associés) commandité(s), tel n'est plus le cas depuis la Loi AIFM de 2013.

---

1 – Trib. com. Anvers du 30 juin 1894, obs. anonymes, ***R.P.S.***, p. 188.

2 – Commentaire législatif, II, n° 30.

3 – Trib. com. Anvers du 30 juin 1984, obs. anonymes, ***R.P.S.***, p. 192.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – La gestion est réservée à un ou plusieurs gérants

L'intérêt tant de la société que des tiers commande que la direction de la société ne soit pas confiée à des associés qui ne peuvent perdre que leur mise et qui pourraient donc être enclins à engager la société dans des **entreprises hasardeuses**[1]. L'associé commanditaire est donc exclu de la gestion du fait qu'il ne peut pas faire d'acte de gestion à l'égard des tiers. En revanche, il est possible qu'il agisse pour le compte de la société sur la base d'une procuration *ad hoc* donnée par un organe de la société sans engager sa responsabilité, à condition d'indiquer qu'il agit en qualité de représentant.

Si, par le passé, la qualité de commandité et celle de commanditaire étaient absolument incompatibles, tel n'est plus le cas depuis la Loi AIFM. Sauf interdiction par les statuts, une personne peut être à la fois commandité et commanditaire sous la seule condition qu'il ne s'agisse pas du seul associé cumulant les deux qualités : il faut au minimum un associé commandité et un associé commanditaire **juridiquement distincts** l'un de l'autre (art. 310-1 (4) L.S.C.).

En revanche, la situation des associés commanditaires est fondamentalement différente de celle de ces associés tenus sans limitation. Ces derniers, s'ils sont juridiquement associés et non prêteurs de fonds[2], sont économiquement de simples **bailleurs de fonds** dont la responsabilité est (à l'instar des associés de sociétés de capitaux) limitée au montant des apports faits à la société. En contrepartie de cette responsabilité limitée, ils sont **exclus de la gestion** de la société ; ils ne peuvent faire « aucun acte de gestion à l'égard de tiers » (art. 310-3 L.S.C.). Que ces deux éléments soient liés est encore démontré par le fait que le jour où un associé commanditaire commence à se mêler de la gestion de la société, il perd la responsabilité illimitée et, à l'égard des tiers, il devient solidairement et indéfiniment responsable « *des engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent* ». Cette conséquence est même applicable « *aux engagements auxquels il n'aurait pas participé s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de tiers* ».

L'alinéa 2 de cet article 310-3 L.S.C. (repris du droit belge) définit à titre d'exemple les actes qui ne portent pas préjudice à l'interdiction donnée à l'associé commanditaire de s'immiscer dans la gestion de la société. Il s'agit des actes suivants : « *Les avis et les conseils, les actes de contrôle et de surveillance et les autorisations données aux gérants pour les actes qui sortent de leurs pouvoirs, n'engagent pas l'associé commanditaire* ». Ces actes ont pour caractéristique commune que le commanditaire ne sort pas de l'obscurité qui lui est imposée dans la société, et ceci, en ne se mettant pas en rapport direct et personnel avec les tiers[3].

Si les commanditaires sont ainsi écartés de la gestion de la société, rien n'exclut qu'ils assument le contrôle et la surveillance de la gestion des commandités, de tels actes n'engageant pas la société et ne mettant pas le commanditaire en relation avec les tiers[4].

---

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 60, ID 11308. Néanmoins, depuis 2013, la gestion peut être confiée à des personnes qui sont non-associés de la société.

2 – Il est vrai qu'un commanditaire peut en même temps être créancier de la société ; V. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, éd. 1950, T. IV, n° 181.

3 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 87, ID 11305.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 60, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La loi (art. 310-7 L.S.C.) permet de désigner un **administrateur provisoire** en cas de décès du gérant. En cas d'incapacité légale ou d'empêchement, cette désignation est faite par le président du « *tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale* » à la requête de tout intéressé, un administrateur commanditaire ou autre. Cet administrateur provisoire a mandat de faire tous les actes urgents et de simple administration durant le délai qui sera fixé par l'ordonnance, sans que ce délai puisse excéder un mois. L'administrateur provisoire n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance ; l'opposition est signifiée tant à la personne désignée qu'à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.

■ § 2 – Immixtion des commanditaires dans la gestion

La situation de l'associé commandité est spécifiée par l'article 310-3 L.S.C. : s'il peut faire toute opération avec la société en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié ne soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire, il ne peut en revanche faire « *aucun acte de gestion à l'égard de tiers. L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent. Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci* ». En substance, la Loi AIFM a ainsi repris le régime déjà applicable antérieurement tout en précisant la notion d'acte de gestion, notion qui n'inclut pas les avis et les conseils donnés à la société, ou encore les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées.

Contrairement à la situation antérieure, l'associé commanditaire peut agir comme mandataire d'un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire.

■ § 3 – Sanction de l'interdiction de laisser inscrire leur nom dans la raison sociale

Autrefois, selon l'ancien article 18 L.S.C. – « *La raison sociale comprend nécessairement le nom d'un ou de plusieurs associés commandités. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale* » –, l'indication des noms des commandités dans la désignation sociale était obligatoire. La sanction de la violation de cette disposition sur la raison sociale (prévue à l'article 20 L.S.C.) était particulièrement sévère dans la mesure où elle prévoyait la **responsabilité solidaire** pour tous les engagements sociaux, et ceci, sans distinguer ceux contractés **avant ou après** l'insertion de son nom dans la raison sociale. L'associé commanditaire se trouvait ainsi dans une situation identique à celle de l'associé en nom collectif.

La Loi AIFM a aboli à l'égard de toutes les formes de sociétés la notion de **raison sociale**. Depuis ce changement, toutes les formes de sociétés sont désignées par une « dénomination sociale » librement choisie qui peut être « soit une dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise » (art. 100-5 L.S.C.). Par conséquent, l'insertion du nom patronymique de l'un ou de l'autre commanditaire

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dans la dénomination sociale reste sans conséquence (à condition que cette dénomination soit toujours suivie de l'indication de la forme de la société).

■ § 4 – La cession des parts d'intérêts de la société

Cette matière a été entièrement réaménagée par la Loi AIFM qui y a consacré l'article 310-6 L.S.C. ainsi libellé : « *Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités.*

Les parts d'intérêts d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social.

Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.

Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les parts d'intérêts d'un ou plusieurs associés et en définir les modalités ».

Cet article distingue donc les cessions de parts de commanditaires de celles de commandités. Dans les deux cas, les cessions ont lieu dans les formes et modalités prévues par le contrat social. En cas de silence de ce dernier, la cession des parts de commanditaires (autre que pour cause de mort) requiert l'agrément des associés commandités, alors que la cession des parts de commandités (autre que pour cause de mort) doit être agréée par les associés statuant comme en matière de modification des statuts.

Les effets de la cession à l'égard de la société et des tiers ne se produisent qu'à partir de leur notification à la société ou de l'acceptation par elle et de la publication à l'égard des tiers « *sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer* ». Concrètement, l'associé commandité qui a cédé ses parts restera **tenu des engagements sociaux** antérieurs à la publication de la cession. Cette solution est entièrement justifiée dans la mesure où les tiers ont traité avec la société en tenant compte de la solvabilité des commandités. Il serait inacceptable que ceux-ci puissent échapper aux engagements en cédant leurs parts à des personnes n'offrant que des garanties de solvabilité bien moindres[1].

■ § 5 – Dissolution de la société

La Loi AIFM, dans les grandes lignes repris tel quel l'ancien article 22 L.S.C. (nouv. art. 310-7 L.S.C.) La société en commandite simple est une société de personnes,

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 102, ID 11305

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

donc fondée sur l'*intuitu personae* des associés, ce qui signifie qu'elle devrait, en application des principes de l'article 1865 C.c., être dissoute par la mort, l'interdiction ou la faillite d'un des associés. Cette disposition n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent prévoir dans l'acte social que la **société subsistera** (en application de l'article 1868 C.c.)[1]. Pour le cas où l'acte de société prévoyait que la société continuerait à exister, mais sans préciser à qui la gestion serait dorénavant confiée, tout intéressé (associé ou créancier) peut demander au président du tribunal d'arrondissement la désignation d'un **administrateur provisoire**[2], associé ou non. Si le choix du président du tribunal tombe sur un commanditaire, alors la responsabilité spéciale prévue par l'article 310-3 L.S.C. ne joue pas à son égard, car « *l'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat* ». Il reste exposé à la seule responsabilité ordinaire de tout mandataire[3]. D'une part, cette solution trouve sa justification dans le fait que le commanditaire est souvent celui qui est le mieux habilité pour assumer les tâches de gestion. D'autre part, il convient de ne pas perdre de vue que le commanditaire ne peut exercer que les actes urgents et d'administration.

La jurisprudence retient à juste titre que l'absence d'activité sociale, même pendant une longue période, ne donne pas lieu à la dissolution de la société. Un tel cas n'est pas visé par l'article 1865 C.c. dans la mesure où il ne constituerait ni une consommation de la négociation ni une extension de la chose[4]. Il est vrai que, très souvent, une telle inactivité prolongée est souvent accompagnée d'un non-respect des formalités imposées aux sociétés par la loi (tenue des assemblées, publication des comptes, etc.). Dans ce cas, l'article 1200-1 L.S.C. devient applicable[5].

La dissolution (ensemble avec le changement de l'objet social, de la nationalité et de la transformation de la société) fait partie des décisions qui sont obligatoirement prises par les associés (art. 310-5 (2) L.S.C.). Sauf dispositions contraire des statuts, ces décisions requièrent l'assentiment de trois quarts des parts d'intérêts et, dans tous les cas, l'assentiment de tous les associés commandités (art. 310-5 (2) L.S.C.).

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 102, ID 11305.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 66, ID 11308.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 66, ID 11308.

4 – TA Lux. du 25 février 1987, n° 34.097, ID 10437.

5 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, p. 38.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE III
LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SPÉCIALE

Issue du projet de loi n° 6471, la loi du 12 juillet 2013[1] relative aux gestionnaires des fonds d'investissement alternatifs (souvent désignée par le terme de « Loi AIFM », portant transposition de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 encore appelée « directive AIFM ») a, comme tant d'autres dispositions légales luxembourgeoises, eu comme objectif de renforcer la situation compétitive des OPC luxembourgeois, pilier essentiel de la place financière. En même temps, cette Loi AIFM, loin de se borner à transposer en droit national les dispositions de la directive européenne, a considérablement amendé le régime de la **société en commandite simple classique**, introduit celui de la société en commandite spéciale (la « S.e.c.s.-Sp. ») et même modifié celui de la société en commandite par actions. Juridiquement, la société en commandite spéciale est une société de personnes dont les règles de fonctionnement sont très proches de la société en commandite simple classique, mais avec une différence de taille, à savoir qu'elle est **dénuée de personnalité juridique**.

Quelle est la raison pour laquelle le législateur national a changé son approche traditionnelle en matière de droit des sociétés, approche qui a consisté à régulièrement accorder la personnalité morale aux sociétés civiles et commerciales ?[2] La raison est à trouver dans des considérations de compétitivité internationale (en fait, souvent anglo-saxonne) « *en matière de fonds d'investissement (réglementés ou non réglementés) visant plus particulièrement les investissements de type* private equity*) ».* En ce domaine, la pratique utilise très fréquemment des *limited partnerships* de droit anglo-saxon (pendant anglo-saxon de nos sociétés en commandite par actions), originaires notamment des îles anglo-normandes Jersey et Guernesey[3]. Ce choix s'explique essentiellement par la flexibilité offerte en matière de rédaction des contrats (en plus de la transparence fiscale éventuelle). Or, ces entités sont souvent dénuées de la personnalité morale, étant entendu que certaines juridictions ont entre-temps amendé leurs dispositions légales applicables en permettant aux acteurs économiques d'opter entre une *limited partnership* dénuée de la personnalité juridique et une forme similaire dotée de la personnalité juridique.

Par suite des changements introduits par la loi du 12 juillet 2013, le Luxembourg fait ainsi partie des quelques pays qui offrent cette **possibilité de choix** entre personnalité morale et absence de personnalité morale. Le fait que la S.e.c.s-Sp. n'a pas de personnalité juridique étant ainsi acquis de façon non contestable (il est explicitement affirmé par l'article 320-1 (2) L.S.C.), il reste à délimiter la portée exacte de cette caractéristique. Malheureusement, la loi du 12 juillet 2013 n'a pas entrepris de définir ce régime de façon tant soit peu détaillée. En somme, elle reproduit à l'endroit de la S.e.c.s.-Sp. la quasi-totalité des dispositions spécifiques applicables aux sociétés en commandite simple classiques avec la simple précision que ces sociétés sont dénuées de la personnalité juridique.

---

1 – Publiée au *Mém.* A 119 en date du 15 juillet 2013, ID 20335.

2 – Il est fait abstraction ici du cas de la société momentanée et de la société en participation, qui ensemble étaient autrefois désignées par le terme « associations commerciales ». Ce changement de terminologie a d'ailleurs également été réalisé par la Loi AIFM.

3 – P. Schleimer, « Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite simple », *Les commandites en droit luxembourgeois*, Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 10.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans une optique d'amélioration de la position concurrentielle par rapport aux législations étrangères, l'objectif de la loi aurait sans doute été mieux satisfait si le législateur avait pris soin de définir le régime juridique applicable à ce type de société, notamment sur la question du **régime patrimonial** de la S.e.c.s.-Sp. Concrètement, la question est de savoir si ce type de société a un patrimoine ou non. Une chose est certaine : si elle n'a pas du tout de patrimoine, l'étendue de ses droits patrimoniaux est sans doute différente (pour être moindre) par rapport aux droits d'une société en commandite simple classique. Il est en effet impensable que le fait de ne pas avoir la personnalité juridique n'ait aucune incidence sur l'étendue de ses droits et obligations et sur la façon dont ses droits et obligations sont exercés.

Selon l'article 320-1 (2), « *La société peut émettre des titres de créance* ». Cette disposition a été interprétée comme constituant la confirmation que la S.e.c.s.-Sp. peut elle-même être titulaire d'obligations[1]. Cette disposition doit être lue ensemble avec celle de l'article 320-2 (2) L.S.C. : « *Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société* ». D'après le document parlementaire n° 6471, p. 203 : « *Le deuxième alinéa vise à assurer que les biens de la société en commandite spéciale ne garantissent que les dettes de la société elle-même. Dès lors, les créanciers personnels d'un associé, quelle que soit leur qualité, n'ont aucun droit sur les actifs de la société. Leur seul recours porte sur les intérêts dans la société détenue par leur débiteur et les droits en résultant dans son chef. Aucune action directe de la part d'un créancier d'un associé n'existe dès lors sur le patrimoine de la société […]* » (faisant abstraction de la responsabilité illimitée des associés commandités pour les dettes de la société).

Dans le domaine des entités dénuées de la personnalité morale, une des questions ayant une portée pratique très importante est de savoir au nom de qui les actifs qui doivent être inscrits dans un registre sont enregistrés. Par exemple, si un FCP achète un immeuble (donc un actif qui, dans la plupart des pays, doit être inscrit dans un livre ou registre foncier), qui va être immatriculé dans le registre en tant que propriétaire ? Concrètement, est-ce le FCP ou s'agit-il des investisseurs ? La Loi de 2016 (article 320-2 L.S.C.) entend résoudre ce problème en disposant : « *(1) Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a un droit sont faites au nom de la société en commandite spéciale* ».

L'article 320-9 L.S.C. précise qu'en cas de transformation de la S.e.c.s.-Sp. en une des formes de sociétés prévues par l'article 100-2, alinéa 1er, L.S.C. donne lieu à « *la création d'une personnalité juridique nouvelle* ». Étant donné que la transformation implique le passage d'une entité non dotée de la personnalité juridique vers une société en bénéficiant, ce passage va de soi. Cette disposition confirme le principe général applicable en matière de transformation d'une forme de société de l'article 100-3 L.S.C. en une autre forme de société de ce même article dans la mesure où ces transformations « *ne donnent lieu ni à dissolution ni à création d'une personnalité juridique nouvelle* » (art. 100-3, 10e alinéa, L.S.C.).

1 – P. Schleimer, « Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite simple », *Les commandites en droit luxembourgeois*, Les dossiers du journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 20.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE IV
LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1999, il existe en réalité **deux sortes de sociétés coopératives** que nous allons aborder tour à tour dans les deux chapitres suivants : en dehors de la société coopérative traditionnelle, qui existe en notre droit des sociétés depuis 1915, le droit luxembourgeois s'est enrichi d'une forme supplémentaire, à savoir la société coopérative **organisée comme une société anonyme**.

Le législateur belge, suivi par son homologue luxembourgeois, avait offert un régime propre sous lequel ce type de société pouvait et devait se placer. La situation était différente en France où la société coopérative devait choisir la forme d'une société commerciale (une société anonyme en général) ou d'une société civile[1]. C'est cette dernière approche que suit également maintenant le législateur national en laissant à ce type de société le choix entre la forme de droit commun et une autre forme qui, elle, reste toujours une forme de société commerciale.

Depuis l'introduction de la société coopérative européenne (SEC), une troisième forme de société coopérative s'est jointe à celles de droit interne. L'étude de ces trois formes de société fait l'objet des trois chapitres suivants.

CHAPITRE I
LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EN GÉNÉRAL

La société coopérative est à maints égards une **société à part**. Elle a fait son apparition en Belgique dans la Loi du 18 mai 1873[2]. Par ce biais, elle fit son entrée en droit luxembourgeois également[3].

En Belgique, notamment, il s'agit actuellement d'une forme très utilisée en pratique et qui s'est écartée de la forme originaire telle que prévue par le législateur, pour lequel elle était destinée à permettre aux ouvriers et artisans de s'unir. En raison de la liberté laissée aux fondateurs pour établir les statuts, elle s'écarte de cette idée traditionnelle pour se rapprocher des sociétés de capitaux[4].

SECTION I
NOTION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Cette forme de société s'est développée au XIXe siècle dans plusieurs pays européens à savoir la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Apparemment, la première

1 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 19.

2 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 805.

3 – J.-P. Spang, « Les changements apportés au droit des sociétés et des associations par les lois introduisant en droit luxembourgeois les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et créant des fonds de pension (SEPCAV et ASSEP) », *BDB*, n° 9, p. 18.

4 – L. Frédéricq, *Précis de droit commercial*, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 444.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

société coopérative fut constituée en Angleterre en 1844. En cette année, 28 tisserands en laine fondèrent à Rochedale une société connue sous le nom « les **Équitable Pionniers de Rochedale** ». Les statuts de cette société devaient par la suite servir de modèle à la plupart des coopératives[1]. La société coopérative « *est issue d'un mouvement d'idées qui s'est développé à partir du milieu du XIXe siècle, dans tous les pays de l'Europe occidentale. Les théoriciens du "mouvement coopératif" préconisent la création de groupements autonomes dont l'objet est de mettre sur pied et de faire fonctionner des entreprises économiques (de production, de distribution ou de crédit) qui, tout en restant purement privées, veulent éliminer le "profit capitaliste" recherché par les apporteurs de capitaux (au stade de la production) et par les commerçants (au stade de la distribution). Cette élimination du profit sans travail est le but économique immédiat des organismes coopératifs* »[2].

Les coopératives constituent un genre tout à fait particulier de sociétés, « *[…] fondées sur une analyse critique des sociétés "capitalistes". "A-capitalistes" elles ne visent pas à réaliser et partager des profits entre leurs membres, mais à promouvoir les activités de ces derniers, ou à leur procurer des biens et des services à moindre coût. Leur philosophie peut être qualifiée d'humaniste* »[3].

Pour éliminer le profit capitaliste, il faut que les membres de la coopérative remplacent les capitalistes, c.-à-d. qu'ils doivent, en même temps que membres, être fournisseurs ou clients de la coopérative en assumant ainsi une **double qualité.** En outre, il est nécessaire que la répartition des excédents se fasse aux membres proportionnellement aux affaires traitées avec la coopérative ; cette volonté conduit à accorder des ristournes aux membres[4].

Selon Claude-Jannet, le coopératisme est la seule expérience sociale du XIXe siècle qui ait réussi[5].

Il est remarquable que l'origine de la société coopérative ne se trouve pas dans une loi. « *Le système coopératif n'est pas sorti du cerveau d'un savant ou d'un réformateur, mais des entrailles mêmes du peuple travailleur* »[6].

Aux termes de l'article 811-1 [anc. art. 113] L.S.C., les caractéristiques fondamentales de la société coopérative sont **la variabilité du nombre des associés et des apports** combinée avec **l'incessibilité des parts** à des tiers[7]-[8]. Ces caractéristiques découlent directement de l'article 811-1 L.S.C. « *La société coopérative est celle qui se compose d'associés dont le nombre ou les apports sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers* ». La société coopérative est donc celle « *dans laquelle les apports des associés peuvent faire l'objet de retraits, dont les associés peuvent*

1 – C. Gide, cité par Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport de la commission spéciale sur les sociétés coopératives, p. 182.

2 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, 4 2, p. 53.

3 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 19.

4 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 2, p. 52.

5 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, Discussion, p. 324.

6 – C. Gide, cité par Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport de la commission spéciale sur les sociétés coopératives, p. 181.

7 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 229, ID 11308.

8 – J.-P. Spang, « Les changements apportés au droit des sociétés et des associations par les lois introduisant en droit luxembourgeois les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et créant des fonds de pension (SEPCAV et ASSEP) », *BDB*, n° 29, p. 19.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

se retirer ou être exclus et dans laquelle de nouveaux membres peuvent se faire admettre ; les parts des associés sont incessibles à des tiers »[1].

Quelles que soient les particularités de la société coopérative par rapport aux autres formes de sociétés, elle est, en premier lieu, une société (donc à but lucratif) et, en deuxième lieu, une société commerciale[2].

Ce caractère commercial n'est pas douteux pour les coopératives de production, pas plus que pour les coopératives de consommation et de crédit qui traitent avec les tiers. La commercialité des opérations d'achat pour revendre et les opérations de crédit est évidente. En revanche, la situation des coopératives qui ne traitent qu'avec leurs membres est plus difficile à apprécier. Les documents parlementaires, en reprenant les développements qui ont été faits en Belgique sur la même question, tranchèrent comme suit cette question : si la coopérative achète pour revendre au même prix, alors elle n'est pas commerciale. Si, en revanche, elle a pour but de revendre à ses membres avec bénéfice, alors la commercialité est donnée par cette recherche de bénéfice. En raison de la personnalité morale de la société, les associés sont des tiers par rapport à la société. Même si, par la suite, les bénéfices de la société sont destinés à être distribués aux associés, ceci n'empêche pas que, dans une première phase, les bénéfices ont été **réalisés par la société**. C'est en leur qualité de tiers acheteurs qu'ils participent à la réalisation du bénéfice et en tant qu'associés dans la répartition de ceux-ci[3].

« *Mais évidemment rien n'empêche les parties d'exiger statutairement de leurs associés actuels et futurs qu'ils professent individuellement, en matière de religion, de politique ou d'économie sociale, telles ou telles opinions déterminées. Semblable clause qui n'est qu'une application naturelle des deux grands principes de liberté d'association et de liberté de conventions, ne peut, en effet, influer d'aucune façon sur l'objet même de la société qui, quelles que soient les convictions politiques, religieuses ou économiques personnelles assignées comme base de recrutement des membres, n'en reste pas moins et essentiellement commerciale* »[4].

En France, le législateur, après de longues hésitations, accorda finalement aux sociétés coopératives la **personnalité morale** (par la loi du 10 septembre 1947, art. 1) mais sans leur accorder une forme propre : elles doivent choisir entre une société commerciale (en général, une société anonyme) et une société civile[5].

■ § 1 – Variabilité du capital et du nombre des associés

Dans la société anonyme (comme d'ailleurs dans la S.à r.l.), le capital fixé dès la constitution est en principe fixe, sauf modification tout à fait exceptionnelle par résolution spéciale des associés. Dans la société coopérative, ce capital varie « continuellement » sans autre limitation que le montant minimal librement déterminé par les statuts, qui peut donc simplement être égal à la somme des valeurs nominales de 2 parts sociales (2 associés au minimum depuis la Loi de Modernisation). La société coopérative comprend un **capital variable,** sauf en ce qui concerne le minimum fixé par les statuts[6].

1 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 237, ID 11308.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 239, ID 11308.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 237, ID 11308.

5 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, p. 19.

6 – Cass. b. du 10 septembre 1963, *Pas.*, 1964, I, p. 39 et Cass b. du 4 juin 1963, *Pas.*, I, p. 1049.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Suivant la Cour de cassation belge, le fonds social doit s'entendre du capital social constitué par les apports des associés. « *Cette interprétation ne nous paraît pas s'imposer. Dans les sociétés coopératives, il est fréquent que des ressources étrangères aux apports des sociétaires contribuent à former le fonds social – notamment les cotisations versées par les associés. Celles-ci ne sont pas à proprement parler des apports ; elles sont soumises à un régime particulier, que la loi n'organise d'ailleurs pas ; elles peuvent être restituées dans certaines circonstances prévues par les statuts. Nous pensons dès lors que l'expression "fonds social" ne s'identifie pas avec le capital social constitué par les apports des associés, mais désigne l'ensemble des ressources qui contribuent à former le patrimoine de la société* »[1].

■ § 2 – L'incessibilité des parts de la société

Cette incessibilité des parts est une conséquence du caractère *intuitu personae* de ce genre de sociétés. En effet, en principe la société coopérative est une société de personnes, de sorte que, en dehors de dispositions légales ou statutaires particulières, ce sont les règles applicables à ces dernières qui s'appliquent. Cette incessibilité des parts est **d'ordre public** : les statuts ne peuvent donc pas y apporter de dérogation ou d'atténuation. Selon la jurisprudence belge, la conséquence de la violation de cette interdiction est la nullité absolue de la société elle-même[2]. Cette nullité de la société entraînerait celle des cessions de parts éventuellement faites en violation de cette interdiction.

La raison d'être de cette restriction était d'éviter que les promoteurs de sociétés n'aient recours à la société coopérative pour se soustraire aux sévères limitations de garantie prises à l'égard de la société anonyme.

Cette incessibilité des parts fait qu'il n'existe aucun lien de droit entre le nouvel associé et l'ancien. Tant le sortant que le nouvel entrant traitent directement, et chacun de son côté, avec la société. Le nouvel associé apporte un bien à la société et l'associé sortant reçoit la contrepartie de ses titres directement de la société dont il se retire[3].

« *Si la cession est toujours prohibée à l'égard des tiers, les statuts peuvent l'autoriser entre associés* »[4]. Cette dernière catégorie de cession ne serait pas contraire à **l'essence** de la société, mais elle serait contraire à sa **nature** (d'où la nécessité de l'autoriser par les statuts)[5].

Cette incessibilité ne concerne que les parts sociales, soit donc les titres – qui représentent des subdivisions du capital social – qui ont été émis en tant que contrepartie d'apports faits à la société. L'incessibilité ne s'étend pas aux titres de nature spéciale créés, par exemple, sous la désignation **de parts bénéficiaires** ou de **fondateurs**, bons de participation ou sous toute autre appellation donnant droit à une certaine participation au bénéfice et ne confère aucun droit dans la participation à la gestion de la société. « *Tous ces titres hors capital peuvent être créés librement cessibles* »[6].

---

1 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 365.

2 – *R.P.S.*, 1902, n° 1297 ; 1901, n° 1200 ; 1900, n° 1112 ; 1897, n° 791.

3 – L. Frédéricq, *Précis de droit commercial*, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 445.

4 – L. Frédéricq, *Précis de droit commercial*, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 445.

5 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 280, ID 11305.

6 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 234, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il semblerait par ailleurs que la convention de **croupier** par laquelle tout associé peut associer une tierce personne relativement à la part qu'il possède dans la société soit parfaitement autorisée[1].

§ 3 – Les principes coopératifs

La société coopérative est dominée par les principes coopératifs suivants :

– elles n'ont **pas de but spéculatif** ; le but n'est pas de réaliser des profits pour les distribuer. Les bénéfices sont souvent distribués sous la forme de ristournes. L'associé qui se retire n'a pas droit aux réserves accumulées. Le remboursement de ses parts se fait à la valeur nominale. De même, en cas de liquidation de la coopérative, les réserves sont attribuées à un organisme coopératif[2] ;

– le caractère « non lucratif » de la société coopérative est lié au principe de la « **double qualité** » selon lequel chaque associé est aussi coopérateur. L'associé n'a pas seulement l'obligation de libérer ses parts, mais il a encore la qualité de contractant avec la société (il est fournisseur, acheteur, etc.) ;

– la prise de décision fonctionne selon le principe « *un homme une voix* », quel que soit le montant du capital que détient l'associé ;

– les coopératives fonctionnent selon le principe de la **porte ouverte**, selon lequel toute personne ayant les qualités objectives requises peut devenir membre de la société.

Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non, qui ne sont responsables que du mandat qu'ils ont reçu. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.

La question de savoir si les sociétés coopératives devaient ou non limiter leurs activités à leurs membres a de tout temps été fort controversée. En effet, ces coopératives avaient pour objet de procurer à leurs membres un prix aussi bas que possible : en leur permettant de traiter également avec des non-membres, ne dépassaient-elles pas cet objectif[3] ? Toutefois, en étendant leurs affaires à des tiers, elles peuvent acheter à de meilleures conditions, etc.

Malgré certaines revendications tendant à prohibition de telles **affaires avec des tiers**, revendications émanant du cercle des commerçants traditionnels, la loi ne prévoit pas de dispositions contraignantes en ce sens, et ceci, non pas pour la raison que celles-ci auraient été considérées comme non souhaitables, mais pour la raison qu'elles étaient considérées comme difficiles à faire respecter.

Sur cette question, les documents parlementaires se sont exprimés comme suit : « *Ce serait méconnaître l'essence même du régime coopératif que de préconiser la vente au public. De deux choses l'une : ou bien la vente se fait au prix coûtant ; nul avantage alors pour la société de faire bénéficier les tiers des conditions de bon marché de l'entreprise Coopérative ; ou bien elle se fait au prix de commerce ; à qui, dans ce cas, reviendra la ristourne ? En faire bénéficier le tiers-acheteur ne serait de nul avantage pour la société ; l'attribuer à celle-ci l'exposerait au reproche*

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 235, ID 11308.

2 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 19.

3 – Projet de loi portant révision de la loi sur les sociétés commerciales, dépêche au Conseil d'État, p. 20, ID 13321.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

d'une spéculation contraire au but coopératif […] ; il faut souhaiter que les entreprises coopératives s'imposent comme règle de conduite stricte de ne vendre qu'à leurs membres »[1].

Certaines pressions (notamment de la part du petit commerce qui s'est senti menacé) se sont fait sentir et ont conduit à envisager que les ventes faites à des non-membres exposeraient les gérants à des sanctions pénales, mais seulement lorsqu'elles seraient faites **sciemment** (ceci correspondait à la solution retenue à l'époque en Allemagne où la vente faite sciemment par le gérant à un non-membre de la coopérative constituait un délit pénal)[2]. De même, la revente par un associé de marchandises achetées de la coopérative exposeraient ce dernier à des sanctions pénales, mais uniquement si celles-ci étaient faites « *habituellement* »[3]. Ces différentes propositions n'ont pas abouti à des dispositions légales concrètes.

Une autre question soulevée dans ce contexte est celle de savoir si la société coopérative doit vendre au prix de revient ou au prix du marché (le prix du jour comme on disait au début du XIXe siècle). « *Le prix du jour est admis presque dans tous les pays ; la coopérative qui vend au prix de revient menacerait donc de se trouver dans une situation légale singulièrement fâcheuse, elle ne constituerait pas une société commerciale, et sa dissolution à la demande des coopérateurs risquerait fort d'être prononcée* »[4].

SECTION II
LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

La société coopérative peut être constituée par **acte sous seing privé,** et ceci, bien qu'en doctrine, on considère qu'elle puisse avoir des traits proches de la société de capitaux. Cette particularité est motivée par des considérations essentiellement d'ordre pratique tirées du degré de fortune très modeste dans lequel sont supposés se trouver les membres de telles sociétés[5].

La loi distingue certaines conditions impératives en dehors de certaines qui sont supplétives.

■ § 1 – Les conditions impératives

La constitution de la société demande qu'il y ait **deux associés** (7 avant la Loi de Modernisation) au moins. Les personnes morales ne sont pas exclues. Le minimum de 7 existant autrefois fut instauré afin d'éviter que la société coopérative ne soit utilisée comme une sorte de société en nom collectif, pouvant bénéficier de la responsabilité limitée (et non solidaire)[6]. Ce nombre doit être atteint au moment de la constitution et **à tout moment de la vie** de la société. Dans la société anonyme,

1 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport de la commission spéciale sur les sociétés coopératives, p. 182.

2 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, Discussion, p. 328.

3 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport de la commission spéciale sur les sociétés coopératives, p. 199, ID 9792.

4 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, Discussion, p. 332.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 9, ID 11308.

6 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 248, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la loi a toujours prévu des sanctions spécifiques au cas où le nombre légal minimum des associés ne serait atteint : responsabilité des fondateurs si cette insuffisance se produit au moment de la constitution ou cause de dissolution si elle se réalise après la constitution de la société. En matière de société coopérative, la condition de sept associés ne connaît aucune atténuation, de sorte que son non-respect est sanctionné par la nullité radicale ou par l'inexistence de la société[1].

Que se passe-t-il si, par la suite, le nombre d'associés tombe en dessous de 7 ? Par le passé, la L.S.C. ne prévoyait pas de solution comme tel est le cas pour les sociétés anonymes. La Loi de Modernisation a remédié à cette lacune en précisant qu'il s'agit d'un cas de nullité de la société si, dans un délai d'un an à compter du moment où la société est passée à moins de deux associés, la société n'a pas ramené le nombre d'associés à deux au moins.

Un **minimum de capital social** (dénommé **fonds social** avant la Loi de Modernisation) doit être souscrit immédiatement ; il n'est pas requis qu'il soit versé de suite[2]. Les parts sociales, généralement d'un montant peu élevé, une fois fait le versement d'un minimum obligatoire, peuvent encore être libérées par imputation sur les **ristournes** à échoir.

Aucun minimum n'est prévu par la loi. Doit encore être précisée la manière dont le fonds social sera constitué ultérieurement. Chaque titre n'est pas nécessairement libéré à concurrence d'un quart, comme tel est le cas pour les sociétés anonymes.

Cette situation contraste avec celle applicable en Belgique où le capital d'une coopérative comprend une part fixe et une part variable, la part fixe étant prévue à peine de nullité dans les sociétés à responsabilité limitée[3].

L'acte constitutif est établi soit sous forme authentique, soit sous seing privé. Cet acte constitutif mentionne obligatoirement les points suivants (811-3 (1) L.S.C.) :

1) la dénomination de la société, son siège ;
2) l'objet de la société ;
3) la forme à responsabilité limitée ou illimitée de la société ;
4) la manière dont le capital social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate.

De cette formulation, il résulte qu'aucun versement n'est exigé sur les parts qui constituent le capital social[4]. Mais il ne faut pas confondre la libération des parts et l'engagement de les souscrire : les statuts doivent mentionner le montant à concurrence duquel l'engagement de souscrire existe. Ce minimum doit être intégralement et valablement souscrit[5].

« *Dans les sociétés en nom collectif, est-ce qu'il est nécessaire, pour que la société existe, qu'il y ait un capital versé ? […] Ne confondons pas, il faut qu'il y ait des engagements pour constituer une société en nom collectif […] La société*

1 – J. Guillery, *Commentaire législatif de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales en Belgique*, Bruxelles, Bruylant, 1886, T. III, n° 950, cité par J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 248, ID 11308.

2 – P. Le Cannu, *Droit des sociétés*, 2e éd., p. 20.

3 – J. Malherbe, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des Sociétés. Précis*, p. 806.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 253, ID 11308.

5 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 254, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

existe sans que nous ayons versé un centime, l'engagement forme le fonds social. Or, ce qui est vrai pour les sociétés en nom collectif est vrai pour les coopératives »[1].

Selon l'article 811-3 [anc. art. 115] L.S.C. ces conditions sont exigées à peine de nullité. La loi prévoit donc à l'égard des sociétés coopératives un **régime de nullité différent** de celui applicable aux sociétés de capitaux (qui est prévu par l'article 100-18 L.S.C.). La loi précise encore : « *Toutefois, ces nullités ne peuvent être opposées aux tiers par les associés ; entre les associés, elles n'opèrent qu'à dater de la demande tendant à les faire prononcer. Si une des mentions obligatoires fait défaut, la société existe, mais elle est frappée de nullité absolue, opposable à tous ; les tribunaux en prononceront la dissolution à la demande de toute personne sans qu'elle ait d'ailleurs à faire la preuve d'un intérêt légitime* »[2].

A – La durée de la société

Comme pour toute société, cette durée peut être limitée ou illimitée. Dans le premier cas, la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l'article 450-3 L.S.C. L'article 811-4 L.S.C. s'empresse de préciser que, dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 C.c. ne sont pas applicables[3]. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Art. 811-4 [anc. art. 116] L.S.C.

« *L'acte indiquera en outre :*

1° la durée de la société qui peut être limitée ou illimitée ;
[...]

2° les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versements ;

3° comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s'il y a lieu, le mode de nomination et de révocation des gérants, des administrateurs, des commissaires ou réviseurs d'entreprises agréés, l'étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat ;

4° les pouvoirs de l'assemblée générale, les droits y conférés aux associés, le mode de convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation ;

5° la répartition des bénéfices et des pertes ;

6° la désignation précise des associés ».

1 – E. Pirmez, *Commentaire législatif de la loi de 1873*, T. III, n° 417.

2 – L. Frédéricq, *Précis de droit commercial*, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 447.

3 – Art. 1869. « *La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contretemps* », ID 11337.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

B – Responsabilité des associés

Traditionnellement, un des points les plus remarquables de la société coopérative était la possibilité de **définir** « à la carte » la **responsabilité** des associés. À cette fin, les choix sont la responsabilité solidaire ou divise, d'une part, et la responsabilité illimitée (donc « *sur tout le patrimoine* ») ou jusqu'à concurrence d'une somme déterminée seulement, d'autre part. Cette somme déterminée pouvait être soit le montant des apports, soit encore un montant plus élevé. En revanche, il n'était pas possible de fixer une responsabilité limitée pour certains et illimitée pour d'autres : tous les associés sont donc soumis au même régime de responsabilité. Ce régime a été amendé par la Loi de Modernisation qui, en se référant au droit belge, a argumenté qu'il est apparu « *souhaitable de mettre clairement en évidence qu'il existe deux formes de sociétés coopératives : les coopératives à responsabilité illimitée et les coopératives à responsabilité limitée*, *dans la mesure où le fait pour une coopérative de relever de l'une ou de l'autre forme intéresse les tiers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est proposé de réformer également l'art. 115 L.S.C. pour lui faire prévoir que l'acte constitutif doit déterminer la forme – à responsabilité illimitée ou limitée – dont relève la société coopérative envisagée* »[1]. « *La disparition de la mention de l'art. 116, 6°, pour la remplacer, à l'art. 115, paragraphe (1), 3°, par l'indication de la forme à responsabilité limitée ou illimitée de la société, semble faire disparaître un choix pour les associés, à savoir celui de diviser leur responsabilité lorsque celle-ci est illimitée* »[2].

Le commentaire des articles de la disposition argumente qu'en droit luxembourgeois la responsabilité illimitée s'accompagnerait automatiquement de la solidarité, de sorte que, si la loi nouvelle ne parle plus que de responsabilité limitée ou illimitée, en supprimant en même temps l'ancien alinéa 5 de l'article 114 L.S.C.[3], elle doit être interprétée dans le sens qu'elle entend combiner responsabilité illimitée avec responsabilité solidaire (ce qui constitue effectivement la règle en droit commercial).

« *Par contre l'art. 1863 du Code civil luxembourgeois dispose que : "Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part". Le champ d'application de ce texte est limité aux sociétés civiles. Il apparaît toutefois que toutes les sociétés commerciales à responsabilité illimitée visées par la L. 10 août 1915 se voient expressément doter d'un régime de solidarité à l'exception éventuelle de la société coopérative à responsabilité illimitée (art. 114, al. 5, précité). En outre, étant donné qu'en droit luxembourgeois, contrairement au droit belge, l'adoption d'une forme commerciale emporte en règle l'acquisition de la qualité de commerçant, l'importance de la notion de solidarité commerciale à défaut de réglementation contraire s'en trouve en quelque sorte renforcée. Les art. 114, al. 5, et 116, 6°, font donc figure ici de réglementation exceptionnelle. À l'issue de l'analyse de cette question, il a été estimé préférable de s'inscrire dans la logique du droit belge liant*

1 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 102, ID 10080.

2 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 102, ID 10080.

3 – « Les associés peuvent s'engager solidairement ou divisément, indéfiniment ou jusqu'à concurrence d'une certaine valeur ».

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

fermement les notions de solidarité et de commercialité. Dans ce cas, il faut supprimer l'alinéa 5 de l'art. 114, objet de la présente proposition »[1].

Par conséquent, on retiendra qu'il y a effectivement eu un changement par rapport à la situation antérieure dans le sens que les choix sont réduits par rapport au passé. Cette restriction paraît d'autant plus acceptable que la situation des sociétés coopératives reste toujours nettement plus flexible que celle de toutes les autres formes de société qui, elles, ne sont en rien autorisées d'amender le régime de responsabilité applicable à leurs associés.

■ § 2 – Les dispositions supplétives

C'est l'art. 811-5 [anc. art. 117] L.S.C. qui contient les dispositions qui régissent la société en l'absence de dispositions contraires des statuts :

1) la société est constituée pour une durée illimité**.**

   Depuis la loi du 7 septembre 1987 la durée de la société coopérative, comme celle de toute autre société luxembourgeoise, peut être de plus de 30 ans.

2) Les associés ne peuvent être exclus de la société que pour inexécution du contrat ; l'assemblée générale prononce les exclusions et les admissions et autorise les retraits de versements.

   Comme indiqué ailleurs, le droit des sociétés luxembourgeois n'a pas repris à l'égard des sociétés de capitaux la faculté d'exclure un associé de la société. Une telle faculté est toutefois prévue à l'égard des sociétés coopératives pour lesquelles l'article 812-5 [anc. art. 123] L.S.C. prévoit la possibilité de l'exclusion d'un associé, exclusion qui résulte d'un procès-verbal signé par un administrateur.

   Si les statuts ne prévoient rien, les associés peuvent se retirer de la société[2].

3) La société est **gérée par un administrateur** et surveillée par un commissaire, nommé, révoqué et délibérant de la même manière que dans les sociétés anonymes.

   En l'absence de dispositions contraires, il est renvoyé aux dispositions applicables aux sociétés anonymes. Par la nature des choses, ce renvoi est toutefois relativement imparfait : en effet, la société anonyme a un conseil d'administration, organe collégial (du moins dans la conception traditionnelle), tandis que la société coopérative n'a qu'**un seul administrateur**. Les dispositions concernant la société anonyme doivent donc être adaptées sur ces points avant de pouvoir être utilement appliquées à ce genre de sociétés. Comme pour la société anonyme, il suffit d'un seul commissaire.

   Le renvoi à la société anonyme implique que l'administrateur puisse être associé ou non, qu'il soit nommé par l'assemblée générale et que son mandat ait une durée de 6 ans. En outre il est révocable *ad nutum.* Son mandat étant de gérer la société, il peut effectuer tous les actes nécessaires pour atteindre son but social[3].

   Sa responsabilité est régie par *l'actio mandati* qui appartient à la société. Il n'est responsable que du mandat qu'il a reçu et n'encourt pas l'aggravation

1 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 102, ID 10080.

2 – L. Frédéricq, *Précis de droit commercial*, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 447.

3 – L. Frédéricq, *Précis de droit commercial*, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 453.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de responsabilité introduite par les articles 441-9 et 442-10 [anc. art. 59 et 60*bis*-10] L.S.C. applicables aux administrateurs (membres du directoire) de sociétés anonymes en cas d'infractions à la loi ou aux statuts[1].

4) Tous les associés peuvent voter dans l'assemblée générale ; ils ont voix égale ; les convocations se font par lettre recommandée, signée par l'administration ; les pouvoirs de l'assemblée se déterminent et ses résolutions sont prises en suivant les règles indiquées pour les sociétés anonymes.
5) Les **bénéfices et les pertes** se partagent chaque année, par moitié par parts égales entre les associés, et par moitié à raison de leur mise. Ce système reflète bien le caractère hybride de la société coopérative : société de personnes (d'où la répartition selon le nombre des associés) et sociétés de capitaux (d'où la répartition en fonction des mises des associés).
6) Le principe retenu par la loi est celui de la société en nom collectif, à savoir la **responsabilité indéfinie et solidaire** de tous les associés. Il va de soi qu'en fait, il est toujours dérogé à cette règle, et ceci, en prévoyant la responsabilité limitée et indivise seulement.

■ § 3 – La tenue du registre des associés

Selon l'article 811-7 [anc. art. 118] L.S.C., toute société coopérative doit tenir un **registre** contenant à sa première page l'acte constitutif de la société et certaines données concernant les associés de la société.

Le régime juridique de la société coopérative est caractérisé par la grande liberté laissée aux parties en matière de constitution et de fonctionnement de ce genre de société. Cette caractéristique, ensemble avec la variabilité du fonds social et du nombre des associés, a fait que des précautions spéciales ont dû être prises afin d'éviter que cette liberté n'engendre le désordre et la confusion[2].

Cette considération est à la base de la constitution, au sein de la société coopérative, d'un mécanisme de constatation régulière et chronologique de tous les éléments essentiels de la vie interne de la société : ce mécanisme consiste en la tenue au siège social d'un registre où sont consignés au jour le jour les événements sociaux.

En première page est reproduit le texte complet de l'acte constitutif, précaution importante quand il s'agit d'un acte qui peut être rédigé par écrit sous seing privé en deux exemplaires. Ce livre social contient encore :

1) les noms, professions et demeures des sociétaires ;
2) la date de leur admission, de leur démission ou de leur exclusion ;
3) le compte des sommes versées ou retirées par chacun d'eux ;
4) la date des révisions opérées et les noms des commissaires ou réviseurs d'entreprises agréés.

Depuis la Loi de Modernisation, ce livre n'est plus coté, paraphé et visé soit par un des juges du « *tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale* », soit par le bourgmestre de la commune, et sans frais. L'associé qui effectue des **retraits** est tenu de signer ceux qu'il effectue. Cette disposition assure la

1 – L. Frédéricq, *Précis de droit commercial*, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 453.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 266, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conservation dans le chef de la société d'une quittance de sommes remboursées (qui complète la décharge que l'associé doit effectuer dans son propre livret nominatif)[1].

Le registre en question a le caractère d'un **livre de commerce** d'un caractère spécial en relation avec le caractère particulier des opérations qu'il a pour but d'enregistrer[2].

En plus de ce registre, il existe un second moyen pour l'associé d'établir sa qualité d'associé. Il s'agit d'un titre nominatif « *[…] qui porte la dénomination de la société, les nom, prénoms, qualité et demeure du titulaire, la date de son admission, de ses souscriptions successives et de sa démission, le tout signé par le titulaire et par un administrateur. Il mentionne, par ordre de date, les versements et les retraits de sommes par le titulaire. Ces annotations sont, selon le cas, signées par un administrateur ou par le titulaire et valent quittance. Il contient les statuts de la société. Il est exempt du timbre et de l'enregistrement* ».

La question se pose de savoir si cette inscription sur le registre est une condition de **forme substantielle** exclusive de la constatation de la qualité d'associé. À cette question, il fut répondu négativement, notamment sur la base de l'argument de texte selon lequel le registre constate la qualité d'associé. Pour éviter les difficultés auxquelles cette disposition donna lieu en Belgique, le projet Corbiau rajouta au texte belge de base le bout de phrase suivant : « *indépendamment des autres moyens de preuve du droit commercial* »[3].

Comme dans les sociétés ayant des titres nominatifs ou des parts appartenant à des personnes désignées, il existe dans la société coopérative un registre des associés. L'originalité du registre de la société coopérative est qu'il doit être signé par l'associé lui-même, ce qui n'est pas le cas des autres sociétés. Ce registre reprend encore le nombre des parts dont chaque associé est à tout moment titulaire.

■ § 4 – Des changements dans le personnel et du fonds social

Une des caractéristiques de la société coopérative étant la variabilité continue de son capital social, il en découle, pour tout associé, le droit de se retirer par voie de démission au moment qu'il détermine librement.

L'associé démissionnaire reçoit **restitution de sa part sociale** calculée d'après le bilan final de l'année au cours de laquelle il se retire et il reste tenu des **engagements** sociaux afférents à ladite **année entière**.

Est-ce qu'un associé peut se retirer l'année même de son entrée dans la société ? Corbiau répond affirmativement à cette question[4].

En principe, les parts sont librement cessibles entre associés si les statuts le permettent (elles sont seulement incessibles à des tiers), cette possibilité pouvant cependant être limitée par les statuts.

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 267, ID 11308.
2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 267, ID 11308.
3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 271, ID 11308.
4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 273, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 812-1 [anc. art. 119] L.S.C.
« *La qualité de sociétaire, ainsi que le nombre de parts sociales dont chacun se trouve à tout moment être titulaire, sont constatés, indépendamment des autres moyens de preuve du droit commercial, par l'apposition de leur signature, précédée de la date, en regard de leur nom, sur le registre de la société* ».

A – Retrait des associés

Les associés ont toujours le **droit de se retirer**, même si ce droit peut être limité et organisé par les statuts (art. 812-2 L.S.C.). La démission n'est toutefois possible que dans les six premiers mois de l'année sociale. La raison d'être de cette limitation est le souci d'assurer une certaine stabilité à la société.

La démission fait l'objet de l'inscription sur le titre de l'associé ainsi que sur le registre de la société, en marge du nom du démissionnaire. Tout comme pour l'entrée de l'associé dans la société, il y a un double moyen de preuve pour l'associé sortant. De cette façon, chacun des deux intéressés obtient et garde envers lui la preuve écrite de l'opération visée. Mais ce moyen de preuve ne fait pas obstacle à d'autres moyens de preuve[1]. Ces mentions sont datées et signées par l'associé et par un administrateur (art. 812-3 [anc. art. 121] L.S.C.).

Art. 812-4 [anc. art. 122] L.S.C.
« *Si les administrateurs refusent de constater la démission, ou si le démissionnaire ne sait ou ne peut signer, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social.*
Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures.
Le procès-verbal est sur papier libre et enregistré gratis ».

B – Exclusion d'un associé

L'une des principales originalités de la société coopérative par rapport aux autres formes sociales prévues par le droit luxembourgeois tient à la possibilité pour la société **d'exclure** de la société un ou plusieurs de ses membres (art. 812-5 L.S.C.).

Art. 812-5 [anc. art. 123] L.S.C.
« *L'exclusion de la société résulte d'un procès-verbal dressé et signé par un administrateur. Ce procès-verbal relate les faits établissant que l'exclusion a été prononcée conformément aux statuts : il est transcrit sur le registre des membres de la société et copie conforme en est adressée au sociétaire exclu, dans les deux jours, par lettre recommandée* ».

Même si les statuts réservent au conseil d'administration le droit d'exclure un associé sans avoir à justifier de sa décision, les dispositions de l'article 812-5 L.S.C. doivent être suivies et les droits de la défense doivent être respectés. Ainsi, la Cour de cassation belge[2] cassa un arrêt de la Cour de Liège selon lequel le droit d'exclusion discrétionnaire prévu par les statuts d'une société coopérative exemptait le

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 275, ID 11308.
2 – Cass. du 28 septembre 1963, *J.T.*, 1964, p. 6, *R.P.S.*, 1964, p. 17.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conseil d'administration d'entendre l'associé exclu et de lui donner l'occasion de se défendre.

C – Droits des associés sortants

« *L'associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société* » (art. 812-6 L.S.C.). Cet article constate ensuite que, sauf disposition contraire, l'associé n'a droit qu'à la valeur nominale de ses parts sociales. Comment faut-il interpréter cette disposition ?

La jurisprudence luxembourgeoise, dans deux décisions datant de 1983[1], eut l'occasion de se prononcer sur cette question ; il est vrai que ces décisions ont trait au cas des associations agricoles réglementées par l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur les associations agricoles. Toutefois, l'article 14 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre reprend textuellement la même disposition que l'article 124 L.S.C. de l'époque. Il n'y a donc guère de raison pour penser que la solution retenue à l'égard des associations agricoles pourrait ne pas valoir pour les sociétés coopératives. Il résulte des deux décisions citées que :

- l'article 14 de l'arrêté oblige l'association à indemniser l'associé non pas sur la base de la valeur nominale des parts, mais sur la base des valeurs bilantaires. Il convient donc de tenir compte des **réserves bilantaires** (réserves libres, report à nouveau, etc.), mais non pas, semble-t-il, des **réserves cachées**. En effet, en se référant aux seuls chiffres du bilan, cette conclusion devrait s'en dégager : en effet, les réserves cachées, par définition, n'apparaissent pas au bilan.
- cette disposition est d'ordre public, avec donc la conséquence qu'une disposition statutaire (prévue dans les statuts de la société concernée, Luxlait) devrait être écartée au profit de la disposition légale.

La référence à la doctrine et la jurisprudence belges qui permettent de priver un associé démissionnaire du remboursement de sa part fut écartée par le tribunal, car, en Belgique, il est possible d'interdire conventionnellement la démission d'une société coopérative[2]. *A fortiori* serait-il alors possible de prévoir qu'en cas de sortie, seule la valeur nominale des parts serait due. Au Luxembourg, une telle interdiction serait considérée comme anticonstitutionnelle.

Cette règle peut conduire à une véritable **spoliation** de l'associé sortant. En effet, s'il est vrai que les sociétés coopératives n'ont en général pas de bénéfices thésaurisés importants (en raison de leur caractère « non lucratif »), il n'en reste pas moins qu'elles peuvent avoir des réserves cachées (qui sont donc non distribuables) fort importantes. La disposition selon laquelle le remboursement doit se faire à la valeur nominale n'est pas d'ordre public, et les statuts peuvent y déroger.

L'indemnisation de tous les sortants de la société coopérative se fait sur la base du bilan qui **clôture l'année de la sortie**.

Selon la jurisprudence belge, les réserves libres et les réserves statutaires doivent être prises en considération pour le calcul de la valeur de la part, pour autant que les statuts n'en disposent pas autrement. Certaines décisions de jurisprudence ont

1 – TA Lux. du 9 juin 1983 ; TA Lux. du 16 juin 1983, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. V, n° 694.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

cependant écarté l'associé cédant de la participation à la réserve légale au motif que celle-ci serait « intangible ». Cette position est cependant critiquée dans la mesure où l'intangibilité de cette réserve signifie simplement que la société ne peut, par l'ensemble des remboursements qu'elle fait à ses associés, porter atteinte à cette réserve, pas plus d'ailleurs qu'au capital social[1].

Contrairement à cette opinion, le Tribunal de commerce de Liège décida qu'il n'y avait pas lieu de déduire la réserve légale de l'actif social net sur lequel se calcule cette valeur. Selon le tribunal, cette intangibilité de la réserve légale est une question étrangère à la solution de la question. « *L'intangibilité existe à l'égard des tiers, et elle est d'ailleurs comparable à celle du capital social, mais elle n'a rien à voir avec la détermination des droits des associés en cas de liquidation partielle* »[2]. Cette solution doit être approuvée.

En aucun cas les éléments du bilan qui constituent la contrepartie de fonds publics alloués à la société coopérative ne peuvent être distribués. S'il résulte de la situation du bilan de l'exercice au cours duquel la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée que la valeur des parts est inférieure à leur montant nominal, les droits de l'associé sortant sont diminués d'autant.

La question s'est posée de savoir sur la base de quel bilan devait être calculée la valeur des parts de l'associé. La loi belge de 1873 retenait que le bilan servant de référence serait celui précédant la date du retrait. Ce système se vit reprocher de favoriser indûment les démissionnaires dans la mesure où, de cette manière, ils pourraient atteindre la marche des affaires pendant presque 6 mois et, en cas d'évolution défavorable, se retirer sur la base des résultats de l'année précédente. Il était perçu comme « *[…] inadmissible que l'associé sortant pût par une rétroactivité de sa démission s'assurer une décharge par trop commode de faits accomplis avant cette démission même* »[3].

Dans le même sens, ce système pouvait permettre à la société d'exclure certains associés pour les évincer des résultats d'une année qui, dès la première moitié, s'avère fructueuse. Dès l'année 1886, le législateur belge changea de système pour se référer au bilan de **l'exercice en cours**. La loi luxembourgeoise reprit ce même système.

Art. 812-7 [anc. art. 125] L.S.C.
« *En cas de décès, de faillite, de concordat préventif, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent sa part de la manière déterminée par l'art. 812-6.*
Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la société ».

La société coopérative étant essentiellement une société de personnes, il pourrait paraître logique que des événements mettant en cause l'*intuitu personae* de la société donnent lieu à application de l'article 1865 C.c. en cas de décès ou de faillite d'un des associés. Cette solution fut écartée pour des raisons essentiellement pratiques : en effet, le nombre généralement très élevé des associés conduirait inéluctablement à une fin prématurée de la société. En outre, la variabilité du capital social se réalisant notamment par des démissions et des exclusions qui n'ont aucune

1 – J. van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 373.
2 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1966-1971) », *R.C.J.B.*, 1973, p. 531.
3 – J. Corbiau, Avant -projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 279, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

incidence sur l'existence de la personne morale, il paraîtrait tout à fait inique de faire produire au décès, faillite, etc. des effets plus étendus que ceux qui ont été produits par les retraits et les exclusions[1].

De ces considérations découle la solution retenue par l'article 812-7 L.S.C. qui exclut la conséquence de la liquidation de la société coopérative.

D – Responsabilité des associés sortants

Comme dans les sociétés de personnes classiques, l'associé de la société coopérative n'est pas délié de toute responsabilité le **jour où il quitte** la société. En vertu de l'article 812-8 [anc. art. 126] L.S.C., il reste tenu « *[…] dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de la publication de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle sa retraite a été publiée. Les mêmes règles sont applicables dans les cas prévus par l'art. 125* ».

L'associé sortant (qui en principe quitte la société dans la première moitié de l'année) est indemnisé sur la base du bilan de l'année de sa sortie. On en a fort logiquement déduit qu'il devrait encore être tenu des dettes sociales jusqu'à cette même date[2].

Art. 812-10 [anc. art. 128] L.S.C.
« *Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et les dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société* ».

Cette disposition précise les droits des créanciers personnels de l'associé en les limitant à saisir les seuls dividendes et intérêts afférents à la part sociale de l'associé. « *La part elle-même, faisant partie du capital social, lequel forme le patrimoine de la personne morale, reste affectée, comme tous les éléments de celui-ci, à la garantie exclusive des créanciers sociaux ; et ce n'est qu'au moment où, après la dissolution de la société, la liquidation aura enfin fait réintégrer à cette part le patrimoine personnel de l'associé, que les créanciers personnels de ce dernier pourront aller l'y saisir* »[3]. Il est vrai que, le cas échéant, les créanciers pourront faire avancer les échéances en provoquant la faillite ou la déconfiture de leur créancier, ce qui conduit ainsi, par application de l'article 812-7 [anc. art. 125] L.S.C., au retrait forcé de l'associé de la société[4].

Selon la jurisprudence, cette disposition légale n'interdit pas au créancier d'un associé de pratiquer une saisie sur les parts mêmes de cet associé ; elle a pour conséquence immédiate de ne contraindre la société « *qu'à remettre au créancier les intérêts ou dividendes revenant normalement à l'associé tandis que le capital constituant les parts de l'associé ne revient au créancier qu'au jour de la dissolution de l'être moral* »[5].

---

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 283, ID 11308.

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 285, ID 11308.

3 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 293, ID 11308.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 293, ID 11308.

5 – CA du 17 novembre 1998, P. 30, p. 506, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« *L'art. 128 de la loi sur les sociétés commerciales, traitant des sociétés coopératives, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et les dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société. Cette disposition n'interdit pas au créancier d'un associé de pratiquer une saisie sur les parts mêmes de cet associé. Elle a pour conséquence immédiate de ne contraindre la société qu'à remettre au créancier les intérêts ou dividendes revenant normalement à l'associé, tandis que le capital constituant les parts de l'associé ne revient au créancier qu'au jour de la dissolution de l'être moral* »[1].

E – Les comptes annuels de la société coopérative

Initialement, la loi renvoyait tout simplement aux dispositions de la société anonyme en rendant applicables aux sociétés coopératives les dispositions sur l'établissement des comptes annuels (l'article 129 L.S.C. faisait référence à l'article 72 L.S.C.) : « *Chaque année, à l'époque fixée par les statuts, l'administration dresse un inventaire et établit le bilan et le compte des profits et pertes dans la forme prescrite par l'art. 72. Une réserve sera constituée de la manière déterminée par ledit article* ». Il est ainsi fait référence à la notion de réserve légale, applicable à toutes les formes de sociétés de capitaux. À cet endroit surgit une difficulté à laquelle ne sont pas confrontées les sociétés à capital fixe. Dans l'obligation de trouver une base de calcul invariable sur laquelle la **réserve légale** peut être calculée, on se fonde sur le capital social minimum statutaire pour la réserve légale[2].

En 1984, les dispositions de la Quatrième directive telles que reprises dans la section XIII L.S.C. n'avaient pas été reprises à l'égard des sociétés coopératives (et ceci, même à l'égard de celles affichant responsabilité limitée).

Cette situation devait toutefois changer par la suite. La loi du 19 décembre 2002 concernant le R.C.S. rendit obligatoire pour les sociétés coopératives les règles sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ainsi que leur dépôt, dans le mois suivant leur approbation, au R.C.S.) (art. 813-4 L.S.C.).

F – Publication de la liste des associés

La loi (art. 813-5 L.S.C.) rend obligatoire pour les sociétés coopératives le dépôt dans les six mois au R.C.S. d'une « *liste indiquant par ordre alphabétique les noms, professions et demeures de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires. Ceux-ci seront responsables de toute fausse énonciation dans lesdites listes* ». Cette liste est accessible gratuitement au public qui peut en demander copie, sur papier libre, moyennant paiement des « frais administratifs ».

Art. 813-6 [anc. art. 134] L.S.C.

« Dans le mois de leur nomination, les gérants doivent déposer au registre de commerce et des sociétés un extrait de l'acte constatant leur nomination et leur pouvoir.
Ils doivent se présenter au registre de commerce et des sociétés pour donner leur signature, ou la faire parvenir au registre de commerce et des sociétés dans la forme authentique ».

1 – CA du 17 novembre 1998, P. 30, p. 506, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 295, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Selon une décision de jurisprudence : « *En cas d'omission des formalités imposées au gérant d'une société coopérative par l'art. 134 L.S.C., le tiers assigné par la société a seulement le droit de faire surseoir à la procédure jusqu'après l'accomplissement de ces formalités, mais l'action ne saurait être déclarée irrecevable* »[1].

L'affaire portait sur l'obligation imposée par l'ancien article 134 L.S.C. au gérant de déposer dans le mois de leur nomination au greffe du tribunal un extrait de l'acte constatant leur nomination et leur pouvoir et de donner leur signature en présence du greffier. La loi n'attache pas de sanction spéciale à l'inobservation de cette formalité.

SECTION III
FÉDÉRATIONS DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

La possibilité pour les sociétés coopératives de se fédérer pour donner lieu à des fédérations de telles sociétés dotées de la personnalité morale est tout à fait spécifique à ce genre de sociétés.

Art. 813-8 [anc. art. 136] L.S.C.
« ***Les sociétés coopératives pourront se fédérer pour poursuivre en commun, en tout ou en partie, les objets prévus par leurs statuts, ou pour assurer l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires.***
Les fédérations constitueront une individualité juridique distincte de celle des sociétés qui les composent [...] ».

Ces fédérations constituent une **individualité juridique distincte** de leurs membres, c.-à-d. des sociétés qui les composent. Elles sont soumises aux dispositions concernant les sociétés coopératives. Les fédérations de telles sociétés, contrairement aux groupes de sociétés (en général composés de sociétés anonymes), sont donc dotées de la personnalité morale.

SECTION IV
CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Le principe du contrôle applicable à toutes les sociétés coopératives et couvrant tant leur organisation que leur gestion fut repris de la loi allemande du 1er mai 1989. C'est également cette loi qui fut retenue pour servir de modèle pour le règlement à prendre pour le contrôle des coopératives[2].

Les bienfaits de ce contrôle étaient attendus notamment sur le plan de la gestion de ces sociétés. « *L'expérience faite en Allemagne démontre que les échecs subis par la coopérative étaient dus presque toujours, soit à un défaut d'organisation, soit à l'inaptitude des coopérateurs de se rendre compte des résultats financiers ; d'autre part, les mesures appelées à parer au mal et qui ont trouvé leur expression dans la loi de 1889, avaient été appliquées et avaient fait leur preuve longtemps avant la*

1 – C.E., 27 avril 1932, *Pas.*, n° 12, p. 487.

2 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport du Conseil d'État, p. 426, ID 13321.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

promulgation de cette loi, en sorte que celle-ci n'a fait que consacrer officiellement ce qui auparavant avait été pratiqué avec succès »[1].

Art. 813-9 [anc. art. 137] L.S.C.

« *L'article 69, paragraphes 1er, 2 et 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est applicable.*

L'institution des commissaires aux articles 811-2, 811-4, point 3°, et 811-5, point 3°, est supprimée dans les coopératives qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé conformément au premier alinéa.

En cas de violation des prescriptions sur les révisions, les administrateurs des fédérations et des sociétés seront personnellement et solidairement responsables du préjudice résultant de cette violation ».

Avant la loi du 18 décembre 2009, les sociétés coopératives étaient soumises à un contrôle gouvernemental de l'organisation et de la gestion des sociétés coopératives est prévu par l'arrêté grand-ducal du 30 août 1918 concernant le règlement sur le contrôle des sociétés coopératives. Selon ce document, le **contrôle est fait annuellement** au moins par un réviseur nommé par le gouvernement, la nomination étant faite d'office si des propositions de la société ne sont pas parvenues au gouvernement dans les trois mois de la constitution ou encore de la cessation des fonctions du réviseur précédent. La prédite loi de 2009 a rendu la Loi de 2002 applicable au contrôle des sociétés coopératives avec notamment la conséquence qu'à l'égard des sociétés qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé, l'institution du commissaire est supprimée.

1 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport du Conseil d'État, p. 427, ID 13321.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ORGANISÉES COMME DES SOCIÉTÉS ANONYMES

Le projet de loi n° 4463 visant à introduire en droit luxembourgeois le concept de fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (SEPCAV) et d'association d'épargne-pension (ASSEP) fut déposé le 25 août 1998. Ce projet de loi fut par la suite scindé en deux projets, à savoir les projets de loi n° 4463A et 4463B.

C'est la loi du 10 juin 1999 qui introduisit cette catégorie spéciale des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme. La loi du 8 juin 1999 introduisit les fonds de pension proprement dits (SEPCAV et ASSEP) et celle-ci était destinée à accueillir les fonds de pension sous forme de SEPCAV, donc un instrument sociétaire (« *corporate* ») imposable en tant que tel (en tant que collectivité dans le sens de la loi sur l'impôt sur le revenu) et dont les titres sont donc facilement transmissibles, étant donné qu'il s'agit d'actions.

La loi (art. 820-1 [anc. art. 137-1] L.S.C.) prit soin de préciser que ces sociétés sont soumises aux dispositions relatives aux sociétés coopératives (sauf les adaptations indiquées) et aux sociétés anonymes (sauf les adaptations indiquées) ; en outre, quelques dispositions sont spécifiques à ce type de société et non applicables à d'autres.

En somme, on peut résumer ces dispositions de la manière suivante :

– les règles relatives à la constitution de la société coopérative ne s'appliquent pas à la société coopérative sous forme de S.A. ;
– les dispositions sur le registre des associés sont adaptées ;
– les associés peuvent donner leur démission à n'importe quel moment de l'année sociale ;
– les dispositions concernant les comptes annuels ne s'appliquent pas[1].

Une des principales différences par rapport aux sociétés coopératives ordinaires est que le **capital est divisé en actions** avec les caractéristiques qui sont attachées à cette notion, à savoir donc la libre transmissibilité de principe. La loi précise que la référence aux parts doit être comprise comme référence aux actions (art. 820-2 [anc. art. 137-2] L.S.C.). La société coopérative organisée comme société anonyme maintient les deux caractéristiques fondamentales de la société coopérative, à savoir la **variabilité** des membres et du capital combinée à **l'incessibilité** des **titres**[2].

Il est encore précisé (art. 820-3 L.S.C.) que l'article 100-4, alinéa 2, L.S.C., ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme, ce qui signifie donc qu'un acte notarié n'est pas requis.

L'article 410-1 [anc. art. 23] L.S.C. est spécifiquement exclu (ce qui signifie que la responsabilité limitée n'est pas accordée aux associés visés). Les dispositions

1 – J.-P. Spang, « Les changements apportés au droit des sociétés et des associations par les lois introduisant en droit luxembourgeois les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et créant des fonds de pension (SEPCAV et ASSEP) », *BDB*, n° 29, p. 21.

2 – J.-P. Spang, « Les changements apportés au droit des sociétés et des associations par les lois introduisant en droit luxembourgeois les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et créant des fonds de pension (SEPCAV et ASSEP) », *BDB*, n° 29, p. 21.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

concernant le contrôle des apports en nature ne sont pas applicables à ce genre de sociétés.

Le capital de la société coopérative organisée sous forme de société anonyme est variable. À première vue, cette disposition pourrait paraître en contradiction avec les dispositions de la Deuxième directive 77/91/CEE du 13 décembre 1976 qui vise le maintien et les modifications du capital de la société anonyme. Si les sociétés anonymes doivent donc en principe avoir un capital fixe, l'article 1 (2) de la directive permet aux États membres de faire **exception** à cette exigence, et ceci, à l'égard des **sociétés d'investissement à capital variable**. La SICAV luxembourgeoise est en fait fondée sur cette dérogation. La même exception s'applique « *à l'égard des sociétés coopératives constituées sous l'une des formes visées au paragraphe 1)* » soit donc, en ce qui concerne le Luxembourg, les sociétés anonymes[1].

L'article 820-4 [anc. art. 137-4] L.S.C. détermine les dispositions du titre IV – « Des sociétés anonymes et des sociétés européennes » qui sont applicables à la forme de la société coopérative sous forme de société anonyme. Les formes de la société anonyme, d'une part, et celle de la société coopérative, d'autre part, étant assez éloignées l'une de l'autre, le choix du législateur a donc consisté à faire prévaloir d'un cas à l'autre soit la forme de la société anonyme, soit celle de la société coopérative. Sans prétention d'exhaustivité, mentionnons les dérogations suivantes par rapport au droit commun du régime de la société anonyme ou encore au droit commun du régime de la société coopérative :

– le fonds social mentionné à l'acte de société doit être immédiatement souscrit ;
– les règles sur la vérification des apports en nature (art. 420-10 à 420-13 L.S.C.) ne sont pas applicables ;
– les actions émises par la société coopérative ne peuvent avoir la forme au porteur ; les fondateurs ne peuvent donc choisir qu'entre actions nominatives et actions dématérialisées ;
– l'acte de société indique les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versement ;
– etc.

1 – J.-P. Spang, « Les changements apportés au droit des sociétés et des associations par les lois introduisant en droit luxembourgeois les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et créant des fonds de pension (SEPCAV et ASSEP) », *BDB*, n° 29, p. 23.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE III
LA SEC

La SEC (société coopérative européenne) est régie par le **règlement (CE) nº 1435/2003** du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC). Le régime ainsi introduit comporte de nombreuses ressemblances avec le régime de la SE. Comme la SE, elle n'a pas connu un succès débordant ce qui explique également que les développements consacrés à ce sujet sont assez limités. La L.S.C. y consacre le chapitre III (art. 831-1 à 839-1 L.S.C.) du titre VIII dénommé « Des sociétés coopératives ».

Après avoir constaté dans le préambule du règlement cité ci-dessus que les instruments européens de la SE ou du GEIE ne sont pas des instruments entièrement adaptés à la spécificité de l'entreprise coopérative, le Règlement retient que son objet essentiel est de « *[…] permettre la création d'une SEC par des personnes physiques résidant dans des États membres différents ou des personnes morales relevant du droit d'États membres différents […]* »[1].

L'article 2 du règlement CE précité définit les conditions de constitution de ce type de société.

« *1. La SEC peut être constituée comme suit :*

– *par au moins cinq personnes physiques résidant dans au moins deux États membres ;*
– *par au moins cinq personnes physiques et sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d'autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d'un État membre, qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation d'au moins deux États membres ;*
– *par des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d'autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d'un État membre, qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation d'au moins deux États membres ;*
– *par fusion de coopératives constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, si deux d'entre elles au moins relèvent du droit d'États membres différents ;*
– *par transformation d'une coopérative constituée selon le droit d'un État membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, si elle a depuis au moins deux ans un établissement ou une filiale relevant du droit d'un autre État membre […]* ».

Aux termes de l'article 3 du même règlement le capital minimum est fixé à **30 000 euros** en précisant encore que ce capital est **variable,** impliquant donc que les variations du montant du capital ne nécessitent pas de modifications des statuts ni de publicité.

Aux termes de l'article 831-2 L.S.C., la constitution de la SEC se fait par **acte notarié** spécial rédigé et publié selon les prescriptions applicables aux S.A. ; les règles sur les apports en nature des S.A. sont applicables.

1 – Point (13) du préambule du Règlement.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La SEC est dotée de la personnalité morale. Sauf dispositions contraires des statuts, chaque membre ne s'engage qu'à hauteur du capital qu'il a souscrit. Lorsque les membres de la SEC ont une responsabilité limitée, la dénomination sociale de la SEC est suivie des termes « à responsabilité limitée ».

L'administration de la SEC peut se faire, au choix des acteurs économiques, soit selon le système moniste soit selon le système dualiste.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE V
LES SOCIÉTÉS CIVILES

Celles-ci sont réglementées par le Code civil et sont en fin de compte à la base du droit des sociétés commerciales en général (par le biais de l'article 100-1, al. 2, L.S.C.). La définition de la société civile sert de définition de la société tout court. Il suffit donc de renvoyer à cette partie générale au début de ce manuel.

Lors de l'étude des dispositions du Code civil, le point qui ne doit pas être perdu de vue est le suivant : à l'époque de la rédaction du Code civil, la personnalité morale n'était pas reconnue à la société civile. Légalement, ceci n'a été fait au Luxembourg que par la loi du 18 septembre 1933. Comme la jurisprudence l'a noté : « *En l'absence de loi organisant la société civile en considération de sa personnalité morale, le juge doit nécessairement combiner les règles du Code civil, toujours en vigueur dans leur rédaction originaire, avec les conséquences que l'attribution de la personnalité juridique entraîne nécessairement* »[1].

Le caractère distinctif de la société civile est en fait son objet civil, qui est également décrit dans la partie consacrée au droit des sociétés en général. Les seuls points qui restent donc à être abordés sous le présent titre sont le fonctionnement de la société civile, ainsi que la responsabilité des associés qui répondent à un régime différent de celui connu pour les sociétés commerciales.

Art. 1832 C.c.

« *Une société peut être constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun quelque chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d'une personne qui affecte des biens à l'exercice d'une activité déterminée* ».

Cet article fait l'objet de commentaires en différents endroit de ce manuel, voir en particulier à la p. 131.

Un point particulier qui mérite d'être mentionné est celui des « associations de fait » ayant un objet purement civil. Certains ont déduit de la disposition de l'article 100-3 [anc. art. 3] L.S.C. (qui prévoit que les sociétés dont l'objet est civil ont une personnalité morale distincte des associés) que les « associations de fait » exerçant, par exemple, la profession d'avocat seraient en fait de véritables sociétés civiles, donc dotées de la personnalité morale[2].

Art. 1833 C.c.

« *Toute société doit avoir un objet licite et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie* ».

L'article visé est commenté à des endroits divers, notamment à la p. 168.

1 – CA civ. du 10 juillet 2003, n°s 23.054, 24.097 et 26.382, *BIJ*, 2004, n° 2, p. 27.

2 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, p. 67.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE I
DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS

Le Code civil distingue les sociétés universelles des sociétés particulières (art. 1835 C.c.), distinction qui, de nos jours, est tout au plus d'un intérêt scientifique, si ce n'est qu'elle n'avait déjà qu'un intérêt fort limité au moment de son introduction[1].

SECTION I
DES SOCIÉTÉS UNIVERSELLES

Les sociétés en question ont fait leur apparition en France au temps de la féodalité, et ceci, sous les deux formes suivantes, les sociétés de serfs et les **sociétés taisibles.**

« *Les sociétés de serfs étaient généralement formées entre tous les membres d'une même famille qui participaient "au pain, au sel et à la caisse commune" en contrepartie de leur force de travail, mise pour le présent, le passé ou le futur au service de la communauté. Le patrimoine indivis formé entre les parties permettait d'échapper à la règle suivant laquelle tous les biens du serf passaient au seigneur à leur décès en raison de leur incapacité de tester. Ces sociétés assuraient le seigneur de l'existence d'un grand nombre de bras et leur constitution était une condition de la jouissance du sol* »[2]. Les sociétés taisibles étaient fondées tacitement par des hommes libres dans un but économique pour développer l'agriculture et le commerce. Ce type de sociétés a été aboli par le Code civil[3].

« *Les associations connues de nos aïeux sous le nom de sociétés taisibles, et qui se formaient par le seul fait de la cohabitation, ne convenaient plus depuis longtemps à nos mœurs ; le projet a le soin de rappeler le principe général qui veut que toute convention ayant pour objet une valeur au-dessus de 150 francs soit rédigée par écrit* »[4]. Mais il est vrai qu'il reste possible de constituer des sociétés universelles. Le changement se limite au régime de la preuve applicable.

Les règles de preuve applicables en cette matière du droit des sociétés ont donc ainsi été ramenées au droit commun.

Les sociétés universelles étaient déjà au temps du Code civil très rares, de sorte que l'on peut se demander pourquoi elles étaient maintenues. Le premier projet de Code avait maintenu les seules sociétés de gains, ce qui avait donné lieu à des protestations de plusieurs cours[5].

Art. 1836 C.c.

« *On distingue deux sortes de sociétés universelles : la société de tous biens présents, et la société universelle de gains* ».

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 275.

2 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 274.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 274.

4 – Gillet cité par Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 162.

5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 247.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 1837 C.c.

« *La société* de tous biens présents *est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.*

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance ; toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard ».

Il résulte de cette dernière disposition que le Code prohibe la société universelle qui comprend les « *biens présents et futurs* ». Ce dernier genre de sociétés était admis dans l'ancien droit et il avait été proposé de les rétablir, proposition qui devait toutefois être rejetée. « *Il est de l'essence de la société que les choses qui y entrent soient connues, sauf l'incertitude des bénéfices ou des pertes ; or, elles ne peuvent l'être dans la société de biens à venir. Personne ne peut connaître les successions qui lui échoiront, et il est de principe qu'elles ne peuvent être l'objet d'aucun traité. Les pactes successoires sont prohibés ; si la loi les permet entre époux, c'est par faveur pour le mariage. Il n'y avait aucune raison de déroger au droit commun en matière de sociétés* »[1].

Les sociétés universelles sont de façon générale de véritables donations, donations non favorisées par le législateur. « *D'après l'article 943, la donation entre vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur ; il fallait donc interdire la société de biens futurs, qui peut si facilement déguiser une libéralité ; c'est ce motif qui détermina la section de législation à limiter la société universelle aux biens présents* »[2].

Le premier alinéa de l'article 1837 C.c. énumère les biens que la société de tous biens présents comporte de droit. Le deuxième alinéa mentionne les biens qui peuvent y entrer de façon facultative : peuvent y entrer toutes espèces de gains. S'il est fait fruit de cette faculté, on dit qu'il y a « *une société universelle de biens présents et une société universelle de gains* »[3].

Art. 1838 C.c.

« *La société* universelle de gains *renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement* ».

On a fait remarquer que la désignation de « *société universelle de gains* » est en fait inappropriée. En effet, cette société comporte les meubles présents des associés, ce qui ne correspond pas à des gains. Il s'agit donc d'une société de biens présents limitée à la fortune mobilière des associés[4].

1 – Bigot-Préameneu, Séance du Conseil d'État du 14 nivôse an XII, Locré, T. VII, p. 230.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 249.

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 251.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 252.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Sont inclus seulement les **gains de l'industrie**, notion à interpréter strictement. Sont encore exclus les immeubles personnels de façon générale, et non seulement ceux qui existent au moment du contrat[1].

La société universelle de gains est **usufruitière** de l'universalité du patrimoine des associés avec pour conséquence de devoir supporter les charges en relation avec les revenus visés[2].

Art. 1839 C.c.
« *La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains* ».

Cette disposition est empruntée à Pothier qui la fait remonter au droit romain. « *Toute convention qui tend à exproprier ne pouvant être entendue que dans le sens le plus étroit, la simple convention de société universelle n'emportera qu'une société de gains* »[3]. La différence entre les deux sociétés est que la société universelle de gains comporte uniquement le mobilier présent, alors que la société de biens présents comporte aussi les immeubles.

Art. 1840 C.c.
« *Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes* ».

Le Code civil prévoit des interdictions de donner et de recevoir entre certaines catégories de personnes. Ces dispositions, au demeurant peu nombreuses sont comprises aux articles 907 à 909 C.c. « *Or, ce que la loi a expressément défendu, ce qu'on ne peut faire directement, il serait inconséquent et dérisoire de le tolérer indirectement. Il ne faut donc pas que, sous les fausses apparences d'une société, on puisse, en donnant en effet, éluder la prohibition de la loi qui a défendu de donner, et que ce qui est illicite devienne permis en déguisant sous les qualités d'associés celles de donateur et de donataire* »[4].

À cet endroit, la loi présume que les sociétés universelles contractées entre personnes incapables de donner ou de recevoir sont des donations.

La disposition commentée fait encore référence aux personnes auxquelles il « *est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes* ». Cette disposition vise les héritiers réservataires qui, par le biais de la constitution de sociétés universelles, ne peuvent être dépouillés de leur réserve héréditaire[5].

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 253.
2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 254.
3 – Boutteville, Rapport, n° 9, Locré, T. VII, p. 248.
4 – J.-B. Treilhard, Exposé des motifs, Locré, T. VII, p. 242.
5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 256.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION II
DES SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES

De nos jours, les sociétés, et notamment les sociétés commerciales, font toujours partie du genre des « sociétés particulières ». Ce point est encore renforcé par l'article 1842 C.c. qui prévoit une présomption en ce sens et applicable dans le cas où le contrat n'est pas explicite à cet égard.

Art. 1841 C.c.
« *La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir* ».

Art. 1842 C.c.
« *Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière* ».

Il semblerait que les sociétés commerciales soient nécessairement des sociétés particulières en raison du principe de spécialité statutaire, principe qui leur impose d'indiquer avec précision leur objet[1].

1 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 275.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dans ce chapitre sont commentées, l'une après l'autre, en suivant l'ordre des articles au Code civil, les différentes dispositions du titre IX du Code civil applicables à ce type de sociétés, mais également aux autres sociétés.

Art. 1843 C.c.
« *La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque* ».

Il est parfaitement possible de faire débuter la société à un **moment autre** que celui de la **signature** du contrat. Il est rarement fait fruit de cette possibilité. Ce moment ne peut toutefois pas être antérieur à la date du contrat. **L'effet rétroactif** est exclu, en tout cas il serait inopposable aux tiers.

Art. 1844 C.c.
« *S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869 : ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire* ».

Les parties sont libres de fixer la durée de la société. En général, les associés prennent soin de fixer un terme à leur société. Si les statuts sont muets sur ce point, la société est supposée conclue pour toute la **vie des associés**. La question de savoir si la société est à terme ou à durée illimitée est importante au vu de la possibilité de dissolution de la société. Selon l'article 1844 C.c., une société sera à durée limitée lorsqu'elle est conclue pour réalisation d'une affaire à durée limitée : si tel est le cas, la société sera à durée limitée. Dans ce cas, la volonté d'un associé ne peut plus mettre fin à la société : celle-ci prend fin avec la réalisation de l'affaire que la société se propose de réaliser[1]. En revanche, lorsque la société est constituée pour une série d'opérations, alors il n'est plus possible d'assigner une limite précise à la société. « *Dans l'esprit de nos lois modernes, on ne peut pas contracter d'engagements perpétuels ; c'est déjà un engagement perpétuel, au point de vue de l'homme, qu'un engagement contracté à vie ; aussi les lois romaines qualifient les sociétés à vie de sociétés perpétuelles. La loi admet les sociétés à vie, quoiqu'elle réprouve le louage de service contracté à vie (art. 1780)[…]* »[2].

Art. 1845 C.c.
« *Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur* ».

1 – Fr. LAURENT, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 375.
2 – Fr. LAURENT, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 375.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cet article applique le **droit commun**. L'obligation de l'apporteur consiste à donner et il est donc tenu de livrer la chose et de la conserver en bon père de famille jusqu'à la livraison (art. 1136 et 1137 C.c.)[1].

Le privilège accordé par l'article 1612 C.c. au vendeur pour la garantie du paiement du prix n'appartient pas à celui qui fait un apport dans une société. Dès lors, le sociétaire qui n'a pas encore reçu les actions formant la contrevaleur de son apport, n'est pas fondé à se prévaloir d'un **droit de rétention** sur un immeuble de la société, et l'action en déguerpissement intentée à son encontre par un tiers acquéreur de l'immeuble est fondée[2].

Cette disposition a encore été empruntée à Pothier qui la justifie comme suit : « *La société est un contrat commutatif, chacun des associés s'engage à donner ou à faire une chose qui est l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour lui (art. 1104). L'équivalent consiste dans le bénéfice qui est en proportion de la mise ; or, en cas d'éviction, l'associé se trouve sans mise ou sa mise est diminuée ; partant il doit indemniser la société de la perte qu'elle éprouve par l'éviction* »[3].

La garantie n'est toutefois due que si l'apport consiste en un corps certain.

Art. 1846 C.c.

« *L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.*
Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.
***Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu* ».**

Cet article **déroge au droit commun** dans la mesure où l'article 1153 C.c. prévoit que des dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la demande. Cette dérogation est basée sur la nature même du contrat de société par rapport aux autres contrats. Pour ces autres contrats, une mise en demeure est nécessaire pour constater que le créancier subit un dommage du fait de l'inexécution des obligations par le débiteur. « *Dans le cas de la société*, *le dommage est constaté par la nature même du contrat. Les parties contractantes spéculent sur l'emploi des mises, donc la société est en perte par cela seul qu'elle ne perçoit pas les intérêts de la somme qu'un des associés a promis d'apporter […]* »[4].

L'article 1846 C.c. s'applique à toutes les obligations découlant pour les associés du pacte social[5]. Le bout de phrase « *Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu* » constitue une seconde dérogation par rapport au droit commun dans la mesure où, en droit commun, les **dommages-intérêts** résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ayant pour objet une somme d'argent ne

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 259.

2 – Cour du 10 juillet 1903, *P.*, n° 6, p. 366, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 261.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 263.

5 – CA du 30 juillet 1927, *P.*, n° 11, p. 554, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi. « *Cette exception résulte aussi de la nature du contrat de société. On ne s'associe point pour retirer l'intérêt légal des mises sociales, on s'associe pour faire des bénéfices qui excèdent le profit que l'on retire d'ordinaire de ses capitaux ; le dommage étant supérieur à l'intérêt légal, la loi a dû donner aux associés une action en dommages-intérêts* »[1].

Les termes « *sommes prises dans la caisse sociale* » ne doivent pas être pris littéralement. Il se peut que, dans une société civile, il n'y ait pas de caisse sociale. « *Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, importe peu, il y a toujours un fonds commun ; et dès que l'un des associés détourne de sa destination une partie du fonds social, dans son intérêt particulier, l'article 1846 doit recevoir son application* »[2].

À partir de quel moment les intérêts sont-ils dus ? À partir du moment où les fonds ont été retirés de la caisse sociale, donc détournés de leur destination sociale. Il est seulement nécessaire de prouver que les fonds ont été retirés, et non qu'ils ont été effectivement utilisés au profit de l'associé. Les intérêts sont dus indépendamment du fait de savoir si l'associé a effectivement retiré un profit des fonds ainsi retirés et courent à ce qu'il restitue la somme retirée de la caisse sociale[3].

Art. 1847 C.c.

« *Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société* ».

L'article visé fait encore partie d'une des nombreuses dispositions qui remontent à Pothier. Ce dernier a expliqué que, si l'associé apporteur a une autre industrie qui ne fait pas l'objet de la société, alors il ne doit pas compte à ses co-associés des gains qu'il en retire[4]-[5]. Cette solution est logique et équitable.

Art. 1848 C.c.

« *Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière : mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée* ».

L'hypothèse envisagée par cet article est celle où **un des associés** est créancier d'une tierce personne et que ce débiteur est en même temps débiteur de la société à laquelle cet associé participe. Le débiteur paye un acompte sur la dette sans qu'il ne soit procédé à une imputation de ce montant sur les deux créances. L'article 1848 C.c. prévoit que, dans ce cas de figure, l'imputation doit se faire sur la

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 263.
2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 271.
3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 272.
4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26. p. 266.
5 – CA Lyon du 18 juin 1856, *D.*, 1857, n° 2, p. 71.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

créance de l'associé et sur celle de la société dans la proportion de leurs créances respectives. La raison de cette disposition, donnée par Pothier, est que chaque associé doit aux affaires de la société le même soin qu'à ses propres affaires. Si les créances de l'associé et de la société sont également exigibles le payement doit profiter à l'une et à l'autre de façon égale, c.-à-d. proportionnellement aux montants dus[1].

Art. 1849 C.c.
« *Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part* ».

Cette disposition est encore empruntée à Pothier. Il convient en premier lieu de préciser l'hypothèse dans laquelle Pothier se place, à savoir celle où les associés ont un pouvoir réciproque, c.-à-d. donc qu'ils se sont donnés pouvoir l'un pour l'autre de faire les affaires de la société. « *Devant exiger le paiement pour le compte de la société, il n'a pas dû préférer son intérêt particulier à celui de la société. En revanche, si l'associé n'avait pas pouvoir de recevoir la créance sociale, on ne peut pas lui reprocher d'avoir négligé les intérêts communs ; car ce n'était pas lui qui était chargé de recouvrer la créance, il n'a même pas le droit d'en recevoir le paiement* »[2].

Art. 1850 C.c.
« *Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ses dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires* ».

De quelle faute s'agit-il ? Selon la doctrine, il y a lieu de se référer au droit commun tel que contenu à l'article 1137 C.c. Par conséquent, l'associé sera tenu d'apporter aux affaires sociales les soins d'un bon père de famille[3]. Quel est le sens de l'interdiction de compensation des dommages avec les profits générés dans d'autres affaires ? Selon Pothier, la raison en est la suivante : l'associé doit son industrie à la société. En lui apportant tous les profits que son industrie procure, il ne fait que s'acquitter envers elle de tout ce qu'il devait. La société ne lui doit donc rien qu'il puisse opposer en compensation de ce qu'il lui doit[4].

Mais il ne faut pas perdre de vue que le Code civil envisage une hypothèse tout à fait spéciale, celle où le dommage a été causé dans une affaire et où le profit a été procuré dans une autre. S'il s'agissait donc d'une seule et même affaire, l'associé pourrait compenser les profits avec les pertes. Cette position ne fait toutefois pas l'unanimité[5].

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 273.
2 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 285.
3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 266.
4 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 287.
5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 270.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 1851 C.c.

« Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.

Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation ».

Cet article vise les **apports en jouissance**, soit donc les apports où l'associé garde la propriété de la chose, alors que la société bénéficie de l'usage et de la jouissance de la chose. Lorsque la société est débitrice d'un corps certain, le Code civil applique les règles relatives aux dettes d'une chose déterminée. La société sera donc libérée par le **cas fortuit**, sauf qu'elle devra le prouver dans la mesure où il est allégué par la société. « *Elles sont à ses risques, comme l'explique Pothier, en ce sens que si elles ont été détériorées sans la faute des associés, il les reprendra dans l'état où elles se trouvent, et si elles ont été entièrement péries, la société serait déchargée envers lui de l'obligation de les lui restituer* »[1].

Art. 1852 C.c.

« Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion ».

Pothier donne comme exemple les **frais de voyage** que l'associé a encourus pour le compte de la société. Dans ce même contexte, il est encore admis que la société doit des intérêts sur les sommes que l'associé a déboursées pour le compte de la société[2].

L'associé peut encore se retourner contre la société en raison des obligations contractées de bonne foi pour les affaires de la société. L'hypothèse est celle où l'associé traite en son nom et qu'il est donc personnellement engagé envers les tiers. Ayant par hypothèse traité pour le compte de la société, il peut la mettre en cause (ou ses associés si la société était dénuée de la personnalité morale). La condition est toutefois que l'associé ait agi de **bonne foi**[3]. Pothier donne comme exemple le cas d'un associé qui a vendu des effets appartenant à la société : l'associé doit être indemnisé par la société de l'obligation de garantie qu'il encourt envers l'acheteur[4].

La loi est pourtant restrictive dans mesure où elle n'accorde indemnité que pour les « *risques inséparables de sa gestion* ». En d'autres termes, l'associé n'a pas d'action pour tous les risques qu'il peut courir, mais seulement pour ceux qui sont inséparables de sa gestion. Pothier déduit de cette règle que, si un associé est dépouillé par des **voleurs** au cours d'un voyage fait pour le compte de la société, alors celle-ci

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 284.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 290.

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 290.

4 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 288.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

doit l'indemniser pour les sommes qu'il avait sur lui dans la mesure où il ne pouvait pas s'en passer, mais où la société ne doit pas porter le risque du superflu[1].

Art. 1852*bis* C.c.

« *Sauf dispositions contraires des statuts, si un titre est grevé d'un usufruit notifié à la société ou accepté par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 :*

1° *le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier, et*

2° *l'usufruitier a droit au bénéfice que la société décide de distribuer.*

En cas de rachat par la société de ses propres titres, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont respectivement droit à la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit portant sur ces titres.

Lors de la dissolution de la société, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit exercé conformément à l'article 587 sur les sommes versées au nu-propriétaire ou sur la valeur des biens qui lui ont été remis ».

Cet article fait encore partie des nombreuses innovations de la Loi de Modernisation. Antérieurement à cette loi, le droit des sociétés luxembourgeois ne comportait pas de dispositions précises quant au traitement des démembrements de propriété, concrètement du cas où un droit d'usufruit est concédé par le détenteur de titres, conduisant ainsi à un démembrement entre nue-propriété et usufruit. Par le passé, le cas des usufruitiers/nus-propriétaires était traité comme celui des indivisaires : à l'égard de ces derniers, la L.S.C. (en son article 38, devenu art. 430-2 L.S.C.) permettait déjà à la société de suspendre l'exercice des droits afférents aux titres en indivision jusqu'au moment où une seule personne soit désignée à son égard comme étant propriétaire de l'action.

Comme souligné par le commentaire des articles dans le document parlementaire n° 5730, les questions soulevées par les démembrements de propriété sont multiples : droit de vote, droit à l'information, droit aux dividendes, droits respectifs (du nu-propriétaire et de l'usufruitier) aux réserves, droits respectifs aux DPS, droits respectifs en cas de rachat d'actions ou d'amortissement d'action, etc.

La Loi de Modernisation a procédé par une approche diversifiée cumulant des dispositions de nature générale (applicables à toutes les sociétés) dont fait partie l'article 1852*bis* C.c. ensemble avec l'article 1865*bis* C.c. avec des dispositions spécifiques applicables seulement à l'une ou l'autre forme de sociétés ; font partie de ce dernier type de dispositions les articles 420-24 et 420-26 L.S.C. applicables aux S.A. ou encore les articles 710-12 et 710-24 L.S.C. applicables aux S.à r.l., etc.

Art. 1853 C.c.

« *Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.*

À l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

Lorsqu'il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits financiers respectifs à la performance d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société ».

1 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 288.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La convention des parties étant muette sur le partage dans les bénéfices et les pertes, la part de chacun est en proportion de la mise de chacun dans le « *fonds de la société* »[1]. Le Code civil a ainsi réglé une vieille controverse de l'ancien droit : alors que Domat enseignait que, si la convention ne prévoyait rien, les portions des gains et des pertes de chacun devraient être égales, Pothier préconisait **l'égalité proportionnelle**.

La loi « *laisse, en principe, pleine liberté aux parties contractantes. C'est le droit commun. Il était inutile de le proclamer* »[2]. Par conséquent, la répartition des bénéfices relève du champ d'application de la **liberté contractuelle** : toute règle impérative imposée par le législateur pour faire prévaloir l'égalité entre associés malgré l'inégalité des mises risque en fait de ne pas satisfaire à cet objectif : « *Il est évident que ceux qui forment une société sont les seuls qui puissent bien connaître et justement apprécier ce que chacun d'eux y apporte en valeurs réelles, mais surtout en industrie, en zèle, en talents, en activité, en courage* »[3].

Probablement mus par un optimisme béat, les associés ont tendance à ne prévoir que la participation aux bénéfices. Se pose donc la question de savoir quelle est la participation aux pertes dès que celles-ci existent (qui souvent correspondent à des pertes de démarrage, « *start-up losses* »). Souvent elles précèdent donc la réalisation des bénéfices.

Quelle solution faut-il adopter lorsque l'acte de société ne prévoit rien quant au **partage des pertes** ? La solution traditionnelle consiste à répartir les pertes dans la même proportion que les bénéfices. C'est donc l'égalité proportionnelle que les associés sont censés vouloir par cela seul qu'ils n'y ont pas dérogé[4].

Cette question donne lieu à quelques questions intéressantes pour la raison que leur analyse permet de tirer des conclusions importantes sur les notions « d'apport » et de « partage ». Le cas qui est mentionné ici est celui où le contrat de société prévoit des mises inégales alors que les pertes (et les bénéfices) doivent, selon l'accord des associés, se partager de façon égalitaire.

Prenons le cas (qui a donné lieu à un litige finalement dévolu à la Cour de cassation française) d'une société de commerce dans laquelle deux personnes apportent respectivement 30 000 et 20 000 francs, alors qu'il est prévu que les résultats sont partagés par moitié entre les associés[5]. Quelques années plus tard, les pertes d'exploitation absorbent la totalité du capital social et la société est liquidée. L'associé qui avait fait l'apport le plus important prétendit alors qu'il avait le droit de répéter contre son co-associé la somme de 5 000 francs. Cette demande fut toutefois rejetée par la Cour de Paris et par la Cour de cassation[6]. « *Les apports ne se prélèvent pas, ils se confondent dans une masse commune appartenant aux deux associés dans la proportion stipulée pour le partage des bénéfices, c'est-à-dire pour moitié. Ainsi, les 50 000 francs, montant des apports, auraient été partagés par moitié si le fonds social était resté intact ; l'associé qui avait apporté 30 000 francs n'aurait eu droit*

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 306.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 293.

3 – Boutteville, que cite Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 293.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 294.

5 – Cet exemple est tiré de Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 294.

6 – Ch. civ. du 27 mars 1861, *D.*, 1861, I, p. 161.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

qu'à 25 000 francs ; c'est aussi cette somme que chacun d'eux perd quand le fonds social est perdu »[1].

L'auteur cité ici commente encore une des difficultés classiques inhérentes à la solution des parts proportionnelles : il s'agit de la question du traitement de celui qui n'apporte que son **industrie**. La solution retenue, qui peut étonner de prime abord, car elle semble témoigner d'un certain dédain pour le travail[2], fut proposée par le tribunal à la suite du raisonnement suivant : « *Donnerons-nous la plus forte ou la plus faible des parts des autres associés à celui qui n'apporte que ses bras, sa tête et son courage, et qui néglige de faire régler la part qui lui sera accordée ? […] Si nous lui donnons la plus forte, n'encouragerons-nous pas l'insouciance et l'oubli de la précaution la plus facile à prendre ? En ne lui assignant que la plus faible, nous lui donnons le sage avertissement de ne jamais négliger de stipuler lui-même ses intérêts et de faire régler son sort* »[3].

Certains considèrent qu'il s'agit d'une peine, et ceci, pour la raison que l'apport en industrie serait le plus susceptible d'une **estimation arbitraire**. En tout état de cause, cette disposition est d'interprétation stricte : elle ne vise que le cas de l'associé qui n'a apporté que son industrie, avec donc la conséquence que, si l'associé a apporté en même temps autre chose (argent, titres), alors l'article 1853 n'est plus applicable. On revient au droit commun avec donc la conséquence que l'associé demandeur devra prouver la valeur de son apport. Ce point fut confirmé par la jurisprudence[4].

Une autre particularité de l'apport en industrie (qui représente une obligation de faire) est la suivante : l'apport se réalise successivement avec donc la conséquence que l'apporteur en industrie ne reçoit sa pleine part dans les bénéfices que dans la mesure où il a fourni son travail pendant toute la durée de la société. En d'autres termes, si la société était contractée pour dix ans et dissoute après cinq ans, l'associé industriel n'aurait réalisé que la moitié de son apport et ne pourrait prétendre qu'à la moitié de sa part dans les bénéfices[5].

Est-il possible d'avoir une participation différente dans les bénéfices et dans les pertes ? Contestée en droit romain, la question fut tranchée positivement dans l'ancien droit et également par le Code civil. Comme l'explique Domat : « *Comme les associés peuvent contribuer différemment, les uns plus, les autres moins de travail, d'industrie, de soin, de crédit, d'argent ou d'autre chose, il leur est libre de régler inégalement leurs portions, selon que chacun doit avoir sa condition plus ou moins avantageuse, à proportion de la différence de ce qu'ils contribuent* »[6]. Cet auteur, tout comme Pothier, ne fait pas une condition de validité de la clause du fait qu'il y ait effectivement une inégalité des contributions.

Un argument de texte peut être trouvé dans les dispositions du Code civil : les articles 1811 et 1521 C.c. interdisent la clause dans le cheptel simple et dans la communauté. Ces exceptions supposent qu'en règle générale les parties peuvent convenir d'une part différente dans les bénéfices et dans les pertes[7].

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 294.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 308.

3 – Boutteville, Rapport n° 14 (Locré, T. VII, p. 250) Gillet, Discours n° 16 (Locré, p. 255).

4 – Cass. du 14 janvier 1865, *D.*, 1866, I, p. 133 ; Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 308.

5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 309.

6 – J. Domat, *Lois civiles*, Livre I, titre VIII, section I, p. 89.

7 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 304.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 1854 C.c.

« *Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.*

Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution ».

Cette disposition vise un cas tout à fait particulier, à savoir celui où les parties se sont rapportées à l'un d'eux ou à un tiers. Cette disposition, encore une fois empruntée à Pothier, n'est pas et n'a jamais été dans les mœurs : il est contre la nature de la société que les associés d'une société s'abandonnent à l'autorité d'un seul, étant donné que **l'égalité** est de l'essence de la société[1].

Art. 1855 C.c.

« *La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle.*

Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.

Ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs, organisent la cession ou l'acquisition de droits sociaux, qui n'ont pas pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux ».

Pour plus de détails, voir à différents endroits sous société (ou clause) léonine.

Selon Pothier : « *Il est de l'essence du contrat de société que les parties se proposent, par le contrat, de faire un gain ou un profit dans lequel chacun des associés puisse espérer d'avoir part à raison de ce qu'il apporte à la société. C'est pourquoi si, par le contrat d'une prétendue société, il était convenu que le profit appartiendrait en entier à l'une des parties contractantes, sans que l'autre y pût prétendre de part en aucun cas, une telle convention ne serait pas un contrat de société, et elle serait nulle comme manifestement injuste* »[2].

La non-participation aux pertes de l'associé exclu des bénéfices, loin de corriger cette exclusion des bénéfices (en rendant nulle la société léonine) serait en fait un autre vice pour la raison que l'alinéa 2 de l'article 1855 C.c. interdit d'affranchir un associé des pertes sociales.

Si la loi prohibe qu'un des associés reçoive la totalité des bénéfices, elle n'interdit pas une **participation inégale** qui peut trouver son origine dans le fait que celui qui a une part plus grande rend des services plus importants à la société. Même si tel n'est pas le cas, la répartition en question reste valable, car l'article 1855 C.c. ne s'applique pas en l'occurrence[3].

En revanche, la doctrine retient que la prohibition de la clause léonine reste applicable au cas où le contrat de société attribuerait à un des associés une part si minime

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 306.

2 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 244.

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 298.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dans les bénéfices qu'elle serait illusoire. Dans ce cas, la société n'est pas conclue dans l'intérêt commun des associés. En accordant ainsi à l'un des associés une part nominale, les associés n'ont fait qu'éluder la prohibition de l'article 1855 C.c., ce qui serait un cas de fraude à la loi[1].

La disposition légale donne lieu à certaines hésitations lorsque la participation aux bénéfices n'est pas certaine. Toujours selon Pothier, le fait qu'un associé puisse, dans un certain concours de circonstances, être exclu des bénéfices de la société ne serait pas un cas d'application de l'article 1855 C.c. Il suffit que chaque partie puisse espérer avoir droit au bénéfice.

Pothier donne l'exemple suivant : il y a contrat de société entre un apporteur de pierres précieuses et un apporteur en industrie ; ce dernier s'efforce de vendre les pierres ayant appartenu au premier. Il aura droit à la part de bénéfices qui excède le montant de 10 000 francs et n'aura rien si le prix ne dépasse pas cette somme[2].

L'article 1855 C.c., en interdisant également qu'un associé soit affranchi des pertes, déroge à l'ancien droit : pour ce dernier, une telle convention était valable. Si le Code civil s'est ainsi éloigné de l'ancien droit, il semble que les deux clauses aient été considérées comme étant contraires à l'essence de la société[3].

L'article 1855 C.c. constituant une **restriction** au principe de la **liberté des conventions,** il y a lieu de l'interpréter de manière restrictive. L'alinéa 2 visant la stipulation qui affranchirait des pertes uniquement « les sommes et effets » mis à la disposition de la société, on en déduit que l'apporteur en industrie peut être exclu de la participation aux pertes[4].

Est encore valable la clause qui dispense un associé de contribuer aux pertes au-delà de sa mise. Cette clause est valable pour la seule raison qu'elle n'est pas prohibée. Dès que la décharge n'est pas absolue, la convention est en principe valable[5].

La convention qui se heurterait à l'article 1855 C.c. et qui serait ainsi **nulle comme société** pourrait être validée comme **prêt**[6].

En 2016, l'article 1855 C.c. a été complété par l'alinéa 3 suivant : « *Ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs, organisent la cession ou l'acquisition de droits sociaux, qui n'ont pas pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux* ».

L'objet de cet amendement introduit par la Loi de Modernisation était de limiter l'interdiction de la clause léonine au seul cas où la clause porte atteinte à la répartition des résultats telle que prévue par le pacte social. Ainsi donc, une convention entre associés par laquelle un des associés s'engage à racheter à un prix correspondant au prix nominal de ces actions (en garantissant donc au bénéficiaire de cet engagement que ce dernier ne peut subir de perte sur son investissement) ne constitue pas une clause léonine interdite par le Code civil (car elle n'impacte pas la répartition des résultats prévue par le contrat de société). En revanche, si la société s'engageait à

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 298.

2 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 244.

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 302.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 302.

5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 302.

6 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

racheter à l'un ou l'autre des associés leurs actions à la valeur nominale, alors il y aurait potentiellement clause léonine dans la mesure où certains associés seraient ainsi déchargés de la participation aux pertes, faveur qui serait ainsi financée par les autres associés.

Art. 1856 C.c.

« *L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.*

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure ; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat ».

Cet article vise le cas où le gérant est désigné par clause spéciale du contrat de société. Dans ce cas de figure, la nomination est l'œuvre de tous les associés.

L'article commenté répond encore à la question de savoir si le **gérant** est **révocable**. La loi distingue le gérant nommé par le contrat de société de celui nommé par un acte postérieur. Dans le premier cas, le mandat donné au gérant est l'objet d'une clause de la convention et, selon l'approche traditionnelle, ces clauses ne peuvent être modifiées que de l'accord unanime. Selon le Code civil, il peut y avoir « révocation » pour « cause légitime », ce qui serait synonyme d'incapacité ou d'infidélité. « *Quand la loi parle de révocation, elle entend une destitution prononcée par le juge, elle ne l'admet que pour cause légitime ; dès lors, il faut que la question soit soumise au juge : les associés ne peuvent pas juger, puisqu'ils sont parties en cause* »[1].

Art. 1857 C.c.

« *Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration* ».

En cas de **pluralité de gérants**, ceux-ci ne forment pas un collège, mais chacun a le pouvoir de faire tous les actes d'administration sans l'autre. Telle est la solution que l'on peut en pratique observer dans certaines S.à r.l.

Art. 1858 C.c.

« *S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration* ».

Même les cas d'urgence ne semblent pas permettre à un des gérants d'agir si la convention est qu'il ne peut agir sans l'autre[2].

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 313.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 310.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 1859 C.c.

« À défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes :

1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.

2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.

3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.

4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent ».

Cette disposition règle la question très importante de la gestion de la société en cas de **silence des statuts**. La loi n'organise donc pas directement l'administration de la société : elle n'intervient que dans l'hypothèse où les associés n'ont pas prévu de dispositions concernant cette administration. Le législateur a donc prévu, à **titre supplétif**, les clauses les plus habituelles rencontrées en la matière. Mais il va de soi que la solution de loin la plus adaptée est que les associés décident du mode de gestion de leur société tout en tenant compte des points suivants : « *Les associés ne peuvent pas tous gérer à la fois, ce serait l'anarchie. Ils doivent donc constituer une administration. Quels sont les pouvoirs du gérant ? C'est le point essentiel, et il donne lieu à un conflit d'intérêts. Les associés peuvent craindre que le gérant n'abuse de ses pouvoirs ; mais s'ils les restreignent dans des limites trop étroites, l'administration, impuissante pour le mal, sera aussi impuissante pour le bien. Il faut donc une certaine latitude d'action pour la gestion des affaires sociales, et il faut les garanties pour prévenir l'abus. Il est évident que le législateur est sans qualité pour réglementer des intérêts qui varient d'une convention à l'autre. C'est aux associés d'organiser une administration qui réponde au but de la société et aux droits qu'il s'agit de sauvegarder* »[1].

Aux termes de l'alinéa 1, chacun des associés dispose d'un mandat d'administrer et peut donc administrer au nom de tous sans avoir besoin de leur consentement. Ils y ont consenti d'avance en se donnant le mandat réciproque d'administrer. Les termes « sont censés » n'indiquent pas une présomption. « *Il y a donc mandat tacite résultant de la force des choses et du droit égal de tous les associés […] En effet, si chaque associé n'avait pas le droit d'agir, tous les associés devraient concourir dans tous les actes faits au nom de la société : or, ce concours de toutes les volontés pour chaque acte d'administration est impossible, car l'administration est une affaire de tous les jours, de tous les instants […]* »[2].

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 310.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 320 ; l'auteur admet toutefois que la question est controversée.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 1860 C.c.

« *L'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société* ».

Cet article fait suite à l'article 1859 C.c. qui suppose que l'acte social n'a pas nommé d'administrateur. Dans ce cas de figure, les associés se donnent **mandat d'administrer** sans avoir la qualité d'administrateur. C'est par rapport à ces associés qui ne sont pas administrateurs que la loi dispose qu'ils n'ont pas le droit de disposer des choses mobilières ou immobilières qui dépendent de la société.

La loi interdit à tout associé qui n'est pas administrateur d'aliéner tout en y ajoutant le terme « et d'engager » en entendant ainsi prohiber tout acte de disposition, vente ou concession de droits réels. « *D'ordinaire la loi se sert du mot hypothéquer pour exprimer cette idée ; dans l'espèce, elle ne pouvait l'employer, puisqu'elle étend la prohibition aux choses mobilières ; or, on n'hypothèque pas les meubles, quoiqu'on puisse les donner en gage. La loi veut donc dire que l'associé ne peut pas faire acte de propriété, soit en aliénant les choses mobilières ou immobilières appartenant à la société, soit en les grevant de droits réels* »[1].

Art. 1861 C.c.

« *Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société ; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration* ».

Cet article consacre deux principes : un associé, fût-il administrateur, ne peut sans le consentement des autres associés associer un autre nouvel associé. Dans les termes de Pothier : « *C'est une chose qui paraît dépasser les bornes d'une simple administration que de donner à ses associés un associé qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes* »[2].

En revanche, l'associé peut s'associer un tiers relativement à la part qu'il a dans la société. À cette fin, il n'a pas besoin du consentement des autres associés, étant donné que la convention qui le lie au tiers est étrangère au contrat de société conclu avec les autres associés[3]. La convention ainsi conclue entre l'associé et le tiers est désignée par le terme de « **convention de croupier** ».

Pour plus de détails, voir sous ce terme.

Art. 1862 C.c.

« *Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir* ».

Le chapitre III du titre IX du Code civil consacré au contrat de société est intitulé « *Des engagements des associés entre eux et à l'égard des tiers* ». La loi ne parle

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 322.

2 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 275.

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 343.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

pas des engagements de la société à l'égard des tiers, mais de ceux des associés. La raison en est que, dans l'optique du Code civil, la société n'a pas de personnalité juridique distincte de celle des associés : il n'y a donc pas de société débitrice, mais des associés débiteurs. « *C'est en ce sens que l'article 1862 dit que l'un des associés ne peut obliger les autres que si ceux-ci lui en ont conféré le pouvoir ; donc quand l'un des associés a le pouvoir d'obliger les autres, ceux-ci se trouvent obligés personnellement par les engagements que l'associé a contractés en leur nom ; il n'est pas question d'une société obligée* »[1].

Cet article confirme le droit commun en matière d'obligations civiles pour lesquelles la solidarité ne se présume pas, mais doit être expressément stipulée ou encore établie par une disposition légale (voir article 1202 C.c.). L'obligation se divise donc entre les associés.

Selon une jurisprudence aujourd'hui dépassée, est civile l'association de fait qui a pour objet la mise en valeur d'un terrain par la construction d'immeubles. Il s'ensuit que les associés, à moins de conventions contraires, sont obligés envers les créanciers non pas solidairement, mais chacun pour une somme et part égales[2].

Art. 1863 C.c.

« *Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part* ».

L'article consacre le principe selon lequel les associés sont tenus pour une **part virile**, ce qui signifie que, s'ils sont deux, chacun est tenu pour la moitié, etc., même si, selon l'acte de société, l'un des associés doit supporter une moindre part[3].

Conformément à la même remarque que celle faite sous l'article précédent, les auteurs du Code civil partaient de l'hypothèse où la société n'a pas de personnalité morale : il en résulte que ce sont les associés qui sont tenus à l'égard des tiers pour une part virile, ce qui implique que le créancier poursuit les associés, et non une personne morale distincte[4].

D'un autre côté, l'article 1853 C.c. dispose que la part des associés dans les bénéfices et les pertes est proportionnelle à leur mise, avec donc la conséquence que souvent la part virile avec laquelle les associés sont tenus à l'égard des tiers n'est pas la part réelle pour laquelle ils contribuent aux dettes entre eux[5].

Cette disposition a pour conséquence que les associés restent tenus de leur part virile, alors même que le tiers aurait connaissance du pacte social prévoyant des parts différentes à l'égard des divers associés[6].

---

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 364.

2 – CA du 6 décembre 1933, *P.*, n° 13, p. 534, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 358.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 364.

5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 358.

6 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 359.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Si la **personnalité juridique** de la société civile est reconnue depuis longtemps par la jurisprudence luxembourgeoise[1] (avant d'être confirmée par la loi du 18 septembre 1933 sur les S.à r.l.), cette même jurisprudence n'a pas toujours déduit les conséquences correctes de cette personnalité morale : en effet, l'arrêt précité de 1875 retint qu'« *une société civile, quoique constituant un être moral, ne peut ester en justice autrement qu'au nom de tous les associés, qui doivent figurer à l'instance* ». Cette décision, justifiée par la maxime « *nul ne plaide par procureur* » est loin de convaincre. En effet, si la société a la personnalité morale, elle ne plaide pas par procureur si elle agit en son nom et pour son compte : l'identité du plaideur est désignée à suffisance, puisqu'il s'agit de la société civile elle-même.

« *La société civile jouissant de la personnalité juridique, c'est la société elle-même qui, disposant d'un patrimoine autonome, répond de ses dettes sur les biens sociaux dont elle est seule propriétaire, les associés n'étant pas copropriétaires des biens sociaux, mais n'étant que titulaires d'un droit de créance à l'encontre de la société* »[2].

Les créanciers d'une société civile doivent d'abord réclamer leur dû à la société elle-même avant de pouvoir se retourner contre les associés en vue du paiement des dettes sociales[3].

Dans la société civile, « *chaque associé peut agir en responsabilité contractuelle contre le gérant pour faute de gestion pour la part de dommage, même collectif, qu'il a éprouvée, et que chaque associé peut agir en annulation des délibérations irrégulières et des décisions prises par les organes de la société (gérant, assemblée générale) qui excèdent les pouvoirs de ceux-ci, sont le résultat d'une machination frauduleuse ou se trouvent entachées d'excès de pouvoir, chaque associé ayant un droit individuel à l'observation de la loi et des statuts […]*

En revanche, la personnalité morale de la société s'imposant dans les relations extérieures, les associés sont en principe dépourvus de qualité pour agir en nullité des actes que la société, représentée par son gérant, a conclus avec des tiers. Dans ce cas, seule la société civile a qualité pour exercer les actions sociales par l'intermédiaire de son gérant (cf. action pour lésion) […] »[4]

Art. 1864 C.c.

« *La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société* ».

L'article est de nos jours de peu d'intérêt, son objet étant de définir dans quelle mesure la société dénuée de personnalité morale était engagée par les actes d'un de ses associés.

1 – V. CSJ du 11 mars 1875, *P.*, nº 1, p. 63.

2 – Cour 11 mars 1999, *BIL-Viloti S.C.I.*, nº 21.955, *P.*, nº 31, p. 124, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour 11 mars 1999, *BIL-Viloti S.C.I.*, nº 21.955, *P.*, nº 31, p. 124, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA civ. du 10 juillet 2003, nºs 23.054, 24.097 et 26.382, *BIJ*, 2004, nº 2, p. 28.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 1865 C.c.
« *La société finit :*
1° par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ;
2° par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;
3° par la mort naturelle de quelqu'un des associés ;
4° par l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ;
5° par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société ».

L'article ajoutait « la mort civile ». La mort civile est abolie par l'article 18 de la Constitution et ne peut donc plus justifier une dissolution[1].

L'article dit : « *la société finit* », ce qui signifie que cet effet se produit, que les associés le veuillent ou non. La société est **dissoute de plein droit** lorsqu'un des cas mentionnés par les alinéas 1 à 5 est réalisé. Si les associés décident de continuer la société, il y aura une nouvelle société, et non continuation de la société ancienne[2].

Ad 1 : La société finit par l'expiration du terme.

Ce sont les associés qui ont librement défini le terme de la société. C'est donc par la **volonté des parties** que la société est dissoute. Cette volonté s'est exprimée au moment de la conclusion du contrat de société : elle n'a plus besoin de s'exprimer lorsque le terme est échu[3]. Les parties sont libres de fixer la durée de leur société. Si les statuts sont muets sur la question, la société est supposée conclue pour toute la vie des associés. La question de savoir si la société est à terme ou à durée illimitée est importante au vu de la possibilité de dissolution de la société. Selon l'article 1844 C.c., une société sera à durée limitée lorsqu'elle est conclue pour réalisation d'une affaire à durée limitée : si tel est le cas, la société sera à durée limitée. Dans ce cas, la volonté d'un associé ne peut plus mettre fin à la société : celle-ci prend fin avec la réalisation de l'affaire que la société se propose de réaliser[4]. En revanche, lorsque la société est constituée pour une série d'opérations, alors il n'est plus possible de lui assigner une limite précise. « *Dans l'esprit de nos lois modernes, on ne peut pas contracter d'engagements perpétuels ; c'est déjà un engagement perpétuel, au point de vue de l'homme, qu'un engagement contracté à vie ; aussi les lois romaines qualifient les sociétés à vie de sociétés perpétuelles. La loi admet les sociétés à vie, quoiqu'elle réprouve le louage de service contracté à vie (art. 1 780) […]* »[5].

Ad 2 : La société finit encore par l'extinction de la chose.

Au terme « chose », il faut donner la même signification que celle que lui donne l'article 1832 C.c. Selon Pothier, « *[L]orsque la société a été contractée d'une certaine chose, il est évident que la société doit finir par l'extinction de cette chose* »[6]. Pour

1 – CA du 2 février 1977, *P.*, n° 24, p. 58 , cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 372.

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 374.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 375.

5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 375.

6 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 291.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Pothier, extinction est synonyme de **perte totale** ; exemple donné : la mort d'un animal mis en commun. En cas de **perte partielle**, on convient de dire que la dissolution n'est pas automatique, mais qu'elle pourrait être décidée par les juridictions sur la base de l'article 1871 C.c. (donc de causes légitimes)[1].

La société est encore dissoute par « *la consommation de la négociation* ». Par cette expression, on entend le cas où l'affaire pour laquelle la société a été contractée est consommée. Même si l'alinéa 2 mentionne ce cas en même temps que celui de l'extinction de la chose, il est vrai qu'il existe une différence fondamentale entre ces deux cas de figure. Dans le premier cas, le but de la société est atteint de sorte que la société n'a plus de raison d'être, alors que, dans l'autre, le but ne peut plus être atteint[2]. À quel moment peut-on considérer qu'il y a consommation de la négociation ? Pothier donne l'exemple de deux marchands qui achètent ensemble une certaine quantité de marchandises qu'ils vendent à une foire. La négociation est consommée lorsque toutes les marchandises sont vendues[3].

Ad 3 :

Cet alinéa se réfère à la mort naturelle, car le Code Napoléon connaissait encore la mort civile (qui entraînait d'ailleurs également la dissolution de la société).

Si, de façon générale, on contracte pour soi et pour ses héritiers (voir art. 1122 C.c.), cette disposition comporte une restriction importante, à savoir « *à moins que le contraire ne résulte de la nature de la convention* ». Le contrat de société fait partie justement des conventions qui, par leur nature, ne peuvent se transmettre aux héritiers : la société est fondée sur la confiance fondée sur la capacité et la moralité de la personne avec laquelle on s'associe. En maintenant la société à l'égard des héritiers, les survivants se seraient associés à des inconnus[4].

Le contrat de sociétés est conclu en considération des qualités personnelles des associés : « *Je ne dois donc pas être obligé, lorsque l'un de mes associés est mort, à demeurer en société avec les autres, parce qu'il se peut faire que ce ne soit que par les considérations personnelles de celui qui est mort, que j'ai voulu contracter la société* »[5]. Il est vrai que le contrat de société peut valablement prévoir la continuation de la société avec les héritiers de l'associé décédé.

L'alinéa 3 de cet article doit être complété par l'article 1868 C.c.

Ad 4 :

L'interdiction d'un associé conduit à la dissolution de la société. Elle équivaut donc à la mort de l'associé. L'aliénation met l'associé dans l'impossibilité de rendre les services qu'il était supposé rendre à la société. Comme il est mis sous tutelle, ce serait en réalité le tuteur qui serait associé[6].

Il est en revanche requis que l'interdiction soit prononcée. L'état de folie habituelle serait insuffisant. Mais, dans ce cas, la dissolution pour justes motifs serait

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 382.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 378.

3 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 292.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 384.

5 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 293.

6 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 393.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

envisageable en application de l'article 1871 C.c. C'est au demandeur d'établir la preuve des justes motifs constitués par l'aliénation mentale de l'associé.

La **déconfiture** d'un associé est une cause de dissolution pour la raison suivante :

« *[…] l'insolvabilité est un dérangement dans les affaires, suite d'une mauvaise gestion ou de l'inconduite ; on ne se serait certes pas associé avec une personne insolvable ; dès lors l'insolvabilité doit mettre fin à la société* »[1].

La déconfiture est mise sur le même niveau que l'interdiction, et ceci, bien qu'il y ait des différences sensibles entre ces deux notions. Si l'interdiction qui prive la personne concernée de l'exercice de ses droits opère un changement d'état, il n'en va pas de même de la déconfiture. En effet, le débiteur insolvable reste à la tête de ses affaires[2]. La loi est silencieuse en ce qui concerne la **faillite**. La question s'est posée de savoir si l'on peut étendre à la faillite la disposition qui textuellement vise uniquement la déconfiture. La jurisprudence, depuis très longtemps, y a répondu affirmativement, en décidant que la faillite est la déconfiture du commerçant et que donc le terme de déconfiture comprendrait donc celui de la faillite[3]. Les effets de la faillite étant bien plus importants que ceux de la déconfiture à l'égard des non-commerçants, on peut faire état non seulement d'un argument par analogie, mais également d'un argument *a fortiori* pour justifier de l'application de l'article 1865 (4) C.c. au cas de la faillite d'un associé.

Lorsque, suite à un concordat, le débiteur est replacé à la tête de ses affaires, cela met fin à son dessaisissement. Le concordat n'a pas d'effet sur la dissolution de la société. Celle-ci doit avoir lieu dès le jugement déclaratif de la faillite ; elle ne saurait revivre du fait du concordat[4].

Ad 5 :

Cet alinéa permet à première vue à tout associé de mettre fin à la société par simple **déclaration de volonté**. Cette interprétation est trop absolue et inexacte[5]. En effet, l'alinéa 5 trouve son complément dans l'article 1869 C.c. La dissolution par la volonté d'une des parties est applicable uniquement aux sociétés à **durée illimitée**.

Les causes de dissolution prévues par la loi constituent des règles prévues pour le cas de silence des statuts. En vertu de la liberté contractuelle, les associés de la société peuvent écarter ces causes de dissolution ou encore en prévoir d'autres. Cette liberté s'exerce dans le cadre des règles d'ordre public et des bonnes mœurs. Les causes de dissolution sont, en général, d'intérêt privé[6].

Mais la faculté de renonciation prévue par l'article 1869 C.c. est d'ordre public avec donc la conséquence qu'il ne peut pas y être dérogé (donc renoncé d'avance).

Le système introduit par le Code civil est basée sur la distinction entre sociétés à terme et sociétés à durée illimitée. Les sociétés à durée illimitée sont dissoutes par la volonté d'un (ou de plusieurs) associé(s) de ne plus rester en société (art. 1865,

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 395.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 395.

3 – Cour de Paris du 5 janvier 1853, *D.*, 1854, nº 5, p. 708.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 396.

5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 400.

6 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 398.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

5°, C.c.) : encore faut-il que cette renonciation soit faite de bonne foi et non à contre-temps.

Quant aux **sociétés à terme**, la dissolution avant l'arrivée de ce terme ne peut être demandée qu'à condition qu'il y ait de justes motifs (art. 1871 C.c.).

Compte tenu des différences importantes existant entre les sociétés selon qu'elles sont ou non à terme, il est utile de se pencher sur la définition des sociétés à terme. La possibilité pour un associé de mettre fin à une société conclue pour une durée illimitée, alors que tous les associés avaient librement accepté cette situation dans le contrat de société, constitue une entorse à une règle fondamentale du droit des conventions. En effet, ces conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de commun accord des associés. « *Quelle est la raison de l'exception ? Les sociétés dont la durée est illimitée n'ont d'autre fin que la mort des associés (art. 1844) ; en ce sens, elles sont perpétuelles, puisqu'elles enchaînent les associés pendant toute leur existence. Or les sociétés perpétuelles ont de graves inconvénients. La défiance et le désordre peuvent prendre la place de la confiance et de l'amitié ; si la société devait continuer jusqu'à la mort de l'un des associés, elle deviendrait la source d'incessantes contestations […]* »[1].

Quand est-ce que la société est à terme ? « *D'après l'esprit de la loi […] il faut considérer comme société illimitée celle qui est perpétuelle, ou qui peut l'être ; et la société l'est dès qu'elle doit durer pendant toute la vie des associés, tandis que la société est à terme quand elle n'embrasse pas la vie entière des associés* »[2].

Selon la doctrine, on considère que la société **contractée à vie** est une société pour une durée illimitée. L'argument que cette société serait affectée d'un terme certain (la mort) est écarté par un argument de texte tiré de l'article 1844 C.c. qui parle des sociétés conclues pour toute la vie des associés tout en renvoyant à l'article 1869 C.c. (qui mentionne les seules sociétés à durée illimitée)[3].

Il résulte encore de ce système qu'une société formée pour un terme peut être considérée comme société à durée illimitée, et ceci, dans la mesure où le terme fixé dépasse la durée de vie des associés[4].

La faculté de renonciation de l'article 1869 C.c. est **d'ordre public** et doit s'appliquer à toutes les sociétés, donc également aux sociétés par actions (en principe).

Mais, en fait, il est de tout temps admis qu'il existe une exception au droit de renoncer, à savoir dans le cas où chaque associé peut vendre ses droits sociaux et se retirer de la société. Il est vrai que, dans ce cas, provoquer la dissolution de la société n'a pas véritablement de sens pour l'associé qui peut se libérer de cet engagement dans la société[5].

Si les associés peuvent déroger aux autres fins de dissolution prévues par l'article 1865 C.c., tel n'est pas le cas de la faculté de renonciation de l'article 1869 C.c.

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 401.
2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 402.
3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 403.
4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 402.
5 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 404.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 1865*bis*

« *La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.*

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d'une société peut dissoudre cette société à tout moment.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal d'arrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l'associé ».

Cet article a été introduit par la Loi de Modernisation, et il contient d'abord une disposition relative au **droit d'usufruit** (alinéa 3 souligné ci-dessus). « *Cet alinéa – inspiré de l'art. 1844-5, alinéa 2, du Code civil français – confirme la position selon laquelle le nu-propriétaire de parts sociales doit en principe être considéré comme l'associé […]* »[(1)].

L'objet principal de cet article concerne la réglementation de ce qu'on appelle parfois « *la "dissolution-confusion" s'inspirant de l'article 1844-5 du Code civil français, réglementation qui serait applicable à toutes les sociétés, de manière à assurer la protection des créanciers de la société dissoute selon un mécanisme comparable à celui qui est mis en œuvre dans le cadre des opérations de fusion-scission et de réduction du capital* »[(2)].

Art. 1866 C.c.

« *La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société* ».

Cet article prévoit la possibilité de proroger la société. Cette prorogation suppose l'accord de tous les associés : « *les mêmes formes que pour le contrat de société* ». Il est toutefois admis que ce consentement soit exprimé de façon tacite[(3)].

Il résulte de la faculté de prorogation ainsi que de la persistance de la personnalité juridique durant la liquidation qu'une société anonyme peut toujours souscrire à des engagements dont l'étendue dépasse sa durée[(4)].

1 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 52, ID 10080.

2 – *Doc. parl.*, n° 5730, p. 52, ID 10080.

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 378.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 205, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 1867 C.c.

« Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société ».

À noter que, si la loi parle de l'apport de jouissance, elle entend que la société n'aura qu'un simple droit de **jouissance sur les fruits,** et non un usufruit. En effet, l'usufruit, en tant que droit réel, est soumis aux mêmes règles que le droit de propriété, avec pour conséquence que la mise de l'usufruit se fait immédiatement. « *Par suite, si la chose vient à périr, la société ne sera point dissoute, car l'associé n'est point sans mise ; il n'a pas promis une jouissance successive à la société, il a promis un usufruit et il a rempli son obligation* »[1]. Ainsi donc la perte est pour la société dans la mesure où, si la chose périt, la société perd la jouissance de la chose, et ceci, tout en restant obligée envers l'associé. La société n'est pas tenu d'indemniser l'associé pour la perte de la chose, mais elle devra le faire si la perte s'est faite par la faute des associés[2].

L'alinéa 2 de cet article est justifié comme suit : « *Il est de l'essence de la société que chacun des associés y contribue, c'est-à-dire ait une mise ; il ne peut donc plus y avoir de société lorsque l'un des associés n'a plus rien de quoi y contribuer ; or si la chose dont il a promis la jouissance à la société périt, il n'y a plus de mise, car il a promis une jouissance successive pendant toute la durée de la société ; dès que cette jouissance devient impossible par la perte de la chose, il n'y a plus de mise, ce qui entraîne la dissolution de la société* »[3].

Cette disposition soulève quelques difficultés d'interprétation : si l'on donne à l'alinéa 1 sa signification première, celle donc où il serait applicable en cas d'apport d'un **corps certain**, alors il y a contradiction avec l'alinéa 3 de la même disposition.

Il convient donc de donner à cet alinéa une autre signification, soit donc qu'il ne s'applique que dans le cas où il n'y a pas de transfert de propriété. C'est cette hypothèse qu'envisage la loi par les termes « *avant que la mise soit effectuée* »[4].

Art. 1868 C.c.

« S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies ; au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède ».

L'article visé prévoit la **clause de maintien de la société entre les survivants**.

Elle n'est expressément autorisée que s'il y a plus de deux associés. « *S'ils ne sont que deux, le décès de l'un entraînera inévitablement la dissolution, à moins que*

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 205, ID 11308.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 286.

3 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 284 et p. 382, qui se réfère à R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 291.

4 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 282.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

le contrat ne contienne une clause prévoyant la continuation de la société avec les héritiers ou avec l'un d'eux »[1].

Art. 1870 C.c.

« ***La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.***
Elle est faite à contretemps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée ».

Sur la notion de contretemps, Pothier explique qu'il s'agit du cas où « *[…] elle est faite dans un temps où les choses ne sont plus entières, et où il est de l'intérêt de la société d'attendre un temps plus favorable pour consommer la négociation qui a fait l'objet de la société ; comme si ayant contracté avec vous une société de commerce, je voulais dissoudre la société dans un temps où il est de l'intérêt de la société de garder les marchandises que nous avons achetées en commun, et d'attendre le temps favorable de les revendre* »[2].

Art. 1871

« ***La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges*** ».

Concernant les sociétés qui sont contractées pour un certain temps limité, Pothier écrit : « *Dans ces sociétés, les associés, en convenant du temps que la société doit durer, sont censés être convenus de ne la dissoudre qu'après l'expiration de ce temps, à moins qu'il ne leur survienne quelque juste sujet de la dissoudre plus tôt. C'est pourquoi l'un deux ne peut, sans un juste sujet, dissoudre la société avant le temps, au préjudice de ces associés* »[3].

Parmi les cas visés par la disposition se trouve l'infirmité habituelle qui rend l'associé inhabile aux affaires de la société. **L'infirmité** doit être **habituelle** dans le sens qu'une maladie seulement passagère ne suffit pas pour entraîner la dissolution de la société.

En présence d'un juste motif, la société sera dissoute, même si le contrat de société prévoit une clause expresse que les associés ne pourraient se désister de la société avant l'échéance du terme prévu[4].

Art. 1872 C.c.

« ***Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés*** ».

La question que l'on se pose est de savoir si cet article renvoie à toutes les règles relatives aux **successions**. À première vue, l'article 1872 C.c. utilise une formulation très

1 – J. Van Ryn et J. Heenen, *Principes de droit commercial*, T. 1, p. 293.
2 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 295.
3 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 295.
4 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 295.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

générale, car il se réfère aux « *[…] règles concernant le partage des successions* ». Mais, en réalité, la phrase continue et l'article mentionne alors « *la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre cohéritiers* ». En fait, cette partie de la phrase comporte une restriction par rapport à la première partie qui elle semble être tout à fait générale[1].

On convient à dire que le partage en droit des sociétés tout comme en matière successorale est **déclaratif**[2] (pour plus de détails, le lecteur est prié de se porter à la p. 295). Dans les termes de Pothier : « *Il y a une grande différence entre notre droit français et le droit romain sur l'effet du partage. Par le droit romain, le partage était une espèce d'échange […] ; chacun des copartageants était censé acquérir de ses copartageants les parts qu'ils avaient, avant le partage, dans les effets compris dans son lot, et leur céder à la place celle qu'il avait, avant le partage, dans les effets compris dans le leur. […] Au contraire, selon notre droit français, un partage n'est pas regardé comme un titre d'acquisition, mais comme un acte qui ne fait autre chose que déterminer les parts indéterminées que chacun des copartageants avait, avant le partage, dans la communauté qui était entre eux, aux seules choses échues au lot de chacun d'eux* »[3].

Tel est le principe de l'effet déclaratif du partage tel qu'il est retenu par l'article 883 C.c. :

« *Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession* ».

Art. 1873 C.c.

« *Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce* ».

Cet article rejoint l'article 100-1 L.S.C. qui dispose que les sociétés commerciales « *se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers et par le droit civil* ». L'article 1873 C.c. édicte que le Code civil s'applique aux sociétés à défaut de règles contraires résultant des lois et usages de commerce. Cette disposition reproduit dans un ordre inverse l'article 18 du Code de commerce de 1808 ainsi libellé : « *Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce et par les conventions des parties* ».

Il est vrai que cet ordre retenu par la L.S.C. respecte mieux la logique[4] du fait que les sociétés commerciales sont régies en premier lieu par les conventions des parties dans la mesure où elles n'ont rien de contraire aux lois qui intéressent l'ordre public ou aux bonnes mœurs, qu'elles modifient les règles simplement dispositives (et non prohibitives ou impératives), les lois et usages particuliers au commerce, et, subsidiairement seulement, par le Code civil. En effet, ces dernières dispositions ne sont applicables aux sociétés commerciales « *que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages de commerce* » (art. 1873 C.c.). Sur le fond, on peut noter que les usages de commerce (non repris par le Code de 1808 même si ce n'était que par un oubli[5]) ont repris la place qu'ils ont dans le Code civil qui, dans son article 1873 précité, admet que les usages de commerce puissent **déroger au droit civil**.

1 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 417.

2 – Fr. Laurent, *Principes de droit civil*, T. 26, p. 422.

3 – R. Pothier, *Œuvres de Pothier*, R.J. Bugnet et R.J. Pothier, T. IV, *De la société*, p. 306.

4 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 25, ID 11305.

5 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 25, ID 11305.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE VI
LES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

Le « *groupement d'intérêt économique* » est une notion d'origine française et, à l'origine, le groupement ainsi créé était en fait destiné à permettre la **coopération entre entreprises** dans des cas où l'objectif n'était pas de faire des bénéfices, mais plutôt de faire des économies. Par conséquent, selon une interprétation stricte de l'article 1832 C.c., il n'y avait pas de société (faute de recherche de bénéfices à partager).

Afin de néanmoins permettre la coopération entre de telles entreprises, et ceci, sans avoir recours à l'instrument d'une association sans but lucratif, la notion de groupement d'intérêt économique fut introduite en droit français dès 1967 (par l'**Ordonnance du 23 septembre 1967**). Cette notion fut reprise en droit communautaire en 1985 (par le règlement 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985, publié au *J.O.* L. 199/1 du 31 juillet 1985) pour les coopérations transfrontalières. Ce règlement trouvait son fondement dans l'article 235 du traité instituant la Communauté économique européenne ainsi libellé : « *Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, […] prend les dispositions appropriées* ». Le règlement est entré en vigueur le 3 août 1985, mais il est seulement applicable à partir du 1er juillet 1989, à l'exception des articles 39, 41 et 42 qui sont entrés en vigueur le 3 août 1985.

Les considérants du règlement (inspirés de l'article 2 du traité CE) indiquent les **motifs de l'introduction** de cet instrument dans le droit des États membres. « *Considérant qu'un développement harmonieux des activités économiques et une expansion continue et équilibrée dans l'ensemble de la Communauté dépendent de l'établissement et du fonctionnement d'un marché commun européen rend nécessaire ou plutôt souhaitable la création à l'intention des personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques d'un cadre juridique qui facilite l'adaptation de leurs activités aux conditions économiques de la Communauté* ».

Les entreprises doivent pouvoir coopérer effectivement au-delà des frontières.

Cet instrument de coopération devrait être tel que les obligations auxquelles il serait soumis ne dépendraient pas de l'implantation de cette entité en les soumettant à des charges et obligations différentes. La coopération transfrontalière doit être similaire à celle qui peut se faire sur un marché national.

Il n'a toutefois pas été envisagé de constituer une forme de coopération économique dans laquelle les entreprises perdraient leur indépendance tant juridique qu'économique, mais de mettre en place « *[…] une structure juridique particulière qui permettrait aux entreprises de promouvoir en commun certains secteurs de leurs activités tout en préservant leur autonomie juridique et économique* »[1].

1 – Avis du Comité économique et social du 27 février 1975.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Adopté sous forme de règlement, ce texte est obligatoire dans tous ses éléments et il est **directement applicable** dans tous les États membres (art. 288 TFUE). L'instrument ainsi créé devait être adaptable aux conditions économiques, et ceci, au moyen de la grande liberté dont jouissent les membres dans la détermination de leurs rapports contractuels[1].

CHAPITRE I
L'OBJET ET LE BUT DU G.E.I.E.

Selon l'article 3 du règlement, le but du groupement est « *[…] de faciliter ou de développer l'activité de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; il n'est pas de réaliser des résultats pour lui-même* ».

Le groupement est créé pour prendre le **relais de l'activité économique de ses membres**, leur permettre grâce aux fonctions qu'ils mettent temporairement en commun de développer leur propre activité et, le cas échéant, d'accroître leurs propres résultats[2].

Le G.E.I.E. a pour objet de mettre en œuvre les moyens destinés à faciliter et à développer l'activité économique des membres. Cette notion, très répandue en droit de l'Union européenne, revêt à cet endroit son sens le plus large possible.

L'activité du G.E.I.E. doit s'insérer dans le **prolongement de l'activité de ses membres,** afin d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.

L'activité du G.E.I.E., qui est de nature **auxiliaire,** ne peut être qu'une activité liée à celle des membres, qui devront donc notamment avoir eux-mêmes une activité économique. Le G.E.I.E. ne peut avoir pour objet ni de se substituer à l'activité de ses membres ni d'absorber celle-ci. « *Il ne doit pas, en effet, supprimer l'activité qu'il favorise* »[3]. Il est par conséquent exclu que les membres du G.E.I.E. fassent apport de leur fonds de commerce et, de ce fait, n'aient plus d'activité propre[4].

Le groupement doit encore être **distingué de la société**, et ceci, notamment au double point de vue suivant : le groupement peut être constitué sans le moindre capital, et la constitution du groupement ne donne pas lieu par elle-même à la réalisation et au partage de bénéfices. Ceci n'empêche toutefois pas que le groupement **réalise des bénéfices**. Si tel était le cas, ces bénéfices seraient directement acquis aux membres[5]. La réalisation de bénéfices par le groupement lui-même n'est pas à être considérée comme une hypothèse exceptionnelle. En effet, le Conseil des ministres avait proposé un amendement à l'article 40 du règlement destiné à supprimer l'adjectif « *éventuels* » dans la phrase relative au régime fiscal et libellée ainsi : « *Les bénéfices éventuels du groupement ne sont imposables qu'au niveau des membres* »[6].

1 – Avis du Comité économique et social du 27 février 1975.

2 – D. VAN GERVEN, « Le Groupement européen d'intérêt économique – G.E.I.E. », *R.P.S.*, 1986, p. 185.

3 – D. VAN GERVEN, « Le Groupement européen d'intérêt économique – G.E.I.E. », *R.P.S.*, 1986, p. 187.

4 – Cass. fr. crim. du 1er février 1972, *J.C.P.*, 1973, II, 17.304, note J.J. Brust.

5 – D. VAN GERVEN, « Le Groupement européen d'intérêt économique – G.E.I.E. », *R.P.S.*, 1986, p. 188.

6 – D. VAN GERVEN, « Le Groupement européen d'intérêt économique – G.E.I.E. », *R.P.S.*, 1986, p. 196.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le groupement obtient sa capacité juridique et donc sa personnalité morale (si tant est que l'État visé accorde celle-ci à ce véhicule juridique) selon l'État membre du lieu de son siège. Les membres ont le choix entre le lieu de l'administration centrale du groupement ou, si le groupement y a une activité réelle, le lieu où un de ses membres a une administration centrale ou, s'il s'agit d'une personne physique, son activité à titre principal (art. 12, alinéa 2). Les G.E.I.E. peuvent ainsi exercer leur activité principale à l'extérieur de l'Union européenne[1].

Lorsque le **siège est transféré** dans un autre État membre, le G.E.I.E. doit se faire immatriculer à l'endroit de son nouveau siège. Selon la législation de l'État d'accueil il acquiert ou il perd alors la personnalité morale. La décision de transférer le siège doit être prise à l'unanimité et elle prend effet à partir de la date d'immatriculation au registre du pays d'accueil.

Le G.E.I.E. ne peut par ailleurs pas exercer des fonctions concernant les membres de la société : il ne peut exercer « *[…] directement ou indirectement, le pouvoir de direction ou de contrôle des activités propres de ses membres ou des activités d'une autre entreprise, notamment dans les domaines relatifs au personnel, aux finances et aux investissements* »[2].

1 – D. VAN GERVEN, « Le Groupement européen d'intérêt économique – G.E.I.E. », *R.P.S.*, 1986, p. 199.
2 – Art. 3 (2) du règlement.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES

Par règlement des CE[1] a été institué le G.E.I.E., une nouvelle forme de « *coopération transnationale pour exercer en commun certaines […] activités, telles que p.ex., la recherche et le développement, l'achat, la production et la vente […] le traitement de données par ordinateur, la formation de consortiums multidisciplinaires dans le domaine de la construction en vue de la soumission de marchés publics ou privés* »[2]. Le G.E.I.E. doit être composé au moins de :

– deux sociétés ayant leur administration centrale dans deux États différents (article 4 du règlement) ; s'agissant d'une forme de collaboration inter-entreprises, le groupement doit comprendre au moins deux membres sans qu'un nombre maximal ait été fixé ;
– deux personnes physiques exerçant leur activité à titre principal dans des États membres différents.

Afin d'offrir aux personnes physiques et morales luxembourgeoises les mêmes possibilités de coopération que celles qui sont données par le G.E.I.E. sur le plan trans-national, le législateur national a également introduit le groupement d'intérêt économique **(G.I.E.)** par une autre loi[3]-[4]. Juridiquement, les points suivants, en principe communs aux deux catégories de groupements, sont à relever :

1. la constitution a lieu par acte notarié ou sous seing privé ;
2. le groupement a la **personnalité juridique** (dès la conclusion du contrat pour le G.I.E. ; dès l'immatriculation au R.C.S. pour les G.E.I.E.) ; le règlement dans son article 1er, § 3, donne aux législateurs nationaux l'option d'accorder ou non la personnalité juridique aux groupements inscrits à leurs registres nationaux. En revanche, au vœu du règlement, le groupement doit avoir la **capacité en son nom d'être titulaire de droits et d'obligations** de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques, et d'agir en justice. Les auteurs du règlement avaient entendu éviter l'expression de personnalité morale, et ceci, pour la raison que cette notion couvre des contenus fort différents d'un État à un autre[5]. Le règlement n'utilise pas le terme de personnalité morale, mais celui de personnalité juridique ;
3. les **membres répondent indéfiniment et solidairement de toutes les obligations** du groupement ; il s'agit d'une conséquence plus ou moins inéluctable du fait que le groupement n'a pas nécessairement un capital social. C'est donc la responsabilité indéfinie et solidaire qui est destinée à protéger les tiers, créanciers et salariés notamment ;
4. le but exclusif est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. L'activité doit

1 – Règlement n° 2137/85 adopté le 25 juillet 1985 par le Conseil des ministres, *JOCE*, 31 juillet 1985, n° 2199/1.

2 – *Bull. CE*, Supplément 3/87.

3 – Loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, ID 9566.

4 – Loi du 25 mars 1991 sur les groupements européens d'intérêt économique, ID 9569.

5 – D. van Gerven, « Le Groupement européen d'intérêt économique – G.E.I.E. », *R.P.S.*, 1986, p. 187.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

se rattacher à celle des membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Il ne peut :

– exercer le pouvoir de direction ou de contrôle des activités propres de ses membres ;
– détenir des **participations** dans les entreprises membres, rechercher des bénéfices pour son propre compte. Cette dernière restriction se justifie par le souci de ne pas voir le G.E.I.E. devenir une société *holding* d'un groupe. En revanche, il n'est pas exclu que le groupement acquière une participation dans la mesure où il peut y avoir détention d'une participation dans une autre entreprise à condition « *[…] qu'elle soit nécessaire pour atteindre l'objectif du groupement et où elle a lieu pour les comptes de ses membres* ». Il en serait ainsi dans le cas où il y aurait création dans un pays en voie de développement d'une *joint-venture* entre un G.E.I.E. et ce pays[1] ;

5. les contrats du groupement sont déposés et publiés selon les dispositions de la Loi de 2002. Le groupement est immatriculé au R.C.S., sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité ;
6. le groupement est géré par une ou plusieurs personnes membres ou non du groupement.

1 – D. VAN GERVEN, « Le Groupement européen d'intérêt économique – G.E.I.E. », *R.P.S.*, 1986, p. 199.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE III
ASPECTS FISCAUX

Les indications données sur ce point sont très limitées[1].

SECTION I
TRANSPARENCE FISCALE

D'après l'article 40 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) :

« *Le résultat provenant de l'activité du groupement n'est imposable qu'au niveau de ses membres* ». Cette disposition est reprise dans la législation nationale non seulement à l'égard des G.E.I.E. (article 13 de la loi du 25 mars 1991 sur le G.E.I.E.), mais également à l'égard des G.I.E. (article 29 de la loi du 25 mars 1991 sur le G.I.E.). La transparence fiscale est confirmée à l'égard des G.E.I.E. par une **circulaire administrative**[2]antérieure aux deux lois en question. Cette circulaire prévoit que le groupement n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu des collectivités et est à assimiler aux sociétés de personnes. Est ainsi consacrée la transparence du groupement d'après laquelle la détermination du bénéfice se fait comme si chaque co-exploitant exploitait individuellement[3].

L'établissement du revenu du groupement fait l'objet d'un bulletin d'imposition séparé qui détermine la base d'imposition. Cette base d'imposition est répartie sur les membres qui sont débiteurs des impôts auxquels l'activité du groupement donne lieu. L'activité du groupement n'est pas nécessairement commerciale, avec la conséquence qu'il n'y a pas nécessairement assujettissement à l'impôt commercial communal.

Si l'article 40 du règlement avait initialement utilisé l'expression « *bénéfices* », le Conseil des ministres a remplacé ce terme par celui de « *résultat* », de nature à inclure également les pertes : la conséquence en est donc que tant les bénéfices que les pertes sont imposables (déductibles) dans le chef des membres du groupement[4].

SECTION II
CONVENTIONS CONTRE LA DOUBLE IMPOSITION INTERNATIONALE

En tant qu'entité transparente le groupement ne pourra pas, en principe, bénéficier des conventions conclues entre le Luxembourg et les États tiers (sauf dispositions contraires de ces conventions).

Exemple
Un groupement qui est composé de membres français et belges perçoit des intérêts des États-Unis ; dans ce cas, la convention conclue entre le Luxembourg et les États-Unis ne s'applique pas.

1 – Pour plus de détails, v. J.-P. Winandy, *Les impôts sur le revenu et sur la fortune*, p. 792.

2 – Circ. L.I.R. n° 116 du 3 février 1989, ID 12230.

3 – Art. 57 L.I.R., ID 1.

4 – D. van Gerven, « Le Groupement européen d'intérêt économique – G.E.I.E. », *R.P.S.*, 1986, p. 201.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

D'après les dispositions des conventions, il y a imposition au Luxembourg uniquement s'il y a **établissement stable**. Lorsque le groupement se limite à des activités **préparatoires et auxiliaires**, par rapport à l'activité de ses membres, il n'y a pas d'établissement stable au Luxembourg. En effet, les conventions contre la double imposition prévoient en général que de telles activités ne sont pas considérées comme donnant lieu à l'existence d'un établissement stable dans l'autre État.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE VII
LES FONDS DE PENSION

Il s'agit de deux formes de fonds de pension (les « *associations d'épargne-pension* » ASSEP et les « *sociétés épargne-pension à capital variable* » SEPCAV) basées sur la loi du 8 juin 1999 et dont les caractéristiques juridiques sont fondamentalement différentes. Il convient donc de les étudier séparément, ce qui sera fait dans les deux chapitres suivants : chapitre I – la SEPCAV, chapitre II – l'ASSEP.

CHAPITRE I
LA SEPCAV

L'objet de la SEPCAV est la collecte d'avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques d'investissement et de maximiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses actionnaires la disposition d'un **capital au moment de leur retraite** de la vie professionnelle. Les actions émises par la SEPCAV sont réservées à un cercle de bénéficiaires définis par les statuts. Les statuts stipulent que le montant du **capital** est égal à tout moment à la valeur de **l'actif net** de la société.

Ce type de société ne peut procéder à une répartition régulière de revenus à ces actionnaires ; en d'autres termes, les résultats accumulés ne peuvent sortir de la société que sous forme de paiements de pension effectués aux assurés. Les bénéficiaires du plan de pension sont les actionnaires de la société. La société n'est pas ouverte au public et les actions ne peuvent être transférées à des tiers.

Le capital social minimum de la société est de **1 million d'euros** ; ce capital social est constamment identique à la valeur de l'actif net de la société (comme pour la SICAV) ; la constitution de différents **compartiments** à l'intérieur d'une même SEPCAV est autorisée. La SEPCAV est gérée par un conseil d'administration.

Un **règlement de pension** doit être préparé et annexé aux statuts de la société. Une banque luxembourgeoise doit être désignée comme banque dépositaire des avoirs du fonds de pension.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

CHAPITRE II
L'« ASSEP – ASSOCIATION D'ÉPARGNE-PENSION »

Cette deuxième structure a recours au statut d'une **association sans but lucratif**. La principale différence qui la distingue de la SEPCAV est qu'elle peut payer des pensions non seulement en tant que capital, mais encore sous forme de **rentes**, concrètement sous forme de **rentes viagères**. En outre, les bénéficiaires ne sont pas les actionnaires (ou plutôt les membres de l'association). La loi prévoit que les statuts doivent stipuler que les provisions constituées pour les prestations actuelles et futures sont à tout moment couvertes par la valeur de l'actif net de l'ASSEP. Les bénéficiaires des prestations doivent être désignés par les statuts. L'ASSEP jouit de la personnalité juridique. L'actif net minimum est de **1 million d'euros**.

Comme pour la SEPCAV, des **compartiments** différents peuvent être ouverts au sein d'une ASSEP ; une banque luxembourgeoise doit être désignée comme dépositaire des avoirs de l'ASSEP. Une importance particulière est accordée à la **gestion du passif** sous un schéma de bénéfices assurés, des plans de financement détaillés doivent être préparés et soumis à l'autorité de surveillance.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE III
AUTRES PARTIES CONCERNÉES PAR LES FONDS DE PENSION

En premier lieu, il convient de noter que les fonds de pension tout comme les OPC sont soumis à une supervision qui ne s'exerce pas seulement au moment de la mise en place de la structure, mais qui est continue, ce qui signifie qu'elle dure tant que le fonds de pension existera.

SECTION I
AUTORITÉ DE SURVEILLANCE

C'est la CSSF qui est désignée en tant qu'autorité de surveillance (comme pour les OPC). Chaque fonds de pension doit être autorisé par cette autorité de surveillance qui devra approuver les statuts de l'entité, le règlement de pension, la banque dépositaire, ainsi que le gestionnaire d'actif ou de passif.

SECTION II
LA BANQUE DÉPOSITAIRE

À l'instar des OPC, les deux types de structures doivent désigner une banque dépositaire qui est responsable pour l'administration générale et la garde des avoirs du fonds de pension. La banque dépositaire est également investie d'une mission de contrôle. Tout comme les OPC, les deux types de fonds de pension doivent désigner un réviseur d'entreprises établi et autorisé au Luxembourg afin de réviser les comptes annuels de ces entités.

Le fonds de pension peut déléguer la gestion de ses actifs à un gestionnaire d'actifs qui doit être un « *gérant de fortune* » au sens de la loi du 5 avril 1993 concernant le secteur financier.

L'ASSEP peut également désigner un **gestionnaire de passif** qui doit être une société autorisée au Luxembourg et agréée par l'autorité de surveillance. Cette société doit notamment disposer de connaissances suffisantes en matière de calculs actuariels.

Les revenus de valeurs mobilières (donc dividendes, intérêts d'obligations et plus-values en capital réalisées sur de tels actifs) de la SEPCAV sont **exonérés d'impôts**. Cette exemption est sujette à la condition que le fonds soumette aux autorités fiscales du Luxembourg une **liste des bénéficiaires** détaillant le montant de leurs droits actualisés et des rachats d'actions effectués au terme prévu. Ces informations pourront donc être transmises aux autorités fiscales étrangères ; l'idée derrière cette disposition est de transmettre les informations en question aux autorités fiscales de l'État de résidence des bénéficiaires. L'objectif est ainsi d'obtenir pour les fonds de pension le bénéfice des conventions contre la double imposition conclues par le Luxembourg avec d'autres États. La SEPCAV bénéficie également de l'exonération de l'impôt sur la fortune.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE VIII
LES SOCIÉTÉS D'IMPACT SOCIÉTAL

La « loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal » (et modifiant diverses autres lois existantes) a introduit cette forme de société qui fait partie des sociétés non commerciales relevant de **« l'économie sociale et solidaire »** tout en adoptant l'une des trois formes de sociétés commerciales suivantes : la S.A., la S. à r.l. ou encore la société coopérative. S'agissant d'une forme non commerciale de société, qu'elle doive ou non faire partie des sujets traités dans le présent manuel est discutable. Toutefois, son traitement ici est justifié du fait qu'elle utilise les différentes formes des sociétés commerciales, à savoir la S.A., la S. à r.l. et la société coopérative.

CHAPITRE I
DÉFINITION DE CE TYPE DE SOCIÉTÉ

Pour pouvoir prétendre à ce régime de la société d'impact sociétal définie par la loi du 12 décembre 2016, la société doit remplir cumulativement les conditions suivantes :

« 1. poursuivre une activité continue de production, de distribution ou de services,

2. répondre à titre principal à l'une au moins des deux conditions suivantes :

a) Elles ont pour but d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l'entreprise,

b) Elles ont pour but de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, à la parité hommes-femmes, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, à la protection de l'environnement, au développement d'activités culturelles ou créatives et au développement d'activités de formation initiale ou continue,

3. Disposer d'une gestion autonome au sens où elles sont pleinement capables de choisir et de révoquer leurs organes directeurs ainsi que de contrôler et d'organiser l'ensemble de leurs activités,

4. Appliquer le principe selon lequel au moins la moitié des bénéfices réalisés sont réinvestis dans le maintien et le développement de l'activité de l'entreprise ».

La société d'impact sociétal n'est pas nécessairement à but lucratif, donc visant à procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect (art. 2 de la Loi du 12 décembre 2016).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL

Le régime de ce type de société est attribué sur **agrément accordé après demande** faite par une société existante ou encore une société en formation au ministre ayant l'économie sociale et solidaire dans ses attributions. Ce ministre, assisté par une Commission consultative, est chargé de la surveillance de ce type de sociétés d'impact sociétal (art. 10 de la loi du 12 décembre 2016). Pour bénéficier de cet agrément, il faut que les statuts :

– définissent de façon précise l'objet social poursuivi dans le cadre de l'article 1er, point 2 ;
– prévoient des indicateurs de performance permettant de vérifier de façon effective et fiable la réalisation de l'objet social poursuivi.

L'agrément est accordé par arrêté ministériel. Une copie de l'arrêté ministériel d'agrément est déposée au registre de commerce et des sociétés. Les modifications des statuts dument approuvées par le ministre font l'objet d'une publication au RESA conformément aux dispositions de la Loi de 2002.

Les **formes de sociétés éligibles** pour bénéficier de ce régime sont les seules sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives. Il est précisé par la loi du 12 décembre 2016 que la L.S.C. est applicable à ce type de sociétés chaque fois qu'il n'y est pas dérogé par une disposition légale expresse.

Du point de vue du droit des sociétés, une des principales originalités de la loi du 12 décembre 2016 est que le capital est composé de **parts d'impact** et (le cas échéant, en plus) de **parts de rendement**. Les parts de rendement confèrent un droit aux bénéfices de la société, mais sous la condition que l'objet social évalué au moyen d'indicateurs de performance visés à l'article 3 soit effectivement atteint.

Les parts d'impact et les parts de rendement sont **exclusivement nominatives**. La conversion d'une forme de parts dans l'autre est possible, mais seulement à sens unique : les parts de rendement sont convertibles en parts d'impact. Par ailleurs, ces parts d'impact doivent toujours représenter au moins 50 % du capital social. Le réviseur d'entreprises agréé (qui est obligatoirement appelé à contrôler les comptes annuels de la société d'impact sociétal) doit vérifier et certifier annuellement le respect de cette condition. Le bénéfice attribuable à ces parts d'impact doit être constamment réinvesti dans le maintien et le développement de l'activité de la société d'impact sociétal. La Loi du 12 décembre 2016 (art. 14) attache des conséquences importantes au fait que le capital social est composé à 100 % de parts d'impact : ces sociétés sont **exemptées d'impôt** sur le revenu des collectivités, d'impôt commercial communal et d'impôt sur la fortune.

L'assemblée des associés (actionnaires) peut décider de verser des dividendes aux titulaires de parts de rendement, mais à condition qu'il résulte du rapport d'impact extra-financier que l'objet social évalué au moyen **d'indicateurs de performance** prévus par les statuts a été effectivement atteint à la date de clôture de l'exercice au titre duquel une distribution de dividendes est envisagée (art. 7 Loi du 12 décembre 2016).

En cas de retrait définitif de l'agrément (qui intervient lorsque la société ne remplit plus les conditions légales), la dissolution de la société peut être prononcée par le

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale agissant sur demande du procureur d'État. Quel que soit le mode de **liquidation**, le solde éventuel du boni de liquidation est obligatoirement affecté :

– soit à une donation en faveur d'une autre société d'impact sociétal poursuivant un but identique ou comparable à celui de la société d'impact sociétal en liquidation ;
– soit à une fondation de droit luxembourgeois ou à une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique par arrêté grand-ducal.

De ces dispositions, il résulte donc que les associés (actionnaires) de la société d'impact sociétal ne peuvent rien récupérer au moment de la liquidation. Ceci n'est pas illogique en soi pour une société sans but lucratif. Toutefois, il en va un peu différemment si, en cours de vie de la société, les associés peuvent bénéficier de distributions de bénéfices (comme expliqué ci-dessus). Dans un tel contexte, l'interdiction absolue de toute distribution peut paraître manquer de cohérence et l'on pourrait argumenter que les actionnaires devraient, au moment de la liquidation de la société, pouvoir retirer de celles-ci les montants qu'ils auraient pu retirer avant la dissolution de la société (dans la mesure où ils ont omis de ce faire). La solution retenue par la loi constitue une incitation de retirer constamment le maximum de ce qui est possible de retirer en cours de vie de la société.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE IX
LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Le titre XIII L.S.C., malgré les modifications importantes qu'elle a connues depuis son origine, contient toujours la subdivision suivante : certaines sociétés étrangères ne réalisent au Luxembourg que des opérations accidentelles ; l'article 1300-1 L.S.C. est applicable à leur égard. « *D'autres au contraire, sont, aux termes de l'article [1300-2] entièrement soumises à cette loi, parce qu'elles ont dans le Luxembourg leur principal établissement [administration centrale], bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger* »[1]. Finalement il y a une situation intermédiaire applicable aux sociétés qui agissent au Luxembourg par le biais d'une succursale ; c'est l'article 1300-3 L.S.C. qui s'applique.

Les sociétés étrangères se voient accordées un certain nombre de prérogatives par le droit des sociétés luxembourgeois, notamment au regard de leur **capacité**. Une telle capacité juridique est en fait une exigence de **droit européen** à l'égard des sociétés des autres États membres. Ceci vaut en particulier pour les droits suivants reconnus par la loi luxembourgeoise, à savoir « faire leurs opérations » et « ester en justice dans le Grand-Duché » (voir affaire *Überseering*) (art. 1300-1 L.S.C.).

L'article 1300-1 L.S.C. est libellé comme suit : « *Toutes sociétés ou associations constituées ou ayant leur siège en pays étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice dans le Grand-Duché* ». Ce texte comporte deux divergences par rapport au texte belge de l'époque : le texte belge ne vise pas les associations en se limitant donc aux seules *sociétés* commerciales. En outre, l'article 1300-1 L.S.C. vise les sociétés « *constituées ou ayant leur siège en pays étranger* », alors que la loi belge dont cette disposition est reprise utilise la conjonction « et ». Le texte luxembourgeois est manifestement erroné, il signifie qu'une société qui a son siège au Luxembourg peut faire ses opérations et ester en justice au Luxembourg, ce qui est une évidence.

Il est regrettable que cette erreur, signalée par la doctrine depuis fort longtemps[2], n'ait jamais été redressée par le législateur.

La reconnaissance des sociétés étrangères suppose qu'elles soient **valablement constituées** sous leur loi nationale. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'elles remplissent les conditions de la loi luxembourgeoise de la personnification civile, pas plus qu'elles soient des sociétés commerciales au sens de la loi luxembourgeoise[3].

La façon dont fonctionne la société étrangère est régie par sa loi nationale. C'est donc la loi étrangère qui décide dans quelle mesure et sous quelles conditions les organes sociaux sont habilités à engager la société[4].

1 – A. Nyssens, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 339, ID 11305.

2 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 189.

3 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 190, qui se réfère à la situation de la Belgique.

4 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 191.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE I
ADMINISTRATION CENTRALE AU LUXEMBOURG

Selon la version d'origine L.S.C. (qui remonte à 1915), c'était le « principal établissement » qui déterminait la nationalité d'une société. « *Quand une société a son principal établissement dans un pays, n'est-ce pas ce pays qui a intérêt à lui imposer ces règles ? N'est-ce pas la loi, sous la protection de laquelle elle vit et fonctionne, qui doit la régir, plutôt qu'une loi étrangère sous laquelle un accident ou une fraude l'a fait naître ?* »[1].

Il résulte de cet article que n'importe quelle société de la terre (donc constituée à l'étranger) est soumise à la loi sur les sociétés commerciales luxembourgeoise du simple fait qu'elle maintient son principal établissement au Luxembourg. Cette notion du principal établissement a, par l'effet de la loi du 25 août 2006, été remplacée par la notion **d'administration centrale**.

Il résulte de l'article 1300-2 L.S.C. que toute société dont l'administration centrale est située dans le Grand-Duché est soumise à la loi luxembourgeoise (même si l'acte constitutif a été passé en pays étranger). Un autre changement fut introduit par la loi du 31 mai 1999 sur la domiciliation des sociétés prévoyant que le domicile au Luxembourg est également un critère d'attribution de la nationalité.

SECTION I
NOTION D'ADMINISTRATION CENTRALE

Aux termes du commentaire des articles relatifs à la Loi de 1915, il s'agit du pendant du domicile des particuliers qui, selon l'article 102 C.c. fixe le domicile au centre des affaires.

Lorsque la société maintient divers établissements éparpillés sur différents pays, se pose la question de savoir quel est le critère qui prime afin de pouvoir déterminer de façon non ambiguë à quel endroit se trouve le siège de la société.

Il s'agit de l'endroit où se trouve le **centre des affaires**[2]. La notion d'administration centrale, dans ce contexte de détermination de la nationalité d'une société, ne soulève aucun problème lorsque l'activité de direction et l'activité d'exploitation sont exercées sur le territoire du même État. En revanche, il en va différemment si la direction est séparée de l'exploitation et s'exerce donc sur les territoires de deux États différents. Dans cette hypothèse, il faut décider quel est l'élément décisif : s'agit-il de l'exploitation matérielle de l'entreprise ou du centre de gravité intellectuel de la société ? La réponse donnée à cette question est que « *l'accord paraît […] se faire pour attribuer le caractère et les effets juridiques du principal établissement à l'endroit où, par l'installation de leur action directrice, les sociétés doivent être considérées comme ayant fixé le centre, le cœur et le cerveau de leur organisation sociale, là où se tient la haute direction, où se réunissent conseils d'administration et assemblées générales, où se centralisent archives, comptabilité et documents sociaux, en un mot,*

1 – E. Pirmez, *Commentaire législatif de la loi de 1873*, II, n° 86.

2 – Selon la définition de Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 386, ID 11308, citée par L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 181.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

à leur siège d'administration, au siège de leur vie intellectuelle, plutôt qu'à celui de leur vie matérielle »[1].

Dans le commentaire relatif au projet de loi 571 (qui a donné lieu à la loi de l'impôt sur le revenu, L.I.R), les termes « leur siège de direction » avaient, sur proposition du Conseil d'État, été remplacés par « leur principal établissement », et ceci, pour assurer la concordance de la notion de droit fiscal avec celle consacrée à l'article 159 [ancien] L.S.C. sur les sociétés commerciales. « *En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés, le principal établissement se trouve, suivant la doctrine, au siège de l'administration, c.-à-d. à l'endroit où se tiennent les assemblées générales et les conseils d'administration, où sont mises à jour les écritures, où se concentre l'activité de conduite des affaires sociales* »[2].

SECTION II
LA NATIONALITÉ DES SOCIÉTÉS

La nationalité des sociétés définit l'existence légale de la société, sa validité, le statut personnel de la société. Comme il a été souligné en jurisprudence, la notion de « *nationalité des sociétés ne peut pas être identique en tous points à celle des personnes physiques, ni produire toutes les conséquences attachées à cette dernière ; qu'il s'agirait, dans une large mesure, d'une question de terminologie, le terme de "allégeance" étant d'ailleurs préférable à celui de "nationalité" afin de dissiper toute équivoque* »[3].

Si, en théorie, on peut hésiter entre les critères de détermination de la nationalité (ou d'allégeance ou d'attribution de la *lex societatis*), il existe en droit luxembourgeois (et belge), contrairement à la loi française, un critère précis de solution des conflits : l'article 1300-2 [anc. art. 159] L.S.C. : il s'agit de celui de l'administration centrale (qui a remplacé celui du principal établissement). Si donc une société a son administration centrale au Luxembourg, alors elle se rattache à la législation luxembourgeoise qui détermine les conditions de son existence et celles de son fonctionnement[4].

« *La nationalité d'une société se détermine par le lieu de son principal établissement. Le lieu de ses sièges d'exploitation, de même que l'endroit où a été passé son acte constitutif ou encore la nationalité de la majorité de ses actionnaires ou celle de ses dirigeants sont irrelevants à cet égard* »[3].

La théorie de l'administration centrale (où du **siège réel**) s'oppose à celle du **contrôle** selon laquelle c'est la nationalité de la majorité des associés qui détermine la nationalité de la société. Cette théorie a pu faire une apparition éphémère pendant les temps de guerre pour être de nouveau abandonnée une fois la paix revenue[5].

---

1 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 386, ID 11308.

2 – L. Kunsch, « La réforme de l'impôt sur le revenu des collectivités », *Études fiscales*, 1969, n°s 29 et 30, p. 10.

3 – TA Lux. du 21 avril 1971, *P.*, n° 22, p. 63, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA Lux. du 21 avril 1971, *P.*, n° 22, p. 67, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 182.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

C'est la situation du domicile, c'est-à-dire de l'administration centrale, qui « *prévaut dans la recherche de la nationalité d'une société de capitaux. Est par conséquence luxembourgeoise une société constituée par un acte reçu par un notaire luxembourgeois, comptant parmi les fondateurs six de nationalité luxembourgeoise, dont 50 actions seulement sur 1000 ont été souscrites par un ressortissant allemand, et dont le centre d'exploitation et le rayon d'action ont toujours été au Grand-Duché, alors même que lors de sa mise en liquidation par l'occupant, 83,50 % des actions se sont trouvées entre les mains de ressortissants allemands* »[1].

« *Lorsqu'une société a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement appliquée. Lorsqu'une société a son domicile à l'étranger, mais qu'elle a au Grand-Duché de Luxembourg un ou plusieurs sièges quelconques d'opération, le lieu de son établissement le plus important au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elle indique à cet effet dans la publication de ses actes prescrite par la loi, constitue le domicile secondaire de cette société au Grand-Duché de Luxembourg.*

Le défaut de domicile connu constitue dans le chef d'une société une contravention grave à la loi, susceptible de lui faire encourir la dissolution ou la fermeture judiciaires conformément aux dispositions des articles 203 et 203-1 ».

SECTION III
RECONNAISSANCE DES PERSONNES MORALES ÉTRANGÈRES

En application de l'article 3, alinéa 3, du Code civil, les lois concernant **l'état et la capacité** des personnes régissent les Luxembourgeois, même résidant en pays étranger. La jurisprudence conclut de cette règle au principe général que l'état et la capacité des personnes « *sont réglés par la* **loi de la nation à laquelle elles appartiennent** »[2].

Cette acceptation des règles étrangères concernant le statut des personnes morales serait toutefois limitée par l'ordre public de l'État dans lequel la société veut faire valoir ses droits. En effet (C.c. b de 1911), « *l'ordre public [belge] s'oppose néanmoins à ce que la personnalité juridique et la faculté d'ester en justice soient reconnues à une société anonyme étrangère dépourvue de tous les caractères essentiels que semblable contrat doit réunir d'après la loi belge* »[3]. Accorder des prérogatives à des sociétés étrangères ouvrirait la porte à beaucoup d'abus possibles.

1 – CA du 8 octobre 1947, *P.*, n° 14, p. 346, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cass. b. du 12 avril 1888 et du 5 janvier 1911.

3 – L. METZLER, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 184.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
LES SUCCURSALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Selon la jurisprudence luxembourgeoise, par les termes « succursale » ou « siège quelconque d'opération » il faut entendre « *tout établissement secondaire, toute installation commerciale dépendante, tout centre de vie sociale accessoire, mais établi de façon stable et régulière en un lieu fixe, où se tient un préposé qui y représente à demeure la société et y traite avec le public au nom de celle-ci* »(1).

SECTION I
EXTENSION DES OBLIGATIONS DE PUBLICATIONS

Art. 1300-3 [anc. art. 160] L.S.C.

« *Les articles relatifs à la publication des actes et des bilans et les art. 462-1, 603 et 813-2 sont applicables aux sociétés étrangères commerciales ou constituées dans les formes des sociétés de commerce, qui fonderont dans le Grand-Duché une succursale ou un siège quelconque d'opération.*

Les personnes préposées à la gestion de l'établissement luxembourgeois sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société luxembourgeoise.

Les articles mentionnés à l'al. 1er sont également applicables aux sociétés étrangères possédant dans le Grand-Duché une succursale ou un siège d'opération, au moment de la mise en vigueur de la présente loi ».

Les sociétés étrangères qui veulent fonder dans le Grand-Duché une succursale ou un siège quelconque d'opération doivent, aux termes de l'article 1300-3 L.S.C., y publier préalablement leur **acte constitutif**(1).

Le **gérant** de la succursale luxembourgeoise étant lui-même **responsable** de l'accomplissement des **formalités légales**, il ne peut être considéré comme un tiers ayant qualité pour se prévaloir du défaut de publication de l'acte social à l'effet de faire déclarer irrecevable une action à lui intentée par la société(1).

L'article 1300-3 L.S.C. concernant les sociétés commerciales dispose que les articles relatifs à la publication des actes sont applicables aux sociétés étrangères commerciales ou constituées dans les formes des sociétés de commerce qui fonderont dans le Grand-Duché une succursale ou un siège quelconque d'opération.

« *Une société étrangère a un siège d'opération ou une succursale au Grand-Duché au sens dudit article 160 quand elle y accomplit des actes rentrant dans le cadre de ses activités commerciales et qu'elle y est représentée par un mandataire capable de l'engager envers les tiers* »(2). Selon ce même jugement, cette condition n'est pas remplie à l'égard d'une personne qui est liée à la société par un contrat

1 – CA du 22 mars 1926, *Pas.*, n° 11, p. 239, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 19 novembre 1970, *Pas.*, n° 21, p. 426, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de louage de service, et non par un contrat de mandat : celui qui s'engage dans le cadre d'un louage de service « *contrairement au mandataire, s'engage non pas à exécuter un acte juridique au lieu et place du maître de l'ouvrage, mais se charge, moyennant rémunération, d'une mission comportant l'exécution d'un ou de plusieurs actes matériels ou intellectuels mais non juridiques, n'impliquant la substitution d'une personne à une autre par la voie de la représentation (De Page, T. IV, n° 884 et ss)* »[1].

La succursale ou agence d'une société commerciale n'a pas de vie propre. Il s'ensuit qu'à défaut de personnalité morale propre, distincte de celle de la société, la succursale, créancière d'un tiers, peut se voir opposer la **compensation légale**, si le tiers débiteur est à son tour créancier de la société[2].

Art. 1300-4 [anc. art. 160-1] L.S.C.

« *Pour les sociétés visées aux articles 462-1 et 1300-9, l'article 1300-3, alinéa 1er, est remplacé par les articles 160-2 à 160-11* ».

Art. 1300-5 [anc. art. 160-2] L.S.C.

« *Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui relèvent du droit d'un autre État membre de l'Union européenne et auxquelles s'applique la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés sont tenues de publier selon les modalités du titre Ier, chapitre V*bis *de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les actes et indications suivants :*

1° *l'adresse de la succursale ;*

2° *l'indication des activités de la succursale ;*

3° *le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre ;*

4° *la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société ;*

5° *la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :*

a) en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 14, lettre d) de la directive 2017/1132/UE précitée ;

b) en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs ;

6° *a) la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 14, lettres h), j) et k) de la directive 2017/1132/UE précitée ;*

1 – CA du 19 novembre 1970, *Pas.*, n° 21, p. 430, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 1er octobre 1963, *Pas.*, n° 14, p. 210, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

b) une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet ;

7° *les documents comptables dans les conditions indiquées à l'article 1300-6 ;*

8° *la fermeture de la succursale* ».

Art. 1300-6 [anc. art. 160-3] L.S.C.

« *L'obligation de publicité visée à l'article 1300-5, point 7°, ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre dont la société relève, en conformité avec les directives 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises et 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Les documents comptables visés à l'alinéa précédent doivent être publiés dans une des langues suivantes : français, allemand, anglais* ».

Art. 1300-7 [anc. art. 160-4] L.S.C.

« *Lorsqu'au Grand-Duché de Luxembourg, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l'article 1300-6 peut être faite dans le dossier d'une de ces succursales selon le choix de la société.*

Dans ce cas, l'obligation de publicité des autres succursales porte sur l'indication du numéro d'immatriculation de cette succursale sur ce registre ».

Art. 1300-8 [anc. art. 160-5] L.S.C.

« *Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l'article 26 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert, ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre* ».

L'art. 1300-9 [anc. art. 160-6] L.S.C. prévoit des mesures de publicité correspondantes à l'égard des succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre de l'Union européenne, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 2017/1132/UE.

SECTION II
EXTENSION DES OBLIGATIONS DE CONTRÔLE

Lorsque la succursale dépasse les critères d'une « petite entreprise » (voir p. 397), tels que ces critères sont fixés à l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le R.C.S. ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises est obligatoire. L'article 36 de ladite loi s'applique également.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

CHAPITRE III
LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Les règles de droit international privé (DIP) applicables en la matière sont essentiellement les suivantes :

« *Les conditions constitutives de l'existence des personnes morales et l'étendue de leur capacité sont exclusivement régies par la loi du pays où elles ont leur siège* »[1].

Quant à **l'étendue des pouvoirs des organes** légaux ou statutaires des sociétés anonymes étrangères, « *elle est déterminée par les lois du pays où elles ont leur principal établissement, sous réserve de l'ordre public international belge* »[2].

1 – Cass. b. du 12 avril 1988, 1888, I, p. 186.

2 – Cass. b. du 24 septembre 1963, *Pas.*, 1964, I, p. 86.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com



PARTIE IV – LES RESTRUCTURATIONS ET LES GROUPES DE SOCIÉTÉS

LEXNOW

LEXNOW

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Il est inévitable que les sociétés se voient de temps à autre obligées de revoir les structures qu'elles ont adoptées dans un passé plus ou moins lointain afin de s'adapter à leur environnement économique qui, lui, change continuellement. Afin justement de permettre ces adaptations, il est indispensable que le droit offre aux entreprises (et donc aux sociétés) la faculté de changer, et ceci, sans formalités et sans coûts légaux et fiscaux démesurés. De ce point de vue, on peut affirmer sans risque de se tromper que la loi luxembourgeoise est raisonnablement bien faite et qu'elle permet donc des restructurations dans des conditions assez favorables. Heureusement, le champ d'application de certaines dispositions légales, relativement limité par le passé, a récemment été considérablement étendu avec les lois sur les fusions et les scissions de sociétés, les transferts d'activité, de branche d'activité et de patrimoine professionnel.

Au Luxembourg comme ailleurs, les grandes entreprises économiques sont la plupart du temps organisées en **groupes de sociétés,** c.-à-d. qu'une société mère détient un nombre important de filiales sur lesquelles elle exerce un contrôle plus ou moins direct et plus ou moins intensif. Ce contrôle est assuré par le biais de la participation qui lui permet, au moyen de l'exercice des droits d'actionnaires, de prendre une influence déterminante sur la marche économique de la filiale : nomination (et révocation) des organes de gestion et de contrôle, politique de distribution des résultats, etc.

La doctrine et la jurisprudence traditionnelles sont toujours parties de l'hypothèse de l'indépendance de chacune des sociétés appartenant au groupe. Chacune de ces sociétés devrait donc, en principe, être gérée dans son intérêt propre**. L'intérêt social** serait donc la mesure de toute décision. Cette vue n'est toutefois que partielle, car il est aujourd'hui admis que : « *[…] dans les groupes de sociétés, les filiales peuvent tenir compte de l'intérêt du groupe dans la mesure où celui-ci comprend leur intérêt propre* »[1].

La Cour de cassation de France résume comme suit la doctrine applicable en la matière : « *Le concours apporté, par les dirigeants de fait ou de droit d'une société, à une autre entreprise d'un même groupe dans lequel ils sont intéressés directement ou indirectement, doit être dicté par l'intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, et ne doit être démuni de contrepartie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge* »[1].

1 – E. Wymeersch, « Comment le droit pourrait aborder certains groupes de sociétés », *Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe*, p. 706.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

De cette jurisprudence se dégage une ligne de conduite pour les filiales : les dirigeants de la filiale peuvent tenir compte de l'intérêt du groupe et suivre les instructions données dans la perspective du groupe à condition de respecter la double limitation de la Cour de cassation de France. Ainsi, il peut être tenu compte de l'intérêt du groupe tout en maintenant que seul l'intérêt de la filiale est pris en compte.

Dans ce contexte, il convient de noter que le respect de l'intérêt propre du groupe n'est en cause que dans la mesure où des tiers sont concernés, qu'il s'agisse d'actionnaires minoritaires ou encore de créanciers. Lorsque la filiale concernée est une filiale à 100 % de la société mère, il convient de tenir compte uniquement de l'intérêt des créanciers. En revanche, quand des actionnaires minoritaires participent également à la filiale, la protection doit être plus poussée, puisqu'il faut également veiller à la protection des intérêts de ces actionnaires-là.

CHAPITRE I
LES TRANSFORMATIONS DE SOCIÉTÉS AVANT LA LOI DE MODERINSATION

La transformation n'est pas autre chose que le **changement de forme juridique** de la société. Ce changement exige donc les adaptations des statuts de la société requises pour la forme nouvelle choisie par la société. Les effets juridiques d'une telle opération dépendent de la question de savoir si la personnalité juridique est ou non maintenue. Si la réponse à cette question est affirmative, alors la transformation n'affecte en rien les droits et les engagements de la société. En revanche, si la transformation de la société implique la discontinuité de la personnalité morale, elle s'analyse logiquement en une **dissolution** de la société dans sa forme initiale, suivie d'un apport des actifs et passifs à la société nouvelle[1]. Jusqu'à récemment, le **transfert universel** de patrimoine était donc inconnu en droit luxembourgeois (en dehors des cas de scission et de fusion), avec donc la conséquence que les cocontractants de la société devraient individuellement donner leur accord au transfert de leurs droits/obligations sur une autre personne juridique. Ces exigences rendent souvent pratiquement impossibles les opérations de transformation impliquant changement de la personnalité morale.

Selon la jurisprudence belge, la transformation d'une société commerciale entraînait une discontinuité de la personnalité juridique[2]. La forme de la société faisait partie des éléments essentiels du contrat de société et, par conséquent, elle ne pouvait être changée, même pas de l'accord unanime des associés (en tout cas pas sans donner lieu à une personne juridique nouvelle).

Traditionnellement, on considérait que la transformation de la société portait atteinte à un des éléments du contrat de société considérés comme **essentiels** et considérés donc comme **intangibles**[3]-[4]. Quels sont les éléments qui sont visés sous ce terme ?

1 – J. Delvaux, *La société anonyme*, p. 136.

2 – Cass. du 10 février 1955 (deux espèces), *Pas.*, 1955, I, pp. 612 et 617 ; Cass. du 20 novembre 1962, *Pas.*, 1963, I. p. 362.

3 – Th. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 46.

4 – J. Corbiau, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, p. 151, ID 11308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

On peut reconnaître ce caractère à l'objet de la société, à sa nationalité, à l'étendue de la responsabilité (limitée ou illimitée) qu'elle entraîne pour ses membres. « *Il y en a d'autres qui ne peuvent être déduits que de l'ensemble des données du contrat social, d'après les règles ordinaires d'interprétation des conventions* »[1].

Les conséquences du changement d'un tel élément essentiel étaient importantes : « *Les statuts de la société ne pouvaient être modifiés qu'à l'unanimité lorsque la modification affectait un élément essentiel. Cette notion d'élément essentiel s'est toutefois réduite comme une peau de chagrin ; les lois des 6 janvier 1958 et 23 février 1967 ont successivement autorisé la modification de l'objet social (art. 70*bis*) et de la forme de la société (art. 165 et s.) à des majorités spéciales. Ne subsistent plus guère comme éléments essentiels dont la modification requiert une décision unanime que la "nationalité" de la société et la libre cessibilité des actions si elle n'a pas été restreinte dans l'acte constitutif* »[2].

Mais cette approche ne devait pas perdurer. « *Une évolution remarquable est cependant en cours : les éléments considérés traditionnellement comme essentiels perdent progressivement ce caractère. L'objet de la société n'est plus un élément essentiel de celle-ci depuis que la loi du 6 janvier 1958 (art. 70*bis *des lois coordonnées) permet de le changer par une modification des statuts décidée à certaines conditions (de présence et de majorité notamment) […]* »[3].

La question de savoir si les éléments essentiels de la société pouvaient être changés ou non faisait l'objet d'une controverse entre la Cour supérieure de justice et le Conseil d'État : alors que la première se prononçait pour la reprise du texte belge dans la mesure où ce dernier exigeait l'unanimité des voix pour le changement des bases essentielles de la société (afin de pouvoir bénéficier de la doctrine et de la jurisprudence belges), le Conseil d'État, pour sa part, préconisait la solution française permettant la modification de ces bases essentielles également à une majorité qualifiée[4].

Au Luxembourg, sous la version introduite par la loi du 18 septembre 1933, l'article 3 [ancien] L.S.C. (amendé par la loi du 7 septembre 1987) contenait la précision que la transformation n'entraînait pas de modification de la personnalité morale « *à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un changement des bases essentielles du pacte social ou du prolongement de sa durée* ». Ce bout de phrase fut supprimé par la loi du 7 septembre 1987. Depuis lors, la L.S.C. comporte une disposition très flexible sur ce sujet de la transformation des sociétés dans le sens qu'elle prévoit que n'importe quelle société commerciale d'une forme donnée peut se transformer en société d'une autre forme, et ceci, sans donner lieu à une **individualité juridique nouvelle**. Pour être juridiquement valables, ces changements sont soumis à certaines conditions de forme et de fond.

« *Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l'époque de leur constitution, si aucune disposition de leur contrat constitutif ne l'interdit, être transformées en*

1 – Projet de loi portant révision de la loi sur les sociétés commerciales, Avis du Conseil d'État, p. 98, ID 13321.

2 – L. Simont, « Réflexion sur l'abus de minorité », *Liber Amicorum Jan Ronse*, p. 307.

3 – Cass. b. du 12 novembre 1965, *R.C.J.B.*, 1966, note J. van Ryn, p. 408.

4 – Projet de loi portant révision de la législation sur les sociétés commerciales, rapport du Conseil d'État, p. 424, ID 13321.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

sociétés à forme commerciale, par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les statuts de la société. Sa décision n'est valable que si elle obtient l'adhésion des titulaires de parts représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales.

Pourra enfin chacune des six sociétés énumérées à l'art. 2, quelles que soient la nature primitive de son objet et l'époque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat constitutif ne l'interdit, être transformée en une société de l'un des cinq autres types prévus par le dit article. Dans tous les cas visés par les alinéas 4 et 5, la transformation ne donnera pas lieu à une personnalité juridique nouvelle. Les droits des tiers sont réservés ».

Ces transformations, dans la mesure où elles ne comportent pas la création d'une personnalité morale nouvelle, ont, en application du principe dit de la **permanence de la personnalité morale**, pour conséquence que les droits et obligations de la société avant transformation sont conservés automatiquement et à l'identique au profit et à charge de la société issue de la transformation[1]-[2].

SECTION I
CONDITIONS DE FOND

Le changement de forme de la société ne peut se faire que si, au moment de ce changement, les conditions de fond de la nouvelle forme sont remplies. Il faut donc notamment avoir le capital minimum, le nombre d'associés minimum, etc. requis par la forme de société vers laquelle a lieu le changement envisagé. Il faudra encore créer les organes sociaux requis par cette nouvelle forme de manière à satisfaire aux conditions spécifiques de la forme en faveur de laquelle on change.

Ces transformations, bien que se mouvant à l'intérieur de la sphère des sociétés de capitaux, ne se font pas sans difficultés pratiques.

Le régime juridique est précisé par l'article 31-1 L.S.C. : « *Les dispositions concernant la constitution des sociétés anonymes sont applicables en cas de transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme* ».

La première difficulté tient au fait que les conditions de formation des deux formes de sociétés ne sont pas identiques, à savoir que pour les S.A. une évaluation des **apports en nature** par un réviseur d'entreprises est requise, alors que tel n'est pas le cas dans les S. à r.l. Par conséquent, lorsqu'une S. à r.l. se transforme en S.A., il faut un rapport du réviseur d'entreprises portant évaluation des « apports » faits à la S.A. au moment de la transformation. Il est bien vrai qu'il n'y a en réalité pas d'apport, mais simplement continuation de la même personne juridique sous une autre forme, sans rupture de la personnalité juridique (voir 100-3 L.S.C).

Une autre question qui se posait dans un tel cas de figure était celle de savoir si l'on pouvait transformer une société qui a subi des **pertes,** de sorte que le capital social de la forme dans laquelle la transformation est faite n'était plus atteint. La pratique notariale semble retenir que la transformation n'est pas possible. Cette position

1 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, p. 83.

2 – V. encore TA Lux. du 4 mars 1993, L-1976/93, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

paraissait critiquable. Il nous semble que l'attitude suivante devrait être adoptée : en cas de changement de S.A. vers la S. à r.l., la société qui avait initialement un capital de 30 000 euros pouvait se transformer, même si son capital est devenu négatif par suite de pertes d'exploitation. Le changement d'une forme vers une société ayant un capital minimum plus élevé (de S. à r.l. vers S.A.) ne sera pas possible pour la raison que la société n'a jamais eu le capital qui est requis en vertu de la nouvelle forme adoptée.

En cas de transformation en S.A., on invoquait, à juste titre, la disposition formelle de l'article 31-1 L.S.C. qui exigeait en fin de compte que le capital social effectif soit au moins équivalent au capital nominal, donc que des pertes bilantaires ne puissent pas avoir entamé ce dernier. L'article 31-1 L.S.C. a été introduit par la loi du 24 avril 1983 sur demande du Conseil d'État, et ceci, afin d'éviter que les nouvelles dispositions ne soient contournées par la constitution d'une S. à r.l. transformée en S.A. peu de temps après.

Cette mesure du législateur national trouve encore un fondement dans l'article 13 de la Deuxième directive de la CE (77/91/CEE) en matière de droit des sociétés et qui demande aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour maintenir des garanties identiques en cas de transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme. Envisagée comme **mesure anti-abus**, on pourrait en conclure que rien ne s'oppose à ce qu'une société anonyme se transforme en S. à r.l. sans avoir un capital social effectif correspondant à son capital social nominal, sous la seule condition que l'actif net soit au moins équivalent au capital social légal minimum[1].

SECTION II
CONDITIONS DE FORME

Les conditions de forme sont différentes selon le cas de figure envisagé. Soit le changement de forme se fait dans le sens d'une forme de société qui comporte une **augmentation** des **engagements** des associés, soit tel n'est pas le cas (ces engagements ou bien restent inchangés ou bien diminuent). Dans ce contexte, on peut noter que le changement d'une société de personnes vers une société de capitaux comporterait en principe une diminution des engagements des associés. Le changement dans le sens inverse reviendrait à augmenter les engagements des associés et demanderait donc l'unanimité des associés.

Il reste que l'article 3 (ancien) L.S.C., tout en résolvant en principe tous les cas de transformation de sociétés commerciales, n'était pas exhaustif dans la mesure où d'autres cas de transformation peuvent se poser en pratique. Pour de tels cas, la continuation de la personnalité morale n'est donc pas assurée. Ainsi la loi était-elle muette sur les transformations de société commerciale en société civile, sur les transformations mettant en cause les G.I.E. (G.E.I.E.), donc d'une société commerciale en un tel groupement ou encore d'un tel groupement en une société commerciale, sur celles concernant les a.s.b.l., etc.

Le projet de loi n° 4992 tel que déposé le 26 juin 2002 (et qui a abouti à la loi du 23 mars 2007) proposa de modifier un certain nombre de dispositions L.S.C. et avait,

1 – V. A. Schwachtgen qui se réfère à J.-M. Ueberecken, « La transformation d'une S. à r.l. en S.A. », *Tax today. Mélanges de droit des sociétés,* 18-19 avril 2007, p. 4.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

entre autres, prévu d'amender l'article 3 de ladite loi en abandonnant le système retenu par la L.S.C. de la commercialité par la forme au profit de la **commercialité par l'objet**. Le projet précisait que les sociétés à objet civil constituent aussi une individualité juridique distincte de celle de leurs associés et proposait d'assurer la continuité de la personnalité juridique en cas de transformation d'une société dotée de la personnalité juridique en un autre type de sociétés dotées de la personnalité juridique, y compris en cas de transformation d'un GIE en un type de société dotée de la personnalité juridique (et vice versa). La loi du 23 mars 2007 n'a cependant pas retenu le système de la commercialité par l'objet et ne s'est prononcée ni en faveur du maintien de la personnalité juridique en cas de transformation d'un GIE en société commerciale (et vice versa) ni sur ce maintien en cas de transformation d'une société commerciale en société civile.

La loi contient encore le passage suivant : « *les droits de tiers sont réservés* ». La signification de ce dernier passage est aisée à voir : en cas de changement de forme de la société, les droits des créanciers sont directement affectés. En effet, avoir une créance sur une société de personnes ou une société de capitaux comporte (toutes choses égales par ailleurs) une garantie plus ou moins grande pour le créancier : si, dans le premier cas, il bénéficie de la garantie de la totalité de la fortune personnelle des associés, la créance sur une société de capitaux ne porte comme garantie que le seul patrimoine de la société elle-même. Les créanciers antérieurs à la transformation ne peuvent être privés de cette garantie supplémentaire en raison du simple changement en société de capitaux[1]. Il est à noter que les obligataires réunis en AG doivent donner leur accord lors de toute modification de l'objet ou de la forme de la société[2].

Les parts ou les actions de la société issue de la transformation prennent la place des parts de la société transformée, et ceci, par subrogation[3].

1 – L. Metzler, *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, p. 146.

2 – Art. 450-3 (2), (3) [anc. art. 67-1 (2), (3)] L.S.C., ID 7520.

3 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 288.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
LES TRANSFORMATIONS DE SOCIÉTÉS DEPUIS 2016

Un des apports positifs de la Loi de Modernisation a été le regroupement des dispositions applicables en matière de transformation de société en société d'une autre forme en un chapitre séparée de la L.S.C. Ledit chapitre est le chapitre 1er appelé « De la transformation » du titre X « Des restructurations », chapitre qui comporte les articles 1010-1 à 1010-12 L.S.C. En raison de l'augmentation constante des formes de sociétés introduites par le législateur luxembourgeois pendant les dernières décennies, le nombre de cas de transformations possibles augmente de manière exponentielle, et il est donc certainement avantageux de les retrouver résolus dans un chapitre distinct de la L.S.C. En outre, le sens de ces transformations est loin d'être neutre, c.-à-d. qu'une transformation d'une S.e.n.c. en S.A. (p. ex.) est fondamentalement différente d'une transformation d'une S.A. en S.e.n.c. Par conséquent, le régime juridique applicable doit en tenir compte.

SECTION I
CHAMP D'APPLICATION DU TITRE X

En fait, ledit chapitre 1er du titre X ne réglemente pas tous les cas de transformation : ceux concernant la transformation de la S.A. en SE ainsi que ceux concernant la société coopérative européenne (SEC) en société coopérative (ainsi que la transformation en sens inverse) ne sont pas traités par le chapitre 1er du titre X (art. 1010-1 (1) L.S.C.), mais par les parties respectives de la L.S.C. consacrées à ces formes de sociétés.

Le régime de la transformation mis en place par la Loi de Modernisation est calqué sur celui applicable aux cas de transformations des sociétés de droit européen que sont la SE et la SEC, ainsi que des cas de restructurations classiques des fusions et scissions de société pour lesquelles le droit européen (via des directives) a introduit un régime détaillé qui a, par la suite, été étendu à d'autres cas de figure que ceux visés expressément et obligatoirement par les directives européennes.

La loi (art. 1010-1 (2) L.S.C.) distingue implicitement trois cas de transformation :

5) les transformations d'une société civile, d'un GIE d'une S.e.n.c. d'une S.e.c.s. ou d'une société coopérative en S.A. (ou S.e.c.a.) ;
6) les transformations d'une S. à r.l. en S.A. (ou S.e.c.a.) si celle-ci a fait l'objet d'un apport en nature ou d'un quasi-apport tel que visé à l'article 420-11 L.S.C. dans les deux ans précédant la décision de transformation en S.A. (S.e.c.a.) et que cet apport n'a pas fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises conformément à l'article 420-10 L.S.C., etc. ;
7) les autres transformations.

Il résulte de cette classification que deux des trois cas de transformation concernent des transformations en S.A. (S.e.c.a.). Le caractère distinctif de ces cas par rapport aux autres cas de transformation est que les apports en nature faits à des S.A. (S.e.c.a.) faisaient obligatoirement l'objet d'un **rapport d'un réviseur d'entreprises**. La L.S.C. (dans sa version antérieure à la Loi de Modernisation) avait pour cette raison également prévu l'intervention obligatoire d'un réviseur d'entreprises pour le cas

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de transformation d'une S. à r.l. en S.A. (S.e.c.a.). En effet, l'article 31-1 L.S.C. (qui a été aboli par la Loi de Modernisation) disposait que : « *Les dispositions concernant la constitution de la société sont applicables à la transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme* ». Cette solution s'expliquait par le souci du législateur d'éviter que des biens soient apportés à une S. à r.l. et que cette société soit peu de temps après transformée en S.A. (S.e.c.a.), ce qui éviterait ainsi le contrôle du réviseur d'entreprises. Une telle **utilisation abusive** des dispositions de la L.S.C. contournant l'obligation de contrôle des apports en nature à une S.A. était ainsi évitée par la loi elle-même. Toutefois, la solution de la loi était manifestement excessive : en plus des cas relevant d'un comportement de contournement des dispositions légales, étaient atteints de nombreux autres cas ne justifiant en rien l'intervention d'un réviseur d'entreprises, notamment ceux où (à l'extrême) la S. à r.l. aurait à son actif uniquement des actifs monétaires, tels que comptes bancaires, encaisse, etc. Obliger la S. à r.l. à recourir à un réviseur d'entreprises dans un tel cas est une solution dénuée de la moindre justification.

Heureusement, la Loi de Modernisation a adopté une solution qui a le mérite de limiter l'intervention du réviseur d'entreprises aux cas qui sont clairement abusifs, à savoir ceux où il y a eu apport en nature à la S. à r.l. (sans intervention d'un réviseur) suivi de la transformation en S.A. dans les deux ans de l'apport en nature. Tous les autres cas échappent aux dispositions du contrôle obligatoire des apports en nature. Pour couper court à toute controverse susceptible de naître à ce sujet, le législateur a arrêté que « *[l]es dispositions relatives à la spécification et au contrôle des apports en nature […] en cas d'augmentation de capital ou de constitution de la société au moyen de souscriptions ne sont pas applicables à la transformation en […] société anonyme et en société en commandite par actions* » (art. 1010-10 L.S.C.).

SECTION II
PROCÉDURE DE TRANSFORMATION

La première étape de la procédure de transformation consiste à « *établir un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation* » (art. 1010-2 L.S.C.). Cet article précise encore que, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice clôturé moins de six mois avant l'assemblée générale, ces comptes annuels (en fait, le bilan) servent d'état résumant la situation active et passive de la société. En un mot, si l'assemblée générale se prononçant sur la transformation se réalise dans la première moitié de l'année, alors aucun travail additionnel n'est requis.

Même si cette condition n'est pas remplie (donc la transformation se réalisé plus de six mois après la clôture de l'exercice), alors aucune situation n'est requise à condition que « *tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote* » y **renoncent** (art. 1010-2, alinéa 2, L.S.C.).

Les conditions de transformations sont considérablement alourdies pour les cas où la transformation se fait vers une S.A./S.e.c.a., ce qui rend applicable les articles 1010-1 à 1010-4 L.S.C., avec la conséquence que cette situation active et passive est ensuite soumise à un réviseur d'entreprises désigné en principe par l'organe de gestion (et, dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

à responsabilité limitée, les GIE et les sociétés civiles, par l'assemblée générale) qui fait **rapport sur cet état comptable** en se prononçant notamment sur la question de savoir s'il y a surestimation de l'actif net.

En outre, l'organe de gestion établit un **rapport justificatif** sur la proposition de transformation annoncée dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation ; la situation active et passive est jointe à ce rapport. Il est toutefois loisible à l'ensemble des porteurs de titres ayant droit de vote de **renoncer** à cette formalité (art. 1010-4 L.S.C.).

Tout associé et toute autre personne autorisée à participer à l'assemblée a le droit d'obtenir gratuitement quinze jours avant l'assemblée une copie de la situation comptable (ou des derniers comptes annuels), du rapport de l'organe de gestion et du rapport du réviseur d'entreprises, ainsi que du projet de modification des statuts (art. 1010-5 L.S.C.).

La loi précise encore que l'absence d'un des rapports requis en vertu des articles 1010-3 et 1010-4 L.S.C. entraîne la **nullité** des décisions de l'assemblée générale (art. 1010-6 L.S.C.).

Si, à première vue, cette procédure peut paraître excessivement lourde, il convient de souligner que la loi a prévu la possibilité de renonciation (étant toutefois entendu que celle-ci doit être donnée à l'unanimité des associés et autres porteurs de titres ayant droit de vote) à la situation active et passive et au rapport justificatif de l'organe de gestion, de sorte que, dans cette hypothèse de renonciation, les formalités requises se réduisent à très peu de choses. Le rapport du réviseur d'entreprises est toutefois inévitable, mais il est justifié comme expliqué ci-dessus.

Les transformations sont, fort logiquement, assimilées à des **modifications de statuts,** ce qui signifie donc que la transformation ne peut être décidée que sous les conditions de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts de la société qui sera transformée, étant entendu que les statuts de cette société pourraient prévoir des conditions plus strictes (art. 1010-7 L.S.C.).

Pour certaines formes de transformation, cette majorité n'est pas suffisante, étant donné que la L.S.C. exige **l'unanimité** soit de tous les associés, soit de certaines catégories d'associés. Ainsi, la transformation d'une S.e.c.s. ou d'une S.e.c.a. (en plus des conditions normales de modification des statuts) requiert l'unanimité de tous les associés commandités. De même, la transformation en S.e.c.s. et S.e.c.a. requiert l'accord unanime de tous les associés commandités.

L'accord de tous les associés est encore requis dans les cas de l'article 1010-7 (4) L.S.C., notamment :

- transformation en S.e.n.c, S.e.c.s., GIE ou en société civile. Cette condition de l'unanimité s'explique aisément, étant donné que le régime de responsabilité change de façon fondamentale et qu'il y a donc de fortes chances que les engagements des associés augmentent du fait de la transformation ;
- transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d'une S.e.c.s., d'une S.e.c.a., d'une S. à r.l. ou d'une SA ;
- transformation d'une S.e.n.c., d'une coopérative à responsabilité limitée d'un GIE ou d'une société civile.

Finalement, l'unanimité est exigée lorsque les statuts excluent la transformation en une autre forme : une telle clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité (art. 1010-7 (4) L.S.C.).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Immédiatement après la transformation, les statuts de la société sous la forme nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité, faute de quoi la décision de transformation reste sans le moindre effet (art. 1010-8 L.S.C.).

La transformation exige quasiment toujours un **acte authentique,** sauf le cas où elle se fait entre deux formes de sociétés (groupements) qui peuvent valablement être constituées sous seing privé. Compte tenu qu'en matière de sociétés commerciales, les sociétés de capitaux dominent de façon écrasante, ceci ne sera que rarement le cas.

L'acte de transformation et les statuts de la société dont la forme est adoptée sont publiés en entier (ou par extraits), et la société est opposable aux tiers dans les conditions prévues par la Loi de 2002.

En cas de surévaluation des actifs dans « *l'état résumant la situation active et passive* », les associés (membres) d'une S.e.n.c., d'une société coopérative à responsabilité illimitée, d'un GIE ou d'une société civile et les membres de l'organe de gestion de la société à transformer sont tenus envers les intéressés de la surévaluation des actifs.

L'article 1010-12 L.S.C. traite de la responsabilité des associés à l'égard des tiers pour les engagements de la société antérieurs à la transformation et est relatif aux cas de transformation de société de personnes, etc. (S.e.n.c., p.ex.) et en de telles sociétés de personnes : il n'étonnera personne que, si une S.e.n.c. abandonne son statut en faveur de celui d'une S.A., p.ex., les associés de l'ancienne S.e.n.c. restent tenus solidairement des dettes de la S.e.n.c. contractés avant que cette transformation soit devenue opposable aux tiers. C'est la solution retenue par le 1er alinéa dudit article. L'alinéa 2 de ce même article 1010-12 L.S.C. retient une solution qui est moins évidente pour le cas inverse (donc la transformation en S.e.n.c., S.e.c.s., etc.). La L.S.C. soumet les engagements antérieurs à la transformation au régime de la responsabilité conjointe ou solidaire applicable à partir de la transformation. Par conséquent, la situation des créanciers sociaux s'améliore en principe du fait de cette transformation. En pratique, les cas de telles transformations seront certainement très rares.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE III
LES FUSIONS ET SCISSIONS DE SOCIÉTÉS

Les fusions et les scissions de sociétés sont des opérations qui, traditionnellement, étaient nées de la pratique en l'absence de texte spécifique les régissant ; ni le Code de commerce de 1808 ni la Loi de 1915 ne comportaient la moindre disposition portant sur ce sujet. C'est sur la base de directives communautaires (donc de normes assez récentes) que des dispositions ont finalement été introduites dans la L.S.C. pour réglementer cette matière.

La loi du 7 septembre 1987 a introduit dans la loi sur les sociétés commerciales les dispositions des Troisième et Sixième directives CE[1] sur les fusions et les scissions de sociétés anonymes[2] ; en vertu de ces textes, les opérations visées pouvaient se réaliser par suite d'une « dissolution sans liquidation » de la société, des sociétés ou de certaines de ces sociétés entrant dans de telles opérations. Ces dispositions, initialement ne concernaient que les sociétés anonymes (et depuis la loi du 10 juin 1999, les sociétés coopératives organisées comme sociétés anonymes).

Qu'en est-il des fusions entre sociétés autres que les sociétés anonymes ? Il est à noter à cet égard que le législateur national n'avait pas adopté la même approche que son homologue belge dans le sens qu'il n'avait pas étendu aux autres formes de sociétés les dispositions que les directives rendaient obligatoires à l'endroit des sociétés anonymes. Pour le gouvernement belge, « *ne viser que les opérations mettant en cause des sociétés anonymes aurait abouti à maintenir pour les sociétés d'un autre type la relative insécurité juridique actuelle. Quant aux opérations mettant en cause des sociétés de forme juridique différente, il n'a pas paru opportun de les interdire, mais elles s'entourent de garanties propres à rassurer aussi bien les actionnaires que les tiers. Ces garanties s'inspireront très logiquement de celles qui sont prévues en cas de transformation de sociétés* »[3]. À notre sens, tel aurait également dû être le choix du législateur luxembourgeois dès 1987. Le Luxembourg ne s'est engagé dans cette voie qu'en 2007.

C'est la loi du 23 mars 2007[4] qui procéda finalement à la double extension des dispositions applicables aux fusions et scissions de sociétés : d'une part, en les étendant aux **autres formes de sociétés** (toutes les formes de sociétés commerciales) ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique ; d'autre part, en disposant qu'une société dotée de la personnalité juridique en vertu de la L.S.C. ou un groupement d'intérêt économique peuvent contracter une fusion avec une **société étrangère** pour autant que le droit national de la société étrangère ne s'oppose pas à une telle fusion (art. 1020-1 [anc. art. 257] L.S.C.).

---

1 – La transposition en droit national de ces directives ne s'est d'ailleurs faite qu'avec un retard assez considérable dans la mesure où ces directives auraient dû être transposées en droit national dès 1981 (fusions) et 1986 (scissions).

2 – Les dispositions en question ont été introduites aux articles 1033-1 à 1050-9 [anc. art. 257 à 308] L.S.C., ID 7520.

3 – G.-A. Dal et M. van den Abeele, « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *R.P.S.*, 1993, p. 195.

4 – Loi du 23 mars 2007, ID 9444.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il est vrai que, déjà avant la transposition de la directive 2005/56/CE[1], les fusions transfrontalières avaient été rendues possibles par le législateur national, et ceci, au moyen de la loi du 23 mars 2007 « *portant modification des articles 257, 271, 273*bis *et 276 de la loi modifiée du 10 août 1915 […]* »[2].

La loi de 2007 n'avait pourtant pas prévu une transposition intégrale de la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. En fait, elle ne faisait qu'envisager le cas d'absorption d'une société étrangère par une société luxembourgeoise. Ce cadre légal introduit au début de 2007 devrait encore changer lors de l'implémentation complète de la directive 2005/56/CE par la loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux[3].

La loi du 10 juin 2009 sur les fusions transfrontalières avait choisi non de réglementer les fusions par des chapitres séparés de la loi, mais de les faire régir par les mêmes dispositions de la loi, à savoir la section XIV L.S.C. consacrée aux fusions et la section XV consacrée aux scissions. Afin de tenir compte des spécificités inévitables de ces opérations transfrontalières, le législateur a choisi d'insérer, le cas échéant, un paragraphe particulier consacré aux opérations impliquant une ou plusieurs sociétés étrangères. Ci-après nous reprenons la même approche.

On peut donc retenir que, dans l'état actuel des choses, les opérations de fusions et de scissions peuvent se réaliser non seulement entre sociétés anonymes (comme tel était le cas avant 2007), mais encore entre toutes les sociétés dotées de la personnalité morale (donc les sept formes de sociétés commerciales en plus des sociétés civiles), et finalement encore des groupements d'intérêt économique. En outre, et ceci depuis la loi du 10 juin 2009, ces opérations peuvent mettre en cause des sociétés non luxembourgeoises, mais sans qu'il soit requis qu'il s'agisse de sociétés d'un autre État membre de l'Union européenne. En effet, de telles opérations peuvent se réaliser avec des sociétés de n'importe quel pays, sous la seule condition que « *la législation étrangère ne s'y oppose pas* » (art. 1020-1 L.S.C.). Il n'est donc nullement requis que la loi étrangère régissant la société concernée prévoie des conditions positives permettant de telles opérations, mais il suffit que la loi étrangère ne s'y oppose pas formellement : « *Il est bien entendu que si le droit national ne prévoit pas de disposition spécifique aux fusions transfrontalières cela n'empêche pas qu'une telle fusion soit possible au regard du droit luxembourgeois puisque le droit étranger ne s'y oppose pas et que, par définition, les dispositions et formalités nationales inexistantes sont automatiquement respectées* »[4].

Cette restriction va de soi, car une fusion transfrontalière ne peut produire effet que si elle est reconnue par les deux États en présence. Le droit luxembourgeois se distingue toutefois de certaines législations étrangères sur le point qu'il ne demande pas que le droit étranger « *autorise* » la fusion (art. 163a de la loi fédérale sur le droit international privé suisse). Toutefois, l'interprétation de cette disposition en droit suisse

1 – Par la loi du 23 mars 2007, ID 9444, *Doc. parl.*, n° 4992, ID 9910.

2 – V. projet de loi n° 5658, ID 10069. Il y a lieu de noter que cette loi avait été prise dans le contexte de la reprise de Arcelor par Mittal, de sorte que la mise à disposition d'un cadre légal adéquat avait pris une certaine urgence.

3 – Loi du 10 juin 2009, ID 11253, *Doc. parl.*, n° 5829, ID 10111.

4 – *Doc. parl.*, n° 5829, p. 16, ID 1011.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

est que le silence du droit étranger est considéré comme valant autorisation[1]. Sur un plan européen, la transposition de la directive de 2005 vaut autorisation à l'égard des sociétés y visées, soit donc les sociétés de capitaux. La condition de l'absence d'opposition joue donc surtout en matière de fusions autres qu'européennes.

Dans les deux sections suivantes, la convention de langage suivante s'applique, et ceci, pour éviter les lourdeurs d'expression : lorsque nous parlons de société, cette notion couvre également les groupements d'intérêt économique (GIE et GEIE). De même, la notion d'« associé » inclut celle de « membre d'un GIE ou GEIE ».

SECTION I
LES FUSIONS

On considère traditionnellement que celles-ci peuvent se faire soit par absorption, soit par constitution d'une société nouvelle (parfois encore appelée « *fusion proprement dite* »). Déjà la Troisième directive avait repris cette distinction.

- **Fusion par absorption** : l'ensemble du patrimoine d'une ou de plusieurs sociétés est transféré par suite d'une dissolution sans liquidation à la société absorbante ; cet apport est rémunéré par l'attribution aux actionnaires de la (ou des) société(s) absorbée(s) d'actions de la société absorbante et, le cas échéant, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions (ou parts) attribuées ou à défaut de valeur nominale de leur pair comptable[2].
- **Fusion par constitution d'une nouvelle société** : l'ensemble du patrimoine de plusieurs sociétés est transféré à une société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation ; l'apport est rémunéré par des actions (ou parts) de la nouvelle société et, le cas échéant, par une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions[3].
- **Opérations assimilées** : l'opération d'absorption d'une société filiale par la société mère qui en détient 90 % au moins des actions (art. 1023-1 à 1023-6 L.S.C.) ; les opérations susvisées comportant une soulte dépassant 10 % de la valeur nominale des actions (parts) attribuées ou à défaut de valeur nominale de leur pair comptable ainsi que les opérations impliquant des sociétés qui sont en état de liquidation (art. 1024-1 L.S.C.).

L'article 30 de la Troisième directive permet aux États membres d'autoriser une soulte plus élevée que 10 %. En application de cette faculté, le législateur belge a opté pour une limite de 20 %. La loi luxembourgeoise fait également fruit de la possibilité laissée par l'article 30, mais sans fixer un taux précis au-delà duquel l'opération serait disqualifiée. Cette solution s'explique par la considération que les dispositions protectrices prévues par la directive pourraient être facilement écartées en fixant une soulte dépassant le taux limite de 10 %. Toutefois, en pratique, on ne risque guère de voir beaucoup de cas où une soulte serait fixée à un niveau dépassant ce seuil : la raison en est que les dispositions fiscales de faveur permettant de réaliser de telles opérations en exemption d'impôt sur le revenu ne sont pas applicables lorsque la soulte dépasse le seuil de 10 %.

1 – P.-H. Conac, *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 69.

2 – Art. 1020-3 L.S.C., ID 7520.

3 – Art. 1020-4 L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le fait qu'une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés, ne fait pas obstacle à l'application de ces règles (art. 1020-1, alinéa 2, L.S.C.). Cette disposition permet en fait de faire appliquer le traitement du transfert universel de droits et d'obligations. Il est ainsi possible de faire transférer les actifs et passifs d'une société dont le terme est arrivé en application de ces dispositions.

La fusion requiert la réalisation de quatre conditions[1] :

1. l'existence préalable de deux sociétés (au moins) ;
2. le transfert de l'ensemble du patrimoine de la société absorbée (ou encore de toutes les sociétés fusionnantes à la société nouvelle) ;
3. la dissolution sans liquidation de la société fusionnée ;
4. l'acquisition des actions de la société (issue de la fusion) par les associés de la société fusionnée avec une soulte maximale de 10 % (en principe).

Ad 1 :

En application de cette exigence les sociétés fusionnantes doivent avoir été régulièrement constituées et avoir eu une existence indépendante avant la réalisation de la fusion. Aux termes de la loi luxembourgeoise, elles doivent être dotées de la personnalité morale.

Ad 2 :

Les sociétés fusionnantes transfèrent l'intégralité de leur patrimoine activement et passivement. Selon l'exposé des motifs de la loi belge, « *Sa conséquence essentielle doit être soulignée de manière nette : l'entreprise de la société absorbée se poursuit sans solution de continuité, dans la société absorbante, exactement comme lorsqu'une société adopte une forme juridique nouvelle. Une fusion est donc une opération toute différente d'un simple apport ou d'une simple vente* »[2].

Les effets de la fusion sont ainsi assimilés à ceux que l'on connaît en matière de droit des successions où l'héritier « *continue la personne du défunt qu'il représente quant à ses droits et quant à ses obligations. Il en résulte que la société fusionnée peut sans autres formalités que celles de la fusion exercer les droits de la société disparue* »[3].

Ad 3 :

La société absorbée (les sociétés fusionnantes) fait l'objet d'une « *dissolution sans liquidation* ». La liquidation étant inutile, tous les biens sont tels quels transférés à la société bénéficiaire. Faute de liquidation, il n'y a pas non plus lieu de faire survivre passivement la société dissoute (les sociétés dissoutes) pendant une durée de cinq années en application de l'article 1400-6 [anc. art. 157] L.S.C.

1 – G.-A. Dal et M. van den Abeele, « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *R.P.S.*, 1993, p. 203.

2 – Exposé des motifs, p. 4.

3 – G.-A. Dal et M. van den Abeele, « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *R.P.S.*, 1993, p. 207.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La pratique notariale au Luxembourg semble être que les acteurs économiques puissent à leur choix procéder soit à la liquidation de la société, soit ne pas y procéder, notamment dans le cas de la reprise de tous les actifs et passifs par une personne physique. Cette pratique est fort discutable, au moins dans les cas qui sont couverts par la L.S.C. En effet, le droit européen ne laisse pas le choix de faire autre chose que d'appliquer les dispositions de la loi fondées sur les directives[1].

Ad 4 :

L'attribution des titres de la société bénéficiaire aux associés tant des sociétés survivantes que des sociétés disparues dans la fusion ne représente pas nécessairement la seule rémunération des associés de la société apporteuse dans la mesure où une soulte (soit donc un paiement au comptant) de 10 % au plus de la valeur nominale des actions émises peut leur être attribuée.

Il existe un autre cas de figure également visé par la loi et qui ne comporte pas d'attribution de titres aux associés : il s'agit du cas de l'absorption de la société filiale par la société mère qui en détient 100 % des actions ou parts. Dans ce cas, il n'y a pas d'augmentation de capital de la société absorbante : l'opération consiste simplement en un échange de titres contre les actifs et les passifs de la société absorbée. Dans ce cas tout à fait particulier, le principal problème de toute opération de fusion (à savoir celui de la détermination du rapport d'échange existant entre les actions anciennes et nouvelles) est évité.

L'importance de ce problème du rapport d'échange est encore amplifiée lorsque la fusion concerne deux sociétés qui ne sont pas entièrement indépendantes étant donné que l'une détient une participation substantielle dans l'autre, de sorte que cette société est en mesure d'influencer les organes de l'autre société[2]. La solution à ce problème fut cherchée dans le rapport de réviseur qui doit être émis et doit se prononcer de façon spécifique et avec précision sur le rapport d'échange.

■ § 1 – Fusion par absorption

Un certain nombre de formalités sont inévitables.

A – Étapes de la fusion

Conformément à la directive, la réalisation de la fusion exige l'établissement d'un projet de fusion qui, depuis la transposition de la directive de 2005, s'appelle « *projet commun de fusion* » (*Doc. parl.*, p. 16).

1 – I. Corbisier, *Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, p. 47.

2 – G.-A. Dal et M. van den Abeele, « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *R.P.S.*, 1993, p. 209.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

1) Établissement d'un projet commun de fusion

La rédaction de ce projet commun de fusion incombe aux organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent. Il mentionne obligatoirement (art. 1021-1 L.S.C.)[1] :

« 1° *la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion ;*

2° *le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèce ;*

3° *les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante ;*

4° *la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;*

5° *quelle que soit la date d'effet de la fusion suivant les articles 1021-13, 1021-14, 1021-15 et 2021-16, la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante ;*

6° *les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard ;*

7° *tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 1021-6, aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent* ».

Selon le point 5°, il est demandé au projet commun de fusion d'indiquer « *la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante* ». À ce sujet, on parle parfois de **rétroactivité** de la fusion. Une telle expression est certainement critiquable dans la mesure où il ne s'agit pas de rétroactivité. Pour la doctrine belge, il s'agit uniquement de « *déterminer la date à laquelle l'on se place pour fixer les termes d'échange et à partir de laquelle, par voie de conséquence, les modifications de la valeur des actions ou parts demeurent sans incidence sur l'opération* »[2].

Il convient de noter que tel n'est pas le seul effet de la fixation de cette date. En réalité, les opérations sont, à partir de cette date, considérées comme étant effectuées par la société absorbante.

(3) Lorsqu'une **société européenne** (SE) est constituée par la voie d'une fusion, le projet comprend en outre :

« *1° les statuts de la société européenne (SE) ;*

2° des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs ».

1 – Art. 1021-1 [anc. art. 261] L.S.C., ID 7520.

2 – P. Van Ommeslaghe, « La réforme des fusions et des scissions », *Quo vadis ius societatum ? Liber amicorum P. Sanders*, Kluwer 1972, p. 129.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

(4) En cas de **fusion transfrontalière**, le projet commun de fusion comprend en plus :

« *1° les statuts de la société absorbante ;*

2° une description des effets probables de la fusion sur l'emploi ;

3° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive (UE)2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ;

4° des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société absorbante ;

5° les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion ».

2) Publication du projet commun de fusion

Ce projet commun de fusion est obligatoirement publié conformément aux dispositions de la Loi de 2002 (art. 1021-2 L.S.C.).

« (2) *En cas de fusion transfrontalière, la publication doit également comporter les indications suivantes :*

1° la forme, la dénomination et le siège statutaire de la société qui fusionne ;

2° le registre de commerce et des sociétés auprès duquel les actes visés [par la Loi de 2002] *ont été déposés par la société absorbante et le numéro d'immatriculation dans ce registre, s'il s'agit d'une société luxembourgeoise ; si la législation de l'État dont la société de droit étranger relève prévoit la tenue d'un registre, le registre auprès duquel les actes visés à l'article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Conseil, du 17 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ont été déposés par la société de droit étranger et si la législation de l'État dont la société de droit étranger relève prévoit un numéro d'inscription dans ce registre, le numéro d'inscription dans ce registre ;*

3° une indication pour chacune des sociétés qui fusionnent des modalités d'exercice des droits des créanciers de la société concernée, ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités ».

3) Approbation de la fusion par chacune des sociétés

La fusion requiert en principe l'approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent aux conditions requises pour les modifications des statuts[1]. Sous certaines conditions, l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante n'est pas nécessaire et, en particulier, si un ou plusieurs des associés de la société absorbante disposant d'au moins 5 % des actions ont le droit de requérir la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer

1 – Art. 1021-3 [anc. art. 263] L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

sur l'approbation de la fusion[1]. Dans ce cas, l'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

À l'inverse, depuis que les fusions ne sont plus limitées aux seules sociétés anonymes, mais peuvent également se faire entre les sociétés caractérisées par le fait que les entités dans lesquelles les associés (ou membres) encourent une responsabilité illimitée (voire solidaire), il n'est pas toujours suffisant de disposer de la majorité requise pour la modification des statuts, mais il faut, le cas échéant, obtenir l'unanimité des associés (membres), et ceci, en application du principe que l'augmentation des engagements des associés suppose l'unanimité de ceux-ci. Tel est le cas notamment si une société en nom collectif absorbe une société anonyme (p. ex.) : les associés de la S.A. prennent la qualité d'associés d'une société de personnes avec donc la responsabilité illimitée et solidaire.

Les règles afférentes sont comprises à l'article 1021-3 L.S.C.

« *(3) L'accord de tous les associés est requis :*

1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt économique ;

2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est :

a) une société en nom collectif ;

b) une société en commandite simple ;

c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement ;

d) une société civile ;

e) un groupement d'intérêt économique.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, point 1° et point 2°, a), b) et c), l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.

(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis ».

Tout associé de la société absorbante a le droit un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion de prendre connaissance au siège social des documents suivants :

– projet commun de fusion ;
– comptes annuels ainsi que rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent ;
– le cas échéant, un état comptable récent ;
– les rapports des organes de gestion des sociétés qui fusionnent et qui justifient la fusion (art. 1021-7 L.S.C.) ;
– le cas échéant, les rapports des experts prévus à l'article 1021-6 L.S.C.[2].

Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié ; il en est de même du projet commun de fusion lorsque la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent[3].

1 – Art. 1021-4 [anc. art. 264] L.S.C., ID 7520.

2 – Art. 1021-7 L.S.C., ID 7520.

3 – Art. 1021-12 [anc. art. 271] L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le projet commun de fusion est un document qui, en soi, n'a pas de force juridique particulière si ce n'est que les organes de gestion qui l'ont mis au point sont obligés de le soumettre à leurs assemblées respectives[1].

Les conditions sont légèrement modifiées en cas d'absorption d'une société par une autre possédant **90 % ou plus des actions** de la première. Si tel est le cas, il convient encore de distinguer selon que la société absorbante détient ou non la **totalité** des actions et autres titres conférant droit de vote.

– Si elle détient la totalité de ces titres, certaines dispositions ne sont pas applicables : en particulier, les articles 1021-5 (rapport écrit des organes d'administration ou de direction sur le projet commun de fusion), 1021-6 (examen et rapport d'un réviseur externe) et 1021-7 L.S.C. (dépôt de certains documents).

D'autre part, l'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante n'est pas requise dans tous les cas.

– Si elle ne détient pas la totalité des actions (et autres titres conférant droit de vote), le rapport des conseils d'administration ainsi que le rapport du réviseur sont en principe nécessaires. Ces formalités peuvent toutefois être évitées, en particulier si les associés minoritaires de la société absorbée peuvent faire acquérir leurs actions par la société absorbante. À quelques différences mineures près, on retombe ainsi dans le cas de la détention de la totalité des titres par la société absorbante.

Les dispositions des articles 1021-5 et 1021-7, paragraphe 1 (d) restent toutefois applicables en cas de fusions transfrontalières. Ceci signifie donc que, dans ce cas, un examen du projet commun de fusion est à faire et à déposer conformément à la Loi de 2002.

La jurisprudence relative à des opérations de ce type est très rare. On peut citer l'affaire *Famaplast*[2] (affaire fiscale soumise au tribunal administratif).

Selon acte notarié du 15 juin 1989, la société anonyme FAMAPLAST S.A., entendait fusionner avec la société anonyme X. S.A., par absorption de cette dernière par la première. À la date de cet acte, la société absorbante détenait la totalité des actions de la société absorbée ; l'acte notarié prévoyait que « **les opérations de X. S.A. sont à considérer du point de vue comptable comme accomplies au nom et pour compte de FAMAPLAST S.A. à partir du 30 juin 1989** » ; que « *la fusion ne prend effet entre parties qu'un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil Spécial C, conformément à l'article 9 L.S.C. sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée* », et qu' « *à défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par l'assemblée, la fusion deviendra définitive un mois après la publication comme indiquée sub 5) et entraînera de plein droit les effets prévus par l'article 1021-17 L.S.C. sur les sociétés commerciales* ».

L'objet du litige soumis au tribunal était en fait de savoir quelle était la portée de la fixation au 30 juin 1989 comme date à laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées comme accomplies au nom de la société absorbante[3]. Le tribunal a considéré que : « *Cette date a certes pour effet de fixer le point de*

1 – G.-A. Dal et M. van den Abeele, « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *R.P.S.*, 1993, p. 223.

2 – Tadm. du 2 juin 1999, n° 10.788, ID 262.

3 – Fixation intervenue conformément à l'article 1021-1 [anc. art. 261 (2)] L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

référence temporel pour déterminer la situation comptable de la société absorbée en vue de l'établissement du rapport d'échange et d'arrêter les valeurs auxquelles les biens seront inscrits dans la comptabilité de la société absorbante, mais elle ne saurait par contre avoir pour effet d'avancer le moment du transfert de patrimoine entre les deux sociétés »[1].

Selon le tribunal, la date de transfert du patrimoine serait à fixer de la façon suivante :

« *Il se dégage encore du libellé de l'article 279 L.S.C. que la fusion ne peut prendre effet entre parties qu'au plus tôt un mois après la publication du projet de fusion, date à laquelle les associés sont censés avoir tacitement approuvé la fusion si la tenue d'une assemblée n'aura pas été requise dans ce délai. Une décision concordante au sens de l'article 272 L.S.C. ne peut ainsi être admise dans le chef de la société absorbante que soit un mois après la publication du projet de fusion si la tenue d'une assemblée générale n'aura pas été demandée, soit à la date d'une telle assemblée qui aura approuvé la fusion. Une fusion, qui est de nature à entraîner des conséquences importantes pour la société, ne saurait en effet prendre effet avant que les associés n'aient eu l'occasion d'assurer valablement la défense de leurs droits ès qualité. Il s'ensuit qu'en l'absence de demande de tenue d'une assemble générale formulée par un associé de la société demanderesse, la fusion a été réalisée en l'espèce le 10 septembre 1989, soit un mois après la publication du projet de fusion qui a eu lieu en date du 10 août 1989* »[1].

Par conséquent, le tribunal a donné droit au directeur des contributions de n'avoir accepté les conséquences fiscales de la fusion que pendant l'exercice 1989-1990, et non durant l'exercice précédent. Cette décision devait donner lieu à une autre décision de la même juridiction[2] où le litige portait sur la question de l'évaluation de la créance au 30 juin 1989 de la société mère sur la filiale qui devait être absorbée[3]. Compte tenu du fait que les comptes annuels à cette date étaient établis sur la base de l'hypothèse que la fusion serait réalisée à cette date-là (décision non confirmée par le tribunal), il fut enjoint à la société demanderesse d'établir des comptes séparés à la date de fin juin 1989.

4) Établissement d'un rapport justifiant le projet de fusion

Aux termes de l'article 1021-5 L.S.C. (article 10 de la directive), il est fait obligation aux organes de gestion de chacune des sociétés qui fusionnent d'établir un « *rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet*

1 – Tadm. du 2 juin 1999, n° 10.788, ID 262.

2 – Tadm. du 28 juin 2000, n° 10.788, ID 345.

3 – Les discussions y menées quant à l'évaluation de la créance sont difficilement intelligibles en raison du fait que toutes les données chiffrées ont été supprimées. S'agissant de données bilantaires d'une société tenue à la publication de ses états financiers, on peut se demander si ces précautions, motivées par le souci de respecter le secret fiscal, ne sont pas excessives. – L'argument avancé par le contribuable (p. 3) que le directeur ne saurait reconnaître la dépréciation de la participation tout en n'acceptant pas la dépréciation de la créance, est intenable : en effet, les actionnaires sont, en cas de liquidation de la société, subordonnés aux créanciers ; il est donc parfaitement possible que les avoirs de la société soient suffisants pour désintéresser les créanciers totalement ou partiellement tout en laissant les actionnaires sans le moindre produit de liquidation.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions ». En outre, le rapport doit indiquer les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe.

5) Établissement d'un rapport par des experts indépendants

Le projet commun de fusion fait l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés obligatoirement établi par **un ou plusieurs experts** indépendants à désigner par l'organe de gestion ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent. Au Luxembourg ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d'entreprises agréés. En revanche, dans le cas de fusion transfrontalière, ces experts n'ont pas nécessairement la qualité de réviseurs d'entreprises[1].

Toutefois, il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas, la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.

En cas de fusion transfrontalière, le rapport susdit doit être disponible un mois avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.

Le réviseur d'entreprises assume une mission de contrôleur de l'opération de fusion. Si le notaire a pour mission de vérifier la légalité des opérations de fusion (de scission), la mission du réviseur est d'assurer la viabilité de l'opération du point de vue économique. Cette expression de réviseur doit d'ailleurs être regardée dans son sens large, dans le sens que, le cas échéant, ce rôle de contrôleur peut être exercé par quelqu'un qui n'est pas réviseur d'entreprises : tel est le cas s'il s'agit d'une opération transfrontalière mettant en jeu une société non européenne. C'est alors la loi étrangère qui définit la qualification professionnelle de la personne intervenante.

En cas de constitution d'une société européenne (SE) par la voie de fusion ou en cas de fusion transfrontalière, les sociétés qui fusionnent peuvent demander conjointement la désignation d'un ou de plusieurs experts indépendants au magistrat présidant une chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel une des sociétés a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, ou à l'autorité judiciaire ou administrative d'un autre État dont relève l'une des sociétés qui fusionnent, ou recourir à un ou plusieurs experts indépendants agréés par une telle autorité (art. 1021-6 L.S.C.).

En premier lieu, la loi prend soin de noter que l'article 420-10 L.S.C. (concernant les apports en nature à des sociétés par actions) ne trouve pas à s'appliquer (art. 1021-6, (3) et art. 1022-1, (4), L.S.C.) en cas de constitution de société nouvelle. Le droit commun relatif aux apports en nature se trouve donc ainsi écarté. Le réviseur ne doit donc intervenir qu'en vertu des dispositions spécifiques prévues en matière de fusion ou de scission. Son rôle consiste à faire un examen et un rapport écrit établi par l'organe de direction ou d'administration de chacune des sociétés concernées (art. 1021-6 L.S.C.).

Une importante dérogation à cette obligation est prévue par l'article 1021-6 (5) L.S.C. selon lequel un tel examen et un tel rapport d'expert ne sont pas requis si

1 – Art. 1021-6 L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

tous les associés et autres porteurs de titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont ainsi décidé. Une telle unanimité de tous les associés n'est guère envisageable que si le nombre des associés est très limité.

Les réviseurs ont le droit d'accéder à tous les documents utiles et peuvent procéder à toutes les vérifications nécessaires (art. 1021-6 (4) L.S.C.).

Les réviseurs d'entreprises sont désignés par l'organe de gestion respectif de chacune des sociétés concernées. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d'entreprises indépendants. Toutefois, il pourra être procédé à la désignation d'un seul réviseur pour toutes les sociétés qui fusionnent si la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la société absorbante (donc celle qui survivra) a son siège social. Ces réviseurs sont tenus d'établir un rapport dans lequel ils doivent (au moins) déclarer si, à leur avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

L'article 1021-6 L.S.C. reprend l'article 10 de la directive d'une façon identique.

Le rapport dressé par les organes de gestion des sociétés doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique le rapport d'échange des actions.

Il importe de préciser que le projet de fusion n'a pas de nature contractuelle.

Les sociétés ne s'engagent pas quant au principe de fusionner, ni quant aux conditions concrètes de la fusion, étant donné que le rapport de fusion a été établi par des personnes qui n'ont pas le pouvoir d'engager la société quant aux conditions de la fusion ; c'est uniquement l'assemblée générale des associés qui vote sur la fusion ou la scission de sociétés[1].

Les organes de gestion sont obligés de soumettre le projet de fusion au vote des associés sans pouvoir le modifier par la suite ; tel ne pourrait être le cas que dans des circonstances exceptionnelles.

a) La détermination du rapport d'échange

Le calcul du rapport d'échange est directement lié aux méthodes d'évaluation des sociétés impliquées dans la fusion[2].

La L.S.C. prévoit que le rapport d'échange doit faire l'objet d'un examen par un ou plusieurs experts, mais elle n'impose pas la méthode de calcul du rapport d'échange.

Par conséquent, les organes de gestion respectifs sont libres de déterminer le rapport d'échange, qui a seulement besoin d'être approuvé par les associés.

La L.S.C. n'impose pas non plus des méthodes d'évaluation des sociétés impliquées dans la fusion. Les associés ont le droit de s'écarter des conclusions des experts.

Pour cette raison, aucune règle précise n'a été établie.

1 – Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, Kluwer, p. 175.

2 – Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, Kluwer, p. 165.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

On peut donc retenir que :

i) Plusieurs méthodes doivent être appliquées

La L.S.C. en tant que telle n'exige pas que plusieurs méthodes soient utilisées, mais la doctrine est majoritairement de cet avis. En cas d'application de plusieurs méthodes, la L.S.C. prévoit que l'expert donne un avis sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue[1].

Les méthodes les plus répandues sont les suivantes :

– valeur intrinsèque de la société. Elle est calculée à partir de l'actif net corrigé, c'est-à-dire la valeur comptable des entreprises, adaptée pour tenir compte d'éléments non comptabilisés (tels que plus-values latentes, impôts différés, engagements hors bilan) ;
– valeur actuelle de la capacité d'autofinancement, du bénéfice et des dividendes ; valeur nette ajustée, augmentée de la survaleur (*goodwill*) ;
– utilisation de ratios adaptés au secteur d'activité de la société en tant que multiplicateurs du chiffre d'affaires, du bénéfice, de la capacité d'autofinancement ;
– cours boursier, qui devrait déjà prendre en compte tous ces éléments. Il doit toutefois être adapté en cas de liquidité insuffisante du marché bousier concerné[2].

Ces méthodes prennent en compte l'évolution future des sociétés impliquées dans la fusion. Elles peuvent être combinées entre elles, l'une ou l'autre sera probablement éliminée[3].

ii) Les méthodes appliquées aux différentes sociétés concernées doivent être identiques et comparables.

Ceci veut dire que le même ensemble de méthodes (ou au moins des méthodes homogènes) doit être utilisé pour la même période au même moment, en faisant les mêmes corrections.

iii) Les méthodes ont besoin d'être appropriées

Les méthodes ont besoin d'être adaptées aux sociétés impliquées dans la fusion. Le cas échéant, des ajustements sont requis, en éliminant, par exemple, les bénéfices exceptionnels. En général le bénéfice moyen sur une période pluriannuelle est pris en compte.

b) Le rapport d'échange doit être pertinent et raisonnable

La directive précise que le rapport d'échange doit être « pertinent et raisonnable »[4]. Les législations française et belge ont également repris cette notion de la directive. Pertinent signifie qu'il est permis de prendre en compte pour le calcul du rapport d'échange d'autres éléments, plus appropriés que les éléments comptables

1 – P. Della Faille, *Fusions, acquisitions et évaluations d'entreprises*, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2001, p. 437.

2 – Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, Kluwer, p. 168.

3 – Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, Kluwer, p. 167.

4 – Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, Kluwer, p. 166.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

s'ils sont plus significatifs que les valeurs d'exploitation des sociétés. Il est important de souligner que l'expert n'a pas besoin lui-même de calculer le rapport d'échange, il a seulement besoin de donner son appréciation du rapport d'échange proposé par les organes de gestion des sociétés impliquées dans la fusion.

Même si l'expert a conclu que le rapport d'échange n'est pas pertinent et raisonnable, il n'a pas besoin de déterminer un rapport respectant ces critères[1].

Le rapport d'échange des actions est le rapport du nombre d'actions de la société absorbée qui doivent être échangées contre des actions de la société absorbante[2]. Ce rapport varie en fonction de l'importance économique et financière des sociétés impliquées dans la fusion.

Ce rapport ne dépend pas exclusivement de la valeur relative des sociétés en présence. Il dépend encore du rapport de force existant entre les sociétés désireuses de fusionner, étant donné qu'une fusion résulte de négociations entre les dirigeants des sociétés impliquées dans la fusion. L'objet de ces négociations est de déterminer si ce seront les associés de la société absorbante ou ceux de la société absorbée qui profiteront de la valeur additionnelle créée par la fusion.

Ce point peut être illustré à l'aide d'un exemple.

Exemple

La société ABC est évaluée à 6 000 000,00 d'euros alors que la société DEF est évaluée à 2 000 000,00 d'euros. La valeur totale de la société fusionnée (donc après la fusion) est estimée à 9 600 000 euros. La valeur ajoutée créée se chiffre donc à 1 600 000 euros.

Le prix maximal que les associés de ABC sont prêts à payer pour DEF est de 3 600 000 euros (il en résulte un rapport d'échange de 1,667). Le prix minimum est de 2 000 000 d'euros (rapport d'échange de 3).

Dans le premier cas, la valeur ajoutée sera attribuée en totalité aux associés de la société DEF, dans le deuxième, ce sont les seuls associés de la société ABC qui en profitent. Inutile d'ajouter qu'il existe une infinité de solutions intermédiaires, qui consistent à partager la plus-value entre les deux groupes d'associés[1].

C'est en fonction du rapport d'échange choisi que l'importance relative des deux groupes d'associés variera.

Certains auteurs prétendent que le rapport d'échange a besoin d'être unique (traitement égal pour tous les associés). Il serait donc exclu d'avoir des rapports d'échanges différents pour les associés possédant une participation dominante du capital d'une société[3]. D'autres spécialistes estiment qu'un traitement préférentiel de certains associés n'est pas exclu[4].

---

1 – P. Della Faille, *Fusions, acquisitions et évaluations d'entreprises*, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2001, p. 441, qui se réfère l'Institut des Réviseurs d'Entreprises belges. On peut supposer que la position de l'Institut luxembourgeois serait très proche de celle de son homologue belge.

2 – P. Della Faille, *Fusions, acquisitions et évaluations d'entreprises*, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2001, p. 435.

3 – P. Della Faille, *Fusions, acquisitions et évaluations d'entreprises*, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2001, p. 436.

4 – Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, Kluwer, p. 170.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

c) Contrôle du rapport d'échange par les juridictions

Le contrôle effectué par les juridictions est « marginal » (ne permettant donc que de sanctionner les rapports d'échange tombant en dehors de la marge d'appréciation laissée par les juridictions), étant donné que le législateur a accordé aux organes de gestion une certaine marge d'appréciation concernant les évaluations faites, et les méthodes d'évaluation utilisées[1]. Les juges ne peuvent substituer leurs appréciations à celles des organes de gestion.

6) Réalisation de la fusion

Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié ; il en est de même du projet de fusion lorsque la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent.

Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de fusion.

Aux termes de l'article 1021-13 L.S.C., la fusion est réalisée au moment où sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause. Il s'agit donc du moment où la dernière des décisions en question a été prise pour le cas où celles-ci ne sont pas prises au même moment (voir aussi ci-dessus l'affaire *Famaplast*).

Par contre, ces effets à l'égard des tiers ne se produisent qu'après la publication faite conformément à la Loi de 2002 pour chacune des sociétés qui fusionnent (art. 1021-14 L.S.C.).

7) Particularité du cas de la participation de la société absorbée dans la société absorbante

Dans le chef de la société absorbée, les parts ainsi détenues constituent un actif comme tout autre dont la valeur est au moins égale à la valeur comptable tout en dénotant souvent une plus-value latente. Il en va autrement dans le chef de la société absorbante dans la mesure où celle-ci va trouver dans le patrimoine de la société absorbée des actions qui sont à son égard des actions propres et qui devront être annulées. Les actions visées suivent le régime du rachat des propres actions[2].

Lorsque les actions ne sont que partiellement libérées, une solution consisterait à donner dans une première phase aux titulaires de ces actions une contrepartie correspondant aux actions entièrement libérées (p. ex., si les actions sont libérées à concurrence de 25 %, les associés en question se voient dans une première étape attribuer pour 25 % des titres entièrement libérés de la société).

De tels ajustements sont toutefois inutiles, car la société dont le capital n'est que partiellement libéré porte à son actif une « créance » (qui tant que le montant n'est

1 – Th. Tilquin, *Traité des fusions et scissions*, Kluwer, p. 173.

2 – G.-A. Dal et M. van den Abeele, « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *R.P.S.*, 1993, p. 234.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

pas appelé n'est que potentielle) sur les associés qui n'ont pas encore libéré leurs actions[1].

B – Droits des associés

Les associés ont un droit d'information du fait qu'ils peuvent prendre connaissance de certains documents un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion, en consultant au siège social, les documents suivants (art. 1021-7 L.S.C.) :

« *1° le projet commun de fusion ;*

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent ».

Ces comptes annuels existent de toute façon (ou du moins devraient exister) et un travail supplémentaire n'est pas demandé. Il n'en va pas de même du document suivant qui doit être spécialement établi pour l'opération de fusion.

« *3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date* ».

La préoccupation du législateur est que la fusion se fasse sur la base de documents comptables récents. L'état comptable n'est requis que si le projet commun de fusion est établi plus de six mois après la fin de l'exercice précédent (soit donc dans la deuxième moitié de l'année si l'année financière correspond à l'année de calendrier). En dehors de cette période, une situation comptable doit être établie qui, elle aussi, est soumise à des contraintes de date.

Exemple

La société A qui a clôturé ses comptes au 31 décembre 2017 entend absorber la société B. Un projet commun de fusion est établi au 10 août 2018. L'état comptable ne doit pas remonter à plus loin que le 1er mai 2018.

« *4° le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l'article 1021-5 ;*

5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 1021-6 ».

Sous ce dernier point est visé le rapport du réviseur d'entreprises (dont il sera question ci-après). Chaque associé peut obtenir sans frais copie intégrale ou partielle des documents visés au paragraphe 1er de l'article 1021-7 L.S.C.

Le paragraphe 2 du même article apporte les précisions suivantes sur le mode d'établissement de cet état comptable.

« *(2) L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.*

Il n'est pourtant pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.

1 – G.-A. Dal et M. van den Abeele, « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *R.P.S.*, 1993, p. 235.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte :

1° des amortissements et provisions intérimaires ;

2° des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures ».

Il résulte de ces précisions que, en dehors de l'inventaire physique qui n'est pas obligatoire, les règles sont identiques à celles applicables pour l'établissement des comptes annuels ordinaires. Étant donné qu'un tel état comptable spécifique n'est en rien requis pour les rapports de fusion établis dans la première partie de l'année, il est facile d'éviter les coûts liés à l'établissement d'une situation *ad hoc* en réalisant la fusion tout de suite après la date de la dernière clôture de bilan ordinaire.

C – Droits des créanciers

Cette question doit être envisagée dans les deux sens. En premier lieu, il s'agit du sort des créances détenues par la société absorbée : la publicité de la fusion porte à la connaissance de ces débiteurs tiers qu'une opération de fusion a lieu au terme de laquelle il y a un changement de créancier. Il n'est donc pas nécessaire de procéder aux formalités de l'article 1690 C.c.[1].

Selon l'exposé des motifs de la loi belge : « *il n'est donc plus nécessaire de signifier les cessions de créance, d'endosser les lettres de change ou les billets à ordre, de procéder à des inscriptions pour les marques ou les gages sur fonds de commerce ou à des transcriptions* »[2].

La loi (art. 1021-17, (2), L.S.C.), conformément à la directive, prévoit comme exception à cette règle le cas de transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des sûretés réelles sur meubles et immeubles : ces transferts ne sont opposables aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales y afférentes.

Il va de soi que la question du **transfert des dettes** est plus problématique du fait qu'un système de transfert universel, tel que celui prévu par les directives communautaires, est susceptible d'affecter gravement les droits des créanciers. L'article 13 de la directive demande donc aux États membres « *de prévoir un système de protection des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent pour les créances nées antérieurement à la publication du projet commun de fusion et non encore échues au moment de cette publication* ». Au Luxembourg (comme en Belgique), on a opté pour un système calqué sur celui applicable en matière de réduction de capital : l'article 1021-9 L.S.C. permet aux créanciers dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion prévue à l'article 1021-14 L.S.C. de demander au président du tribunal d'arrondissement du siège de la société, dans le délai de deux mois de la publication, la constitution de sûretés pour les créances échues et non échues « *au cas où l'opération de fusion réduirait le gage des créanciers* ».

Les créanciers des sociétés fusionnantes dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion peuvent demander au magistrat présidant la

1 – G.-A. Dal et M. van den Abeele, « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *R.P.S.*, 1993, p. 240.

2 – Exposé des motifs, p. 14.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social la constitution de sûretés pour leurs créances. Cette demande doit intervenir dans les deux mois de la publication des actes constatant la fusion et n'est recevable que dans le cas où l'opération de fusion « *réduirait le gage de ces créanciers* ».

Elle est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou encore si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société après la fusion. La demande peut encore être écartée si la société débitrice paye le créancier, et ceci, même si la créance est à terme.

Il est précisé (art. 1021-10 L.S.C.) que les obligataires ont droit à l'application de mêmes dispositions de protection que l'article 1021-9 L.S.C. rend applicable aux créanciers ordinaires, à moins que « *la fusion ait été approuvée par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement* ».

L'article 1021-11 L.S.C. prévoit que les « *porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des droits spéciaux […]* » doivent jouir, au sein de la société absorbante d'une situation au moins équivalente à celle dont ils ont pu jouir dans la société absorbée.

Une telle disposition spéciale est nécessaire puisque ces détenteurs de titres n'étant pas associés, ils n'ont pas de droit de vote à l'assemblée générale des associés et ne peuvent donc pas s'opposer à la fusion si celle-ci risque de leur être défavorable. Toutefois, comme pour les obligataires, une assemblée générale peut passer outre cette disposition si cette assemblée réunit les porteurs des titres visés (art. 1021-11 (2) L.S.C.).

Cette disposition est opportune : il se peut en effet que, malgré la réduction de leurs droits, l'opération soit en définitive favorable aux porteurs de ces titres. En abandonnant la décision à l'assemblée générale statuant à des conditions de majorité, on évite également que l'un ou l'autre détenteur de quelques titres puisse bloquer les opérations pour des raisons non pertinentes.

D – Aménagement à ces dispositions en raison de l'extension des fusions aux sociétés autres que des S.A.

Les dispositions applicables aux S.A. doivent par la force des choses subir des aménagements plus ou moins importants dans le cas où les sociétés concernées ne sont plus exclusivement des S.A. (qui en fait sont des groupements de capitaux plutôt que des associations de personnes), mais des sociétés d'autres types qui se distinguent de la S.A. notamment sur les points suivants :

– certains des associés, voire tous les associés, subissent la responsabilité illimitée (et/ou solidaire) ;
– les associés se sont groupés *intuitu personae* avec pour conséquence que, du fait de la fusion, ils retrouveront généralement d'autres associés que ceux avec lesquels ils avaient initialement décidé de s'associer.

Ces deux points sont liés dans la mesure où la responsabilité illimitée (et surtout solidaire) implique toujours que la société soit conclue *intuitu personae*. Mais l'inverse n'est pas vrai dans le sens qu'il se peut qu'une société soit à caractère *intuitu personae*, mais sans qu'il y ait responsabilité solidaire.

Par conséquent, des changements sont nécessaires au sujet du droit de vote qui est prévu à l'article 1021-3 L.S.C. Si le principe du vote majoritaire aux conditions

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

requises pour les modifications des statuts est maintenu (paragraphe 1), des exceptions importantes sont prévues aux paragraphes suivants :

« *(2) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social ;*

(3) L'accord de tous les associés est requis :

1° dans les ***sociétés absorbantes ou à absorber*** *qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt économique ;*

2° dans les ***sociétés à absorber*** *lorsque la société absorbante est :*

a) une société en nom collectif ;

b) une société en commandite simple ;

c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement ;

d) une société civile ;

e) un groupement d'intérêt économique.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, point 1° et point 2°, a), b) et c), l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.

(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

(5) S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 68 est applicable ».

Tant que les seules sociétés anonymes pouvaient entrer dans de telles opérations de fusion ou de scission, la question concernant les conditions de quorum et de majorité qui étaient à respecter était simple à résoudre : il fallait réunir les conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts des sociétés anonymes. Avec l'extension du nombre des formes de sociétés pouvant entrer dans de telles opérations, la situation a considérablement changé (dans le sens de la complexification, bien entendu) : en effet, il convient de tenir compte du fait que, parmi les sociétés admissibles à participer à de telles opérations, figurent également des sociétés ayant **responsabilité illimitée** qui, généralement, s'accompagne encore de la responsabilité solidaire. Tel est le cas des sociétés en nom collectif, des S.e.c.s., des sociétés civiles, des sociétés en commandite simple et des GIE/GEIE. Dans de tels cas de figure, l'unanimité est requise[1].

La question des conditions de majorité requises peut se résumer comme suit :

1) il faut tenir compte du fait que, en raison des règles de responsabilité spécifiques à ces différents types d'entités (autres que celles que nous désignons par le terme de « sociétés de capitaux »), celles-ci sont caractérisées par un caractère d'*intuitus personae* très prononcé avec la conséquence que **l'accord unanime** est requis lorsque ce type d'entités est concerné.

1 – Pour plus de détails J.-P. Spang, « Les restructurations d'entreprises », *Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 88.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2) en outre convient-il de tenir compte non seulement de la situation actuelle des associés (ou membres), mais encore de leur situation future, donc de quel type d'entité ces associés seront associés après que l'opération de restructuration soit réalisée. Ainsi, si les actionnaires d'une S.A. votent sur une scission (totale) où l'une des sociétés bénéficiaires est une S.e.n.c., alors les actionnaires actuels deviendront à l'avenir associés d'une société conférant la qualité **d'associé à responsabilité illimitée et solidaire** avec donc la conséquence que **l'accord unanime** des actionnaires est requis.
3) finalement, dans le cas de la S.e.c.s., l'accord unanime des associés commandités est encore requis.

Les autres modifications apportées à la L.S.C. sont de pure forme, en remplaçant notamment les termes « *conseils d'administration* » par « *organes de gestion* », en ajoutant les mots « *ou parts* » après le mot « *actions* », en remplaçant le mot « actionnaire *s* » par le mot « *associé* », etc.

L'article 1021-9 L.S.C. traite de la responsabilité envers les tiers des associés de la société. Contrairement à ce qui se passe pour les sociétés anonymes (où seuls sont en cause des associés à responsabilité limitée), pour les autres sociétés, il y a souvent des associés qui encourent une responsabilité plus importante. La loi, comme suite à la directive, tient compte de ce fait en prévoyant que, dans les cas où la société absorbée est une S.e.n.c., une S.e.c.s., une société coopérative (à associés indéfinis et solidaires), une société civile et un GIE/GEIE, les associés (sauf les commanditaires) restent tenus des engagements de la société à l'égard des tiers en ce qui concerne les engagements de la société dissoute.

La situation est en somme identique dans le cas où la société absorbante est, au moins pour partie, à associés indéfiniment responsables : les associés concernés sont tenus des engagements de la société dissoute antérieurs à la fusion. Contrairement à ce qui se passe dans le cas précédent, il y a ici possibilité de s'exonérer de cette responsabilité au moyen d'une clause expresse dans le projet commun de fusion.

La divergence de traitement entre ces deux cas est justifiée : dans le deuxième cas de figure, il n'y a guère de raisons que les associés de la société absorbante soient responsables des dettes de la société absorbée antérieures à la fusion. En effet, au moment de traiter avec la société, les créanciers de cette société n'ont pas pu compter sur la solvabilité des associés d'une société absorbante qui, à ce moment, n'avait pas le moindre lien avec la société contractante.

Art. 1021-9 [anc. art. 268] (2) et (3) L.S.C.

« *(2) Si la société absorbée est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de fusion conformément à l'article 1021-14.*

(3) Si la société absorbante est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la fusion. Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l'acte de fusion, opposable aux tiers conformément à l'article 1021-14 ».

Des règles indiquées ci-dessus, on peut déduire les conclusions suivantes :

Cas n° 1 – une S.e.n.c. absorbe une S.à r.l. : l'accord unanime des associés est requis pour la S.e.n.c., il en est de même pour la S. à r.l. Si la solution est donc identique dans les deux cas, la raison n'en est pas la même. Pour la S.e.n.c., l'unanimité est toujours requise. Pour la S. à r.l., elle est requise dans le cas présent pour la raison que la société absorbante est une société où tous les associés subissent la responsabilité limitée. Par conséquent, en approuvant la fusion, tout associé de la S. à r.l. accepte une augmentation de ses engagements : ceci ne peut se faire contre la volonté ne fût-ce que d'un seul associé.

Cas n° 2 – une S.à r.l. absorbe une S.e.n.c. : il s'agit du cas inverse du précédent. La décision est prise à la majorité dans le chef de la S.à r.l., et à l'unanimité dans la S.e.n.c. Dans le présent cas, le statut des associés de la S.à r.l. n'est pas modifié : l'unanimité n'est donc en rien requise.

E – Effets de la fusion

Aux termes de l'article 1021-17 L.S.C., « *la fusion entraîne de « plein droit » et simultanément les effets suivants :*

1° transmission universelle […] de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante ;

2° les associés de la (ou des) société(s) absorbée(s) deviennent associés de la société absorbante ;

3° la société absorbée cesse d'exister ;

4° l'annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante ou la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de l'une de ces sociétés »[1].

1) La transmission universelle du patrimoine de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante

Il est précisé par la loi que cet effet s'exerce tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers. La loi prévoit certaines entorses à ces principes, notamment à l'égard des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles qui ne sont opposables aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. La société absorbante peut procéder elle-même à ces formalités.

1 – Art. 1021-17 L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2) L'échange de droits d'associé

La fusion a pour effet que les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante. La détermination du rapport d'échange entre les associés des deux sociétés est souvent une difficulté majeure de l'opération. Pour éviter que, soit les associés de l'une, soit ceux de l'autre société ne soient lésés dans l'opération, il convient d'évaluer au plus juste les valeurs respectives des deux sociétés en présence. Cette tâche fait appel aux services des experts visés par l'article 1021-6 L.S.C. et qui, au Luxembourg, sont choisis obligatoirement parmi les réviseurs d'entreprises. Une mention particulière doit être faite des deux cas suivants pour lesquels la situation est simplifiée de façon considérable : si la société absorbante détient la totalité des titres de la société absorbée, aucun échange ne se produit entre titres de deux sociétés. En deuxième lieu, lorsque la composition de l'actionnariat est exactement identique pour toutes les sociétés fusionnantes, aucun problème de rapport d'échange ne peut se poser. En effet, les effets positifs et négatifs de toute mauvaise évaluation se compensent exactement les uns avec les autres dans le chef du même associé.

Ces dispositions de simplification sont prévues par les articles 1023-1 L.S.C. (100 % des actions) et 1023-4 L.S.C. (90 % au moins sans avoir détention de 100 % des actions) qui reprennent l'article 15 de la directive 2005/56/CE. La particularité des fusions transfrontalières est que celles-ci requièrent dans tous les cas de figure une assemblée générale de la société absorbante, alors qu'une telle assemblée peut être évitée dans le cas de fusion nationale (cas d'unanimité)[1].

Il est à noter que ces dispositions ne permettent pas d'éviter l'examen et le rapport par l'expert externe dans tous les cas où ceci peut paraître justifié : en effet, dans le cas de **fusion à l'envers (« *downstream merger* »)** comportant donc l'absorption de la société mère par la société filiale, les dispositions de simplification prévues par les articles 1023-1 et 1023-4 L.S.C. ne sont pas applicables ; celles-ci, supposant une détention de plus de 90 % des titres de la société filiale par la société mère, ne sont applicables que dans le cas de l'absorption de la filiale par la société mère, et non pas dans le cas inverse. C'est à cet égard que la disposition nouvellement introduite de l'article 1021-6 (5) L.S.C. prend toute son utilité : cet article applicable tant aux fusions nationales qu'aux fusions transfrontalières permet d'éviter l'examen du projet commun de fusion et le rapport d'expert lorsque les associés et les porteurs des autres titres conférant droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont ainsi décidé. Cette disposition prend toute son importance dans les cas de réorganisation intra-groupe où l'unanimité est d'autant moins un problème que, très souvent, il s'agit de sociétés n'ayant qu'un seul actionnaire.

Est-il possible d'absorber une société ayant un actif net négatif ? La question se pose du fait qu'une absorption se traduit normalement par une augmentation de capital de la société absorbante. Il va de soi qu'une telle augmentation de capital ne peut se produire si la valeur nette de la société absorbée est négative[2]. En réalité, toutes les fusions ne se traduisent pas par une augmentation de capital : tel est le cas si la société absorbante détient une participation dans la société absorbée et si, à l'extrême, cette participation est

1 – J.-P. Spang, « La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois : regard du praticien », *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois et comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 92.

2 – J.-P. Spang, « La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois : regard du praticien », *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois et comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 94.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de 100 %. S'il en est ainsi, la fusion absorption ne conduit en rien à une augmentation de capital dans le chef de la société absorbante, mais n'est pas autre chose qu'une restructuration d'actifs : la société mère, en annulant sa participation dans la filiale, ne fait que troquer une détention indirecte des actifs (et passifs) de la société filiale contre une détention directe de ces mêmes actifs (et passifs). Dans de tels cas, la fusion absorption d'une société à actif négatif est considérée parfaitement possible[1].

3) La disparition de la société absorbée

Cette société cesse d'exister, disparition qui comporte un certain nombre de conséquences tant en droit privé qu'en droit fiscal. Il se pose en particulier la question de savoir si l'opération doit avoir des conséquences fiscales (sous forme de découverte et d'imposition de plus-values latentes) ou si la fusion est fiscalement neutre. La tendance est de nos jours très clairement d'assurer la neutralité fiscale de ces opérations de restructuration. Il est accepté de façon relativement générale que l'opération reste fiscalement sans effets, sous la condition toutefois que les réserves cachées qui sont attachées aux biens de la société restent exposées à une imposition ultérieure. Telle est en particulier l'approche de la directive européenne du 23 juillet 1990 (90/434/CEE).

Juridiquement, la situation est assez simple dans la mesure où le transfert universel du patrimoine comporte que tous les avoirs et toutes les dettes de la société absorbée soient repris par la société absorbante. Par universalité de droit, on entend « *un ensemble de biens constituant un patrimoine autonome avec actif et passif propres. Le patrimoine est une universalité de droit alors que l'universalité de fait est une collection ou agrégation de biens qui ont été réunis par le propriétaire* »[2].

L'universalité est encore définie comme l'intégralité du patrimoine activement et passivement qui vise l'ensemble du patrimoine, actif et passif, aucun élément d'actif ou de passif ne peut être exclu[3].

La loi du 23 mars 2007 modifiant la L.S.C. a élargi les dispositions légales pour inclure les transferts de branche d'activité et d'universalité ainsi que du patrimoine professionnel[3].

4) L'annulation des actions ou parts de la société absorbée

La disparition de la société absorbée a pour conséquence directe l'annulation de tous les titres de capital émis par la société absorbée : peu importe que ceux-ci soient détenus par la société absorbante, la société absorbée ou encore par une autre personne « *agissant en son nom propre mais pour le compte de l'une de ces sociétés* ». Ceci ne vaut bien entendu que pour les titres de capital : pour les titres

1 – J.-P Spang, « La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois : regard du praticien », *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois et comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 95, qui se réfère en particulier à J.-J. Daigre, « Peut-on absorber une société ayant un actif net négatif ? », *J.C.P.* E, 1993, II, n° 165, pp. 363, spéc. n° 1.

2 – Th, Tilquin, « Le transfert d'une universalité ou d'une branche d'activité », *J.T.*, 1996, p. 497.

3 – Loi du 23 mars 2007, ID 9444.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de dettes, rien ne s'oppose en principe à ce que ces dettes soient reprises par la société absorbante qui en est le débiteur vis-à-vis des détenteurs de ces titres.

5) Responsabilité des administrateurs et des experts

Aux termes de l'article 1021-18 L.S.C. (pris sur la base des dispositions des directives applicables en cette matière), les associés de la **société absorbée** peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d'administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation, ou les experts lors de l'accomplissement de leur mission (prévue par l'article 1021-6 L.S.C.), une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise par ces organes administration et de direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de l'accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d'administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s'en décharger s'il démontre qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.

Cette disposition s'applique uniquement aux organes et experts de la société absorbée. La responsabilité des organes de la société absorbante peut être mise en cause par application des dispositions de l'article 441-9 L.S.C.[1].

F – Nullité de la fusion

En application des dispositions de l'article 1021-18 L.S.C., la nullité de la fusion ne peut intervenir que dans des conditions très restrictives (en ligne avec celles prévues par l'article 100-18 L.S.C. (anc. art. 12*ter* L.S.C.) traitant de la nullité des sociétés de capitaux en application des dispositions de la Première directive) et exhaustives :

1) Cas d'ouverture très limités

Lorsque la fusion est réalisée conformément à l'article 1021-13 L.S.C., la nullité ne peut être prononcée que pour défaut d'acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou de l'autre des sociétés participant à la fusion est nulle.

2) Délais

L'action en nullité n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui l'invoque, ou bien si la situation a été régularisée.

3) La nullité doit être prononcée par décision judiciaire

La loi privilégie la solution de la régularisation dans la mesure où, si cette dernière est possible, le tribunal doit accorder aux sociétés intéressées un délai pour

1 – G.-A. Dal et M. van den Abeele, « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *R.P.S.*, 1993, p. 250.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

régulariser la situation. Une fois la décision d'annulation prononcée, la loi veille à ce que cette décision ne puisse pas faire l'objet à son tour d'une remise en question sur un laps de temps prolongé ; en effet, la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon la Loi de 2002.

Les effets de la fusion sont également limités dans la mesure où, au vœu de la loi, la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision d'annulation et postérieurement à la date visée à l'article 1021-13 L.S.C.

4) Possibilité de régularisation

Lorsque la régularisation de la situation est possible, le tribunal compétent accorde un délai pour y procéder.

5) Solidarité entre sociétés participant à la fusion

Toutes les sociétés ayant participé à la fusion sont solidairement responsables des obligations de la société absorbante.

6) Publicité

La décision prononçant la nullité de la fusion est publiée selon l'article 9 [ancien] L.S.C. La tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision. La décision prononçant la nullité de la fusion ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à charge ou au profit de la société absorbante antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date de l'article 1021-13 L.S.C.

■ § 2 – Fusion par constitution d'une nouvelle société

Les règles décrites pour les fusions par absorption s'appliquent également aux fusions du type susvisé[1]. Dans ce contexte, les expressions « *sociétés qui fusionnent* » et « *société absorbée* » désignent les sociétés qui disparaissent, et l'expression société absorbante la nouvelle société. Le projet commun de fusion qui contient le projet de l'acte constitutif de la nouvelle société doit être approuvé par l'assemblée générale des associés de chacune des sociétés qui disparaissent. La nouvelle société existe à partir de la dernière approbation.

SECTION II
LES FUSIONS TRANFRONTALIÈRES

En droit national luxembourgeois (comme dans celui d'autres États membres), des opérations de fusion ont été réalisées avant qu'un cadre juridique spécifique

1 – Art. 1022-1 L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de ces opérations n'ait été prévu par la loi nationale : l'opération se réalisait par la dissolution de la société absorbée suivie de l'apport de l'ensemble de l'actif et du passif à la société absorbante ou nouvellement créée[1]. En matière internationale, la situation était similaire : ici encore, la pratique précédait le législateur en réalisant de telles opérations de restructuration en faisant application des seuls principes applicables en matière de droit des sociétés. En effet, en doctrine, ces opérations faisaient l'objet de développements dès la fin du XIXe siècle[2]. Toutefois, cette pratique avait maints désavantages (en particulier l'exigence de l'unanimité) et, en fin de compte, les fusions réalisées de telle façon restaient affectées d'une certaine insécurité juridique (voir notamment le régime des nullités).

Cette pratique devrait finalement trouver un aval de poids sous la forme de l'approbation d'une telle fusion par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dans **l'arrêt *Sevic System***[3]. Dans cette affaire, il s'agissait d'une société de droit allemand qui absorbait une société de droit luxembourgeois. La réalisation de cette fusion-absorption se heurtait alors au refus de la juridiction allemande compétente de procéder à l'inscription au registre national du commerce de la fusion au motif que le droit allemand ne permettait des fusions qu'entre sociétés ayant leur siège social en Allemagne[4].

Saisie par renvoi préjudiciel de la part de la juridiction allemande, la CJCE retint que le principe de la liberté d'établissement (articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) s'opposait à ce qu'un État membre refuse de manière générale de reconnaître une fusion transfrontalière entre deux sociétés dont une relevait du droit d'un autre État membre, alors qu'une telle fusion est possible lorsque les sociétés participant à la fusion ont toutes leur siège social sur le territoire de cet État membre[4].

Au Luxembourg, la transposition de la directive fusion transfrontalière a été réalisée en deux étapes. Une première loi du 23 mars 2007[5] s'est bornée à prévoir les mesures nécessaires pour pouvoir réaliser une opération importante impliquant uniquement des sociétés anonymes. Il s'agissait de l'opération de prise de contrôle d'Arcelor S.A., société de droit luxembourgeois, par la société Mittal Steel N.V., conformément à une OPA lancée en janvier 2006 et clôturée en juin 2006. Cette opération résultait dans l'absorption par la nouvelle société **Arcelor Mittal S.A.** de sa société mère néerlandaise Mittal Steel N.V. dans le cadre d'une fusion immigration au Luxembourg avant la fusion de cette société avec Arcelor Mittal S.A. en novembre 2007[6]. Cette loi, basée sur le projet de loi n° 5658, reconnaissait déjà un rôle primordial au notaire qui est appelé à contrôler la légalité des formalités de chacune des sociétés absorbées. Ceci fut confirmé par la suite par la loi du 10 juin 2009 sur les fusions transfrontalières qui reprit le système tel que prévu par la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur « *les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux* ».

---

1 – P.-H. Conac, *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois*, Larcier, 2011, p. 64.

2 – C. Houpin et H. Bosvieux, *Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales et des associations*, T. II, 6e éd., Paris, 1929, n° 960.

3 – CJCE du 13 décembre 2005, *Sevic System AG*, Aff. C-411/03, ID 15884.

4 – P.-H. Conac, *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 63.

5 – Loi du 23 mars 2007 portant modification des articles 271, 273*bis*, et 276 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ID 9444.

6 – P.-H. Conac, *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 65.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il y a lieu d'insister sur le fait que la directive de 2005, conformément à son article 2, b), ne vise que les seules sociétés de capitaux, donc les sociétés dotées de la personnalité juridique ayant un capital social et un patrimoine séparé qui est soumise par sa législation nationale aux conditions de garantie des intérêts des associés et des tiers prévus par la directive 68/151/CEE.

La LSC admet toutes les formes de fusion possibles. « *Il peut s'agir de la fusion par absorption (art. 259 L.S.C.) ou de la fusion par constitution de société nouvelle (art. 260 L.S.C.), de la fusion par immigration au Luxembourg ou par émigration du Luxembourg, de la fusion par absorption de la société mère de droit luxembourgeois (*"upstream merger*" ou* "reverse merger*") ou de la fusion par absorption de la filiale de droit luxembourgeois (*"downstream merger*"). Le législateur luxembourgeois n'exclut pas non plus une fusion réalisée entre plus de deux sociétés* »[1].

Selon la directive, sont visées par les dispositions applicables aux fusions transfrontalières, *« les fusions de sociétés de capitaux constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, si deux d'entre elles au moins relèvent de la législation d'États membres différents* ».

En application de l'article 1020-1 LSC, chacune des sociétés participant à l'opération fait application des dispositions et formalités du droit national dont elle relève. Il y a donc application distributive de la *lex societatis* aux sociétés en présence (conformément à la solution de la directive de 2005). Néanmoins, il peut y avoir des cas où l'application cumulative de ces règles nationales est inévitable[2]. Tel est notamment le cas en ce qui concerne le contenu du traité de fusion dans le cas d'une fusion mettant en jeu des sociétés non européennes.

La fusion transfrontalière reste possible si la soulte prévue dépasse les 10 % lorsque la législation d'au moins un des États impliqués a retenu que les dispositions de la fusion restent applicables aux cas de fusions nationales[3]. Étant donné que tel est justement le cas du Luxembourg, les fusions transfrontalières sont possibles, même dans le cas où l'autre État n'aurait pas prévu cette extension des dispositions de la directive.

Telle est encore la solution de la directive de 2005 qui prévoit que chaque société participant à une fusion transfrontalière se conforme aux dispositions et formalités de la législation de l'État membre dont elle relève et qui seraient applicables à une fusion nationale[4].

La directive 2005/56/CE (et donc la loi luxembourgeoise) retient les principes suivants :

1) chaque société participant à une fusion transfrontalière, ainsi que chaque tiers concerné, reste soumise aux dispositions et aux formalités de la législation nationale qui seraient applicables lors d'une fusion nationale ;

1 – V. P.-H. Conac, *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 68.

2 – V. P.-H. Conac, *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 71.

3 – Art. 3, 1 de la directive 2005/56/CE.

4 – M. Menjucq, « La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux », *Fusions transfrontalières de sociétés. Droit luxembourgeois et droit comparé*, P.-H. Conac (dir.), Bruxelles, Larcier, 2011, p. (3) du préambule de la directive 2005/56/CE.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2) un projet commun de fusion transfrontalière doit être élaboré par écrit par les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent dans les mêmes termes pour chacune des sociétés concernées dans les différents États membres ;
3) pour chacune des sociétés qui fusionnent, tant le projet de fusion transfrontalière que la réalisation de la fusion transfrontalière font l'objet d'une publicité appropriée ;
4) un rapport sur le projet de fusion transfrontalière doit être établi par un ou plusieurs experts pour chacune des sociétés qui fusionnent (possibilité d'un rapport unique) et doit être approuvé par l'assemblée générale de chacune de ces sociétés concernées ;
5) un contrôle de l'achèvement et de la légalité du processus décisionnel est prévu au sein de chaque société qui fusionne. Il est effectué par l'autorité nationale compétente pour chacune de ces sociétés, alors que le contrôle de l'achèvement et de la légalité de la fusion transfrontalière est effectué par l'autorité nationale compétente pour la société issue de la fusion transfrontalière. Au Luxembourg, cette autorité compétente est le notaire. Selon la directive, il peut s'agir également d'un tribunal ou de toute autorité compétente pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière et, le cas échéant, la constitution d'une nouvelle société issue de la fusion transfrontalière lorsque la société issue de la fusion transfrontalière relève de sa législation nationale (art. 11). Le contrôle consiste à vérifier « *en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à l'article 16* ». L'accomplissement de ce contrôle est documenté par l'émission d'un certificat attestant de façon incontestable de l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion (art. 9, 2, directive). Chaque société qui fusionne remet à l'autorité visée ce certificat dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi que le projet commun de fusion approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 9.
6) Pour protéger les intérêts des associés et des tiers, il convient d'indiquer les effets juridiques de la fusion transfrontalière en établissant une distinction selon que la société issue de la fusion est une société absorbante ou une nouvelle société. Dans un souci de sécurité juridique, il convient d'interdire de prononcer la nullité d'une fusion transfrontalière après la date à laquelle la fusion transfrontalière a pris effet.

Le notaire, auquel incombe le contrôle de légalité de l'opération de fusion transfrontalière (selon la loi luxembourgeoise), « *doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet commun de fusion (…)* » (art. 1021-12 (2) ; « *Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié ; il en est de même du projet commun de fusion lorsque la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent* » (art. 1021-12, (1) L.S.C.). Le notaire délivre sans délai « *un certificat attestant de l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion pour la partie de la procédure relative à la société de droit luxembourgeois* ».

Lorsque la fusion transfrontalière se réalise par l'absorption par une société de droit luxembourgeois d'une société de droit étranger, le notaire, en vue d'effectuer

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, le certificat visé à l'alinéa précédent, établi par un notaire ou toute autorité compétente selon la législation nationale de chaque société qui fusionne ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par chaque société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes[1]. Ces dispositions sont reprises telles quelles des articles 10 et 11 de la directive de 2005.

Il est par ailleurs dérogé aux articles 1021-13 et 1021-14 L.S.C. dans la mesure où la fusion par absorption d'une société de droit étranger est réalisée et « *prend effet à l'égard des tiers à partir de la date de la publication conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi précitée du 19 décembre 2002 du procès-verbal de l'assemblée générale de la société absorbante qui décide la fusion* », étant entendu que cette date doit être postérieure à l'accomplissement des contrôles visés à l'article 1021-12 [anc. art. 271] L.S.C. À l'égard des fusions purement nationales, la fusion est réalisée à partir du moment où les décisions concordantes au sein des sociétés en cause sont prises. Un deuxième certificat est prévu par l'article 1021-14 L.S.C., mais qui n'est pas applicable en matière de fusions transfrontalières, l'article 1021-16 L.S.C. dérogeant expressément à l'article 1021-14 L.S.C. L'absence de ce deuxième certificat est pourtant critiquée par certains[2].

L'article 1021-19, (1), 2°, L.S.C. précise un point destiné à contribuer à la sécurité juridique de l'opération : « *Lorsque la fusion est réalisée conformément à l'article 1021-13, elle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou de l'autre des sociétés participant à la fusion est nulle* ».

Le cadre légal de cette matière est tracé par la directive 78/855 du 9 octobre 1978 (la Troisième directive sur le droit des sociétés). Cette directive, qui se base sur l'article 54, 3, g, du Traité de Rome (devenu article 44, 2, sous g) après renumérotation), concerne les fusions de sociétés anonymes.

Il existe un certain nombre de différences entre les fusions nationales et les fusions transfrontalières. En premier lieu, le contenu du projet commun de fusion n'est pas le même dans les deux cas. L'article 1021-1 (4) L.S.C. énumère certains points additionnels que le projet transfrontalier doit contenir.

Une autre différence est qu'il y a nécessairement et dans tous les cas une assemblée de la société absorbante, alors qu'une dérogation à cette règle de principe est possible en cas de fusion nationale (l'application de l'article 1021-3 L.S.C. est écartée par l'article 1023-2 (2) L.S.C.)[3].

1 – Art. 1021-12 [anc. art. 271], nouvel alinéa 2, L.S.C., ID 7520.

2 – J.-P Spang, « La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois : regard du praticien », *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois et comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 91.

3 – J.-P Spang, « La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois : regard du praticien », *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois et comparé*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 93.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION III
LES SCISSIONS

Le champ d'application de cette section est identique à celle applicable aux fusions : sont visées toutes les sociétés dotées de la personnalité morale selon la L.S.C. et les groupements d'intérêt économique (art. 1030-1 L.S.C.). La faillite, le concordat ou autre procédure analogue n'est pas un obstacle à l'application de ces dispositions.

Comme pour les fusions, il y a des scissions purement nationales et des scissions transfrontalières. Si les dispositions sur les fusions ont été considérablement modifiées par la transposition en droit national par la loi du 10 juin 2009 des dispositions de la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières, la situation était différente à l'égard des scissions : en effet, il n'y a pas de directive européenne sur les scissions transfrontalières qui serait le pendant de celle applicable aux opérations de fusions. La question est donc de savoir si de telles opérations transfrontalières sont juridiquement possibles ou non. La réponse est affirmative, et ceci, sur la base de l'article 1030-1, alinéa 3, L.S.C. : « *Une société ou groupement d'intérêt économique […] peut également contracter une opération de scission avec une société ou groupement d'intérêt économique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas* ». Cette disposition est donc la base juridique pour des scissions transfrontalières impliquant tant des sociétés de l'Union européenne que des sociétés non européennes. La situation est en fin de compte la même que celle applicable aux opérations de fusions transfrontalières avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 2009.

En outre, une scission peut encore être contractée avec une société ou un groupement d'intérêt économique étranger, à condition que le droit national applicable à cette entité étrangère ne s'y oppose pas[1]. Cette restriction va de soi, car une scission transfrontalière ne peut produire effet que si elle est reconnue par les deux États en présence. Sur un plan européen, la transposition de la directive de 2005 vaut autorisation à l'égard des sociétés y visées, soit donc les sociétés de capitaux. La condition de l'absence d'opposition joue donc surtout en matière de fusions autres qu'européennes.

Il est à noter qu'à l'égard des opérations transfrontalières, la situation des **scissions** n'est pas exactement symétrique de celle des fusions transfrontalières. En effet, si les fusions transfrontalières impliquent des sociétés de l'Union européenne régies par la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières, tel n'est pas le cas des scissions transfrontalières qui, elles, sont laissées en dehors du champ d'application de cette directive. Les scissions transfrontalières restent néanmoins possibles (que ce soit d'ailleurs avec des sociétés de l'Union européenne ou avec des sociétés hors de cette Union européenne), sous la seule condition que le droit étranger ne s'y oppose pas.

Comme pour les fusions, on distingue différentes formes de scissions.

1 – Art. 1030-1 [anc. art. 285] L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – Différentes formes de scissions

La scission s'opère par :
– absorption ;
– constitution de sociétés nouvelles ;
– combinaison des deux procédés[1].
– Scission par absorption : elle comporte le transfert par suite de la dissolution, sans liquidation, de l'ensemble du patrimoine à plusieurs autres sociétés ; aux associés de la société scindée sont attribuées des actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission (ainsi qu'éventuellement une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions émises).
– Scission par constitution de nouvelles sociétés : elle comporte le transfert de l'ensemble du patrimoine (par suite de dissolution sans liquidation) à plusieurs sociétés nouvellement constituées ; aux associés de la société scindée sont attribuées des actions des sociétés bénéficiaires et éventuellement une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées.

Ne sont pas visées par les dispositions sur les scissions de sociétés les sociétés qui sont « *absorbées ou qui disparaissent font l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d'une ou de plusieurs de ces sociétés [...]* » (art. 1020-1 L.S.C.).

La procédure porte de très fortes ressemblances avec celle applicable aux fusions.

En effet, l'article 1031-1 L.S.C. prévoit que les organes de gestion des sociétés qui participent à la scission établissent par écrit un projet de scission.

Ce projet mentionne :

« *1° la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission ;*

2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

3° les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ;

4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;

5° la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou de l'autre des sociétés bénéficiaires ;

6° les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard ;

7° tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 1031-6, aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la scission ;

8° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires ;

1 – Art. 1030-2 [anc. art. 286] L.S.C, ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

9° la répartition aux associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée ».

Aux termes de l'article 1031-8 L.S.C. tel que modifié par la loi du 10 juin 2009 sur les fusions transfrontalières, ni un examen du projet de scission ni le rapport d'expert ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres comportant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont ainsi décidé.

La L.S.C. prévoit encore une règle permettant de trancher les cas litigieux d'attribution d'actif. La solution est différente selon qu'il s'agit d'un élément actif ou de passif. L'élément d'actif est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission. Chacune des sociétés bénéficiaires est solidairement responsable de l'élément passif. Cette responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est limitée à l'actif net attribué à chacune d'entre elles (art. 1031-1 L.S.C.).

Aux termes de l'article 1031-3 L.S.C., la réalisation de la scission requiert l'approbation des assemblées générales de chacune des sociétés participant à la scission et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions (parts). Cette décision requiert les conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.

Ces dispositions viennent de connaître des aménagements lors de l'extension des dispositions sur les fusions et les scissions à d'autres formes de sociétés (par la loi du 23 mars 2007 modifiant la L.S.C.). Par l'ajout de nouveaux paragraphes (2) à (5) à l'article 1031-3 L.S.C., il est d'abord précisé que, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social, et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

« *(3) L'accord de tous les associés est requis :*

1° dans les sociétés à scinder ou bénéficiaires qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt économique ;

2° dans les sociétés à scinder lorsque l'une au moins des sociétés bénéficiaires est

a) une société en nom collectif ;

b) une société en commandite simple ;

c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement ;

d) une société civile ;

e) un groupement d'intérêt économique.

Dans les cas visés au paragraphe 3, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.

(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

(5) S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 450-4 est applicable ».

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le lecteur intéressé est prié de se référer aux commentaires faits à l'occasion des dispositions correspondantes des fusions de sociétés.

« *Le projet de scission est publié conformément à [la Loi de 2002] pour chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission* » (art. 1031-2 L.S.C.).

Par dérogation à ces règles générales, il peut être renoncé à l'approbation de la scission par l'assemblée générale d'une société bénéficiaire. Pour que tel soit le cas, il faut que les conditions suivantes soient remplies :

a) le projet de scission est publié pour la société bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission ;
b) tous les associés de la société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 1031-7, paragraphe (1) ;
c) le ou les associés de la société bénéficiaire disposant d'au moins 5 % des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la société scindée, la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission.

Comme pour la fusion, il faut un rapport écrit établi par l'organe de gestion de chacune des sociétés participant à la scission « *expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de scission et, en particulier, le rapport d'échange des actions ainsi que le critère de leur répartition* ».

Ce rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe. Il mentionne également l'établissement du rapport sur la vérification des apports autres qu'en numéraire, visé à l'article 420-10 (2) L.S.C. et son dépôt conformément à l'article 9 [ancien], paragraphes 1 et 2.

La L.S.C. exige encore que le conseil d'administration de la société scindée informe l'assemblée générale de la société scindée ainsi que les conseils d'administration des sociétés bénéficiaires de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée (art. 1031-5 L.S.C.).

Comme pour les fusions, le projet de scission doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés établi par un réviseur d'entreprises. Sur demande portée devant le président du tribunal d'arrondissement, un seul réviseur peut être nommé.

Dans le rapport destiné aux associés, le réviseur doit notamment se prononcer sur la question de savoir si le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

A – Droits des associés et des créanciers

En premier lieu, les associés ont un droit d'information leur permettant, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, d'obtenir ou de prendre connaissance au siège social des documents suivants (art. 1031-7 L.S.C.) :

« *1° le projet de scission ;*

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à la scission ;

3° un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ;

4° le cas échéant, les rapports des organes de gestion des sociétés participant à la scission, mentionnés à l'article 1031-5, paragraphe 1er ;

5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 1031-6 L.S.C. [...]

(2) L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

[…]

(3) *Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande* ».

Des mesures de protection sont également prévues à l'égard des **créanciers**. En effet, ceux des créanciers des sociétés participant à la scission dont la créance est antérieure à la date de publication du projet de scission prévue à l'article 1031-2 [anc. art. 290] L.S.C. peuvent, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de scission réduirait le gage de ces créanciers. La demande est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière des sociétés participant à la scission. La société débitrice peut, en tout état de cause, écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme. Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible (art. 1031-10 L.S.C.).

L'article 1031-10 L.S.C. précise encore que, si un créancier ou obligataire de la société scindée n'a pas eu satisfaction de la part de la société à laquelle l'obligation a été transférée conformément au projet de scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation. Toutefois, la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est limitée à l'actif net attribué à chacune d'entre elles.

Ces dispositions viennent de connaître des aménagements lors de l'extension des dispositions sur les fusions et les scissions à d'autres formes de sociétés (par la loi du 23 mars 2007 modifiant la L.S.C.). Au vœu de ces nouvelles dispositions, si la société dissoute est une S.e.n.c., une S.e.c.s., une S.e.c.a., une société coopérative dont les associés sont tenus solidairement et indéfiniment, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, alors les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, **des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers** de l'acte de scission (art. 1031-10, nouveau paragraphe 3e L.S.C.).

Ces règles sont tout à fait cohérentes dans la mesure où les associés indéfiniment (et solidairement) responsables des engagements de la société dissoute ne peuvent pas échapper à leurs engagements passés simplement en procédant à la scission de la société.

De même, lorsque la société bénéficiaire est une S.e.n.c., une S.e.c.s., une S.e.c.a., une société coopérative dont les associés sont tenus solidairement et

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

indéfiniment, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, alors les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la scission et transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission.

Cette solution peut paraître excessivement favorable aux créanciers dans la mesure où les associés indéfiniment responsables sont tenus également pour des engagements antérieurs (d'une société anonyme, par exemple) alors que ces créanciers ne pouvaient pas compter sur une telle couverture personnelle au moment de contracter avec la société qui a entre-temps été dissoute. La solution est toutefois fortement tempérée par la possibilité pour les associés visés d'être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse du projet et de l'acte de scission (art. 1031-10 (4) L.S.C.).

Art. 1031-11 [anc. art. 298] L.S.C.

« *Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l'article 1031-10 aux obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la scission a été approuvée par une assemblée des obligataires, ou par les obligataires individuellement* ».

Art. 1031-12 [anc. art. 299] L.S.C.

« *(1) Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles ces titres peuvent être invoqués conformément au projet de scission, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée.*

(2) Le paragraphe 1er n'est pas applicable si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l'article 1031-3.

(3) À défaut de convocation de l'assemblée prévue au paragraphe précédent, ou, en cas de refus d'acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de scission et vérifiée par les experts prévus à l'article 1031-6 ».

Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la scission sont établis par acte notarié : il en est de même du projet de scission lorsque la scission ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés participant à la scission. Le notaire est tenu de vérifier l'existence et la légalité des formalités incombant à la société. La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.

B – Effets de la scission

À l'égard des tiers, les effets de la scission se produisent à la publication faite conformément à la Loi de 2002 pour chacune des sociétés participant à la scission.

Aux termes de l'article 1031-16 L.S.C. :

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« *(1) La scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :*

1° la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires ; cette transmission s'effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l'article 1031-1, paragraphe 3 ;

2° les associés de la société scindée deviennent associés d'une ou des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission ;

3° la société scindée cesse d'exister ;

4° l'annulation des actions de la société scindée détenues par la ou les sociétés bénéficiaires ou par la société scindée ou encore par une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de ces sociétés.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. La ou les sociétés bénéficiaires peuvent procéder elles-mêmes à ces formalités ».

Dans un cas d'espèce, le projet de scission prévoyait que « *tous les litiges nés et actuels, ainsi que les litiges futurs relatifs aux comptes énumérés, intentés par les titulaires desdits comptes ou des personnes tierces, ou intentés par (l'ancienne société B) sont transférés à la Société C. qui reprend tous les droits et obligations en résultant […]* ». En l'occurrence, l'avocat agissait contre la nouvelle société B et non pas contre C (l'autre société issue de la scission). La publication du projet de scission ayant été dûment faite, ce dernier avait effet contre les tiers, de sorte que la Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable pour ne pas avoir été dirigé contre C[1].

C – Responsabilité des administrateurs et experts

Art. 1031-17 [anc. art. 304] L.S.C.

« *Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes de gestion et les experts de la société scindée, une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise par les membres des organes de gestion lors de la préparation et de la réalisation de la scission ou par les experts lors de l'accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes de gestion ou les experts de la société scindée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s'en décharger s'il démontre qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable* ».

D – Nullité de la scission

Le régime des nullités est très restrictif. Selon l'article 1031-18 [anc. art. 305] L.S.C., la nullité de la scission ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

« *1° elle doit être prononcée par décision judiciaire ;*

1 – CA com. du 19 janvier 2005, n° 28.452, ID 10323.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

2° lorsque la scission est réalisée conformément à l'article 1031-14, elle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte notarié ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou de l'autre des sociétés participant à la scission est nulle ;

3° l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ;

4° lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation ;

5° la décision prononçant la nullité de la scission fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par [la Loi de 2002] *;*

6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la scission n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon [la Loi de 2002] *;*

7° la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 1031-14 ;

8° chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle la scission a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société scindée répond aussi de ces obligations. La responsabilité de la société bénéficiaire est toutefois limitée à l'actif net qui lui a été attribué ».

■ § 2 – Scission par constitution de nouvelles sociétés

L'article 1032-1 L.S.C. prend soin de préciser quels sont les articles de la loi applicables à ce genre d'opérations. Il s'agit des articles 1031-1, 1031-2, 1031-3, 1031-5 ainsi que de l'article 1031-6, paragraphes 1er, 2 et 4 et des articles 1031-7 à 1031-18 L.S.C.

Il est encore précisé que, dans la présente hypothèse, l'expression « *sociétés participant à la scission* » désigne la société scindée, l'expression « *société bénéficiaire des apports résultant de la scission* » désigne chacune des nouvelles sociétés.

« *(3) Le projet de scission qui contient le projet de l'acte constitutif de chacune des nouvelles sociétés doit être approuvé par l'assemblée générale de la société scindée.*

(4) Les règles prévues à l'article 420-10, paragraphes 2 à 9 ne s'appliquent pas lorsqu'un rapport sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.

(5) Les règles prévues aux articles 1031-5, 1031-6 et 1031-7, paragraphes 1er, points 3°, 4° et 5° ne s'appliquent pas à la constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société ».

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

■ § 3 – Autres opérations assimilées à la scission

Par définition, même les opérations de scission et de fusion ne devraient pas comporter de soulte en espèces excédant 10 %. La question se pose donc de savoir si les dispositions relatives à ces opérations restent applicables dans ce cas. La réponse est donnée par l'article 1033-1 L.S.C. qui précise que, si la soulte en espèces dépasse 10 %, les sections 1re et 2 restent applicables. Il en est de même lorsqu'une société se met en liquidation et transmet son actif et son passif à plusieurs autres sociétés moyennant attribution d'actions de ces dernières aux associés de la première société, avec ou sans soulte. Cette dernière opération ne répond pas non plus à strictement parler aux opérations de scission prévues par la loi.

A – Scission par absorption

Les conseils d'administration des sociétés qui participent à la scission établissent un projet de scission.

1) Contenu du projet de scission

Le projet de scission mentionne[1] :
- la forme, la dénomination et le siège des sociétés participant à la scission ;
- le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
- la modalité de la remise des actions des sociétés bénéficiaires ;
- la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou de l'autre des sociétés bénéficiaires ;
- etc.

Le projet de scission est publié conformément à la Loi de 2002 pour chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission[2]. L'accord des assemblées générales de chacune des sociétés participant à la scission et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou parts est en principe requis, décisions qui sont prises aux conditions (quorum et majorité) nécessaires pour la modification des statuts[3].

Dans certains cas, **l'accord de tous les associés** est requis. Aux termes de l'article 1031-3 (3) L.S.C., il en va ainsi dans le cas des :

> « *1° **Dans les sociétés à scinder ou bénéficiaires** qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt économique ;*

1 – Art. 1031-1 L.S.C., ID 7520.
2 – Art. 1031-2 L.S.C., ID 7520.
3 – Art. 1031-3L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

*2° **Dans la société à scinder** lorsque l'une au moins des sociétés bénéficiaires est :*
a) une société en nom collectif ;
b) une société en commandite simple ;
c) une société coopérative dont des associés sont tenus indéfiniment et solidairement ;
d) une société civile ;
e) un groupement d'intérêt économique.
[...]
(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis ».

2) Exception à l'approbation du projet de scission

Sauf dans les cas prévus par l'article 1031-3 (3) L.S.C., l'approbation de la scission par l'assemblée générale de la société bénéficiaire n'est pas requise sous certaines conditions et, en particulier, si des associés disposant **d'au moins 5 % des actions** ou parts du capital de la société bénéficiaire ont le droit de requérir la convocation d'une assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission[1].

Les organes de gestion de chacune des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit et détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de scission et, en particulier, le rapport d'échange des actions ou parts. Ce projet de scission fait l'objet d'un examen et d'un rapport écrit par un expert indépendant et destiné aux associés. Dans leur rapport, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le **rapport d'échange** est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; il doit encore « *indiquer si cette méthode ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue* »[2].

Le ou les experts ont le droit d'obtenir auprès des sociétés participant à la scission tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires. Le cas échéant, un rapport du réviseur portant sur l'évaluation des apports en nature est requis : tel sera le cas à chaque fois que la société bénéficiaire de l'apport sera une société par actions[3].

Ni un examen du projet de scission ni un rapport d'expert ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en décident ainsi[4].

Les créanciers des sociétés participant à la scission dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de scission peuvent demander en justice

1 – Art. 1031-4 L.S.C, ID 7520.
2 – Art. 1031-6 (2) L.S.C., ID 7520.
3 – Art. 1031-6 (3) L.S.C., ID 7520.
4 – Art. 1031-8 (1) L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la constitution de sûretés pour des créances au cas où l'opération réduirait le gage de ces créanciers.

B – Scission par constitution de nouvelles sociétés

Les dispositions décrites ci-dessus pour la scission par absorption s'appliquent au présent type d'opérations, sauf que certains ajustements sont prévus[1].

C – Autres opérations assimilées à la scission

Restent soumises à la loi les opérations pour lesquelles la soulte en espèce dépasse 10 % ou encore celles où une société est mise en liquidation pour transmettre son actif et son passif à plusieurs autres sociétés moyennant attribution d'actions aux associés de la première société.

1 – Art. 1032-1 L.S.C., ID 7520.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE IV
LES TRANSFERTS D'ACTIFS, DE BRANCHES D'ACTIVITÉS ET D'UNIVERSALITÉ ET TRANSFERT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

Dans deux nouveaux chapitres appelés respectivement chapitres IV et V de la version coordonnée de la L.S.C. introduits dans la L.S.C. par la loi du 23 mars 2007 sont rendues possibles certaines opérations qui auparavant ne l'étaient que très difficilement.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2007, le transfert du patrimoine des sociétés concernées portait nécessairement sur l'intégralité de celui-ci : en réalité, ces opérations impliquaient toujours la disparition juridique de la (ou des) sociétés « *apporteuses* ».

L'apport de la loi du 23 mars 2007 était précisément d'abandonner cette approche « extrême » en rendant également possible la **transmission partielle** du patrimoine sans avoir à observer les règles de droit civil concernant la cession de créances et de dettes (voir notamment les articles 1689 et suivants du Code civil)[1].

Une société, tout en transférant une partie de son patrimoine à un tiers, peut continuer à exister en tant que personne morale. Il est important de noter que, contrairement à ce qui se passe pour les opérations de fusion et de scission étudiées dans les chapitres précédents, le recours aux règles concernant les opérations de scission n'est **pas obligatoire** : les sociétés concernées (la société transférante et la société bénéficiaire) peuvent décider d'un commun accord d'appliquer les règles des articles 1030-1 à 1033-1 L.S.C. (sauf l'article 1031-16 L.S.C.) ou bien de ne pas les appliquer. La différence est que les effets de la transmission universelle du patrimoine ne seront accessibles que dans le premier cas de figure.

Le deuxième volet de ces innovations de la loi du 23 mars 2007 est celui des « *transferts du patrimoine professionnel* ».

Inspirée du droit suisse, cette réglementation n'est pas sans soulever toute une série de questions. La notion de « *patrimoine professionnel* », inconnue en tant que telle en notre droit privé, n'est pas définie par la loi visée. On peut considérer qu'en notre droit la notion de patrimoine professionnel à l'égard d'une société commerciale n'a réellement aucun sens : tout le patrimoine fait par définition partie du patrimoine professionnel. La situation est certes différente à l'égard des personnes physiques, mais le système mis en place fait entorse au principe de l'unité du patrimoine[2].

SECTION I
DES TRANSFERTS D'ACTIFS, DE BRANCHE D'ACTIVITÉS ET D'UNIVERSALITÉ

C'est la loi du 23 mars 2007 modifiant la loi du 10 août 1915 qui a, de toutes pièces, introduit une réglementation de droit commercial relative aux transferts d'actifs, de branche d'activité et d'universalité. Cette réglementation est applicable à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la L.S.C. et aux groupements d'intérêt économique.

1 – D. Kolbach et J.-M. Schmit, « Les grands chantiers du droit luxembourgeois », *ACE*, janvier 2006, p. 3.
2 – D. Kolbach et J.-M. Schmit, « Les grands chantiers du droit luxembourgeois », *ACE*, janvier 2006, p. 3.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les dispositions du chapitre IV sont optionnelles dans la mesure où la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles 1030-1 à 1033-1, hormis l'article 1031-16 (art. 1040-2 L.S.C.). L'exclusion de cet article 1031-16 est logique pour la raison que cet article prévoit les effets spécifiques applicables en cas de scission d'une société, notamment que la société scindée (donc la société apporteuse) cesse d'exister. Ces effets sont de toute façon incompatibles avec celui du transfert d'actifs tel que défini ci-dessus. Une autre conséquence de la non-application de l'article 1031-16 L.S.C. est que les titres émis en rémunération des apports faits à la société bénéficiaire des apports sont **attribués directement à l'apporteur,** et non aux associés de l'apporteur (comme tel est le cas pour les fusions de sociétés, p.ex.).

L'apport d'une branche d'activités est défini comme « *l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport* ».

La notion de branche d'activité, qui a été préférée par le législateur belge à celle plus traditionnelle de fonds de commerce, est issue du droit fiscal et reconnue par le droit comptable. Il s'agit de « *l'ensemble des éléments d'actifs et de passif d'une division d'une société qui constituent du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner avec ses moyens propres* »[(1)].

Ici encore le régime prévu par la loi est applicable de façon facultative : les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport « *peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions du chapitre III […] hormis l'article 1031-16* ». Si cette option est prise, l'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.

La L.S.C. définit la branche d'activités comme « *un ensemble qui, du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens* ».

En fin de compte, l'apport peut consister en une universalité définie comme « *l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports* » (art. 1040-4 L.S.C.).

La société qui apporte une universalité à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent soumettre l'opération aux dispositions du chapitre III du présent titre hormis l'article 1031-16 L.S.C. Dans ce cas, « *l'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent* ».

SECTION II
DES TRANSFERTS DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

La loi du 23 mars 2007 modifiant la L.S.C. permet encore « *le transfert de tout ou partie du patrimoine professionnel* » par les sociétés, les groupements d'intérêt

1 – Th. TILQUIN, « Le transfert d'une universalité ou d'une branche d'activité », *J.T.*, 1996, p. 500.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

économique et les personnes physiques « *à un autre sujet de droit dans le cadre d'une affectation professionnelle* » (art. 1050-1 L.S.C.).

Les dispositions du chapitre III, hormis l'article 1031-16, s'appliquent lorsque les sujets transférant et reprenant sont des sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi ou des groupements d'intérêt économique et que les associés de la société ou du groupement transférant reçoivent des actions ou parts sociales de la société ou groupement reprenant. Les règles prévues par la loi **s'appliquent d'office** aux transferts de patrimoine professionnel (alors qu'elles n'étaient que facultatives à l'égard des apports de branche d'activité, etc.).

De tels transferts sont également possibles à « *une société, groupement d'intérêt économique ou personne physique étranger* » à condition que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas. On retrouve donc à cet endroit la même solution très libérale que celle décrite à l'occasion des scissions : ces opérations ont vocation à s'appliquer également dans un **cadre transfrontalier** sous la seule réserve que la loi de **l'autre État ne s'y oppose pas**. Cette règle s'applique tant à l'égard des sociétés de l'Union européenne que non européennes.

Quant aux effets d'une telle opération, l'article 1050-1 L.S.C. retient que le transfert du patrimoine professionnel entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.

La décision sur l'opération de transfert est prise par chacune des parties au contrat de transfert aux « *conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts* » (art. 1050-2 L.S.C.).

Les organes de gestion des sujets qui participent au transfert établissent par écrit un projet de transfert.

Ce projet mentionne :

1° la forme juridique, la dénomination ou le nom, et le siège social ou domicile des sujets participant au transfert ;

2° un inventaire qui désigne clairement les éléments du patrimoine actif et passif qui seront transférés ;

3° la valeur totale des actifs et des passifs qui seront transférés ;

4° l'éventuelle contre-prestation.

Le transfert de patrimoine n'est possible que si l'inventaire présente un **excédent d'actifs**. Cette exigence de la L.S.C. soulève la question de savoir si la détermination du solde des actifs sur les passifs doit se faire sur la base des valeurs comptables ou des valeurs réelles. Il se peut en effet que, sur la base des valeurs comptables, les passifs excèdent les actifs, alors que l'inverse est le cas lorsqu'il est pris référence aux valeurs réelles, donc aux valeurs de marché des biens ; la société apporteuse possède un immeuble acquis il y a trente ans et dont la valeur réelle excède considérablement la valeur comptable.

La loi prévoit des règles destinées à résoudre les cas litigieux pour lesquels il n'est pas certain de savoir à quel bénéficiaire l'attribution d'un bien doit être faite. Dans un tel cas, cet élément d'actif demeure au sein du sujet transférant. S'il s'agit d'un élément du passif, les parties au transfert en sont solidairement responsables (art. 1050-3 (1) L.S.C.). Mais il est entendu que, de façon générale, la responsabilité solidaire du sujet reprenant est limitée à l'actif net qui lui est attribué. Cette dernière règle est une conséquence directe du principe que le transfert d'actif doit présenter un excédent d'actif.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Pour chacun des participants, le projet de transfert est publié conformément à la Loi de 2002 un mois au moins avant la conclusion du contrat de transfert, c.-à-d., le cas échéant, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.

Comme pour les scissions (et les fusions), l'organe de gestion de chacun des participants au transfert doit établir un rapport écrit détaillé dont l'objet est d'expliquer et de justifier « *du point de vue juridique et économique le projet de transfert* » et, en particulier, les points suivants :

« *1° le but et les conséquences du transfert de patrimoine ;*

2° le contrat de transfert ;

3° la contre-prestation pour le transfert » (art. 1050-5 L.S.C.).

Une question d'intérêt primordial est celle du sort des dettes contractées avant le transfert. La loi retient que « *le transférant reste solidairement obligé pendant trois ans avec le sujet reprenant de l'exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine* ».

Ces créanciers peuvent dans certains cas demander la constitution de sûretés (art. 1050-6 L.S.C.).

Les règles quant aux effets de cette opération sont similaires à celles prévues pour les fusions.

– le transfert de patrimoine est réalisé lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises par les cocontractants ;
– à l'égard des tiers, ces effets ne se produisent qu'après la publication faite conformément à la Loi de 2002 pour chacun des participants (art. 1050-7 L.S.C.)

La nullité du transfert de patrimoine professionnel ne peut intervenir que dans des conditions très restrictives, calquées sur celles des nullités de sociétés. La nullité doit être prononcée par décision judiciaire, l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le transfert de patrimoine est opposable à celui qui invoque la nullité, la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon la Loi de 2002 (art. 1050-9 L.S.C.).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE V
LES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Le droit luxembourgeois des sociétés, comme le droit belge d'ailleurs, ne comporte pas de réglementation globale régissant les groupes de sociétés. Par ailleurs, l'harmonisation prévue sur un plan européen se fait attendre : la Neuvième directive, en principe consacrée à ce sujet ne fait pas de progrès et son avenir est très incertain. À cet égard, les efforts d'harmonisation se sont à ce jour limités à la présentation consolidée des comptes sociaux des groupes des sociaux.

Néanmoins, les groupes de sociétés sont devenus une réalité incontournable que le droit ne peut ignorer.

SECTION I
NOTION DE GROUPE

Les sociétés faisant partie d'un groupe de sociétés restent soumises au droit commun du fait qu'elles sont des **êtres juridiques distincts** les uns des autres[1]. Sauf très rares exceptions, le droit respecte la personnalité juridique distincte des différentes sociétés membres du groupe.

■ § 1 – Reconnaissance partielle de la réalité du groupe

Par exception, le droit fiscal et le droit du travail soit facultativement (**intégration fiscale**[2]), soit obligatoirement (droit du travail) dépassent cette conception basée sur la personnalité morale distincte de chaque société.

En droit fiscal, des sociétés apparentées remplissant certaines conditions (principalement, détention de 95 % au moins du capital des filiales par une société de capitaux résidente) peuvent faire une demande d'intégration fiscale dont le résultat est que les sociétés concernées peuvent compenser les résultats positifs et négatifs de toutes les sociétés comprises dans l'intégration fiscale.

Ainsi encore, en droit du travail, des sociétés juridiquement distinctes peuvent constituer une unité économique et sociale considérée comme une seule entreprise, notamment au regard de l'article L. 124-2 (1) du Code du travail, imposant à l'employeur qui occupe 150 salariés au moins l'obligation de procéder à un entretien préalable au licenciement. « *Les critères à prendre en considération à cet effet sont, du point de vue économique, une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires, et, du point de vue social, une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts avec, par exemple, un statut social semblable* »[3].

Il est souvent regretté que l'existence des groupes de sociétés soit mal prise en compte par le droit des sociétés qui lui s'en tient à la fiction juridique de **sociétés autonomes**[4].

1 – J.-P. Spang, « Vers un droit des groupes de sociétés », *ALJB Droit bancaire et financier*, Vol. 3, pp. 1069 ss.

2 – Pour plus de détails, V. J.-P. Winandy, *Précis de droit fiscal*, Luxembourg, Legitech, 2006, p. 190.

3 – CA (trav.) du 4 mars 1999, ID 6871.

4 – CA Bruxelles du 9 octobre 1984, *R.P.S.*, 1986, note M. Maréchal, p. 55.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La jurisprudence « *reconnaît la caractéristique fondamentale du groupe de société, à savoir l'existence d'un "intérêt de groupe" distinct de l'intérêt des sociétés qui composent l'ensemble et qu'il est légitime de poursuivre* »[1]-[2]. Cette jurisprudence fait suite à des décisions antérieures qui ont nié l'existence d'un tel **intérêt du groupe** : ainsi, la Cour d'Anvers[3] a-t-elle arrêté que le groupe, comme tel, n'a pas la personnalité juridique et que l'appartenance de fait à un groupe ne peut justifier la poursuite d'un intérêt différent de l'intérêt social[4].

Dans cette ligne de pensée, le Tribunal de commerce de Bruxelles[5], après avoir constaté que deux sociétés avaient conclu des accords de coopération ayant abouti à une intégration d'une partie importante de leurs activités, a admis que les administrateurs de l'une des sociétés avaient pu légitimement estimer que, en raison de cette intégration, il était de l'intérêt de celle-ci d'aider l'autre société en vue de prévenir les conséquences de la défaillance de cette dernière[6].

Le Tribunal de commerce de Liège, pour sa part, a accepté qu'une société puisse venir en **aide à une autre société du** même **groupe** pourvu que les conditions suivantes soient remplies : « *une certaine perméabilité patrimoniale peut toutefois être admise lorsqu'une société aide momentanément une autre société, à la condition que les sacrifices ne soient pas hors de proportion avec les possibilités réelles de l'entreprise qui les consent et qu'ils n'entraînent pas de difficultés graves que leur caractère excessif permet de prévoir au moment où la décision est prise* »[7].

En cas d'assistance apportée par une société à une autre (notamment sous la forme de la dation en garantie d'éléments d'actifs), le non-respect de ces conditions pourrait, selon le tribunal, être sanctionné par l'action paulienne, ou encore être fondé sur l'abus de majorité et finalement se traduire par la mise en cause de la responsabilité des administrateurs[8].

La question qui se pose dans ce contexte est donc régulièrement celle de savoir si une société peut favoriser une autre société faisant partie du même groupe sans commettre un **abus de majorité**. Il a ainsi été jugé qu'une société peut accorder une aide « *momentanée* » à une société sœur en difficulté dans la mesure où elle ne comporte « *aucun sacrifice durable* » et qu'elle « *ne compromet pas les actifs de la société* »[7]. L'aide ne peut menacer les intérêts des créanciers de la société aidante, impliquer des sacrifices hors de proportion avec les possibilités de l'entreprise et de nature à l'entraîner à son tour dans des difficultés[9].

« *Il faut donc exiger de la société membre d'un groupe, comme de toute autre société, une décision justifiable et proportionnée sauf erreur à ses moyens ainsi qu'aux avantages qu'elle peut espérer. L'aide à une autre société du groupe n'est*

1 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 631.

2 – Pour une appréciation en droit luxembourgeois, v. aussi S. Oostvogels et D. Boone, « De l'intérêt social à l'intérêt de groupe en droit des sociétés : perspectives luxembourgeoises », *ALJB Droit bancaire et financier*, Vol. 3, p. 1037.

3 – Cour d'Anvers du 2 mars 1978, *Revue*, 1979, p. 312.

4 – CA Bruxelles du 9 octobre 1984, *R.P.S.*, 1986, p. 50, note M. Maréchal.

5 – Trib. com. Bruxelles du 27 avril 1978, *R.P.S.*, 1978, p. 276.

6 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 631.

7 – Trib. com. Liège du 13 octobre 1981, *R.P.S.*, 1982, p. 45.

8 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 632.

9 – CA Bruxelles du 9 octobre 1984, *R.P.S.*, 1986, note M. Maréchal, p. 56.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

pas "légitime en soi". Ni "illégitime en soi". Elle n'est légitime que si la société poursuit en réalité son intérêt social propre, qui n'est pas forcément à courte vue et qui peut se réaliser notamment grâce aux avantages procurés par la participation au groupe en contrepartie de certains sacrifices. L'intérêt du groupe ne peut se substituer à l'intérêt social en l'état actuel de notre droit »[1].

■ § 2 – Limitations aux concours entre sociétés du groupe

La question de savoir dans quelle mesure de tels concours financiers sont autorisés à l'intérieur d'un groupe de sociétés se pose quotidiennement. Il existe à ce sujet, différentes limitations qui peuvent jouer et rendre de tels concours impossibles.

La première limitation est celle de **l'objet social** : l'objet, tel qu'indiqué obligatoirement dans les statuts de la société, peut interdire de tels concours financiers. Compte tenu de la pratique luxembourgeoise consistant à prévoir un objet très large, une telle non-conformité de concours financiers avec l'objet social est toutefois peu fréquente.

On considère en général que l'objet social ne représente pas une limitation à la **capacité** de la société, mais qu'il détermine **l'étendue des pouvoirs des organes** de la société. Telle est encore la conception de la Cour de cassation belge : « *Pour tous les actes juridiques que n'exclut pas sa nature d'être moral, sa capacité est en principe la même que celles des personnes physiques, si la loi ne l'a pas restreinte ; mais attendu que l'être moral ne peut agir qu'à l'intervention de personnes physiques, ses organes ; que ceux-ci n'agissent en cette qualité, et dès lors ne s'identifient avec l'être moral, que s'ils restent dans les limites de leurs attributions* »[2].

La doctrine interprète cet arrêt dans la mesure où l'objet social ne constitue pas une restriction de la capacité de la personne morale, mais seulement une limitation des pouvoirs de ses organes[3]. « *L'objet ne limite pas la capacité de la société mais les initiatives de ses dirigeants* »[4].

La seconde limitation est celle de **l'intérêt social**. Il n'y a pas confusion entre ces deux notions dans la mesure où il est possible qu'un acte qui respecte parfaitement l'objet social soit contraire à l'intérêt social. En un autre endroit (p. 161), nous avons consacré quelques développements à cette notion que le législateur s'est toujours gardé de définir.

Traditionnellement, l'intérêt social était l'intérêt des **seuls actionnaires** (conception capitaliste). Cette conception a graduellement fait place à une conception large (dite conception entrepreneuriale) qui assimile l'intérêt de la société à **l'intérêt de l'entreprise**, en se référant ainsi non seulement aux intérêts des actionnaires, mais aussi à ceux des salariés, des créanciers, de la collectivité en général, etc[5].

À cette notion d'intérêt social s'ajoute la réalité du groupe des sociétés dans la mesure où cette réalité infléchit les règles et les concepts élaborés pour les sociétés individuelles. Certains parlent d'intérêt du groupe qui s'opposerait ainsi à la notion d'intérêt de la société individuelle. « *Comment reconnaître un intérêt propre à*

1 – CA Bruxelles du 9 octobre 1984, *R.P.S.*, 1986, note M. Maréchal, p. 57.

2 – Cass. du 31 mai 1957, *Pas.*, 1957, I, p. 1176.

3 – L. du Jardin, « Le crédit et les garanties entre sociétés groupées », *J.T.*, 2000, p. 609.

4 – Y. Chaput, note sous Cass. fr du 18 juillet 1988, *Rev. soc.*, 1990, pp. 598 ss.

5 – L. du Jardin, « Le crédit et les garanties entre sociétés groupées », *J.T.*, 2000, p. 611.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

un phénomène de concentration (le "groupe") dépourvue de personnalité juridique ? La réalité de ce phénomène de concentration est indéniable : son "intérêt" ne paraît cependant pouvoir être appréhendé que par l'interprétation de l'intérêt des sociétés qui le composent […] Il s'agit d'interpréter l'intérêt de la société d'une manière suffisamment large pour y englober l'intérêt que représente pour elle l'appartenance au groupe (Nelissen-Grade, De la validité et de l'inexécution des conventions de vote) »[1].

Ces développements expliquent « *pourquoi l'existence d'un groupe peut autoriser des efforts ou sacrifices éprouvant l'intérêt social de la société qui s'engage : c'est le cas lorsque le groupe fait précisément partie de cet intérêt* »[1].

Dans ce contexte, il est souvent fait référence à l'**arrêt *Rozenblum*** (pris en matière d'abus de biens sociaux) de la Cour de cassation française[2] dans lequel la cour a formulé trois conditions : « *Le concours financier apporté par les dirigeants de fait ou de droit d'une société à une autre société, entreprise d'un même groupe, dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, doit :*

7) *être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe ;*
8) *ne doit être ni démuni de contrepartie, ni rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées ;*
9) *ne doit pas excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge* ».

En général, le concours financier accordé par une société mère à une de ses filiales sera dans l'intérêt de cette société mère. Mais l'accomplissement de cette condition doit à chaque fois être vérifiée.

Lorsque la société a réalisé un acte en violation de son intérêt social, alors cet acte contraire à l'intérêt social qui, en général, ne constitue pas une violation de la loi, sera constitutif d'une faute de gestion. La responsabilité des dirigeants peut être retenue sur la base de l'article 1382 C.c. dans la mesure où il s'agit d'une violation du devoir général de prudence[1].

Si le droit des sociétés (au sens étroit) a ses difficultés pour tenir compte de la réalité des groupes de sociétés, le **droit comptable**, pour sa part, depuis longtemps impose l'établissement de comptes consolidés afin de rendre une image fidèle de la réalité économique chiffrée de l'importance effective d'un groupe de sociétés.

SECTION II
LES COMPTES CONSOLIDÉS

En théorie pure, il existe deux approches différentes de la consolidation des comptes.

– En premier lieu, on peut considérer que les comptes consolidés représentent une **extension des comptes individuels** de la société qui détient des participations. En effet, lorsque la société détient une participation dans une autre société, alors le poste « participations » maintenu au bilan de la société mère et comptabilisé au coût d'acquisition historique fait écran : les comptes consolidés

1 – L. DU JARDIN, « Le crédit et les garanties entre sociétés groupées », *J.T.*, 2000, p. 612.

2 – Cass. fr. du 4 février 1985, *Rev. soc.*, 1985, p. 648, note B. Bouloc.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

enlèvent cet écran en présentant les choses comme si la filiale n'était pas une entité distincte de la société mère, mais une succursale de la société mère[1].

– La deuxième approche relative à la consolidation est que les comptes consolidés ont uniquement pour objet de représenter la réalité non pas de l'entreprise mère consolidante, mais d'un **groupe de sociétés**. Ces comptes n'intéressent pas seulement l'entreprise mère, mais toutes les entreprises du groupe consolidé, ainsi que leurs associés et leurs créanciers[2].

Il est vrai que la Septième directive n'opte pas en faveur de l'une ou de l'autre de ces conceptions mais, dans une approche purement technique, elle se borne à définir quelles sont les conditions dans lesquelles les sociétés de capitaux visées par la Quatrième directive sont obligées de consolider. Par conséquent, le fait qu'une société soit obligée de consolider ses filiales ne permet en rien de conclure qu'il existe un véritable groupe de sociétés.

Ladite Septième directive a pour objet d'obliger certains groupes de sociétés à procéder à l'établissement de comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes, annexe) ainsi qu'un rapport de gestion consolidés, de procéder au contrôle de ces comptes. « *Il est, en effet, reconnu de plus en plus que les seuls comptes individuels d'une entreprise, pour nécessaire qu'ils soient, peuvent ne pas être suffisants pour donner une information complète et suffisante lorsque cette entreprise a des liens financiers plus ou moins étroits avec une ou plusieurs autres entreprises. Le remède au caractère insuffisant ou inadapté des informations fournies par le bilan individuel […] est recherché dans les comptes consolidés.*

L'objectif de ceux-ci est de réunir les bilans et les comptes de profits et pertes de deux ou de plusieurs entreprises en un seul bilan et un seul compte de profits et pertes comme s'il s'agissait des comptes d'une seule entreprise »[3].

En droit comptable luxembourgeois, l'obligation de consolidation des comptes existe depuis la loi du 11 juillet 1988[4] qui a transposé en droit luxembourgeois les dispositions de la **Septième directive** en matière de droit des sociétés, adoptée par le Conseil des ministres des Communautés européennes en date du 13 juin 1983, directive qui était le complément, à l'égard des groupes de sociétés, de la Quatrième directive applicable en matière de comptes individuels des sociétés de capitaux.

L'obligation de consolidation des comptes est une obligation très **onéreuse** que le législateur ne pense pas pouvoir imposer à tout groupe de sociétés, mais seulement à ceux d'une certaine importance. En effet, les comptes consolidés, loin de remplacer les **comptes individuels**, s'y ajoutent. Il convient donc de définir le champ d'application exact de l'obligation de consolidation.

■ § 1 – Champ d'application de l'obligation de consolidation des comptes

Cette obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion concerne les sociétés visées par la Quatrième directive, à savoir donc « *toute société anonyme, toute société en commandite par actions, toute société par actions simplifiée toute société à responsabilité limitée et toute société visée à l'article 77, alinéa 2, points 2° et 3°* [de la Loi de 2002] » (art. 1711-1 L.S.C.). Le législateur luxembourgeois,

1 – *Doc. parl.*, n° 3154, exposé des motifs, p. 18, ID 9821.

2 – *Doc. parl.*, n° 3154, exposé des motifs, p. 18, ID 9821.

3 – *Doc. parl.*, n° 3154, exposé des motifs, p. 18, ID 9821.

4 – Loi du 11 juillet 1988, ID 9564, *Doc. parl.*, n° 3154, ID 9821.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

conformément à son attitude « minimaliste » en matière de transposition des directives européennes, n'a pas voulu étendre cette obligation aux **sociétés de personnes** (sauf celles qui n'ont que des associés indéfiniment responsables consistant en des sociétés de capitaux), comme la directive le lui aurait permis de le faire.

Les conditions qui doivent être remplies sont celles qui sont destinées à établir le **lien de domination** que la société mère peut exercer sur ses filiales. Selon le cas la société mère :

« *1° a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, ou*

2° a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise,
ou

3° est actionnaire ou associé d'une entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci ».

Ad a : Il s'agit de la majorité des droits de vote d'une entreprise. C'est la majorité **absolue** qui est requise en excluant ainsi les situations où la société est majoritaire aux assemblées en raison de l'abstentionnisme des autres associés. La majorité est calculée non par rapport à la participation au capital, mais par rapport à celle dans les **droits de vote** de la société. Il résulte de cette disposition que c'est le contrôle, ou plutôt la possibilité de contrôle, sur les entreprises filiales qui compte[1].

Ad b : L'obligation d'établir des comptes consolidés existe lorsqu'une société, sans détenir la majorité des droits de vote, a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la société. Cette possibilité fonde sur un **lien contractuel** – par exemple, une convention passée entre, d'une part, l'entreprise bénéficiaire du droit et, d'autre part, l'entreprise filiale ou un autre actionnaire[1]. Il s'agit de l'organe de gestion donc du conseil d'administration de la S.A. classique (directoire ou conseil de surveillance dans la structure bicéphale) ou du gérant de la S.à r.l. Il est encore à noter que la notion « organes de direction » ne vise pas les membres de la direction qui sont liés à leur entreprise par un **contrat d'emploi**[2]. Cette condition est susceptible d'avoir une très grande importance pratique dans la mesure où les gérants des S.à r.l. sont quasiment toujours liés à leur société par un contrat de travail.

Ad c : Le cas visé est celui où une société, associé d'une entreprise sans en avoir la majorité des droits de vote, « *contrôle cette majorité en vertu d'un accord avec d'autres associés ou actionnaires de l'entreprise* »[1]. Le cas visé ici est évidemment celui des **pactes d'actionnaires** portant sur l'exercice des droits de vote des associés.

A – Nature des liens existants entre les entreprises visées

L'article 1711-2 L.S.C. donne des précisions utiles et importantes sur la question de savoir comment les droits de vote sont calculés en précisant que : « *les droits*

1 – *Doc. parl.*, n° 3154, commentaire des articles, p. 20, ID 9821.

2 – *Doc. parl.*, n° 3154, commentaire des articles, p. 21, ID 9821.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de vote de nomination ou de révocation de la société mère doivent être additionnés des droits de toute entreprise filiale ainsi que de ceux d'une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société mère ou de toute autre entreprise filiale ».

En général, les liens qui donnent lieu à l'obligation de consolider sont les **liens directs**, tels que ceux par lesquels une société mère détient, par exemple, 60 % des actions donnant droits de vote de l'entreprise filiale. L'article 1711-2 L.S.C. précise à cet égard qu'aux liens directs existant entre société mère et entreprise filiale il y a lieu d'ajouter les « *liens indirects* » par lesquels une filiale de la société mère détient à son tour des droits de vote sur l'entreprise filiale.

Exemple 1
La S.A. HoldCo détient directement 20 % du capital (et des droits de vote) de la S.à r.l. LuxCo. En même temps, elle détient 60 % des parts de la société en nom collectif belge BelCo qui détient à son tour 40 % du capital et des droits de vote de la S.à r.l. LuxCo. Le résultat est qu'il existe une obligation de consolidation du fait que HoldCo détient 80 % des actions de LuxCo (et non seulement 60 % : il y addition pure et simple des droits de vote détenus par la filiale).

Exemple 2
A détient 60 % de B qui détient à son tour 60 % de C. Dans ce cas C est filiale de A.

Sont encore additionnés aux droits de vote afférents à des titres détenus par la société mère ceux détenus par toute personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société mère : sont visés notamment les relations fiduciaires.

B – Périmètre de consolidation

Ce même article 1711-2 L.S.C. spécifie encore que l'obligation de consolider n'est pas limitée aux entreprises filiales nationales, mais qu'elle inclut les **entreprises étrangères**. En effet, au vœu de l'article 1711-3 L.S.C. :

« *(1) La société mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice de l'article 1711-8 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.*
(2) Pour l'application du paragraphe 1er, toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme celle de la société mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider. [...] ».

Si l'entité consolidante doit en principe avoir la forme d'une société de capitaux (voir ci-dessus), une telle condition n'existe pas à l'égard des filiales : en effet, celles-ci doivent être consolidées dans la mesure où il s'agit d' « *entreprises* ». Il s'agit d'une « *notion essentiellement économique qui ne se prête pas facilement à une définition juridique précise* »[1]. Cette notion inclut en tout cas toutes les sociétés définies par l'article 48, alinéa 2, du traité instituant la Communauté économique européenne, donc « *les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés ne poursuivant pas de but lucratif* »[1]. En tout état de cause, les personnes physiques sont exclues[1].

1 – *Doc. parl.*, n° 3154, commentaire des articles, p. 20, ID 9821.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En vertu de cette disposition, sont donc à consolider toutes les filiales, que celles-ci se trouvent au Luxembourg, dans un autre Etat membre ou encore dans n'importe quel pays du monde : il s'agit d'une obligation de **consolidation mondiale**.

■ § 2 – Exemptions

Comme indiqué ci-dessus, le législateur national, conformément aux dispositions de la directive, a prévu un certain nombre d'exemptions garantissant que tous les groupes remplissant les conditions de l'article 1711-1 L.S.C. ne doivent pas être consolidés dans les comptes de la société mère.

On peut distinguer à cet égard les exemptions prévues à l'égard des **sociétés mères** de celles prévues à l'égard des **filiales**.

A – Exemptions à l'égard des sociétés mères

Celles-ci sont prévues par les articles 1711-4 à 1711-7 L.S.C.

Il s'agit des cas suivants que nous allons aborder tour à tour ci-après :

– la société mère est à la tête d'un « petit groupe » (art. 1711-4 L.S.C.) ;
– la société mère est elle-même une société filiale qui se trouve incluse dans la consolidation d'un ensemble plus grand (art. 1711-5 et 1711-6 L.S.C.).

1) Exemption prévue à l'égard des sociétés de participation financière

Conformément à une option accordée par la Septième directive aux États membres, le Luxembourg avait introduit dans la loi nationale une telle exonération à l'égard des sociétés de participation financière (anc. art. 312 L.S.C.). Cette exemption était fort utile en pratique. Selon le commentaire des articles du projet de loi n° 3154 : « *[…] l'établissement de comptes consolidés par les sociétés de participation financière ne répond pas à une nécessité réelle. L'établissement et la publication par ces sociétés d'un bilan et d'un compte de profits et pertes individuels […] suffisent pour satisfaire au besoin légitime d'information des associés et des tiers* »[1].

C'est la loi du 18 décembre 2015 transposant la directive 2013/34/UE relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés qui a aboli cette exemption (en abolissant l'article 312 L.S.C.).

2) Exemption à l'égard des petits groupes

Par le terme de « petits groupes » (qui bénéficient donc d'une exemption de consolidation), on entend les petits ensembles de sociétés qui, à la date de clôture du bilan de la société mère, ne dépassent pas deux des trois critères spécifiés dans l'article 1711-4 L.S.C. Cet article prévoit une exemption de l'obligation de consolidation pour toute société mère lorsque, à la date de clôture de son bilan, l'ensemble des entreprises qui devraient être consolidées ne dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, deux des trois critères suivants :

– total du **bilan** : **20 millions** d'euros ;

1 – *Doc. parl.*, n° 3154, commentaire des articles, p. 24, ID 9821.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– montant net du **chiffre d'affaires** : **40 millions** d'euros ;
– nombre de membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au courant de l'exercice : **250 salariés.**

Ces seuils sont identiques à ceux prévus par l'article 47 de la Loi de 2002 et destinés à définir les entreprises qui sont autorisées à publier un compte de profits et pertes abrégé. Il est encore précisé par l'article 1711-4 L.S.C. que les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d'affaires peuvent être **augmentées de 20 %** lorsqu'il n'est pas procédé à la compensation visée à l'article 1712-4, paragraphe 1er, ni à l'élimination visée à l'article 1712-11, paragraphe 1er, points 1° et 2°.

Cette disposition constitue une mesure de simplification à l'égard des sociétés dont le chiffre d'affaires et la somme des bilans consolidés seraient relativement proches des seuils légaux, mais à l'égard desquels on ne serait pas *a priori* sûr si le seuil est effectivement dépassé au non. Le paragraphe 2 veut éviter à ces groupes de devoir procéder à un essai de consolidation afin de vérifier ce point avec précision. La loi (en reprenant une option laissée par la directive) permet de simplement procéder à une addition des bilans et profits et pertes des sociétés à consolider en comparant ces chiffres aux seuils légaux, mais augmentés de 20 % (taux maximum accepté par la directive). Ce relèvement est entièrement justifié pour la raison que, en procédant à la véritable consolidation, certains postes sont éliminés, de sorte que le bilan consolidé serait nécessairement inférieur au bilan simplement cumulé des différentes entités à consolider.

L'exemption de l'article 1711-4 L.S.C. ne s'applique toutefois pas lorsque l'une des entreprises à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs établie dans un État membre de l'Union européenne.

3) Exemption pour cause de consolidation à un niveau supérieur

Lorsqu'on est en présence d'une structure de participation verticale à plusieurs niveaux, mettant en jeu exclusivement des sociétés de capitaux – par exemple, A détient B, B détient C qui à son tour détient D (à chaque fois il y a détention majoritaire) –, alors il y a en principe obligation de consolider dans le chef de chaque société mère. Chaque société mère doit consolider toutes ses filiales : donc B, C et D en ce qui concerne A, C et D en ce qui concerne B, et D en ce qui concerne C. « *Dans certains États, on opère actuellement de la sorte au motif que les actionnaires ou associés de chaque société sont supposés intéressés à recevoir les informations fournies par la consolidation sur l'ensemble dont leur société est la mère. Dans d'autres États, le raisonnement est différent. On y voit dans la structure verticale A-B-C-D un seul groupe, et c'est sur celui-ci qu'il importe d'avoir des informations.*

Ces sociétés forment un groupe unique et pas plusieurs, et il suffit en conséquence d'établir un seul bilan consolidé et ce au niveau de la mère de cet ensemble qui est la société A »[(1)]. La solution de la directive consiste en fait à ne pas trancher entre ces deux conceptions (déjà mentionnées ci-dessus) et à laisser aux États

1 – *Doc. parl.*, n° 3154, commentaire des articles, p. 27, ID 9821.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

membres le choix d'accorder l'exemption sous des conditions très nettement circonscrites.

L'exemption prévue par la directive revient donc en réalité à la **substitution** d'une **consolidation par une autre** plus grande[1].

Cette exemption est obligatoire pour autant que les conditions prévues par la loi soient remplies.

L'article 1711-5 L.S.C. prévoit qu'est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion « *toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre de l'Union européenne* ».

Dans un tel cas, donc celui d'une société mère luxembourgeoise qui est elle-même la filiale d'une entreprise d'un autre État membre, il n'y a pas d'obligation de consolidation dans deux cas précis :

« *1° l'entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette société exemptée. Les parts ou actions de cette société détenues par des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération ;*

2° l'entreprise mère détient 90 % ou plus des parts ou actions de la société exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette société ont approuvé l'exemption.

(2) L'exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes :

1° La société exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 1711-8, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises, dont l'entreprise mère relève du droit d'un État membre de l'Union européenne ;

2° a) les comptes consolidés visés au point 1° ainsi que le rapport consolidé de gestion de l'ensemble plus grand d'entreprises sont établis par l'entreprise mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l'État membre dont celle-ci relève ;

b) les comptes consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion visé au point 1°, ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes, font l'objet de la part de la société exemptée d'une publicité effectuée selon les modalités de l'article 100-13 ;

3° l'annexe des comptes annuels de la société exemptée doit comporter :

a) le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés au point a) ;

b) la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion ».

Il convient de noter que la condition d'exemption est liée au pourcentage de détention du **capital,** et non des droits de vote. Il en résulte donc que les actionnaires détenteurs d'actions sans droit de vote sont pris en compte pour décider si l'exemption s'applique.

L'exemption de la société luxembourgeoise s'applique uniquement si la société luxembourgeoise est détenue par une entreprise relevant du droit d'un État membre de l'Union. Cet État membre peut être le Luxembourg lui-même : dans ce cas, cette

1 – *Doc. parl.*, nº 3154, commentaire des articles, p. 28, ID 9821.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

société mère doit être une société de capitaux (étant donné qu'au Luxembourg, ce sont les seules à devoir consolider). Si l'entreprise est établie dans un autre État membre, alors cette entité consolidante pourrait bien ne pas être une société de capitaux, dans la mesure où cet autre État membre soumet à l'obligation de consolidation des entités autres que les sociétés de capitaux (cette exemption était autorisée par la Septième directive).

4) Exemption pour les sociétés mères elles-mêmes consolidées

a) Consolidation dans un autre État membre

L'article 1711-6 L.S.C. complète le dispositif de l'article 1711-5, paragraphe 1er L.S.C. (qui exige une détention soit de 100 %, soit de 90 % des actions ou parts au moins). Si ces pourcentages ne sont pas atteints, mais qu'il y a **consolidation** dans une entreprise d'un **autre État membre**, alors il n'y a pas d'obligation de consolidation, à moins que : « *[…] les actionnaires ou associés de la société exemptée, titulaires d'actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d'au moins 10 %, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et d'au moins 20 % si elle est une société à responsabilité limitée, n'ont pas demandé l'établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice* ».

b) Consolidation dans une entreprise mère établie hors Union européenne

Alors que les articles 1711-5 et 1711-6 L.S.C. concernent les cas où il y a consolidation dans le chef d'une entreprise mère établie dans l'Union européenne, l'article 1711-7 L.S.C., pour sa part, étend cette exemption au cas où l'entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre. Dans ce cas, l'exemption est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

« *1° la société exemptée, ainsi que, sans préjudice de l'article 1711-8, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises ;*

2° les comptes consolidés visés au point 1° et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions de la présente section ou de façon équivalente ;

3° les comptes consolidés visés au point 1° ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes.

L'article 1711-5, paragraphe 2, point 2°, lettre b) et point 3°, et paragraphe 3 ainsi que l'article 1711-6 sont applicables ».

B – Exemptions accordées au niveau des sociétés filiales

Les exemptions visées par les articles 1711-8 et 1711-9 L.S.C. se distinguent des exemptions précédentes par le fait qu'elles sont accordées au **niveau des filiales** : en d'autres termes, dans les cas visés ici, il y a obligation de consolider dans le chef de la société mère, mais l'une ou l'autre des filiales ne peuvent ou ne doivent pas être consolidées.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

1) Exemption des filiales d'intérêt négligeable

Au vœu de l'article 1711-8 L.S.C., tel est le cas (facultativement) lorsque la filiale « *ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 1721-1, paragraphe 3* ». La filiale de **faible importance** peut être laissée en dehors de la consolidation si l'atteinte portée au principe de l'image fidèle n'est que faible.

La loi précise encore que le critère de l'importance économique ne peut être apprécié isolément au niveau d'une seule filiale. Par conséquent, lorsque plusieurs filiales, qui isolément satisfont au critère de l'importance économique négligeable, sont en cause et qu'ensemble elles représentent un poids non négligeable, alors l'exemption ne peut plus être invoquée : toutes les filiales sont à inclure dans la consolidation[1].

2) Exemption des filiales difficiles à consolider ou sur le point d'être vendues

Le paragraphe 3 de cet article prévoit encore trois exemptions (facultatives) de l'obligation de consolider. Tel est le cas lorsque :

« *1° des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise ;*

2° les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié ;

3° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure ».

Ad a) et b) : Ces exemptions s'expliquent essentiellement par le fait que, la consolidation étant mondiale, elle concerne également des filiales en pays lointains[1]. Les cas d'application de ces dispositions restent néanmoins rares.

Ad c) : Cette disposition permet à la société mère d'exclure les filiales qui sont destinées à faire l'objet d'une cession ultérieure, celles destinées à être détenues sur une base temporaire. « *Il ne serait guère défendable en effet d'inclure des entreprises qui n'appartiendraient que passagèrement au groupe. L'image que les comptes consolidés sont appelés à donner de ce dernier ne pourrait qu'en être déformée, et la comparaison des comptes consolidés du même groupe dans le temps en souffrirait encore davantage* »[1]. Comme le relève encore le commentaire des articles, la question est à cet égard surtout de savoir quand cette condition est réalisée. « *Si elle est prévue dans un avenir lointain, l'exclusion en serait abusive. Au contraire, simplement envisagée dans un délai rapproché sans que la forme de la cession soit nettement précisée devrait suffire pour justifier l'exclusion. La question serait cependant à réexaminer si l'intention de cession sérieusement envisagée tarderait finalement à se réaliser* »[1].

La Commission des normes comptables a pris la position que cette disposition suppose que la vente ait lieu dans un délai de 12 mois. Il nous paraît que cette position est trop restrictive.

1 – *Doc. parl.*, n° 3154, commentaire des articles, p. 31, ID 9821.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

3) Exemption obligatoire des filiales déformant l'image fidèle

L'ancien article 318 L.S.C. prévoyait qu'il y avait lieu **d'exclure obligatoirement** de la consolidation les entreprises ayant des activités à ce point différentes que leur inclusion dans la consolidation serait contraire à l'obligation d'image fidèle qui est prévue. Cette disposition a été abrogée par la loi du 10 décembre 2010.

SECTION III
MODES D'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDÉS

L'article 1712-1 L.S.C. est le pendant à l'égard des comptes consolidés de l'article 26 de la Loi de 2002 applicable aux comptes individuels des entreprises. Il est ainsi précisé que les comptes consolidés « *comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout* ».

Les comptes consolidés (comme les comptes individuels) doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente loi. Ils doivent encore donner « *une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation* ».

La loi renvoie ensuite aux comptes individuels, à savoir aux articles 34, 37 à 46 et 48 à 50 de la Loi de 2002.

Il existe différentes méthodes de consolidation. En doctrine comptable, on fait état des trois méthodes suivantes :

– la consolidation globale ;
– la consolidation proportionnelle ;
– la mise en équivalence.

■ § 1 – La méthode de l'intégration globale

La méthode de **l'intégration globale** consiste à reprendre dans les comptes consolidés la totalité des actifs et passifs compris dans les comptes individuels des entreprises consolidées. Telle est la solution reprise par la L.S.C. dont l'article 1712-3 dispose que : « *Les éléments d'actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé* ».

Il est évident que, si la société consolidante détient moins de 100 % du capital des entreprises consolidées, alors l'intégration totale de tous les avoirs des filiales consolidées dans le bilan de la société mère conduit à un bilan incorrect. En effet, le bilan consolidé de la société consolidante contient des actifs (et des passifs) qui ne lui reviennent pas, mais qui reviennent à des **associés minoritaires**.

L'intégration globale est donc compensée partiellement par l'attribution aux autres associés d'une quote-part de la valeur de l'actif net de la filiale égale à la quote-part de ces autres associés, les associés minoritaires.

■ § 2 – La méthode de l'intégration proportionnelle

L'« erreur » mentionnée au paragraphe précédent, inhérente à la méthode d'intégration globale, est directement corrigée par la méthode d'intégration proportionnelle

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

qui reprend dans le bilan consolidé uniquement les actifs et passifs dans la proportion détenue par la société mère.

Cette méthode est également envisagée par la directive, mais de façon **facultative**. Ce droit d'option prévu par la directive est transmis aux entreprises. En effet, en application de l'article 1712-17 L.S.C., il est prévu qu'en cas de direction conjointe d'une entreprise, celle-ci puisse être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus par l'entreprise comprise dans la consolidation.

Art. 1712-17 [anc. art. 335] L.S.C.

« *(1) Lorsqu´une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l´entreprise comprise dans la consolidation.*

(2) Les articles 1711-8 à 1712-16 s´appliquent mutatis mutandis *à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe (1).*

(3) En cas d´application du présent article, l´article 1712-18 ne s´applique pas lorsque l´entreprise faisant l´objet d´une consolidation proportionnelle est une entreprise associée au sens de l´article 1712-18 ».

■ § 3 – La méthode de mise en équivalence

La troisième méthode de consolidation est celle de la mise en équivalence également prévue par la loi (article 1712-18 L.S.C.) pour le cas où une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise non comprise dans la consolidation dans laquelle elle détient une participation, cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant.

Art. 1712-18 [anc. art. 336] L.S.C.

« *(1) Lorsqu´une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d´une entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 41 [de la Loi de 2002], cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant.*

Il est présumé qu´une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu´elle a 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L´article 1712-2 est applicable.

(2) Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1) celle-ci est inscrite au bilan consolidé :

1° soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d´évaluation prévues par la section XIII [au chapitre II du titre II de la Loi de 2002]. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l´annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois,

2° soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l´entreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d´évaluation prévues par le titre II du chapitre II [de la Loi de 2002] est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l´annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.

3° Le bilan consolidé ou l´annexe doit indiquer lequel des points 1° ou 2° a été utilisé.

4° Pour l´application des points 1° ou 2°, le calcul de la différence peut s´effectuer à la date d´acquisition des actions ou parts ou, lorsque l´acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l´entreprise est devenue une entreprise associée.

[...]

(9) Il peut être renoncé à l´application du présent article lorsque les participations dans le capital de l´entreprise associée ne présentent qu´un intérêt négligeable au regard de l´objectif visé à l´article 1712-1 paragraphe 3 ».

Il est présumé qu'une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a **20 % ou plus des droits de vote** des actionnaires ou associés de cette entreprise.

La mise en équivalence est une consolidation simplifiée encore parfois appelée consolidation « sur une ligne », alors que la consolidation globale et la consolidation proportionnelle représentent des consolidations « ligne par ligne ».

D'après l'article 1712-18 L.S.C., la consolidation selon la mise en équivalence n'est obligatoire que s'il y a participation détenue par une entreprise comprise dans la consolidation. Cette entreprise peut être soit la société mère soit une entreprise filiale pour autant qu'elle soit consolidée. « *Il en résulte que la mise en équivalence à l'égard des entreprises associées n'est obligatoire que dès lors qu'il y a effectivement établissement de comptes consolidés. Autrement dit, en présence d'une mère et de plusieurs filiales possédant des participations dans des entreprises associées, celles-ci peuvent ne pas être traitées par la méthode de mise en équivalence si des comptes consolidés entre le mère et les filiales ne sont pas établis, quelle que soit d'ailleurs la raison qui motive l'absence d'établissement des comptes consolidés* »[1].

1 – *Doc. parl.*, n° 3154, commentaire des articles, p. 51, ID 9821.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

5

PARTIE V – LE DROIT DE LA FAILLITE

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Cette partie n'est pas limitée à la faillite proprement dite (au sens strict de cette notion), mais elle inclut toutes **les procédures collectives de règlement** des difficultés financières des entreprises qui ne sont plus à même de régler leurs créanciers dans les délais prévus. Sont donc visés en premier lieu, bien entendu, la faillite, mais également la gestion contrôlée, le concordat, le sursis de paiement, etc.

Un projet de loi[1] adopté en début 2009 concernant les particuliers a pour objet d'introduire en droit luxembourgeois le régime de la faillite civile, dit « *procédure de rétablissement personnel* » consistant en un effacement des dettes avec liquidation du patrimoine. Dans son avis sur ce projet de loi, l'ABBL s'interroge quant à l'utilité du maintien dans le Code civil des dispositions relatives à la **déconfiture** civile. « *On vise ici l'article 1244, alinéa 2, en particulier qui confère au juge le pouvoir d'accorder des délais de paiement ou même un sursis à exécution. Ces mesures auront-elles désormais lieu de s'appliquer ou ne resteront-elles pas désormais lettre morte ? Les auteurs du projet de loi n'ont en effet pas abrogé les dispositions de droit commun, de sorte qu'un débiteur pourrait théoriquement invoquer à la fois les dispositions du Code civil et celles de la loi sur le surendettement. La jurisprudence française a toutefois précisé que les dispositions sur le surendettement dérogent au droit commun et ne peuvent donc se cumuler avec lui, ce qui n'est qu'une application du principe selon lequel le spécial déroge au général* ».

1 – *Doc. parl.*, n° 6021.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE I
LA FAILLITE

Le régime moderne de la faillite trouve ses sources au **Moyen Âge**, et ceci, plus précisément dans les statuts des villes commerciales de l'Italie du Nord. Ces statuts reconnaissaient l'état de cessation des paiements, le dessaisissement du débiteur, la période suspecte, le concordat[1].

Au Luxembourg, la législation sur la faillite est comprise dans le Code de commerce (Livre III – Des faillites, banqueroutes et sursis, art. 437-614), mais les dispositions visées ne reprennent pas les dispositions du Code de commerce de 1808. En effet, comme le législateur belge, le législateur luxembourgeois a procédé à une réforme de cette matière, et ceci, par la loi du 2 juillet 1870. Celle-ci reprend d'ailleurs de façon plus ou moins littérale les solutions introduites par la loi belge du 18 avril 1851.

Par ailleurs, un projet de loi relative à « *la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite […]* » (*Doc. parl.*, n° 6539 déposé le 1er février 2013) est en instance d'élaboration. À ce jour, ce projet de loi n'a pas encore été adopté[2].

CHAPITRE I
LES CONDITIONS DE LA FAILLITE

L'état de la faillite est prévu par l'article 437 C.com., ainsi libellé : « *Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit est ébranlé est en état de faillite* ».

La mise en faillite suppose donc la réalisation de trois conditions de fond (détaillées ci-après), ainsi que d'une condition de forme.

Les trois conditions de fond sont :

1) le débiteur est **commerçant** et,
2) il a **cessé les paiements** et,
3) le **crédit** est **ébranlé**.

Ad 1 : Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite si la cessation de paiements remonte à une époque où il était encore commerçant. La faillite d'un commerçant peut être déclarée **après son décès**, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiements.

Ad 2 : La cessation de paiements est l'impossibilité constatée dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à ses engagements[3].

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 42.

2 – Du fait que ce projet de loi va sans doute changer fondamentalement la matière de la faillite en droit luxembourgeois, il a été renoncé à procéder à une refonte globale du présent titre de cet ouvrage.

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 68.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Ad 3 : La cessation de paiements et la constatation que le crédit est ébranlé sont deux éléments qui sont en relation étroite l'un avec l'autre. La cessation de paiements est la conséquence de l'**absence de crédit** : « *Le commerçant cesse ses paiements parce que sa caisse est vide et qu'il ne trouve plus à emprunter* »[1]-[2].

La loi considère le commerçant comme failli par cela seul qu'il a cessé ses paiements et que son crédit se trouve ébranlé ; il résulte de ce principe que le tribunal de commerce se trouve **obligé** de tirer la conséquence légale des faits patents en cause, c.-à-d. de déclarer la faillite, sans avoir égard ni à la solvabilité éventuelle du débiteur ni aux mobiles plus ou moins intéressés qui ont déterminé son créancier à demander la faillite.

Spécialement, le tribunal ne pourrait accorder au débiteur en cessation de paiements les délais par application de la loi du 18 mars 1915, celle-ci ne s'appliquant pas à une cessation générale de paiement[3].

SECTION I
LA QUALITÉ DE COMMERÇANT

Les conditions requises pour être considéré comme commerçant font l'objet du premier chapitre de la première partie (voir p. 33).

Le droit de la faillite faisant partie du droit spécial des commerçants, la faillite ne peut atteindre les personnes qui sont incapables d'exercer une profession commerciale (p. ex., les mineurs, les incapables, autrefois la femme mariée).

La situation est différente à l'égard des personnes qui, nonobstant l'interdiction d'exercer le commerce qui leur est faite, font de façon habituelle des actes de commerce, fût-ce de manière accessoire, en infraction avec la défense qui leur a été faite. Ainsi un avocat, un notaire, un huissier, etc. peuvent tomber en faillite[4] (mais uniquement s'ils poursuivent une activité commerciale en violation des règles régissant leurs professions respectives).

Si un fonds de commerce est exploité non par son propriétaire, mais par un tiers agissant en son nom personnel et pour son propre compte, cette exploitation se traduit par une répétition d'actes de commerce, accomplie à titre professionnel, ce qui suffit à conférer à l'exploitant la qualité de commerçant, bien que le fonds de commerce ne lui appartienne pas. L'exploitant est dès lors susceptible d'être déclaré en faillite[5].

En réalité, il convient de distinguer selon que le débiteur est une **personne physique** ou non.

---

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 74.

2 – CA Gand du 18 août 1923, *Pas.*, 1924, III, p. 141.

3 – TA Lux. du 18 mars 1916, *P.*, nº 10, p. 216, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 64.

5 – TA Lux. du 23 novembre 1967, *P.*, nº 21, p. 99.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

■ § 1 – Le débiteur est une personne physique

La qualification de commerçant, souverainement appréciée par les juges du fond, résulte de la **situation de fait** et des circonstances du cas d'espèce qui conduisent à conclure à **l'exercice d'un commerce**(1). Elle ne résulte pas des qualifications qu'un individu se donne, le cas échéant faussement, que ce soit par erreur ou de manière intentionnelle(1).

■ § 2 – Le débiteur est une société

Pour pouvoir être déclaré en état de faillite, il faut être commerçant ou bien avoir été commerçant dans les six mois antérieurs à la déclaration de faillite. Le commerçant qui depuis plus de six mois a cessé tout commerce ne peut plus être déclaré en état de faillite(2).

S'agissant d'une société commerciale, le statut de commerçant du débiteur est incontestable. La société dont la **clôture de la liquidation** est intervenue depuis plus de six mois ne peut plus être déclarée en faillite(3). Cette clôture met définitivement fin à la société, avec la seule entorse que, pendant cinq ans, la société peut être attaquée en justice (par le biais de son liquidateur) pour répondre aux actions des tiers (« survivance passive »). L'action en déclaration de faillite se trouve donc limitée dans le temps à un délai de six mois seulement après cette clôture de la liquidation. Une société peut être déclarée en faillite même si plus de six mois se sont écoulés depuis sa **dissolution** et sans qu'il faille démontrer que le liquidateur a accompli des actes de commerce par nature. Elle conserve son caractère commercial tel qu'il découle de son objet statutaire jusqu'à la **clôture de la liquidation**(4).

La dette commerciale étant le résultat d'un acte de commerce, mais n'en constituant point l'exercice, il s'ensuit que le seul fait que le défendeur à une demande en déclaration de faillite est tenu de dettes commerciales ne saurait lui conférer la qualité de commerçant, ni partant justifier sa déclaration en état de faillite(5).

■ § 3 – Le débiteur s'est retiré des affaires

Il est question ici du cas où le commerçant a cessé son activité commerciale au moment du jugement déclaratif de la faillite. Nonobstant le fait que, à ce moment-là, il ne s'agissait donc plus d'un commerçant, la faillite peut être déclarée à son égard, mais à condition que l'état de cessation de paiements remonte à une période où le débiteur était encore commerçant. La même solution s'applique au cas où le commerçant est décédé avant le jugement déclaratif. La raison de cette solution est la suivante : « *La cause de la faillite, existant au moment où le débiteur exerçait le*

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 64.

2 – Cour du 17 février 1876, 1, 199 ; Cour du 28 janvier 1887, *P.*, 3, p. 145 ; Diekirch, 20 juin 1890, *P.*, 3, p. 164, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – CA Bruxelles du 13 octobre 1951, *Pas.*, 1952, III, p. 64. ; Cass. du 2 décembre 1952, *R.C.J.B.*, p. 288, note J. Heenen, p. 299.

4 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 383.

5 – TA Lux. du 3 novembre 1960, *P.*, no 15, p. 286, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

commerce, doit logiquement produire ses effets et faire reconnaître aux créanciers un droit acquis »[1].

Pour qu'il y ait lieu à déclaration de faillite d'un commerçant après son décès, il faut qu'il soit mort en état de cessation de paiements ; cette cessation doit être effective. Des versements à compte et paiements isolés destinés plutôt à masquer l'état de cessation de paiements sont impuissants à annihiler cet état, qui a réellement préexisté à l'époque critique[2].

■ § 4 – Extension de la faillite au maître de l'affaire

La théorie de l'extension de la faillite au maître de l'affaire, pratiquée la première fois en 1951[3], a connu un « *extraordinaire développement* »[4] dans le courant des années 1960 et 1970.

A – Extension prétorienne de la faillite

Dès la fin des années 1960, la jurisprudence est sortie de sa réserve, et ce fut la période de gloire de l'extension de faillite. Le caractère d'automaticité est devenu de plus en plus poussé, de sorte que la faillite d'une petite société entraînait presque inévitablement celle du **maître de l'affaire**[5].

Ainsi, un arrêt de cour d'appel[6] étendit la faillite d'une société à deux autres sociétés en considérant que les deux sociétés exerçaient le commerce par **prête-nom** à l'intervention de la troisième. Les éléments de fait sous-jacents étaient notamment les suivants : les sociétés avaient les mêmes associés, les mêmes gérants, le même siège social, utilisaient partiellement la même marque, le personnel passait de l'une à l'autre, les dettes des unes étaient payées avec les ressources des autres, les biens respectifs des différentes sociétés ne pouvaient plus être distingués[7].

L'extension de la faillite au maître de l'affaire a été justifiée de deux façons différentes : soit l'on considérait que la société était en réalité un **prête-nom** pour le maître de l'affaire, soit l'on invoquait le **caractère fictif** de la société dont la personnalité morale s'effaçait en faisant apparaître le seul maître de l'affaire[8]. L'extension de la faillite peut en effet se faire sur deux fondements différents : soit la société est fictive, soit il y a interposition de personnes. Dans les deux cas, le véritable commerçant est le maître de l'affaire. En écartant la situation simulée au profit de la situation

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 64.

2 – Cour du 15 mai 1903, *P.*, n° 6, p. 399, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Trib. com. Bruxelles du 17 février 1951, *J.C.B.*, 1951, p. 159.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 633.

5 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 246.

6 – CA Gand du 14 mars 1978, *R.P.S.*, 1979, p. 269.

7 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 264.

8 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 273.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

réelle (donc l'acte ostensible au profit de la contre-lettre), il apparaît que les dettes sociales vis-à-vis des créanciers sont en fait les siennes[1].

Cette sanction est bien différente dans ses effets de la responsabilité des dirigeants sociaux pour fautes : les organes sociaux doivent rendre compte de leurs fautes à leurs mandants et parfois aux tiers. Leur responsabilité est limitée au dommage imputable directement à leur faute de gestion.

L'extension de la faillite sanctionne le recours jugé artificiel aux techniques du droit des sociétés. « *La règle de la responsabilité limitée est utilisée abusivement par un commerçant qui veut éviter d'exposer tous les biens aux risques d'entreprise. Il crée de toutes pièces, avec la complicité d'un ou de plusieurs hommes de paille, une société qui n'est qu'une façade et dont la raison d'être est d'abriter son patrimoine et de le soustraire à l'emprise de ses créanciers* »[2].

Depuis la reprise en droit national des dispositions de la Première directive en matière de droit des sociétés, il paraît certain qu'il ne sera plus possible d'invoquer le caractère fictif de la société, du moins pas à l'égard des sociétés de capitaux. En effet, à l'égard de celles-ci, l'absence d'*affectio societatis* n'est plus une cause de nullité de la société[3].

Dire qu'une société est fictive, c'est dire qu'elle n'existe pas. Or, les cas de nullité sont énumérés limitativement par la directive[4]. En tout état de cause, même à supposer qu'une cause de nullité existe, elle n'aurait pas d'effet *ex tunc*, mais seulement *ex nunc*.

Pas plus que sur la base de la théorie de la fictivité, l'existence de la société ne peut être écartée sur la base de celle de **l'inexistence**[5]. En effet, l'article 11 de la directive ne se limite pas aux cas de nullité des sociétés, mais vise les cas « *d'inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d'annulabilité* ». Seuls les cas de nullité prévus par la L.S.C. peuvent être mis en œuvre.

La fictivité de la société étant ainsi écartée (du moins pour les sociétés soumises à la Première directive), reste à invoquer une autre forme de simulation, celle de **l'interposition de personne**. La simulation peut se limiter à une ou plusieurs opérations déterminées que le prête-nom exécute pour le compte du mandant. Il se peut aussi qu'il exerce un « office permanent » pour le compte du maître de l'affaire. « *La société, qui abrite l'activité personnelle du maître de l'affaire, est un prête-nom. La simulation est écartée lorsque sont révélés, généralement après déclaration de la faillite de la société, les véritables rapports contractuels entre les créanciers sociaux et le maître de l'affaire, mandant. Les tiers peuvent se prévaloir de la contre-lettre – c'est-à-dire de la convention tacite de prête-nom qui permet au maître de l'affaire d'utiliser la société à son profit exclusif – si tel est leur intérêt. Ils tiendront ainsi le maître de l'affaire pour leur propre débiteur* »[6].

---

1 – Cass. b. du 1er juin 1979, note F. t'Kint, *R.C.J.B.*, 1981, p. 55.

2 – Cass. b. du 1er juin 1979, note F. t'Kint, *R.C.J.B.*, 1981, p. 54.

3 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 273.

4 – Cass. b. du 1er juin 1979, note F. t'Kint, *R.C.J.B.*, 1981, p. 61.

5 – Cass. b. du 1er juin 1979, note F. t'Kint, *R.C.J.B.*, 1981, p. 62.

6 – Cass. b. du 1er juin 1979, note F. t'Kint, R.C.J.B., 1981, p. 69.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette utilisation critiquable de la personnalité morale (et de la responsabilité limitée) aura pour conséquence de mettre le passif de la société à charge du maître de l'affaire ou de lui étendre la faillite sociale. Sur la base de certains éléments de fait, la Cour de Bruxelles[1] a étendu la faillite de la société anonyme à son administrateur délégué : prolongation par la société de l'activité personnelle exercée auparavant par cet administrateur-délégué, confusion du patrimoine social et du patrimoine personnel de celui-ci, utilisation par la société d'actifs personnels ni apportés ni vendus, paiements de dettes personnelles par les fonds prélevés dans les caisses de la société sans comptabilisation adaptée, etc.[2]

L'extension de la faillite ne peut plus être basée sur le caractère fictif de la société elle-même[3].

Certaines décisions prononcent la faillite du maître de l'affaire après celle de la ou des sociétés exploitées par lui à son avantage personnel. Les **critères** dégagés par la jurisprudence pour justifier une telle extension sont notamment les suivants :

- capitalisation insuffisante de la société ;
- absence de fonctionnement ou fonctionnement irrégulier des organes sociaux ;
- dépassement des pouvoirs accordés par les statuts ou par les organes de la société ;
- confusion des comptes de l'associé prépondérant et des comptes de la société ;
- absence de comptabilité régulière, utilisation des deniers de la société pour l'apurement des dettes personnelles ou inversement ;
- utilisation d'actifs de la société comme des actifs propres, etc.[4]

Il faut que les trois conditions de la faillite du maître d'affaire soient remplies dans son chef, et le juge du fond doit en constater la réalité. En particulier, le maître de l'affaire doit être personnellement commerçant, qualité qui peut résulter de l'exploitation du commerce de la société dont il était le maître. Mais, en ce cas, la faillite ne peut être déclarée plus de six mois après celle de la société, étant donné que l'activité commerciale aura cessé à ce moment-là[5].

Dans ces cas d'extension de la faillite, les différentes décisions relèvent notamment les faits suivants (qui sont très proches de ceux du cas précédent) :

- une participation prépondérante et même écrasante (mais ce point n'est jamais suffisant en tant que tel) ;
- le non-fonctionnement des organes sociaux ;
- le fait que des décisions très importantes sont prises par le maître de l'affaire sans passer par les organes sociaux légalement ou statutairement compétents ;
- le manque de distinction entre le patrimoine de la société et celui du maître de l'affaire ;
- l'utilisation par le maître de l'affaire de biens sociaux à des fins personnelles ;

1 – Cour de Bruxelles du 20 février 1963, *R.P.S.*, 1964, p. 214.

2 – J. van Ryn et P. van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965, p. 317.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 250.

4 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 634.

5 – P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 635.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

- la conclusion de prêts sans intérêts pour la société, mais à l'avantage soit du maître de l'affaire soit d'autres sociétés du groupe ;
- des prélèvements faits à titre personnel dans une caisse noire de la société ;
- tenue de la comptabilité d'une manière complètement irrégulière ;
- etc.[1].

À propos du principe de **l'extension de la faillite** au maître de la société : « *Attendu que, pour l'analyse de ce principe et son application, il échet de se référer primordialement à la jurisprudence et à la doctrine belges […]* »[2].

« *Il est actuellement admis, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que la faillite d'une société peut, dans certains cas, être étendue ou appliquée à celui qui a été le véritable maître de l'affaire. L'effet recherché par l'extension de la faillite au dirigeant d'une société est de sanctionner l'abus ou l'utilisation détournée de la personnalité juridique d'une personne morale, cet abus de pouvoir consistant un détournement des fonctions de l'entreprise à des fins personnelles ou étrangères à l'entreprise* »[3].

« *L'abus ne découle pas de la détention d'une position dominante, mais du comportement du dirigeant, qui ne respecte ni la finalité distincte de la société, ni le fonctionnement des organes sociaux, ni son autonomie patrimoniale. Le dirigeant, qui agit de la sorte, est le bénéficiaire occulte de l'exploitation exercée par la société. Il acquiert ainsi la qualité de commerçant à travers les actes commerciaux de la personne morale, de sorte qu'il n'y a pas alors lieu de rechercher, si le dirigeant a accompli lui-même des actes de commerce pendant les six mois qui précèdent le jugement déclaratif de faillite de la personne morale. Le dirigeant ne perd alors sa qualité de commerçant qu'au moment où la société elle-même cesse ses activités, la combinaison des articles 437, alinéas 2 et 3, et 442, alinéa 3, du Code de commerce conduit à la conclusion que la faillite du maître de l'affaire ne peut être déclarée plus de six mois après la faillite de la société (cf. Trib. com. Bruxelles, 8 septembre 1980, précité, p. 231 ; Cass. belge, 26 octobre 1979, Rev. prat. soc., 1981, p. 106 ; Trib. Lux., 29 mars 1985, faillite Philco c/Becker et les références y citées)* »[4].

Dans cette espèce, le juge ne retint pas l'extension de la faillite dans la mesure où le prétendu « maître de l'affaire » avait conservé une activité commerciale en son nom propre tant avant qu'après la déclaration de faillite de la S.à r.l. concernée : « *Eu égard à cette autonomie de l'activité commerciale de [le prétendu « maître de l'affaire »] par rapport à [la S.à r.l.], la défaillance de l'une n'a pas rendu impossible la survivance de l'autre, de sorte que l'exigence que seuls peuvent être déclarés en faillite les commerçants qui ont cessé leurs paiements et dont le crédit est ébranlé, doit être remplie, quelles que soient les modalités d'ouverture de la faillite, ou la qualification que le demandeur donne à sa demande (cf. Cour d'appel de Bruxelles, 30 juin 1982, Rev. prat. soc., 1982, p. 209 ; Cass., 11 septembre 1981, Pas. belge, 1982, I, 56 et 3 septembre 1981, Pas. belge, 1982, I, 18)* »[4].

---

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 264 et les multiples références de jurisprudence y citées.

2 – TA Lux. du 28 juin 1968, n° 22.684, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Trib. com. Bruxelles, 8 septembre 1980, *Rev. prat. soc.*, 1980, p. 229 et les références y citées.

4 – TA Lux. du 9 juin 1989, n° 38.792, ID 11930.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Pour songer à **étendre la faillite d'une S.à r.l. à son gérant**, « *il doit être établi que le dirigeant a, à titre personnel, cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé, la faillite de la société n'en étant pas une preuve suffisante* ». En l'espèce, diverses **fautes du gérant** étaient invoquées, mais celles-ci étaient en elles-mêmes susceptibles d'engager la responsabilité de l'intéressé envers la société et les tiers, et ce, uniquement pour les conséquences dommageables de ces fautes. « *Le gérant d'une société à responsabilité limitée, fût-il même associé, voire associé majoritaire, n'a pas pour autant et nécessairement la qualité de commerçant. Cette qualité ne peut lui être attribuée qu'exceptionnellement et à condition que soit établie, non seulement la "confusion des patrimoines", mais encore :- soit la fictivité pure et simple de la personnalité juridique de la société ; – soit un abus systématique de la personnalité morale de la société par le dirigeant, la société n'étant que le prête-nom à travers lequel dirigeant exerce une activité commerciale propre (Cass. belge, 11 septembre 1981, Pas. belge 1982, I, 56 ; Cour d'appel de Mons, 9 novembre 1988, RPS 1989, 193)* »[1].

B – Extension légale de la faillite

Entre-temps, le législateur a consacré la possibilité d'extension de la faillite par des dispositions légales.

Art. 495 C.com.

« *En cas de faillite d'une société, peut être déclaré personnellement en faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, qui a*

- *sous le couvert de la société masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ou*
- *disposé des biens sociaux comme des siens propres ou*
- *poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.*

Le passif de la faillite du dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant la faillite de la société ».

Art. 495-1 C.com.

« *Lorsque la faillite d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur, que les dettes doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l'égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite.*

L'action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir, sans toutefois que le délai pour exercer l'action puisse être inférieure à un an ».

1 – TA Lux. du 10 janvier 1992, ID 11935.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Ces dispositions ont été introduites par la loi du 21 juillet 1992. La loi distingue deux sanctions bien différentes : l'article 495 C.com. déclare **l'extension** de la faillite de la société aux **dirigeants sociaux**, alors que l'article 495-1 C.com., sans aller jusqu'à déclarer ceux-ci comme personnellement en faillite, met le **passif social à la charge des gérants** ayant commis des fautes graves et caractérisées dans la mesure où celles-ci ont contribué à la faillite.

En vertu de cette dernière disposition, les dirigeants sociaux, au sens large, peuvent être déclarés redevables des dettes sociales lorsque des « *fautes graves et caractérisées* » ont été établies à leur égard afin de « *combler le passif* » (action en comblement de passif).

En dehors de ces cas, il peut y avoir mise en cause de la responsabilité des organes de la société, et encore, sur la base de dispositions générales relatives à la responsabilité des dirigeants des sociétés : il s'agit en particulier des articles 441-9 et 710-16 L.S.C. rendant les dirigeants des S.A. et des S.à r.l. responsables des dommages causés par eux en raison de la violation des dispositions légales ou encore des dispositions statutaires.

Par ailleurs, même les tiers sont susceptibles d'engager leur responsabilité à l'égard de la société, et ceci, sur la base du droit commun de la **responsabilité civile délictuelle** de l'article 1382 C.c. À ce titre, peut notamment être mise en cause la responsabilité du **banquier** dispensateur du crédit, auquel il est reproché d'avoir, par son comportement consistant à renouveler de manière imprudente le crédit au commerçant, contribué à l'aggravation du passif social. Il peut donc être condamné pour être redevable de l'**augmentation du passif social** qui s'est produite entre le moment du renouvellement du crédit et le jour du jugement déclaratif de la faillite[1].

Ces dispositions peuvent également atteindre les dirigeants sociaux dans la mesure où ils sont tenus pour coupables d'avoir continué de manière déraisonnable l'exploitation « *d'une activité irrémédiablement compromise* ». Est donc mise à charge des dirigeants l'augmentation du passif social non couvert par l'actif réalisé depuis le moment où la cessation de paiements aurait dû être déclarée par les dirigeants[2].

Lorsqu'il existe une confusion caractérisée d'activité et de patrimoine entre deux sociétés et que l'une d'elles a été déclarée en faillite, le tribunal est fondé à prononcer l'extension de la faillite à l'égard de l'autre société[3].

SECTION II
CESSATION DE PAIEMENTS

La cessation de paiements est **l'impossibilité** constatée dans laquelle se trouve le débiteur de **faire face à ses engagements**[4]. La constatation de cette situation appartient au pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond.

1 – TA Lux. du 7 décembre 1990, n° 39.413, ID 11170.

2 – TA du 19 décembre 1997, n° 40.811, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. 18 février 1970, *P.* , n° 21, p. 393, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 68.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La déclaration de faillite n'est possible que si la cessation de paiements est inhérente à des dettes commerciales[1].

■ § 1 – Notion de cessation de paiements

La **cause** de la cessation de paiements est **indifférente**. Il est sans objet de savoir quels éléments ou événements ont conduit à cette situation. Peu importe que le débiteur soit fautif ou que la situation soit due à un cas de force majeure. Il est encore sans importance de savoir quels sont les mobiles qui poussent le créancier à poursuivre en faillite. Il en va de même de la question de savoir si la faillite est dans **l'intérêt des créanciers**[2].

L'état de cessation de paiements doit être distingué de la notion **d'insolvabilité**. Un débiteur est insolvable si son passif (ses dettes) dépasse la valeur de son actif. En d'autres termes, la réalisation de tous ses actifs ne permettra pas de désintéresser tous les créanciers. Cette situation correspond en fait à la notion de **déconfiture,** notion qui ne concerne que les particuliers autres que des commerçants : « *la déconfiture d'un particulier non-commerçant répond à une situation où son passif exigible est supérieur à son actif réalisable, c'est-à-dire lorsque l'actif global que possède ce débiteur ne peut suffire à payer l'ensemble de ses créanciers* »[3].

La notion de cessation de paiements est autre : il se peut en effet qu'un débiteur soit insolvable dans ce sens-là, sans être pour autant en cessation de paiements. S'il arrive à faire face aux échéances, car son crédit est toujours suffisant, il n'est pas en état de cessation de paiements.

Tel est le cas notamment d'une société filiale d'un groupe ayant réalisé des pertes importantes qui font plus qu'absorber ses fonds propres, y compris le capital social. La société n'est pas en cessation de paiements pour la raison que sa société mère met à disposition de la filiale les ressources lui servant à faire face à ses échéances au moyen de prêts ou d'avances.

L'inverse est vrai aussi : un débiteur peut être en cessation de paiements tout en étant parfaitement solvable. Il se peut que les actifs soient réalisables seulement avec difficulté, de sorte que la cessation de paiements existe, car le débiteur ne peut faire face aux échéances sans pour autant bénéficier de crédits auprès de ses créanciers[4].

■ § 2 – Éléments révélateurs de l'état de cessation de paiements

La loi ne définit pas les éléments que le juge doit prendre en considération pour conclure à l'état de cessation de paiements. Le juge a un pouvoir d'appréciation discrétionnaire à cet égard. Il prendra généralement en considération les points suivants :

– l'aveu de la cessation de paiements par le débiteur ;

– les protêts d'effets de commerce dont le commerçant est débiteur principal ;

1 – E. Escarra et J. Rault, *Principes de droit commercial* ; CA com. du 16 février 2005, nº 29.172.

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 75.

3 – M.-F. Antoine, *Tout savoir sur la faillite*, p. 1.

4 – M.-F. Antoine, *Tout savoir sur la faillite*, p. 12.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

– les assignations en paiement ;
– l'aveu de la réalisation de tous les éléments d'actif ;
– la fermeture de magasins ;
– la disparition du commerçant sans laisser de mandataire-liquidateur[1].

Selon la jurisprudence, l'ouverture de la faillite ne peut être fixée qu'au jour où il y avait cessation de paiements et où le crédit était ébranlé ; cet état doit résulter clairement des faits articulés et le juge appréciera la pertinence de ces faits ; un simple protêt n'implique pas nécessairement l'état de cessation de paiements, surtout lorsqu'il n'est pas accompagné d'autres circonstances qui démontrent qu'il y a cessation de paiements évidente[2].

Les éléments constitutifs de la faillite, à savoir la cessation de paiements et **l'ébranlement du crédit,** peuvent résulter non seulement de poursuites dirigées contre le commerçant ou de protêts, mais de tous faits patents attestant le désarroi des affaires du débiteur et son impuissance à faire face à ses obligations. Ne peuvent toutefois être prises en considération que les **créances liquides et exigibles** à l'exception de celles qui sont sérieusement contestées[3].

Une gêne financière momentanée du débiteur ne constitue pas la cessation de paiements nécessaire pour entraîner sa mise en faillite[4]-[5]. Dans une affaire soumise au tribunal d'arrondissement, la faillite fut demandée par les administrations fiscales. Après le jugement de faillite, tous les retards d'impôts furent réglés par un des administrateurs. La société faillie a fait appel contre la décision du tribunal en contestant que, au jour du prononcé, le crédit ait été ébranlé. La cour fit droit à cette argumentation en retenant « *Le fait par un administrateur et propriétaire de la société de mettre à disposition de la société les fonds nécessaires pour apurer ses dettes fait présumer que le crédit de la société n'était pas ébranlé au jour de la faillite. Le crédit ne doit en effet pas nécessairement provenir d'un institut de crédit tel que l'entend le tribunal* »[6].

Le tribunal de commerce saisi d'une demande en sursis de paiement ne commet aucun excès de pouvoir en prononçant d'office la faillite du débiteur si l'instruction révèle que celui-ci a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé ; ce n'est qu'après avoir accordé un sursis provisoire et avoir émis l'avis requis par les articles 597 et 598 du Code de commerce qu'il se trouve provisoirement dessaisi au profit de la cour jusqu'après la décision de celle-ci[7].

---

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 69.

2 – Lux. du 5 décembre 1874, *P.*, nº 1, p. 6, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 4 février 1933, *P.*, nº 13, p. 51, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 20 février 1934, *P.*, nº 13, p. 268, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – TA du 20 février 2006, *BIJ*, 2006, nº 8, p. 210.

6 – CA (com.) du 16 février 2005, nº 29.172, *F. Fayot*, *BIJ*, 2006, nº 2, p. 44, ID 20886.

7 – Cour 6 novembre 1934, *P.*, nº 13, p. 296, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION III
CRÉDIT ÉBRANLÉ

La cessation de paiements et la constatation que le crédit est ébranlé sont deux éléments en relation étroite l'un avec l'autre. La cessation de paiements est la conséquence de l'absence de crédit : « *Le commerçant cesse ses paiements parce que sa caisse est vide et qu'il ne trouve plus à emprunter* »[1]-[2].

Cette condition ne figurait pas dans la loi française de 1838 et fut introduite dans la loi belge de 1851.

L'ébranlement du crédit est le reflet de la perte de confiance des contractants du commerçant qui soit refusent de lui accorder de nouveaux crédits (en ce qui concerne les établissements de crédit), soit refusent d'accorder des délais de paiement (fournisseurs, p. ex.)[3].

Si la souscription d'une **lettre de change** constitue l'exercice d'un acte de commerce, cette souscription ne procure cependant jamais par elle-même des ressources à celui qui la pratique et n'est par conséquent pas susceptible d'être l'objet d'une profession. Dès lors, la seule souscription de lettres de change, même d'une façon habituelle, par le défendeur à une demande en déclaration de faillite ne saurait lui conférer la qualité de commerçant ni, partant, justifier sa déclaration en état de faillite[4].

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 74.

2 – CA Gand du 18 août 1923, *Pas.*, 1924, III, p. 141.

3 – M.-F. Antoine, *Tout savoir sur la faillite*, p. 13.

4 – Lux. du 3 novembre 1960, *P.*, no 18, p. 286, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
L'ÉTAT DE FAILLITE

Le mot faillite trouve sa racine dans le verbe latin « fallere » qui signifie « tromper ». Dans ce sens, celui qui ne fait pas face aux engagements aux dates prévues trompe ceux qui lui ont fait crédit. L'activité commerciale est basée sur le crédit personnel qui en est l'âme[1].

SECTION I
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE

La faillite est réservée à la classe des commerçants.

§ 1 – Dualité des régimes d'insolvabilité

Seuls les commerçants sont susceptibles de tomber en faillite. Cette solution se justifie par leurs **particularités** par rapport aux particuliers notamment. En effet, les effets de l'insolvabilité du commerçant sont autrement importants que ceux résultant de la **déconfiture** des débiteurs civils. En général, les dettes des commerçants (que ce soit en nombre ou en montant) sont plus importantes que celles des particuliers. En outre, les commerçants doivent pouvoir compter sur les rentrées de trésorerie aux échéances convenues, et ceci, surtout afin de pouvoir faire face à leurs propres engagements. Le non-paiement d'une dette donnée peut avoir des **effets en cascade** mettant donc en cause la solvabilité non seulement du créancier, mais encore celle des créanciers de ce créancier, etc.

Si les non-commerçants sont également obligés de payer leurs dettes aux échéances prévues, la loi ne prévoit pas de réglementation d'ensemble à leur égard.

Le Code civil ne comprend que quelques dispositions éparses à l'égard des débiteurs qui sont en « déconfiture ». La déconfiture est un état de pur fait qui se distingue principalement de l'état de faillite résultant d'un jugement publié[2]. Ces créanciers d'un non-commerçant ne sont pas groupés en une masse dont les intérêts sont confiés à un mandataire spécial, mais chaque créancier agit en vertu d'un droit individuel et pour son compte individuel[2]. Le débiteur civil n'est pas dessaisi de l'administration de ses biens. Les actes qu'il a posés ne peuvent être attaqués que par **l'action paulienne** dans la mesure où ils sont faits en fraude aux droits de leur créanciers. Le débiteur civil ne peut pas bénéficier d'un concordat des créanciers.

En cette matière, le législateur a introduit une procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre de la loi du 8 décembre 2000 concernant la prévention du **surendettement** et portant introduction d'une procédure de règlement collectif en cas de surendettement[3]-[4].

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 37.

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 38.

3 – *Mém.* A 136 du 27 décembre 2000, p. 2972.

4 – N. Stoffel et M. Lemal, « Aperçu sur le traitement du surendettement des particuliers au G.-D. de Luxembourg », *ALJB, Droit bancaire et financier*, Vol. 2, pp. 603 ss.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette procédure comporte une phase de règlement conventionnel et une phase de règlement judiciaire devant le juge de paix. Sont exclus de cette procédure les commerçants (soumis aux règles de la faillite, etc.). Tant dans la phase du règlement conventionnel que dans celle du redressement judiciaire, il peut y avoir remise totale ou partielle des dettes (art. 5 et 14 de la loi du 8 décembre 2000)[1].

§ 2 – Unité et universalité de la faillite

La faillite « *est une et indivisible : il ne doit y avoir qu'une seule faillite, qu'une seule procédure, qu'une seule juridiction compétente puisque le but même de la faillite est de soumettre à un même régime l'ensemble des intérêts ayant trait à une même masse créancière. Cette unité réduit les frais, diminue les lenteurs de la procédure, et évite la contrariété des jugements. Le résultat que la faillite doit permettre d'atteindre, n'est-il pas une répartition aussi égale que possible de l'actif, dans un minimum de temps, avec un minimum de frais ? Pratiquement, l'institution ne peut rendre pareils services que si elle embrasse en leur totalité l'actif et le passif, quels que soient les endroits où se trouvent leurs divers éléments* »[2].

Ce principe explique en particulier qu'un débiteur ne puisse être déclaré en faillite une deuxième fois avant que la première faillite ne soit clôturée. Ce principe est illustré par l'adage « *Faillite sur faillite ne vaut* »[3]. Il ne peut être appliqué qu'une seule faillite à un moment donné à l'égard d'un même débiteur.

La règle de **l'unité de la faillite** qui soumet la faillite à une loi unique entraîne son universalité dont l'effet est l'application intégrale de cette loi unique. Cette règle peut se justifier soit par l'argument selon lequel la faillite concerne le statut personnel du commerçant, soit par le principe d'égalité entre créanciers qui doit être respecté et selon lequel l'intégralité du patrimoine du débiteur est le gage commun des créanciers entre lesquels règne une **égalité rigoureuse**[4].

Si l'application de ces règles d'unité et **d'universalité de la faillite** ne soulève pas de difficultés majeures sur un plan purement national, il n'en va pas de même en cas de faillite dont les effets concernent plusieurs États. Ainsi, lorsqu'une faillite a été déclarée à l'étranger et que l'actif du débiteur comprend des actifs situés au Luxembourg (notamment des immeubles), alors les formalités de la loi luxembourgeoise devront être respectées si l'on veut procéder à l'exécution de la réalisation des biens visés.

La loi sur les faillites, en tant qu'elle règle **l'état et la capacité** du failli, relève du **statut personnel**. Dès lors, le dessaisissement qui résulte de la faillite est inhérent à la personne du failli et s'étend à tous ses biens, quel que soit le pays où ils sont situés[5].

---

1 – S'adressant exclusivement à des particuliers non commerçants, l'étude de ce régime dépasse le cadre du présent ouvrage.

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 50.

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 51.

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 52.

5 – Diekirch du 2 août 1894, *P.*, no 4, p. 17 ; Lux. du 22 janvier 1909, *P.*, no 8, p. 22, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

■ § 3 – Procédure collective de la faillite

L'effet de la déclaration de faillite est que les créanciers perdent le **droit d'agir personnellement** contre leur débiteur. « *Une liquidation globale de l'actif est organisée au profit de l'ensemble des créanciers qui forment obligatoirement "masse", et qui sont légalement représentés par un curateur ; les créanciers, qui ne peuvent plus exercer de poursuites individuelles, sont groupés en une espèce d'association de plein droit, dont le gage commun est liquidé par un mandataire judiciaire, agissant au nom et dans l'intérêt de tous* »[1]. Cette procédure fondée sur le principe **d'égalité** des créanciers devrait avoir des effets favorables sur le crédit commercial. « *Par la nature égalitaire, que consacre le concours obligé dans la masse, l'institution de la faillite favorise le crédit commercial, puisque quiconque traite avec un commerçant sait qu'il obtiendra sa part équitable dans l'actif, si, par malheur, son débiteur cesse ses paiements. Le paiement n'est plus le prix de la course entre les créanciers !* »[1].

■ § 4 – Possibilité de concordat

Dans la quasi-totalité des cas, la procédure de déclaration de faillite se traduit par la réalisation judiciaire des biens. Cette issue n'est toutefois pas inéluctable. Le curateur, après avoir établi l'état des biens et des dettes du débiteur failli, peut proposer un **arrangement** appelé « **concordat** ». Cette proposition est faite à la communauté des créanciers regroupés en assemblée générale. Cette assemblée décide par vote majoritaire d'adopter cette convention qui lie le débiteur à ses créanciers. Ce concordat n'est obligatoire pour tous les créanciers qu'à partir du moment où il est **homologué** par le tribunal[1]. L'effet du concordat est encore de replacer le débiteur à la direction de ses affaires, le dessaisissement prenant fin.

La possibilité d'un tel concordat préventif de la faillite est prévue par la loi du 14 avril 1886[2]. Le concordat en tant que convention consistant dans la remise des dettes accordée par les créanciers à leur débiteur, est sujet à l'accord de la **moitié des créanciers** représentant au moins **trois quarts** du montant nominal **des créances** « *non contestées ou admises par provision* », étant entendu que les créanciers qui n'ont pas fait de déclaration sont comptés comme adhérant à la convention[3].

Le concordat suppose que le débiteur s'adresse par requête au tribunal de son domicile en joignant un certain nombre de documents dont l'état estimatif de son actif, la liste des créanciers et celle des propositions concordataires (art. 3).

La **demande en obtention du concordat,** après sa remise au greffe du tribunal, fait l'objet d'une inscription dans un registre spécial. Si le tribunal répond négativement à cette demande, la faillite sera prononcée, et ce jugement sera susceptible d'appel dans les quinze jours.

En revanche, si le tribunal estime qu'il y a lieu de poursuivre la demande en obtention du concordat, « *il fixera immédiatement les lieu, jour et heure auxquels les créanciers seront convoqués, et il indiquera un ou plusieurs journaux dans lesquels*

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 47.

2 – Loi concernant le concordat préventif de la faillite, *Mém*. A 21 du 15 avril 1886, p. 225.

3 – V. art. 2 de la loi de 1886.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

la convocation sera insérée dans les trois jours »[1]. Sur ordre du juge délégué, il sera procédé à la **convocation individuelle** des créanciers par lettre recommandée personnelle à la poste, huit jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée. Ces lettres contiennent les **propositions concordataires**.

Les créanciers privilégiés, ou nantis de gages, n'ont pas voix délibérative dans les opérations relatives au concordat, à moins qu'ils renoncent à leurs privilèges, hypothèques ou gages, étant entendu que le vote à cette assemblée comporte de plein droit cette renonciation (art. 10).

Un procès-verbal relatant les résultats de l'assemblée sera dressé ; celui-ci reprend notamment la liste des créanciers comparaissant avec l'indication du montant et de la nature de leur créance, les propositions définitives du débiteur, le résultat du vote sur ces propositions, etc.

Pendant la huitaine qui suit l'assemblée, il peut y avoir production de créance supplémentaire au greffe avec les pièces à l'appui.

Au jour fixé pour que le juge délégué fasse rapport au tribunal, les créanciers et le débiteur peuvent être entendus, et le tribunal se prononce par un seul et même jugement sur les contestations et sur **l'homologation**. En même temps, le tribunal procède à la fixation de la cessation de paiements (art. 15).

Le jugement ayant statué sur l'homologation du concordat est susceptible d'opposition (art. 20), mais seulement de la part des créanciers qui n'auraient pas été convoqués, qui ne se seraient pas présentés volontairement ou qui n'auraient pas fait usage de la possibilité laissée par l'article 14.

Appel contre la décision est possible par le débiteur et par les créanciers qui n'auraient pas été convoqués, ceux qui auraient voté contre le concordat ou dont les créances auraient été rejetées ou qui contesteraient la date de cessation de paiements (art. 21). La rapidité étant d'importance fondamentale en cette matière, le délai d'appel est de **huit jours** seulement et est calculé à partir du jugement pour le débiteur et à compter de la publication du jugement pour les créanciers.

Certains points sont remarquables dans cette procédure. Le concordat est sans effet relativement :

– aux impôts et autres charges publiques ;

– aux créances garanties par les privilèges, hypothèques et nantissements ;

– aux créances dues à titre d'aliments.

Par l'effet de l'homologation par le tribunal, le concordat est obligatoire pour tous les créanciers, étant entendu qu'il ne s'applique qu'aux seuls engagements contractés antérieurement à son obtention.

En outre, le concordat ne comporte pas de remise définitive des dettes. En application de l'article 25, celui qui a obtenu le concordat est tenu en cas de **retour à meilleure fortune** de payer intégralement les créanciers.

Le concordat reste toujours exposé à une remise en cause dans la mesure où les créanciers liés par le concordat peuvent toujours en demander l'annulation, soit par suite de la condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après l'homologation, soit pour cause de dol découvert après l'homologation et résultant de la dissimulation de l'actif ou de l'exagération du passif (art. 26).

1 – Art. 5 de la loi du 14 avril 1886.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le concordat préventif de faillite comporte de la part des créanciers certains **sacrifices** destinés à rendre possible le remboursement au moins d'une partie des dettes de la société. Il est encore prévu que le juge délégué examine tous les **trois mois** l'état des affaires du débiteur du concordat. Avec la même périodicité le juge fera un rapport au tribunal qui, le cas échéant, peut prononcer la faillite et la résolution du concordat (art. 28). Pour le cas où la faillite est prononcée dans un délai de six mois après la résolution du concordat, la date de cessation de paiements peut être fixée au jour où le concordat avait été demandé (art. 29).

■ § 5 – Comité des créanciers

La loi du 30 juin 1930 a institué un « comité des créanciers » ayant pour mission de sauvegarder les intérêts des créanciers dans les faillites et les concordats[1]. Aux termes de cette loi, le juge-commissaire, dans les quinze jours de la déclaration de toute faillite, est en principe tenu de « *désigner un comité de créanciers composé de trois membres choisis parmi les principaux créanciers chirographaires* ». Ce comité, dont la mission est d'assister le curateur et de surveiller les opérations de la faillite, a un rôle **purement consultatif**. En pratique, ce comité n'est jamais institué. L'inobservation de ces dispositions légales n'est toutefois pas sanctionnée[2].

SECTION II
DÉCLARATION DE FAILLITE

En droit luxembourgeois, la faillite doit être déclarée. La loi ne connaît pas la faillite « de fait » et le juge ne peut reconnaître aucun effet juridique à une telle situation de pur fait[3]. « *La faillite affecte non seulement les droits et les obligations du failli, mais aussi les droits des tiers de sorte que l'ordre public est intéressé à voir cet état publiquement constaté par une décision judiciaire* »[3]. En droit luxembourgeois, comme en droit belge, la déclaration judiciaire de la faillite est donc requise.

Pendant un certain temps, la jurisprudence française retenait la **faillite virtuelle** (ou non déclarée) en appliquant les règles de fond de la faillite et les règles relatives à la nullité de certains actes accomplis pendant la période suspecte[3].

Un jugement déclaratif de faillite, attaqué par la voie de l'opposition, peut être **rabattu**, soit pour cause d'incompétence du tribunal ayant prononcé la faillite, soit pour défaut de la qualité de commerçant, soit enfin pour absence de preuve de la cessation de paiements et de l'ébranlement du crédit. Les conditions exigées pour la mise en faillite s'apprécient au jour du jugement déclaratif de la faillite.

La juridiction saisie d'une opposition ou d'un appel contre un jugement déclaratif de faillite doit se référer à la situation prévalant **au jour de ce jugement** et ne saurait le réformer au motif que le débiteur aurait entre-temps assaini sa situation financière, soit en désintéressant ses créanciers, soit en obtenant du crédit[4].

---

1 – Loi du 30 juin 1930, ID 11657.

2 – TA Lux. du 27 juin 2005, ID 10296.

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 81.

4 – Lux. du 11 janvier 1967, *P.* , nº 20, p. 361, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – Juridiction compétente

C'est le tribunal de commerce qui est compétent, ce qui s'explique par le fait que le but de la faillite est la liquidation d'un patrimoine commercial et que la faillite concerne uniquement les commerçants[1]. Est territorialement compétente la juridiction du domicile du débiteur. Il s'agit donc du domicile (dans son acception commerciale du terme, le principal lieu d'affaires du débiteur[2]) de la personne physique ou du siège de la personne morale. Au Luxembourg, le tribunal territorialement compétent est le tribunal d'arrondissement (chambre commerciale) de Luxembourg ou de Diekirch.

Les tiers, et comme tels les créanciers personnels des associés, peuvent, s'ils y ont intérêt, invoquer contre les associés la nullité de la société. « *Cette faculté est un droit que les créanciers personnels d'un associé tiennent directement de la loi et, en exerçant cette faculté, ils agissent* jure proprio *et, dès lors, comme tiers au point de vue de l'article 42 du Code de commerce. En cas de concours de créanciers sociaux préférant considérer la société comme valable, avec des créanciers personnels désirant la faire annuler, ce sont ces derniers qui doivent l'emporter*.

L'annulation d'une société ayant un effet rétroactif, il s'ensuit qu'une société annulée n'a jamais eu d'existence juridique et que sa déclaration en état de faillite est impossible en droit et en fait »[3]. Cette jurisprudence est dépassée actuellement, et ceci, en raison du nouveau régime des nullités des sociétés (voir art. 100-18 et suivants L.S.C).

Une faillite ne peut être prononcée qu'à la double condition que le débiteur commerçant soit en état de cessation de paiements et que son crédit soit ébranlé. Si le refus de paiement d'une seule dette peut suffire pour établir la cessation de paiements, il faut pourtant que la dette soit **liquide**, **exigible** et **certaine.** Pour être certaine, une dette ne doit être contestée ni dans son existence, ni dans son montant, ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire.

Le créancier qui succombe dans sa demande en déclaration de faillite ne peut, de ce seul fait, être condamné à des dommages-intérêts envers le débiteur. Si, cependant, il a commis un abus de droit en agissant de mauvaise foi ou de façon téméraire, il doit être condamné à réparer le préjudice subi par le débiteur.

La Cour d'appel de Luxembourg réforma un jugement du tribunal d'arrondissement qui avait retenu l'abus dans le chef du débiteur qui avait lancé une assignation en faillite en 2005, deux ans après une première assignation en faillite qui entretemps avait été rayée. La première assignation en faillite avait donné lieu au paiement d'un acompte substantiel sur la dette litigieuse. La Cour, contrairement au tribunal, ne retint pas l'abus dans le fait que le débiteur n'avait pas procédé à des rappels ou à des actes d'exécution comme suite à la radiation de la première assignation en faillite[4].

---

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 81.

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 86.

3 – Lux. du 8 avril 1911, *P.*, nº 9, p. 229, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – CA com. du 15 novembre 2006, nº 30.768 BIJ nº 2/2007, p. 34.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'assignation en déclaration de faillite n'est admissible que si le défaut de paiement est la manifestation non équivoque de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à ses engagements ; elle ne doit pas être utilisée comme moyen d'intimidation contre le débiteur *in bonis*.

Le porteur d'une traite acceptée et protestée qui assigne immédiatement le tiré en faillite commet une lourde erreur, équipollente au dol et génératrice de responsabilité, alors que le mode normal de recouvrement des lettres de change est la demande en paiement soumise au tribunal compétent[1].

Le tribunal ne doit pas se préoccuper de savoir si la faillite concorde avec **l'intérêt des créanciers.** Lorsque les trois conditions légales de la faillite sont réunies (qualité de commerçant, cessation de paiements, ébranlement du crédit), il a le devoir de prononcer la faillite[2].

Un commerçant peut être déclaré en faillite pour défaut de paiement de dettes civiles, et même d'une seule dette civile – n'étant même pas en relation avec son activité commerciale –, si les autres conditions de la faillite sont remplies[3].

■ § 2 – Cas d'ouverture de la faillite

Aux termes de l'article 442 C.com., le jugement déclaratif de la faillite est rendu « *soit sur aveu du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office* ».

A – Faillite sur aveu

Art. 440 C.com.

« *Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.*

Lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société coopérative dans laquelle l'étendue de la responsabilité des associés est illimitée, la déclaration doit contenir les noms et domiciles de chacun des associés indéfiniment tenus des engagements de la société.

Pour toutes sociétés, la déclaration doit indiquer les noms des administrateurs ou gérants. La procédure se poursuivra contre ceux-ci, qui sont tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous renseignements et de comparaître devant eux quand ils en seront requis ».

La question qui peut se poser est de savoir si **l'aveu** lie le tribunal, en d'autres termes, si le tribunal devant lequel l'aveu est fait doit nécessairement prononcer la faillite. La doctrine répond négativement à cette interrogation : le tribunal doit dans tous les cas vérifier si les conditions de la faillite sont réunies et, notamment, si la cessation de paiements existe.

1 – Lux. du 14 janvier 1972, *P.*, n° 22, p. 306, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour 18 novembre 1998, *P.*, n° 31, p. 69, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La règle que le tribunal compétent est celui du domicile ou du siège social du commerçant est **d'ordre public,** de sorte que le tribunal doit se déclarer incompétent d'office. Le domicile pertinent est celui du moment de l'action en déclaration de faillite[1].

Par ailleurs, les tribunaux luxembourgeois sont incompétents pour déclarer la faillite d'une société anonyme dont le siège du principal établissement se trouve à l'étranger[2].

Il faut entendre par siège du principal établissement d'une société le lieu où se trouve son centre d'activité le plus important au point de vue de ses affaires ; ce siège peut ne pas être le siège social statutaire de la société[2].

Art. 441 C.com.

« *Le failli joindra à son aveu :*
le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêcheraient de le déposer ; les livres prescrits par les articles 9 à 11 du Code de commerce ; ces registres seront arrêtés par le greffier, qui constatera l'état où ils se trouvent.
[...] ».

De cette obligation de joindre le bilan vient l'expression « ***déposer le bilan*** ». Une simple déclaration du failli n'est pas suffisante : le débiteur doit exposer sincèrement et nettement sa situation, expliquer quelles sont ses dettes et quel est son actif.

La demande émanant des créanciers peut se faire soit par **assignation**, soit par simple requête adressée au tribunal : cette dernière option est ouverte pour la raison que le tribunal peut déclarer d'office la faillite. Si l'assignation, en permettant au débiteur de s'expliquer, est la méthode la plus recommandable d'un point de vue purement juridique, elle comporte des risques non négligeables dans la mesure où elle expose les créanciers au risque que le débiteur procède au **détournement des biens**. Pour faire face à ce risque, la demande peut être introduite par simple **requête** ; il est loisible au tribunal d'ordonner la mise en cause du débiteur pour vérifier le bien-fondé de la requête du créancier[3].

B – Faillite sur demande des créanciers

La plupart du temps, la faillite est le résultat des efforts d'un ou de plusieurs créanciers engageant des actions destinées à conduire au paiement de leurs créances restées impayées à leur échéance. Il doit s'agir d'une créance certaine, liquide et exigible ; en particulier, la créance doit donc ne pas être contestée[4]. Il n'est pas nécessaire que la cessation de paiements soit généralisée. Il est vrai qu'un créancier qui, au moindre retard de paiement d'une dette exigible, demanderait la mise en faillite serait susceptible d'engager sa responsabilité.

1 – TA (com.) du 6 mars 2002, n° 73.057, *BIJ*, 2005, n° 7, p. 125.

2 – Lux. du 10 mai 1952, *P.*, n° 16, p. 177, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 93.

4 – TA Lux. du 14 janvier 1972, *P.*, n° 22, p. 306, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

« *Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d'après les éléments de la cause dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal ne prononcera la faillite d'office qu'après avoir convoqué le failli par la voie du greffe en la chambre du conseil pour l'entendre sur sa situation.*

Par le même jugement ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement ».

Cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite. En pratique, la cessation de paiements est régulièrement fixée à la date exactement antérieure de six mois à la date du jugement de faillite.

En l'absence de détermination spéciale, la cessation de paiements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli.

C – Faillite prononcée d'office

Le tribunal peut déclarer d'office (donc en dehors de toute demande) la faillite, et ceci, du vivant du commerçant ou encore après son décès. Ce mode de prononciation est fort rare en pratique ; s'il intervient, ce sera suite à une intervention officieuse du parquet ou encore spontanément à la suite de renseignements recueillis[1]. Cette possibilité est tout à fait extraordinaire, car il est inhabituel pour les tribunaux d'agir d'office. Comme indiqué sous A ci-dessus, la règle trouve sa justification dans la nécessité de prévenir les **détournements** et les **fraudes** qui peuvent se produire si les créanciers sont absents, incapables ou dans l'impossibilité d'agir[2].

■ § 3 – Faillite d'une société en liquidation

La société dont la dissolution a été décidée et qui, de ce fait, se trouve en état de liquidation, continue d'exister pour les fins de la liquidation (art. 1100-1 L.S.C.). On en déduit que la société reste soumise aux règles régissant le commerce, en particulier celles relatives au droit sur la faillite. Par conséquent, une société en liquidation peut tomber en faillite. Il paraîtrait encore que l'on puisse trouver un autre argument tenant à la *ratio legis* de l'article 1100-5 L.S.C. qui permet aux liquidateurs de **s'endetter** pour payer les dettes sociales, et ceci, dans le **but d'éviter la faillite** de la société. La doctrine en conclut à juste titre que, dans l'esprit du législateur, il n'y avait jamais de doute quant à la possibilité de mettre en faillite une société en état de liquidation[3].

La déclaration de la faillite est inéluctable à partir du moment où les conditions de l'article 437 C.com. sont réalisées. Cet article est d'ordre public. Le seul moyen pour le débiteur d'échapper à la faillite est de conclure un concordat amiable avec les

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 93.

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 96.

3 – C. Erkelens et P. Colle, « Quelques réflexions à propos de la faillite d'une société en liquidation », *R.P.S.*, 1992, p. 91.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

créanciers ou d'introduire une requête devant le tribunal de commerce afin d'obtenir un concordat judiciaire[1].

■ § 4 – Contenu du jugement déclaratif

Le terme « jugement déclaratif » est utilisé par la loi. Toutefois, ce jugement est en fait **constitutif** d'un état nouveau. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation belge du 21 février 1861[2], la théorie de la **faillite virtuelle** est condamnée. La faillite n'existe en effet qu'à dater du jugement qui la prononce : il n'y a pas de « faillite de fait »[3].

Le jugement déclaratif de la faillite contient obligatoirement les points suivants :

– Il déclare l'état de la faillite, c.-à-d. « vérifie et constate un état de fait préexistant tout en constituant une situation nouvelle »[4] ;
– Il nomme un ou plusieurs curateurs ; ceux-ci sont librement choisis par le tribunal. Il s'agit pratiquement toujours d'avocats, le cas échéant accompagnés de réviseurs d'entreprises ou d'experts-comptables ;
– Il fixe la date de cessation de paiements ;
– Il nomme un juge-commissaire ; en général celui-ci est choisi parmi les magistrats qui ont siégé lors du prononcé du jugement ;
– Il ordonne l'apposition de scellés pour empêcher le détournement de l'actif ;
– Il fixe le délai pour la déclaration des créances ; ce délai ne peut dépasser vingt jours ;
– Il détermine la date de vérification des créances ;
– Il indique les journaux dans lesquels est publié le jugement déclaratif de faillite.

La déclaration de faillite d'une société en nom collectif implique la constatation de la cessation de paiements et de l'ébranlement du crédit de tous les associés[5]. Telle est la position de la Cour de cassation belge qui déduit cette conséquence du fait qu'en raison « *[…] de la nature même de cette société, dont la personnalité se confond pratiquement avec celle des associés, la déclaration de faillite d'une société en nom collectif implique constatation de la cessation des paiements et de l'ébranlement de crédit de tous les associés* »[6].

■ § 5 – Exécution du jugement déclaratif

En matière de faillite, toute décision est en principe **exécutoire par provision,** nonobstant opposition ou appel. Cette disposition se justifie par le souci d'empêcher que le gage des créanciers ne puisse être diminué en mettant immédiatement sous main de justice tout ce qui appartient au débiteur failli[7].

---

1 – C. Erkelens et P. Colle, « Quelques réflexions à propos de la faillite d'une société en liquidation », *R.P.S.*, 1992, p. 102.

2 – Cass. b. du 21 février 1861, *Pas.*, 1861, I, p. 142.

3 – Cass. b. du 1er juin 1979, note F. t'Kint, *R.C.J.B.*, 1981, p. 58.

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 97.

5 – Cass. b. du 1er juin 1979, note F. t'Kint, *R.C.J.B.*, 1981, p. 59.

6 – Cass. b. du 15 décembre 1938, *Pas.*, 1938, I, p. 383, *J.T.*, 1939, p. 189.

7 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 101.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 465 C.com.

« *Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision ; le délai ordinaire pour en interjeter appel n'est que de quinze jours, à compter de la signification. Ne seront susceptibles d'opposition, ni d'appel, ni de requête civile :*

1° les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des curateurs ;

2° les jugements qui statuent sur les demandes de secours pour le failli et sa famille ;

3° les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou, conformément à l'article 453, paragraphe 3, la remise de la vente d'objets saisis ;

4° les jugements qui prononceront sursis au concordat ;

5° les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions ».

L'article 465 C.com., avec ses délais très réduits, ne s'applique qu'aux actions nées de la faillite, donc uniquement si l'action a son fondement dans la législation particulière de la faillite. « *Il ne s'applique pas au jugement qui a statué sur des contestations qui, bien que nées au cours de la faillite et intéressant la masse de la faillite, ont cependant une cause étrangère à la législation sur les faillites et auraient pu naître indépendamment de cette faillite* »[1]. Il a été ainsi jugé à l'occasion d'une action tendant à la restitution de trois voitures exercée par le curateur de la faillite contre P, action accueillie favorablement par le tribunal et contre laquelle P fit appel, mais hors du délai de quinze jours, en argumentant devant la cour d'appel (avec succès) que cette action n'était pas couverte par l'article 465 C.com.

La décision tomba dans l'autre sens dans une affaire où la contestation portait sur la vérification d'une créance et sur son admission au passif privilégié de la société faillie. Pour la cour, « *[L]es contestations de créance sont des contestations nées de la faillite, en raison de ce que leur objet est l'admission au concours des créanciers par l'inscription, sur la liste, selon les masses constituées (Novelles, Les concordats et la faillite, n°s 2652 et suivants)* »[2].

■ § 6 – Effet du jugement déclaratif

Ce jugement produit ses effets non seulement vis-à-vis du failli, mais vis-à-vis de tous, et ceci, par dérogation à l'article 1351 C.c.[3]. La procédure de liquidation ainsi organisée s'impose à l'égard de tous les créanciers. De même, les biens du débiteur sont « *frappés d'une mainmise judiciaire* »[4].

Un jugement étranger déclaratif de faillite ne saurait produire des effets juridiques sur le territoire luxembourgeois tant qu'il n'est revêtu de la formalité de l'***exequatur***,

1 – CA com. du 19 novembre 2003, n° 27.718, *BIJ*, 2004, n° 1, p. 6, ID 21248.

2 – CA com. du 6 juin 2003, n° 27.845, *BIJ*, 2004, n° 1, p. 5.

3 – « *L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles contre elles en la même qualité* », ID 11695.

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 85.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

qui seule peut rendre exécutoire sur le territoire national des actes ou jugements émanant des autorités étrangères[1].

L'*exequatur* préalable n'est requis que lorsqu'il s'agit de procéder à des actes d'exécution proprement dits, c'est-à-dire des mesures de contraintes sur la personne ou les biens du failli, et le curateur étranger a qualité pour poser valablement, dans le Grand-Duché, avant toute sentence d'*exequatur*, les simples actes conservatoires, par exemple poursuivre le recouvrement des créances ou intervenir dans une instance concernant le failli[2].

Quant à la capacité de la personne faillie : « *En présence des principes de l'unité et de l'universalité de la faillite, le jugement déclaratif de faillite, rendu par un tribunal étranger, a, quant à la capacité et au patrimoine du failli au Luxembourg, l'autorité de la chose jugée et y produit les mêmes effets que dans le pays étranger, et cela, même avant toute sentence d'*exequatur »[3].

La loi sur les faillites, en tant qu'elle règle l'état et la capacité du failli, relève de son **statut personnel** et, dès lors, cette capacité est réglée d'après la loi du pays où la faillite a été ouverte[4].

Les syndics nommés par jugement étranger peuvent donc ester en justice dans le Grand-Duché, avant que le jugement déclaratif de faillite y ait été rendu exécutoire[5].

Un Belge déclaré en état de faillite en France doit être réputé tel dans le Grand-Duché, sans qu'il soit nécessaire que le jugement déclaratif ait été rendu exécutoire par les tribunaux luxembourgeois[6].

L'époque qui peut être fixée comme étant celle de la cessation de paiements est limitée, en principe général, par les six mois qui précèdent la déclaration de la faillite et, par exception, par la demande de sursis (art. 613 C.com.) ; elle ne peut sous aucun prétexte être reculée au-delà de ces deux dates[7].

La cour étant investie, par l'effet dévolutif de l'appel, du pouvoir de connaître des difficultés de fait et de droit soumises au premier juge, auquel elle est substituée avec la même étendue et plénitude de juridiction, elle peut, le cas échéant, faire remonter la cessation de paiements à la même époque que celle que le premier juge aurait pu la fixer, c'est-à-dire à six mois avant la date du jugement dont il est fait appel[8].

---

1 – Lux. du 5 février 1898, *P.*, n° 4, p. 466, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 13 décembre 1932, *P.*, n° 13, p. 357, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 11 octobre 1961, *P.*, n° 18, p. 470, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Diekirch du 2 août 1894, *P.*, n° 4, p. 17 ; Cour du 10 juillet 1891, *P.*, n° 4, 44 ; Lux. du 22 janvier 1909 ; *cf.* Cour du 18 juin 1909, *P.*, n° 8, p. 22, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cour du 10 juillet 1891, *P.*, n° 6, p. 44, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Diekirch du 2 août 1894, *P.*, n° 4, p. 17, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

7 – Lux. du 24 juin 1876, *P.*, n° 1, p. 209, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

8 – Cour du 28 janvier 1887, *P.*, n° 3, p. 165, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Si le tribunal ne fait pas droit à la demande en déclaration de faillite, son jugement n'est **pas opposable à tous**. Il n'a d'autorité que vis-à-vis des parties en cause. Il n'est pas exclu que le même créancier introduise ultérieurement une seconde demande fondée sur des faits nouveaux. De même, un autre créancier peut assigner sur la base des mêmes faits qui n'ont pas emporté conviction du juge la première fois. L'autorité de chose jugée ne s'applique que dans la mesure où il y a identité de personnes[1].

■ § 7 – Recours contre le jugement déclaratif

Deux voies de recours sont prévues : **l'opposition** (devant le tribunal d'arrondissement qui a rendu le jugement déclaratif) et **l'appel** (devant la cour d'appel), étant entendu que ni l'une, ni l'autre n'ont d'effet suspensif sur le jugement déclaratif de la faillite. Aucun événement postérieur au jugement déclaratif ne peut être pris en considération : il convient de se replacer au moment du jugement déclaratif pour apprécier exclusivement si, à ce moment-là, il y avait cessation de paiements et ébranlement du crédit. Si tel était le cas, le jugement déclaratif devra être confirmé même si, entre-temps, les créanciers ayant renoncé à une partie de leurs créances ont tous été payés[2]. Dans un tel cas de figure, il ne reste que la **réhabilitation**.

A – L'opposition

En procédure civile et administrative, l'opposition est une voie de recours ouverte au plaideur contre lequel a été rendue une décision par **défaut** et qui lui permet de saisir à nouveau le tribunal qui a déjà statué en lui demandant de juger l'affaire à nouveau[3]. En matière de faillite, la faculté de faire opposition a été élargie à toute personne intéressée à la rétractation du jugement déclaratif. La raison de cet élargissement réside dans le fait que le jugement a un caractère universel. Il s'agit en réalité d'une **tierce opposition**[2].

L'article 472 C.com.

« *Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de paiement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, affichés dans l'auditoire du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, où ils resteront juxtaposés pendant trois mois. Ils seront, également dans les trois jours, insérés par extraits dans les journaux qui s'impriment dans les lieux ou dans les villes les plus rapprochées des lieux où le failli a son domicile ou des établissements commerciaux,et qui auront été désignés par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Il sera justifié de cette insertion par les feuilles contenant lesdits extraits, avec la signature de l'imprimeur légalisée par le bourgmestre* ».

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 95.

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 102.

3 – *Lexique de termes juridiques*, Vo opposition, Dalloz.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 473 C.com.

« *Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé l'époque de la cessation de paiement seront susceptibles d'opposition de la part des intéressés qui n'y auront pas été parties.*

L'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partie intéressée dans la quinzaine de l'insertion de ces jugements dans celui des journaux mentionnés à l'article 472 qui s'imprime dans le lieu le plus voisin de leur domicile ».

Parmi les intéressés visés par l'article 473 C.com., il faut comprendre principalement les créanciers du failli. La voie de recours dont il est question n'est pas une opposition proprement dite, mais a le caractère de la **tierce opposition**, fondée sur des intérêts qui seraient lésés par le jugement déclaratif[1].

« *S'il paraît rationnel d'exiger, sous peine d'irrecevabilité, que l'opposition relevée par des créanciers d'un failli contre un jugement déclaratif de faillite soit notifiée, non seulement aux curateurs, mais encore au failli, il ne s'ensuit pas que la mise en cause du failli ne puisse être valablement réalisée après l'expiration du délai de quinzaine visé à l'article 473 ; la déclaration de faillite étant chose indivisible, l'opposant est relevé, par l'effet de l'opposition régulière formée contre l'un des colitigants, de la déchéance qu'il avait encourue du droit de former opposition contre l'autre, à la condition de mettre celui-ci en cause ultérieurement avant le jugement qui statue sur l'opposition* »[2].

Le délai de huitaine de l'article 473 C.com. réglant l'opposition au jugement déclaratif de faillite n'est ni franc ni susceptible d'augmentation à raison des distances[3].

Le jugement déclaratif de faillite est susceptible d'opposition de la part de tout intéressé. Parmi les intéressés, il faut comprendre principalement les créanciers du failli, qui, toutefois, doivent indiquer **l'intérêt** qu'ils ont à intervenir. Cet intérêt doit être **réel** ; il peut consister à empêcher l'annulation des hypothèques consenties avant le jugement[4].

L'article 473 C.com. réglant l'opposition au jugement déclaratif de faillite déroge au droit commun en ce sens qu'il accorde le droit d'opposition aux seuls intéressés qui n'ont pas été parties au jugement. « *En conséquence, la voie de l'opposition est interdite au failli qui, ayant été assigné en déclaration de faillite par un créancier, a été par là même, partie au procès, encore qu'il n'ait pas comparu* »[5].

Le jugement déclaratif de faillite ne peut être entrepris par le failli par la voie de l'appel, mais seulement par celle de l'opposition, lorsque la faillite a été prononcée d'office et **en dehors de la présence légale du failli**, le droit d'appel n'appartenant,

1 – Cour du 30 décembre 1896, *P.*, n° 4, p. 225, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Lux. du 6 décembre 1902 ; *cf.* Cour du 6 mars 1903, *P.*, n° 6, p. 238, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cass. du 1er février 1951, *P.*, n° 15, p. 102 ; Cour du 5 janvier 1949, *P.*, n° 14, p. 458, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Lux. du 20 avril 1905, *P.*, n° 15, p. 36, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Lux. du 11 mars 1933, *P.*, n° 13, p. 57, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

dans cette matière, qu'à ceux qui ont été partie en première instance. Il en est ainsi, même si l'appel est fait par un failli qui, ayant disposé du droit d'opposition, ne l'a pas exercé régulièrement en temps utile[1].

Le commerçant qui, assigné en faillite, n'a pas comparu devant le tribunal de commerce, peut faire opposition au jugement déclaratif de faillite rendu par défaut contre lui[2].

Les jugements déclaratifs de faillite sont susceptibles d'opposition de la part de tout intéressé. Parmi les intéressés, il faut comprendre les **actionnaires** d'une société déclarée en faillite[3].

L'intéressé qui a fait l'aveu de la cessation de ses paiements peut se pourvoir contre la décision qui ne le déclare pas en état de faillite[4].

Lorsque les curateurs d'une faillite prononcée par défaut ont figuré dans l'instance d'opposition, il faut leur reconnaître le droit de se pourvoir contre le jugement qui y a mis fin, en rabattant la faillite[4].

En vue de hâter la solution des litiges intéressant les faillites, l'article 465 C.com. dispose que tout jugement rendu en matière de faillite est **exécutoire par provision** et que le délai ordinaire pour en interjeter appel n'est que de quinze jours à compter de la signification. Ce délai de quinzaine ne peut être augmenté ni en raison de la distance ni pour cause d'extranéité[5].

La deuxième voie de recours est l'appel.

B – L'appel

Comme le droit d'appel appartient uniquement à ceux qui ont été partie en première instance, l'appel prévu à l'article 465 C.com. n'est à la disposition que de ceux qui ont été partie au jugement ; les personnes qui n'y ont pas été partie disposent de la tierce opposition, aux termes de l'article 473[6].

Le failli a le droit d'appel chaque fois qu'il a été partie en cause. Il n'est pas partie en cause si la faillite est prononcée d'office ou à la requête des créanciers et en dehors de la présence légale du failli ; dans ce cas, il ne dispose que de la voie de l'opposition instituée par l'article 473 C.com. Le failli ne peut être considéré comme étant devenu partie en cause en raison de la présentation d'une requête en obtention d'un concordat préventif[7].

---

1 – Cour du 15 janvier 1964, *P.*, n° 19, p. 270.

2 – Lux. du 23 novembre 1967, *P.*, n° 21, p. 99 ; TA Lux. du 18 février 1970, *P.*, n° 21, p. 393, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 18 février 1970, *P.*, n° 21, p. 393, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 6 mars 1903, *P.*, n° 4, p. 238, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cour du 16 décembre 1964, *P.*, n° 19, p. 541, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC) ; Cour du 30 décembre 1896, *P.*, n° 4, p. 225, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Cour du 12 novembre 1886, *P.*, n° 2, p. 424, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

7 – Cour du 5 juin 1908, *P.*, n° 8, p. 150, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le jugement déclaratif de la faillite statuant sur une matière indivisible, les créanciers intervenus en première instance ont le droit d'intervenir en instance d'appel[1].

Les créanciers qui n'ont pas été partie en première instance ont le droit d'intervenir devant la cour sur l'appel dirigé contre le jugement déclaratif de la faillite de leur débiteur[1].

Lorsque, par un même jugement, le tribunal a refusé de suivre la requête en obtention d'un concordat préventif et a déclaré la faillite du débiteur, l'appel relevé contre cette dernière décision, conformément à l'article 465 C.com., remet également en cause celle qui a rejeté le concordat préventif, et en défère l'appréciation à la Cour[1].

L'appel dirigé contre un jugement refusant à la fois d'homologuer le concordat préventif déclarant la faillite et fait dans les formes et dans le délai prescrit par l'article 21 de la loi du 14 avril 1886, saisit régulièrement le juge d'appel, non seulement de la disposition qui refuse l'homologation, mais également de celle qui déclare la faillite[2].

Lorsque, sur l'appel d'un jugement refusant de suivre la requête en obtention d'un concordat préventif et déclarant la faillite du débiteur, la cour réforme et déclare la faillite rapportée, les frais d'instance, sauf ceux occasionnés par l'intervention des créanciers, doivent rester à charge du débiteur appelant[3].

Si, en général, le **délai d'appel** court à partir de la signification du jugement, cette règle reçoit, par la force des choses, exception dans les cas où le jugement ne doit pas être signifié. Spécialement, lorsqu'un créancier demande par voie de requête la faillite de son débiteur sans appeler ce dernier en cause, le délai d'appel contre le jugement qui rejette la demande court, pour le demandeur, à partir de la prononciation du jugement[4].

À l'égard du jugement déclaratif de faillite, le droit d'appel appartient uniquement à ceux qui ont été parties en première instance. Il s'ensuit que le failli, qui n'a pas été partie au jugement déclaratif de faillite ne peut attaquer ce jugement que par voie de l'opposition[5].

S'il est vrai que l'article 465 C.com. prévoit pour l'appel d'un jugement rendu en matière de faillite un délai spécial de quinze jours courant à partir de la signification, il est cependant admis que cette disposition exceptionnelle ne trouve application que lorsque la décision est intervenue sur les actions qui sont nées de la faillite, c'est-à-dire celles qui, sans la faillite, n'auraient pas pu surgir, soit qu'elles fussent nées de l'état de faillite, soit qu'elles aient trouvé leur source, leur principe ou leur fondement dans la législation de la faillite, soit qu'elles se rattachent directement à la procédure qui est la conséquence de la faillite.

---

1 – Cour du 30 décembre 1896, *P.*, n° 4, p. 225, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 14 juillet 1905, *P.*, n° 7, p. 343, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 30 décembre 1896, *P.*, n° 4, p. 225, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 13 août 1887, *P.*, n° 3, p. 165, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cass. du 1er février 1951, *P.*, n° 15, p. 102, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les actions qui échappent par leur objet aux causes de la faillite qui lui sont étrangères et même antérieures en date sont soumises, quant aux délais d'appel, aux règles de droit commun prévues à l'article 443 du Code de procédure civile.

Il en est ainsi spécialement de la demande en paiement introduite par le failli contre un débiteur avant la déclaration de faillite et reprise dans la suite par le curateur de la faillite[1].

Pour pouvoir faire appel, il faut avoir été directement mêlé à la procédure du premier degré. Si tel n'est pas le cas, il ne reste que l'opposition. Le délai pour faire appel qui normalement est de quarante jours est réduit à **quinze jours**. L'effet de l'arrêt de la cour d'appel qui maintient la faillite produit également ses effets *erga omnes*. Si la cour d'appel rapporte la faillite, le rôle du curateur prend fin, et le commerçant reprend l'administration de ses biens. Si l'arrêt de la cour infirme le jugement rejetant la faillite et prononce celle-ci, il renvoie les parties devant le tribunal de commerce précédemment saisi. La cour ne peut ni désigner pour l'exécution un tribunal autre que celui dont le jugement a été infirmé ni retenir l'exécution de l'arrêt (article 596 NCPC).

La disposition selon laquelle le délai pour interjeter appel contre un jugement rendu en matière de faillite n'est que de quinze jours à partir de la signification doit s'appliquer toutes les fois que la contestation n'aurait pu se produire sans l'avènement de la faillite[2].

Le délai d'appel des jugements rendus en matière de faillite est **d'ordre public** et ne peut être augmenté en raison des distances, même en faveur des personnes domiciliées à l'étranger[2].

Le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 465 C.com. ne s'applique que lorsque le jugement entrepris a statué sur une action qui est née de la faillite, donc sur une action qui n'aurait pas pu être intentée sans la faillite. La disposition étant d'interprétation restrictive, elle ne s'applique pas à un jugement qui statue, même partiellement, sur une contestation fondée sur une cause indépendante de la faillite[3].

Le curateur agira en prenant toutes les mesures qui s'imposent, même si l'appel ou l'opposition a été introduite.

« *La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'un appel n'est pas une simple nullité d'acte de procédure ou d'exploit pour vice de forme, mais constitue une déchéance absolue ; étant étrangère à l'article 173 du Code de procédure civile, elle n'est couverte ni par la constitution d'avoué, ni par un acte de procédure subséquent et doit être suppléée d'office par le tribunal* »[4].

Si, en principe, le délai d'appel ne commence à courir qu'à partir de la signification de la décision judiciaire, cette règle doit recevoir exception en cas de rejet de la demande en déclaration de faillite, lorsqu'il n'est pas certain que le débiteur assigné se trouve au courant de la procédure suivie à son encontre et que dès lors

1 – Cour du 12 juillet 1965, *P.*, n° 20, p. 30, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 24 avril 1985, *P.*, n° 26, p. 345, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 19 novembre 2003, *P.*, n° 32, p. 430, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 21 janvier 1981, *P.*, n° 25, p. 465, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

il n'a pu faire pareille signification. Dans ce cas, le délai d'appel court à partir de la prononciation du jugement de rejet de la demande[1].

Il résulte du texte de l'article 465 C.com. et des discussions parlementaires qui ont précédé en Belgique l'adoption de cet article que le législateur a voulu simplement réduire le délai d'appel pour les jugements rendus en matière de faillite, mais qu'il n'a pas touché au mode de computation du délai qui consiste à exclure le *dies a quo* et *le dies ad quem,* d'après la règle générale tracée dans l'article 1033 [art. 1256 NCPC] du Code de procédure civile[2].

SECTION III
LES « ORGANES » DE LA FAILLITE

Il est vrai que l'expression même d'organe pourrait être critiquée pour la raison que la masse des créanciers n'a pas de personnalité morale. Par le terme d'organes, nous entendons donc toutes les personnes et institutions qui agissent en vue de la liquidation de la faillite.

On peut distinguer quatre organes différents.

§ 1 – Le curateur

Il s'agit de l'organe principal de la faillite. Par l'effet du **dessaisissement**, le failli perd l'administration de son patrimoine qui est confiée aux agents de justice que sont les curateurs. Étant donné que les curateurs sont nommés par le jugement déclaratif de la faillite, le patrimoine du failli n'est à aucun moment laissé à **l'abandon** : au moment où le failli est dessaisi du patrimoine, le curateur prend la relève[3].

A – Nomination du curateur

Autrefois, les créanciers choisissaient eux-mêmes le curateur. De nos jours, les créanciers n'ont plus aucune influence sur ce choix : c'est pour cette raison que le terme curateur a remplacé celui de **syndic** de la faillite. « *Le projet dit "curateur" et non "syndic", parce que cette dernière dénomination ne convient guère qu'à celui qui peut être considéré comme l'agent ou le délégué des créanciers, et parce qu'il propose de ne plus faire participer ces derniers à la nomination des administrateurs des faillites. La dénomination de curateur convient, en effet, à celui qui est institué par la puissance publique pour conserver et administrer des biens dont l'administration est vacante par suite du dessaisissement dont le failli est frappé* »[4].

Le tribunal désigne un ou plusieurs curateurs selon l'importance de la faillite. Il les choisit librement.

---

1 – Cour du 8 juin 1970, *P.*, n° 21, p. 510, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 3 janvier 1979, *P.*, n° 24, p. 275, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 307.

4 – Exposé des motifs de la loi belge, cité par L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 308.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La loi, dans son article 456 C.com., fait référence à des « *liquidateurs assermentés* » (qui seraient nommés par le Grand-Duc), parmi lesquels les curateurs aux faillites seraient en principe choisis. Un tel groupement n'a jamais existé au Luxembourg. La même disposition précise qu'à défaut de tels liquidateurs assermentés, si le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pense devoir faire un autre choix : « *[…] les curateurs seront nommés parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour l'intelligence et la fidélité de leur gestion. Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s'ils avaient été choisis parmi les liquidateurs assermentés* ».

Dans l'état actuel de la législation luxembourgeoise « *[…] le mandat de curateur de faillite n'est pas incompatible avec les fonctions de membre de l'ordre judiciaire, spécialement avec celle de greffier-adjoint, la loi du 18 février 1885, qui seule règle aujourd'hui cette matière, ne décrétant aucune incompatibilité de ce genre ; même en admettant qu'il y ait incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire de l'ordre judiciaire et les fonctions de curateur de faillite, cette incompatibilité n'aurait d'autres effets que d'exposer le contrevenant à des peines disciplinaires et resterait sans influence sur la nature et les conséquences juridiques des actes posés par lui comme curateur ; il s'agirait non d'une incapacité, mais seulement d'une incompatibilité*[(1)] ».

1) Fin du mandat du curateur

Le mandat du curateur prend normalement fin par la clôture de la faillite. Il peut y avoir **révocation** du curateur ou d'un ou plusieurs des curateurs pour le(s) remplacer par d'autre(s). La révocation a lieu soit d'office soit sur dénonciation de toute personne ayant un intérêt à voir remplacer un curateur incapable, malhonnête ou simplement inactif[(2)].

2) Les pouvoirs du curateur

Le curateur est tenu de gérer la faillite en bon père de famille en agissant sous la surveillance du juge-commissaire ; il ne peut déléguer à d'autres ses pouvoirs, mais il peut se faire assister. En particulier, il se fait souvent aider par le failli lui-même. Dans ce cas, ce sera le juge-commissaire qui fixe les conditions du travail fourni par le failli.

Art. 477 C.com.

« Les curateurs pourront, sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente. Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu'en vertu de l'autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire, et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode et les conditions de la vente ».

1 – Cass. du 31 juillet 1908, *P.*, nº 8, p. 155, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 325.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Art. 493 C.com.

« *Les curateurs pourront employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail* »[1].

Lorsque plusieurs curateurs ont été nommés, ceux-ci ne sont pas tenus d'agir collectivement[1].

B – Statut du curateur

Le curateur est un **mandataire salarié**. On enseigne traditionnellement qu'il **représente** à la fois **le failli et la masse** des créanciers. Cette conception est toutefois critiquable dans la mesure où la masse, en l'absence de personnalité morale, ne peut pas faire l'objet d'une représentation. Dans ce sens, on a considéré qu'il serait plus correct de dire que le curateur exécute une mission déterminée par la loi et qu'il tient ses pouvoirs du jugement qui le nomme[2].

Les curateurs d'une faillite « représentent » aussi bien la personne faillie que la masse des créanciers de cette dernière ; en cette **double qualité** « *[…] ils sont non seulement chargés d'administrer les biens de la faillite, mais autorisés à suivre, comme demandeurs ou comme défendeurs, toutes les actions qui ont pour but la conservation de l'actif qui doit servir de gage aux créanciers, de même que la reconstitution ou l'accroissement de cet actif dans l'intérêt commun de ces derniers ; il en est autrement lorsque l'action n'a pour but que la fortune personnelle de l'un ou de l'autre des créanciers ; dans ce cas le droit d'agir appartient exclusivement au créancier intéressé* »[3].

Lorsque le curateur, en application de l'article 445 C.com., agit en annulation de certains actes faits, il n'agit pas au nom, mais au profit de la masse. « *Ces considérations ont fait dire que le curateur, étranger au failli et à ses créanciers, n'est le mandataire de personne. Représentant de la loi, il n'est ni l'homme des créanciers, ni celui du failli* »[2].

Le curateur est donc un **mandataire judiciaire** qui tient son mandat du tribunal et dont les pouvoirs sont légalement déterminés.

La question de savoir si les créanciers, en tant qu'ils constituent une masse « représentée » par le curateur, sont par rapport au failli des tiers ou des ayants cause est généralement résolue en ce sens que les **créanciers** ne sont pas d'une manière absolue exclusivement tiers ou exclusivement ayants cause, mais qu'ils peuvent avoir tantôt l'une, tantôt l'autre qualité, suivant qu'ils puisent leurs droits dans leurs propres titres ou dans les titres de leur débiteur. D'après cette distinction, la masse est ayant cause du failli lorsqu'elle exerce les droits de celui-ci en vertu de la disposition générale de l'article 1166 du Code civil ou de la saisine particulière de l'article 444 de la loi du 2 juillet 1870 ; elle est tiers par rapport au failli lorsqu'elle exerce les droits que la loi lui confère directement soit en vertu de l'article 1167 du Code civil, soit en vertu des articles 445 à 449 de la loi du 2 juillet

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 317.

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 309.

3 – Cour du 2 juillet 1880, *P.*, no 2, p. 49 ; Lux. du 10 août 1891, *P.*, no 3, p. 537, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

1870. Spécialement, les curateurs qui, avant l'instance, ont reconnu la sincérité d'un acte de bail par une dénonciation pure et simple de ce même bail ne sauraient, en cours d'instance, critiquer ce bail en qualité de tiers pour n'avoir pas date certaine. Les curateurs ne pouvant plus dans ces circonstances exercer un droit propre provenant soit de l'article 1167 C.c., soit des articles 445 à 449 C.com. ne peuvent plus exercer que les droits du failli. Ces droits, ils ne peuvent les exercer que dans la mesure et dans les limites où ils appartiennent au failli lui-même ; or, le failli ne saurait critiquer un bail par lui consenti pour n'avoir pas date certaine ; le bail doit donc, dans les circonstances données, faire foi de sa date à l'égard des créanciers comme à l'égard du failli[1].

Le curateur d'une faillite n'est **pas un tiers** dans les termes de l'article 1328 C.c. Administrant les biens du failli dessaisi de cette administration par la loi et le jugement déclaratif de faillite, il représente aussi bien le failli, que la masse de ses créanciers ; « *[…] il est notamment l'ayant cause du failli lorsqu'il s'agit d'apprécier le résultat des conventions faites et des comptes réglés de bonne foi par le failli encore à la tête de ses affaires ; spécialement il ne peut pas en cette qualité repousser les conventions faites par le failli, qui n'auraient pas acquis date certaine avant la faillite par le seul motif de l'absence de cette date, alors qu'il n'argue pas ces conventions de fraude ni d'antidate* »[2].

Le curateur d'une faillite est obligé de respecter, au même titre que le failli lui-même, les contrats que ce dernier a valablement conclus avant la déclaration de la faillite ; spécialement il est obligé de respecter le contrat d'assurance dans lequel il est stipulé que le paiement de l'indemnité immobilière ne sera fait que si le bâtiment est en bonne voie de reconstruction[3].

C – Responsabilité du curateur

Le curateur étant un **mandataire**, il ne contracte aucune obligation personnelle, du moins s'il agit dans la limite de ses pouvoirs. Les frais exposés par lui sont supportés par la masse. De façon générale, les règles du **mandat** (**civil**) sont applicables à son égard. Le curateur est donc responsable de ses fautes et négligences. Il doit réparer les dommages causés par lui.

■ § 2 – Le juge-commissaire

A – Nomination du juge-commissaire

En même temps qu'il nomme le(s) curateur(s), le jugement déclaratif de la faillite nomme un juge-commissaire (art. 466 C.com.).

1 – Lux. du 8 février 1902, p. 6, p. 312, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 17 mars 1881, *P.*, n° 2, p. 41, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 12 mai 1893, *P.*, n° 3, p. 237, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Aux termes de l'article 462 C.com., le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres.

« *Les juges-commissaires aux faillites sont nommés et remplacés par le tribunal de commerce, sans distinguer s'il s'agit d'un remplacement définitif ou momentané, ni suivant que ce remplacement a pour objet l'ensemble des fonctions conférées au juge-commissaire, ou seulement l'un des actes compris dans l'exercice de ces fonctions ; l'assemblée des créanciers présidée par un juge qui n'a pas reçu mandat à cet effet par le tribunal de commerce est irrégulièrement constituée, ce qui entraîne la nullité de tout ce qui a été fait et décidé* »[1].

B – Fonctions du juge-commissaire

D'après l'article 463 C.com., le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite ; « *[…] il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître ; il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il présidera les réunions des créanciers du failli. Les ordonnances du juge-commissaire sont exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances seront portés devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale* ».

Le rôle actif est joué par le curateur de la faillite, sous le contrôle du juge-commissaire. La procédure devrait garantir la célérité des opérations. Avant de pouvoir liquider les actifs et surtout avant de pouvoir en répartir le produit en guise de paiement des créanciers, il faut faire **l'état des lieux** : répertorier les actifs et faire l'état des créances.

Le même jugement désignera les jour et heure auxquels il sera procédé, au palais de justice, à la clôture du procès-verbal de **vérification des créances** et aux débats sur les contestations à naître de cette vérification. Ces jours seront fixés de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et vingt jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et la clôture du procès-verbal de vérification, et un intervalle semblable entre cette clôture et les débats sur les contestations.

L'inventaire des actifs peut, selon le cas, se faire soit avec, soit sans l'apposition de scellés (art. 468 C.com.). La loi précise encore que certains objets ne peuvent être placés sous scellés : il s'agit en particulier des livres comptables, des biens sujets à dépérissement, etc. (art. 471 C.com.).

■ § 3 – Le procureur d'État

Au vœu de l'article 464 C.com., le procureur d'État « *[…] peut assister à toutes les opérations de la faillite, prendre inspection des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il jugera utiles* ».

1 – Cour du 12 juillet 1895, *P.*, n° 4, p. 35, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 4 – Les experts

Le cas échéant, il est fait recours à des experts, qui sont nommés par le tribunal sur proposition du curateur et après avis du juge-commissaire. Ils ont pour mission d'assister le curateur dans les tâches dans lesquelles les connaissances techniques lui font défaut.

SECTION IV
RÔLE DU FAILLI

Le rôle du failli est très réduit, mais il est loin d'être inexistant et, en pratique, il peut être très important. La loi tient compte des réalités pratiques en décidant que le failli **collabore** avec le curateur. Par la force des choses, c'est le failli qui, mieux que quiconque, connaît la situation de l'entreprise telle qu'elle s'est présentée au moment de la déclaration de la faillite.

La loi institue ainsi un véritable devoir de collaboration (ou d'information) à l'égard du failli : « *[…] Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs* » (art. 482 C.com.). (Art. 483 C. com. « *Les curateurs appelleront le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence* ») en lui défendant de s'absenter « *sans l'autorisation du juge-commissaire* » (art. 482 C.com.).

Art. 474 C.com.
« *Si un débiteur, en faisant l'aveu de sa faillite, a déclaré que son actif est plus que suffisant pour payer toutes ses dettes, et s'il a demandé un sursis, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, sans arrêter la marche de la faillite, pourra ordonner la vérification immédiate de l'état de ses affaires par un ou plusieurs experts ; et si, d'après le résultat de cette vérification, il reconnaît que l'actif du débiteur dépasse réellement son passif, il ordonnera la convocation immédiate des créanciers, et il sera procédé comme il est dit au titre IV* ».

Le failli sera appelé à **l'homologation** ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. Les curateurs pourront aussi, avec l'autorisation du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.

Art. 494 C.com.
« *En toute faillite, les curateurs, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir. Le juge-commissaire transmettra immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur d'État. S'il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il en préviendra le procureur d'État, et lui indiquera les causes du retard* ».

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

SECTION V
DES EFFETS DE LA FAILLITE

Le premier effet est le **dessaisissement** de plein droit du failli.

Art. 444 C.com.
« *Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit* ».

Dessaisissement n'est pas synonyme d'incapacité : le failli pourrait notamment participer à une nouvelle société, à laquelle il ne pourrait toutefois apporter que son industrie, et non les biens sur lesquels il n'a plus de pouvoir de disposition(1).

Le failli, encore que dessaisi de l'administration de ses biens, n'est pas en état d'interdiction et on ne saurait lui dénier le droit de s'adonner à un travail pour assurer son existence ni de prendre des engagements ou de faire des actes de disposition valables. Mais les fruits de son activité viendront accroître la masse active pour tout ce qui excède les besoins de son entretien et de celui de sa famille, déduction faite des frais d'acquisition qu'il a exposés et des charges légitimes dont les biens nouvellement acquis sont grevés(2).

Quel est le moment exact du début de dessaisissement ? En Belgique, on s'accorde pour dire que les effets du dessaisissement remontent à la **première heure du jour** du jugement déclaratif de la faillite(3). La jurisprudence luxembourgeoise se rallie à cette position connue sous le terme de « *règle de 0 heure* ».

Les effets de la faillite ne s'arrêtent pas à ce dessaisissement qui a effet pour l'avenir, mais remontent au passé précédant immédiatement la faillite. Ceci fait référence à la notion de la **période suspecte**. Certains actes que le failli a réalisés avant sa déclaration de faillite peuvent être annulés.

■ § 1 – Nullité des actes réalisés par le failli

La loi appréhende le débiteur failli avec une certaine suspicion. En présumant que la faillite est due à ses fautes, il est dessaisi de ses affaires avec donc la conséquence que désormais il ne peut plus apporter la moindre modification à son patrimoine. La gestion de ce patrimoine est confiée au curateur nommé par le tribunal(4).

Les effets de la faillite remontent même dans le temps, dans la mesure où certains actes faits pendant la période de temps appelé **période suspecte** peuvent

1 – T. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, T. 1, p. 346.

2 – Cour du 3 mars 1921, *P.*, n° 11, p. 546, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 84.- « Le jugement de faillite sort ses effets à zéro heure, le jour du prononcé, en sorte que le jour entier au cours duquel intervient le jugement de faillite fait partie de la période de faillite et que les paiements faits ce même jour sont nuls de droit » ; Cour du 21 janvier 1981, *P.*, n° 25, p. 373.

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 47.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

et, dans certains cas, doivent être **annulés** dans la mesure où ils s'avèrent préjudiciables à la communauté des créanciers[1].

A – Notion de période suspecte

La période suspecte est comprise entre le jour de la cessation de paiements et la date du jugement déclaratif de faillite. L'importance de la période suspecte réside dans le fait que certains actes faits par le débiteur au cours de cette période (y compris un **délai de dix jours** qui précède le début de cette période) sont susceptibles d'être frappés de nullité.

La jurisprudence sur cette matière est très abondante.

En matière d'assurance contre les accidents, le droit à l'indemnité n'est pas exclusivement attaché à la personne de l'assuré et, partant, la masse des créanciers de l'assuré failli a qualité et titre pour actionner l'assureur en versement de l'indemnité[2].

Lorsque plusieurs curateurs ont été nommés, chacun d'eux a mandat pour **agir séparément** dans l'intérêt de la masse[3]. L'action intentée par deux curateurs en l'absence du troisième est recevable s'ils ont été autorisés à cet effet par le tribunal de commerce[4].

Il est de principe, en matière de faillite, que le créancier ne peut exercer une action qui intéresse la masse entière. Il n'en est cependant pas ainsi de l'action en dommages-intérêts, qui appartient à quiconque est lésé dans ses droits et dont l'exercice est entièrement indépendant de l'intervention ou de l'adhésion d'un tiers. Cette règle ne s'applique du reste aux masses faillies que tant que la liquidation n'est pas terminée ; lorsque les opérations de la faillite sont clôturées, les créanciers de la faillite rentrent dans l'exercice de leurs actions personnelles[5].

Les créanciers d'un failli, agissant dans l'intérêt de tous les créanciers et non pour réclamer un droit purement personnel, sont recevables à se joindre à la demande formée par les curateurs[6].

L'intervention d'un créancier de la faillite à un procès engagé par le curateur est justifiée du moment que sa production n'est pas définitivement rejetée et annulée par une décision coulée en force de chose jugée ; cette intervention ne saurait donc être refusée pour le seul motif que la production se trouve contestée et non admise au passif de la faillite[7].

---

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 48.

2 – Lux. du 19 juillet 1893, *P.*, nº 3, p. 463, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 30 janvier 1895, *P.*, nº 4, p. 34, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Lux. du 4 juillet 1894, *P.*, nº 4, p. 388, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Lux. du 20 mars 1891, *P.*, nº 2, p. 344, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Cour du 2 juillet 1880, *P.*, nº 2, p. 49, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

7 – Lux. du 8 février 1902, *P.*, nº 6, p. 312, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Le curateur d'une société en nom collectif faillie a qualité pour produire au passif de la faillite personnelle de chacun des associés pour le montant intégral du passif social, sauf à déduire de cette production le montant des productions qu'auraient faites individuellement les créanciers sociaux[1].

Lorsque, dans une demande en séparation de biens introduite par la femme contre son mari déclaré en état de faillite et contre le curateur de la faillite, les défendeurs viennent à succomber, ils doivent, en conformité de l'article 130 du Code de procédure civile être condamnés aux dépens, et ce, chacun pour moitié ; les frais exposés par la demanderesse sont à prélever sur l'actif de la faillite, à savoir ceux exposés contre le mari, à titre chirographaire et ceux exposés contre le curateur, à titre privilégié[2].

Par suite de son dessaisissement, le failli n'a pas la capacité de faire un aveu opposable à la masse[3].

Est irrecevable le serment litisdécisoire déféré au failli, alors que ce serment implique une transaction et que le failli est **incapable de transiger**[4].

Par effet d'une déclaration de faillite, le **compte courant** arrive à son terme de plein droit ; en vertu du principe d'indivisibilité de ce compte, la compensation entre les différents postes y inscrits s'opère automatiquement jusqu'à due concurrence[5].

Si les articles de crédit et de débit d'un compte courant forment un ensemble indivisible dont l'arrêté de compte permet seulement de dégager le solde à charge de l'un ou l'autre des correspondants, de sorte que ce solde est opposable à la masse des créanciers du failli, le même principe ne saurait être appliqué aux soldes respectifs de plusieurs comptes courants existant entre les mêmes parties, chaque compte gardant dans ce cas son individualité propre.

Même s'il a été convenu que les comptes sont à considérer comme constituant un compte-courant unique et qu'à tout moment et sur simple avis les soldes débiteurs peuvent être transférés aux comptes créditeurs ou inversement, toujours est-il que, tant que le transport effectif des masses respectives de l'actif et du passif n'a pas été opéré, les comptes individuels subsistent avec leur personnalité propre, de sorte qu'en cas de déclaration de faillite, ils ne peuvent se compenser et que l'article 445 du Code de commerce doit éventuellement trouver son application[6].

À partir du jugement déclaratif de faillite, aucune **compensation**, ni légale, ni judiciaire, ni conventionnelle ne peut se produire même entre créances préexistantes, si

1 – Cour du 26 janvier 1885, *P.*, n° 2, p. 448, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Diekirch du 22 novembre 1900, *P.*, n° 6, p. 100 ; Lux. du 4 mai 1904, *P.*, n° 6, p. 286 ; *Contra* : Lux. du 10 juin 1896, *P.*, n° 4, p. 286, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Diekirch du 24 janvier 1934, *P.*, n° 13, p. 317, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Diekirch du 9 juillet 1932, *P.*, n° 13, p. 261, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cour du 2 mars 1923, *P.*, n° 11, p. 134, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Lux. du 8 novembre 1930, *P.*, n° 13, p. 269, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

elles ont manqué jusqu'à cette date d'une des trois qualités de liquidité, d'exigibilité et de fongibilité[1].

Tant qu'il n'y a pas faillite déclarée, l'action en résolution de la vente peut être exercée par le vendeur contre l'acheteur d'objets mobiliers non payés.

L'action régulièrement intentée avant l'ouverture de la faillite constitue pour le demandeur un droit acquis à se voir reconnaître judiciairement le droit de résolution qui lui appartenait au moment de l'introduction de la demande, et ce, nonobstant la survenance de la faillite[2].

La concession de cabaretage étant susceptible d'aliénation ne saurait être considérée comme un droit attaché à la personne du failli et tombe par conséquent dans la masse de la faillite en vertu de l'article 444 du Code de commerce[3].

Après la clôture de la faillite, le dessaisissement du failli subsiste quant aux valeurs qui, à tort, n'ont pas été comprises dans la liquidation[4].

La compensation des créances et des dettes réciproques du failli et d'un tiers peut s'opérer même durant la période suspecte, si elle a été convenue de bonne foi avant le commencement de cette période entre les deux parties contractantes. Les règles et usages des barreaux admettent que l'avocat convienne avec son client, dont il est le conseil habituel en vue de la récupération de créances nombreuses, de retenir ses frais et honoraires sur les sommes recouvrées, ce qui implique, au profit de l'avocat, la compensation entre les créances qu'il perçoit et ses honoraires. Convenue de bonne foi, cette compensation s'opère même pour les devoirs professionnels accomplis par l'avocat pendant la période suspecte, de sorte que l'avocat n'est pas tenu de verser les honoraires afférents à la masse de la faillite et de subir de ce chef la loi du dividende.

Si, en principe, le dessaisissement qui résulte d'un jugement déclaratif de faillite fait obstacle à toute **compensation** entre créances et dettes du failli jusqu'alors non liquides ni exigibles, il en est autrement lorsque les créances réciproques sont nées d'une même source et découlent d'un même contrat conclu avant la période suspecte avec un tiers.

En raison de la connexité d'origine existant dans ce cas et de l'interdépendance des obligations du failli et du tiers, sont compensables au profit du tiers toutes les créances réciproques antérieurement au jugement déclaratif de faillite, à condition que les créances du tiers soient certaines dans leur principe, même si, au jour du jugement, elles ne sont pas liquidées[5].

1 – Cour du 2 mars 1923, *P.*, n° 11, p. 134, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 16 juin 1938, *P.*, n° 14, p. 193, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 7 mars 1924, *P.*, n° 11, p. 535, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Lux. du 14 janvier 1914, *P.*, n° 10, p. 32, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Lux. du 15 juin 1966, *P.*, n° 20, p. 212, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Le curateur de faillite n'a qualité ni pour exercer une action en réparation d'un dommage moral éprouvé par le failli ni pour interjeter appel contre un jugement ayant alloué à celui-ci une indemnité pour dommage moral[1].

À la suite de l'abolition de la procédure du reproche, un failli peut être entendu comme témoin dans les contestations concernant son propre passif[2].

B – Justification de la période supplémentaire de dix jours

On considère souvent que ce délai supplémentaire de dix jours qui s'ajoute au délai de six mois est arbitraire et que sa justification se trouve surtout dans des raisons historiques (« *parce qu'il est entré dans nos usages dans nos mœurs […]* »)[3].

La solution légale a également été critiquée par ceux qui ont considéré que, si la faillite a déjà existé auparavant, alors il fallait la déclarer. Si la cessation de paiements n'a pas existé à ce moment-là, il n'y a pas lieu de frapper les actes à ce moment déjà. « *La solution légale ne procède pas d'une logique rigoureuse mais elle permet d'atteindre des opérations particulièrement préjudiciables […] faites pendant une période qui, sans impliquer une suspension des paiements* stricto sensu*, présente un caractère équivoque* »[3].

C – Actes annulables de droit

L'article 445 C.com. énumère les actes qui doivent **obligatoirement** être annulés : « *Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque* :

Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour ;

Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ;

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ».

L'article 445 C.com. comporte deux sortes de chefs d'annulation : soit il y a annulation pour cause de déséquilibre entre la prestation donnée et celle reçue lors de la transaction elle-même, soit le principe d'égalité n'est pas respecté du fait du paiement.

Ce dernier cas est encore subdivisé en deux : les paiements pour **dettes non échues** sont toujours à annuler ; les paiements pour **dettes échues** ne sont critiqués que s'ils concernent des paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce.

---

1 – Cour du 10 octobre 1978, *P.*, n° 24, p. 204, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 10 juillet 1991, *P.*, n° 28, p. 231, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 217.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il s'agit, finalement, des sûretés constituées pour dettes antérieurement contractées. La nullité de l'article 445 est en réalité une « **action paulienne** *adoucie et facilitée basée moins sur la notion de fraude que sur la nécessité de garantir une liquidation égalitaire* »[1].

En ce qui concerne les premiers, ils provoquent un grave **soupçon de fraude** et ils sont toujours préjudiciables à la masse. La nullité doit obligatoirement être prononcée si les conditions légales sont remplies. Les circonstances de ces opérations, tout comme la bonne ou la mauvaise foi des parties, sont sans la moindre influence sur la décision[2].

La nullité est une **nullité relative** qui n'existe qu'à l'égard de la masse. « *Sont nuls et sans effet relativement à la masse* ». L'acte n'est pas inexistant et il doit être annulé par les juridictions. L'action peut être exercée seulement par le curateur qui représente la masse. La nullité ne pourrait pas être invoquée par le failli, par ses représentants ou ayants cause. Le cocontractant ne pourrait invoquer la nullité pour échapper à ses obligations[3].

Les seules conditions requises par la loi sont donc, d'une part, que l'acte entre dans l'énumération limitative prévue par la loi et, d'autre part, qu'il ait été réalisé pendant la période suspecte ou pendant les dix jours qui précèdent la date de cessation de paiements.

Nous allons ci-après commenter les différents opérations visées par l'article 445 C.com. :

– les libéralités faites par le débiteur ;
– les paiements de dettes non échues et dations en paiement de dettes échues ;
– les constitutions de sûretés réelles pour dettes antérieures contractées.

1) Les libéralités

Le caractère critiquable de ces opérations va de soi. Il est en effet inadmissible qu'un débiteur dont les affaires vont mal fasse des libéralités qui ne peuvent aller qu'au préjudice de la masse des créanciers. Si de telles libéralités ont été faites pendant la période visée, il doit y avoir restitution, et ceci, même si le tiers est de bonne foi[4].

On a fait valoir que la formule de l'article 445 C.com. serait trop étroite. En effet, ne seraient pas seulement visés « *tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit* », mais le législateur a entendu atteindre toute libéralité généralement quelconque. Peu importe que le bien ne soit pas une propriété et la forme sous laquelle elle est faite[4]. Il suffirait que le débiteur entame son capital sans compensation pour que la nullité soit applicable. « *Le texte légal vise le don manuel, les libéralités qui ne sont pas des aliénations, comme la constitution à titre gratuit de droit réels, la jouissance gratuite d'un immeuble, la remise d'une dette, la renonciation*

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 213.
2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 216
3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 214.
4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 219.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

gratuite à une succession, à un legs ou à tous autres droits (p. ex., à un procès intenté, au bénéfice du terme, à la possibilité d'agir en rescision) »[1].

Sont encore visés par le même alinéa 2 de l'article 445 C.com. les opérations suivantes :

– les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour.

Dans ce cas de figure, on est en présence d'actes qui sont pour partie des **actes à titre gratuit,** mais qui sont déguisés sous forme d'actes à titre onéreux. La raison pour procéder à l'annulation de ces actes est identique à celle qui est à la base de l'annulation des actes à titre gratuit. L'annulation est nécessaire pour éviter que la masse des créanciers ne subisse un dommage du fait de l'exécution de telles opérations déséquilibrées.

Toutefois, l'annulation n'est requise que s'il y a déséquilibre manifeste entre les prestations des parties en présence.

2) Paiements de dettes non échues et dations en paiement de dettes échues

La formulation de l'article est peu heureuse et il serait plus clair d'écrire : « tous paiements de dettes non échues sont annulables. En ce qui concerne les dettes échues, les seuls paiements par dations en paiement sont à annuler ».

L'article 445 C.com. instaure une protection spéciale aux intérêts de la masse pour la période qui s'écoule entre la date de cessation de paiements et la faillite déclarée. Cette mesure s'explique par le fait que le droit commun assure une protection insuffisante : en effet, l'article 1167 C.c. relatif à l'action paulienne exige des conditions trop restrictives en demandant la preuve que le débiteur a agi « *en fraude des droits de ses créanciers* » en leur causant donc de mauvaise foi préjudice. Il faut en outre que le **tiers cocontractant** du débiteur soit **complice** de la fraude[2].

Pourquoi les paiements de **dettes non échues** sont-ils toujours annulés ? Pour la raison qu'il n'est pas normal qu'un commerçant, dont la trésorerie est très serrée et qui ne sait plus faire face aux paiements des dettes échues procède au paiement de dettes non échues : il y a rupture incontestable de l'égalité entre créanciers[3].

Les seuls paiements valables dans la période suspecte sont ceux qui constituent une exécution fidèle de la convention : il s'agit pratiquement toujours des paiements en espèces, mais ceci n'est pas absolument nécessaire. Un paiement en une chose autre que celle qui a été prévue initialement sera annulable[4]. Ceci vaut en particulier pour la dation en paiement : « *la remise d'un objet autre que celui que le débiteur devait livrer ne se fait en général que sous la pression d'un créancier qui veut échapper aux inconvénients de la faillite* »[5].

Les paiements sont encore valables s'ils consistent en **effets de commerce**. Cette solution se justifie par le fait que les usages commerciaux assimilent ces

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 219.
2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 213.
3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 225.
4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 231.
5 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 230.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

paiements à des paiements en **espèces**[1]. En revanche, la résolution amiable d'une vente intervenue dans la période suspecte n'est pas une dation en paiement[2].

Les autres paiements pour dettes échues sont nuls. Sont visés (et ceci, par référence au premier bout de phrase de l'alinéa 3 de l'article 445 C.com.) en particulier les paiements suivants :

– par transport ;
– vente ;
– compensation ;
– autrement.

Les paiements par transport font référence aux cas où le débiteur, pour s'acquitter de sa dette, cède à son créancier la créance qu'il possède sur un tiers, ou encore en donnant ordre au tiers de payer entre les mains de son créancier[3].

Ce moyen de paiement n'est attaquable que s'il concerne le paiement d'une dette préexistante échue. Si la délégation est consentie en même temps que la négociation d'un contrat à titre onéreux, elle est valable[4].

Les paiements par vente font référence aux cas de paiements par marchandises, et ceci, quelle que soit la forme que prend ce paiement. Un des cas de figure est le suivant : le débiteur doit une somme de X à un tiers. N'étant pas à même d'en payer le prix, le débiteur vend des marchandises à ce même tiers pour un montant X : les parties procèdent à la compensation de leurs créances.

Il se peut encore que le débiteur, en période suspecte, envoie à son créancier des marchandises en **consignation** avec mandat de les réaliser et de se payer sur le prix[5].

La compensation prohibée est la **compensation conventionnelle**. Sont ainsi interdits les cas où le débiteur et le créancier, pendant la période suspecte, s'entendent pour compenser les deux obligations, bien qu'elles ne remplissent pas toutes les conditions requises pour la compensation légale[6]. Une telle compensation avantage indûment un créancier au détriment de la masse.

Le jugement déclaratif comporte comme effet la **déchéance du terme**. « *La déchéance du terme tend à réaliser l'égalité entre tous les créanciers et ne peut donc avoir pour résultat d'avantager parmi eux celui dont le titre n'est pas arrivé à échéance. Ainsi, l'exigibilité ne peut produire aucune compensation entre la dette non échue du failli et la somme que le créancier pourrait lui-même devoir* »[7]. La compensation n'est possible que si les deux créances sont déjà liquides et exigibles au moment de la déclaration de faillite. Cette condition n'est pas remplie si l'une des dettes n'échoit que par l'effet de la faillite.

Les paiements par compensation ne concernent pas les cas de compensation légale : celle-ci se produit de droit, et ceci, même pendant la période suspecte[8].

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 232.
2 – Cour de Mons du 21 avril 1975, *Pas.*, 1976, II, p. 27.
3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 233.
4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 234.
5 – CA Liège du 11 mai 1915, *Pas.*, 1915-1916, II, p. 144.
6 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 237.
7 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 295.
8 – V. notamment Cass. fr. du 24 avril 1923, *D.*, 1926, I, p. 16.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette compensation légale s'opère de plein droit entre deux créances qui ont pour objet une somme d'argent (ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce) et qui sont également liquides et exigibles. « *La compensation légale admise suppose que les contractants n'aient aucune intervention active dans l'opération ; il en découle que l'article 445 atteindra la compensation malgré son apparence légale lorsque, pour la préparer et la rendre possible, quelque contrat volontaire est intervenu en temps suspect entre le failli et le tiers, qui prétend compenser avec lui. Pareille combinaison a pour effet de créer une compensation légale fictive. Or, la fraude corrompt tout* »[1].

Pour la jurisprudence, la période suspecte n'empêche pas la compensation de se faire : « *Elle n'est pas un "acte" du débiteur, elle opère à son insu ; l'article 445 du Code de commerce ne la vise pas (Les Novelles, T. IV, nº 456, p. 141)* »[2]. Il est requis que les dettes et les créances soient réciproques, en plus d'être certaines, liquides et exigibles.

« *Une dette est à considérer comme liquide […] bien qu'elle soit de la part du débiteur l'objet de contestations, si le créancier en a la preuve en main et peut en justifier promptement* »[2].

Par « autrement » sont visés en particulier les dations en paiement, voir plus haut.

3) Constitution de sûretés réelles pour dettes antérieures

Le dernier alinéa vise aussi les cas de constitution d'hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur. Le traitement de ces sûretés est différent selon que la constitution intervient au moment de la constitution de l'obligation principale ou **ultérieurement**. Dans le premier cas de figure, il y a indivisibilité dans la mesure où, si le créancier a exigé une telle garantie pour accorder un crédit, alors la garantie doit être maintenue. En revanche, si la garantie est constituée ultérieurement, il est suspect que le créancier qui initialement avait accordé le crédit sans garantie en obtienne une plus tard. Au regard de l'égalité entre créanciers, cette constitution de garantie a le même effet qu'une **libéralité** accordée à son profit[3].

L'acte de gage constitué pour la sûreté d'une dette civile doit avoir acquis **date certaine** avant la période suspecte, alors que le gage commercial est valable s'il peut être établi, par toutes voies de droit, qu'il est né antérieurement à cette période[4].

L'article 445 C.com. a pour but évident de maintenir l'égalité entre créanciers chirographaires et d'empêcher le futur failli d'avantager l'un d'eux en lui accordant une sûreté qui n'avait pas été constituée lors de la naissance de la dette[5].

Mais cet article ne s'applique pas aux sûretés constituées au moment même où la dette a été contractée. « *Spécialement, si un prêt a été consenti durant la période suspecte au futur failli moyennant l'engagement pris par ce dernier de garantir ce prêt*

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 236.

2 – CA com. du 5 mai 2004, nos 27.857, *BIJ* 2004, nº 9, p. 180.

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 238.

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 243.

5 – CA com. du 28 octobre 1969, *P.*, nº 21, p. 232, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

par une mise en gage du fonds de commerce, mais que ce gage n'ait pu être documenté par écrit que quelques jours après l'octroi du prêt, le prêt et la mise en gage du fonds de commerce se fondent en une opération unique, en sorte que le prêt ne saurait être considéré comme antérieur à la mise en gage du fonds de commerce »[(1)]. La mise en gage du fonds de commerce n'est donc pas entachée de nullité.

4) Effets de la nullité

La nullité produit ses effets à l'égard de la masse et profite à tous les créanciers qui la composent. À l'égard des ayants cause directs du failli, il y a lieu d'annuler les effets de l'acte (libéralité, p. ex.), que le bénéficiaire de celui-ci ait été de bonne ou de mauvaise foi. En cas de paiement anticipé ou de dation en paiement, le créancier payé anticipativement en espèces ou en effets de commerce doit rembourser les fonds encaissés. Les intérêts encaissés sur les sommes en question doivent également être rétrocédés : la nullité doit frapper l'opération dans toutes ses conséquences[(2)].

À l'égard des sous-acquéreurs éventuels (en cas de cession des biens par les ayants cause directs), la situation est un peu plus complexe dans la mesure où le tiers cessionnaire échapperait à la nullité. Selon le cas, il peut encore être distingué selon que le transfert en question est à titre gratuit ou à titre onéreux. Dans le premier cas de figure, la nullité atteint également le deuxième transfert, et ce, même si le bénéficiaire est de bonne foi[(3)-(4)].

L'action en nullité n'agit pas *in rem*, mais *in personam* : cette solution est conforme au fondement de la nullité en période suspecte. Il s'agit pour le tiers de **réparer** le **préjudice** qu'il a causé à la masse par sa faute ; il faut donc que le sous-acquéreur ait su qu'il lésait la masse[(4)].

a) Constitution de garanties

L'article 445 C.com. n'est applicable qu'à **l'hypothèque conventionnelle** ou judiciaire et ne saurait être étendu à l'hypothèque légale[(5)].

Comme le contrat de gage est un **contrat** essentiellement **réel**, qui ne se forme que par la délivrance de la chose entre les mains du créancier, est nul, en vertu de l'article 445 C.com., le nantissement constitué, depuis l'époque de la cessation de paiements, pour une dette antérieurement contractée, lors même qu'il eut fait l'objet d'une **promesse** de gage antérieure, consentie au moment de la naissance de la créance[(6)].

---

1 – CA com. du 28 octobre 1969, *P.*, n° 21, p. 232, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 248.

3 – V. Cass. b. du 9 janvier 1890, *Pas.*, 1890, I, p. 59, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 251.

5 – Lux. du 2 juillet 1902, *P.*, n° 6, p. 283, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Cass. du 23 décembre 1892, *P.*, n° 3, p. 163, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Une promesse d'hypothèque n'équivaut pas à l'acte de constitution. Par conséquent est nulle l'hypothèque constituée par le failli en période suspecte pour une dette antérieurement contractée, alors même que la promesse d'hypothèque a été concomitante au prêt[1].

L'article 445 C.com. englobe tous actes de libéralité, même non translatifs de propriété, et notamment les renonciations pures et simples à un droit. « *Est donc nulle à l'égard de la masse une mainlevée d'hypothèque consentie pendant la période suspecte, bien que la dette garantie ne soit pas éteinte, une telle mainlevée constituant un acte de libéralité* »[2].

La nullité de l'article 445 C.com. ne s'applique pas à l'hypothèque constituée pendant la période suspecte en vue de garantir une avance à faire après l'acte et sans qu'il y ait fraude[3].

La nullité de droit, édictée par l'article 445 C.com., n'ayant d'autre but que de maintenir l'égalité entre les créanciers chirographaires et d'empêcher le futur failli d'avantager l'un d'eux en lui accordant une sûreté qui n'avait pas été constituée lors de la naissance de la dette, cette nullité ne saurait s'appliquer aux sûretés qui ont été constituées au moment même où la dette a été contractée.

Spécialement, si un prêt a été consenti durant la période suspecte au futur failli moyennant l'engagement pris par ce dernier de garantir ce prêt par une **mise en gage du fonds de commerce**, mais que ce gage n'a pu être documenté par écrit que quelques jours après l'octroi du prêt, le prêt et la mise en gage du fonds de commerce se fondent en une **opération unique**, de sorte que le prêt ne saurait juridiquement être considéré comme antérieur à la mise en gage du fonds de commerce. Par voie de conséquence, la mise en gage du fonds de commerce n'est pas entachée de nullité par application de l'article 445 C.com.[4].

Si le tuteur failli s'est fait ouvrir par une banque un crédit en compte courant et que, pour la garantie des engagements pris, il a, pendant la période suspecte, constitué en gage son fonds de commerce, cette mise en gage est frappée de la nullité de droit, édictée par l'article 445 C.com. dans la mesure où, au moment de la constitution de cette sûreté, le compte courant présentait déjà une position débitrice à la charge du futur failli[5].

b) Dation en paiement

La dation en paiement constitue une **modalité de paiement** consistant en une convention en vertu de laquelle les parties conviennent de modifier l'objet du

1 – Cour du 5 janvier 1933, *P.*, n° 14, p. 219, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Diekirch 24 janvier 1934, *P.*, n° 13, p. 317, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 20 février 1934, *P.*, n° 13, p. 261, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 28 octobre 1969, *P.*, n° 21, p. 232, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Lux. du 29 septembre 1967, *P.*, n° 21, p. 246, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

paiement, en sorte que la remise d'une chose différente de celle qui était convenue entraînera néanmoins la libération du débiteur[1].

La clause en vertu de laquelle le vendeur d'une voiture nouvelle s'oblige à reprendre à un prix déterminé la **voiture ancienne** de son acheteur ne forme qu'une des conditions de la vente de la voiture nouvelle et fait corps avec ce contrat parfaitement valable. Intervenue pendant la période suspecte, cette opération n'a pas le caractère d'une dation en paiement interdite par l'article 445 C.com.[2].

La convention de résiliation d'une vente pour défaut de paiement du prix équivaut à une dation en paiement. En conséquence, lorsque pareille résiliation a eu lieu en période suspecte, elle est nulle de plein droit conformément à l'article 445 C.com.[3].

Si la résolution d'une vente et la restitution des objets vendus au vendeur, qui en est la suite, sont susceptibles d'annulation par application des articles 445 et 446 C. com., lorsqu'elles ont été opérées pendant la période suspecte, ce n'est qu'en tant qu'actes du débiteur qui impriment à la résolution un caractère amiable et qui font de la restitution une dation en paiement. Au contraire, au cas où le vendeur, faisant fruit d'une clause résolutoire expresse insérée au contrat de vente à crédit, opte pour la résolution, celle-ci résulte d'un acte du créancier, acte qui intervient indépendamment de la volonté actuelle du débiteur, et elle demeure valablement acquise, même si elle se produit pendant la période suspecte, à la seule condition que le contrat qui lui sert de base soit lui-même inattaquable[4].

c) Compensation

Toute **compensation** légale, judiciaire ou conventionnelle est interdite en principe après la faillite, alors que, équivalant à un double paiement abrégé, une telle compensation permettrait au créancier qui en bénéficierait d'échapper à la loi du concours. Il est cependant admis, par exception, que la compensation après faillite est possible entre dettes connexes trouvant leur cause dans un même contrat synallagmatique, et cela même lorsque l'une des dettes n'est née qu'après la faillite[5].

Constitue une convention de compensation la clause du contrat de vente d'une voiture automobile stipulant qu'en cas de résolution de la vente par la faute de l'acheteur, les acomptes par lui versés sont acquis au vendeur à titre de jouissance, d'usure, d'indemnité de résiliation, etc., sans préjudice à de plus amples dommages-intérêts. En conséquence, cette clause est nulle au regard de la faillite de l'acheteur, si elle est appliquée en période suspecte, et le vendeur doit rembourser à la faillite les acomptes reçus, quitte à être colloqué pour le même montant au passif chirographaire[6].

---

1 – P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations », *R.C.J.B.*, 1988, p. 109.

2 – Cour du 18 juillet 1934, *P.*, n° 13, p. 236, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 30 juin 1933, *P.*, n° 13, p. 129, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 25 avril 1967, *P.*, n° 21, p. 65, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Lux. du 1er avril 1977, *P.*, n° 23, p. 556, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Cour du 30 juin 1936, *P.*, n° 14, p. 12, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

La rétrocession en tout ou en partie de la chose vendue au vendeur, à la suite de la résiliation d'un contrat de vente opérée pendant la période suspecte, constitue un paiement irrégulier aux termes de l'article 445 C.com. prohibant pour les dettes échues tous paiements autres que ceux faits en espèces ou en effets de commerce[1].

N'est pas nul par rapport à la masse le **gage** constitué **en même temps que le prêt** si le prêteur n'a pas eu connaissance de la cessation de paiements de son cocontractant, déclaré après en faillite[2].

En cas de vente intervenue entre le failli et un tiers pendant la période suspecte, la circonstance que l'acheteur était au moment de la vente créancier du failli et que les parties ont stipulé que le prix se compensait jusqu'à due concurrence avec la créance de l'acheteur, ne suffit pas pour entraîner la nullité de la vente en vertu de l'article 445 C.com. Il faut, pour que cet article puisse trouver son application, qu'il soit établi qu'il ne s'agissait en réalité, dans l'intention des parties, que d'un mode de paiement détourné, ou d'une dation en paiement déguisée, contraire à la notion d'égalité consacrée en matière de faillite[3].

Les opérations qui se rattachent à un **seul** et même **marché** forment un tout **indivisible** et constituent les éléments d'un compte unique dont le reliquat final est seul à considérer lorsqu'il s'agit de régler la situation réciproque des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les opérations qui constitueraient l'exécution du contrat et celles découlant de sa violation[4].

En cas d'ouverture de crédit, les dettes du crédité ne naissent que par l'utilisation et au fur et à mesure de l'utilisation du crédit. En conséquence, une hypothèque constituée par le failli pendant la période suspecte en garantie d'une ouverture de crédit est nulle seulement quant aux avances faites antérieurement à sa constitution, mais valable quant à celles faites postérieurement. S'il a existé entre parties une convention de compte courant, ce n'est qu'à la clôture du compte que la qualité de créancier ou de débiteur de l'une ou l'autre partie peut être fixée. Par suite de **l'indivisibilité** du **compte**, il n'y a, tant qu'il dure, ni créance ni dette, toutes les opérations réciproques ne constituant que de simples articles de débit et de crédit. Il en est ainsi bien que des balances provisoires aient été dressées pendant la durée du compte, les soldes que celles-ci ont fait apparaître étant devenus à leur tour des articles de compte. Il suit de ces principes qu'en cas de compte courant, la dette du crédité ne prend naissance qu'à la clôture du compte et que, par suite, une hypothèque constituée pendant la période suspecte, mais avant la clôture du compte pour en garantir le solde, est valable, encore qu'en fait tout ou partie des avances aient été faites antérieurement à sa constitution[5].

---

1 – Lux. du 14 juin 1951, *P.*, n° 15, p. 162, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Lux. du 5 janvier 1952, *P.*, n° 15, p. 255, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 10 novembre 1926, *P.*, n° 11, p. 247, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Lux. du 16 février 1929, *P.*, n° 12, p. 349, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Lux. du 10 décembre 1927, *P.*, n° 12, p. 20, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Si, au cours de la période suspecte, le failli offre au vendeur la résiliation d'un marché conclu avec lui et que le vendeur accepte cette offre après que la marchandise a été expédiée et est entrée dans les magasins du failli, cette convention est nulle en vertu de l'article 445-3 C.com., alors que le failli est devenu propriétaire de la marchandise et débiteur du prix et que, par conséquent, en rétrocédant la marchandise faute de pouvoir la payer, il s'est libéré de sa dette autrement qu'en espèces ou par effets de commerce(1).

Les renonciations ne se présument pas ; en conséquence, le fait que le créancier produisant au passif d'une faillite déclarée dans le Grand-Duché ait exercé, en pays étranger, les droits lui conférés par la législation de ce pays en pratiquant des saisies et intentant des actions ne saurait impliquer de sa part une renonciation à produire à la faillite dans le Grand-Duché. La procédure par lui instituée en pays étranger ne peut avoir d'autre conséquence que de l'obliger, le cas échéant, en vertu des principes sur l'universalité de la faillite et sur l'égalité entre les créanciers qui dominent le régime luxembourgeois sur les faillites, à rapporter à la masse les sommes et valeurs qu'il aurait réalisées en Allemagne au détriment des autres créanciers(2).

La **résiliation d'un contrat de vente** intervenue pendant la période suspecte, mais avant la déclaration de la faillite, en vertu d'une clause du contrat réservant au vendeur la propriété de la chose vendue jusqu'au paiement intégral du prix de vente et prévoyant qu'à défaut du paiement d'une échéance la convention serait résiliée de plein droit après une sommation demeurée infructueuse, ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles 445 et 546 C.com.(3).

En cas de faillite du souscripteur, le paiement fait dans ces circonstances avant l'échéance des traites, encore qu'il ait eu lieu dans les six mois précédant la faillite, ne saurait être annulé comme se rapportant à une dette non échue(4).

Est nulle à l'égard de la masse de la faillite une hypothèque judiciaire constituée pendant la période suspecte sur les biens du failli à raison d'une créance née d'un délit commis par lui ; cette créance n'a, en effet, pas pris naissance au moment et par effet du jugement, mais au moment où s'est produit le fait générateur de l'obligation du failli. D'autre part, l'article 445, alinéa 4, C.com. a une portée générale : en se servant des termes « dettes antérieurement contractées », la loi a visé le cas le plus fréquent sans pour autant exclure les dettes nées d'une autre cause(5).

Lorsqu'une vente d'objets mobiliers a été résiliée en vertu d'une clause résolutoire expresse, le vendeur peut revendiquer, à l'égard de la masse de la faillite, les objets vendus et livrés, même si la résolution du marché n'est intervenue que pendant la période suspecte(6).

1 – Cour du 20 mai 1927, *P.*, n° 11, p. 309, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 3 avril 1914, *P.*, n° 9, p. 118, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 2 juillet 1935, *P.*, n° 13, p. 519, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 21 novembre 1934, *P.*, n° 13, p. 331, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cour du 26 novembre 1920, *P.*, n° 11, p. 437, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Cour du 10 mars 1931, *P.*, n° 12, p. 216, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le curateur de la faillite a seul qualité pour faire prononcer les nullités prévues aux articles 445 et 446 C.com. Une fois prononcées, leurs effets ne sauraient cependant être restreints exclusivement à la masse, mais peuvent aussi s'étendre à certains créanciers *ut singuli*. Spécialement, lorsque le failli avait donné en gage des objets appartenant à un tiers et que ce gage a été annulé en vertu de l'article 445 C.com., le tiers propriétaire peut les revendiquer contre la masse de la faillite[1].

Les articles 445 et 446 C.com. et les dispositions de la loi du 2 juillet 1870 sur les faillites ne frappent de nullité les actes visés relativement à la masse que pour autant qu'ils sont faits en fraude des créanciers de la masse[2].

La circonstance que l'acheteur a eu connaissance de sa situation obérée au moment de la vente ne saurait constituer une cause de nullité de la vente, au vœu des articles 445 et 446 C.com.[3].

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une cession de créance consentie par le failli avant la période suspecte puisse être valablement signifiée au cédé pendant cette période[4].

Est nulle à l'égard de la masse toute hypothèque judiciaire résultant d'une décision judiciaire rendue durant la période suspecte[5].

Si, en règle générale, la résolution d'une vente intervenue pendant la période suspecte antérieure à la déclaration de faillite entraîne l'extinction des obligations réciproques des parties et ne constitue pas en conséquence l'un des actes réputés nuls et sans effet relativement à la masse par l'article 445 C.com., les juges du fond peuvent néanmoins rechercher quelle était la volonté réelle des parties lors de cette résolution et examiner si, en raison des circonstances propres à la cause, cette résolution ne constituait pas en réalité, au moment où elle a eu lieu, l'un des actes visés par ledit article 445[6].

d) Compte courant

En stipulant une clause d'unicité de comptes, les parties conviennent que les différents comptes du client constituent, en fait et en droit, les éléments d'un **compte unique**, indivisible, permettant la compensation des soldes à l'instar de ce qui se passe pour le compte-courant. Le solde de l'arrêté de compte est opposable aux tiers comme celui d'un compte courant et, comme tel, il est également opposable à la masse des créanciers, à moins qu'il ne soit établi que le fait de placer leurs

1 – Lux. du 28 mai 1925, *P.*, n° 11, p. 206, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Lux. du 29 juillet 1911, *P.*, n° 9, p. 216, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 29 juillet 1911, *P.*, n° 10, p. 293, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 4 mars 1932, *P.*, n° 12, p. 460, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cour du 14 mars 1988, *P.*, n° 27, p. 231, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Cass. du 8 juillet 1993, *P.*, n° 29, p. 222, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

relations contractuelles dans le cadre d'une compensation globale ne procède d'un montage manifestement frauduleux.

Pour qu'il en soit ainsi, il faut cependant que la **volonté commune** des parties de s'engager dans une convention qui doit présenter les caractères d'un compte courant soit **indiscutable**. Le banquier et son client doivent respecter la logique de leur accord. Tel n'est pas le cas d'un banquier qui, dans sa déclaration de créance, ne se réfère pas au solde débiteur du prétendu compte unique, mais déclare comme créance la somme des découverts des différents comptes débiteurs[1].

e) Contrats de garantie financière

Par « *contrat de garantie financière* », on comprend les contrats de gage, de transfert de propriété à titre de garantie, de mise en pension ou de fiducie-sûreté régis par la loi du 5 août 2005 (art. 1er de la loi du 5 août 2005).

La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière[2]a considérablement amendé cette matière qui était restée inchangée depuis un siècle au moins. L'objet de cette loi a été de transposer en droit luxembourgeois « *la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 19 mai 1998 concernant les contrats de garantie financière* ».

L'objectif de cette directive était essentiellement de renforcer la sécurité juridique des contrats de garantie financière « *en faisant en sorte de les soustraire à certaines dispositions de leur législation en matière d'insolvabilité […]* » (point 5 du préambule de la directive).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2005, les règles du Code de commerce se trouvent considérablement amendées par l'article 21 de ladite loi du 5 août 2005 :

« *(1) Les contrats de compensation et les contrats de garantie financière conclus ainsi que la constitution d'avoirs en garantie en vertu d'un contrat de garantie financière faite le jour de l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de la prise d'une mesure d'assainissement, mais avant le prononcé de la décision d'ouverture d'une telle procédure ou de la prise d'effet d'une telle mesure, sont valables et opposables aux tiers, commissaires, liquidateurs, curateurs ou autres organes similaires.*

(2) Lorsqu'un contrat de compensation ou un contrat de garantie financière a été conclu ou qu'une obligation financière couverte a pris effet ou lorsque les avoirs ont été constitués en garantie à la date d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de la prise d'effet de mesures d'assainissement, mais après l'ouverture de cette procédure de liquidation ou de la prise d'effet de ces mesures d'assainissement, ce contrat produit ses effets juridiques et est opposable aux tiers, commissaires, curateurs, liquidateurs et aux organes similaires si le preneur de la garantie prouve qu'il ignorait que cette procédure avait été ouverte et que ces mesures avaient été prises ou qu'il ne pouvaient raisonnablement le savoir ».

1 – Cour du 17 mars 1999, *P.*, n° 31, p. 129, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Loi du 5 août 2005, ID 1680 ; *Doc. parl.*, n° 5251, ID 13265.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

D – Actes annulables facultativement

C'est l'article 446 C.com. qui énumère les actes dont l'annulation n'est que facultative.

« *Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement* ».

Sont visés par cet article :

– les paiements pour dettes échues ;
– les autres actes à titre onéreux ;
– si, de la part du cocontractant, ils ont eu lieu avec la connaissance de la cessation de paiements.

S'il peut paraître étonnant que la **simple connaissance** de l'état de cessation des paiements puisse avoir comme conséquence l'annulation d'un acte qui autrement serait valable, cette solution trouve la justification dans le fait suivant : « *dès que le créancier sait que son débiteur ne peut plus faire face à ses engagements, il a le devoir de ne pas cher cher à se faire privilégier aux dépens de la masse ; il n'a d'autre droit que de faire déclarer la faillite dans l'intérêt de tous* »[1].

Le curateur a la charge de la preuve et doit donc établir que les conditions légales sont bien remplies. Même si tel est le cas, le tribunal n'est **pas obligé** de déclarer la nullité : il a un pouvoir discrétionnaire à cet égard[2] : « *[…] pourront être annulés* ».

Le curateur de la faillite « *[…] a seul qualité pour faire prononcer les nullités prévues aux articles 445 et 446 C.com. ; ces nullités, une fois prononcées, leurs effets ne sauraient cependant être restreints exclusivement à la masse, mais elles peuvent profiter aussi à certains créanciers* ut singuli *; spécialement, lorsque le failli avait donné en gage des objets appartenant à un tiers et que ce gage a été annulé en vertu de l'article 445, le tiers propriétaire peut les revendiquer contre la masse de la faillite* »[3].

« *Pour prospérer dans une demande en annulation d'un paiement fondée sur l'article 446 C.com., il appartient au curateur de prouver sans équivoque la connaissance de l'état de cessation de paiements dans le chef du créancier du failli.*

Cette connaissance ne résulte pas nécessairement du seul fait que le créancier a assigné son débiteur en faillite, alors qu'une telle assignation n'est souvent qu'un moyen de pression pour obtenir paiement. Il est par conséquent requis que d'autres faits viennent corroborer de façon plus précise la connaissance de la cessation de paiements »[4].

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 252.

2 – Cass. fr. du 2 janvier 1935, *S.*, 1935, I, p. 69.

3 – Lux. du 28 mai 1925, *P.*, no 11, p. 206, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 25 janvier 1978, *P.*, no 24, p. 158, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

1) Paiements pour dettes échues

À première vue, il peut paraître étrange que le paiement par des moyens normaux reçu pour une dette échue puisse être annulé. Il est certain que toute idée de fraude est écartée dans ce cas de figure, et donc **l'action paulienne** ne sera d'aucune utilité pour attaquer de tels paiements. La raison d'être de l'annulation de tels actes est donc une fois de plus le **principe d'égalité** entre créanciers qui doit être sauvegardé : c'est « *la faute commise par la lésion du principe d'égalité qui doit régner entre créanciers* »[1].

2) Autres actes à titre onéreux

Sont visés tous les actes à titre onéreux, tous les actes, les engagements, que ce soit de nature civile ou commerciale, les ventes et achats immobiliers, les baux, les transactions, etc.[1]

3) Effets de la nullité de l'article 446 C.com.

L'article 445 C.com. précise que la nullité agit « relativement à la masse » seulement. Cette précision n'est pas donnée pour l'article 446 C.com., mais la doctrine considère que cette solution prévaut également à l'égard de l'article 446 C.com.[2]. Par conséquent, la nullité ne peut être invoquée que par la masse, et **non par le cocontractant**, ni par un créancier individuel[3]. Les actes visés doivent avoir été posés pendant la période suspecte : les dix jours précédents sont exclus.

La nullité ne peut donc être invoquée que par le curateur, et elle ne produit ses effets qu'à l'égard de la masse, indépendamment de la question de savoir si la créance est née avant ou après l'acte litigieux[4].

Lorsque l'annulation concerne le paiement, le créancier doit restituer la chose ou la somme d'argent augmentée des intérêts.

Lorsque l'annulation concerne une opération à titre onéreux, de nature synallagmatique, la **restitution** est due par le créancier. De son côté, le failli est tenu de restituer ce qu'il a reçu en exécution de la convention ; toute autre solution reviendrait à enrichir indûment la masse des créanciers[4].

La connaissance de l'insolvabilité ne se confond pas avec la connaissance de la cessation de paiements[5].

L'offre de preuve tendant à établir la connaissance de la cessation de paiements n'est pas pertinente lorsqu'elle est conçue en des termes tellement vagues qu'il serait impossible de la combattre par la preuve contraire ; la preuve doit porter sur une articulation de faits détaillés, dont le tiers, contre lequel la nullité est poursuivie, doit avoir eu connaissance[6].

---

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 255.

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 253.

3 – Cass. b. du 12 décembre 1878, *Pas.*, 1878, I, p. 98, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 270.

5 – Lux. du 2 juillet 1902, *P.*, no 6, p. 283, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Lux. du 2 juillet 1902, *P.*, no 6, p. 283, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

L'admission sans réserves du solde d'une créance au passif de la faillite n'implique pas dans le chef du curateur renonciation au droit de demander l'annulation des paiements partiels faits au créancier pendant la période suspecte[1].

En cas de faillite d'un commerçant dans les six mois qui suivent la résolution du concordat préventif, le paiement des dividendes fait aux créanciers en exécution du concordat peut être annulé si l'égalité entre les créanciers n'a pas été assurée[2].

4) Nullité des inscriptions hypothécaires

Art. 447 C.com.

« Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. Néanmoins, les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de paiement ou postérieurement pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription ».

Cette disposition doit être lue en relation avec l'article 445, alinéa 4, C.com. qui ne concerne que les constitutions hypothécaires. L'article 447 C.com. est relatif à leurs inscriptions. Si l'acte de constitution de l'hypothèque a été passé plus de dix jours précédant la période suspecte, alors l'acte est inattaquable par rapport à la masse au regard de l'article 445 C.com. Si son inscription est postérieure à ce moment, c'est par rapport à l'article 447 C.com. que sa validité doit être appréciée : aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, la nullité peut être prononcée si plus de quinze jours se sont écoulés entre la constitution et l'inscription de l'hypothèque[2].

La disposition qui déclare nulle toute hypothèque constituée dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de paiements doit être appliquée, bien que la constitution ait été faite pour une dette dont le créancier n'était antérieurement que la caution du failli, lorsqu'il constate de la cause qu'il n'y a pas eu **novation** ni constitution de dette nouvelle[3].

Il n'y a pas lieu d'annuler l'inscription prise après la cessation de paiements du débiteur d'une hypothèque judiciaire dont le titre date de plus de quinze jours, si la délivrance tardive de l'expédition du jugement a empêché le créancier d'observer le délai indiqué à l'article 447 C.com. et qu'il n'a commis aucune négligence[4].

Est nulle à l'égard de la masse toute hypothèque judiciaire résultant d'une décision judiciaire rendue durant la période suspecte[5].

---

1 – Cour du 21 novembre 1933, *P.*, n° 13, p. 122, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC)

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 242.

3 – Lux. du 22 juin 1881, *P.*, n° 2, p. 71, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Lux. du 15 décembre 1934, *P.*, n° 13, p. 504, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cour du 14 mars 1988, *P.*, n° 27, p. 231, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

5) Nullité des actes faits en fraude des créanciers

L'article 448 C.com. contient une disposition « anti-fraude » **générale** en déclarant nuls tous les actes ou paiements faits en fraude des créanciers et spécifiant « *quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu* ». L'acte contenant vente de son mobilier par un failli, fait après l'époque à laquelle la cessation de paiements a été remontée, est à considérer comme fait en fraude des droits des créanciers, alors même que cette vente ne serait faite que sous la condition suspensive du paiement intégral du prix d'acquisition, s'il résulte d'autres circonstances que les parties avaient l'intention de frustrer les créanciers(1).

L'article 448 C.com. prévoit une variante spéciale de l'action paulienne. Les conditions de l'action sont celles de l'action paulienne de l'article 1166 C.c. Par dérogation au droit commun, l'inopposabilité de l'acte attaqué profite à tous les créanciers de la masse, sans distinction selon que leurs droits soient antérieurs ou postérieurs à cet acte(2). Selon la doctrine, l'action ne serait pourtant pas recevable si toutes les créances (voire la grande majorité de celles-ci) étaient postérieures à cet acte(3).

Les actes litigieux doivent avoir pour objet de créer ou **d'aggraver l'insolvabilité** du débiteur, soit que ces actes diminuent la valeur de son patrimoine, soit qu'ils substituent à des biens saisissables des biens faciles à dissimuler aux créanciers ou des biens que ceux-ci auront de la peine à réaliser(4).

L'effet de l'action paulienne est que l'acte attaqué est inopposable au créancier demandeur de sorte qu'il peut exercer ses droits sur les biens aliénés ou grevés comme si l'acte attaqué n'existait pas(5)-(6).

Si les biens ne se retrouvent pas en nature dans le patrimoine de l'acquéreur, ce dernier peut être tenu d'une restitution par équivalent, évaluée d'après la valeur des biens en cause(7).

Selon la jurisprudence, le curateur qui agit attaque les actes du failli comme étant faits en fraude des droits du créancier, à considérer comme un tiers avec donc la conséquence que les actes du failli n'ont pas de **date certaine** à son égard (qui peut donc contester que cet acte a été posé en dehors de la période suspecte)(8).

Art. 454 C.com.

« *Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.*

1 – Cour du 9 mai 1890, *P.*, n° 4, p. 136, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Trib. com. Liège du 13 octobre 1981, *R.P.S.*, 1982, p. 45.

3 – P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations », *R.C.J.B.*, 1988, p. 129.

4 – Cass. fr. du 18 février 1971, *RTD civ.*, 1971, p. 841.

5 – Cour de Mons du 19 septembre 1978, *Rec. gén.*, 1979, p. 275.

6 – P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations », *R.C.J.B.*, 1988, p. 129.

7 – P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations », *R.C.J.B.*, 1988, p. 132.

8 – CA com. du 11 décembre 2003, n°s 26.824, *BIJ*, 2004, n° 7, p. 121.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit en faveur du propriétaire ».

La caution ne peut pas demander la discussion du débiteur principal qui est en état de faillite, celle-ci ne comportant aucune mesure d'exécution de la part d'un créancier qui ne possède pas de garanties spéciales ; il importe peu que le bénéfice de discussion résulte de la loi ou découle d'une convention ; sauf les dérogations résultant du contrat, le bénéfice de discussion conventionnel se trouve régi par les mêmes règles que le bénéfice de discussion légal[1].

■ § 2 – Suspension des poursuites individuelles

La faillite a pour effet que le débiteur est **dessaisi de l'administration** de ses biens et donc de l'exercice des actions actives et passives concernant son patrimoine. « *Ces actions tombent dans la masse et seront désormais intentées par le curateur ou contre lui* »[2].

Art. 452 C.com.
« *À partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite. Le tribunal ne peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante* ».

Depuis le jugement déclaratif de la faillite jusqu'à la clôture, aucune action judiciaire ne peut être valablement intentée contre le failli seul, quant aux biens frappés du dessaisissement. L'intervention volontaire du curateur ne couvre pas la nullité de la procédure[3].

Comme l'appel dirigé contre un jugement déclaratif de faillite remet en question l'existence de la faillite, laquelle est indivisible et ne saurait être rapportée à l'égard de certains créanciers et maintenue à l'égard des autres, et qu'il intéresse tous les créanciers, il exige la mise en cause du curateur, seul représentant de la masse[4].

Le cantonnement a pour effet d'affecter les sommes consignées exclusivement au paiement du créancier saisissant, lequel n'a plus à craindre le concours de saisissants ultérieurs ou la survenance de la faillite du saisi, même si celle-ci est antérieure au jugement de validité[5].

Au sens de l'article 452 C.com., les créanciers chirographaires et ceux jouissant d'un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni

1 – Cour du 5 juillet 1889, *P.*, n° 3, p. 506, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 278.

3 – Lux. du 12 janvier 1935, *P.*, n° 14, p. 27, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Lux. du 18 mars 1916, *P.*, n° 10, p. 216, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cour du 23 décembre 1992, *P.*, n° 29, p. 43, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

même le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration de créance ou de l'action en admission pour faire reconnaître leur créance[1].

Bien que l'article 452 C.com. n'envisage que le cas où le failli est défendeur, la même solution doit s'appliquer dans le cas où le failli est demandeur[2]. La faillite a pour effet de suspendre les poursuites individuelles des créanciers chirographaires. « *Perdant l'exercice de ses actions individuelles, le créancier chirographaire ne pourra plus agir pour se procurer un titre exécutoire et il ne pourra plus faire usage du titre qu'il aurait. Il ne lui appartient plus que de faire reconnaître l'existence et le montant de sa créance par la production d'une déclaration de créance à la faillite* »[3].

■ § 3 – Exigibilité des dettes à terme

A – Base légale de cette exigibilité

Cet effet de la faillite a une double base légale, à savoir l'article 450 C.com. et l'article 1188 C.c. L'article 450 C.com. dispose que : « *Le jugement déclaratif de la faillite rend exigible, à l'égard du failli, les dettes passives non échues : si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.*

Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année, ne seront admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.

En cas de paiement immédiat par l'un des coobligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il sera fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste jusqu'à l'expiration du terme ». En outre, selon l'article 1188 C.c., « *[L]e débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite* ».

La justification de cet effet de la faillite réside dans le fait que le terme est généralement accordé en raison de la confiance qu'inspire le débiteur. La déclaration de la faillite met fin à cette confiance, de sorte que le **bénéfice du terme** n'a plus de raison d'être. Cette règle est en même temps dans l'intérêt de la masse pour la raison que le maintien du terme ne ferait que considérablement prolonger les opérations de liquidation[4].

Un autre effet du jugement déclaratif est la **cessation du cours des intérêts**. Celle-ci résulte de l'article 451. « *À compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement. Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque* ».

---

1 – Cass. du 13 novembre 1997, *P.*, n° 30, p. 265, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 279.

3 – TA (com.) du 10 juin 2005, *BIJ* , 2005, n° 7, p. 127.

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 279.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Cette disposition s'explique par la volonté de définitivement arrêter les droits des créanciers ordinaires au jour où la faillite est ouverte. Le dividende qui revient aux créanciers est calculé sur le passif existant à ce jour[1]-[2]. Le texte de la loi englobe tous les intérêts, donc les intérêts moratoires, judiciaires, conventionnels, etc. Le **cours des intérêts** ne s'arrête qu'à l'égard des créanciers chirographaires : il n'est pas arrêté à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés, car ils **ne font pas partie de la masse**. Il est à noter que les intérêts ne sont pas dus dans la mesure où le créancier n'est pas payé sur les biens frappés du privilège ou de l'hypothèque : cette solution se comprend pour la raison que, dans cette mesure-là, le créancier n'a pas de privilège[3].

La cessation du cours des intérêts se produit uniquement à l'égard de la masse des créanciers. Les intérêts continuent à courir à l'égard des débiteurs, de la caution, des codébiteurs. Ceci signifie en particulier qu'à la clôture de la faillite, les créanciers peuvent en principe reprendre leurs actions à l'égard du débiteur et que les intérêts ont continué à courir dans les relations entre créancier et débiteur[4]. La Cour de cassation belge a même retenu que la déclaration de créance valait mise en demeure et pouvait donc servir comme point de départ des intérêts moratoires dus à un créancier chirographaire ou encore bénéficiant d'un privilège général sur les meubles[5].

Les créanciers privilégiés ne sont pas touchés par cette disposition, de sorte que le cours des intérêts ne s'arrête pas à leur égard au moment du jugement déclaratif de faillite[6].

B – Inscription d'une hypothèque légale

À compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs. « *[…] Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui ; l'inscription sera prise au nom de la masse par les curateurs, qui joindront à leur bordereau un certificat du greffier constatant leur nomination. Ils seront tenus, en outre, de prendre inscription au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés. Ils sont également tenus de prendre inscription, au nom des salariés, des privilèges reconnus à ceux-ci pour le paiement des salaires et des indemnités pour inobservation du délai-congé ou à raison de la résiliation abusive du contrat*[7] » (art. 487 C.com.).

L'article 451 C.com., loin d'apporter une modification virtuelle à l'article 1254 C.c., entend, au contraire, quant aux intérêts, laisser les créances privilégiées et

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 296.

2 – I. Verougstraete, *Manuel de la faillite et du concordat*, Waterloo, Kluwer, 1998, p. 301.

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 296.

4 – I. Verougstraete, *Manuel de la faillite et du concordat*, p. 301.

5 – Cass. b. (com.) du 16 février 1995, *A.C.*, 1995, p. 301.

6 – TA Lux. du 5 novembre 2002, *BIJ*, 2002, n° 2, p. 36.

7 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 299.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

hypothécaires sous l'empire du droit commun et maintenir à leur égard les règles ordinaires de l'imputation. En conséquence, le créancier privilégié ou hypothécaire qui ne reçoit qu'un paiement partiel dans la masse hypothécaire de la faillite est autorisé à imputer ce paiement de préférence sur les intérêts courus même après la déclaration de la faillite, et de concourir pour le restant de sa créance dans la masse chirographaire[1].

■ § 4 – Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits

Art. 537 C.com.

« *Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son parfait et entier paiement* ».

Les paiements reçus par les créanciers d'un **codébiteur solidaire** du failli depuis l'ouverture de la faillite, ne sont pas à défalquer de la créance due au moment de cette ouverture, à l'inverse de ce qui a lieu pour les paiements faits avant la faillite[2].

Le créancier qui a reçu, après la faillite du débiteur principal, la partie de la dette cautionnée solidairement par un tiers non failli, peut conclure au rejet de la production faite par la caution et participer aux dividendes de la faillite pour l'intégralité de la somme qui lui était due, sans déduction du paiement que lui a fait la caution[3].

Le créancier d'une société en nom collectif déclarée en état de faillite, porteur d'un engagement garanti personnellement et solidairement par un associé déclaré également en état de faillite, a le droit de produire au passif des faillites des coobligés solidaires pour la valeur nominale de sa créance, jusqu'à entier paiement. Il n'est pas déchu du droit d'être admis, à titre individuel, à la masse de la faillite personnelle de l'associé, par la circonstance que le curateur de la société faillie a produit au passif de la faillite pour le montant intégral du passif social, mais la somme pour laquelle le créancier a été admis à la masse de la société est à déduire de la production faite par le curateur de la faillite de la société à la faillite personnelle de l'associé ; et le créancier ne sera pas compris pour cette somme, dans la répartition à faire par le curateur de la faillite de la société, des deniers qu'il touchera à la faillite personnelle de l'associé[4].

Tous les créanciers ne se trouvent pas dans la même situation au moment de la faillite. En effet, certains ont des privilèges leur permettant de bénéficier d'une situation de préférence par rapport aux autres créanciers qui sont appelés **créanciers chirographaires.**

---

1 – Cass. du 27 mars 1896, *P.*, n° 4, p. 123, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 29 mai 1884, *P.*, n° 2, p. 349, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 23 février 1907, *P.*, n° 8, p. 483, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 15 juillet 1898, *P.*, n° 4, p. 563, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Si, entre créanciers chirographaires, il existe une égalité absolue, tel n'est absolument pas le cas entre les créanciers privilégiés. En effet, au vœu du Code civil (art. 2096) entre créanciers privilégiés (selon les articles 2098 à 2102 C.c.), la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. En outre existe-t-il des règles relatives aux hypothèques accordant ainsi des privilèges sur les immeubles du créancier (voir art. 2114 à 2180 C.c.).

Entre ceux-ci, il existe donc une **hiérarchie** très **complexe** répondant à des règles qui ne sont pas toujours faciles à appliquer en pratique.

A – Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles

Art. 542 C.com.
« *Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire* ».

Ces créanciers nantis de gages ne sont pas des créanciers dans la masse. Pourquoi la loi demande-t-elle alors leur inscription dans la masse, fût-ce pour mémoire ? La raison en est assurément celle que les créanciers dont le gage est réalisé entrent dans la masse pour les cas où le **produit de réalisation** serait **inférieur** au montant de leur créance. Il existe donc un risque que ces créanciers gagistes viennent augmenter le volume des créances regroupés dans la masse.

B – Hiérarchie des privilèges

Le Code civil, dans son article 2101, prévoit un privilège **général sur les meubles** au profit de certaines créances. Ces privilèges s'exercent accessoirement sur les **immeubles** (voir art. 2104 C.c.).

1) Privilège général sur les meubles

Les privilèges visés par l'article 2101 s'exercent dans **l'ordre** suivant :

1° les **frais de justice** ;
2° les **frais funéraires** ;
3° les **frais** quelconques de la **dernière maladie**, quelle qu'en ait été la terminaison, pendant un an, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
4° les **salaires, traitements** et indemnités résultant du contrat de travail se rapportant aux **six derniers mois de travail** ainsi que les créances d'indemnités de toute nature résultant de la rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage pour le solde non couvert par le super privilège visé au paragraphe (2) du présent article ;
5° les **fournitures de subsistance faites au débiteur** et à sa famille ; à savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En réalité, cette énumération n'est pas complète, et ceci, essentiellement pour deux raisons :

Elle ne tient pas compte du fait que les créanciers de salaires bénéficient en fait d'un rang plus avantageux pour une partie de leurs créances ; on parle du superprivilège des salariés (mentionné au paragraphe 2 de l'article 2101 C.c.), mais celui-ci est limité au sextuple du salaire minimum de référence. Le solde prend le rang 4 ci-dessus ;

Elle ne tient pas compte non plus du privilège du Trésor public. « *Le privilège du Trésor public et des organismes d'assurance sociale bénéficie d'un rang immédiatement postérieur au privilège des frais de justice et au superprivilège des salariés*. *Il prime tous les autres privilèges généraux de l'article 2101 du Code civil et les privilèges spéciaux, tel le privilège spécial accordé à l'assureur par l'article 22 de la loi modifiée du 16 mai 1891 […]* »[1].

Il se dégage donc une nouvelle hiérarchie des privilèges :

1) les frais de justice ;
2) les créances salariales superprivilégiées ;
3) les créances du Trésor public/organismes de sécurité sociale, chambres professionnelles (loi du 4 avril 1924) ;
4) les frais funéraires ;
5) les frais de dernière maladie ;
6) les fournitures de subsistance faites au failli, etc.

2) Privilège sur certains meubles

En outre, **l'article 2102 C.c.** prévoit un privilège sur **certains meubles**.

Sont visés par cet article :

1° les créances du **bailleur** : « *les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme […]* » ;

2° la créance sur le gage dont le créancier est saisi ;

> « *Les privilèges mobiliers généraux prévus par la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accises et des cotisations des assurances sociales, et* a fortiori *celui prévu par l'article 23 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du louage de services des ouvriers, priment tous les autres privilèges, y compris ceux prévus aux articles 2102 et suivants du Code civil et notamment celui du gagiste* »[2].

Il est loisible au curateur de retirer les gages en payant le créancier gagiste (art. 543 C.com.).

En cas de réalisation du gage, l'excédent du prix de vente sur le montant de la dette revient à la masse. En cas d'insuffisance du prix de réalisation, le créancier gagiste entre dans la masse en tant que créancier chirographaire (art. 544 C.com.).

1 – CA du 13 décembre 2000, ID 10263.

2 – Cour du 2 mai 1979, *P.*, n° 24, p. 317, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

En matière de concordat préventif de la faillite, les commis des marchands n'ont droit ni au privilège établi par l'article 2101, n° 4, du Code civil au profit des gens de service, ni au privilège établi pour les ouvriers et commis des faillis par l'article 545 de la loi sur les faillites[1].

La garantie étatique des créances des rémunérations et indemnités dues au salarié à la date du jugement déclaratif de faillite pour les six derniers mois de travail s'étend aux créances se rapportant à des périodes antérieures de plus de six mois à la faillite[2].

3° les frais faits pour la conservation de la chose ;

4° le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état que celui dans lequel cette livraison a été faite ;

Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;

Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;

5° les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;

6° les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;

7° les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;

8° les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.

Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.

Ce privilège ne sera primé par aucun autre privilège général ou spécial, y compris celui du Trésor.

3) Privilège sur immeubles

Celui-ci est régi par l'article 2103 C.c. qui énumère les créanciers suivants :

1° le vendeur sur l'immeuble vendu pour paiement du prix ;

2° ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;

3° les **cohéritiers**, sur les immeubles de la succession, pour la **garantie des partages** faits entre eux et des soultes ou retour de lots ;

1 – Lux. du 30 janvier 1904, *P.*, n° 6, p. 432, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour adm. du 9 décembre 1997, ID 15886.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

4° les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments ;
5° ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège.

Art. 547 C.com.
« *Les curateurs présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera.*

C – Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles

Art. 548 C.com.
« *Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourront à proportion de ce qui leur restera dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies* ».

Les articles 548 et 582 de la loi du 2 juillet 1870 sur les faillites ne sont pas applicables à l'état d'insolvabilité d'un non-commerçant, les règles de la faillite ne pouvant, en l'absence d'un texte spécial, être étendues à la déconfiture[1].

Art. 550 C.com.
« *Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui voudront en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire* ».

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire au profit de laquelle il en sera fait distraction.

D – La répartition entre les créanciers

Art. 561 C.com.
« *Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti, entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées* ».

1 – Lux. du 26 février 1896, *P.*, n° 4, p. 89, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

À cet effet, les curateurs remettront tous les mois au juge-commissaire un état de la situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des consignations ; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixera la quotité.

Les créanciers seront avertis des décisions du juge-commissaire et de l'ouverture de la répartition, par circulaires chargées à la poste de la manière prescrite par l'article 496 C.com.

Le caractère d'universalité attribué à la faillite, ainsi que le principe d'égalité entre les créanciers de la masse, principe qui est de droit et d'ordre public, interdisent au juge luxembourgeois d'accorder pendant la faillite à un créancier au détriment de la masse des avantages et privilèges qu'il ne possédait pas avant la faillite[1].

Art. 562 C.com.

« *S'il existe des créanciers non vérifiés, à l'égard desquels le délai prolongé en vertu de l'article 497 n'est pas encore expiré, ou des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore jugées, il ne sera procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve de la part correspondante à leurs échéances, telles qu'elles sont portées au bilan, quant aux premiers, et telles qu'elles ont été déclarées et affirmées, quant aux seconds* ».

Lorsque les créances appartenant à des créanciers domiciliés ou résidant hors du Grand-Duché, à l'égard desquels le délai aura été prolongé conformément à l'article 498, ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux curateurs à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale.

Art. 563 C.com.

« *Aucun paiement ne sera fait par les curateurs que sur la représentation du titre constitutif de la créance.*

Les curateurs mentionneront sur le titre la somme par eux payée ou mandatée conformément à l'article 480. En cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition ».

E – De la vente des immeubles du failli

Art. 564 C.com.

« *S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le rejet ou l'annulation du concordat, les curateurs seuls seront admis à poursuivre la vente ; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire, conformément aux dispositions spéciales réglant la matière* ».

1 – Lux. du 22 janvier 1909 ; *cf.* Cour du 18 juin 1909, *P.*, n° 8, p. 22, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les curateurs pourront toujours arrêter les poursuites commencées, en procédant dans les mêmes formes, avec l'autorisation du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli appelé, à la **vente des immeubles** saisis.

Ils feront, dans ce cas, notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé. Semblable notification sera faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d'inscription.

Art. 565 C.com.

« *Pendant quinzaine après l'adjudication, toute personne aura le droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication ; elle sera faite par exploit d'huissier notifié au notaire qui aura procédé à l'adjudication et dénoncé aux curateurs et à l'adjudicataire. L'adjudication par suite de surenchère sera faite à la requête des curateurs sans autorisation ultérieure, par le même officier public et de la même manière que la première adjudication. Toute personne sera admise à concourir à cette adjudication, qui demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère* ».

La forme de la **surenchère,** telle qu'indiquée par l'article 565 C.com., est une et indivisible en ce sens que, dans le seul et même délai de quinzaine après l'adjudication, l'intention de surenchère doit être notifiée tant au notaire instrumentaire qu'à l'adjudicataire et au curateur. L'article 565 C.com. prévoyant un droit exceptionnel au droit commun, l'exercice doit en être rigoureusement limité et subordonné à l'observation des devoirs et formes y prescrits. Les règles quant à la surenchère en cas de vente des immeubles du failli sont substantielles, et la validité même de la surenchère dépend de leur rigoureuse observation. Dès lors, la surenchère dénoncée après le délai de quinzaine susmentionné doit être déclarée nulle et de nul effet[1].

Lorsqu'un créancier hypothécaire se rend acquéreur d'un immeuble dépendant d'une faillite, le prix de vente ne se compense pas avec la créance à laquelle l'immeuble vendu se trouve affecté hypothécairement, la compensation ne pouvant s'opérer entre une dette du failli ayant une existence antérieure à la faillite et une créance qui naît postérieurement à la faillite au profit de celle-ci[2].

Ne dépasse pas les limites du pouvoir d'administration du curateur et est valable et opposable aux créanciers hypothécaires la convention en vertu de laquelle le curateur, à ce dûment autorisé par le juge-commissaire, a abandonné l'excédent éventuel du forfait stipulé pour les frais d'une vente d'immeubles au notaire instrumentaire, lequel, moyennant cet abandon, s'est chargé de garantir la solvabilité de l'acquéreur et escompter le prix à toute réquisition du curateur[3].

1 – Lux. du 22 avril 1885, *P.*, n° 3, p. 264, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Lux. du 27 novembre 1895, *P.*, n° 5, p. 487, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 27 novembre 1895, *P.*, n° 5, p. 487, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

F – De la revendication

Traditionnellement, le créancier-vendeur n'avait que la possibilité de revendiquer le bien sous les conditions restrictives de l'article 546 C.com. Toutefois, depuis la loi du 31 mars 2000, la clause de **réserve de propriété** a été reconnue comme valable en cas de faillite (art. 567-1 C.com.), sous les conditions y prévues (voir à la p. 988).

Art. 546 C.com.

« *Le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l'article 2102 du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers ainsi que le droit de résolution ne seront pas admis en cas de faillite. Néanmoins, ce privilège continuera à exister pendant deux ans, à partir de la livraison, en faveur des fournisseurs de machines et appareils employés dans les établissements industriels* ».

Il n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte constatant la vente soit transcrit dans un registre spécial, tenu à cet effet au greffe du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile, et, à défaut de domicile, au greffe du tribunal dans lequel le débiteur aura sa résidence. Le greffier du tribunal sera tenu de donner connaissance de cette transcription à toutes les personnes qui en feront la demande.

Ce privilège pourra être exercé même si les machines et appareils sont devenus immeubles par destination ou par incorporation. La livraison sera établie, sauf preuve contraire, par les livres du vendeur.

En cas de faillite du débiteur, déclarée avant l'expiration des deux années de la durée du privilège, celui-ci continuera à subsister jusqu'après la liquidation de ladite faillite.

Lorsqu'une vente d'objets mobiliers a été résiliée en vertu d'une clause résolutoire expresse, le vendeur peut revendiquer, à l'égard de la masse de la faillite, les objets vendus et livrés, même si la résolution du marché n'est intervenue que pendant la période suspecte[1].

Si les dispositions de la loi font obstacle à ce que, après la déclaration de la faillite, le vendeur d'objets mobiliers non payés exerce l'action résolutoire prévue aux articles 1184 et 1654 du Code civil ou obtienne, en vertu de quelque pacte commissoire, la résolution de plein droit de la vente, ces mêmes dispositions ne visent pourtant pas une résolution du contrat intervenue régulièrement avant la déclaration de la faillite.

En conséquence, lorsque, dans une vente à tempérament, il a été stipulé que le défaut de paiement d'une seule traite autoriserait le vendeur à résilier le marché sans aucune formalité judiciaire, trois jours après une simple mise en demeure, la résolution de la vente qui s'est accomplie par l'effet de cette stipulation avant l'ouverture de la faillite est opposable aux créanciers du failli[2].

1 – Cour du 10 mars 1931, *P.*, n° 12, p. 216, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 18 juillet 1934, *P.*, n° 13, p. 235, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

La **résiliation d'un contrat de vente** intervenue pendant la période suspecte, mais avant la déclaration de la faillite, en vertu d'une clause du contrat réservant au vendeur la propriété de la chose vendue jusqu'au paiement intégral du prix de vente et prévoyant qu'à défaut du paiement d'une échéance, la convention est résiliée de plein droit après une sommation demeurée infructueuse, ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles 445 et 546 C.com.[1].

Tant qu'il n'y a pas faillite déclarée, l'action en résolution de la vente peut être exercée par le vendeur contre l'acheteur d'objets mobiliers non payés. L'action régulièrement intentée avant l'ouverture de la faillite constitue pour le demandeur un droit acquis à se voir reconnaître judiciairement le droit de résolution qui lui appartenait au moment de l'introduction de la demande, et ce, nonobstant la survenance de la faillite[2].

En l'absence d'un jugement de mise en faillite rendu par le tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal de commerce, la loi sur les faillites ne peut être appliquée en matière civile, même partiellement, et alors même qu'il résulte des circonstances de la cause que le débiteur se trouve en état de cessation effective de paiements[3].

Si, dans un contrat de *leasing* véritable, le bailleur reste propriétaire de la chose louée jusqu'à la levée de l'option, et peut donc opposer son droit de propriété à la faillite du locataire, il en va différemment lorsque le contrat constitue en réalité une vente avec réserve de propriété dissimulée sous l'apparence juridique d'une location avec option d'achat[4].

Le privilège inscrit à l'article 546 C.com. n'est pas établi en faveur du seul fournisseur originaire de machines ou d'appareils employés dans un établissement industriel, mais profite également au cessionnaire des droits du fournisseur. Une entreprise de transports ayant pour objet la prestation de services assurant la circulation de produits et ne participant aucunement à leur élaboration ne peut être assimilée à un établissement industriel pouvant bénéficier du privilège prévu à l'article 546 C.com.[5].

L'article L. 125-1 (1) du Code du travail (article 30 (1) de la loi du 24 mai 1989), en vertu duquel le salarié a droit au maintien des salaires ou traitements se rapportant au mois de la survenance de l'événement et au mois subséquent, et à l'attribution d'une indemnité égale à 50 % des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément à l'article L.124-3 du Code du travail (article 20 de la loi de 1989), ne règle pas les droits des salariés pour les salaires échus, mais uniquement leurs droits après la faillite, le terme de « maintien » des salaires visant à l'évidence la conservation aux salariés pour l'avenir d'un droit qu'ils auraient normalement perdu par l'effet de la faillite et de la résiliation avec

1 – Cour du 2 juillet 1935, *P.*, n° 13, p. 519, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 16 juin 1938, *P.*, n° 14, p. 193, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 8 avril 1911, *P.*, n° 9, p. 225, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 25 mai 1977, *P.*, n° 23, p. 533, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Lux. du 16 mars 1977, *P.*, n° 24, p. 61, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

effet immédiat du contrat de travail qui s'ensuit. Décider le contraire et inclure les salaires échus pour les jours de travail effectif dans l'indemnité pour rupture prévue à l'article 30 susdit reviendrait à rémunérer ces jours deux fois[1].

1) Effets de commerce, titres non payés

Art. 566 C.com.

« *Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés* ».

Lorsqu'une lettre de change, endossée valeur en compte courant à l'ordre d'une société déclarée en faillite, était déjà parvenue en la possession de celle-ci avant la déclaration de la faillite non remontée à une époque antérieure, cette traite ne peut plus être revendiquée par l'endosseur ; la créance de l'endosseur ne jouit ainsi d'aucun privilège[2].

Sont rendus en matière de faillite les jugements statuant sur les actions en revendication basées sur les articles 566 et suivants C.com., alors que ces articles contiennent, en cas de faillite, une réglementation spéciale du droit de revendication.

Il s'ensuit que le jugement statuant sur pareille demande en revendication est à considérer comme ayant été rendu en matière de faillite et que l'appel interjeté contre ce jugement plus de quinze jours après la signification est irrecevable pour cause de tardiveté[3].

2) Biens donnés en consignation

Peuvent encore être revendiqués les biens transmis sur la base d'un **contrat de consignation**.

Art. 567 C.com.

« *Les marchandises consignées au failli, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire, peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se trouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure. En cas de revente de ces marchandises par le failli avant l'ouverture de la procédure, le propriétaire peut réclamer le prix ou la partie du prix dont l'acheteur ne s'est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du jugement déclaratif de faillite* ».

1 – CA du 20 février 1997, ID 4995.

2 – Cour du 22 juin 1883, *P.*, n° 2, p. 191, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 16 décembre 1964, *P.*, n° 19, p. 541, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Si le revendiquant, qui agit contre la masse de la faillite, doit fournir la preuve de sa propriété exclusive des objets revendiqués et de leur identité, il n'est pourtant pas nécessaire, quand il s'agit de titres au porteur acquis par une banque pour compte de plusieurs personnes, que les numéros des titres devant être remis à chacune d'elles puissent être spécifiés. Il suffit qu'il soit établi par les faits de la cause que, parmi les titres détenus par la masse, se trouvent, à l'exclusion de tout doute, ceux acquis pour le compte des revendiquants, la répartition des titres entre eux pouvant alors se faire sans aucune difficulté et les numéros des titres étant indifférents[1].

Pour savoir si, en cas de faillite, le droit de revendication d'une chose existe ou non, il faut se référer à la loi appelée à régir le contrat en vertu duquel le failli détient la chose[2].

3) Clause de réserve de propriété

Art. 567-1 C.com.

« *Le vendeur d'un bien mobilier non fongible, qui est convenu avec le failli de s'en réserver la propriété jusqu'au paiement intégral du prix, peut revendiquer ce bien, lorsqu'il se retrouve en nature au moment de l'ouverture de la procédure ou peut être récupéré sans dommage pour le bien dans lequel il a été incorporé, dans un délai de trois mois suivant la dernière des publications du jugement déclaratif de faillite dont il est question à l'article 472* ».

En cas de faillite, cette clause n'est valide que depuis 2000. La jurisprudence prise sous la loi antérieure n'est donc plus applicable. Cette jurisprudence s'exprimait comme suit : « *La clause réservant au vendeur d'objets mobiliers la propriété de la chose vendue et délivrée à l'acheteur jusqu'au paiement intégral du prix de vente est en cas de faillite de l'acheteur inopposable à la masse* »[3]. L'article 546 C.com., dispose que le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l'article 2102 du Code civil au profit du vendeur d'objets mobiliers ainsi que le droit de résolution ne sont pas admis en cas de faillite. Cet article s'applique non seulement aux marchandises acquises par le failli pour les besoins de son commerce, mais également aux choses destinées à son usage personnel[4].

La clause de réserve de propriété doit être constatée dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ou de la première livraison s'agissant d'un écrit régissant un ensemble d'opérations. En cas de revente du bien par le failli avant l'ouverture de la procédure, le vendeur peut réclamer, dans le même délai, le prix ou la partie du prix dont l'acheteur ne s'est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du jugement déclaratif de faillite.

---

1 – Lux. du 28 mai 1925, *P.*, n° 11, p. 206, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Lux. du 13 janvier 1962, *P.*, n° 18, p. 507, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 5 novembre 1932, *P.*, n° 12, p. 529 ; *P.*, n° 14, p. 83 ; *P.*, n° 13, p. 235, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 18 juin 1929, *P.*, n° 11, p. 532, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Toutes les clauses et conventions qui ont pour but de rétablir indirectement au profit du vendeur les garanties dont l'article 546 C.com. le prive en cas de faillite de l'acheteur, sont nulles à l'égard de la masse. Il en est ainsi de la clause réservant au vendeur la propriété de la chose vendue et délivrée à l'acheteur jusqu'au paiement intégral du prix[1].

La Cour de cassation cassa un arrêt de cour d'appel qui avait retenu que la revendication d'un tracteur routier était faite tardivement. Le jugement déclaratif était paru le 13 février 2002 et la société requérante avait revendiqué le tracteur le 14 février 2002 auprès du curateur de la faillite. La cour d'appel a ensuite déclaré tardive l'assignation en justice lancée contre le curateur en date du 16 mai 2002 pour avoir été introduite hors du délai de trois mois[2].

La disposition de l'article 546 C.com. n'a pas pour but de créer un privilège au profit des fournisseurs de machines et d'appareils, mais seulement d'assurer, en cas de faillite, la persistance de ceux consacrés par l'article 2102, n° 4 du Code civil au profit de ces mêmes fournisseurs[3].

Ne sauraient être assimilés à des « *machines et appareils employés dans les établissements industriels* » des machines ou appareils ayant le caractère d'immeubles par nature[3].

La disposition de faveur de l'article 546, alinéa 2, C.com., qui maintient au profit du fournisseur de machines employées dans les établissements industriels le privilège du vendeur d'effets mobiliers en cas de faillite de l'acheteur, ne peut être invoquée que par le constructeur et celui qui fait profession de vendre des machines neuves. Ainsi, la créance d'un garagiste qui cède son établissement avec les machines y attachées n'est pas privilégiée[4].

La stipulation que la chose vendue resterait la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix est inopérante en matière de faillite, le bénéfice de l'article 2102, n° 4 du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers se trouvant aboli par l'article 546 de la loi sur les faillites[5].

Toutes les clauses et conventions qui ont pour but de rétablir indirectement au profit du vendeur les garanties dont l'article 546 C.

com. le prive en cas de faillite de l'acheteur sont nulles à l'égard de la masse. Il en est ainsi de la clause réservant au vendeur la propriété de la chose vendue et délivrée à l'acheteur jusqu'au paiement intégral du prix[6].

En cas de faillite de l'acheteur, le vendeur d'objets mobiliers dont le prix n'est pas entièrement payé n'est pas admis à revendiquer à l'égard de la masse les choses

1 – Cass. 8 juillet 1993, *P.*, n° 29, p. 222, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cass. com. du 9 mars 2006, n° 2.213, *BIJ*, 2006, n° 3, p. 110.

3 – Lux. du 24 décembre 1901, *P.*, n° 6, p. 1, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Lux. du 25 mai 1935, *P.*, n° 13, p. 564, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Lux. du 29 juillet 1911, *P.*, n° 10, p. 293, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Lux. du 30 juillet 1925, *P.*, n° 11, p. 470, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

vendues, bien qu'aux termes du contrat de vente il s'en soit réservé la propriété jusqu'au paiement intégral[1].

Les décisions de justice prises sous la loi applicable avant 2000 sont évidemment dépassées depuis l'entrée en vigueur de l'article 567-1 C.com.

Art. 568 C.com.

« *Pourront aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli* ».

Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et sur connaissements ou lettres de voitures signés par l'expéditeur.

Le terme « magasin » employé à l'article 568 C.com. doit être pris dans un sens très large. Il faut notamment y comprendre les quais d'une gare de chemin de fer quand le failli est autorisé à y entasser ou conserver ses marchandises, soit en vertu d'une concession formelle soit en vertu d'un usage et par simple tolérance, et que ces marchandises n'y sont pas seulement déposées accidentellement, mais pour y rester un temps plus ou moins long, l'acheteur en ayant seul la disposition pendant cette époque[2].

En cas de vente de bois en coupe, le parterre de la coupe est à assimiler au magasin pour l'application de l'article 568 C.com., lorsqu'à raison d'une certaine publicité ayant entouré soit la vente soit l'exploitation de la coupe, les tiers ont connu l'acheteur et ont pu considérer les bois acquis par lui comme un élément de son crédit, notamment lorsque l'acheteur ou ses ouvriers ont procédé au mesurage, à l'écorçage, au découpage et au façonnage du bois[3].

La clause du cahier des charges dressé pour l'adjudication d'une coupe de bois portant que le parterre de la coupe ne sera pas considéré comme le chantier ou le magasin de l'adjudicataire, et que les bois y déposés et non payés pourront être retenus en cas de faillite, n'a rien d'illicite.

Portée à la connaissance du public, entre autres par la lecture qui a été donnée des conditions de l'adjudication lors des enchères, elle est opposable aux tiers, et spécialement à la masse de la faillite de l'adjudicataire[4].

Art. 569 C.com.

« *Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes* ».

---

1 – Cour du 18 juin 1929, *P.*, n° 11, p. 532, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Lux. du 11 décembre 1926, *P.*, n° 12, p. 73, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 5 novembre 1932, *P.*, n° 12, p. 529, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 31 juillet 1934, *P.*, n° 13, p. 205, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 570 C.com.

« *Pourront être retenues pour le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte* ».

Le vendeur de marchandises *achetées* par un failli et non encore expédiées au moment de la déclaration de la faillite peut, en cas de refus des curateurs d'en prendre livraison et d'en payer le prix, demander la résolution du contrat de vente, avec dommages-intérêts[1].

Le vendeur, en opérant la délivrance de la chose vendue, renonce définitivement au droit de rétention qu'il pouvait exercer à raison du défaut de paiement du prix ; si, par la suite, il reprend, du consentement de l'acheteur, la possession de l'objet vendu, il ne peut plus faire valoir à l'égard de la masse de la faillite l'article 570 C.com.[2].

Art. 571 C.com.

« *Dans le cas prévu par les articles 568 et 570, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre lui et le failli* ».

Les curateurs peuvent, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication, et, s'il y a contestation, le tribunal statuera (art. 572 C.com.).

En matière de faillite, le revendiquant n'est recevable à soumettre sa prétention au tribunal qu'après avoir sans succès tenté de la faire admettre amiablement par le curateur de la faillite avec l'approbation du juge-commissaire[3].

G – L'action en comblement de passif

Introduite par la loi du 21 juillet 1992 et inspirée par l'article 99 de la loi française de 1967, cette disposition a donné lieu à un important contentieux relatif à ce qu'on appelle l'action en comblement de passif. Cette action consiste effectivement à permettre le comblement du passif au moyen d'une action exercée contre les dirigeants pour le cas où la faillite ferait apparaître que les actifs nets sont insuffisants pour désintéresser tous les créanciers. L'article visé suppose que soit établie la faute des dirigeants et que ces fautes aient conduit à la faillite.

Les juridictions peuvent décider l'extension de la faillite au maître de l'affaire (voir p. 922).

Aux termes de l'article 1298 C.c., la **compensation** ne peut nuire aux droits acquis des tiers. Cette disposition est applicable toutes les fois qu'un concours se produit entre celui qui invoque la compensation et d'autres créanciers de l'autre

1 – Cass. du 4 août 1893, *P.*, n° 3, p. 193, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Lux. du 30 juillet 1925, *P.*, n° 11, p. 470, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 13 janvier 1962, *P.*, n° 18, p. 507, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

partie à l'opération de compensation avant que les conditions de la compensation n'aient été réunies[1].

Par exception, la compensation reste possible lorsqu'il existe une étroite connexité entre les dettes réciproques. Cette connexité peut résulter de ce qu'elles procèdent d'une opération unique ou de leur incorporation dans un compte indivisible. Cette règle s'applique soit lorsque les dettes sont antérieures au concours, mais que les conditions de la compensation n'ont été réalisées que postérieurement, soit que l'une des dettes est postérieure au concours[2].

■ § 5 – Interdiction contre les dirigeants d'exercer une activité commerciale

Aux termes de l'article 441-1 C.com., il peut y avoir prononciation d'une interdiction d'exercer une activité commerciale.

Celle-ci est susceptible de frapper le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, d'une société déclarée en état de faillite, qui a contribué à la faillite par une faute grave et caractérisée. Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite peut prononcer à l'encontre de ces personnes l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu'une fonction d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes, de réviseur d'entreprises ou toute fonction conférant le pouvoir d'engager une société. L'interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse.

La durée de l'interdiction d'exercice ne peut être inférieure à un an ni supérieure à vingt ans.

L'interdiction cesse dans tous les cas si :

– le jugement déclaratif de faillite est rapporté ;

– le failli obtient l'homologation du concordat ;

– le failli obtient sa réhabilitation.

Il y a lieu de noter que sont visés par cette disposition non seulement les commerçants susceptibles de tomber en faillite, mais encore **tous les dirigeants** de droit ou de fait qui « *par une faute grave et caractérisée* » ont contribué à la faillite.

Lorsqu'une telle faute est retenue, alors les personnes visées peuvent être condamnées à « *l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu'une fonction d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes, de réviseur d'entreprises ou toute fonction conférant le pouvoir d'engager une société* ».

Le délai pour introduire la demande est de **trois ans**.

SECTION VI
ADMINISTRATION ET LIQUIDATION DE LA FAILLITE

Un des effets directs et inévitables de la faillite est que tous les créanciers chirographaires se trouvent réunis en une masse.

1 – P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations », *R.C.J.B.*, 1988, p. 133.
2 – P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations », *R.C.J.B.*, 1988, p. 134.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – Notion de masse des créanciers

Le regroupement de tous les créanciers en une masse a pour but d'assurer l'égalité entre créanciers en ne reconnaissant à chacun d'eux qu'un dividende proportionnel à l'importance de la créance admise. La **masse est définie** comme « *[…] une sorte de communauté forcée, fortuite, ayant pour double fin la diminution de la perte de tous, et la communauté de tous,* pro modo crediti cujusque*, à la perte commune, présumée certaine* »[1]. Ou encore : « *La masse constitue une espèce d'association pécuniaire, régie par les dispositions spéciales de la loi sur les faillites, et qui présente une double caractéristique ; sa création, d'une part, est forcée, car elle se forme obligatoirement entre les créanciers chirographaires par le seul effet de la faillite, et d'autre part, son administrateur est désigné par justice et non par les créanciers eux-mêmes* »[2].

La masse est souvent comparée à une société. Dans le cadre de cette analogie, on peut retenir que les organes de ce groupement sont : le curateur qui est le gérant, le juge-commissaire qui en assume la surveillance et l'assemblée générale qui procède à des délibérations notamment pour décider sur le concordat. Ces décisions prises majoritairement sont obligatoires pour l'ensemble des créanciers[3].

A – La question de la personnalité de la masse

S'il est vrai qu'aucun texte de loi n'accorde la personnalité morale à la masse des créanciers, il est souligné en doctrine que certains effets de la loi peuvent difficilement être justifiés sans recourir à la notion personnalité morale[4].

Parmi ceux-ci, on peut mentionner la possibilité pour le curateur d'agir en nullité de certains actes du failli, et ceci, en tant que représentant de la masse des créanciers. En principe, le curateur devrait désigner individuellement les membres composant la masse quand il agit pour cette dernière[4]. Les dettes contractées pour l'administration de la faillite sont des dettes de la masse : il est difficile de concevoir que la masse puisse avoir des créanciers sans avoir un **patrimoine propre**[5].

B – Distinction entre créanciers de la masse et créanciers dans la masse

Les créanciers de la masse sont **privilégiés** par rapport aux créanciers dans la masse (créances qui en général résultent des frais d'administration de la faillite) dans la mesure où ils ont un droit de préférence sur les biens du failli. Ils n'ont pas à faire accepter leurs créances suivant la procédure d'acceptation applicable aux créanciers dans la masse[2].

---

1 – E. Delamare et M. Le Poitvin, *Traité théorique et pratique de droit commercial*, T. VI, n°s 68 et s., cités par L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 270.

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 270.

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 276.

4 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 276.

5 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 277.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 2 – Le concordat

Il est loisible au failli de déposer une requête en concordat. S'il est répondu favorablement à cette demande, l'effet en est qu'il est mis fin au dessaisissement du failli. Cette forme du concordat (appelé **concordat après faillite**) doit être distinguée du concordat judiciaire[1].

Le moment du vote sur le concordat après faillite est un moment charnière de la procédure. On distingue trois phases dans la procédure de la faillite :

– la phase préparatoire ;

– le concordat ;

– la phase de liquidation.

Avant la procédure concordataire, le curateur prend des mesures conservatoires dont l'objet est de sauvegarder le patrimoine du failli[2]. Tombent dans cette catégorie un certain nombre de mesures prévues par la loi elle-même et parmi lesquelles on peut mentionner celles de dresser inventaire, de clôturer les comptes du failli, de vérifier le bilan, le cas échéant, de l'établir et de le déposer au greffe du tribunal de commerce.

A – Le concordat après faillite

Les créanciers de la faillite sont convoqués et sont appelés à se prononcer sur les propositions du failli. La convocation est faite à l'initiative du curateur par annonce dans le RESA et dans les journaux. Les créanciers sont convoqués individuellement.

L'assemblée se réunit dans les quinze jours qui suivent le jugement rendu sur les contestations de créance. Les créanciers se prononcent par un vote sur les propositions concordataires faites par le failli. Si ce vote est positif, il y a concordat ou traité concordataire[3]. En général, les propositions du failli auront pour objet une **remise partielle des dettes**, et toute créance sera payée à concurrence d'un certain pourcentage.

L'omission, dans l'assemblée des créanciers convoqués en vue de la formation du concordat, du rapport du curateur sur l'état présent et l'issue probable de la faillite, vicie et annule la procédure suivie[4].

B – De la formation du concordat

La validité du traité concordataire est subordonnée à certaines formalités. En particulier, il doit être approuvé par **majorité** en nombre des créanciers représentant les **trois quarts** de la totalité des créances admises définitivement ou par provision, le tout à peine de nullité (art. 512 C.com.).

Les créanciers hypothécaires et les créanciers privilégiés ou nantis de gage n'auront pas voix dans les opérations relatives au concordat, sauf s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges. Le vote au concordat emporte de plein

1 – M.-F. Antoine, *Tout savoir sur la faillite*, p. 60.

2 – M.-F. Antoine, *Tout savoir sur la faillite*, p. 64.

3 – M.-F. Antoine, *Tout savoir sur la faillite*, p. 64.

4 – Lux. du 25 mai 1895 ; *cf.* Cour du 12 juillet 1895, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

droit cette renonciation ; elle demeurera sans effet si le concordat n'est pas admis (art. 513 C.com.).

Ces créanciers pourront toutefois voter au concordat en ne renonçant à leurs privilèges, hypothèques ou gages que pour une quotité de leurs créances équivalant au moins à la moitié. Dans ce cas, ces créances ne seront comptées que pour cette quotité dans les opérations relatives au concordat.

L'homologation du concordat par le tribunal le rend obligatoire pour tous les créanciers portés ou non au bilan, vérifiés ou non (art. 518 C.com.).

Au moment même où le concordat est passé en force de chose jugée, les fonctions des curateurs cessent et le failli est replacé à la tête de ses opérations (art. 519 C.com.).

C – De l'annulation et de la résolution du concordat

Le même jugement que celui qui prononce l'annulation ou la résolution du concordat, charge les curateurs précédemment nommés de reprendre leurs fonctions ou en nomme de nouveaux. Il ordonne aux créanciers du failli, postérieurs à l'homologation du concordat, de faire la déclaration de leurs créances dans le délai fixé à l'article 466 C.com. (art. 524 C.com.).

Les curateurs pourront faire apposer les scellés. Ils procéderont sans retard, avec l'assistance du juge de paix ou du juge-commissaire, s'il a été chargé de l'apposition des scellés sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et papiers, et feront, s'il y a lieu, un supplément d'inventaire. Ils dresseront un bilan supplémentaire, et adresseront aux nouveaux créanciers la circulaire mentionnée à l'article 496 C.com.

D – Déclaration et vérification des créances

La liquidation de la faillite commence nécessairement par la détermination exacte du montant des dettes du failli et le montant exact des créances de chacun. C'est sur la base de la connaissance de ces créances que les actifs de la faillite seront répartis. Le bilan qui, le cas échéant, a pu être déposé par le failli, offre à cet égard des garanties insuffisantes. Il s'y ajoute que la plupart du temps aucun bilan n'est remis à ce moment, compte tenu du fait que, souvent depuis des années déjà, aucune comptabilité digne de ce nom n'est tenue.

Une procédure spéciale de déclaration, d'affirmation et de vérification des créances a donc été instituée[1]. La procédure est caractérisée par le fait que tous les créanciers sont en droit de s'associer au travail de vérification ; de cette façon, le caractère contradictoire de la procédure est garanti. Le curateur vérifie les créances déclarées. La vérification a lieu en assemblée générale sous la surveillance du juge-commissaire.

Ces formalités sont d'ordre public. Aucune dérogation n'est donc possible. « *La production d'une créance équivaut à une demande en justice ; elle saisit le tribunal de la réclamation ; elle interrompt donc la prescription de la créance du prix vis-à-vis du failli et fait courir les intérêts à son égard* »[2].

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 368.

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 369.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Tous les créanciers sont en principe soumis à la procédure de **déclaration et de vérification de la créance**. En principe, cette procédure concerne donc les créanciers chirographaires. Mais on considère en général que la même solution prévaut à l'égard des créanciers qui ont un privilège mobilier général sur l'ensemble des avoirs mobiliers du failli. En revanche, ceci ne vaut pas à l'égard des créanciers bénéficiant de sûretés particulières, tel que le créancier gagiste ou hypothécaire(1).

En Belgique, comme au Luxembourg, il est fait exception à cette règle pour les créances du Trésor public ; les administrations fiscales peuvent agir par voie de contrainte.

Art. 496 C.com.

« *Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tiendra état et en donnera récépissé.*

Les créanciers sont avertis à cet effet par les publications et affiches prescrites par l'article 472. Ils le seront, en outre, par une circulaire chargée à la poste, que les curateurs leur adresseront aussitôt qu'ils seront connus. Cette circulaire indiquera les jours et heures fixés pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances et les débats de contestations à naître de cette vérification.

Les bulletins de chargement seront et demeureront annexés à la minute de la circulaire, qui sera visée par le juge-commissaire ».

La **portée de la déclaration de créance** a donné lieu à des décisions contradictoires de jurisprudence. « *La jurisprudence luxembourgeoise aux termes de laquelle le fait pour le créancier de ne pas avoir déclaré sa créance entraîne l'extinction de cette créance repose toutefois sur une disposition française qui n'est pas reprise dans le droit luxembourgeois.*

D'ailleurs l'article 53 de la loi française du 25 janvier 1985 qui prévoit l'extinction des créances non déclarées et non relevées de forclusion, alors que le droit luxembourgeois consacre le principe de la réintégration des créanciers dans l'intégralité de leurs droits à l'encontre de leur débiteur à la fin du règlement collectif a été déclaré contraire à l'ordre public international luxembourgeois (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. 8 février 2002, n° 65.239, LJUS 99819986) »(2).

La déclaration de chaque créancier doit énoncer ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d'où elle résulte.

Sauf le cas de fraude, une production au passif de la faillite faite sous un prête-nom est en général valable, aucune disposition légale ne l'ayant prohibée(3).

Les règles de la faillite ne sont pas applicables à la créance privilégiée du Trésor public sur les biens de ses débiteurs faillis ; donc, les receveurs des contributions ne

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VII, 1re partie, p. 370.

2 – TA Lux. du 5 novembre 2002, *BIJ*, 2002, n° 2, p. 22.

3 – Cour du 6 avril 1900, *P.*, n° 5, p. 250, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

sont pas astreints à déclarer et à affirmer la créance privilégiée appartenant à l'État pour les contributions dues par un failli. En conséquence, le curateur d'une faillite est tenu de payer les impôts dus par le failli avant toute distribution aux créanciers des deniers de la faillite, alors même que le receveur ne lui en aurait pas adressé la demande[1].

L'Administration des contributions est en droit de réclamer au curateur le paiement des impôts même après la clôture des opérations de la faillite et en l'absence de toute demande antérieure de sa part ; le curateur, à raison de sa qualité de dépositaire des fonds provenant du chef du failli redevable du Trésor, est tenu, avant de distribuer aux créanciers les deniers de la faillite, de s'assurer que les contributions dues sont payées[2].

Pour décider du caractère privilégié d'une créance produite au passif d'une faillite déclarée au Luxembourg, il convient de reconnaître compétence à la loi du pays où la créance a pris naissance. Le privilège octroyé par cette loi, doit donc être respecté au Luxembourg[3].

Art. 499 C.com.

« *La déclaration contiendra, de la part du créancier non domicilié dans la commune où siège le tribunal, élection du domicile dans cette commune. À défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations pourront leur être faites ou données au greffe du tribunal* ».

Pour faire courir le délai d'appel, la signification du jugement doit être faite au domicile élu et non au domicile réel des créanciers produisants, et ce, conformément au prescrit de l'article 499 de la loi du 2 juillet 1870[4].

La disposition de l'article 499 de la loi du 2 juillet 1870 de même que celle de l'article 422 du Code de procédure civile ne sont pas comminatoires en ce sens que les significations doivent être faites soit au domicile élu, soit au greffe, mais ces dispositions laissent aux parties toutes facultés de faire signifier leurs exploits au domicile réel de la partie adverse, conformément au principe général de l'article 68 du Code de procédure civile[5].

Art. 500 C.com.

« *La vérification des créances aura lieu, de la part des curateurs, à mesure que la déclaration en sera faite au greffe ; elle sera opérée en présence du commissaire et à l'intervention du failli, ou lui dûment appelé. Les titres en seront rapprochés des livres et*

1 – Lux. du 22 novembre 1884, *P.*, n° 2, p. 318, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Lux. du 22 novembre 1884, *P.*, n° 2, p. 318, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 23 février 1972, *P.*, n° 22, p. 280, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 10 août 1876, *P.*, n° 1, p. 212, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Cour du 31 janvier 1896, *P.*, n° 4, p. 62, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

écritures du failli. Les créances des curateurs seront vérifiées par le juge-commissaire. Un procès-verbal des opérations sera dressé par les curateurs et signé à chaque séance par eux et le juge-commissaire. Il indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs. Il contiendra la description sommaire des titres produits, mentionnera les surcharges, ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou contestée. En cas de contestation ou si la créance ne paraît pas pleinement justifiée, les curateurs ajourneront leur décision jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification, et si, au moment de cet ajournement, le créancier n'est pas présent en personne ou par fondé de pouvoir, ils lui en donneront immédiatement avis par lettre chargée à la poste ».

En général et sauf cas de dol ou de fraude, l'admission d'une créance sans restrictions ni réserves au procès-verbal de vérification de créances constitue un contrat judiciaire qui place la créance admise, ainsi que les divers articles d'un compte ayant servi au règlement du chiffre de cette créance, à l'abri de toute contestation ultérieure[1].

Si, en principe, l'hypothèque que la loi confère à la femme à raison des engagements qu'elle a contractés pour son mari, n'est opposable aux tiers que du moment où ces engagements ont acquis date certaine, il doit en être autrement lorsque l'existence de la dette au moment litigieux se trouve reconnue par la partie qui inhibe de l'article 1328 du Code civil ; a reconnu l'existence de la dette le curateur qui a admis la créance au passif de la faillite en vertu de pièces constatant l'engagement de la femme en même temps que celui du mari aux dates litigieuses[2].

Le curateur à une faillite qui, après avoir réclamé à une partie une créance de la faillite, admet ensuite la même partie comme créancière à la faillite lors de la vérification des créances, sans faire de réserve au sujet de sa dette et sans invoquer la compensation, est censé avoir reconnu le fondement de la créance de cette partie et le non-fondement de sa dette et n'est pas recevable à poursuivre dans la suite le paiement de la créance de la faillite[3].

L'administration de la faillite exige la conversion des monnaies étrangères en monnaie nationale (à l'époque en francs luxembourgeois) et la doctrine la plus répandue enseigne que la conversion doit se faire au cours du jour de la vérification des créances[4].

Art. 502 C.com.

« *Dans la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, toute créance déclarée qui sera contestée ou qui n'aura pas encore été admise sera examinée contradictoirement. Les curateurs signeront sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante : Admis au passif de la faillite de... pour la somme de... le...*

1 – Lux. du 13 juillet 1898, *P.*, n° 5, p. 250, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 29 mai 1903, *P.*, n° 6, p. 283, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 25 juillet 1907, *P.*, n° 8, p. 393, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Cour du 2 mars 1923, *P.*, n° 11, p. 134, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Le juge-commissaire visera la déclaration ; il renverra au tribunal toutes les contestations relatives aux créances non admises. Toutefois, s'il y a des contestations qui, à raison de la matière, ne sont pas de la compétence du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, elles seront renvoyées devant le juge compétent, pour la décision du fond, et devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, pour y être statué, conformément à l'article 504, jusqu'à concurrence de quelle somme le créancier contesté pourra prendre part aux délibérations du concordat ».

L'admission d'une créance au passif d'une faillite lors de la vérification des créances constitue un **contrat judiciaire** qui met la créance à l'abri de toute contestation aussi bien par rapport à sa quotité que par rapport à sa qualité. Tel n'est cependant pas le cas pour les matières qui intéressent l'ordre public et dans lesquelles il est interdit aux parties de transiger. Spécialement, le privilège ne pouvant exister qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi, l'admission au **passif privilégié** d'une faillite d'une créance qui n'est pas légalement nantie d'un droit de préférence est nulle en ce qui concerne le privilège octroyé à cette créance[1].

Sous la réserve du fond du litige, la compétence du tribunal de commerce en matière de faillite s'étend aux contestations nées à l'occasion de la demande d'admission de créances déclarées après la clôture du procès-verbal de vérification des créances, cette hypothèse étant prévue par l'article 508 C.com. L'admission d'une créance au passif d'une faillite, sans restriction ni réserve et après l'expiration des délais pour contredire, lie le créancier produisant et le curateur par un contrat judiciaire irrévocable, réserve faite seulement des cas de dol, de fraude ou d'une créance née d'un contrat contraire à l'ordre public, mais sans que ce contrat puisse être remis en discussion sous le prétexte d'une erreur de fait ou de droit.

L'admission sans réserves du solde d'une créance au passif de la faillite n'implique pas, dans le chef du curateur, renonciation au droit de demander l'annulation des paiements partiels faits au créancier pendant la période suspecte[2].

En matière de faillite, la contestation portant sur l'existence d'une sûreté spéciale pour le recouvrement des cotisations échues et dues au Service des allocations familiales est une pure question de droit civil qui ne rentre pas dans les attributions de la juridiction commerciale, mais dans celle du tribunal civil[3].

La décision du juge-commissaire, consignée au procès-verbal de vérification des créances, met la créance admise à l'abri de toute modification et empêche le créancier de demander ultérieurement un changement de la quotité ainsi fixée.

Le caractère **irrévocable** du contrat judiciaire intervenu entre parties par l'admission au passif de la faillite d'une créance produite est fondé sur la stabilité et la sécurité des opérations de la faillite, ce qui empêche aussi bien le créancier admis que le curateur de se soustraire aux effets de ce contrat, de sorte qu'une demande ultérieure du créancier tendant à remettre en discussion le montant de la créance admise est irrecevable, alors même que le curateur s'est refusé

1 – Cour du 25 novembre 1930, *P.*, n° 13, p. 80, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Cour du 21 novembre 1933, *P.*, n° 13, p. 122, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 4 février 1950, *P.*, n° 15, p. 132, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

formellement à proposer des moyens d'irrecevabilité, afin d'obtenir une décision sur le fond du litige[1].

En cas de concordat par voie d'abandon d'actif, les contestations des créances doivent être examinées quant au fond et le tribunal y procède suivant le droit commun des faillites. Si une déclaration de production de créance dans un concordat par abandon d'actif n'est qu'un acte simplement conservatoire, elle équivaut cependant à une demande en justice lorsqu'elle vient à être contestée. Il s'ensuit qu'une commune peut valablement faire une production de créance sans autorisation administrative préalable, mais qu'elle doit se pourvoir de cette autorisation à partir du moment où la créance est contestée[2].

La **vérification des créances** en cas de faillite ayant pour but de déterminer définitivement les droits respectifs des créanciers, il s'ensuit que l'admission pure et simple d'une créance, qu'elle ait eu lieu amiablement ou par autorité de justice, implique ou un contrat judiciaire ou une décision équivalente par l'effet desquels cette créance est désormais à l'abri de toute contestation nouvelle tendant à l'anéantir, la réduire ou la modifier. Cependant, le contrat judiciaire, de même que l'autorité de la chose jugée, ne peut s'étendre qu'à la matière qui a fait l'objet de la contestation[3].

Art. 503 C.com.

« *Le failli et les créanciers vérifiés ou portés au bilan pourront assister à la vérification des créances et fournir des contredits aux vérifications, faites et à faire. Après la clôture du procès-verbal de vérification, les contredits aux vérifications faites et comprises dans ce procès-verbal ne pourront, à peine de nullité, être formés que par actes signifiés aux créanciers déclarants, et déposés au greffe avec les pièces justificatives deux jours avant l'audience fixée pour les débats sur les contestations. Les contredits aux vérifications qui seraient faites après la clôture du procès-verbal de vérification devront, sous la même peine, être signifiés dans les dix jours qui suivront l'admission de la créance contestée. Toutefois, ce délai ne courra, à l'égard des créanciers admis postérieurement à cette dernière époque, qu'à compter de la vérification de leurs créances* ».

Art. 505 C.com.

« *Toutes contestations, concernant la liquidation des faillites, qui seraient de la compétence des tribunaux civils, y seront portées à bref délai et jugées par urgence. Il en sera de même pour toutes les contestations de cette espèce qui seront portées devant la cour supérieure de justice* ».

Si les tribunaux de commerce ont, d'une façon générale, compétence pour statuer sur les contestations en matière de faillite, la doctrine et la jurisprudence n'entendent cependant cette règle de compétence qu'avec le tempérament que les contestations

1 – Cour du 9 mars 1966, *P.*, n° 20, p. 83, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Lux. du 25 novembre 1971, *P.*, n° 22, p. 247, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Cour du 3 janvier 1979, *P.*, n° 24, p. 275, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

civiles, dont la cause et l'origine ne résident pas nécessairement dans l'état de faillite, restent soumises au droit commun en matière de juridiction. Partant les demandes en paiement de loyers et en réparations locatives ressortissent de la juridiction civile après comme avant la déclaration de faillite[1].

Il en est de même des actions qui concernent un **droit réel immobilier**[2].

Le juge civil appelé à statuer sur le mérite de créances produites à une faillite sur renvoi du tribunal de commerce juge la validité et le montant de la réclamation sans prononcer l'admission au passif ; le tribunal de commerce est seul compétent à cet effet[3].

Si c'est le tribunal civil qui connaît de la validité des actes par application des articles 445 et 446, c'est cependant le tribunal de commerce qui est compétent pour connaître des frais d'actes formant une partie accessoire de la créance à vérifier[4].

Le tribunal civil est compétent pour décider sur l'existence et le caractère d'une créance produite au passif d'une faillite, lorsque cette créance est de nature civile, mais le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur l'admission de la créance au passif de la faillite et sur la participation éventuelle aux distributions des dividendes[5].

Lorsqu'un juge civil statue sur l'existence et l'importance d'une dette qu'un failli a contractée avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur *qualitate qua* à payer cette somme au créancier ni décider de l'admission de la créance au passif de la faillite, mais doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l'admission de sa créance au passif de la faillite[6].

Art. 507 C.com.

« *Il sera tenu au greffe, pour chaque faillite, un tableau divisé en colonnes et contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes :*

1° le numéro d'ordre ;

3° les nom, prénoms, profession et résidence du créancier qui aura déposé sa déclaration et ses titres ;

3° la date de ce dépôt ;

4° le montant de la créance déclarée ;

5° la désignation sommaire des biens ou objets sur lesquels on prétend qu'elle serait hypothéquée ou privilégiée ;

1 – Lux. du 6 juillet 1895, *P.*, n° 6, p. 446 ; Lux. du 7 mai 1971, *P.*, n° 22, p. 117, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – Lux. du 22 avril 1885, *P.*, n° 3, p. 264, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – Lux. du 19 juin 1901, *P.*, n° 5, p. 507, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – Lux. du 22 juin 1881, *P.*, n° 2, p. 71, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

5 – Lux. du 30 juillet 1910, *P.*, n° 10, p. 214, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

6 – Cour du 21 février 1979, *P.*, n° 24, p. 270, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

6° son admission au passif ou son rejet par les curateurs ;
7° la date de cette admission ou de ce rejet ;
8° les contredits ;
9° les noms des opposants ;
10° les dates des contredits ;
11° le jour auquel le procès-verbal de vérification sera clos ;
12° le jour où s'ouvriront les débats sur les contestations ;
13° le sommaire de la décision définitive ;
14° la date de cette décision ; et
15° les autres renseignements qu'il pourra être utile de porter à la connaissance des intéressés ».

Ce tableau sera dressé par le greffier ; les énonciations exigées y seront faites successivement jour par jour, et au fur et à mesure que les faits et circonstances auxquels elles se rattachent se reproduiront. Il sera, à toute réquisition, communiqué aux intéressés.

E – De la liquidation de la faillite

1) Les travaux de liquidation proprement dits

La mission des curateurs est de procéder au plus vite à la liquidation de la faillite Dans cette optique, ils font vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, ils paient les dettes sous la surveillance du juge-commissaire (art. 528 C.com.).

En outre, le curateur de faillite a la mission légale de **représenter la masse** des créanciers ; par conséquent, seules les actions qui présentent pour l'ensemble des créanciers chirographaires un intérêt commun peuvent être exercées par le curateur, mais ce dernier est sans qualité pour invoquer un privilège qui peut exister en faveur de quelques créanciers et qui ne profite pas à la masse[1].

2) Des contrats en cours

Une question très importante en pratique est celle du sort des contrats en cours. En principe, les contrats qui sont conclus par le failli avant le jugement de faillite restent valables. Il est vrai que, souvent, les contrats stipulent que la faillite de l'un des cocontractants met, de plein droit, fin au contrat. Ces clauses sont évidemment à respecter. Dans ce contexte, il faut noter que, si le curateur décide de continuer les contrats en cours, les créances qui résultent de l'exécution de ce contrat seront des « créances de la masse » qui sont donc préférées par rapport aux créances « dans la masse ».

Une mention spéciale est à faire pour les contrats de travail. En effet, en application de l'article 30 de la loi du 24 mai 1989 (L. 125-1 (1) du Code du travail), le contrat de travail est résilié avec effet immédiat, notamment en cas de faillite de l'employeur. Mais le curateur peut, en accord avec l'un ou l'autre des salariés, en

1 – Cass. du 13 novembre 1952, *P.*, n° 15, p. 403, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

décider autrement en continuant donc le contrat de travail. « *En cas de faillite de l'employeur les contrats d'emploi le liant à ses employés sont résiliés de plein droit, si le curateur de la faillite ne continue pas l'exploitation de l'entreprise. Dans le cas, au contraire, où l'exploitation de l'entreprise est continuée par le curateur, les contrats d'emploi subsistent avec tous leurs effets. Si l'employé peut dès lors se prévaloir à l'égard du curateur de tous les droits résultant de son contrat, il est en contrepartie, tenu d'en respecter toutes les obligations* »[1].

1 – C. arb. du 17 novembre 1970, *P.*, n° 21, p. 385.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE III
LA GESTION CONTRÔLÉE

La base juridique de ce régime, qui trouve son origine en droit belge, est l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 « *[…] complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée* »[1].

SECTION I
OBJECTIFS DU RÉGIME

Ce régime (introduit en Belgique par l'arrêté royal du 15 octobre 1934) était destiné à « *permettre au commerçant d'échapper à la faillite sans avoir à subir les inconvénients inhérents à l'organisation du concordat préventif de la faillite ou du sursis de paiement* »[2].

La gestion contrôlée était un moyen d'éviter la faillite à la disposition du commerçant de **bonne foi**, dont le crédit était ébranlé ou qui constate que l'exécution intégrale de ses engagements est compromise. Il lui était ainsi possible de réorganiser son affaire ou de réaliser son actif dans de meilleures conditions en se plaçant sous le contrôle des délégués de justice et avec l'assentiment de la majorité des créanciers[3].

■ § 1 – Délimitation par rapport à la faillite

Les conditions d'application de ce régime dénotent la délimitation par rapport à la faillite dans le sens qu'il ne doit pas y avoir de cessation de paiements. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935, *« [L]e commerçant dont le crédit est ébranlé ou l'exécution intégrale des engagements compromise, peut demander le bénéfice de la gestion contrôlée en vue soit de la réorganisation de ses affaires, soit de la bonne réalisation de son actif*.

Une requête motivée, appuyée des documents justificatifs et notamment de la liste des créanciers, est présentée à cet effet au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel le commerçant a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une société, son siège social.

Dans ce dernier cas, la requête est présentée à la diligence de la majorité des administrateurs ou gérants ou de la majorité des commissaires.

La requête n'est plus recevable lorsque la faillite du requérant a été déclarée par un jugement coulé en force de chose jugée ».

■ § 2 – Conditions requises par la loi

La loi luxembourgeoise sur la gestion contrôlée, contrairement à la loi belge, n'exige pas explicitement que le débiteur soit de bonne foi. « *[…] celle-ci doit*

1 – Arrêté grand-ducal du 24 mai 1935, ID 10221.

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VIII, 2e partie, p. 1035.

3 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VIII, 2e partie, p. 1036.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

cependant exister et les tribunaux peuvent donner à cet élément une importance décisive. Pour que le commerçant puisse être qualifié de mauvaise foi, il doit s'être rendu coupable de fautes lourdes ou d'irrégularités graves »[1].

Pour qu'une entreprise puisse bénéficier du régime de la gestion contrôlée, il faut qu'il existe une possibilité de réorganisation de cette entreprise de nature à améliorer la marche des affaires et à diminuer le passif[2].

Au vu des informations qui lui sont soumises, « *[…] le tribunal estime les chances d'une bonne réalisation de l'actif de la requérante des plus aléatoires, compte tenu notamment du fait que les commissions à réaliser sur le chiffre d'affaires renseigné ne suffisent pas pour assurer le remboursement des intérêts, atteignant les 2 millions de francs par trimestre, de la dette bancaire. Par ailleurs, l'allégation que des amateurs se seraient manifestés pour reprendre l'actif de la société est restée des plus vagues. Il ne résulte pas des éléments produits que la mesure sollicitée peut rendre meilleures les conditions de la réalisation de l'actif de la société requérante* »[3].

La demande de gestion contrôlée sera rejetée si les conditions économiques d'exploitation de l'entreprise sont peu solides. « *Il échet de relever que ces créances sont incertaines et partant difficilement récupérables, étant donné que le refus de paiement se trouve motivé par l'existence de malfaçons sur la totalité des chantiers réalisés. Dans ces conditions, la liquidation dans le cadre de la gestion contrôlée ne présente aucun avantage par rapport à la réalisation de l'actif et sa distribution dans le cadre de la faillite, étant donné que le curateur à la faillite a également pour mission de réaliser l'actif mobilier en intentant des actions contre les éventuels créanciers du failli pour autant que la créance est certaine […]* »[4].

SECTION II
PROCÉDURE INSTITUÉE

La procédure débute par une **requête motivée**, appuyée par des documents justificatifs et en particulier par la liste des créanciers, qui doit être déposée au tribunal de commerce de l'arrondissement où le commerçant a établi son principal établissement et, s'il s'agit d'une société, de son siège social. Toujours en cas de société, la requête doit être introduite à la requête de la majorité des administrateurs (gérants) ou la majorité des commissaires (art. 1).

La procédure comporte trois phases :

– l'instruction de la demande ;

– l'établissement du projet ;

– l'approbation du projet.

---

1 – CA . du 17 février 1982, et CA du 10 février 1982, *P.*, nº 25, p. 301, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 19 novembre 1986, nº 9457, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA (com.) Lux. du 7 février 1992, gestion contrôlée 140/92, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

4 – TA (com.) Lux. du 26 février 1987, gestion contrôlée 122/87, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

§ 1 – L'instruction de la demande

D'abord, le débiteur est entendu en chambre du conseil. La requête est rejetée s'il ne résulte pas des éléments produits que la mesure sollicitée aura pour effet soit **d'assurer** progressivement **l'assainissement** et l'exercice normal du commerce du requérant, soit encore de rendre meilleures les conditions de la réalisation des actifs.

Si la requête ne fait pas l'objet d'un rejet, un juge sera délégué pour instruire le dossier et pour faire rapport sur la situation du commerce du requérant dans le délai fixé par le tribunal.

Cette désignation a pour effet de donner lieu, de plein droit, à un sursis provisoire « *à tous les actes d'exécution* » tout en comportant interdiction de faire certains actes susceptibles de préjudicier aux créanciers[1].

Cette décision a encore pour conséquence que le commerçant ne peut, à peine de nullité, aliéner, constituer des gages ou des hypothèques, etc. sans autorisation écrite du juge délégué (art. 3).

Comme suite à cette instruction de la demande, le tribunal peut placer la gestion du patrimoine sous le contrôle d'un ou de plusieurs commissaires chargés d'élaborer le **plan de réorganisation** ou de liquidation de l'actif dans le délai fixé[1].

Selon l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935, « *[L]e tribunal entend le requérant et examine la requête en chambre du conseil. Il la rejette si des éléments produits il ne résulte pas que la mesure sollicitée peut soit assurer progressivement l'assainissement et l'exercice normal du commerce du requérant, soit rendre meilleures les conditions de la réalisation de l'actif.*

S'il ne rejette pas la requête, le tribunal délègue l'un de ses juges pour lui faire rapport, dans le délai qu'il fixe, sur la situation du commerce du requérant.

Le juge délégué peut, pour procéder à la vérification de l'état des affaires du requérant, se faire assister d'un expert qui prête entre ses mains le serment de bien et fidèlement remplir sa mission ».

Il est loisible à la juridiction commerciale de rejeter la requête en octroi du bénéfice de la gestion contrôlée « *à n'importe quel stade de la procédure dès qu'elle acquiert la conviction que la mesure sollicitée ne peut ni assurer progressivement l'assainissement et l'exercice normal du commerce concerné, ni rendre meilleures les conditions de la réalisation de l'actif* »[2]. Tel est en particulier la solution si le régime de gestion contrôlée n'offre pas d'avantage par rapport au régime de la faillite pure et simple.

Le rapport déposé, le tribunal, réuni en chambre du conseil, entend le requérant et, statuant en audience publique, rejette la requête ou place la gestion du patrimoine du requérant sous le contrôle d'un ou de plusieurs commissaires. Cette dernière décision est, à la diligence des commissaires, publiée par extrait au RESA.

Si, en plaçant sous le contrôle d'un ou de plusieurs commissaires la gestion du patrimoine du requérant, le tribunal constate que celui-ci est en état de cessation de paiements, il peut, soit par ce jugement, soit par un jugement postérieur, déterminer l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiements. Cette époque ne peut

1 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VIII, 2e partie, p. 1036.

2 – CA du 26 juillet 1982 ; CA du 29 avril 1998, n° 21924, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

toutefois être fixée à une **date antérieure à plus de six mois au dépôt** de la requête. Cependant, la faillite ne pourra être prononcée, s'il y a lieu, qu'après la décision définitive de rejet prévue à l'alinéa précédent ainsi qu'aux articles 2 et 9.

Si les premiers juges ont à juste titre dit que la condition de bonne foi, quoique non expressément prévue par l'arrêté grand-ducal de 24 mai 1935 – contrairement à la législation belge afférente – doit exister dans le chef du requérant, non seulement lors du dépôt de la requête, mais également durant les trois phases de la procédure en gestion contrôlée, toujours est-il que, d'après l'article 4, alinéa dernier, dudit arrêté, le tribunal, même s'il a la conviction que le débiteur n'est plus de bonne foi, ne peut prononcer la faillite qu'après la décision définitive de rejet de la requête, soit immédiatement après son dépôt, soit après le rapport du juge-délégué, soit après la communication du projet établi par les commissaires. En effet, cette disposition est claire et précise et n'est pas susceptible de la moindre interprétation. Il est d'ailleurs énoncé sans équivoque possible dans l'avis du Conseil d'État du 17 mai 1935, que « *pour lever tout doute au sujet du pouvoir que le tribunal pourrait puiser dans l'article 442 C.com. qui détermine la prononciation de l'état de faillite, il est opportun de déclarer expressément que la procédure concernant la gestion contrôlée, une fois entamée, devra être épuisée par une décision de rejet formel avant que le juge ne puisse statuer éventuellement dans le sens de l'article précité* »[(1)].

Dès lors qu'en raison de l'écroulement du marché du vanadium, l'installation de sa production est à l'arrêt, que le redémarrage de celle-ci obligerait la requérante à une production à perte et que le gouvernement en conseil a décidé de retirer à la requérante ses autorisations d'établissement, cette dernière estime qu'une réorganisation de ses affaires est impossible. « *En effet, l'incertitude quant aux problèmes économiques et quant à l'autorisation administrative justifie le changement du régime de la gestion contrôlée pour réorganisation des affaires en régime de la gestion contrôlée pour liquidation des affaires. En outre, une liquidation de l'entreprise dans le cadre d'une gestion contrôlée est de nature à rendre meilleures les conditions de réalisation de l'actif, de sorte qu'il échet de faire droit à la demande* »[(2)].

La décision du tribunal déléguant un juge entraîne de plein droit au profit du requérant et jusqu'à décision définitive sur la requête, **sursis à tous actes ultérieurs d'exécution** même par les créanciers hypothécaires, privilégiés ou gagistes.

À dater de la même décision, le commerçant ne peut, à peine de nullité, aliéner, constituer des gages ou hypothèques, s'engager ou recevoir un capital mobilier sans l'autorisation écrite du juge délégué.

La loi ne défendant que tous les **actes ultérieurs d'exécution**, il reste permis aux créanciers de faire tous les actes conservatoires de leurs droits, et notamment de poursuivre la saisie-arrêt ou proposition jusqu'au jugement qui en prononce la validité.[(3)].

Le moyen visant à transposer à la gestion contrôlée certaines solutions admises en matière de faillite d'après lesquelles les actions commencées avant le jugement déclaratif peuvent être continuées après ce dernier, est à rejeter, « […] *car la faillite est*

1 – CA du 24 mars 1982, n° 6376, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA (com.) Lux. du 22 novembre 1989, gestion contrôlée n° 124/87, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA (civ.) Lux. du 6 mai 1988, n° 37 617, ID 12442.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

une pure voie d'exécution collective aboutissant toujours à la liquidation de l'entreprise du failli et à la distribution de l'actif parmi les créanciers. Par contre, l'organisation de la gestion contrôlée permet de sauver les entreprises saines, menacées par la crise et évite une réalisation désastreuse de celles qui ne sont plus viables »[1].

■ § 2 – Établissement du projet

Une fois que le rapport du juge délégué est déposé, le tribunal, après avoir entendu le requérant, soit rejette sa requête, soit le place sous le contrôle d'un ou de plusieurs commissaires. Cette décision est publiée selon les conditions de la Loi de 2002. Si la décision du tribunal est de placer la gestion du patrimoine du requérant sous le contrôle d'un ou de plusieurs commissaires et si le tribunal constate plus tard que le requérant est en état de cessation de paiements, il peut déterminer l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiements. Cette époque ne peut toutefois être fixée à une date antérieure de plus de six mois au dépôt de la requête.

Dès leur nomination, les commissaires établissent le projet et le font examiner par les créanciers. Ces derniers, non regroupés en assemblée générale, sont consultés individuellement. Le projet est accepté lorsque plus de la **moitié des créanciers** représentant plus de la **moitié du passif** donnent leur accord.

■ § 3 – Approbation du projet

Le projet qui a trouvé l'accord des créanciers est **approuvé** par le **tribunal**. Ce jugement a pour objet de rendre le projet obligatoire pour le débiteur ainsi que pour tous les créanciers[2].

« *Aux termes de l'article 8, alinéa 5, de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 sur la gestion contrôlée, le tribunal ne peut approuver le projet des commissaires que si plus de la moitié des créanciers représentant, par leurs créances non contestées par les commissaires, plus de la moitié du passif ont donné leur adhésion. Les créanciers qui s'abstiennent sont comptés parmi les adhérents. En l'espèce, la condition de l'adhésion des créanciers au projet des commissaires suivant les règles de majorité inscrites à l'article 8 précité est remplie. L'adhésion des créanciers au projet des commissaires, indispensable pour que la gestion contrôlée soit possible, ne suffit pas. Il faut encore que le tribunal l'approuve. Le dernier mot appartient aux magistrats, représentants de l'intérêt public (Louis Fredericq, Gestion contrôlée, n° 44, p. 57). Il résulte du texte clair et précis de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 que ce pouvoir d'appréciation du plan appartient aux seules juridictions de jugement compétentes, à l'exclusion de tout autre pouvoir de l'État. En l'espèce, le plan des commissaires respecte le rang des privilèges et hypothèques tel qu'il résulte de la loi et tient équitablement compte dans toute la mesure du possible de tous les intérêts en cause et notamment de celui des créanciers et de l'intérêt collectif. Le but poursuivi par l'arrêté grand-ducal de 1935 fut d'enrayer dans l'intérêt général, le déclin catastrophique de nombreuses entreprises. Cet avis a été exprimé à l'époque tant par le Conseil d'État (avis du 17 mai 1935) que par le Ministre d'État (exposé des motifs du 6 mai 1935) où il est dit textuellement que*

1 – CA du 28 mai 1997, n° 17.418 et 20.009, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – L. Frédéricq, *Traité de droit commercial belge*, T. VIII, 2e partie, p. 1037.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

"ce qu'il s'agit de juger c'est l'entreprise bien plus que l'entrepreneur, ce qu'il s'agit de sauvegarder c'est l'intérêt collectif bien plus que l'intérêt particulier de l'intéressé". En l'espèce, la solution proposée sert l'œuvre de redressement économique que l'arrêté grand-ducal de 1935 a en vue, il est certes dans l'intérêt de la collectivité de sauver l'entreprise et les emplois. Dans ces conditions, le tribunal approuve le plan de réorganisation de la société. En principe, après l'approbation du plan par le tribunal, le contrôlé redevient maître de ses biens, à moins que des restrictions viennent entraver sa liberté »[1].

Si le tribunal estime ne pouvoir approuver le projet des commissaires, il rejette la requête ou assigne aux commissaires un bref délai dans lequel sera dressé un **nouveau projet**. Celui-ci est rendu public conformément à l'article 8 et la procédure prévue par cet article est à nouveau suivie.

L'interdiction de la compensation sans autorisation des commissaires à la gestion contrôlée résulte de l'interprétation de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 aux termes duquel le commerçant ne peut, à peine de nullité « faire aucun paiement » sans l'autorisation des commissaires. Cette interdiction a pour but de faire régner l'égalité entre les créanciers et ne vise que la compensation entre des dettes étrangères l'une de l'autre. En l'espèce, il existe entre les deux créances un lien de connexité étroit provenant de l'unité de leur origine de nature à justifier qu'une compensation s'opère entre elles[2].

Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée, « *à peine de nullité, le commerçant ne peut, sans l'autorisation des commissaires […] plaider […]* ». La conséquence de cette disposition est que « *le débiteur contrôlé ne pouvant plus plaider sans autorisation, l'action en justice sera dirigée et contre le débiteur, pour y répondre personnellement, et contre les commissaires, pour l'autoriser. Les commissaires doivent être mis en cause, puisqu'ils représentent la masse des créanciers dans l'intérêt de laquelle la nullité existe* » *(Louis Fredericq, Gestion contrôlée, Commentaire de l'Arrêté Royal du 15 octobre 1934, n° 27, I, 1°, p. 32)* »[3].

Aux termes de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 instituant le régime de la gestion contrôlée, les commissaires ont qualité pour **intenter**, mais avec l'autorisation du tribunal, les **actions** dérivant des articles 441-9, 443-2, alinéa 3, 600-2 L.S.C. sur le régime des sociétés commerciales. L'action en responsabilité contre les administrateurs ne peut dès lors être exercée par les commissaires à la gestion contrôlée qu'avec l'autorisation du tribunal. Par conséquent, il y a lieu de décider que, de même que le commerçant placé sous gestion contrôlée ne peut, à peine de nullité, accomplir les actes visés à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 sans l'autorisation des commissaires, l'autorisation du tribunal requise pour l'exercice de l'action en responsabilité constitue, par analogie notamment avec les autorisations requises en matière de tutelle entraînant la nullité des

1 – TA (com.) Lux. du 21 février 1986, gestion contrôlée n° 110/84, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 20 janvier 1988, n° 9.031, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

3 – TA (com.) Lux. du 10 mai 1984, réf. n° 342/84, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

actes passés seuls par le tuteur pour lesquels l'autorisation du conseil de famille ou l'homologation du tribunal sont requises, une condition de recevabilité de l'action, de sorte que l'action engagée sans autorisation requise est à déclarer irrecevable[1].

D'après les demandeurs, le défendeur est à considérer comme occupant sans droit ni titre, en raison du fait que le contrat de bail, conclu durant le régime de la gestion contrôlé par les propriétaires qui ne pouvaient agir qu'avec l'autorisation du commissaire, n'a pas été contresigné par ce dernier. L'organisation de la procédure en obtention de la gestion contrôlée démontre la volonté du législateur d'attribuer en cette matière compétence exclusive aux tribunaux de commerce. Il en est forcément ainsi pour le présent litige qui est né en raison de la gestion contrôlée et ne saurait exister sans elle. Par conséquent, dès lors que les demandeurs ne versent en cause aucun jugement du tribunal de commerce portant annulation durant le régime de la gestion contrôlée du contrat de bail conclu en cause, que suite à l'approbation du projet du commissaire le défendeur a repris le libre exercice de tous ses droits et l'obligation de n'agir qu'avec une autorisation est levée, qu'il est redevenu maître de ses biens, dans les limites et, le cas échéant, avec les restrictions conventionnelles introduites dans le projet et que le contrat de bail conclu en violation de la législation sur la gestion contrôlée n'a pas été annulé durant le régime, le défendeur ne saurait être considéré comme occupant sans droit ni titre, et la demande en déguerpissement ne se justifie pas de ce chef (Justice de paix, Luxembourg, 28 avril 1986). Selon les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 instituant le régime de la gestion contrôlée, l'autorisation des commissaires est requise tant pour demander que pour défendre. Par ailleurs, si elle n'est soumise à aucune forme particulière, elle doit néanmoins être expresse et spéciale. Ainsi, la nullité qui résulte du défaut d'autorisation n'est pas une nullité de forme soumise à la réglementation de l'article 173 du Code de procédure civile, mais une nullité de fond pour constituer une violation d'une règle fondamentale tenant à l'organisation judiciaire qui peut être soulevée en tout état de cause et même d'office[2].

S'il est vrai que l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 instituant le régime de la gestion contrôlée entraîne la formation de la masse des créanciers du commerçant bénéficiant de cette procédure, toujours est-il que cet arrêté confère à cette dernière les caractéristiques d'une procédure de liquidation collective tendant à assurer la solution égalitaire d'un concours né entre tous les créanciers du débiteur relativement à l'intégralité de l'actif du patrimoine de ce dernier. C'est ainsi notamment que ledit arrêté **suspend** en son article 3 les **mesures d'exécution individuelles** à partir du jugement recevant la requête en obtention de la gestion contrôlée et déléguant un des juges pour faire rapport. Il est de la nature de toute procédure de liquidation collective qu'afin d'assurer l'égalité des créanciers, les droits de ceux-ci au moment de la mise en œuvre de la procédure se « cristallisant » à cette date, l'ensemble de ces créanciers forme, quant à ces droits cristallisés, une masse. Il en va partant de même dans le cadre du régime de la gestion contrôlée, et ce, à partir de la décision judiciaire visée à l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 qui, en l'espèce, est intervenue le 18 décembre 1978. De même, l'existence d'une masse dans le cadre

1 – TA (com.) Lux. du 30 janvier 1987, n°s 32.198 et 37.233, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – CA du 23 mars 1988, n° 9.030, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

de la gestion contrôlée peut encore se déduire de l'article 5 de l'arrêté grandducal précité qui, sous certaines conditions, confère aux commissaires notamment le droit d'exercer avec l'autorisation du tribunal les actions prévues aux articles 445, 446 et 447 C.com., définies dans leur cadre d'origine de la faillite comme n'étant pas des actions en nullité à proprement parler, mais comme tendant à voir déclarer inopposables à la masse des créanciers certains actes qui restent néanmoins valables dans les relations entre le débiteur et son cocontractant. Ainsi, il résulte de l'existence de cette masse et des nécessités de liquidation de celle-ci que le débiteur, assisté ou même contraint par le juge-délégué et, plus tard, par les commissaires, peut traiter pour les besoins de cette liquidation avec les tiers de façon à ce que ceux-ci soient assurés d'échapper à la loi du dividende, faute de quoi personne ne consentirait à traiter avec lui, avec comme conséquence que toute gestion contrôlée deviendrait matériellement irréalisable. Par conséquent, les dettes, régulièrement contractées après la formation de la masse pour les besoins de la liquidation de celle-ci, sont dès lors à considérer comme dettes de la masse et devront être payées avant tous les autres créanciers. Une créance, née comme créance de la masse, conserve ce caractère, nonobstant le jugement de faillite intervenu dans les circonstances de fait-ci dessus énoncées. Il suit de ce qui précède que l'appelante doit être reconnue comme créancière de la masse de la faillite et que sa créance doit être remboursée avant toute distribution aux créanciers dans cette masse, même privilégiés[1].

Les commissaires établissent dans le délai fixé par le tribunal, soit un projet de réorganisation du commerce du requérant, soit un projet de réalisation et de répartition de l'actif.

Art. 7.

« *Le projet de réorganisation ou de réalisation et de répartition de l'actif tient équitablement compte de tous les intérêts en cause. Il respecte le rang des privilèges et des hypothèques, tel qu'il résulte de la loi et sans que les clauses conventionnelles de déchéance, de résolution et de pénalités soient opérantes à l'encontre soit de la réorganisation, soit de la réalisation et de la répartition de l'actif* ».

■ § 4 – Égalité des créanciers

Ce principe d'égalité des créanciers est constamment invoqué par les juridictions.

« *La faillite entraîne le concours des créanciers. Il y a concours quand il y a rencontre, due à l'initiative des créanciers ou la volonté du législateur, de prétentions contradictoires des créanciers sur un ou plusieurs biens du débiteur dont celui-ci a perdu la libre disposition. […] En cas de faillite le concours naît de plein droit, par l'effet de la loi. Les biens du débiteur failli sont affectés exclusivement au désintéressement des créanciers existants au jour de la faillite. […]*

Le concours ne se crée qu'entre les créanciers dont la créance est cristallisée au moment de la faillite ; entre ces créanciers, la répartition égalitaire des biens qui existent au moment de la faillite, augmentés de ceux qui peuvent ultérieurement échoir

1 – CA du 26 février 1986, n° 8.264, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

au failli ou être récupérés par l'exercice des actions en responsabilité ou inopposabilité, est la règle, sauf lorsque le régime des hypothèques et privilèges permet d'y déroger.

***L'égalité**, toutefois, n'est qu'un **principe relatif** dont la portée s'amenuise. La loi impose dans une variété de situations, d'observer un ordre de répartition prioritaire pour certaines créances liées directement à l'administration de la faillite : ce sont les dettes de la masse […]*

Ce principe séculaire de l'égalité dans le concours est en outre fortement affaibli par diverses causes de préférences rompant l'égalité des créanciers. Le nombre très élevé de privilèges établis par la loi a rendu creuse la notion même de répartition égalitaire en cas de faillite. L'égalité reste encore applicable comme principe résiduaire et explique en outre de nombreux mécanismes de la loi sur les faillites, mais cette égalité ne profite en réalité aux créanciers chirographaires et privilégiés généraux que de manière marginale »[(1)]*.*

Afin d'assurer le principe d'égalité des créanciers, on reconnaît en premier lieu à la collectivité des créanciers la caractéristique d'une **masse** des créanciers. « *D'une part, pour arriver à la conclusion qu'il existe une masse dans le cadre de la gestion contrôlée, le tribunal, a considéré que s'il est vrai que l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 ne s'exprime pas expressément au sujet de cette question, le texte légal confère tout de même à l'institution qu'il réglemente les caractéristiques d'une procédure de liquidation collective. De plus, afin d'assurer l'égalité des créanciers, leurs droits se "cristallisent" au moment de la mise en œuvre d'une procédure de liquidation collective en formant quant à ces droits "cristallisés" une masse. D'autre part, le tribunal s'est fondé sur l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935, qui se réfère aux articles 445, 446 et 447 C.com. attribuant aux commissaires, sous certaines conditions, l'exercice d'actions tendant à voir déclarer certains actes inopposables à la masse des créanciers. Dès lors, le tribunal a estimé que les dettes régulièrement contractées après la formation de la masse, c'est à dire, après le 19 octobre 1982, et pour les besoins de la liquidation de celle-ci, sont à considérer comme des dettes de la masse et devraient être payées sur l'actif avant tous les autres créanciers. Le tribunal a encore considéré que les dettes de la masse peuvent résulter de contrats conclus par le ou les organes chargés de la gestion et de la liquidation de la masse, mais aussi de contrats conclus antérieurement par le débiteur lui-même et repris ou continués par ces mêmes organes. Il a par ailleurs constaté qu'en l'espèce les contrats de travail, qui n'avaient pas été résolus de plein droit par l'institution de la gestion contrôlée de S., avaient été tacitement mais certainement continués et repris par la masse des créanciers, alors que S. avait sollicité et obtenu l'autorisation du juge délégué de régler les salaires pour le mois d'octobre 1982, c'est-à-dire pour la période postérieure au jugement du 19 octobre 1982 »*[(2)].

Aux termes de l'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée, le plan de réalisation et de répartition de l'actif doit notamment respecter le rang des privilèges et des hypothèques.

1 – I. Verougstraete, *Manuel de la faillite et du concordat*, Kluwer, 1998, p. 398.

2 – CA du 11 juillet 1984, n° 7.145, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Les commissaires communiquent le projet aux créanciers, aux codébiteurs solidaires et cautions connus ; lorsqu'il s'agit d'une société, le projet est, en outre, publié par extrait au RESA. Il est soumis à l'approbation du tribunal.

Dans les quinze jours de la communication ou de la publication prévues à l'alinéa précédent, les créanciers font parvenir au greffe du tribunal leur adhésion ou leur opposition au projet des commissaires ; ils peuvent, tout comme le commerçant, les actionnaires, les codébiteurs solidaires et cautions, adresser des observations écrites au greffe du tribunal. Celui-ci entend, en chambre du Conseil, le commerçant ; il peut aussi inviter à comparaître les intéressés qui ont fait parvenir leurs observations ou leur opposition. Le jugement est rendu en audience publique. Le tribunal ne peut approuver le projet des commissaires que si plus de la moitié des créanciers représentant, par leurs créances non contestées par les commissaires, plus de la **moitié** du **passif** ont donné leur **adhésion**. Les créanciers qui s'abstiennent sont comptés parmi les adhérents.

Malgré l'adhésion des majorités requises par l'article 8 précité, le tribunal conserve un **pouvoir d'appréciation** et doit vérifier si le plan tient équitablement compte de tous les intérêts en cause conformément à l'article 7 de l'arrêté grand-ducal. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le projet a été approuvé par environ 16 % des créances admises et environ 5 % du passif total. Ainsi, si le tribunal approuve le projet des commissaires, il deviendra obligatoire pour tous les créanciers, malgré le fait qu'il n'a trouvé l'adhésion que d'une infime minorité[1].

■ § 5 – Approbation du projet des commissaires

Aux termes de l'article 10 : « *Le jugement approuvant le projet des commissaires est obligatoire pour le commerçant, pour les créanciers de celui-ci et, même s'ils ont acquitté la dette après le jugement, pour les codébiteurs solidaires et les cautions. Il est publié par extrait, à la diligence des commissaires, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal désigné par le tribunal*.

En principe, le commerçant placé sous gestion contrôlée reprend le libre exercice de ses droits, une fois le projet approuvé par le tribunal, soit aux fins de réorganisation, soit, comme en l'espèce, en vue de la liquidation de son négoce. Il n'appartient dès lors pas au tribunal de prononcer la dissolution d'une société placée sous le régime de la gestion contrôlée et de désigner les liquidateurs, du moment du moins que ladite société, disposant d'organes statutaires réguliers est en état de fonctionner et d'opérer elle-même sa liquidation conformément soit à ses statuts et à défaut conformément aux dispositions légales régissant la matière. Cependant, il paraît opportun que la liquidation se fasse sous la surveillance des commissaires de la gestion contrôlée, cette restriction conventionnelle à la liberté d'action du commerçant n'étant pas contraire à l'esprit du texte de l'arrêté grand-ducal »[2].

Aux termes de l'article 10 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 relatif à la gestion contrôlée, le **jugement** approuvant le projet des commissaires **est obligatoire** pour le commerçant et pour les créanciers de celui-ci. À partir de ce jugement, le

1 – TA (com.) Lux. du 8 juin 1994, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA (com.) Lux. du 11 février 1976, gestion contrôlée n° 45/74, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

régime établi par le projet entre en vigueur ; le projet des commissaires devient un « traité », c'est à dire un contrat obligatoire pour tous, qui peut être révoqué uniquement pour cause d'annulation ou de résolution par application du droit commun[1].

Le commissaire à la gestion contrôlée arrête le passif selon les règles de la faillite – il est vrai en l'absence d'un texte formel à cet égard – et opère le paiement en exécution du projet de réalisation et de répartition de l'actif approuvé par la décision judiciaire et devenu « traité », soit donc un contrat obligatoire pour tous. Cela veut dire que le traité qui est le projet approuvé des commissaires ne dégage pas les débiteurs solidaires ni les cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion. Ceux-ci sont en effet tiers par rapport au projet exécuté, qui est une mesure prise en faveur du débiteur. Ils doivent donc s'exécuter[2].

Les honoraires des commissaires et ceux des experts sont taxés par le tribunal d'après la difficulté de leurs travaux ; ils sont, ainsi que les déboursés, à charge du requérant et sont payés par privilège. Les créanciers du demandeur, qui ont été nommés commissaires, n'ont pas droit à des honoraires.

1 – TA (com.) Lux. du 27 mars 1987, n° 37.146. V. aussi TA (civ.) Lux. du 16 décembre 1987, n° 34.619, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

2 – TA (com.) Lux. du 6 mai 1988, n° 35.681, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

CHAPITRE IV
DES SURSIS DE PAIEMENT

Le Code de commerce prévoit une procédure spéciale limitée aux commerçants ayant connu des difficultés imprévues, mais ne remplissant **pas** les conditions de la **cessation de paiements**. Le sursis de paiement institué à cette fin est prévu par les articles 593 à 613 C.com.

Il faut en premier lieu que le commerçant soit en **cessation de paiements temporaire,** mais que la solvabilité reste suffisante afin de permettre le paiement de toutes les dettes sociales, y compris les intérêts. C'est ce qu'exprime l'article 593 C.com.

« *Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint* ***de cesser temporairement ses paiements****, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffisants pour satisfaire tous ses créanciers en principal et intérêts. Le sursis de paiement pourra également être accordé si la situation du commerçant, bien qu'actuellement déficitaire, renferme des éléments sérieux de rétablissement de l'équilibre entre l'actif et le passif.*

En cas de décès d'un commerçant, le sursis au paiement de ses dettes pourra être accordé à ses héritiers bénéficiaires, pour les causes et dans les conditions déterminées au paragraphe précédent ».

■ § 1 – Procédure applicable

La procédure est particulière à plus d'un égard.

A – Requête du débiteur

Aux termes de l'article 594 C.com., la procédure est entamée par le débiteur qui s'adresse, par requête, simultanément au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel il est domicilié et à la Cour supérieure de justice.

Il est tenu de joindre à sa requête :

« *1° l'exposé des événements sur lesquels il fonde sa demande ;*

2° l'état détaillé et estimatif de son actif et de son passif ;

3° la liste nominative de ses créanciers, avec l'indication de leur domicile et du montant de leurs créances.

La requête adressée à la Cour supérieure de justice sera communiquée par le président au procureur général ; elle devra être signée par un avoué près de cette Cour ».

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 595 C.com.

« *La requête adressée au tribunal de commerce sera remise au greffier, qui en donnera récépissé sans en dresser acte de dépôt.*

Dans la quinzaine du dépôt de cette requête, les créanciers seront convoqués.

Le tribunal nomme un ou plusieurs experts, avec la mission de procéder à la vérification de l'état des affaires du débiteur et nomme un de ses juges pour en surveiller les opérations. Le tribunal peut accorder au débiteur un sursis provisoire.

Si le tribunal fait droit à la demande, il nomme un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant la durée de ce sursis ».

Selon l'article 596 C.com., le juge-commissaire procédera à la **convocation individuelle** des **créanciers** par lettres recommandées et remises au bureau des postes huit jours au moins avant celui qui aura été fixé pour la réunion. La convocation sera, en outre, insérée à trois reprises différentes dans les journaux désignés par le juge-commissaire. La convocation reproduira le texte des articles 597 et 599 C.com., tels qu'ils sont complétés ou modifiés par le présent arrêté.

Un exemplaire des journaux dans lesquels la convocation aura été insérée sera déposé au greffe avant la réunion des créanciers.

Le débiteur déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de ces convocations et insertions entre les mains du greffier par les soins duquel elles seront faites.

Art. 597 C.com.

« *Au jour indiqué, le juge-commissaire fera son rapport au tribunal en présence des créanciers ou de leurs fondés de pouvoirs.*

Les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs seront entendus contradictoirement avec le débiteur ; ils déclareront individuellement le montant de leurs créances et s'ils adhèrent ou n'adhèrent pas à la demande.

Tout créancier peut valablement faire par écrit la déclaration de sa créance accompagnée de son vote ; cette déclaration doit parvenir au greffe avant le jour de l'assemblée des créanciers. Il sera dressé du tout un procès-verbal détaillé, auquel seront annexées les pièces qui auraient été produites tant par les créanciers que par les débiteurs. Le tribunal y joindra son avis motivé ».

Art. 598 C.com.

« *L'avis du tribunal, ainsi que toutes les pièces relatives à la demande, seront transmis, dans les trois jours, au procureur général près la Cour supérieure de justice, qui les soumettra, avec ses conclusions, au président ; celui-ci commettra un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statuera dans la huitaine de la réception des pièces* ».

Le tribunal de commerce, saisi d'une demande en sursis de paiement, ne commet aucun excès de pouvoir en prononçant d'office la faillite du débiteur si l'instruction de la demande établit que celui-ci a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé. Ce n'est qu'après avoir accordé un sursis provisoire et émis l'avis requis

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

par les articles 597 et 598 C.com. que le tribunal se trouve provisoirement dessaisi au profit de la Cour jusqu'après la décision de celle-ci[1].

B – Approbation du sursis par les créanciers

Il n'est pas suffisant que le créancier remplisse les conditions de l'article 593 C. com. susmentionné pour pouvoir profiter du **sursis**. Il faut encore que cette mesure soit approuvée par les créanciers. Cet accord doit être donné par la **majorité** des créanciers représentant au moins les **trois quart des créances** sur le débiteur concerné (art. 599 C.com.).

Ces majorités du nombre des créanciers et des créances s'établissent en comptant comme adhérents à la demande pour le montant de leurs créances les personnes des créanciers qui n'ont pas fait une déclaration verbale ou écrite. Ne comptent pas non plus les créances déclarées privilégiées par l'article 605 C.com., ni les personnes auxquelles ces créances sont dues.

Art. 600 C.com.

« *La Cour, en accordant un sursis, en fixe la durée. Elle nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée du sursis. Le sursis peut être prolongé sur la requête du débiteur, le procureur général entendu en ses conclusions écrites. Cette requête sera adressée à la Cour supérieure de justice et devra être signée par un avoué près de cette Cour. La Cour entendra le débiteur et le ou les commissaires. Le rejet de la demande emporte, de plein droit, révocation du sursis provisoire. Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers du débiteur auquel il a été accordé, sauf le cas d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire* ».

■ § 2 – Effets du sursis

A – Suspension des poursuites

L'effet principal du sursis (qui est celui recherché par le commerçant demandant l'application de ce régime) est de **suspendre** toutes **les poursuites** pendant sa durée. Cette conséquence résulte de l'article 604 C.com. ainsi libellé : « *Pendant la durée du sursis, aucune voie d'exécution ne peut être employée contre la personne ou les biens du débiteur. La contrainte par corps ou les saisies pratiquées avant le sursis demeureront en état, mais le tribunal pourra, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et les commissaires surveillants. Le sursis ne suspend pas le cours des actions intentées ni l'exercice d'actions nouvelles contre le débiteur, à moins que ces actions n'aient pour objet la demande de paiement d'une créance non contestée* ».

Indépendamment de la nullité prononcée par l'article 445 C.com., sont nuls et sans effet tous les actes faits par le débiteur, sans l'autorisation des commissaires surveillants, dans les cas où cette autorisation est requise (art. 613, alinéa 2, C.com.).

1 – CA du 6 novembre 1934, *P.*, n° 13, p. 296, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Il est encore précisé par la même disposition qu'il « *ne pourra être pris, pendant la durée du sursis provisoire et définitif, aucune inscription hypothécaire sur les immeubles du débiteur, en vertu de jugements rendus durant les mêmes périodes* ».

L'article 603 C.com. prévoit par ailleurs que, pendant la période du sursis, il y a lieu d'observer strictement le principe d'égalité entre créanciers, ce qui signifie en particulier qu'il ne peut y avoir de paiement des créances existant au moment de la demande « *qu'à tous les créanciers proportionnellement à leurs créances* ».

B – Situation du débiteur

L'autre effet du sursis est que, **sans** comporter **dessaisissement** du débiteur, ce dernier est obligé d'avoir l'accord du tribunal de commerce pour les opérations suivantes :

« *aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme, faire aucun paiement, ni se livrer à aucun acte d'administration* ». En cas d'opposition, il sera statué par le tribunal de commerce.

Il existe certaines **limitations légales** au sursis : en premier lieu (et en application de l'article 605 C.com.), le sursis ne s'applique qu'aux engagements contractés antérieurement à son obtention. Il ne bénéficie pas aux codébiteurs, ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion.

En sont encore écartés (art. 605 C.co) :

« *1° les impôts et autres charges publiques ;*

2° les créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantissements ;

3° les créances dues à titre d'aliments ;

4° les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois qui ont précédé le sursis ».

En principe, le jugement qui aura accordé, refusé ou révoqué un sursis provisoire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel (art. 609 C.com.). Le débiteur pourra toutefois former opposition au jugement portant révocation du sursis provisoire si, par suite d'un empêchement légitime, il n'a pas été entendu.

Art. 611 C.com.

« *Le débiteur sera puni de la même peine que le banqueroutier simple :*

1° si, pour déterminer ou faciliter la délivrance du sursis, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son passif ou exagéré son actif ;

2° s'il a fait ou laissé intervenir aux délibérations relatives à la demande de sursis un ou plusieurs créanciers supposés, ou dont les créances en raison desquelles ils ont pris part aux délibérations, ont été exagérées ».

En cas de faillite du débiteur, dans les six mois qui suivront l'expiration du sursis, l'époque de cessation de paiement remonte, de plein droit, au jour de la demande de sursis (art. 613 C.com.).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE V
LE RÈGLEMENT EUROPÉEN

Le règlement CE nº 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité est entré en vigueur le 31 mai 2002.

Le Règlement (qui est obligatoire et directement applicable dans les différents États membres, sans qu'il ne soit nécessaire de prendre des mesures législatives nationales, comme tel est le cas à l'égard des directives CE) s'applique seulement aux procédures ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur (fixée au 31 mai 2002).

L'entrée en vigueur du Règlement a eu pour conséquence de remplacer dans les relations entre États membres un certain nombre de conventions bilatérales conclues entre différents États. Ces conventions reprises à l'article 44 du Règlement sont essentiellement de nature bilatérale et parfois multilatérale.. Le nouveau règlement (CE) nº 2015/848 du 25 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilités transnationales (refonte) été publié au *Journal officiel de l'Union européenne* et il abroge le règlement (CE) nº 1346/2000. Ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin 2017. Les actes accomplis par le débiteur avant cette date continueront d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis. Le règlement (CE) nº 1346/2000 continuera de s'appliquer aux procédures d'insolvabilité relevant du champ d'application dudit règlement et qui seront ouvertes avant le 26 juin 2017.

SECTION I
JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT

Les auteurs du règlement CE nº 1346/2000 sont partis de la constatation que les entreprises européennes sont de plus en plus actives dans un cadre transfrontalier. Cet état des choses a notamment pour conséquence qu'elles sont de plus en plus affectées par le droit de l'Union européenne.

Il a donc été jugé nécessaire de prendre des mesures coordonnées concernant le patrimoine de débiteurs insolvables, tout en évitant les tentatives des débiteurs « *[…] de déplacer les avoirs ou les procédures judiciaires d'un État à un autre en vue d'améliorer leur situation juridique* (**forum shopping**) »[1].

SECTION II
DISTINCTION ENTRE PROCÉDURES PRINCIPALES ET PROCÉDURES SECONDAIRES

Le règlement CE fait une distinction fondamentale entre **procédure principale** (qui est unique pour une entreprise donnée) et une ou plusieurs **procédures secondaires**.

1 – Point 4 du préambule du Règlement.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Au Luxembourg sont visés les régimes suivants : la faillite, la gestion contrôlée, le concordat préventif de la faillite et le régime spécial de liquidation du notariat pour les procédures d'insolvabilité principale et, pour les procédures d'insolvabilité secondaire, la faillite et le régime spécial de liquidation du notariat.

Aux termes du règlement CE, les juridictions compétentes pour ouvrir les procédures d'insolvabilité principales sont celles de l'État membre sur le territoire duquel est situé le **centre des intérêts principaux**.

Il appartient au juge saisi de décider si le centre des intérêts principaux se situe effectivement sur le territoire national.

Dans une affaire de faillite sur aveu, le tribunal devait se prononcer sur une société domiciliée au Luxembourg auprès d'une fiduciaire, alors que les salariés étaient occupés en France où se trouvaient également les stocks de matériel médical appartenant à la société. Si le centre des intérêts principaux des sociétés est présumé être au siège statutaire, tel n'était pas le cas en l'occurrence : le tribunal se déclare donc incompétent pour connaître de l'aveu de faillite[1].

Le débiteur peut, en outre, être l'objet de procédures secondaires dans l'État dans lequel il maintient un établissement. Les effets de ces procédures se limitent aux actifs situés dans cet État. Cette procédure ne peut être qu'une procédure de liquidation.

Ceci requiert toutefois des règles de coordination indispensables avec les procédures principales qui satisfont l'unité nécessaire au sein de l'Union européenne.

■ § 1 – Compétence judiciaire pour l'ouverture des procédures respectives

La décision ouvrant la procédure d'insolvabilité prise par la juridiction d'un État membre est **reconnue dans tous les États** membres (et ceci, sans aucune autre formalité) dès le moment qu'elle produit ses effets dans l'État membre d'ouverture. Les effets de cette procédure ne peuvent être contestés dans aucun autre État membre (art. 17 du règlement CE). Les juridictions des autres États membres ne sont donc pas compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité principale. Le cas échéant et dans la mesure où les conditions de l'article 3, paragraphe 2 sont remplies, c.-à-d. si un établissement stable est maintenu sur son territoire, il peut y avoir ouverture d'une **procédure secondaire**.

L'ouverture d'une procédure principale permet encore de procéder dans un autre État membre à l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité **sans** avoir à nouveau à **analyser l'insolvabilité** du débiteur dans cet État membre. La loi applicable à cette procédure secondaire est celle de l'État où cette procédure est ouverte (art. 28 du règlement CE). L'ouverture de cette procédure d'insolvabilité secondaire peut être demandée par le syndic de la procédure principale ou encore par toute personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure secondaire est demandée.

Tout créancier peut produire sa créance tant à la procédure principale qu'à toute procédure secondaire.

1 – Cass. com. du 7 avril 2006, *BIJ*, 2006, nº 5, p. 130.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Sur la question de savoir à quel moment les tribunaux doivent se placer pour apprécier la localisation du centre des intérêts principaux, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé qu'il fallait se placer au moment de la demande d'ouverture de la procédure[1].

■ § 2 – Connexion entre procédure principale et procédure secondaire

Lorsque la liquidation des actifs de la procédure secondaire permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné transfère le **surplus d'actif** au syndic de la procédure principale (art. 35).

■ § 3 – Procédure territoriale d'insolvabilité

En application de l'article 3 du règlement CE, une procédure territoriale d'insolvabilité ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure principale dans le cas où « *l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement stable* ».

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a fait une application de cette disposition dans un cas d'une société britannique ayant une succursale au Luxembourg et qui était assignée par des requérants ayant des créances salariales sur cette succursale. Aucune procédure de faillite n'avait été entamée en Grande-Bretagne. Le tribunal jugea qu'en raison de l'existence de la succursale au Luxembourg à laquelle les créances salariales se rattachaient, il y avait lieu de faire droit aux demandes des requérants tendant à la mise en faillite de l'assignée au Luxembourg[2].

Les juridictions luxembourgeoises admettent qu'il puisse y avoir procédure de faillite secondaire au Luxembourg, et ceci, directement sur la base du règlement européen, même en l'absence d'un texte national[3]. Il est à noter que le projet de loi 5157 devrait porter organisation des faillites secondaires.

1 – CJCE du 17 janvier 2006, Aff. C-1/04, ID 11670.

2 – TA (com.) du 2 juillet 2004, n° 88.225, ID 10351.

3 – TA du 3 décembre 2004, jugement n° 365/05 du 15 avril 2005 ; TA n° 549/05 du 27 mai 2005, ces décisions ne figurent pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE II
LES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE FAILLITE

Le législateur a prévu plusieurs « régimes de faillite » (au sens large) à l'égard de certains secteurs particuliers. Ces régimes sont dus aux particularités de ces entités par rapport au droit commun de la faillite. Il s'agit de secteurs qui font l'objet d'une supervision particulière exercée par une **autorité de surveillance** (Commission de surveillance du secteur financier, Commissariat aux assurances, Conseil de l'ordre des notaires). Cet aspect explique que cette autorité de surveillance exerce en général un rôle fort important dans le déroulement de cette procédure.

Sont notamment visés le régime d'assainissement et de liquidation des entreprises d'assurances, celui de l'assainissement et de liquidation d'établissements du secteur financier, la liquidation des OPC et celui d'assainissement et de réorganisation du notariat.

CHAPITRE I
ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCES

La loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances prévoit, dans son article 244, que le **sursis à tout paiement** d'une entreprise d'assurances peut intervenir :

– lorsque le **crédit** est **ébranlé** ou lorsqu'elle se trouve dans une impasse de liquidité qu'il y ait cessation de paiements ou non ;
– lorsque **l'exécution intégrale** des **engagements** de l'entreprise est compromise ;
– lorsque **l'agrément** de l'entreprise a été **retiré** et que cette décision n'est pas encore définitive.

Dans les trois cas prévus ci-dessus, le sursis de paiement peut être converti en une **procédure de liquidation** de l'entreprise, et ceci, par décision du tribunal d'arrondissement sur requête soit du procureur d'État, soit du Commissariat aux assurances, prononçant la dissolution et la liquidation de l'entreprise :

– lorsque le régime de sursis ne permet pas de redresser la situation ; ou
– lorsque la situation de crédit est ébranlée au point que l'entreprise ne peut plus faire face à ses engagements ; ou encore
– lorsque l'agrément de l'entreprise a été retiré et que cette décision est devenue définitive (art. 248, alinéa 1, de la loi du 7 décembre 2015).

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un **juge-commissaire** ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation tout en rendant applicables (et ceci dans la mesure qu'il détermine) les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer la date de cessation de paiements, qui ne peut pas précéder de plus de six mois le dépôt de la requête demandant le sursis de paiement (art. 250, paragraphe 2, de la loi du 7 décembre 2015).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

CHAPITRE II
ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION D'ÉTABLISSEMENT DU SECTEUR FINANCIER

La loi du 5 avril 1993 (telle que modifiée par la suite) relative au secteur financier reprend de façon quasi littérale les dispositions de la loi du 6 décembre 1991 (devenue la loi du 7 décembre 2015) sur le secteur des assurances.

Dans son article 60, la loi du 5 avril 1993 prévoit que le **sursis de paiement** et la **gestion contrôlée** peuvent intervenir :

– lorsque le **crédit** est **ébranlé** ou lorsque l'entreprise se trouve dans une impasse de liquidité, qu'il y ait cessation de paiements ou non ;
– lorsque **l'exécution intégrale** des **engagements** de l'entreprise est compromise ;
– lorsque **l'agrément** de l'entreprise a été **retiré** et que cette décision n'est pas encore définitive.

Dans les trois cas prévus ci-dessus, le sursis de paiement peut être converti en une **procédure de liquidation** de l'entreprise, et ceci, par décision du tribunal d'arrondissement sur requête soit du procureur d'État, soit de la Commission de surveillance du secteur financier, prononçant la dissolution et la liquidation de l'entreprise :

– lorsque le régime de sursis ne permet pas de redresser la situation ; ou
– lorsque la situation de crédit est ébranlée au point que l'entreprise ne peut plus faire face à ses engagements ; ou
– lorsque l'agrément de l'entreprise a été retiré et que cette décision est devenue définitive (art. 61 de la loi du 5 avril 1993).

La crise financière mondiale de 2008 a frappé de plein fouet le Luxembourg en donnant ainsi lieu à une jurisprudence importante au sujet des règles sur le sursis de paiement telles que prévues par la partie IV de la loi du 5 avril 1993. Il en va ainsi des décisions dans *Lehman Brothers (Luxembourg) S.A.*, *Landsbanki Luxembourg S.A.*, *Glitnir Luxembourg S.A.* et *Kaupthing Bank Luxembourg S.A.*

La réglementation nationale prise en cette matière est le fruit de la transposition en droit luxembourgeois par la loi du 19 mars 2001 de la directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement (sursis de paiement, art. 60-1 de la loi du 5 avril 1993) et la liquidation des établissements de crédit (art. 61 de la loi du 5 avril 1993). Les différentes décisions prises dans ces affaires montrent l'originalité de la notion de « *sursis bancaire* » qui ne peut être assimilée au sursis de droit commun réglementé par les articles 593 et suivants du Code de commerce[1]. La plupart des procédures de sursis de paiement ouvertes contre les banques nommées ci-dessus devaient par la suite être trasnsformées en procédure de liquidation. Une description détaillée de ces procédures dépasserait le cadre du présent ouvrage[2]-[3].

1 – V. notamment CA du 28 janvier 2009, ID 12782.

2 – Pour une étude approfondie de cette matière, le lecteur est prié de se reporter à l'article de M. ELVINGER, « Enseignements jurisprudentiels récents en matière de sursis de paiement dans le secteur financier », *BDB*, n° 43, p. 7.

3 – V. jugements TA Lux. du 3 octobre 2008, n° 1162/08, ID 10494 ; TA Lux. du 9 octobre 2008, n° 1183/08, ID 10496 ; TA Lux. du 8 octobre 2008, n°1181/08, ID 10495.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE III
LIQUIDATION DES OPC

La loi du 17 décembre 2010 concernant les OPC prévoit des mesures spéciales applicables à la liquidation des OPC. L'article 105*bis* de ladite loi dispose qu'il peut y avoir prononciation par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale « *[…] sur la demande du procureur d'État, agissant d'office ou à la requête de la CSSF, [de] la dissolution et la liquidation des OPC visés par les articles 2 et 63 de la présente loi, dont l'inscription à la liste prévue à l'article 94, paragraphe (1), aura été définitivement refusée ou retirée.*

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu'il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

[…]

(8) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers l'OPC de l'exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.

(9) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs de l'organisme et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents.

Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.

Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus. Cette publication comprend en outre :

– *l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;*
– *l'indication des mesures prises conformément à l'article 107 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou associés dont la remise n'a pu leur être faite […]* ».
– Le régime institué reste très proche du droit commun. Ceci se démontre notamment par les points suivants :
– les OPC sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation (tout en restant soumis à la surveillance de la CSSF en cas de liquidation non judiciaire) ;
– le tribunal en ordonnant la faillite, nomme le liquidateur et le juge-commissaire […] ;
– toutes les pièces émanant d'un OPC en état de liquidation mentionnent qu'il est en liquidation ;
– etc.

Il est encore à noter qu'en cas de liquidation non judiciaire d'un OPC, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Ils doivent présenter toutes les garanties d'honorabilité et de qualification professionnelles.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Dans l'affaire *LUXALPHA* tranchée par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg[1], une institution de retraite complémentaire CGIS a invoqué, à titre principal, la responsabilité contractuelle sur la base de l'article 36 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la loi de 2002) d'UBS (Luxembourg) et, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle d'UBS (Luxembourg). L'institution de retraite complémentaire CGIS invoque la responsabilité de la société UBS AG, en sa qualité de promoteur, qu'elle estime être assimilé à un dirigeant, sur la base de l'article 59, alinéa 2, de la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915 et sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

L'institution de retraite complémentaire CGIS invoque la responsabilité délictuelle des sociétés de gestion, UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY et ACCESS MANAGEMENT LUXEMBOURG, et du réviseur d'entreprises ERNST & YOUNG.

« *Action dirigée contre la société anonyme UBS, dépositaire du fonds, sur base de l'article 36 de la loi de 2002*

La CGIS, institution de retraite complémentaire, argumente de l'article 36 de la loi de 2002 en faisant valoir que ce texte lui accorde une action directe contre la banque dépositaire.

En principe, ***l'action directe*** *permet au créancier d'exercer son droit de gage sur le patrimoine du débiteur, en agissant contre le débiteur de celui-ci, le sous-débiteur. À la différence de l'action oblique, elle donne au créancier un droit propre contre le sous-débiteur : celui-ci devient débiteur direct du créancier, sans l'intermédiaire du patrimoine du débiteur (cf. Malaurie et Aynès, Obligations, T. 3, n° 88). Elle permet à un créancier de poursuivre directement, en son nom et pour son propre compte, le débiteur de son débiteur (cf. Terré, Simler et Lequette, Les obligations, n° 1090).*

Selon la thèse classique, l'action directe constitue un mécanisme sui generis*, qui n'est pas rattaché à un mécanisme connu du droit des obligations, et ne peut donc être légitimée que par la volonté expresse du législateur.*

L'article 36 de la loi de 2002 dit que : "Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard des actionnaires de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations" ».

« *Avant de dire si une telle interprétation est de mise, il y a lieu de se pencher sur le mécanisme juridique de* ***l'action directe****.*

L'analyse du régime des actions directes retient que l'action directe, dans son exercice, est doublement limitée : d'une part, son titulaire ne peut l'exercer que si et dans la mesure où il est créancier du débiteur principal ; d'autre part, le sous-débiteur n'est obligé envers le créancier que si et dans la mesure où il est débiteur du débiteur principal (cf. Malaurie et Aynès, Obligations, T. 3, n° 90).

Dans ses conclusions, la partie demanderesse décrit elle-même l'action directe comme "l'action directe est de façon générale, celle qui permet à un créancier de poursuivre directement, en son nom et pour son compte, un tiers, qui est (en principe) débiteur de son débiteur".

1 – Jugement TA du 4 mars 2010, n° 315/10, nos 122656, 125 275 et 125 650 du rôle, ID 23349.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Or, une condition primordiale fait défaut dans le chef de l'actionnaire-investisseur : il n'est pas créancier de LUXALPHA SICAV pour les sommes dont condamnation est requise.

En effet, même si on distingue entre les actions introduites avant la liquidation de la société et celles introduites postérieurement, il y a lieu de dire que l'actionnaire d'une société non dissoute a uniquement un droit financier au dividende, il n'est sûrement pas créancier de sa part d'actif, et, en cas de liquidation de la société, si les associés d'une société dissoute, qui se survit pour les besoins de sa liquidation, ont un droit ouvert au partage du reliquat de l'actif après paiement du passif, ils ne sont pas pour autant des créanciers (Cour de Cass. fr., chambre civile 1 du 2 oct. 2002, n° de pourvoi : 99-10947).

En considération de ce développement, il y a lieu de conclure que l'actionnaire ne dispose pas d'une action directe contre la banque dépositaire ».

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE IV
ASSAINISSEMENT ET RÉORGANISATION DU NOTARIAT

L'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 concernant l'assainissement et la réorganisation du notariat a introduit un régime spécial applicable aux notaires et destiné soit à la réorganisation de ses affaires, soit à la bonne réalisation de son actif.

D'après ce régime, le notaire dont le **crédit est ébranlé** ou lorsque **l'exécution** intégrale de ses **engagements est compromise**, peut être soumis à ce régime spécial (art. 1). L'article 2 du même arrêté grand-ducal précise que « *la faillite d'un notaire ne peut être prononcée qu'à la requête du Conseil de gérance, créé par le présent arrêté. Le notaire ne pourra demander ni un sursis de paiement ni un concordat préventif de la faillite ni une gestion contrôlée tant que le régime spécial prévu par le présent arrêté ne lui aura été refusé* ».

Ce régime est tout à fait surprenant dans la mesure où il revient à appliquer aux notaires, une des professions libérales des plus classiques, le régime de la faillite. En fait, il s'agit d'une curiosité historique, dépourvue de la moindre importance pratique actuelle. Ce régime remonte à un temps où les notaires avaient pour habitude d'accorder des crédits, surtout dans les régions rurales du pays. Ces temps sont révolus : de nos jours, les banques ont le monopole du crédit, de sorte qu'il n'est plus guère envisageable que le « *crédit des notaires puisse être ébranlé* ».

Par conséquent, l'importance pratique de ce régime est nulle.

Les développements y consacrés seront donc limités au strict minimum. L'arrêté prévoit deux régimes spéciaux :

– le régime spécial d'assainissement ;

– le régime spécial de liquidation.

Peut être soumis à ce régime il est requis que le passif excède même sensiblement l'actif, de façon que l'exécution intégrale des engagements du notaire semble compromise, pour autant que l'exploitation soit en situation favorable, de sorte que l'assainissement de l'étude puisse être escompté.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

TITRE III
DES BANQUEROUTES

Lorsque les fautes à l'origine de la faillite sont d'une certaine gravité, le débiteur s'expose aux sanctions de la banqueroute : les effets de cet état sont essentiellement d'ordre pénal. Selon le cas et en fonction de la gravité des infractions, il s'agit de la banqueroute simple (constitutive d'un **délit**) ou de la banqueroute frauduleuse (qui est un **crime**). La réhabilitation est exclue dans ce deuxième cas.

Les peines de la banqueroute ne peuvent être prononcées que contre un commerçant failli. Il n'y a donc aucune difficulté particulière pour les sociétés où les associés sont personnellement responsables des dettes sociales : ces associés ont en effet toujours la qualité de commerçant.

En revanche, les administrateurs et les gérants de sociétés anonymes, S.à r.l. et S.e.c.a. n'ont pas la qualité de commerçant : les peines de la banqueroute ne devraient donc pas leur être appliquées. Mais telle n'est pas la position de la jurisprudence belge[1]. Selon celle-ci, les peines de la banqueroute peuvent être prononcées à l'encontre des organes d'une société, pourvu que celle-ci soit commerçante et réunisse les conditions de la faillite. Cette solution ne découle pas de la théorie de l'organe : celle-ci conduirait normalement à condamner la société pour banqueroute. Tel n'est pas le cas en application de la règle : *societas delinquere non potest*[2]. « *Tant que l'on s'en tient au principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales, il faut donc constater que la condamnation des organes pour faits de banqueroute est une solution prétorienne : la Cour juge opportun, dans ce cas précis, de percer le voile de la personnalité morale pour saisir les personnes qui agissent dans l'ombre de l'être moral* »[3].

Le principe de la **personnalité des peines**, principe consacré par notre droit pénal, veut que seule la personne physique agissant avec conscience et librement peut être l'auteur pénalement responsable d'une infraction d'une certaine gravité[4]. « *Ce sont les représentants légaux d'une personne morale ou d'une façon générale ceux qui prennent une part active à sa gestion, donc les personnes physiques par l'intermédiaire desquelles elle agit, qui sont les auteurs des infractions qui en sont pénalement responsables* »[5].

1 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de s*ociétés, p. 243.

2 – Cet adage est pourtant aujourd'hui dépassé en droit luxembourgeois. V. sous Responsabilité pénale des sociétés.

3 – M. Coipel, *Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, p. 243.

4 – V. A. De Nauw, « La délinquance des personnes morales et l'attribution de l'infraction à une personne physique par le juge », *R.C.J.B.*,
1992, p. 552.

5 – TA (corr.) du 18 mars 2004, nº 1005/2004, ID 11992.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Art. 438 C.com.

« La faillite est qualifiée banqueroute simple et punie correctionnellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par le chapitre Ier du titre II ci-après.

Elle est qualifiée banqueroute frauduleuse et punie criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de fraude prévus par le chapitre II du même titre ».

CHAPITRE I
LA BANQUEROUTE SIMPLE

La loi distingue ceux qui obligatoirement (art. 573 C.com.) sont sanctionnés de ceux qui le sont facultativement (art. 574 C.com.) de banqueroute simple.

En application de l'article 573 C.com., **sera déclaré banqueroutier** simple, « *tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants :*

1° si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ;

2° s'il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ;

3° si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours ; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;

4° s'il a supposé des dépenses ou des pertes ou s'il ne justifie pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement ;

5° si, après la cessation de ses paiements, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse ».

D'après l'article 574 C.com., **pourra** être **déclaré banqueroutier** simple, « *tout commerçant qui se trouvera dans l'un des cas suivants :*

1° s'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;

2° s'il est de nouveau déclaré en faillite, sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ;

3° si, ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, il ne s'est pas conformé à l'article 69 ;

4° s'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l'article 440 ; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; si, en le faisant, il n'a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l'article 441, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts ;

5° s'il s'est absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs ;

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

6° s'il n'a pas tenu les livres prescrits par l'article 9 ; s'il n'a pas fait l'inventaire exigé par l'article 15 ; si ses livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude ».

Si l'article 574 C.com. laisse au juge la faculté de ne pas prononcer les peines prévues, il n'en va pas de même pour l'article suivant qui oblige le juge à prononcer la condamnation pour autant que les faits punissables soient établis.

Art. 575 C.com.

« *Seront condamnés aux peines de la banqueroute simple, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application de l'article 578 :*

1° ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ;

2° ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérées ;

3° le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli ;

4° le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.

5° Les coupables seront, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers, et qui ne pourra être moindre de 3 euros ».

Art. 576 C.com.

« *Pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements inexacts.*

Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du curateur ».

La Cour de cassation belge retient constamment que la banqueroute peut être retenue à la charge des **organes des sociétés commerciales** (même s'ils n'ont pas personnellement la qualité de commerçants) qui ont cessé leurs paiements à partir du moment où les conditions de la faillite ont été réunies dans le chef de la société. En même temps, la Cour de cassation souligne qu'il ne suffit pas d'être gérant de la société, mais « *pour être condamné comme banqueroutier cette condamnation doit être fondée sans ambiguïté sur des faits constitutifs de la banqueroute dont il est constaté qu'ils ont été commis par le gérant en sa qualité d'organe de la société faillie et relativement à la gestion de celle-ci* »[1].

Néanmoins, l'assimilation des organes à la société elle-même n'est pas complète, au moins selon certaines décisions. Ainsi, le Tribunal de commerce d'Anvers[2]

1 – V. Cass. b. du 28 février 1972, *Pas.*, I, p. 1587.

2 – Trib. com. Anvers du 7 octobre 1977, *R.P.S.*, 1978, p. 231.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

n'a pas voulu appliquer l'article 467 C.com. qui autorise l'emprisonnement du failli qui ne se rend pas aux convocations du curateur ou qui fournit des renseignements sciemment inexacts. Le motif de cette décision était que cette mesure n'étant applicable qu'au failli et qu'un organe de la société n'ayant pas cette qualité, une requête du curateur tendant à ordonner l'emprisonnement d'un gérant devait être refusée[1].

1 – J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981, p. 260 ; ces auteurs sont à juste titre critiques à l'égard de cette décision.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE II
LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE

Si la plupart des dispositions pénales connues en matière de droit des sociétés sont relativement récentes, celles concernant la banqueroute sont anciennes.

Les infractions sanctionnées sont visées par les articles 577 et 578 C.com.

Art. 577 C.com.

« *Sera* **déclaré banqueroutier frauduleux**, *tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants :*

1° s'il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 C.com., ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu ;

2° s'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

3° si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas ».

Sont également passibles des mêmes peines les complices de banqueroutier frauduleux, ceux qui, auront soit provoqué aux faits constitutifs de la banqueroute, soit donné des instructions pour les commettre, soit avec connaissance aidé le banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé ou facilité sa banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée[1].

En cas de procédure pour banqueroute, les juridictions saisies se prononceront sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits. En effet, les biens en question devront servir à indemniser les créanciers de la faillite (art. 579 C.com.).

En outre, les conventions seront déclarées nulles à l'égard de toutes personnes et même à l'égard du failli. Par conséquent, le créancier est tenu de rapporter les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées.

1 – L'article 578 C.com., ID 10468, contient une référence aux « moyens indiqués en l'article 60 du Code pénal ». Cette référence est manifestement erronée, car l'article visé parle du cumul de peines.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CHAPITRE III
DE LA RÉHABILITATION

La loi prévoit un régime de « réhabilitation » à l'égard des personnes faillies qui ont intégralement payé les dettes propres ou ceux de la société tombée en faillite.

Art. 586 C.com.

« *Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation. Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé solidaire d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.*
Le failli pourra être réhabilité après sa mort ».

La réhabilitation suppose que le failli ait acquitté intégralement toutes ses dettes, « *en principal, intérêts et frais* »[1]. Par conséquent, les cas de réhabilitation sont très rares en pratique. Par ailleurs, l'acquittement doit être un vrai acquittement. Il ne suffirait pas que le failli soit libéré des dettes par l'effet de la prescription[2]. Devront notamment être acquittés les intérêts courus pendant la période de la liquidation de la faillite dont le cours est suspendu à l'égard de la masse : « *[…] le failli reste tenu de ses intérêts. S'il veut obtenir sa réhabilitation, il devra les acquitter en entier* »[3].

SECTION I
PROCÉDURE DE RÉHABILITATION

La demande émanant de la personne condamnée doit (en application de l'article 587 C.com.) être adressée à la Cour supérieure de justice sous forme de **requête**. Elle sera accompagnée des quittances et autres pièces justificatives. Le procureur général près la Cour supérieure de justice, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées au procureur d'État et au président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale du domicile du demandeur, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur d'État et au président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée sur la vérité des faits qui auront été exposés.

À cet effet, à la diligence du procureur d'État, copie de ladite requête restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience du tribunal civil et du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale qu'à la maison commune, et sera insérée par extraits dans les papiers publics.

1 – CA du 1er décembre 1999, n° 22.513, ID 11821.

2 – I. Verougstraete, *Manuel de la faillite et du concordat*, Kluwer, 1998, p. 603.

3 – CA du 9 mars 1994, n° 15.951, cette décision ne figure pas dans la base de données du Parquet général (CREDOC).

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

SECTION II
RECOURS CONTRE DÉCISION

L'article 588 C.com. permet à tout **créancier** qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance, y compris en intérêts et frais, de former **opposition** à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne sera pas partie dans la procédure relative à la réhabilitation.

LEXNOW

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

BIBLIOGRAPHIE

Beck'sches Steuerberaterhandbuch 2004/2005, Munich et Frankfurt, Beck C. H., 2004

Afschrift, Th., « Simulation et réalité juridique à propos des sociétés étrangères constituées dans le but d'éviter l'impôt belge », *Le droit fiscal international belge et l'évitement de l'impôt*, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 1996.

Allard, A., Rapport de la Commission de Longé.

Antoine, M.-F., *Tout savoir sur la faillite*, Bruxelles, Story-Scientia, 1987.

Benoit-Moury, A., « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », *R.P.S.*, 1986, p. 2.

Benoit-Moury, A., « Des justes motifs de dissolution des sociétés commerciales de l'article 1871 du Code civil à l'article 102 des L.C.S.C. »*, Liber amicorum Jan Ronse*, Bruxelles, Story-Scientia, 1986.

Benoit-Moury, A., note sous Cass., 12 novembre 1987, *R.C.J.B.*, 1989, pp. 385 ss.

Berna, P., *Statut des administrateurs de sociétés anonymes*, Bulletin du Cercle François Laurent, 1987, II, p. 36.

Bertolotti, A., note sous CA Luxembourg, 29 avril 2004, *Droit des sociétés*, 2005, n° 74, p. 153.

Bosly, H.-D, « Le droit pénal des sociétés. Examen de doctrine et de jurisprudence », *R.P.S.*, 1974.

Bougnoux, A., « Théorie des apports. Notion d'apport en société », *JCl. Sociétés Traité*, Paris, LexisNexis, 2011, fasc. 10-10, n° 103.

Bouloc, B., V° Dissolution, *Encyclopédie juridique Dalloz. Répertoire de droit des sociétés*, Paris, Dalloz, [s.d.], pp. 191 ss.

Bours, J.P. et Hermant, P., « Les principes généraux du droit des sociétés », *Traité pratique de droit commercial*, T. IV, *Les sociétés*, Diegem, Kluwer, 2014.

Brunet, E., Servais, J. et Resteau, Ch., *Répertoire pratique de droit belge*, Bruxelles et Paris, Bruylant et Librairie Générale de Droit, 1943.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

CAMPION, L., *La théorie de l'abus des droits*, Bruxelles, Bruylant, 1925.

CARBONNIER, J., *Droit civil*, Paris, PUF, 2000.

CHAPUT, Y., note sous Cass. fr du 18 juillet 1988, *Rev. soc.*, 1990, pp. 598 ss.

COIPEL, M., *Répertoire notarial*, T. XII, *Le droit commercial et économique*, Livre 2/1, *Dispositions communes à toutes les sociétés. Dispositions de droit civil et commercial applicables aux actes de sociétés*, Bruxelles, Larcier, 1982.

COIPEL, M. *et al.,* « La société dans tous ses états », *Le droit des sociétés. Aspects pratiques et conseils des notaires*, B. Cartuyvels (dir.), Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 51 à 116.

CONAC, P.-H., *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois*, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 69.

COPPENS, P., « Le cas des sociétés anonymes paralysées par deux groupes hostiles et le "juste motif" de dissolution de l'article 1871 du Code civil », *R.P.S.*, 1954, pp. 213 ss.

CORBIAU, J., *Des sociétés commerciales. Avant-projet de loi élaboré pour le Grand-Duché de Luxembourg*, Luxembourg, Imprimerie et librairie de la Cour Victor Bück, 1905.

CORBISIER, I., *Droit des sociétés. Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français*, Études du Laboratoire de droit économique, Bruxelles, Bruylant, 2000.

CORBISIER, I., « Quelques réflexions en filigrane des développements récents qu'a connus le droit de responsabilité des administrateurs d'une personne morale », *R.P.S.*, 1994, p. 57.

CORBISIER, I. et PRÜM, A., « De nouveaux espaces de liberté dans le droit des sociétés luxembourgeois », *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, A. Prüm (dir.), Bruxelles, Larcier, 2017.

CORBISIER, I. et BURBI, D., *Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009. Regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé*, coll. Les Dossiers du Journal des tribunaux Luxembourg, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 36 ss.

COZIAN, M., *Les grands principes de la fiscalité des entreprises*, Recommandation n° 7 de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, p. 97.

COZIAN, M., VIANDIER, A. et DEBOISSY Fl., *Droit des sociétés*, 16e éd., Manuels JurisClasseur, Litec-LexisNexis, 2003.

CROES, C., « Obligations convertibles et warrants : description du cadre juridique belge », *R.P.S.*, 1995.

CUTAJAR-RIVIÈRE, C., *La société écran. Essai sur sa notion et son régime juridique*, Paris, LGDJ, 1998.

DABIN, J., note sous Cass. du 16 décembre 1848, *R.C.J.B.*, 1949, p. 102.

DAGOT, M., *La simulation en droit privé*, T. LXXIII, Paris, LGDJ, 1967.

DAIGRE, J.-J., « Peut-on absorber une société ayant un actif net négatif ? », *J.C.P.* E, 1993, II, n° 165, pp. 363 ss., spéc. n° 1.

DAL, G.-A. et VAN DEN ABEELE, M., « Les fusions et scissions de sociétés commerciales », *R.P.S.*, 1993, p. 195.

DEBARD, Th. et GUINCHARD, S., *Lexique des termes juridiques*, Paris, Dalloz.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Deboissy,Fl., *La simulation en droit fiscal*, Paris, LGDJ, 1997.

de Juglart, M. et Ippolito, B., *Cours de droit commercial*, Vol. 1, 4e éd., Paris, Montchrestien, 1971, p. 111.

Delamare, E. et Le Poitvin, M., *Traité théorique et pratique de droit commercial*, Paris, Charles Hingray, 1861.

Della Faille, P., *Fusions, acquisitions et évaluations d'entreprises*, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2001.

Delplanque, C., *Le Code de commerce 1807-2007 : Les actes du colloque*, Association du Bicentenaire du Code de commerce, Dalloz, 2008.

Delvaux, J., *La société anonyme*, 2005 (polycopié distribué dans le cadre des cours complémentaires en droit luxembourgeois obligatoires en vue de l'admission au barreau du Luxembourg), 24 janvier 2005.

Delvaux, J., Wildgen, A. et Breininger, R., « La réunion de tous les titres d'une société anonyme en une seule main », *Ann. dr. lux.*, 1993, Vol. 2, p. 103.

Demeur, P., « La part bénéficiaire confère-t-elle la qualité d'associé ? », *R.P.S.*, 1957, p. 57.

De Nauw, A., « La délinquance des personnes morales et l'attribution de l'infraction à une personne physique par le juge », *R.C.J.B.*, 1992, p. 552.

De Page, H., *Traité élémentaire de droit civil belge*, Bruxelles, Bruylant, 2000.

Diab, N. A. et Boustany, I.H.G., *La titrisation des actifs*, Bruxelles, Jdeidet-el-Metn et Paris, Bruylant, Delta et LGDJ, 2003.

Diener, P., « Les sociétés en nom collectif dont tous les associés sont des EURL », *J.C.P.* E, 1992, I, p. 153.

di Stefano, M. et Cousquer, C., « La responsabilité solidaire des membres du conseil d'administration tenus de la libération effective d'un quart du capital souscrit », *Tax Today*, Kluwer, octobre 2005.

Domat, J., *Lois civiles*, Livre I.

Dostert, H., « L'impôt sur le revenu III », *Études fiscales*, 1er avril 1976, n° 50/51, p. 267.

Dufis, P., Lopater, Cl. et Guyomard, E., *Mémento pratique Francis Lefebvre Comptable 2002*, coll. Mémento pratique Francis Lefebvre, Paris, Fr. Lefebvre, 2002.

du Jardin, L., « Le crédit et les garanties entre sociétés groupées », *J.T.*, 2000, p. 609.

Dupong, J., « Le changement de nationalité d'une société luxembourgeoise », *Diagonales à travers le droit luxembourgeois*, Livre jubilaire de la Conférence Saint-Yves 1946-1986, Luxembourg, Saint-Paul, 1986.

Elvinger, M., « Enseignements jurisprudentiels récents en matière de sursis de paiement dans le secteur financier », *BDB*, n° 43, p. 7.

Erkelens, C. et Colle, Ph., « Quelques réflexions à propos de la faillite d'une société en liquidation », *R.P.S.*, 1992, p. 91.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

ESCARRA, E., *Cours de droit commercial*, éd. 1952.

ESCARRA, E. et RAULT, J., *Traité théorique et pratique de droit commercial*, T. III, Paris, Sirey, 1955.

FAYOT, Fr., « Chronique. Droit des sociétés (1997-2002) », *Ann. dr. lux.*, Vol. 11, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 543 à 592.

FERRAN, E., « Simplification of European company law on financial assistance », *European Business Organization Law Review*, n° 1, mars 2005, pp. 93 à 99, spéc. p. 95.

FERRIER, D., « La liberté du commerce et de l'industrie », *Libertés et droits fondamentaux*, R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche et Th. Revet (dir.), Paris, Dalloz, 2005, pp. 649 à 662.

FLAMÉE, M., « Le régime des acomptes sur dividendes », *R.P.S.*, 1987.

FOLLIET, E., *Le bilan dans les sociétés anonymes*, Paris, Payot, 1937.

FORIERS, P.-A., « Décharge, réception, quittance », *La fin du contrat*, G. Carle (dir.), Bruxelles, Association belge des juristes d'entreprise, 1993.

FRANCÈS, M., *Essai sur les notions d'urgence et de provisoire dans la procédure du référé*, Thèse, Université de Toulouse, Paris, recueil Sirey, 1935.

FRANCK, P.-A., « De la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes », *R.P.S.*, 1956.

FRÉDÉRICQ, L., *Précis de droit commercial*, Bruxelles, Bruylant, 1970.

FRÉDÉRICQ, L., *Traité de droit commercial belge*, Gand, Rombaud-Fecheyr, 1946-1955.

FREY, G., *Die Behandlung steuerlicher Sachverhalte nach der 4. EG-Richtlinie*, Betriebs-Berater, 1978.

GILLEN-SNYERS, M.-P., « Les banques luxembourgeoises et le *corporate governance* », *Droit bancaire et financier au Luxembourg,* Vol. 3, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2004, p. 1115.

GUIHO, P., *Dictionnaire juridique*, Lyon, L'Hermès, 2000.

GUILLERY, J., *Commentaire législatif de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales en Belgique*, T. II, n° 60, Bruxelles, Bruylant, 1886.

HEENEN, J., « Le choix des actionnaires », *R.P.S.*, 1956.

HEINTZ, G., « L'impôt sur le revenu des collectivités », *Études fiscales*, 1999.

HELLINCKX, H., « Les difficultés de qualification de la libération du capital par incorporation de créances réciproques en droit des sociétés luxembourgeois », *BDB*, n° 9, 1986, pp. 25 ss.

HÉMARD, J., *Théorie et pratique des nullités de sociétés et des sociétés de fait*, 2e éd., Paris, Sirey, 1926.

HORSMANS, G., « Le juge des référés et le droit des sociétés », *R.P.S.*, 1969.

HOSCHEIT, TH., « La représentation en justice des personnes morales de droit privé, à propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 1996 *Parfumerie Douglas Nederland N.V.*c/ *Parfumerie Douglas S.à r.l.* », *P.*, n° 31, pp. 51 à 76, spéc. p. 53.

HOSS, P. et SCHUMMER, L., *Les obligations convertibles. Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2016.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

HOUPIN, C. et BOSVIEUX, H., *Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales et des associations*, Paris, Administration du Journal des notaires et des avocats, 1935.

JACOBY, St., « Dispositions transitoires et entrée en vigueur de la loi », *La réforme du droit des sociétés luxembourgeois*, A. Prüm (dir.), Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 291 ss.

JOSSERAND, L*., Cours de droit positif français I*, Paris, Recueil Sirey, 1939.

KIRKPATRICK, J. et GLANSDORFF, B., « Les statuts d'une société de personnes peuvent-ils conférer à la majorité des associés le pouvoir de dissoudre la société avant le terme convenu ou d'exclure un associé ? », *R.C.J.B.*, 1967, p. 208.

KNOBBE-KEUK, Br., *Bilanz-und Unternehmenssteuerrecht*, 9e éd., Köln, Otto Schmidt, 1993.

KOLBACH, D. et SCHMIT, J.-M, « Les grands chantiers du droit des sociétés luxembourgeois », *ACE*, janvier 2006, p. 3.

KUNSCH, L., « La réalisation des réserves occultes par le partage successoral », *Études fiscales*, 1965, no 13, p. 10.

KUNSCH, L., « La réforme de l'impôt sur le revenu des collectivités », *Études fiscales*, 1969, nos 29 et 30, p. 10.

LAURENT, Fr., *Principes de droit civil*, Bruxelles et Paris, Bruylant et Pedone, 1869-1878.

LE CANNU, P., *Droit des sociétés*, 2e éd., Paris, Montchrestien, 2003.

LECHNER, H., *Des droits propres des actionnaires*, thèse Université de Nancy, Nancy, Rigot, 1932, p. 24.

LEHRER, J., « La dissolution des sociétés pour justes motifs », *R.P.S.*, 1962.

LEHRER, J., « La notion de gestion journalière. Recherche d'une méthode », *R.P.S.*, 1957.

LEVY, L., *La nationalité des sociétés*, Paris, LGDJ, 1984.

LITTMANN, E., *Das Einkommensteuerrecht*, 13e éd., Stuttgart, Schäffer, par. 6, p. 433

LOUIS, J.-V., « Le franc belge n'est plus requis dans les actes publics et administratifs », *J.T.,* 1991, p. 669.

LYON-CAEN, C. et RENAULT, L., *Droit commercial*, Paris, LGDJ, 1918.

MAEYENS, L. et ROOSE, P., « Syndicats d'actionnaires de société anonyme », *R.P.S.*, 1964, p. 63.

MALHERBE, J., LAMBRECHT, Ph. et MALHERBE, Ph., *Droit des sociétés*. *Précis*, Bruxelles, Bruylant, 2004.

MARTENS, H. J., *Réserves et provisions apparentes et non apparentes*.

MEDUS, J.-L., « De quelques problématiques contemporaines de droit comptable (1re partie) », *Les Petites Affiches*, 4 février 1999, no 25, p. 18.

MENJUCQ, M., « La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux », *Fusions transfrontalières de sociétés. Droit luxembourgeois et droit comparé*, P.-H. Conac (dir.), Bruxelles, Larcier, 2011, p. (3) du préambule de la directive 2005/56/CE.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

MERSCH, M., « Note sur la liquidation des sociétés commerciales », *R.D.C.B.*, 1985.

METZLER, L., « La personnalité morale et ses limites dans la législation luxembourgeoise », *P.*, n° 15, p. 16.

METZLER, L., « Le régime légal des sociétés et des associations en droit luxembourgeois », *R.P.S.*, p. 244.

METZLER, L., *Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée*, Paris, Bruxelles, Luxembourg, Sirey, Bruylant et Bruck, 1933.

P. NAMUR, *Le Code de commerce belge*, 2e éd., T. II, Bruxelles, Bruylant, 1884, n° 1.088.

NIBOYET, J.-P, « Existe-t-il vraiment une nationalité des sociétés ? », *Rev. DIP*, 1927, p. 402.

NUDELHOLE, S. J., Note sous arrêt Cass. du 22 janvier 1981, *R.C.J.B.*, 1981.

NYSSENS, A, Avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, rédigé à la demande du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, 1884.

OBERT, R., *Pratique des normes IAS/IFRS*, 6e éd., Paris, Dunod, 2003.

OOSTVOGELS, S. et BOONE, D., « De l'intérêt social à l'intérêt de groupe en droit des sociétés : perspectives luxembourgeoises », *ALJB Droit bancaire et financier*, Vol. 3, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 1994, p. 1037.

PARLÉANI, G., « Les pactes d'actionnaires », *Rev. soc.*, 1991, no 1.

PARTSCH, P.-E., « Dans quelle mesure le conseil d'administration d'une société anonyme peut-il adopter des décisions sans réunion physique de ses membres ? », *R.P.S.*, 1995, p. 198.

PASSELECQ, F. et CAMBIER, J.-F., « Traité des sociétés commerciales », *Les novelles, corpus juris Belgici. Droit commercial 3*, Bruxelles, Larcier, 1934.

PASQUALINI, Fr.., *Le principe de l'image fidèle en droit comptable*, Paris, Litec, 1992, p. 52 ss.

PESCATORE, P., *Introduction à la science du droit*, Université du Luxembourg.

PICARD, Ed. et D'HOFFSCHMIDT, N., *Pandectes belges. Encyclopédie de législation, de doctrine, de jurisprudence belges*, Bruxelles, Larcier, 1878 à 1933.

PIRMEZ, E., in J. Guillery, *Commentaire législatif des lois du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886*, I, Bruxelles, Bruylant, 1886.

PIRMEZ, E., in J. Guillery, *Commentaire législatif de la loi du 18 mai 1873*, Bruxelles, Bruylant, 1878, II.

PIRMEZ, E., « Notes posthumes », *R. P.S.*, 1891.

PIRMEZ, E., *Observations présentées sur l'avant-projet de loi sur les sociétés commerciales* [rédigé par A. Nyssens], Luxembourg, 1885.

PLANIOL, M. et RIPERT, G., *Traité élémentaire de droit civil*, Paris, LGDJ, 1949.

P. PONT, *Commentaire-traité des sociétés civiles et commerciales*, T. 1, Paris, Delamotte Fils et Cie, 1880, p. 466.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

PORTALIS, J.-E.-M., *Exposé des motifs sur le Code civil de 1804*.

POTHIER, R. J., *Œuvres de Pothier*, par BUGNET J.J., T. IV, Paris, Videcoq Père et fils, 1847.

PRIOUX, R., « L'article 197 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, disposition méconnue de droit international privé belge », *R.G.D.C.*, 1989, p. 483.

RECKINGER, P. et SCHLEIMER, P., « Le régime de la S.à r.l. sous l'influence de la S.A. », *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, A. Prüm (dir.), Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 423 ss.

RENAULD, J., « La reconnaissance mutuelle des sociétés dans le Marché commun », *R.P.S.*, 1968, pp. 207 ss

RESTEAU, Ch., *Commentaire législatif de la loi du 25 mai 1913 portant modification aux lois sur les sociétés commerciales*, Bruxelles, 1913.

RESTEAU, Ch., *Traités des sociétés anonymes*, 2e éd., Bruxelles, Librairie judiciaire, 1933.

RALET, O., « L'administrateur personne morale et le mandataire substitué », *R.P.S.*, 1994.

RALET, O., *Responsabilité des dirigeants de sociétés*, Bruxelles, Larcier, 1996.

RIGAUX, Fr. et FALLON, M., *Droit international privé*, T.II, *Droit positif belge*, Bruxelles, Larcier, 1993.

RIPERT, G., *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, Paris, LGDJ, 1946.

RIPERT, G., *Traité élémentaire de droit commercial*, Paris, LGDJ, 1954.

SAVATIER, J., « Contribution à une étude juridique de la profession », *Dix ans de conférences d'agrégation. Études de droit commercial offertes à Joseph Hamel*, Paris, Dalloz, 1961, p. 8.

SCHAEFFER, E., « Des causes d'ordre public de dissolution de sociétés », *Dix ans de conférences d'agrégation. Études de droit commercial offertes à Joseph Hamel*, Paris, Dalloz, 1961, p. 230.

SCHLEIMER, P., « Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite simple », *Les commandites en droit luxembourgeois*, Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2013.

SCHMIDT, D., « Les opérations de portage de titres de sociétés », *Les opérations fiduciaires*, Colloque de Luxembourg des 20 et 21 septembre 1984, Paris, LGDJ, 1985.

SCHUMMER, L. et WEYDERT, S., « Le nouveau régime des titres », *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, A. Prüm (dir.), Bruxelles, Larcier, 2017, p. 180.

SCHWACHTGEN, A., « Le contrôle des apports en capital au Luxembourg », *Vennootschapsrecht in EG-perspectief*, Berlin, Springer, 2001, p. 201.

SCHWACHTGEN, A., « L'interprétation de l'article 100 sur les sociétés », *Tax today*. *Mélanges de droit des sociétés*, 18-19 avril 2007.

SCHWACHTGEN, A., « La transformation d'une S.à r.l. en S.A. », *Tax today. Mélanges de droit des sociétés*, 18-19 avril 2007.

SIMONART, V., « La contractualisation des sociétés ou les aménagements contractuels des mécanismes sociétaires », *R.P.S.*, 1995, p. 102.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Simont L., « Conflits d'intérêt : les implications des nouveaux articles 60 et 60*bis* », *R.P.S.*, 1996.

Simont, L., « La loi du 6 mars 1973 », *R.P.S.*, 1974, p. 72.

Simont, L., « Réflexion sur l'abus de minorité », *Liber amicorum Jan Ronse*, Bruxelles, Story-Scientia, 1986, p. 307.

Simont L., Foriers P.-A. et De Bandt, J.-P., « La distribution de réserves disponibles en cours d'exercice », *Liber amicorum J.-P. De Bandt*, Bruxelles, 2004, p. 602.

Soumrani, P., *Le portage d'actions*, Paris, LGDJ, 1996.

Spang, J.-P., « Les changements apportés au droit des sociétés et des associations par les lois introduisant en droit luxembourgeois les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et créant des fonds de pension (SEPCAV et ASSEP) », *BDB*, n° 29.

Spang, J.-P., « La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois : regard du praticien », *La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois et comparé*, P.-H. Conac (dir.), Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 81 à 97.

Spang, J.-P., « Les organes de gestion », *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 146.

Spang, J.-P., « Les restructurations d'entreprises », *Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés*, A. Prüm (dir.), Bruxelles, Larcier, 2008, p. 88.

Spang, J.-P, « Vers un droit des groupes de sociétés », *ALJB Droit bancaire et financier*, Vol. 3, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 1994, p. 1069.

Spielmann, D., « La responsabilité des personnes morales en droit pénal luxembourgeois », *Ann. dr. lux.*, Vol. 4, p. 127.

Spindler, G. et Berner, O., « Der europäische Wettbewerb um das Gesellschaftsrecht ist endgültig eröffnet », *RIW*, 2003, p. 949.

Steichen, A., *Précis de droit des sociétés*, Luxembourg, Imprimerie Saint-Paul, 2006.

Stoffel, N. et Lemal, M., « Aperçu sur le traitement du surendettement des particuliers au Grand-Duché de Luxembourg », *ALJB Dr. banc. fin.*, Vol. 2, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 1994, p. 603.

Terré, Fr., Simler, Ph. et Lequette, Y., *Droit civil. Les obligations*, Paris, Dalloz.

Thaller, E., *Traité général théorique et pratique de droit commercial*, Paris, A. Rousseau, 1908 à 1924.

Theisen, M. R. et Wenz, M., « Germany », *The Tax Treatment of Financial Instruments. A Survey to France, Germany, The Netherlands and the United Kingdom*, Coll. Series on International Taxation, Kluwer Law International, 2003, p. 171.

Tilquin, Th., « Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé », *R.P.S.*, 1991.

Tilquin, Th., « Le renouveau de la société en commandite par actions », *Rev. banque*, 1991.

Tilquin, Th., « Le transfert d'une universalité ou d'une branche d'activité », *J.T.*, 1996, p. 497.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

TILQUIN, Th., « L'incorporation comme facteur de rattachement de la *lex societatis* », *R.P.S.*, 1998.

TILQUIN, Th., *Traité des fusions et scissions*, Waterloo, Kluwer, 1993.

TILQUIN, Th. et SIMONART, V., *Traité des sociétés*, Waterloo, Kluwer, 1996.

T'KINT, Fr., « Les actions et le droit de vote », *R.P.S.*, 1989, pp. 242 ss.

T'KINT, Fr., « Le concours des créanciers d'une société en liquidation », *R.P.S.*, 1977, p. 178.

VANDEPLAS, A. et SPREUTELS, J.-P., *L'adaptation du droit des sociétés anonymes*.

VAN DER HAEGEN, M. et VERBAEKEN, C., « L'adaptation de la législation belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés », *J.T.*, 1974, pp. 125 ss.

VAN GERVEN, D., « Le groupement européen d'intérêt économique – G.E.I.E. », *R.P.S.*, 1986.

VAN OMMESLAGHE, P., « Les conventions d'actionnaires en droit belge », *R.P.S.*, 1989.

VAN OMMESLAGHE, P., « Examen de jurisprudence (1979-1990), *R.C.J.B.*, 1992, p. 679.

VAN OMMESLAGHE, P., « Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations », *R.C.J.B.*, 1988.

VAN OMMESLAGHE, P. et DIEUX, X., « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1992, p. 700.

VAN OMMESLAGHE, P. et DIEUX, X., « Examen de jurisprudence (1979-1990) », *R.C.J.B.*, 1993, pp. 674 ss.

VAN OMMESLAGHE, P., « Observations sur les limites imposées à l'activité des personnes morales en droit comparé », *R.C.J.B.*, 1958, p. 293.

VAN OMMESLAGHE, P., « La réforme des fusions et des scissions », *Quo vadis ius societatum ? Liber amicorum P. Sanders*, Waterloo, Kluwer, 1972, p. 129.

VAN OMMESLAGHE, P., « Les sociétés de fait », *J.T.*, 1957, p. 710.

VAN OMMESLAGHE, P. et SIMONT, L., « Cour de cassation du 17 mai 1962 », *R.C.J.B.,* 1964, p. 86.

VAN RYN, J., *Principes de droit commercial*, T. 1, 1re éd., Bruxelles, Bruylant, 1954.

VAN RYN, J. et HEENEN, J., *Principes de droit commercial*, *2e* éd., Bruxelles, Bruylant, 1976.

VAN RYN, J., « Conséquences du transfert en Belgique du siège social d'une société étrangère et du transfert à l'étranger du siège social d'une société belge », *R.C.J.B.*, 1966 p. 399.

VAN RYN, J. et VAN OMMESLAGHE, P., « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales », *R.C.J.B.*, 1962, p. 368.

VAN RYN, J. et VAN OMMESLAGHE, P., « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1961-1965) », *R.C.J.B.*, 1965.

VAN RYN, J. et VAN OMMESLAGHE, P., « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1966-1971) », *R.C.J.B.*, 1973, p. 541.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

VAN RYN, J. et VAN OMMESLAGHE, P., « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1972-1978) », *R.C.J.B.*, 1981.

VAN RYN, J. et DIEUX, X., « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (1979-1990) (1) », *R.C.J.B.*, 1993, p. 813.

VEROUGSTRAETE, I., *Manuel de la faillite et du concordat*, Waterloo, Kluwer, 1998.

VIANDIER, A., HILAIRE, J., MERLE, H. et SERBAT, H., *La société en commandite entre son passé et son avenir*, coll. Le droit des affaires, Paris, Librairies Techniques, 1983.

VIDAL, J., *Essai d'une théorie générale de la fraude en droit français. Le principe « Fraus omnia corrumpit »*, thèse Toulouse, 1957, Paris, Dalloz, 1957.

WAUWERMANS, P., *Manuel pratique des sociétés anonymes*, 4e éd., Bruxelles et Paris, 1924.

WEILL, A. et TERRÉ, F., *Droit civil. Les obligations*, 2e éd., Paris, Dalloz, 1975.

WENZ, M., « The European Company (*Societas Europaea*). Legal concepts and tax issues », *Euro Tax*, 2004, Vol. 44, no 1, pp. 4 à 11.

WICKER, G., *Rép. dr. civ.* (Dalloz), Vo Personne morale.

WINANDY, J.-P., *Abus de droit et simulation en droit fiscal luxembourgeois*, thèse de doctorat, Publications de l'Université de Luxembourg, 2004.

WINANDY, J.-P., *Fiscalité et comptes annuels des entreprises*, Luxembourg, Portalis, 2005.

WINANDY, J.-P., *Les impôts sur le revenu et sur la fortune*, Luxembourg, Promoculture, 2002.

WINANDY, J.-P., *Manuel de la TVA au Luxembourg*, Luxembourg, Portalis, 2005.

WINANDY, J.-P. *Précis de droit fiscal*, Luxembourg, Legitech, 2006.

WYMEERSCH, E., « Article 23 of the second company law directive: the prohibition on financial assistance to acquire shares of the company », *Festchrift für Ulrich Drobnig*.

WYMEERSCH, E., « Comment le droit pourrait aborder certains groupes de sociétés », *Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe*, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 703 à 729, spéc. p. 706.

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com LEXNOW

INDEX

A
Absence de volonté 208
Absentéisme 201, 510
Abus
de biens sociaux 27, 164, 352, 374, 904
de droit 188, 195, 507, 620, 655, 728, 937
de majorité 164, 199 ss, 284, 334, 523, 633 ss, 902
de minorité 164, 199 ss
Achat pour revendre 44, 46, 774
Acompte sur dividendes 359, 577 ss, 646 ss, 699
Acte
conservatoire 256, 554, 617, 652 ss, 943, 1007
d'administration 571, 581, 624, 759, 810
de commerce mixte 48
de disposition 110, 571, 683, 759 ss, 761, 955
ostensible 149, 924
solennel 93
unilatéral 86, 88, 93, 105, 106, 172, 265, 744
Actio mandati 572, 594 ss, 625, 642, 739, 781
Action(s)
au porteur 25, 26, 499, 525, 528, 627, 628
de garantie 592
de jouissance 549, 556
directe 69, 286, 338, 342, 343, 476, 626, 764 ss
en comblement de passif 928, 991
en déclaration de simulation 149
en dissolution de la société 187
gratuites 542, 544
nominatives 192, 501, 503 ss, 524 ss, 628
oblique 118 ss, 224, 263, 342 ss, 471, 764
rachetables 511
sans droit de vote 194, 246, 511, 543, 910
subrogatoire 594, 765
Action paulienne 149, 150, 155, 224, 728, 902, 932, 961, 972 ss
Action sociale 346, 594, 595, 597, 743
Activisme 1
Administrateur 68, 69, 75, 128, 162, 202, 253, 275, 290, 291, 329, 342, 358, 424, 439, 444 ss, 451 ss, 542 ss, 565, 779, 880, 892
provisoire 165, 202, 255, 257, 633, 670, 767
Ad nutum 128
révocation – 128, 582, 583
Affaire
Banque Ottomane 275
Caisse rurale de Manigod 83
Caldwell Sàrl 177, 178
Cartesio 276
Centros 204, 278, 479
Enron 449
Famaplast 865, 871
Fruehauf 164
Glitnir Luxembourg S.A. 1023
Groupe Bertelsmann 60, 221
Hellas Telecommunications 66, 67, 260, 279, 282, 362, 564, 643, 644, 680
Inspire Art 276, 278
Kaupthing Bank Luxembourg S.A. 1023
Lamot 273
Landsbanki Luxembourg S.A. 1023
Lehman Brothers 1023
Meubles Gasperini 670
Parmalat 390, 449
Rozenblum 904
Sarcofebat 262
Sevic System 882

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Société Générale de Belgique 522
Tomberger 405
Ubbink Isolatie 218
Überseering 276, 278, 836
Vale Costruzioni 277
Worldcom 390, 449
Affectation des bénéfices 522
Affectio societatis 120 ss, 153 ss, 181, 189, 195, 209 ss, 246, 248, 317, 320, 494, 671, 690, 924
Agent d'affaires 41, 45
Aggravation du passif 928
Agiotage 481, 525 ss
Agrément 18, 349, 463, 506, 507, 662, 663, 664, 665, 666, 690, 697, 700, 702, 703, 704, 732, 733, 768, 834, 1022, 1023
Aléas sociaux 135 ss, 145, 146
Aliénation mentale 208, 817
Amortissement
extraordinaire 397
normal 397
pour diminution de substance 403
Anatocisme 57
Annualité de l'impôt 298, 392
Anthropomorphisme 101
Apparence trompeuse 36, 149
Appel
de fonds 180 ss, 224, 283, 299, 343, 486, 487, 698
public à l'épargne 418, 419, 478, 494, 731
Apport 135 ss
à titre onéreux 136, 145 ss
en industrie 114, 139, 150, 158, 249, 486, 556
en jouissance 136, 137, 249, 804
en nature 72, 136 ss, 150, 153, 180, 275, 370, 446, 463, 470, 486, 518, 522, 544, 557, 730, 747, 792, 850, 867, 895
en numéraire 136 ss, 153, 486, 493, 518, 724
mixte 145 ss
pur et simple 145 ss
surévaluation des – 141, 143, 144, 489
Apports en nature
contrôle des – 141, 144, 792
Apposition de scellés 941, 953
Appréciation marginale 163, 203, 522, 523, 602, 603
Approbation des comptes 255, 266, 291, 365, 432, 446, 581, 639, 640, 647, 736
Arbitraire 380
Articles
of association 205, 266
of incorporation 266
Assemblée générale 477, 510, 511, 514, 519, 520, 545 ss, 565, 577, 581, 626 ss, 667, 681, 708, 710
Assemblées délibérantes 298, 428, 439, 585, 629, 630
Assistance financière 537, 538
Association
commerciale 102, 115, 118, 125, 279, 343, 507
en participation 35, 100, 108, 112 ss, 125, 135, 245, 343 ss
momentanée 35, 108, 112 ss, 118, 135, 327, 328
religieuse 162
sans but lucratif 62, 102 ss, 347
Association d'épargne-pension (ASSEP) 791 ss, 830 ss
Assureur et assuré 82
Auto-école 45
Autonomie patrimoniale 223, 926
Autorisation d'établissement 46, 63, 169, 204
Autorisation gouvernementale 2 ss, 96, 141, 172, 477

B

Bailleur de fonds 2, 116 ss
Banqueroute
frauduleuse 935, 992, 1028, 1029, 1032
simple 992, 1028 ss
Bases essentielles 265, 849
Bénéfice de division 52
Bénéfices
répartition des – 114, 159, 182, 266, 510, 640, 779, 806
Bonne foi 75, 76, 171, 181, 187 ss, 201, 245, 252, 262, 345, 352, 379, 381, 487 ss, 578, 593, 596, 621 ss, 642, 952, 958, 960, 964, 1004 ss
Bon père de famille 159, 330, 379, 384, 595, 621 ss, 695, 801, 803, 950
Bons de caisse 560, 561
But désintéressé 102, 103, 165

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

C

Cabaret 47
Cadastre 137
Cadbury
rapport – 451
Caisse des dépôts et consignations 306
Calculs actuariels 832
Canal de Suez
Société du – 289
Capacité
active 175, 326
de contracter 109, 209
de jouissance 166, 224
d'exercice 169, 224
limitée 288, 567
passive 105, 175, 294, 326
Capital autorisé 415, 480, 519, 520, 559, 634 ss
Capitalisme populaire 4
Capital social
maintien du – 512, 532, 540
Cas fortuit 804
Cause de nullité 119, 152, 168, 208, 211, 248, 724, 924, 969
Cautionnement gratuit 163
Cautions solidaires 339
Certificat
de blocage 139, 543, 724
de participation au capital (CPC) 564
Cessation des paiements 920, 921, 927, 929, 941, 971
Cessions
à cause de mort 732, 733, 734
de créance 133, 308, 309, 527, 897, 969
entre vifs 732, 733
Changement
de nationalité 191, 267 ss, 272, 708, 709
Charpentier 45
Clause
d'agrément 503, 507, 665, 666
de maintien de la société entre les survivants 820
de non-acquisition 665, 667
de reprise des biens 137
de sortie simultanée 667
d'exclusion 189
léonine 130, 159, 236, 808, 809, 810
Code de conduite 453
Code Savary 38
Cogestion 334, 619, 620
Comité des créanciers 936
Commanditaire/commandité. Voir Société léonine
Commencement d'écrit 49
Commissaire 63, 68, 192, 193, 196, 252, 261, 290, 291, 294, 295, 304, 305, 308, 311, 312, 317, 344, 346, 349, 352, 358, 362, 363, 365, 371, 375, 416, 427, 428, 430, 449, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 553, 564, 572, 577, 591, 595, 596, 597, 599, 600, 609, 627, 628, 634, 637, 638, 639, 642, 643, 647, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 661, 681, 683, 685, 686, 700, 701, 704, 736, 746, 747, 776, 779, 781, 782, 790, 887, 970, 992, 997, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1024
Commission des normes comptables 912
Comparants 206, 478, 493, 725
Compartiments multiples 689
Compensation 43, 118, 143, 220, 227, 283, 293, 377, 394, 402, 407, 411, 412, 803, 841, 909, 957 ss, 966, 969, 970, 984, 991, 992, 998, 1009
Compétence réservée 254, 610
Complice 351, 354, 575, 961, 1032
Comply or explain 27
Comptabilisation des recettes dépenses 384
Compte courant 395, 957, 965, 969, 970
Comptes
reddition des – 127, 399, 673
Conception contractuelle 84 ss, 124, 134, 154, 160, 161, 264
Concordat 289, 299, 553, 585, 652, 702, 786, 817, 842, 886 ss, 919, 927, 932, 934 ss, 940, 941, 947, 950, 973, 977, 981, 983, 992, 993, 994, 999 ss
Concordat après faillite 994 ss
Concours réel 369
Concubinage 123
Concurrence déloyale 98, 230 ss, 283
Condition
résolutoire 57, 188, 546, 671
suspensive 213, 507, 526, 546, 974
Conflit d'intérêt 587, 589 ss, 811
Confusion 133, 782
de créance 143

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Connexité 67, 958, 992, 1009
Conseil
d'administration. Voir Administrateur
de surveillance 252, 255, 363, 428, 477, 564, 565, 606 ss, 681, 682, 709, 714, 719, 736, 747, 906
général 456, 656 ss
Consentement 57, 86, 88, 91, 94, 117, 127, 154, 184, 208, 209, 210, 211, 219, 235, 236, 253, 264, 265, 321, 436, 437, 442, 443, 493, 500, 503, 507, 524, 632, 665, 753, 811, 812, 819, 991
Consignation 196, 301, 305, 326, 962, 987
Consolidation
des comptes 904 ss
exemption de – 908
mondiale 908
Constitution de société. Voir Société
Consul 36
Contrat
aléatoire 93
commutatif 93, 801
consensuel 91, 92, 93, 172
d'association 100, 102
de louage d'industrie 39, 127
de mandat 104, 127, 252, 260, 424, 444, 447, 457, 570, 582, 841
de société 54, 82, 86, 91, 92, 99, 112, 115, 118, 120, 123 ss, 158, 159, 160, 161, 175, 186, 204, 209, 225, 235 ss, 251, 264, 265, 323, 324, 358, 443, 487, 549, 582, 671, 673, 725, 753, 755, 756, 801 ss, 848
innommé 102
pluripartite 94, 95, 186
solennel 92, 93, 172
successif 120
synallagmatique 86, 94, 100, 292, 966
Contre-lettre 124, 149, 924
Contribution aux dettes 51
Contrôle des comptes 18, 397, 398, 416, 417, 449, 451, 459, 463, 464, 465, 467, 656, 911
Contrôle marginal. Voir Appréciation marginale
Convention de La Haye 126, 272
Conversion judiciaire 244
Coopératisme 773
Coopérative
de consommation 774
de crédit 83, 774
de production 774
Cooptation 455, 457, 566, 569, 582, 607, 608, 634
Corps certain 138, 800, 804, 820
Correction de valeur 387, 388, 403, 414, 699
Correspondance des formes 266
Coup d'accordéon 191, 202, 672
Coupures d'actions 498, 504
Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) 59
Coutume 56
Créance
apport de – 142, 490
Créances obligataires 303
Créanciers
chirographaires 301, 936, 963 ss, 978, 979, 982, 992, 993, 996, 1002, 1012
concours des – 220, 299, 300, 301, 304
dans la masse 978, 979, 993
Croupier
convention de – 117, 118, 776, 812

D

Dation en paiement 446, 486, 961, 962, 964, 965, 966, 967
Décharge 143, 294, 304, 312, 346, 369, 372, 432, 456
Décision par défaut 944
Déclaration des créances 941, 953
Décodification 55
Déconfiture 50, 786 ss, 815, 817, 919, 929, 932, 982
Delaware
(sociétés du –) 270
Délégations d'entreprise 568
Délivrance 369, 384, 703, 884, 885, 964, 973, 991
Dénomination sociale 63, 74, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 320, 348, 349, 674, 675, 678, 759, 760, 764, 767, 768, 794
Dépenses spéciales 297
Détournement des biens 939
Dette liquide, exigible et certaine 937
Devise du capital social 157, 206
Dilution 153, 201, 203, 515, 544, 558, 564
Directive
douzième – 132, 133, 172, 709

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Directoire 145, 255, 425, 428, 457, 470, 489, 500, 522, 564, 565, 577, 578, 579, 606, 639, 647, 649, 650, 709, 714, 782, 906
Dirigeant de fait 623
Dirigeant social. Voir Administrateur
Dissolution
  judiciaire 185, 188, 195, 211, 302, 322, 747
  sans liquidation 288, 289, 857, 887
Dividende
  fictif 151, 345, 358, 360, 361, 362, 578, 580
  intérimaire 577, 647
  privilégié 510 ss
Dol 209, 235, 284, 304, 344, 360, 373
  spécial 359, 369, 373
Domiciliation de société 176
Dommage
  grave et imminent 533
  moral 959
Don manuel 677, 960
Double qualité 587, 613, 773, 776, 951
Droit
  acquis 184, 267, 649, 713, 991
  cambiaire 49
  de préemption 662, 663, 665, 758
  de recours (des créanciers) 300
  de rétention 801, 991
  de retrait 758
  de veto 127, 682, 761
  de vote 87, 180, 191 ss, 221, 264, 357, 405, 432 ss, 480, 486, 487, 496, 498, 509, 510, 511, 520, 522, 534 ss, 556, 564, 576, 586, 631, 632, 633, 652, 667 ss, 736, 737, 747, 748, 865, 868, 874, 875, 878, 888, 895
  d'information 191, 192, 196, 736, 872, 889
  discrétionnaire 129, 202, 486, 737
  d'opposition 128, 945
  fonction 202
  préférentiel de souscription 515, 518, 519, 528, 543, 544, 559
  primaire 12
  privilégié au remboursement de l'apport 511
  réel 137 ss, 820, 960, 1001
  secondaire 12
  subjectif 195, 202, 301, 728
Droit-fonction 195, 576
Droit international privé 89, 270, 273, 274, 843, 858
Droits d'enregistrement 145, 146, 402

E

Ébranlement du crédit 930 ss, 936, 941, 944
Édit de Charles IX 38
Effet
  dévolutif 943
  direct 13
  suspensif 944
Égalité
  entre associés 94, 182, 543, 547, 565, 806
  entre créanciers 293, 301, 933, 961, 963, 972, 993, 1018
Endossement 499
Engagements perpétuels 188, 289, 800, 815
Enrichissement sans cause 47, 220, 249
Enron 390, 449
Enseigne 63, 760
Entérinement 172
Entreprise 39, 479 ss, 543 ss, 568, 602 ss, 696 ss, 711 ss, 823 ss, 847 ss, 901 ss, 919 ss
  d'assurances 1022
  de transformation 45
  étrangère 907
  européenne 1019
  liée 410, 413, 414
  mère 423, 905, 910
Épizooties 82
Équitables Pionniers de Rochedale 773
Equity kicker 562
eRCS 74
Esclavage 150, 557
Escompte 293, 300, 312, 342, 487
  pour dettes non exigibles 293
Escroquerie 358, 369
Espace Économique Européen 706
Exclusion incidente 672
Exécutoire par provision 314, 941, 942, 946
Exequatur 942, 943
Eyschen Paul 3

F

Fable d'Ésope 237
Factoring 523
Faculté de renonciation 817
Faillite
  de fait 941
  extension de la – 302, 326, 923, 991
  sur faillite ne vaut 933

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Faux bilan 323, 359, 372 ss
Faux en écriture 154, 372, 373
Fédérations (de coopératives) 789
Féodalité 796
Fiction légale 222, 226, 542
Fiduciaire 96, 381, 633, 693, 907, 1020
  opération – 357, 381, 633
Filiale 165, 404, 405, 415, 416, 421, 520, 534, 539, 662, 664, 670, 677, 706 ss, 714 ss, 847 ss, 859, 866, 878, 883, 901 ss, 929
Finances publiques 392
Fixité du capital social 157, 158, 207, 479
Fondateurs
  responsabilité des – 143, 144, 174, 725, 727, 778
Fondation 62, 86, 102, 105, 106, 126, 151, 165, 239, 272, 347, 418
Fondé de pouvoir 623, 998
Fonds
  de commerce 39 ss, 121, 143, 152, 155, 229, 760, 824, 873, 898, 921, 964
  de pension 190, 465, 772, 773, 791, 792, 830, 832
  de titrisation 464, 693, 694
  publics 786
  social 109, 116, 134, 154, 156, 243, 281, 286, 340, 368, 757, 775, 778, 782, 783, 802, 806, 807
Fonds Commun de Placement (FCP) 464, 687, 695
Fonds de commerce 760
Fonds d'investissement spécialisés 687
Forme
  contractuelle 687
  statutaire 687
Forum shopping 1019
Frais
  de recherche et de développement 198, 385, 404, 421, 578, 642
  d'établissement 197, 385, 394, 399, 402, 412, 413, 578, 642
Fraude à la loi 269, 809
Fusion
  par absorption 308, 859, 861, 881, 883, 885
  par constitution d'une nouvelle société 859, 881

G

Gérant 126, 127, 128
Gestion
  contrôlée 553, 652, 887, 919, 1004, 1020, 1023, 1027
  d'affaires 216, 220
  du passif 831
  journalière 104, 109, 129, 261, 262, 332, 427, 431, 575, 576, 584, 589, 609, 635, 709, 739, 740
GIE/GEIE 875, 876
Golden shares 182
Goodwill 117, 403, 543, 869
Groupe de sociétés 901 ss
Groupement d'intérêt économique (GIE) 62, 106, 823, 826, 857, 864, 875, 886, 888, 890, 891, 894, 895, 899
Groupe Spécial de Négociation (GSN) 713 ss
Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung (GoB) 377

H

Homologation du concordat 935, 992, 995

I

Image fidèle 377, 393, 401, 415, 419, 468, 904, 912 ss
Immunité pénale 353
Impôt commercial communal 117, 704, 828, 1004, 1009
Impôts latents 391 ss
Inaction prolongée 230
Incendie 82, 500
Indemnités de licenciement 384
Indivisibilité 235, 437, 499, 957, 963, 967
Indivision 109, 123, 134, 295, 296, 297, 436, 437
Inexistence 212, 242, 281, 327, 328, 778, 924
Infirmité habituelle 186, 320, 821
Injures 129
Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE) 460, 461, 464, 469, 488
Intention
  criminelle 357, 360
Intérêt
  des créanciers 151, 389, 848, 929, 938
  du groupe 164, 847, 902
  égoïste 201

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Intuitu personae 4, 111, 112, 140, 190, 236, 455, 507, 752, 758, 769, 775, 786, 874
Inventaire
  permanent 400
  physique 400, 401, 873
Investisseur averti 689, 697, 701

J
Jetons de présence 570
Juridictions consulaires 31, 38
Juste motif 161, 183, 185 ss, 211, 289, 320 ss, 554, 671, 673, 674, 779, 816, 817, 818, 821
Juste prix 531, 537

L
Langues
  régime des – 206
Leasing 138, 381, 403, 986
Légalisme 101
Lésion 141, 524, 814, 972
Lettre de change 39, 58, 931, 976, 987
Leveraged buy-out 695
Liberté contractuelle 26, 34, 85, 89, 113, 141, 160, 176, 269, 302, 563, 661, 665, 806, 817
Liberté d'association 34, 102, 665, 774
Liberté d'établissement 12, 275 ss, 882
Libertés fondamentales 59, 275, 314
Lien de causalité 155, 325, 330, 351, 471, 589, 621, 643
Liquidation
  clôture de la – 63, 133, 220, 226, 227, 280, 284 ss, 294, 304 ss, 312, 314, 339, 345, 701, 764, 922, 1024
  du notariat 1020
Liste des bénéficiaires 832
Loi sur la domiciliation des sociétés 319
Louis XIV 38
Luca Paciolo 37

M
Mainmorte 289
Maître de l'affaire 154, 246, 326, 367, 923, 991
Majeurs sous tutelle 209
Majorité
  bouleversements de – 520
Mandat. Voir Contrat de mandat
  apparent 75, 171, 262, 472
  en blanc 435, 436
  gratuit 570, 581, 582, 655, 740, 745
  institution du – 444
Mandataire
  judiciaire 934, 951
  substitué 626
Manœuvres frauduleuses. Voir Dol
Marge bénéficiaire 406
Marge de sécurité 151, 156
Mark to market 699
Masse 283, 288, 290, 297, 301, 403, 488, 551 ss, 626, 643, 651, 652, 687, 693, 803, 806, 932 ss, 942, 949 ss, 1002, 1009 ss, 1029 ss
  des obligataires 551, 652, 653
Matière réservée 204
Mésintelligence entre associés 186, 190, 321, 671
Mesures conservatoires 581, 994
Michel de l'Hospital 31
Millstein
  rapport – 452
Mineur émancipé 444
Minorité de blocage 202, 203, 520
Mise en demeure 147, 320, 734, 801, 977, 985
Mise en équivalence 404, 913 ss
Mise en pension 43, 357, 970
Mise en réserve systématique des bénéfices 200
Mort civile 815
Mouvement coopératif 4, 773
Moyen dilatoire 937
Mutuus dissensus 185

N
Normes de révision 469, 471
Normes IAS/IFRS 382, 387, 418, 420, 422
Notariat
  organisation du – 206
Novation 86, 126, 973
Nue-propriété 138, 437
Nullité
  absolue 205, 242, 526, 755, 775, 779, 924
  de la société 63, 65, 82, 122, 130, 152, 154, 159, 168, 211, 225, 235, 236, 489, 494, 726, 756, 775, 924, 937
  relative 92, 235, 242

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

O
Objet civil 95 ss, 337, 795, 852
Objet social 15, 27, 63, 76, 95 ss, 161, 166 ss, 177, 180, 225, 229, 237, 245, 254, 260 ss, 288, 290, 314, 320, 321, 348, 426, 432, 447, 480, 532, 571 ss, 575 ss, 607, 609, 616, 622 ss, 849, 903
Obligation(s)
  aux dettes 53, 764
  convertible(s) 415, 528, 544, 558, 559, 563, 572
  de faire 140, 186, 655, 666, 807
  de moyen 469, 471
  de résultat 469, 471
Officier ministériel 41
Offre publique
  d'achat 529
  d'échange 529
Oligarchie 264
Opération de portage 693
Opérations fiduciaires 240, 381
Opposition d'intérêts 86, 587
Option d'achat 240, 562, 693, 986
Ordonnance
  de 1673 38, 753
  de Colbert 38
Ordre du jour 7, 439 ss, 482, 569, 585 ss, 627, 628, 630, 631, 634 ss, 638, 646 ss, 711, 855
Ordre public 31, 47 ss, 87 ss, 111, 128, 160, 182, 185, 188 ss, 208, 225, 236, 259, 263, 286, 295, 302, 319, 324, 341, 432, 506, 516, 519, 542, 563, 565, 583, 613, 631, 640, 645, 650, 660 ss, 682, 745, 769, 775, 785, 817 ss, 936, 939, 940, 948, 983, 995, 999
Ordre public économique 672
Organe statutaire 329, 427
Organisme(s)
  de capitalisation 197
  de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 687 ss
  de placement collectif non coordonnés (OPC Partie II) 688 ss
  de placement collectif (OPC) 306, 406, 464, 687 ss, 832, 1022, 1024, 1025
Originator 693

P
Pacte
  commissoire 671, 985
  sur successions futures 526
  syndicataire 666
Paiement de dettes non échues 961
Pair comptable 140, 151, 408, 481, 488, 498, 512, 533, 536, 859
Parères 58
Parmalat. Voir Affaire Parmalat
Part
  bénéficiaire 415, 464, 518, 543, 555 ss, 775
  virile 51, 296, 297, 340, 759, 813
Pas de privilège sans texte 111
Passage vers l'euro 266, 549
Passeport européen 688
Patrimoine d'affectation 51, 84, 106
Pénalisation 27, 352
Période suspecte 149, 920, 936, 955 ss, 985, 999
Personnalité
  des peines 353, 1028
  morale incomplète 89, 346
Perte de la moitié du capital 325, 650
Photographe 45
Plan de réorganisation 1009
Pluralité de gérants 369, 444, 740, 761, 810
Portage 536
  opérations de – 239
Portalis 1, 40
Porte-fort 173, 174, 216, 723, 727
Porte ouverte 419, 776
Position de force 198, 525
Prête-nom 100, 117, 153, 246, 248, 923, 996. *Voir aussi* Simulation
Prêt partiaire 117
Preuve
  par témoin 49, 257
PRICAF 701
Prime d'émission 151, 157, 181, 197, 407 ss, 483 ss, 521
Principal établissement 12, 175, 176, 269 ss, 331, 707, 836, 843, 883, 939, 1004
Principe
  d'égalité 182, 184, 221, 293, 315, 516, 532, 534, 933, 972, 983, 1012, 1018
  de la spécialité statutaire 167, 225
  de l'évaluation individuelle 395, 396, 407
  de l'imparité 388, 396
  de l'intangibilité du bilan d'ouverture 395
  de prudence 385 ss, 394
  d'une comptabilité régulière 377

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Principe général du droit 60, 215, 221, 377, 675
Principes coopératifs 776
Private equity 695
Prix équitable (OPA) 529
Procédure d'insolvabilité
  principale 1020
  secondaire 1020
Produit de liquidation 93, 199, 224, 293, 300 ss, 311, 498, 866
Professions libérales 131 ss, 225, 426, 460, 1027
Profit capitaliste 4, 773
Projet commun de fusion 861 ss, 872 ss, 876, 878, 881 ss
Promesse
  d'apporter 136
  de contrat 92
  de société 92
  de vente 666
Prorogation de l'assemblée 645
Protêt 929
Publication
  des comptes annuels 192, 322, 365, 492
  intégrale 62, 65, 70, 71
  par extrait 62, 70, 71, 314, 764

Q

Quasi-apports 492, 638
Quitus. Voir Décharge
Quorum 197, 266, 290, 554, 585, 630, 648, 708, 711, 875, 888, 894, 899

R

Rachat d'actions 363, 512, 532, 538, 540, 805
Raison sociale 35, 63, 121, 228, 320, 348, 349, 477, 677 ss, 721, 728 ss, 754, 759 ss
Rapport
  d'échange 707, 861, 862, 866, 878, 887, 889, 894
  de gestion 365, 368, 398, 416
Ratification des engagements 727
Ratification tacite 173, 174, 262
Réalité économique 381, 904
Recouvrement de créances 45
Réduction de capital social 247, 535, 545, 546, 548, 672, 738, 873
Réévaluation des bilans 390, 391
Régime matrimonial 61, 63, 123, 131, 725, 1029
Règle de preuve 40, 49, 796
Règlement
  CE 606, 1019
  de pension 830, 832
  intérieur 205, 429
Réhabilitation 944, 992, 1028, 1033
Renvoi
  théorie du – 274
Réparation civile 200
Répétition 37, 45, 56, 258, 921
Représentation 14, 27, 45, 68, 75, 87, 113, 170, 202, 217, 225, 252, 261, 265, 329 ss, 424, 426, 427, 430, 431, 439, 442, 443, 445, 446, 472, 480, 568, 573 ss, 609 ss, 620, 674 ss, 711, 712, 713, 717, 719, 739, 841, 951, 983
Réquisition d'inscription 64
Réserve
  de réévaluation 390, 391, 407
  légale 197, 311, 362, 363, 408, 542, 579, 641, 646, 688, 698, 786, 788
Réserve de propriété
  clause de – 399, 985, 988
Réserves cachées 386, 389, 543, 785, 879
Res perit debitori 94
Res perit domino 94
Responsabilité
  contractuelle 104, 278, 345, 593, 595, 620, 669, 814
  délictuelle 174, 231, 345, 597, 598, 624, 643
  du banquier 928
  personnelle (de l'organe) 278, 279
Rétention de résultats 198
Retour à meilleure fortune 935
Rétractation 944
Retrait forcé 183, 787
Réunion de tous les titres en une seule main 304, 324
Revendication 242, 776, 981, 985, 987 ss
Réviseur d'entreprises 63, 77, 141, 142, 144, 145, 151, 193, 305, 349, 423, 459 ss, 488, 489, 528, 557, 559, 564, 577, 654 ss, 691, 697, 700, 703, 730, 832, 850, 867 ss, 872, 889, 992
Révision
  rapport de – 139, 142, 145, 470, 489, 557, 559

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

Manuel de droit des sociétés
Jean-Pierre WINANDY

Révocation *ad nutum* 128, 582, 583
Ristournes 395, 412, 773, 776, 778

S

Sanctions pénales 27, 195, 312, 314, 351, 354, 360, 362, 372, 426, 777
Sarbanes-Oxley 450
Scission 14, 17, 204, 288, 289, 349, 464, 708, 847, 848, 857 ss, 880, 886 ss
  par absorption 887, 894
  par constitution de nouvelles sociétés 887, 893, 896
  projet de – 887 ss
Sécurité juridique 14, 91, 166, 170, 173, 236, 244, 260, 271, 350, 445, 884, 970
Séquestre 256, 257
Siège
  réel 70, 175, 268 ss, 838
  social 63, 70, 104, 111, 175, 176, 206, 229, 232, 268 ss, 302, 321, 331, 349, 480, 490, 503, 504, 524, 552, 555, 567, 674, 782, 784, 862, 864, 872, 873, 874, 882, 887, 899, 923, 938, 1004, 1005, 1006
  statutaire 12, 175, 264, 268, 272, 276, 691, 706, 707, 708, 709, 719, 793, 863, 883, 1020
  transfert de – 177, 178, 268, 273, 274, 708
Simulation 117, 124, 149, 150, 152, 210, 243, 364, 381, 924
  de souscriptions 370
Societas delinquere non potest 353, 1028
Société
  apparente 36
  constitution de – 16, 71, 124, 148, 173, 270, 798, 867, 883, 887
  créée de fait 119, 205
  d'impact sociétal 213
  de fait 92, 119, 174, 205, 218, 327
  de gestion 464, 687
  de titrisation 464, 694
  en commandite par actions 2, 4, 71, 133, 246, 248, 344, 677, 678, 679, 682, 688, 697, 763 ss, 876, 905, 911
  en commandite simple 2, 4, 72, 85, 131, 276, 506, 677, 679, 697, 698, 752, 756, 763, 864, 875, 888, 895
  en nom collectif 2, 35, 52, 67, 72, 85, 98, 102, 113 ss, 167, 169, 186, 205, 223, 228, 242, 266, 284, 332, 339, 447, 698, 704, 752, 764, 777, 864, 875, 888, 894, 895, 907, 938, 941, 957, 978
  en participation 112 ss
  européenne 706, 712, 714, 715, 862, 867
  fictive 152, 210, 246 ss
  léonine 114, 158, 198, 237, 242, 757, 808
  momentanée 108, 113, 279, 770
  occulte « atypique » 117
  particulière 799
  taisible 251, 796
  unipersonnelle 84, 91, 132, 172, 210, 242, 608, 722
  universelle 796, 797, 798
Société(s) coopérative(s) 158, 190, 242, 458, 772 ss, 791, 938
Société coopérative européenne 793, 794
Société d'agrément 34
Société d'épargne-pension à capital variable (SEPCAV) 158, 207, 705, 791, 830 ss
Société d'investissement
  à capital variable (SICAV) 158, 207, 306, 500, 687, 695, 699, 792
  en capital à risque (SICAR) 465, 695 ss
Société en formation 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 728
Société en participation 247, 248
Solidarité légale 339
Sondages 469
Soulte 297, 298, 859 ss, 883, 887, 894, 981
  en espèces 887, 894, 896
Souscription
  du capital 147, 266, 299, 484
  publique 215, 365, 494, 730 ss
Spécialité
  des personnes morales 165, 260
  légale 165, 167, 168, 225
Statut personnel 838, 933, 943
Stipulation pour autrui 143
Structure
  dualiste 255, 565, 606, 626
  moniste 255, 565, 607
Substance
  économique 381, 403
Substance over form 381
Surenchère 984
Surendettement 919, 932
Sûretés
  constitution de – 545, 873, 874, 890, 896, 900, 963
Sursis de paiement 553, 652, 887, 919, 930, 1004, 1012, 1015, 1016, 1017, 1022

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW

Survivance
de l'être moral 287
passive 285
Syndicat 35, 151, 165, 167, 181, 328, 331, 371, 435, 497, 660, 665
d'assureurs 331

T
Tantièmes 570, 653
Théorie
de l'accessoire 47
de la fiction 222
de la réalité 222, 276
de l'organe 86, 278, 279, 424 ss, 1028
de l'apparence 75
des cadres légaux obligatoires 34
des éléments essentiels 264
des risques 94
du contrat 84
fonctionnelle 90
Tierce opposition 14, 244, 881, 893, 900, 944
Tirage au sort 548, 652
Titre exécutoire 976
Titrisation 464, 693
Tontine 93
Tradition manuelle 525, 528
Trafic de vote 195
Traité
d'Amsterdam 12
de Vienne 2
Traité concordataire 994
Transfert
du siège social 63, 70, 271, 272, 275, 276
universel 848, 860, 873, 879
Transformation de société 10, 851, 853, 856, 857
Travail à façon 40
Tyrannie des majoritaires 221

U
Ultra vires 260, 447
Unicité de compte 969
Unité de la faillite 933
Universalité
de la faillite 933, 943, 968
du patrimoine 289, 798
Usages de commerce 48, 54, 56, 58, 95, 159, 160, 199, 754, 822, 961
Usufruit 136 ss, 436, 437, 490, 700, 819, 820

V
Vacance d'une place d'administrateur. Voir cooptation
Valeur nette d'inventaire (VNI) 197, 691
Vanadium 1007
Vente
à l'encan 41
à réméré 693
à tempérament 985
Venture Capital 695
Vérification
des apports 142, 151, 489, 491, 492, 522, 889
des comptes 196, 405
Verrouillage de la société 532
Vice caché 137, 141, 527
Vice du consentement 141, 235
Vote
par correspondance 438, 737
plural 194, 736

W
Warrant
obligation à – 544, 562, 563
Winter
rapport – 451
Worldcom 390, 449

Imprimé le 18/07/2022 par shannon.mckee@stibbe.com
LEXNOW